Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ
Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI

MEDENÎ USUL HUKUKU

5. Baskı

ANKARA 2019

ÖNSÖZ

Bu kitap, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Prof Dr. Ejder YILMAZ, Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ ve Doç. Dr. Emel HANAĞASI tarafından, hukuk fakültesi öğrencilerinin medeni usul hukuku dersinde başvurabilecekleri, uygulamacıların da medenî usul hukukuna ilişkin temel bilgilere ulaşabilecekleri kaynak olması amacı ile hazırlanmıştır.

Kitapta, medeni usul hukukumuzun ana kaynağı olan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun yaptığı düzenlemeler ve koyduğu kurallar, sekiz yılı aşkın uygulama sonuçları ile bu dönemde açıklanan bilimsel görüşler de dikkate alınarak açıklanmış ve değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, hak arama özgürlüğü ve yaşama geçirilmesi, hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargılamaya hâkim olan ilkeler gibi temel konulara geniş yer verilmiştir. HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra, başka kanunlarla konulan usul hükümleri de incelenmiştir.

Kitapta, medeni usul hukukuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay içtihadı birleştirme kararları ve çok sınırlı sayıda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile daire kararları, ilgili oldukları konular hakkında yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, özellikle öğrencilerin bazı açıklamaları daha iyi anlayabilmesi için, Kitaptaki örneklerin bir kısmı Yargıtay kararlarından alınmıştır. Aynı düşünce doğrultusunda Yargıtay ile ortak görüşlerimiz arasında farklılık bulunan durumlarda, kişisel görüşümüz yanında Yargıtayın görüşü de belirtilmiştir.

Bölge Adliye (istinaf) Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamıştır. HMK Geçici Madde 3 hükmü gereğince, uzun bir süre daha uygulanması gerekecek olan, HUMK'nun 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerine de Kitapta yer verilmiş; bu hükümlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kitapta, özel görevli hukuk mahkemelerinin kuruluş ve görevleri ile bu mahkemelerce HMK hükümleri yanında uygulanan usul kuralları da açıklanmıştır. Ayrıca, hâkimlerin hukuki sorumluluğu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve iç tahkim konuları da yeterince ele alınıp incelenmiştir.

Bu baskıda da kitap tamamen gözden geçirilmiş; ilgili mevzuattaki değişiklikler işlenmiştir. Öte yandan HMK'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulaması devam eden ve istinaf mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen kararlara karşı başvurulacak kanun yolları bakımından geçerli olan HUMK hükümlerine ilişkin açıklamalar "italik" verilmek suretiyle eski ve yeni kanun yollarına ilişkin açıklamaların birbirinden ayrılması tercih edilmiştir.

Kitabın başında, yararlanılan eserleri içeren "Genel Kaynakça"ya yer verilmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı "Kısaltmalar Cetveli"nde gösterilmiştir.

Kitabın sonuna ayrıntılı bir kavramlara göre arama cetveli konularak, okuyucunun o kavram ve konu hakkında bilgi edinebileceği yer gösterilmiştir.

Kitapta yer alan kavramlar cetvelini hazırlayan Ar. Gör. Hikmet BİLGİN, Ar. Gör. Gökberk ÖZSÖKER ve Ar. Gör. Furkan ULUGÜN'e teşekkür ederiz.

Kitabı "Yetkin" yayını olarak basan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.'nin değerli yöneticileri Y. Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER'e, titiz ve başarılı dizgi operatörü Serap ÖZER ROL'e teşekkür ederiz.

Eylül 2019

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Prof. Dr. Ejder YILMAZ
Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ
Doç. Dr. Emel HANAĞASI

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
İçindekiler 9
Kısaltmalar cetveli 45
Genel Kaynakça 49

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MEDENÎ USUL HUKUKUNA GİRİŞ 51
A) Kavramsal olarak medenî usul hukuku 51
B) Medenî usul hukukunun amacı 52
C) Medenî usul hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi 53
D) Uyuşmazlık kavramı ve uyuşmazlık çözüm yolları 55
E) Medenî usul hukukunun kaynakları 56
I - Anayasa 57
II - Hukuk Muhakemeleri Kanunu 57
III - Maddî hukuka ait kanunlardaki usul hükümleri 58
IV - Diğer kanunlar 59
V - Medenî usul hukuku ile ilgili yönetmelikler 59
VI - Yargıtay kararları 59
VII - Doktrin 60
F) Medenî usul hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması 60
I - Yer bakımından uygulanma 60
II - Zaman bakımından uygulanma 61
1) Kural 61
2) Geçiş (intikal) hükümleri 65
G) Medenî usul hukuku kurallarının yorumu 66

§ 2. YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI 67
A) Yargı kavramı 67
B) Yargı yolları (çeşitleri, kolları) 68
I - Anayasa yargısı 70
II - İdari yargı 71

1) İdari yargının işlevi ve yapısı 71
2) İdari yargı-medeni yargı ilişkisi 73
III - Adli yargı 75
1) Genel olarak 75
2) Ceza yargısı 76
3) Medeni yargı 77
a) Genel olarak 77
b) Çekişmeli yargı 78
c) Çekişmesiz yargı 79
aa) Kavram ve çekişmeli yargıyla ilişkisi 79
bb) Çekişmesiz yargının ölçütleri 80
IV - Uyuşmazlık yargısı 82
1) Genel olarak 82
2) Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı 83
a) Olumlu görev uyuşmazlığı 83
b) Olumsuz görev uyuşmazlığı 84
3) Hüküm uyuşmazlığı 85
V - Hesap yargısı 86

§ 3. MAHKEMELER 87
A) Mahkeme kavramı 87
B) Yargı sisteminde bulundukları yere göre mahkemeler 87
I - İlk derece mahkemeleri 87
II - Üst derece ve yüksek mahkemeler 88
1) İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri (ikinci derece mahkemeleri) 89
a) İstinaf mahkemelerinin yapısı ve kuruluşu 89
b) İstinaf mahkemelerinin görevleri 91
2) Yargıtay 92
a) Yargıtay'ın kuruluşu ve yapısı 92
aa) Hukuk daireleri (HD) 93
bb) Hukuk genel kurulu (HGK) 93
b) Yargıtay'ın görevleri 94
aa) Genel olarak 94
bb) Yargıtay hukuk dairelerinin görevleri 94
cc) Yargıtay hukuk genel kurulunun görevleri 96

c) İçtihatların birleştirilmesi 96
aa) Genel olarak 96
bb) İçtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini gerektiren haller 97
cc) İçtihatların birleştirilmesine karar verecek kurullar 98
dd) İçtihatların birleştirilmesi talebi ve incelenmesi 98
ee) İçtihadı birleştirme kararlarının niteliği ve bağlayıcı gücü 99
C) Görevlerine göre mahkemeler 100
I - Genel görevli mahkemeler 101
II - Özel görevli mahkemeler (uzmanlık mahkemeleri) 103
D) Kuruluş ve örgütlenme bakımından mahkemeler 105

§ 4. YARGI GÖREVLİLERİ 106
A) Kavram 106
B) Hâkim 106
I - Hâkimlik mesleğine giriş 107
1) Adaylık 107
2) Hâkimliğe atanma 107
II - Hâkimlik mesleği 108
III - Hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve teminatı 111
1) Hâkimlerin bağımsızlığı 112
2) Hâkimlik teminatı 115
IV - Hâkimin yasaklılığı ve reddi 117
1) Genel olarak 117
2) Hâkimin yasaklılığı 118
a) Sebepler 118
b) Yasaklılığın tespiti ve ileri sürülmesi 120
3) Hâkimin reddi 120
a) Sebepler 120
b) Ret usulü 123
aa) Taraflardan birisinin hâkimi reddetmesi 123
bb) Hâkimin kendisinin çekilmesi 123
cc) Ret sebeplerini inceleyecek merci 124
dd) Ret sebeplerinin incelenmesi ve karar verilmesi usulü 125

ee) Merci kararına karşı kanun yolları 125
ff) Ret talebinin kabulü 126
V - Hâkimlerin sorumluluğu 126
1) Sorumluluk sisteminin genel özellikleri 126
2) Sorumluluk sebepleri 128
3) Tazminat davası açılması 130
C) Cumhuriyet savcısı 131
D) Yazı işleri personeli (görevlileri) 133
I - Yazı işleri müdürü 133
II - Zabıt kâtibi 134
III - Mübaşir ve hizmetli 135
E) Avukat 135
I - Genel olarak 135
II - Avukatlık mesleğine giriş 136
III - Barolar ve Türkiye Barolar Birliği 137
IV - Avukatların ödevleri 138
V - Avukatların hakları 139
F) Noter 141
I - Genel olarak 141
II - Noterlerin görevleri 142

§ 5. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 144

A) Adil yargılanma hakkı 144
I - Kanunî, tarafsız, bağımsız mahkeme önünde yargılanma hakkı 145
1) Kanunî (tabiî) hâkim önünde yargılanma 145
2) Tarafsızlık ve bağımsızlık 145
II - Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı 146
III - Açık (aleni) yargılanma 147
IV - Hakkaniyete uygun yargılanma (silahların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkı) 148
1) Bilgi sahibi olma hakkı 149
2) Açıklama ve ispat hakkı 150
3) Dikkate alınma hakkı ve kararların gerekçeli olması 151
B) Tasarruf ilkesi 151
C) Kendiliğinden (resen) harekete geçme ilkesi 153

D) Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi 154
E) Kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi 155
F) Taleple bağlılık ilkesi 156
G) Usul ekonomisi 157
H) Teksif ilkesi 157
İ) Doğrudanlık ilkesi 158
J) Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi 159
K) Davayı aydınlatma ödevi 160
L) Sözlülük-yazılılık ilkesi 161
M) Hâkimin hukuku uygulaması 162
I - Genel olarak 162
II - Yabancı hukukun uygulanması 163
N) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 163

§ 6. USUL İŞLEMLERİ 165
A) Genel olarak hukukî işlem 165
B) Usul işlemi ve çeşitleri 165
I - Tanım 165
II - Çeşitleri 166
1) Taraf usul işlemleri 166
2) Mahkeme usul işlemleri 168
III - Usul işlemlerinin özellikleri 169

§ 7. SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 171
A) Süreler 171
I - Genel olarak 171
II - Sürelerin çeşitleri ve özellikleri 171
III - Sürelerin başlaması ve hesaplanması 173
IV- Adlî tatil 175
B) Eski hale getirme 178
I - Genel olarak 178
II - Eski hale getirme talebinin koşulları 178
III - Eski hale getirme talebinin süresi 179
IV - Eski hale getirme talebinin şekli, kapsamı ve incelenmesi 180

§ 8. TEBLİGAT 183
A) Tebligatın amacı ve önemi 183
B) Tebligat yapılma şekilleri 184

C) Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı 186
I - Genel olarak 186
II - Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi 186
III - Tüzel kişilere tebligat 190
IV - Tebligatta özel bazı durumlar 190
V - İlânen tebligat 191
VI - Usulsüz tebligat 191
D) Tebligat suçları 192

MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ

§ 9. GÖREV 196
A) Ana kural 196
I- Asliye hukuk mahkemesi 196
II- Asliye ticaret mahkemelerinin durumu 197
1) Ticarî dava kavramı 197
a) Mutlak ticarî davalar 197
b) Nispî ticarî davalar 198
2) Ticarî davalara bakan mahkemeler 198
a) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerler 199
b) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerler 200
B) Ana kuralın istisnaları 200
I - Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu davalar ve işler 200
1) Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar 200
2) Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları 201
3) Yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar 201
4) Çekişmesiz yargı işleri 202
5) HMK'nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini görevlendirdiği dava ve işler 202
II - Özel görevli mahkemelerin görevli olduğu davalar ve işler 203
C) Kişivarlığı haklarına ilişkin dava ve işlerde asliye hukuk mahkemesi görevlidir 203
D) Görev kurallarının niteliği 204
E) Mahkemenin görevli olup olmadığını incelemesi 204

F) Görevsizlik kararı 206
G) Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 206

§ 10. YETKİ 209
A) Genel olarak 209
B) Yetki türleri 210
I - Genel yetki 210
1) Gerçek kişilerin yerleşim yeri (ikametgâhı) 211
a) Türkiye'de yerleşim yeri olanlara karşı dava açılması ... 211
b) Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlara karşı dava açılması 211
aa) Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılacak malvarlığı haklarına ilişkin davalarda genel yetki 212
bb) Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılacak kişivarlığı haklarına ilişkin davalarda genel yetki 212
2) Tüzel kişilerin yerleşim yeri 213
3) Davalıların birden fazla olması halinde genel yetkili mahkeme 213
a) Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olması 213
b) İstisnalar 213
aa) Ortak yetkili mahkeme bulunması 213
bb) Davanın sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açılması 214
4) Genel yetki kurallarının niteliği 215
II - Özel yetki kuralları 215
1) Sözleşmeden doğan davalarda yetki 216
a) Genel bilgi 216
b) Sözleşmeden doğan davalarda yetkinin niteliği 217
2) Haksız fiilden doğan davalarda yetki 217
3) Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 218
4) Miras ile ilgili davalarda yetki 220
a) Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkisi 220
b) Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin olmayan yetkisi 221
5) Karşı davada yetki 221

6) Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi 222
7) Sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki 223
a) Zarar (mal) sigortalarında 223
b) Can (hayat) sigortalarında 223
c) Malî mesuliyet sigortasında 223
8) Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi 223
9) Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 224
10) Diğer Kanunlardaki özel yetki kuralları 224
a) Türk Medenî Kanunundaki özel yetki kuralları 224
b) Türk Ticaret Kanunundaki özel yetki kuralları 226
c) İcra ve İflâs Kanunundaki özel yetki kuralları 226
d) Özel görevli mahkemelerin kuruluşuna ilişkin Kanunlardaki yetki kuralları 226
11) Türkiye'nin her yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu haller 227
III - Yetki kurallarının niteliği 227
1) Kesin yetki kuralları 227
2) Kesin olmayan yetki kuralları 228
C) Tarafların yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmaları 228
I - Yetki sözleşmesi 228
1) Genel bilgi 228
2) Yetki sözleşmesinin yapılmasının mümkün olduğu haller 230
a) Yalnızca tacirler veya kamu tüzel kişileri yetki sözleşmesi yapabilirler 230
b) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konularla kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi yapılamaz 230
3) Yetki sözleşmesinin şekli 231
4) Uyuşmazlığın belirli veya belirlenebilir olması 231
5) Mahkemenin veya mahkemelerin belli olması 231
6) Yetki sözleşmesinin kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırıp kaldırmayacağı 232
7) Yetki sözleşmesinin etkisi 232
II - Davalının yetki itirazında bulunmaması 233
D) Yetki İtirazı 233
I - Yetki itirazında bulunma süresi 234

II - Yetki itirazının yapılması 234
III - Yetki itirazının incelenmesi 235
IV - Yetki itirazının reddi 235
V - Yetkisizlik kararı 235
VI - Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 236
E) Yetkinin kesin olduğu hallerde yetki itirazı 237

§ 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ 239
A) Yargı yeri belirlenmesi sebepleri 239
I - Görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına bir engel çıkması 239
II - İki mahkemenin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmesi 240
III - İki mahkemenin yargı çevreleri konusunda tereddüt edilmesi 241
IV - Kesin yetki kuralının bulunduğu bir halde iki mahkemenin verdiği yetkisizlik kararının kesinleşmesi 242
B) İnceleme yeri, usulü ve sonucu 243

§ 12. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE) 244
A) Genel olarak 244
B) Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında hukukî yardım (istinabe) 246
C) Naip tayini 247

DAVA

§ 13. TARAFLAR 250
A) Taraf ehliyeti 251
I - Genel bilgi 251
II - Gerçek kişilerin taraf ehliyeti 251
1) Her gerçek kişinin taraf ehliyeti vardır 251
2) Ölüm ile taraf ehliyeti son bulur 252
3) Dava açıldıktan sonra ölen tarafın taraf ehliyeti kalmaz 254
III - Tüzel kişilerin taraf ehliyeti 254
1) Özel hukuk tüzel kişileri 255
2) Kamu tüzel kişilerinin taraf ehliyeti 255
IV - Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların taraf ehliyeti de yoktur 256

1) Adî ortaklığın taraf ehliyeti yoktur 256
2) Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur 257
V - Bir davada tarafların taraf ehliyetine sahip olmaları dava şartlarındandır 258
B) Dava ehliyeti 258
I - Gerçek kişilerin dava ehliyeti 259
1) Tam dava ehliyetine sahip olanlar 259
2) Sınırlı dava ehliyetine sahip olanlar 259
3) Dava ehliyeti olmayanlar 260
4) Yasal temsilcinin dava ehliyeti olmayan tarafı davada temsil etmesi 260
a) Veli 261
b) Vasi 261
c) Kayyım 261
II - Gerçek kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır 262
III - Tüzel kişilerin dava ehliyeti ve davada temsili 263
1) Özel hukuk tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili 263
2) Kamu tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili 263
IV - Tüzel kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır 264
C) Dava takip yetkisi 265
D) Taraf sıfatı (husumet) 266

§ 14. DAVAYA VEKÂLET 269
A) Giriş 269
B) Davada vekille (avukatla) temsil zorunluluğu yoktur 270
C) Davada vekil olabilecek kişiler 270
I - En az üç avukat bulunan yerler 271
II - Üç avukat bulunmayan yerler 271
D) Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişiler dava takip edemez 272
E) Vekâletin verilmesi 273
I - Vekâletname 273
II - Vekâletnamenin şekli 274
F) Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi 275
I - Vekil, vekâletnameyi mahkemeye vermekle yükümlüdür 275
II - Vekâletnamenin mahkemeye verilmemesi halinde yapılacak işlemler 276

1) Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek isteyen kişinin vekâletnamesini vermemesi 276
2) Vekâletnamesiz dava açılması 277
G) Davaya vekâletin kapsamı 278
I - Davaya vekâletin kanunî kapsamı 278
II - Vekile özel yetki verilmesini gerektiren haller 279
H) Davanın birden fazla vekil ile takibi 280
J) Davaya vekâletin sona ermesi 281
I - Vekilin istifası 281
II - Vekilin azli ve diğer sona erme halleri 282
K) Vekil ile takip edilen davalarda müvekkilin durumu 283
L) Avukatlık (vekâlet) ücreti 284

§ 15. DAVA ŞARTLARI 285
A) Dava şartları kavramı 285
B) Dava şartlarının çeşitleri 286
I - Mahkemeye ilişkin dava şartları 286
1) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması 286
a) Yargı hakkının ülke yönünden sınırları 286
b) Yargı hakkının kişi yönünden sınırları 286
aa) Yabancı devletlerin yargı muaflığı 286
bb) Diplomatik temsilcilerin yargı muafiyeti 287
2) Yargı yolunun caiz olması 288
3) Mahkemenin görevli olması 288
4) Kesin yetki hallerinde mahkemenin yetkili olması 288
II - Taraflara ilişkin dava şartları 288
1) Davada iki tarafın bulunması 288
2) Taraf ehliyeti 288
3) Dava ehliyeti 289
4) Dava takip yetkisi 289
5) Yasal temsilcinin gerekli niteliğe sahip olması 289
6) Davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname 289
7) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi 289
III - Dava konusuna ilişkin dava şartları 290
1) Davacının yatırması gerekli gider avansının yatırılmış olması 290

2) Davacının dava açmakta hukukî yararının bulunması 290
a) Eda davalarında hukukî yarar 291
b) Tespit davalarında hukukî yarar 292
c) Belirsiz alacak ve tespit davalarında hukukî yarar 292
d) İnşaî davalarda hukukî yarar 293
e) Her talep için hukukî yarar şarttır 293
3) Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması 294
4) Kesin hüküm bulunmaması 294
IV - Özel kanunlardaki özel dava şartları 294
C) Dava şartlarının incelenmesi 295

§ 16. DAVA ÇEŞİTLERİ 298
A) Mahkemeden istenen hukukî korunmaya göre dava çeşitleri 298
I - Eda davaları 298
1) Genel bilgi 298
2) Kısmî dava 299
3) Belirsiz alacak ve tespit davaları 301
II - Tespit davaları 303
1) Genel bilgi 303
2) Tespit davası eda davasının öncüsüdür 304
3) Tespit davasının şartları 304
a) Hak veya hukukî ilişki şartı 305
b) Hukukî yarar şartı 305
c) Hak, hukukî ilişki ve hukukî yarar dava şartıdır 306
4) Tespit davası çeşitleri 307
a) Müspet tespit davası 307
b) Menfi tespit davası 307
5) Tespit hükmü 307
III - İnşaî davalar 308
1) Genel bilgi 308
2) İnşaî dava bir inşaî hakka dayanır 308
3) İnşaî davada verilen hüküm 309
4) İnşaî dava çeşitleri 310
a) Geleceğe etkili inşaî davalar 310
b) Geçmişe etkili inşaî davalar 310
B) Dava konusu hakkın niteliğine göre dava çeşitleri 311

C) Dava konusu mala göre dava çeşitleri 311
D) Dava konusunun aynî hak veya zilyetlik olmasına göre dava çeşitleri 311
E) Talep sonucunun sayısına göre dava çeşitleri 311
I - Terditli davalar 311
1) Genel bilgi 311
2) Terditli davaların çeşitleri 312
a) Taleplerin dayandığı vakıaların aynı olması 312
b) Taleplerin dayandığı vakıaların farklı olması 313
3) Terditli davanın incelenmesi 313
II - Seçimlik davalar 313
III - Davaların yığılması 314
IV - Hakların yarıştığı davalar 315
F) Talep sonucundan yararlanacaklara göre dava çeşidi olarak topluluk davası 316
G) Seri dava 317

§ 17. DAVA AÇILMASI 318
A) Genel bilgi 318
B) Dava dilekçesi 318
I - Dava dilekçesinin içeriği 319
1) Mahkemenin adı 319
2) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri 320
a) Davacının adı, soyadı ve adresi 320
b) Davalının adı ve soyadı ve adresi 320
3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 320
4) Varsa tarafların yasal temsilcileri ve davacı vekilinin ad ve soyadları ile adresleri 321
5) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri 321
6) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri 322
7) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği 324
8) Dayanılan hukukî sebepler 325
9) Açık bir şekilde talep sonucu 326
10) Davacının (varsa yasal temsilcisinin veya vekilinin) imzası 328

II - Dava dilekçesinde eksiklik bulunması 328
III - Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi 329
IV - Davanın açılma zamanı 330
V - Tensip tutanağı 331
§ 18. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 332
A) Dava açılmasının maddî hukuk bakımından sonuçları 332
I - Zamanaşımının kesilmesi 332
II - Hak düşürücü sürenin korunması 332
III - Bazı kişivarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi 332
IV - İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi 333
V - Davalının mütemerrit olması 333
B) Dava açılmasının usul hukuku bakımından sonuçları 333
I - Mahkemenin davayı incelemesi zorunluluğu doğar 333
II - Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre belirlenir 333
III - Dava, açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanır 334
IV - Derdestlik durumu ortaya çıkar 334
V - İhtiyati tedbir ve/veya ihtiyatî haciz korunur 335
VI - Davayı geri alma yasağı 335
C) Dava açılmasının diğer sonuçları 336

§ 19. DAVAYA CEVAP 337
A) Genel bilgi 337
B) Davalının cevapları 337
I - Davalının davayı kabul etmesi 337
II - Davalının dava dilekçesindeki vakıalara karşı koyması 338
1) Davalı dava dilekçesindeki vakıaları inkâr edebilir 338
2) Davalı dava dilekçesindeki vakıaların davayı haklı gösterecek nitelikte olmadığını bildirebilir 338
III - Davalının lehine olan karşı vakıalar ileri sürmesi 339
1) Maddî hukuka dayanan savunma araçları 339
a) Def'iler 339
b) İtirazlar 340
2) Usul hukukuna dayanan savunma araçları 340
a) İlk itirazlar 340
b) Diğer usulî itirazlar 341
C) Cevap dilekçesi 341
I - Cevap dilekçesinin içeriği 341

1) Mahkemenin adı 341
2) Davacı ile davalının adı ve soyadı ve adresleri 342
3) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 342
4) Varsa tarafların yasal temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri 342
5) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri 342
6) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği 342
7) Dayanılan hukukî sebepler 342
8) Açık bir şekilde talep sonucu 343
9) Davalının veya varsa yasal temsilcisinin yahut vekilinin imzası 343
II - Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 343
III - Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi 343
D) Cevap süresi 344
I - Cevap süresi 344
II - Cevap süresinin uzatılması 345
E) Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 345
F) Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonuçları 345

§ 20. CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ 346
A) Cevaba cevap dilekçesi 346
B) İddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı 347
I - Genel bilgi 347
II - İddiayı genişletme veya değiştirme sayılan haller 348
1) Talep sonucunu genişletmek veya değiştirmek 348
2) Dava sebebini genişletmek veya değiştirmek 349
III - İddiayı genişletme veya değiştirmenin yasak olmadığı haller 350
1) Talep edilenden başka bir şeye de hüküm verilebilen haller 350
2) Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar 351
3) Dava açılmasından sonra doğan olaylar 351
4) Belirsiz alacak davası bakımından kabul edilen özel durum 351
5) Tarafta iradî değişiklik 352
IV - İddiayı genişletme veya değiştirme yasağının istisnaları 353

C) İkinci cevap dilekçesi 354
D) Savunmayı genişletme ve değiştirme yasağı 355
I - Genel bilgi 355
II - Savunmayı genişletme sayılan haller 356
1) Def'iler 356
2) Vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi savunmayı genişletmedir 356
3) İtirazların ileri sürülmesi ve savunmayı genişletme 357
III - Savunmayı genişletme yasağının istisnaları 357
IV - Savunmayı genişletmenin yasak olmadığı haller 359
1) Mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken hususlar 359
2) Sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi 359

YARGILAMA
(ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)

§ 21. ÖN İNCELEME 362
A) Genel bilgi 362
B) Ön incelemenin kapsamı 363
C) Ön inceleme duruşması 365
I - Ön inceleme duruşmasına davet 365
II - Ön inceleme duruşmasının yapılması 365
§ 22. YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ 368
A) Genel bilgi 368
B) Yargılamanın yapılış biçimi 368
I - Duruşma 368
1) Genel bilgi 368
2) Duruşma yapılması zorunludur 370
3) Tarafların duruşmaya çağrılması 370
4) Duruşma gününün ve saatinin belirlenmesi 371
II - Tutanaklar 372
III - Dava dosyası 373
§ 23. TAHKİKAT 374
A) Genel olarak 374
B) Tahkikatın yapılması 374

§ 24. İSTİCVAP 376
A) Genel bilgi 376
B) İsticvabın konusu 377
C) İsticvap usulü 377

İSPAT VE DELİLLER

§ 25. GENEL HÜKÜMLER 380
A) İspatın konusu ve delil 380
B) Delilin konusu 381
C) İspat hakkı 382
D) İspat yükü 383
I - Genel bilgi 383
II - İspat yükü, zamanı ve önemi 384
III - İspat yükü konusunda genel kural 385
IV - Genel kuralın istisnaları 385
1) Normal durumun aksinin ispatı 385
2) İspat yükünün kanunla belirlendiği haller 386
3) Karineler 387
a) Fiilî karineler 387
b) Kanunî karineler 387
V - Karşı ispat 388

§ 26. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE DELİL ÇEŞİTLERİ 390
A) Delillerin gösterilmesi 390
I - Genel bilgi 390
II - Delillerin hasredilmesi 391
III - Delillerin incelenmesi 392
IV - Delillerin incelenmesinden sonra yeni delil gösterilmesi 392
B) Hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller 393
C) Delil çeşitleri 394
I - Kesin deliller 394
II - Takdirî deliller 395

§ 27. İKRAR 396
A) İkrarın niteliği ve konusu 396
B) İkrarın yapılış şekli 397
I - Mahkeme dışı ikrar 397

II - Mahkeme içi ikrar 397
III - İkrardan dönme 397
C) İkrarın etkisi 398
D) İkrarın çeşitleri ve bölünmesi 398
I - Basit ikrar 398
II - Nitelikli ikrar 399
III - Bileşik ikrar 399
1) Bağlantılı bileşik ikrar 400
2) Bağlantısız bileşik ikrar 401

§ 28. SENET VE BELGE 402
A) Kavram 402
B) Senet çeşitleri 403
I - Adî senetler 404
1) Kavram ve içeriği 404
2) Adî senetlerin ispat gücü 404
a) Adî senet kesin delildir 404
b) Sahtelik iddiası 405
c) Sahtelik davası 406
3) Adî senetlerin üçüncü kişiler hakkında ispat gücü 408
II - Resmî senetler 408
1) Genel bilgi 408
2) Noter senetleri 409
a) Düzenleme biçimindeki noter senetleri 409
b) Onaylama biçimindeki noter senetleri 410
c) Yabancı ülkelerde düzenlenen noter senetleri 410
3) Resmî makamların yetkileri dahilinde usulüne göre düzenledikleri belgeler 410
4) Resmî senetlerin ispat gücü 411
a) Genel bilgi 411
b) Resmî senetlerin sahteliği ve sahtelik davası 411
III - Senetlerdeki çıkıntılar ve silintiler 413
C) Belgelerin mahkemeye verilmesi 414
I - Genel bilgi 414
II - Belgelerin mahkemeye verilmesi zorunluluğu 415
1) Mahkemeye verilmesi zorunlu olan belgeler 415
2) Belgeyi vermek zorunda olan kişiler 416

D) Senetle ispat zorunluluğu 418
I - Genel bilgi 418
II - Kanundaki ispat sınırından fazla hukukî işlemlerin senetle ispatı zorunludur 419
1) Birinci ana kural 419
2) Birinci ana kuralın istisnaları 420
a) Yakın hısımlar arasındaki hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir 420
b) Senede bağlanmaması gelenek olan hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir 421
c) Senet alınması mümkün olmayan haller 422
d) Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir 422
e) Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir 423
f) Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir 423
g) Haksız fiilden doğan tazminat alacakları tanıkla ispat edilebilir 424
h) Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir 424
i) Delil sözleşmesi varsa 426
j) Kadastro davaları 426
3) İstisnalar dışında birinci ana kural uygulanır 426
4) Hukukî fiiller tanıkla ispat edilir 427
III - Senede karşı senetle ispat zorunluluğu 428
1) İkinci ana kural 428
2) Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 430
a) İkinci ana kuralın istisnaları daha azdır 430
b) Senet alınması mümkün olmayan haller 431
c) Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir 431
d) Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir 432
e) Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir 432
f) Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir 433
g) Delil sözleşmesi varsa 433
h) Senede karşı haksız fiil iddiası varsa 433

3) İstisnalar dışında senede karşı senetle ispat kuralı uygulanır 433

§ 29. YEMİN 435

A) Genel bilgi 435

B) Yemin teklifi 435

C) Kendisine yemin teklif edilen tarafın yemin için davet edilmesi ve buna karşı davranışı 437

I - Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelmezse 438

II - Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelirse 438

1) Yemin teklifinin kabulü ve yemin edilmesi 438

2) Yeminden kaçınma 439

3) Yeminin iadesi 439

D) Yemin taraflarca edilir 440

E) Usul hükümleri 440

TAKDİRÎ DELİLLER

§ 30. TANIK 443

A) Genel bilgi 443

B) Tanık ile ispatın mümkün olduğu haller 443

C) Tanıkların gösterilmesi 444

D) Tanıkların mahkemeye davet edilmesi 445

E) Tanıklık etmek zorunludur 445

F) Tanıklıktan çekinme 446

I - Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 446

II - Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 446

III - Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 447

IV - Tanıklıktan çekinmenin caiz olmadığı haller 447

V - Tanıklıktan çekinme usulü 447

G) Tanıkların dinlenmesi 448

H) Hâkim tanık ifadelerini serbestçe takdir eder 449

§ 31. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 450

A) Bilirkişi kavramı ve tanıktan farkı 450

B) Bilirkişi incelemesini gerektiren haller 451

C) Bilirkişi incelemesine karar verilmesi 453

D) Bilirkişi seçimi, görevlendirilmesi ve görevin yerine getirilmesi ... 454

E) Bilirkişinin yasaklılığı ve reddi 456
F) Bilirkişilik yapmak kural olarak zorunlu değildir 456
G) Bilirkişi incelemesi ve sonucunun sunulması 457
H) Bilirkişi oy ve görüşüne itiraz 458
İ) Hâkim bilirkişi oy ve görüşünü serbestçe değerlendirir 459
J) Bilirkişi gider ve ücreti 461
K) Bilirkişinin sorumluluğu 461
L) Kasten gerçeğe aykırı raporun yargılamanın iadesi nedeni olması 462

§ 32. KEŞİF 463

§ 33. UZMAN GÖRÜŞÜ 466

§ 34. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DİĞER DELİLLER 467

§ 35. DELİL SÖZLEŞMESİ 468
A) Genel bilgi 468
B) Delil sözleşmesinin çeşitleri 468
I - Münhasır delil sözleşmesi 469
II - Münhasır olmayan delil sözleşmesi 470
C) Delil sözleşmesinin şekli 470

YARGILAMA ve HÜKÜM

§ 36. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKMÜN VERİLMESİ 472
A) Tahkikatın sona ermesi 472
B) Sözlü yargılama 473
C) Hükmün verilmesi 473

§ 37. HÜKÜM 475
A) Karar çeşitleri 475
I - Ara kararları 475
II - Nihaî kararlar 476
1) Hükümler 476
2) Usule ilişkin nihaî kararlar 477
3) Davanın konusuz kalması halinde verilen kararlar 478
B) Hüküm 479
C) Hükmün doğurduğu sonuçlar 483

DAVADA ÖZEL DURUMLAR

§ 38. ÖN SORUN 486
A) Kavram 486
B) Ön sorunların incelenmesi 487

§ 39. BEKLETİCİ SORUN 488
A) Genel bilgi 488
B) Bekletici sorun çeşitleri 488
I - Zorunlu bekletici sorun 490
1) Anayasa mahkemesi kararının beklenmesi 490
2) Uyuşmazlık mahkemesi kararının beklenmesi 490
3) İcra mahkemesinin bekletici sorun yapması 490
II - İhtiyarî bekletici sorun 491
1) Görülmekte olan bir davanın bekletici sorun yapılması 491
2) Yeni açılacak bir davanın bekletici sorun yapılması 494

§ 40. DAVANIN İHBARI 495
A) Kavram 495
B) Davayı ihbar usulü 496
C) Davayı ihbarın sonuçları 497

§ 41. DAVAYA MÜDAHALE 499
A) Ferî müdahale 499
I - Kavram 499
II - Ferî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları 500
B) Davaya aslî müdahale (aslî müdahale davası) 504
I - Kavram 504
II - Aslî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları 505

§ 42. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 507
A) Davaların birleştirilmesi 507
I - Kavram 507
II - Davaların birleştirilmesi usulü 508
B) Davaların Ayrılması 511
I - Kavram 511
II - Davaların ayrılması usulü 512

§ 43. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 514
A) Genel olarak 514
B) Dava konusunun davalı tarafından üçüncü kişiye devri 515
I - Davacı isterse, davalıya karşı açtığı davadan vazgeçerek davayı dava konusunu devir alan üçüncü kişiye devam ettirir 515
II - Davacı, isterse davalıya karşı açmış olduğu davasını tazminat davasına dönüştürür 516
C) Dava konusunun davacı tarafından üçüncü kişiye devri 517

§ 44. KARŞI DAVA 519
A) Genel bilgi 519
B) Karşı dava açılabilmesinin şartları 519
I - Asıl davanın görülmekte olması gerekir 520
II - Asıl dava ile karşı dava arasında yakın ilişki bulunması gerekir 520
1) Takas veya mahsup ilişkisi bulunması 520
2) Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunması 521
III - Karşı davanın caiz olmaması 522
C) Karşı dava açma süresi 522
D) Karşı davanın açılması 523
E) Karşı davaya cevap 523
F) Karşı davada hüküm 524

§ 45. ISLAH 525
A) Genel olarak 525
B) Islahın yapılması usulü 528
I - Tamamen ıslah 530
II - Kısmen ıslah 530
C) Islahın etkisi 531
D) Maddî hataların düzeltilmesi 532

§ 46. DAVADA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 533
A) Genel olarak 533
B) HMK'na göre teminat gösterilmesi 533
I - Türkiye'de mutat meskeni bulunmayan Türk vatandaşının teminat göstermesi 534
II - Ödeme güçlüğü içinde bulunanın teminat göstermesi 535

III - Teminat gösterilmesinin istisnaları 535
IV - Teminat tutarı 537
C) Türk vatandaşı olmayanların (yabancıların) teminat göstermesi 537

§ 47. DAVA ARKADAŞLIĞI 539
A) Dava arkadaşlığı kavramı 539
B) İhtiyarî dava arkadaşlığı 540
I - İhtiyarî dava arkadaşlığının mümkün olduğu haller 540
1) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması 540
2) Ortak bir işlemle, davacıların veya davalıların hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmeleri 541
3) Davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukukî sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması 541
II - İhtiyarî dava arkadaşlığında usul 542
C) Zorunlu (mecburî) dava arkadaşlığı 544
I - Zorunlu dava arkadaşlığının çeşitleri 544
1) Maddî zorunlu dava arkadaşlığı 544
2) Şeklî zorunlu dava arkadaşlığı 545
II - Zorunlu dava arkadaşlığında usul 546
1) Maddî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır 547
2) Şeklî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorunda değildir 548

§ 48. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 549
A) Genel olarak 549
B) Dava dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren haller 549
C) Dosyanın işlemden kaldırılması kararı ve sonuçları 551
D) Davanın yenilenmesi 552
E) Dosyanın yeniden işlemden kaldırılması 553
F) İşlemden kaldırılan davanın açılmamış sayılması ve sonuçları .. 554

DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

§ 49. DAVADAN FERAGAT 557
A) Genel olarak 557
B) Davadan feragat usulü ve davadan feragatin sonuçları 557

§ 50. DAVAYI KABUL 562
A) Genel olarak 562
B) Davayı kabul usulü ve davayı kabulün sonuçları 562

§ 51. SULH 566
A) Genel olarak 566
B) Sulh usulü ve sulhun sonuçları 567

GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR

§ 52. İHTİYATÎ TEDBİRLER 573
A) Genel olarak 573
B) İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesinin şartları 573
C) İhtiyatî tedbir usulü 574
D) İhtiyatî tedbir kararının uygulanması 577
E) İhtiyatî tedbirin kalkması 577
F) Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası 579

§ 53. DELİL TESPİTİ 582
A) Genel bilgi 582
B) Delil tespitinin istenebileceği haller 583
C) Delil tespiti usulü 583

KANUN YOLLARI

§ 54. KANUN YOLU KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 586
A) Kanun yolu kavramı 586
B) Kanun yolu çeşitleri 588
I - Olağan kanun yolları 588
II - Olağanüstü kanun yolları 589
C) Genel olarak kanun yollarına başvuru usulü 589
D) Uygulanacak olan kanun yolları hükümleri 591

§ 55. İSTİNAF 593
A) Niteliği 593
B) İstinaf sistemine egemen olan ilkeler 594
C) Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilen kararlar 595
I - İlk derece mahkemesi kararı olması şartı 595

II - Nihaî karar şartı 595
III - Belli parasal sınırı (istinaf sınırını) geçme şartı 596
D) İstinaf sebepleri 597
E) İstinaf süresi 597
F) İstinaf dilekçesi 597
I - İstinaf dilekçesinin hazırlanması 598
II - İstinaf dilekçesinin verilmesi 598
III - Gerekli harç ve giderlerin ödenmesi 599
IV - İstinaf dilekçesinin kararı veren mahkeme tarafından usulden reddi 600
G) İstinaf dilekçesine cevap 600
H) İstinaf yoluna başvurma hakkından feragat 600
İ) Katılma yoluyla istinafa başvurma 601
J) İstinaf yoluna başvurmanın icraya etkisi 601
K) Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 602
L) İstinaf mahkemesinin ön inceleme yapması 602
M) İstinaf mahkemesinde esastan inceleme (tahkikat) 603
I - Genel olarak 603
II - İncelemenin kapsamı 604
III - Duruşma 604
a) Duruşma yapılmasına gerek olmayan durumlar 604
b) Duruşma yapılmasına karar verilecek olan durumlar 606
c) Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 606
N) İstinaf mahkemesinde yapılamayacak işlemler 606
O) İstinaf mahkemesi kararı 607
I - Duruşma yapmadan verilen kararlar 608
II - Duruşmalı verilen kararlar 609
Ö) İstinaf mahkemesinde uygulanacak diğer hükümler 610

§ 56. TEMYİZ 611
A) Niteliği 611
B) Temyiz edilebilen kararlar 612
C) Temyiz edilemeyen kararlar 612
D) Temyiz sebepleri 613
E) Temyiz süresi 614
F) Temyiz dilekçesi 614
I - Temyiz dilekçesinin hazırlanması 614

II - Temyiz dilekçesinin verilmesi 615
III - Temyiz dilekçesi üzerine yapılacak işlemler 615
G) Temyiz dilekçesine cevap 616
H) Katılma yoluyla temyize başvurma 616
İ) Temyiz yoluna başvurma hakkından feragat 617
J) Yargıtay'ın ön inceleme yapması 617
K) Temyiz yoluna başvurmanın icraya etkisi 617
L) Kötüniyetli temyiz başvurusunda bulunulması 618
M) Yargıtay'da asıl inceleme 618
N) Yargıtay kararı 619
I - Bozma kararı 620
II - Onama kararı 624
III - Düzelterek onama kararı 624
IV - Yargıtay kararının tebliği 624
O) Bozmaya uyma veya direnme 624

§ 57. KANUN YARARINA TEMYİZ 626

§ 58. YARGILAMANIN İADESİ 628
A) Konusu 628
B) Yargılamanın iadesi sebepleri 629
I - Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması 629
II - Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara katılmış bulunması 630
III - Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması 630
IV - Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen (bulunamayan) bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması 631
V - Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin sahte olduğunun mahkeme veya resmî makam önünde ikrar edilmiş olması 632
VI - İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının sabit olması 633
VII - Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması 633

VIII - Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin, ikrar veya yazılı delille sabit olması 634
IX - Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkmış olması 635
X - Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli bir davranışta bulunmuş olması 635
XI - Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de kesinleşmiş olması 635
XII - Kararın, insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararı ile tespit edilmiş olması veya dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucu düşme kararı verilmesi 636
C) Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 637
D) Yargılamanın iadesi süresi 638
E) Yargılamanın iadesi usulü 639
F) Yargılamanın iadesine konu olmayan kararlar 642

§ 59. TEMYİZ (HUMK M. 427-439, 443-444'E GÖRE) 643
A) Genel olarak 643
B) Temyiz edilebilen kararlar 643
C) Temyiz edilemeyen kararlar 644
D) Temyiz sebepleri 646
I - Maddî hukuka dayanan temyiz sebepleri 646
II - Usul hukukuna dayanan temyiz sebepleri 647
1) Mutlak temyiz sebepleri 647
2) Nispî temyiz sebepleri 648
E) Temyiz yoluna başvurulması 649
I - Temyiz süresi 650
II - Temyiz talebi 650
1) Temyiz dilekçesi 650
2) Temyiz dilekçesine cevap 651
3) Dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi 652
III - Temyize başvurmanın hükmün icrasına etkisi 653

F) Temyiz incelemesi 653
G) Yargıtay kararı 656
I - Bozma kararı 657
1) Mahkemenin bozma kararına uyması 658
2) Mahkemenin kendi kararında direnmesi 659
II - Onama kararı 661
III - Hükmün düzeltilerek onanması 662
H) Kanun yararına temyiz 662

§ 60. KARAR DÜZELTME 664
A) Düzeltilmesi istenebilecek kararlar 665
B) Karar düzeltme sebepleri 668
C) Karar düzeltme yoluna başvurulması 669
D) Karar düzeltme talebinin incelenmesi 670
I) Karar düzeltme talebinin esastan reddedilmesi 671
II) Karar düzeltme talebinin esastan kabul edilmesi 672

§ 61. YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) 673
A) Yargılamanın iadesi sebepleri 673
I - Yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmiş olması 674
II - Hükme esas alınan senedin sahte olduğunun sonradan anlaşılması 675
III - Hükme esas alınan bir ilâmın kesin bir hükümle ortadan kalkmış olması 676
IV- İfadesi hükme esas alınan bir tanığın hükümden sonra yalan tanıklıktan mahkûm edilmiş olması 676
V - Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun bir mahkeme hükmü ile sabit olması 676
VI - Lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin kendi ikrarı veya yazılı delil ile sabit olması 677
VII - Lehine hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile kullanmış olması 677
VIII - Vekil veya temsilci olmayan kişiler huzuru ile davanın görülüp hükme bağlanmış bulunması 678
IX - Davaya bakması yasak olan bir hâkim tarafından davaya bakılmış ve hüküm verilmiş olması 679
X - Tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir dava hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması 679
XI - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararı 680

XII - Lehine hüküm verilen ile aleyhine hüküm verilen arasında hile yapılmış olması 680
B) Yargılamanın iadesi usulü 681
C) Yargılamanın iadesi istenemeyecek olan kararlar 684

KESİN HÜKÜM

§ 62. ŞEKLÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 686
A) Genel olarak 686
B) Şeklî anlamda kesinliğin meydana gelmesi 686
C) Şeklî anlamda kesinliğin sonuçları 686
D) Şeklî anlamda kesinliğin sona ermesi 686

§ 63. MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 688
A) Genel olarak 688
B) Maddî anlamda kesin hükmün şartları 688
I - Tarafların aynı olması 689
II - Dava sebeplerinin aynı olması 690
III - Dava konularının aynı olması 692
C) Maddî anlamda kesinliğin ortaya çıkması 694
D) Maddî anlamda kesin hükmün uygulama alanı 694
I - Kararların çeşidi bakımından 694
1) Maddî anlamda kesinliğe elverişli olmayan kararlar 694
2) Maddî anlamda kesinliğe elverişli olan kararlar 694
II - Kararın içeriği bakımından maddî anlamda kesin hükmün uygulama alanı 695
1) Hüküm sonucu 695
2) Gerekçe 695
E) Maddî anlamda kesin hükmün etkileri 696
I - Kesin hükmün bağlayıcı olması 696
II - Kesin hükmün olumsuz dava şartı olması 697
III - Kesin hükmün kesin delil olması 698
F) Maddî anlamda kesin hüküm ve yenilik doğuran etki 699

§ 64. HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İLE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ 700
A) Genel olarak 700
B) Hukuk mahkemesi kararlarının ceza mahkemesine etkisi 700

I - Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin hüküm oluşturması 700
II - Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin delil oluşturması 701
C) Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine etkisi 702
I - Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin hüküm oluşturması 702
II - Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturması 702
1) Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin hüküm oluşturduğu hallerde kesin delil oluşturması 702
2) Haksız fiilden doğan tazminat davalarında ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturması 703
3) Boşanma davalarında ceza mahkemesi kararının kesin delil oluşturması 704
4) Yargılamanın iadesinde ceza mahkemesi kararının kesin delil oluşturması 704
5) Bekletici sorun yapılan hallerde ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturması 705
III - Hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturan ceza mahkemesi kararının aksinin ispatı 705

§ 65. MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN SONA ERMESİ 706
A) Yargılamanın iadesi 706
B) Değişiklik davası 706

§ 66. HÜKMÜN TASHİHİ VE HÜKMÜN TAVZİHİ 708
A) Hükmün tashihi 708
B) Hükmün tavzihi 709
I - Tavzihi gerektiren haller 709
II - Tavzih usulü 710

YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM

§ 67. YARGILAMA HARÇLARI VE GİDERLERİ 713
A) Yargılama harçları 713
B) Yargılama giderleri 716
C) Yargılama harç ve giderlerinden sorumluluk 719

D) Avukatlık (vekâlet) ücreti 722
I - Müvekkil ile vekil arasındaki avukatlık ücreti 722
1) Ücret sözleşmesi yapılmış ise 723
2) Ücret sözleşmesi yapılmamış ise 724
II - Yargılama gideri olan vekâlet ücreti 724
III - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 726
IV - Ortak hükümler 727

§ 68. ADLÎ YARDIM 728
A) Kavram 728
B) Talepte bulunabilecekler ve adli yardımın koşulları 728
C) Adlî yardımın kapsamı 730
D) Adlî yardım talebi, inceleme, karar ve sonuçları 730
E) Adlî yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 731

BASİT YARGILAMA USULÜ ve ÇEKİŞMESİZ YARGI

§ 69. BASİT YARGILAMA USULÜ 733
A) Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler 733
B) Yargılama usulü 734

§ 70. ÇEKİŞMESİZ YARGI 737
A) Genel bilgi 737
B) Çekişmesiz yargı işleri 737
C) Çekişmesiz yargı usulü 738

ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER

§71. AİLE MAHKEMELERİ 741
A) Aile mahkemelerinin kuruluşu 741
B) Aile mahkemelerinin görevleri 742
C) Aile mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 742

§ 72. İCRA MAHKEMELERİ 744

§ 73. İŞ MAHKEMELERİ 745
A) İş mahkemelerinin kuruluşu 745
B) İş mahkemelerinin görevi 745

C) İş davalarında zorunlu arabuluculuk ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda kuruma başvurma zorunluluğu 746
D) İş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 747

§ 74. KADASTRO MAHKEMELERİ 749
A) Kadastro mahkemelerinin kuruluşu 749
B) Kadastro mahkemelerinin görevleri 749
C) Kadastro mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 750
§ 75. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 754
A) Tüketici mahkemeleri 754
I - Tüketici mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 754
II - Tüketici mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 755
B) Tüketici hakem heyetleri 756
I - Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu ve görevleri 756
II - Tüketici hakem heyetlerinde uygulanan inceleme usulü 757

§ 76. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ 761
A) Kuruluş 761
B) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bakımından açılacak davalar ve özellikleri 762
C) Sınai Mülkiyet Kanunu bakımından açılacak davalar ve özellikleri 763

§ 77. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI 767
A) Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi 767
I - Genel bilgi 767
II - Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine karar verilebilmesi için gerekli şartlar 767
III - Tenfiz usulü 768
1) Görevli ve yetkili mahkeme 768
2) Tenfiz talebi 768
3) Tenfiz talebinin incelenmesi ve karara bağlanması 769
B) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması 769
I - Genel bilgi 769
II - Tanımanın şartları 770
III - Tanıma usulü 770
1) Kesin hüküm itirazı için tanıma 770

2) Kesin delil için tanıma 770
3) İdarî bir işlemin yapılması için tanıma 770
4) Yabancı çekişmesiz yargı kararlarının tanınması 771
C) Yabancı hakem kararlarının tenfizi ve tanınması 771

BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI

§ 78. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 772
A) Genel olarak 772
B) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru 773
I - Kuruluş ve bireysel başvuru hakkı 773
II - Bireysel başvuru usulü 774
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru 776
I - Kuruluş ve bireysel başvuru hakkı 776
II - Bireysel başvuru usulü 776

§ 79. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 778
A) Genel bilgi 778
B) Arabuluculuğun konusu ve temel ilkeleri 778
C) Arabulucu 780
D) Arabuluculuk usulü 781

§ 80. TAHKİM 785
A) Genel olarak 785
B) Tahkimin niteliği 786
C) Tahkim sözleşmesi 788
I - Tahkim sözleşmesinin çeşitleri 789
II - Tahkim sözleşmesinin şartları 789
1) Yazılı şekil 789
2) Konusu 790
3) Uyuşmazlık belirli olmalıdır 790
III - Tahkim sözleşmesinin etkisi 790
D) Hakem sözleşmesi ve hakemler 792
I - Hakem sözleşmesi 792
II - Hakemler 792
1) Hakemlerin seçimi 792

2) Hakemlerin reddi 793
3) Hakem ücreti 794
E) Tahkim Usulü 794
I - Dava açılması 794
II - Yargılama usulü 795
III - Tahkim süresi 796
IV - Hakem kararı 797
F) Hakem kararlarına karşı başvuru yolu 798
I - İptal sebepleri 798
II - İptal usulü 799
III - Yargılamanın iadesi 800

§ 81 EKLER 801
Ek No: 1 - Dava dilekçesi 801
Ek No: 2 - Cevap dilekçesi 802

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 805

KISALTMALAR CETVELİ

AİHM	: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS	: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AK	: Avukatlık Kanunu
AK Ücret Tarifesi	: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
AK Yönetmeliği	: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
AYİMK	: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu
aşa.	: aşağıda
b.	: bent
BK	: (eski) Borçlar Kanunu
bkz.	: bakınız
C.	: Cilt
c.	: cümle
CD	: Yargıtay Ceza Dairesi
CGK	: Yargıtay Ceza Genel Kurulu
CK	: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
CMK	: Ceza Muhakemesi Kanunu
DK	: Danıştay Kanunu
dn.	: dipnot
f.	: fıkra
HD	: Yargıtay Hukuk Dairesi
HGK	: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

NOT:

1 - Kanun ismi verilmeden yalnız madde (m.) numarası ile anılan maddeler, kural olarak HMK'na aittir. İstisna olarak, kanun ismi verilmeden anılan madde (m.) numaraları, o konuyla ilgili olup, daha önce anılmış olan ana kanun maddelerini gösterir (örneğin, Kadastro Kanunu gibi).

2 - Madde numaralarından sonra gelen Arap rakamları fıkraları gösterir. Örneğin, m. 90, 1 kısaltması, HMK'nun 90. maddesinin birinci fıkrasını gösterir.

3 - Madde (bazen hem madde hem de fıkra) numaralarından sonra gelen ve onlardan bölme çizgisi (/) ile ayrılmış olan harfler ise bentleri gösterir. Örneğin, m. 114, 1/a kısaltması, HMK'nun 114. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendini gösterir.

4 - Madde (bazen hem madde hem de fıkra) numaralarından sonra (c.) kısaltmasını takip eden rakamlar, o maddenin (veya fıkranın) cümle numarasını gösterir. Örneğin m.150, 2/c. 2 kısaltması, HMK'nun 150. maddesinin ikinci fıkrasının 2. cümlesini gösterir.

HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HSK	: Hâkimler ve Savcılar Kurulu
HSYK	: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
HSKK	: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu
HUAK	: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
HUMK	: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İBK	: İçtihadı Birleştirme Kararı
İİK	: İcra ve İflâs Kanunu
İYUK	: İdarî Yargılama Usulü Kanunu
K.	: Kanun
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
karş.	: karşılaştırınız
m.	: madde
MERNİS	: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
MÖHUK	: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
MTK	: Milletlerarası Tahkim Kanunu
Niz.	: Nizamname
NK	: Noterlik Kanunu
RG	: Resmî Gazete
s.	: sayfa (veya sayılı)
sa.	: sayı
SEGBİS	: UYAP'ta ses ve görüntünün aynı anda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
TBK	: (Yeni) Türk Borçlar Kanunu
TCK	: Türk Ceza Kanunu
Teb.K.	: Tebligat Kanunu
Teb.Yön.	: Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
THH Yönetmeliği	: Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
TL	: Türk Lirası
TMK	: Türk Medenî Kanunu
TTK	: (Yeni) Türk Ticaret Kanunu
Tüz.	: Tüzük
UMK	: Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun

UYAP	: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
vb.	: ve benzeri
vd.	: ve devamı
vs.	: ve saire
VVM Tüz.	: Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
Y	: Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliği
YKD	: Yargıtay Kararları Dergisi
YSK	: Yüksek Seçim Kurulu
Yön.	: Yönetmelik
yuk.	: Yukarıda

GENEL KAYNAKÇA

Alangoya, Yavuz: *Medeni Usul Hukuku Esasları*, 3. Baskı, İstanbul 2003

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis: *Medeni Usul Hukuku Esasları*, 8. Baskı, İstanbul 2011

Ansay, Sabri Şakir: *Hukuk Yargılama Usulleri*, Ankara 1960

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan Ersin: *Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı*, Ankara 2018

Berkin, Necmettin: *Tatbikatçılara Medenî Usul Hukuku Rehberi*, İstanbul 1981

Bilge, Necip: *Medenî Yargılama Hukuku Dersleri*, Ankara 1967

Bilge, Necip / Önen, Ergun: *Medenî Yargılama Hukuku Dersleri*, Ankara 1978

Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol: *Medeni Usul Hukuku*, Ankara 2018

Görgün, Şanal L./Börü, Levent/Yorman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet: *Medenî Usûl Hukuku*, 6. Baskı, Ankara 2018

Karslı, Abdurrahim: *Medeni Muhakeme Hukuku*, 4. Baskı, İstanbul 2014

Kuru, Baki: *İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku*, İstanbul 2018

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: *Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı*, 24. Baskı, Ankara 2014

Muşul, Timuçin: *Medeni Usul Hukuku*, 3. Baskı, Ankara 2012

Önen, Ergun: *Medeni Yargılama Hukuku*, Ankara 1979

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: *Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı*, 5. Baskı, İstanbul 2018

Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya (Editörler): *Medenî Usul Hukuku (3 Cilt)*, İstanbul 2017

Postacıoğlu, İlhan E.: *Medenî Usul Hukuku Dersleri*, İstanbul 1975

Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer: *Medenî Usul Hukuku Dersleri*, 7. Baskı, İstanbul 2015

Sungurtekin Özkan, Meral: *Türk Medeni Yargılama Hukuku*, İzmir 2013

Tanrıver, Süha: *Medenî Usûl Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması*, 2. Baskı, Ankara 2018

Ulukapı, Ömer: *Medeni Usul Hukuku*, 3. Baskı, Konya 2015

Üstündağ, Saim: *Medeni Yargılama Hukuku*, Cilt I-II, 7. Baskı, İstanbul 2000

Yılmaz, Ejder: *Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (3 Cilt),* Ankara 2017

§ 1. MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ

A) KAVRAMSAL OLARAK MEDENÎ USUL HUKUKU

"Medenî usul hukuku" kavramı genel kabul görmekle birlikte, aynı anlama gelmek üzere, "medenî muhakeme hukuku", "hukuk usulü", "hukuk muhakemeleri usulü", "hukuk yargılama usulleri" veya "medenî yargılama hukuku" gibi kavramlar da kullanılmaktadır[1].

Bu alanın pozitif dayanağı olan Kanunun ismi ise, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu"dur (HMK). Görüldüğü üzere, bu isimde "usul" sözcüğü bulunmamaktadır.

Öte yandan Kanunun isminde "muhakeme" ifadesi yer almaktadır. Esasen, "yargılama" ve "muhakeme", tümüyle örtüşen kavramlar olmayıp, muhakeme daha geniş bir anlama sahiptir. Muhakeme, yargı organlarının yargılama faaliyeti dolayısıyla meydana gelen ve hukukî ilişkilerin süjeleri tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür. Başka bir ifadeyle "muhakeme", sürecin bütününü ve yargılamanın tüm süjelerini kapsarken; yargılama, yalnızca hâkim (mahkeme) tarafından gerçekleştirilen faaliyeti nitelemeye daha uygundur. Ayrıca, "yargılama", tüm bu süreç içerisinde yer alan kesitlerden yalnızca birisinin adıdır (m. 186). Muhakeme ise, sürecin bütününü ifade eden bir kavramdır.

Türk hukukunda usul hukuku düzenlemesi olmaları nedeniyle ortak görülebilecek alanlarda da kavram birliği olmadığı dikkat çekmektedir. Örneğin, ceza hukukunda, "Ceza Muhakemesi Kanunu"; idare hukukunda, "İdari Yargılama Usulü Kanunu" kavramı kullanılmıştır. Bugün yürürlükte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'ndan önceki Kanunumuzun adı ise "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu" (HUMK)'dur. Benzer bazı kanunlarda da "yargılama usulü" kavramı geçmektedir. Örneğin 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da da bunu görmek mümkündür. Dolayısıyla kavramlar birbirinin yerine kullanılmakta; özellikle de "yargılama" kavramı, çoğunlukla "muhakeme"yi kapsar şekilde anlaşılmaktadır.

"Usul" ise, "yol, yöntem, metot, tarz" gibi anlamlara gelmektedir. Geniş anlamda usul, belli bir sonuç almak için birbiri ardınca yapılması gereken işlemlerdir. Dar anlamıyla usul ise, kişiler arasında çıkan uyuşmazlıkların, Devletin yargı organları önünde çözümlenmesine, haklı ve haksızın belirlenmesine ve adlî gerçeğin sağlanmasına ilişkin yolları, uyulması zorunlu ku-

---

[1] Almanca: Zivilprozessrecht; Fransızca: Procédure civile, Droit judiciaire privé; İtalyanca: Diritto processuale civile; İngilizce: Civil procedure.

ralları anlatır. Bu durumda "usul" sözcüğünün tek başına muhakeme kavramı yerine geçecek bir anlamda da kullanıldığı görülmektedir. Bu anlamda olmak üzere biz de medenî usul hukuku kavramını tercih etmekteyiz.

Öte yandan, "medenî"[2] sözcüğü, "kamu"nun tersini, başka bir deyişle, özel hukuka ilişkin olan alanı belirtmek üzere kullanılmaktadır. Böylece medenî usul hukuku ile kast edilen, özel hukuk ilişkilerinden, yani birbiriyle eşit gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların veya özel hukuka ilişkin bazı malvarlığı veya kişivarlığı işlerinin karara bağlanma yöntemleri ve yollarına ilişkin sistem olmaktadır.

B) MEDENÎ USUL HUKUKUNUN AMACI

Medenî usul hukukunun amacının[3] ne olduğu, teorik olduğu kadar pratik bakımdan da önem taşımaktadır. Çünkü, ilgili kanunlar bu amaca uygun düzenlenecek; kanunların yorumunda da amaç, yol gösterici olacaktır.

Medenî usul hukukunun amacı, devletlerin politik yapılanmaları doğrultusunda farklılık göstermektedir. Nitekim liberal bir hukuk anlayışının geçerli olduğu sistemde, yargılamada taraf egemenliği baskındır; hâkim daha pasif bir konumdadır. Buna karşılık, devletçi sistemlerde hâkim daha aktif bir rol üstlenir. Her iki sistemi de saf biçimde uygulamayan sistemlerde ise, hâkim ve tarafların işbirliği içerisinde yargılamayı yürüttükleri görülmektedir.

Doktrinde usulün amacının adaletli karar vermek, hukuk barışını sağlamak, ihkakı hakkı ikame etmek (hakkın yerine getirilmesini sağlamak ve kendi kendine hak almayı önlemek), hukuk birliğini sağlamak, hukuk düzenini gerçekleştirmek, kesin hükme ulaşmak, maddî gerçeği bulmak veya özel hukukta düzenlenen hakların tespiti, korunması ve gerçekleştirmesine hizmet etmek olduğu biçiminde farklı görüşler mevcuttur.

Türk hukukunda bu konuda görüş birliği olmamakla birlikte, HMK'nun Genel Gerekçesinde, usul hukukunun amacının **maddî gerçeğe ulaşmak** olduğu ifade edilmiştir[4]. Ancak, "gerçeğin bulunması" veya "gerçeğe ulaşmak" kavramı kullanıldığında, bu kez bir başka sorun ortaya çıkar. Medenî usul hukuku, temelinde özel hukuk ilişkilerinin bulunduğu uyuşmazlıkları çözmekle ilgilendiği için, burada özellikle ceza usulü ile medenî usul hukuku arasında bir farklılık göze çarpmakta; ceza yargısında "maddî" gerçeğin arandığı; hukuk yargısında ise "şeklî" gerçekle yetinildiği gibi bir sonuç ifade edilmektedir. İleride değinileceği üzere, her iki hukuk sisteminin temelinde yatan ve korunan menfaatler (yararlar) farklı olduğundan, farklı ilke ve usuller geçerli olmaktadır. Medenî usul hukukunda taraf menfaati ön plandayken, ceza yargısında (ve idarî yargıda) kamu yararı belirleyicidir. Bu nedenle ceza hâkimine geniş bir araştırma yetkisi verilmişken; hukuk hâkimi, tarafların

---

2 Buradaki "medenî" sözcüğü ile kast edilen yalnızca medenî hukuk olmayıp, tüm özel hukuktur.

3 Bkz. Sema Taşpınar, Medenî Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s. 759-787.

4 Bkz. Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası, Notlu-Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2019.

kendisine sunduğu dava malzemesiyle bağlıdır. Dolayısıyla hukuk hâkiminin kural olarak, dosya dışına çıkıp, gerçeği araştırma yetkisi bulunmaz. Hâkim dosyaya sunulan bilgi ve belgeler ile diğer delillerin izin verdiği ölçüde gerçek durumu tespit etmeye çalışır. Bu nedenle mutlak anlamda gerçeğin bulunması söz konusu olmaz. Ayrıca, gerçek bulunamasa da, hâkim, ispat yükü kuralları çerçevesinde mutlaka bir taraf aleyhine karar vermek zorundadır. Bu karar, ceza yargılamasındaki gibi, delil yetersizliğinden beraat kararı gibi değildir. Yine ceza yargısından farklı olarak, hukuk yargısında katı (kesin delille) ispat sisteminin (m. 200 vd.) varlığı da zaman zaman gerçek duruma uygun karar verilememesine neden olabilir. Aynı şekilde, ceza yargısında ikrar hâkimi bağlamazken; hukuk yargısında kural olarak hâkim ikrarla bağlıdır (m. 188). Bunun sebebi, tarafın kendi aleyhine olan bir hususu (vakıayı) doğrulamayacağı düşüncesi de olamaz. Aksi halde boşanma davalarında da hâkimin ikrarla bağlı olması beklenirdi; oysa boşanma davalarında ikrar, hâkimi bağlamaz (TMK m. 184).

Öte yandan, davada yer alan hususların (vakıaların) veya kararın hatalı ya da yalnızca gerçeğe aykırı olması, o kararın kesin hüküm gücünü sarsmaya (azaltmaya) yeterli olmaz; zira yargılamanın yenilenmesi sebepleri sınırlıdır (m. 375; HUMK m. 445).

Burada temel düşünce, hukuk davasında birbiriyle yararları çatışan, iddiaları birbirine zıt iki tarafın olması nedeniyle, tarafların kendi menfaatlerini daha iyi koruyacağı ve böylece gerçeğin ortaya çıkacağı varsayımıdır. Ancak yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, genel olarak, usul hukukunun mutlak anlamda ve tek başına gerçeği bulmayı hedefleyen bir amacı olduğunu kabul etmek zordur. Ne var ki, hiç kuşkusuz, ortaya çıkan sonuç, gerçekle örtüştüğü ölçüde tatmin edici olur.

Hakları başkası tarafından saldırıya uğrayanlar, medenî usul hukukunun yardımıyla, Devletin mahkemelerinde haklı olduklarını tespit ettirebilirler. Devlet mahkemelerinin kararı ile kesin olarak tespit edilen hakkın yerine getirilmesi için son aşama, cebrî icradır. Cebrî icra (icra ve iflâs) hukukunun yardımıyla, kişilerin hakkı Devletin cebrî icra organları (icra-iflâs daireleri) tarafından yerine getirilir ve kişiler haklarına kavuşur. Şu halde medenî usul hukuku, objektif hukukun kişilere tanımış olduğu ve fakat başkaları tarafından itiraza uğrayan **sübjektif hakların gerçekleşmesini** veya **korunmasını** sağlamak suretiyle, toplum içinde **hukuk barışını sağlamak** gibi çok önemli bir görev yapmaktadır; bu hukuk dalının çok önemli bir işlevi vardır. Bütün bunların adil yargılanma hakkını sağlayan kurallarla gerçekleştirilmesi asıldır.

C) MEDENÎ USUL HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Hukuk disiplinleri, pedagojik amaçlı olarak Roma Hukukundan bu yana klasik bir ayrıma konu olmaktadır. Buna göre özel hukuk, kamu hukuku ve karma nitelikli hukuk dalları olmak üzere üçlü bir ayrımdan söz etmek mümkündür.

Özel hukuk alanında bireylerin irade özgürlüğü (özerkliği-serbestîsi) esas ve taraflar birbirleriyle eşit iken; kamu hukukunda emredici, kamu düzenine ilişkin ve aksi taraflarca kararlaştırılamayan kurallar geçerli olup, taraflardan birisi, üstün güç (kamu gücü) olarak belirleyicidir; dolayısıyla kamu hukukuna ilişkin bir alanda tarafların eşitliğinden söz edilemez. Bu ayrım çerçevesinde medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi alanlar özel hukuka dahil olurken; ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku gibi alanlar kamu hukuku içerisinde görülmektedir. Buna karşılık, iş hukuku gibi bazı hukuk dalları ise karma hukuk disiplinleri arasında kabul edilmektedir.

Medenî usul hukuku da, esasen özel hukuk uyuşmazlıklarının çözüme bağlanmasına yönelik kuralları öngörmektedir. Uyuşmazlığın temeli özel hukuktur; özel hukuk ilişkileridir. İleride daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere[5], usul hukukunun pek çok ilkesi de bu esasa dayanmaktadır. Nitekim, hiç kimsenin lehine olan bir davayı açmaya zorlanamaması, dava malzemesini tarafların getirmesi, hâkimin tarafların getirdiği vakıa, delil ve istem sonuçlarıyla bağlı olması veya tarafların iradeleriyle davaya son verebilmeleri, özel hukuktaki irade özgürlüğünün tipik yansımalarıdır. Ancak ne var ki, bu durum, medenî usul hukukunu özel hukuka dahil saymaya yetmez. Çünkü, medenî usul hukuku, tarafların hangi yol, araç ve yöntemlerle, nerede hak arayacaklarını ve hukukî himayeye kavuşacaklarını düzenlemektedir. Başka bir ifadeyle, Devlet, hak arama yöntem ve usulünü belirlemektedir. Tarafların bu usulün dışına çıkabilmeleri veya bu usulün aksini kararlaştırabilmeleri, kural olarak mümkün değildir. Örneğin, HMK, hangi mahkemeye başvurulacağını, yargılamanın kesitlerini, tarafların hangi şekilde ve sayıda dilekçe verebileceklerini, yargılamanın nasıl ve kim tarafından yürütüleceğini, hâkimin ne tür karar vereceğini düzenlemiştir. Çünkü, usul hukukunda, yalnızca taraflar arasındaki uyuşmazlığın içeriği ve kapsamı tartışma konusu olmayıp; dava açılmasıyla taraflar ve mahkeme arasında üçlü bir ilişki de meydana gelmektedir. İşte bu üçlü ilişkinin kuralları, çoğunlukla emredici ve kamu düzenindendir. Devletin yargılama usulüne yönelik getirdiği bu kurallar, kamu hukuku niteliğinin ağır bastığı düzenlemelerdir. Ancak ne var ki, mahkeme önünde tartışılan hukukî ilişkinin, uyuşmazlığın özel hukuka ait olması ve bunun yansıması olan kurallar (örneğin m. 307 vd.) nedeniyle de, medenî usul hukukunu tek başına kamu hukukuna dahil saymak doğru olmaz. Bu bakımdan medenî usul hukukunu, karma bir hukuk dalı olarak kabul etmek daha doğru (isabetli) olur.

Hukuk kuralları, maddî (esas) hukuk ve şeklî (biçimsel) hukuk (usul) kuralları olarak da ikili bir ayrıma tâbi tutulmaktadır. Belirli bir şekilde davranmayı emreden veya belirli hususları yasaklayan ya da izin veren davranış normları maddî hukuk kuralı olarak kabul edilmektedir. Medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku veya anayasa hukuku gibi alanlar, maddî hukuk kurallarına örnek gösterilebilir. Buna karşılık, maddî hukukun öngördüğü veya düzenlediği hakların hayata geçmesine, uyuşmazlıkların çözülmesine hizmet eden kurallar, şeklî (biçimsel) hukuk (usul)

[5] Bkz. aşa. § 5.

kurallarıdır. Medenî usul hukuku, idarî yargılama usulü veya ceza muhakemesi hukuku, şeklî hukuk kurallarına örnektir. Ancak, bir şeklî hukuk kuralı, maddî hukuk kuralları arasında da yer alabilir. Nitekim, TMK veya TTK'nda da çeşitli usul hükümleri bulunmaktadır (örneğin, TMK m. 184 ve TTK m. 5).

"Usul, esasa takaddüm eder" biçimindeki söz, usul kurallarının maddî hukuk kurallarından önce geldiğine ve önemine işaret etmektedir. Gerçekten de bir kimsenin maddî hukuk bakımından haklı olması yetmez; bu hakkını, usulüne uygun ve doğru bir biçimde mahkeme önünde ispat etmesi gerekir.

Çünkü, usul kuralları, katı ve biçimsel özellikler gösterir. Dava, zamana yayılan bir süreç olduğu için, tarafların hak ve yetkilerini belirli süreler içinde kullanmaları, aksi halde bazı hak kayıplarıyla karşılaşmaları mümkündür. Ancak ne var ki, bu durum, aslında bir yandan diğer taraf için güvence oluşturur. Zira, böylece taraflar için belirlilik ve öngörülebilirlik sağlandığı için, kuralları önceden belirlenmiş bir sürecin işleyeceği ilgililerce bilinmiş olur. Uyuşmazlık veya hukukî sorunun belirli bir (makul) sürede çözülmesi de gerektiğinden, usul kurallarının iyi bilinmesi ve doğru uygulanması son derece önemlidir. Maddî hukuk bakımından haklı olunduğu halde, özellikle ispat hükümlerinin gereğinin yerine getirilmemesi veya başka usulî hatalar nedeniyle hak kayıplarının yaşanabilmesi mümkündür. Ancak daha sonra görüleceği üzere[6], bu hata veya kayıpların giderilmesi bakımından ıslah veya eski hale getirme gibi bazı düzenlemeler (mekanizmalar) mevcuttur.

Bir kuralın maddî hukuk kuralı mı yoksa şeklî (biçimsel) hukuk kuralı mı (yani usul kuralı mı) olduğu, pratik olarak da önemli sonuçları olan bir konudur. Aşağıda da değinileceği gibi, bu husus, kuralların yer ve zaman bakımından uygulanması ile yorumu bakımından da özellik taşır.

D) UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Uyuşmazlık (çekişme, niza), bir hakkın varlığı, kapsamı veya ihlâl edilip edilmediği konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıktır.

Uyuşmazlıkların çözüm yolları bakımından, uyuşmazlığın konusu, türü ve uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin sıfatı önem taşımaktadır.

Uyuşmazlıklar, suç oluşturan bir fiille ilgili olabileceği gibi, bireyle idare (bir kamu otoritesi) arasında da olabilir. Yine uyuşmazlık, kişilerin özel hukuk ilişkilerinden de kaynaklanabilir.

Uyuşmazlığın türüne ve tarafların sıfatına göre çözüm araçları da değişir. Ancak uyuşmazlık hangi alanda veya ne tür olursa olsun, kural olarak, kişilerin kendiliğinden hak alması (ihkakı hak) yasaktır[7]. Esasen Devletin yargı

---

6 Bkz. aşa. § 7, B; § 45.

7 Hukuk kuralları, istisnai olarak kendiliğinden hak almaya izin vermektedir. Toprak sahibinin, toprağına taşıp da zarar veren bir ağacın dal ve köklerini kesip mülkiyetine geçirme veya bu dallarda yetişen meyvaları toplayıp alma (TMK m. 740); zorunlu sebeplerden dolayı başkasının taşınmazına müdahale etme (TMK m. 753); zilyedin gasp ve saldırıyı zor kullanarak savma (defetme), elkoyanı kovma ve taşınır malı geri alma (TMK m. 981); meşru müdafaa (haklı savunma), zorunluluk (ıztırar) hali ve kendi hakkını korumak için kuvvet kullanılması (TBK m. 64) ve taşınmaza zarar veren başkasının hayvanını alıkoyma hakkı

gücünü elinde tutmasının en önemli sebeplerinden birisi de, kendiliğinden hak almayı yasaklamaktır. Herkesin kendi hakkını almaya çalıştığı bir ortam, yalnızca kaosa neden olur. Bunun (kaosun) önlenmesi için uyuşmazlıkların, hukuk sistemlerinin gösterdiği biçimde çözülmesi gerekir.

Uyuşmazlıkların çözüm yollarını ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Buna göre, uyuşmazlıklar, **dava** veya **alternatif** (dostane) **uyuşmazlık çözüm yollarından** birisiyle çözülebilir.

Dava yoluyla çözüm de kendi içerisinde **ikiye** ayrılabilir. Buna göre, ilk olarak, **Devlet yargısı** (mahkemeler) önünde dava yoluyla çözüm; ikinci olarak ise Devlet yargısına alternatif bir yargılama yolu olan **tahkim** yoluyla çözüm.

Alternatif (dostane) uyuşmazlık çözüm yolları olarak dile getirilen ikinci yol ise, birden fazla ve geniş bir yelpazeden oluşan (arabuluculuk, uzlaştırma, müzakere, kısa duruşma, vakıaların tespiti gibi) çözüm yöntemlerini kapsar. Bu yol, Devlet yargısının alternatifidir. Nitekim burada tarafların hiç Devlet yargısı veya tahkim yoluna başvurmadan, kendi iradeleriyle ya da istisnai hallerde dava şartı olarak zorunlu tutulduğu (örneğin TTK m. 5/A; İş Mahk. K. m. 3, 1) için tarafsız bir üçüncü kişi gözetimi, denetimi veya yardımı çerçevesinde uyuşmazlık çözümünü sağlamaları söz konusudur. Ancak burada devlet yargısında veya tahkimde olduğu gibi bir yargılama yapılmaz ve varılan sonuç, kural olarak mahkeme kararı (ilâm) gücünde olmaz. Yine tarafların alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurması halinde taraflara bir karar veya sonuç dayatılamaz; bu yolda anlaşma sağlanamazsa yargı yolu açıktır[8].

Medenî usul hukukunun konusu, ilke olarak, Devlet yargısı, yani mahkemeler önünde gerçekleşen yargılamanın yapılma biçimidir. Nitekim HMK, görevli ve yetkili mahkemeleri, yargılama usulünü, tarafların hak ve yetkilerini, hâkimin yargılamayı yürütmesi ve karar verme usulünü ayrıntılı biçimde düzenlemektedir. Öte yandan HMK, tahkime ilişkin hükümler de içermektedir (m. 407 vd.). Zira, Devlet yargısının alternatifi olmakla birlikte, tahkim de mahkeme kararının sahip olduğu kesin hüküm gücünü taşır ve uyuşmazlığı bütün bir gelecek için sona erdirir[9].

E) MEDENÎ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Medenî usul hukukunun temelini (dayanağını) oluşturan hukuk kuralları na bu hukuk dalının kaynakları denir. Bu kurallar Anayasa, kanun ve tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerle konulmuş olabilir.

(TBK m. 68) gibi. Bu istisnalar dışında, hukukumuzda kendiliğinden hak alma yasak olup, alacaklı, ancak Devlet kuvveti (mahkemeler ve icra-iflâs daireleri) yardımıyla veya hukukun izin verdiği diğer yöntemlerle (tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi) borçlusunu borcunu yerine getirmeye zorlayabilir.

8 Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşa. § 79.

9 Tahkim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşa. § 80.

I – ANAYASA

Medenî usul hukukunun kaynaklarının başında Anayasa gelmektedir. Çünkü Devletin üç önemli erkinden birisi olan yargı yetkisinin kullanılması başta olmak üzere (Anayasa m. 9), mahkemelerin kuruluşu, yargılama usulleri ve yargı çeşitleri ile yüksek mahkemeler ve hâkimlik mesleğine ilişkin genel hükümler Anayasada (Anayasa m. 36, 37, 138 vd.) yer almaktadır.

II – HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK)[10,11]

Medenî usul hukukunun ikinci temel kaynağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'dur. HMK, 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bundan önce 1927 tarihli 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yürürlükteydi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, hızlı ve köklü bir kanunlaştırma (resepsiyon) dönemi yaşanmıştır. Bu çerçevede özel hukuk alanında, Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu İsviçre'nin federal kanunlarından alınmıştır. Ne var ki, bu kanunların aksine (o dönemde) İsviçre'nin federal bir usul kanunu bulunmadığı için[12] kanton kanunları değerlendirilmiş ve o tarihlerde en yeni kanun olarak Nöşatel Kantonu'nun Medenî Usul Kanunu (esas) alınmıştır. Bu Kanun, Alman ve İtalyan Hukuku yanında Nöşatel'in gelenek hukukunun da izlerini taşımaktaydı. Nöşatel Medenî Usul Kanunu, Türk hukukuna aynen aktarılmamış; özellikle günümüzde de önemini koruyan ispat sistemi bakımından ondan farklı hükümler içermiştir. Şöyle ki, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemindeki batılılaşma hareketleri içinde Fransız Medenî Kanunu ve Usul Kanunundan alınan kesin delille (senetle) ispat kuralı, HUMK döneminde de korunmuş; yani Nöşatel Medenî Usul Kanununun serbest ispata ilişkin hükümleri bize alınmamıştır.

İhtiyaçlar sebebiyle zaman zaman yapılan değişikliklerle[13], HUMK'nun millî bünyemize uydurulmasına çalışılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, esas itibariyle; 1086 sayılı HUMK'nun aksayan ve eskiyen yanlarının düzeltilmesi, ihtiyaç duyulan bazı yeni hükümlerin kabulü, yargılama sistemimizin daha basitleştirilmesi, usul hukukunun amacı olan maddî gerçeğe ulaşılmasını sağlama yönünde düzenlemeler yapılması, mahkeme dışı çözüm yolları ile sulh veya uzlaşmayı mümkün kılacak alt yapının oluşturulması ve yargılamada güncel teknik ge-

---

10 Bu kitapta, kanun ismi verilmeden yalnız madde (m.) numarası ile anılan maddeler, kural olarak HMK'na aittir (bkz. yuk. Kısaltmalar Cetveli not. 1).

11 Bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-HMK, Ankara 2019.

12 Daha sonra İsviçre'de Federal Medenî Usul Kanunu (Schweizerische Zivilprozessordnung) kabul edilmiş ve 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle Türk HUMK'nun kaynağı olan Nöşatel Usul Kanunu da bugün varlığını korumamaktadır.

13 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nu değiştiren kanunlar ile değiştirilen maddeleri gösteren cetvel için bkz.: Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, En Son Değişikliklere Göre Notlu -Gerekçeli - Sözlüklü Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 35. baskı, Ankara 2010, s.22-25. Ayrıca bkz. Ejder Yılmaz, Dünden Bugüne Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz (Yılmaz-Makaleler, Cilt 2, s. 1289-1322).

lişme ve kolaylıklardan yararlanılması gibi temel ilkeler çerçevesinde hazırlanmıştır; bu arada Kanunun dili de oldukça anlaşılır hale getirilmiştir[14].

HMK'nun hazırlanması aşamasında Alman, Avusturya ve İsviçre usul kanunları da dikkate alınmış olmakla birlikte, HMK, esas itibariyle bugüne kadarki yargı uygulaması ve birikimini koruyan bir yapıya sahip, yerli bir Kanun olma özelliğini taşımaktadır.

HMK, medenî yargıya dahil genel ve özel görevli hukuk mahkemelerinde, bölge adliye (istinaf) mahkemelerinde ve Yargıtay'da uygulanır. Bundan başka, HMK'nun bazı hükümleri, idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, Danıştay'da, Sayıştay'da, Yüksek Seçim Kurulu'nda, tüketici sorunları hakem heyetlerinde ve Rekabet Kurulu'nda da uygulanır[15].

HMK hükümleri ayrıca, örneğin mecburî tahkimde; CMK'nda ve Çocuk Koruma Kanunu'nda (m. 42) hüküm bulunmayan hallerde, kıyasen uygulanır.

Aşağıda inceleneceği üzere, HUMK'nun kanun yollarına ilişkin hükümleri eski (20.07.2016'dan önce karara bağlanan) davalar bakımından uygulanmaya devam etmektedir (HMK Geçici m. 3). Bu bakımdan HUMK da medenî usul hukukunun kaynakları arasındaki yerini korumaktadır.

III – MADDÎ HUKUKA AİT KANUNLARDAKİ USUL HÜKÜMLERİ

HMK dışında, maddî hukuk ilişkilerini düzenleyen bazı kanunlarda da usul hükümleri vardır. Maddî hukuka ait kanunlarda yer almış olmakla beraber, bu usul hükümleri de nitelikleri bakımından medenî usul hukukunun kaynaklarına dahildir. Örneğin TMK m. 6, 7, 160, 168, 184, 294, 299; TTK m. 4 ve 5-5/A'daki usul hükümleri gibi. Bundan başka, bazı özel kanunlarda, konularıyla ilgili hususlar hakkında özel usul hükümleri vardır (bkz. örneğin: Kamulaştırma Kanunu m. 14-18). Ayrıca, İİK'nda, icra-iflâs işlerine ilişkin davalar için özel yetki ve usul hükümleri vardır (bkz. örneğin: İİK m. 69,II; 72, 158, 258, 281).

Yukarıdaki açıklamalar, çekişmeli yargıya ilişkin usul hükümleri içindir. Maddî hukuka ait kanunlarda çekişmesiz yargıya ilişkin usul hükümleri de vardır ve bunların sayısı daha fazladır. Örneğin gaiplik usulü (TMK m. 32-35), vesayet hukukuna ilişkin usul hükümleri (TMK m. 396 vd.; VVMTüz.[16]

---

[14] Kanun Gerekçesi için bkz.: TBMM Dönem:23, Yasama Yılı: 3, S.Sayısı 393, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/574). Bu konuda bkz.: Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-HMK, s.19-32; Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdikleri (ABD 2011/2 s. 213-253); Ramazan Arslan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Medenî Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler, Prof. Dr. Gürgân Çelebican'a Armağan, Ankara 2011, s. 439-458. Hukuk Muhakemeleri Kanununun İngilizce çevirisi için bkz. Mustafa Göksu, Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, Ankara 2016, s. 287-472.

[15] Ayrıca bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İcra İflâs Uyuşmazlıklarında Uygulanabilirliği (Prof. Dr. Ramazan Arslan Armağanı Cilt 2, Ankara 2015, s. 1835-1866).

[16] RG 10.08.2003, sa.25195.

m. 8-31), rehin senedinin iptali usulü (TMK m. 925-926; 651-652, 661, 667, 757-765), deniz raporu ile ilgili işlerde yargılama usulü (TTK m. 1098-1101), dispeççi tayini ve dispeçin tasdiki usulü (TTK m. 1280-1284) hakkındaki usul hükümleri gibi.

IV – DİĞER KANUNLAR

HMK dışında pek çok kanun da medenî usul hukukunun kaynakları arasındadır. Bunların başında 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun gelmektedir. Ayrıca İş Mahkemeleri Kanunu, Kadastro Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi kanunlarla kurulmuş olan özel görevli mahkemelerde uygulanan yargılama usulleri hakkında, yine bu özel kanunlarda bazı usul hükümleri yer almaktadır. Özel görevli mahkemeleri ve bunlarda uygulanan özel yargılama usullerini ileride inceleyeceğiz[17].

Bu kanunlar dışında yüksek mahkemelerin kuruluşuna ilişkin kanunlar, Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Tebligat Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu veya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gibi pek çok kanun da usul hukukunun kaynaklarındandır.

V – MEDENÎ USUL HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili bazı yönetmelikler (m. 268, 317, 386, 449) çıkartılacağını belirtmektedir (m. 449, 1/c). Önemli usul hükümleri içeren Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik[18], medenî usul hukukunun kaynaklarından biridir. Kitabımızda bu Yönetmeliğin hükümleri yeri geldikçe değerlendirilmiş olup, "Y" kısaltması ile anılmıştır. Ayrıca, Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliği[19]; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği[20]; Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik"[21]. Bu Yönetmelik, hukuk davalarında da uygulanır (Y m. 218, 8).

VI – YARGITAY KARARLARI

Yargıtay'ın medenî usul hukukuna ilişkin kararları, medenî usul hukuku bakımından çok önemli bir kaynaktır. Bu kararlar yardımıyla, Kanunun açık olmayan noktaları aydınlanmakta, boşlukları doldurulmakta ve usul kuralların Yurdun her yerinde aynı şekilde uygulanması sağlanmaktadır. Özellikle usul kanunları, bütün ihtimalleri öngörecek şekilde hüküm koyamamakta,

---

17 Bkz. aşa. § 71-76.
18 RG 06.08.2015, sa. 29437.
19 RG 03.08.2017, sa. 30143.
20 RG 02.06.2018, sa. 30439.
21 RG 20.09.2011, sa. 28060.

kanunun her olayın özelliğine göre uygulanması, doğal olarak mahkemelere, bölge adliye mahkemelerine ve Yargıtay'a kalmaktadır[22].

İşte bu nedenle, âdeta HMK'nun uygulanış biçimini gösteren ve bundan dolayı çok önemli bir kaynak olan Yargıtay (hatta bölge adliye mahkemesinin) kararlarının bütün ilgililerce bilinmesi (yani, yayımlanması) gerekir (ayrıca bkz. İİK m. 14, II). Çünkü günümüzde gittikçe önem kazanan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, "şeffaflık" ilkesi, her alanda olduğu gibi yargı alanında da büyük önem taşır. Mahkeme kararlarının yayımlanması, çağdaş Dünya'da, **halkın** (milletin) kendi **adına** yargılama yapan **mahkemelerin yaptığı yargılamaları** ve bunun sonucunda verilen **kararları denetlemesi** çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu husus (aleniyet), bizde yalnızca duruşma ile sınırlandırılarak "**aleniyet**" ilkesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

1975 yılından itibaren, Yargıtay Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü tarafından Yargıtay Kararları Dergisi isimli bir (aylık) dergi yayınlanmaktadır[23]. Bunun dışında baro dergileri, hukuk fakültesi dergileri, alanında uzmanlaşan hukuk dergileri ve elektronik veri tabanları ve içtihat bankalarında da çok sayıda Yargıtay kararı yer almaktadır. Ticarî olarak hizmet veren elektronik veri bankaları yanında Yargıtay'ın web sitesi üzerinden de ücretsiz olarak hemen hemen bütün kararlara ulaşılabilmesi sevindiricidir[24].

VII – DOKTRİN (ÖĞRETİ)

Medenî usul hukukunun doktrine yönelik kaynakları da, bu alanda yapılmış akademik çalışmalar, yazılan tezler, makaleler, monografiler ve şerhlerdir. Bu çalışmalardan, kanunların yapımında ve mahkeme kararlarının verilmesinde yararlanılmakta; bu kaynaklar, tartışma ve görüş oluşturmak bakımından büyük önem taşımaktadır.

F) MEDENÎ USUL HUKUKU KURALLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

I – YER BAKIMINDAN UYGULANMA[25]

Medenî usul hukuku kurallarının, maddî hukuk kurallarından farklılıkları olduğuna yukarıda işaret edilmişti. Bu farklardan birisi medenî usul hukuku-

---

22 Burada söz edilen Yargıtay veya bölge adliye mahkemesinin kararları, somut olaylar çerçevesinde verilen kararlardır. Buna karşılık Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile 5235 s. K. m. 35 uyarınca bölge adliye mahkemeleri arasında çıkan karar uyuşmazlığını gidermek üzere Yargıtay tarafından verilen kararlar, hukuk mahkemelerini benzer bütün uyuşmazlıklarda bağlayıcı olduğu için bu kararların Resmî Gazetede yayımı ve herkes tarafından bilinmesi zorunludur.

23 Bkz. 2797 s.K. m. 48-50.

24 Bkz. İİK'nun 14. maddesi hükmüne dayanılarak kabul edilen, Yargıtaydan Verilen İcra ve İflâs İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik (RG 12.04.2014, sa. 28970).

25 Bkz. Ersin Erdoğan, Medenî Usul Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Ankara 2016.

nun yer bakımından uygulanmasıyla ilgilidir. Buna göre, bir uyuşmazlık veya hukukî ilişkiye, meydana geldiği yer hukuku (lex causae) uygulandığı halde; usul hukukunda hâkimin hukuku (**lex fori**), yani davanın açıldığı yerdeki usul hukuku uygulanır. Bu ilke, yabancı unsurlu hukukî ilişkiler bakımından önem taşır. Örneğin, Alanya'da yaşayan iki Alman vatandaşının Alanya'da açtığı boşanma davasında kural olarak, Alman Medenî Kanunu hükümleri geçerli olur; ancak dava açılması, davanın görülmesi veya hâkimin karar verme usulü HMK'na tâbidir. Başka bir deyişle Türk aile mahkemesi Türk usul hukukunu uygulayıp Alman Medenî Kanununa göre karar verir. Burada karşımıza çıkan önemli bir istisna, deliller hakkındadır. Delil, usul hukukuna tâbi olmakla birlikte, lex fori ilkesinin uygulanmadığı durumlar söz konusudur. **Locus regit actum** (şekil, yapılan yere tâbidir) ilkesi gereğince örneğin, tarafların kendi hukuk kurallarına göre yaptıkları delil sözleşmesi geçerli olur.

II – ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA[26]

1) Kural

Kanunların gelişen şartlar çerçevesinde, zaman içerisinde değiştirilmesi bir zorunluluktur. Kanun koyucu, kanunlarda değişiklik yaptığı takdirde, bunun yürürlüğe gireceği zamanı da belirleyebilir. Ancak bazen bir kanun yürürlüğe girdiği halde, uygulanmayabilir. Çünkü, kanunun zaman bakımından uygulanması ile yürürlüğe girmesi her zaman aynı anlama gelmez.

Mevcut kuralların değiştirilmesi, ister istemez eski ve yeni kanun çatışması doğurabileceğinden iki düzenleme arasında bir köprüye, uyuma gereksinim duyulur. Bu anlamda kanun koyucu, getireceği özel hükümlerle yeni kanunun hangi andan itibaren uygulanacağını belirleyebilir. Ancak burada sorulacak ilk soru, kanun koyucunun düzenleme serbestîsinin bir sınırının olup olmadığı; ikincisi, kanun koyucunun hiçbir hüküm getirmemesi halinde geçerli bir ilkenin varlığından söz edilip edilemeyeceğidir.

Ceza kanunlarıyla ilgili, aleyhe ceza hükümlerinin geçmişe uygulanmayacağı yönündeki Anayasal düzenleme (Anayasa m. 38) dışında tüm hukuk sistemimizi kapsayan genel bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak Türk hukukunda kanunların zaman bakımından uygulanması konusunda benimsenmiş ortak ilkeler söz konusudur. Bu ilkeler, hukuk disiplinlerine göre farklılık gösterir. Buna göre, kişilerin iradesinin ön planda olduğu özel hukuk ilişkilerinde, bu iradeye saygı duyulmaktadır. Aslında bu sonuç, doğal, mantıki ve rasyoneldir. Zira, özel hukuktaki kanunlar, kişilerin özel hukuk alanındaki ilişkilerine yönelik emir veya yasaklar içerip, belli işlemlerin yapılmasına izin verdiklerine göre, kişiler, ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini ve hangi biçimde hukukî ilişkilere girebileceklerini o an itibariyle yürürlükte olan kanunlara göre belirlerler. Hiç kimsenin, gelecekte yürürlüğe girecek bir kanuna göre davranışını düzenlemesi beklenemez. O nedenle özel (maddî) hukuk bakımından, kural olarak, uyuşmazlığın ortaya çıktığı ta-

[26] Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013.

rihte yürürlükte olan kanun değil, ilişkinin, işlemin veya olayın gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan kanun uygulama bulur[27]. Kanunun geçmişe yürümemesi veya geçmişe uygulanmaması adı verilen bu durum, kazanılmış haklara saygının bir ifadesidir. Çünkü ilgililerin o kanunlarla hak kazandıkları, dolayısıyla bu hakların ihlal edilmemesi gerektiği kabul edilmektedir.

Örneğin, TMK m. 202 uyarınca yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma olarak kabul edilmiştir. TMK, 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra gerçekleşen boşanmalar bakımından, evliliğin yapıldığı tarihte geçerli mal rejimi ne ise, 01 Ocak 2002 tarihine kadar bu rejim; 2002'den sonra edinilen mallar için ise, edinilmiş mallara katılma rejimine göre tasfiye yapılır. Başka bir deyişle, yeni mal rejimi sistemi, geçmişe dönük uygulanmaz. Zira evlilik birliğinin kurulduğu tarihte eşler, mevcut (yasal) mal rejimine tâbi oldukları bilinci ile hareket etmişlerdir.

TBK, belirsiz süreli kira sözleşmeleri bakımından, daha önce var olmayan bir sınırlama getirmiş ve on yılın sonunda, kiralayanın sözleşmeyi sona erdirme hakkı olduğunu öngörmüştür (TBK m. 347, 2). TBK, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu kuralın 01.07.2012 tarihinden sonra yapılan kira sözleşmeleri bakımından geçerli olması gerekir TBK'nun yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101 sayılı Kanun, geçici 2. maddesiyle bu kuralın, mevcut kira sözleşmesi bakımından nasıl uygulanacağını özel olarak düzenlemiştir. Buna göre, örneğin kira sözleşmesi 01 Temmuz 2012 itibariyle on yılı doldurmuş olsa bile yeni kanun derhal değil, iki yıl sonra (01 Temmuz 2014) itibariyle uygulanır.

Bir başka örnek de TBK m. 583'te yer alan kefalet sözleşmesinden verilebilir. Kanun, kefalet için yazılı geçerlilik şekli yanında, ayrıca kefil olanın kendi el yazısı ile kefalet miktarı ve tutarını belirtme zorunluluğu getirmiştir. Bu hüküm de 01 Temmuz 2012'den sonra yapılan sözleşmeler için geçerli olup, bu tarihten önceki sözleşmelerin geçerliliğini etkilemez. Bütün bu örnekler, özel (maddî) hukukta, kanunların kural olarak geçmişe uygulanmadığını göstermektedir.

Buna karşılık kamu hukukunda "**derhal uygulanma**" ilkesi geçerli olup, bu alanda "kazanılmış hak"tan söz edilemez. Ancak bu durum, kanun koyucunun bu alanda yaptığı tüm değişiklikleri derhal uygulayabileceği gibi bir anlam taşımaz. Zira kamu hukukunda da, "tamamlanmış işlem veya durum"lar dikkate alınmalıdır. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi, kararlarında, kanun koyucunun yalnızca Türk hukukunu değil, hukukun genel ilkeleri ve evrensel hukuk ilkelerini dikkate alarak düzenleme yapmasını; bireylerin temel haklarının ve hukukun genel ilkelerinin gözetilmesini, geçmişe dönük sorumluluklarının artırılmaması, yasal düzenlemelerle güvenin sarsılmaması, kanun koyucunun

---

[27] Ancak özel hukukta da bazı hallerde yeni kanun, eski kanun zamanında yapılmış işlemlere uygulanabilir. Bu konuda ortak nokta, yeni düzenlemenin kamu düzeni ve genel ahlâkı sağlamaya dönük olması veya içeriği kanunla belirlenen bir ilişki olmasıdır (bkz. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 1-3; 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 4; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun).

kamu yararı, ölçülülük ve hukukî güvenliği gözeterek geçiş düzenlemeleri yapması gerektiğini ifade etmektedir. O halde kamu hukukunda derhal uygulanma ilkesi geçerli olmakla birlikte, tamamlanmış işlem veya durumların yeni kanundan etkilenmemesi; hukuk devleti ve hukukî güvenliğin gereği olarak görülmektedir.

Usul hukuku bakımından ise, derhal uygulanma ilkesi geçerlidir. Yani, yeni usul kanunu (hükümleri), bundan sonra açılacak davalarda uygulanacağı gibi, yeni kanun yürürlüğünden önce (yeni, eski usul kanunu hükümlerine göre) açılmış bulunan derdest davalara da uygulanır. Bu ilkenin benimsenmesinin nedeni, yeni usul hükümlerinin, kamu düzeniyle ilgili olmasından ve davada tarafların haklarının gerçekleştirilmesi bakımından, eskisine oranla, daha iyi ve daha adil olduğu inancından kaynaklanmaktadır. Bu husus, Yargıtay'ın 13.04.2018 tarihli ve 02/04 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile de benimsenmiştir[28]. Nitekim HMK da, bu konuyu düzenlediği 448. maddesinde, "bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır" demektedir. Kanunların derhal uygulanması, geçmişe uygulanması değildir. Çünkü, tamamlanmış hukukî durum veya işlemlerin sarsılmaması esastır. Bu bakımdan yeni kanunun lehe veya aleyhe olması önem taşımaz.

Kanun koyucu, HMK'nun yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2011'den sonra açılan davalara değil, bu tarihte derdest bütün davalara uygulanmasını öngörmüştür. Aynı şekilde, 01 Ekim 2011 tarihinden önce kurulan hukukî ilişkiden kaynaklanan bir uyuşmazlık, 01 Ekim 2011'den sonra dava konusu yapıldığında da artık tümüyle HMK hükümlerine tâbi olmuştur. Buna karşılık, bu

---

28 "Kanunların zaman bakımından uygulanması maddi hukuka ilişkin kanun değişiklikleri ile yargılama (usul) hukukuna ilişkin kanun değişiklikleri bakımından da ayrıma tabi tutulmaktadır. Kural olarak **maddi hukuka ilişkin kanun değişiklikleri sadece yürürlüğe girmelerinden sonra ortaya çıkan hukuki olgu ve ilişkilere uygulanır**. Yürürlüğünden önce ortaya çıkan olaylar ve hukuki ilişkiler, ortaya çıktıkları tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine tabidir. Böylelikle kanun geriye yürütülmemiş ve özellikle hukuki işlemi yapan kişi ya da kişilerin, işlem tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükümleri çerçevesinde ulaşmayı düşündükleri hedefler konusunda belirsizlik yaratılmamış olur. **Yargılama** (usul) **hukukuna ilişkin değişiklikler ise 'derhal uygulanma' kuralına tabidir.** Bu ilkenin benimsenmesinin nedeni ise bu kanun hükümlerinin kamu düzeni ile yakından ilgili olduğu, daima eskisinden daha iyi ve amaca en uygun olduğu fikri ile kanun koyucunun, fertlere ait olan hakların yeni usul hükümleri ile daha önce yürürlükte olan kısımdan daha iyi ve daha adil korunacağına ilişkin inancıdır...Kural olarak bireylerin usul kurallarının değişmeyeceğine olan güvenleri korunmaz. Buna göre her usul işlemi, işlem tarihinde yürürlükte olan kanuna göre yapılır. Derdest bir davada önceki kanuna göre tamamlanmış işlemlerin yeni kanuna göre tekrarlanmasına gerek yoktur. **Yeni usul kanunu, yürürlüğe girmeden önce açılmış olan davalarda tamamlanmamış işlemlere uygulanır.** Bu nedenle yargılama esnasındaki her usul işlemi ayrı ayrı değerlendirilmeli, bunların tamamlanmış olanları için yeni usul kanunu uygulanmamalıdır. Derhâl uygulama ilkesi, usul kanunlarının geçmişe uygulandığı anlamında yorumlanmamalıdır. Bu nedenle kazanılmış hak ihlalinden de söz edilemez... Usul hukuku alanında geçerli evrensel nitelikteki temel ilke, yargılanmaya ilişkin kanun hükümlerinin derhâl uygulanmasıdır. Derhâl uygulanmadan kasıt; **yeni usul kanununun, hem yeni kanunun yürürlüğünden sonra açılacak davalarda, hem de eski usul kanunu zamanında açılmış derdest davalara uygulanmasıdır**" 13.04.2018 gün ve 02/04 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinden- RG 19.09.2018, sa. 30539).

uyuşmazlığa uygulanacak maddî hukuk kuralı, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan kanundur. Bu sonuç, maddî hukuk ve usul hukuku kuralları arasındaki farkın tipik örneğidir.

HMK, bir hukuk davasını dilekçeler teatisi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm biçiminde aşamalara ayırmıştır. Hüküm verildikten sonra ilk derece mahkemesi önündeki yargılama sona erer ve bundan sonra kanun yolları aşaması söz konusu olur. Ancak HMK'nun, HUMK'nun uygulandığı dönemde açılan davalara uygulanması bakımından bu aşamalar değil, dava hangi aşamada olursa olsun, yapılan işlemler ve bunların tamamlanmış olup olmadığı esas alınmıştır. Kanun'da açıkça belirtilmemekle birlikte burada işlemden kasıt "usul işlemleri"dir[29]. Örneğin, yazılı yargılama usulünde iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, dava dilekçesinin verilmesiyle başlamakta iken (HUMK m. 185/2; 202), HMK m. 141 hükmü, bunu ikinci dilekçeye, yani cevaba cevap dilekçesine kadar uzatmıştır. HMK'nun yürürlüğe girmesinden önce dava açan davacının bu dilekçesi geçerliliğini korur; ancak, davalının verdiği cevaptan sonra davacı, HMK'nun sağladığı olanak nedeniyle iddiasını değiştirip genişletebilir (m. 141).

Aynı şekilde örneğin, 01 Ekim 2011 tarihinden önce açılan bir davada yazılı delil başlangıcı niteliği taşımayan belge, HMK'nun yeni düzenlemesi uyarınca delil başlangıcı (m. 202) olarak dikkate alınabilir. Bunun gibi, HUMK döneminde hâkimin taraflara yemin teklif etme olanağı varken (HUMK m. 355-356), HMK bu yolu kapatmıştır. Dolayısıyla, 01 Ekim 2011'den önce açılan bir dava da olsa, tarafın teklif ettiği yeminden ayrı, hâkim yemin teklif edemez. Çünkü, usul kuralları, tamamlanmış işlemlere dokunulmamak kaydıyla derhal uygulanır. Yine bir başka örnek verilecek olursa, TTK m. 4, 2'de 7101 s. K. ile yapılan değişiklik sonucu miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulanacağı kabul edilmiş ve söz konusu Kanun, 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda, değeri yüz bin TL'nin altında olup da 15 Mart 2018 tarihinden önce açılan bir ticarî dava, açıldığı tarihte yazılı yargılama usulüne tâbi iken, değişiklik yapan Kanunda özel bir geçiş hükmü kabul edilmemiş olduğundan, bundan sonra basit yargılama usulü uygulanacaktır. Örneğin, davalının cevap dilekçesi tebliğ edilmiş ve bu arada Kanun yürürlüğe girmişse davacının cevaba cevap verme hakkı olmayacaktır. Çünkü, basit yargılama usulünde taraflar sadece birer dilekçe verebilirler (m. 317, 3). Yine yazılı yargılama usulünde mahkeme, tahkikatın sona ermesi üzerine tarafları ayrı bir sözlü yargılama ve hüküm duruşmasına davet etmek zorunda iken (m. 186); basit yargılama usulünde tahkikat ve sözlü yargılama aşamaları birlikte gerçekleşeceğinden mahkeme, tahkikatın bittiği duruşmada hükmünü verebilir (m. 321, 1).

Usul kurallarının derhal uygulanması nedeniyle, tarafların aleyhine bazı durumların doğması da mümkündür. İşte bunları önlemek bakımından kanunlarda geçiş (intikal) hükümleri veya geçici hükümler başlığı altında düzenlemeler yapılır. Ancak bu tür düzenlemeler bulunmadığı veya yetersiz ol-

[29] Bkz. aşa. § 6.

duğu takdirde de, hukukî güvenlik ve menfaatler dengesi gözetilerek, derhal uygulanmanın getirdiği sakıncalar mahkeme kararlarıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Nitekim HMK'nun uygulandığı davalar bakımından da benzer yorumlar yapılmıştır.

2) Geçiş (İntikal) Hükümleri

Yukarıda da belirtildiği üzere, birbirini izleyen eski ve yeni kanunî düzenlemelerden hangisinin uygulanacağı sorunu, derhal uygulanma veya geçmişe uygulanmama ilkeleri uyarınca çözülür. Ancak kanun koyucu bazı durumlarda eski ve yeni hükümler arasında köprü kurmak suretiyle de düzenleme yapabilir. Bu halde, bazen eski hüküm bir süre daha uygulanabilir.

HMK m. 450'de, "18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır" ifadesi yer almaktadır. Öte yandan HMK, 451. maddesinde de, "Bu Kanun 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer" demektedir. Her iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, HUMK'nun tümüyle yürürlükten kalktığı, bunun yerine HMK'nun yürürlüğe girdiği söylenebilir. Ne var ki, yürürlüğe girmesine veya yürürlükten kalkmasına rağmen hem HMK hem de HUMK uygulanmaya devam etmektedir. Buna olanak veren hükümler ise, Kanunda Geçici Madde başlıkları altında yer alan hükümlerdir. Geçiş (intikal) hükümleri veya geçici hükümler de denilen bu düzenlemelerle, yürürlüğe giren HMK'nun bazı maddelerinin uygulanması ertelenmekte veya HUMK'nun bazı maddelerinin uygulamasına devam etmeye olanak tanınmaktadır. O halde, geçiş hükümleri, erteleme hükümleri olarak kabul edilebilir.

HMK, başlangıçta üç geçici madde ile düzenleme yapmıştı. Buna göre, ilk olarak HMK'nun yürürlüğe girmesinden önce açılan ve görülmekte olan derdest davalar bakımından mahkemelerin görevlerinde ve yargı yolunda HMK ile yapılan değişikliklerin uygulanmasına engel olunmuştur (Geçici Madde 1, 1). Buna göre örneğin, HUMK hükümlerine göre 01 Ekim 2011 tarihinden önce sulh hukuk mahkemesinde açılan 5.000 TL tutarındaki alacak davasında, mahkeme, malvarlığına ilişkin tüm davaların asliye hukuk mahkemesinde açılacağı (m. 2) gerekçesiyle görevsizlik kararı veremeyecektir.

Gerek HUMK'nda gerekse HMK'nda hukukî işlemlerin ispatı veya kanun yoluna başvuru bakımından parasal sınırlar getirilmiştir. HMK Geçici Madde 1, 2 hükmüyle, HMK'nun senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümlerinin, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Örneğin, 01 Ekim 2011'den önce açılan bir davada 2011 yılı için kabul edilen senetle ispat sınırı 590 TL iken, HMK'nun yürürlüğe girmesi ile bu rakam 2.500 TL'ye çıkmıştır. Derhal uygulanma ilkesine bu şekilde özel (geçiş hükmüyle) bir istisna getirilmemiş olsaydı, taraflar hukukî ilişkiye girerken bilmedikleri bir rakam bakımından işlem yapmak veya tedbir almak gibi kendilerinden beklenemeyecek bir yükümlülük altına girmiş olacaklardı. Kanun koyucu bu tür bir hükümle, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açı-

lan davalar bakımından bazı parasal sınırları adeta dondurmuş, bunlar hakkında artış hükümlerinin uygulanmayacağını kabul etmiştir.

İleride görüleceği üzere, HMK, imza atamayanların senet düzenlemesiyle ilgili olarak HUMK'ndan ayrılan bir düzenleme getirmiştir (m. 206). Bu nedenle de, *"1086 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunan senetlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da geçerliliklerini"* koruyacakları ayrıca öngörülmüştür (Geçici Madde 2).

HMK Geçici Madde 3 ile de, kanun yollarında uygulanacak kurallar ile HMK'nda bölge adliye mahkemelerine verilen görevlerle ilgili hükümlerin, bu mahkemeler kuruluncaya kadar nasıl anlaşılacağına ilişkin bir hüküm getirilmiş olup; bu konuya kanun yolları kısmında değinilecektir[30].

6763 sayılı Kanun ile HMK'na Geçici Madde 4 eklenmiş ve istinaf mahkemelerinin faaliyete başlamasından önce verilen kararlara karşı Yargıtay incelemesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

G) MEDENÎ USUL HUKUKU KURALLARININ YORUMU

Usul kuralları da, maddî hukuk kuralları gibi yoruma ihtiyaç gösterebilir. Bu konuda maddî hukukta kullanılan yorum yöntemleri geçerlidir. Bu anlamda kanun metnine bağlı kalınarak yapılan sözel (lafzı) yorum, amaca yönelik yorum, sistematik yorum ve tarihsel yorum (yasama yorumu) yöntemleri dikkat çekmektedir. Öte yandan, başta Anayasa'da bulunan yargısal temel haklar ve adil yargılanma hakkı olmak üzere, HMK'nda düzenlenen yargılamaya hâkim ilkeler (m. 24-33) de yorumda dikkate alınmalıdır. Ayrıca, HMK'nda yer alan madde kenar başlıkları da yorumda kullanılmalıdır.

Gerekçe de tarihsel yorum yöntemi içinde dikkate alınmakla birlikte, yorum yaparken, gerekçenin kanun metnine dahil olmadığı unutulmamalıdır.

---

30 Bkz. aşa. § 54-61.

§ 2. YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI

A) YARGI KAVRAMI

Yargı, yasama ve yürütmenin yanında ayrı bir erk olup, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır (Anayasa m. 9).

Yargı kavramı, maddî ve şeklî (organik) olmak üzere iki anlama gelmektedir:

Şeklî (organik) **anlamda yargı** tanımında, faaliyeti yürüten organın "mahkeme" olarak nitelendirilmiş olmasına bakılmakta ve mahkemenin tüm faaliyetleri yargısal sayılmaktadır. Bu, yargının geniş anlamda ele alınmasıdır ve bu anlayışa göre, mahkemelerin her türlü faaliyeti yargısaldır. Anayasa ve kanunların "mahkeme" olarak nitelendirmediği Hâkimler ve Savcılar Kurulu (Anayasa m. 159) ve Yüksek Seçim Kurulu gibi yargı ile ilgili (298 sayılı Kanun m. 111, II) veya önüne gelen konu hakkında kesin karar veren kurum ve kuruluşlar da geniş anlamda yargı organı olarak nitelendirilebilir. O halde şeklî (organik) anlamda yargı, yalnızca faaliyetin bir mahkeme tarafından yapılmasını dikkate alır ve faaliyetin içeriğine bakılmaksızın onun yargısal olduğunun kabul edilmesini gerektirir. Ayrıca bunun dışında mahkeme olarak açıkça nitelendirilmemekle birlikte bazı kurullar da verdikleri kararların niteliğinden dolayı yargısal faaliyet yapıyor gibi kabul edilebilir.

Maddî anlamda yargı ise, bir hukuka aykırılık iddiasının veya uyuşmazlığın, kesin hüküm teşkil edecek biçimde çözümlenmesidir. Bu ise, dar ve teknik anlamda yargı olarak tanımlanır. Bu tanıma göre yargısal faaliyetin en önemli unsuru, bir hukuki uyuşmazlığın tüm yönleriyle esastan çözümlenerek karara bağlanması ve bu kararın kesin hüküm niteliği taşımasıdır. Kesin hüküm, davanın tarafları arasındaki hukuki ilişkinin, bütün bir gelecek için kesin olarak tespiti veya düzenlenmesi ve aynı davanın hükmün kesinleşmesinden sonra yeniden açılamamasıdır.

Mahkemelerin yazı işleri faaliyetlerinin yürütülmesi (dosya veya arşiv tutulması ya da tebligat işlemlerinin yapılması gibi) veya iç işleyişlerine ilişkin bazı düzenlemeler yapmaları gibi bir kısım idarî faaliyetleri de bulunmaktadır. Mahkemeler bu faaliyetleri ile ne bir uyuşmazlık çözmekte ne de hukuka aykırılık iddiasını hükme bağlamaktadırlar. Dolayısıyla bu işlemler, daha çok idarî niteliktedir.

Bunun yanında, mahkemelerin bir uyuşmazlık çözme özelliği göstermeyen veya bir hukuka aykırılık iddiası içermeyen, verdikleri kararların kesin hüküm gücüne sahip olmadığı bir kısım faaliyetleri daha vardır. Bunlar ise, **çekişmesiz yargı** işleridir (m. 382 vd.). Hâkimler bu işleri yaparken, çekişmeli yargıda olduğu gibi, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak hareket ederler; burada, "kesin olarak uyuşmazlık çözme" söz konusu olmaz. Ancak Ana-

yasa Mahkemesi, çekişmesiz yargıyı da maddî anlamda yargı kavramına dahil etmektedir[1]. Çekişmesiz yargı konusuna ileride değinilecektir[2].

Yargılama yetkisini kullanan hâkim, özel güvencelere sahip, bağımsız ve tarafsız bir kişi olarak hareket eder. Bu nedenle yargısal faaliyet, hem yürütme hem yasama faaliyetinden kesin bir şekilde ayrılır.

B) YARGI YOLLARI (ÇEŞİTLERİ, KOLLARI)

Yargı, bir üst kavram olarak hukuka aykırılık iddialarının veya uyuşmazlıkların kesin olarak çözümü ya da belirli konularda karar verilmesi yetkisi olarak ele alındığında; bu kez, yargı organlarının görevine giren bütün hususlar bakımından aynı usul ve kuralların geçerli olup olmayacağı, başka bir deyişle, bütün bu sorunları karara bağlayacak tek tür bir yargı organı veya mahkemenin mi, yoksa farklı usuller uygulayan birden fazla mahkemenin mi olacağı sorusu sorulacaktır.

Türk hukukunda örgütsel yapılanmaya bakıldığında, Anayasanın yargı düzenlemesi başlığı altında farklı yüksek mahkemelere yer verdiği görülür (Anayasa m. 145-158; 160).

Anayasada açıkça yargı çeşidi, kolu veya yolu gibi bir kavram bulunmamaktadır. Ancak Anayasa, 158. maddesinde, "adlî, idarî yargı mercileri"[3] arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarından söz etmektedir. Anayasa Mahkemesi de bu hususu, farklı "yargı düzenleri" biçiminde ifade etmekte ve bundan, "kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu bütünlüğü" anlamaktadır.

Doktrinde de, Türk yargı örgütünün bu parçalı yapısı, yargı çeşidi, yargı yolu ve yargı kolu gibi isimlerle ifade edilmektedir. Bu kavram, uyuşmazlık veya konu itibariyle birbirine benzer nitelikte olan yargılama konusu olan hususların, ortak usul hukuku ilkeleri altında toplanarak karara bağlanmasını anlatmaktadır.

Yargı çeşidi (kolu-yolu) pozitif hükümler bakımından henüz yerleşmiş bir kavram değildir. Nitekim, hem Anayasa hem de Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, yargı mercileri arasında "görev" uyuşmazlığından söz ederek, bu durumu bir "görev" sorunu olarak ele almaktadır (Anayasa m. 158, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu m. 1, 10 vd.). Buna karşılık HMK, "yargı yolunun caiz olması"nı bir dava şartı olarak ayrıca düzenlemiştir (m. 114, 1/b).

"Yargı yolu", "görev"e oranla bir üst kavramdır. Çünkü, kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilebilen (aynı yüksek mahkemede kanun yolu incelemesine tâbi olan), yani aynı çatı (yargı yolu) altında bulunan farklı mahkemeler söz konusu olmakta ve bu çatı altında da "görev" sorunu ortaya

---

1 Anayasa Mahkemesi'nin bu yöndeki kararlarından birisi için bkz. Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası, Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, 17. Baskı, Ankara 2019, s. 85-87.

2 Bkz. aşa. § 70.

3 Anayasa m. 142, II'ye göre, disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.

çıkmaktadır. Hatta burada, bu çatıyı oluşturan yüksek mahkeme, "görev" sorununu çözmektedir. Oysa, farklı çatılar arasında çıkan "görev" uyuşmazlığı teknik olarak "görev" değil, bir "yargı yolu" uyuşmazlığıdır. Örneğin, bir alacak davasının asliye hukuk mahkemesinde mi, yoksa tüketici mahkemesinde mi görüleceği hususu, bir görev sorunudur ve bu konuda öncelikle istinaf mahkemesi, ancak nihaî olarak Yargıtay karar verir. Buna karşılık, bir tazminat davasının asliye hukuk mahkemesinde mi, idare mahkemesinde mi görüleceği konusunda bir tereddüt oluştuğunda, bu konuda nihaî olarak karar verecek olan ne Yargıtay ne de Danıştay olup, Uyuşmazlık Mahkemesi'dir. Çünkü iki ayrı yargı yolundan hangisinin bu davaya bakacağı bir görev değil, yargı yolu sorunudur.

Burada "yargı yolu" kavramıyla karıştırılabilecek bir başka kavram ise, "kanun (yasa) yolu"dur. Kanun yolu, teknik olarak, mahkeme kararlarına karşı bir üst mahkemeye veya aynı mahkemeye başvuruyu, bir hukukî çareyi ifade eder. Kanun yolu, olağan veya olağanüstü olabilir. Her yargı yolu içerisinde kendisine özgü kanun yolları düzenlenmiştir[4]. O nedenle kanun yolu ve yargı yolu birbirinden çok farklı ve karıştırılmaması gereken kavramlardır.

Buna karşılık, yukarıda da belirtildiği üzere, "yargı yolu" ve "görev" kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir.

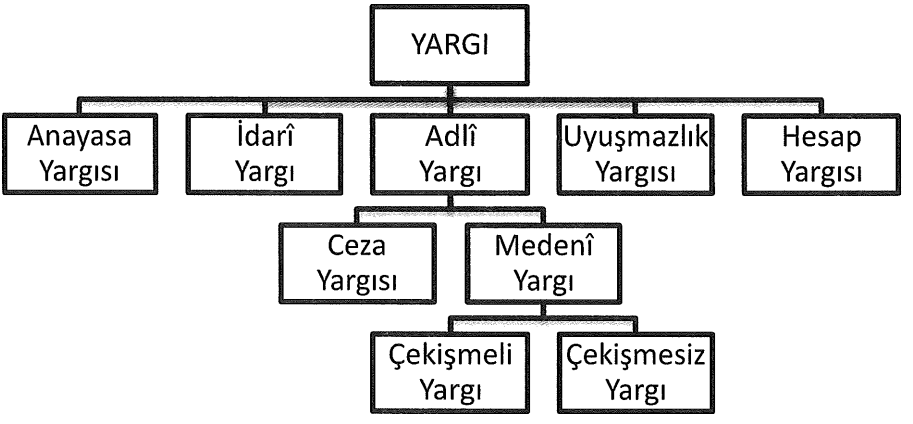
Türk hukukunda yargı örgütü parçalı bir yapı özelliği göstermekte, yani yargı tek bir çatı altında toplanmamaktadır. Bu nedenle esasen Türk yargı örgütü şeması bakımından yargı birliği değil, yargı ayrılığından söz edilebilir. Yukarıda belirtildiği üzere, Anayasa, 158. maddesinde adlî, idarî yargı mercilerinden, bir yargı yolu olarak söz etmekle birlikte, Anayasanın 146-160. maddelerinde öngörülen yüksek mahkemelerden hareketle, beş temel yargı yolunun varlığı kabul edilebilir: 1. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı, 2. Yargıtay ve Adlî Yargı, 3. Danıştay ve İdarî Yargı, 4. Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlık Yargısı. 5. Sayıştay ve Hesap Yargısı.

Bu yargı yolları arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmamaktadır. Hiçbir yargı yolundaki mahkeme, diğer yargı yoluna bağlı değildir. Bütün mahkemeler, bağımsızlık esasına ve hâkimlik teminatına göre görev yapar. Her yargı yolunda, o yargı yoluna ilişkin ilkeler çerçevesinde yargılama yürütülür. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi kararları, tüm yargı organlarını bağlar (Anayasa m. 153, VI); ayrıca diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır (Anayasa m. 158, III).

Kanımızca temel olarak anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, uyuşmazlık yargısı ve hesap yargısı biçiminde bir ayrımla yargı yollarını incelemek mümkündür. Burada yargı yolları, medenî usul hukuku bakımından önem taşıdığı ölçüde ve kısaca açıklanacaktır. Çünkü, bir davanın medenî yargıda görülebilmesi için "yargı yolu"nun caiz olması, genel bir dava şartıdır (m. 114, 1/b).

---

4 Bkz. aşa. § 54 vd.



I – ANAYASA YARGISI

Anayasa normlar hiyerarşisinde, en üstte bulunmakta ve hukuk devletinin hayata geçmesi için temel ilkeleri içermektedir. Anayasa, hukuk devleti ve insan hakları bakımından bir çerçeve öngörmekte; yasama organı da gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından, **kanunların** (Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İç Tüzüğü'nün) Anayasaya şekil ve içerik bakımından **uygunluğu denetlenmektedir.** Zira kanunlar Anayasaya aykırı olamaz (Anayasa m. 11).

Öte yandan, meclis çoğunluğunu elinde tutan parti veya partiler tarafından yasama yetkisinin sınırsızca, keyfî veya Anayasaya aykırı bir şekilde kullanılmasını önlemenin güvencesi de Anayasa Mahkemesi'nin denetimidir.

Anayasaya uygunluk kontrolü, Anayasa Mahkemesi'nin en önemli görevi olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi'ne, **Yüce Divan yargılaması** yapmak, **siyasi partilerin malî denetimlerini** gerçekleştirmek, TBMM'nin kanun dışındaki bazı kararlarını denetlemek gibi başka görevler de verilmiştir (Anayasa m. 146-163).

Öte yandan, 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'ne **"bireysel başvuru"** olanağı getirilmiştir. Buna göre, "Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir" (Anayasa m. 148, III). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında yargıyı ilgilendiren husus, adil yargılanma hakkıdır. Adil yargılanma hakkı, Anayasada da ifadesini bulmuş bir hak (Anayasa m. 36) olmasının yanında, taraf olduğumuz AİHS'nin de bir parçasıdır (AİHS m. 6; Anayasa m. 90). Adil yargılanma hakkına ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusuna da-

ha sonra ayrıntılı olarak değinileceğinden[5], burada yalnızca anayasa yargısının medenî yargı bakımından gösterdiği diğer özelliklere yer verilecektir.

Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası (soyut norm denetimi) veya itiraz yolu (somut norm denetimi) ile gidilir. Anayasada sayılan kişiler iptal davası açabilirken, mahkemeler de görülmekte olan bir davada[6] uygulayacakları kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmektedirler (Anayasa m. 150, 152). Hukuk mahkemelerinin, davada uygulanacak bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu kanısına varmaları halinde, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaları ileride incelenecektir[7].

Anayasaya uygunluk denetimi bakımından bir kanun hükmünün maddî hukuk veya usul hukuku kuralı olmasının önemi yoktur. Nitekim, HMK'nun kabulünden sonra çeşitli maddeleri (m. 3; 20; 23, 2; 46; 57; 109, 2; 150; 166-167; 240, 3; 317, 3; 357, 2; 367, 2; 353; 398), Anayasa Mahkemesi önüne götürülmüştür[8]. Bunlardan, örneğin HMK m. 3 Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş[9]; iptal kararı üzerine mahkemeler, yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle usulden ret kararı vermişlerdir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra uygulanacak kurallar, usul kurallarının iptali halinde de geçerli olur; örneğin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geçmişe etkili olmaz[10].

Nitelikleri gereği medenî yargı ile anayasa yargısı arasında pratik olarak dava şartı biçiminde (m. 114, 1/b) bir yargı yolu ilişkisi ortaya çıkmaz.

II – İDARÎ YARGI

1) İdarî Yargının İşlevi ve Yapısı

İdarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması, idarenin de hukukla bağlı olması, hukuk devleti olmanın gereğidir. Nitekim, Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere, Türk yargı örgütü, par-

---

5 Bkz. aşa. § 78.

6 Anayasa Mahkemesi, çekişmesiz yargıya ilişkin bir kuralı uygulayan hâkimin de Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurabileceğini kabul etmektedir. Karar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 85-87.

7 Bkz. aşa. § 39.

8 Kararlar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 113-119, 127-130, 131, 149-150; 151-153, 154-156.

9 Anayasa Mahkemesi'nin 16.02.2012 gün ve 35/23 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s.113-119. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi, HMK'nun 20. maddesindeki "...bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten..." ibaresi (Anayasa Mahkemesi'nin 10.02.2016 tarihli ve 96/09 sayılı kararı, RG 23.02.2016, sa. 29633) ile m. 398, 1'de yer alan "ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır" hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir (Anayasa Mahkemesi'nin 11.07.2018 tarihli ve 1/83 sayılı kararı, RG 20.02.2019, sa.30692).

10 Bkz. bu konuda Sema Taşpınar Ayvaz, HMK m. 3'ün İptali Üzerine Ortaya Çıkan Bazı Usulî Sorunlar (Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 3-5-6 Nisan 2013, Ankara Barosu Yayını, s. 363-384).

çalı bir yapı göstermektedir. Bu anlamda, idarenin eylem ve işlemlerine karşı ayrı bir yargı yolu olarak idarî yargı öngörülmüştür (Anayasa m. 155).

İdarî yargı, genel olarak, idarenin kamu gücüne dayalı olarak yaptığı, kamu hukuku kurallarına tâbi işlem, eylem ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli yargı yoludur. İdarî yargının konusu, idarenin idare (kamu) hukuku alanındaki faaliyetiyle ilgili uyuşmazlıklardır (idarî davalardır). Oysa medenî yargının konusu, özel hukuk alanındaki (özel hukuka ilişkin) uyuşmazlıklardır (hukuk davaları ve işlerdir). İdare (örneğin Devlet), bir işlemi, eylemi veya sözleşmeyi yaparken özel hukuk kişilerinin üstünde, kamu yetkisi/gücü kullanarak, bir kamu tüzel kişisi olarak hareket etmiş ise, uygulanacak hukuk, idare hukuku yani kamu hukukudur. Bu nedenle, böyle bir idarî işlem, eylem veya sözleşmeye ilişkin dava, kural olarak, idarî yargı mercilerinde (idarî mahkemelerde) görülür[11]. Örneğin, Devlet, bir memurunu emekliye ayırmış ve memur da bu işlemin kanuna (hukuka) aykırı olduğu kanısında ise, memurun başvuracağı yer, idarî yargı merciidir. Çünkü, burada Devletin kamu hukuku kurallarına göre yapmış olduğu bir (idarî) işlem söz konusudur. Fakat idarenin, istisnaî olarak bazı hallerde bir kamu kurumu olarak değil de, özel hukuk tüzel kişisi gibi özel hukuk kurallarına göre işlem, eylem veya sözleşme yapabilmesi de mümkündür. Örneğin, belediye, sahip olduğu bir dükkânı kiraya vermiştir. Bu kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda idareye karşı açılan dava, idarî yargı mercilerinde değil, hukuk mahkemelerinde görülür. Çünkü, burada davanın taraflarından biri idare (belediye) olmakla beraber, idarenin özel hukuk alanına giren bir faaliyeti söz konusudur ve özel hukuk alanında, idarenin, özel hukuk kişilerine karşı bir üstünlüğü yoktur. O halde bir uyuşmazlığın tarafının idare olması, onun mutlaka idarî yargıda çözülmesi gerektiğini göstermez.

İdarî yargı içerisinde yer alan yargı yerlerinden idare ve vergi mahkemeleri, ilk derece mahkemesi; bölge idare mahkemeleri ise, üst derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır[12]. Anayasada öngörülen yüksek mahkeme-

---

[11] İdarî davalar, hukuk mahkemelerinde karşı dava (m. 132) olarak da açılamaz (bkz. aşa. § 44).

[12] 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanun, bölge idare mahkemeleriyle ilgili önemli bir yenilik yapmıştır. Buna göre, asıl görevi idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlara ve Kanunda sınırlı sayıda belirtilen kurul halinde verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak olan bölge idare mahkemelerinin, istinaf mercii olarak tümüyle yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. 2576 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde, Adalet Bakanlığı'nın, 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (28.06.2014'ten) itibaren üç ay içinde 2576 sayılı Kanunun, 6545 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinde öngörülen bölge idare mahkemelerini kurması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca, 2577 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesinde de, 6545 sayılı Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümlerin, istinaf mercii olarak kurulacak olan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacağı öngörülmüş ve bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, 28.09.2014 tarihi itibariyle, istinaf mercii olarak görev yapacak bölge idare mahkemelerinin kurulması; durumun Resmî Gazete'de ilân edilmesi ve ardından bölge idare mahkemelerinin idari yargıda ikinci derece (istinaf) mah-

lerden biri olan Danıştay ise, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanında, idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece mahkemesidir (Anayasa m. 155)[13].

İdarî yargıda yer alan yargı organlarının kuruluş, görev ve yargılama usullerine ilişkin 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) mevcuttur.

İYUK, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözüm usullerini düzenlemektedir. İdarî yargı, medenî usulden büyük ölçüde farklıdır. Bununla birlikte, idarî yargı ile ilgili bütün kurallar, İYUK'nda düzenlenmemiş; HMK'na atıf yapılmıştır. Bu nedenle HMK, idarî yargıda da belirli ölçüde uygulama alanı bulur[14]. Buna göre, İYUK'nda hüküm bulunmayan ve açıkça atıf yapılan konularda HMK uygulanır. Bu düzenleme karşısında, iki yargı yolu bakımından genel-özel ilişkisi kurulamaz; zira, yalnızca açıkça atıf yapılan konularda HMK uygulanır[15].

2) İdarî Yargı-Medenî Yargı İlişkisi

Yukarıda da belirtildiği üzere, davalı tarafın idare olduğu ve bir özel hukuk kişisi olarak hareket etmediği hallerde, davanın idarî yargıda mı, medenî yargıda mı açılacağı önemli bir sorundur. Bu konu, olan ve olması gereken hukuk bakımından iki boyuta sahiptir.

İlk olarak, kanunlarda açıkça yargı yolu düzenlemesi yapılmasına rağmen, davacının yanlış yargı yerine başvurması (idarî yargı yerine medenî yargıya veya tam tersi) mümkündür. Yargı yolunun caiz olması, bir dava şartı olması nedeniyle, davanın başında, ön inceleme aşamasında dikkate alınması gereken bir hususdur (m. 114, 1/b; 138). Bu konudaki tereddütler veya belirsizlikler, yargı yolu uyuşmazlığına yol açar. Çünkü, bazı hallerde bir davanın idarî yargıda mı medenî yargıda mı görüleceği kolay tespit edilememekte; bu durumda, her iki yargı yerinin aynı davayı ayrı ayrı yürütmesi veya her ikisinin de davaya bakmaması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

---

kemeleri olarak görev yapmaya başlamaları öngörülmüştür. Bu mahkemeler **20.07.2016 tarihinde göreve başlamıştır.** Bkz. RG 07.11.2015, sa. 29525.

13 Danıştay, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir" (2575 s. K. m. 1).

14 "Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) hükümleri uygulanır. Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'sen yapılır" (2577 s. K. m. 31).

15 İdari yargıda inceleme, kural olarak dosya üzerinden yapılır (2577 s. K. m. 1/2) ve idari yargılama usulünde, delillerin araştırılmasında kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi uygulanır (2577 s. K. m. 20).

Bu sorunlar yargı yolu uyuşmazlığına yol açmakta olup, uyuşmazlık yargısı başlığı altında aşağıda incelenmektedir[16].

Konunun olması gereken hukuk bakımından dikkate alınacak yanı ise, bir tarafın Devlet (idare) olduğu, taraflar arasında eşit bir ilişkinin bulunmadığı uyuşmazlıklarda kanun koyucunun yargı yolunu belirlemede serbest olup olmadığıdır.

Bu konuda ilk olarak, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen HMK m. 3 örnek verilebilir. Bu hüküm, "Her türlü idarî eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddî ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır" şeklinde idi ve böylece, aslında idarî yargıyı ilgilendiren bir dava, medenî yargı konusu yapılmıştı.

Bu konuya ikinci bir örnek olarak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 101. maddesinde yer alan "...bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür" hükmü verilebilir. Burada, uyuşmazlığın bir tarafı idare, yani Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu halde, bu uyuşmazlıklarla ilgili davalar iş mahkemelerine, yani medenî yargıya görev olarak verilmiştir[17]. Bu konudaki örnekleri artırmak mümkündür. Nitekim, hâkimin fiil veya kararlarından dolayı veya bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı rapor vermesi ve bunun hükme esas alınması halinde Devlete karşı açılan tazminat davalarının medenî yargıda görülmesi (m. 47; 286); tapu sicilinin tutulmasından dolayı Devlete karşı tazminat davası açılması (TMK m. 1007, 3) ya da icra dairesi görevlilerinin fiil veya işlemlerinden dolayı Devlete karşı dava açılması halinde de (İİK m. 5), davanın bir tarafı "Devlet"tir. Aynı şekilde, kamulaştırma ile ilgili bazı davalar (Kamulaştırma K. m, 10; 14 ve 37); İmar Kanunu'na göre bedelin indirilmesi davası (İmar K. m. 17); işleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin bulunanlar dahil, Karayolları Trafik Kanunu'ndan doğan tazminat davaları (Karayolları Trafik K. m. 110); Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca açılacak dava; orman sınırlamasına itiraz davaları (Orman K. m. 11) idarî yargıda değil, medenî yargıda açılır.

---

[16] Bkz. aşa. § 2, IV.

[17] Anayasa Mahkemesi bu hükmü Anayasaya aykırı görmemiştir (Anayasa Mahkemesi'nin 22.12.2011 gün ve 65/169 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik s. 111-113). Bu kararın gerekçesindeki, "İdarî yargının denetimine bağlı olması gereken idarî bir uyuşmazlığın çözümü, haklı neden ve kamu yararının bulunması halinde yasa koyucu tarafından adlî yargıya bırakılabilir. 5510 s. K. ile birlikte sosyal güvenlik tek çatı altında toplanmış, özel hukuk niteliği ağır basan sosyal güvenlik hukuku alanı oluşturulmuştur... İş mahkemeleri, iş hukuku alanındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevli, ihtisaslaşmış adlî yargı mahkemeleridir. Yasa koyucu 5510 s. K. kapsamındaki iş ve işlemler, prim esasına dayalı yeni sistemin niteliğine bağlı olarak, iş mahkemelerinin görev alanı kapsamına alabilir..." ibareleri dikkat çekicidir.

Yargı yolları arasında mutlak bir ayrım olmadığı, kanunlardaki bu tür düzenlemelerden anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi, esasen bir yargı yolunu belirlemenin kanun koyucunun takdirinde bulunduğunu, kişilere hukukî himaye sağlamanın önemli olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, idarî yargı yolunda görülmesi gereken bir uyuşmazlığın medenî yargıda çözülmesini öngören veya tam tersi bir düzenleme yapan kanunu, Anayasaya uygunluk bakımından denetime tâbi tutmaktadır. Anayasa Mahkemesi, bu tür düzenlemelerde **"haklı neden** ve **kamu yararı"** bulunup bulunmadığı noktasından yaptığı değerlendirme ile bir sonuca varmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, idarî yargıda görülmekteyken medenî yargıya taşınan tazminat davaları bakımından HMK m. 3'ü bu gerekçelerle iptal ederken[18]; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 101. maddesini Anayasaya aykırı bulmamıştır.

Bir hukuk davası içerisinde, idarî yargı tarafından çözümlenmesi veya idareye başvurulması gereken hallerle de karşılaşılabilir. Hukuk mahkemesinin, idarenin veya idarî yargının görevine giren bir konuda karar vermesi, mümkün değildir; zira, yargı yolu dava şartıdır. Ancak, bu hususun çözümü, hukuk mahkemesinin kararını etkileyecekse, hâkim, bu durumu, bekletici sorun yapabilir (m. 165). Bu halde, hukuk mahkemesi, idarî yargının vereceği karara kadar kendi elindeki davayı görmez, idarî yargının kararını bekler.

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine karşı (davalı gösterilerek) idarî yargıda idarî dava açılamaz; idarî davalar idareye karşı açılır. Bir idarî işlem veya eylem ile ilgili olsa bile, özel hukuk kişilerine karşı dava, hukuk mahkemelerinde açılır. Hukuk mahkemesinde özel hukuk kişisine karşı açılan bir davada idare de (aynı davada dava arkadaşı olarak) davalı gösterilirse, hukuk mahkemesi, idareye karşı açılmış olan davayı ayırarak (m. 167) davanın bu bölümü için yargı yolunun caiz olmadığına karar verir; özel hukuk kişisine karşı açılmış olan davayı ise inceleyip sonuçlandırır.

Bunun gibi, idarî yargıda açılan bir idarî davada, idarenin yanında bir özel hukuk kişisi de dava arkadaşı olarak davalı gösterilirse, mahkeme, özel hukuk kişisine karşı açılmış olan dava için ayırma ve yargı yolunun caiz olmadığı kararı verir; idareye karşı açılmış olan davayı ise inceleyip sonuçlandırır. Fakat, özel hukuk kişileri, idarî yargı yerinde idareye karşı açılmış olan davaya hukukî menfaatleri bulunmak şartı ile, davalı idare yanında fer'i müdahil olarak katılabilirler (2577 s. K. m. 31; m. 66-69).

III – ADLÎ YARGI

1) Genel Olarak

Yargı yolları arasında en geniş alana sahip yargı yolu, adlî yargıdır. Anayasanın 154. maddesinde düzenlenen Yargıtay çatısı altında adliye mahkemelerinden söz edilmektedir. Bu yargı çeşidinin bu denli geniş olması, iki büyük alt yoldan (koldan) oluşmasından kaynaklanmaktadır. Zira adlî yargıda,

---

[18] Anayasa Mahkemesi'nin 16.02.2012 gün ve 35/23 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası- Usul Pratik, s.113-119.

hem kişilerin özel hukuk ilişkilerinden veya toplumsal yaşamdan kaynaklanan uyuşmazlıklarının hem de cezaî sonuçlar doğuran bazı fiillerin dava konusu olması söz konusudur. O nedenle adlî yargı, **medenî yargı** ve **ceza yargısı** biçiminde bir ayrıma, alt yola, tâbi tutulmaktadır. Medeni yargı alt yolu geniş olarak incelenmeden önce, ceza yargısını kısaca tanımakta yarar vardır.

2) Ceza Yargısı

Adlî yargının büyük kolundan biri olan **ceza yargısı**, kanunların (Devletin) suç saydığı fiillerin cezalandırılması usullerini içermektedir. Bu yargı ile ilgilenen yargı koluna, "ceza usulü hukuku" (ceza muhakemeleri usulü; ceza muhakemesi hukuku) da denir.

Adlî yargı, tek bir çatı altında toplanmış olmasına rağmen, medenî yargı ve ceza yargısı, yargılama konularının ve bunların temelinde yatan korunmaya değer menfaatlerin farklılığı nedeniyle birbirinden farklı ilke ve usullere sahiptir.

Ceza yargısı, kanunların suç saydığı fiillerin cezalandırılmasına ilişkin usulleri içermektedir. Suç işlenmesi, kamu düzenini bozan bir durum yarattığı için, fiilin ağırlığına göre, ilgilisi tarafından şikâyetle ya da cumhuriyet savcıları tarafından resen (kendiliğinden) kovuşturulmak suretiyle ceza mahkemesi önüne getirilir. Ceza yargısının temelinde yatan kamu düzenini koruma düşüncesi, resen araştırma ilkesinin uygulanmasına neden olmaktadır. Öte yandan, suçsuzluk karinesi, şüphenin sanık lehine yorumlanması, hâkimin vicdanî kanaatine göre karar vermesi, takdirî delillerle ispatın geçerli olması yönleriyle, ceza yargısının medenî yargıdan ayrılan pek çok özelliği bulunmaktadır. Ceza hâkimi, hukuk hâkiminin tersine, ceza davasında aktif bir rol üstlenmektedir.

Ancak bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık bazen cezaî sonuçlara da sahip olabilir; benzer şekilde cezaî sonuç doğuran bir fiil, hukukî sonuçlar da doğurabilir. Örneğin, bir senedin tahrif edilerek borç miktarının değiştirilmesi veya imza taklidi yoluyla senet düzenlenmesi halinde, kişi borç altına girmiş, cebrî icra tehdidi altında kalmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda ceza hukuku açısından da sahtecilik suçuna yol açar. Buna rağmen özel bir düzenleme ile bu hususun medenî yargıda görülebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, bir senedin sahteliğinin tespiti için hukuk mahkemesinde ayrı bir dava açılabileceği gibi, görülmekte olan bir hukuk davasında da sahtelik iddiası ileri sürülebilir (m. 209). Bu durumda hukuk ve ceza mahkemelerinin sahtelik konusundaki kararlarının birbirine etkisi ayrıca düzenlenmiştir (m. 214).

Yine, ölümlü veya yaralamalı bir trafik veya iş kazası hem ceza davasına hem de tazminat davasına konu olabilir. Bu durumda hukuk mahkemesi, fiilin suç teşkil edip etmediği bakımından ceza mahkemesinin kararını bekletici sorun yapabilir (m. 165). Beklenen dava sonucunda çıkan kararın hukuk

mahkemesindeki davaya etkisi ise ayrıca TBK'nda düzenlenmiştir (TBK m. 74)[19].

Bu durumun tam tersi de söz konusu olabilir. Bir fiilin suç sayılıp sayılmaması, özel hukuka ilişkin bir sorunun çözümlenmesine bağlı ise, ceza mahkemesi, bunu ceza usulü kurallarına göre kendisi karara bağlayabilir. Bununla beraber ceza mahkemesi, o sorunu kendisi çözmeyip, yargılamayı erteleyerek, hukuk mahkemesinde hukuk davası açmaları için ilgililere bir süre verebilir ve hukuk mahkemesinin bu konudaki kararını bekleyebilir (CMK m. 218).

Bazı hallerde ise, aslında medenî yargıya tâbi olan bir davanın, özel bir kanun hükmü ile ceza yargısında görülebileceği hükme bağlanmıştır; örneğin, ceza mahkemelerinde kovuşturma evresinde suçtan zarar görenlerle sanıkların yaşlarında ceza hükümleri bakımından gerekli görülecek düzeltmelerin Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki usule göre yapılması ceza mahkemesine aittir[20].

Buna karşılık, hukuk mahkemesinde edilen yeminin veya yapılan tanıklığın (ve bilirkişiliğin) gerçeğe aykırı olmasından dolayı, hukuk mahkemesi ilgiliye ceza veremez. Bu konudaki ceza davaları, ceza mahkemesinde görülür (m. 239; 375, 1/e, f, g)[21].

Öte yandan bazı hallerde hukuk hâkimine cezaî yaptırımlar veya disiplin para cezası uygulama yetkisi de verilmiştir (m. 42, 4; 49; 151; 182; 218, 2; 245; 291, 3; 329, 2; 446). Bundan başka, İİK'nun 331 ve sonraki maddelerindeki icra-iflâs suçlarının büyük bir kısmına bakmak ve bu suçlar için ceza vermek, ağırlıklı olarak icra hukuk mahkemesi olarak görev yapan icra mahkemesinin görevi içindedir.

Hukuk ve ceza mahkemeleri arasındaki ilişkinin niteliği açık bir şekilde düzenlenmemiştir. Her iki mahkemenin kararlarının istinaf merciinin bölge adliye mahkemesi ve temyiz merciinin Yargıtay olması ve adlî yargı çatısı altında bulunmaları nedeniyle hukuk ve ceza mahkemeleri arasındaki ilişki, yargı yolu ilişkisi değildir. Bu mahkemeler arasında aynı tür mahkemeler arasında söz konusu olan "görev" ilişkisinin bulunduğu da söylenemez. Ancak Yargıtay, burada görev ilişkisi varmış gibi, yargı yeri belirlenmesi (m. 21-23) hükümlerini[22] uygulamaktadır.

3) Medenî Yargı

a) Genel Olarak

Medenî yargı, özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile bireylerin kişi veya malvarlığı değerlerini, dolayısıyla hukukî durumlarını ilgilendiren bazı konularda karar verme usullerini içermektedir. Bu nedenle me-

---

19 Bu düzenleme yalnızca haksız fiiller bakımından geçerli olup, konu aslında genel olarak hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının birbirine etkisinin ne olacağı bakımından daha geneldir. Bu konuda bkz. aşa. § 64.

20 Bkz. CMK m. 218, II; 31.01.1945 gün ve 22/3 sayılı İBK (RG 20.03.1945, sa. 5960).

21 Bkz. aşa. § 64.

22 Bkz. aşa. § 11.

denî yargı da, kendi içerisinde **çekişmeli yargı** ve **çekişmesiz yargı** adı altında bir sınıflandırmaya konu olmaktadır.

"Medenî" sözcüğü, "kamu"nun tersi, yani "özel" (sivil, civil) alana ilişkin olmayı ifade eder. Burada, eşit kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara veya bireyin kişi veya malvarlığına ilişkin hukukî durumuna ilişkin bazı kararların alınması söz konusu olmaktadır. Özel hukuk, medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, eşya veya miras hukuku gibi alanları kapsamaktadır.

Gerçek kişiler bakımından bireyin hukukla teması, daha dünyaya gelmeden başlamakta, anne karnındaki cenin, bazı koşullarla "hak" sahibi sayılmakta ve "hak ehliyeti"ne sahip olmaktadır (TMK m. 28). Doğumdan sonra ise, kendi başına işlem yapma yeteneğine sahip olmayan "çocuk", anne babası veya üçüncü bir kişi tarafından temsil edilmektedir (TMK m. 16). Yine hukuk, kişilerin ilişkilerini belirli nedenlerle düzenlemekte, örneğin, "nişanlanma"ya hukukî sonuç bağlamakta; "evlenme"yi düzenlemektedir (TMK m. 118 vd.; 124 vd.). Bunun yanında hısımlık, aile ilişkileri de hukukun alanına girmektedir (TMK m. 283 vd.). İnsan yaşamının değişik aşamaları ve süreçleri de hukuka konu olmaktadır. Örneğin, yaşlanma veya diğer sebeplerle ortaya çıkan ehliyet veya yaşamı idame ettirme sorunları da hukukun kayıtsız kalamayacağı alanlardır (TMK m. 396 vd.). Yaşamın sonlanması, yani ölüm de hukuken ortaya yeni sorunların çıkmasına sebep olabilmektedir (TMK m. 495 vd.).

Bütün bu örnekler, olağan ve hukukla en az temas eden kişiler bakımından, olası özel hukuk sorunlarıdır. Bunun yanında günlük yaşamda kurulan alım-satım, ödünç veya kira gibi pek çok basit ve sıradan ilişki yanında, daha karmaşık (nitelikli) işlemler de karşımıza çıkmakta, ticari hayatın getirdiği pek çok sorun söz konusu olabilmektedir. Öte yandan, bu sayılan sorunların bir kısmı gerçek kişileri ilgilendirmekte; buna karşılık, hukuk sistemi aynı zamanda tüzel kişileri de öngörmekte ve bunları dernek, vakıf, şirket ve benzeri adlarla düzenlemektedir. Dolayısıyla, özel hukuka ilişkin tüzel kişilere yönelik ve onlara özgü hükümler de bulunmaktadır (TMK m. 47 vd.).

İşte burada ortaya çıkan sorunların çözüm veya karara bağlanma usulleri, medenî yargının konusunu oluşturmaktadır. Medenî yargı da, çekişmeli ve çekişmesiz yargı olarak ikiye ayrılmaktadır.

b) Çekişmeli Yargı

Yukarıda ifade edilen gerçek veya tüzel kişileri ilgilendiren, özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, medenî yargıda "çekişmeli yargı"nın alanını belirlemektedir. Esasen çekişmeli yargı, medenî yargının temelini oluşturur. Burada menfaat çatışması içinde olan iki taraf söz konusudur. Ancak taraflar arasında bir hiyerarşik (altlık-üstlük) ilişki bulunmayıp, taraflar eşittir.

Çekişmeli yargı, dava ile başlayan bir süreci; davanın çeşitli aşamalarını, tarafların ve mahkemenin görev, yetki ve haklarını ve karar verilmesi ile karara karşı kanun yollarına başvurulması yol ve usullerini içermektedir.

HMK da, ağırlıklı olarak, çekişmeli yargıyı esas alarak düzenleme yapmış, bu konuda ilkeler öngörmüştür. Medenî usul hukuku da, bu ilke ve usulleri konu edinmektedir.

c) Çekişmesiz Yargı

aa) Kavram ve Çekişmeli Yargıyla İlişkisi

Yargısal faaliyet, uyuşmazlıkların belirli usullerle, kesin bir şekilde (bütün bir gelecek için) karara bağlanması çalışmasıdır. Ancak bu niteleme, yargının maddî anlamındaki tanımına karşılık gelmektedir. Oysa yukarıda da belirtildiği üzere, yargının bir de şeklî (organik) anlamda tanımı vardır; buna göre, mahkemelerin her türlü faaliyeti yargısaldır.

Öte yandan Anayasaya göre, hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka, resmî veya özel bir görev yapamazlar (Anayasa m. 140, V). O halde burada sorunu şu şekilde ortaya koymak mümkündür: Hâkimlerin bütün faaliyetleri yargısal mıdır veya kanunlarla hâkimlere, uyuşmazlık çözmek dışında bir kısım görevler verilmesi, bunları yargısal faaliyet haline getirir mi?

Soruları cevaplamadan önce, hâkimlerin maddî anlamda yargı faaliyeti sayılmayan görevlerine örnekler vermek uygun olacaktır. Örneğin, hâkimler, kendilerine bağlı görev yapan yazı işleri personelini denetlemekte, bu konuda çeşitli kararlar vermektedirler. İşte bu kararlar veya tasarrufların yargı yetkisinin kullanılmasıyla bir ilgisi yoktur. Bunlar, idarî işler olup, bu bakımdan hâkimler, Adalet Bakanlığına bağlı görev yaparlar (Anayasa m. 140, VI). Nitekim, bu tür konularda Adalet Bakanlığı, mahkemelere genelge gönderebilmektedir (karş. Anayasa m. 138, II). Bu hususlar şeklî anlamda da yargı faaliyeti sayılmaz.

Buna karşılık, mahkemelere verilen bir kısım görevler vardır ki, bunlarda da tipik bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan sorun veya bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Hatta, bunların bir kısmında mahkeme, yalnızca "onay" makamı olarak faaliyet göstermektedir. Örneğin, nüfus kayıtlarında yer almasına rağmen gerçekte kullanmadığı ismini değiştirmeyi isteyen kişi veya boşandıktan hemen sonra yeniden evlenmek isteyen kadın ya da cinsiyet değiştirmek isteyen kişi ya da ölüm halinde, murisin mirasçısı olduğunu belirten kişi, bütün bu isteklerini herhangi bir idarî makama başvurarak ya da tek başına kendi iradesiyle gerçekleştirmemektedir. Yine örneğin, noterler, göreve başlamadan önce, mahkeme önünde yemin ederler. Mahkemeler, bu gibi işlerde bazen "onay", bazen "izin" makamı, bazen de "yeni bir durum oluşturmaya" yönelik karar organı gibi görev yapmaktadırlar. Bütün bu sonuçlar, bireylerin malvarlığını veya kişivarlığını doğrudan doğruya etkilemektedir. Buna karşılık, yalnızca biçimsel bir anlam taşıyan, mahkeme önünde "yemin" edilmesinde bu özellik de bulunmamaktadır. Oysa çekişmeli yargıda, mevcut bir hukukî ilişki bakımından ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması esastır ve burada kural olarak yeni bir durum yaratılmaz. Öte yandan, burada uyuşmazlıklar, bütün bir gelecek için "kesin hüküm" teşkil edecek ve bir daha mahkeme önüne getirilemeyecek şekilde çözüme kavuşturu-

lur. Oysa çekişmesiz yargıda, bir uyuşmazlık çözümü söz konusu olmadığı gibi, mahkemenin bu konuda verdiği karar da kural olarak kesin hüküm teşkil etmez (m. 388); yani aynı konu (sorun) tekrar mahkeme önüne getirilebilir.

Mahkemelerin, tipik uyuşmazlık çözme faaliyetine dahil olmayan bu işlerine, **"çekişmesiz yargı"** adı verilmektedir.

Bu noktada, mahkemelere bu görevlerin neden verildiği sorusu sorulabilir. Gerçekten, aslî görevi uyuşmazlık çözmek olan mahkemelere bu tür görevler verilebilir mi?

Anayasa Mahkemesi, çeşitli kararlarında, yargı faaliyetinin şeklî (organik) ve maddî anlamda olduğunu, çekişmesiz yargı işlerinin daha çok "yönetim" işlerinden sayılacağını, ancak hâkimlerin bu faaliyetlerinin de yargısal olduğunu kabul etmektedir. Anayasa Mahkemesi, **"kamu yararı"** düşüncesiyle, çekişmesiz yargı işlerinin bağımsız, tarafsız ve güvenceli görev yapan hâkimlere bırakılmasının uygun olacağını, bu konuda kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin aslî görevinin uyuşmazlık çözmek olduğu gerçeğinin de gözden uzak tutulmaması ve mahkemelerin bu görevlerini aksatacak ölçüde çekişmesiz yargı işleriyle uğraşmaması gerektiğini ifade etmektedir[23].

Çekişmesiz yargı işlerinin mahkemelerin aslî görevi olmadığı düşüncesiyle, bir kısmının mahkemelerden alınarak, örneğin noterler tarafından yapılması gündeme gelmektedir. Bu anlamda, belirli koşullarla mirasçılık belgesinin noterlerce düzenlenmesi ve terk eden eşin ortak konuta davetinin noter tarafından yapılabilmesi olanağı getirilmiştir (Noterlik K. m. 71A-C)[24].

bb) Çekişmesiz Yargının Ölçütleri

Çekişmesiz yargı, ilk defa HMK'nda ayrı bir kısım ve terim olarak yer almıştır (m. 382-388). Bundan önce, çekişmesiz yargı işleri için "dava", "hasımsız dava" ve "tek taraflı dava" terimleri kullanılmaktaydı. Oysa dava, iki taraf sistemine göre kurulmuştur. Çekişmesiz yargıda ise birbiriyle uyuşmazlık (çekişme) halinde olan iki taraf yoktur. Bu nedenle, çekişmesiz yargı işleri için dava, hasımsız dava veya tek taraflı dava terimlerinin kullanılması yanlıştı; HMK m. 382 vd.da yapıldığı gibi, bunlara çekişmesiz yargı işleri denilmesi gerekir. Nitekim bazı Yargıtay kararlarında çekişmesiz yargı işlerinde herhangi bir kişinin hasım olarak gösterilmesinin gereksiz olduğu belirtilmekte ve çekişmesiz yargı işleri için dava terimi kullanılmayıp, **"istek"** veya **"istem"** (talep) terimi kullanılmaktadır ki, doğru olan da budur.

HMK, çekişmesiz yargıyı, "hukukun, mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanması" olarak kabul etmekte (m. 382) ve bu konudaki ölçütleri daha önce doktrinde savunulan görüşler doğrultusunda şu şekilde sıralamaktadır:

---

[23] Bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 85-87.

[24] Anayasa Mahkemesi, bu yetkinin noterlere verilmesini Anayasaya aykırı bulmamıştır. Karar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s.133-134.

a) İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller,

b) İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı haller,

c) Hâkimin resen harekete geçtiği haller.

Buna göre, çekişmeli yargı; taraflar arasında ortaya çıkmış bulunan bir uyuşmazlık hakkında karar verilmesi talebi ile açılan davalarla ilgilenir. Buna karşılık, çekişmesiz yargıya tâbi işlerde, ortada ilgililer arasında kural olarak bir **çekişme (uyuşmazlık) yoktur.** Yani çekişmesiz yargıda mahkemenin, ilgililer arasında mevcut bir uyuşmazlık hakkında karar vermesi söz konusu değildir. Bu ölçüte göre, mahkemelerin baktığı (ve ilgililer arasında uyuşmazlık konusu olmayan) bütün işler çekişmesiz yargı işidir (m. 382). Örneğin: ergin kılınma (TMK m. 12), evlenmeye izin verilmesi (TMK m. 126, II), evlenme sürelerinin kısaltılması (TMK m. 132), adın (ismin) değiştirilmesi (TMK m. 27), bir kimsenin gaipliğine karar verilmesi (TMK m. 32-35), vasiye dava açmak için izin verilmesi (TMK m. 462, 8), vesayet ve kısıtlama işleri (TMK m. 396 vd.), mirasçılık belgesi (TMK m. 598) verilmesi[25], ticarî defterlerin kaybolması halinde belge verilmesi (TTK m. 82, 7), kıymetli evrakın iptali (TTK m. 651; 657; 661 vd.) ve evlat edinmeye izin verme (TMK m. 315-316) işleri, çekişme yokluğu ölçütüne göre çekişmesiz yargı işleridir.

Medenî yargıya dahil olan ve uyuşmazlık konusu oluşturan bütün işlerin çekişmeli yargı işi olduğu söylenemez; uyuşmazlık içermelerine rağmen, çekişmesiz yargıya dahil olan başka işler de vardır. İlgililerin özel hukuk kişilerine karşı ileri sürebilecekleri sübjektif haklarının bulunmadığı işler, (uyuşmazlık konusu olsalar bile) **"sübjektif hakkın yokluğu"** ölçütüne göre çekişmesiz yargıya tâbidir. Örneğin, velâyetin kaldırılması (TMK m. 348) ve vasinin görevden alınması (TMK m. 483) işleri gibi.

Bundan başka, hâkimin kendiliğinden (resen) harekete geçmesi (işe el koyması) gereken bütün işler, "**kendiliğinden harekete geçme**" ölçütüne (m. 385, 2) göre çekişmesiz yargıya tâbidir. Örneğin, boşanmadan sonra meydana gelen yeni bir durum nedeniyle çocuklar hakkında durumun gerektirdiği yeni tedbirlerin alınmasına karar verilmesine (TMK m. 183), çocuklar hakkında koruma tedbirleri alınmasına (TMK m. 346) ve çocukların bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesine (TMK m. 347) karar verilmesi işleri gibi. Çekişmeli yargıda yargılamaya (davaya) başlama, davacının isteği (dava açması) ile olur. Başka bir deyişle, çekişmeli yargıda, mahkemenin kendiliğinden bir davaya bakması imkânsızdır (m. 24)[26]. Yalnız kanun, kamu yararının korunmasının ağır bastığı bazı hallerde, Cumhuriyet savcılarına hukuk davası açma yetkisi tanımıştır (m. 70), ancak bu da resen harekete geçme değildir; çünkü hâkim, burada savcı tarafından açılan davaya bakmaktadır[27].

HMK, getirdiği bu ölçütler yanında, uzunca bir liste yapmak suretiyle özel hukuka ilişkin alanlarda, farklı kanunlarda yer alan çekişmesiz yargı işlerini saymıştır (m. 382, 2). Bu konuda iki hususa dikkat etmek gerekir. İlk olarak, bu sayma, sınırlı olmayıp, örnek niteliğindedir. İkinci husus ise, burada sayı-

---

25 Ayıca bkz. Noterlik K. m. 71/A.

26 Bkz. aşa. § 5, B.

27 Bkz. aşa. § 4, C.

lan işler, HMK'nun belirttiği ölçütlere uygun olmasa da çekişmesiz yargı işi niteliğindedir. Başka bir ifadeyle Kanun, saydığı bu işlerin, yine Kanunda belirtilen ölçütleri taşıdığını kabul etmektedir. O halde, Kanunda belirtilen ölçütler, Kanunda açıkça çekişmesiz yargı işi olarak belirtilmeyen hususlar bakımından yol gösterici olacaktır.

Görüldüğü gibi, çekişmesiz yargı, çekişmeli yargıdan önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Medenî usul hukukunun konusu da büyük ölçüde çekişmeli yargıdır. Nitekim HMK, düzenlemelerini, çekişmeli yargıyı esas alarak yapmıştır. Ancak yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere, mahkemelerin çekişmesiz yargı alanında da oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. Bu nedenle, çekişmesiz yargının taşıdığı özellikler, çekişmeli yargıya ilişkin hususlar tamamlandıktan sonra daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır[28].

IV – UYUŞMAZLIK YARGISI[29]

1) Genel Olarak

Türk yargı örgütü sistemi parçalı bir görünüm taşıdığından ve birbirinden farklı ilkelerle işleyen yargı yollarından oluştuğundan, kimi konularda yorum farklılıkları oluşması ve böylece tereddütler olması kaçınılmazdır. Esasında her yargı yolunun en tepesinde bir yüksek mahkeme bulunduğu için, son karar mercii orası olacaktır. Dolayısıyla, bir yargı yolu içerisindeki bazı sorunlar, o yargı yolunun yüksek mahkemesinde çözülecektir. Ancak aynı konuda iki yargı yolu (çeşidinin) kendisini görevli kabul etmesi veya hiçbirisinin kendisini görevli görmemesi halinde hangi yargı yoluna başvurulacaktır? Yine, bir yargı yolunda bir karar verilip kesinleştiği halde, bir başka yargı yerinde de aynı konuda, ancak tam tersine bir karar verildiğinde hangi karara üstünlük tanınacaktır? Bütün mahkeme kararları bağlayıcı olduğu (Anayasa m. 138) için bir yargı yerinin diğer yargı yerinin kararına karşı üstünlüğü bulunmamaktadır. İşte bu gibi hallerde sorunu çözecek bir başka yargı yoluna ihtiyaç duyulmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, istisnai birkaç halde bu ihtiyaç ortadan kalkar. Nitekim, Anayasanın 158. maddesinin üçüncü fıkrasında "diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır" hükmü bulunmaktadır. Yine, Anayasanın 160. maddesinin ikinci fıkrasına göre, "vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır" düzenlemesi vardır.

Söz edilen bu hükümler dışında, ortaya çıkabilecek yargı yolu ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmek üzere, bir başka yargı yolu düzenlenmiş ve yüksek mahkeme kurulmuştur. Bu yargı yolu, uyuşmazlık yargısı ve görevli mahkeme de Uyuşmazlık Mahkemesi'dir. Buna göre, "Uyuşmazlık Mahkemesi adlî

---

[28] Bkz. aşa. § 70.

[29] Bkz. Ufuk Yeşil, Türk Yargı Sisteminde Görev ve Hüküm Uyuşmazlıklarının Çözüm Usulü, Ankara 2016.

ve idarî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye" yetkilidir (Anayasa m. 158, I)[30].

Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk mahkemeleri ile idarî mahkemeler (idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay) arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümler.

Daha önce de ifade edildiği gibi, Anayasada "yargı yolu" değil, "görev" kavramı kullanılmıştır. Ancak HMK, m. 114, 1/b'de açıkça "yargı yolu"nun caiz olmasını bir dava şartı olarak düzenlemiş, mahkemenin "görev"li olmasını da ayrı bir dava şartı olarak hükme bağlamıştır (m. 114, 1/c). "Görev", aynı yargı yolundaki mahkemeler arasında söz konusuyken, "yargı yolu", farklı yargı kolları (yolları) arasında geçerlidir. Nitekim ileride değinileceği üzere, bir hukuk mahkemesinin görevsizlik kararı üzerine yapılması gereken işlemler (m. 20)[31] ile yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle davanın usulden reddi farklı hükümlere bağlanmıştır. Ancak bu kavramlar birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Nitekim Anayasada ve 2247 sayılı Kanunda, "görev" uyuşmazlığı denilmiştir. Aşağıdaki açıklamalarda Kanunun ifadesine yer verdiğimizden, kullandığımız "görev" kavramı, esasen "yargı yolu"nu karşılamaktadır.

2) Yargı Yolu (Görev) Uyuşmazlığı

Uyuşmazlık Mahkemesi, ilk olarak; adlî ve idarî yargı mercileri arasındaki yargı yolu (görev) uyuşmazlıklarını karara bağlar.

Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı, **olumlu görev uyuşmazlığı** ve **olumsuz görev uyuşmazlığı** olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Olumlu Görev Uyuşmazlığı

Olumlu görev uyuşmazlığı, iki ayrı yargı yolunun, (iki ayrı yargı yoluna mensup olan mahkemenin) bir davada kendini görevli sayarak davayı görmesi halinde ortaya çıkar. Nitekim, adlî ve idarî yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin **her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları**; görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında ise, bu kararların kesinleşmiş bulunması durumunda, olumlu görev uyuşmazlığından söz edilir (2247 s. K. m. 17, I).

Bir yargı yerinde dava açıldıktan sonra aynı konu, sebep ve taraflar arasında bir başka davanın açılamaması gerekir. Çünkü buna "derdestlik" engeldir. Medenî yargıda, bu şekilde bir dava açılması halinde, davanın her aşamasında bir dava şartı olarak "derdestlik"in bulunduğu, dolayısıyla aynı konu, sebep ve taraflar arasında, bu ikinci davanın görülemeyeceği her zaman ileri sürülebilir (m. 114, 1/ı). Buna karşılık, örneğin, bu davaların birisinin medenî, diğerinin idarî yargıda açılması halinde, teknik anlamda (m. 114, 1/ı)

---

30 Bkz. Anayasa m. 158; 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun.

31 Bkz. aşa. § 9, G.

derdestlik itirazı ileri sürülemeyip; burada, her iki yargı yolundan birisinin bu davayı göremeyeceğinin ifade edilmesi gerekir. Ancak, burada tarafların doğrudan doğruya Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurma yetkileri bulunmamaktadır. Bu konuda 2247 sayılı Kanun, "uyuşmazlık çıkarılması"ndan söz etmektedir. Buna göre, "başka bir yargı düzeninin görevi içine girdiği gerekçesi ile görevsizlik itirazının mahkemece reddi üzerine, görev alanı korunmak istenen yargı düzeni içinde yer alan Başsavcının (Danıştay-Yargıtay Başsavcısının), görev konusunun incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesi'nden istemesi" gerekir (2247 s. K. m. 10, I). Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik itirazı adlî yargı yararına ileri sürülmüş ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, idarî yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başsavcısıdır. (2247 s. K. m. 17, IV).

Yetkili başsavcının Uyuşmazlık Mahkemesi'nden istekte bulunabilmesi için, görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci oturumda, ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine başlamadan önce; idarî yargı yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır (2247 s. K. m. 17, II). Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret kararı kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenemez (2247 s. K. m. 17, V).

Görev itirazının ilgili yargı yolunda kabul edilerek görevsizlik kararı verilmesi halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesi'nce incelenebilmesi, kanun yolu incelemesi sonucunda bu kararın bozulmuş (kaldırılmış) ve yargı merciince de kaldırmaya (bozmaya) uyularak görevli olduğuna karar verilmiş bulunmasına bağlıdır (2247 s. K. m. 17, III).

b) Olumsuz Görev Uyuşmazlığı

Olumsuz görev uyuşmazlığında, **iki ayrı yargı merciinin** açılan davada kendisini "**görevsiz**" görmesi ve bu nedenle davayı usulden reddetmesi söz konusudur. Bu durumda hukukî himaye arayışında olan tarafın başvurabileceği bir yargı yolu tespit edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Örneğin, bir taraf gittiği asliye hukuk mahkemesinde "yargı yolunun" caiz olmadığı, bu davanın idarî yargıda görüleceği gerekçesiyle geri çevrilmekte, bu karar da istinaf mahkemesi tarafından doğru bulunmakta ve Yargıtay tarafından da onanmaktadır (veya kanun yolu incelemesinden geçmeden kesinleşmektedir). Bu durumda, davanın adlî yargıda görülemeyeceği kesin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kez idarî yargıya giden davacıya idarî yargıdan da bu davanın adlî yargıda görüleceği cevabı verilmekte ve bu karar da kanun yolu incelemesinden geçmeden veya geçmek suretiyle kesinleşmektedir. Bu durumda davacı, elinde iki ayrı yargı yoluna mensup mahkeme tarafından verilip kesinleşmiş "görevsizlik" kararlarıyla karşı karşıya kalmakta, ancak bu davanın hangi yargı yolunda çözüleceği sorusu ortada bulunmaktadır. İşte burada bir "olumsuz görev uyuşmazlığı" çıkmış olmaktadır.

Olumsuz görev uyuşmazlığı, adlî ve idarî yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görme-

leri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş bulunması halinde söz konusu olur (2247 s. K. m. 14, I). Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca ileri sürülebilir.

Olumlu veya olumsuz görev uyuşmazlığında, Uyuşmazlık Mahkemesi, görevli yargı yerini tespit eder. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin **kararları kesindir** (2247 s. K. m. 29) ve ilgili yerleri ve kişileri bağlar. Uyuşmazlık Mahkemesi kararları **geciktirilmeksizin uygulanır.**

3) Hüküm Uyuşmazlığı

Yargının temel özelliği, bir uyuşmazlık veya hukuka aykırılık iddiasını, bütün bir gelecek için çözmesidir. Bu bakımdan mahkeme kararlarının "kesin hüküm" gücünden söz edilir. Bir karara karşı, o yargı yolu içerisindeki mevcut kanun yolları tüketildiğinde, karar, kesin hüküm teşkil eder (m. 303). Kesin hüküm ise, tarafları bağlayıcıdır.

İki taraf arasında belirli bir konu ve sebebe dayalı davanın karara bağlanması ve hükmün kesinleşmesi üzerine, aynı konu ve sebebe dayalı olarak aynı taraflar arasında yeni bir dava açılamaz. Bir davada kesin hüküm bulunmaması, dava şartıdır (m. 114, 1/i). Ayrı yargı yolları bakımından da, aynı davanın tekrar açılması kabul edilemez. Bu, hem kararlar arasında çelişki olabileceği için hem de usul ekonomisine aykırılık olacağı için istenmeyen bir durumdur. Ancak iki farklı yargı yolunda, aynı sebep ve konuya ilişkin, taraflarından en az birisi aynı olan bir dava açılmış ve her ikisinde de kararlar kesin hüküm halini almışsa, burada bazı sorunlarla karşılaşılır. Kararlar arasında bir çelişki olmadığı takdirde, herhangi bir sorun yoktur. Buna karşılık, kararlar arasında bir çelişki varsa, bu durumda, her ikisi de kesinleşmiş ve bağlayıcı olan kararın hangisinin uygulanacağı veya hukukun nasıl gerçekleştirileceği sorunu ortaya çıkar.

Hüküm uyuşmazlığı[32], adlî ve idarî yargı mercilerinden en az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde ortaya çıkar (2247 s. K. m. 24, I). Ceza kararlarında da hüküm uyuşmazlığı olabilir. Ceza davalarında hüküm uyuşmazlığının olabilmesi için sanığın, fiilin ve maddî olayların aynı olması gerekir (2247 s. K. m. 24, II).

Hüküm uyuşmazlığının giderilmesi için, taraflar ya da ilgili makam, doğrudan doğruya Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurur (2247 s. K. m. 24, III). Bu halde olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılması ile ilgili usul kuralları uygulanır.

---

[32] Bkz. Erdal Tercan, Farklı Yargı Kollarına Mensup Mahkemeler Arasında Hüküm Uyuşmazlığı, Ankara 2014; Ejder Yılmaz, Farklı Mahkemelerin Kararları Arasında Ortaya Çıkan Adalet Çelişkisine Son Verme İhtiyacı: Hüküm Uyuşmazlığı ve Çözüm Usulü (Ulusal Uyuşmazlık Yargısı Sempozyumu, Ankara 2016, s. 145-172).

Hüküm uyuşmazlığında, Uyuşmazlık Mahkemesi, **her iki yargı yerinin verdiği kararla da bağlı olmaksızın** kendisi bir karar verir (2247 s. K. m. 25).

V – HESAP YARGISI

Sayıştay, Anayasanın "yargı" başlığını taşıyan üçüncü bölümünde Yüksek Mahkemeler arasında yer almıştır.

Sayıştay'ın görevleri, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, Kanunla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak şeklinde sayılmıştır (Anayasa m. 160).

"Hesap yargılaması" terimi Anayasada (Anayasa m. 164, III) yer almakla birlikte açıkça bir yargı yolu/kolu olarak zikredilmiş değildir. Sayıştay'ın bir yargı organı olup olmadığı tartışılmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi, önceki kararlarının aksine, son yıllardaki kararlarında Sayıştay'ın yargı yetkisini kullanan bir "mahkeme" olduğunu vurgulamakta, Sayıştay'ı hesap yargısı alanında görevli yargı yeri olarak nitelemektedir. Anayasa Mahkemesi, denetleme ve kesin hükme bağlama görevleri bulunan Sayıştay'ın, denetleme işleri bakımından bir mahkeme niteliğinde olmadığını, buna karşılık, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama açısından yargısal bir faaliyet[33] gerçekleştirdiğini kabul etmektedir. Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır (Anayasa m. 160, II).

Sayıştay'ın hesap yargılaması konusunda uygulayacağı usul ve kurallar Sayıştay K. m. 48-60 arasında düzenlenmiştir. Ayrıca bu Kanunda yargılama usulüne ve kanun yollarına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde HMK'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı da öngörülmüştür (Sayıştay K. m. 61)[34].

---

33 "...yargısal faaliyetin en önemli unsuru, bir hukuki uyuşmazlığın tüm yönleriyle esastan çözümlenerek karara bağlanması ve bu kararın kesin hüküm niteliğini taşımasıdır. Kesin hüküm, davanın tarafları arasındaki hukuki ilişkinin, bütün bir gelecek için kesin olarak tespiti veya düzenlenmesi ve aynı davanın hükmün kesinleşmesinden sonra yeniden açılamamasıdır. Sayıştay, sorumluların hesap ve işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı, hukuka aykırı ise kamu zararı doğurup doğurmadığı ve hukuka aykırı mali işlem ile kamu zararı arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı yolunda, 6085 sayılı Kanun'da öngörülen yargılama usullerini izleyerek bir inceleme yaptıktan sonra, her üç koşulun da gerçekleşmesi durumunda kamu zararının hesap sorumlusundan tazminine karar vermektedir. Sayıştayın tazmin kararı vermesi, hukuka aykırılığın müeyyidesidir. Anayasa'nın 160. maddesinin birinci fıkrasında, Sayıştayın bu kararının kesin hüküm niteliğinde olduğunun açıkça belirtilmesi ve bu karara karşı yargı organları dâhil hiçbir makam ve merciye başvurma yolunun öngörülmemiş olması, Sayıştay kararının yargısal anlamda kesin hüküm niteliğinde olduğunu göstermektedir" (Anayasa Mahkemesi'nin 27.12.2013 gün ve 102/207 sayılı kararı: RG 02.04.2013. sa. 28606-mükerrer).

34 Ejder Yılmaz/Atilla İnan, Yargılama Usulü Kurallarının Önemi ve Sayıştayın Durumu (Sayıştay Dergisi 1998/Özel Sayı s. 65-82; Yılmaz-Makaleler Cilt 1, s. 993-1009).

§ 3. MAHKEMELER

A) MAHKEME KAVRAMI

Mahkeme, "hüküm verilen yer" anlamına gelir. Zaman zaman, "mahkeme" ve "muhakeme" kavramları birbiriyle karıştırılmaktadır. Ancak, muhakeme (yargılama), bir süreci ifade ederken, mahkeme, hüküm verilen yerdir; yargı yeridir (yargılıktır). Aynı şekilde, zaman zaman hâkim yerine mahkeme kavramının kullanıldığı da görülmektedir (örneğin m. 19; 20, 2; 27; 28, 1; 48, 2; 56, 1).

Anayasa Mahkemesi, bir yerin mahkeme sayılabilmesi için, karar organlarının hâkimlerden oluşması, yargılama tekniklerini uygulayarak ve genelde dava yolu ile uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözümlemekle görevli olması ve Anayasada sayılan ve başında bir yüksek mahkemenin bulunduğu yargı düzenlerinden birinde yer alması gerektiğini kabul etmektedir.

Mahkemeler hakkındaki temel düzenleme, Anayasada bulunmakta ve burada yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade edilmektedir (Anayasa m. 9; 138 vd.). Anayasada ayrıca yargı hizmetlerinin yürütülme biçimine ve yüksek mahkemelerin oluşumuna ilişkin hükümler yer almaktadır.

Adlî yargı bakımından mahkemelerin örgütsel yapısı, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda ve Anayasa m. 154 ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Mahkemeler, çeşitli bakımlardan farklı sınıflandırmalara konu olmaktadır. Buna göre, mahkemeleri ilk olarak, yargı sisteminde bulundukları yere göre, ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemeler biçiminde bir ayrıma tâbi tutmak mümkündür.

B) YARGI SİSTEMİNDE BULUNDUKLARI YERE GÖRE MAHKEMELER

Yargı sistemleri, çeşitli ülkelerde faklı örgütlenme modellerine sahiptirler. Bu anlamda bir, iki veya üç dereceli yargılamadan söz etmek mümkündür. Türk hukuku bakımından da konuyu, ilk derece mahkemeleri, üst ve yüksek mahkemeler biçiminde bir ayrıma tâbi tutarak incelemek mümkündür.

I – İLK DERECE MAHKEMELERİ

Bir davayı ilk defa ele alan, inceleyen ve karar veren mahkeme, ilk derece mahkemesidir. İlk derece mahkemesine, **vakıa**, bidayet, hüküm **mahkemesi** veya yerel (mahallî) mahkeme de denilmektedir. 5235 s. K., ilk derece mahkemesi terimini tercih etmiştir.

Hukuk mahkemeleri olarak ilk derece mahkemeleri, sulh hukuk, asliye hukuk, asliye ticaret mahkemeleri ve özel kanunlarla kurulan diğer mahke-

meler olarak belirtilmiştir (5235 s. K. m. 4-5). Ayrıca bir denetim mahkemesi olmakla birlikte, kanunun gösterdiği hallerde, bazı üst veya yüksek mahkemelerin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla bazı davaları görebilmeleri mümkündür. Örneğin, bir ilk derece mahkemesi hâkiminin fiil veya kararından ötürü Devlete karşı tazminat davası açılması halinde, bu davayı Yargıtay'ın ilgili hukuk dairesi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla görür (m. 47, 1). O nedenle bir mahkemenin üst veya yüksek mahkeme olması, onun bazı hallerde ilk derece mahkemesi olarak hareket etmesine engel değildir. Yine esasında üst veya yüksek mahkeme olarak kurulmuş olmasına rağmen, altında bir ilk derece mahkemesi bulunmayan mahkemeler de vardır. Örneğin, Anayasa Mahkemesi, bir yüksek mahkeme olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmek için öncelikle bir ilk derece mahkemesine gitmek zorunlu değildir. Başka bir anlatımla Anayasa Mahkemesi, bir ilk derece mahkemesi üzerine kurulmuş mahkeme değildir.

İlk derece mahkemelerinin kuruluş, yapı ve görevleri hakkında aşağıda daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

II – ÜST DERECE VE YÜKSEK MAHKEMELER

Üst derece mahkemesi veya yüksek mahkeme bir davanın sonuçlanmasından sonra, o davada verilen kararın hukuka uygunluğunu denetleyen bir mahkeme olabileceği gibi, bizzat yeniden yargılama yaparak, vakıaların doğru değerlendirilip değerlendirilmediğini ve kararın hukuka uygun olup olmadığını inceleyen mahkeme de olabilir. Bunun dışında, bir kararın hukuka uygunluğunu denetlemek üzere faaliyet yapan bir mahkeme de yüksek mahkeme sayılır. O nedenle yüksek mahkeme ve üst derece mahkemesi kavramları her zaman eş anlamlı değildir.

Yüksek mahkemelerin neler olduğu asıl olarak Anayasada düzenlenmiştir (Anayasa m. 146-158). Buna göre, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi, yüksek mahkemelerdir. Yukarıda da belirtildiği üzere, yüksek mahkeme, mutlaka bir ilk derece mahkemesinin varlığını gerektirmez. Nitekim, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay'ın altında bir ilk derece mahkemesi bulunmaz.

Buna karşılık bir üst derece mahkemesinden söz edildiğinde, dereceli bir yargılama gündeme gelmektedir. Bir mahkeme kararının bir başka üst mahkeme tarafından denetlenmesi, hukukî himaye arayanlar bakımından bir güvence oluşturmaktadır. Çünkü, bir üst derece mahkemesinin daha kıdemli ve deneyimli hâkimlerden oluşması esastır ve üst mahkeme toplu (birden fazla üyeli) mahkeme olarak kurulmaktadır.

Adil yargılanma hakkı (AİHS m. 6) bakımından, medenî yargı alanında, ceza yargısından farklı olarak, dereceli bir yargılama zorunlu görülmemektedir. Hukukumuzda bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin göreve başlaması

ile (**20.07.2016'dan itibaren**[1]) hukuken üç dereceli bir yargılama sistemine geçilmiştir.

Denetim mekanizmalarını artırmak hukukî himaye arayanlar için güvencedir. Ancak her denetim seviyesi, aynı zamanda hukukî himayenin gecikmesine de yol açmakta; bu kez makul sürede yargılanma hakkı ihlâl edilebilmektedir. O halde, önemli olan güven veren yargılamayı makul sürede ve usul ekonomisi ilkesini de gözetecek şekilde yapmaktadır (gerçekleştirmektir).

Burada kısaca bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'ın kuruluşu, yapısı ve görevleri hakkında bilgi verilecek; bu mahkemelerin kanun yollarına ilişkin olarak işleyişleri ve görevleri, kanun yolları kısmında ayrıntılı olarak incelenecektir.

1) İstinaf (Bölge Adliye) Mahkemeleri (İkinci Derece Mahkemeleri)[2]

Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, istinaf[3] (bölge adliye) mahkemeleridir (5235 s. K. m. 3). Bu mahkemelerin asıl görevi, ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları incelemektir.

a) İstinaf Mahkemelerinin Yapısı ve Kuruluşu

İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri, bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde kurulur (5235 s. K. m. 25). 5235 s. K., istinaf mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarihin Resmî Gazete ile ilân edileceğini öngörmüştür (5235 s. K. geçici m. 2).

Bu hüküm uyarınca İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van'da istinaf mahkemeleri kurulmuştur[4]. Ancak, HSYK (bugün HSK) 29.02.2016 tarihli ve 53 sayılı kararıyla istinaf mahkemelerinin ilk etapta bazı merkezlerde faaliyete geçirilerek, her bir bölge için daire sayısının artırılması suretiyle Yargıtay'daki ihtisaslaşmaya benzer bir şekilde ihtisas daireleri

---

1 İstinaf (bölge adliye) mahkemelerinin 20.07.2016 tarihinde bütün yurtta görev başlamalarına ilişkin Adalet Bakanlığı kararı için bkz. RG 07.11.2015, sa. 29525.

2 Bkz. Ejder Yılmaz, İstinaf, Ankara 2005; Kâmil Yıldırım, Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, İstanbul 2000; Cenk Akil, İstinaf Kavramı, Ankara 2010; Tolga Akkaya, Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009; Muhammet Özekes, 100 Soruda İstinaf ve Temyiz, Ankara 2016; Halûk Konuralp/Emel Hanağası, Fransız Hukukunda İptal Amaçlı İstinaf Yolu (LEGAL Hukuk Dergisi, Haziran 2007, s. 1795-1818); Emel Hanağası, Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri (Açık Sayfa 2005/60, s. 38-43); Emel Hanağası, Hukuk Davalarında İstinaf Usulü (Açık Sayfa 2005/60, s. 44-56).

3 5235 sayılı Kanun, ikinci derece mahkemeleri için, idarî yargıdaki "bölge idare mahkemeleri" deyimine paralel olarak, "bölge adliye mahkemeleri" tabirini kullanmaktadır. HMK m. 341 vd. hükümleri, bu mahkemelerdeki kanun yoluna "istinaf" demektedir. Biz, eskiden beri kullanılmakta oluşu sebebiyle, "bölge adliye mahkemeleri" tabiri yerine "**istinaf mahkemeleri**" **tabirini kullanmayı tercih ediyoruz.**

4 HSYK'nun 15.05.2007 tarihli ve 205 sayılı (RG 05.06.2007, sa. 26543) ve 07.06.2011 tarihli ve 187 sayılı (RG 07.11.2015, sa. 29525) kararları.

oluşturularak uygulama birliğinin temin edilebileceği ve bu şekilde içtihat farklılıklarının azaltılarak ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanabileceği gerekçesiyle, bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarını yeniden belirlemiştir. Bu çerçevede 20.07.2016 tarihi itibariyle Antalya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilmiş; daha sonra HSK'nun 03.08.2017 gün ve 703 sayılı kararı ile de Adana ve Bursa istinaf mahkemeleri 05.07.2017 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bundan sonra HSK, 06.06.2018 gün ve 217 sayılı kararı ile Konya ve Sakarya istinaf mahkemelerinin faaliyete başlamasına karar vermiş ve bu amaçla mahkemelerin yargı çevresini yeniden belirleyip ilân etmiştir. Son olarak HSK, 26.06.2019 gün ve 230 sayılı kararı ile **Diyarbakır, Kayseri, Trabzon** ve **Van** istinaf mahkemelerinin de 02.09.2019 tarihinde faaliyete başlamasına karar vermiştir. Buna göre, başlangıçta (2007 yılında öngörülen) istinaf mahkemesi sayısına ulaşılmış ve bugün görev yapan istinaf mahkemesi sayısı **on beş** olmuştur[5].

01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK da, bölge adliye mahkemelerini dikkate alarak istinaf ve temyiz kanun yollarını düzenlemiştir. Ancak, HMK'nun geçici 3. maddesinin 2. fıkrasına göre, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlama tarihi olan **20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilen kararlar hakkında**, bu kararlar kesinleşinceye kadar, **1086 sayılı HUMK'nun** 26.09.2009 tarihli ve 5236 s. K. ile yapılan değişiklikten önceki **427 ilâ 454. madde hükümlerinin** (yani, HUMK'nun temyize ilişkin m. 427-439, m. 443-443; karar düzeltmeye ilişkin m. 440-442/A ve yargılamanın ia-

---

5 Buna göre istinaf mahkemelerinin güncel yargı çevreleri şu şekildedir: **Adana Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye; **Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi**: Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu ve Kırşehir; **Antalya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta; **Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova; **Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak; **Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli; **Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa; **İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ; **İzmir Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak; **Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi**: Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat; **Konya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman; **Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak; **Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi:** Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat; **Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi**: Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize; **Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi**: Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinin mülki sınırları olarak tespit edilmiştir (HSK'nun 26.06.2019 gün ve 230 sayılı Genel Kurul kararı: RG 28.06.2019, sa. 30815). Yeni istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle yargı çevresinin değişmesi üzerine yetkisizlik kararı verilemez. Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf mahkemesinden geçen dosyalar, yeniden istinaf incelemesine konu edilmesi halinde de, ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılır (694 s. KHK ile değişik 5235 s. K. Ek Madde 1). Yeni istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle yargı çevresinin değişmesi üzerine yetkisizlik kararı verilemez. Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf mahkemesinden geçen dosyalar, yeniden istinaf incelemesine konu edilmesi halinde de, ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılır (694 s. KHK ile değişik 5235 s. K. Ek Madde 1).

desi yollarına ilişkin 446-454 hükümlerinin) **uygulanmasına devam olunacaktır.** Bu hüküm çerçevesinde, **HMK'nun düzenlediği istinaf** (m. 341-360), temyiz (m. 361-381) ve yargılamanın iadesi (m. 374-381) **hükümlerinin uygulanabilmesi için, mahkeme kararının 20 Temmuz 2016 tarihinden** (bu tarih dahil) **itibaren** (sonra) **verilmiş olması gerekir.**

İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinin üzerinde, Yargıtay'ın bugüne kadar bilinen yapısına benzer bir modelle kurulmuştur.

İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri, başkanlık, ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk daireleri başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. Her istinaf (bölge adliye) mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur; gerekli hallerde bu sayı artırılıp azaltılabilir. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur (5235 s. K. m. 26, 29).

Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir daire toplanamazsa, bölge adliye mahkemesi başkanının kararıyla diğer dairelerden, bu da mümkün olmazsa, HSK tarafından diğer istinaf mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır. Daire başkanının hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamaması halinde dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar (5235 s. K. m. 46).

b) İstinaf Mahkemelerinin Görevleri

İstinaf (bölge adliye) mahkemelerinin görevleri genel olarak şunlardır: 1) Adlî yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak; 2) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak (5235 s. K. m. 33).

Kanunda istinaf mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri de şöyle belirtilmektedir: 1) Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak; 2) Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek; 3) Yargı çevresindeki yetkili adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın istinaf mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek; 4) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak (m. 36).

36. maddenin konuluş gerekçesinde: "Maddede, bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevleri sayılmaktadır. Bölge adliye mahkemeleri öncelikle adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamakla görevli kılınmıştır. Bu düzenleme tabiîdir. Çünkü adlî yargı ilk derece mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan kararlara karşı tarafların başvurabilecekleri ilk kanun yolu istinaf yolu olacaktır. ... Bölge adliye mahkemelerinin diğer bir görevi, merci tayinine ilişkindir. Hukuk mahkemeleri arasındaki, olumsuz yetki ve görev uyuşmazlıkları da bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevine gir-

mektedir. Mevcut düzenlemede bu uyuşmazlıkların çözümü temyiz incelemesi sırasında Yargıtay tarafından yapılmaktadır. Ancak, yetki ve görev gibi esasa ilişkin olmayan uyuşmazlıkların temyiz incelemesine konu olmayıp, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde incelenip sonuçlanması daha uygun olacağından, bu yönde değişiklik yapılmıştır. Bunun gibi, yetkili adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıkması veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edilmesi hâlinde bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar verecektir. Son olarak hukuk daireleri kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirecektir" denilmektedir.

İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinden verilen nihaî kararları, talep çerçevesinde yeniden inceleyip, yargılama yapıp bir karar verebilir. İstinaf mahkemesi, bunu bizzat yeniden tahkikat ve yargılama yaparak gerçekleştirir. Burada ilk derece mahkemesinin somut olayda (davada) verdiği kararın isabetli olup olmadığı bu şekilde ortaya çıkar. İstinaf mahkemesinin bu faaliyeti hem somut olaya uygunluk hem de hukuka uygunluk denetimini ifade eder.

İstinaf kanun yolu ileride[6] incelenecektir.

2) Yargıtay

Yargıtay, Anayasanın 154. maddesinde yüksek mahkemeler arasında yer almıştır. Buna göre, "Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar" hükmü yer almaktadır (Anayasa m. 154).

a) Yargıtay'ın Kuruluşu ve Yapısı

Yargıtay'ın kuruluşu ve işleyişi, kanunla düzenlenir (Anayasa m. 154, VI). Bunun için 2797 sayılı **"Yargıtay Kanunu"** yürürlüğe konulmuştur. Bundan başka, Yargıtay'daki kurulların, başkan ve üyelerin, tetkik hâkimleri ile diğer personelin Yargıtay Kanunu'nda gösterilmeyen ve Yargıtay Kanunu'na aykırı düşmeyen ödev ve yetkilerini, çalışma usullerini, seçimlerin yönetimini, tutulacak defterleri ve basılı kâğıtların kullanılış şeklini düzenlemek ve Yargıtay'ın iç düzenini ve Yargıtay Kanunu'nun uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılan **"Yargıtay İç Yönetmeliği"** vardır[7].

Yargıtay, Birinci Başkanlık (m. 4), Birinci Başkanlık Kurulu (m. 10; 17-18), Yönetim Kurulu (m. 12, 20), Daireler (m. 5; 14; 40), Cumhuriyet Başsavcılığı (m. 27-28) ve idarî birimler ve bürolardan (m. 48-53) oluşur (Yargıtay K. m. 2; Yargıtay Yön. m. 2).

Yargıtay'da on iki hukuk, on iki ceza dairesi olmak üzere toplam yirmi dört daire vardır (6723 s. K. ile değişik Yargıtay K. m.5). Bu değişiklikten önce Yargıtay'da yirmi üç adet hukuk, yirmi üç adet ceza dairesi mevcuttu.

---

6 Bkz. aşa. § 55.

7 Bkz. RG 29.08.1983, sa.18150.

6723 s. K. ile 2797 s.K.na eklenen Geçici Madde 15, 12'ye göre daire sayısı üç yıl içinde on iki hukuk, on iki ceza olmak üzere azaltılacaktır. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22.12.2016 tarih 398 sayılı kararı ile 6., 7. ve 18. Hukuk Daireleri ile 23. Ceza Dairesi 13.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmıştır. Ne var ki, Kanunda öngörülen daire sayısına henüz ulaşılmış olmayıp, hâlihazırda Yargıtay'da bugün yirmi adet hukuk dairesi, yirmi iki adet ceza dairesi olmak üzere toplam kırk iki daire bulunmaktadır. Birinci Başkanın başkanlığında, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Yargıtay üyelerinden meydana gelen kurula, **Yargıtay Büyük Genel Kurulu** (BGK) denir (m. 8; 16, 42). Hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinin oluşturduğu kurula **Hukuk Genel Kurulu** (HGK); ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin oluşturduğu kurula da **Ceza Genel Kurulu** (CGK) denir (m. 7; 15; 41).

Bu genel açıklamadan sonra, hukuk daireleri ve Hukuk Genel Kurulu ile Başkanlar Kurulu hakkında da kısaca bilgi vermek gerekir.

aa) Hukuk Daireleri (HD)

Daireler heyet (kurul) halinde çalışır; heyet bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder. Heyetler işi müzakere eder ve salt çoğunlukla karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.

Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları, mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse, karşı oy yazısı, kararların asıl ve örneklerinde gösterilir (6110 s. K. ile değişik m. 40; Yargıtay Yön. m. 17).

Her dairede yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur (Yargıtay K. m. 36). Tetkik hâkimleri, daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosyaları süresinde incelerler; incelemeleri sonucunu düşünceleriyle birlikte bütün delilleri kapsayacak ve anlaşılacak biçimde düzenleyecekleri raporlarını kurulda okurlar; gerekli açıklamayı yaparlar. Bu raporlar, kurulca imzalanan karar ile birlikte ayrı bir kartonda saklanır (Yargıtay Yön. m. 58).

bb) Hukuk Genel Kurulu (HGK)

Tüm hukuk dairelerinin başkan[8] ve üyelerinin oluşturdukları kurula Hukuk Genel Kurulu denir. Hukuk (ve Ceza) Genel Kurulu, görevlerinin özelliği göz önüne alınarak, kanunda belirlenen sayıya göre toplanır (Yargıtay K. m. 7).

---

[8] HGK'nun yapısıyla ilgili olarak geçici bir düzenleme öncelikle 696 sayılı KHK ile yapılmış; daha sonra 7079 s. K. m. 40 uyarınca aynen kabul edilerek Yargıtay Kanunu'na **Geçici Madde 16** eklenmiştir. Buna göre, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, içtihadı birleştirme toplantılarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, **31/12/2022** tarihine kadar **sürekli görev yapan** üyelerden oluşturulacaktır ve burada daire başkanlarının bulunması şart değildir. Çünkü, Hukuk Genel Kurulu, her hukuk dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla **Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen yirmişer üye**den oluşur. Bu kurullara, Birinci Başkan veya ilgili başkanvekili, bunların bulunmaması halinde kurulların en kıdemli üyesi başkanlık eder. Üyeler Hukuk Genel Kurulunda **sürekli** olarak görev yaparlar. Ancak, iş duru-

b) Yargıtay'ın Görevleri

aa) Genel Olarak

Yargıtay, adlî yargı alanındaki yüksek mahkeme olup, aslî görevi, adı **"temyiz"** olan denetimdir.

Mahkeme kararlarına karşı iki tür denetim mevcut olup, bunlardan birisi "istinaf", diğeri ise "temyiz"dir. Temyiz, istinaf aşamasından sonra gelen aşama olup, ülkede hukuk birliğinin sağlanması, hukuk kurallarının her yerde aynı şekilde uygulanmasını sağlama amacını güder.

Yargıtay, ilk derece mahkemelerinin kararlarının hukuka uygun olup olmadığını denetlemekle birlikte, istinaf (bölge adliye) mahkemeleri göreve başladıktan (20.07.2016'dan) sonra, ilk derece mahkemelerinin değil, bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan bir yüksek mahkemedir[9].

Yargıtay, yargılama değil, hukuka uygunluk denetimi yapan bir yüksek mahkemedir. Yargıtay, önüne gelen mahkeme kararının hukuka uygun olup olmadığını inceler. Yargıtay da talep üzerine bir karar verir; ancak Yargıtay, hukuka uygunluk denetimi yaptığı için, kural olarak tarafların gösterdiği sebeplerle bağlı olmaksızın inceleme yapar. Yargıtay, tahkikat yapamaz, delil inceleyemez; bu nedenle örneğin, Yargıtay bilirkişiye başvuramaz veya tanık dinleyemez. Ancak önüne temyiz incelemesi talebiyle gelen bir davada, tanık dinlenilmesi gerektiği halde dinlenmemişse veya bilirkişiye gidilmesi gerektiği halde gidilmemişse ya da tam tersi bir durum gerçekleşmişse, kararı bu nedenle bozabilir.

Yargıtay, bir ilk derece mahkemesi kararını doğru bulursa, onama; yanlış görürse, bozma kararı verir. Yargıtay'ın bir de düzelterek onama yetkisi vardır ki, bu da yine bir onama kararıdır (m. 370-371). O halde, Yargıtay, kararını temyizen incelediği mahkemeye nasıl karar vermesi gerektiği konusunda yol göstermekte; böylece hukukun, ülkenin bütününde aynı ve doğru uygulanmasına çalışmaktadır. Yargıtay'ın bu işlevini yerine getirmek üzere içtihatları birleştirme kararı verme yetkisi tanınmıştır. Öneminden ötürü bu konuya ayrıca değinilecektir.

bb) Yargıtay Hukuk Dairelerinin Görevleri

Yargıtay hukuk daireleri, kural olarak temyiz denetimi görevini yerine getirmekle birlikte, bazı hallerde kanunlarla verilen görevler çerçevesinde bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak da bakar. Örneğin, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde (sorumluluğa yol açan davada verilen kararı inceleme görevi hangi daireye aitse o dairede) ilk derece mahkemesi sıfatıyla Devlete karşı tazminat davası açılır (m. 47, 1).

---

mu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Büyük Genel Kurul tarafından karar verilebilir (Yargıtay K. Geçici Madde 16).

9 Bkz. aşa. § 55, § 59.

Yargıtay dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktıkları davalar dışında, asıl görevleri temyiz incelemesi yapmaktır. Yargıtay, değişik tür ve içerikteki davalar bakımından yukarıda kısaca belirtilen şekilde temyiz denetimi yaparken, bunu birden fazla dairesi arasındaki işbölümü esasıyla gerçekleştirir. Yargıtay daireleri, belirli konular bakımından âdeta uzmanlaşma esasına göre çalışmaktadır.

Yargıtay'ın hukuk dairelerinden hangisinin ne tür davaları inceleyeceği, yani daireler arasındaki işbölümü, Yargıtay K. m. 14 uyarınca tespit edilmiş esaslara göre, Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır. Bu karar tasarısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu (BGK) tarafından onaylanmasını takiben Resmî Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girer[10] (Yargıtay K. m. 14). Böylece Yargıtay dairelerinin görevleri, bir anlamda her yıl değişebilmektedir[11].

Bir mahkeme kararı temyiz edilince, kararı vermiş olan istinaf mahkemesi dairesi dosyanın temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalmaksızın görevli daireye gönderilmesini sağlar (Yargıtay K. m. 60, I).

Yargıtay daireleri arasındaki işbölümü, teknik anlamda bir görev ilişkisi olmayıp, bir **işbölümü** (iş dağılımı) ilişkisidir. Yanlış dairelere dosya gönderilmesi nedeniyle ortaya çıkan zaman kaybını önlemek veya hangi dosyanın hangi daire tarafından inceleneceği konusundaki tereddütleri en aza indirmek için Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulmuştur[12].

Dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda iş bölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı görevli olduğu kanısına vardığı ilgili hukuk dairesine gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra veya duruşma günü verilen dosya hakkında gönderme kararı verilemez. Gönderme kararı üzerine dosya kendisine gelen hukuk dairesi iki hafta içinde yapacağı ön inceleme sonucunda görevli olmadığı kanaatindeyse, varsa geçici hukukî koruma tedbirle-

---

10 Bkz. 6545 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 13/b; Yargıtay Büyük Genel Kurulunun bu (Geçici Madde 13/b) madde uyarınca aldığı, hukuk (ve ceza) daireleri arasındaki işbölümüne ilişkin 30.01.2019 gün ve 2019/01 sayılı kararı için bkz. RG 31.01.2019, sa. 30672.

11 Bu Kanun değişikliğinden önce Yargıtay K. m. 14'te, dairelerin hangi tür davaların temyiz incelemesini yapacağı tek tek sayılmış, ancak iş dengesini sağlamak üzere her yıl bazı değişiklikler yapma yetkisi Başkanlar Kuruluna verilmişti. Yargıtay K. m. 14 ile getirilen bu yeni düzenlemenin Anayasaya aykırılığı ileri sürülmüşse de Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu reddetmiştir (Anayasa Mahkemesi'nin 30.03.2012 gün ve 29/49 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası- Usul Pratik, s. 122-125).

12 "Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla olmamak kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulur; burada çalışmak üzere yeteri kadar tetkik hâkimi ve personel görevlendirilir... Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder; asıl üyelerin eksikliği yedek üyelerin katılımıyla tamamlanır. Kurul, ayda en az iki hafta çalışır. Bu süre zarfında Kurul üyeleri dairelerindeki çalışmalara katılmaz" (Yargıtay K. m. 60, 2/4-5).

rine dair talepler hakkında da karar vermek suretiyle dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderir. İki haftalık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonunda verilen işbölümüne ilişkin karar kesindir (6723 s. K. ile değişik Yargıtay K. m. 60, 1; m. 60, 3).

cc) Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Görevleri

Hukuk Genel Kurulunun (HGK) başlıca dört görevi vardır:

HGK, Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerin vermiş oldukları direnme (ısrar) kararlarını temyizen inceleyip kesin olarak karara bağlar[13].

İlk derece mahkemesi olarak ilgili Yargıtay daireleri tarafından verilen hükümlerin temyiz incelemesini yapar (**7072** s. K ile değişik Yargıtay K. m. 15, 3).

Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her halde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır (m. 373, 6; HUMK m. 429, IV).

HGK, Yargıtay dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri hüküm ve kararları temyizen inceler[14].

HGK, bazı hallerde içtihatların birleştirilmesine de karar verir (Yargıtay K. m. 15, 2).

c) İçtihatların Birleştirilmesi[15]

aa) Genel Olarak

Yargıtay dairelerinin veya HGK'nun kararı, yalnızca o dava dosyası, taraflar ve mahkeme için bağlayıcıdır. Başka bir ifadeyle Yargıtay içtihatları (kararları), ilgilileri bakımından sonuç doğurur.

Mahkemelerin, bozulan kararlarında ısrar etme (direnme) hakları da vardır. Nitekim, Yargıtay'ın bozma kararına karşı mahkemeler direnme kararı verebilir. Ancak sonuçta kanun yollarının tüketilmesi üzerine karar, taraflar için bağlayıcı olmakta; kesin hüküm oluşturmaktadır (m. 303).

Yargıtay dairelerinin aynı konuya ilişkin olarak hukuk kuralını farklı yorumlamaları ve kararların bu şekilde kesinleşmesi de mümkündür. Bu durumda hukukî himaye arayanlar için farklı sonuçlar doğmakta, hukuk birliği zedelenmektedir. Mahkemelerin benzer olaylar hakkında verdikleri kararlar arasında çelişki bulunması, kanun önünde eşitlik ilkesini (Anayasa m. 10)

---

13 Bkz. Yargıtay K. m. 15, 1; aşa. § 59, G.

14 6644 sayılı Kanunla HMK m. 47, 1'de yapılan değişiklik sonucu, Yargıtay 4. veya 3. Hukuk Dairesinin devlete karşı açılan tazminat davasında vermiş olduğu kararı HGK temyiz mercii olarak inceler.

15 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Baki Kuru, İçtihatların Birleştirilmesi Yolu ile İlgili Bazı Sorunlar, Ankara 1977; Ejder Yılmaz, İçtihadı Birleştirme veya Adaletteki Çelişkiye Sonverme İhtiyacı (Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XVII, Ankara 2000, s. 1-30; Yılmaz, Makaleler C. 1, s. 1159-1171).

zedeleyeceği gibi, adalet duygusunu incitici ve yerine göre temelden sarsıcı bir etki de yapabilir. "İşte sosyal bakımdan çok ağır olan bu sakıncayı önlemek üzere Anayasa, Yargıtay'a, adlî yargı alanında hukuk uygulamalarında birliği sağlamak görevini dahi vermiştir"[16].

Mahkemelerin benzer konulardaki kararları arasında çelişki olmaması, mahkemelerin her olay hakkında verdikleri aynı yöndeki kararlarla sağlanır. Bir üst mahkeme (istinaf[17], Yargıtay) dairesinin (veya kurulunun) kendi kararları arasında ve kendi kararları ile diğer üst mahkeme daireleri ve kurullarının kararları arasında uyum varsa, kanunlar bütün yurtta aynı şekilde uygulanıyor demektir. Buna karşılık, üst mahkemenin veya yüksek mahkeme Yargıtay'ın kararları arasında böyle bir uyum yoksa, çelişik kararlar veriliyorsa, o zaman, kanunların bütün yurtta aynı şekilde uygulanmasını sağlamak için, üst (veya yüksek) mahkeme kararları arasındaki bu uyuşmazlığın Yargıtay tarafından giderilmesi gerekir; bu ise, içtihatların birleştirilmesi yolu ile olur.

Adlî yargı alanında içtihatların birleştirilmesi, Yargıtay Kanunu'nda (m. 7; 15, 2; 16, 5; 17, 1; 45; 58) ve Yargıtay İç Yönetmeliğinde (m. 13-14) düzenlenmiştir. Bundan başka, yürürlükten kalkmış bulunan 1730 sayılı (eski) Yargıtay K. m. 22, 3 ve m. 51 gereğince hazırlanmış ve yayımlanmış, İçtihadı Birleştirme Görüşmelerine ve Kararların Yazılmasına İlişkin (18 maddelik) bir İlke Kararı vardır[18].

bb) İçtihatların Birleştirilmesi Yoluna Gidilmesini Gerektiren Haller

İçtihatların birleştirilmesi yoluna, aynı nitelikteki hukukî konular hakkında **birbirine aykırı** (uymayan, çelişik) **en az iki Yargıtay kararı bulunması** halinde gidilir.

İçtihatların birleştirilmesi yoluna gidilebilmesi için, birbirine aykırı olan Yargıtay kararlarının, "benzer olaylar" hakkında olması yeterlidir. Çünkü, Yargıtay kararları arasındaki içtihat uyuşmazlığı, hukukî bir sorun hakkındadır. İçtihadı birleştirme kararı, "belli bir olaya uygulanacak yasanın veya nesnel nitelikte olan tüzük ve yönetmelik kuralları gibi öbür kurallardan hangisinin, hangi anlamda uygulanacağını saptamak için verilir". Örneğin, ölü kişiye karşı açılmış bir davaya mirasçılarına karşı devam edilip edilemeyeceği[19]. Yine örneğin, HMK m. 394 ile, ihtiyati tedbir talebinin kabulü veya reddi ha-

---

16 Anayasa Mahkemesi'nin 12.06.1969 gün ve 38/34 sayılı kararı için bkz. RG 29.01.1970, sa. 13412.

17 İçtihatların birleştirilmesi bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri ve farklılık arz eden kararlar bakımından da geçerlidir. Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu, Yargıtay **ilgili hukuk dairesinden** talep eder. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak dairece bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir (7079 s. K. ile değişik 5235 s. K. m. 35, 2). Bu şekilde verilmiş bir karar için bkz. Y. 19. CD, E. 2019/23974, K. 2019/9339, RG 19.06.2019, sa. 30806.

18 Bkz. RG 13.07.1975, sa. 15294. Bu karar, bundan sonraki açıklamalarda yalnız "İlke Kararı" olarak anılacaktır (bkz. ayrıca: Yargıtay K. m. 17, 1c).

19 İBK 04.05.1978, 04/05 (RG 01.06.1978, sa. 16303).

linde verilen kararlara aynı mahkemede itiraz edilebileceği, itiraz üzerine mahkemenin kararına karşı da "kanun yolu"na gidileceği kabul edilmiştir. İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmediği dönemde, m. 394'te söz edilen kanun yolunun ne olacağı Yargıtay dairelerinin kararlarında farklı yorumlara yol açmıştır. Bir kısım daireler, bu kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğunu kabul edip, temyiz incelemesi yaparken, bir kısım daireler temyiz yolunun kapalı olduğu gerekçesiyle bu konudaki kararların temyiz edilmeyeceğini belirtmiş, temyiz başvurularını reddetmiştir. Bu farklı yorumlar karşısında, içtihatları birleştirme talep edilmiş ve bu kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu yönünde içtihadı birleştirme kararı verilmiştir[20].

cc) İçtihatların Birleştirilmesine Karar Verecek Kurullar

İçtihat uyuşmazlığının niteliğine göre, içtihatların birleştirilmesine karar verecek kurul, HGK veya Yargıtay Büyük Genel Kurulu (BGK)'dur.

Yargıtay **hukuk dairelerinden** biri, **yerleşmiş içtihadından dönmek** isterse[21]; bir Yargıtay **hukuk dairesi** benzer olaylarda (aynı hukukî sorun hakkında) **birbirine uymayan kararlar** vermiş bulunursa veya Yargıtay **hukuk daireleri** (yani, bir hukuk dairesi ile diğer bir hukuk dairesi veya daireleri) **arasında içtihat uyuşmazlığı** bulunursa, içtihatların birleştirilmesine **HGK** karar verir.

Buna karşılık, **HGK'nun** benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği **kararları arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını giderme** ve içtihatların birleştirilmesine karar verme görevi ile **HGK** ile **CGK;** HGK ile bir hukuk dairesi; HGK ile bir ceza dairesi; CGK ile bir **hukuk dairesi;** bir hukuk dairesi ile **ceza dairesi** arasındaki içtihat uyuşmazlığını giderme ve içtihatların birleştirilmesine karar verme görevi, Yargıtay BGK'na aittir (Yargıtay K. m. 16, 5).

dd) İçtihatların Birleştirilmesi Talebi ve İncelenmesi

İçtihatların birleştirilmesini, Yargıtay Birinci Başkanı doğrudan doğruya ilgili içtihadı birleştirme kurulundan isteyebilir. Bundan başka Birinci Başkan, Yargıtay'daki dairelerin veya Genel Kurulların verdikleri kararlar doğrultusunda veya Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yazı ile başvurması halinde, ilgili içtihadı birleştirme kurulundan içtihatların birleştirilmesini istemekle yükümlüdür (Yargıtay K. m. 45, I).

Bundan başka, **diğer merciler** (örneğin mahkemeler) ve **kişiler de** (örneğin avukatlar da), Yargıtay Birinci Başkanlığına başvurarak içtihatların birleştirilmesini isteyebilirler. Bu halde, içtihadı birleştirme yoluna gitmenin ge-

---

20 İBK 21.02.2014, 01/10 (bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası- Usul Pratik, s. 173-184).

21 Yargıtay'ın bir dairesinin içtihadından dönmek istemesi halinde, içtihadı birleştirme kararı yoluna başvurulması gerekir. Yargıtay'ın aynı dairesinin diğer içtihadıyla çelişecek şekilde ve makul bir gerekçe ortaya konulmadan ve sonrasında istikrarlı bir şekilde uygulanmadan benzer nitelikteki uyuşmazlığın zıddı olacak şekilde davanın sonuçlanmasının hukuki belirsizliğe yol açıp hakkaniyete uygun (adil) yargılanma hakkının ihlâl edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 22.01.2019 gün ve 2015/17453 numaralı bireysel başvuru kararı için bkz. RG 12.02.2019, sa. 30684.

rekip gerekmediğine Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu karar verir; bu karar kesindir (Yargıtay K. m. 45, 2; Yargıtay Yön. m. 13). Birinci Başkanlık Kurulu içtihadı birleştirme yoluna gitmenin gerekli olduğuna karar verirse, Birinci Başkan, içtihatların birleştirilmesini ilgili içtihadı birleştirme kurulundan ister.

Her iki halde de, ilgili içtihadı birleştirme kurulundaki içtihadı birleştirme görüşmeleri, alınmış olan İlke Kararı çerçevesinde yürütülür ve kararlar bu İlke Kararına göre yazılır (Yargıtay K. m. 45, 4).

İçtihadı birleştirme kurulları, toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir; ancak, birinci ve ikinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlası (salt çoğunluğu) ile karar verilir (Yargıtay K. m. 41, 1; 42, 1).

İlgili içtihadı birleştirme kurulu, birbirine aykırı kararlardan birindeki görüşü doğru bularak onu benimseyebilir; fakat, o kararlardaki görüşle bağlı olmayıp, yeni bir görüşü (çözüm şeklini) de benimseyebilir (Yargıtay K. m. 45, 7).

İlgili içtihadı birleştirme kurulu, içtihatların birleştirilmesine karar verince, bu kararın niteliğini açıkça belirten özet, kararın verilmesini izleyen (takip eden) en kısa zamanda Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı, bütün adliye mahkemelerine ve Cumhuriyet savcılıklarına içtihadı birleştirme kararının özetini en kısa zamanda duyurur (Yargıtay K. m. 45, 6).

İçtihadı birleştirme kararları Resmî Gazetede yayımlanır (Yargıtay K. m. 58).

İçtihadı birleştirme kararları kesindir; bu kararlara karşı başvurulacak bir kanun yolu yoktur.

İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir. İçtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesinin veya kaldırılmasının istenmesi ve buna karar verilmesi de (yukarıda incelenmiş olan) içtihadı birleştirme kararı verilmesi usulüne bağlıdır (Yargıtay K. m. 45, 3).

ee) İçtihadı Birleştirme Kararlarının Niteliği ve Bağlayıcı Gücü

İçtihadı birleştirme kararları ilke kararlarıdır ve benzer hukukî konularda **Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini** ve **adliye mahkemelerini bağlar** (Yargıtay K. m. 45, 5). İçtihadı birleştirme kararlarını Yargıtay'ın diğer içtihatlarından ayıran husus da budur. Zira, yukarıda da belirtildiği üzere, Yargıtay'ın kararları, yalnızca o davanın taraflarını bağlar. Buna karşılık, içtihadı birleştirme kararları, hem Yargıtay'ın ilgili kurul ve dairelerini hem de adlî yargı alanındaki tüm mahkemeleri bağlayıcı niteliktedir. Bu kararlar âdeta kanun gücündedir.

Yargıtay'ın bu yetkisinin Anayasanın güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüşse de, Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne göre, "İçtihadı birleştirme kararı, o zamana değin (kadar) hukuk alanında hukuk kuralı olarak bulunmayan yeni bir kural koymayı erek (amaç) edinmiş olan bir hukuk işlemi değildir. İçtihadı birleştirme kararı, belli bir olay için **yeni bir hukuk kuralı koymak gereği** (amacı) **ile değil**, ancak ve ancak belli bir olaya uygulanacak yasanın veya nesnel (objektif) ni-

telikte olan tüzük ve yönetmelik kuralları gibi öbür hukuk kurallarından hangisinin, hangi anlamda uygulanacağını saptamak için verilir".

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'a ülkede hukuk (içtihat) birliği sağlama görevinin Anayasa tarafından verildiğini; yargı bağımsızlığının, yargının dış etkenlerden korunmasına hizmet ettiğini; bir hâkimin kararının başka bir hâkim tarafından denetlenmesi halinde yargı bağımsızlığının zedelendiğinden söz edilemeyeceğini; Yargıtay'ın bağlayıcı yorum yapmasının mahkemelere verilen talimat veya emir gibi algılanamayacağını; Yargıtay'ın bu yetkisinin tüm yargı yollarını kapsamayıp yalnızca adlî yargı bakımından geçerli olduğunu; içtihadı birleştirme kararlarının bağlayıcı (kesin) olmasının da Anayasaya aykırı olmadığını, zira denetim mekanizmasının ilk derece mahkemeleri için söz konusu olup, yüksek mahkeme olarak Yargıtay'ın kararlarının kesin olabileceğini; ayrıca içtihadı birleştirme kararlarının değiştirilmesinin de mümkün olması nedeniyle, hukukun kalıplaşacağı iddiasının da yerinde olmadığına karar vermiştir[22].

Yargıtay'a göre ise, "bir konunun içtihadı birleştirme kararıyla aydınlanması, amelî sonuç (pratik uygulama) bakımından, o konuda yeni bir yasa (kanun) çıkarılması anlamına gelmektedir". Yargıtay'ın bu görüşü Anayasa Mahkemesi kararına uygun yorumlanmalıdır.

İçtihadı birleştirme kararlarının özelliği, uygulamaları bir esasta toplamak, yanlışlıklara meydan vermemek ve TMK'nun 1. maddesi uyarınca uygulama alanında meydana gelen boşluğu doldurmaktır.

Mahkemeler, bakmakta oldukları davaları yeni verilen içtihadı birleştirme kararına göre inceleyip karara bağlarlar. Bir dava hakkındaki karar daha önce Yargıtay tarafından bozulmuş ve mahkemenin bu bozmaya uymuş olması nedeniyle usule ilişkin kazanılmış hak doğmuş olsa bile mahkeme, bozma kararıyla gösterilen yolu bırakarak, yeni içtihadı birleştirme kararı gereğince inceleme yapmak ve karar vermekle yükümlüdür.

C) GÖREVLERİNE GÖRE MAHKEMELER

Mahkemeler, üstlenmiş oldukları görevler bakımından da bir ayrıma tâbi tutulabilir. Baktıkları dava ve işler, konu veya tarafların konumları bakımından sınırlanmamış mahkemeler, genel görevli mahkeme adını alırken; belirli tür dava ve işlere bakan ya da yalnızca belirli sıfatlara sahip kişileri ilgilendiren dava ve işlere bakan mahkemelere özel görevli mahkemeler adı verilmektedir.

5235 s. K.'da bu tür bir ayrım veya tanım yer almamakla birlikte, Kanundaki düzenleme, bu tür bir sınıflandırmaya olanak tanımaktadır. Nitekim mahkemelerin kuruluşu ile ilgili 5235 s. K. da, hukuk mahkemelerini, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleri olarak nitelendirmiştir (5235 s. K. m. 4-5).

---

[22] Anayasa Mahkemesi'nin 12.06.1969 gün ve 38/34 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 88-90.

I – GENEL GÖREVLİ MAHKEMELER

5235 sayılı Kanun, 4. maddesinde "Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir" hükmünü koymuştur. Yine aynı Kanunun "hukuk mahkemelerinin görevleri"ni düzenleyen 6. maddesine göre, **sulh hukuk mahkemeleri**, HMK (bkz. HMK m. 447) ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir. **Asliye hukuk mahkemeleri** ise, sulh hukuk mahkemeleri ile özel görevli mahkemelerin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar. İleride görüleceği üzere, sulh hukuk mahkemeleri HMK m. 4'te sayılan davalarla, HMK'nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği dava ve işlere bakar.

HMK m. 2, 1'e göre, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalar ile kişivarlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, **aksine bir düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi**dir[23].

Sulh hukuk mahkemeleri, kural olarak HMK ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir (5235 s. K. m. 6 ve HMK m. 4).

Sulh hukuk mahkemelerinin görevini gösteren HMK m. 4, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın saydığı davalara sulh hukuk mahkemesinde bakılacağını düzenlemiştir[24]. Bu açıdan, HMK'nun sulh hukuk mahkemelerinin görev alanını daralttığı söylenebilir. Ancak buna rağmen, sulh hukuk mahkemelerinin görev alanı, özel görevli mahkemelerle karşılaştırıldığında çok geniştir.

Sulh hukuk mahkemeleri, HMK m. 4'te üç bent halinde sayılan dava ve işlerdeki görevlerinin yanı sıra, kanunların gösterdiği diğer davalarda da görevlidir. Bu arada, çok geniş bir uygulama alanı bulunan çekişmesiz yargı işlerinde de (m. 382 vd.) görevli mahkeme, aksine hüküm bulunmadıkça, sulh hukuk mahkemesidir (m. 383). Bu durumu itibariyle sulh hukuk mahkemelerinin, belli kişiler (örneğin, işçi ve işveren) arasında çıkan uyuşmazlıklarda görevli iş mahkemeleri veya belli çeşit (örneğin, Kadastro Kanunu'nun uygulanmasından doğan) uyuşmazlıklara bakmak için kurulan kadastro mahke-

---

[23] Oysa, 1086 sayılı HUMK'nda, malvarlığı davaları bakımından sulh hukuk mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasında bir görev bölüşümü (paylaşımı) söz konusu idi. HUMK m. 8'de belirtilen parasal sınırı (miktarı) geçmeyen malvarlığı davaları sulh hukuk mahkemesinde, sınırı geçen malvarlığı davaları ise asliye hukuk mahkemesinde görülürdü. Böylece malvarlığı davaları (özel kanunlarla kurulan özel mahkemelerin görevine girenler ve HMK ile diğer kanunlarda açık olarak belirtilenler hariç), asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri arasında dağıtılmıştı. Her iki genel mahkemenin görevi arasında, parasal bir sınır öngörüldüğü için, sulh hukuk mahkemelerinin ve asliye hukuk mahkemelerinin aralarındaki sayısal iş dengesini sağlamak üzere parasal sınır, enflasyon paralelinde, zaman zaman (son yıllarda her yıl otomatik olarak) arttırılmakta idi.

[24] Bkz. aşa. § 9, B. HMK m. 2'nin, HUMK'nun 8. maddesindeki (asliye hukuk-sulh hukuk ayırımıyla ilgili) sınırı kaldırmış olması sebebiyle, kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğunun açıkça gösterilmediği malvarlığı davaları, değer veya miktarı ne olursa asliye hukuk mahkemesi tarafından görülür. Değeri örneğin bin TL olan bir malvarlığı davasında görevli mahkeme, eskiden (HUMK döneminde) sulh hukuk mahkemesi iken, 6100 sayılı HMK'na göre, bu dava da artık asliye hukuk mahkemesinde görülür.

meleri gibi "özel görevli mahkemeler"e oranla, yine de genel görevli mahkeme niteliğinde olduğu söylenebilir. Buna karşılık, herhangi bir sınır (tutar) belirtilmeksizin sulh hukuk mahkemelerinin bakacakları iş ve davaların, ayrı ayrı sayılması karşısında da, sulh hukuk mahkemelerinin, bir anlamda özel görevli mahkemelere yaklaştığı da belirtilebilir. Ancak, sulh hukuk mahkemesinin görevlerine bakıldığında (m. 4), ne konu, ne de taraflar açısından bir sınırlama vardır. Birbirinden farklı türde bazı davalar veya işler sulh hukuk mahkemesinin görev alanına bırakılmıştır. Bu görev konularının farklılıkları, bu mahkemenin özel görevli mahkeme olarak kabulüne engeldir. Çünkü özel görevli mahkemeler, belirli konularda uzmanlaşmış mahkemelerdir. Oysa sulh hukuk mahkemelerinin çok farklı türde dava ve işlere bakmaları benimsendiğinden, özel görevli mahkeme olarak nitelenmeleri mümkün değildir.

Asıl olan, bir davanın **genel görevli mahkeme**lerde görülmesidir. Yani özel görevli mahkemede bakılacağına dair özel bir kanun hükmü bulunmayan her dava, genel mahkemelerde görülür (m. 2).

Asliye hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesinin üstünde bir mahkeme değildir. Her iki mahkeme de, ilk derece hüküm mahkemesidir. Yalnız, çok istisnaî bazı hallerde (genellikle de çekişmesiz yargıda), sulh hukuk mahkemesinin kararına karşı asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir (bkz. örneğin: TMK m. 461, II; 488). Bundan başka, TMK m. 463'de düzenlenen durumlarda sulh hukuk mahkemesinin kararı alındıktan sonra asliye mahkemesinin de izni gereklidir.

Her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu gözönünde tutularak belirlenen ilçelerde, bulunduğu il veya ilçenin adıyla anılan asliye ve sulh hukuk mahkemesi vardır (5235 s. K. m. 5, 6; 7, 2). Yani, bütün il merkezlerinde ve işi çok olan büyük ilçelerde ayrı asliye ve sulh hukuk mahkemeleri vardır ve bu mahkemenin hâkimi, kural olarak, yalnız asliye veya sulh hukuk işlerine bakar.

İşi daha çok olan yerlerde (örneğin il merkezlerinde) hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır (örneğin Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi veya Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi gibi). Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir. Bu kararlar, Resmî Gazetede yayımlanır. **Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır** (5235 s. K. m. 5, V). Bunların hepsi, o yer asliye veya sulh hukuk mahkemesine dahil olup, bu mahkemelerden her biri o yer asliye veya sulh hukuk mahkemesinin birer dairesi durumundadır.

Aynı yerdeki birden fazla asliye veya sulh hukuk mahkemesinin kendi arasındaki ilişki, görev ilişkisi değil, sadece bir **iş dağılımı**dır. İş dağılımı, esasen bir yerde bulunan aynı tür mahkemeler arasında sayısal bir eşitlik ve denge kurmaya yöneliktir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere HSK'nun uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliğini dikkate alarak mahkemeler arasında bir iş dağılımı yapma yetkisi, kanımızca kanunen

görevlendirilmiş bir mahkemenin görev alanını daraltma sonucunu doğurmaktadır.

II – ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER[25] (UZMANLIK MAHKEMELERİ)

Genel görevli mahkeme deyiminin karşıtı olarak, belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belli çeşit uyuşmazlıklara bakmak için kurulmuş olan mahkemelere, "özel görevli mahkemeler" denir.

Çağımızın hızlı teknolojik gelişmeleri, üretim, ticaret ve hukukî ilişkilerin gittikçe karmaşıklaşması sonucunu doğururken, hukukî açıdan da özel ve teknik sorunlar yaratmaktadır. Buna bağlı olarak da özel hukuk ilişkileri 21. yüzyılda farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu bakımdan, sorunlara, kişilere veya konulara göre uzman (ihtisaslaşmış) mahkeme anlayışı da önem kazanmıştır.

Özel görevli mahkemeler, olağanüstü veya kişiye özel kurulmuş mahkemeler değildir. Bu mahkemeleri özel kılan husus, baktıkları iş veya davaların sınırlı olması, özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bütün davalara değil, bunların içerisinden konu veya tarafların konumu ya da sıfatlarına göre seçilmiş belirli türde davalara bakmalarıdır. Bu yolla mahkemelerin belirli konularda uzmanlaşması (ihtisaslaşması) sağlanarak daha isabetli ve tatmin edici kararlara ulaşılması amaçlanmaktadır. O nedenle bu mahkemelere ihtisas veya uzmanlık mahkemeleri de denilmektedir.

Özel görevli mahkemelerin kurulabilmesinin hukukî dayanağı, yukarıda belirtildiği üzere, adlî mahkemelerin kuruluşu ile ilgili 5235 s. K. m. 6'dır. Genel görevli mahkemelerin yanında ayrı özel görevli mahkemeler kurulması, Anayasanın 37. maddesindeki "kanunî hâkim güvencesi" (**tabiî hâkim**) ilkesine aykırı değildir[26]. Çünkü, Yargıtay'ın da belirttiği gibi, Anayasa m. 37 hükmü, belli bir tür davayı görmek üzere kurulmuş mahkemeler varken, bu davalardan bir veya birkaç kişiye ilişkin belli davaları görmek üzere özel mahkeme kurulmasını yasaklamak için konulmuştur. Yoksa belli türden olan davalar için, örneğin iş davaları veya aile hukukuna ilişkin konularda için özel görevli mahkeme kurulmasını önlemek söz konusu değildir.

Özel görevli mahkemelerin kuruluşu, mutlaka ayrı bir kanun hükmü ile düzenlenir (Anayasa m. 142). Ancak bu şekilde, özel görevli mahkemelerin kuruluşu, tabiî hâkim (kanunî hâkim güvencesi) ilkesine aykırı düşmez.

Aile mahkemesi, icra mahkemesi, tüketici mahkemesi, iş mahkemesi ve kadastro mahkemesi ile fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi medenî yargıda yer alan özel görevli mahkemelerdir[27].

---

25 Bkz. Havva Gül Şahan, Kuruluşu, İşleyişi ve İşlevleri Bakımından Medenî Yargılama Hukukunda Özel Görevli Mahkemeler, Ankara 2012.

26 Anayasanın 37. maddesine göre: "Hiç kimse **kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz** (fıkra I). Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz (fıkra 2)".

27 Bkz. aşa. § 71-76.

Özel görevli mahkemeler, uzmanlaşma amacına yönelik olmakla birlikte, bu mahkemelerin hâkimleri de meslekten hâkimdirler. Anayasa m. 140, II, hâkimlerin hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yapacağını ve bu yetkinin meslekten hâkimlerle yürütüleceğini düzenlemektedir. Hâkimlik teminatı, hâkimlere tanındığından, meslekten olmayanların yargı görevi ifa etmeleri mümkün değildir. Nitekim, iş mahkemelerinde işçi ve işveren temsilcilerinin bulunmasını öngören İş Mahkemeleri Kanunu'nun 2-4 ve 6. maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir[28]. Türk hukuku bakımından uzmanlaşma, o konunun teknik anlamda uzmanı tarafından görülmesi değil, o tür iş ve davaları gören hâkim tarafından yürütülmesi biçiminde uygulanmaktadır. Bu da hâkimlerin, tercihan, o konuya olan özel ilgisi veya bu alanda lisansüstü çalışmalar yapmış olmaları gibi ölçütlerle sağlanmaktadır.

Genel ve özel görevli mahkemeler arasındaki ilişki **görev** ilişkisidir.

Özel görevli mahkemelerin genel görevli mahkemeler kadar yaygın kurulması mümkün olamamaktadır. Gerek iş gerekse hâkim yetersizliği nedeniyle ayrı özel görevli mahkemenin kurulamaması ve ilgili kanunda özel bir düzenleme bulunmaması halinde, o özel görevli mahkemenin işlerine de kapsamlı ve geniş görevli genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi, özel görevli mahkeme sıfatıyla (m. 297, 1/a) bakar. Ancak bazı özel görevli mahkemeler bakımından HSK'nun kararları[29] doğrultusunda belirli bir asliye hukuk mahkemesinin de görevlendirilmesi mümkündür. Örneğin HSYK (şimdi HSK), ayrı iş mahkemesi kurulmayan yerlerdeki iş davalarına o yerdeki 1 numaralı asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılacağına karar vermiştir[30].

Özel görevli mahkemede uygulanacak yargılama usulü hakkında ilgili kanunlar ile bazı özel usul hükümleri konulmuştur; bu özel usul hükümleri dışında, HMK hükümleri özel görevli mahkemelerde de uygulanır. Örneğin, İş Mahkemeleri K. m. 9, 1'e göre, "Bu kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 6100 sayılı Kanun hükümleri uygulanır".

Buna göre, özel görevli mahkemelerin kuruluşu, işleyişi ve bu mahkemelerde uygulanan yargılama usulü, genel görevli mahkemeye oranla bazı özellikler taşır. Bu nedenle, özel görevli mahkemelerin çeşitleri, kuruluşu, işleyişi, görevleri ve yargılama usulleri, genel görevli mahkemelerde uygulanan yargılama usulü görüldükten sonra incelenecektir[31].

---

28 13.04.1971 gün ve 63/38 sayılı karar için bkz. RG 16.11.1971, sa. 14077.

29 Bkz. HSYK'nun çeşitli tarihlerde güncellenen 24.03.2005 tarihli ve 188 sayılı kararı.

30 Bu durumda ortaya aynı yerde yer alıp özel görevli mahkeme sıfatıyla davaya bakmakla görevlendirilen mahkeme ile o yerde bulunan aynı sıfat ve düzeydeki mahkemeler arasındaki ilişki bir sorun oluşturmaktadır. Örneğin iş mahkemesi kurulmayan bir yerde 1. asliye hukuk mahkemesi yerine davaya 3. asliye hukuk mahkemesinin bakması halinde, söz konusu mahkemeler arasındaki ilişki bir iş dağılımı mı (5235 s. K. m. 5, 5), görev ilişkisi (m. 2 vd.) olarak mı kabul edilecektir? Yargıtay'ın bazı daireleri bu tür görevlendirmelerin "iş dağılımı" değil, "görev" olduğunu kabul etmekte iken bazı daireleri ise tam tersini benimsemektedir.

31 Bkz. aşa. § 71-76.

D) KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME BAKIMINDAN MAHKEMELER

Mahkemeler, kuruluş ve örgütlenme bakımından **tek hâkimli mahkeme** veya **toplu** (çok hâkimli) **mahkeme** biçiminde bir ayrıma tâbi tutulmaktadır. Bir mahkemenin tek hâkimli olması halinde, hem tahkikat hem yargılama aynı hâkim tarafından yürütülür. Buna karşılık toplu mahkemelerde birden fazla hâkim bulunur ve mahkeme heyet (kurul) halinde çalışır. Bu halde mahkemenin bir başkanı ve üyeleri mevcut olup, tahkikatın, bir üye tarafından yapılması mümkündür (m. 185); karar birlikte verilir, ancak oy çokluğu ile karar verilmesi mümkündür (m. 296).

Bir mahkemenin toplu mahkeme olması, hukukî himayenin sağlanması bakımından güvencedir; zira kurul olarak verilen kararların müzakere ve tartışma ile daha isabetli olması beklenir. Buna karşılık, kurul halinde çalışma, her zaman beklenen verimi sağlamayabilir, yargılamayı uzatıcı bir etki yaratabilir; hâkimlerin tek başına karar vermek zorunda olmamaları, onların inisiyatif alma becerilerini olumsuz etkileyebilir. Tek hâkimin karar vermesi halinde sorumluluk duygusu daha fazla gelişir. Öte yandan, tek hâkimli mahkeme kurmanın maliyeti daha azdır. Bütün bu sakınca ve yararları dengelenmek suretiyle kanun koyucu bir tercih yapmaktadır.

İlk derece mahkemeleri, asliye ticaret mahkemesi dışında, tek hâkimli iken; üst ve yüksek mahkemeler (istinaf -bölge adliye- mahkemeleri ve Yargıtay) toplu mahkeme biçiminde kurulmuştur.

Toplu mahkemeler, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça[32] **bütün üyelerin** (yani, asliye ticaret mahkemeleri ve istinaf mahkemeleri üç; Yargıtay daireleri beş üyenin) **hazır bulunması** ile oluşur; bütün üyelerin hazır bulunmasıyla müzakerede bulunulur, usul işlemi yapılır ve karar (ara karar ve nihai karar) verilir. Başka bir ifadeyle, üyelerin tamamı bir araya gelmemişse müzakere ve işlem yapılamaz, karar verilemez. Çünkü ancak üyelerin tamamının birlikte toplanması halinde "toplu mahkemeden" söz edilebilir. Bu sebeple **eksik üye ile müzakere ve usul işlemi yapılamaz**, karar verilemez. Aksi halde yapılan müzakere, işlem ve karar yok hükmündedir. Bununla birlikte üyelerin tamamının bir araya gelmesi halinde oy çokluğuyla işlem yapılabilmesi ve karar verilebilmesi mümkündür.

---

32 Örneğin toplu mahkeme olarak kurulan asliye ticaret mahkemelerinin 5235 s. K. m. 5 ile getirilen düzenleme ile dava konusu 300.000 TL'nın altında bulunan ticarî davalarda kural olarak tek hâkimle bütün usul işlemlerini yapıp karara bağlaması öngörülmüştür.

§ 4. YARGI GÖREVLİLERİ

A) KAVRAM

Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemeler, aynı zamanda yargılama faaliyetinde bulunma görevini de yerine getirir. Yargılamayı yürüten kişi, "hâkim" olmakla birlikte, yargılama, kolektif (toplu) bir faaliyettir. Bu bakımdan yargılamada doğrudan veya dolaylı olarak görev alan pek çok kişi vardır. HMK'nda yargı görevlileri kavramı kullanılmamakla birlikte, Kanunun değişik yerlerinde bu konuda çeşitli hükümler bulunmaktadır (m. 34 vd.; 45; 70; 71 vd.; 76; 157; 159; 203; 206; 208, 4).

Burada, yargı görevlileri başlığı altında, yargılamanın değişik aşamalarında farklı rolleri olan kişiler toplu halde incelenmek suretiyle, yargı örgütünün insan unsuru ve boyutu hakkında genel olarak bilgi verilecektir:

B) HÂKİM

Hâkim, yargılamayı yürüten kişidir. İleride yargılamaya hâkim olan ilkeler kısmında açıklanacağı üzere, hâkim, yargılamayı sevk ve idare etme yetkisine sahiptir (m. 32)[1]. Anayasa m. 9 hükmü ile yargı yetkisinin kullanılması, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Dolayısıyla hâkim, yalnızca sürecin yürütülmesi konusunda biçimsel bir işleve değil, esas görevi olan uyuşmazlıkları nihaî olarak çözme görevine de sahiptir.

Devletin temeli olan adaleti uygulayan, dağıtan ve gerçekleştiren hâkimlerin çok önemli bir görev yerine getirdikleri açıktır. Bir toplumda son söz hâkimlerindir ve hâkimlerin kararı ile toplumdaki adaletsizlikler giderilir. Bu nedenle, hâkimlerin statüsü diğer kamu görevlilerinden ayrı olarak düzenlenmiş ve hâkimlere diğer kamu görevlisi veya Devlet memurlarının sahip bulunmadıkları bazı teminatlar (güvenceler) tanınmıştır.

Hâkimlerin nitelikleri[2], atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir (Anayasa m. 140, III). Bu kanun, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'dur.

---

1 Bkz. aşa. § 5.

2 Bkz. Recep Akcan, Hâkimin Vasıfları, Ankara 2013.

I – HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

1) Adaylık

Bir Türk hukuk fakültesi mezununun hâkim olabilmesi için ilk önce adaylık (staj) dönemi geçirmesi ve bunun sonucunda adayın hâkimliğe ehil olduğunun anlaşılması gerekir. Hâkim (ve savcı) adayları[3] **Adalet Bakanlığı** tarafından yazılı yarışma sınavı ve mülakatla[4] tespit ve tayin edilir.

Avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçiş ile doğrudan doğruya hâkimlik mesleğine aday olunması halinde farklı ölçütler aranmakta ve adaylar, ayrı yazılı yarışma sınavına tâbi olmaktadırlar. Adaylık koşulları ve adayların mahkemelerde ve savcılıklarda görecekleri staj ve eğitim hakkında Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 7-15'de ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır.

Hâkim adaylarının meslek öncesi (adaylık) döneminde eğitimleri ve daha sonra da meslek içi eğitim göreviyle kurulan ve 703 sayılı KHK[5] ile kapatılan Türkiye Adalet Akademisi 34 nolu CK ile yeniden kurulmuştur[6].

Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananların adaylık süresi iki, avukatlık mesleğinden adaylığa atananlar için bir yıldır[7]. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşur. Adaylar, eğitim süresini "aday memur" statüsünde Adalet Bakanlığına bağlı olarak geçirirler[8].

2) Hâkimliğe Atanma

Adaylık süresinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde başarılı olan adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) karar verilir.

Görev yerleri HSK'nca yapılacak ad çekme (kur'a) yöntemiyle belirlenir; atamaları HSK'nca yapılır (Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 13).

Hâkimlik (ve savcılık) mesleği, üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır (Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 15).

---

3 Hâkim ve savcı adaylarının, hâkimlik veya savcılık görevlerinden hangisini yapacakları, adaylık döneminde belirlenir ("Adlî yargı adaylarından; meslek öncesi eğitimlerinin altı ayını, avukatlık mesleğinden adaylığa geçenlerden meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayanlar, adlî yargı teşkilâtının ihtiyaç durumu ile 11 inci madde gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılırlar" Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 10, 4).

4 Anayasa Mahkemesi, hâkim ve savcı adaylarının belirlenmesinde mülakat yapılmasını Anayasaya aykırı bulmamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 07.02.2007 gün ve 47/14 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 97-99.

5 RG 09.07.2018, sa. 30473.

6 RG 02.05.2019, sa. 30762.

7 2802 s. K. m. 10 (7165 s. K. m. 5 ile değişik).

8 Adaylar, henüz hâkimlik mesleğine kabul edilmediklerinden bu aşama, Adalet Bakanlığının gözetimi ve denetimi altında geçen bir süreçtir. Öte yandan, adaylık ve staj dönemi konularında 4954 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. Ancak bu düzenleme, adayların hâkim statüsünde olduğunu göstermez (2802 s. K. m. 12; 4954 s. K. m. 28).

II – HÂKİMLİK MESLEĞİ

Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar (Anayasa m. 138). Hâkimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler (Anayasa m. 138, I). Bir davaya bakmakta olan hâkim, o davada uygulanacak bir kanun (veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi) hükümlerini Anayasaya aykırı görürse, durumu Anayasa Mahkemesi'ne bildirir ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır (bkz. Anayasa m. 152). Böylece hâkim, Anayasaya aykırı gördüğü bir kanun hükmünü uygulamamakla ödevlidir.

Adalet dağıtımı gibi çok önemli bir görev yapan hâkimlerin, bunu en iyi bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak için, hâkimler diğer kamu görevlilerinden başka bir statüye tâbi tutulmuşlardır: Hâkimlerin atama, yer değiştirme, nakil, terfi, izin gibi özlük işlerinde karar verme yetkisi, HSK'na aittir[9]. Hâkimler, diğer kamu görevlilerinden farklı olarak (üç yılda değil) her iki yılda bir derece yükselmesi incelemesine tâbi tutulurlar (Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 18, 2).

Hâkimler bazı genel yükümlülüklerden muaf tutulmuştur. Örneğin; hâkimlik mesleği mensupları vasilikten kaçınabilirler (TMK m. 417, 5). Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar (Anayasa m. 140, V). Örneğin, hâkimler hükümet komiseri veya iflâs idare memuru olarak tayin edilemez; hâkimler hakemlik (m. 407 vd.) yapamaz; hâkimler vasiyeti yerine getirme görevlisi (TMK m. 550) olamaz.

Hâkimlerin yargı görevinden başka bir görev yapabilmeleri, ancak özel bir kanun hükmü ile mümkündür. Örneğin, hâkimlerin seçim kurullarında çalışmaları[10] böyledir.

Hâkimin taşıması gereken özellikler Mecellede çok özlü bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre, hâkim, çok bilgili, uzman, ilim sahibi (hakîm, hikmet sahibi, filozof); zeki, akıllı, anlayışlı (fehîm); doğru yoldan ayrılmayan, namuslu, dürüst (müstakîm); güvenilir, korkusuz, saygın (emîn); güçlü, nüfuz sahibi, onurlu (mekîn), ve sözünden dönmez, dayanıklı, sağlam, soğukkanlı (metîn) olmalıdır[11].

Hâkimlik mesleğinin özellikleri ve hâkimin yapacağı görev dikkate alınarak günümüzde hâkimin sahip olması gereken nitelikler ve yargı sistemleri hakkında uluslararası alanda ilkeler oluşturulduğu görülmektedir. Nitekim, 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri, 2003 tarihli Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği İlkeleri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik Tavsiye Kararı, Venedik Komisyonunun 2007 tarihli Yargısal Atamalar Raporu, yine aynı Komisyonun 2010 tarihli Yargıçların Bağımsızlığı Raporu, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyinin görüşleri, Hâkimlerin Statüsüne İlişkin Avrupa Şartı gibi metinler incelendiğinde hâkimlik teminatı, yargı üst kurulla-

---

9 Anayasa m. 159. Ayrıca bkz. HSKK m. 1.

10 Bkz. Anayasa m. 79; 298 s.K. m. 10-20.

11 **"Hâkim, hakîm, fehim, müstakîm ve emîn, mekîn, metîn olmalıdır"** (Mecelle m. 1793).

rının oluşumu, atama ve terfi sistemi, disiplin soruşturma usulü, yargı bütçesi, hâkim ve savcıların özlük hakları, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile etik değerler, ortak konu başlıkları olarak görülmektedir.

Bunlardan Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği Kurallarını benimseyen ve uygulanması hususunu bir genelge ile Türk hâkim ve savcılarına duyuran HSK[12] da, (esas itibariyle Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği Kuralları paralelinde hazırlanan) **"Türk Yargı Etiği Bildirgesi"** adı altında bir metin yayımlamıştır[13]. Bildirge'nin girişinde "Hâkimler ve savcılar, görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, mesleki sorumluluk içinde davranan, bütün işlemleri ile karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin ve toplum nezdindeki saygınlıklarının korunmasının Türk yargısının itibarını da yükselteceğinin bilincinde olan 'hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn' insanlardır. Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde, hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürütürler. Bu bildirgede belirtilen etik ilkeleri içtenlikle benimser, gerek mesleki, gerekse sosyal hayatlarında bu ilkeler doğrultusunda davranmayı, onurları ve vicdanları üzerine söz verirler" denildikten sonra, ilkeler şöyle sıralanmaktadır: 1- İnsan onuruna saygı, insan haklarını koruma ve herkese eşit davranma[14]; 2- Bağımsızlık[15]; 3- Tarafsızlık[16]; 4- Dürüstlük ve tutarlılık[17]; 5- Yargıya

---

12 HSK'nun 27.06.2006 gün ve 315 sayılı kararı.

13 RG 14.03.2019, sa. 30714.

14 Hâkimler ve savcılar, **1-İnsan onuruna saygılıdır, insan haklarını korur ve herkese eşit davranırlar: 1.1.** İnsan onurunun dokunulmaz olduğuna dair medeniyetimizin ve evrensel kabulün bir tezahürü olarak, İnsan onurunu esas alır; bütün davranışlarında insan hak ve özgürlüklerine uygun hareket ederler. **1.2.** İnsan haklarına dayalı devlet ilkesinin, ancak insan hak ve özgürlüklerinin etkin bir şekilde korunması ile gerçekleşebileceğinin farkında ve bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğun bilincindedirler.**1.3.** Bir arada yaşamanın; farklılıklara saygı duymayı, birbirine anlayışla yaklaşmayı ve herkese eşit davranmayı gerektirdiğini kabul ederler. **1.4.** Görevlerini yerine getirirken dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, uyruk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum, hemşehrilik, yaşam biçimi, yaş, sağlık durumu, dış görünüş, medeni hâl ve benzeri sebeplerle ayrımcılığı kesin bir biçimde reddeder ve ayrımcı bir dil kullanmazlar. Anayasada yer verilen pozitif ayrımcılığın, eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmediğini bilirler. **1.5.** Adalet hizmetinden faydalanmak isteyenler başta olmak üzere, meslektaşları, avukatlar, adalet personeli, tanık, bilirkişi gibi yargısal sürece dâhil olanlara ve topluma eşitlik ilkesinin uygulandığına dair güven verirler. Görev ve yetki alanı içerisinde, bu güveni zedeleyebilecek her türlü davranışı önlerler.

15 **2- Bağımsızdırlar: 2.1.** Bağımsızlıklarıyla adil yargılanmanın ve hukuk devletinin güvencesidirler. **2.2.** Yargı bağımsızlığının, yargılama fonksiyonunun baskı ve tesirden uzak bir şekilde yerine getirilmesi için tanındığının bilinciyle hareket ederler. **2.3.** Bağımsızlıklarına doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilecek baskı ve tesiri kayıtsız şartsız reddederler. **2.4.** Kararlarını; kişilerin, kurumların ya da kamuoyunun tepkisini çekeceği endişesi duymaksızın ve onları memnun etme kaygısı taşımaksızın bağımsız olarak verirler. **2.5.** Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için bağımsız olmak kadar, bağımsız görünmenin de önemli olduğu bilincindedirler. **2.6.** Bağımsızlığın, sorumsuz ve ayrıcalıklı olmak anlamına gelmediğinin, bilakis hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde adaletin tecelli etmesini sağlama amacı taşıdığının farkındadırlar. **2.7.** Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hesap verebilirliğin; bağımsızlıklarını zedelemeyen, aksine toplumsal meşruiyetlerini arttırmak suretiyle güçlendiren bir ilke olduğunun bilincindedirler.

16 **3- Tarafsızdırlar: 3.1.** Adil yargılamanın gereği olarak, herhangi bir tarafa İltimas göstermeden ve ayrımcılık yapmadan tarafsız bir şekilde hareket ederler. **3.2.** Tarafsız hareket

olan güveni temsil[18]; 6- Mahremiyeti gözetme[19]; 7- Mesleğe yakışır şekilde davranma[20]; 8- Yetkinlik ve meslekte özenli davranma[21].

---

etmekle yetinmez, objektif bir bakış açısıyla tarafsızlıklarına ilişkin her türlü kuşkuyu bertaraf edecek bir duruş sergilerler. Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için tarafsız olmak kadar, tarafsız görünmenin de önemli olduğu bilincindedirler. **3,3.** Meslekî ve sosyal hayatlarında tarafsızlık ilkesine aykırı düşebilecek her türlü ayrımcı söylem ve davranıştan kaçınır; konuşma ve beden dilini tarafsızlıklarını ihlal etmeyecek biçimde kullanmaya özen gösterirler. **3,4.** Sosyal medya başta olmak üzere, kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapacakları yorum, değerlendirme ve paylaşımların kolaylıkla amacını aşan sonuçlar doğurabileceğini ve tarafsızlıklarını sorgulanır hale getirebileceğini öngörerek hareket ederler. **3.5.** Kişisel kanaat ve düşüncelerinin, tarafsızlıklarına gölge düşürmesine izin vermez ve ön yargılı şekilde hareket etmezler. Görevlerini yürütürken ön yargı ve tercihlerinden etkilenip etkilenmediklerini sorgularlar. **3.6.** Toplumda, herhangi bir olay ile ilgili olumlu veya olumsuz bir kanaat oluştuğu durumlarda dahi tarafsızlıklarını korurlar. **3.7.** Görevlerini yerine getirirken kendileri, yakınları ve sosyal çevrelerini gözetmek amacıyla taraflı davranışlarda bulunmayı reddeder, tarafsızlıklarından ödün vermezler. **3.8.** Görevde olan veya görevinden ayrılarak avukatlık, bilirkişilik, arabuluculuk ve benzeri görevler yürüten meslektaşlarına ayrıcalıklı davranmaz, bu yönde bir izlenim oluşturmazlar.

17 **4- Dürüst ve tutarlıdırlar: 4.1.** Dürüstlük ve doğruluğun, mesleğin gerektirdiği yüksek karakterin vazgeçilmez unsurları olduğunun bilinciyle gerek meslekî yaşamlarında gerekse sosyal hayatlarında bu yönde bir duruş sergilerler. **4.2.** Özü sözü bir kişilikleriyle oldukları gibi görünür ve göründükleri gibi olurlar. **4.3.** Mesleki itibarlarının korunması için sözlerini yerine getirmekte hassasiyet gösterirler. Dürüstlüklerine gölge düşürebilecek durumlar içinde bulunmama konusunda özenli davranırlar. **4.4.** Neticesinden olumsuz şekilde etkileneceklerini öngörseler dahi gerek iş ve işlemlerinde gerek söz ve davranışlarında doğruluktan ayrılmazlar. **4.5.** Yargısal süreçte aleyhine karar verilen taraf da dâhil olmak üzere, dürüstlüklerinden şüphe duyulmamasını sağlayacak şekilde davranırlar. **4.6.** Hukuki güvenlik ilkesi gereği uygulamalarında tutarlılığı gözeterek görevlerini yerine getirirler. **4.7.** Tutarlılığı sabit fikirlilik olarak yorumlamazlar ve toplumsal değişimleri dikkate alırlar.

18 **5- Yargıya olan güveni temsil ederler: 5.1.** Kendilerine duyulan güvenin, yargıya olan güvenle doğrudan ve ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunun bilinciyle bütün işlem, eylem ve kararlarında yargıya güveni temin eder ve güçlendirirler. **5.2.** Vakur duruşlarıyla adına karar verdikleri Türk Milleti başta olmak üzere, herkesin kendilerine güven duymasını sağlarlar. **5.3.** Görevlerini yaparken kendilerine duyulan güvene halel getirebilecek bir algı, kuşku veya tereddüt oluştuğunu fark ettiklerinde, görevden çekilmelerinin gerekip gerekmediğini azami dikkat ve özenle değerlendirirler. **5.4.** Yargıya olan güveni tartışmalı hale getirebilecek veya zedeleyebilecek tutum ve davranışlardan her zaman ve her yerde titizlikle kaçınırlar. **5.5.** Özel hayatlarında, meslekî güvenilirliklerine gölge düşürebilecek davranışlarda bulunmamaya hassasiyet gösterirler. **5.6.** İfade özgürlüklerini, yargıya duyulan güveni sarsmayacak ve siyasi tarafgirliğe düşmeyecek biçimde kullanırlar.

19 **6- Mahremiyet gözetirler: 6.1.** Mahremiyeti, toplumdan bilgi saklamak için değil; aksine yargısal sürece dâhil olanların haklarını koruyarak adaletin yerini bulması amacıyla gözetirler. **6.2.** Görevleri nedeniyle vâkıf oldukları devlet sırları, ticari sırlar ile kişilere ve kurumlara ait gizli kalması gereken bilgilerin mahremiyetini korurlar. **6.3.** Gizli kalması gereken bilgi ve sırları, kendi yararına ya da başkalarının yarar veya zararına olabilecek şekilde kullanmazlar. Bu bilgilerin mahremiyetini sosyal medya veya başka bir yolla İhlal etmezler. **6.4.** Adliye personeli başta olmak üzere, görevleri gereği gizli kalması gereken bilgilere erişim imkânı olanların, gizliliğe riayet etmesini sağlarlar. **6.5.** Gizli kalması gereken bilgileri doğru belirlerler. Mevzuatta öngörülen açıklık ve şeffaflık İlkeleri; lekelenmeme, bilgi edinme ve savunma hakları; basın, haber alma ve ifade özgürlükleri ile mahremiyetin karşı karşıya geldiği hallerde, kişilerin şeref ve itibarı ile kamusal yarar arasındaki hassas dengeyi gözeterek hareket ederler. **6.6.** Yargıya teslim edilen bilgi ve sırların korunduğuna ilişkin güveni temin eder, bu bilgilerin ve sırların gizliliğini görevleri sona erse dahi gözetirler.

20 **7- Mesleğe yakışır şekilde davranırlar: 7.1.** Mesleklerinin yaşamlarına kattığı değer ve yüklediği sorumluluğun bilinciyle görevlerinin gerektirdiği hassasiyetle davranırlar. **7.2.**

III – HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE TEMİNATI

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır (Anayasa m. 9). Mahkemelere verilen bu bağımsızlık aslında hâkimlere tanınmıştır; zira yargı görevini hâkimler yerine getirmekte; hâkimler yargı yetkisini kullanmaktadır. Bağımsız bir mahkeme önünde yargılanma, adil yargılanmanın temel garantisidir.

Bağımsızlık ve teminat (güvence), genellikle eş anlamda kullanılmaktadır. Oysa bunlar farklı kavramlardır: Hâkimlerin bağımsızlığı veya yargı bağımsızlığı daha genel ve objektif olup, hâkimlik teminatı (güvencesi) hâkimlerin bağımsızlığını korumaya yönelik kurumlardan en önemlisidir[22]. Anayasa,

---

Meslekî ve sosyal ilişkilerinde muhataplarına karşı saygı ve nezaket ilkeleri çerçevesinde hareket eder, söz ve davranışlarının onlar üzerindeki etkisini gözetirler. **7.3.** Toplumun kendilerinden yargı hizmetinin kaliteli sunulmasının yanı sıra erdemli olmalarını da beklediğinin bilincindedirler. **7.4.** Olaylar ve durumlar karşısında uzlaştırıcı bir dil kullanır, sağduyulu ve temkinli davranırlar. **7.5.** Görevin yerine getirilmesi sırasında, diğer meslektaşlarla uyum, iş birliği ve karşılıklı saygı içinde çalışarak verimli bir iş ortamı oluştururlar. **7.6.** Meslekî bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşma hususunda istekli davranırlar. **7.7.** İfade özgürlüğü kapsamında yazılı, görsel, işitsel ya da sosyal medyada düşüncelerini açıklarken veya paylaşımlarda bulunurken, mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun hareket ederler. **7.8.** Meslekî işleyişe ilişkin konular ile yargı kararlarına dair yorum ve değerlendirmelerinde yapıcı ve ölçülü olurlar. Meslektaşlarının yetkinliklerini, yargının saygınlığına ve yargıya olan güvene zarar verebilecek şekilde tartışmaya açmazlar. **7.9.** Görevin yerine getirilmesiyle ilgili olan veya ilgili görülebilecek herhangi bir hediye, bağış, borç, yardım ya da iltimas kabul etmezler. Konumları ve mesleklerinin sağladığı nüfuzdan fayda sağlamazlar. Yakınlarının ve birlikte çalıştıkları personelin de bu hususa riayet etmelerini sağlarlar. **7.10.** Hizmet gereklerini gözeterek kamu mal ve hizmetleri ile insan kaynaklarının en etkili ve doğru biçimde, amacına uygun olarak kullanılmasını temin ederler. **7.11.** Meslekî saygınlığın korunabilmesi için özel hayatlarına gereken dikkati gösterirler. **7.12.** Özel hayatlarında iletişim içinde oldukları kişilerin, işlem ve kararlarım etkilemesine fırsat vermedikleri gibi etkileme güçleri bulunduğu izlenimine yol açabilecek tavır ve davranışlardan da kaçınırlar. Herhangi birinin de bu izlenimi oluşturmasına imkân tanımazlar. **7.13.** Sosyal hayatlarının gereği olarak içinde bulunacakları ortam ve mekânları titiz bir şekilde seçmek suretiyle mesleki saygınlıklarını korurlar.

21 **8- Yetkindir ve mesleklerinde özenli davranırlar: 8.1.** Görevlerini vicdani kanaatleri doğrultusunda, ahlaki olgunluklarına, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde yaparlar. **8.2.** Kararlarının veya işlemlerinin, bu tasarruflardan etkilenenlerin dünyasında ve toplum üzerinde bırakacağı tesirin farkındadırlar. Bu nedenle, bütün meslekî faaliyetlerinde gereken dikkat, önem ve özeni gösterirler. Her soruna çözüm odaklı ve aynı duyarlılıkla yaklaşırlar. **8.3.** Kararlarını hakkaniyetle verebilmek için gerekli bütün bilgi kaynaklarına ulaşmaya ve işlemlerini yeterli gerekçelerle desteklemeye özen gösterirler. **8.4.** Meslekî bilgilerini güncel tutmak ve geliştirmek amacıyla gerekli eğitimleri alma; alanıyla ilgili akademik çalışmaları, ulusal ve uluslararası alandaki hukuki gelişmeler ile yargı içtihatlarını takip etme konusunda kendilerini sorumlu hissederler. **8.5.** Meslekî yetkinliklerini arttırmanın, dış etkilerden bağımsız olarak karar vermelerine katkı sağlayacağını bilirler. **8.6.** Görevlerini adaletin tecellisini geciktirmeyecek şekilde ve makul sürede yerine getirirler. **8.7.** Görevlerine bağlılıkları, gayretleri ve çalışkanlıklarının yanı sıra davranışlarına gösterdikleri özen ile de meslek etiği yönünden örnek olurlar. **8.8.** Çalışma saatlerini verimli kullanır, kamu hizmetini aksatmamak için azami özen gösterirler. Zamanın herkes için değerli olduğunu bilir ve bu konuda duyarlı davranırlar. **8.9.** Atama, yer değiştirme ve özlük haklarına ilişkin diğer hususlarda, hak ve adalete uygun düşmeyen bir istekte bulunmazlar.

22 Hâkimlerin bağımsızlığı ve teminatı için ayrıntılı bilgi için bkz. Baki Kuru, Hâkim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara 1966; Şeref Ünal, Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı, Ankara 1982; Sibel İnceoğlu, Yargı Bağım-

hâkimlerin (mahkemelerin) bağımsızlığı ve teminatı (güvencesi) ayrımına uymuş ve buna göre hükümler öngörmüştür (bkz. Anayasa m. 138 ve m. 139).

1) Hâkimlerin Bağımsızlığı

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır (Anayasa m. 9). Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler (Anayasa m. 138, I; Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 4, 2).

Hukukumuzda da geçerli bulunan ve çağdaş demokrasinin temellerinden olan **güçler ayrılığı ilkesi**; yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi sınırları içinde görevlerini yerine getirmesini, yetkilerini kullanmasını, gerektirir. Hâkimlerin, yürütme ve yasama organları karşısında bağımsızlığını koruyabilmek ve hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, hukuka ve vicdanlarına göre karar vermelerini sağlayabilmek amacıyla, bazı ilkeler bizzat Anayasada öngörülmüştür.

Hâkimlerin, Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanmaları, diğer kamu görevlilerinden farklı bir görev üstlendiklerini gösterir. Bu nedenle hâkimlerin mesleğe kabul, atama, terfi, disiplin, yer değiştirme gibi bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisi, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) aittir (Anayasa m. 159). Bu Kurul hakkında 2017 yılında Anayasada önemli değişiklikler yapılmış ve HSK yeni bir yapıya kavuşmuştur.

"HSK onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakan yardımcısı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından **Cumhurbaşkanı tarafından,** üç üyesi **Yargıtay üyeleri,** bir üyesi **Danıştay üyeleri,** üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından **Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.** Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli

---

sızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri, İstanbul 2008; Bülent Yavuz, Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara 2012.

oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır". (Anayasa m. 159, II-V)

HSK, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez. Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar (Anayasa m. 159, I; HSKK m. 1, 3).

Kurul, Adalet Bakanlığının bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; hâkim ve savcıları mesleğe kabul, atama ve nakil, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar.

HSK'nun bağımsız bir kurul olduğu ifade edilmekte ise de, yürütmenin temsilcisi olan Adalet Bakanı, HSK'nun başkanı olarak Kurulu yönetmek ve temsil etmek görevine ve yetkisine sahiptir. Adalet Bakanının bu yetkisi, temsili bir görev niteliğinde olmayıp, Bakan, Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek yanında oy kullanma hakkına da sahiptir (HSKK m. 6). Yine Genel Kurulun gündemini belirleme (HSKK m. 29) ve Genel Kurul tarafından gösterilen üç aday arasından Genel Sekreteri atama yetkisi de (HSKK m. 6) Başkana (Adalet Bakanına) aittir.

Adalet Bakanı, disiplin işleriyle ilgili genel kurul toplantılarına katılamamakla birlikte, ilgili dairenin teklifi üzerine hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması işlemleri ile inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere olur verme yetkisine sahiptir (HSKK m. 6). Bu ise, hâkimler üzerinde disiplin konularında son karar merciinin Adalet Bakanı olduğunu göstermektedir[23].

Yürütme organına bağlı olan, yürütmeyi temsil eden Adalet Bakanının ve Yargıtay veya Danıştay üyesi sıfatı bulunmayan Adalet Bakan Yardımcısının, hâkimleri mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun

[23] Teftiş Kurulunun Adalet Bakanlığından alınıp, HSK içerisinde yapılanması olumlu bir adım olmakla birlikte, disiplin konusunda son karar merciinin Adalet Bakanı olması eleştiriye açıktır. Öte yandan HSK'nun meslekten çıkarma dışındaki disiplin cezalarına karşı yargı yolu da kapalıdır (Anayasa m. 159, X).

görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek ve Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmekle de görevli olan HSK Genel Kurulunda asıl üye olarak görev yapmasının mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri ile bağdaşmadığı kanısındayız.

Bunun dışında, hâkimlerin idarî bakımdan Adalet Bakanlığına bağlı bulunmasının da (Anayasa m. 149, IV; Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 5) hâkim bağımsızlığı ilkesine aykırı olduğu kanısındayız. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonunun "Türkiye Cumhuriyeti'nde Yargı Sisteminin İşleyişi" başlıklı istişarî ziyaret raporlarında da hâkimlerin idarî açıdan da olsa Adalet Bakanlığına bağlılıklarına son verilmesi gerektiğine haklı olarak işaret edilmektedir.

Hâkimlerin bağımsızlığı, onların gerek yürütme gerek yasama organına bağlı olmadıkları, bu organlardan bağımsız oldukları; bu organların hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği ve tavsiyelerde bulunamayacağı anlamına gelir. Buna göre, hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz (Anayasa m. 138, II)[24].

Bu kural, yargı yetkisinin kullanılması ile sınırlıdır. Çekişmesiz yargıda da hâkim, bir yargılama faaliyetinde bulunduğu için bu kural, çekişmesiz yargı için de geçerlidir. Buna karşılık, mahkemelerin, doğrudan doğruya hukukî uyuşmazlıkları çözme veya bireylerin hukukî durumları hakkında karar verme faaliyetleri dışında kalan, personelin yönetimi ve yazı işlerinin yürütülmesi gibi idarî işlem ve faaliyetlerinde, bu yasaklar ya da sınırlamalar geçerli değildir. Hâkim ve savcılar, bu tür idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olup, Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve savcılar üzerinde gözetim hakkını haizdir (Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 5, III-IV).

Mahkemeler, yasama organına karşı da korunmuştur. Buna göre, görülmekte olan bir dava hakkında TBMM'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz; görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz (Anayasa m. 138, III).

Ayrıca, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez (Anayasa m. 138, IV).

Hâkimlerin bağımsızlığını sağlayabilmek için, yasama ve yürütme organları yanında diğer mahkemelere karşı da korunmaları, yani onlardan da emir ve talimat almamaları gerekir. Ancak, yüksek mahkemelerin kararlarının belirli bir noktada ilk derece mahkemelerini bağlaması, hukuk sisteminin işle-

---

[24] Bir davanın taraflarından birinin veya birkaçının veya sanıkların veya davaya katılanların, mağdurların leh ve aleyhine, yargı görevi yapanlara emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne surette olursa olsun adı geçenleri hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir (TCK m. 277).

mesi açısından zorunlu görülmektedir. Bu durum, üst mahkemelerin ilk derece mahkemelerine talimat veya emir vermesi olarak nitelendirilemez. Tersine, üst mahkemelerin denetim görevi, bu tür bir yapılanmayı gerektirmekte ve yargı kararlarına bir noktadan sonra kesinlik kazandırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Burada istisna olabilecek husus, Yargıtay K. m. 45'te Yargıtay HGK, CGK ve BGK'a tanınan içtihatları birleştirme kararı verme yetkisine dayanarak verilen içtihadı birleştirme kararlarının tüm adlî yargı mahkemelerini bağlayıcı olmasıdır[25]. Ancak bu da, diğer mahkemelere talimat ve emir verme olarak nitelenmeyip, Yargıtay'ın ülkede hukuk birliğini sağlama işlevinin gereği olarak kabul edilir.

Hâkimlerin bağımsız karar verebilmeleri için yasama, yürütme ve yargı dışında kalan diğer etkenlere karşı da korunmaları gerekir. Bu nedenle, hâkimlerin kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamayacakları kabul edilmiştir (Anayasa m. 140, V). Bu düzenlemenin amacı, hâkimleri, etkilenmeleri muhtemel bu tür çevrelerden uzak tutmak, faaliyetlerini yargılama faaliyeti ile sınırlamaktır.

Bu sayılanlar dışında günümüzde dördüncü kuvvet olarak nitelenen basın ve ayrıca sosyal iletişim ağları da hâkimlerin bağımsızlığı bakımından dikkate alınmalıdır. Anayasanın 26. maddesinde, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla sınırlanabileceği öngörülmüş; ayrıca yargılamaların aleniyeti (m. 28) bakımından, basınla ilgili özel düzenlemeler yapılmıştır (bkz. Basın K. m. 19; ayrıca bkz. CMK m. 183; TCK m. 288).

Görüldüğü gibi, hâkim bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hâkimin her türlü etki, baskı veya yönlendirmeden uzak, yani bağımsız ve tarafsız olarak görev yapabilmesini ifade etmektedir. Bağımsızlık, bu sayılan güçlere karşı öngörülmüş olmakla birlikte, tarafsızlık, hâkimin davanın taraflarına eşit uzaklıkta ve objektif olmasını gerektirir.

Hâkimin tarafsızlığı da adil yargılanma hakkının bir unsurudur[26]. Hâkimin tarafsızlığı, objektif ve sübjektif tarafsızlık kavramlarıyla ifade edilmektedir. Hâkimin sübjektif tarafsızlığı, onun karar verirken kendi önyargı, kanaat, inanç, eğilim ve ideolojisinden arınmak suretiyle vicdanî kanaatini oluşturması ve bu doğrultuda hukuka uygun karar vermesini ifade eder. Objektif tarafsızlık ise, tarafların hâkimin tarafsız olduğuna inanmaları ve güvenmelerini ifade eden biçimsel bir kavramdır. Aşağıda ayrıca açıklanacağı gibi HMK, tarafsızlığı sağlamak üzere, hâkimin yasaklılığı ve reddi kurumlarını kabul etmiştir (m. 34 vd.).

2) Hâkimlik Teminatı

Mahkemelerin, dışarıdan gelecek her türlü etki, baskı veya yönlendirmelere kapalı olması, onların bağımsızlığı için zorunludur. Ancak hâkimlerin bağımsızlık tavrını sergileyebilmeleri, bazı güvencelere (teminatlara) sahip

---

[25] 5235 s. K. m. 35 uyarınca istinaf mahkemelerinin benzer uyuşmazlıklarda kesin olarak verdiği kararlar bakımından Yargıtay'ın ilgili dairesi tarafından verilen karar da kesindir.

[26] Bkz. aşa. § 5, A.

olmaları halinde gerçekleşir. Aksi halde hâkimlerden, bir anlamda "kahramanlık" yapmaları beklenmiş olur.

Yargı bağımsızlığı, yargı fonksiyonunu ifa eden hâkimlerin hiçbir baskı veya korkutma ile karşılaşmaksızın, görevlerini tam bir özgürlük ve tarafsızlıkla yerine getirebilmeleriyle gerçek bir anlam kazanır. Bu bakımdan Anayasada hâkimlik teminatına ilişkin temel bazı güvenceler kabul edilmiştir. Hâkimlerin bağımsızlığını tam olarak sağlayabilmek için, hâkimlere kişisel teminatlar tanınmalıdır ki, hâkim, her türlü maddî ve manevî kaygı ve etkilerden uzak olarak, görevini Anayasaya, kanunlara ve hukuk kurallarına uygun olarak vicdanî kanısına göre (Anayasa m. 138, I) yapabilsin[27].

Hâkimlik teminatı, hâkimlere tanınan bir ayrıcalık değildir. Hâkimlerin teminatı, adına yargı yetkisini kullandıkları millet için kabul edilmiş olup, hâkimlerin görevlerini tam bir güven ve tarafsızlık içinde yapabilmelerini sağlayan bir kurumdur. Burada söz konusu olan, hâkimin kişisel yararı değil, kamu yararıdır. Hâkimlik teminatının amacı, hâkimlerin kişisel nüfuz ve itibarlarının yükseltilmesi ve huzurlarının sağlanmasından çok, hâkimlerin serbest ve tarafsız olarak hüküm verebilmelerini sağlamak ve dolayısıyla halka, adaletin her türlü baskı ve etkiden uzak olarak dağıtıldığı hususunda güven vermektir.

Hâkimlik teminatının unsurları şu şekilde belirtilebilir:

Hâkimler azlolunamaz (Anayasa m. 139, I; Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 44);

Hâkimler istekleri dışında, 65 yaşından önce **emekliye sevkedilemezler** (Anayasa m. 139, I; 140, IV; Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 44).

Hâkimler, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, **aylık ve ödeneklerden** ve diğer özlük haklarından **yoksun kılınamazlar** (Anayasa m. 139, I; Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 44-45)[28].

Anayasaya göre, "**hâkimler idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar**" (Anayasa m. 140, VI) ve "Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkimler (ve savcılar) üzerinde gözetim hakkını haizdir" (Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 5, III-IV). Tekraren vurgulamak gerekirse, hâkimleri, idarî görevleri yönünden olsa bile Adalet Bakanlığına bağlı saymak, Anayasanın 138. maddesinde açık ifadesini bulan hâkimlerin bağımsızlığı ilkesine aykırıdır. Hâkimleri, idarî görevleri yönünden de HSK'na bağlamak, hâkimlerin bağımsızlığı ilkesine daha uygun bir çözüm şeklî olurdu.

Hâkimlerin, kendi istemleri olmasa bile görev yaptıkları yerden başka bir yere atanmaları mümkündür. Yani hâkimlerin **coğrafî** (yer) **teminatı** yoktur. Onun yerine, hâkimlerin (ve savcıların) HSK'nun hazırlayacağı Atama ve

---

27 "Hâkimlik ve savcılık teminatı hâkim ve savcıların görevlerinde herhangi bir düşünce ve fütura kapılmadan tamamen vicdan rahatlığı içerisinde görevlerini yapabilmelerinin garantisidir" (Anayasanın 139. maddesinin gerekçesinden).

28 "Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevlerini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarına uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır" (Anayasa m. 139, II).

Nakil Yönetmeliğine uygun olarak, aynı veya başka yerlerdeki eşit veya daha üst görevlere kazanılmış hak, aylık ve kadro dereceleriyle naklen atanacakları ilkesi kabul edilmiştir.

Ülkemiz bakımından hâkimlik teminatının en önemli unsurlarından birinin de, hâkimlere diğer kamu görevlilerinden farklı bir şekilde, yeterli **aylık ve ödenek** verilmesi olduğuna kuşku yoktur.

IV – HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ

1) Genel Olarak

Adil yargılanma hakkı, herkesin kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkını içerir (AİHS m. 6; Anayasa m. 36).

Mahkemelerin bağımsızlığı, daha çok yasama organı veya yürütme (siyasî otorite) ile ilgiliyken, tarafsızlık, daha çok hâkime yönelik içsel bir duruma işaret eder. Öte yandan, bağımsızlık, kurumsal olarak yargıyı kapsarken; tarafsızlık somut olay veya dava bakımından söz konusu olur. Dolayısıyla bağımsızlık, genel ve soyut olarak yargıyı ilgilendirirken, tarafsızlık, somut ve kişiseldir.

Hâkimin tarafsızlığı objektif ve sübjektif tarafsızlık kavramlarıyla ifade edilmektedir. Hâkimin sübjektif tarafsızlığı, onun karar verirken kendi önyargı, kanaat, inanç, eğilim ve ideolojisinden arınmak suretiyle vicdanî kanaatini oluşturması ve bu doğrultuda hukuka uygun karar vermesini ifade eder. Objektif tarafsızlık ise, tarafların hâkimin tarafsız olduğuna inanmaları ve güvenmelerini ifade eden biçimsel bir kavramdır.

Hâkimin objektif ve iki tarafa eşit uzaklıkta bulunması, yer alması ve buna göre karar vermesi gerekir; zira, hâkim, uyuşmazlığın tarafı değil, çözücüsü konumundadır. Ancak çeşitli nedenlerle hâkimlerin tarafsızlığını koruyamaması mümkündür. İşte kanun koyucu, hâkimin, mevcut dava veya iş bakımından tarafsız kalamayacağına kesin gözüyle baktığı (tarafsız kalamayacağını varsaydığı) hallerde, hâkimin o davaya bakmasını **yasaklamıştır.** Buna karşılık, önceden ve kesin olarak tespit edilememekle birlikte, hâkimin tarafsız kalamayabileceği (tarafsız kalamayacağı kuşkusu olan) hallerde de, hâkimin o davaya bakamayabileceği ve bu nedenle **reddedilebileceğini** öngörmüştür. Böylece iki temel düzenleme (kurum) ortaya çıkmıştır: "Hâkimin yasaklılığı ve hâkimin reddi" (m. 34, m. 36 vd.).

Bu iki kurum (düzenleme), birbirinden birçok bakımdan farklıdır. Her şeyden önce, yasaklılık sebepleri **sınırlı** iken; ret sebepleri **örnek** niteliğinde sayılmıştır. Yasaklı bir hâkimin davaya bakması, **her aşamada**, hatta hükmün kesinleşmesinden sonra dahi dikkate alınabilirken; hâkimin reddinin **ileri sürülebileceği** zaman sınırlıdır. Yine, hâkimin yasaklılığı sebepleri, üst ve yüksek **mahkeme tarafından denetlenir**ken; hâkimin reddi sebeplerinin var olup olmadığı ve hâkimin o davaya bakıp bakamayacağına, **bir başka hâkim** karar verir. Son olarak, yasaklı hâkimin yaptığı işlemler ve verdiği kararların akıbeti ile reddi istenen hâkimin işlem ve kararlarının sonuçları birbi-

rinden farklıdır. Ana hatları ile ortaya konabilecek bu farklılıklar da dikkate alınarak bu iki kurumun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilir.

Son olarak, aşağıda belirtilecek olan ve Kanunda yer alan yasaklılık ve ret hükümlerinde, her ne kadar "dava"dan söz edilmekteyse de, **çekişmesiz yargı** işleri de Anayasa bakımından yargı faaliyeti sayılmaktadır[29]. O nedenle, hâkimin tarafsızlığını sağlamaya dönük hükümlerin çekişmesiz yargıda da geçerli olacağından kuşku duyulmamalıdır. Zira kanun koyucu, çekişmesiz yargı işlerini, idarî işlerden saymamak suretiyle, ancak bu işlerin de güvenceli hâkimler tarafından yapılması konusunda özel bir tercihte bulunmuştur. O nedenle çekişmesiz yargı işleri de, bağımsız ve tarafsız hâkim önünde yürütülmelidir.

2) Hâkimin Yasaklılığı

a) Sebepler

Hâkimin yasaklı (memnu) olduğu durumlar Kanunda sınırlı (numerus clausus) olarak sayılmıştır (m. 34). Bu sebeplerin genişletilmesi mümkün değildir. Bu hallerin varlığı halinde, hâkimin tarafsız kalamayacağı kesin olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, "hâkim, aşağıdaki hâllerde davaya bakamaz; talep olmasa bile çekinmek zorundadır" şeklinde düzenleme yapılmıştır (m. 34).

Kanunda ilk olarak, hâkimin kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada hâkimlik yapamayacağı belirtilmektedir (m. 34, 1/a).

Hâkimin, tarafların dışında üçüncü bir kişi olması gerektiğinden, hiç kimsenin kendi davasında karar verici konumda olamaması nedeniyle, doğal olarak, bir hâkim, kendisine ait olan, yani davacısı veya davalısı olduğu bir davaya bakamaz. Yine örneğin, hâkimin bir sözleşmeden kaynaklanan, borcu olması söz konusu ise, bu borcun kefiline karşı açılan davaya bakamaz. Çünkü bu dava, dolaylı olarak kendisini ilgilendirir.

İkinci yasaklılık sebebi, aralarında **evlilik bağı kalksa bile** hâkimin, **eşinin** davasına bakamamasıdır (m. 34, 1/b). İlk durumdan farklı olarak, burada hâkimin bu davayla bir ilgisi yoktur; sadece önündeki davanın taraflarından birisi, hâkimin (eski veya halihazırdaki) eşidir. Buna karşılık, hâkimin eşini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren davalar buraya girmez.

Nişanlanmaya da hukukî sonuçlar bağlayan TMK hükümleri doğrultusunda kanun koyucu, hâkimin, **nişanlısının** taraf olduğu bir davaya bakamayacağını da öngörmüştür (m. 34, 1/e). Yalnız burada eşte olduğu gibi bir açıklık bulunmadığından, hâkimin, aralarında nişanlılık bağı kalkmış, yani eski nişanlısının taraf olduğu bir dava bakımından yasaklılık hali bulunmamaktadır. Ancak bu durum, hâkimin tarafsızlığından kuşku doğuracak önemli bir sebep olarak kabul edilebileceğinden, hâkimin reddi (m. 36) sebebi olabilir.

---

[29] Bkz. yuk. § 2, A.

Hâkimin belirli dereceye kadar hısımlarının davalarına da bakamayacağı, bunlardan da yasaklı olduğu ayrıca belirtilmiştir. Buna göre, hâkim, kendisi veya eşinin **altsoy** veya **üstsoyu**nun davasında; kendisi ile arasında **evlatlık bağı** bulunanın davasında, yani bu sayılan kişilerin o hâkim huzurundaki davalarda davalı veya davacı olmaları halinde, bu davalara da bakamaz (m. 34, 1/c-ç). Buna göre, örneğin hâkim, kendisinin veya eşinin çocuğunun, torununun ya da anne ve babasının taraf olduğu bir davada hâkimlik yapamaz. Yine, hâkimin evlat edinmesi veya hâkimin evlat edinilmesi halinde, bu kişilerin taraf olduğu davalara da bakamaz.

Hâkimin yasaklı olduğu bir başka yakınlık ise, belirli derecedeki kan veya kayın hısımlığıdır. Buna göre, hâkim, **üçüncü derece de dahil** olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında, davaya bakamayıp, yasaklıdır (m. 36, 1/d). Kan veya kayın hısımlığı ve dereceler, TMK'na göre tespit edilecektir (TMK m. 17-18). Örneğin hâkim, kendisinin veya eşinin amcası, dayısı, halası, teyzesi veya kardeşlerinin taraf olduğu davalarda hâkimlik yapamaz.

Burada, dikkati çeken bir husus, maddede, evlilik bağı kalkmış olsa dahi, hâkimin eşinin üçüncü dereceye kadar hısımlarının da davasına bakmaktan yasaklı olmasına rağmen; aynı maddenin (c) bendinde, altsoy ve üstsoy için bu şekilde düzenleme yapılmamış olmasıdır. Kanımızca burada amaca uygun yorum yapmak suretiyle, (c) bendi bakımından da aynı sonuca varılmalıdır. Zira, eski eşin daha uzak hısmı olan üçüncü derecedekiler için bile yasaklılık hükmü getiren Kanunun, hâkimin eski eşinin altsoy ve üstsoyu için yasaklılık öngörmemesi, bir çelişki olurdu[30].

Son olarak kanun koyucu, hâkimin, iki taraftan birinin **vekili, vasisi, kayyımı** veya **yasal danışmanı** sıfatıyla hareket ettiği davadan da yasaklı olduğunu ifade etmektedir (m. 34, 1/f). Örneğin, avukatlıktan hâkimliğe geçen hâkimin önüne, kendisinin vekil olduğu dava gelirse, bu davaya bakamaz.

Burada ayrıca, hâkimin yasaklılığı (ve reddi) hükümlerinde, yasaklılık sebeplerinin **hâkim ile taraflar arasında** olması gerektiğine değinmek gerekir. Dolayısıyla, hâkimle taraflardan birisinin vekili arasındaki ilişki (örneğin hâkimle taraflardan birisinin avukatı arasındaki akrabalık bağı), yasaklılık kapsamında değerlendirilmez. Ancak burada AK m. 13, özel bir düzenleme öngörmek suretiyle hâkim ile taraflardan birisinin vekili arasında ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) bir hısımlık varsa, avukatın o davaya kabul edilmeyeceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, hâkimle taraflardan birisinin vekili arasındaki bağ, hâkimin yasaklılığını gerektirmez; tersine avukatın o davaya vekâlet ehliyeti olmaz.

---

30 Madde gerekçesinde, hükmün HUMK'na oranla dilinin sadeleştirildiği, yasaklılık sebeplerinin ayrı ayrı bentlerde sayıldığı; kan ve kayın hısımları arasındaki derece farkının kaldırıldığı ve nişanlılığın da yasaklılık sebeplerine eklendiği ifade edilmiştir (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-HMK, m. 34 gerekçesi). HUMK m. 28, II'de tek bir bent halinde yer alan düzenlemenin, HMK'nda bentler arasında ayrım yapılması nedeniyle unutulduğu, kanun koyucunun, hâkimin eski eşinin altsoy veya üstsoyunun da davasına bakamayacağını öngörmek istediği sonucu, madde gerekçesiyle de desteklenebilir.

b) Yasaklılığın Tespiti ve İleri Sürülmesi

Hâkimin yasaklı olduğu bir davaya bakmaması ve o davadan **"çekinmesi"** gerekir (m. 34, 1). Taraflar da, böyle bir çekinme sebebinin varlığını öğrendikleri zaman, yargılamanın her aşamasında, bu hususu ileri sürebilirler. Bu durum, kamu düzenine ilişkin olduğu için, üst mahkemece de resen dikkate alınabileceği gibi, alt derece yargılamasında ileri sürülmemiş olsa bile, ilk defa kanun yolu aşamasında da bu husus dile getirilebilir. Yasaklı bir hâkimin davayı görmüş olması, ağır bir usul kuralı ihlali olduğu için, bu hüküm kesinleşmiş olsa bile, bu sebeple, verilen hükmün iptali, yani yargılamanın iadesi talep edilebilir (m. 375, 1/b; HUMK m. 445, 1/9).

Hâkim, kendiliğinden veya talep üzerine "çekinme" kararı verir. Bu bir nihaî karar olduğu için, bu karara karşı üst mahkemeye başvurulabilir ve hâkimin çekinme kararının yerinde olup olmadığı, üst mahkeme tarafından denetlenir (m. 35, 1). Çekinme kararı ilk derece mahkemesi hâkimi tarafından verilmişse, istinaf mahkemesinin vereceği karar kesindir (m. 35, 2).

Hâkimin çekinme talebini reddetmesi halinde, bu bir ara karar olduğu için, tek başına değil, ancak nihaî kararla birlikte kanun yoluna götürülebilir.

Hâkimin çekinmesini gerektiren sebep, davanın başında olmamakla birlikte dava sırasında doğabilir; işte bu halde de, hâkim derhal dosyadan el çekmelidir.

Üst mahkeme, yasaklı olduğunu tespit ettiği hâkimin o ana kadar yaptığı işlemleri iptal edebilir. Burada iptal edilecek işlemler mahkemenin usul işlemleri olup, taraf usul işlemleri geçerliliğini korur. Buna göre, örneğin, yasaklı hâkimin yaptığı keşfi, üst mahkeme iptal edebilir; buna karşılık, yasaklı bir hâkime sunulan dava veya cevap dilekçeleri geçerliliğini korur.

Yasaklı hâkim, çekinmemiş ve karar da vermişse, üst mahkeme, hüküm veya kararları mutlaka iptal eder. Bu durumda hâkim, yargılama giderlerine mahkûm edilebilir (m. 35, 1).

Görüldüğü gibi, sonuç olarak, burada bir hâkimin somut olay çerçevesinde bir davaya bakamaması söz konusudur. Üst mahkeme de, yapacağı inceleme sonucunda, yalnızca yasaklılık sebebinin mevcut olup olmadığına bakar. Ancak bu karar, o davaya hangi hâkimin bakacağı sorusunun cevabını vermemektedir. Bu konu, aşağıda yargı yeri belirlenmesi başlığı altında ele alınacaktır[31].

3) Hâkimin Reddi

a) Sebepler

Yasaklılık sebeplerinden birisinin varlığı halinde, Kanun, hâkimin tarafsız kalamayacağını varsaymaktadır. Buna karşılık, Kanun, hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde ise, taraflardan birisinin hâkimi reddedebileceği gibi hâkimin de bizzat çekilebileceğini öngörmektedir. Burada, bazı sebeplerden dolayı, hâkimin tarafsızlığından kuş-

[31] Bkz. aşa. § 11.

ku duyulmayı gerektirecek bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak, taraflar ve hâkim bakımından zorlayıcı bir durum bulunmayıp, taraflardan birisi veya hâkim, bizzat kendisi isterse, davadan çekilebilmektedir. Kanun, yasaklılık halinde hâkimin "**çekinmesi**"nden söz ederken; ret halinde, hâkimin "**çekilmesi**" kavramını kullanmaktadır.

Hâkimin yasaklılığının tersine, ret sebepleri sınırlı olarak sayılmamıştır. Nitekim Kanun, "özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir" demek (m. 36, 1) suretiyle bu hususu vurgulamaktadır.

Ret sebeplerinin başında, "**torba**" sebep olarak da nitelenebilecek olan, "**hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin varlığı**" gelmektedir. Hâkimin tarafsızlığından kuşku duymayı gerektiren olaylar, kişiden kişiye ve somut olayın özelliklerine göre değişebilir. Örneğin Yargıtay, bir kararında hâkimin hatalı ara kararı vermesini ret sebebi olarak kabul etmezken, bir başka kararında ret sebebi olarak değerlendirmiştir.

Esasen hâkimin hukukî değerlendirmesi ile tarafların yorumunun farklı olması, bir ret sebebi olmaz. Bu çerçevede örneğin, hâkimin, davanın açılmamış sayılması kararını vermemesi, tedbir talebini reddetmesi veya işine gerekli özen göstermemesi, onun tarafsızlığını kaybettiği anlamına gelmez.

Hâkimin tarafsızlığından kuşku duyulmasını gerektiren önemli bir sebebin bulunup bulunmadığı konusunda, Kanun, örnekleme yoluyla düzenleme yapmıştır.

Buna göre, ilk olarak, hâkimin, davada, iki taraftan birine **öğüt vermiş** ya da **yol göstermiş olması** ret sebebi olarak düzenlenmiştir (m. 36, 1/a). Hâkim, taraflara eşit uzaklıkta, objektif bir konumda bulunmalıdır. Hâkimin taraflardan birisine öğüt vermiş, yol göstermiş veya yönlendirmiş olması, onun tarafsızlığından kuşku duyulmasına sebep olabilir. Örneğin, hâkimin bir tarafa zamanaşımı defini hatırlatmış olması, ret sebebi oluşturur. Zira hâkim, tarafların söylemediği şeyi dikkate alamayacağı gibi, onları hatırlatması da yasaktır (m. 25, 1). Hâkimin önüne dava gelmeden önce de o dava ile ilgili yol göstermiş olması da, genel sebebe göre ret sebebi olabilir.

Hâkimin tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik etmesi (m. 137) bir zorunluluk olup, hâkimin bu konudaki tavrı, bir ret sebebi oluşturmaz. Ancak hâkimin tarafları sulhe teşvik çerçevesinde tarafsızlığını kaybetmesi halinde ise, elbette ret hükümleri uygulama alanı bulur.

İkinci bir ret sebebi ise, hâkimin, davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye **kanunen gerekmediği halde görüşünü açıklamış** olmasıdır. Hâkimler, görüşlerini, tüketilmesi gereken aşamalardan sonra, kararlarıyla açıklarlar. Çünkü, kararı oluşturan sürecin bir arka planı vardır; bunun için tahkikat aşaması ve delillerin değerlendirilmesi söz konusudur. Oysa hiç bunlar yapılmadan, herhangi bir zamanda veya yerde, hâkimin, o davaya ilişkin görüşünü açıklamış olması, onun objektif ve tarafsız olamayacağını gösterir; çünkü hâkim, ön yargısıyla veya yüzeysel bir değerlendirmeyle hareket etmiş, **"ihsas-ı rey"**de bulunmuş olur.

Hâkimin, görülmekte olan bir davanın olası sonucu hakkında görüş beyan etmesi, üçüncü kişiler karşısında bu davanın olası sonucundan söz etmesi, duruşma sırasında taraflardan birisine haksız veya haklı olduğunu söylemesi, bir sempozyum veya bilimsel toplantıda görülmekte olan davayı örnek vermesi ya da konu hakkında makale yazması halinde, tarafsızlığından kuşku duyulur. Bu durum, o davada karar verilinceye kadardır; karar verildikten sonra, karar henüz kesinleşmemiş olsa da, mahkeme kararı çeşitli değerlendirmelere konu olabilir.

İhtiyati tedbir talebini kabul veya reddeden hâkimin, ihsası reyde bulunduğu söylenemez. Öncelikle, ihtiyati tedbir konusunda hâkimin tutumu, esas davada vereceği kararın göstergesi değildir. Bunun yanında, nihaî kararından önce, geçici bir hukukî koruma olan ihtiyati tedbir hakkında karar vermeye kanun gereği görevli ve yetkilidir. Aynı şekilde ihtiyati haciz, adlî yardım veya delil tespiti talebini kabul veya reddeden hâkimin reddi istenemez. Çünkü tüm bu hallerde hâkim, kanunen gerektiği için karar vermiştir. Yine, kararı üst mahkeme tarafından kaldırılan veya bozulan bir hâkimin önüne dosyanın tekrar gelmesi halinde, hâkimin, görüşünü bildirdiği gerekçesiyle reddi mümkün değildir. Çünkü hâkim, burada da kanunen gerekli olduğu için bir karar vermiştir. Aynı şekilde, hâkimin direnme kararı vermesi de bir ret sebebi oluşturmaz.

Kanunda düzenlenen ret sebeplerinden üçüncüsü, hâkimin, **önündeki davada** (daha önce), **tanık** veya **bilirkişi olarak dinlenmiş** veya **hâkim** ya da **hakem sıfatıyla hareket etmiş olması**dır (m. 36, 1/c). Burada hâkimin, tanık, bilirkişi, hakem veya hâkim sıfatıyla hareket ettiği bir davanın, bu kez hâkimi olması ihtimali öngörülmüştür. Örneğin, daha önce hakemlik yaptığı dava ile ilgili iptal davası açılması ve hakemin bu sırada iptal davasına bakan hâkim olması (m. 439; 5235 s. K. m. 5) veya hâkim olarak karar verdikten sonra üst mahkemeye üye olan hâkimin, bu kez karar verdiği dosyayı kanun yolu mahkemesinin bir üyesi olarak incelemek durumunda kalması, bu fıkraya göre bir ret sebebi olur.

Dördüncü ret sebebi, davanın, **dördüncü derece de dahil** yansoy hısımlarına ait olmasıdır (m. 36, 1/ç). Buradaki ret sebebinde, yasaklılıktan farklı olarak, kan ve kayın hısımları arasında ayrım yapılmamıştır. Ancak burada da aynı şekilde yorum yapılıp, hem kan hem kayın hısımları bakımından ret sebebi bulunduğu kabul edilmelidir. Buna göre örneğin, hâkim, kendisinin veya eşinin kuzenlerinin davasına bakmayabilecektir. Dördüncü dereceden daha uzak hısımların davaları bakımından bir ret sebebi öngörülmemiştir. Ancak, burada genel ret sebebi olarak hâkimin tarafsızlığından kuşku duyulmasını (m. 36, 1) gerektiren bir durum varsa, hâkimin reddi mümkün olabilir.

Son olarak, Kanun, **hâkimin iki taraftan birisi ile davası** veya **aralarında bir düşmanlık bulunması** durumunu da bir ret sebebi olarak saymıştır. Zira, aralarında bir düşmanlık veya dava ilişkisi olması halinde, hâkimin objektifliğini koruyamayacağı, kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu sebebe dayanılabilmesi için, Yargıtay, ret sebebi olarak gösterilen davanın, hâkimin reddi-

nin istendiği davadan önce açılmış olması gerektiğine işaret etmektedir. Aksi halde, hâkimi reddetmek için uydurma davalar açılabilmesi tehlikesi vardır. Öte yandan yine Yargıtay, dava sırasında hâkimin şikâyet edilmesini de başlı başına ret sebebi olarak kabul etmemektedir.

Yasaklılık konusunda ifade edildiği üzere, ret sebeplerinin de hâkimle taraflardan birisi arasında olması gerekir. O nedenle hâkimle taraflardan birisinin vekili arasındaki dava veya düşmanlık, bir ret sebebi oluşturmaz.

b) Ret Usulü

Hâkimin reddini gerektiren bir sebep varsa, taraflardan birisi hâkimi reddedebilir. Aynı şekilde, hâkim de davadan bizzat çekilebilir. Hâkim, reddini gerektiren sebeplerden biri varken bizzat çekilmezse, iki taraftan biri ret talebinde bulununcaya kadar davaya bakabilir (m. 37).

aa) Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi

Hâkimin reddi, hem zaman bakımından hem de usul bakımından özel olarak düzenlenmiştir. Hâkimin reddi, ilk derece yargılaması sırasında, karar aşamasına kadar yapılabilir. Ancak hâkimin reddi sebebini bilen tarafın, ret talebini en geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekir. Tarafların hâkimi ret süresi, dilekçeler aşamasıyla ilişkilendirilmemiştir. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada, yeni bir işlem yapmadan önce bu talebini hemen bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret talebi dinlenmez (m. 38, 1).

Ret talebinin dilekçeyle yapılması şarttır (m. 38, 2). Hâkimi ret için avukatın bu hususta özel yetkisinin de bulunması gerekir (m. 74). Ret dilekçesinde ret talebinin dayandığı sebepler ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin dilekçeye eklenmesi gerekir (m. 38, 2). Ancak tarafın, dilekçesinde açıkça "ret" sözcüğünü kullanmamasına rağmen, hâkimi çekilmeye davet ettiğini bildirmesi de ret hükmündedir (m. 38, 8).

Hâkimin reddi dilekçesi, reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir; ret talebi geri alınamaz (m. 38, 3-4).

Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir; karşı taraf buna bir hafta içinde cevap verebilir. Bu süre geçtikten sonra ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri, dosya ile birlikte yazı işleri müdürü tarafından reddi istenen hâkime verilir. Hâkim, bir hafta içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin kanuna uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek, dosyayı hemen ret talebini inceleyecek olan mahkemeye (merciye, m. 40) gönderilmek üzere yazı işleri müdürüne verir (m. 38, 5; 39).

bb) Hâkimin Kendisinin Çekilmesi

Önüne gelen bir davada, hâkim de, Kanunda belirtilen sebepler veya başka sebeplerle tarafsız kalamayacağı kanısında ise kendi kendisini reddedebilir, yani davadan çekilebilir (m. 37). Kanunda, hâkimin taraflarca reddedilmesi usulü düzenlenmiş; buna karşılık, hâkimin kendisinin (bizzat) çekil-

mesi halinde izlenecek yol açıklanmamıştır. Ancak burada da, niteliğine uygun düştüğü ölçüde tarafların hâkimi reddi usulü uygulanır. Buna göre, hâkimin davadan çekilme isteği ve nedenlerini içeren kararı, yazı işleri müdürü tarafından taraflara tebliğ edilmeli; tarafların görüşüyle birlikte, dosya, çekilmenin yerinde olup olmadığı konusunda inceleme yapılmak üzere ilgili merciye verilmelidir (m. 38, 5'e kıyasen). Başka bir deyişle, hâkimin bir davada tarafsızlığını koruyamayacağı gerekçesiyle davadan çekilmesiyle, çekilme tamamlanmış olmaz. Çünkü, ret sebebinin geçerli ve kabul edilebilir olup olmadığının bir başka merci (hâkim) tarafından incelenip karara bağlanması gerekir (m. 39).

cc) Ret Sebeplerini İnceleyecek Merci

Ret sebeplerinin yerinde ve kabul edilebilir olup olmadığı, reddi istenen hâkim dışında başka bir hâkim tarafından incelenir.

Ancak **üç halde**, reddi istenen hâkimin kendisi de, **ret talebi hakkında ret kararı verme yetkisine sahiptir.** Buna göre; ret talebi süresinde yapılmamışsa; ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmemişse; ret talebinin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa; **reddi istenen hâkimin kendisi**, ret talebini reddeder (m. 41).

Burada gerçek anlamda bir ret sebebi incelemesi söz konusu değildir. Tersine, ret talebinin inandırıcı olmaması, ret sebebi gösterilmemesi, ret talebinin süresinden sonra yapılması ya da ret talebinin kötüniyetle yapıldığının düşünülmesi (kanısının varlığı) halinde, ret istemi, esastan incelenmeden reddedilir. Yani bu hallerde, reddi istenen hâkim, ret talebini merciye iletmez. İlk derece mahkemesinin veya istinaf mahkemesinin bu kararlarına karşı istinaf veya temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte başvurulabilir (m. 41, 3).

Ret talebi hakkında, reddi istenen hâkimin bizzat karar verip, ret başvurusunu reddettiği bu durum dışında, ilke, bir başka hâkimin ret sebeplerini incelemesidir. Buna göre, toplu mahkeme (örneğin, asliye ticaret mahkemesi) hâkimlerinden birisi reddedilmişse, ret istemi, reddi istenen hâkim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir. Reddedilen hâkimin katılmamasından dolayı mahkeme toplanamıyor ya da mahkeme tek hâkimden oluşuyor ise, ret talebi, o yerde asliye hukuk hâkimliği görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından incelenir. O yerde, asliye hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, asliye ceza hâkimi varsa onun tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesince incelenir. Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret talebi, o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir. O yerde, sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, bulunma sıralarına göre; o yerdeki sulh ceza hâkimi, asliye hukuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulunmaması hâlinde, en yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir (m. 40).

Ret talebini inceleyecek hâkime, uygulamada "**refik hâkim**" denilmektedir.

dd) Ret Sebeplerinin İncelenmesi ve Karar Verilmesi Usulü

Hâkimin reddi talebine ilişkin karar, ret sebebine ve merciin takdirine göre dosya üzerinden veya duruşma yapılarak verilebilir (m. 42, 1).

Ret sebeplerini incelemeye yetkili merci, ret sebebinin niteliğine göre, her türlü delili serbestçe değerlendirerek karar verir. Nitekim, "ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz" denilmek suretiyle (m. 38, 7), hâkimin herhangi bir kesin delille bağlı olmadığı vurgulanmıştır.

Öte yandan, burada tam ispat da aranmaz. Zira, "ret sebebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilir" biçimindeki hükümle (m. 38, 7), bu konuda karar verecek mahkemeye bir serbesti tanınmıştır. Böylece, ret sebebi tam ispat edilemese bile, ret sebebinin varlığının ihtimal dahilinde olması da yeterlidir.

Ret talebinin incelenmekte olduğu süre içinde, davanın seyri de önemlidir. Ret hakkında merci tarafından **karar verilinceye kadar, reddi istenen hâkim, o davaya bakamaz.**

Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan iş ve davalar bunun dışındadır. Örneğin, reddi istenen hâkim, merci bu konuda karar vermeden, ihtiyati tedbir talebi veya tedbir nafakası hakkında karar verebilir. Daha önce hakkındaki ret talebi mercice reddolunan hâkimin, aynı durum ve olaylara dayanarak yeniden reddedilmesi hâli, hâkimin davaya bakmasına engel oluşturmaz (m. 42, 2).

Ret talebinin merci tarafından kabul edilmemesi hâlinde, reddi istenen hâkim davaya bakmaya devam eder. Merci, ret talebinin kötüniyetle yapıldığına kanaat getirir ve esas yönünden reddederse, talepte bulunanların her biri hakkında disiplin para cezasına da hükmeder (m. 42, 3-4). Böylece hâkimin reddini isteyen tarafın kötüniyetli davranışı cezalandırılmış olmaktadır. Zira hâkim reddedildiğinde, o davaya bakılmamakta, gecikmeden taraflar zarar görmekte, usul ekonomisi ilkesi ihlal edilmiş olmaktadır.

Her iki taraf da, kendisi bakımından söz konusu olan bir ret sebebiyle hâkimi reddedebilir. Ancak bir hâkim, aynı davada aynı tarafça birden çok reddedilir ve bu reddin kötüniyetle yapıldığı anlaşılır ve aynı zamanda ret talebi reddedilirse, verilecek disiplin para cezası, en az önceki cezanın iki katıdır (m. 42, 5).

ee) Merci Kararına Karşı Kanun Yolları

Bu konuda birbiriyle çelişir görünen iki hüküm vardır. Bunlardan birisi, ret usulü başlığı altında, hem ret talebinin kabulü hem de reddi halinde geçerli olmak üzere, bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yollarına başvurulabileceğini düzenlemektedir (m. 38, 9). Bir başka kanun yolu hükmü ise, ret talebinin, bizzat reddi istenen hâkim tarafından reddedilmesi halinde, ancak nihaî kararla kanun yoluna başvurulmasıdır (m. 41, 3). Bunun dışında iki ayrı maddede kanun yolu düzenlemesi yapılmıştır (m. 43-44)[32]. Merci ka-

[32] Kanımızca m. 38, 9 ve 41, 3 ile m. 43-44 uyumsuzdur. Olması gereken hukuk bakımından m. 38, 9 hükmü Kanundan çıkarılmalıdır. Çünkü, Kanun esasen, hâkimin kendisinin merci-

rar verinceye kadar kural olarak reddi istenen hâkim herhangi bir karar veremediği için öncelikle, reddedilen hâkimin durumunun netliğe kavuşması gerekir. Esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde hâkimin reddi talebiyle ilgili merci kararları kesindir. Esas hüküm bakımından istinaf yolu açık bulunan dava ve işlerde ise ret talebi hakkındaki merci kararlarına karşı tefhim veya tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir; bu hâlde 347. madde hükmü uygulanmaz. Bölge adliye mahkemesinin bu hususiaki kararları kesindir (m. 43). O nedenle bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. İstinaf mahkemesi hâkimlerinden birisinin reddi hâlinde verilen kararlara karşı, esas hüküm bakımından temyiz yolu açıksa temyize başvurulabilir iken, esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı olan kararlara karşı ise temyize gidilebilir (m. 44).

ff) Ret Talebinin Kabulü

Ret talebinin merci tarafından kabulü ve bu kararın kesinleşmesi üzerine, ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren, reddedilen hâkimce yapılmış olan ve ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa ilişkin işlemler, davaya daha sonra bakacak olan hâkim tarafından iptal olunur (m. 43-44).

Burada yasaklı hâkimin işlemlerinin sonucundan iki bakımdan farklılık vardır. İlk olarak, reddedilen hâkimin tüm işlemleri değil, ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen ve esasa ilişkin işlemler iptal edilir. İkinci fark ise, bu işlemleri iptale yetkili merci açısındandır. Yasaklı hâkimin işlemleri kanun yolunda iptal edilmekteyken, reddedilen hâkimin işlemlerini, davaya daha sonra bakacak hâkim iptal eder.

V – HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU

1) Sorumluluk Sisteminin Genel Özellikleri

Yargılama görevi yapan ve kesin hüküm gücünde karar verme yetkisine sahip olan hâkimlerin, bu kararlarından ötürü herhangi bir sorumluluklarının bulunup bulunmayacağı önemli bir hukuk politikası sorunudur. Burada söz edilen sorumluluk, hâkimin tazminat sorumluluğu, yani hukukî sorumluluktur. Bunun dışında hâkimlerin cezaî ve disiplin sorumluluğu da bulunmaktadır.

Hâkimlerin bütün hatalı kararlarından ötürü sorumlu olmaları, onların serbestçe işlem yapıp vicdanî kanaatlerine göre karar vermesine engel olup, çekingen veya ürkek davranmalarına neden olabilir. Öte yandan, hâkimlerin hiçbir şekilde sorumlu tutulmamaları da, keyfiliğe yol açabilir.

---

ye göndermeden karara bağladığı ret istemleri hakkındaki kararların nihaî kararla istinaf veya temyiz yoluna gitmesini öngörmüş (m. 41, 3); buna karşılık mercinin incelediği ret istemleri bakımından ise böyle bir koşul aramamıştır (m. 43-44) Bu halde, zaten davaya kural olarak devam edilmediği için (m. 42, 2), bu sonuç doğaldır. Ne var ki, m. 38'de hiçbir ayrım yapılmadan, burada verilen kararların, ancak nihaî kararla kanun yoluna götürülebileceği hükmü tereddüt uyandırmaktadır. Zira m. 38'deki durumlar hem hâkimin kendisinin karar vereceği hem de mercinin karar vereceği durumlara ilişkin olabilir.

Türk hukukunda ortalama bir yol izlenmiş, hâkimlerin sorumlulukları belirli sebeplerle ve ikincil olarak kabul edilmiş; bu konuda Devlet doğrudan muhatap olarak alınmıştır.

Hâkimlerin sorumlulukları ile ilgili olarak çeşitli tarihlerde farklı düzenlemeler yapılmıştır. Medenî yargıda görev yapan hukuk hâkimleri için sorumluluk sebepleri ve diğer hususlar münhasıran HMK'nda yer almaktadır (m. 46 vd.) ve bu sistem ilk derece ve yüksek mahkeme hâkimleri için de geçerlidir. Ceza hâkimleri için ise farklı bir düzenleme söz konusudur[33].

Türk hukukunun sorumluluk konusunda tercih ettiği sistem, **sınırlı sebeplerle** ve **kasta yaklaşan kusur sorumluluğu**dur. Buna göre, hâkimler, HMK'nda sayılan sebeplerle sorumlu olacaklar; ancak, tazminat davası doğrudan doğruya kendilerine değil, Devlete karşı açılabilecektir. Hâkimlerin fiil ve kararlarından Devletin sorumluluğu, yalnızca HMK'nda sayılan sebepler ve durumlar için geçerli olup, hâkimlerin yargı yetkisinin kullanılması sırasında kişisel kusur veya haksız fiilleriyle verdikleri zararlardan ötürü ayrıca kişisel sorumlulukları mevcuttur[34]. Örneğin, hâkimin duruşma sırasında taraflardan birisine hakaret etmesi halinde, sorumluluk HMK m. 46 vd. hükümlerine tâbi değildir.

HMK, 1086 sayılı Kanunun 573-576. maddelerinde düzenlenen ve tazminat davasının doğrudan hâkime karşı açılmasını öngören esastan ayrılmıştır. Bunun gerekçesi olarak karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler gösterilmekte ve ayrıca şu hususlar dile getirilmektedir: "Böyle bir düzenleme ile hâkimlerin hukukî sorumluluğuna ilişkin durum, idarenin memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri eylem ve yaptıkları işlemlerden birinci derecede Devleti sorumlu tutan ve daha sonra da Devletin sorumlu kişiye rücu etmesini kabul eden, Anayasanın 129 uncu maddesinin beşinci fıkrası

---

33 1086 sayılı HUMK'nun hâkimin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri 6110 sayılı Kanunla değiştirilmiş, burada sorumluluk davasının hâkime değil, Devlete karşı açılabileceği kabul edilmiş; arkasından, aynı düzenlemeyi içeren HMK m. 46 vd. 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu arada 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'na, tazminat davaları ile ilgili bir hüküm eklenmiş ve hâkimlerin yargı yetkisi kullandığı sırada verdiği zararlarla ilgili olarak, kişisel kusur, haksız fiil veya başka bir sebepten de doğsa, tazminat davasının yalnızca Devlete karşı açılabileceği yolunda bir maddeye yer verilmiştir (6110 s. K. m. 12 ile eklenen 93/A maddesi). Bu düzenleme, hukuk ve ceza hâkimi ayrımı olmaksızın bütün hâkimler için geçerli idi. Ancak söz konusu madde, 6526 sayılı Kanunun 19. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonra, 6545 sayılı Kanunla CMK'nun 141. maddesinde, ceza hâkimleri ve cumhuriyet savcılarının "koruma tedbirleri nedeniyle tazminat" sorumluluğu ayrıca yeniden düzenlemiştir: Buna göre, "Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir" (CMK m. 141, 3). Burada sorumluluk genişletilmiş ve davanın açılacağı mahkeme, "zarara uğrayan kişinin oturduğu yer ağır ceza mahkemesi; eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu istemle ilişkili ise aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yerdeki ağır ceza mahkemesidir" (CMK m. 142, 3) biçiminde düzenlenmiştir.

34 Hâkimlerin yargı yetkisinin kullanılması sırasında kişisel kusur veya haksız fiilleriyle verdikleri zararların tazmini bakımından da Devlete karşı dava açılmasını öngören 2802 s. K. m. 93/A hükmünün 6526 sayılı Kanunun 19. maddesiyle kaldırılması isabetli olmuştur.

hükmüne de uygundur"[35]. Kanımızca, hâkimler, bir kamu hizmeti yapmakla birlikte, idarenin memuru değildir. Kaldı ki, dayanak olarak belirtilen madde, Anayasanın "yürütme" kısmında düzenlenmiştir[36].

2) Sorumluluk Sebepleri

Sorumluluk, **hâkimlerin yargısal faaliyetleriyle ilgili olan** karar ve işlemlerinden kaynaklanır. Ancak, hâkimlerin, yanlış olan her türlü karar veya işlemleri değil, yalnızca Kanunda sayılan türdekiler bakımından sorumluluk doğar. Bu sebepler, **sınırlı sayıda olup genişletilemez.** Ayrıca hâkimin kararının usule veya esasa ilişkin olması da, sorumluluk bakımından önem taşımaz.

Buna göre, aşağıdaki sebeplere dayanılarak, hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir:

İlk olarak, **kayırma** veya **taraf tutma** yahut taraflardan birine olan **kin** veya **düşmanlık** sebebiyle **hukuka aykırı bir hüküm veya karar** verilmiş olması, bir sorumluluk hali olarak öngörülmüştür (m. 46, 1/,a). Bu sebeple sorumluluk doğabilmesi için, hâkimin hukuka aykırı bir karar vermiş olması, ancak bunun taraflardan birisine duyduğu yakınlık, sempati, antipati veya kin ya da düşmanlık gibi bir kişisel (sübjektif) duyguya dayanması gerekir. Hâkim, yargılamanın her aşamasında tarafsız görünümünü korumalı, buna özen göstermelidir. Hâkim, yargı kararını, inanç ve duygularının aracı olarak kullanamaz. Çünkü hâkim, hukuka uygun olarak vicdanî kanaat oluşturmak zorundadırlar. Hâkimin tarafsızlığını kaybettiğini gösteren işaretlerin varlığı halinde, ayrıca karar da hukuka aykırı ise sorumluluk doğar.

İkinci bir sorumluluk sebebi, **kanuna aykırı bir hüküm** veya karar verilmiş olması ve bunun, **sağlanan** veya **vaat edilen bir menfaat** sebebiyle yapılmış olmasıdır (m. 46, 1/ b). Burada özellikle belirtilmelidir ki, hâkimin kanuna aykırı karar vermiş olması, sorumluluk için yeterli değildir; hâkimlerin hukuka (kanuna) aykırı her kararı sorumluluk yaratmaz. Bu anlamda örneğin, ilk derece mahkemesi hâkiminin kararının üst mahkeme tarafından bozulması veya iptali tek başına, sorumluluk doğurmaz. Zira hâkimler, farklı yorum veya takdir hakkı nedeniyle değişik kararlar verebilirler. Sorumluluk için burada aranan koşul, bu kanuna aykırılığın, sağlanan veya vaat edilen bir menfaat karşılığında yapılmış olmasıdır[37]. Menfaatin maddî veya manevi, küçük veya büyük olmasının bir önemi yoktur.

Sorumluluk doğurabilecek üçüncü durum, hâkimin **farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı** karar veya hüküm vermiş olmasıdır (m. 46, 1/c). Yukarıda da ifade edildiği üzere, kanunların hâkime takdir yetkisi tanıdığı hallerde, somut olay çerçevesinde tak-

---

35 Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-HMK, m. 46 vd.da yer alan madde gerekçesi.

36 Anayasa Mahkemesi, bu davanın, hâkime karşı değil de, Devlete karşı açılması hükmünün Anayasaya aykırı olmadığına; hükmün, hâkim ve savcıların Anayasada belirtilen bağımsızlık ve tarafsızlığını güvenceye almaya yönelik olduğuna karar vermiştir. Karar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 125-126.

37 Hâkime bir menfaat sağlanması, aynı zamanda TCK anlamında suç oluşturur. Ancak bu husus, sorumluluk davasının açılmasının koşulu değildir (m. 46, 2).

dir yetkisi farklı kullanılabilir. O nedenle bir kanun hükmünün farklı yorumu, sorumluluk doğurmaz. Örneğin, m. 107 uyarınca, "davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukukî ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir". Yeni bir dava türü olarak hukukumuza giren belirsiz alacak davasının hangi hallerde açılabileceği, yorum gerektirmektedir. O nedenle belirsiz alacak davası açılamayacağı halde, davayı kabul eden hâkim veya tam tersi karar veren hâkim için sorumluluk doğduğu söylenemez.

Buna karşılık, hâkimin ihtiyati haciz kararı verebilmesi için, alacağın vadesinin gelmiş olması ve alacağın rehinle temin edilmemiş olması gerekir (İİK m. 257). Hâkimin alacağı karşılamaya yeterli ipotek bulunduğu halde alacaklının ihtiyati haciz kararı vermesi halinde, açık ve yoruma elverişli olmayan bir kanun hükmü ihlâl edilmiş olur.

Hâkimin sorumluluğu konusunda bir başka sebep, **duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm** verilmiş olmasıdır (m. 46, 1/ç). Yargılama sırasında, yazılı veya sözlü işlemler yapılır ve sözlü yapılan tüm işlemlerin tutanağa geçirilmesi gerekir (m. 154). Bu tutanaklar, yargılamanın seyri ve ispatı bakımından tek araçtır (m. 156). Hâkimin kararı da, dosya ve tutanaklar çerçevesinde olmalıdır. Tutanağa geçmeyen, tahkikatta tartışma ve inceleme konusu olmayan bir husus, kararın dayanağı olamaz. Çünkü kararın gerekçesinin dosyadaki dilekçe, belge ve tutanaklara dayanması gerekir. Hâkimin duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayalı karar vermiş olması, onun keyfî davranışı olarak sorumluluk doğurur.

Tutanaklarla ilgili diğer bir sebep ise, duruşmada tutanak tutulmuş olmasına rağmen, bu tutanaklarda tahrifat yapılmasıdır. Buna göre, **duruşma tutanakları** ile **hüküm** veya **kararların değiştirilmiş** yahut **tahrif edilmiş** veya **söylenmeyen bir sözün hüküm** ya da **karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş** ve buna dayanılarak hüküm verilmiş olması, sorumluluk doğurur (m. 46, 1/d)[38].

Dava açılması üzerine ortaya çıkan sonuçlardan birisi, hâkimin davayı inceleme ve bir karar verme zorunluluğudur. Hâkim, usulden reddedilecek bir dava olsa dahi, karar vermek zorundadır. Hâkimin aslî görevi olan hukukî himayeyi sağlama konusunda gösterdiği isteksizlik, **hakkın yerine getirilmesinden kaçınma** (ihkak-ı haktan istinkaf) biçiminde olursa; yani kişi, hukukî himayeye kavuşamıyorsa burada da bir sorumluluk hali doğar. Burada, hâkimin davayı sürüncemede bırakması söz konusudur. Ancak, davanın hâkimin elinde olmayan sebeplerle uzamış olması bu çerçevede değerlendirilemez. Burada, koşulları varsa, adil (makul sürede) yargılanma hakkının ihlâl edildiği ileri sürülebilir (m. 30). Sorumluluk doğabilmesi için, davanın uzaması ye-

[38] Hâkimin böyle bir tahrifat yaptığı iddiası, aynı zamanda TCK anlamında resmî evrakta sahtecilik suçunu oluşturur. Ancak bu husus, sorumluluk davasının açılmasının koşulu değildir (m. 46, 2).

terli olmayıp, hâkimin davayı yürütmeye yönelik usulî veya esasa ilişkin işlemler yapmaması veya karar vermemesi gerekir[39].

Görüldüğü gibi, hâkimin sorumluluğu bakımından söz konusu olan sebepler, çoğunlukla "**ağır kusur**"a veya çok özel durumlara dayanmaktadır.

3) Tazminat Davası Açılması

Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisinin varlığı halinde, tazminat davasının açılması, hâkime karşı bir ceza soruşturmasının yapılması yahut mahkûmiyet şartına bağlı değildir (m. 46, 2). O halde, tazminat davası açılabilmesi için hâkimin, iddia konusu fiilden ceza alması veya bir soruşturmaya muhatap olması gerekmez. Hatta, tazminat davasını gören mahkeme, böyle bir ceza davasını bekletici sorun da yapamaz (m. 165).

Yukarıda da belirtildiği üzere, tazminat davası, ilgili hâkime değil, Devlete karşı açılır (m. 46, 1).

Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin işlem, fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili (yani hâkimin karara bağladığı davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli) hukuk dairesinde; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların işlem, fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülür. Dava, bu dairenin Başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise, yargılama Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinde yapılır. Verilen kararların temyiz incelemesi, Hukuk Genel Kurulunca yapılır. Temyiz incelemesine, kararı veren başkan ile üyeler katılamaz (m. 47, 1)[40].

Davacı, dava dilekçesinde, hangi sorumluluk sebebine dayanıldığı ve delillerini açıkça belirtir, varsa belgeleri de ekler (m. 48, 1).

Davacının davada gerekli hukukî yollara, örneğin, karara karşı kanun yollarına başvurmaması, hâkimin sorumluluğu davasını açmasına engel teşkil etmez; ancak bu husus tazminatın tayininde rol oynayabilir.

Tazminat davasından feragat (m. 307 vd.) edilemeyeceği kabul edilmektedir. Buna göre, davacı davadan feragat etse bile davaya devam edilir. Bu durum, tasarruf ilkesinin (m. 24) bir istisnası ise de, burada kamu yararının varlığı kabul edilmektedir. Ayrıca tazminat davası açacak vekilin, vekâletnamesinde bu konuya ilişkin özel yetkisinin de bulunması gerekir (m. 74).

Bu davanın tarafları, ilgili hâkimin kararından zarar gören davacı; davalı da Devlet (maliye hazinesi) olmakla birlikte, burada kanun koyucu özel bir düzenleme yapmak suretiyle, Devletin bu davayı, ilgili hâkime resen ihbar etmesini istemektedir (m. 48, 2). İleride görüleceği üzere[41], bir davanın sonucunda, taraflardan birisinin üçüncü kişiye rücu etmesi veya kendisine rücu

---

39 Hakkın yerine getirilmesinden kaçınma aynı zamanda bir suçtur (TCK m. 257). Ancak bu husus, sorumluluk davasının açılmasının koşulu değildir (m. 46, 2).

40 Daha önce Yargıtay ilgili hukuk dairesi ve HGK'nda ilk derece mahkemesi sıfatıyla davanın görülüp temyiz incelemesinin Büyük Genel Kurulda yapılmasını öngören HMK m. 47, 1 düzenlemesi 6644 sayılı Kanunla yukarıdaki şekilde değişmiştir.

41 Bkz. aşa. § 40.

edilmesi olasılığı varsa, bu kişiyi davadan haberdar etmesi, yani davayı ona bildirmesi gerekir (m. 61). Kendisine dava ihbar edilen kişinin de, bu davaya fer'î müdahil olarak katılması beklenir (m. 66). Taraf yardımcısı gibi bir konumu olan fer'î müdahil, lehine katıldığı tarafın davayı kazanması için ona yardım eder. İhbar kurumu, taraflardan birisinin talebi üzerine işlerlik kazanır. Ancak burada Kanun, istisnaî bir hükümle hâkimin davayı resen ilgili hâkime ihbar etmesini düzenlemiştir.

Devlet, bu dava sonucunda mahkûm olur ve ödeme yaparsa, ödediği tazminat nedeniyle, sorumlu hâkime, ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder. Devletin sorumlu hâkime karşı açacağı rücu davası, tazminat davasını karara bağlamış olan mahkemede görülür (m. 47, 2).

Bu dava, haksız fiile dayalı bir tazminat davasıdır. Davanın kabul edilebilmesi için, haksız fiile dayalı diğer davalarda olduğu gibi, hâkimin Kanunda sayılı sebeplerden kaynaklanan fiili, işlemi veya kaçınma durumu bulunmalı, hâkim kusurlu olmalı, fiil ile sonuç (karar) arasında uygun nedensellik bağı bulunmalı ve son olarak davacı bir zarar görmüş olmalıdır (TBK m. 49 vd.). Ortaya çıkan zararın, maddî olabileceği gibi manevi de olabileceği kanısındayız.

HMK, açılacak tazminat davasının zamanaşımını göstermemiştir. Bu dava, niteliği itibariyle haksız fiile dayalı tazminat davası olması sebebiyle, burada TBK m. 72 hükmü kıyasen uygulanır. Ancak burada zarar, mahkeme kararının kesinleşmesiyle ortaya çıkacağından, davanın, (kesinleşmeden sonra) ortaya çıkan zararın öğrenilmesinden ve her halde kesinleşmeden itibaren on yıl içinde açılması gerektiği kanısındayız (karş. CMK m. 142, 1).

Dava esastan reddedilirse, davacı, disiplin para cezasına mahkûm edilir (m. 49). Buna karşılık, davanın usulî sebeplerden reddedilmesi halinde (örneğin dava şartları gibi), bu cezaya hükmedilmez.

C) CUMHURİYET SAVCISI[42]

Mahkeme kurulmuş bulunan her il merkezi ve ilçede, o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet **başsavcısı** ve yeteri kadar Cumhuriyet **savcısı** bulunur.

Cumhuriyet başsavcılığının; **kamu davasının** açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak; yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak; kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesiyle ilgili işlemleri yapmak ve izlemek gibi görevleri vardır. Cumhuriyet savcısı ise, adlî göreve ilişkin işlemleri yapar, duruşmalara katılır ve kanun yollarına başvurur; Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirir; gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet eder ve Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar. Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi

---

[42] Bkz. Ejder Yılmaz, Savcıların Hukuk Davalarındaki Görevleri (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 1972/XXIX/1-2, s.255-288; Yılmaz, Makaleler C. 1, s. 21-50); Mustafa Saldırım, Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri, Ankara 2005.

veya ilçenin idarî sınırları ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler (5235 s. K. m. 16-21). Cumhuriyet savcılarının asıl görevi, ceza muhakemesi alanındadır. Ancak istisnaen hukuk davalarında da savcıya bir kısım görevler verilmiştir.

Türk hukukunda kabul gören şeklî taraf kuramı gereği, herkes, davacı olarak "taraf" konumunda bulunabilir. Başka bir ifadeyle, bir dava dilekçesinde kendisini davacı olarak gösterip dava açan kimsenin, gerçekten o dava konusu üzerinde bir hak ve yetkisinin bulunup bulunmadığına bakılmaz. Ancak o davada esas hakkında bir karar verilebilmesi için, davacının dava konusuyla bir ilgisinin bulunması gerekir. Bu ilgi, "sıfat" olarak nitelenir. Medenî usul hukukunda, hak ve dava hakkı birbirine bağlı olduğu için, kural olarak, ancak hak sahibi, davacı sıfatına sahiptir. Ancak bu kuralın önemli istisnalarından birisi, Cumhuriyet savcısının hukuk davası açması veya açılan davada taraf olarak yer alabilmesidir (m. 70).

Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların söz konusu olduğu usul hukukunda, kamu düzeni düşüncesi, bazı hallerde dava açılmasını hak sahibinin inisiyatifine bırakmayı tercih etmemiştir. Tersine bu durumda, ilgilisi dava açmasa dahi, aslında dava konusu üzerinde hak sahibi olmayan bir kişi, yani Cumhuriyet savcısı, kamu yararı için dava açabilmektedir.

Cumhuriyet savcısının dava açabilmesi veya mahkemeden talepte bulunabilmesi, kanunlarda bu konuda açık bir düzenleme bulunmasına bağlıdır. Nitekim, örneğin savcılar, derneklerin feshi davası (TMK m. 89), evlenmenin reddine ilişkin dava (TMK m. 138), evlenmenin butlanı davası (TMK m. 146), soybağının kurulmasına itiraz (TMK m. 294), tanımaya itiraz (TMK m. 298), yaş, ad, soyadı ve diğer (nüfus) kayıt düzeltme (Nüfus Hizmetleri K. m. 36) taleplerini ileri sürebilir, dava açabilirler. Savcılar, bazı hallerde sendikaların faaliyetten men edilmesini iş mahkemesinden isteyebilirler (Sendikalar K. m. 58,I).

Cumhuriyet savcısı, açılmış davada da yer alabilir (m. 70, 1). Savcının bu davadaki konumu, **"taraf"** olmak biçimindedir[43]. Zira Kanun, açıkça bunu ifade etmiş olup, bu konuda fer'î müdahale hükümlerine bir atıf yapılmamıştır.

Cumhuriyet savcısı, kanunda öngörülen hukuk davalarını kendiliğinden açabileceği gibi, resmi bir dairenin veya kurumun bildirimi üzerine de açabilir. Örneğin, nüfus müdürlüğü, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvuramamakla birlikte, savcının başvurması için bildirimde bulunabilir (Nüfus Hizmetleri K. m. 36). Cumhuriyet savcısı, resmî dairenin bildirimine rağmen dava açmaz ise, ihbar eden resmî daire, Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza merkezine en yakın kıdemli asliye hukuk mahkemesi hâkimine itiraz edebilir. Bu hususta CMK 172. ve 173. maddeleri kıyasen uygulanır.

---

[43] HUMK'nda savcıların açılmış hukuk davasına fer'î müdahil olarak katılabileceği kabul edilmekteyken (HUMK m. 58), HMK, savcının müdahil değil, bizzat "taraf" olmasını öngörmüştür.

Cumhuriyet savcısının yer aldığı veya açtığı dava ve işler üzerinde taraflar serbestçe tasarruf edemezler (m. 70, 3). Bu davalar kamu düzeninden olup, hâkim resen araştırma ilkesi[44] uyarınca inceleme yapar.

Cumhuriyet savcısının hukuk davalarındaki bir başka görevi, kanun yolları konusundadır. Tarafların kanun yoluna götürmediği bir kararın üst mahkeme incelemesine tâbi tutulması söz konusu olmaz. Ancak istisnai, olarak HMK m. 363 (HUMK m. 427, VI) gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kararı, kanun yararına temyiz eder[45].

Bu söylenenler dışında, hukuk davalarında savcı yer almamaktadır. Çünkü, özel hukuk uyuşmazlıkları gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle olan eşit düzeydeki ilişkilerini ilgilendirir.

D) YAZI İŞLERİ PERSONELİ (GÖREVLİLERİ)

Kolektif bir faaliyet olan yargılamanın nitelikli, düzgün ve usul ekonomisine (m. 30) uygun işlemesi için, yazı işleri personeli de çok önemlidir. Yardımcı meslek personeli, adlî personel veya yargı çalışanı denilen bu meslek grubu, yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi ve mübaşir ile diğer görevlilerden oluşur. Yazı işleri hizmetleri, ilgisine göre mahkeme hâkiminin denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ve onun yönetiminde, zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür.

I – YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Yazı işleri müdürü, mahkeme kaleminin (yazı işleri bürosunun) başıdır ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Yazı işleri müdürü, bu görevini, bağlı olduğu hâkimin gözetimi altında sürdürür.

Yazı işleri müdürüne verilen çeşitli görevler Kanunda sayılmıştır (m. 38, 5; 158, 1; 159; 216, 4; 301; 372, 1; 393, 2; 445, 3).

Yazı İşleri Yönetmeliği (Y), "yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi" başlığı altında, yazı işleri personelinin görevlerini ayrıca saymıştır. Buna göre, yazı işleri müdürünün aslî görevi, mahkeme yazı işlerini denetlemektir. Bunun dışında, talep halinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak; harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak; zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak; dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek; yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek; hukukî başvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli işlemleri yapmak ya da yaptırmak; bilirkişilere fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek; harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak; dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak; yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek; arşivin düzenli tutulmasını sağlamak; teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirmek ve mevzuattan kaynaklanan veya hâkim tara-

---

44 Bkz. aşa. § 5, E.

45 Bkz. aşa. § 57; § 59, H.

fından verilen diğer görevleri yerine getirmek gibi görevleri bulunmaktadır (Y m. 169, 3/a-k). Yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yazı işlerinde görevli personele devredemez (Y m. 169, 7).

II – ZABIT KÂTİBİ

Yargılamanın resmî tanığı konumunda olan görevli kişi (süje), zabıt kâtibidir. Zabıt kâtibi, yargılamanın aktif ve çok önemli bir parçasıdır. Nitekim Kanun, hem duruşmada yapılan işlemlerin tutanağa bağlanmasında hem de duruşma dışında hâkim huzurunda gerçekleşen keşif gibi işlemlerde zabıt kâtibi bulunmasını şart koşmaktadır (m. 157).

Duruşmalarda alınan taraf veya tanık beyanları başta olmak üzere, ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri ancak tutanakla ispat olunur (m. 156). Tüm bu tutanakların zabıt kâtibi tarafından tutulması ve altının da onun tarafından imzalanması gerekir. Öte yandan zabıt kâtibi, hâkim gibi, gerekçeli kararı da imzalar (m. 297, 1/d).

Görüldüğü gibi zabıt kâtibi, hâkimin yanında, mahkeme salonunda veya dışında son derece önemli bir görev yapmaktadır. Zabıt kâtibinin görevleri de, Y m. 169'da sayılmıştır.

Yukarıda belirtilen temel görevleri dışında zabıt kâtibi, ara kararları yerine getirmek; gerekçeli kararları hâkimin bildirdiği şekilde yazmak; yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek; tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak; tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek; karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak; cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak; dizi pusulası düzenlemek; mevzuattan kaynaklanan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek gibi görevlere sahiptir (Y m. 169, 4/a-h)

Zabıt kâtibinin bu önemli görevleri, onlar bakımından özel bir yükümlülük de getirmektedir. Buna göre zabıt kâtipleri, hâkimin yasaklılığı ve reddi sebeplerine dayanarak reddedilebilir (m. 45)[46]. Kanun, her ne kadar yasaklılık sebeplerinin varlığı halinde, "zabıt kâtibi 34 üncü maddedeki sebepleri bildirerek görevden çekinebilir" demekte ise de, burada isteğe bağlı bir durum olmayıp, zabıt kâtibi çekinmek zorundadır.

Zabıt kâtibi hakkındaki ret talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkeme tarafından karara bağlanır. Bu konuda verilecek kararlar kesindir (m. 45, 2). Burada zabıt kâtibinin reddini gerektirecek bir sebebin olup olmadığı, bir başka mahkeme tarafından değil, zabıt kâtibinin bağlı olduğu mahkeme hâkimi tarafından karara bağlanır. Aynı husus, hâkimin yasaklılığında da geçerlidir. Ancak, zabıt kâtibinin, aynı işte hâkim ile birlikte reddi veya çekinmesinin istenmesi halinde, hâkim hakkında ret veya çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında karar verir (m. 45, 3).

---

[46] Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Zabıt Kâtiplerinin Reddi (Prof. Dr. Bilge Umar'a Armağan, İzmir 2010, C. 1, s. 595-615).

III – MÜBAŞİR VE HİZMETLİ

Mübaşir de yargılamada önemli görevlere sahip bir süjedir. **Mübaşirin görevleri** şunlardır (Y m. 169, 5/a-j): Kâtip tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere duruşma gününden önce hâkime götürmek; günlük duruşma listesini yapmak ve görülebilecek bir yere asmak; duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek; duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak; yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak; müzekkereler ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek; duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak; hâkimin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı olmak; ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek; arşive gitmesi gereken dosyalar ile arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak; fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak; hâkimin ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Hizmetlinin görevleri ise şunlardır (Y m. 169, 6/a-c): Mahkemeye ait alanları tertipli, düzenli ve temiz halde tutmak; mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı olmak; hâkimin ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

E) AVUKAT[47]

I – GENEL OLARAK[48]

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder (AK m. 1).

Avukatlık, kamu hizmeti olmakla birlikte, serbest bir meslektir.

Avukatlığın amacı; hukukî ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukukî sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla, hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu

---

47 Bkz. Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Hukuku, İzmir 2006; Semih Güner, Avukatlık Hukuku, Ankara 2015; Ejder Yılmaz, Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995/44/1-4, s.193-208; Yılmaz Makaleler C. 1, s. 863-876); Ejder Yılmaz, Avrupa Birliği ile Bütünleşmede Avukatlık Mesleği (Avukatlık Mesleği; Sorunlar-Çözüm Perspektifleri, İstanbul 1996, s.331-346; Yılmaz Makaleler C. 1, s. 787-802); Ejder Yılmaz, Çağdaş Dünyada ve Türkiye'de Avukatlık (Hukuk Merceği, Konferans ve Paneller, Ankara 2000, s.347-381); Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2013.

48 Ancak günümüzde avukatlar avukat ortaklığı biçiminde veya bir başka avukat yanında çalışma şeklinde mesleklerini yerine getirmektedirler. Bkz. Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (RG 26.12.2015, sa. 29574).

kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir (AK m. 2).

Avukatlık mesleği, Avukatlık Kanunu (AK) ile düzenlenmiştir. AK'nun bazı maddeleri, zaman içerisinde çeşitli kanunlarla değiştirilmiş veya kaldırılmıştır.

Ayrıca, AK m. 182 gereğince hazırlanmış Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği vardır[49]. AK m. 110/16 gereğince belirlenmiş Meslek Kuralları da yayımlanmıştır[50].

II – AVUKATLIK MESLEĞİNE GİRİŞ

Avukatlık mesleğine kabul şartları, AK m. 3'te yazılıdır. Bunlardan en önemlileri, adayın hukuk fakültesi mezunu olması ve avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmasıdır. Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, Türk hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak gerekir.

Avukatlık stajı bir yıldır (AK m. 15).

Ülkemizde çok sayıda hukuk fakültesi bulunması ve artan mezun sayısı, avukatlık mesleğine girişte de bir sınav getirilmesi tartışmalarını uzun zamandır gündemde tutmaktadır. Son olarak 2001 yılında 4667 sayılı Kanunla avukatlık mesleği bakımından sınav öngörülmüş, ancak hükmün beş yıl sonra uygulanması kabul edilmişti. Sınavın uygulanacağı zaman, 2006 yılında çıkarılan 5558 sayılı Kanunla, sınav öngören geçici madde kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi ise, söz konusu hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesinde hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulunun "bağımsız yargı", yargının olmazsa olmaz koşulunun da "savunma" ile birlikte anlam kazandığını; savunmanın, "sav-savunma-karar" üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez öğesi olduğunu; adaletli bir yargılamanın varlığının ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabileceğini; avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınmasının hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereği olduğunu ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi, ayrıca, güçlü ve bağımsız savunma mesleğinin, hukukun üstünlüğünün, hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın güvencesi olduğunu; bu değerlerin de, mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla teminat altına alınacağına işaret etmiştir[51].

---

[49] Bkz. RG 19.06.2002 sa. 24790; RG 06.09.2008, sa. 26989; RG 27.06.2009, sa. 27271.

[50] Bkz. TBBBD 1971, S. 5. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Faruk Erem, Meslek Kuralları (Şerh) 3. baskı, Ankara 1977.

[51] Anayasa Mahkemesi'nin 12.10.2009 gün ve 16/147 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 103-106.

Avukatlık mesleğine girişte bir sınav yapılması konusu bugün için kanun koyucunun takdirine bırakılmış durumdadır[52]. Ancak kanımızca, öncelikle hak arayanların menfaatlerinin en üst düzeyde korunması başta olmak üzere, adalet hizmeti kalitesinin yükseltilmesi ve mesleğin itibarının korunması bakımından objektif ölçütlerle bir sınav getirilmesi yerinde olacaktır.

III – BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Bölgesi içinde en az otuz avukat bulunan her il merkezinde bir **baro** kurulur. Barolar, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır (AK m. 76-108).

Baroların görevi, Avukatlık Kanunu'nda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, meslekî ahlâk ve dayanışmayı korumak ve avukatlığın genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamaktır (AK m. 76).

Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin **baro levhasına yazılmakla yükümlüdür** (AK m. 66, I)[53].

Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukat unvanını taşıyamaz ve avukatlara ait yetkileri kullanamazlar; buna aykırı eylemde bulunanlar cezalandırılır (AK m. 63, I-II).

Baroda yazılı avukat olmayan kişiler, vekil sıfatıyla mahkemeye kabul olunmaz.

Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, Türkiye'nin her yerinde avukatlık yapmaya yetkilidir (AK m. 66, II).

Bütün baroların katıldığı **Türkiye Barolar Birliği** (TBB), tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur (AK m. 109-133).

Türkiye Barolar Birliği; baroları ilgilendiren konularda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek; baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak; **baro mensuplarının genel menfaatleri**ni ve mesleğin ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak; **meslek bağını kuvvetlendirmek;** vatandaşlarda kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak; **kanunların ülke ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi** ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak; mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak; uyulması zorunlu **meslek kurallarını tespit** ve tavsiye **etmek; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak,** bu kavramlara işlerlik

---

52 Türkiye Barolar Birliği, Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan bir Yönetmelikle mesleğe girişte sınav öngörmüş (bkz. RG 17.06.2014, sa. 29033), ancak Avukatlık Kanunu'nun 182. maddesine 6552 sayılı Kanunla ikinci fıkra eklenerek "yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim öngörülemez" hükmü getirilmiştir.

53 Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır (Bkz. Avukatlık Kanunu'na 3003 sayılı Kanunla ilâve edilen Ek Madde 1). **Kamu avukatları** hakkında bkz.: Ejder Yılmaz, Kamuda Çalışan Avukatlar (AÜHFD 2008, C. 57/3, s.733-751; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 1621-1638).

kazandırmak gibi görevleri yerine getirir (AK m. 110). TBB bu görevlerini, organları (AK m. 113-133) eliyle yerine getirir.

IV – AVUKATLARIN ÖDEVLERİ

Avukatlık bir kamu hizmeti olmakla beraber, Devlet hizmeti olmayıp, serbest bir meslektir (AK m. 1). Ancak, avukatların kamu hizmetini gereği gibi yerine getirebilmeleri için, Devlet memurlarına (özellikle hâkimlere) benzer şekilde, avukatlara bazı yasaklamalar konulmuş ve **bazı ödevler** yüklenmiştir. Burada, bunların en önemlilerine kısaca değinilecektir:

Avukatlar, (memurlar gibi) kural olarak aylık, ücret ve kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan hiçbir iş yapamazlar (AK m. 11; bu kuralın istisnaları için bkz. AK m. 12).

En az dört yıl süre ile hâkimlik veya savcılık yapmış olanlar, bu görevlerinden ayrılınca, avukatlık stajı yapmadan avukatlık mesleğine kabul edilirler (AK m. 4). Emeklilik ve istifa gibi nedenlerle **görevlerinden ayrılan hâkimlerin** (ve savcıların), son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden itibaren **iki yıl** süre ile avukatlık yapmaları yasaktır (AK m. 14, I-II).

Bir **hâkim veya savcının eşi**, kan ve dünür (sebep veya nesep) hısımlığı itibariyle alt ve üstsoyundan (usul ve fürundan) veya ikinci dereceye kadar **hısımlarından olan avukat**, o hâkim veya savcının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez (AK m. 13).

Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukukî yardımda bulunan avukat, yararı çatışan (menfaati zıt) öbür tarafın vekâletini alamaz (AK m. 38/b; Meslek Kuralları m. 36, I). Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar (AK m. 38, II).

Avukat, el koyduğu işlere ait **çekişmeli hakları edinmekten** veya bunların edinilmesine aracılıktan **yasaklı**dır (AK m. 47).

Avukatların iş elde etmek için, **reklam** sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları **yasaktır** (AK m. 55; Meslek Kuralları m. 7, 8)[54]. Bu yasağa uymayan avukatlara disiplin cezası verilir (AK m. 136).

Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret veya herhangi bir çıkar karşılığında **avukata iş getirmeye aracılık edenler** ve aracı kullanan avukatlar cezalandırılır (AK m. 48). Aracılık eden ile avukat (veya iş sahibi) arasındaki anlaşmalar geçersizdir.

Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdürler (AK m. 34; TBK m. 506, II).

---

54 Bkz. Ali Çetin Aslan, Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı, İstanbul 2015.

Avukat, kendisine yapılan iş teklifini yolsuz veya haksız görür veya sonradan işin yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa, **teklifi** (işi) **reddetmek zorunluluğu**ndadır (AK m. 38/a).

V – AVUKATLARIN HAKLARI

Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalâa (görüş) vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adlî işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir (AK m. 35, I). Buna göre **avukatlar,** vekâleten iş (dava) takip etmek için bir çeşit **tekel**e (inhisara) sahiptirler. Bu hüküm ve istisnaları, ileride davaya vekâlet bölümünde incelenecektir[55].

Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı **uzlaşmaya davet** edebilirler. Karşı taraf bu davete uyar (icabet eder) ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren **tutanak**, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar İİK'nun 38. maddesi anlamında **ilâm** niteliğindedir (AK m. 35/A)[56]. Aynı şekilde taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın **ilâm** niteliğinde belge sayılır (HUAK m. 18, 2).

Avukatlar, yaptıkları hukukî yardıma karşılık iş sahiplerinden bir **ücret** (vekâlet ücreti) **istemek hakkı**na sahiptirler (AK m. 163-175). Vekâlet ücreti, yargılama giderleri bölümünde incelenecektir[57].

Avukatlar **savunma dokunulmazlığı**ndan yararlanır. Avukatların, bir dava hakkında yargı mercilerine verdikleri dilekçe, belge veya yaptıkları iddia ve savunmaların ihtiva ettiği hakareti içeren yazı ve sözlerinden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılamaz. Ancak, dava ile ilgili olmayan ve ilgili olduğu takdirde dahi iddia ve savunma sınırını aşan hakareti içeren yazı ve sözler bunun dışındadır (TCK m. 128).

Dava ve takip **dosyaları**, yalnız avukatlar veya stajyerleri yahut taraflarca mahkeme ve icra kalemlerinde **incelenebilir** (AK m. 46, II; HMK m. 161; AK Yönetmeliği m. 39). Avukat, dava ve takip dosyalarını, **vekâletname ibraz etmeden** (vermeden) **de** inceleyebilir. Ancak, vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kâğıt ve belgelerin örneği (sureti) verilmez (AK m. 46, III).

Avukat, yanında çalışan stajyer veya sekreter eliyle de örnek aldırabilir. Adalet dairesi içinde imkân bulunduğu ve gerekli giderler de ödendiği takdirde, fotokopi yoluyla örnek çıkartılabilir (AK m. 46, I).

---

55 Bkz. aşa. § 14.

56 Bkz. bu konuda: Ejder Yılmaz, Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, Avukatlık K. m. 35/A, (Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s.843-856; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 1239-1250). Serhat Sarısözen, Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Ankara 2011.

57 Bkz. aşa. § 67, D.

Avukat, iş sahibinin kendisine verdiği **vekâletnamenin örneğini** çıkarıp, bu örneğin aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir (AK m. 56, I). Avukatın onayladığı vekâletname örnekleri, bütün yargı mercileri, resmî daireler, bankalar, kurumlar ile gerçek ve her türlü tüzel kişilere karşı resmî örnek hükmünde olarak kullanılabilir (AK m. 56, I; AK Yönetmeliği m. 19).

Tebligatın PTT tarafından yapılması esastır. Fakat, vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekiller makbuz karşılığında **birbirlerine tebligat yapabilirler** (Teb. K. m. 38; Teb. Yön. m. 60).

Baro levhasında yazılı bulunmayanlar veya işten yasaklanmış olan avukatlar, kendilerine ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra (ve iflâs) işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri (AK m. 35, I) kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. Bu hükme aykırı eylemde bulunanlar para cezasına ve tekerrürü halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler (AK m. 63, I-II).

Avukatlar, meslekî çalışmalarını, aynı büroda birlikte veya **avukatlık ortaklığı** şeklinde de yürütebilirler. Aynı büroda yürütülen birlikteliğin tüzel kişiliği olmamasına karşılık, avukatlık ortaklığının tüzel kişiliği vardır (AK m. 44).

Avukatlar yanında, bugün için gittikçe uygulaması azalmış bulunan **dava takipçileri**[58] de, en az üç avukatın bulunmadığı yerlerde bazı dava ve işleri, belirli koşullarla (vekâleten) takip edebilirler (AK geçici m. 17, I)[59].

---

[58] Dava vekillerini, dava takipçileri ile karıştırmamak gerekir (4667 s. K. m. 96 ile değiştirilen AK geçici m. 13). **Dava vekilleri**, 3499 sayılı eski Avukatlık Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden (01.12.1939 tarihinden) önce, dava vekâleti ruhsatnamesi almış olan kişilerdir. Nisan 1340 tarih ve 460 sayılı Muhamat Kanunu'nun 12. maddesine göre, beş sene süre ile adalet hizmetinde bulunanlara baro bulunmayan yerler için dava vekâleti yapabilme yetkisi tanınmış idi; bu kişilere dava vekâleti ruhsatnamesi verilmiştir (özellikle 06.01.1926 gün ve 708 sayılı Kanun'un 6. maddesine göre). Dava vekâleti ruhsatnamesi, yukarıda da belirtildiği gibi, 01.12.1939 tarihine kadar verilmiştir. Bu tarihten sonra dava vekilliği ruhsatnamesi verilemez (3499 sayılı eski Avukatlık Kanunu muvakkat madde III). 1136 sayılı yeni Avukatlık Kanunu'na göre de, gerek 3499 sayılı Kanun gerek yeni Avukatlık Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra dava vekâleti ruhsatnamesi verilemez (AK geçici madde 12, I). 3499 sayılı eski Avukatlık Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihte (01.12.1939 tarihinde) dava vekâleti ruhsatına sahip olan dava vekilleri, **beş avukat bulunmayan yerlerde vekâlet icra edebilirler** (bkz. 3499 s. K. muvakkat madde IV; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu geçici madde 13, c.1). Buna göre dava vekili, o yerdeki diğer avukatlarla birlikte AK m. 35, I'deki adlî işlemleri (o yerde) yapma bakımından bir tekele sahiptir (karş. AK geçici m. 17, I). Bugün için ülkemizde, yaş itibariyle dava vekilliği yapan kalmamıştır.

[59] Şu kimseler dava takipçisi olabilir; yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra (ve kanımızca iflâs) müdürlükleri nezdinde yazı işleri müdürlüğü, zabıt kâtipliği, zabıt kâtibi yardımcılığı, icra müdürlüğü (ve kanımızca iflâs müdürlüğü) veya yardımcılığı görevlerinden birini (veya bu görevlerden birkaçını toplam olarak) en az on yıl süre ile yapmış olan kimseler (AK geçici m. 17, I). Yukarıda sayılan **adalet hizmetlerinde en az on yıl süre ile çalışmış olan kimseler, yalnız** en az üç avukat olmayan bir yerde dava takipçiliği yapabilirler. Dava takipçilerinin çalıştıkları yerdeki **avukat sayısının üçü bulması halinde,** dava takipçilerinin o yerde vekâlet görevi yapma hakkı kendiliğinden sona erer. Bu halde, görevi kendiliğinden sona eren dava takipçisinin bakmakta olduğu (derdest) dava ve işleri sonuçlandırmaya yetkisi yoktur; yani, artık bu işlere devam edemez. Çalıştığı yerdeki avukat sayısının üçü bulması nedeniyle görevi kendiliğinden sona eren dava takipçisi, sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde, aynı baro veya başka bir baro bölgesi içinde, üç avukatın bulunmadığı başka bir yere nakledip (büro açarak) orada dava takipçiliği yapabilir.

F) NOTER[60]

I – GENEL OLARAK

Noterler, mahkemelerin faaliyetine doğrudan doğruya katılmazlar; fakat, yaptıkları işler ile mahkemelerin faaliyetine dolaylı olarak yardım ederler: "Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için **işlemleri belgelendirirler**" (NK m. 1). Noterler, ortak konutu terk eden eşin ortak konuta davet ihtarı (TMK m. 164) ve mirasçılık belgesi verilmesi ile ilgili **çekişmesiz yargı** işlerinde (m. 382) de görevlidir (NK m. 71/A). Noterlik mesleği, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile düzenlenmiştir. Ayrıca, NK m. 198 gereğince hazırlanmış bir Noterlik Kanunu Yönetmeliği vardır.

Her asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerde (il veya ilçede), o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Her noterliğin başında bir noter bulunur. Noter olabilmek için, hukuk fakültesi mezunu olmak ve noterlik stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış bulunmak şarttır (NK m. 5-21). Ayrık haller başlıklı NK'nun 6. maddesinde düzenlenen hükme göre noterlik stajına tâbi olmayanlar da noter olabilirler. Avukatlık stajı yapanlar, noterlik stajından muaf olduğu için uygulamada çoğunlukla ayrıca noterlik stajı yapılmamaktadır. Noterlik bir kamu hizmetidir (NK m. 1). Fakat, noterler Devlet memuru değildir ve Devletten maaş almazlar. Noterler, gördükleri hizmete karşılık iş sahiplerinden Noterlik Ücret Tarifesine göre belli bir ücret alırlar (NK m. 112-117). Bundan başka, noterler, tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden yüzde üç oranında noter hissesi alırlar (NK m. 118,II). Ayrıca, noterlere 3468 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, pul ve kıymetli kâğıt satışından dolayı (yüzde beşi geçmemek üzere) satış (beyiye) aidatı ödenir (verilir).

Noterler, **Devlet memuru olmadıkları** halde, memurlar gibi Adalet Bakanlığı tarafından tayin edilir (NK m. 22-30); 65 yaş sınırlamasına tâbidir (NK m. 56); kural olarak hiç bir hizmet ve görev noterlikle birleşmez; noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmî dairelerle birlikte başlar (NK m. 51); noterlerin tatil gün ve saatlerinde iş yapmaları (kural olarak) yasaktır. Ancak günümüzde pilot uygulama olarak hafta sonu ve tatillerde bir kısım noterliklerin açılması, "nöbetçi noterlik" uygulamasına geçilmiştir.

Ayrı noter bulunmayan yerlerdeki (ilçelerdeki) noterlikler (dördüncü sınıf noterlikler), o yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonunun teklifi (inhası) üze-

---

[60] Bkz. Ömer Ulukapı, Noterlik Mesleği, Noterin Hak ve Yükümlülükleri, Konya 2003; Ömer Ulukapı/Murat Atalı, Noterlik Hukuku, Ankara 2013; Seyithan Deliduman, Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001; Mustafa Özbek, Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara 2013: Ejder Yılmaz, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve Türkiye'de Noterlik (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi 1995/87, s. 9-16; Yılmaz, Makaleler C. 1 s. 757-766); Ejder Yılmaz, Noterlik İşlemlerinin Hukuk Davalarındaki ve İcra-İflâs Takiplerindeki Önemi (Noterlik Hukuku Sempozyumu: I-II, Ankara 1997 s.41-62; Yılmaz, Makaleler C. 1, s. 929-948); Ejder Yılmaz, Noter ve Tebligat (Noterlik Hukuku Sempozyumu: III-IV-V, Ankara 1999, s.101-134; Yılmaz, Makaleler C. 1 s. 1045-1070); Ejder Yılmaz, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları (Noterlik Hukuku Sempozyumu: VI, Ankara 2001 s.15-24; Yılmaz, Makaleler C. 1 s. 929-948).

rine, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya kâtip sınıfından bir adalet memuru (genellikle mahkeme yazı işleri müdürleri) tarafından geçici olarak yönetilir. Bu gibilere, geçici yetkili noter yardımcısı adı verilir (NK m. 32; bkz. ayrıca: NK m. 33, 34, 35; 197; NK Yönetmeliği m. 72). Dördüncü sınıf noterlik veya geçici noter yardımcılığının uygulaması artık bulunmamaktadır.

Üç veya daha fazla noterlik bulunan her belediye sınırı içinde bir **noter odası** kurulur. Her noter, bölgesi içinde bulunduğu noter odasına kaydolmak zorundadır (NK m. 179-188).

Türkiye Noterler Birliği, bütün noterlerin tabiî üyesi bulundukları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur (NK m. 163-178, 189-190). Noter odaları, Türkiye Noterler Birliğinin bölgesel organlarıdır (NK m. 180, I).

II – NOTERLERİN GÖREVLERİ

Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar (NK m. 1). Noterlerin; yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukukî işlemleri düzenlemek; kanunlarda resmî olarak yapılmaları emredilen (m. 206) ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukukî işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak; gayrimenkul (taşınmaz) satış vaadi sözleşmesi yapmak; dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek; belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek; protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek gibi genel görevleri vardır (NK m. 60).

Noterlerin anılan genel görevlerinin yanı sıra, tespit işleri (NK m. 61; HMK m. 401, 2); emanet işleri (m. 62-67); defter onaylama (NK m. 68; TTK m. 64 vd.; HMK m. 222); vasiyetname ve ölüme bağlı tasarrufları saklama ve zamanı gelince bildirme (NK m. 69); tebligat yapma (NK m. 70) gibi özel görevleri vardır. Noterler ayrıca, mahkemeler gibi, evi terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerini de yapabilirler (NK m. 71/A). Bu işlemlerde noterler[61], ilgilinin yazılı veya sözlü başvurusu üzerine, talep edilen işlemle ilgili bir tutanak düzenler; işlemler yapılırken, o işlemlerle ilgili özel kanunlarındaki usuller de gözetilir; talebin konusu bir belge düzenlenmesini gerektiriyorsa, noter, ilgilisine bu belgeyi de düzenleyerek verir. Mirasçılık belgesi verilmesinin yargılamayı gerektirmesi, nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması veya mirasçılık

[61] Noterlerin yaptığı diğer işlerden farklı olarak söz konusu çekişmesiz yargı işlerinin bizzat noterler tarafından veya noterlik dairesinde imza yetkisi verilmiş hukuk fakültesi mezunu görevli veya noter stajyeri tarafından yapılması gerekir; bu konuda noter başkâtibine yetki devredilemez (NK m. 71/B, II).

belgesinin yabancılar tarafından talep edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi noterler tarafından verilemez (NK m. 71/B)[62].

Noterlik işlemlerinin şekli, NK m. 72-108'de düzenlenmiştir. Noter senetlerinin çeşitleri ve ispat gücü ileride incelenecektir[63].

62 Bkz. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (RG 04.10.2011, sa. 28074).

63 Bkz. aşa. § 28, B, II.

§ 5. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HMK, yargılamaya hâkim (egemen) olan ilkeler başlığı altında, 24-33. maddelerinde, medenî yargı alanında geçerli ilke veya kuralları düzenlemiştir.

Bir yargı faaliyeti olarak medenî yargı da, kaynağını Anayasadan almakta ve Anayasada veya uluslararası sözleşmelerde yer alan yargısal temel haklar geçerli olmaktadır. Bu anlamda aşağıda öncelikle temel haklardan birisi olan adil yargılanma hakkı üzerinde durulacaktır. Bu hak, Anayasal düzeyde ve uluslararası sözleşmelerle korunan bir haktır. HMK'nda adil yargılanma hakkının bazı unsurları açıkça düzenlenmekle birlikte, hakkın bütününe ayrıca yer verilmemiştir.

A) ADİL YARGILANMA HAKKI[1]

Anayasanın "hak arama hürriyeti" başlıklı 36. maddesinde herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu ifade edilmektedir. Yine ülkemizin de taraf olduğu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin (AİHS) 6. maddesinde adil yargılanma hakkının unsurları düzenlenmektedir.

Adil yargılanma hakkı, medenî yargı bakımından da son derece önemli olup, ilk derece yargılamasında bu hakkın ihlâli, hem kanun yolu incelemesinin hem de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvuruların da konusunu oluşturabilir.

Adil yargılanma hakkı, yalnızca kararın adil olmasının değil, yargılama sürecinin adil yürütülmesinin de güvencesidir.

AİHS m. 6, 1 uyarınca, *"Herkes, gerek medenî hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar (uyuşmazlıklar), gerek cezaî alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir".*

Madde düzenlemesi dikkate alınarak, adil yargılanma hakkının unsurları şu şekilde belirtilebilir. Yargılama, kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız

---

[1] Bkz. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2002; Sezin Aktepe Artık, Medenî Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2014.

mahkemece; makul sürede; açık (alenî) ve hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

I – KANUNÎ, TARAFSIZ, BAĞIMSIZ MAHKEME ÖNÜNDE YARGILANMA HAKKI

1) Kanunî (Tabiî) Hâkim Önünde Yargılanma

Doktrinde, kanunî veya **tabiî hâkim** (doğal yargıç) olarak da ifade edilen ilke, Anayasanın 37. maddesinde, "Kanuni Hâkim Güvencesi" olarak yer almıştır. Buna göre, "hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz".

Bu ilke, öncelikle mahkemelerin bir yasama organı tarafından kabul edilen "kanun"la kurulmasını gerektirmektedir. Nitekim Anayasa m. 142, mahkemelerin kuruluşunun kanunla gerçekleştirilmesini öngörmekte, HMK m. 1 de bu hususu ayrıca ifade etmektedir. O halde, bir mahkeme kurma kararını yasama organı verecektir. Ancak, ilgili mahkemenin kurulması, HSK'nun olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir (5235 s. K. m. 5, 1). O halde, yasal bir dayanak olmaksızın Adalet Bakanlığının, idarî işlem veya kararla yeni bir mahkeme kurulmasına karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Anayasanın açık hükmü karşısında kanun hükmünde kararname (KHK) ile de mahkeme kurulamaz.

Tabiî hâkim ilkesi bakımından, mahkemenin kanunla kurulmuş olması yeterli olmayıp, mahkemenin uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce kurulması gerekir. Buna göre, belirli bir olaya veya belirli kişilere uygulanmak veya onlar için geçerli olmak üzere mahkeme kurulamaz. Ancak, aynı tür bütün uyuşmazlıklara ve aynı konumda olan bütün ilgililere uygulanmak koşuluyla, özel görevli mahkemelerin (uzmanlık mahkemelerinin) kurulması mümkün ve geçerlidir. Tabiî hâkim ilkesinin yasakladığı husus, kişiye veya olaya özgü ya da olağanüstü yetkili mahkemelerin kurulmasıdır.

2) Tarafsızlık ve Bağımsızlık

Yargılamanın adil olabilmesi için ikinci koşul, yargılama makamının "tarafsızlığı"dır. Burada mahkemenin değil, "hâkim"in tarafsızlığı söz konusudur. Hâkim, her iki tarafa da eşit uzaklıkta olmalı, objektif bir yargılama yapmalıdır. Bu da hâkimin davanın tarafları ile duygusal, maddî veya manevî bir bağ içerisinde olmamasını gerektirir. Bu güvenceyi sağlamak bakımından HMK, "hâkimin yasaklılığı ve reddi" düzenlemelerini öngörmüştür (m. 34-44).

Yargı erkini elinde bulunduran (yargı yetkisini kullanan) mahkemelerin bağımsızlığı da son derece önemlidir.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne anlama geldiği konusu daha önce incelendiği için, burada yukarıdaki açıklamalarımıza yollama yapmakla yetiniyoruz[2].

II – MAKUL (UYGUN) SÜREDE YARGILANMA HAKKI

Yargılama, doğası gereği zamana yayılan bir süreci ifade eder. Zira hem tarafların iddia ve savunmaları ile delillerini ileri sürebilmeleri hem de hâkimin bunları değerlendirip karar vermesi zaman gerektirir. Esasen, nitelikli yargılama yapılabilmesi için taraflara uygun sürelerin tanınması bir zorunluluktur. Ne var ki, kanunlarda öngörülen sürelerin ölçüsüz bir şekilde aşılması, hukukî himaye arayışında olan tarafların beklentilerini olumsuz etkilemekte, geciken adalet, tatmin edici olmaktan uzaklaşmakta ve **"geciken adalet, adalet değildir"** özdeyişi haklılık kazanmaktadır. Bu bakımdan, yargılamanın makul (uygun) sürede gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. Nitekim, Anayasa m. 141, IV'de, "davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir" ifadesi yer almaktadır. Öte yandan HMK m. 30'da "usul ekonomisi" başlığı altında, yargılamanın "makul süre" içinde yürütülmesi hâkime yüklenmiş bir ödevdir.

Burada yargılamanın bir an önce, acele veya hızlı sonuçlanması değil, tarafların hak ve yetkilerini hayata geçirebilecek şekilde, ancak bunun kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi suretiyle herkesçe kabul edilebilir uygun bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Anayasa ve HMK'nda bu görev hâkime verilmiş olmakla birlikte, bu konuda hem yasama organına hem yürütmeye hem de taraflara görevler düşmektedir. Kanun koyucunun usul kanunlarında süre hükümlerini ölçülü ve uygun bir şekilde düzenlemesi, tarafların da bu konudaki haklarını dürüstlük kuralına uygun kullanmaları gerekir. Yargılamayı sevk ve idare eden hâkim de (m. 32), tarafların yargılama içindeki taleplerini bu açıdan iyi değerlendirmelidir. Aynı şekilde yargılamada yer alan bilirkişi, tanık veya uzmanların da yargılamanın gecikmesine sebep olmamaları gerekir. Öte yandan yargılamanın gecikmesinde, özellikle tebligat hükümlerinin işletilmesindeki zorluklar, kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanmasındaki sıkıntılar, adliye personelinin yeterli nitelik ve nicelikten yoksun olması, adaletin zamanında yerine getirilmesi konusunda bilinç ve eğitim düzeyindeki yetersizlikler vb. önemli rol oynamaktadır.

Bir davada makul sürenin ne kadar olduğu önceden belirlenemez. Yargılamada makul sürenin aşılıp aşılmadığı her somut olay çerçevesinde değerlendirilmelidir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), makul süreyi tespit ederken, dava dosyasının kapsamı, davanın zorluğu, karmaşıklığı; benzer davaların sonuçlanma süresi ve tarafların yargılamadaki davranışlarına bakmaktadır. Örneğin, AİHM, tarafların mazeret dilekçeleri ile ek süre almaları veya kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri zamanında yerine ge-

---

[2] Bkz. yuk. § 4, B, III.

tirmemelerinden dolayı dava uzun sürmüşse, bu durumu makul sürenin aşılması içerisinde değerlendirmemektedir.

Makul süre, yalnızca ilk derece mahkemesindeki yargılamayı değil, kararın kesinleşmesine kadar geçen bütün süreyi kapsar.

III – AÇIK (ALENÎ) YARGILANMA

Adil yargılanma hakkının diğer bir unsuru, yargılamanın açık (alenî) bir şekilde yapılmasıdır. Bu hak hem Anayasa'da (Anayasa m. 141, 1) hem de HMK'nda "aleniyet ilkesi" [3] olarak (m. 28) yer almıştır.

Anayasa m. 9 uyarınca, Türk Milleti adına yargı yetkisini bağımsız mahkemeler kullanmaktadır. Bu bakımdan yargının saydam ve demokratik işleyişi, yargının herkesin denetimine açık olmasıyla sağlanabilir. Açıklık, adalete olan güveni de artırır; aynı zamanda hâkimlerin daha dikkatli görev yapmalarını da sağlar.

Burada, denetime açık olmaktan kasıt, mahkemelerin hukukî anlamda kontrolü olmayıp, yargının işleyişinin isteyen herkes tarafından izlenebilmesidir. Başka bir deyişle, yargı yetkisi, "kapalı kapılar ardında" kullanılmamalıdır. Bu hak yalnızca bireylere tanınmış olup, "doğrudan açıklık (aleniyet)" adını almaktadır. Buna karşılık, "dolaylı açıklık (aleniyet)"e hizmet eden basın mensuplarının duruşmalara fotoğraf makinası, kamera vb. araçlarla girmesi ve kayıt yapması yasaktır (m. 153).

Yargılamanın açıklığı, her şeyden önce duruşmaların herkese açık olması anlamına gelir. Aynı şekilde, kararın tefhimi (sözlü bildirimi) de açıktır. Esasında, özel hukuk ilişkisinin söz konusu olduğu bu davalar bakımından zaman zaman açıklık ilkesi, yargılamanın sağlıklı yürütülmesine engel de olabilir. Zira, davaya yabancı üçüncü kişilerin duruşmada bulunması, tarafların veya tanıkların kendilerini iyi bir şekilde ifade etmelerine engel olabilir. Ancak bu durum, başlı başına açıklığın kaldırılmasına sebep olmaz. Bu konuda TMK m. 184, 6'da bir istisnaya yer verilmiş; hâkimin, boşanma davasında taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebileceği öngörülmüştür.

Yargılamanın herkese açık olması kuralının, her durumda ve mutlak olarak uygulanmasının zorluğu veya bazı durumlarda sakıncalı olması nedeniyle bu hakkın sınırlanabileceği kabul edilmektedir. O nedenle, duruşmalar tamamen veya kısmen gizli (kapalı) olarak da yapılabilir. Nitekim HMK m. 28, duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasının, "ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı" hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebileceğini kabul etmektedir. Bu düzenleme, Anayasa m. 141 ile uyumludur. Ne var ki, tarafı olduğumuz ve Anayasa m. 90 gereği bağlayıcı olup doğrudan uygulanma gücü bulunan AİHS m. 6'da, açıklığın kaldırılması daha farklı şekilde kaleme alınmıştır. Buna göre, yukarıda belirtilen durumlar dışında, "küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektir-

---

[3] Bkz. Nesibe Kurt Koca, Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2009.

diğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda", duruşmalar, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.

Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların söz konusu olduğu medenî yargıda, taraf menfaatleri veya yargılamanın daha sağlıklı yürütülmesi bakımından duruşmaların tamamen veya kısmen gizli yapılması gerekebilir. Bu bakımdan yukarıda belirtilen AİHS m. 6 hükmünün Türk hukuku açısından doğrudan uygulanabilecek bir düzenleme olduğu kanısındayız.

Açıklık, kural olarak duruşma yapılması ve kararın tefhimi ile ilgilidir. Bunun yanında dava ile ilgili dosya ve tutanaklar bakımından açıklık söz konusu değildir. Bir dava dosyası taraflar veya fer'î müdahil için her zaman açıktır (m. 161, 1). Avukatlar da her dava dosyasını inceleyebilir, ancak dava dosyasından örnek alabilmek için vekâletname ibraz etmek zorundadırlar (AK m. 2, III).

Aynı şekilde, davada tutulan tutanakların bir örneği, taraflara ve varsa fer'î müdahile talep halinde verilir (m. 158, 1). Buna karşılık, üçüncü kişilerin dava dosyasını inceleme hakları kural olarak bulunmamaktadır. Ancak HMK, dava ile ilgili olanların bunu kanıtlaması halinde hâkimin izni ile dava dosyasını inceleyebileceklerini düzenlemiştir (m. 161, 1). Davanın tarafı olmayan bir kişinin dava dosyasını incelemekte menfaatinin olup olmadığı, somut olaylar bakımından hâkim tarafından değerlendirilir. Örneğin, kendisine rücu edilebileceğini düşünen kimsenin, davaya müdahale talebinde (m. 66 vd.) bulunmadan önce dava dosyasını incelemekte menfaati olduğu kabul edilebilir.

Yargılamanın açık yapılması kural olmakla birlikte, duruşma tutanaklarında yargılamanın açık veya gizli yapılıp yapılmadığı mutlaka belirtilmelidir (m. 154, 2/c).

Tarafların gizlilik talebi, ön sorunlar hakkındaki hükümler (m. 163-164) çerçevesinde, gizli duruşmada incelenir ve karara bağlanır. Buna göre, hâkim, taraflardan birisinin bu konudaki talebini diğer tarafa tebliğ veya tefhim edip, onun da görüşünü alır ve derhal karar verir. Hâkim bu konuda bir karar vermeden diğer hususları karara bağlayamaz. Gizlilik talebi hakkında mutlaka bir karar vermesi gereken hâkim, bu kararının gerekçelerini, esas hakkındaki kararı ile birlikte açıklar. Hâkim, gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları, o yargılamayla ilgili edindikleri bilgileri açıklamamaları hususunda uyarır ve TCK'nun gizliliğin ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağını ihtar ederek bu hususu tutanağa geçirir (m. 28).

IV – HAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA
(SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ ve HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI)

Adil yargılanma hakkının unsurlarından birisi de "hakkaniyete uygun yargılanma"dır. Geniş bir kapsama sahip olan bu hak, adil yargılanma hakkını niteleyen, hatta bu hakkın özünü oluşturan en önemli unsurdur. Bu unsurdan anlaşılan ise "usulî hakkaniyet" olup, amaç, taraflar arasında dengeli, adil bir

yargılama gerçekleştirilmesidir. Bir yargılamanın hakkaniyete uygun olarak gerçekleşmiş sayılması için, usul kurallarının, davanın taraflarının iddia ve savunma haklarını yeterince ve tam olarak kullanmalarına imkân tanıyacak biçimde düzenlenmiş olması gerekir.

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı temel olarak, "silahların eşitliği ilkesi[4]" ile "hukukî dinlenilme hakkı"nı içerir.

Silahların eşitliği ilkesi, genel olarak, tarafların her birinin, kendisini davanın diğer tarafı karşısında açıkça bir üstünlük (dezavantaj) sağlamayacak şekilde iddia ve delillerini ileri sürebilmek için makul ve kabul edilebilir olanağa sahip olması zorunluluğu olarak tanımlanmaktadır. Anayasanın 10. maddesinde yer alan "eşitlik" ilkesinin yargılama hukukundaki yansıması olan bu ilke, tüm yargılama süresince taraflar arasında usulî hak ve yükümlülükler bakımından "adil bir denge"nin sağlanmasını ve taraflardan hiçbirinin diğeri karşısında açık bir şekilde üstün (dezavantajlı) olma durumuyla karşı karşıya bırakılmamasını gerektirir. Bu ilke uyarınca, taraflara iddia ve savunmada eşit fırsat verilmeli, eşit usulî hak ve yetkiler tanınmalı ve hâkim tarafından taraflara eşit davranılmalıdır. Silahların eşitliği ilkesi, taraflar arasındaki eşitsizliklerin adil yargılamayı engellemesini önlemek işlevini de yerine getirir. Bu da, anayasal bir ilke olan sosyal devlet ilkesini (Anayasa m. 2) gerçekleştirmeye hizmet eder.

Hakkaniyete uygun yargılanmanın diğer unsuru olan hukukî dinlenilme hakkı[5] ise, HMK m. 27'de düzenlenmiştir. Buna göre hukukî dinlenilme hakkı, kural olarak davanın taraflarına tanınan bir hak olmakla birlikte, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukukî dinlenilme hakkına sahiptirler (m. 27, 1).

Hukukî dinlenilme hakkı üç unsur içermektedir:

1) Bilgi Sahibi Olma Hakkı

İlk olarak, ilgililer kendi hukukî durumunu ilgilendiren bir konuda kendilerine karşı açılmış bir davadan veya kendilerine yöneltilmiş bir talepten haberdar edilmelidirler. Bu, aynı zamanda, adil yargılanma hakkından bağımsız olarak düzenlenen iddia ve savunma hakkının (Anayasa. m. 36, I) da bir parçasıdır.

Yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunması, usulüne uygun tebligat[6] ile gerçekleşir.

Uygulamada **"taraf teşkili"** (teşkili tarafeyn) yapılmadan, yani dava dilekçesi davalıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmeden ve **dosyaya giriş hakkı** verilmeden dava ile ilgili hiçbir işlemin yapılamayacağı kabul edilmektedir. Bu husus, Yargıtay tarafından da kontrol edilmekte ve bir bozma sebebi teşkil etmektedir.

---

4 Bkz. Emel Hanağası, Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016.

5 Bkz. Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003.

6 Usulüne uygun tebligatın nasıl yapılacağı aşağıda ele alınacaktır. Bkz. § 8.

2) Açıklama ve İspat Hakkı

Hukukî dinlenilme hakkının ikinci unsuru, açıklama ve ispat hakkıdır. Taraflar, yargılamada iddia ve savunma sebeplerini oluşturan olgu ve olayları açıklama hakkına sahiptirler. Taraflar, bu yolla, istemlerine temel oluşturan olayları ve olguları ortaya koyabilme olanağı elde ederler[7]. Nitekim Kanun, m. 119, 1/e'de davacı; m. 129, 1/d'de ise davalı bakımından bu hakkı ifade etmiştir. Aynı zamanda Kanun, tarafların bu hakkı hangi zaman dilimi içerisinde ve kaç defa kullanabileceğini de düzenlemiştir. Buna göre taraflar, **dayandıkları vakıaları davanın her aşamasında değil, davanın başında verdikleri dilekçelerinde ileri sürebilirler** (m. 141); bu hakkı yazılı yargılama usulünde iki kere (m. 136), basit yargılama usulünde ancak bir kere kullanabilirler (m. 317, 3). Kanunda belirtilen süreden sonra yeni bir vakıa ileri sürmek isteyen taraf, ancak bir kereye özgü olmak kaydıyla ıslah yoluyla veya karşı tarafın açık muvafakati varsa bu sınıra bağlı olmaksızın da bunu ileri sürebilir (m. 141, 2).

Açıklama hakkı, aynı zamanda taraflar için bir yük (ödev) de teşkil eder. Çünkü Kanun, tarafların iddialarını ispata elverişli bir şekilde somutlaştırmaları gereğini de düzenlemiştir (m. 194, 1).

İspat hakkı, Kanunda açıkça yer almıştır. Buna göre, **"taraflar, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına sahiptir"** (m. 189, 1). İspat hakkı, tarafların iddiaları konusunda hâkimde kanaat uyandırmak ve onu ikna etmek bakımından ispat araçlarını, yani delilleri gösterme hakkını ifade eder. Kanun, tarafların iddialarında olduğu gibi delillerinin de vakıalarla birlikte dilekçeyle gösterilmesini ve eklenmesini istemiş (m. 119, 1/f; 129, 1/e; 194, 2), süresinden sonra delil gösterme hakkını sınırlı haller dışında yasaklamıştır (m. 145). Öte yandan Kanun, hangi tür delillerin hangi vakıaların ispatında kullanılabileceğini ve delillerin gücünü de ayrıca düzenlemiştir. Bu anlamda Türk hukukunda hukukî işlemler bakımından geçerli olan senetle (kesin delille) ispat zorunluluğu (m. 200 vd.), ispat hakkının kullanımını zorlaştırsa da, işlem güvenliği bakımından kabul edilmiş ve istisnalarla yumuşatılmış bir kuraldır.

---

[7] **Açıklama hakkı,** kural olarak dilekçeler aracılığıyla kullanılır. Bu bakımdan "duruşma", hukukî dinlenilme hakkının zorunlu bir unsuru değildir. Hatta HUMK m. 73'te yer alan, hâkimin iki tarafı dinlemeden hüküm veremeyeceği hükmü HMK'na alınmamıştır. Ancak yazılı yargılama usulü bakımından, hâkimin duruşma yapmadan karar verebileceği haller, yalnızca dava şartları ve ilk itirazlar olup, bu da ön inceleme aşamasında geçerlidir (m. 138). Bu durum dışında, hâkimin ön inceleme duruşması yapması (m. 139-140), tarafları tahkikat için duruşmaya davet etmesi (m. 147) ve nihayet sözlü yargılama duruşması ve hüküm için duruşma yapması (m. 186), bunun için de tarafları duruşmaya davet etmesi zorunludur. O halde yazılı yargılama usulü bakımından, hâkimin dosya üzerinden, duruşma yapmadan karar vermesi kural olarak mümkün değildir. Buna karşılık basit yargılama usulünde, hâkim, mümkün olan hallerde duruşma yapmadan da karar verebilir (m. 320, 1). Bu husus, adil yargılanma hakkına aykırılık oluşturmaz. Zira, adil yargılanma hakkı, tarafların mutlaka duruşmada dinlenmelerini zorunlu kılmaz, onlara açıklama imkânı verilmesini yeterli görür.

3) Dikkate Alınma Hakkı ve Kararların Gerekçeli Olması

Hukukî dinlenilme hakkının üçüncü unsuru, "mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini" içermektedir.

Hâkim, taraflar iddia ve savunmaları ile delillerini ileri sürdükten sonra tahkikat aşamasında inceleme ve yargılama yaparak karar verir. İşte taraflar, getirdikleri bu malzemenin hâkim tarafından dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptirler.

Tarafların dikkate alınıp alınmadığı ise, hâkimin gerekçeli kararında ortaya çıkar. Mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiği, hem Anayasada (m. 141, III) hem de HMK'nda ayrıca ve açıkça (m. 27, 2/c) vurgulanmıştır. Öte yandan HMK m. 297, 1/c'de, gerekçenin nasıl yazılacağı ifade edilmiş; tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesinin, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebeplerin kararda yer alacağı belirtilmiştir.

Bütün bu hususların kararda yer alması, tarafların dava sonucunda sürpriz bir kararla karşılaşmamaları ve ikna olmaları bakımından önemlidir. Mahkemenin yalnızca esasa ilişkin nihaî kararları (hüküm) değil, usule ilişkin kararları da gerekçeli olmalıdır. Keza, yalnızca nihaî kararlar değil, ara kararlar da gerekçelendirilmelidir. Bu kural yalnızca ilk derece mahkemeleri için değil, üst ve yüksek mahkemeler (istinaf mahkemeleri ve Yargıtay) için de geçerlidir. Nitekim Anayasa, "bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" hükmünü içermektedir (Anayasa m. 141, III). Bu nedenle "formül onama" uygulamasının doğru olmadığı görüşündeyiz.

B) TASARRUF İLKESİ

HMK, "yargılamaya hâkim olan ilkeler" başlığı altında ilk olarak tasarruf ilkesine[8] yer vermiştir (m. 24).

Medenî usul hukuku, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasına ilişkin yöntemleri konu almaktadır. Özel hukuku karakterize eden husus (ayırt edici temel özellik) ise, irade serbestisi veya özerkliğidir. Buna göre, herkes kanunların çizdiği sınırlar çerçevesinde dilediği tür, şekil ve içerikte hukukî işlem yapma özgürlüğüne sahiptir (TBK m. 12, 1; 26).

Bu özgürlüğün medenî usul hukukuna yansıması, "tasarruf ilkesi" olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, **"davacı yoksa hâkim de yoktur"**. Kanunda bu ifadeyi karşılamak üzere, "hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz" denilmiştir (m. 24, 1). Bu ilke, kendiliğinden harekete geçme ilkesinin tersidir. Tasarruf ilkesi, hâkimin kendiliğinden bir dava veya işi göremeyeceği; talebin (davanın, işin) mutlaka ilgililer tarafından usulüne uygun olarak mahkeme önüne

---

[8] Bkz. Nedim Meriç, Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011; Fulya Teomete Yalabık, İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi ile Delillerin Toplanmasında Hâkimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul 2016.

getirilmesi gerektiğini belirtir. O halde hâkim, kendiliğinden bir dava veya işi çözme yetkisine sahip değildir. Çok istisnai hallerde hâkimin resen harekete geçebilmesi mümkün ise de (m. 382, 1/c), bu durum medenî usul hukukuna hâkim bir ilke değildir. Tersine medenî usul hukukunda, özellikle çekişmeli yargıda kural, tasarruf ilkesidir.

Kanunlarda bazı hallerle sınırlı olarak Cumhuriyet savcısına hukuk davası açma yetkisi de tanınmıştır (m. 70)[9]. Ancak bu durum da tasarruf ilkesinin bir istisnası değildir; çünkü, burada davacı sıfatı Cumhuriyet savcısına ait olup, hâkim kendiliğinden harekete geçmemekte, savcı tarafından açılan bu dava üzerine yargılama yapmaktadır.

Tasarruf ilkesi, bir yandan **dava açılmadıkça hâkimin davaya bakamayacağını** ifade ederken, öte yandan, **hiç kimsenin lehine olan bir davayı açmaya zorlanmamasını** da içermektedir. Buna göre, "kanunda açıkça belirtilmedikçe, hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya veya hakkını talep etmeye zorlanamaz" (m. 24, 2). Kanunlarda bazı hallerde belli süreler içerisinde dava açılmamasının sonucu özel olarak düzenlenmekte ve bazı yaptırımlar öngörüldüğü için ilgili, adeta dava açmaya zorlanmaktadır. Örneğin, resmî bir senedin sahteliği ileri sürüldüğünde hâkim, bunu ileri süren tarafa, ayrı bir sahtelik davası açması için iki haftalık süre verip, bu hususu, bekletici sorun yapabilir. Bu süre içinde dava açılmazsa, hâkim, sahtelik iddiası yapılmamış gibi davaya devam eder (m. 208, 4; 165, 2). Aynı şekilde, genel haciz yoluyla takipte adi senet altındaki imzaya itiraz edildiğinde ve icra mahkemesi tarafından itiraz geçici olarak kaldırıldığında, borçlu yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmazsa, itirazın geçici kaldırılması kesin kaldırmaya, konulmuşsa geçici haciz kesin hacze dönüşür (İİK m. 69, III; aynı şekilde diğer örnekler için bkz. İİK m. 33a, II ve İİK m. 65, V; İİK m. 264).

Tasarruf ilkesinin **üçüncü** boyutu, tarafların dava açıldıktan sonra da davayı takip edip etmeme konusunda irade serbestilerinin devam etmesidir. Nitekim Kanunda bu husus, "tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hakkında, **dava açıldıktan sonra da tasarruf yetkisi devam eder**" biçiminde düzenlenmiştir (m. 24, 3).

Medenî yargı bakımından tasarruf ilkesi, duruşma yapılması halinde tarafların duruşmaya katılmaları gereği olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, tarafların duruşmaya gelmemesi veya bir tarafın gelmesine rağmen diğer tarafın davayı takip etmek istememesi halinde, dosya işlemden kaldırılır, hâkim kendiliğinden davaya devam edemez (m. 150).

Bunun dışında, tarafların maddî hukuktaki tasarruf özgürlüklerine paralel olarak bazı işlemlerle de davaya son verebilmeleri mümkündür. Başka bir ifadeyle, açılan her dava mutlaka mahkemenin esasa ilişkin bir kararıyla sonuçlanmak zorunda değildir. Buna göre davacı, hüküm kesinleşinceye kadar davasından feragat edebileceği (m. 307) gibi, davalı da davayı kabul (m. 308) edebilir veya dava, tarafların sulh (m. 313) olmaları ile de sona erebilir.

---

[9] Bkz. yuk. § 4, C.

Tasarruf ilkesinin bu konuda getirdiği sınır (koşul) ise, dava konusu üzerinde tarafların serbestçe tasarruf edebilecek olmalarıdır. Tarafların hangi konularda serbestçe tasarruf edebilecekleri Kanunda belirtilmiş değildir. Ancak bu kavram, Kanunda pek çok yerde kullanılmaktadır. Örneğin, yetki sözleşmesinin yapılamayacağı haller (m. 18, 1), Cumhuriyet savcısının dava açtığı haller (m. 70, 3), tarafların arabulucuya veya sulhe teşvik edileceği haller (m. 137, 1); arabuluculuğa veya tahkime elverişliliğe ilişkin kural (HUAK m. 1, 2; 17, 1/d; HMK m. 408) gibi. Bir davanın feragat, kabul veya sulh ile sona erip ermeyeceği, yani tasarruf yetkisinin söz konusu olup olmayacağı, somut olaylar ve dava konusu bakımından değerlendirilir.

Taraflar, dava sonunda verilen hükme razı olup, onu kanun yoluna (istinaf, temyiz) götürmeyebilir. Bu halde hâkim, dosyayı kanun yolu incelemesi için, kendiliğinden üst veya yüksek mahkemeye gönderemeyeceği gibi, üst mahkeme de kendiliğinden (kanun yolu talebi olmadan) işe el koyamaz (hükmü inceleyemez)[10].

C) KENDİLİĞİNDEN (RESEN) HAREKETE GEÇME İLKESİ

Kanun, kendiliğinden harekete geçme ilkesi adı altında bir ilke düzenlememiştir. Ancak bu ilke, doktrinde, tasarruf ilkesinin karşıtı olarak ele alınmaktadır. Kanunda da çekişmesiz yargı işlerinin ölçütlerinden birisi olarak, "hâkimin resen harekete geçtiği hâller"den (m. 382, 1/c) söz edilmektedir.

Kendiliğinden harekete geçme ilkesi, hâkimin, usulüne uygun açılan bir dava olmaksızın bir işe veya davaya bakmasıdır. Buna göre, kamu yararı (düzeni) düşüncesi ile hâkim, bazı hallerde, tarafların bir talebi olmadan da, kendiliğinden harekete geçebilir; yani işe el koyabilir ve onu karara bağlayabilir. Kendiliğinden harekete geçme ilkesi, esas olarak, **çekişmesiz yargı işlerinde uygulanır.**

Çekişmeli yargıda, tasarruf ilkesi uygulanır. O nedenle bir tarafın mahkemeye başvurmaması halinde hâkimin, sırf kendi bilgisine dayanarak veya kendisine yapılan bir ihbarla bir davaya bakması mümkün değildir. Yukarıda belirtildiği üzere, Kanunda Cumhuriyet savcısına hukuk davası açma olanağı tanınan hallerde de (m. 70), yine tasarruf ilkesi geçerli olup, burada hâkimin kendiliğinden harekete geçmesi söz konusu değildir.

Çekişmeli yargıda hâkimin kendiliğinden harekete geçmesi, hâkimin tarafsızlığı ilkesine de uygun düşmez; çünkü hâkim, menfaat çatışması içerisinde bulunan taraflara eşit uzaklıkta olmalıdır. O nedenle kendiliğinden harekete geçme ilkesi, çekişmesiz yargıda uygulanabilen bir ilkedir. Ancak, çekişmesiz yargıda da kural olarak tasarruf ilkesi geçerlidir. O halde kendiliğinden harekete geçme ilkesi, çekişmesiz yargıda dahi istisnaen karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde çocuklar hakkında gereken tedbirlerin alınması, velayetin değiştirilmesi; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çer-

[10] Bunun istisnası kanun yararına temyizdir (bkz. aşa. § 57; § 59, H).

çevesinde şiddet mağduru kadının çocukları hakkında hâkimin karar vermesinde hâkim resen hareket edebilir.

D) TARAFLARCA GETİRİLME (HAZIRLAMA) İLKESİ

Bir davada, davanın temelini oluşturan iki önemli konu bulunmaktadır; dava malzemesi olarak da nitelenen bu iki konu, davada dayanılan vakıalar ve bunların delilleridir.

Tasarruf ilkesinin ve irade özerkliğinin bir sonucu olarak, bir kimse dava açıp açmamaya serbestçe karar verdiği gibi, neyi ne ölçüde dava konusu yapacağına da karar verir ve bunların delilini de kendisi sağlar. Bu anlamda, dava malzemesinin taraflarca getirilmesi veya hazırlanması (ihzarı) söz konusudur. **Bu ilke, tasarruf ilkesinin doğal bir sonucu ve tamamlayıcısıdır.**

O halde taraflarca getirilme ilkesi; davanın malzemesi olan vakıaların ve delillerin taraflarca getirilmesi, hâkimin kendiliğinden vakıaları gözetememesi ve delil toplayamamasıdır. Nitekim bu husus, Kanunda açıkça ifade edilmiştir. Buna göre, "Kanunda öngörülen istisnalar dışında, **hâkim,** iki taraftan birinin söylemediği şeyi **veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz** ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz. Kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, **kendiliğinden delil toplayamaz"** (m. 25).

Bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık söz konusu olduğu için, Kanun, tarafların uyuşmazlık noktaları konusundaki iradesine itibar etmektedir. Bu bakımdan medenî yargıda hâkim, tarafların ileri sürdüğü ve davaya getirdiği vakıalarla bağlı olup, onların söylemediği vakıaları dikkate alamadığı gibi, bunları hatırlatabilecek davranışlarda da bulunamaz. Çünkü hâkimin kanunen gerekmediği halde görüşünü belirtmesi veya yol göstermesi, hâkimin tarafsızlığından kuşku duyulmasını gerektiren önemli bir sebep olarak onun reddine (m. 36, 1/a-b) yol açabilir.

Hâkim, sadece kendisine usulüne uygun biçimde bildirilmiş olan hususları ve vakıaları inceleme konusu yapabilir ve bu vakıalardan anlaşılan itiraz sebeplerini kendiliğinden gözetmekle yükümlüdür. Buna karşılık, **hâkim,** kendisine usulüne uygun biçimde bildirilmemiş (**dava dosyasından anlaşılamayan**) **itiraz sebeplerini kendiliğinden gözetemez.** Maddî hukuk anlamındaki **def'iler**, dava dosyasına usulüne uygun biçimde girmiş olan dava malzemesinden anlaşılsa bile, def'iden yararlanacak kimse tarafından ileri sürülmemiş ise, hâkim bu def'ileri kendiliğinden gözetemez; örneğin, hâkimin zamanaşımı def'ini kendiliğinden gözetememesi gibi (TBK m. 161). Zamanaşımı, ilgilisine tanınmış bir hak olduğu için, hâkimin bu hakkı tarafa hatırlatması, onun tarafsızlığına gölge düşürür ve bu durum, taraflarca getirilme ilkesine aykırıdır.

Hâkimin taraflarca ileri sürülmeyen vakıaları dikkate alamaması veya hatırlatamaması kural olmakla birlikte, dava dosyasına girmiş, ancak, çelişik hususları veya belirsizlik taşıyan vakıaları açıklattırması, onun aydınlatma görevine girer (m. 31). Burada esasen taraflarca ileri sürülmüş olmasına

rağmen açıklık taşımayan vakıaların aydınlatılması söz konusudur. Bu ise yasak olmayıp, tersine hâkimin görevidir.

Taraflarca getirilme ilkesinin ikinci boyutu, delillere ilişkindir. Buna göre, **hâkim, Kanunda belirtilen durumlar dışında kendiliğinden delil toplayamaz**, taraflar, dayandıkları delilleri dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

Taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalar bakımından, keşif ve bilirkişi delili, hâkimin kendiliğinden de başvurabileceği delillerdendir. Nitekim Kanunda açıkça hâkimin bu yetkisi belirtilmektedir (m. 266; 288, 2). Ticarî davalar bakımından hâkimin ticarî defterlerin resen ibrazını isteme yetkisi de bulunmaktadır (m. 222, 1).

Hâkim, aydınlatma ödevi çerçevesinde gerekli olan delillerin gösterilmesini ve verilmesini isteyebileceği (m. 31) gibi, isticvaba da kendiliğinden karar verebilir (m. 169, 1).

Yukarıda belirtilenler dışında, hâkimin tarafların dayandığı deliller dışında delil toplama yetkisi bulunmamaktadır.

Çekişmesiz yargıda taraflarca getirilme ilkesi uygulanmaz (m. 385, 2).

E) KENDİLİĞİNDEN (RESEN) ARAŞTIRMA İLKESİ

Kendiliğinden araştırma ilkesi HMK'nda açıkça yer almış veya düzenlenmiş bir ilke değildir. Ancak çekişmesiz yargı işleri bakımından Kanunda **"aksine bir hüküm bulunmadıkça resen araştırma ilkesi geçerlidir"** (m. 385, 2) hükmü bulunmaktadır.

Kendiliğinden araştırma ilkesi, **taraflarca getirilme ilkesinin karşıtıdır.** Bu ilke, dava malzemesinin (vakıalar ve delillerin) hazırlanmasında, tarafların yanında hâkimin de görevli olmasını ifade eder.

Özel hukuk ilişkisi içinde tarafların kendi menfaatlerini en iyi şekilde koruyacağı, o nedenle, asıl sorumluluğun tarafların omzunda olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık, yine özel hukuk ilişkisi içerisinde olmakla birlikte, bazı davalarda tarafların menfaatleri yanında, üçüncü kişilerin veya toplumun da menfaatlerinin etkilenebileceği kabul edildiğinden, bu tür davalarda taraf inisiyatifi yerine (onun yanında) hâkimin de aktif hale getirilmesi söz konusu olmaktadır. Böylece, bu tür davalarda hâkimin tarafların getirdiği vakıalarla bağlı olmadığı, tarafların ileri sürmediği hususları araştırabileceği ve kendiliğinden delil toplayabileceği kabul edilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulama alanı, esasen çekişmesiz yargı işlerindedir (m. 385, 2).

Çekişmeli yargıda da, kamu yararı düşüncesinin ağır bastığı ve kanunun gösterdiği hallerde kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulanacağı kabul edilmektedir. Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar, daha çok **tarafların dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri davalardır**;

Derneklerin feshine ilişkin davalar (TMK m. 89), Cumhuriyet savcısı tarafından açılan veya Cumhuriyet savcısının taraf olduğu hukuk davaları

(m. 70), soybağına ilişkin davalar (TMK m. 284, 1), evlenmenin butlanı[11] (TMK m. 160) sosyal güvenlik hakkına ilişkin davalar gibi özel hukuk davalarında kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanır.

Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda hâkim kesin delillerle bağlı olmayıp, delilleri vicdanî kanaatine göre serbestçe değerlendirmektedir (m. 198). Ayrıca bu tür davalarda hâkim isticvaba (m. 169 vd.) başvuramayacağı gibi, yemin ve diğer kesin deliller de hâkimi bağlamaz. Taraflar arasında çekişmeli olmayan (örneğin, ikrar edilen) vakıaları da, hâkim kendiliğinden inceleme konusu yapar. Bundan başka, hâkim, tarafların ileri sürmedikleri **vakıaları da kendiliğinden araştırıp,** kararını bu vakıalara dayandırabilir. Burada hâkim, davanın ispatı için gerekli **bütün delillere kendiliğinden** başvurabilir. Aynı nedenle, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda ikinci tanık listesi verilebilir. Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda delil sözleşmesi yapılamaz.

Yine, bu davalarda iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı (m. 141) uygulanmaz ve hâkim, tarafların talepleriyle bağlı olmaksızın (karş. m. 26) karar verebilir.

Çekişmeli yargıda kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulanması bir istisnadır. Bununla birlikte taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalar da dahil olmak üzere her türlü davada, **dava şartlarının incelenmesi kendiliğinden araştırma ilkesine** tâbidir.

Çekişmeli yargıda kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanması halinde dahi, tasarruf ilkesinin geçerli olduğu; hâkimin kendiliğinden harekete geçemeyeceğini tekrar belirtmek gerekir.

F) TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

Tasarruf ilkesi ve taraflarca getirilme ilkesi, hâkimin, tarafların bildirdiği vakıalarla bağlı olmasını ve onların istemleri doğrultusunda hareket etmesini gerektirmektedir. Taleple bağlılık ilkesi de, bu kuralları tamamlar. Buna göre, hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir (m. 26, 1). Hâkim, hüküm sonucunda (fıkrasında) da tarafların taleplerini dikkate alıp bunlar hakkında karar vermek zorundadır (m. 297, 2). Hâkim tarafların talepleri dışına çıkamaz. Buna göre davada, davalının elli bin TL'ye mahkûm edilmesi talebi karşısında hâkim, elli bin beş yüz TL'ye hükmedemez; buna karşılık hâkim, davacının talebinin kırk bin TL'sini kabul ederken, on bin TL'lik kısmını reddedebilir. Benzeri şekilde, davacının faiz istememesi halinde, hâkim resen faize hükmedemez. Hâkim, yalnızca davacının istem

---

[11] Buna karşılık, **boşanma ve ayrılık davalarında,** kendiliğinden araştırma ilkesinin sınırlı bir şekli mevcut olup, hâkim boşanma veya ayrılık için gösterilen olayları (vakıaları), mevcudiyetlerine vicdanen kanaat getirmedikçe sabit addedemez; yemin teklif olunamaz; ikrar hâkimi bağlamaz (TMK m. 184; karş. TMK m. 166, III). Bu nedenle boşanma davaları, kendiliğinden araştırma ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı davalar değildir. Bu davalarda yalnızca deliller bakımından hâkime daha geniş bir yetki tanınmış olup, vakıalar bakımından taraflarca getirilme ilkesi uygulanır.

sonucuna değil, davalının talebine de dikkat etmelidir. Örneğin, davalının davayı kısmen veya tamamen kabul etmiş olmasına rağmen, hâkimin bunu dikkate almaması, taleple bağlılık ilkesine aykırılık oluşturur.

Hâkim, davacının talebinden başka bir şeye karar veremez. Örneğin, davacı malın aynen iadesini talep etmişse, hâkim, malın bedelinin ödenmesine veya tazminata karar veremez. Ancak kanunların hâkime açıkça yetki verdiği hallerde hâkim, talepten başka bir şeye de hüküm verebilir. Örneğin, davacı boşanma davası açmış olmasına rağmen hâkim, boşanma yerine ayrılığa karar verebilir (TMK m. 170, 3). Yine, TTK m. 531'e göre, anonim şirketin feshinin istenmesi halinde, mahkeme feshe veya fesih yerine davacı pay sahiplerinin şirketten çıkartılmalarına veya diğer bir çözüme karar verebilir.

Taleple bağlılık ilkesi, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda geçerli değildir. Buna karşılık, taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalarda da, kimi zaman, hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri nedeniyle, bu kural uygulanmaz. Örneğin, davada yargılama giderleri talep edilmemiş olsa bile, hâkim, kendiliğinden davada haksız çıkan tarafı yargılama giderlerine mahkûm eder (m. 332, 1).

G) USUL EKONOMİSİ

Adil yargılanma hakkının bir unsurunun, yargılamanın makul sürede bitirilmesi olduğu, yukarıda ifade edilmişti. Kanunumuz yargılamanın süresini de kapsayan, ancak ondan daha geniş bir ilkeyi düzenlemektedir. Usul ekonomisi[12] adı verilen bu ilke, hâkime, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesi ve gereksiz gider yapılmamasını sağlama görevini yüklemektedir (m. 30; Anayasa m. 141, IV). Doktrinde kısaca, çabukluk, basitlik ve ucuzluk biçiminde ifade edilen bu ilke, hâkimin yargılamayı basit, gereksiz gecikmelere ve gider yapılmasına neden olmadan makul sürede tamamlaması görevi olarak anlaşılmaktadır.

Yargılamanın sevk ve idaresini gerçekleştiren hâkim (m. 32), davanın düzgün, amaca uygun ve gereksiz zaman, emek ve gider kaybına yol açmadan sonuçlanması için gereken tedbirleri alacaktır.

H) TEKSİF İLKESİ

Teksif ilkesi (dava malzemesinin başlangıçta yığılması ilkesi) adı altında bir ilke HMK'nda yer almamakta; doktrinde bu ilkenin varlığı kabul edilmektedir. Buna göre taraflar, iddia ve savunmalarını, yargılamanın belirli bir aşamasına kadar getirmek (ileri sürmek) durumundadırlar; bundan sonra kural olarak, yeni bir vakıa ileri sürülemez. Bu tür bir ilkenin sebebi, davada tahkikata konu olacak vakıaların belirli bir zaman kesitine kadar ortaya konulması ve tahkikatın bu konulara yoğunlaştırılmasıdır. Yargılamanın her aşamasında yeni vakıaların serbestçe ileri sürülebilmesi, yargılamanın sağlıklı bir şe-

---

[12] Bkz. Ejder Yılmaz, Usul Ekonomisi (AÜHFD c, 57/1 - Prof. Dr. Necip Bilge'nin Anısına Armağan, s. 243-274); Cumhur Rüzgâresen, Medenî Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013.

kilde ve makul bir sürede yapılabilmesine engel olur. Çünkü her yeni vakıa, inceleme gerektireceği için bunların sınırsızca ve her zaman ileri sürülmesi, tahkikatın genişlemesine yol açar. Bu nedenle, hukuk sistemlerinin bir kısmı son derece katı; bir kısmı daha yumuşak olmak üzere bu tür yasaklar getirmektedir.

Bu kural açıkça ilkeler arasında düzenlenmemekle birlikte, Kanunumuzda "iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi" başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre, yazılı yargılama usulünde taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise, ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. İstisnai olarak ise, ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez (m. 141, 1). Bir dava hangi usule tâbi olursa olsun, dilekçelerden sonra iddia veya savunmasını değiştirip genişletmek isteyen tarafın, bunu yapabilmek için iki olanağı daha vardır. Buna göre, karşı taraf, iddia veya savunmanın genişletilip değiştirilmesine açıkça muvafakat edebilir veya bu değişikliği yapmak isteyen taraf, karşı tarafın iznine gerek olmaksızın dilekçesini ıslah edebilir. Ancak ıslah hakkı, bir davada her bir tarafça yalnızca bir kere kullanılabilir (m. 141, 2).

Basit yargılama usulünde ise taraflar, yalnızca birer dilekçe verebildiklerinden, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, bu dilekçelerin verilmesi ile başlar (m. 319). Basit yargılama usulünde, kural olarak ayrı bir ön inceleme duruşması yapılmadığından (m. 320), yazılı yargılama usulü için yukarıda söz edilen istisna söz konusu olmaz.

İ) DOĞRUDANLIK İLKESİ[13]

Bir davayı yürüten hâkimin, dava ile ilgili ileri sürülen delilleri bizzat incelemesi ve hüküm vermesi esastır. Buna göre, bir davada deliller mümkün olduğunca birlikte ve aynı duruşmada incelenmelidir (m. 197, 1). Delillerin bir arada ve aynı duruşmada incelenmesi, usul ekonomisi bakımından önemlidir. Aynı şekilde delillerin davanın hâkimi tarafından incelenmesi, delille hâkim arasına bir aracının girmemesi, usul hukukunda "doğrudanlık" veya "doğrudan doğruyalık" olarak ifade edilmektedir. O halde kural olarak, örneğin, dava ile ilgili gösterilen tanıkları hâkim bizzat dinlemeli veya dava konusu yeri hâkim kendi gözleriyle görmelidir. Böylece delillerin daha sağlıklı değerlendirilmesi mümkün olur. Ancak bu durum, mahkemeye getirtilebilen deliller bakımındandır. Buna karşılık, mahkemeye getirtilemeyen deliller için istinabe yoluna gidilir[14] (m. 197, 2).

---

[13] Bkz. Aziz Serkan Arslan, Medenî Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012.

[14] Bkz. aşa. § 12.

İstinabe, mahkemeler arasında cereyan eden hukukî yardımlaşma olup, bir mahkemenin bir başka mahkemenin yargı çevresinde yapılması gereken iş için ondan yardım istemesi anlamına gelir. Böylece mahkemenin yargı çevresi dışında oturan tanığı başka bir hâkim dinler (m. 259, 4) veya yargı çevresi dışında bulunan keşfi (m. 289, 1) bir başka hâkim yapar. İstinabe edilen hâkim, yalnızca kendisinden istenen delilleri toplamakla yetinir, bunlar hakkında değerlendirmeyi davanın hâkimi yapar. Aynı şekilde tarafın isticvabı (m. 172, 1) veya yemin etmesi (m. 236) de bu şekilde gerçekleştirilir.

Bütün bu durumlarda ideal olan, davanın hâkiminin doğrudan doğruya delillerle veya taraflarla temas etmesi ise de, hâkimin yargı çevresi dışında işlem yapması mümkün olmadığı ve medenî yargıda tarafları veya üçüncü kişileri, davanın görüldüğü mahkeme önüne zorla getirtebilmek gibi bir olanak bulunmadığı için, istinabe bir zorunluluk oluşturmaktadır. Bu konudaki güçlükleri azaltmak için kanun koyucu, mümkün olan hallerde ses ve görüntü nakli yoluyla duruşma icrasına olanak tanımaktadır (m. 149)[15].

Toplu mahkemelerde naip üye (m. 185) uygulamasının da, doğrudanlık ilkesine bir istisna oluşturmakta olduğu söylenebilir[16].

J) YARGILAMANIN HÂKİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

Dava açılması ile, taraflar ve mahkeme arasında üçlü bir ilişki kurulmaktadır. Adil yargılanma hakkı, tarafların eşitlik temelinde bu sürece katılımını gerektirir. Hâkim de bu ilişkide objektif, tarafsız bir üçüncü kişi konumundadır. Ancak hâkimin burada çok önemli bir rolü ve işlevi bulunmaktadır. O da

---

15 Yazı İşleri Yönetmeliğinin (Y), **"ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası ve diğer usulî işlemler"** başlığını taşıyan 218. maddesine göre, mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, **SEGBİS** (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ya da benzeri sistemlerle aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme tanığın, bilirkişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, SEGBİS veya benzeri sistemler vasıtasıyla ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir. Yemin edecek taraf, mahkemenin bulunduğu yerden başka bir yerde oturuyor ise SEGBİS veya benzeri sistemler vasıtasıyla aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkündür (Y m. 218, 1-3). SEGBİS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve görüntü verileri de 6100 sayılı HMK m. 199'a göre **elektronik belge** hükmündedir (Y m. 218, 4). Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta, dinlenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin başlangıç ve bitiş zamanı, dinlemenin süresi, hazır bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir. Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fizikî olarak tutulan tutanak ise taranıp, güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden gönderilir. Belge asılları mahallinde saklanır (Y m. 218, 5-6). SEGBİS veya benzeri sistemlerle duruşmaya katılan tarafların beyanlarının imzalanması gerektiğinde, dinlemenin yapıldığı yer mahkemesince talepte bulunan mahkemece tutulan tutanağın bir çıktısı alınarak imzalatılır, imzalanan tutanak tekrar elektronik ortama aktarılır ve tutanağın aslı mahkemesine gönderilir (Y m. 218, 7). Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri, Yazı İşleri Yönetmeliği m. 218'e aykırı olmadıkça hukuk davalarında da uygulanır (Y m. 218, 8).

16 Bkz. aşa. § 12, C.

hâkimin, bu sürecin yürütülmesinden sorumlu olmasıdır. Nitekim Kanunda da açıkça **"yargılamayı, hâkim sevk ve idare eder; yargılama düzeninin bozulmaması için gerekli her türlü tedbiri alır"** ifadesi yer almaktadır (m. 32, 1).

Burada söz edilen "sevk ve idare", yargılamanın görünüş itibariyle (şeklî anlamda) yürütülmesidir. Kural olarak duruşma yapılması, duruşmalarda yapılması gereken işlemler, duruşmanın yönetilmesi, ilgili yerlere müzekkere (bir makama yazılan resmî yazı) yazılması veya tebligat yapılması gibi işlemler, yargılamanın sevk ve idaresi çerçevesindedir. Nitekim, hâkimin dava açılır açılmaz bir tensip tutanağı düzenlemesi, duruşmalarda tutanak tutulması zorunluluğu (m. 154), duruşma düzeninden hâkimin sorumlu olması ve bu çerçevede gerekli tedbirleri alma yetkisi (m. 151), duruşmada kayıt yapılmasına karar vermesi (m. 153), ses ve görüntü nakli yoluyla duruşma icrası (m. 149), tarafların, tanık veya duruşmadaki üçüncü kişilere soru yöneltmesi (m. 152, 1) konusunda karar verilmesi gibi pek çok durum, hâkimin yargılamayı sevk ve idare yetkisini göstermektedir.

Kanun bu çerçevede ayrıca, mahkemeye yöneltilen taleplerin biçimine ilişkin de bir düzenleme yapmıştır. Mahkemeye sunulan dilekçelerin asgarî bazı standartlarda olması gerekir. Bu anlamda öncelikle dilekçe, okunaklı olmalıdır. Dilekçelerin artık günümüzde elle yazılmadığı dikkate alındığında bu durum, çok sık görülebilecek bir sorun değildir. Buna karşılık, zaman zaman savunma hakkının sınırlarını aşan veya hakaret ya da uygunsuz ifadeler içeren dilekçe sunulması halinde mahkeme, bu dilekçenin yerine yenisinin verilebilmesi için ilgili tarafa uygun süre verir. Yeni bir dilekçe verilsin veya verilmesin, önceki dilekçe dosyada kalır. Verilen süre içinde yeni bir dilekçe düzenlenmezse, tekrar süre verilemez (m. 32, 2).

K) DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ[17]

Taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğu davalarda hâkimin, tarafların ileri sürdüğü vakıaların dışına çıkamayacağı, hatta tarafların ileri sürmediği vakıaları onlara hatırlatamayacağı hususu (m. 25) yukarıda belirtilmişti. Ancak, zaman zaman tarafların getirdiği vakıalar, çelişik veya belirsiz olabilir. Hâkimin, hukuku doğru uygulayabilmesi, önüne gelen malzemeye bağlıdır. Taleple ve tarafların getirdiği vakıalarla bağlılık kuralı korunmakla birlikte, getirilen vakıaların aydınlatılması çerçevesinde hâkime aydınlatma (açıklama yaptırtma) görevi verilmektedir (m. 31).

Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda, hâkimin aydınlatma ödevinden söz etmek doğru olmaz. Çünkü, bu davalarda hâkim, tarafların ne iddiaları ve talep sonuçları ne de getirdikleri delillerle bağlıdır. Davayı aydınlatma ödevi, asıl olarak, taraflarca getirilme ilkesi bakımından bir anlam taşır.

---

[17] Bkz. Varol Karaaslan, Medenî Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2019.

Hâkimin aydınlatma ödevi, **iki yönlüdür.** İlk olarak, vakıalar bakımından yeterli açıklık bulunmayan hallerde hâkim, **tarafları dinleyebilir, soru sorabilir.** Hâkim bu amaca hizmet etmek üzere isticvaba da (m. 169) başvurabilir. Hâkimin ayrıca, duruşmalarda taraflara soru sorması veya açıklama istemesi de mümkündür (m. 144). Örneğin davacı, dilekçesinde toplam bir rakam belirterek maddî ve manevî tazminat talep etmişse, hâkim, hangi tür tazminat için ne kadar talep ettiğini açıklattırmalıdır. Yine, davacı, dava dilekçesinde davanın konusunu "alacak davası" olarak belirtmiş, ancak istem sonucunda "alacağımın tespit edilmesini istiyorum" demişse hâkim, talebini açıklattırarak, davanın türünü belirler. Aynı şekilde, HMK ile getirilen yeni dava türü olan belirsiz alacak davası (m. 107) ile kısmî dava (m. 109) çoğu kez birbirine karışmaktadır. Bu karışıklık dava dilekçelerinde de yapılmakta, aynı dilekçede davanın hem belirsiz alacak davası hem kısmî dava olduğu biçiminde ifadeler yer alabilmektedir. Bu durumda hâkimin aydınlatma ödevi çerçevesinde davacıya, açtığı davanın türünü sorması, açıklattırması gerekir. Benzer bir aydınlatma ödevi de, alacaklının açtığı iptal davasının, tasarrufun iptali (İİK m. 277 vd.) mi, yoksa TBK m. 19'da yer alan muvazaaya dayalı iptal davası mı olduğunun davacıya sorulması suretiyle yerine getirilmiş olur.

Aydınlatma ödevinin ikinci yönü, delillere ilişkindir. Hâkim, belirsiz veya çelişkili gördüğü hususlarda **taraflardan delil gösterilmesini de isteyebilir.** Burada hâkim, taraflarca gösterilmemiş olsa bile bir delile başvurabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere hâkim, keşfe veya bilirkişiye gidilmesine kendiliğinden de karar verebilir. Oysa burada kast edilen, hâkimin, yalnızca bu deliller değil, bunlar dışındaki delillere başvurabilmesidir. Esasen, burada taraflarca getirilme ilkesi geçerli olduğu için, delillerle ilgili sorumluluk taraflarda olup, hâkim kendiliğinden delil toplayamaz. Ancak, davacının getirdiği delillerle iddia kanıtlanamıyor, davalının karşı delilleri ile de iddianın aksi saptanamıyorsa, davanın çözümü bakımından, hâkim, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde kalmak üzere, ispat yükünü taşıyan tarafa başka delili olup olmadığını sorabilir. Dolayısıyla, hâkimin buradaki yetkisi, kendiliğinden araştırma ilkesinde olduğu şekilde geniş bir yetki değildir.

Hâkimin aydınlatma ödevinin sınırlarını çizmek çok kolay değildir. Zira hâkimin, tarafsızlığını kaybetmemesi gerekir. Buna rağmen, hâkimin HMK m. 31 hükmünün lafzını (sözünü) ve ruhunu (özünü) dikkate alarak, bu ilkenin kabul edilme gerekçesini de gözeterek, ilkeyi uygulaması gerekir.

L) SÖZLÜLÜK-YAZILILIK İLKESİ

Yargılama içerisinde gerek mahkeme gerekse tarafların yaptığı usul işlemlerinin, belli bir şekle bağlı olup olmadığı hususu da önem taşımaktadır. Usul işlemlerinin tamamı bakımından ortak bir sonuca varmak mümkün değildir. Örneğin, davanın mutlaka dilekçeyle açılması ve mutlaka dilekçeyle cevap verilmesi gerekirken; bir kısım talepler, duruşmada sözlü olarak veya dilekçe ile de ileri sürülebilir. Bunlar, usul işlemlerinin şekli ile ilgilidir[18].

[18] Bkz. aşa. § 6.

Yazılılık veya sözlülükten anlaşılması gereken, tahkikat ve yargılama işlemlerinin nasıl yürütüleceğidir. Yazılı yargılama usulüne tâbi davalarda kural olarak, hâkim duruşma yapmalıdır (m. 140; 147; 186). Ancak bu usulde hâkim, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında, ön inceleme duruşması yapmadan da dosya üzerinden karar verebilir (m. 138). Bunun dışında kural, hâkimin duruşma yapması ve kararı tefhim etmesidir. Hâkimin duruşma yaptığı hallerde, tahkikat işlemlerinin sözlü olmasından söz edilir. Ancak, duruşma yapılması halinde, duruşma icrasının, talep ve beyanların mutlaka tutanağa bağlanması gerekir (m. 154). O halde, yazılı yargılama usulünde, yazılılık ve sözlülük birlikte uygulanmaktadır.

Basit yargılama usulünde ise, hâkimin mutlaka duruşma yapması zorunluluğu bulunmayıp, hâkim, "mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verir" (m. 320, 1) hükmü uyarınca tüm yargılama işlemleri ve karar, dosya üzerinden, yani yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Ancak bu, istisnaî bir durum olup, Yargıtay, hukukî dinlenilme hakkının sağlanması bakımından basit yargılama usulünde de, hâkimin duruşma yapması gerektiğine karar vermektedir.

Sonuç olarak, medenî yargıda yazılılık ve sözlülük ilkelerinin birlikte uygulandığını söylemek mümkündür.

M) HÂKİMİN HUKUKU UYGULAMASI

I – GENEL OLARAK

Taraflarca getirilme ilkesi, tarafların iddia ve savunmalarının dayanağı olan vakıaları ve delilleri getirmelerini öngörmektedir. Tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile (varsa, ikinci dilekçelerinde) hukukî sebebi bildirmeleri de söz konusu olup, bunlar da dava ve cevap dilekçesinin içeriğine dahil bulunmaktadır (m. 119, 1/g; 129, 1/f). Ancak hukukî sebeplerin belirtilmemiş olması, dava veya cevap dilekçesinde bir eksiklik olarak düzenlenmemiştir (m. 119, 2; 130).

Hukukî sebep, tarafların ileri sürdükleri vakıaların hukukî nitelendirmesi olup, tarafların kendilerini haklı çıkarmak için dayandıkları hukuk kurallarıdır. Bu nitelendirmeyi yapmak hâkime aittir. Nitekim Kanun, hâkimin kararının gerekçesinde hukukî sebeplere yer vermesini emretmektedir (m. 297, 1). İşte bu düzenlemelerin nedeni ise, hâkimin "**hukuku bilmesi**" (iura novit curia) **ilkesi**dir. Adı geçen ilke, Kanunda "hâkim, Türk hukukunu resen uygular" (m. 33) biçiminde ifade edilmiştir.

Hâkim Türk hukukunu kendiliğinden (resen) uygulamakla yükümlüdür (m. 33). Buradaki "**Türk hukuku**" deyimi, kanunların yanı sıra mevzuat ile örf ve âdet hukukunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri de kapsar; yani ilgili mevzuatı hâkim resen uygular.

Tarafların bildirdikleri hususlara ve vakıalara uygulanacak hukuk kuralını (kanun hükmünü) bulup uygulamak, başka bir deyimle bu vakıaların hukukî niteliğini (hukukî sebebini) belirlemek, Türk hukukunu (kanunlarını) uygulamak demektir. O halde, bu husus, Türk hukukunu kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olan (m. 33) hâkimin işidir. Hâkim, tarafların bildirdikleri hu-

kukî sebeple bağlı olmadığı[19] (karş. m. 26) gibi, tarafların hukukî sebep göstermemiş olması halinde de, davada uygulanacak hukuk kuralını kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlüdür.

Hâkimler, **Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine** göre hüküm verirler (Anayasa m. 138, I), **Hâkim, hukuk kurallarını bu sıraya göre uygular**; bunu yaparken, kendisinden daha üstün olan hukuk kuralına aykırı olan hukuk kuralını uygulamamakla ödevlidir. Buna göre, bir davaya bakmakta olan hâkim (mahkeme), o davada uygulanacak bir kanun (veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi) hükmünün **Anayasaya aykırı olduğu kanısına varırsa**, durumu Anayasa Mahkemesi'ne bildirir ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda (kendisine geliş tarihinden itibaren 5 ay içinde) vereceği karara kadar davayı geri bırakır (Anayasa m. 152). Böylece hâkim, Anayasaya aykırı bulduğu bir kanun hükmünü uygulamamakla ödevlidir.

II – YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI

Bir davada hâkimin Türk hukuku dışında yabancı hukuku da uygulaması gerekebilir.

Yabancı hukukun uygulanması MÖHUK m. 2 tarafından düzenlenmiştir. Hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını (MÖHUK m. 9 vd.) ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku kendiliğinden uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun içeriğinin (muhtevasının) tespit edilmesinde tarafların yardımını isteyebilir (MÖHUK m. 2, 1). Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku uygulanır.

Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması, yalnızca kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilâflarda göz önüne alınır ve bu hukukun (usul hukuku kuralları değil) maddî hukuk hükümleri uygulanır (MÖHUK m. 2, 2-3).

Uygulanacak yabancı hukuku seçme imkânının bulunduğu durumlarda; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, seçilen hukukun (usul hukuku kuralları değil) maddî hukuk hükümleri uygulanır (MÖHUK m. 2, 4). Hukuku uygulanacak olan yabancı Devlet, iki veya daha çok bölgesel birime ve bu birimler de değişik hukuk düzenlerine sahip iseler, hangi bölgenin hukukunun uygulanacağı, o Devletin hukukuna göre belirlenir; o Devlet hukukunda belirleyici bir hüküm bulunmaması halinde ise, uyuşmazlıkla en sıkı ilişkili bölge hukuku uygulanır (MÖHUK m. 2, 5).

N) DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Özel hukuk bakımından genel düzenleme olan TMK, herkesin hakları kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uyması gerektiğini ifade etmektedir (TMK m. 2).

Usul hukukunda da taraflar, başta dava açılması olmak üzere, çeşitli usul işlemleri yapmaktadırlar. İşte bu işlemleri yaparken taraflar, dürüstlük kuralı-

---

[19] Bu konuda TBK m. 60'daki mütelahik davaya ilişkin hüküm, bir istisna olarak görünmektedir.

na[20] uygun davranmak zorundadırlar (m. 29, 1). Örneğin, komşusunun balkon kapatmasına izin veren tarafın açtığı dava, dürüstlük kuralına aykırı bulunarak reddedilebilir.

Dürüstlük kuralına dayanan tarafın kendisinin de dürüst davranması gerekir. Kanuna karşı hile amacıyla yapılan bir sözleşmenin taraflarından birinin, bu sözleşmenin geçersizliğine dayanması, dürüstlük kuralına aykırıdır.

Dürüstlük kuralı, hem davalı hem davacı için söz konusudur.

Usul hukukunda dürüstlük kuralının uygulanmasıyla ilgili bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin, hâkimin dürüstlük kuralına aykırı olan taraf değişikliği talebini reddedebilmesi (m. 124, 3); gereksiz yere davanın uzamasına ya da gider yapılmasına sebep olan tarafı, lehine karar verilmiş olsa bile yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edebilmesi (m. 327); kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan davacıyı, yargılama giderlerinden başka, karşı tarafın vekiliyle kararlaştırdıkları akdî vekâlet ücretini kısmen veya tamamen ödemeye mahkûm edebilmesi ve ayrıca disiplin para cezasına hükmetmesi (m. 329); hâkimin, kötüniyetli ıslahı dikkate almadan karar vermesi (m. 182); bir kimsenin sırf kendi yerleşim yerinden başka bir yere getirilmek amacıyla, yerleşim yerinden başka bir yerde açılan dava hakkında yetkisizlik kararı verilmesi (m. 7, 2) gibi.

Kanunda taraflar için öngörülen bir başka yükümlülük, tarafların davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmaları gereğidir (m. 29, 2)[21].

Taraflarca getirilme ve tasarruf ilkesi, dava malzemesi üzerinde tarafların serbestçe tasarruf edebilmesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle taraflar, diledikleri vakıaları dava konusu yapabilirler. Tarafların, bunu yaparken, kendi aleyhlerine olan hususları bildirmeleri gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak ileri sürdükleri hususların doğru olması, beyan ve açıklamalarının gerçeğe aykırı olmaması, dürüstlük kuralının gereğidir. Çünkü mahkeme tarafların açıklamaları doğrultusunda, bir inceleme ve yargılama yapar; bu açıdan tarafların mahkemeyi de yanıltmamaları gerekir. Doğruyu söyleme ödevi, hem yazılı hem de sözlü beyan ve açıklamalar için geçerlidir. Bu ödeve aykırılık halinde beyanlar, mahkemece dikkate alınmaz ve değerlendirilmez. Ayrıca tarafın bilinçli olarak yalan söylemesi, bir usul hilesi ve dolayısıyla yargılamanın iadesi sebebi oluşturabilir (m. 375, 1/h).

---

[20] Bkz. Ramazan Arslan, Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

[21] Bkz. Nesibe Kurt Konca, Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Ankara 2016.

§ 6. USUL İŞLEMLERİ

A) GENEL OLARAK HUKUKÎ İŞLEM

En genel anlamıyla hukukî işlem, hukukî bir sonuç doğurmaya yönelik irade beyanıdır. Hukukî işlem, tek taraflı, iki veya çok taraflı olabilir. Maddî hukukta, hukukî işlemlerin şekli, işlemlere bağlanan sonuçlar ve irade bozukluğu gibi durumlar ayrıca düzenlemiştir (TBK m. 1-40).

B) USUL İŞLEMİ VE ÇEŞİTLERİ[1]

Dava açılmasıyla birlikte, davacı-davalı ve mahkeme arasında bir usulî ilişki doğar. Davayla ilgili olarak, davadan önce veya dava açıldıktan sonra, taraflar ve hâkim tarafından pek çok işlem yapılmakta, mahkemeye bir kısım talepler yöneltilmekte, mahkeme de çeşitli kararlar vermektedir. İşte söz konusu bu işlemlerin hukukî niteliği ve özellikleri üzerinde durmak gerekir. Çünkü bu işlemler, çeşitli bakımlardan maddî hukuktaki hukukî işlemden farklılık gösterir.

HMK'nda **işlem** sözcüğü geçen birçok madde (m. 14, 35, 38, 43, 44, 57, 73, 77, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 129, 137, 139, 147, 148, 150, 154, 156, 157, 178, 181, 209, 226, 232, 246, 262, 274, 278, 290, 306, 320, 325, 357, 382, 397, 402, 406, 425, 428, 445, 448) bulunmaktadır. Aynı şekilde HMK'nda **hukukî işlem** (m. 170, 2; 200-201; 203; 206; 226; 232; 251; 382, 7) terimi de kullanılmıştır. Bunun yanında, açıkça **usul işleminden** söz eden (m. 60, 68, 77, 149, 176, 179, 181) hükümler bulunduğu gibi, **tahkikat işlemi, yargılama işlemi** (m. 28, 4; 154; 156; 445); **taraf işlemleri** (m. 307-315); **yargılamayla ilgili işlem** (m. 54, 77) ve **yasal işlem** (m. 79) kavramı da kullanılmıştır[2].

I – TANIM

Yukarıda belirtildiği gibi, HMK'nda, usul işlemi veya usulî işlem biçiminde bir niteleme veya tanımlama yapılmamış; ancak Kanunda değişik yerlerde bu terim yer almıştır.

Usul işlemi tanımı konusunda doktrinde bir uzlaşma bulunmamakla birlikte; usul işlemlerinin, şekil, içerik, amaç ve yapılma biçimleri başta olmak üzere, işlemlerin geri alınması, şarta bağlanması, irade bozuklukları nedeniyle ortadan kaldırılmaları gibi pek çok bakımdan maddî hukuktaki hukukî işlemden farklı olduğu kabul edilmektedir. Bu bakımında usul işleminin ne olduğunun tespiti gerekir.

---

1 Bkz. Abdurrahim Karslı, Medeni Usul Hukukunda Usulî İşlemler, İstanbul 2001.

2 Bütün bunların dışında, teknik bir anlam taşımayan ve belli bir şekilde davranmak veya bir hukuk kuralını uygulamak anlamında da **işlem** sözcüğünün kullanıldığı (m. 80; 82, 2; 83; 246; 262; 306) maddeler vardır.

Doktrinde (öğretide) usul işlemi, dar veya geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır.

Dar anlamda usul işlemi, yargılamanın ilerlemesi için yapılan, etkileri ve koşulları usul hukuku tarafından düzenlenen işlemlerdir.

Geniş anlamda (işlevsel) **usul işlemi** tanımında ise, usul işlemi işlevsel olarak ele alınmaktadır. Buna göre, bir işlemi usul işlemi saymak için, onun hem etkisinin hem de koşullarının usul hukuku tarafından düzenlenmiş olması gerekmez. Aksine, işlemin doğurduğu aslî ve doğrudan etkinin usul hukukunda ortaya çıkması, o işlemi usul işlemi olarak kabul etmek için yeterlidir.

Geniş anlamda usul işlemi (işlevsel usul işlemi) tanımı büyük ölçüde taraftar bulan ve kabul edilen görüştür[3]. Buna göre, bir işlemin kendisinden ayrı düşünülemeyecek aslî etkileri, o işlemin ait olduğu alanı belirlemelidir. Eğer yaratılmak istenen aslî etki, usul hukukuna ilişkin ise, yani bir usulî ilişkiyi kurmak, değiştirmek veya ortadan kaldırmak amaçlanıyorsa, bu işlem usul işlemidir ve usul hukukunun ilkelerine tâbi olmalıdır. Ancak bir işlemin usul işlemi sayılması için, mutlaka koşullarının da usul hukukunca düzenlenmiş olması gerekmez.

Bazı işlemlerin hem maddî hukuka hem usul hukukuna ilişkin etkileri vardır. Burada aslî ve doğrudan etkinin hangi alanda doğduğunu belirlemek her zaman kolay değildir. Bu halde **karma işlemlerden** söz edilir. Örneğin, feragat, kabul veya sulh, davayı sona erdirici bir etkiye (m. 307 vd.) sahip olmakla birlikte, aynı zamanda maddî hukuktan kaynaklanan işlemlerdir. Bu durumda her iki hukuk alanının etkilerini görmek mümkündür.

II – ÇEŞİTLERİ

Usul işlemleri değişik açılardan birçok sınıflandırmaya tâbi tutulabilir. Buna göre, usul işlemleri **taraf usul işlemleri** ve **mahkeme usul işlemleri** olarak ikiye ayrılmakta; burada işlemi yapan kişi veya organa göre bir değerlendirme yapılmaktadır.

1) Taraf Usul İşlemleri

Taraf usul işlemleri, tek taraflı ve iki taraflı usul işlemleri olarak ele alınabilir.

Tek taraflı usul işlemleri, aslî etkilerini usul hukukunda gösteren, bir usulî ilişkinin kurulması, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasını amaçlayan olumlu veya olumsuz bir taraf işlem, eylem veya hareketidir. Dava açılması, cevap dilekçesi verilmesi, delil bildirilmesi, ikrar vb. işlemler tek taraflı usul işlemlerine örnek olarak verilebilir.

---

[3] Dar anlamda usul işlemi tanımı, yalnızca tek taraflı işlemleri kabul ettiği, usul sözleşmelerini dışladığı; usul işlemini mutlaka derdest bir davayla ilişkilendirip, davadan önce yapılan hiçbir işlemi buraya dahil etmediği; maddî hukuk işlemi olmakla birlikte bir dava içerisinde usulî bir niteliğe bürünen takas, iptal, fesih, feragat vb. işlemlerin özel durumlarını açıklamakta yetersiz kaldığı için eleştirilmiştir.

İki taraflı usul işlemi ise, **usul sözleşmeleri**ni ifade eder. Delil sözleşmesi, yetki sözleşmesi, teminata ilişkin sözleşme veya tahkim sözleşmesi birer usul sözleşmesidir. Burada tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanları, usulî birer edimi gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır. Örneğin, yetki sözleşmesinde, sözleşmenin konusu, yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmak; delil sözleşmesinde ise, tarafların bir davada kullanabilecekleri delilleri sınırlamak biçiminde olabilir. Bir usul sözleşmesi, maddî hukuk sözleşmesinin içerisinde (bir "şart", "kloz", "kayıt" şeklinde) yer alabileceği gibi, tek başına (bağımsız, ayrı) da yapılabilir. Usul sözleşmelerinin yapılması ve geçerlilik koşulları, kural olarak usul hukuku tarafından belirlenir. Ancak hakkında özel düzenleme bulunmayan hallerde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, maddî hukuktaki sözleşmelere ilişkin kurallar uygulama alanı bulur.

İki taraflı usul işlemleri bakımından ayrı bir kategori oluşturabilecek olan bir grup ise, **muvafakat** (veya mutabakat) **beyanları**dır. Nitekim, kesin delille ispatın gerekli olduğu hallerde karşı tarafın açık muvafakatı ile tanık dinlenebilmesi (m. 202, 2), davanın geri alınması (m. 123) veya tarafta iradî değişiklik yapılması (m. 124, 1) gibi hallerde karşı tarafın "açık muvafakat"ı yanında bu beyanların ilgilinin imzasıyla tutanağa geçirilmesi gerekir (m. 154). Burada karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından çok, mahkemeye yönelen bir irade açıklaması vardır. Bu beyanlar teknik anlamda sözleşme unsurları olarak değerlendirilemez.

Taraf usul işlemleri, sonuçlarını meydana getirmek bakımından **mahkemenin kararına ihtiyaç duyulan** veya buna gerek olmadan **kendiliğinden** sonuç doğuran işlemler olup olmamalarına göre de değerlendirilmektedir.

Maddî hukukta, hukukî sonuç doğurmaya yönelik beyanların kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde, amaçlanan hukukî sonuç da ortaya çıkar.

Usul işlemleri bakımından ise, durum biraz daha farklıdır. Nitekim tarafların yaptığı bazı usul işlemleri, kendiliğinden sonuç doğurur; örneğin, dava açılması veya cevap dilekçesinin verilmesinde olduğu gibi. Dava açılmasına veya süresinde cevap dilekçesinin verilmesine veya verilmemesine Kanunun bağladığı sonuçlar, mahkemenin bu konuda bir karar vermesini gerektirmeksizin kendiliğinden doğar (m. 118; 128; 131). Buna karşılık, örneğin süresinde cevap dilekçesi veremeyen tarafın geçerli bir mazereti varsa eski hale getirme talebinde bulunması veya cevap süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde, mahkemenin bir kararı üzerine, bir usulî sonuç çıkar (m. 100; 127)[4].

---

[4] Doktrinde bu gruba, **talepler, iddialar** ve **delil ikamesi**nin dahil olduğu kabul edilmektedir. **Talepler**, mahkemeye yönelen ve bir karar verilmesini gerektiren irade açıklamalarıdır. Bu açıklamalar, esasa yönelik olabileceği gibi usule ilişkin de olabilir ve yazılı ya da sözlü olarak da dile getirilebilir. Örneğin, dava açılması (m. 118), cevap dilekçesi verilmesi (m. 126) hâkimin reddi talebi (m. 38, 2), ihtiyati tedbire itiraz (m. 394, 4), delil tespiti talebi (m. 402) gibi. Bu taleplerden bir kısmında örneğin, dava dilekçesinde davalının mahkûmiyetine karar verilmesini veya cevap dilekçesinde davanın reddini talepte olduğu gibi, esasa ilişkin hususlar söz konusu iken; davaların birleştirilmesi, ayrılması, ihtiyati tedbire karar verilmesi veya dosyanın görevli/yetkili mahkemeye gönderilmesi istemleri usule ilişkindir. **İddialar** ise, taraflardan birisinin verilmesi istenen karara etkili olmak üzere, uygulanacak hukuk ve-

Yukarıda belirtilen türdeki işlemlerde hâkimin bir kararı gerekli iken, burada söz edilecek usul işlemlerinin sonuç doğurması veya etkili olması için **mahkemenin kararının gerekmediği** kabul edilmektedir[5]. Örneğin, tarafların yapmış olduğu yetki (m. 17) veya delil sözleşmesinin (m. 193) etki doğurması veya bir tarafın başvurduğu ıslahın (m. 176, 1) kabulü, mahkeme kararına bağlı değildir.

2) Mahkeme Usul İşlemleri

Dava açılmasının ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birisi, hâkimin bir karar vermesi zorunluluğudur. Karara ulaşmak için de dava açıldığı andan itibaren, hâkimin yapması gereken bir dizi "işlem" vardır. Bu anlamda, ilk olarak tensip tutanağı tutulması (düzenlenmesi), dava dilekçesinin tebliği, dilekçeler teatisinin sağlanması ve bu arada söz konusu dilekçelerde adı geçen belgelerin getirtilmesi için ilgili yerlere yazı yazılması vb. işlemlerin yapılması gerekir (m. 118 vd.). Bundan sonra, Kanunun öngördüğü süreler içerisinde ve usule uygun olarak ön inceleme aşaması ve tarafların ön inceleme duruşmasına daveti gerçekleşeceği gibi, hâkimin reddi, yasaklılığı veya görevsizlik, yetkisizlik veya diğer dava şartlarının eksikliği gibi farklı nedenlerle, davanın usulden retle sona ermesi de mümkündür (m. 34 vd.; 138-140).

Davanın bu şekilde usulden reddi yanında, bir hak düşürücü sürenin veya zamanaşımının tespiti nedeniyle esastan reddi de söz konusu olabilir (m. 142). Hâkimin tahkikat aşamasına geçmesi halinde de, yapacağı inceleme ve delil değerlendirmesi ile bir karara varması gerekmektedir (m. 294 vd.).

---

ya olaylar (olgu, vakıa) hakkındaki bilgisini ve görüşünü hâkime iletmesidir. Bunlar tarafların kişisel değerlendirmeleri olup, hâkimi bağlamaz. Tarafların olaylara ilişkin iddiaları hâkim tarafından değerlendirilir; hukuka ilişkin iddialar ise hâkimi bağlamaz. Burada "iddia" kavramı, geniş anlamda olup, hem davacı hem davalı bakımından geçerlidir. **Delil gösterilmesi** (ikamesi), bu konudaki son işlem kategorisidir. Delil gösterilmesi ve somut olayda (davada) başvurulacak delillerin neler olacağı hususu tarafların sorumluluğundadır (m. 194, 2). Tarafların, ellerinde bulunmayan veya üçüncü kişi, kurum veya makamlarda bulunan delillerin getirtilmesini de mahkemeden talep etmeleri mümkündür (m. 140, 5; 195). Tarafların ileri sürdükleri delillerin davada kullanılıp kullanılmayacağına veya caiz olup olmadığına, hâkim (m. 189, 4) karar verir ve kural olarak delilleri serbestçe değerlendirir (m. 198); işte bunlar taraf işlemi olmayıp hâkimin yapacağı işlemlerdir.

5 Sonuç doğurmak için hâkimin bir kararını gerektirmeyen işlemler tek tek sayılamamakla birlikte, doktrinde bir gruplandırma yapılmaktadır. Buna göre, ilk olarak **irade beyanları**ndan söz edilebilir İrade beyanlarının, iki taraflı olanları usul sözleşmeleri; tek taraflı olanları ise ıslah, davanın geri alınması, aslî müdahale, karşı tarafın veya üçüncü kişinin işlemine muvafakat, usulî bir defi veya ilk itirazdan feragat, kanun yollarına başvurmaktan feragat, davanın veya savunmanın genişletilmesine muvafakat gibi beyanlardır. İkinci olarak, **irade bildirimleri** gelmektedir. Burada da, tarafa veya üçüncü kişiye yapılan bildirimler söz konusudur. Bu açıdan tebellüğ, yeminin kabulü, yeminin yerine getirilmesi, tarafların delillerini zikretmesi veya hasretmeleri, davanın ihbarı bu gruba verilecek örneklerdendir. Üçüncü grup taraf usul işlemi ise **irade anlatımları**dır. Alındı veya tebellüğ belgesi, yeni bir avukat tayini gibi işlemler de bu gruba dahil sayılmaktadır. Son olarak da dilekçelerin verilmesi, delillerin elde edilmesi, harç ödenmesi veya avukatlar arasında yapılan tebliğ gibi **fiiller** ifade edilebilir.

Bu anlamda mahkeme usul işlemleri, bir davanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması bakımından mahkeme tarafından yapılması gereken işlem ve kararlar olarak anlaşılır.

Doktrinde mahkeme usul işlemleri olarak, **kararlar** ve **hükümler** dile getirilmektedir. Hâkimin davadan el çekmesini sağlayan usule veya esasa ilişkin nihaî karar ve hükümler yanında, davadan el çekmeyi gerektirmeyen **ara kararları** da mevcuttur. Ancak karar verme süreci içinde mahkeme önünde veya dışında birçok işlemin yapılması ve karara ulaşma yolunda ortaya çıkan taleplerin dikkate alınması veya engellerin de ortadan kaldırılması gerekir. Hâkimin yapması gereken bu işlemlerin bir kısmı yargılamanın sevk ve idaresi, başka bir deyişle yargılamanın şeklî anlamda işleyişiyle ilgili her türlü tedbiri alma yetkisi (m. 32, 1) çerçevesindedir. Buna göre, duruşma gün ve saatinin tespiti, tutanaklar tutulmasının sağlanması, duruşmanın yönetimi, dilekçelerin tebliği, ilgili veya yetkili makamlarla yapılan yazışmalar gibi işlemler yargılamanın **dış görünüm bakımından işleyişi**ni ilgilendiren işlemlerdir. Bunun dışında resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda dava malzemesinin toplanması, taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğu davalarda olguların ve delillerin dikkate alınıp değerlendirilmesi gibi, daha çok kararı oluşturmaya yönelik bazı işlemler yapılması söz konusudur. Bu tür işlemler de, **yargılamanın iç işleyişi**ne ilişkin işlemler olarak görülmektedir.

III – USUL İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Değişik bakımlardan sınıflandırmalara tâbi tutulan usul işlemleri, pek çok açıdan özellik taşımaktadır. Bilhassa taraf usul işlemleri, maddî hukuk işlemleriyle karşılaştırıldığında bu farklar ortaya çıkmaktadır.

Hukukî işlemler bakımından, kural olarak irade ve şekil serbestisi geçerliyken; usul işlemleri tür, içerik ve yapılma biçimleri bakımından sınırlandırılmıştır. Örneğin, dava veya cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlar Kanunda düzenlenmiş (m. 119, 129), tarafların verebilecekleri dilekçe sayısı sınırlandırılmıştır (m. 136; 317, 3). Öte yandan, hâkimin de usul işlemlerini ne şekilde yapacağı Kanunda yer almıştır. Örneğin, yargılamanın işleyişiyle ilgili tutanak tutulması ve tutanakta yer alması gereken hususlar (m. 154) ya da kararda bulunması gereken hususlarda olduğu gibi (m. 297).

Hukukî işlemler kural olarak şekle bağlı değilken; usul işlemleri Kanunda öngörülen şekilde yapılmak zorundadır. Hukukî işlemlerin şekle bağlanması, ispat kolaylığı, işlem güvenliği veya tarafları düşünmeye sevk etmek nedenleriyle olabildiği halde; usul işlemleri, davanın belirli bir düzen içerisinde yürümesi bakımından şekle bağlı kılınmaktadır. Bir kısım usul işlemi sözlü olarak da (m. 163; 177, 2; 188; 307 vd.) yapılabilmekle birlikte, usul işlemleri genellikle yazılı olmaktadır (m. 38, 2; 97; 119; 129; 136 vb.).

İki taraflı usul işlemleri olarak karşımıza çıkan usul sözleşmeleri de şekle tâbi kılınmıştır. Örneğin, yetki sözleşmesi (m. 18, 2) yazılı yapılmalıdır. Sözlü yapılabilen usul işlemlerinin de tutanağa bağlanması gerektiğinden (m. 193, 154), sonuçta bu işlemlerin geçerliliği bakımından olmasa bile, ispatı açısından bir şekil ortaya çıkmaktadır.

Hukukî işlemlerin irade bozukluğu sebeplerine dayalı olarak iptali söz konusu olabilirken (TBK m. 39), hatalı yapılan veya irade bozukluğuna uğrayan usul işlemleri için kural olarak bu olanak bulunmamaktadır. Unutulan veya hatalı yapılan bir usul işleminin, ancak ıslah yoluyla düzeltilmesi (m. 176 vd.) mümkündür. Yine, örneğin, mahkeme önünde gerçekleştirilen ikrar bakımından irade bozukluğuna dayalı olarak ikrardan dönmek mümkün değildir. Nitekim Kanun, ikrardan, ancak maddî hata nedeniyle dönülebileceğini düzenlemiştir (m. 188). Karma hukukî niteliği bulunan feragat, kabul veya sulhun irade bozukluğu sebebiyle iptali açıkça Kanunda öngörülmüştür (m. 311; 315, 2). Usul işlemleri bakımından genel olarak bu tür bir yol bulunmamaktadır. Öte yandan, mahkemenin bir kararını yanlış bulan taraf, kararı, usul hukuku kuralları çerçevesinde kanun yollarına götürerek düzelttirebilir.

Mahkeme de, kural olarak yaptığı işlem veya kararlardan dönemez. Mahkemenin kararı üst mahkeme tarafından bozulduğunda veya kaldırıldığında yeni bir karar verebilir. Mahkeme, usulî kazanılmış hak oluşturmayan ara kararlarından dönebilmekle birlikte, nihaî kararlardan dönemez. Bir mahkemenin kesinleşmiş kararı ise, ancak sınırlı sebeplerle yargılamanın iadesi yoluyla iptal edilebilir (m. 375 vd.; HUMK m. 445 vd.).

O halde usul işlemleri, türleri, yapılma biçimleri, özellikleri ve ortadan kaldırılmaları bakımından hukukî işlemlerden ayrılmakta, usul hukukuna tâbi olmaktadır.

§ 7. SÜRELER ve ESKİ HALE GETİRME

A) SÜRELER

I – GENEL OLARAK

Dava (yargılama), bir sürece (zamana) yayılmaktadır. Yargılamada tarafların hak ve yetkilerini kullanmaları veya hâkim tarafından yapılması gereken işlemlerin, önceden belirlenmiş ve ilgilileri tarafından bilinen bir zaman dilimi içerisinde yapılması, adil yargılanma hakkının unsurlarından olan makul sürede yargılanma hakkının gereğidir. Böylece taraflar, öngörülebilir ve önceden belirlenmiş belli süreler içerisinde gerekli işlemleri yapacaklar, bu süre içerisinde işlemlerin yapılmaması halinde yargılamanın nasıl bir seyir izleyeceğini de bileceklerdir. Sonuç olarak, davada izleyecekleri yol da buna göre değişebilecek, karşı tarafın süresinde işlemi yapmamasından kendi lehine bir hak (usulî kazanılmış hak) doğabilecek, böylece bir taraf avantaj kazanabilecektir.

Aynı şekilde, mahkeme de, önüne gelen işi veya uyuşmazlığı belirli aşamalardan geçmek üzere çözümleyeceği için, süreler, mahkeme bakımından da son derece önemlidir.

II – SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ[1]

HMK, sürelerin kime yönelik olduğu, nasıl hesaplanacağı, ne zaman işlemeye başlayacağı ve sürelerin çeşitleri hakkında bir kısım hükümler öngörmüştür (m. 90-94).

HMK'nun sürelere ilişkin düzenlemesinin maddî hukuka değil, usul hukukuna ilişkin olduğu, öncelikle belirtilmelidir. Çünkü burada, usulî bir sürecin yürütülmesi bakımından getirilen süreler söz konusu olup, hak aramaya veya hakkın düşümüne yol açan süreler, esas olarak maddî hukukta yer almaktadır.

Süreler, **Kanunda** açıkça **belirtilmiş** olabileceği gibi (m. 20, 1; 38, 5; 82, 1; 83; 104; 127; 136 vd.), **hâkim tarafından da tespit edilebilir** (m. 90, 1). Süreyi hâkimin verdiği (belirlediği) hallerde, bu süre Kanunda açıkça belirtilmiş olabileceği gibi (m. 127; 140, 5; 144, 2 vb.), somut olayın gerekleri çerçevesinde hâkim tarafından da belirlenebilir (m. 77, 1; 88, 1; 115, 2). Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hâkim kanundaki süreleri artıramaz veya eksiltemez (m. 90, 2). O nedenle, hâkim, süre verirken Kanundaki hükümlere uygun hareket etmeli; özellikle Kanunun, hâkim tarafından verilen sürenin kesin olduğunu ifade ettiği durumlarda, buna göre süre belirlenmelidir. Hâkim, kendisinin tespit ettiği süreleri, haklı sebeplerle artırabilir veya

---

[1] Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanununda Süreler (Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, C. III, İzmir 2015, s. 3167-3190; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 2091-2108).

eksiltebilir; gerekli gördüğü takdirde, bu konudaki kararından önce tarafları da dinler (m. 90, 2).

Kanundaki süreler, **taraflara yönelik** olabileceği gibi, **mahkemeye yönelik** de olabilir. Taraflara yönelik süreler, taraflardan birisinin veya her ikisinin belirli bir süre içinde o işlemi yapması gereğini ifade eder. Mahkemeye ilişkin süreler ise, hâkimin yapması gereken işlemlerin süresi bakımından getirilmiştir. Bu süreler arasındaki temel fark, taraflara yönelik sürelere uyulmaması hak düşümüne yol açarken; mahkemeye yönelik sürelerin düzenleyici olmaları nedeniyle, ihlâlleri halinde, işlemin geçerliliğini, kural olarak, etkilememesidir. Örneğin, davalı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermezse davayı inkâr etmiş sayılır (m. 128) veya davalı, cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını ileri sürmezse bu hakkı düşer (m. 117, 1). Hâkimin belirlediği süre içerisinde delil avansını yatırmayan taraf, o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılır (m. 324, 2). O halde, Kanunda öngörülen veya hâkim tarafından belirlenen süre içinde işlem yapmayan taraf, bu işlemin sağlayacağı avantaj veya haktan yoksun kalacaktır. Buna karşılık, örneğin, Kanun hâkimin, kısa kararı (hükmü) tefhim ettikten sonra en geç bir ay içerisinde gerekçeli kararı yazmasını emretmektedir (m. 294, 4). Hâkimin bir ay geçtikten sonra gerekçeli kararı yazmış olması halinde, bu durum, kararın geçerliliğini etkilemez; belirtilen süreden sonra da yazılmış olsa karar geçerli ve bağlayıcıdır.

Bir işlemi Kanunun öngördüğü süre içinde yapmayan hâkim kusurlu ise, kendisine disiplin cezası verilebileceği gibi, m. 46, 1/e'ye göre hâkimin bu davranışı nedeniyle, koşulları varsa, Devlete karşı tazminat davası da açılabilir. Devlet, ödediği tazminat nedeniyle, sorumlu hâkime rücu eder (m. 46).

Süreler bir başka açıdan da, **kesin süre** ve **kesin olmayan süre** biçiminde bir ayrıma tâbi tutulmuştur. Bu ayrım, taraflara yönelik süreler için geçerlidir. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar (m. 94, 3), buna karşılık kesin olmayan süre bakımından bu hak düşümü gerçekleşmez.

Kesin süre, Kanundan doğabileceği gibi, **hâkim tarafından da verilebilir.** Ancak, Kanunun belirlediği sürelerin kesin olduğu açıkça belirtilmekle birlikte (m. 94, 1), hâkimin verdiği süreler bakımından aynı şey söylenemez. Şöyle ki, Kanunda açıkça belirtilmiş olmadıkça, hâkimin verdiği sürenin kesin olması için, **hâkimin, bu hususu kararında belirtmesi gerekir.** Hâkim, kararında, verdiği sürenin kesin olduğunu açıkça belirtmemişse, bu süre, kesin sayılmaz ve dolayısıyla kesin süreye uyulmamasının yaptırımı söz konusu olmaz (m. 94, 2). Bu durumda, süreyi geçiren taraf, yeniden süre isteyebilir. Bu şekilde verilecek ikinci süre, Kanun gereği kesindir ve yeniden süre verilemez (m. 94, 2).

O halde, hâkimin verdiği ilk sürenin kesin olup olmadığı, kural olarak hâkimin kararından anlaşılacaktır. Yargıtay, bu konuda oldukça duyarlı davranmakta ve hâkimin taraflara süre verirken, sürenin kesin olduğunun, belirtilen süre içerisinde söz konusu işlemin yapılmaması halinde hakkın düşeceğinin (veya uygulanacak yaptırımın) de mutlaka karara yazılmasını (ihtaratta bulu-

nulmasını) istemektedir. Öte yandan Yargıtay, hâkim tarafından verilen kesin sürenin, işin niteliğine uygun olması gerektiğini de ifade etmektedir.

O halde, m. 94, 2 uyarınca hâkimin, kesin süre verirken, usulüne uygun hareket etmesi çok önemlidir. Hâkim, kararında verilen sürenin kesin süre olduğunu belirtmiş olsa dahi, Yargıtay'ın aradığı ölçütleri taşımayan (özellikle süreye uyulmamasının yaptırımını içermeyen) "kesin süre"yi geçiren tarafın, ikinci kez süre talep edilebilme hakkı olur. Yargıtay, bu konuda, tarafın avukatla temsil edilip edilmediğinin de önemli olmadığını, kesin sürenin mutlaka usulüne uygun biçimde verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Hâkim, ilk kesin süreyi usulüne uygun biçimde vermemişse, taraf, ikinci kez süre isteyebilir; bu kez (ikinci kez) verilen sürenin kesin olduğu belirtilmese bile, Kanun gereği süre kesin olacağından, süre sonunda Kanunun öngördüğü sonuçlar doğar; yeni bir süre de talep edilemez (m. 94, 2).

Davaların makul sürede bitirilebilmesi (usul ekonomisi) bakımından da hâkimin, süre verirken bu kurallara uygun hareket etmesi son derece önem taşımaktadır.

III – SÜRELERİN BAŞLAMASI VE HESAPLANMASI

Kanun, sürelerin işlemeye başlaması bakımından genel bir düzenleme yapmıştır. Buna göre, süreler, taraflara tebliğ tarihinden veya Kanunda öngörülen hâllerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye başlar (m. 91).

Tebliğ, herhangi bir hususun muhatabına bildirildiğinin yazılı olarak belgelendirilmesi; **tefhim** ise, hâkim tarafından yüze karşı okuma veya sözlü anlatma anlamına gelir.

Sürelerin nasıl işleyeceği konusunda Kanunun getirdiği temel kural, süreye bağlı işlemin, ilgilisine tebliğ edilmiş olmasıdır. Örneğin, aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında hâkim boşanma kararını, taraflara tefhim etmiş olsa dahi, taraflar bu karara karşı henüz kanun (istinaf) yoluna gidemezler. Çünkü aile mahkemesinin kararına karşı iki haftalık istinaf süresi, ilâmın usulen taraflardan her birine tebliği üzerine başlar (m. 345). Buna karşılık, örneğin icra mahkemesi kararlarına karşı, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren istinafa gidilebileceği düzenlenmiştir (İİK m. 363, I). Bu durumda istinaf süresi, kararın tefhimi anında mahkemede bulunan taraf bakımından hemen işlemeye başlar, eğer karar tarafa tefhim edilmemişse, süre, tebliğden itibaren işler. Anayasa Mahkemesi, tefhimden itibaren sürenin işlemeye başlayabilmesi için, tefhim edilen kararın Kanuna uygun (m. 297) şekilde gerekçeli karar olmasını aramakta; aksi halin hak ihlâli oluşturduğunu kabul etmektedir.

HMK, kural olarak, sürelerin tebliğle işlemeye bağlayacağını, tefhimle bir sürenin işleyebilmesi için bu hususun açıkça Kanunda öngörülmesi gerektiğini belirtmiştir (m. 91). O nedenle sürelerin başlangıcını belirlemek için Kanunda yer alan ifadelere dikkat etmek gerekir. Öte yandan, çok istisnai de olsa bazı hallerde Kanun, sürenin başlangıcını **"öğrenme"** (ıttıla) olgusuna da bağlamıştır. Örneğin, m. 387'de, çekişmesiz yargı işlerinde ilgililerin kararı "öğrenmeleri"nden (m. 92) itibaren kanun yoluna başvurabilecekleri düzen-

lenmiştir. Yine usulsüz tebligat halinde, muhatabın öğrendiğini bildirdiği tarih, tebliğ tarihi sayılır ve böylece süre işlemeye başlar (Teb. K. m. 32).

Elektronik yolla tebligatta tebliğ, muhatabın adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır (Teb. K. m. 7, IV).

HMK, süreleri genellikle hafta olarak düzenlemiştir. Ancak bunun yanında sürelerin gün, ay veya yıl olarak da ifade edilmiş olması mümkündür. Her durumda sürelerin nasıl hesaplanacağı önem taşımakta olup, Kanun tarafından bu husus düzenlenmiştir. Buna göre, **süreler gün olarak belirlenmiş ise** tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz, ertesi gün tebliğin birinci günü olarak kabul edilir ve süre, son günün tatil saatinde biter.

Süre; **hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise** başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter (m. 92). Buna göre örneğin, tarafların her ikisinin de duruşmaya gelmemesi nedeniyle dosya, 30 Kasım tarihinde işlemden kaldırılmıştır. Taraflardan hiçbirisi bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde yenileme talebinde bulunmazsa, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir (m. 150). Bu durumda 3. ay, şubat ayına rastladığı, ancak şubat ayında 30 gün olmadığı için, yenileme süresinin son günü 28 veya duruma göre 29 Şubattır.

Yıl olarak belirlenmiş süreler, yılın kaçıncı ayının kaçıncı günü işlemeye başlamış ise, biteceği yılın aynı gününde sona erer (m. 92, 2).

Resmî tatil günleri, süreye dahildir[2] (m. 93, 1). Yani, sürenin içinde kalan resmî tatil günleri (Örneğin Pazar günleri) de hesaba dahil edilir ve bundan dolayı süre uzatılamaz. Bunun gibi sürelerin hesaplanmasında, sürenin başlamasına rastlayan resmî tatil günleri de hesaba dahil edilir. Örneğin, ilâm davalıya 30 Aralık Cumartesi[3] günü tebliğ edilmiş ise, 30 Aralık Cumartesi günü işlemeye başlayan bir aylık temyiz süresinin (m. 361, 1) hesabına, 31 Aralık Pazar günü ile 1 Ocak Yılbaşı tatili (Pazartesi günü) de dahildir ve temyiz süresi 30 Ocak tatil saatinde biter. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter (m. 93, 1).

Öğleden sonraları tatil olan günler (28 Ekim günü ile Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günleri) iş günüdür. Bu nedenle, son günü öğleden sonrası tatil olan bir güne rastlayan bir süre, o gün saat 13.00'te sona erer.

Yukarıdaki örneklerde de belirtildiği gibi, gün, hafta, ay ve yıl olarak tayin edilen süreler, sonuncu günün tatil saatinde bitmiş sayılır. Sonuncu gün tatil

---

2 Resmî tatil günleri şunlardır: 28 Ekim saat 13.00'ten sonrası ve 29 Ekim günü (Ulusal Bayram), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 19 Mayıs (Atatürk'ün Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı), 30 Ağustos (Zafer Bayramı), Ramazan Bayramı (arife günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür), Kurban Bayramı (arife günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür), 1 Ocak (Yılbaşı tatili), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 15 Temmuz Günü (Demokrasi ve Milli Birlik Günü) Cumartesi ve Pazar günleri (hafta tatili); bkz. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 99, II.

3 Cumartesi resmî tatil günü ise de, resmî tatil günlerinde tebligat yapılabileceğinden resmî tatil (Cumartesi) gününde yapılan tebligat üzerine de süre işlemeye başlar.

günüyse, bu günü izleyen ilk çalışma günü çalışma saati sonunda süre bitmiş sayılır.

Bakanlar Kurulu tarafından zaman zaman ilân edilen **idarî tatil** veya idarî izinler, sürelerin işlemesi bakımından dikkate alınmaz.

Adlî tatilin sürelere etkisi ise ayrıca düzenlenmiştir (m. 104 vd.).

IV – ADLÎ TATİL

Adlî tatil, kural olarak yargılamaların ertelendiği bir dönemi ifade eder. Buna göre, mahkemeler[4], her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında tatil yaparlar, yeni adlî yıl, 01 Eylülde başlar (m. 102)[5].

Öncelikle belirtilmelidir ki, adlî tatil, dava açılmasına değil, davaların görülmesine engel olur. Adlî tatilde davaların görülmesi kural olarak 40 gün süreyle Kanun gereği kendiliğinden ertelenmektedir. Ancak istisnai olarak adlî tatile rağmen yürütülecek dava ve işler söz konusu olduğundan Kanun, bu hususu ayrıca düzenleme ihtiyacı duymuştur. Bu nedenle de, adlî tatile tâbi olan ve olmayan dava ve işler olarak iki grup dava ve iş ortaya çıkmaktadır.

Adlî tatile tâbi olmayan, yani adlî tatilde görülmeye devam edecek dava ve işler bakımından bir özellik söz konusu değildir; bu davalar ve işler, adlî tatilden etkilenmediği için normal seyrinde devam eder. Kanun koyucu, ertelemeye tahammülü olmayan veya ivedi saydığı işler bakımından adlî tatil hükümlerinin geçerli olmayacağını kabul etmiştir.

Adlî tatilde görülecek olan bu davalara ve işlere **nöbetçi mahkemeler** tarafından bakılır. HSK, her yıl adlî tatilden önce, bir yerdeki hâkimlerden (mahkemelerden) hangisinin nöbetçi kalacağını kararlaştırır[6]. Bu nöbetçi hâkimler, adlî tatilde aşağıda belirtilecek davalara ve işlere bakarlar. Adlî tatilden yararlanamayan nöbetçi hâkimler, adlî tatilden sonra yıllık izinlerini kullanırlar. Tek hâkimli yerlerdeki hâkimler adlî tatilden yararlanamazlar.

HMK m. 103 hükümleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanır (m. 103, 4). Yani, adlî tatilde bakılabilecek davalar ve işler hakkındaki kanun yolu incelemeleri, adlî tatilde de yapılır. Bu kanun yolu incelemelerini yapmak için, **istinaf mahkemelerinde** ve **Yargıtay'da bir nöbetçi hukuk dairesi** kurulur (Yargıtay K. m. 56; Yargıtay İç Yönetmeliği m. 58-60). Bu nöbetçi hukuk dairesi, yukarıda adlî tatilde bakılacağını gördüğümüz davalar ve işlerle ilgili kanun yolu incelemelerinden başka, bütün davalara ait icranın geri bırakılması taleplerini (İİK m. 36) de karara bağlar.

---

4 Burada yalnız hukuk mahkemelerindeki adlî tatil incelenecektir. Ceza mahkemelerindeki adlî tatil için bkz. CMK m. 331; Danıştay'daki adlî tatil için bkz. Danıştay K. m. 86-87; Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerindeki adlî tatil için bkz. İYUK m. 61-62; Sayıştay'daki adlî tatil için bkz. Sayıştay K. m. 101; Uyuşmazlık Mahkemesi'ndeki adlî tatil için bkz. UMK m. 5, III.

5 Bkz. 650 sayılı KHK m. 33 (RG 26.08.2011 sa. 28037) ile değişik m. 102.

6 "Hâkim ve savcılar, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden (adlî tatilden) yararlanırlar. Yıllık ara vermeden yararlanan hâkim ve savcılara o yıl içinde ayrıca yıllık izin verilmez. Yıllık ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemleri Hâkimler ve Savcılar Kurulunca saptanır" (Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 55).

Adlî tatile tâbi olmayan dava ve işlerin bir kısmı Kanunda sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki iş ve davalar adlî tatilde görülmeye devam edecektir (m. 103):

a) İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukukî koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflâs ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adlî tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

HMK'ndaki bu sayma sınırlı değildir. Nitekim, "kanunlarda ivedi olduğu belirtilen" iş veya davaların da adlî tatilde görüleceği kabul edilmektedir (m. 103, 1/h). Örneğin, İİK m. 18, 1, "icra mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır" demek suretiyle icra mahkemelerinde adlî tatil hükümlerinin uygulanmayacağını ifade etmektedir.

Bu konudaki diğer istisna ise, adlî tatile tâbi olmakla birlikte, taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerin de adlî tatilde görülebilmesidir (m. 103, 1/h).

Öte yandan, bunun tam tersi de mümkündür. Buna göre, aslında adlî tatilde görülebilecek olmasına rağmen, tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, bu iş ve davalara bakılması, adlî tatilden sonraya bırakılabilir (m. 103, 2).

Adlî tatilde görülecek dava ve işler bakımından adlî tatilin bir önemi yoktur; zira bu dava ve işler görülmeye devam edecektir.

Buna karşılık, **adlî tatile tâbi olan davalara adlî tatilde bakılamaz**. Bu iş ve davalar, adlî tatilden sonraki bir zamana ertelenir.

Ancak adlî tatile tâbi davalar için Kanun, iki bakımdan düzenleme getirmiştir. İlk olarak, adlî tatil, bu tür davaların açılmasına engel olmadığı için, **adlî tatilde her türlü dava açılabilir**[7]; ancak bu davaların **görülmesi, adlî tatil sonuna** kalır. Öte yandan, dava açılmasından başka, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilâm verilmesi,

---

7 Bir alacağın zamanaşımının sonu, adlî tatil dönemine rast gelirse, alacağın zamanaşımına uğramaması için davanın adlî tatil döneminde açılması gerekir.

her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay'a gönderilmesi işlemleri de yapılır (m. 103, 3)[8].

Ancak adlî tatilin önemi, usul kanunlarında öngörülen süreler bakımından ortaya çıkmaktadır. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere, adlî tatilde dava açılabilmekte veya dilekçeler tebliğ edilmekte ya da ilâm alınabilmektedir. Bu durumda süreler işlemektedir. Oysa kanun koyucu, yalnızca mahkemeler bakımından değil, taraflarca yapılacak işlemlerin de adlî tatil süresince yapılmamasını düzenlemektedir. İşte bunu gerçekleştirebilmek için HMK, "adlî tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği **sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa,** bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adlî tatilin bittiği günden itibaren **bir hafta uzatılmış sayılır"** hükmünü getirmiştir (m. 104).

Burada uzayacak süreler, **yalnızca usul kanunlarında belirtilen süreler** olup, örneğin, dava açma süresinin son günü adlî tatile rastlayan ve dava açmayan kişi, böyle bir uzatmadan yararlanamaz[9]. O halde, sürenin usulî bir süre olması ve son gününün adlî tatil içerisine denk gelmesi gerekir. Örneğin, asliye hukuk mahkemesinin kararı 12 Temmuz 2019 tarihinde kendisine tebliğ edilen davacı için iki haftalık istinaf süresi 26 Temmuz 2019 tarihinde dolar; ancak bu tarih, adlî tatile denk geldiği için, davacının istinafa başvurma hakkı, adlî tatilin bittiği tarihten itibaren bir hafta daha uzar. Adlî tatilin bittiği gün 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü olduğundan, davacının bu tarihten itibaren bir hafta daha istinaf dilekçesi verme olanağı olacaktır. Buna göre davacı, 07 Eylül 2019 Cumartesi gününe kadar istinaf dilekçesi verebilecek ise de, m. 93 uyarınca, bu süre 09 Eylül 2019 Pazartesi günü çalışma (mesai) saati sonuna kadar uzar. Buna karşılık, adlî tatilde işlemeye başlamış olan bir sürenin iki haftalık bir sürenin sonu 01 Eylülde bitiyorsa, o zaman sürenin bir hafta daha uzatılmış sayılması mümkün değildir.

Öte yandan m. 104 uyarınca adlî tatil içerisinde uzayacak olan süreler, adlî tatile tâbi dava ve işlerde **Kanunun öngördüğü süreler** olup, mahkeme (hâkim) tarafından verilen sürelerin uzaması söz konusu olmaz (karş. m. 90, 1).

---

8 HMK m. 103, 3 hükmüne göre, adlî tatilde bakılamayacak olan bir dava ile ilgili olarak adlî tatilde verilen bir dilekçenin veya ilâmın tebliği üzerine, karşı tarafın buna karşı yapabileceği işlem veya verebileceği cevap hakkındaki kanunî süreler (örneğin istinaf süresi veya cevap süresi) adlî tatilde işlemeye başlar ve tatil günleri süreye dahildir. Ancak, böyle bir sürenin (örneğin adlî tatilde tebliğ edilen ilâm üzerine işlemeye başlayan istinaf süresinin veya adlî tatilde açılan bir dava dilekçesinin davalıya tebliği üzerine işlemeye başlayan cevap süresinin) bitmesi adlî tatile rastlarsa, süre (örneklerde istinaf veya cevap süresi) m. 104'e göre bir hafta daha uzatılmış sayılır (bkz. 14.02.1934 gün ve 49/2 sayılı; 16.01.1946 gün ve 26/2 sayılı İBK, RG 23.05.1934, sa. 2709 ve RG 02.04.1946, sa. 6272).

9 Bir alacağın zamanaşımının sonu, adlî tatil dönemine rast gelirse, alacağın zamanaşımına uğramaması için davanın adlî tatil döneminde açılması gerekir. Çünkü adlî tatil, bir maddî hukuk konusu olan zamanaşımını durduran bir kurum değildir.

B) ESKİ HALE GETİRME[10]

I – GENEL OLARAK

Kanunda belirtilen süreler ve hâkim tarafından usulüne uygun verilen kesin süreler içerisinde, ilgililerin gerekli işlemleri yapmamaları halinde, haklarının düşeceği (m. 94) yukarıda belirtilmişti. Yargılamanın belirli bir düzen ve makul süre içerisinde bitirilebilmesi için bu tür bir düzenleme gereklidir. Ancak taraflar, bu süreleri bazen ellerinde olmayan bir nedenle veya kusurları olmaksızın geçirebilirler. İşte bu hallerde de, hakkın düşmüş sayılması, süreyi kaçıran için ağır bir sonuçtur. Bu nedenle kanun koyucu, adeta bir telafi mekanizması öngörmüş, böylece durumu eski haline getirmek suretiyle, sanki o süre hiç kaçırılmamış gibi bir hukukî sonuç düzenlemiştir.

Örneğin, hüküm kendisine tebliğ edilmiş olan taraf çok ağır hastadır ve hükme karşı kanun yoluna başvuracak bir vekili de yoktur. Bu nedenle kanun yoluna başvurma süresini geçiren taraf, iyileştikten sonra eski hale getirme talebinde bulunur; talebi kabul edilirse, hükme karşı süresinde kanun yoluna başvurmuş sayılır.

II – ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN KOŞULLARI

Eski hale getirme, talep üzerine gerçekleşir. Buna göre, "elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hale getirme talebinde bulunabilir" (m. 95, 1).

Eski hale getirme yoluna gidebilmek için, ilk olarak, **kesin bir süre**nin kaçırılması gerekir. Bu sürenin Kanunda öngörülmesi veya hâkim tarafından verilmiş olmasının önemi yoktur. Öte yandan, bu sürenin mutlaka HMK'nda düzenlenmiş olması da gerekmez. HMK'nun 95. maddesinde, (HUMK m. 166'da olduğu gibi, "bu kanun" ibaresine değil) **"kanunda belirtilen süre"** ifadesine yer verilmiştir. Bu sebeple, sadece HMK'nda değil, medenî yargılamaya ilişkin diğer kanunlarda belirlenen kesin sürelerin kaçırılması hallerinde de, eski hale getirme yoluna başvurulabileceği kabul edilmiştir. Örneğin, aile mahkemelerine veya tüketici mahkemelerine ilişkin özel hükümlerle getirilen sürelerin elde olmayan sebeplerle kaçırılmış olması halinde de bu hükümler uygulanır[11].

Ancak, eski hale getirme talebi için, kaçırılan sürenin "kesin" olması, yani bir hak düşümünün gerçekleşmiş olması gerekir.

Eski hale getirme yoluna gidilebilmesi için ikinci koşul, işlemi yapmak zorunda olan kimsenin veya vekilinin, elde olmayan sebeplerle (kusuru olmaksızın) o işlemi süresi içinde yapamamış olması gerekir (m. 95); elde olmayan sebep, **tarafın iradesi dışında ortaya çıkan** haklı ve objektif bir engel veya durum olmalıdır.

Belli bir süre içinde bir işlemi yapmak zorunda olan bir taraf, o işlemi yapamayacak ve kendisine bir vekil tayin edemeyecek derecede ağır hasta ise, iyileştikten sonra eski hale getirme talebinde bulunabilir. Doktor raporunda

---

[10] Bkz. Erdal Tercan, Medeni Usul Hukukunda Eski Hale Getirme, Ankara 2006.

[11] Bkz. Hükmün gerekçesi (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-HMK m. 95).

gösterilen hastalığın, eski hale getirme sebebi teşkil edip etmeyeceğini, eski hale getirme talebini inceleyen mahkeme (veya üst mahkeme) takdir eder.

Belli bir süre içinde bir işlemi yapmak zorunda olan bir taraf, yangın, yer sarsıntısı (deprem), yer kayması veya su basması gibi bir afet nedeniyle, o işlemi süresinde yapamamış ise, bu afetin son bulması ve (tarafın) o işlemi yapabilecek duruma gelmesi üzerine, eski hâle getirme talebinde bulunabilir.

Tarafın ağır hastalık, kaza vb. sebeplerle süresi içinde işlem yapamaması üzerine eski hak getirme talebinde bulunması mümkündür.

Vekil ile takip edilen bir davada, sürenin vekilin elinde olmayan bir sebeple kaçırılmış olmasını da eski hale getirme sebebi olarak kabul etmek gerekir. Örneğin, şehir dışından gelen bir avukatın, hava muhalefeti veya bir kaza nedeniyle duruşmaya katılamaması halinde de vekilin elinde olmayan bir sebep söz konusudur (m. 95, 1).

Dava ehliyeti bulunmayanlar adına yasal temsilci tarafından takip edilen davalarda, yasal temsilcinin yukarıdaki (yani m. 95'deki) gibi bir engelinin (mazeretinin) bulunması halinde de, yasal temsilci, engelin kalkmasından itibaren süresi içinde eski hale getirme talebinde bulunabilir.

Eski hale getirme, kaçırılan sürenin telafi edilebilmesi için öngörülmüştür. O nedenle, eski hale getirme yoluna başvurmadan aynı sonuca ulaşmayı sağlayan başka bir olanak varsa, o kullanılmalıdır (m. 95, 2). Başka bir deyişle, eski hale getirme, en son çaredir. Yani, eski hale getirme talebinin yapılabilmesi (kabul edilebilmesi) için aranan diğer şart, **başka bir hukukî yola başvurma olanağının bulunmamasıdır**. Buradaki "**hukukî yol**"dan kasıt, istinaf ve temyiz gibi kanun yolları değildir. Buradaki hukukî yoldan maksat, davaya bakıldığı sırada, HMK'nun veya hâkimin belirlediği, kaçırılmış olan süre ile düşen hakkın davanın görüldüğü sırada yeniden elde edilmesi için kabul edilmiş olan hukukî imkânlardır. Örneğin, usulsüz tebligatı öğrenen muhatap, tebligatın usulsüz olduğu, bunun da kendi kusurundan kaynaklanmadığını ileri sürerek eski hale getirme yoluna gidemez. Çünkü muhatap, usulsüz tebligatı öğrendiğini bildirdiği zaman, süreler işlemeye başlar; muhataba ayrıca veya yeniden bir tebligat yapılması gerekmez (Teb. K. m. 32). O halde, muhatabın "öğrendiğini bildirmesi", eski hale getirme yoluyla ulaşmak istediği sonucu sağlamaktadır.

III – ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN SÜRESİ

Yukarıda belirtilen şekilde bir kesin süreyi kaçıran taraf, belirli bir süre içerisinde eski hale getirmeyi talep etmelidir. Bu da, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan **engelin ortadan kalkmasından itibaren iki** haftadır (m. 96, 1). Buna göre, örneğin, kaza geçirmesi veya tedavi görmesi nedeniyle davadaki herhangi bir kesin süreyi kaçıran taraf, kazanın ardından tedavisinin tamamlanmasından itibaren iki hafta içinde, eski hale getirmeyi talep etmelidir. Bu süre, hak düşürücüdür.

Davada pek çok işlem art arda sıralanmakta, davanın değişik aşamalarında kesin süreler söz konusu olmaktadır. O nedenle, davanın değişik evrelerinde eski hale getirme yoluna başvurulması ihtiyacı olabilir. Bu bakımdan

kanun koyucu, kural olarak, **en geç nihaî karar verilinceye kadar** eski hale getirme talebinde bulunulabileceğini kabul etmiştir (m. 96, 2).

Burada yalnızca bir halde, nihaî karardan sonra, ancak karar öncesinde kaçırılan bir süre bakımından eski hale getirme yolu açık tutulmuştur. Buna göre, "nihaî karar bir tarafın yokluğunda verilmişse, tahkikat aşamasında kaçırılan süreler için kararın verilmesinden sonra da eski hale getirme talebinde bulunulabilir" (m. 96, 2).

HMK m. 96, 2 hükmü ile, bir tarafın yokluğunda (m. 186) verilen nihaî karardan (hükümden) sonra, tahkikat aşamasında kaçırılmış olan sürelerden dolayı, bir tarafın yokluğunda hüküm vermiş olan mahkemeden eski hâle getirme istenebilir. Ancak, eski hale getirme talebi, hükmün icrasını durdurmayacağından (m. 99), bir tarafın yokluğunda (m. 186) verilmiş hükme karşı işlemeye başlamış olan kanun yolu süresinin işlemesini de durdurmaz. Bu nedenle, eski hale getirme talebinde bulunan taraf, bu talebinin reddi ihtimalini dikkate alarak, kanun yolu süresi içinde yokluğunda verilen hükme karşı kanun yoluna da başvurmalıdır.

Bir hükme karşı kanun yolu süresini kaçırmış olan taraf, m. 95'de düzenlenen şartlar varsa, m. 96'daki iki hafta içinde, üst mahkemeden eski hale getirme isteyebilir (m. 98, 2).

Taraflar, koşulları mevcut olduğu sürece, aynı davada birden fazla eski hale getirme yoluna gidebilirler; Kanunda bu konuda bir sınırlama bulunmamaktadır. Eski hale getirme yolunu taraflar için bir defa ile sınırlayan HUMK m. 174 hükmü, isabetli olarak, HMK'na alınmamıştır.

IV – ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN ŞEKLİ, KAPSAMI VE İNCELENMESİ

Eski hale getirme, dilekçeyle talep edilir; duruşmada yapılan sözlü talepler kabul edilmez, talebin mutlaka yazılı olması aranır (m. 97).

Dilekçede, talebin dayandığı eski hale getirme sebepleri ile bunların delil veya emareleri gösterilir. Buna göre, soyut veya genel bir ifadeyle eski hale getirme talep edilemeyip, ilgili tarafın, mutlaka dayandığı sebepleri ve ayrıca bunların delil veya emaresini göstermesi beklenir. Burada, ileri sürülen mazeretin inandırıcılığını sağlayacak her türlü delil (doktor raporu, kaza tutanağı veya tanık) söz konusu olabilir.

Eski hale getirme talebinde bulunan tarafın talepte bulurken, aynı zamanda **süresinde yapılamayan işlemi** de eski hale getirme talebinde bulunmak için öngörülen **süre içinde yapması zorunlu**dur. O halde eski hale getirme talebinde bulunan taraf, henüz bu talebi hakkında karar verilmese dahi, hatta talebinin kabul edilmeme olasılığı da bulunsa, yine de bu süre içinde, süresinde yapamadığı işlemi de yapmak zorundadır (m. 97). Buna göre, süresi içinde delil avansı yatıramayan veya cevap dilekçesi veremeyen taraf, eski hale getirme talebinde bulunabileceği iki hafta içerisinde, aynı zamanda cevap dilekçesi vermek veya delil avansını yatırmak zorundadır.

Yapılamayan işlem için eski hale getirme, bu işlem hakkında hangi mahkemede inceleme yapılacak idiyse, o mahkemeden talep edilir (m. 98, 1).

Yargılama sırasında kaçırılan süreler için, kural olarak yargılamayı yapan mahkemeye başvurulur. Buna karşılık, kanun yoluna başvuru süresi kaçırılmışsa, kanun yolu incelemesini yapacak mahkemeden eski hale getirme talep edilir. Buna göre, örneğin, istinaf süresini elinde olmayan nedenlerle kaçıran taraf, bu konudaki mazeretini ve delillerini istinaf (bölge adliye) mahkemesine başvurmak suretiyle eski hale getirme ister (m. 98, 2).

Hükmün verilmesine kadar herhangi bir aşamada, bir tarafın elinde olmadan kesin bir süreyi kaçırması ve bu nedenle de, yargılamanın çok ileri bir aşamasında da eski hale getirme talebinde bulunması söz konusu olabilir. Bu durumda eski hale getirme talebinin, mevcut yargılamayı etkileyip etkilemeyeceği önemli bir sorundur. Kanun, eski hale getirme talebinin yapılmış olmasının, kural olarak, yargılamanın ertelenmesini gerektirmeyeceğini veya hükmün icrasına engel olmayacağını kabul etmiştir (m. 99). Ancak, talebi inceleyen mahkeme, talebi haklı görürse, teminat gösterilmek şartıyla, yargılamanın ertelenmesine veya hükmün icrasının geri bırakılmasına karar verebilir. Mahkeme, gerektiğinde teminat gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine veya icranın geri bırakılmasına karar verebilir (m. 99).

Eski hale getirme talebini inceleyecek mahkeme ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ise, bunu, ön sorunlar hakkında hükümlere (m. 163-164); Yargıtay ise, temyiz usulüne göre inceler (m. 100).

Eski hale getirme talebini inceleyen mahkeme, diğer tarafı, eski hale getirme talebinden haberdar ederek, somut olayın gerekleri çerçevesinde mümkün olduğunca ivedi bir şekilde karar verir.

Mahkemenin eski hale getirme talebini kabul etmesi halinde, bu kez, o ana kadar yapılan işlemlerin kaderi ve yargılamanın bundan sonraki seyrinin nasıl olacağı sorunu ortaya çıkar. Bu halde mahkeme, hangi işlemlerin geçersiz hâle geldiğini kararında belirtir. Islahla geçersiz kılınamayan işlemler, eski hale getirme talebinden de etkilenmez (m. 100, 2). Örneğin, davalının cevap veremediğini, ancak ön inceleme duruşmasından önce davalının bu talepte bulunduğunu varsayalım. Hâkimin talebi kabul etmesi üzerine bu kez, davalının cevap dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesi gerekir ve davalının ikinci cevap dilekçesi verme hakkı doğar (m. 136). O nedenle, bir anlamda süreç geriye döner. Yargılamanın daha ileri bir aşamasında kaçırılan bir süre söz konusu ise, hâkimin o ana kadar pek çok işlem yaptığı düşünülecek olursa, talebin kabulü ile bu işlemlerin bir kısmı gereksiz kalır. İşte hâkim, bu işlemler hakkında da bir karar verir. Ancak, eski hale getirme talebinin kabulü ile, kural olarak mahkemenin veya karşı tarafın işlemleri, yapılmamış hale getirilemez (m. 100, 2; 179, 2-3).

Bir tarafın, süresi geçtikten çok sonra mazereti nedeniyle eski hale getirmeyi talep etmiş olduğu hallerde, karşı taraf ve mahkeme de bir kısım işlemlerin kesinleştiğine güvenerek diğer işlemleri yapmaya devam etmekte olabilir. Ne var ki, bu talebin kabulü halinde, hâkim, bazı işlemleri geçersiz sayar. İşte bu durumda önceki işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, dava sonunda kime yükletileceği sorunu çıkar. Çünkü, yargılama giderleri, kural olarak davada haksız çıkan tarafa yükletilir (m. 326). Kanun koyucu burada,

genel kuraldan ayrılma ihtiyacı duymuş ve eski hale getirme talebi sebebiyle ortaya çıkan giderlerin talepte bulunan tarafça üstlenileceğini kabul etmiştir. Ancak, karşı taraf eski hâle getirme talebine karşı asılsız itirazlar ileri sürerek giderlerin artmasına sebep olmuşsa, hâkim, giderlerin tümünün veya bir kısmının karşı tarafa yükletilmesine karar verebilir (m. 101).

§ 8. TEBLİGAT[1]

A) TEBLİGATIN AMACI VE ÖNEMİ

Tebligat, muhataba yapılan bildirimin yazılı olarak belgelendirilmesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tebligat, sürelerin başlangıcını tespit bakımından da son derece önemlidir (m. 91). Ancak tebligat (tebliğ) ve tebellüğ kavramları birbirinden ayrıdır. Bir hususun muhataba bildirilmek üzere hazırlanıp tebliğe çıkarılması, muhatap açısından süreyi başlatmaz. Tersine, muhataba belgenin ulaştığı ve bunun belgelendirildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır ve muhatap bakımından süre, tebellüğden itibaren işler.

Öte yandan tebligat, hukukî dinlenilme hakkının bir unsuru olan "bilgi sahibi olma" hakkının gerçekleşmesini sağlar. Nitekim Yargıtay da, kararlarında, "taraf teşkili" sağlanmadan herhangi bir işlem yapılamayacağını özellikle belirtmektedir. Ancak tebligat, yalnızca dava dilekçesinin davalıya tebliği ve böylece taraf teşkili için kullanılmaz; davanın çeşitli aşamalarında taraflara tebligat yapılması mümkündür.

Tebligat, 7201 sayılı **Tebligat Kanunu** hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veya memur aracılığıyla yapılır. Buna göre, yargı mercileri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre yapılır (Teb. K. m. 1).

Tebligat Kanunu'nun uygulama şeklini gösteren Tebligat **Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik**[2] ve **Elektronik Tebligat Yönetmeliği**[3] vardır.

HMK, tarafların ve üçüncü kişilerin duruşmaya davetlerini de düzenlemektedir. Mahkemenin, bir kimseyi taraf, taraf vekili, tanık veya bilirkişi olarak huzuruna çağırmasına **davet**, davetin yazılı şekline de **davetiye** denir.

Davetin davadaki önemi büyüktür. Mahkeme, tarafları dinlemeden ve onları iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için usulüne uygun olarak davet etmedikçe hükmünü veremez (m. 27). Taraflar, özellikle ön inceleme duruşmasına (m. 139) ve diğer ilk duruşmaya davetiye ile davet edilmelidir. Bundan sonraki duruşmalar için, taraflara davetiye gönderilmesine gerek yoktur; sonraki oturum günü duruşmada kendilerine sözlü olarak bildirilir (tefhim olunur).

---

1 Bkz: Ejder Yılmaz/Tacar Çağlar, Tebligat Hukuku, Ankara 2013.
2 RG 25.01.2012, sa. 28184.
3 RG 06.12.2018, sa. 30617.

Davet (çağrı) **ile tebliğ** (tebligat), **aynı şeyler değil**dir. Davet, bir kimsenin mahkeme huzuruna çağrılmasıdır. Bu davet ile birlikte, o kimseye duruşma gününden başka bir tebligat da yapılabilir; örneğin, davalıya tebliğ olunan dava dilekçesi ile birlikte aynı zamanda davalı duruşmaya da davet edilir. Fakat her tebliğ, bir daveti kapsamaz; örneğin, hükmün taraflara tebliği gibi.

Davet, bir davetiye ile yapılır. Davetiyeye neler yazılacağı Tebligat Kanunu (m. 9) ve Tebligat Yönetmeliğinde (m. 14) gösterilmiştir: 1) Tarafların kimlikleri ve adresleri, 2) Kısaca tebliğin konusu, 3) Davet edilen kimsenin hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması gerektiği ve bu merciin yeri, 4) Davetiyeyi çıkaran mahkemenin mühürü ve yazı işleri müdürünün imzası.

B) TEBLİGAT YAPILMA ŞEKİLLERİ

Tebligat, yazılı, memur eliyle veya elektronik yolla olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Yazılı tebligat, PTT eliyle yapılmaktadır. Yargı organları bakımından ayrı bir adlî tebligat yapılanması bulunmadığından, diğer posta hizmetleri içerisinde adlî tebligat da yürütülmektedir.

Tebligat, kural olarak **PTT tarafından** yapılır (Teb. K. m. 1; Teb. Yön. m. 4). Bu kuralın bazı **istisnaları** vardır:

Adlî ve idarî yargı mercileri ile diğer adalet daireleri kendiliğinden (resen) veya talep halinde işin niteliğine göre, dairelerinde çalışan **memurlar aracılığıyla tebligat** yapılmasına karar verebilirler (Teb. K. m. 41). Bu husus, tamamen mahkemenin takdirine bağlı olup, kendi memuru aracılığıyla tebligat yapılmasına karar veren mahkeme, bunun gerekçesini de gösterir. Bu tür tebligat, daha hızlı olmakla birlikte, iş yoğunluğu nedeniyle çok az kullanılan bir yöntemdir.

Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya ertelenmesinde sakınca olacak işlerde veya **aynı yerde bulunan** Teb. K. m. 1'de yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan kişilere yapılacak tebligat, o müesseselerin kendi memurları veya mahallî mülkî âmirin emriyle zabıta aracılığıyla yaptırılır (Teb. K. m. 2; Teb. Yön. m. 4).

Oturum (duruşma) **esnasında** veya kalemde, davaya ait belgelerin taraflara, ilgili üçüncü kişilere, müdahile veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir (Teb. K. m. 36; Teb. Yön. m. 58).

Oturum (duruşma) esnasında, mahkeme tarafından sıfatları usulen tespit edilen avukat sekreterlerine ve stajyerlerine (karş. AK m. 46), müteakip **oturum gün ve saatinin bildirilmesi, avukata tebliğ hükmünde**dir (bkz. Teb. K. m. 37; Teb. Yön. m. 59).

Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, **vekiller makbuz mukabilinde** birbirlerine tebligat yapabilirler (bkz. Teb. K. m. 38; Teb. Yön. m. 60). Bundan başka avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adlî kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kâğıt ve belgelerin birer nüshası,

gerekli harç, vergi ve resim ödemek şartıyla, ilgili yargı merciinin dosyasına konur (AK m. 56, IV).

Kanunda (Teb. K. m. 7/a, I) açıkça belirtilen gerçek ve tüzel kişilere (01.01.2019 tarihinden itibaren) **tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu**dur. Bu kişiler arasında baro levhasına kayıtlı **avukatlar**, sicile kayıtlı **arabulucular** ve **bilirkişiler, noterler** ile **adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri** veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimler de vardır[4].

Ayrıca Kanunun açıkça belirttiği kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, **elektronik yolla tebligat** olanağı vardır[5] ve talepleri hâlinde kendilerine elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. Elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde tebligat, Tebligat Kanunu'nda belirtilen diğer usullerle yapılır (Teb. K. m. 7/a, II-III)

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen **beşinci günün sonu**nda yapılmış sayılır (Teb. K. m. 7/a, IV; Elektronik Tebligat Yön. m. 9, 6. Muhatabın elektronik tebligatı açtığı veya gördüğü tarihin önemi olmayıp, tebligat, muhatabın elektronik postasına ulaştığı tarihten itibaren beşinci gün sonunda yapılmış sayılacağı için, süreler de bu tarihten işlemeye başlar. Yukarıdaki istisnalar dışında tebligat, PTT tarafından yapılır. Ancak, tebligatın PTT tarafından yapılması, Türkiye'de yapılacak tebligat hakkındadır.

Yabancı bir ülkede tebligat, o ülkenin yetkili makamı aracılığıyla yapılır. Bunun için anlaşma[6] varsa veya o ülke kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasî memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan ister (Teb. K. m. 25)[7]. Ancak kendisine yabancı ülkede tebligat yapılacak kimse Türk vatandaşı ise, tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya konsolosu aracılığıyla da yapılabilir (Teb. K. m. 25/a). Bu (m. 25/a) maddeye göre mahkemeler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.

---

4 Kanunda (Teb. K. m. 7/a'da) sayılan **diğer kişiler** şunlardır: Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler; özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları; kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri; idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları.

5 Bkz. Elektronik Tebligat Yön. m. 9-16.

6 "Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin **Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme**" Türkiye tarafından da onaylanmıştır (bkz. 1483 s. K.: RG 17.09.1971, sa. 13959). Bu sözleşmenin Türkçe ve Fransızca metinleri için bkz. RG 17.06.1972, sa. 14218. Bu sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı genelgesi için bkz. RG 23.03.1972, sa. 14137, s.10-11. Bundan başka, Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi'nin 1-7. maddeleri, adlî ve gayri adlî evrakın tebliğini düzenlemektedir.

7 Yabancı ülkelerde yapılacak veya yabancı ülkelerden gelecek veya Türkiye'de yabancılara yapılacak tebligat hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Teb. K. m. 25-27; Teb. Yön. m. 38-47.

Bu halde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar. Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinden, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat, otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap, Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde, tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir (Teb. K. m. 25/a).

Yabancı ülkelerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir (Teb. K. m. 25, II). Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça (Adalet Bakanlığınca) doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir (Teb. K. m. 25, III).

C) TEBLİGATIN NEREDE VE NASIL YAPILACAĞI

I – GENEL OLARAK

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, **bilinen en son adresi**nde yapılır. Ancak, kendisine tebliğ yapılacak kişinin başvurusu veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması da mümkündür (Teb. K. m. 10). Bu nedenle tarafların önceden veya tebligat anında, tebligatı kabul etmek suretiyle, tebligat adresi konusunda anlaşma yapmaları mümkündür. Bunun dışında ise, tebligatın bilinen en son adrese yapılması gerekir.

"Adres" ile "yerleşim yeri" kavramları da birbirinden farklıdır. Adres, bir kişiye doğrudan ulaşılabilecek bilgileri içeren açıklamalardır. Bir kişinin bir yerleşim yeri bulunması gerekirken, birden fazla adresi bulunabilir. Ayrıca yerleşim yeri, doğrudan doğruya adresi ifade etmez. Örneğin, bir kişinin yerleşim yerinin Ankara olduğu bilgisi, tebligat yapılabilmesi bakımından yeterli değildir.

II – TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİ, ADRES VE TEBLİĞ TARİHİ

Tebligatın, muhatabın bilinen en son adresine yapılması ve böylece muhataba ulaşılması amaç olmakla birlikte, bu konudaki zorluklar, kanun koyucuyu bazı varsayımları kabule zorlamış, bir yandan da bireyleri bazı yükümlülükler altına sokmuştur. Bunlardan birisi de İçişleri Bakanlığı nezdinde tutulan, adrese dayalı merkezi **nüfus** (adres) **kayıt sistemi**ne (MERNİS) bir adres bildirme zorunluluğudur. Böylece, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır (Teb. K. m. 10, II).

Ancak burada ilk olarak, muhatabın bilinen adresine tebligat yapılmaya çalışılmalıdır; bu adreste tebligat yapılamazsa, o takdirde muhatabın MERNİS kaydındaki adresine yapılan (bilinen en son adres kabul edildiği için) tebligat geçerli ve usulüne uygundur. Dolayısıyla bir kimsenin doğrudan doğruya MERNİS adresine tebligat yapılması mümkün olmayıp MERNİS adresine tebligat, ikincil bir yol veya çare olarak kullanılır.

Usulüne uygun tebligatın gerçek ve tüzel kişiler bakımından nasıl ve ne şekilde yapılacağı ayrı ayrı düzenlenmiş, burada da farklı olasılıklar gözetilmiştir.

Gerçek kişiler bakımından, muhatabın bizzat kendisine tebligat yapılması gerekir. Ancak her zaman ve her durumda muhataba ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle kanun koyucu, muhatap yerine tebligat yapılabilecek kişileri de düzenlemiştir. Buna göre, örneğin, kendisine tebliğ yapılacak kişi adresinde bulunmazsa tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır (Teb. K. m. 16).

Muhatap yerine başka bir kişiye tebligat yapılabilmesi için, bu kişinin muhatapla birlikte aynı konutta yaşaması gerekir. Aynı konut, ortak ev anlamına gelip, bir apartman dairesindeki komşu veya apartman görevlisi, muhatap yerine tebligat yapılabilecek bir kişi değildir. Çünkü bu kişiler, aynı konutta yaşamamaktadırlar. Aynı konutta muhatap yerine tebligat yapılabilecek kişi ile muhatap arasında bir kan bağı veya yakınlık olması gerekmez. Bu nedenle muhatabın ev arkadaşına da tebligat yapılabilir. Öte yandan muhatap yerine tebligat yapılacak kişinin o konutta "devamlı" olarak oturuyor olması gerekir. O nedenle geçici olarak o evde bulunan bir kimseye veya konuğuna (misafire) tebligat yapılamaz. Teb. K. m. 16'da belirtilen "hizmetçi" ise, o eve günübirlik gelen yardımcıyı değil, o evde sürekli olarak ve bir iş ilişkisiyle bulunan kişiyi ifade eder.

Muhatapla aynı konutta oturan ve muhatap yerine tebligat yapılabilecek kişinin görünüş itibariyle **on sekiz yaşından aşağı olmaması** ve belirgin bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması da gerekir (Teb. K. m. 22). Bu düzenlemenin amacı, muhatap yerine tebligatı alan kişinin, tebligatın önemini kavrayıp, onu muhataba ulaştırması gerektiği bilincine sahip olması düşüncesine dayanır. Bu nedenle, çocuk veya ehliyetinden kuşku duyulan bir yaşlıya tebligat yapılmamalıdır.

Muhatap yerine tebligatı kabul edebilecek kişilere tebligat yapılabilmesinin de istisnası bulunmaktadır. Muhatap ve tebligatı almaya yetkili kişinin aynı davada hasım (karşı taraf) olması halinde, bu kişiye tebligat yapılamaz (Teb. K. m. 39). Örneğin, aynı evde yaşayan kadın, kocası adına tebligatı almaya yetkili olmakla birlikte, kendisinin açtığı boşanma davasının dilekçesini muhatap adına alamaz.

Muhatap veya muhatap yerine kendisine tebligat yapılabilen kişiye tebliğ evrakı verilir, bu kişilerin imzası alınır ve bu husus, tebliğ memuru tarafından tutulan tutanakta belirtilir. Bu tarih, muhatabın evrakı tebellüğ tarihi olup, tebliğle işlemeye başlayan süreler, bu andan itibaren işleyecektir.

Muhatabın adresine gelindiğinde her zaman muhatap veya muhatap adına tebligatı kabule yetkili kişileri bulmak mümkün olmayabilir veya bu kişiler evrakı almaktan kaçınabilirler. Bu durumda tebligatın nasıl gerçekleştirileceği de ayrıca ele alınmıştır.

İlk olarak, **muhatap** veya muhatap yerine kendisine tebligat yapılacak kişilerden birisi **adreste bulunmazsa** (örneğin, gelinen adreste hiç kimse bulunmaz, kapı açılmazsa) veya bulunmasına rağmen, **tebligatı almaktan kaçınırsa**, tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tekrar söz konusu adrese geri gelir. Bu kez, evrakı alan kişinin (tesellüm edenin) adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır ve aynı zamanda, yalnızca adreste bulunmama haline özgü olmak üzere, tebliğ olunacak kişiye haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. **İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih,** tebliğ tarihi sayılır (Teb. K. m. 21, 1). Muhatap, tebligatı almaktan kaçınmış ve evrak muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birisine teslim edilmişse, artık komşu, yönetici veya kapıcıya haber verme koşulu bulunmayıp, yalnızca ihbarnamenin kapıya yapıştırılmasıyla yetinilecektir. Çünkü, tebligatı kabulden kaçınan muhatap veya muhatap adına tebligatı kabule yetkili kişi, tebligattan haberdar olmuştur. Bu şekilde tebligat yapılması durumunda, kapıya yalnızca ihbarname yapıştırılır ve bu tarih, tebliğ tarihi kabul edilir. Ancak ilgilinin, tebligatın içeriğini öğrenebilmesi için, ihbarnamede belirtilen kişi ve adrese başvurup evrakı alması gerekir. İlgili, evrakı daha sonraki bir tarihte almış ve içeriğini geç öğrenmiş olsa bile, tebligat, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı o gün itibariyle yapılmış sayılır ve süreler işlemeye başlar.

Burada karşılaşılabilecek bir başka olasılık, gösterilen adrese gelindiğinde, bu adresin **muhataba ait olmadığı** veya onun bu adresten taşınmış olduğu ya da muhatabın bu adreste hiç yaşamamış olduğu gerekçesiyle **tebligatın yapılamamasıdır.** Muhatabın bilinen en son adresine tebligat yapılması kural olduğu için, esasen muhatabın oturmadığı veya ona ait olmayan adrese tebligat yapılamaz. Bu durumda tebliğ memurunun komşu, yönetici veya diğer kişilerden de sormak suretiyle yeni adresi tespit etmeye çalışması gerekir. Dolayısıyla kural olarak muhataba ait olmayan bir adrese tebligat yapılamaz. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, Tebligat Kanunu, bir varsayım olarak MERNİS'te yer alan (adres kayıt sistemindeki) adresi, bilinen en son adres olarak kabul etmiş (Teb. K. m. 10) ve kişilere bir yükümlülük getirmiştir. Buna göre, gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti üyesinden birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi, gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır (Teb. K. m. 21, II).

Her iki durumda da, kendilerine evrak teslim edilebilecek muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri, zabıta amir ve memurları, kendilerine verilen evrakı kabul etmek zorundadırlar (Teb. K. m. 21, III).

Tebligat konusunda sık karşılaşılan olasılıklardan birisi de, muhatap adına tebligatı kabule yetkili kişilerin, **muhatabın adresten geçici olarak ayrıldığını** bildirmeleridir. Örneğin, muhatabın eşi, muhatabın altı ay için yurt dışında gittiğini belirtebilir. Bu beyana rağmen, tebligatı kabule yetkili kişiler, tebliğ edilen evrakı almak zorundadırlar. Tebliğ memuru, ilgilinin bu beyanını tebliğ tutanağına yazarak, evrakı kendisine verir ve bu kişiler evrakı almak zorundadırlar. Bu evrakı aldıkları takdirde, bu tarihte muhatabın kendisine tebligat yapılmış sayılır. Ancak bu kişiler, evrakı almaktan veya beyanlarını imzadan kaçınırlarsa, tebliğ eden kaçınmaya ilişkin bu beyanı tutanağa yazıp imzalar. Tebliğ evrakını kabulden **kaçınma** halinde tebligat, yukarıda belirtilen Teb. K.'nun 21. maddesine göre yapılır. Ancak burada yukarıdaki durumdan farklı olarak, tebliğ tarihi farklı olabilir. Şöyle ki, muhatap adına tebligatı kabule yetkili kişi, evrakı alırsa, bu tarih, tebliğ tarihi olacaktır. Buna karşılık, muhatap yerine tebligatı kabule yetkili kişi, evrakı kabul etmemiş ise, tebliğ memuru, evrakı, muhtar veya ihtiyar heyeti ya da zabıta amir veya memurlarına bırakır ve muhatabın kapısına da ihbarname yapıştırır. Bu halde tebligat, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren **on beş gün sonra yapılmış sayılır** (Teb. K. m. 20).

Her durumda tebligatın yapılıp yapılmadığı veya kime yapıldığı ile tebligata ilişkin diğer hususlar **tebliğ mazbatasında** gösterilir (Teb. K. m. 23).

Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda (işlerde) tebligat mutlaka **vekile yapılır**[8]; **asıla** (müvekkile) **yapılamaz**. Vekil varken, asıla yapılan tebligat usulsüzdür. Bir kişinin birden fazla vekili varsa, tebligat bunlardan birine yapılır (Teb. K. m. 11, I). Avukat tarafından takip edilen işlerde avukatın bürosuna yapılacak tebligatın resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılması gerekir (Teb. K. m. 11, II).

Vekile yapılan tebligatın geçerli olması için, vekilin bu sıfatla davaya bizzat katılmış olması gerekir. Örneğin, vekâleten dava açmış, cevap dilekçesi vermiş veya duruşmaya gelerek vekâletnamesini verip vekil sıfatıyla yargılamada bulunmuş olmak gibi. Bir kimsenin genel vekiline yapılacak tebligat (eğer genel vekil henüz davaya katılmamışsa) ancak genel vekilin kabulü halinde mümkündür. Çünkü, genel vekilin müvekkilini her davada temsil etmek zorunluluğu yoktur. Buna karşılık, bir davayı takip etmiş olan vekilin yetkisi bu dava sonucunda verilen hükmün icrasını da kapsadığından (HMK m. 73), icra emrinin (bkz. İİK m. 24 vd.) davayı takip etmiş olan vekile tebliğ edilmesi gerekir.

Dava ehliyeti bulunmayanlara (yasal temsilcileri bulunanlara) yapılacak tebligat, bunların yasal temsilcilerine yapılır[9].

---

[8] Bkz. Teb. K. m. 11, I; Teb. Yön. m. 18, I; 10.07.1940 gün ve 7/75 sayılı İBK (RG 30.09.1940, sa. 4625).

[9] Bkz. Teb. K. m. 11, II; Teb. Yön. m. 19. Dava ehliyeti bulunmayan ve yasal temsilcisi olmayanlara (yasal temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere, TMK m. 404 vd.) usulü daire-

Resmî tatil günlerinde ve adlî tatil sırasında da tebligat yapılabilir (Teb. K. m. 33, IV; Teb. Yön. m. 55). Gece vakti de tebligat yapılabilir (bkz. Teb. K. m. 33; Teb. Yön. m. 54).

III – TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT

Tüzel kişilere nasıl tebligat yapılacağı da ayrıca düzenlenmiştir. Burada muhatap, tüzel kişi olduğu için muhatap adına tebliğ evrakını kimin alabileceği önemlidir.

Tüzel kişilerin **yetkili temsilcileri,** tebligat yapılabilecek gerçek kişilerdir. Birden fazla yetkili temsilcisi varsa, bunlardan yalnızca birisine yapılması yeterlidir (Teb. K. m. 12). Yetkili temsilcilerin bizzat tebligatı alamaması halinde tebligat, o tüzel kişinin memur veya çalışanlarına yapılır (Teb. K. m. 13). Buna göre, örneğin, bir belediyeye yapılacak tebligat, yetkili temsilci olan belediye başkanına yapılacaktır. Ancak genellikle tüzel kişilerde bir evrak birimi oluşturulmuştur ve tebligat buradaki görevlilere yapıldığı an, yetkili temsilciye yapılmış sayılır.

IV – TEBLİGATTA ÖZEL BAZI DURUMLAR

Tebligat konusunda çeşitli özel durumlarla karşılaşılabilmektedir. Örneğin, muhatabın hastanede olması, tutuklu veya asker olması, öğrenci olup da yurtta kalması gibi hallerde, muhataba doğrudan doğruya ulaşılması zor olabilmektedir. Bu durumlarda tebligatın nasıl yapılacağı ayrıca düzenlenmiştir (Teb. K. m. 14, 15, 17, 18, 19).

Uygulamada önem taşıyan ve sıkça karşılaşılan bir başka durum ise, dava sırasında adres değişikliğidir. Dava açıldıktan sonraki yerleşim yeri değişiklikleri mahkemenin yetkisini etkilememekle birlikte, adresini değiştiren davalı veya davacının, artık yeni adresine tebligat yapılması gerekir. Çünkü adil yargılanma hakkı gereği taraflar, bilgi sahibi olma hakkına sahiptirler. Ancak burada, davanın başında olduğu gibi bir adres araştırmasına girişilmez. Çünkü, kendisine Tebligat Kanunu'nun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, **adresini değiştirirse**, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan mahkemeye bildirmek zorundadır. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır (Teb. K. m. 35, I).

Burada, taraflarca yeni adresin bildirilmemesi halinde sorun çıkmaktadır. Örneğin, davacının daha önce tebligat yapılan adresine isticvap davetiyesi gönderilmiş ve davacının o adreste oturmadığı veya taşındığı ifade edilerek tebligat evrakı geri dönmüştür (bilâ tebliğ gelmiştir). Bu durumda mahkeme, davacının yeni adresini tespit etmek için araştırma yaptırmaz, yalnızca davacının MERNİS'te (adres kayıt sisteminde) bir adresinin bulunup bulunmadığına bakar. Eğer burada bir adres varsa oraya tebligat yapılır; burada bir adres yoksa, bu takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir örneği, ilk tebligat yapılan (eski adrese ait) **binanın kapısına asılır** ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayı-

---

sinde yasal temsilci tayini (TMK m. 411, 419, 426) cihetine gidilir ve tebligat, tayin edilen bu yasal temsilciye yapılır (bkz. Teb. Yön. m. 19, 2).

lır. Ayrıca bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır (Teb. K. m. 35, II-III). Buradaki düzenleme gerçek kişiler bakımından olup, tüzel kişiler için, daha önce hiç tebligat yapılmamış olsa bile, resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır (Teb. K. m. 35, IV).

V – İLÂNEN TEBLİGAT

Adil yargılanma hakkı, muhatabın bilgisine ulaşacağına güvenilen bir yöntemle tebligatın yapılmasını gerektirir. Bu bakımdan değişik olasılıklar gözetilerek ve araştırmalar yapılarak muhataba ulaşılmaya çalışır. Bu konudaki yetki, mahkemeye aittir. Mahkeme, tapu sicil müdürlüğü, bankalar resmî kurumlar, kuruluşlar veya telefon şirketleri gibi çeşitli yerlere veya tebligat talep eden tarafın bildirdiği adreslere müzekkere yazmak suretiyle muhataba ait bir adres bulmaya çalışır. Bütün bu çabalar sonuç vermez ve muhatabın MERNİS'te kayıtlı bir adresine de ulaşılamazsa, tebligatta **son çare**, tebligatın ilânen yapılmasıdır. Böylece alenî bir şekilde tebliğ konusunun muhataba bildirilmesi amaçlanmaktadır. İlânen tebligat yapılabilmesi için muhatabın adresinin "**meçhul**" olması gerekir. Tebliğ memurunun tebligat yapamaması ve yukarıda belirtilen usullerle mahkeme tarafından yaptırılan araştırmaların sonuçsuz kalması üzerine, bu durum tutanak altına alındığında, muhataba ilânen tebligat yapılabilir (Teb. K. m. 28).

Bir kimsenin yurt dışında yaşıyor olması, adresinin bilinmediği anlamına gelmez; ona karşı yurt dışı tebligat usulüne uyulmak suretiyle tebligat yapılması gerekir.

İlânen tebligatın nasıl yapılacağına mahkeme karar verir. Bu konuda ilgililerin öğrenebilmelerine en elverişli araç ne ise ona başvurulması uygun olur. Bu ilân genellikle gazete yoluyla yapılmaktadır. İlan için Basın İlan Kurumuna başvurulmakta ve mahkemenin belirlediği ölçütler çerçevesinde yurt çapında dağıtımı yapılan belirli tirajlı gazetelerde ilânen tebligat yaptırılmaktadır. İlânen tebligat, ayrıca elektronik yolla da yapılmaktadır (Teb. K. m. 29-30).

İlânen tebliğ, **son ilân tarihinden itibaren yedi gün sonra** yapılmış sayılır. İlânen tebliğe karar veren mahkeme, duruma göre daha uzun bir süre belirleyebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez (Teb. K. m. 31).

VI – USULSÜZ TEBLİGAT

Yukarıda kısaca değinildiği gibi, tebligatın yapılma biçimi, ayrıntılı ve şekilci bir düzenlemeye konu olmuştur. Bu nedenle tebliğ memuru tarafından yapılacak en küçük hata, tebligatı "usulsüz" hale getirir. Ancak, **usulsüz tebligat, "geçersiz" tebligat anlamına gelmez**. Nitekim Tebligat Kanunu, "tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır" diyerek (Teb. K. m. 32), muhatabın öğrenmiş olması halinde tebligatı geçerli saymakta, usulsüz tebligatın adeta iyileştiğini (usulüne uygun duruma geldiğini) kabul etmektedir. Ancak, temelde tebligat usulsüz olduğundan, yani mevzuatta öngörülen yöntem izlenmeden yapıldığından, bu noktada, **muhatabın öğrendiğini bildirdiği tarih,** tebliğ tarihi sayılmaktadır.

Ayrıca usulsüz tebligat alan ve öğrendiğini bildiren tarafın, kendisine yeniden ve usulüne uygun bir tebligat çıkarılmasını istemek veya bunu beklemek gibi bir hakkı bulunmamaktadır. **Usulsüz de olsa, tebligatı alan kimse** (öğrendiğini beyan ettiği) bu tarihten itibaren, o işlem için **öngörülen sürede gereğini yapmazsa hakkını kaybedebilir.** Örneğin, apartman görevlisine yapılan tebligatı aynı gün alan kişi, bu tarihten itibaren gerekli işlemi yapmalıdır. Bu tebligatın usulsüz olması, tebligatı alan veya öğrenen muhatap bakımından sürenin işlemesine engel olmaz.

Muhatap (yukarıdaki örnekte davalı), usulsüz tebliği öğrenememişse, tebligat (örnekte apartman görevlisine yapılan tebligat) yapılmamış sayılır (Teb. Yön. m. 53, 1). Muhatabın usulsüz tebliği öğrenip öğrenmediği ve öğrenmişse bunun tarihi, **muhatabın kendi beyanına göre** tespit edilir. Yoksa, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatına izin verilmemektedir (Teb. Yön. m. 53, 3).

Usulsüz tebliğ ve onun muhatabın öğrenmesi ile geçerli hale gelmesi, yapılmış ve fakat usulsüz olan tebliğler içindir. Buna karşılık, (usulsüz de olsa) **henüz hiç bir tebligat yapılmamış ise,** Teb. K. m. 32 hükmü uygulanmaz; yani, muhatabın kendisine tebliğ edilecek olan hususu tebliğden başka bir şekilde öğrenmesi ile o husus kendisine geçerli biçimde tebliğ edilmiş sayılmaz.

D) TEBLİGAT SUÇLARI

Tebligat Kanunu'nun önemli özelliklerinden biri de, bazı tebligat suçları kabul etmiş olmasıdır. Bu suçlar şunlardır: Yanlış adres bildirilmesi (Teb. K. m. 53); kendisine yapılması gereken tebligatı almamak (m. 54, II); muhatap adına kendilerine tebligat yapılan kimselerin, tebliğ evrakını muhataba vermemeleri (Teb. K. m. 54); yalan beyan (Teb. K. m. 55): (a) Muhatabın kendisi hakkında yalan beyanda bulunması; (b) Muhatap adına kendisine tebligat yapılabilecek kimselerin, tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunmaları; (c) Muhatap olmadığı veya muhatap adına tebellüğ etmeye yetkili bulunmadığı halde, tebliğ memuruna kimliği ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını almaları; tebliğ evrakının taliki (asılması) ile ilgili suçlar (Teb. K. m. 56).

Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği, tebliğin muhatabına ulaşması ve onun tarafından kabul edilmesi için etkili tedbirler almıştır. Ancak Tebligat Kanunu; bu Kanunu ve Tebligat Yönetmeliğini uygulayan (tebligatı yapan) memurların tebligatı en kısa bir zamanda düzenli bir şekilde yapmalarını sağlamak için hemen hiçbir tedbir öngörmemektedir. Bu yüzden uygulamada adlî tebligattan şikâyet edilmektedir. Kanımızca, davaların uzun sürmesinin en önemli sebeplerinden biri de, adlî tebligatın çok ağır işlemesidir. Bunu önlemek için, adlî tebliğleri en kısa zamanda yapmayan memurlar ve Tebligat Kanunu'na uymayarak tebligatı uzatan ilgililer hakkında yeterli cezaî hükümler konulmalıdır.

Öte yandan, tebligat mevzuatının incelikleri ve özelliklerinin yeterince bilinmemesi de usulsüz tebliğlere yol açmaktadır. O nedenle, mümkünse adlî tebligat yapılanmasının ayrıca oluşturulması son derece yararlı olacaktır.

MAHKEMELERİN GÖREV ve YETKİSİ

Belirli bir davaya, aynı yargı yolundaki (kolundaki, çeşidindeki) ilk derece (hüküm) mahkemelerinden hangisinin bakacağını düzenleyen kurallara, **görev** ve **yetki kuralları** denir.

Bir davaya hangi (adlî veya idarî) yargı yolundaki mahkeme tarafından (örneğin hukuk mahkemesi tarafından mı, yoksa idare mahkemesi tarafından mı) bakılacağı hususu, görev değil, "**yargı yolu**" ilişkisidir; fakat uygulamada yargı yolu ilişkisine de (hatalı olarak) görev ilişkisi de denilmektedir.

Elinizdeki kitabın konusu medenî yargı olduğu için, burada hukuk mahkemelerinin görev ve yetkisi incelenecektir; yani, belirli bir hukuk davasına hangi yerdeki hangi hukuk mahkemesi tarafından bakılacağını düzenleyen kurallar (görev ve yetki kuralları) açıklanacaktır. Örneğin, açmayı düşündüğümüz bir dava için hangi yerdeki hukuk mahkemesine başvuracağız? (yetki). Bunu tespit edince, davayı o yerdeki (genel, özel) hukuk mahkemelerinden hangisinde açacağız? (görev). İşte bu iki soruya, yetki ve görev kuralları cevap verir.

Görev, bir davaya o yerdeki (il veya ilçedeki) hukuk (hüküm) mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir. Yukarıda görüldüğü gibi, bir yerdeki hüküm mahkemeleri, genel ve özel görevli mahkemeler olmak üzere ikiye ayrılır. İşte **hangi** davalara genel görevli **mahkeme**de ve hangilerine özel görevli mahkemelerde bakılacağı hususuna görev, bunu düzenleyen kurallara da görev kuralları denir.

Yetki ise, davaya hangi yerdeki görevli hüküm (hukuk) mahkemesi tarafından bakılacağını belirtir. Örneğin, açılacak bir davanın asliye hukuk mahkemesinin görevine girdiği tespit edilirse, bu davanın hangi yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılacağı, örneğin Ankara, İzmir, yoksa Van asliye hukuk mahkemesinde mi açılacağı sorusu gündeme gelir. Bir davanın **hangi yer**de görüleceği hususuna yetki, bunu düzenleyen kurallara yetki kuralları denir.

Yetki ve görev kavramları, geniş anlamda yetki (salâhiyet) kavramı içinde toplanabilir. Nitekim bazı kanun hükümlerinde, "salâhiyet" terimi (görev ve yetkiyi kapsar şekilde) geniş anlamda kullanılmıştır. Bu geniş anlamda yetki kavramından hareket edilerek, görev için "şey -madde- yönünden yetki" ve yetki için de "yer itibariyle yetki" terimleri kullanılmaktadır (bkz. örneğin, MÖHUK m. 40).

Bu konuda kavram karışıklığını önlemek için, Anayasanın (m. 142) ve HMK'nun (m. 1-19) yaptığı gibi, görev yerine "**görev**" (vazife), yetki yerine de "**yetki**" (salâhiyet) terimlerinin kullanılması uygun olur[1].

Mahkemelerin görev ve yetkileri **kanunla** düzenlenir (Anayasa m. 142); kanun dışındaki bir hukuk kuralıyla (örneğin, yönetmelikle) mahkemelerin

---

[1] CMK da, "görev" (CMK m. 3 vd.) ve "yetki" (CMK m. 12 vd.) terimlerini kullanmaktadır.

yetkisi ve görevi belirlenemez. Bunun bir Anayasa ilkesi olarak kabul edilmesinin nedeni, bir kimsenin kanunen tâbi bulunduğu mahkemeden (tabiî hâkiminden) başka bir merci (mahkeme) önüne çıkarılmasını önlemektir (bkz. Anayasa m. 37).

Genel mahkemelerin görev ve yetkileri kural olarak HMK'nda (m. 1-19) ve 5235 s. K. m. 1 vd.'de düzenlenmiştir. Özel mahkemelerin görev ve yetkileri ise, bu mahkemelerle ilgili özel kanunlarda düzenlenmiştir.

§ 9. GÖREV

Görev, belirli bir davaya o yerdeki (il veya ilçedeki) hüküm mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir.

Belirli bir dava hakkındaki görevli mahkemeyi tespit ederken, ilk önce, o davanın genel mahkemelerin mi, yoksa özel mahkemelerin mi görevine girdiği araştırılır. Özel görevli mahkemelerin görevi, genel görevli mahkemelerin görevinden önce gelir. Açık kanun hükmü ile özel görevli mahkemelerde görüleceği belirtilmemiş olan bütün davalar, genel görevli mahkemelerin görevine girer. Ayrı ayrı (özel) kanunlarla düzenlenen özel görevli mahkemelerin görevi ileride incelenecektir[1]. Burada genel görevli mahkemelerin görevleri inceleme konusu yapılacaktır.

HMK m. 1'e göre, genel görevli mahkemelerin görevi kanunla belirlenir. **Asliye hukuk** mahkemelerinin görevi HMK m. 2'de (5235 s. K. m. 6, II'de); **sulh hukuk** mahkemelerinin görevi, kural (esas) olarak HMK m. 4'te (5235 s. K. m. 6, I'de) gösterilmiştir. Diğer kanunlarda (özellikle, TMK, TBK ve TTK'nda) da genel görevli mahkemelerin görevine ilişkin hükümler vardır.

Genel görevli mahkemelerden asliye hukuk mahkemesinin görevi, sulh hukuk mahkemesinin görevine girmeyen dava ve işlerle özel görevli mahkemelerin görevine dahil olmayan bütün dava ve işlerdir. Asliye hukuk mahkemesinin bu kurala göre belirlenen görevine malvarlığına ve kişivarlığına dahil olan konular girer.

A) ANA KURAL

I- ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konusu para veya para ile ölçülebilen bir şey (mal, hak) olan davalar, malvarlığı hukukundan doğan davalardır; alacak (örneğin para alacağı) davaları, taşınır veya taşınmaz mal davaları gibi.

Yukarıda da belirtildiği üzere, dava konusunun (müddeabihin) değer ve miktarına bakılmaksızın **davalarda** (genel, asıl) görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça, **asliye hukuk mahkemesi**dir (m. 2, 1). HMK m. 2'nin (eski HUMK'ndan farklı olarak) getirdiği bu yeni kural nedeniyle, dava konusunun para veya paradan başka bir şey olup olmamasının, asliye hukuk mahkemesinin görevi bakımından artık belirleyici bir önemi bulunmamaktadır[2].

---

1 Bkz. aşa. § 71-76.

2 HUMK m. 8'in benimsediği sistem (parasal sınır) nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda; malvarlığı davalarında davanın konusunun para olup olmadığı; buna faiz, icra tazminatı ve giderlerin eklenip eklenmeyeceği (HUMK m. 1); dava konusunun paradan başka bir şey olması halinde, bunun değerinin hangi tarihe göre belirleneceği, belirlemenin doğru olmaması halinde neler yapılması gerektiği (HUMK m. 2); ayrıca, dava yığılması (objektif dava birleşmesi), seçimlik dava, terditli dava (HUMK m. 3), kısmî dava (HUMK m. 4), karşılık dava (HUMK m. 5), irtifak haklarına ilişkin dava (HUMK m. 6) gibi özel durumlarda

II- ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN DURUMU

Yukarıda belirtildiği gibi, hukuk davalarında asıl görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir (m. 2). Ancak TTK'nun 5. maddesine göre, aksine hüküm bulunmadıkça, **ticarî davalar, asliye ticaret mahkemelerinde** (kısaca: ticaret mahkemelerinde) **görülür.**

1) Ticarî Dava Kavramı

Hangi davaların ticarî dava olduğu TTK m. 4'te sayılmıştır. Bundan başka, özel kanunlarda, bazı davalara ve işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılacağı düzenlenmiştir (TTK m. 5, 2). Bu hükümlerde sayılan ticarî davalar, mutlak ticarî davalar ve nispî ticarî davalar olarak ikiye ayrılır.

a) Mutlak Ticarî Davalar

Mutlak ticarî davalar, esas itibariyle, TTK m. 4'te sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki davalar, **tarafların tacir** ve **uyuşmazlığın bir ticarî işletme ile ilgili olup olmadıklarına bakılmaksızın** mutlak olarak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1):

TTK'nda düzenlenmiş olan bütün hususlardan doğan hukuk davaları, mutlak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/1). Örneğin, tacir olmayan kişiler arasındaki bir bonoya veya poliçeye ilişkin dava ticarî davadır.

TMK'nun 962-969. maddelerinde düzenlenmiş olan rehin karşılığında ödünç verme işlerinden doğan hukuk davaları mutlak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/b).

TBK'nun, bir işletmenin satılması veya diğerleriyle birleştirilmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine ilişkin 487-501, kredi mektubu ve kredi emrine ilişkin 515-519, komisyona ilişkin 532-545, ticarî mümessiller ve diğer ticarî vekiller hakkındaki 547-554. maddelerinde düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/c).

Fikrî mülkiyet hukukunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/d).

TTK'nun 4. maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki özel hükümlerde düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/e).

Bankacılık K.'nda ve Ödünç Para Verme İşleri K.'nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/f).

TTK m. 4 hükmü dışında, diğer bazı kanunlarda da mutlak ticarî davalara ilişkin düzenlemeler vardır. Bu davalara ticaret mahkemesinde bakılabilmesi için, tarafların tacir olması veya bir ticarî işletmeye ilişkin bulunmaları gibi bir şart aranmadığı (TTK m. 5, 2) için, bu davaların da mutlak ticarî davalar ola-

---

görevin nasıl belirleneceğine ilişkin özel hükümler bulunmakta ve bu konularda önemli görev sorunları çıkmakta ve davalar bu sebeple uzayabilmekte idi. HMK m. 2'nin getirdiği yeni kural, bu konulardaki karmaşayı ortadan kaldırıcı niteliktedir (bu konuda bkz.: HMK m. 2 ve 4'e ilişkin TBMM Genel Kurul Tutanaklarında Yer Alan Gerekçe).

rak nitelendirilmesi gerekir. Örneğin Kooperatifler K.'ndan (m. 99, I) doğan davalar mutlak ticarî davadır.

İflâs davaları ticaret mahkemesinde görülür (İİK m. 154, 156, 158, 173, 174, 179). Bundan başka, iflâsın kaldırılmasına (İİK m. 182) ve kapanmasına (İİK m. 254) iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesi karar verir. İflâsta sıra cetveline itiraz davaları iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesinde açılır (İİK m. 235). Taksiratlı müflis ve adî müflis hakkında itibarın yerine getirilmesine iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesi karar verir (İİK m. 313-314). Konkordatonun tasdiki ve feshi işlerine de ticaret mahkemelerinde bakılmaktadır.

b) Nispî Ticarî Davalar

Burada inceleyeceğimiz davalar, kural olarak hukuk davasıdır (hukuk mahkemelerinde görülür). Fakat, bu davalar bir **ticarî işletmeyi ilgilendirmekte** veya **iki taraf için de ticarî sayılan hususlardan doğmakta ise**ler, ticarî dava sayılırlar. İşte bu nedenle (şarta bağlı olarak ticarî dava sayıldıkları için) bu davalara nispî ticarî davalar denir.

Nispî ticarî davaları ikiye ayırarak incelemek gerekir:

TTK'nun saydığı **sınırlı sayıdaki** bazı davalar, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın **taraflardan birinin ticarî işletmesi ile ilgili** iseler, ticarî dava sayılır. Buna göre, TBK'nun havale hakkındaki 555-560, vedia hakkındaki 561-580 inci maddelerinde düzenlenen ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan hukuk davaları (bir ticarî işletme ile ilgili iseler) ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1/c, TTK m. 4, 1/son cümle). Bu davalar taraflardan birinin işletmesi ile ilgili değilse, ticarî dava sayılmaz; dar anlamda hukuk davası sayılır (TTK m. 4, 1/son cümle).

Buna karşılık, yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki davalar, genel olarak, TTK'nun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince **her iki taraf için ticarî sayılan hususlardan doğmaları sebebiyle** ticarî dava sayılır (TTK m. 4, 1). Bu hükme göre, bir davanın (nispî) ticarî dava sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın bir arada bulunması gerekir: i) Davanın her **iki tarafının** da **tacir** olması ve ii) Dava konusu uyuşmazlığın her iki tarafın da **ticarî işletmesiyle ilgili** bulunması. Şu halde, davanın taraflarından biri tacir değilse, o dava ticarî dava değildir. Bunun gibi, iki taraf da tacir olsalar bile, dava konusu uyuşmazlık taraflardan birinin ticarî işletmesi ile ilgili değilse, o dava ticarî dava değildir (bkz. TTK m. 19, 2).

2) Ticarî Davalara Bakan Mahkemeler

Ticarî davalarda, asliye hukuk mahkemeleri görevlidir (karş. TTK m. 5,1)[3]. Ancak, ülkemizde ticarî uyuşmazlıkların çok olduğu yerlerde, asliye hukuk

[3] HUMK m. 8'in uygulandığı dönemde, değer veya miktarı belli sınırın altında kalan davalara sulh hukuk mahkemeleri baktığından, bu belli sınırın altındaki ticarî davalarda da sulh hukuk mahkemesi görevli idi. Sulh hukuk mahkemesinin görevlerini gösteren HMK m. 4'teki yeni düzenleme sebebiyle, bu maddede (ve özel kanunlarda) sayılan davalar dışında kalan bütün davalar değer veya miktarı ne olursa asliye hukuk mahkemesinde görüleceğinden, ticarî davalarda sulh hukuk mahkemelerinin görevi kalmamıştır.

mahkemelerinin daireleri durumunda olmak üzere, ayrı asliye ticaret mahkemeleri kurulmuştur.

a) Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerler

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Adana ve Konya gibi ticarî uyuşmazlıkların yoğun olduğu bazı yerlerde, asliye hukuk mahkemesinin yanı sıra ayrı asliye ticaret mahkemesi kurulmuştur. Ayrı asliye ticaret mahkemesi olan yerlerde, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ticarî davalara o yerdeki asliye ticaret mahkemesinde bakılır (TTK m. 5, 2).

5235 s. K. m. 5, 3'e göre: Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri **üç yüz bin Türk lirasının üzerinde olan dava ve işler ile** dava değerine bakılmaksızın; 1) İflâs, iflâsın kaldırılması, iflâsın kapatılması, konkordato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan iş ve davalara; 2) TTK'nunda düzenlenen, hâkimin kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davalara; 3) Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organların azline ve geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalara; 4) HMK'na ve MTK'na göre yapılan tahkim yargılamasında tahkim şartına ilişkin itirazlara, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara ilişkin tüm yargılama aşamaları, **bir başkan ve iki üye** ile toplanan heyetçe yürütülür ve sonuçlandırılır[4]. Heyet halinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hâkimler arasında iş dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.

Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerdeki **asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi** ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisidir ve bu durumda göreve ilişkin hükümler (m. 1 vd.; 20; 114, 1/c; 115) uygulanır (TTK m. 5, 3).

---

4 Asliye ticaret mahkemesinin bazı dava ve işleri tek hâkimle bazılarını ise heyet olarak görmesinin uzmanlığa dayalı sistem oluşmasına ve adaletin etkin bir şekilde ve süresinde gerçekleşmesine engel olduğu gerekçeleriyle Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de, Anayasa Mahkemesi, heyet halinde karar verilmesi öngörülen durumlar dışında tek hâkimle davanın görüleceği; asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren hususların tek hâkimle veya heyetle görülmesi konusundaki takdir yetkisinin kanun koyucuda olduğu; bu yetkinin ölçülülük ilkesi çerçevesinde kullanılacağı; kanun koyucunun ticarî bütün uyuşmazlıkların çözümünü asliye ticaret mahkemesine verdiği; bu bakımdan parasal bir sınır öngörmeyerek uzmanlaşmayı sağladığı gibi gerekçelerle 5235 s. K. m. 5'te yer alan düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir (Anayasa Mahkemesi'nin 15.05.2019 gün ve 2018/143 E, ve 2019/39 K. sayılı kararı için bkz. RG 12.07.2019, sa. 30829).

Bir yerdeki (örneğin, Ankara'daki) birden fazla asliye ticaret mahkemelerinin kendi aralarındaki ilişki, bir görev ilişkisi değildir. Bir yerdeki birden fazla asliye ticaret mahkemesi arasındaki ilişki, bir yerdeki birden fazla asliye hukuk mahkemeleri arasındaki **iş dağılımı** ilişkisi gibidir; yani yalnız bir iç ilişkidir. Taraflar bu iş dağılımına itiraz edemezler. Ancak, bir yerde birden fazla asliye ticaret mahkemesinin (dairesinin) bulunması halinde ve Kanunların bunlardan birini özel bir konuda (örneğin, bankacılık konusunda) görevlendirmesi halinde, Yargıtay, görevlendirilen asliye ticaret mahkemesi (dairesi) ile diğer asliye ticaret mahkemeleri (daireleri) arasındaki ilişkiyi görev ilişkisi olarak görmektedir.

Başka yerlerdeki ticaret mahkemeleri (örneğin Ankara Ticaret Mahkemesi ile İstanbul Ticaret Mahkemesi) arasındaki ilişki, yetki (m. 5 vd.) ilişkisidir. Bunun gibi, bir yerdeki (örneğin Ankara'daki) asliye ticaret mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi bulunmayan başka bir yerdeki (örneğin, Çankırı'daki) asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişki de yetki ilişkisidir.

b) Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunmayan Yerler

Ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görevine giren ticarî davalara da (diğer hukuk davaları gibi) asliye hukuk mahkemesinde bakılır (TTK m. 5, 1).

Bu halde, bir ticarî davanın asliye hukuk mahkemesine, asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla açılmasına gerek yoktur. Dava, asliye hukuk mahkemesi sıfatıyla açılmış olsa bile, asliye hukuk mahkemesi davaya asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla bakmak zorundadır; görevsizlik kararı veremez (TTK m. 5, 3). Bunun gibi, asliye hukuk mahkemesine asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla açılmış olan bir dava da, asliye hukuk mahkemesi sıfatıyla açılması gerekirdi gerekçesiyle reddedilemez.

B) ANA KURALIN İSTİSNALARI

I – SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR VE İŞLER

Malvarlığı davalarında asıl görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olmakla birlikte, kanunlarda aksine hüküm bulunması sebebiyle (m. 2, 1) bazı dava ve işler (dava konusunun değerine bakılmaksızın) **sulh hukuk mahkemesinde** görülür. Bu davalar (ve işler) şunlardır:

1) Kira İlişkisinden Doğan Tüm Uyuşmazlıkları Konu Alan Davalar

Kira ilişkisinden doğan, alacak davaları da dahil olmak üzere, **tüm uyuşmazlıkları** konu alan davalar, sulh hukuk mahkemesinde görülür (m. 4, 1/a).

HMK m. 4, 1/a hükmü, eski HUMK m. 8,II/1 hükmüne oranla sulh hukuk mahkemelerinin görev alanını genişletmiştir. Çünkü HUMK m. 8, II/1 hükmü, sulh hukuk mahkemelerinin kira sözleşmesine dayalı olarak görebileceği davaları **sınırlı** şekilde **sayarak tespit** etmişti. Bunlar; "her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat

davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar"dan ibaretti. HUMK m. 8, II/1 hükmünün uygulamasında da; görev kurallarının kanunla belirlenmesi gerektiği ilkesi (Anayasa m. 142) sebebiyle, kira ilişkisinden doğmasına rağmen, burada sayılan davalar dışında kalan (kira ilişkisi ile ilgili diğer) davaların, sulh hukuk mahkemesinin görevine girmediği kabul edilmekte idi. Örneğin, (sayılan davalarla birlikte değil de) ayrı açılan kira alacağı davasının HUMK m. 8, I'deki sınırdan fazla olması halinde alacak davasının sulh hukuk mahkemesinde değil, asliye hukuk mahkemesinde açılacağı; sulh mahkemesinde açılacak olan tespit davalarının, her türlü tespit davası değil yalnızca kira bedelinin tespiti davası ile sınırlı olduğu yolunda sonuçlara varılmakta idi.

Oysa HMK m. 4, 1/a (HUMK m. 8, II/1'den farklı olarak), "**kira ilişkisinden doğan** alacak davaları da dahil olmak üzere **tüm uyuşmazlıklar**" hükmünü taşıdığı için, **sulh hukuk mahkemesi** (İİK m. 269; 272 vd. hükümlerine göre ilâmsız icra yoluyla tahliye hariç) kira ilişkisinden kaynaklanan bütün dava ve işlerde **genel görevli mahkeme**dir. Bu çerçevede örneğin, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye davaları[5]; taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin geçerli olmadığı (batıl olduğu) gerekçesiyle açılan kira sözleşmesinin iptali dahil, kira ilişkisine dayanan her türlü akdin feshi davaları; yalnızca kira bedelinin tespiti davası ile sınırlı olmaksızın, kira ilişkinden kaynaklanan her türlü olumlu veya olumsuz tespit davaları; (kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları ile birlikte açılıp açılmadığına bakılmaksızın) her türlü kira alacağı ve tazminat davaları ile bunlara karşı açılan karşı davalar (m. 132 vd.) ile kira ilişkisinden doğan diğer dava ve işler (kanunlarda aksine açık bir hüküm bulunmadıkça) sulh hukuk mahkemesinin görevine girer.

Öte yandan Yargıtay, HUMK'ndan farklı olarak, kira ilişkisi bakımından taşınmaz-taşınır ayrımı yapmamakta ve taşınırlarla ilgili kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da, sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğunu kabul etmektedir.

2) Paylaştırma ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına (TMK m. 698-699, 703) ve ortaklığın giderilmesine yönelik (izalei şüyu) davalar (TMK m. 642), dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın) **sulh hukuk mahkemelerinde** görülür (m. 4, 1/b).

3) Yalnız Zilyetliğin Korunması ile İlgili Davalar

Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar, dava konusu malın değerine bakılmaksızın, **sulh hukuk mahkemelerinde** görülür (m. 4, 1/c).

Bu davalar, "zilyetliğin gasbında dava hakkı" ve "zilyetliğe saldırıya dava hakkı" ile ilgili TMK m. 982-984'de (ve TMK m. 992, II'de) düzenlenen dava-

---

[5] Taşınmazı fuzulî işgal edene karşı açılacak el atmanın (müdahalenin) önlenmesi davası ise, kira ilişkisine dayanan bir dava olmadığından bu kapsama girmez.

lardır. Çünkü TMK m. 982-984'deki davalar, yalnız zilyetliğin korunmasına ilişkin olup, bu davalarda davacının, "şeye malik olduğunu veya zilyetlik hakkını beyana lüzum olmadan, sadece zilyetlik sıfatını ileri sürerek, saldırıyı ispat etmesi yeterlidir".

Buna karşılık, TMK'nun 985 ve sonraki maddelerinde düzenlenmiş olan zilyetliğe haklılık davası, zilyetliğe istihkak davası veya zilyetliğin iadesi davası olarak isimlendirilen davalar, yalnız zilyetliğe değil, hakka dayanan davalar olduğundan, bu davalarda görevli mahkeme, malvarlığı davalarında genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesidir.

4) Çekişmesiz Yargı İşleri

Kanunlarda aksine açık bir hüküm bulunmadıkça çekişmesiz yargı işlerinde (m. 382) genel görevli mahkeme, **sulh hukuk mahkemesi**dir (m. 383).

Kanunların açıkça sulh hukuk mahkemesi dışında başka bir mahkemeyi görevli kıldığı çekişmesiz yargı işleri ise, sulh hukuk mahkemesinin görevine girmez. Örneğin konkordato mühleti verilmesi ve konkordato komiseri atanması, bir çekişmesiz yargı işi olmasına (m. 382, 2/6) rağmen, bu iş sulh hukuk mahkemesinin değil, İİK m. 285'e göre asliye ticaret mahkemesinin görevine girer. Keza, iflâsın kaldırılması, asliye ticaret mahkemesinin görevine girdiğinden (İİK m. 182, I;154, IV), sulh hukuk mahkemesi bu konuda da görevli değildir.

Çekişmesiz yargı işlerinde, aksine bir düzenleme bulunmadıkça, (genel) görevli mahkemenin, sulh hukuk mahkemesi olduğunu belirten HMK m. 383 hükmü dolayısıyla, çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesi genel görevli mahkeme olarak belirlenmiş olduğundan (başka bir ifade ile asliye hukuk mahkemesinin çekişmesiz yargı işlerindeki görevi istisnai hale getirildiğinden) bundan böyle, az önce görüldüğü gibi, yalnız "mahkeme" veya "hâkim" terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işlerinde de (açık bir şekilde asliye hukuk mahkemesinin veya hâkiminin görevi belirtilmedikçe) artık asliye hukuk mahkemelerinin değil, sulh hukuk mahkemelerin görevli olduğu kanısındayız. Örneğin, bazı çekişmesiz yargı işlerinin açıkça asliye mahkemesinde görüleceği belirtilmemiş; yalnız "**mahkeme**"nin (TMK m. 32, 102 vd.; TBK m. 44, 187, 542) veya "**hâkim**"in (TMK m. 926; TBK m. 123) çekişmesiz yargı işinde görevli olduğu belirtilmiş olabilir. Bu durumda, özel görevli mahkemelerin görevi saklı kalmak kaydıyla, görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olacaktır.

5) HMK'nun ve Diğer Kanunların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler

HMK'nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini veya hâkimlerini görevlendirdiği dava ve işleri de sulh hukuk mahkemesi görür (m. 4, 1/ç).

Sulh hukuk mahkemesini görevli kılan **diğer kanunlar**a, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık (Kat Mülkiyeti Kanunu Ek madde 1) veya Kooperatifler K. m. 21, III ile Dernekler K. m. 27 örnek olarak verilebilir.

II – ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR VE İŞLER

Buraya kadar, malvarlığı haklarından doğan davalarda asıl görevli olan asliye hukuk mahkemesi ile istisnaî bazı dava ve işler için görevlendirilmiş bulunan ancak yine de genel görevli mahkeme niteliğini koruyan sulh hukuk mahkemesinin görevlerini inceledik.

Çeşitli kanunlarda yer alan hükümlere göre, malvarlığı haklarından doğan bazı dava ve işler, özel görevli mahkemelerde görülür.

C) KİŞİVARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVA ve İŞLERDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİDİR

Bir davanın konusunun malvarlığı veya kişivarlığı hakkı olduğu, **o hakkın niteliğine göre** belirlenir. Yoksa, davacının dilekçesinde dava konusunun para ile ölçülemeyen (değerlendirilemeyen) bir şey olduğunu ve bu nedenle davanın belli olmayan bir değere (miktara) ilişkin olduğunu bildirmesi, dava konusunun para ile ölçülemeyen bir şey (dolayısıyla kişivarlığı hakkı) olduğunun kabulü için yeterli değildir. Mahkemenin, dava konusu hakkın niteliğini kendiliğinden (resen) araştırması gerekir.

Kişivarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun (müddeabihin), yani dava ile korunması istenen hakkın para ile ölçülebilecek (mamelekî) bir değeri yoktur. Bu haklara kişivarlığı hakları denir. **"Kişivarlığı hakları"** terimi, "malvarlığı hakları" teriminin karşıtıdır. Kişivarlığı hakları, malî (parasal/mamelekî) bir değere sahip değildir; dolaşıma (tedavüle) elverişli değildir, başkasına devredilemez ve paraya çevrilemez.

Kişivarlığı haklarına ilişkin davalar, daha çok kişiler hukuku (TMK m. 8 vd.) ve aile hukukuna (TMK m. 118 vd.) ilişkin davalardır. Örneğin kişilik haklarına yapılan tecavüzün (saldırının) önlenmesi davası (TMK m. 24, I), evlenmenin butlanı davası (TMK m. 156 vd.), boşanma (ve ayrılık) davası (TMK m. 161 vd.) ve babalık davası (TMK m. 301 vd.), kişivarlığı haklarına ilişkin davalardır.

Kişivarlığı davalarının bir kısmı, **aile mahkemesi**nin görevine girmektedir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanuna (m. 4) göre, Türk Medenî Kanunu'nun vesayete ilişkin Üçüncü Kısım hükümleri (TMK m. 396-494) hariç olmak üzere, aile hukuku başlığını taşıyan İkinci Kitabı hükümleri (TMK m. 118-395) ile Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 4722 sayılı Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler aile mahkemesinin görevlerindendir (4787 s. K. m. 4).

Burada, asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, aile mahkemesinin veya sulh mahkemesinin görevi ise istisna olduğundan, özel bir kanun hükmü ile açıkça aile mahkemesinde veya sulh mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen ve konusu para ile ölçülemeyen bir şey (kişivarlığı) olan dava ve işler, aile mahkemesinde veya sulh hukuk mahkemesinde görülmez. Bu kural gereğince, örneğin kişilik haklarına saldırının önlenmesi davası (TMK m. 24, I) asliye hukuk mahkemesinde görülür.

Ayrıca belirtelim ki, yukarıda görüldüğü üzere, malvarlığı davalarında da (kanunun açıkça belirttiği istisnalar dışında), asıl görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olduğundan (m. 2), kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle açılan maddî veya manevî tazminat davaları (TMK m. 24, II), malvarlığı haklarından doğan davalardır; bu nedenle (tutarı ne olursa olsun) maddî ve manevî tazminat davalarında, görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.

Derneklerin feshi (kapatılması) davaları asliye hukuk mahkemesinde görülür (TMK m. 89).

Yaş, ad, soyadı ve diğer **nüfus kayıt düzeltme** talepleri, ilgilinin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesinde görülür (Nüfus Hizmetleri K. m. 36).

MÖHUK'na (m. 51, I) göre **yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi** hakkında görevli mahkeme, asliye mahkemesidir.

Yukarıda ayrı ayrı görüldüğü üzere, malvarlığı davalarında da, kişivarlığı davalarında da, asıl görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir (m. 2, 1).

HMK, kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça "diğer dava ve işler bakımından da" asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğunu belirtmektedir (m. 2, 2). Bu hükmün konuluş gerekçesi, özel kanunlarla başka mahkemelerin görev alanına girdiği belirtilmeyen tüm dava ve işlerin asliye hukuk mahkemelerinde bakılacağının belirtilerek, görev konusunda bir tereddüdün yaşanmamasının veya boşluğun doğmamasının sağlanmasıdır[6].

Bazı çekişmeli yargı dava ve işlerinde de görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu açıkça belirtilmeden "mahkemenin" veya "hâkim"in görevli olduğu belirtilmiş olabilir. Bu durumda görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.

D) GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ

Görev kuralları, **kamu düzenindendir** (m. 1, c. 2) ve mahkemenin görevli olması **dava şartları**ndandır (m. 114, 1/ c). Bu nedenle, mahkeme, davanın her aşamasında görevli olup olmadığını **kendiliğinden** (resen) **inceler** ve görevsiz olduğu kanısına varırsa görevsizlik kararı verir (m. 115, 1).

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, yetki kurallarındakinin (m. 17) aksine, taraflar **sözleşme ile görevli mahkemeyi değiştiremezler**; yani, "görev sözleşmesi" yapılamaz.

E) MAHKEMENİN GÖREVLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMESİ

Bir dava şartı (m. 114, 1/c) da olması itibariyle görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, **mahkeme**, görevli olup olmadığını (davanın her aşamasında) **kendiliğinden inceler** (gözetir) ve görevsiz olduğu kanısına varırsa, (tarafların ileri sürüp sürmediğine bakmaksızın) kendiliğinden görevsizlik kararı verir (m. 115).

Taraflar da, **davanın her aşamasında** görev itirazında bulunabilirler. Görev itirazı, kural olarak davalı tarafından yapılır. Ancak, davacının da bu itira-

---

6 TBMM Genel Kurul tutanaklarında yer alan gerekçe.

zı yapmasına hukuken bir engel yoktur; çünkü, davacı davasını açtığı mahkemenin görevli mahkeme olmadığını, görevli olmayan mahkemede dava açmış olduğunu sonradan fark edebilir. Bu durumda mahkemenin veya karşı tarafın bu konudaki davranışını beklemeden, davasının bir an önce görevli mahkemeye gönderilmesini sağlamak üzere itiraz etmesinde (talepte bulunmasında) hukukî menfaati bulunur.

Görev itirazı yapılmış ise (veya yapılmamış olsa bile resen), mahkeme, **ilk önce görevli olup olmadığını** (görev itirazını, sorununu) **inceleyip** karara bağlamalıdır. Çünkü, ön inceleme ile ilgili 137. maddeye göre, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra yapılacak ön incelemede dava şartları ve bu arada görev konusunda karar verilir.

Mahkeme, görev hakkında **dosya üzerinden** karar verebileceği gibi, gerekli görmesi halinde bu konuda yapacağı **ön inceleme duruşması**nda tarafları dinledikten sonra da karar verebilir (m. 138). Ancak bu hükümden de anlaşıldığı üzere, önemli ve acele karar verilmesini gerektiren bir durum olması itibariyle, görev konusunda ön inceleme duruşmasının (m. 140) beklenmesine gerek bulunmamaktadır.

HMK m. 138'de, mahkemenin öncelikle görev (dava şartları) hakkında karar vermesinin öngörülmüş olması, isabetli bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin, uygulamada (görevsiz olmasına rağmen) bazı mahkemelerin (görev konusunu davanın başında hemen karara bağlamadıkları için) yargılamayı yıllarca sürdürüp, hatta tanık, keşif, bilirkişi incelemesini yaptıktan sonra görevsizlik kararı vererek davayı uzun süre sürüncemede bırakmasından kaynaklanan sakıncaları ortadan kaldıracağı kanısındayız.

Mahkeme, başlangıçta kendisini görevli görmüş ve yargılamaya devam etmiş olmasına rağmen, yargılamanın ilerleyen aşamalarında konuyu daha yakından inceledikten sonra bu kez görevli olmadığı kanaatine varacak olursa, yargılama sırasında da kendiliğinden görevsizlik kararı vermesi mümkündür.

Hüküm mahkemeleri gibi, **üst ve yüksek mahkemeler de** kendi incelemeleri sırasında, hükmü veren mahkemenin görevli olup olmadığını kendiliğinden gözetip **incelemekle yükümlüdür**. Bunun için, tarafların hükme karşı görevsizlik nedeniyle kanun yoluna başvurmuş olmalarına gerek yoktur.

Görev kurallarına aykırılık (mahkemenin görevsiz olması), hüküm kesinleşinceye kadar gerek davayı gören ilk derece mahkemesi gerek üst veya yüksek mahkeme tarafından kendiliğinden (resen) gözetilir (ki, görev konusu usulî müktesep hakkın istisnasıdır) ve taraflarca da ileri sürülebilir; ancak, **hüküm kesinleştikten sonra ileri sürülemez**. Yani, görevsiz mahkemenin verdiği (kesinleşmiş) hüküm, bu nedenle geçersiz (batıl) sayılamaz ve aynı nedenle hükme karşı yargılamanın yenilenmesi (iadesi) istenemez.

Mahkeme **görev itirazını reddederse**, davanın esası hakkında incelemeye girişir. Görev itirazının reddine ilişkin karar, nihaî karar olmadığı (ara kararı olduğu) için, yalnız başına kanun yoluna götürülemez; ancak esas hükümle birlikte kanun yoluna götürülebilir.

F) GÖREVSİZLİK KARARI

Mahkeme, yapacağı inceleme sonucunda, görevsiz olduğu kanısına varırsa, görevsizlik kararı verir. Mahkeme, görevsizlik kararında görevli mahkemeyi bildirmeli ve dava dosyasının bu (görevli) mahkemeye gönderilmesine karar vermelidir.

Görevsizlik kararından sonra davaya başka bir mahkemede (yani, görevli mahkemede) devam edilirse **yargılama giderleri**ne, o mahkeme; davaya o mahkemede (yani, görevli mahkemede) devam edilmezse, talep üzerine, davanın açıldığı (yani, görevsizlik kararı veren) mahkeme (dosya üzerinden bu durumu tespit ederek) **karar verir** (m. 331, 2).

Mahkeme, görevsizlik kararı ile davadan elini çeker; yani, görevsizlik kararı bir nihaî karardır.

Miktar veya değeri belli bir parasal sınırı (HMK m. 341, 2 ve Geçici Madde 3 dolayısıyla HUMK m. 427, II) geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin görevsizlik kararları kesindir. Bundan başka, özel kanun hükümleri ile haklarında verilecek kararların (hükümlerin) kesin olduğu kabul edilen dava ve işlere ilişkin görevsizlik kararları da kesindir.

Bunun dışında (HMK m. 341, 2 ve Geçici Madde 3 dolayısıyla HUMK m. 427, II'de) belirtilen parasal sınırı geçen davalarda, görevsizlik kararlarına karşı kanun yoluna gidilebilir.

G) GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Görevsizlik kararı veren mahkeme, görevsizlik kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir; dava dosyasını kendiliğinden (resen) görevli mahkemeye gönderemez.

Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilebilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için **taraflardan** (davacı veya davalıdan) **bi**rinin, **iki hafta** içinde, görevsizlik **kararı veren mahkemeye**[7] **başvurması gerekir;** aksi halde, mahkemece dava açılmamış sayılmasına karar verilir (m. 20).

İki haftalık başvuru süresi, görevsizlik kararı verildiği anda **kesinse** (yani, karara karşı kanun yolu kapalı ise), görevsizlik kararının **tebliği tarihinden**[8]; görevsizlik kararına karşı kanun yolu açıksa ve fakat süresi içinde kanun yoluna gidilmediği için görevsizlik kararı kesinleşmişse kesinleşme tarihinden; görevsizlik kararına karşı kanun yoluna gidilmiş ve ancak kanun yolu uygun

---

7 HMK m. 20, 1 hükmü, tereddüde yer vermeyecek şekilde, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için (görevli olduğu belirtilen mahkemeye değil) **kararı veren mahkemeye** başvurulması gerektiğini belirtmektedir. Hükmün Gerekçesinde de, "başvurunun görevli olduğu belirtilen ve fakat dosya henüz kendisine gönderilmemiş olan mahkemeye yapılmasının pratik olmadığı" vurgulanarak, başvurunun görevsizlik kararı veren mahkemeye yapılacağı ifade olunmuştur.

8 HMK m. 20, 1'deki "...bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten..." ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 10.02.2016 tarihli ve 96/09 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu karar yürürlüğe girmiştir. Karar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, Usul-Pratik, s. 149-151.

görülmeyerek başvuru reddedilmişse, ret kararının tebliği tarihinden itibaren başlar (m. 20, 1).

Dosya kendisine gönderilen görevli mahkeme, taraflara kendiliğinden davetiye göndererek yargılamaya devam eder.

Bir mahkemenin verdiği görevsizlik kararı, **kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşmiş ise**, bu görevsizlik kararı, dosya (m. 20'ye göre) kendisine gönderilen mahkemeyi bağlamaz (m. 23); o mahkeme de görevsizlik kararı (yani kendisinin görevli olmadığına, bilâkis, görevsizlik kararı vermiş bulunan ilk mahkemenin görevli olduğuna) karar verebilir.

Bu görevsizlik kararı da usulüne göre kesinleşirse, o zaman iki mahkeme arasında olumsuz bir **görev uyuşmazlığı** çıkmış olur. Bu olumsuz görev uyuşmazlığı, **yargı yeri belirlenmesi yolu** (m. 21) ile giderilir ve görevli mahkeme, üst mahkemece belirtilir[9]. Bu olumsuz görev uyuşmazlığı yargı yeri belirlenmesi yolu ile giderilmedikçe, dava dosyası ilk görevsizlik kararını veren mahkemeye gönderilemez ve davaya, ilk (veya ikinci) görevsizlik kararını veren mahkeme tarafından bakılamaz.

Buna karşılık, görevsizlik kararı **kanun yoluna gidilmesi sonucu kesinleşmiş ise**, bu görevsizlik kararı, dosya (m. 20, 2'ye göre) kendisine gönderilen (kesinleşen görevsizlik kararında görevli olduğu bildirilen) mahkemeyi bağlar (m. 23, 2); o mahkeme, görevsiz olduğu kanısına varsa bile, görevsizlik kararı veremez, davayı görmek zorundadır.

Dava dosyası kendisine **gönderilen mahkeme, görevli olduğunu kabul ederse** veya görevsizlik kararı kanun yolu incelemesi sonucu kesinleştiği için gönderilen mahkeme görevsizlik kararı ile bağlı ise, davayı görmeye başlar. Bu şekilde (görevsizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde) başvurulması üzerine görevli mahkemede görülmeye başlanan dava, yeni bir dava olmayıp, görevsiz mahkemede açılmış olan **davanın devamıdır**. Bu nedenle, görevli mahkemede yeniden harç alınmaz; zamanaşımı veya hak düşürücü süre, görevsiz mahkemede davanın açıldığı zamana göre hesaplanır; görevsiz mahkemece konulan *ihtiyatî tedbir* ve *ihtiyatî haciz* devam eder (karş. HMK m. 397); nafakaya, görevsiz mahkemede açılan dava tarihinden itibaren hükmolunur.

Tarafların görevsiz mahkemede yapmış oldukları **usul işlemleri**, görevli mahkemede de **geçerlidir**. Örneğin, açılan davada başlamış olan iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı görevli mahkemede de geçerlidir. Aynı şekilde, görevsiz mahkemede yapılan ve belgelendirilen ikrar (m. 188; 154, 3/ç), görevli mahkemede de geçerlidir; yani ikrar eden taraf (görevli mahkemede de) ikrarı ile bağlıdır. Görevsiz mahkemede edilen yemin (m. 228 vd.), görevli mahkemede de geçerlidir. Bunun gibi, görevsiz mahkemede feragat, kabul ve sulhun de görevli mahkemede geçerli olması gerekir. Tarafların görevsiz mahkemede yeni delil gösterme hakları kalmamış ise, taraflar görevli mahkemede görevsiz mahkemede göstermiş oldukları delillerle bağlıdırlar; yani yeni delil gösteremezler.

---

[9] Bkz. aşa. § 11.

Buna karşılık, **görevsiz mahkeme tarafından yapılmış usul işlemleri, kural olarak geçersizdir**; yani görevli mahkemeyi bağlamaz. Bu işlemlerin görevli mahkemede tekrarlanması gerekir. Fakat görevli mahkeme, görevsiz mahkemenin yapmış olduğu işlemleri (özellikle tespit etmiş olduğu delilleri), bunların tekrarlanması için bir neden yoksa, kararına esas alabilir. Örneğin, görevsiz mahkemede dinlenmiş olan tanıkların görevli mahkemede tekrar dinlenmeleri için hiçbir neden yoksa mahkeme, görevsiz mahkemedeki tanık ifadeleri ile yetinebilir. Görevsiz mahkemece yapılan keşfin görevli mahkeme tarafından tekrarlanmasını haklı gösterecek bir sebep ileri sürülmemiş ise (özellikle taraflar görevsiz mahkemedeki keşfe itiraz etmeyip, bilâkis bu keşfe göre karar verilmesini istemişlerse) görevli mahkeme, görevsiz mahkemenin yapmış olduğu keşif ile yetinebilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, iki hafta içinde (m. 20, 1) görevsizlik kararını vermiş olan mahkemeye başvurulmazsa, görevsiz mahkemede açılmış olan **davanın açılmamış sayılmasına karar verilir** (m. 20, 1/c.2). Hâkim bu kararı iki haftalık sürenin sona ermesinden çok sonra verse bile, bu karar, davanın açılmamış sayıldığı tarihi tespit eden bir karardır; davanın açılmamış sayılmasının sonuçları, iki haftalık sürenin sonundan itibaren doğar. Açılmamış sayılan davadaki talep de hiç yapılmamış (vaki olmamış) sayılır (m. 150, 7).

Davanın m. 20, 1/c.2 hükmü gereğince açılmamış sayılması ile davacı, davasından feragat etmiş (m. 307) olmaz; sadece davasını takipten vazgeçmiş ve terk etmiş sayılır. Bu nedenle davacı, açılmamış sayılan davasını, **yeniden harç ödemek suretiyle** tekrar açabilir.

HMK m. 20, 1/c. 2'ye göre, görevsiz mahkemede açılmış olan davanın açılmamış sayılması üzerine, görevsiz mahkemede **dava açılması ile meydana gelen sonuçlar ortadan kalkar**; yani, yeniden harç verilerek açılan yeni davada eski davanın açılmasının sonuçları devam etmez. Bu nedenle, görevsiz mahkemeye dava açılması ile meydana gelen zamanaşımı kesilmesi (TBK m. 154) sonucu (olgusu), HMK m. 20, 1/c.2 gereğince davanın açılmamış sayılması ile hükümsüz hale gelir.

Ancak, bu arada (yani dava konusu hakkın, alacağın muaccel olduğu tarih ile görevsiz mahkemede açılan davanın, m. 20, 1/son cümle gereğince açılmamış sayıldığı tarih arasında) zamanaşımı süresi bitmiş (alacak zamanaşımına uğramış) ise, davacı (TBK m. 158'deki) **altmış günlük ek** (munzam) **süre** içinde davasını yeniden açabilir. TBK m. 158'deki altmış günlük ek süre, HMK m. 20, 1'deki iki haftalık sürenin bitmesinden (yani görevsizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren iki haftalık sürenin geçmesinden) sonra işlemeye başlar.

§ 10. YETKİ[1]

A) GENEL OLARAK

Yetki, bir davanın **hangi yer**deki (hangi il veya ilçedeki) görevli mahkeme tarafından görüleceğini ifade eder.

Yetki kavramı, uluslararası (dış) yetki ve iç yetki olmak üzere ikiye ayrılır.

Uluslararası (dış) **yetki**, bir davaya hangi Devletin mahkemelerinde bakılacağı hakkındadır. Örneğin bir Türk kadını, İtalyan kocasına karşı boşanma ve nafaka davası açmak istediğinde davayı Türkiye'de mi yoksa İtalya'da mı açacaktır? İşte bu sorunun cevabı uluslararası yetki kurallarına göre verilir.

İç (dahilî, millî, ülke içi) **yetki**, bir davaya belirli bir Devletin ülkesi içinde hangi yerdeki mahkemede bakılacağını belirler. Yukarıdaki örnekte Türk kadınının, İtalyan kocasına karşı Türk mahkemelerinde dava açabileceğini kabul edelim (uluslararası yetki). Acaba bu boşanma davası Türkiye'deki hangi yerdeki (ildeki, ilçedeki) mahkemede açılacaktır? İşte bu soruya da iç yetki kuralları cevap verir.

Burada iç yetki kuralları, yani belirli bir dava için Türkiye'nin neresindeki mahkemenin yetkili olduğu (**Türk mahkemelerinin yetkisi**) ayrıntılı olarak inceleme konusu yapılacaktır (uluslararası yetki, uluslararası özel hukukun konusuna girdiğinden[2], bu kitapta incelenmeyecektir).

Yukarıda belirtildiği gibi yetki kuralları ile görev kuralları farklıdır. Yetkide, dava konusunun niteliği değil, yer bakımından bir davanın hangi (neredeki) mahkeme tarafından görüleceği söz konusudur. Örneğin bir davada sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu belirlendikten sonra, bu davanın hangi yerdeki sulh hukuk mahkemesinde (Ankara'da mı, İzmir'de mi, Çankırı'da mı vs.) açılacağı sorusuna cevap aranır. İşte bu soruya (bundan sonra inceleyeceğimiz) iç yetki kurallarına göre cevap verilir.

Her mahkemenin yargı yetkisi, belli bir coğrafî bölge ile sınırlıdır; buna o mahkemenin **yargı çevresi** denir. 5235 sayılı Adlî Mahkemeler Kanunu'ndan önce, her ilçede hukuk mahkemesi kurulurdu ve bir mahkemenin yargı çevresi, o ilçenin idarî sınırları ile belirlenirdi. 5235 s. K., bu ilkeyi değiştirmiş olup, her ilçede değil, **her il merkezi** ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğuna göre **uygun görülecek ilçelerde** mahkeme kurulması esası getirilmiştir (5235 s. K. m. 5, I). Buna göre, bir hukuk mahkemesinin yargı çevresi, bulunduğu il merkezi veya ilçe ile buna adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediye sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemele-

---

1 Bu konuda bkz. Dilek Karademir Aydemir, Medenî Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi, Ankara 2019.

2 Bkz. MÖHUK m. 40-47.

rinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenir (5235 s. K. m. 7, II).

Mahkemelerin yetkisi **kanunla** düzenlenir (Anayasa m. 142); hiç kimse, kanunen tâbi olduğu (kanunla yetkili kılınan) mahkemeden başka bir mahkeme önüne çıkarılamaz (Anayasa m. 37, I). Bu nedenle, bir **tüzük** veya **yönetmelik hükmü ile yetki kuralı konulamayacağı** gibi, davalı (kıyas yolu ile) kanunen yetkili olan mahkemeden başka bir mahkeme önünde kendisini savunmaya zorlanamaz.

B) YETKİ TÜRLERİ

Bir davanın nerede açılacağı konusundaki ilke, bir hukuk politikası konusudur. Buna göre, ya henüz bir iddiadan ibaret olan bir savı ileri süren davacı veya kendisinden talepte bulunulan taraf olan davalının menfaatleri dikkate alınır. Kanun koyucu burada, davanın nerede açılacağı konusunda bir tercih yapar.

Yetki kuralları, bütün davalar ve bazı davalar için olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan kural olarak bütün davalar için uygulanan yetki kuralına, **genel yetki kuralı** ve bu kurala göre belirlenen mahkemeye de **genel yetkili mahkeme** denir. İleride görüleceği gibi, genel yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) mahkemedir: Her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, açıldığı tarihte davalının (TMK gereğince) yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde görülür (m. 6). Görüldüğü üzere kanun koyucu, genel yetkili mahkemeyi belirlerken, davacının değil, davalının yerleşim yerini tercih etmiştir.

Bundan başka, bazı davalar için, davalının yerleşim yeri mahkemesinin yanında, başka yer mahkemeleri de yetkili kılınmıştır. Örneğin sözleşmeden doğan davalarda, sözleşmenin ifa edileceği (yerine getirileceği, icra olunacağı) yerdeki (TBK m. 89) mahkeme de yetkilidir (m. 10). İşte, bazı dava veya dava çeşitleri için kabul edilen istisnaî nitelikteki yetki kurallarına (genel olmayıp, yalnız belirli durumlara ilişkin oldukları için) **özel yetki kuralları** (m. 8 vd.) denir.

Bir kanun hükmü ile bazı davaların mutlaka belli bir yer mahkemesinde açılması öngörülmüştür ki, bu halde **kesin yetki** söz konusudur. Örneğin, taşınmazın aynına ilişkin davalar, yalnız taşınmazın bulunduğu yerde açılabilir (m. 12); davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılamaz. Bu hallerde (kesin yetki hallerinde), genel yetki kaldırılmış olup, **dava yalnız** bu özel ve **kesin yetkili mahkemede açılabilir**. Buna karşılık **kesin olmayan yetki**nin söz konusu olduğu davalarda, davacıya, birden fazla yetkili mahkemeden birine başvurma konusunda seçim hakkı tanınır.

I – GENEL YETKİ

Genel yetkili mahkeme, **davalının yerleşim yeri** (ikametgâh) **mahkemesi**dir. Yani her dava (hakkında kesin bir yetki hükmü bulunmadıkça), dava açıldığı tarihte davalının (TMK gereğince) yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde görülür (m. 6).

HMK m. 6'da açıkça belirtildiği gibi, genel yetkili mahkeme, davalının **dava açıldığı** tarihteki yerleşim yerine göre belirlenir. Davalının yerleşim yerindeki mahkemede dava açıldıktan sonra davalı yerleşim yerini değiştirirse, bu değişiklik, mahkemenin yetkisini etkilemez. Yani, davanın yeni yerleşim yerindeki mahkemeye gönderilmesini isteyemez ve mahkeme de yerleşim yeri değişikliği nedeniyle yetkisizlik kararı veremez[3].

Davalının yerleşim yerinde dava açılmasını, gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı incelemek gerekir:

***1) Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri** (İkametgâhı)*

Gerçek kişilere karşı (onların yerleşim yerinde) dava açılmasını, gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşim yeri olup olmamasına göre ikiye ayırarak incelemek gerekir.

a) Türkiye'de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Dava Açılması

Türkiye'de yerleşim yeri olan gerçek kişiye karşı dava, onun dava açıldığı tarihte (TMK m. 19 gereğince) yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde açılır (m. 6, 1). Bilindiği gibi, bir kimsenin yerleşim yeri, onun sürekli kalmak (yerleşmek) niyetiyle oturduğu yerdir (TMK m. 19, I).

Tebligat açısından ihtiyaç duyulan adres ile yerleşim yeri aynı anlama gelmez. Bir kimsenin hukuken tek yerleşim yeri olmasına rağmen (TMK m. 19, 2) birden fazla adresi olabilir. Örneğin yerleşim yeri Ankara olan davalının birden fazla ev adresi ve iş yeri adresi bulunabilir.

b) Türkiye'de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Dava Açılması

Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlara (Türklere, yabancılara ve vatansızlara) karşı, HMK m. 8 vd.'nda belirtilen (ve diğer kanunlardaki) özel yetkili mahkemelerde dava açılabileceğine kuşku yoktur. Bu özel yetki halleri ileride görülecektir[4].

Burada, (HMK m. 8 vd. ve diğer kanunlardaki) özel yetki halleri dışında **Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlara** karşı açılacak davalarda genel yetkili mahkeme, davalının Türkiye'de mutad (bilinen) meskeninin[5] bulunduğu yer mahkemesidir (m. 9, 1/c.1).

---

[3] Ancak adres değişikliğini bildiren tarafın yeni adresine tebligat yapılır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, MERNİS'te (adres kayıt sisteminde) adres varsa buraya, yoksa eski adrese tebligat yapılmaya devam eder (Teb. K. m. 35).

[4] Bkz. aşa. § 10, B, II.

[5] **"Mutad mesken"**, "yerleşim yerine" oranla daha dar, "oturma" kavramına göre ise daha geniş bir anlama sahiptir. Mutad meskende, yerleşim yerinde olduğu gibi bir yerde devamlı yerleşme niyeti yoktur; ancak ilgili, orada tesadüfen veya arızi olarak değil, iradi ve belirli bir zamandan beri yaşıyor olmalı; tüm hayat ilişkilerini orada yoğunlaştırmalıdır. Bu nedenle örneğin, Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşına karşı Türkiye'de dava açılabilmesi için davalının Türkiye'de bir evinin veya bankada hesabının (parasının) olması yeterli değildir. Bu kimsenin aynı zamanda Türkiye'de bulunma süresi, bu süre içinde yaptığı iş veya faaliyetleri (yaşam ilişkileri-eğitim, evlilik, iş vs.) de dikkate alınacak ve buna göre Türkiye'de mutad meskeninin bulunup bulunmadığına karar verilecektir.

aa) Türkiye'de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Genel Yetki

Bu davalar, yalnız mal davaları olmayıp, malvarlığı haklarına ilişkin her türlü mal ve alacak davalarıdır.

Türkiye'de yerleşim yeri olmayan tarafa karşı Türkiye'deki mutad (bilinen) meskeninin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılır (m. 9, 1/c.1). Ancak, diğer özel yetki halleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin dava, **uyuşmazlık konusu malın** (malvarlığı unsurunun) **bulunduğu yer**de de açılabilir (m. 9, 1/c. 2). Ancak taşınmazın aynına ilişkin davalar için davalının Türkiye'de mutad meskeninin olduğu yer mahkemesi değil, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir (m. 12).

Alacak davalarında, dava konusu alacak Türkiye'de doğmamış (yabancı davalının kendi ülkesinde doğmuş) olsa bile, bu alacak için davalının Türkiye'de mutad meskenin olduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

Türkiye'de yerleşim yeri olmayan **davalının Türkiye'de mutad meskeni yoksa**, dava konusu mal da Türkiye'de değilse, (o kişinin Türkiye'de başka mal, alacak ve teminatları bulunsa dahi) o kişiye karşı, m. 9'a göre, Türkiye'de dava açılamaz[6].

bb) Türkiye'de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Kişivarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Genel Yetki

Türkiye'de yerleşim yeri bulunmayan Türk vatandaşlarının, kişi hallerine ilişkin davaları[7], yabancı ülke mahkemesinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede; böyle bir yetkili mahkeme bulunmaması halinde ilgilinin Türkiye'de sakin olduğu yer mahkemesinde; Türkiye'de sakin değilse, Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesinde; o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir Mahkemelerinden birinde görülür[8].

Türkiye'de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları, ilgilinin Türkiye'de sâkin olduğu yer, sâkin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir (MÖHUK m. 42; karş. HMK m. 9).

Mirasa ilişkin davalar, ölenin Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesinde, son yerleşim yerinin Türkiye'de olmaması halinde ise terekeye dahil malların bulunduğu yer mahkemesinde görülür (MÖHUK m. 43).

---

6 HUMK'nun, Türkiye'de yerleşim yeri bulunmayan ve Türkiye'de sakin de olmayan kişinin Türkiye'de malının veya teminatının bulunduğu yerde dava açılmasına olanak veren m. 16 hükmü, Türkiye'de verilen kararların yabancı ülkelerde tanınması ve tenfizi gerektiğinde "aşkın yetki" gerekçesiyle tanıma ve tenfizi talebinin reddini engellemek amacıyla HMK'na alınmamıştır (HMK m. 9'un Gerekçesinden).

7 Yani, kişivarlığı haklarına ilişkin davalar; mesela, evlenmenin butlanı davası (TMK m. 145 vd.), boşanma ve ayrılık davaları (TMK m. 161 vd.) ve babalık davası (TMK m. 301 vd.) gibi.

8 Bkz. MÖHUK m. 41.

2) Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri

Tüzel kişilerin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde (tüzük, ana sözleşme veya vakıf senedi gibi) aksine hüküm bulunmadıkça, işlerinin (işlemlerinin) yönetildiği yerdir (TMK m. 51). Ancak, derneklerin tüzüklerine ve ticaret şirketleri ile kooperatiflerin ana sözleşmelerine, dernek, şirket veya kooperatif merkezinin yazılması zorunludur[9]. Bundan başka, vakıf senedinde vakfın yerleşim yerinin gösterilmesi gerekir (TMK m. 106). Bu nedenle, dernek, şirket kooperatif veya vakıfların yerleşim yerini, kuruluş belgesine (tüzük, ana sözleşme veya vakıf senedine) bakarak kolayca tespit etmek mümkündür. Buna göre, dernek, ticaret şirketi, kooperatif veya vakıflara karşı açılacak davalarda genel yetkili mahkeme, bunların merkezinin (yerleşim yerinin) bulunduğu yer mahkemesidir (m. 6).

Buradaki inceleme konumuz genel yetkidir ve tüzel kişilere karşı açılacak davalarda genel yetkili mahkeme, **tüzel kişinin yerleşim yeri**nin (merkezinin) bulunduğu yer **mahkemesidir**. Bazen, tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi, tüzel kişiler tarafından açılacak davalar ve üyelerin birbirine karşı açacakları davalar için de yetkilidir (m. 14, 2). Bu hallerde, tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesinin genel yetkisinden söz edilemez; çünkü, bu hallerde tüzel kişi, davalı durumunda olmayıp, tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi, özel ve kesin yetkili mahkeme durumundadır (m. 14, 2).

3) Davalıların Birden Fazla Olması Halinde Genel Yetkili Mahkeme

Buraya kadar, davalının bir (tek) kişi olması halinde genel yetkili mahkemeyi inceledik. Şimdi, davalıların birden fazla olması halinde genel yetkili mahkeme inceleme konusu yapılacaktır:

a) Davalılardan Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olması

Bir davada davalı sayısı birden fazla ise (davalı tarafta, birden fazla dava arkadaşı varsa) dava, bunlardan **birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir** (m. 7, 1/c. 1); örneğin bir anne veya baba, birden fazla çocuğuna karşı çocuklardan yalnız birinin yerleşim yeri mahkemesinde yardım nafakası davası (TMK m. 364) açabilir (TMK m. 365, VI) veya alacaklı hem asıl borçlu hem de kefili davalı olarak göstererek, bunlardan birisinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

b) İstisnalar

Birden fazla davalıya karşı, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabileceği kuralının (m. 7, 1/c.1) bazı **istisnaları** vardır:

aa) Ortak Yetkili Mahkeme Bulunması

Kanun dava sebebine göre, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belli edilmiş ise, davaya o (ortak yetkili) mahkemede ba-

---

9 Bkz. Dernekler K. m. 4/a; TTK m. 213, 305, 339, 567, 576; Kooperatifler K. m. 4, 1.

kılır hükmünü koymuştur (m. 7, 1/c. 2). Bu halde, davalılardan birinin yerleşim yerindeki mahkemede dava açılamaz.

Kanunun ortak yetkili mahkemeyi gösterdiği hallerden biri, haksız fiilden doğan davada yetkiyi gösteren m. 16 hükmüdür. Bir **haksız fiil** birden fazla kişi tarafından işlenmiş ise, bu kişilere karşı açılacak tazminat davası (TBK m. 49 vd.) için **ortak yetkili mahkeme, haksız fiilin işlendiği** (veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer) ya da **zarar görenin yerleşim yeri mahkemesidir** (m. 16). Bu nedenle, birden fazla kişiye karşı birlikte açılacak tazminat davası için yetkili mahkeme, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi (m. 7, 1/c. 1) değildir (m. 7, 1/c. 2). Buna karşılık, ayrı ayrı dava açılırsa her bir davalının yerleşim yeri yetkilidir.

bb) Davanın Sırf Davalılardan Birini Kendi Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye Getirmek Amacıyla Açılması

Kanunda davalıların tamamı için ortak yetkili bir mahkemenin belli edilmemiş olduğu hallerde, m. 7, 1/c.1 hükmünün, yani birden fazla davalıya karşı, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabileceği kuralının uygulanması da mutlak değildir: Davanın, sırf (şeklen m. 7, 1/c.1 hükmünden yararlanmak suretiyle) davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, belirtiler veya başka delillerle anlaşılırsa, mahkeme onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir (m. 7, 2). Yani davanın, sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden (Anayasa m. 37) başka bir mahkemede davalı duruma sokmak amacıyla, yapay yetkili mahkeme yaratılması halinde, mahkeme yetkisizlik ve ayırma kararı verir; örnekler:

İnşaat malzemesi üretimi işiyle uğraşan (B) Anonim Şirketi, Konya ili merkezinde faaliyette bulunmaktadır. Bu şirketin çeşitli ortakları mevcuttur ve en büyük ortaklarından biri de yerleşim yeri Ankara'da olan (C) Holding AŞ'dir. (B) Anonim Şirketinin işçilerinden (İ), kazaen fabrikadaki vincin altında kalarak ölmüştür. İ'nin mirasçıları, Ankara'da bir destekten yoksun kalma tazminatı davası açmış ve bu davada (B) Anonim Şirketi ile (C) Holding AŞ davalı olarak gösterilmiştir. Böyle bir olayda; eğer bir sorumluluk varsa, bunun muhatabının işveren durumunda bulunan Konya'daki (B) Anonim Şirketi'nin olması; (B) Anonim Şirketi'nin ortaklarından olup merkezi Ankara'daki (C) Holding AŞ'nin olayda anonim şirketi ortağı sıfatıyla ticaret hukuku açısından herhangi bir sorumluluğunun bulunmasının mümkün olmadığı ve davada onun davalı olarak gösterilmesinin HMK m. 7, 2'ye aykırı olduğu gerekçesiyle davanın ayrılarak; davanın, (B) Anonim Şirketi bakımından (merkezinin Konya olması itibariyle) yetkisizlik yönünden usulden ve (C) Holding AŞ açısından ise (sorumlu tutulmasının hukuken mümkün olmaması itibariyle) esastan reddine karar verilmesi gerekir.

Başka bir olayda, (A)'nın otomobili ile (B)'nin otobüsü çarpışmış, (A) yaralanmış ve (A)'nın otomobili de hasar görmüştü. (A)'nın otomobili (G) Sigorta Şirketine, (B)'nin otobüsü ise (R) Sigorta Şirketine sigortalıdır. (A), (B)'ye ve (kendi sigorta şirketi olan) (G) Sigorta Şirketine karşı [(G) Sigorta Şirketi-

nin merkezinin bulunduğu] İstanbul'da tazminat davası açmıştır. [(B)'nin ikametgâhı İstanbul dışında bir yerdir). (B), yetki (ilk) itirazında bulunmuş, mahkeme yetki itirazını reddetmiş, Yargıtay mahkemenin kararını (haklı olarak) aşağıdaki gerekçe ile bozmuştur: "Davacının (A'nın) aracı kendi aracının üçüncü kişilere verdiği zararı karşılamak üzere (G) Sigorta Şirketine sigorta ettirilmiştir. Davalının (B'nin) otobüsünün sigortası ise (R) Sigorta Şirketince sağlanmıştır. O halde davacı arabasının uğradığı zarardan ötürü kendi aracını trafik sigortası kurallarına göre sigorta eden (G) Sigortadan değil, ancak (R) Sigorta Şirketinden isteyebilir. Bu yönün gözetilmesi gerekir. Böylece dava kendisine husumet düşmeyecek olan (G) Sigortanın da araya katılmasıyla ve kötüniyetle İstanbul'da açılmıştır. Usulün 9. maddesinin 3. fıkrası (şimdi: HMK m. 7, 2) bu yoldadır. Bu nedenle dava edilen şoför (B)'ye karşı açılan dava için yöneltilen yetki itirazının ret edilmiş bulunması usul ve yasaya aykırıdır. Verilen karar yetki nedeniyle bozulmalıdır".

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi mahkeme, m. 7, 2'deki durumun var olup olmadığını, ancak davalının yetki (ilk) itirazı (m. 116, 1/a) üzerine inceler. Davalı yetki itirazında bulunmazsa, mahkemenin yetkisini kabul etmiş sayılır (m. 19, 4).

4) Genel Yetki Kurallarının Niteliği

Buraya kadar incelediğimiz m. 6'da düzenlenen genel yetki kuralı, kural olarak bütün davalar içindir. Ancak, kesin yetki halleri genel yetkiye istisnadır. Yani, (örneğin m. 12'de olduğu gibi) bir dava için **kesin yetkili mahkeme** belirlenmiş ise, o dava **genel yetkili** (davalının yerleşim yerindeki) **mahkemede açılamaz**. Bunun dışında, bir dava için özel yetki kuralı bulunsa bile, davacının genel yetki ile özel yetki arasında bir seçim hakkı vardır. Davacı, davasını dilerse genel yetkili mahkemede, dilerse özel yetkili mahkemede açar.

Taraflar, yetki sözleşmesi[10] ile yetkili olmayan bir mahkemeyi yetkili kılarsa, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, dava sadece sözleşmeyle belirlenen mahkemede açılacağından, genel yetkili mahkemenin yetkisi ortadan kalkar.

II – ÖZEL YETKİ KURALLARI

Kanun, genel yetkili mahkemeden (m. 6) başka, bazı davalar için özel yetki kuralları ile başka yetkili mahkeme ya da mahkemeler göstermiştir (m. 8 vd.). Bu özel yetkili mahkemeler, ilişkin oldukları davalar ile herhangi bir şekilde ilgilidir. Örneğin, dava konusu taşınmaz o mahkemenin yargı çevresi içindedir (m. 12) veya dava konusu sözleşme orada yerine getirilecektir (m. 10) gibi.

Özel yetki kuralları, kural olarak kesin değildir; örneğin m. 8'de ve 10'da yer alan yetki kuralları gibi. Bazı özel yetki kuralları istisnaî olarak **kesindir**;

---

[10] Bkz. HMK m. 17-18, aşa. § 10. C, I.

örneğin m. 11, 1; 12 veya 14, 2'deki yetki kuralları gibi. Bu halde dava yalnız kesin yetkili yerde (mahkemede) açılabilir, başka yerde açılamaz.

Hangi özel yetki kurallarının kesin yetkiyi düzenlediği, aşağıda özel yetki halleri incelenirken ayrı ayrı belirtilecektir. Özel yetki hallerinin incelenmesi bittikten sonra, bir yetki kuralının kesin olup olmamasının hüküm ve sonuçları görülecektir.

Burada, özel yetki kurallarını ayrı ayrı incelemeye geçmeden önce, kesin olmayan özel yetki kuralları ile genel yetkili mahkemenin (m. 6) yetkisinin ortadan kaldırılamayacağını bir kez daha belirtmek gerekir. Davacı, davasını genel veya özel yetkili mahkemede açmak hususunda bir seçim hakkına sahiptir.

Özel yetki kuralları şunlardır:

1) Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki

a) Genel Bilgi

HMK m. 10, sözleşmeden doğan davalar için özel bir yetki kuralı koymuştur. Bu kuralın incelenmesine geçmeden önce, buradaki sözleşme teriminin açıklanması gerekir. Buradaki sözleşme terimi, konusu malvarlığı hakkı olan **borçlar hukukuna ilişkin sözleşmeler** anlamındadır; örneğin satış, ödünç (karz), hizmet, kira, istisna (eser yapım) ve vekâlet sözleşmelerinden doğan davalar; sözleşmenin yerine getirilmesine (sözleşmedeki alacağın ödenmesine, malın teslimine, cezaî şartın ödenmesine) ilişkin davalar sözleşmenin yerine getirilmemesinden doğan tazminat davaları; sözleşmenin geçerli olup olmadığına ilişkin tespit davaları gibi.

Konusu kişivarlığı hakkı olan (kişiler hukuku ve aile hukukuna ilişkin) sözleşmeler buraya (m. 10 hükmüne) dahil değildir. Miras hukukuna ilişkin sözleşmeler de m. 10 hükmüne tâbi değildir.

HMK m. 10 hükmü sözleşmeden doğan davalar içindir. Bu nedenle, kanundan ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar için m. 10 hükmü uygulanmaz.

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin (akdin) **ifa edileceği** (yerine getirileceği, icra edileceği) **yer** mahkemesinde dava açılabilir (m. 10)[11].

Sözleşmenin ifa edileceği yer, ilk önce **tarafların açık** veya **örtülü** (üstü kapalı-zımnî) **isteğine göre belirlenir**; bu yer belli ise, dava o yerde açılabilir. Örneğin, bir sözleşmenin feshi ve sözleşmeye aykırılıktan doğan tazminat (ve bu sözleşme gereğince verilen bonoların iptali) davası, (açıkça kararlaştırılan veya üstü kapalı anlaşılan) ifa yerindeki mahkemede açılabilir.

---

[11] HUMK m. 10'da, HMK'den farklı olarak, sözleşmeden doğan davalarda iki özel yetki kuralı konulmuştu. Bunlardan biri, HMK m. 10'daki gibi ifa yeri mahkemesinin yetkisi; diğeri ise, davalı veya vekilinin orada bulunması şartıyla sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin yetkisi idi. Davalı veya vekilinin, dava açılmadan önce sözleşmenin yapıldığı yerde bulunup bulunmadığının tespitindeki zorluk ve buna bağlı olarak uygulama alanı bulunmadığı gerekçesiyle bu ikinci yetki kuralı, HMK m. 10'a alınmamıştır. İİK m. 50'ye göre de, icra takibine esas olan sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi de takibe yetkilidir.

Tarafların sözleşmenin yerine getirileceği yer hakkındaki **açık** veya **örtülü** (üstü kapalı-zımnî) **isteğinin anlaşılamadığı** (ifa yerinin açıkça belirtilmediği) **hallerde,** sözleşmenin yerine getirileceği yer **TBK m. 89'a göre belirlenir**. Buna göre:

Davanın konusu, sözleşmeden doğan bir para borcu olup da sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ise, bu para borcu **alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde** ödenir (TBK m. 89, 1). Yani, bu para borcunun yerine getirileceği (icra, ifa edileceği) yer alacaklının yerleşim yeridir. Bu durumda, alacaklı, bu para borcunun ödenmesi için (borcun yerine getirileceği yer olan) kendi yerleşim yerinde dava açabilir (HMK m. 10).

TBK m. 89, 1 hükmü, götürülecek (yani alacaklının yerleşim yerinde ödenecek) borçlar içindir. **Aranacak** (veya aldırılan) **borçlar için TBK m. 89, 1 hükmü uygulanmaz**; yani bu borçlar, borçlunun yerleşim yerinde ödenir. Örneğin, kambiyo senetlerinden doğan alacaklar aranacak alacaklardır; bu alacaklar için (alacaklının değil) borçlunun yerleşim yerinde dava açılabilir.

b) Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetkinin Niteliği

HMK m. 10 hükmü, yalnız sözleşmenin tarafları için değil, aynı zamanda tarafların kefilleri ile cüz'î ve küllî halefleri için de uygulanır.

HMK m. 10'daki (sözleşmeden doğan davalar hakkındaki yukarıda incelediğimiz) yetki kuralları **kesin** yetki kurallarından **değildir**. Sözleşmeden doğan davalar için yetki anlaşması (sözleşmesi) yapılabilir (veya sözleşmeye yetki şartı konabilir). Bu halde, taraflarca (sözleşmede) aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşme ile belirlenen bu mahkemelerde açılır (m. 17).

2) Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki

Haksız fiilden (TBK m. 49 vd.) doğan davalarda aşağıdaki mahkemeler yetkilidir: a) **Haksız fiilin işlendiği** (vuku bulduğu, meydana geldiği) **yer** mahkemesi; b) **Zararın meydana geldiği** yahut zararın **gelme ihtimalinin bulunduğu yer** mahkemesi; c) **Zarar görenin yerleşim yeri** mahkemesi (m. 16).

Haksız fiil bir gazete (veya gazetede yayımlanan bir ilân) ile işlenmişse, gazetenin yayımlandığı ve satıldığı (dağıtıldığı) **yerlerdeki mahkemeler**, bu haksız fiilden doğan dava için yetkilidir.

Bir haksız fiil **birden fazla kişi** tarafından işlenmiş ise, bu kişilere karşı (birlikte) açılacak tazminat davası, ortak yetkili mahkeme olan haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalînin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde görülür (m. 16). Bu halde, davalıların **hepsine karşı** (birlikte) davalılardan birinin yerleşim yerindeki mahkemede dava açılamaz (m. 7, 1/c. 2).

Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinin yetkisi de kesin yetki değildir.

3) Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki

Taşınmaz (TMK m. 704) üzerindeki aynî hakka veya aynî hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine veya alıkoyma hakkına ilişkin davalar, **taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır** (m. 12, 1).

Eşya hukuku konularına dahil olan aynî haktan kasıt, bir kimseye bir şey üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve bu sebeple herkese karşı ileri sürülebilen haktır. Bunlar, esas itibariyle, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklardır (irtifak hakları, rehin hakları, taşınmaz yükü). **Taşınmazın aynına ilişkin davaların** neler olduğu m. 12, 1'de açıklanmıştır. Bunlar: i) Taşınmaz üzerindeki aynî hakka ilişkin davalar; ii) Aynî hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar; iii) Taşınmazın zilyetliğine ilişkin davalar; iv) Taşınmazın alıkoyma (hapis) hakkına ilişkin davalar.

Kanunun (m. 12) kullandığı "ayın" tabiri nedeniyle, bu hüküm, taşınmaz üzerindeki kişisel haklara ilişkin davalarda uygulanmaz.

Buna göre, taşınmazın aynına (taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka) ilişkin oldukları için, taşınmazın bulunduğu yerde açılması gereken davalara, **istihkak davaları** (TMK m. 683), **tescil davaları** (TMK m. 713) ve **yolsuz tescilin** silinmesi ve değiştirilmesi (düzeltilmesi) davaları (TMK m. 1025) örnek verilebilir.

İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır (m. 12, 2).

Taşınmaza ilişkin **taksim** ve **paydaşlığın** (şüyuun) **giderilmesi davaları,** taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

Bunun gibi, **şuf'a** (önalım) **davası** (TMK m. 732-735) da taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

Buna karşılık, **taşınmaz üzerindeki kişisel haklara ilişkin davalar**, m. 12 hükmüne tâbi değildir; örneğin, **kira alacağının** (bedelinin) **ödenmesi** için açılan davalar veya **kira bedelinin tespiti davaları**, kiralanan taşınmazın aynına ilişkin olmadığı için m. 12 hükmüne tâbi değildir. **Kiralanan taşınmazların tahliyesi** için açılan davalar (tahliye davaları), taşınmazın aynına ve taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka ilişkin değildir. Bu nedenle, tahliye davaları m. 12 hükmüne tâbi değildir.

Taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka ilişkin bulunmadıkları için m. 12 hükmüne tâbi olmayan davalara başka örneklere geçmeden önce, kira sözleşmesine dayanarak açılan davalarda yetki konusu üzerinde durmakta yarar vardır: Kira sözleşmesine dayanarak açılan, kira alacağı, kira bedelinin tespiti ve tahliye davaları, taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka ilişkin olmadıkları için m. 12 hükmüne tâbi değildir. Fakat bu, sözü geçen davaların, **taşınmazın bulunduğu yerde açılamayacağı anlamına gelmez**. Bu davalar, m. 12 hükmüne tâbi değildir; yani bu davaların taşınmazın bulunduğu yerde m. 12'ye göre açılması zorunlu değildir. Fakat, **kira sözleşmesine dayanan bu davaların** (kira alacağı, tespiti ve tahliye davalarının) **diğer yetki kurallarına** (m. 6, 8, 10 vb. hükümlerine) göre **taşınmazın bulunduğu yerde açıl-**

ması mümkündür. Özellikle, taşınmazın bulunduğu yer kira sözleşmesinin ifa edileceği (yerine getirileceği, icra olunacağı) yerdir. Bu nedenle, kira sözleşmesine dayanan bir dava (örneğin tahliye davası) sözleşmenin ifa olunacağı yer olan taşınmazın bulunduğu yerde açılabilir (m. 10).

Kira sözleşmesine dayanarak açılan davaların, m. 12 hükmüne göre değil de başka hükümlere (özellikle m. 10 hükmüne) göre taşınmazın bulunduğu yerde açılmasının sonucu şudur: Kira sözleşmesine dayanan davalar için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi kesin değildir. Bu davalar, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de (m. 6) açılabilir. Bundan başka, taraflar kira sözleşmesine koyacakları bir yetki şartı veya yapacakları ayrı bir yetki sözleşmesi (m. 17) ile başka bir yer mahkemesinin yetkili olduğunu kararlaştırabilirler. Bu davalarda, yetki itirazı ilk itiraz olarak ileri sürülebilir; mahkeme yetkisizliğini kendiliğinden (resen) dikkate alamaz.

Bu ara açıklamadan sonra, taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka ilişkin olmadıkları için m. 12 hükmüne tâbi bulunmayan davalara başka örnekler vermeye devam edelim: Kiracının kiralamış olduğu bir arazinin teslimi, kiralayanın da **kira akdinin feshi ile kiraya vermiş olduğu taşınmazın kendisine teslimi** için açmış oldukları dava ve karşı dava, taşınmazın aynına ilişkin olmadığından, bu davalar için m. 12 hükmü uygulanmaz. Bir taşınmazın maliki tarafından, o taşınmazı haksız yere işgal eden kişiye karşı açılan işgal tazminatı (**ecrimisil**) davası, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığından, m. 12 hükmüne tâbi değildir. Taşınmazın satış bedelinin ödenmesi için açılan davalar, m. 12 hükmüne tâbi değildir. Taşınmaz **satış vaadi sözleşmesinin feshi**ne ve bu sözleşme gereğince verilen para ile kararlaştırılan **cezaî şartın ödenmesi**ne ilişkin davalar, m. 12 hükmüne tâbi değildir. **İpotekle temin edilmiş** olan **para alacağının ödenmesi**ne ilişkin davalar, m. 12 hükmüne tâbi değildir.

Davalıya ait arsa üzerine bina yapmış olan davacının, **bina için yaptığı giderlerin ödenmesi** (TMK m. 723) hakkında açtığı dava, taşınmazın aynına ilişkin bir dava değildir; bu nedenle, taşınmazın bulunduğu yerde m. 12'ye dayanarak açılamaz, davalının yerleşim yeri mahkemesinde (m. 6) açılabilir.

Yukarıda gördüğümüz taşınmaz üzerindeki aynî haklara ilişkin davalardan başka, geçici bile olsa, **taşınmazın zilyetliğine veya alıkoyma** (hapis) **hakkına ilişkin** davalar da taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür (m. 12).

HMK m. 12'ye göre taşınmazın bulunduğu yerde açılması zorunlu olan dava, **birden fazla** taşınmaza **ilişkin** ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır (m. 12, 3).

Taşınmazın aynına (ve zilyetliğine veya alıkoyma hakkına) ilişkin davaların taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması hakkındaki (m. 12'deki) yetki kuralı, **kesin yetki**dir.

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisinin kesin olmasının nedeni, bu davalara en kolay, en çabuk, en az giderle, en emin bir şekilde taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi tarafından bakılabileceğidir. Çünkü, tapu kayıtları o ilçededir; keşif orada (m. 288) yapılır ve tanıklar da keşif yerin-

de dinlenir (m. 290). Hâkim, keşifte taşınmazın durumunu bizzat görüp, tanıkları bizzat dinleyeceği için (bu işleri istinabe ile yaptırmasına oranla) dava hakkında daha iyi (doğrudan) bilgi sahibi olur ve taşınmazın durumunu en iyi bilen hâkim olarak en doğru kararı o verebilir.

HMK m. 12'deki yetki kesin olduğu için, bu konuda **yetki sözleşmesi yapılamaz** (m. 17); mahkeme yetkili olup olmadığını (yetkisizliğini) her zaman kendiliğinden gözetir (m. 19, 1); taraflar da davanın her aşamasında yetki itirazında bulunabilirler (m. 19, 1); yani bu halde yetki itirazı ilk itirazlardan (m. 116, 1/a) değildir; **dava şartı**dır.

4) Miras İle İlgili Davalarda Yetki

Miras (tereke) ile ilgili davalar, **mirasbırakanın** (murisin, ölen kimsenin) **son yerleşim yeri mahkemesinde** görülür (HMK m. 11; TMK m. 576). Miras ile ilgili davalar, HMK m. 11 ve TMK m. 576'da sayılmıştır. Bunlar dışındaki davalar için, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi, yetkili değildir.

Mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin **yetkisi kural olarak kesindir**. İstisna olarak, miras ile ilgili bazı davalar, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinden başka bir yerdeki mahkemede de açılabilir. Konuyu, buna göre ikiye ayırarak incelemek gerekir:

a) Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Kesin Yetkisi

Miras ile ilgili davalar bakımından, son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisinin kesin olduğu haller de üçe ayrılır:

aa) Aşağıdaki davalar her halde, yani **terekenin** (mirasın) **taksiminden sonra da** mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde açılır (HMK m. 11, 1/a; TMK m. 576, II): Terekenin taksimi davası (TMK m. 642), taksimin butlanı ve feshi davası (TMK m. 680), mirasçılar arasında terekenin idaresi nedeniyle çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar (m. 11, 1/a), ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları (TMK m. 558-559, 576), tenkis davaları (TMK m. 560-571; 576).

Tenkis davası, bir taşınmaza ilişkin olsa bile (taşınmazın bulunduğu yerde değil) **mirasbırakanın son yerleşim yeri, mahkemesinde açılır.** Miras sebebiyle istihkak davası, HMK m. 11, 2'deki istihkak davasından başkadır. Bu nedenle, miras sebebiyle istihkak davası (TMK m. 576, II'de de açıkça yazılı olduğu gibi) yalnız mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir **(kesin yetki)**; malın bulunduğu yerde açılamaz.

bb) Terekenin (mirasın) **kesin taksimine** (paylaşılmasına) (TMK m. 676 vd.) **kadar terekeye** (yani miras şirketine) **karşı açılacak davalar**a da, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde bakılır (HMK m. 11, 1/b). Örneğin, terekeye (miras şirketine) karşı açılacak alacak davaları ve vasiyetnamenin tenfizi davaları mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Bu (m. 11, 1/b'deki) yetki, terekeye, miras şirketine karşı açılacak davalar içindir. Dava, terekeye karşı değil de, mirasçıya (veya bazı mirasçılara) karşı açılırsa, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi değil, davalı mirasçının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olur. Örneğin, bir mirasçıya karşı

açılan vasiyetnamenin tenfizi davası için, davalı mirasçının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Terekeye karşı açılacak davalar hakkındaki mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi, mirasın kesin taksimine kadar devam eder (m. 11, 1/b). Bundan (kesin taksimden) sonra terekeye (miras şirketine) karşı değil, mirasçılara karşı (karş. TMK m. 681) davalara mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde değil, davalı mirasçının yerleşim yeri mahkemesinde bakılır (m. 6).

Yukarıdaki (yani, HMK m. 11, 1 ve TMK m. 576, II'deki) hallerde, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi, **kesin yetki**dir; bu hallerde mahkeme yetkili olup olmadığını kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür.

cc) Miras hukukundaki **çekişmesiz yargı işleri** (m. 382) için de, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin çekişmesiz yargı işleri hakkındaki yetkisi de kural olarak kesindir. Bunun bazı istisnaları vardır: İleride görüleceği gibi, mirasçılık belgesi verilmesi işinde, son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi kesin değildir (m. 11, 3).

Mirasın reddinin tescili (TMK m. 609; VVM Tüz. m. 40) isteklerinde yetki söz konusu değildir ve bu halde TMK m. 576 ile HMK m. 11 hükümleri uygulanmaz.

b) Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Kesin Olmayan Yetkisi

HMK'nun 11. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı dava ve işlerde, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi kesin değildir. Bu dava ve işlere, hem son yerleşim yeri mahkemesinde hem de başka bir mahkemede bakılabilir. Bu dava ve işleri de ikiye ayırmak gerekir:

aa) Bir mal hakkında terekeye karşı açılacak **istihkak davası** (TMK m. 683) için, terekenin tahrir ve tespiti (terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması, TMK m. 590) zamanında **mal nerede bulunursa,** o yer mahkemesi de yetkilidir (m. 11, 2). Buradaki (m. 11, 2'deki) istihkak davası TMK m. 683'deki istihkak davası (haksız elatmanın önlenmesi davası) **olup**, TMK m. 637-639'daki **miras sebebiyle istihkak davasından tamamen başkadır.** Buradaki istihkak davası ile, mirasçı olmayan bir kimse, mirasbırakanın ve dolayısıyla terekenin (miras şirketinin) zilyetliğinde bulunan bir malın kendisine ait olduğunu iddia ederek, malın kendisine verilmesini istemektedir.

bb) **Mirasçılık belgesinin** (veraset ilâmının) **iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine** ilişkin davalar, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesinde de açılabilir (m. 11, 3).

5) Karşı Davada Yetki

Açılmış bulunan bir davada, davalının da kendi alacağı (hakkı) için aynı mahkemede (ve aynı dava dosyasında) davacıya dava açmasına, **karşı dava** (karşılık dava; mukabil dava; mütekabil dava) (m. 132 vd.) denir. Karşı dava, asıl dava ile birlikte aynı mahkemede görülür.

Karşı davanın asıl dava ile birlikte görülmesini sağlamak amacıyla, kanun özel bir yetki hükmü kabul etmiştir. Buna göre, kesin yetkinin söz konusu olmadığı hallerde, **asıl davanın açılmış olduğu mahkeme**, **asıl davaya karşı açılan karşı davaya bakmaya da yetkilidir** (m. 13).

6) Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi

Genel olarak bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınaî veya ticarî faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları **şube**dir (Ticaret Sicili Yön. m.118, 1). Bankalar bakımından şube, elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların bağımlı bir parçasını oluşturan ve bu kuruluşların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü işyerini; merkez şube ise, yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de açtığı şubeyi, birden fazla şubenin olması halinde ise Kuruma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak şubeyi ifade eder (Bankacılık K. m.3).

Şube kendi başına işlem (muamele) yapabilirse de, bu işlemden doğan hak ve borçlar, merkeze (şubenin bağlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiliğe) aittir. Bu nedenle, **şubenin yaptığı işlemden dolayı** (merkeze karşı) **merkezin bulunduğu yer mahkemesinde** dava açılabilir (m. 6)[12].

Bundan başka, şube ile iş yapanlara kolaylık sağlamak için, **şubenin işlemlerinden dolayı** (merkeze karşı)[13] **şubenin bulunduğu yerde de dava açılabileceği** kabul edilmiştir (m. 14, 1). Buna göre, bir gerçek veya tüzel kişinin başka bir yerde şubesi varsa, o şubenin işlemlerinden dolayı (yani o şubenin yapmış olduğu işlemlerden doğan uyuşmazlıklar için), şubenin bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir (m. 14).

Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu kuralının bazı istisnaları vardır. Şubenin işleminden doğmuş olsa bile, **aşağıdaki davalar şubenin bulunduğu yerde açılamaz**; yalnız merkezin bulunduğu yerde açılabilir:

İflâs davası, yalnız şubenin bağlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişinin işlem (muamele) merkezinin bulunduğu yerde açılır ve bu yetki **kesin**dir (İİK m. 154, III).

Özel hukuk tüzel kişilerinin (örneğin şirket, kooperatif, dernek veya vakıfların) kendi işlerine ilişkin olmak üzere üyelerine karşı ve üyelerin bu sıfatla (üye sıfatıyla) birbirlerine karşı açacakları davalara, özel hukuk tüzel kişisinin (şirket, kooperatif, dernek veya vakfın) yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde bakılır ve bu yetki de **kesin**dir (m. 14).

---

12 Bu hüküm, çeşitli ve değişik yerlerde şubeleri olan tüzel kişilere karşı merkezde dava açmanın zorluğunu gidermek bakımından kabul edilmiştir. Şubenin tüzel kişiliği bulunmadığı için bu davada şubenin davalı sıfatı yoktur; davanın tarafı tüzel kişi olacaktır.

13 HMK m. 14, 1'deki yetki kuralı, şubenin bağlı bulunduğu merkeze karşı açılacak davalar içindir. Buna karşılık şubenin bağlı bulunduğu merkezin açacağı davalar için m. 14, 1'deki yetki kuralı uygulanmaz.

7) Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki

Kanun, sigorta sözleşmesinden doğan davalar[14] için bazı özel yetki kuralları koymuştur (m. 15). Sigorta sözleşmesinden doğan davalara ilişkin özel yetki kurallarını, sigorta çeşitlerine göre ayrı ayrı incelemek gerekir:

a) Zarar (Mal) **Sigortalarında** (TTK m. 1453-1486)

Sigortanın konusu bir **taşınmaz** ise, tazminat davası o taşınmazın bulunduğu yerde de açılabilir (m. 15, 1).

Sigortanın konusu bir **taşınır** mal ise, burada da bir ayrım yapmak gerekir: Taşınır mal (fabrikadaki makine gibi) belli bir yerde kalması şart kılınan bir mal ise, dava malın bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir (m. 15, 1). Taşınır mal (otomobil gibi) bir yerde devamlı kalmayan (müstakar olmayan, hareket eden) bir mal ise, dava tehlikenin doğduğu (hâdis olduğu) yer mahkemesinde de **açılabilir** (m. 15, 1).

b) Can (Hayat) **Sigortalarında** (TTK m. 1487-1520)

Can sigortalarında sigorta ettiren, sigortalının veya lehtarın leh ve aleyhine açılan davalarda onların yerleşim yerindeki mahkeme, **kesin yetkili**dir (m. 15, 2). Buna göre, sigorta ettiren, sigortalı veya lehtar kendi yerleşim yerinde (ikametgâhında) sigorta şirketine karşı dava açabilir.

HMK m. 15, 2'deki bu kesin yetki hükmü, sigortalıları büyük bir ekonomik güce sahip olan sigorta şirketlerine karşı korumak amacıyla konulmuştur. Bu nedenle, sigorta sözleşmelerine m. 15, 2'deki bu yetki hükmüne **aykırı bir yetki şartı konulamaz**; konulmuş ise bu yetki şartı hükümsüzdür.

c) Malî mesuliyet sigortasında yetkili mahkeme, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu veya kazanın meydana geldiği yer mahkemesidir (Karayolları Trafik K. m. 110).

8) Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesinin Yetkisi

Memur, işçi, öğrenci, asker gibi **bir yerde geçici olarak oturan kişilere karşı** açılacak bazı davalar için, belli şartların varlığı halinde, davalının geçici olarak oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir (m. 8). Bunun için gerekli şartlar şunlardır:

Kendilerine karşı geçici olarak oturdukları yerde dava açılacak bu kişilerin **o yerde** oturmaları, orada bulunma sebeplerine (uğraşılarına, meşguliyetlerine) göre **uzunca bir zaman devam edebilecek olmalı**dır. Yukarıda örnek olarak sayılan memur, işçi, öğrenci ve asker ve benzerlerinde bu koşul genellikle vardır. Uzunca bir zaman hastanede, sanatoryumda veya cezaevinde kalacak olan kişilere karşı da, o yerde dava açılabilir. Buna karşılık,

---

[14] HMK m. 15, eski HUMK m. 19'dan farklı olarak, "tazminat davası" tabirini kullanmamıştır ve böylece m. 15'deki yetki kuralının **sigorta sözleşmesinden doğan tazminat davaları dışında diğer davaları da içine alması sağlanmıştır** (Hükümet Gerekçesi).

sırf bir iş takibi için veya turist olarak oraya gelmiş olan kişilerin, uğraşının uzunca bir zaman devam etmesi söz konusu değildir.

Bu kişilere karşı geçici olarak oturdukları yerde açılabilecek davalar **yalnız alacak** ve **taşınır mal davalarıdır** (m. 8). Sözleşmeden doğan alacak davaları buraya dahil olduğu gibi, sebepsiz zenginleşmeden (TBK m. 77 vd.) doğan alacak davaları ve haksız fiilden dolayı maddî veya manevî tazminat davaları gibi davalar da geçici olarak oturulan yer mahkemesinde açılabilir.

HMK m. 8'deki yetki, yalnız alacak ve taşınır mal davaları içindir (taşınır malın iadesi davası gibi). **Taşınmaz davaları** (m. 12), m. 8'e göre davalının geçici olarak oturduğu yerde **açılamaz**.

Bunun gibi, **kişivarlığı haklarına ilişkin davalar** da (m. 8'e göre) davalının geçici olarak oturduğu yer mahkemesinde **açılamaz**. Yalnız, boşanma ve ayrılık davaları, eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de açılabilir (TMK m. 168). Bunun dışında, yani eşler o yerde son defa altı aydan daha kısa bir süre oturmakta iseler veya davalı eş orada altı aydan fazla bir zamandan beri oturmakla beraber davacı eş başka yerde oturmakta ise, davacı eş, (örneğin memur olan) davalı eşine karşı, davalının oturduğu yer mahkemesinde m. 8 hükmüne dayanarak boşanma (veya ayrılık) davası açamaz.

HMK m. 8'deki yetki kuralı, kesin yetki değildir.

9) Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işlerinde, **talepte bulunan kişinin** veya ilgililerden birinin **oturduğu yer mahkemesi** yetkilidir (m. 384). Ancak kanunların kesin yetkiyi düzenlendiği işlerdeki (örneğin m. 12'deki) çekişmesiz yargı işlerindeki yetki de **kesin yetki**dir[15].

10) Diğer Kanunlardaki Özel Yetki Kuralları

Buraya kadar, HMK'ndaki özel yetki kurallarını inceledik. Bundan başka, bazı kanunlarda konuları ile ilgili dava ve işler için özel yetki hükümleri vardır; bu yetki hükümleri saklıdır (m. 5).

Diğer kanunlardaki özel yetki hükümlerinin hepsini burada saymak ve incelemek imkânsızdır. Bu nedenle, burada diğer kanunlardaki başlıca özel yetki hükümlerini belirtmekle yetineceğiz:

a) Türk Medenî Kanunundaki Özel Yetki Kuralları

TMK'nda yetkiye ilişkin birçok kural bulunmaktadır. Bunların başında **boşanma davaları hakkındaki yetki kuralı** gelmektedir.

Boşanma (ve ayrılık ve evliliğin feshi, TMK m. 160) davaları için **iki yetki kuralı** vardır (m. 168). Buna göre, boşanma (ve ayrılık ve evliliğin feshi) davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir (TMK m. 168)[16].

---

[15] Bkz. m. 384'e ilişkin Hükümet Gerekçesi.

[16] HUMK m. 9, III'de boşanma davalarında yetkiyi düzenleyen hüküm, aynı konu TMK m. 168'de de düzenlendiğinden, tekrardan kaçınma gerekçesiyle HMK'na alınmamıştır.

TMK m. 168 hükmü, ilk bakışta HMK m. 6, 1 hükmüne bir istisna gibi görülürse de, bu gerçek bir istisna değildir. Çünkü, eşler, oturacakları konutu birlikte seçerler (TMK m. 186, I) ve kural olarak aynı yerde otururlar. Bu nedenle, karı ve kocanın yerleşim yeri, (kural olarak) aynı yerdedir. Böylece, eşlerden birinin kendi yerleşim yerinde açtığı boşanma (ve ayrılık) davası, aynı zamanda davalının yerleşim yerindeki mahkemede açılmış olmaktadır. Ancak eşlerden birisi ayrı bir yerleşim yeri edinmişse, bu durumda kendi yerleşim yerinde dava açabilir. Örneğin, eşinden şiddet gördüğü için Ağrı'daki ortak evlerini terk edip İzmir'deki ailesinin yanına gelen kadın, boşanma davasını İzmir'de açabilir. Ancak bunun için, İzmir'de geçici olarak bulunmayıp, yerleşme niyetinin olması gerekir[17].

Boşanma (ve ayrılık ve evliliğin feshi) davaları, **eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer** mahkemesinde de açılabilir (TMK m. 168).

Davacı, bu iki yetkili mahkemeden birini seçebilir ve davasını orada açabilir. TMK m. 168'de gösterilen yetkili mahkemelerden birini **seçme hakkı** davacıya tanınmıştır. Davacı, TMK m. 168'deki mahkemelerden birinde boşanma davası açmış ise, davalı eş, davanın diğer yetkili mahkemede açılması gerektiğinden bahisle yetki itirazında bulunamaz. TMK m. 168'deki iki yerden birini seçme hakkı olan davacı, bu hakkını kullanmayarak (kanunen yetkili kılınan iki mahkeme dışındaki) başka bir yerde boşanma davası açarsa, o zaman seçme hakkı (yetki itirazında bulunan) davalıya geçer. Yani, davalı, yetki itirazında TMK m. 168'deki yerlerden hangisini bildirmiş ise, davanın açıldığı (yetkisiz) mahkeme, yetkisizlik kararında dava dosyasının davalının yetki itirazında bildirdiği yer mahkemesine gönderilmesine karar verir (m. 20).

Davacı, kişilik haklarının himayesi için, kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde de dava açabilir (TMK m. 25, V).

Davacı aynı zamanda maddî ve manevî tazminat ile vekâletsiz işgörme hükümleri uyarınca saldırıdan elde edilen kazancın kendisine verilmesini birlikte talep etmiş ise, bu davaları kendi yerleşim yeri mahkemesinde de açabilir (TMK m. 25, V).

Yardım nafakası davası, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır (TMK m. 365, VI).

TMK ve TBK'nda bulunan özel yetki hükümleri daha çok **çekişmesiz yargı işleri** (m. 382) içindir; örnekler: Talepte bulunan ilgilinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu işler (TMK m. 32, 283, 315 gibi), karşı (mukabil) ilgilinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu işler (TMK m. 283, 411 ve 430 gibi); malın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu iş (TBK m. 542; bkz. ayrıca TBK m. 107).

---

17 Yargıtay, yerleşim yerinin tespiti bakımından kadının bu durumda elektrik, su faturası veya kira sözleşmesi gibi bazı belgeleri göstermesini aramaktadır. Dolayısıyla boşanma davaları bakımından zaman zaman kadınların mağdur olduğu görülmektedir: Bu bakımdan olması gereken hukuk açısından boşanma davalarında "yerleşim yeri" kavramından vazgeçmek uygun olacaktır.

b) Türk Ticaret Kanunundaki Özel Yetki Kuralları

Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel yetki kurallarının da çoğu çekişmesiz yargı işleri içindir; örnekler: TTK m. 34, 82, 661, 849, 869, 889, 1098, 1281.

Türk Ticaret Kanunu'ndaki çekişmeli yargı işleri (davalar) için olan özel yetki kurallarına örnekler: TTK m. 445, 561, 1063, 1087 (bkz. ayrıca; Kooperatifler K. m. 53).

c) İcra ve İflâs Kanunundaki Özel Yetki Kuralları

İcra ve iflâs takipleri için hangi yer icra dairesinin yetkili olduğu İİK'nda (İİK m. 34, 50, 148, 154) düzenlenmiştir.

Bundan başka İİK, icra-iflâs hukuku ile ilgili bazı davaların genel mahkemelerde genel hükümler uyarınca görüleceğini de düzenlemiştir; bu davalar (İİK'nda özel usul hükümleri bulunmadıkça) medenî usul hukukuna (HMK'na) tâbidir. İşte İİK, düzenlediği bu davalar için özel yetki hükümleri de koymuştur. İİK'nda hakkında özel yetki kuralı bulunan davalardan bazı örnekler şunlardır: Borçtan kurtulma davası (İİK m. 69, II), menfi tespit ve istirdat davaları (İİK m. 72, VIII), haciz ihbarnamesine itiraz etmeyen üçüncü kişinin takip alacaklısına karşı açabileceği menfi tespit davası (İİK m. 89, III), sıra cetveline itiraz davaları (İİK m. 142, I; 151, III; 235, I), iflâs davası (154, III), ihtiyatî haciz talebi (İİK m. 258; 50; 265), ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası (İİK m. 259, IV), konkordato talebi (İİK m. 285, III), icra-iflâs ceza davaları (İİK m. 348).

d) Özel Görevli Mahkemelerin Kuruluşuna İlişkin Kanunlardaki Yetki Kuralları

Özel görevli mahkemelerin kuruluşuna ilişkin kanunlarda, bazı yetki hükümleri vardır (bkz. örneğin İş Mahkemeleri K. m. 5). Bu özel yetki hükümleri, ileride özel görevli mahkemeler bölümünde incelenecektir[18].

e) Karayolları Trafik K. m. 110, II'ye göre, motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

f) Kamu alacaklarının tahsili bakımından açılacak istihkak davalarına bakmaya, haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (6183 s. K. m. 68).

g) Devletleştirme bedeline itiraz davaları, devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu yer (asliye hukuk) mahkemesinde açılır (Devletleştirme K. m. 9).

h) Orman sınırları dışına çıkarma işlemleri hakkında iptal davası, taşınmazın bulunduğu yer kadastro mahkemesinde açılır (Orman K. m. 11).

---

[18] Bkz. aşa. § 71-76.

11) Türkiye'nin Her Yerindeki Mahkemelerin Yetkili Olduğu Haller

Görüldüğü gibi, bir dava için ya sadece bir yer mahkemesi yetkilidir (kesin yetki) veya birden fazla ve fakat belli mahkemeler yetkilidir (genel ve özel yetkili mahkemeler). Yani, bir davanın hangi mahkeme veya mahkemelerde açılabileceği, kanun tarafından önceden belirlenmiştir; yetkili mahkemeler, kanunda gösterilmiştir (Anayasa m. 142 ve m. 37, I).

Buna rağmen, bazı hallerde hangi mahkemenin yetkili olduğu belirtilmemiş, bu dava ve işler için Türkiye'nin her yerindeki mahkemeler veya duruma göre en elverişli olan yer mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Örneğin, mirasçılık belgesi verilmesi, mirasçılık belgesinin iptali veya yeni belge verilmesi taleplerinde veya davalarında, talepte bulunanın veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir (m. 11, 3; 384).

Yaş, ad, soyadı ve diğer **nüfus kayıt düzeltme talepleri** için, ilgilinin oturduğu yer (asliye hukuk) mahkemesi yetkilidir (Nüfus Hizmetleri K. 36, I).

III – YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ

Görüldüğü gibi, buraya kadar incelemiş olduğumuz genel yetki kuralı (m. 6) ile özel yetki halleri (m. 8 vd.), kural olarak, kesin değildir. Yalnız istisnaî olarak bazı yetki kuralları, kesindir.

Buraya kadar genel ve özel yetki kurallarını inceledikten sonra, şimdi hangi yetki kurallarının kesin olduğunu, hangilerinin kesin olmadığını toplu bir şekilde belirtmekte yarar vardır. Çünkü bundan sonra inceleyeceğimiz konular bakımından, bir yetki kuralının kesin olup olmamasının hüküm ve sonuçları birbirinden çok farklıdır.

1) Kesin Yetki Kuralları

Kanun, hangi yetki kurallarının kesin olduğunu her zaman açıkça belirtmiş değildir. Her ne kadar HMK'ndaki hükümlerde yetkinin kesin olduğu açıkça vurgulanmışsa da, özellikle diğer kanunlarda yer alan yetki kuralarının kesin olup olmadığı, ilgili kanun hükmündeki ifadenin mutlak olup olmamasına ve o yetki kuralının konuluş amacına göre belirlenmektedir. Bu belirleme yukarıda yapılmıştır. Yukarıda görüldüğü gibi, kesin yetki kurallarına şu örnekler verilebilir: İflâs davasına bakacak mahkemenin yetkisi kesindir.

Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir (m. 14, 2). Miras ile ilgili bazı davalar için mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir (m. 11, 1). Taşınmazın aynına ilişkin davalar için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi (m. 12) kesindir. Can (hayat) sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir (m. 15, 2).

Yukarıdaki hallerde hakkında kesin yetki hükmü bulunan bir **dava** (veya iş), **yalnız kesin yetkili mahkemede açılabilir**. Kesin yetki itirazı ilk itiraz

değildir (m. 116, 1/a); her zaman yapılabilir; mahkeme de yetkisizliğini (yani başka bir mahkemenin kesin yetkili olduğunu) her zaman kendiliğinden gözetir. Kesin yetki, dava şartıdır (m. 114, 1/ç).

2) Kesin Olmayan Yetki Kuralları

Yukarıda gördüğümüz kesin yetki halleri dışındaki diğer bütün yetki kuralları kesin olmayan yetkidir. Daha önce de vurgulandığı üzere, medenî yargıdaki yetki hükümleri, kural olarak kesin değildir. Kesin yetki kuralları istisnadır.

Yetkinin kesin olmadığı hallerde, taraflar yetki sözleşmesi ile başka bir mahkemeyi de yetkili kılabilir (m. 17). Bu durumda yetki itirazı ancak ilk itiraz olarak ileri sürülebilir (m. 116, 1/a;19, 2). Yani yetki, dava şartı değil, mahkemenin yetkisiz olması sadece dava engelidir.

Kesin olmayan yetki kuralları, **genel yetki kuralı** (m. 6) ile (m. 10; 11, 2-3; 14, 1; 15, 1 ve 16'daki gibi) **kesin olmayan özel yetki kurallarıdır.**

Burada, genel yetkili mahkemenin (m. 6) yanında, genellikle gerek kanunla (m. 5 vd.) gerek münhasır olmayan yetki sözleşmesi (m. 17) ile kabul edilmiş özel yetkili mahkemeler de vardır. Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden birinde açmak hususunda bir seçim hakkına sahiptir.

C) TARAFLARIN YETKİSİZ MAHKEMEYİ YETKİLİ KILMALARI

Mahkemelerin yetkilerinin kanunla düzenlenmesi esastır (Anayasa m. 142). Buraya kadar kanunla düzenlenmiş (belirlenmiş) olan yetki kurallarını inceledik. Anılan Anayasa hükmü (Anayasa m. 142) karşısında, aslında tarafların kanunen yetkisiz olan bir mahkemeyi yetkili kılamamaları gerekir. Ancak bu husus, kesin yetki kuralları için doğrudur; yani, kesin yetki hallerinde, taraflar bir anlaşma ile yetkisiz bir mahkemeyi yetkili kılamazlar. Zira kesin yetki olduğu hallerde davanın yetkili mahkemede açılması dava şartı olup (m. 114, 1/ç), taraflar dava şartlarını anlaşma ile bertaraf edemezler.

Buna karşılık, **kesin olmayan yetki halleri**nde taraflar, bir anlaşma ile yetkisiz bir mahkemeyi yetkili kılabilirler. Medenî usul hukukundaki yetki hükümleri, kural olarak, kesin yetki kuralı niteliğinde olmadığı için, tarafların yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmaları mümkündür.

Taraflar, yetkisiz bir mahkemeyi iki şekilde yetkili kılabilirler: 1) Yetki sözleşmesi (m. 17) ile; 2) Davalının aslında yetkisiz olan mahkemenin yetkisine itiraz etmemesi (m. 19) ile. Şimdi bu iki hali inceleyeceğiz:

I – YETKİ SÖZLEŞMESİ[19]

1) Genel Bilgi

Tacir veya **kamu tüzel kişisi** olmak koşuluyla tarafların, belli bir dava (uyuşmazlık) için kanunen yetkili olmayan, aslında yetkisiz olan bir mahkemeyi yetkili kılmak için yaptıkları sözleşmeye, **yetki sözleşmesi** (yetki anlaşması) denir (m. 17).

---

[19] Bkz. Nur Bolayır, Medenî Usûl Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, İstanbul 2009.

Yetki sözleşmesi, **usul hukukuna ilişkin bir sözleşmedir**. Çünkü, yetki sözleşmesi asıl etkisini usul hukuku alanında göstermektedir. Yetki sözleşmesi ile, aslında yetkili olmayan bir mahkeme yetkili hale gelmektedir.

Yetki sözleşmesi usul hukuku sözleşmesi olduğu için, bir Türk mahkemesini yetkili kılmak için yabancı bir ülkede yapılmış olan yetki sözleşmesi Türk usul hukukuna tâbidir.

Yetki sözleşmesi, usul hukuku sözleşmesi olarak, ilk önce HMK'ndaki hükümlere (m. 17-18), bunlar dışında ise TBK hükümlerine tâbidir. Örneğin, yazılı şekil (HMK m. 17) ve irade sakatlığı (rızadaki fesat) hakkında TBK hükümleri (TBK m. 13 vd.; 30 vd.) uygulanır.

Yetki sözleşmesi iki şekilde yapılabilir:

a) Ayrı bir sözleşme olarak: Tacir veya kamu tüzel kişisi olan tarafların aralarındaki bir uyuşmazlık hakkında belli bir yer mahkemesini yetkili kılmak için ayrı (müstakil, bağımsız) bir sözleşme yapabileceklerini belirtmiştik. Dar anlamda yetki sözleşmesi ile, bu şekildeki ayrı (konusu yalnız yetkili mahkemeyi kararlaştırmak olan) yetki sözleşmesi kast edilir. Uygulamada, tarafların genellikle önceden ayrı yetki sözleşmesi yapmadıkları, daha çok uyuşmazlık doğduktan sonra bu yola gittikleri görülmektedir.

b) Yetki şartı olarak: Tacir veya kamu tüzel kişisi olmak koşuluyla taraflar yaptıkları bir sözleşmeye, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için belli bir yer mahkemesinin yetkili olacağına ilişkin bir hüküm (madde, şart, kloz) koyabilirler. Örneğin bir satış, kira, kredi açma, şirket veya istisna (eser) sözleşmesine şu şekilde bir yetki şartı konabilir: "İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için Ankara mahkemeleri yetkilidir". Burada yetki, o sözleşmenin yalnız başına konusu değil, bilâkis sadece bir hükmüdür (klozudur; maddesidir; yetki şartıdır). Fakat yalnız bu hüküm (madde, şart), m. 17 anlamında bir yetki sözleşmesidir.

Yukarıda belirtildiği üzere, ayrı yetki sözleşmesinin uygulaması azdır; uygulamada daha çok yetki şartına rastlanır.

Yetki sözleşmesi, sonucu bakımından davacıya, davalıyı tabiî hâkiminden (Anayasa m. 37) başka bir mahkeme önüne çıkarma yetkisini veren bir sözleşme olmaktadır. Tarafların yetki sözleşmesi yapma özgürlüklerine (Anayasa m. 48, I) hiçbir sınır konulmazsa, sosyal veya ekonomik bakımdan güçlü olan taraf sosyal veya ekonomik bakımdan zayıf olan tarafı istediği şekilde bir yetki sözleşmesi yapmaya zorlayabilir ve böylece onu tabiî hâkiminden uzaklaştırabilir. İşte bunu önlemek için, **yetki sözleşmesi yapma özgürlüğüne bazı sınırlamalar konulmuştur**. Başka bir deyişle, yetki sözleşmesi bazı özel şartlara tâbi tutulmuştur (m. 17-18).

2) Yetki Sözleşmesinin Yapılmasının Mümkün Olduğu Haller

a) Yalnızca Tacirler veya Kamu Tüzel Kişileri Yetki Sözleşmesi Yapabilir

HMK m. 17 hükmü, tacirlerin veya kamu tüzel kişilerinin kendi aralarındaki uyuşmazlıkta yetki sözleşmesi yapılabileceklerini düzenlemiştir[20]. Buna göre, tacirlerin kendi aralarında veya kamu tüzel kişilerinin kendi aralarında yahut tacir ile kamu tüzel kişisi arasında yetki sözleşmesi yapılabilmesi mümkündür.

Bu (m. 17) hükmün karşıt anlamından, tacir veya kamu tüzel kişisi olmayan kişilerin yetki sözleşmesi yapamayacakları anlaşılır. Bu konudaki Hükümet gerekçesine göre de; tacirler veya kamu tüzel kişileri dışındaki diğer kişiler (özellikle, tacir olmayan gerçek kişi tüketiciler), tacirler veya kamu tüzel kişilerine karşı hukuken daha zayıf durumda olup, bu kimselerin, daha güçlü olanlara karşı korunmaları gereklidir. Bu amaçla, tacirler veya kamu tüzel kişileri ile bu nitelikte olmayan kimseler (örneğin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi ile bir tacir arasında yahut özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi ile kamu tüzel kişisi) arasında yetki sözleşmesi yapılamaz.

Ayrıca, (gerçek ve tüzel kişi) tacirler veya kamu tüzel kişileri dışındaki diğer kimseler (örneğin, iki gerçek ve tüzelkişi) de kendi aralarında yetki sözleşmesi yapamazlar.

b) Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edemeyecekleri Konularla Kesin Yetki Hallerinde Yetki Sözleşmesi Yapılamaz

Hukukumuzda yetki sözleşmesi, kural olarak bütün davalar (uyuşmazlıklar) için mümkündür.

Bu kuralın (önemli) bir **istisnası** vardır: Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konularda ve kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi yapılamaz (m. 18). Buna göre, örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalar ve iflâs davaları için, taraflar bir yetki sözleşmesi yaparak başka bir yer mahkemesini de yetkili kılamazlar; böyle bir yetki sözleşmesi geçersizdir.

Yukarıda belirtildiği üzere yetki kurallarının kesin olup olmadığı her zaman kanun metninden anlaşılamayabilir. Kanun koyucu burada kesin yetki ölçütü dışında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konularla ilgili davalarda da yetki sözleşmesi yapılamayacağını öngörmüştür. Kanunlarda açıkça bir kesin yetkiden söz edilmemekle birlikte, bazı konularda tarafların tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Örneğin savcıların açtığı veya taraf olduğu hukuk davalarında taraflar serbestçe tasarruf edemezler (m. 70). O nedenle bu tür davalarda tarafların yetki sözleşmesi yapmaları mümkün olmaz. Yine tarafların sulh, feragat veya kabulleriyle davanın sona ermediği

---

[20] Geçerli bir yetki sözleşmesi yapılabilmesi için tacir veya kamu tüzel kişisi olma şartı, HMK m. 17 ile getirilmiştir. HUMK m. 22'de böyle bir şart bulunmadığından, herkesin herkesle yetki sözleşmesi yapma olanağı mevcuttu.

hallerde de, tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkileri bulunmamaktadır.

3) Yetki Sözleşmesinin Şekli

Yetki sözleşmesi **yazılı** olarak yapılmalıdır (m. 18). Yetki sözleşmesinin adî yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Asıl sözleşme resmî şekle tâbi olsa bile, yetki sözleşmesi adî yazılı şekilde yapılabilir. Bunun gibi, asıl sözleşme yazılı şekle tâbi olmasa bile, yetki sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir.

Yazılı şekil, yetki sözleşmesi için geçerlilik şartıdır (HMK m. 18, 2; TBK m. 12, II). Bu nedenle, yazılı olarak yapılmamış olan bir yetki sözleşmesinin varlığı, başka bir delil ile (örneğin yemin veya tanık ile) ispat edilemez. Fakat davalı yetki (ilk) itirazında bulunmazsa, o mahkeme kanunen yetkili hale gelmiş olur (m. 19, 4).

4) Uyuşmazlığın Belirli veya Belirlenebilir Olması

Yetki sözleşmesi, belirli (muayyen) veya belirlenebilir uyuşmazlık için yapılabilir (m. 18, 2). Yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkemenin, hangi uyuşmazlığa bakacağının yetki sözleşmesinden (veya şartından) açıkça anlaşılması gerekir. Örneğin, "A ile B arasında satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle çıkmış olan uyuşmazlık için Ankara mahkemeleri yetkili kılınmıştır" gibi.

Satış, kira, istisna (eser) gibi bir sözleşmedeki "İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar için Ankara mahkemeleri yetkilidir" şeklindeki yetki şartı (yetki anlaşması) da geçerlidir; çünkü burada da uyuşmazlık konusu (hukukî ilişki) belirlidir.

Buna karşılık, "bundan böyle yapacağımız **bütün satış sözleşmeleri**nden doğacak uyuşmazlıklar için Ankara mahkemeleri yetkili olacaktır" veya "bundan böyle aramızda çıkacak **bütün uyuşmazlıklar** için Konya mahkemeleri yetkili olacaktır" şeklindeki bir yetki sözleşmesi geçersizdir; çünkü, burada uyuşmazlık belirli değildir.

5) Mahkemenin veya Mahkemelerin Belli Olması

Yetki sözleşmesi ile, **bir** veya **birden fazla mahkeme** yetkili kılınabilir. Uyuşmazlık konusunda olduğu gibi, sözleşme ile yetkili kılınan mahkemenin veya mahkemelerin de belli (muayyen) olması gerekir. Örneğin "... Ankara mahkemeleri yetkilidir" yahut "... Mut ve Bor mahkemeleri yetkilidir" gibi.

Taraflardan her ikisinin (veya yalnız birinin) **dilediği mahkeme**de dava açabileceğine (veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde dava açılabileceğine) ilişkin bir yetki sözleşmesi **geçersizdir**. Çünkü, bu halde yetkili kılınan mahkeme belli değildir; bu ise kamu düzenine aykırıdır.

Münhasır (kesin) yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda yetki sözleşmesi ile, **yabancı bir mahkeme** de yetkili kılınabilir (MÖHUK m. 47).

6) Yetki Sözleşmesinin Kanunen Yetkili Olan Genel ve Özel Yetkili Mahkemelerin Yetkisini Kaldırıp Kaldırmayacağı

Taraflar, yapmış oldukları yetki sözleşmesi ile, yetkili kıldıkları (bir veya birden fazla) mahkemenin yetkisinin, münhasır yetki olup olmadığını kararlaştırabilirler.

HMK m. 17, 1/c.2'ye göre; **taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa,** dava, **yalnızca yetki sözleşmesi ile belirlenen yetkili mahkemede** açılır. Buna göre, tarafların aksini kararlaştırmamış olmaları halinde, kural, davanın, yalnızca yetki sözleşmesiyle tespit edilen yer mahkemesinde açılmasıdır. Yani, bu durumda **yetki sözleşmesi**, kanunen yetkili kılınan **genel veya özel mahkemelerin yetkisini ortadan kaldırmaktadır**[21].

Taraflar, yetkili kıldıkları mahkemenin yanında, kanunen yetkili kılınan genel veya özel yetkili mahkemelerin (tamamının veya bir kısmının) de yetkisinin devam etmesini istiyorlarsa, yani yetki sözleşmesinin **münhasır olmayan yetki sözleşmesi şeklinde olmasını istiyorlarsa,** bu durumu yetki sözleşmesinde ayrıca belirtmeleri gerekir.

Tarafların, Kanunun belirlediği mahkemelerin yetkisini korumak, yani davacıya yeni alternatifler sunmak amacıyla sözleşme yapmaları halinde, bu sözleşme, **münhasır olmayan yetki sözleşmesi** adını alır. Bu sonucun doğabilmesi, tarafların sözleşmede bunu açıkça öngörmeleriyle mümkündür. Buna göre, örneğin, sözleşmede, "aramızda bu sözleşmeden doğan veya doğacak uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri de yetkilidir" ibaresi yer almışsa, bu, münhasır olmayan bir yetki sözleşmesidir. Buna karşılık sözleşmede, "aramızda bu sözleşmeden doğan veya doğacak uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri yetkilidir" ibaresi varsa, aksi açıkça anlaşılmadığı veya kararlaştırılmadığı için münhasır yetki sözleşmesi yapılmış sayılır ve kanunen yetkili diğer mahkemelerin yetkisi kalkar; yalnızca Ankara mahkemeleri yetkili olur.

7) Yetki Sözleşmesinin Etkisi

Yetki sözleşmesi, taraflardan başka, **tarafların cüz'î ve küllî haleflerini de bağlar**; örneğin, dava konusunu (alacağı) taraflardan birinden devralanı ve tarafların mirasçılarını da bağlar.

Yetki sözleşmesi ile **yetkili kılınan mahkeme,** kendisinde açılan **davaya bakmak zorundadır**; davaya bakmaktan kaçınamaz. Yetki sözleşmesi o davayı kapsamasa veya geçersiz olsa bile, davalı yetki itirazında bulunmazsa, mahkeme, yetki sözleşmesinin o davayı kapsayıp kapsamadığını veya geçersiz olup olmadığını inceleyemez. Çünkü davacının yetkisiz mahkemede dava açması halinde davalı, yetki itirazında (m. 16, 1/a) bulunmazsa, o mah-

---

[21] HMK'nun getirdiği bu düzenlemeden önceki dönemde; öğretinin çoğunluk görüşü ile Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, yetki sözleşmesi ile mevcut genel ve özel mahkemelerin yetkisi kaldırılmaz, yetki sözleşmesi ile diğer yasal yetkili mahkemelerin yanı sıra yeni (ek) bir yetkili mahkeme daha yaratılmış olurdu. MÖHUK m. 47'ye göre yapılan yetki anlaşmasıyla; iş sözleşmesi, tüketici sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi ile ilgili MÖHUK m. 44-46. maddelerde belirtilen mahkemelerin yetkisi ortadan kaldırılamaz.

kemenin yetkisini kabul etmiş sayılır (m. 19, 2/c.1) ve mahkeme davaya bakmak zorundadır.

Yetki sözleşmesinin nasıl ileri sürüleceği veya hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınıp alınmayacağı, Kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Bu nedenle konuya ilişkin bazı hususlar tartışmaya yol açmaktadır. İlk olarak, aslında yetki sözleşmesi yapamayacak olan tarafların yetki sözleşmesi yapması halinde, hâkimin bu durumu kendiliğinden dikkate alıp almayacağı üzerinde durulmalıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, yetki sözleşmesi, yetkinin kesin olmadığı hallerde yapılabilmektedir. Yetkinin kesin olmadığı bir davada, yetki sözleşmesi yapamayacak olan taraflar (örneğin tüketici ile banka) buna rağmen yetki sözleşmesi yapmış ve davacı da, kararlaştırılan mahkemede dava açmışsa, davalı yetki itirazını ileri sürmediği takdirde, bu mahkeme, Kanun gereği yetkili olmaktadır (m. 19, 4). Oysa kanun koyucunun sözleşme yapacak kişileri sınırlandırmaktaki amacı, zayıfı korumaktır. Ancak Kanunda bu konuda hâkime verilmiş açık bir yetki bulunmadığından, yetki konusundaki genel hükümlerin uygulanması gerekir.

Tarafların tacir veya kamu tüzel kişisi olması halinde, kanımızca açık bir düzenleme olmadığı için, hâkimin taraflarca ileri sürülmedikçe kesin olmayan yetki konusuna müdahale etmesi mümkün olmaz. Tarafların yaptığı sözleşme, münhasır yetki sözleşmesi olsa bile, bu etki (m. 17), ancak taraflarca yetki sözleşmesinin ileri sürülmesi halinde ortaya çıkar. O halde, münhasır yetki sözleşmesine rağmen, davacı, davayı bir başka mahkemede açmış ve davalı da süresinde itiraz etmemişse, o mahkeme Kanun gereği yetkili hale gelecektir (m. 19, 4).

II – DAVALININ YETKİ İTİRAZINDA BULUNMAMASI

Yukarıda belirtildiği gibi, yetkinin kesin olmadığı hallerde, taraflar yetkisiz bir mahkemeyi yetkili kılabilirler.

Yetkinin kesin olmadığı hallerde, **yetki itirazı, ancak ilk itiraz** olarak ileri sürülebilir (m. 116, 1/a).

Davalı, yetki itirazını davanın başında, cevap dilekçesinde (m. 117, 1; 127, 1/c.1; 317) ileri sürmek zorundadır. Davalı, davanın başında (cevap süresi içinde ve cevap dilekçesinde) yetki ilk itirazında bulunmamışsa, artık mahkemenin yetkisine itiraz edemez ve davanın açıldığı yetkisiz mahkemenin yetkisini kabul etmiş sayılır (m. 19, 4).

D) YETKİ İTİRAZI

Buraya kadar genel ve özel yetki kurallarını ve tarafların anlaşma ile yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmalarını inceledik. Bu arada, davanın genel ve özel yetkiye sahip olmayan ve yetki sözleşmesi ile de yetkili kılınmamış olan yetkisiz bir mahkemede açılması halinde, davalının süresinde ilk itirazında bulunmamış olmasını ve sonucunu da gördük.

Şimdi, davalının yetkisiz mahkemenin yetkisine itiraz etmesini inceleyeceğiz. Bu yapılırken, ilk önce yetkinin kesin olmadığı hallerde yetki itirazı

üzerinde durulacak, yetkinin kesin olduğu (istisnaî) hallerde yetki itirazı ise en sonra görülecektir.

Yukarıda görüldüğü gibi, yetki hükümleri kural olarak kesin değildir. **Yetkinin kesin olmadığı hallerde**, yetki itirazı yalnız **ilk itiraz** olarak ileri sürülebilir[22]. Bu nedenle, "ilk itirazlar" bölümündeki açıklamalar, yetki itirazı için de geçerlidir. Burada, yalnız yetki itirazının yapılması, incelenmesi ve sonuçlarının gösterdiği özellikler üzerinde durulacaktır.

I – YETKİ İTİRAZINDA BULUNMA SÜRESİ

Yetki itirazı, **davanın başında** yapılır (m. 129, 317). Buna göre:

Yazılı yargılama usulünde, yetki itirazı ancak cevap süresi içinde (esas hakkındaki **cevaplarla birlikte**; m. 129) ileri sürülebilir (m. 117). Cevap süresi kural olarak **iki haftadır** (m. 127, 1). Hâkim, şartlarının gerçekleşmesi halinde davalıya bir defaya mahsus olmak ve ancak **bir ayı** geçmemek üzere **ek cevap süresi** verebilir; bu halde, davalı yetki itirazını hâkimin vermiş olduğu bu ek cevap süresi içinde yapabilir.

İki haftalık cevap süresi ve (söz konusu ise) hâkim tarafından uzatılmış olan cevap süresi, ilk itirazlar bakımından **hak düşürücü nitelikte**dir. Bu nedenle, hâkim, ilk itirazın süresinde yapılıp yapılmadığını kendiliğinden inceler.

İki haftalık cevap süresi (ve uzatılmışsa ek süre) içinde verilen **cevap dilekçesinden sonra**, cevap süresi henüz dolmamış olsa dahi, **artık ilk itirazda bulunulamaz** (m. 131). Örneğin, davalı iki haftalık süre henüz dolmadan sözgelimi, ilk hafta sonunda cevap dilekçesi vermişse, davalının bundan sonraki yasal olarak geriye kalan bir hafta içinde, ek bir dilekçe ile ilk itirazda bulunması mümkün değildir. Çünkü cevap vermekle artık usulî itirazlarını bildirdiğini veya böyle bir itirazı olmadığını ve esasa girdiğini kabul etmek gerekir[23].

Basit yargılama usulünde de, yetki itirazı cevap süresi içinde (m. 317) yapılabilir. Hâkim, şartlarının gerçekleşmesi halinde davalıya bir defaya mahsus olmak ve ancak **iki haftayı** geçmemek üzere ek cevap süresi verebilir (m. 317, 2). Yukarıdaki yazılı yargılama usulüne ilişkin açıklamalar, basit yargılama usulü için de (kıyasen) geçerlidir.

II –YETKİ İTİRAZININ YAPILMASI

Yetki itirazı, yazılı olarak (cevap dilekçesi ile) yapılır (m. 19, 2;129; 317). Davalı yetki itirazında (kendi kanısına göre) **yetkili olan mahkemeyi**; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi **göstermek zorundadır**. Davalı yetki itirazında yetkili mahkemeyi göstermemişse, yetki itirazı dikkate alınmaz; yani yetkisiz mahkeme yetkili hale gelir (m. 19, 2/c.2-3). O halde, davalı cevap dilekçesiyle, "bu mahkeme veya mahkemeniz yetkisizdir" biçiminde bir itirazda bulunmuşsa, bu yetki itirazı, Kanunun aradığı özelliği taşımadığı için geçersiz olup, dikkate alınmaz ve yetkisiz mahkeme, yetkili hale

---

[22] Yetki itirazının ne zaman ve nasıl ileri sürüleceği yetkinin kesin olduğu ve kesin olmadığı ayrımı yapılarak düzenlenmiştir (bkz. m. 19 hakkında Hükümet gerekçesi).

[23] HMK m. 131'e ilişkin Hükümet gerekçesinden.

gelir. O nedenle davalı, yetki itirazını yaparken, "mahkemeniz yetkisizdir; Ankara mahkemeleri yetkilidir" gibi bir ibareyle yetki itirazını yapmalıdır. Genel yetkinin yanında özel yetkili mahkemelerin de bulunması, yani birden fazla yetkili mahkemenin bulunduğu hallerde, davalı, yetki itirazında bu mahkemeleri sıralayıp mahkemenin yetkisine itiraz edemez. Çünkü, birden fazla yetkili mahkemenin bulunması halinde, davalı, bunlardan birisini seçmelidir; yani dava dosyasının oraya gönderilmesini istemelidir.

III – YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ

Davalının yetki itirazı davacıya tebliğ edilir (m. 136, 1; 117, 3; 164, 1). Mahkeme yapacağı ön incelemede dava şartlarından sonra ilk itirazları inceler (m. 137, 1). İlk itirazlar, kural olarak (duruşma yapmadan) dosya üzerinden incelenir. Mahkeme, gerekli görmesi halinde, duruşma (m. 139) yaparak da karar verebilir (m. 138, 140). Yetki itirazı ön sorunlar hakkındaki usule göre çözümlenir (m. 117, 3; 164).

Davacı, davalının **yetki itirazını** (yani davanın açıldığı mahkemenin yetkisiz ve davalının yetki itirazında bildirdiği mahkemenin yetkili olduğunu) **kabul ederse,** taraflar arasında bir çeşit yetki sözleşmesi yapılmış olur. Bu halde, **mahkemenin** (yetki itirazı hakkında bir inceleme yapmadan) yetkisizliğine ve **dosyanın,** davalının yetki itirazında bildirdiği (ve davacının da kabul ettiği) **yetkili mahkemeye gönderilmesine karar vermesi gerekir**. Bu karardan sonra mahkeme dosyayı kendiliğinden gönderemez; m. 20 uyarınca işlem yapılır.

Davacı, yetki itirazını kabul etmez (veya yetki itirazına karşı hiç cevap vermez) ise mahkeme, yetki itirazını yukarıdaki gibi inceleyip karara bağlar.

IV – YETKİ İTİRAZININ REDDİ

Yetki itirazı, **süresi içinde ve usulüne uygun yapılmamışsa** (örneğin, süresi içinde ve cevap dilekçesinde ileri sürülmemiş veya yetkili mahkeme gösterilmemiş ise), **mahkeme**, yetkisiz olsa bile (bu hususu araştırmadan) **yetki itirazının reddine karar verir**.

Bundan başka, **mahkeme**, usulüne uygun bir yetki itirazı üzerine yaptığı inceleme sonucunda **yetkili olduğu** (veya yetkisiz olmakla beraber, davalının yetki itirazında bildirdiği mahkemenin gerçekten yetkili olmadığı) **kanısına varırsa, yetki itirazının reddine karar verir.**

Yetki itirazının reddine ilişkin karar, nihaî karar olmadığı (ara kararı olduğu) için, yalnız başına kanun yoluna götürülemez; ancak esas hükümle birlikte kanun yoluna götürülebilir.

Yetki itirazının reddine karar veren mahkeme, tarafları ön inceleme duruşmasına davet eder (m. 139).

V – YETKİSİZLİK KARARI

Yukarıda görüldüğü gibi, davalının yetki **itirazını inceleyen mahkeme, yetkisiz** (ve davalının yetkili olduğunu bildirdiği mahkemenin yetkili) **olduğu kanısına varırsa,** yetkisizlik kararı verir.

Mahkeme verdiği yetkisizlik kararında, **yetkili mahkemeyi de gösterir** (m. 19, 3).

Mahkeme, yetkisizlik kararı ile davadan elini çeker; yani, **yetkisizlik kararı bir nihaî karardır**.

Miktar veya değeri kanun yolu sınırını (m. 341, 2; Geçici Madde 3; HUMK m. 427, II) geçmeyen davalara ilişkin yetkisizlik kararları kesindir. Bundan başka, özel kanun hükümleri ile haklarında verilecek kararların (hükümlerin) kesin olduğu kabul edilen dava ve işlere ilişkin yetkisizlik kararları da kesindir.

Bunun dışındaki yetkisizlik kararlarına karşı kanun yoluna gidilebilir.

VI – YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Mahkeme, yetkisizlik kararında dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir; dava dosyasını kendiliğinden yetkili mahkemeye gönderemez. Dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilebilmesi ve davaya yetkili mahkemede devam edilebilmesi için **taraflardan birinin iki hafta** içinde yetkisizlik **kararı veren mahkemeye başvurarak**, dava dosyasının yetkili mahkemeye (m. 19, 3) gönderilmesini talep etmesi gerekir (m. 20, 1/c.1).

İki haftalık başvuru süresi, yetkisizlik kararı verildiği anda kesinse (yani, karara karşı kanun yolu kapalı ise), yetkisizlik kararının tebliği tarihinden[24]; yetkisizlik kararına karşı kanun yolu açıksa ve fakat süresi içinde kanun yoluna gidilmediği için yetkisizlik kararı kesinleşmişse, kesinleşme tarihinden; kanun yoluna başvurulmuşsa, bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren başlar (m. 20, 1/c.1).

Taraflardan biri, iki hafta içinde, **yetkisizlik kararı veren mahkemeye başvurarak,** dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini istemezse, yetkisizlik kararını veren mahkeme **davanın açılmamış sayılmasına** karar verir (m. 20, 1/c.2).

Başvurma iki hafta içinde yapılmış ise, dosya kendisine gönderilen yetkili mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir (m. 20, 2), tarafları duruşmaya çağırarak davayı görmeye başlar.

Yetkinin kesin olmadığı hallerde, bir mahkemenin yetkisizlik kararı kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşmiş olsa bile, bu yetkisizlik kararında yetkili olarak gösterilmiş ve bu nedenle dava dosyası m. 20'ye göre kendisine gönderilmiş olan mahkeme, bu yetkisizlik kararı ile bağlıdır. Yetkili olmadığı kanısına varsa bile, yetkisizlik kararı veremez. Kesin yetki hallerinde ise, gönderilen mahkeme bu kararla bağlı değildir; o da yetkisizlik kararı verebilir. Bu durumda yargı yeri belirlenmesi gündeme gelir (m. 21, 1/ç).

Yukarıdaki şekilde, iki hafta içinde başvurulması üzerine yetkili mahkemede görülmeye başlanan dava yeni bir dava olmayıp, yetkisiz mahkemede

---

[24] HMK m. 20, 1'deki "...bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten..." ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 10.02.2016 tarihli ve 96/9 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu karar, yürürlüğe girmiştir. Karar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, Usul-Pratik, s. 149-150.

açılmış olan davanın devamıdır. Bu nedenle, yetkili mahkemede yeniden harç alınmaz; yetkisiz mahkemede dava açılması ile kazanılmış olan haklar (örneğin, zamanaşımı kesilmesi, hak düşürücü sürenin korunması) saklı tutulmuş olur; yetkisiz mahkemece verilen ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz devam eder; tarafların yetkisiz mahkemede yapmış oldukları usul işlemleri, yetkili mahkemede de geçerlidir. Buna karşılık, yetkisiz mahkeme tarafından yapılmış usul işlemleri kural olarak geçersizdir; yani, yetkili mahkemeyi bağlamaz. Fakat yetkili mahkeme, bu işlemleri kararına esas alabilir.

Yukarıda görüldüğü şekilde, yetkisizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren **iki hafta içinde** yetkisizlik kararını vermiş olan **mahkemeye başvurulmazsa,** yetkisiz mahkemede açılmış olan **dava açılmamış sayılır** (m. 20, 1/c.2). Ancak bu sonucun doğması için, mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi gerekir; hâkim bu kararı daha sonra vermiş olsa bile, bu karar, davanın açılmamış sayıldığı tarihi tespit eden bir karar olur; davanın açılmamış sayılmasının sonuçları, iki haftalık sürenin sonundan itibaren doğar. Açılmamış sayılan davadaki talep de, hiç yapılmamış (vaki olmamış) sayılır (m. 150, 7).

Davacı, m. 20, 1/c. 2'ye göre açılmamış sayılan davasını, tekrar harç ödemek suretiyle **yeniden açabilir;** ancak bu dava, yetkisiz mahkemede açılmış olan eski davanın devamı niteliğinde olmayıp, yeni bir davadır.

E) YETKİNİN KESİN OLDUĞU HALLERDE YETKİ İTİRAZI

Buraya kadarki açıklamalar, yetkinin kesin olmadığı haller içindir. Yetkinin kesin olduğu haller ve bu hallerde yetki sözleşmesi yapılamayacağı (m. 17) da belirtilmişti.

Yetkinin kesin olduğu hallerde, yetki itirazı **ilk itiraz** (m. 116, 1/a) **değildir;** dava şartıdır (m. 114, 1/ç). Taraflar (davalı) her zaman (üst mahkemede de) yetki itirazında bulunabilirler; mahkeme de (ve üst mahkeme de) her zaman kendiliğinden yetkili olup olmadığını inceler ve yetkisiz olduğu kanısına varırsa yetkisizlik kararı vermek zorundadır (m. 19, 1).

Bu halde, tarafların yetki itirazı, teknik anlamda bir yetki itirazı olarak nitelendirilemez. Çünkü, bu mahkemeye yetkisiz olduğunu hatırlatma niteliğindedir; belli bir süreye bağlı değildir; her zaman (üst mahkemede de) yapılabilir. Yetki itirazında bulunan tarafın, itirazında yetkili mahkemeyi göstermesine gerek yoktur. Çünkü bu halde mahkeme, yetkili mahkemeyi kendisi araştırıp belirler kendiliğinden de yetkisizlik kararı verir.

Mahkeme, yetkisiz olduğu kanısına varırsa, yetkisizliğine ve dava dosyasının gerçek yetkili mahkemeye (kamu düzenine ilişkin yetkili mahkemeye) gönderilmesine karar verir.

Kanun yolu incelemesi sonucu kesinleşen yetkisizlik kararı, davaya ondan sonra bakacak (dosya kendisine gönderilen) mahkemeyi bağlar (m. 23, 2). Fakat, bir mahkemenin yetkisizlik kararı kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşmiş ise, bu yetkisizlik kararı (m. 20'ye göre), dosya kendisine gönderilen (yani yetkisizlik kararında yetkili olarak gösterilen) mahkemeyi bağlamaz; o mahkeme de yetkisizlik kararı verebilir.

Yetkisizlik kararının verilmesi, kanun yoluna başvuru ve yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler, kesin olmayan yetki hallerindeki gibidir.

§ 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ

A) YARGI YERİ BELİRLENMESİ SEBEPLERİ

Yargı yeri belirlenmesi (merci tayini), medenî yargı içerisinde görevli ve yetkili mahkeme veya davaya bakacak hâkimi belirlemeye yönelik bir ihtiyacın sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, kural olarak belirli hallerde söz konusu olmaktadır. Burada davanın esasına değil, tümüyle usule ilişkin bir sorun mevcuttur. Ancak bu sorunlar her zaman yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmesini gerektirmemektedir.

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler, dört başlık altında ele alınabilir (m. 21).

I – GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN DAVAYA BAKMASINA BİR ENGEL ÇIKMASI

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren ilk durum, görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına "herhangi bir engel" çıkmasıdır (m. 21, 1/a).

Davacı, görevli ve yetkili mahkemede davasını açmış; ancak mahkemenin hâkimi, yasaklı olduğu gerekçesiyle davadan çekinmiş ya da ret nedeniyle çekilmiş ve bu talep ilgili merci tarafından kabul edilmiş olabilir. İşte bu durumda, görevli ve yetkili mahkemenin hâkimi bu davayı göremez. Ancak, yetkili mahkemenin yargı çevresi içerisinde aynı görevi yapabilecek bir başka hâkim varsa, bu takdirde, o hâkim bu davayı görür. Çünkü bir yerde bir mahkemenin birden fazla olması, bu mahkemenin aynı mahkeme olduğu anlamına gelir. Zira, bu mahkemeler, aynı mahkemenin dairesi durumundadır (5235 s. K. m. 5, 5). Nitekim Yargıtay da bir içtihadı birleştirme kararında, bir yerde aynı yetkiye sahip başka hâkim bulunduğu takdirde yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmeyeceğini kabul etmiştir[1]. Örneğin Ankara 75. Aile Mahkemesinde açılan bir davanın hâkiminin yasaklı veya reddedilmiş olması halinde, yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmez. Çünkü, Ankara'da birden fazla aile mahkemesi bulunmaktadır. Burada iş dağılımı yoluyla, bu dava diğer aile mahkemelerinden birisi tarafından görülür. Buna karşılık, yalnızca bir aile mahkemesinin bulunduğu yerdeki hâkim yasaklı olduğu veya reddedilmiş bulunduğu için davaya bakamayacaksa, bu durumda davayı hangi mahkemenin göreceğini belirleyen bir mekanizmaya ihtiyaç doğar; işte bu ihtiyacı karşılayan kurum, yargı yeri belirlenmesidir.

Görevli ve yetkili hâkimin davaya bakmasına başka nedenlerle de engel çıkabilir. Nitekim m. 21, 1/a'da, "herhangi bir engel" olarak ifade edilen bu husus, HUMK m. 25'de, "hukukî ve fiilî engel" olarak yer almaktaydı. Yukarıda açıklanan ve hâkimin yasaklı veya reddedilmiş olması hali de "hukukî en-

---

[1] 19.01.1959 gün ve 29/01 sayılı İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 157.

gel" olarak kabul edilmekteydi. Bunun yanında "fiilî engel" olarak da, görevli ve yetkili hâkimin ölmesi, uzun süreli olarak izinli, raporlu olması veya emekliye ayrılması ve aynı yetkiye sahip bir başka hâkimin de bulunmaması hali ya da deprem, sel veya bir başka doğal afet nedeniyle mahkemelerin çalışamaması durumları örnek verilmekteydi.

HMK, "herhangi bir engel" ifadesiyle genelleme yapmış olmakla birlikte, buraya hem fiilî hem de hukukî engeller dahildir. Ancak, yukarıda sayılan hukukî veya fiilî engeller, HUMK'nun uygulandığı dönemde de, yargı yeri belirlenmesini gerektirmemekteydi. Çünkü, sayılan bu hallerde sorun, tek bir davayı ilgilendirmemektedir; yani, burada bir dava bakımından değil, tüm davalar için çözülmesi gereken bir sorun bulunmaktadır. Bu ise, HSK'nın ilgili yere geçici yetkili hâkim görevlendirmesi veya tüm davaları, bir başka yere aktarması (nakletmesi) suretiyle çözülmektedir (HSKK m. 4; Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 47).

II – İKİ MAHKEMENİN VERDİĞİ GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ

HMK m. 21, 1/c'ye göre, iki mahkemenin aynı dava hakkında göreve ilişkin olarak verdikleri görevsizlik kararları, kanun yoluna başvurulmaksızın (m. 20) kesinleştiği takdirde, davanın görülebilmesini sağlamak üzere yargı yeri belirlenmesi ihtiyacı doğar.

Bu olumsuz görev uyuşmazlığı, genel görevli mahkemeler (sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri) arasında olabileceği gibi, genel görevli mahkemeler ile özel görevli mahkemeler arasında da çıkabilir.

Görüldüğü gibi, buradaki görev uyuşmazlığı, **adlî yargıya dahil hukuk mahkemeleri arasında**dır. Adliye mahkemeleri ile diğer yargı kollarındaki mahkemeler (örneğin idare mahkemeleri) arasındaki uyuşmazlık, teknik anlamda bir görev uyuşmazlığı değil, yargı yolu uyuşmazlığıdır. Bu yargı yolu uyuşmazlığı, HMK m. 21'e göre yargı yeri belirlenmesi yolu ile adlî yargıdaki üst mahkeme veya yüksek mahkeme (istinaf mahkemesi veya Yargıtay) tarafından değil, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından çözümlenir[2].

Ceza mahkemeleri ile hukuk mahkemeleri arasında da teknik anlamda yargı yolu veya görev ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay, ceza ve hukuk mahkemelerinin verdiği görevsizlik kararları bakımından yargı yerinin belirlenmesi (m. 21) hükümlerini uygulamaktadır.

İki mahkeme arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığı, yargı yeri belirlenmesi yolu ile giderilmedikçe ve üst mahkemece davaya hangi mahkemede bakılacağı belirlenmedikçe, görevsizlik kararı veren mahkemelerden hiçbiri davaya bakamaz.

Bir mahkemenin verdiği görevsizlik kararı kanun yoluna başvurulmaksızın **kesinleşmiş ise, bu görevsizlik kararı**, dosya (m. 20'ye göre) kendisine gönderilen mahkemeyi **bağlamaz**; o mahkeme de görevsizlik kararı (yani kendisinin görevli olmadığına, bilâkis ilk mahkemenin görevli olduğuna karar)

---

2 Bkz. yuk. § 2, B, IV.

verebilir. Bu ikinci görevsizlik kararı da kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşirse, görevli mahkeme, yargı yeri belirlenmesi yolu ile üst mahkeme tarafından belirlenir (m. 21, 1/c).

Buna karşılık, yukarıdaki durumda ikinci görevsizlik kararına karşı kanun yoluna başvurulmuş ve üst mahkeme ikinci görevsizlik kararını onamış ise, ikinci görevsizlik kararında görevli olarak gösterilen mahkeme (kural olarak birinci mahkeme) bu kararla bağlıdır; yani, davaya bakmaya mecburdur. Verilen ikinci görevsizlik kararı, birinci mahkeme bakımından "kanun yolu incelemesi sonucu kesinleşen göreve ilişkin bir karardır" ve 23. maddenin 2. fıkrasına göre kanun yolu incelemesi sonucu kesinleşen göreve ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar (m. 23; 2). Bu ihtimalde, yargı yeri belirlenmesi yoluna (m. 21) gidilmesine gerek yoktur. İkinci görevsizlik kararının kesinleşmesi üzerine, dava dosyası (ikinci görevsizlik kararında görevli olduğu belirtilen) mahkemeye (kural olarak birinci mahkemeye) gönderilir (m. 20) ve o mahkeme davayı görmeye başlar.

Yukarıdaki durumda, ikinci görevsizlik kararının, kararına uyulması gerekli olan üst mahkemece bozulması halinde, ikinci mahkeme davayı görmeye devam eder; yani artık görevsizlik kararı veremez (m. 23, 2 kıyasen).

Bir mahkemenin verdiği görevsizlik kararına karşı kanun yoluna gidilmiş ve üst mahkeme bu görevsizlik kararını doğru bulmuş (ve böylece görevsizlik kararı kesinleşmiş) **ise**, dava dosyası (kesinleşen) görevsizlik kararında görevli olduğu bildirilen mahkemeye gönderilir (m. 20); mahkeme, (kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşmiş olan) bu **görevsizlik kararı ile bağlıdır** (m. 23, 2); görevsiz olduğu kanısına varsa bile, görevsizlik kararı veremez; davayı görür. Görüldüğü gibi bu halde, yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmesine gerek kalmamaktadır.

Bir mahkeme, görevli olduğu kanısı (görevli olduğunu açıkça belirterek veya belirtmeyerek) ile esas hakkında karar vermiş, bu karar üst mahkemece görevsizlik nedeniyle bozulmuş ve mahkeme bozmaya uygun biçimde görevsizlik kararı vermiş (yani, üst mahkemenin bozma kararında bildirilen mahkemenin görevli olduğuna karar vermiş) ise, bu görevsizlik kararı, kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşmiş olsa bile, artık o davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar (m. 23, 2). Çünkü, üst mahkeme hangi mahkemenin görevli olduğunu (bozma kararı ile) belirtmiş durumdadır; bundan sonra yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmesine gerek yoktur.

III – İKİ MAHKEMENİN YARGI ÇEVRELERİ KONUSUNDA TEREDDÜT EDİLMESİ

İki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesi konusunda bir tereddüt ortaya çıkması durumu üzerinde durulmalıdır (m. 21, 1/b). Mahkemelerin yargı çevresi, "bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları" olarak ifade edilmektedir (5235 s. K. m. 7, 1). O halde buradaki sorun, bir mahkemenin hangi coğrafî sınırlar içerisinde görev yapacağı, yani yetkisinin hangi sınırlar çerçevesinde olduğunu tespittir. Bu sınır, genellikle il veya ilçenin idarî sınırları ve yapılanma-

sıyla örtüşür. Ancak zaman zaman bu konuda sorun veya belirsizlik ortaya çıkabilir. Örneğin, taşınmazın hangi ilçe veya il sınırları içinde kaldığı, dolayısıyla yetkili mahkemenin neresi olduğu konusu sorun yaratabilir. Her ne kadar kanun koyucu, bu durumu yargı yeri belirlenmesi sebebi olarak ifade etmişse de, dava açmadan önce doğrudan doğruya yargı yeri belirlenmesi yolunun işletilmesi uygulamada kabul edilmemektedir. Çünkü, buradaki sorun bir yetki sorunu olarak görüldüğü için, yetkili olduğu düşünülen yerde dava açılması ve mahkemenin kararı ve daha sonra kanun yolu incelemesi ile yetkili mahkemenin tespiti gerektiği kabul edilmektedir. O nedenle, iki mahkemenin yargı çevrelerinin tespitinde tereddüt olduğu halde, doğrudan doğruya yargı yeri belirlenmesine gidilmemektedir. Ancak kanımızca, öncelikle bu yola başvurup yetkili mahkemeyi kesin biçimde belirledikten sonra dava açılmasına engel bir durum yoktur. Kaldı ki, bu sebep, açıkça Kanunda düzenlenmiştir. Yine, görevli ve yetkili mahkemeyi tespit bakımından yargı yeri belirlenmesi konusunda Kanun, "kesinleşmiş" bir kararı ararken, burada, yalnızca iki mahkemenin yargı çevrelerinin sınırlarında "tereddüt edilmesi" yeterli görmüştür. "Tereddüt"ü "kesinleşmiş" bir mahkeme kararı anlamak doğru olmaz. O nedenle, burada öncelikle herhangi başka bir yolun tüketilmesi gerekmediği, doğrudan doğruya bu yola başvurulabileceği kanısındayız. Aksi uygulama hem usul ekonomisine hem de Kanuna açık aykırılık oluşturur.

IV – KESİN YETKİ KURALININ BULUNDUĞU BİR HALDE İKİ MAHKEMENİN VERDİĞİ YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ

Yargı yeri belirlenmesi gerektiren diğer bir durum ise kesin yetkiyle ilgilidir. Buna göre, "kesin yetki hâllerinde, iki mahkeme de[3] yetkisizlik kararı verir ve bu kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşirse" yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilir (m. 21, 1/d).

Bu sebeple yargı yeri belirlenmesinin istenebilmesi, yukarıda ifade edilen iki mahkemenin kesinleşmiş görevsizlik kararlarında olduğu gibidir. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, kesin olmayan yetkinin bulunduğu hallerde verilen yetkisizlik kararları bakımından yargı yeri belirlenmesinin söz konusu olmadığıdır. Çünkü, kesin olmayan yetkide, yetkisizlik kararı üzerine dosya kendisine gelen mahkeme, yetkili olmadığını düşünse bile yetkisizlik kararı veremeyip, davaya bakmak zorundadır[4].

Bir mahkemenin verdiği yetkisizlik kararına karşı kanun yoluna gidilmiş ve üst mahkeme bu kararı onamış (ve böylece yetkisizlik kararı kesinleşmiş) ise, dava dosyası (kesinleşen) yetkisizlik kararında yetkili olduğu bildirilen mahkemeye gönderilir (m. 20); bu **mahkeme**, (kanun yolu incelemesi sonucu kesinleşmiş olan) **bu yetkisizlik kararı ile bağlıdır** (m. 23, 2); yetkisiz olduğu kanısına varsa bile, yetkisizlik kararı veremez; davayı görmeye başlar.

---

3 İki icra mahkemesi arasındaki olumsuz yetki uyuşmazlığı da HMK m. 21-23'e (bkz. HMK m. 447, 2) göre çözümlenir (İİK m. 50).

4 Bkz. yuk. § 10, D, VI.

Görüldüğü gibi, bu halde yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmesine gerek kalmamaktadır.

Bir mahkeme, (yetkili olduğunu açıkça belirterek veya belirtmeyerek) yetkili olduğu kanısı ile esas hakkında karar vermiş, bu karar üst mahkemece yetkisizlik nedeniyle bozulmuş ve mahkeme bozmaya uygun biçimde yetkisizlik kararı vermiş (yani üst mahkemenin bozma kararında bildirilen mahkemenin yetkili olduğuna karar vermiş) ise, bu yetkisizlik kararı kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşmiş olsa bile, artık davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar (m. 23, 2)[5]. Çünkü üst mahkemenin hangi mahkemenin yetkili olduğunu (bozma kararı ile) belirlemiş durumdadır; bundan sonra, artık yargı yeri belirlenmesi yoluna gidilmesine gerek yoktur.

B) İNCELEME YERİ, USULÜ VE SONUCU

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren ve yukarıda sayılan durumlardan birisinin ortaya çıkması halinde, başvurulacak merci, ilk derece mahkemeleri bakımından istinaf (bölge adliye) mahkemeleri; istinaf mahkemeleri bakımından ise Yargıtay veya ilgisine göre bölge adliye mahkemeleri veya Yargıtay olarak ifade edilmiştir (m. 22)[6].

Yargı yerinin belirlenmesi konusundaki talep, doğrudan doğruya ilgili üst mahkemeye yapılabileceği gibi, dava dosyasının bulunduğu mahkemeye de yapılabilir. Bu dilekçenin karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafın buna cevap verebilmesi olanağının tanınması uygun olur.

Yargı yeri belirlenmesine ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılabileceği gibi, gerekli görülürse duruşma yapılarak incelenebilir (m. 23, 1)[7]. Yargı yeri belirtilmesi işi, acele işlerden olduğundan, diğer işlerden önce ve derhal incelenip karara bağlanır.

Üst mahkemenin yargı yerini (davaya bakacak olan mahkemeyi) belirten kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz. Yargı yerinin belirtilmesine karar veren üst mahkeme, dava dosyasını, yargı yeri olarak belirlediği mahkemeye gönderir ve bu mahkeme, davaya kaldığı yerden devam eder. Bu halde, m. 20 hükmü uygulanamaz. Yani, davacı iki hafta içinde yargı yeri olarak belirtilen mahkemeye başvurmak zorunda değildir.

---

5 Anayasa Mahkemesi bu hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 14.01.2015 gün ve 128/10 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, Usul Pratik, s. 147-148.

6 Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İşbölümü Kararına göre yargı yeri belirlenmesi 20. Hukuk Dairesinin görevine girmektedir (RG 31.01.2019, sa. 30672).

7 Bkz. m. 23'e ait Hükümet gerekçesi.

§ 12. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE)

A) GENEL OLARAK

Bir davanın en önemli aşaması tahkikat olup, bu aşamada hâkim, tarafların gösterdiği veya bizzat başvurabileceği delillerle, davada ileri sürülen hususların (olay ve olguların) doğru olup olmadığını tespit eder.

Bu anlamda hâkim, tanık dinler, keşif yapar ve diğer delilleri inceler. Ancak, davada gösterilen tanık, mahkemenin yargı çevresi dışında yaşayabilir; hatta, yurt dışında olabilir; mahkemenin bazı davalarda tarafları sorguya çekmesi (m. 169 vd. uyarınca isticvap etmesi) veya teklif edilen yeminin tarafça edası için tarafın mahkemede (m. 236) bulunması gerekebilir; davanın tarafı da mahkemenin yargı çevresi dışında yaşıyor olabilir; mahkemenin bir kısım defter, belge veya evrakı incelemesi ya da keşif yapması gerekebilir; söz konusu belge veya evrakın ya da keşif yapılacak yerin, davanın görüldüğü mahkemenin sınırları dışında olması mümkündür.

Bütün bu hallerde tarafın veya tanığın mahkemeye gelmesi gerekir; hatta bu zorunluluğa uymamasının bazı yaptırımları da vardır (m. 171, 2; 228, 2; 245). Ancak, acaba, örneğin Kars'ta veya Almanya'da yaşayan bir tanık, Edirne'de görülmekte olan bir davada tanıklık etmek üzere, Edirne'ye gelmek zorunda mıdır? Aynı şekilde, Ankara'da görülmekte olan bir davada hâkim, keşif yapmak üzere, dava konusu fabrikanın bulunduğu Konya'ya mı gidecektir?

Bu soruların cevaplanabilmesi için mahkemelerin yargı çevresinin ne olduğu üzerinde durulmalıdır. Çünkü mahkemelerin doğrudan doğruya yargılama faaliyeti yapabilecekleri alan, yargı çevreleri ile sınırlıdır. Mahkemelerin yargı çevresi, kural olarak mahkemenin kurulduğu il veya ilçelerin idarî sınırları ile belirlenir. Bu nedenle her mahkeme, yalnızca kendi yargı çevresi içinde işlem yapabilir. Bu bakımdan, hâkim, keşif için Ankara'dan Konya'ya gidemez. Aynı şekilde tarafı veya tanığı da, mutlaka davanın görüldüğü mahkemeye gelmeye zorlamak mümkün değildir. Ancak elbette taraf veya tanık, dilerse, davanın görüldüğü mahkemeye gelebilir (m. 195). Taraf veya tanıkların bulundukları yerden davanın görüldüğü mahkemeye gelmemeleri halinde, onları dinlemek, yemin ettirmek veya sorgulamak için, mahkemeler arasında hukukî yardım veya istinabe adı verilen hükümler uygulama alanı bulacaktır[1]. Bu halde, mahkemeye getirtilmesi mümkün olmayan deliller, bulunduğu yerde incelenir veya dinlenir (m. 195).

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin

---

1 Yukarıda (§ 5, K) belirttiğimiz üzere, SEGBİS'ten yararlanılması halinde istinabeye gerek yoktur.

yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca tespit edilir (5235 s. K. m. 7, 1-2). Bu şekilde yapılan belirlemeye göre bir mahkeme, başka bir ilçenin sınırları içinde de istinabeye gerek olmaksızın işlem yapabilir.

HMK, deliller bakımından 197. maddede istinabeyi açıkça düzenlemiştir. Buna göre, "başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde istinabe yoluyla toplanabilir" denilmektedir (m. 197, 2). Böylece hâkim, yargı çevresi dışında bulunan bir tanığın dinlenilmesini veya keşfin yapılmasını o yargı çevresindeki mahkemeden talep edebilir.

Taraflar bakımından söz konusu olabilecek istinabe ise, ilgili hükümlerde ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, tarafın isticvabı (m. 172) veya yemini (m. 236) bakımından da istinabe hükümleri uygulama alanı bulur.

İstinabe, doğrudanlık veya doğrudan doğruyalık ilkesinin bir istisnasıdır[2]. Çünkü hâkim, burada tanıkla, tarafla veya dava konusuyla doğrudan doğruya yüz yüze gelememektedir.

Uygulamada, istinabe yerine "**talimat**" kavramı da kullanılmaktadır. Ancak, bir mahkemenin bir başka mahkemeye talimat vermesi gibi yanlış anlaşılmaya yol açan bu niteleme uygun değildir.

İstinabe talebinde, **yapılması istenen işlem açıkça gösterilmelidir**; örneğin, "yargı çevrenizde oturan tanık (A)'nın şu vakıa hakkında (m. 259, 4) ifadesine başvurularak, düzenlenecek ifade tutanağının gönderilmesi" gibi. İstinabe talebi, yapılacak işlemin konusu olan kişinin (örneğin dinlenecek tanığın, yemin edecek tarafın) veya şeyin (örneğin incelenecek malın, ticarî defterlerin veya belgelerin) bulunduğu yerdeki mahkemeye gönderilir. Bu mahkemeye **istinabe olunan mahkeme** denir.

İstinabe eden mahkeme, istinabe olunan mahkemeye bir **istinabe talebi** gönderir. İstinabe eden mahkeme, istinabe talebi ile birlikte, istinabe yolu ile yapılmasını istediği işlemler için gerekli **giderleri** istinabe olunan mahkemeye göndermelidir (Harçlar K. m. 35).

İstinabe konusu işlemin nerede ve hangi şekilde yapılacağından tarafların haberdar edilmesi gerekir (m. 197, 3). Bu şekilde taraflar deliller veya beyanlarla ilgili açıklama haklarını kullanabilirler.

İstinabe olunan mahkeme, (yetkili ise) kendisinden istenilen **işlemi yapmak zorundadır**; örneğin dinlenilmesi istenen tanığı çağırıp dinlemek ve ifade tutanağını istinabe eden mahkemeye göndermekle yükümlüdür. İstinabe olunan hâkimin bu zorunluluğa uymaması halinde, başvurulacak bir kanun yolu yoktur. Ancak, hâkim hakkında disiplin kovuşturması yapılması için HSK'na şikâyette bulunulabilir.

İstinabe olunan mahkeme, kendisinden istenen işlemi yapar, bu konuda bir tutanak düzenler ve bu tutanağı (varsa diğer belgelerle birlikte) istinabe eden mahkemeye gönderir.

Bir mahkemenin bir başka mahkemeden bir işlem yapılması için hukukî yardım talep etmesi halinde, istinabe olunan mahkeme, gerekli işlemi yapıp,

---

[2] Bkz. yuk. § 5, I.

istinabe eden mahkemeye ilgili tutanakla birlikte gönderir. Mahkemelerde ayrıca istinabe kaydı tutulur (Y m. 176).

B) TÜRK MAHKEMELERİ İLE YABANCI MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE)

Türk mahkemelerinin yargı hakkı Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ile sınırlı olduğundan ve yabancı mahkemeler Türkiye'de yargısal faaliyette bulunamayacaklarından, Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemelerin karşılıklı olarak birbirlerine hukukî yardımda bulunmaları ihtiyacı doğar. Yani, Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler, yargı hakları dışında kalan hususlarda, karşılıklı olarak birbirlerine hukukî yardımda bulunurlar.

Örneğin, bir Türk mahkemesinde **tanık** olarak gösterilen bir Türk veya yabancı, **Türkiye dışında** (örneğin Almanya'da) bulunmaktadır. Türk hâkiminin o kişiyi Almanya'da dinlemesine, Türk ve Alman mahkemelerinin yargı hakkı elverişli (yeterli) değildir. Elverişli olsaydı bile, bu, çok güç ve pahalı bir yol olurdu. Bu nedenle, Türk (örneğin Ankara) mahkemesi, tanığın bulunduğu yer mahkemesini (örneğin Berlin Mahkemesini) istinabe eder; tanığa sorulması gereken soruları bir istinabe talebine yazar ve bunu, Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yetkili Almanya makamları aracılığı ile Berlin Mahkemesi'ne gönderir. Berlin mahkemesi, o kişiyi tanık olarak dinler ve düzenleyeceği tutanağı, aynı yoldan Ankara mahkemesine gönderir.

Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında hukukî yardımın (istinabenin) caiz olup olmadığı, caiz ise nasıl yapılacağı devletlerarası anlaşmalara (böyle bir anlaşma yoksa, karşılıklılık esasına) göre belirlenir:

Bu konudaki en önemli anlaşma, 01.03.1954 günlü "Hukuk Usulüne Dair **Lahey Sözleşmesi**"dir. Türkiye 1972 yılında (1574 sayılı Kanunla) Lahey Sözleşmesine katılmıştır. Lahey Sözleşmesinin 8-16. maddeleri, istinabeyi düzenlemektedir.

Bir diğer önemli anlaşma, 13.12.2000 tarihli "Hukukî veya Ticari Konularda **Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması** Hakkında Sözleşme"dir. Türkiye 07.04.2004 tarihli ve 5128 sayılı Kanunla bu sözleşmeyi onaylamıştır[3].

Bundan başka, Türkiye'nin de onaylamış bulunduğu, "Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili İle İlgili Sözleşme"nin 7. maddesi de istinabeyi düzenlemektedir.

Türkiye'nin bazı Devletlerle yapmış olduğu **iki taraflı anlaşmalar**da da istinabe ile ilgili hükümler vardır.

Yabancı ülkelerdeki kişilere yapılacak tebligat da, geniş anlamda hukukî yardıma (istinabeye) dahildir. Bundan başka, istinabe taleplerinin yabancı mahkemelere gönderilmesi de tebligat ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, burada **yabancı ülkelerde yapılacak tebligata** kısaca değinmek gerekir.

Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat, Tebligat Kanunu (m. 25-27) ile Tebligat Yönetmeliğinde (m. 38-47) düzenlenmiştir. Bundan başka, Türkiye

---

[3] Sözleşme metni için bkz. RG 15.06.2004, sa. 25493, s.163-180.

"Hukukî veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin **Yabancı Ülkelerde Tebliğine Dair Sözleşme**"ye katılmıştır[4].

Tebligat Kanunu (m. 25-27) ve Tebligat Yönetmeliği (m. 39) gereğince her takvim yılı başında (veya yılsonunda), Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ile ilgili hususlar hakkında bir tebliğ (bildiri) yayımlanmaktadır. Bu bildiride, yukarıda anılan Hukuk Usulüne Dair Sözleşme ve Yabancı Ülkelerde Tebligat Sözleşmesi de dahil olmak üzere, yabancı ülkelere gönderilecek istinabe talepleri ve tebliğler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu nedenle, yabancı ülkelere gönderilecek istinabe talepleri için, bu konudaki en son Adalet Bakanlığı bildirisinin dikkatle incelenmesini tavsiye ederiz.

C) NAİP TAYİNİ

İstinabe ile yakından ilgili bir kurum da **naip** tayinidir. Naip tayini **toplu mahkemeler**de söz konusu olur[5]. Toplu mahkeme, kendi yargı çevresi içinde ve fakat mahkeme binası dışında yapılacak bir işlem (örneğin tanık dinlemek veya keşif) için toplu olarak (mahkeme halinde) oraya (örneklerde tanığın veya keşif yapılacak yerin bulunduğu yere) gitmeyip, üyelerinden bir hâkimi o işlemi yapmakla görevlendirir; bu üyeye **naip üye** (hâkim) denir.

Naip üye (hâkim), örneğin keşif yerine gidip keşfi yapar ve keşif sonucunu bir tutanakla (üyesi bulunduğu) toplu mahkemeye sunar. Hasta veya sakat olan bir tanığı dinlemek için toplu mahkemenin bütün başkan ve üyeleri tanığın bulunduğu yere gitmez; sadece üyelerden biri naip tayin edilerek gönderilir. Böylece toplu mahkeme, zaman ve emekten tasarruf eder.

Görüldüğü gibi, **naip tayini istinabeden farklıdır**. Naip tayin edilen hâkim, üyesi bulunduğu toplu mahkemenin yargı çevresi içinde kendi mahkemesinin işini görür. Oysa, istinabe olunan mahkeme, istinabe eden (işi görülecek olan) mahkemenin yargı çevresinin dışındadır; istinabe eden mahkeme, istinabe olunan mahkemenin yargı çevresinde işlem yapamadığı için, o mahkemeyi istinabe etmektedir. İstinabe olunan mahkeme, istinabe eden mahkemeden ayrı (bağımsız) bir mahkemedir.

Naip tayini, yalnız toplu mahkemelerde olur. Oysa istinabe, hem toplu mahkemelerde hem de tek hâkimli mahkemelerde (bütün mahkemelerde) olabilir.

---

4 Bkz. 1483 sayılı Kanun; Ejder Yılmaz/Tacar Çağlar, Tebligat Hukuku, Ankara 2013.

5 Ticaret mahkemeleri, bazı davalara toplu mahkeme olarak bakar (5235 s. K. m. 5, 3).

DAVA

Dava, maddî hukuk kurallarının kendisine tanıdığı hakkı[1] bir başkası tarafından tanınmayan; tanınmama olasılığı (tehlikesi) ile karşı karşıya bulunan veya haksız bir taleple karşılaşan kişinin, yargı organından (mahkemeden, HMK'nun düzenlediği kurallara uygun olarak, kesin hukukî koruma isteminde (karş. geçici hukukî korumalar, m. 389 vd.) bulunmasıdır. Bir başka deyişle, mahkemeden hukukî koruma isteminde bulunan, aslında belli bir hukukî ilişkiden kaynaklanan istemini (talebini) belli bir hukukî sebebe dayalı olarak davalıya yöneltmekte; mahkemeden haklı olduğu yönünde karar verilmesini istemektedir.

Mahkemeden hukukî koruma isteyen kimseye **davacı** denir.

Dava, davacının hakkını çiğneyen veya davacının hakkını kullanmasını önlemeye çalışan veya davacıdan haksız talepte bulunan kimseye karşı açılır; bu kimseye de **davalı** denir.

Çekişmeli yargı süreci, dava ile başlar. Yani, çekişmeli yargının konusu davadır.

Maddî hukukun tanıdığı (sübjektif) hakkın yargı organında (mahkemede) ileri sürülmesi yetkisine **dava hakkı** denir. Dava hakkının, asıl haktan ayrı bir hak olmadığı baskın görüştür. Bu nedenle, dava hakkının, asıl haktan ayrı olarak (yalnız başına) başkasına devredilemeyeceği veya haczedilemeyeceği; ancak asıl hak ile birlikte devredilebileceği veya haczedilebileceği kabul edilir.

Dava hakkı, Anayasa ile teminat (güvence) altına alınmıştır: Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri (mahkemeler) önünde davacı veya davalı olarak iddia, savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir (Anayasa m. 36, I).

Ancak, dava hakkı hukukî yarar (menfaat) ile sınırlıdır. Yani, mahkemenin bir davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davanın esasına girebilmesi) için davacının dava açmakta hukukî yararının bulunması gerekir[2].

Bundan başka, **dava hakkının** açıkça **kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz**; yani bu halde TMK m. 2, II hükmü uygulanır[3]. Kaldı ki, kötüniyetle dava açılması hukukî niteliği gereği haksız fiil sayılır ve şartlarının varlığı halinde tazminat davasına konu olabilir.

Dava hakkının kötüye kullanılması, dava açılması halinde söz konusu olur. Bir kimsenin kendi lehine olan bir davayı açmaması, hakkın kötüye kul-

---

1 "**Hak**" kelimesi sübjektif nitelikte olduğu için, "sübjektif hak" kavramının kullanılmasına gerek yoktur. Çekişmesiz yargıda taraf değil, ilgili vardır. Geçici hukukî korumada ise geçici hukuki koruma isteyen ve karşı taraf vardır. Uygulamada, hatalı olarak, mahkemeden hukuki koruma istenen her duruma "dava" denilmektedir.

2 Bkz. aşa. § 15, B, III/2.

3 Davada dürüstlük kuralının yeri ve önemi hakkında bkz. Ramazan Arslan, Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

lanılması olarak nitelendirilemez. Çünkü, hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamaz (m. 24, 2).

Mahkeme, iki taraf arasındaki uyuşmazlığa (davaya), ancak davacının dava açması üzerine el koyar ve bu uyuşmazlığı, vereceği hüküm ile çözümler. Başka bir deyişle, davacının davası (talebi) olmadan, mahkeme kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz (m. 24, 1).

Çekişmesiz yargı işlerinde (m. 382-388) ise, aksine bir hüküm bulunmadıkça, kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi geçerlidir (m. 385, 2)[4].

Dava açılması ileride incelenecektir[5]. Davanın açılması, sonuçları ve davanın görülmesi hakkındaki kuralları incelemeden önce, sırasıyla davanın tarafları, davaya vekâlet, dava şartları ve dava çeşitleri konularının incelenmesi gerekir.

---

4 Bkz. yuk. § 5, E.
5 Bkz. aşa. § 17.

§ 13. TARAFLAR

Bir davada davacı ve davalı olmak üzere **iki taraf** (mahkemeden hukukî korunma isteyen ve kendisine karşı hukukî korunma istenilen iki ayrı kişi) **vardır**. Davacı veya davalı tarafta birden fazla kişi (dava arkadaşı) bulunabilirse de (m. 57), davada ikiden fazla tarafın bulunması söz konusu olamaz.

Başka bir deyişle, dava, iki taraf sistemine göre kurulmuştur; buna göre:

Tarafların (davacı ve davalının) başka başka kişiler olması gerekir. **Hiç kimse kendine karşı dava açamaz**[1]. Bunun gibi, bir tüzel kişinin şubesi, bağlı olduğu tüzel kişiye karşı veya aynı tüzel kişinin başka bir şubesine karşı dava açamaz.

Dava sırasında taraflar aynı kişi haline gelirse dava sona erer. Örneğin dava sırasında davacı ölür ve tek mirasçı olarak davalıyı bırakırsa (veya davalı ölür ve tek mirasçı olarak davacıyı bırakırsa) veya davacı ve davalı şirketler birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurulursa (TTK m. 136 vd.) dava son bulur.

Taraf kavramının bir davada büyük önemi vardır. Davacı ve davalı davada eşit (denk) hak ve yetki sahibidir. Bu eşitlik usule ilişkin (şeklî) anlamda bir eşitliktir. Bir davada verilen hüküm, yalnız o davanın tarafları hakkında verilir ve taraflar bakımından kesin hüküm teşkil eder (m. 303). İleride görüleceği gibi, davada tarafların yapacakları birçok taraf işlemleri vardır; yargılama giderleri de ancak taraflara (kural olarak haksız çıkan tarafa) yükletilir (m. 326).

Taraflar, kendi davalarında tanık veya bilirkişi olamaz.

Bir davada birbiri ile uyuşmazlık (çekişme) halinde olan iki kişi (taraf) yoksa, o zaman dava değil, **çekişmesiz yargı işi** (m. 382) söz konusu olur. Uygulamada, çekişmesiz yargı işleri için yanlış olarak dava, hasımsız dava ve tek taraflı dava terimleri kullanılmaktadır. Çekişmesiz yargıda davacı veya davalı terimlerinin yeri yoktur. Bu nedenle, çekişmesiz yargıda taraflar yerine, "ilgili" terimi kullanılmalıdır[2].

Bir davanın taraflarının kimler olduğu, davacı tarafından dava dilekçesinde gösterilir. Bu kişilerin, gerçekten o davada taraf sıfatına sahip olup olmadıkları başlangıçta belli değildir. Bu husus davanın görülmesi sırasında belli olacaktır. İlk önce, davacının dava dilekçesinde taraf olarak gösterdiği kişiler (kendisi ile davalı olarak gösterdiği kişi) arasında davaya devam edilir. Dava sırasında her ikisinin de taraf ehliyeti ve dava ehliyeti ile dava takip yetkisinin bulunduğu anlaşılırsa, o zaman taraflar arasındaki uyuşmazlık (dava) esastan incelenip karara bağlanır.

Taraf kavramının, taraflar arasındaki hukukî durumla ilgisi yoktur. Kimin taraf olduğu, davacının dava dilekçesine göre belirlenir. Örneğin, davacı di-

---

1 Karş. İİK m. 178; TTK m. 377; 634.

2 Bkz. aşa. § 70.

lekçesinde davalıdan alacaklı olduğunu iddia etmekte ise, bu borç ilişkisinin mevcut olup olmamasının taraf durumuna bir etkisi olmaz. Mahkeme, yargılama sonucunda davacının davalıdan alacaklı olmadığı; aksine (tam tersi) bir üçüncü kişinin davalıdan alacaklı olduğu kanısına varırsa, bununla üçüncü kişi davacı durumuna gelmez. Davacı, yine de davayı açandır; ancak, davası esastan reddedilir.

Bir davada taraflarla ilgili olarak aşağıdaki soruların cevabının bilinmesi gerekir.

Açılan davada kimler taraf olabilir? (kim taraf ehliyetine sahiptir?). Kimler davayı takip edebilir? (kimin dava ehliyeti vardır?). Taraf ve dava ehliyetleri olmasına rağmen talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisine sahip olmayanların temsili yetkisi kime aittir? (kimin dava takip yetkisi vardır?). Bir davada taraf olarak gösterilen kişiler gerçekten o dava ile ilgili midir? (sıfat, husumet doğru yöneltilmiş midir?).

Bu sorulara cevap verebilmek için taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi ve sıfat konularının incelenmesi gerekir:

A) TARAF EHLİYETİ[3]

I – GENEL BİLGİ

Taraf ehliyeti, davada **taraf olabilme yeteneği**dir. Taraf ehliyeti, medenî (maddî) hukuktaki hak ehliyetinin medenî usul hukukunda büründüğü şekildir (m. 50). Gerçekten, kimlerin taraf ehliyetine sahip bulunduğu Türk Medenî Kanununa göre belirlenir (TMK m. 8; 48). HMK m. 50'ye göre, medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir.

Buna göre, **hak ehliyeti** bulunan her gerçek (TMK m. 8) ve tüzel (TMK m. 48) kişi, davada **taraf** (olabilme) **ehliyeti**ne de sahiptir.

Yalnız gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır. Yani, yalnız gerçek ve tüzel kişiler, hakların ve borçların sahibi (hamili) olabilir ve bu nedenle haklarının korunması için dava açabilir ve borçlarından dolayı kendilerine karşı dava açılabilir.

Bu genel açıklamadan sonra, gerçek kişiler ile tüzel kişilerin taraf ehliyetinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

II – GERÇEK KİŞİLERİN TARAF EHLİYETİ

1) Her Gerçek Kişinin Taraf Ehliyeti Vardır

Her gerçek kişi, yaşadığı sürece taraf ehliyetine sahiptir. Taraf ehliyeti, çocuğun sağ olarak bütünüyle doğduğu anda başlar (HMK m. 50; TMK m. 8; 28).

Yargılama süresince tarafların, taraf (ve dava) ehliyetine sahip bulunmalarının gerekli olduğu, usul hukukunun temel ilkelerinden biridir. Bu ehliyetin

---

[3] Bkz. Evrim Erişir, Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007; Serdar Kale, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010.

varlığı aşağıda incelenecek olan dava şartlarından biridir. Ancak, **cenin** (çocuk), sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak taraf ehliyetine sahiptir (HMK m. 50; TMK m. 28, II). Cenine tayin edilen kayyım (TMK m. 427, 3), ceninin yasal temsilcisi sıfatıyla cenin adına dava (örneğin babalık davası) açabilir. Çocuk ölü doğarsa, dava, taraf ehliyeti yokluğundan reddedilir. Çocuk doğmadan önce dava sonuçlanır ve ondan sonra çocuk ölü doğarsa, mahkemenin kararı geçersiz (hükümsüz) duruma gelir.

2) Ölüm İle Taraf Ehliyeti Son Bulur

Gerçek kişilerin kişiliği ve bununla hak (medenî haklardan yararlanma) ehliyeti ölümle sona erer (TMK m. 28/I). Bu nedenle, ölmüş olan kişinin taraf ehliyeti yoktur. Dolayısıyla, **dava tarihinden önce ölmüş olan kişiye karşı dava açılamaz**[4].

Yargıtaya göre, dava tarihinden önce ölmüş olan bir kişiye karşı dava açılmış olması halinde, **mahkemenin** davalının taraf ehliyetinin bulunmadığını (dava tarihinden önce ölmüş bulunduğunu) öğrenmesi üzerine, davayı mesmu olmadığından (dava şartı bulunmadığından) dolayı **kendiliğinden reddetmesi** gerekir. Yoksa, ölmüş kişiye karşı açılmış olan davaya, o kişinin mirasçılarına tebligat yapılmak suretiyle mirasçılara karşı devam edilemez. Örnek:

"Ölen bir kimse hakkında açılan davaya bakılmasına, davacı tarafın isteği üzerine mirasçıların duruşmaya davalı olarak çağrılmalarına yahut ıslah yolu ile, kendilerinin davalı sayılmasına mevzuatımız yer vermemiştir. Bu nedenlerle mirasçılar hakkında ayrı bir dava açılması zorunludur. Temel kural budur. Hak aramak durumunda bulunan davacının, davasını açarken davalı olarak gösterdiği kimsenin hayatta olup olmadığını özenle araştırması ödevidir"[5].

Bu içtihadı birleştirme kararından anlaşıldığı gibi, davacının dava dilekçesinde davalı olarak gösterdiği kişinin (davalının) davadan önce ölmüş bulunduğunu davayı açtıktan sonra öğrenmiş olması halinde bile, Yargıtay davacının, ıslah yolu ile davanın, davalının mirasçılarına karşı devamını isteyemeyeceği görüşünde idi.

HMK ise, m. 124, 4 hükmü ile, dava dilekçesinde **tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi**nin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması **halinde**, hâkimin, karşı tarafın onayını almaksızın (karş. m. 124, 1) **taraf değişikliği talebinin kabul edilebileceği**ni düzenlemiştir. HMK'nun 124. maddesinin Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere; "kısa bir süre önce işlem yapılmış ya da sadece vekiliyle muhatap olunmuş bir işlemden sonra muhatabın ölmesi halinde, mirasçılara değil, ölen kişiye karşı dava açılması" kabul edilebilir bir yanılgıya örnektir.

Bir başka deyişle, dava tarihinden önce ölen kişinin taraf ehliyetini yitireceğine kuşku yoktur. Bu nedenle, davanın (usulden) reddedilmesi gerekir ise de, HMK'nun 124. maddesi hükmü gereğince, davanın reddedilmeyip miras-

---

4 Ölenin terekesine ilişkin davalar mirasçılarına karşı açılır (bkz. aşa. § 13. A, IV/2).

5 04.05.1978 gün ve 04/50 sayılı İBK (RG 01.06.1978, sa. 16303).

çılarının davaya katılımlarının sağlanmasıyla yargılama yapılması olanağı getirilmiştir.

Öte yandan, kanunların açıkça gösterdiği hallerde ölmüş kişiye karşı açılmış olan davaya, o kişinin mirasçılarına tebligat yapılmak suretiyle mirasçılarına karşı devam edilebilir. Örneğin:

İdare tarafından, Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre tespit olunan malike veya zilyede karşı açılan davaların (Kamulaştırma K. m. 14, IV) görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir kişi olduğu anlaşıldığı takdirde, dava bu nedenle reddedilemez; davaya, gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur (Kamulaştırma K. m. 14, V).

Kadastro davaları da, mirasçıların tayin edilememesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar hakkında, ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhinde açılabilir. Kadastro mahkemesinde görülen davada, davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhine devam edilir (Kadastro K. m. 29).

Ölmüş kişinin taraf ehliyeti olmadığından, dava tarihinden önce **ölmüş** olan **kişi adına dava açılamaz**[6]. Müvekkilin ölümü ile davaya vekâlet son bulduğundan, müvekkilin sağlığında düzenlediği vekâletname ile yetkili kıldığı vekili (avukatı), müvekkilinin ölümünden sonra onun adına dava açamaz (TBK m. 43, I ve m. 513, I).

Dolayısıyla ilke olarak **vekil müvekkilinin öldüğünü bilmeden** (TBK m. 43, I; TBK m. 513, I) müvekkili adına **dava açmış** olsa bile, davanın taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle reddi gerekir; mirasçılar bu davaya devam edemezler; mirasçıların ayrı bir dava açması gerekir. Ancak, ölen kişi adına dava açılması, m. 124, 4 anlamında kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın onayını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.

Kanımızca, m. 124, 4 hükmünün getirdiği kolaylığın yanı sıra; vekilin, müvekkilinin öldüğünü bilmeden (yanlışlıkla) onun adına açtığı davayı, ölenin mirasçıları adına açılmış bir dava olarak kabul etmek, yararlar dengesine ve usul ekonomisine uygun düşer. Bu nedenle, mirasçılar, bu davaya icazet (onay) verirlerse, davaya devam edilmesi gerekir.

Bundan başka, ölen kişinin vekilinin, dolmak üzere olan zamanaşımı süresini kesmek (veya hak düşürücü süreyi korumak) amacıyla (ölmüş kişi adına) dava açmış olması halinde, mirasçıların (isterlerse) davaya devam edebilmeleri gerekir. Çünkü, bu halde ölen kişinin vekili, onun (mirasçılarının) menfaatlerini korumak için vekâlet görevini yapmaya devam (dava açmak) ile yükümlüdür (TBK m. 513).

---

[6] Ölenin terekesine ilişkin davalar, mirasçıları tarafından açılır (bkz. aşa. § 13, A, IV/2).

3) Dava Açıldıktan Sonra Ölen Tarafın Taraf Ehliyeti Kalmaz

Dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde, ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur (m. 50; TMK m. 28, I). Bu nedenle, davaya ölen tarafa karşı veya onun tarafından devam edilmesine imkân yoktur. Ancak açılmış bir dava bulunduğu için, davanın bir kararla sona ermesi gerekir.

Taraflardan birinin ölümü hâlinde, mirasçılar mirası reddetmemişse (TMK m. 605 vd.), bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kayyım (TMK m. 426 vd.) atanmasına karar verebilir (m. 55).

Bu özel durumun da uygulanabilmesi veya genel olarak davaya devam edilebilmesi için, ölen tarafın mirasçılarına karşı veya onun mirasçıları tarafından davaya devam edilip edilmeyeceğini tespit bakımından, bir ayrım yapmak gerekir:

Yalnız öleni ilgilendiren, yani **mirasçılara geçmeyen** haklara ilişkin davalar, tarafın ölümü ile **konusuz** (dava ilişkisi, davacı-davalı çekişmesi ortadan kalkar) **kalır;** bu davalara ölen tarafın mirasçılarına karşı (veya mirasçıları tarafından) devam edilmesine olanak yoktur. Örneğin, **boşanma davası** devam ederken taraflardan (eşlerden) **biri ölürse**, kural olarak, boşanma davası konusuz kalır; ancak, ölen eşin mirasçılarının, Kanunun öngördüğü durumda, davayı devam ettirebilme hakları vardır (TMK m. 181, II)[7].

Yalnız ölen tarafı ilgilendirmeyen, yani mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu davalara, ölen tarafın mirasçılarına karşı (veya mirasçılar tarafından) devam edilir. Mirasçıları da ilgilendiren davalar, ölen tarafın mirasçılarına geçen alacakları, hakları ve mallarına (TMK m. 599) ilişkin davalardır. Bunlar malvarlığı haklarına ilişkin davalardır.

Bu halde, ölen tarafın mirasçıları, davayı **zorunlu dava arkadaşı**[8] olarak hep birlikte takip ederler:

Dava devam ederken **davacı ölürse**, davacının mirasçıları, davayı zorunlu dava arkadaşı olarak hep birlikte takip edebilirler.

Ölen **taraf davalı** ise, davacı, davayı, kural olarak, davalının mirasçılarının hepsine karşı birlikte devam ettirebilir (davalı tarafta zorunlu dava arkadaşlığı); mirasçıların bazılarına tebligat yaptırarak onlara karşı yürütemez.

III – TÜZEL KİŞİLERİN TARAF EHLİYETİ

Tüzel kişiler, hak (medenî haklardan yararlanma) ehliyetine sahiptir (TMK m. 48); bu nedenle taraf ehliyetine de sahiptir (HMK m. 50). Konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir:

---

7 Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, TMK m. 181, II'nin Anayasa Mahkemesince İptali Çerçevesinde Boşanma Davalarında Mirasçıların Durumunun Usuli Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Erdal Onar'a Armağan, Ankara 2013, C. II, s. 1099-1136).

8 Bkz. Kadastro K. m. 29; aşa. § 47, C.

1) Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Özel hukuk tüzel kişileri, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ve kamu otoritesini temsil etmeyen tüzel kişilerdir; dernekler, vakıflar, ticaret şirketleri, kooperatifler, bankalar, sendikalar gibi.

Dava, tüzel kişinin organı tarafından **tüzel kişi adına açılır**. Tüzel kişinin (organı olmayan) üyeleri veya ortakları, tüzel kişi adına dava açamazlar. Bunun gibi, dava **tüzel kişiye karşı** açılır. Tüzel kişinin üyelerine, ortaklarına veya tüzel kişinin organı olan kişilere karşı açılan dava tüzel kişiye karşı açılmış sayılamaz[9].

Tüzel kişiliğin son bulması ile, artık tüzel kişinin taraf ehliyeti de son bulur. Bundan sonra, tüzel kişiye karşı veya onun adına dava açılamaz. Tüzel kişiliği son bulan (eski) tüzel kişinin malvarlığı haklarına ilişkin davalar, son bulan tüzel kişinin yasal halefi olan tüzel kişiye karşı veya onun adına açılır.

2) Kamu Tüzel Kişilerinin Taraf Ehliyeti

Kamu tüzel kişileri, görevleri bakımından kamu otoritesini temsil eden tüzel kişilerdir. Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur (Anayasa m. 123, III; bkz. ayrıca TMK m. 55).

Kamu tüzel kişileri **taraf ehliyetine sahiptir.**

Kamu tüzel kişilerinin başında **Devlet** bulunur.

Bakanlıkların[10] Devlet tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilikleri yoktur. Çünkü, bakanlıklar Devlet kamu tüzel kişiliğinin organıdırlar. Fakat bakanlıklar, Devlet tüzel kişiliğinin temsilcisi değil, birer organı oldukları için, davada **taraf ehliyetine sahiptirler**.

Bakanlıklara bağlı **bazı genel müdürlüklerin** ayrı bir tüzel kişiliği vardır[11]. Örneğin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi.

Üniversiteler ve diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarının (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Patent ve Marka Kurumu gibi) da ayrı tüzel kişilikleri vardır. Bu nedenle, ayrı tüzel kişiliği olan bu kurum veya kuruluşlar, bağlı bulundukları bakanlıktan veya kurumlar ilgili oldukları bakanlıktan ayrı tüzel kişiler olarak ayrı taraf ehliyetine sahiptirler (bkz. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, I ve II sayılı cetvel).

Ayrı tüzel kişiliği (ve bu nedenle taraf ehliyeti) bulunan (bu gibi) genel müdürlüklerle ilgili davalar, bu genel müdürlükler tarafından veya onlara karşı açılır; bağlı bulundukları bakanlıklara karşı açılamaz[12]. Diğer kamu kurum

---

9 Bkz. aşa. § 13, B, III.

10 Bkz. Bakanlıklar hakkında yeni düzenleme için 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, RG 10.07.2018, sa. 30474.

11 Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı için bkz. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, RG 15.07.2018, sa. 80479.

12 Bazı davalarda Orman Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birlikte (davalı olarak) dava edilir. Hatta, Orman Genel Müdürlüğü açtığı bazı davalarda Orman ve Su İşleri Bakanlığını hak sahibi kişi veya kişilerle davalı (hasım) gösterir (Orman K. m. 11, II-III).

ve kuruluşları ile ilgili davalar da bu kurum ve kuruluşlar tarafından veya onlara karşı açılır; ilgili bulundukları bakanlıklar tarafından veya onlara karşı açılamaz.

İl özel idareleri, köyler, büyükşehir belediyeleri ve **belediyeler** kamu tüzel kişiliğine sahip olup (Anayasa m. 127), bu nedenle **taraf** ehliyetine de sahiptirler.

Buna karşılık, mahallelerin tüzel kişiliği (ve bu nedenle) taraf ehliyeti yoktur.

Kamu iktisadî teşebbüsleri (yani, iktisadî devlet teşekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları) ve bunlara bağlı kurumlar tüzel kişiliğe ve bu nedenle taraf ehliyetine sahiptir.

IV – TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN TOPLULUKLARIN TARAF EHLİYETİ DE YOKTUR

Buraya kadar görüldüğü gibi, yalnız gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır. Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların (topluluk olarak) ve ortaklıkların taraf ehliyeti de yoktur[13]; buna göre:

1) Adi Ortaklığın Taraf Ehliyeti Yoktur

Adi ortaklığın (şirketin) (TBK m. 620 vd.), tüzel kişiliği olmadığı için, taraf ehliyeti de yoktur. Bu nedenle, adî ortaklığa ilişkin davalarda, adi ortaklığı oluşturan kişilerin taraf olarak hep **birlikte hareket etmeleri gerekir**. Buna göre: **Adi ortaklık tarafından** (davacı olarak) **açılacak davaların,** elbirliği mülkiyeti kuralları (TBK m. 638; TMK m. 702) gereğince **bütün ortaklar tarafından birlikte** açılması gerekir (zorunlu dava arkadaşlığı).

Bütün ortaklar tarafından açılacak dava, adi ortaklık adına değil, bütün ortakların ayrı ayrı ad ve soyadlarının gösterilmesi suretiyle açılır ve hüküm de ortaklar hakkında verilir. Adi ortaklık adına hüküm verilemez; örneğin dava konusu taşınmazın adi ortaklık adına tesciline karar verilemez.

Buna karşılık, adi ortaklığa karşı açılacak davalar için bir ayrım yapmak gerekir:

Davanın konusu **paradan başka bir şey** (örneğin taşınır veya taşınmaz bir mal) **ise,** davanın **bütün ortaklara karşı** (davalı olarak) birlikte açılması gerekir. Çünkü ortakların, adi ortaklığın malları üzerinde mülkiyeti elbirliği mülkiyetidir (TBK m. 638) ve bu mallar üzerinde birlikte tasarruf edebilirler (TMK m. 702). Bu durumda, davalı ortaklar arasındaki ilişki zorunlu dava arkadaşlığıdır.

Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak orman sınırlamasına itiraz davalarında hasım (davalı) Orman Genel Müdürlüğü'dür. Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılacak davalarda davalı, hak sahibi olan kişidir (Orman K. m. 11, II, III). Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından Orman K. m. 2'ye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında davalılar, Hazine ve Orman Genel Müdürlüğüdür (Orman K. m. 11, II).

[13] Ancak Yargıtay, belli koşullarda site yönetimleri ve okul aile birliği gibi tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların taraf (husumet) ehliyetinin bulunduğu görüşündedir.

Davanın konusu **para alacağı ise,** ortaklar bu borçtan müteselsilen sorumlu olduklarından (TBK m. 638, III) ve alacaklı müteselsil borçluların her birinden borcun tamamını isteyebileceğinden (TBK m. 163, I), davacı **bir ortağa** veya ortakların tümüne veya bazılarına **karşı,** (ihtiyarî dava arkadaşı olarak) **alacak davası açabilir.**

2) Miras Ortaklığının Taraf Ehliyeti Yoktur

TMK m. 640'a göre, birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık (miras ortaklığı) meydana gelir. Bu ortaklığın (miras ortaklığının) tüzel kişiliği ve taraf ehliyeti yoktur. Bu nedenle, bütün mirasçıların birlikte dava açması veya bütün mirasçılara karşı birlikte dava açılması gerekir. Konuyu, mirasçıların davacı veya davalı olmasına göre ikiye ayırarak incelemek gerekir:

a) Elbirliği mülkiyeti kuralları (TMK m. 640; 702) gereğince, miras ortaklığının (terekenin) tümüne ilişkin davaların zorunlu dava arkadaşı olarak[14], bütün mirasçılar tarafından birlikte açılması gerekir (istisnası: TMK m. 640, IV; 702, IV)

Ancak, bir mirasçı, özellikle acele hallerde, miras ortaklığının hak ve yararlarını korumak için bütün mirasçılar adına, yalnız başına dava açabilir. Örneğin bir mirasçı, hak düşürücü sürenin kaçırılması tehlikesini önlemek için, yalnız başına önalım (şuf'a) davası (TMK m. 732-735) açabilir. Bir mirasçı diğer (acele olmayan) hallerde de, bütün mirasçılar adına, tereke ile ilgili bir davayı yalnız başına açabilir. Ancak, davacı mirasçı açtığı böyle bir davayı **yalnız başına yürütemez.** Davayı bütün mirasçıların birlikte yürütmeleri gerekir. Bu halde mahkeme bir mirasçının açtığı davayı hemen reddedemez. Mahkeme, diğer mirasçıların davaya katılmasını (icazet vermelerini) sağlamak için veya terekeye temsilci tayin ettirmesi (TMK m. 640) için davacıya uygun bir **süre vermelidir.**

b) Mirasçılara karşı dava açılması konusunu ikiye ayırarak incelemek gerekir:

Tereke ile ilgili olup, **konusu paradan başka bir şey** olan davaların, bütün mirasçılara (mirasçıların hepsine) karşı açılması gerekir (zorunlu dava arkadaşlığı). Çünkü, mirasçılar terekedeki mallar ve haklara elbirliği (iştirak) halinde maliktirler ve bunlar üzerinde birlikte tasarruf edebilirler (TMK m. 640, 702). Örneğin, terekedeki bir mal hakkında açılacak istihkak davasının bütün mirasçılara karşı açılması gerekir; terekenin (miras bırakanın) zilyet olduğu bir taşınmaz hakkındaki müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davası bütün mirasçılara karşı açılır. Dava dilekçesinde bütün mirasçılar davalı olarak gösterilmiş değilse, dava bu nedenle hemen reddedilmez. Mahkemenin davayı **diğer mirasçılara da teşmil** etmesi için davacıya bir süre vermesi, davacı bu süre içinde davayı diğer mirasçılara da teşmil ederse, davaya devam etmesi gerekir.

---

[14] Kadastro davaları ise, bir mirasçı tarafından diğerlerinin muvafakatı olmadan da açılabilir ve dava, yalnız onun tarafından yürütülebilir (Kadastro K. m. 29, II).

Tereke ile ilgili olup, **konusu para alacağı** olan davaların bütün mirasçılara karşı açılması zorunlu değildir; bir mirasçıya karşı da alacak davası açılabilir. Çünkü, mirasçılar murisin borçlarından müteselsilen sorumludur (TMK m. 641, I) ve alacaklı müteselsil borçluların birinden borcun tamamını isteyebilir (TBK m. 163). Bu nedenle tereke alacaklısı, alacağının tümü için bir mirasçıya veya mirasçıların hepsine veya bazısına karşı alacak davası açabilir (ihtiyarî dava arkadaşlığı).

c) Terekeye (miras şirketine) bir temsilci atanmış (TMK m. 640) ise, terekeye ilişkin davaları takip yetkisi tereke **temsilcisi**ne aittir.

d) Buraya kadarki açıklamalar, mirasın taksim edilmediği dönem (miras ortaklığı dönemi) içindir. Miras ortaklığı mirasın taksimine kadar devam eder (TMK m. 640, 646 vd.). Mirasın taksiminden sonra, her mirasçı, taksimde kendine düşen alacak veya mal için **yalnız başına dava açabilir** ve ona karşı dava açılabilir.

V – BİR DAVADA TARAFLARIN TARAF EHLİYETİNE SAHİP OLMALARI DAVA ŞARTLARINDANDIR

Davada tarafların taraf ehliyetine sahip bulunması dava şartıdır (m. 114, 1/d). Bu nedenle, davanın taraflarından birinin (veya taraflarının) taraf ehliyetine sahip olup olmadığı mahkemece kendiliğinden gözetilir ve dava şartı eksikliği sonucuna varılırsa dava esasa girilmeden (mesmu olmadığından) reddedilir.

Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, adî ortaklıkta bütün ortakların, miras ortaklığında ise bütün mirasçıların taraf olarak gösterilmemesi hallerinde, bütün ortakların veya mirasçıların davaya katılmalarını sağlamak için mahkemece süre verilebilir ve böylece taraf ehliyeti noksanlığı giderilebilir. Buna rağmen taraf ehliyeti noksanlığı giderilmez (bütün ortaklar veya mirasçılar davaya katılmaz ve onay vermez) ve terekeye bir temsilci de atanmaz ise, işte o zaman, davanın taraf ehliyeti bulunmaması (dava şartı eksikliği) nedeniyle esasa girilmeden reddi gerekir.

B) DAVA EHLİYETİ

Dava ehliyeti (yeteneği), kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir temsilci (vekil) aracılığı ile bir davayı (davacı veya davalı olarak) takip etme ve usul işlemlerini yapabilme ehliyetidir (m. 71; AK m. 36, III).

Dava ehliyeti, medenî hakları kullanma (fiil) ehliyetine göre belirlenir (m. 51). Yani **fiil** (medenî hakları kullanma) **ehliyetine sahip olan** bütün gerçek ve tüzel kişiler, **dava ehliyetine de sahiptir** (m. 51). Başka bir deyişle, dava ehliyeti, fiil ehliyetinin (TMK m. 9) medenî usul hukukunda büründüğü şekildir.

Bu genel açıklamadan sonra, gerçek kişiler ile tüzel kişilerin dava ehliyetini ayrı ayrı inceleyebiliriz:

I – GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ

Gerçek kişilerin dava ehliyetini incelerken, medenî hakları kullanma (fiil) ehliyetine uygun olarak bir ayrım yapmak gerekir:

1) Tam Dava Ehliyetine Sahip Olanlar

Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz), ergin (reşit) olan ve kısıtlı (mahcur) bulunmayan her gerçek kişi tam dava ehliyetine sahiptir (TMK m. 9 vd.). Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, **eşlerden her biri** diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabildiği için (TMK m. 193), **dava ehliyetine sahiptir**. Yani, karı ve koca, evlilik süresi içinde birbirlerine veya üçüncü kişilere karşı dava açabilirler ve birbirlerine karşı cebrî icraya başvurabilirler.

Tam dava ehliyetine sahip olanlar bizzat dava açabilir ve açtığı davayı yürütebilir. Kendilerine karşı açılan davayı takip edebilir. Bu nedenle, örneğin dava tarihinde fiil ehliyetine sahip olan bir kişi (çocuk) adına, fiil ehliyetinin bulunmadığı zamandaki velisi velâyeten dava açamaz; davanın, fiil ehliyetine sahip çocuk (veya onun yetkili kıldığı bir vekil) tarafından açılması gerekir.

2) Sınırlı Dava Ehliyetine Sahip Olanlar
(Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler ve Kısıtlıların Dava Ehliyeti)

Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler ve kısıtlılar kural olarak fiil ehliyetine ve dolayısıyla dava ehliyetine (HMK m. 51) sahip değildir. Bu nedenle, ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar davada yasal temsilcileri tarafından temsil edilir.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, **bazı** (istisnaî) **hallerde** dava ehliyetine sahiptirler; bu nedenle, bu kişilere sınırlı dava ehliyetine sahip kişiler denir. Bu haller şunlardır:

a) Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını kullanmak bakımından yasal temsilcilerinin rızasına muhtaç değildir (TMK m. 16, I/c. 2); bu nedenle, kişiye sıkı olarak bağlı haklarla ilgili davalarda kural olarak dava ehliyetine de sahiptirler; boşanma, ayrılık, babalık davalarında olduğu gibi. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar karşılıksız kazanmaya bağlı haklarını kullanma ile ilgili olarak yasal temsilcilerinin rızası olmadan dava açabilir; kendilerine karşı açılan davayı takip edebilir. Aynı kural, haksız fiillerinden doğan sorumluluğa ilişkin davalarda da geçerlidir (TMK m. 16, I/c.2; 16, II).

b) Kendisine sulh mahkemesi (vesayet makamı) tarafından bir **meslek** veya **sanatla uğraşma izni** verilen vesayet altındaki kimse (TMK m. 453, 462, 7), bu meslek veya sanatın gereği olarak yaptığı işlemlerle ilgili alacak ve borçları için açılan davalarda dava ehliyetine sahiptir. Bunun gibi, kendisine ana ve babası tarafından bir meslek veya sanatla uğraşma izni verilen ayırt etme gücüne sahip küçük (TMK m. 359), bu meslek veya sanatın gereği olarak yaptığı işlemlerle ilgili alacak ve borçları için açılan davalarda dava ehliyetine sahiptir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, **tasarruf**

hakkı kendilerine bırakılmış olan mal ve **alacaklar** (TMK m. 359, 455) için açılan davalarda dava ehliyetine sahiptirler.

Yukarıdaki istisnaî durumlar dışında, ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlıların dava ehliyeti yoktur. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, bu istisnalar dışındaki davalarda yasal temsilcileri tarafından temsil olunurlar. Yani, küçük ve kısıtlılar adına yasal temsilcileri tarafından dava açılır ve takip edilir. Yalnız, ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar tarafından açılmış olan davaya, yasal temsilcisi **onay** (icazet) verebilir. Bunun gibi, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlıya karşı açılan dava onun yasal temsilcisi tarafından takip olunur.

3) Dava Ehliyeti Olmayanlar *(Tam Ehliyetsizler)*

Ayırt etme gücünden (TMK m. 13) **yoksun olan kişiler**in fiil (medenî hakları kullanma) ehliyeti (TMK m. 14-15) yoktur ve bunun sonucu olarak **dava ehliyeti yoktur** (m. 51). Ayırt etme gücü (ve bu nedenle dava ehliyeti) olmayan kişiler, taraf oldukları **davalarda yasal temsilcileri tarafından temsil edilir.**

Ayırt etme gücü olmayan bir kişi adına yasal temsilcisi tarafından dava açılır ve takip edilir. Bunun gibi, ayırt etme gücü olmayan bir kişiye karşı açılan dava onun yasal temsilcisi tarafından takip olunur.

4) Yasal Temsilcisinin Dava Ehliyeti Olmayan Tarafı Davada Temsil Etmesi[15]

Ayırt etme gücü olmayan kişilerin dava ehliyetine sahip olmadıklarını ve ayırt etme gücüne sahip küçüklerin ve kısıtlıların ise, iki istisna dışında, dava ehliyetine sahip olmadıklarını da yukarıda inceledik. Dava ehliyeti bulunmayan bu kişiler, taraf oldukları davalarda **yasal temsilcileri** tarafından temsil edilirler. Başka bir anlatımla;

Dava ehliyeti olmayan kişi adına yasal temsilcisi tarafından dava açılır. Bu durumda, dava dilekçesinde, davacı (taraf) olarak dava ehliyeti bulunmayan kişinin (küçük veya kısıtlının), temsilcisi olarak da yasal temsilcisinin adı, soyadı ve adresi yazılır.

Dava ehliyeti olmayan bir kişiye (küçüğe veya kısıtlıya) karşı açılan dava dilekçesinde, davalı (taraf) olarak dava ehliyeti olmayan kişinin (küçük veya kısıtlının); temsilcisi olarak da yasal temsilcisinin adı, soyadı ve adresi yazılır. Yukarıda açıklandığı gibi, yasal temsilci davada taraf değildir; davanın tarafı, yasal temsilci tarafından temsil edilen küçük veya kısıtlıdır. Yasal temsilci ise, taraf olan küçüğü veya kısıtlıyı davada temsil edendir. Bu nedenle, yasal temsilci tarafından (veya yasal temsilciye karşı) yapılan usul işlemleri, taraf (küçük veya kısıtlı) hakkında hüküm ifade eder. Örneğin, tebligat yasal temsilciye yapılmasına karşın, taraf hakkında hukukî sonuç doğurur (Teb. K. m. 11, 2; Teb. Yön. m. 19).

---

[15] Bkz. Ejder Yılmaz, "Çocuk Hakları" Açısından: Çocuğun Davada Temsilinin ve İradesinin Önemi (Prof. Dr. Bilge Umar'a Armağan, İzmir 2010, s. 819-841; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 1871-1888).

Yasal temsilcinin, dava ehliyeti olmayan tarafı davada temsil etmesine ilişkin bu genel açıklamalardan sonra, şimdi yasal temsilcileri ayrı ayrı inceleyebiliriz:

a) Veli

Küçük (ergin olmayan) çocuklar üzerinde velayet hakkına (TMK m. 335 vd.) sahip olan kişiye veli denir. Velayet hakkı, ya ana ve babada veya evlat edinen kişidedir.

Velayet hakkına sahip ana ve baba (TMK m. 335), küçüğün taraf bulunduğu davalarda, çocuğu temsil eder (TMK m. 342). Burada velâyetin ana babadan birinde veya ana ve babada birlikte olmasına göre bir ayrım yapmak gerekir:

Ölüm, boşanma veya velayetin kaldırılması (nez'i) gibi bir nedenle, velâyet yalnız anada veya yalnız babada ise, veli olan ana veya baba, yalnız başına çocuğu davada temsil eder (TMK m. 336, II-III). Evlilik süresince, kural olarak velayet ana ve babadadır (yani her ikisindedir); ana ve baba, velayet hakkını birlikte kullanırlar (TMK m. 336). Bu nedenle baba veya ana, çocuk adına yalnız başına dava açamaz ve çocuğa karşı açılan davada çocuğu yalnız başına temsil edemez. Çünkü, ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar (TMK m. 336). Babanın veya ananın, yalnız başına çocuk adına dava açmış olması halinde, diğerinden, açılan davaya icazet verip vermeyeceğinin sorulması gerekir. Diğeri, **onay** (icazet) **verirse** davaya devam edilir; icazet vermezse dava, temsilde eksiklik (dava açanın tek başına tarafı temsil ehliyetine sahip olmaması) nedeniyle reddedilir.

Evlat edinen, (küçüğün) evlatlığın velisidir (TMK m. 314). Bu nedenle, velinin, çocuğu davada temsil etmesine ilişkin yukarıdaki açıklamalar, evlat edinen için de geçerlidir. Yani, küçük evlatlık adına açılacak davalar (velisi sıfatıyla) evlat edinen tarafından açılır. Bunun gibi, küçük evlatlığa karşı açılan davalarda da evlatlığı, velisi olan evlat edinen temsil eder.

b) Vasi

Vasi, vesayeti altındaki kişinin (küçüğün veya kısıtlının) taraf bulunduğu davalarda onu temsil eder (TMK m. 448). Ancak vasi, yalnız vasi tayini kararı ile, vesayeti altındaki kişiyi davada temsil edemez. Vasinin, vesayeti altındaki kişi adına dava açıp takip edebilmesi (veya vesayeti altındaki kişiye karşı açılan davayı takip edebilmesi) için, vasiye vesayet makamından (sulh hukuk mahkemesi tarafından) temsil izni (husumet izni) verilmiş olması gerekir (TMK m. 462, I/8).

c) Kayyım

Kendisine kayyım atanan kişi velayet veya vesayet altında değilse, fiil (medenî hakları kullanma) ve dava ehliyetine sahiptir (TMK m. 458, I). Çünkü, bir kimseye kayyım atanması onun fiil ehliyetini etkilemez. Ancak, kendisine kayyım tayin edilen kişi, kayyım tayinini gerektirmiş olan işte (davada), kayyım tarafından temsil edilir (TMK m. 426; 427; 459; 460).

II – GERÇEK KİŞİNİN DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMASI DAVA ŞARTIDIR

Dava ehliyeti, dava şartlarındandır (m. 114, 1/d). Bu nedenle mahkeme, tarafların dava ehliyetine sahip olup olmadıklarını **kendiliğinden gözetmek zorundadır**. Konuyu, davacı ve davalı bakımından ikiye ayırarak incelemek gerekir.

Dava ehliyeti olmayan kişi adına, yasal temsilcisi tarafından dava açılması gerektiğini yukarıda inceledik. Buna rağmen, dava ehliyeti olmayan kişi, davayı kendisi açmış ise, hâkim davacının dava ehliyetinin bulunmadığını kendiliğinden gözetir. Bunun için, davalının itiraz etmesi gerekli değildir; davalı böyle bir itirazı ile, sadece mahkemeye davacının dava ehliyeti bulunmadığını incelemeyi hatırlatmış olur. Dava ehliyeti olmayan kişinin kendisinin dava açmış olması halinde mahkeme, davayı hemen reddetmez. Mahkemenin, dava ehliyeti olmadığı halde kendisi dava açmış olan davacının yasal temsilcisine, davaya **onay** (icazet) verebilmesi için uygun bir süre vermesi gerekir. Yasal temsilci, kendisine verilen süre içinde davacının yalnız başına açmış olduğu davaya **onay** (icazet) verirse, dava artık reddedilemez; davaya yasal temsilci veya onun tayin edeceği vekil tarafından devam edilir. Yasal temsilci, kendisine verilen süre içinde davaya onay vermezse, o zaman dava, dava şartı olan dava ehliyetinin yokluğu nedeniyle, esasa girilmeden reddedilir.

Dava ehliyeti olmayan kişiye karşı dava açılması halinde, dava dilekçesi, davalının yasal temsilcisine tebliğ edilir; davalının yasal temsilcisi yok ise, önce davalıya bir yasal temsilci atanması yoluna başvurulur.

Dava ehliyeti olmayan davalıya karşı veya davalı tarafından yapılan usul işlemleri geçersizdir. Çünkü, dava ehliyetine sahip olan taraf davayı yürütebilir; davada usul işlemleri yapabilir. Ancak, davalının yasal temsilcisi (veya dava sırasında dava ehliyetini kazanan davalının kendisi) davalıya karşı (veya onun tarafından) yapılmış olan usul işlemlerine onay (icazet) verebilir.

Yasal temsilciler, davanın açılıp yürütülmesinin belli bir makamın iznine bağlı olduğu hallerde (TMK m. 462, 8), izin belgelerini, dava veya cevap dilekçesiyle mahkemeye vermek zorundadırlar; aksi takdirde dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamazlar. Şu kadar ki, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahkeme, yasal temsilcilerin bu eksikliği gidermeleri şartıyla dava açmalarına yahut davayla ilgili işlem yapmalarına izin verebilir. İzin belgesinin alınması için mahkemeye başvurulması gerekiyorsa ilgiliye, bunun için kesin süre verilir. Bu süre içinde mahkemeye başvurulması halinde, bu konuda karar verilinceye kadar beklenir. Süresi içinde belgelerin ibraz edilmemesi veya mahkemeye başvurulmaması halinde, dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır (m. 54).

Temsilci niteliği taşımayan kişi huzurunda davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması yargılamanın iadesi sebebidir (m. 375, 1/c).

III – TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ ve DAVADA TEMSİLİ

Tüzel kişilerin fiil (medenî hakları kullanma) ehliyeti vardır (TMK m. 49). Bu nedenle, tüzel kişiler dava ehliyetine de sahiptir. Tüzel kişiler, davayı **yetkili organları aracılığı** ile takip ederler (m. 52; TMK m. 50). Tüzel kişilerin **organları** davada **yasal temsilci** durumundadır.

Tüzel kişinin organı, yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı Avukatlık Kanunu (AK) m. 35'te düzenlenen bütün işlemleri kendisi yapabilir (takip edebilir); bunun için organ durumundaki gerçek kişinin avukat olması gerekli değildir. Ancak, tüzel kişinin organı olan gerçek kişi, AK m. 35'teki işleri (örneğin bir davayı) takip etmek için başkasını vekil tayin etmek isterse, bu vekilin baroda yazılı avukat olması gerekir.

1) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Dava Ehliyeti ve Temsili

Özel hukuk tüzel kişileri, fiil ehliyetine sahip oldukları için, dava ehliyetine de sahiptirler. Tüzel kişilerin dava ehliyeti, kanuna ve kuruluş belgelerine göre bunun için gerekli organlara sahip olmaları ile başlar (TMK m. 49).

Özel hukuk tüzel kişileri, taraf bulundukları davaları organları aracılığı ile takip ederler (m. 52; TMK m. 50; TTK m. 126). Tüzel kişilerin dava takibine yetkili organları, dış organlardır; yani tüzel kişiyi üçüncü kişilere (dışarıya) karşı temsil eden organlardır; örneğin yönetim kurulu ve müdürler gibi. Bundan başka, müdür yardımcısı (temsilcisi), ticarî temsilci ve ticarî vekilin de tüzel kişinin organı olduğu görüşü de vardır.

Kimlerin organ olduğu (ve bu nedenle tüzel kişiyi dışarıya karşı kimlerin temsil edebileceği) kanuna ve tüzel kişinin kuruluş belgesine (örneğin derneklerde, tüzük; şirketlerde, anasözleşme; vakıflarda, senet vb.) göre belirlenir (TMK m. 49). Kanuna ve kuruluş belgesine göre, organ durumunda olmayan (tüzel kişiyi temsil yetkisi bulunmayan) kişiler, tüzel kişinin taraf olduğu bir davayı takip edemez; tüzel kişiyi temsil etmesi için vekil (avukat) tayin edemez.

2) Kamu Tüzel Kişilerinin Dava Ehliyeti ve Temsili

Kamu tüzel kişileri, fiil ehliyetine sahip olduklarından, bunların dava ehliyeti de (m. 51) vardır. Kamu tüzel kişileri de, taraf bulundukları davaları yetkili organları aracılığı ile takip ederler (m. 52).

Kamu tüzel kişileri adına dava takip edilmesini (kamu tüzel kişilerinin davada temsilini), kamu tüzel kişilerinin çeşitlerine göre ayrı ayrı incelemek gerekir:

Kamu tüzel kişilerinin başında Devletin bulunduğu, bakanlıkların Devletten ayrı bir tüzel kişiliklerinin bulunmadığı; ancak Devletin organı olarak taraf ehliyetine sahip bulundukları yukarıda görüldü[16]. Taraf ehliyeti olan bakanlıkların, aynı zamanda dava ehliyetine de sahip oldukları söylenebilir. Ancak, bunun pratik bir önemi yoktur. Çünkü, bakanlıkların taraf oldukları davalar Devletin avukatları (**hazine avukatları**) tarafından takip edilir.

---

[16] Bkz. § 13, A, III.

Buradaki **Devlet davalarından** kasıt, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan bütün Devlet dairelerine, başka bir deyişle bakanlıklara ve genel bütçe içindeki diğer dairelere ait davalardır.

Yukarıda açıklandığı gibi[17], bakanlıklara bağlı bazı genel müdürlüklerin ayrı tüzel kişiliği vardır. Bu genel müdürlüklerin ayrı bir hukuk müşavirliği örgütü ve buna bağlı avukatları vardır. Bu genel müdürlükler, taraf oldukları davaları kendi avukatları aracılığı ile takip ederler. Bu genel müdürlüklerin veya kamu kurumlarının taraf oldukları davalarda, Hazine avukatlarının temsil yetkisi yoktur. Çünkü, bu genel müdürlüklerin veya kamu kurumlarının ayrı bütçeleri vardır. Hazine avukatlarının adlî yargı alanındaki temsil yetkisi, ancak bakanlıklara ve genel bütçe içindeki diğer dairelere ait davalarla sınırlıdır. Buna göre, ayrı tüzel kişiliği ve bütçesi bulunan genel müdürlüklerin veya kamu kurumlarının taraf bulundukları davalar, Hazine avukatları ile değil, **her genel müdürlüğün** veya kamu kurumlarının **kendi avukatları** aracılığı ile takip edilir.

İl özel idaresi tüzel kişiliğini vali temsil eder. Bu nedenle, il özel idaresinin taraf bulunduğu davalarda özel idareyi vali temsil eder (İl Özel İdaresi K. m. 30/c). İl özel idaresine karşı açılan davalarda dava dilekçesinin valiye tebliğ edilmesi gerekir.

Belediyenin taraf bulunduğu davalarda, belediye tüzel kişiliğini belediye başkanı temsil eder (Belediye K. m. 37). Belediye başkanı, başkasını tevkil edebilir; yani vekil atayabilir. Ancak, atanacak bu vekilin, baroda yazılı avukat olması gerekir (AK m. 35).

Büyükşehir Belediyelerinin taraf olduğu davalarda, belediyeyi Büyükşehir Belediye Başkanı temsil eder. Büyükşehir Belediyesi K. m. 18/h hükmü gereğince, Başkan, vekil (avukat) tayin edebilir.

Köyün taraf bulunduğu davalarda, köy tüzel kişiliğini muhtar temsil eder. Köy halkından bazı kişiler, köy adına dava açamaz; davanın muhtar tarafından açılması gerekir. Fakat muhtar, başkasının açtığı davaya onay (icazet) verebilir. Muhtar mahkemede köyü kendisi temsil edebileceği gibi, yerine (köy halkından) diğer birini vekil olarak gönderebilir. Kanımızca, muhtarın (köy halkından) vekil olarak görevlendirdiği kişinin köy adına dava takip edebilmesi için avukat olmasına gerek yoktur; çünkü bu yetki, kanuna (Köy K. m. 37, 7) dayanmaktadır.

IV – TÜZEL KİŞİNİN DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMASI DAVA ŞARTIDIR

Tüzel kişilerin dava ehliyetine sahip olması da taraflara ilişkin dava şartlarındandır (m. 114, 1/d)[18]. Bu nedenle, mahkemenin, tüzel kişilerin taraf bulunduğu davalarda, tüzel kişinin yetkili organı veya temsilcisi tarafından temsil edilip edilmediğini kendiliğinden gözetmesi gerekir.

---

[17] Bkz. yuk. § 13, A, III.
[18] Bkz. yuk. § 13, B, II.

Gerçek kişinin olduğu gibi, tüzel kişinin de dava ehliyetine sahip olması kamu düzeniyle ilgili olduğundan, mahkeme, bu dava şartının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür.

Tüzel kişinin organları temsil belgelerini, dava veya cevap dilekçesiyle mahkemeye vermek zorundadırlar; aksi takdirde dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamazlar. Şu kadar ki, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahkeme, tüzel kişilerin organlarının, eksikliği gidermeleri şartıyla dava açmalarına ya da davayla ilgili işlem yapmalarına izin verebilir. Süresi içinde belgelerin ibraz edilmemesi halinde, dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır (m. 54).

C) DAVA TAKİP YETKİSİ

Dava takip yetkisi, bir davada talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisidir. Bu yetki, kanunda belirtilen istisnaî durumlar dışında, maddî hukuktaki tasarruf yetkisine göre tayin edilir (m. 53).

Kural olarak, taraf ehliyeti (m. 50) ve dava ehliyeti (m. 51) bulunan kişinin, dava takip yetkisi de vardır; davayı açanın dava takip yetkisine de sahip olması gerekir. Ancak bazı istisnaî durumlarda, davada taraf olarak gösterilen kişinin taraf ve dava ehliyeti mevcut bulunmasına karşın, bu kişini dava takip yetkisi mevcut olmayabilir. Örneğin, hakkında iflâs kararı verilen kişinin (müflisin), iflâs masasına giren mallar üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanır ve müflisin her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüz olur (İİK m. 191). İflâs masasının yasal temsilcisi olan iflâs idaresi (İİK m. 227), tasarruf yetkisini kullanır ve müflisin taraf olduğu takiplerde (İİK m. 193) ve hukuk davalarında (İİK m. 194), istisnaî durumlar hariç, davayı takip yetkisi iflâs idaresine ait olur. Bu nedenle, müflisin bu hukuk davalarında taraf ehliyeti ve dava ehliyeti mevcut olmasına rağmen davayı takip yetkisi bulunmamaktadır. Kanunlarda buna benzer düzenlemeler vardır. Örneğin, İİK m. 94, II; 120; TMK m. 550; TTK m. 555, 556'da düzenlenen konularda davacı dava takip yetkisine sahip kılınmaktadır.

Dava takip yetkisinin bulunması **dava şartları**ndandır (m. 114, 1/e). Bu nedenle, davayı açan (yürüten) tarafın takip yetkisinin bulunup bulunmadığı, yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilir ve mahkemece kendiliğinden gözönüne alınır.

Dava takip yetkisi, bu yetkiye sahip olanın usulî işlemleri yapma ve talep sonucu hakkında hüküm elde etme ehliyeti (yetkisi) anlamına gelir. Bu anlamı ile davada sıfattan farklıdır. Çünkü sıfat maddî hukuka ilişkindir, dava takip yetkisi ise şeklîdir (usule ilişkindir). Bu yetkinin bulunması gereken davalarda, yetkiye sahip olmayanın açtığı dava, dava şartı yokluğundan (usulden) reddedilir.

Dava takip yetkisine sahip kişi, davanın tarafı değildir; o nedenle, dava takip yetkisini taşıyan kişi, davayı yürütüp usul işlemleri yapmasına rağmen, hüküm, davada tarafın leh veya aleyhine verilir ve onun hakkında kesin hüküm gücüne sahip olur (m. 303).

Ayrıca, dava takip yetkisinin, zaman zaman davaya vekâlet ile karıştırıldığı veya öyle anlaşıldığı da görülmektedir. Dava takip yetkisinin, dava tekeline sahip avukatlık mesleğiyle çelişen bir yönü yoktur. Zira dava takip yetkisine sahip kişi, davada yasal temsilci gibi özel bir statüye sahiptir. Dava takip yetkisini taşıyan kişi, davayı bizzat kendisi takip etmek istemezse, baroya kayıtlı bir avukata vekâlet verir.

D) TARAF SIFATI (HUSUMET)[19]

"Sıfat" teriminin uygulamada tam anlamı ile yerleşmiş bir terim olduğunu söylemek zordur. Sıfat terimini (kavramını) Almanca'daki "Sachlegitimation" sözcüğünün karşılığı olarak kullanıyoruz.

Uygulamada sıfat için "**husumet**" terimi kullanılmaktadır. İslâm hukukundan gelen bir terim olan husumet (ve husumet itirazı) terimi, en çok sıfat karşılığı kullanılmaktadır. Fakat, husumet (özellikle husumet ehliyeti) teriminin, **taraf ehliyeti** ve **dava ehliyeti** (ve hatta dava takip yetkisi) terimleri için de kullanıldığı görülmektedir. Böylece, bugün uygulamada kullanılan "husumet" teriminin belirli bir anlamı yoktur. Bu terim ile neyin kast edildiğini anlayabilmek için, her olayın ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, husumet terimi yerine, daha açık olan taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve taraf sıfatı terimlerinin kullanılması doğru olur. Bu ayırım yapılmadığı için, husumet teriminin yalnız **sıfat** karşılığı kullanılması uygun olur. Bu nedenle, burada sıfat için husumet terimi de kullanılacaktır.

Sıfat, dava konusu yapılan, maddî hukuktan doğan (sübjektif) **hak** (dava hakkı) **ile taraflar arasındaki ilişkidir.** Taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve davayı takip yetkisi, davanın taraflarının kişilikleriyle ilgili olduğu halde, taraf sıfatı (husumet) dava konusu sübjektif hakka ilişkindir.

Dava dilekçesinde davacı ve davalı olarak gösterilen kişiler, şeklen o davanın taraflarıdır. Ancak mahkemenin, bu taraflar arasında dava konusu hakkın esası hakkında bir karar verebilmesi için, bu kişilerin o davada gerçekten davacı ve davalı sıfatına sahip olmaları gerekir. Bir davada taraf olarak gösterilen kişiler, taraf ve dava ehliyetine ve davayı takip yetkisine sahip olsalar bile, bu kişilerden birinin o davada gerçekten davacı veya davalı olmak sıfatı yoksa, dava konusu hakkın esasına ilişkin bir karar verilemez. Dava, sıfat yokluğundan (husumetten), esastan reddedilir.

Bir sübjektif hakkı dava etme yetkisi (dava hakkı), kural olarak o hakkın sahibine aittir. Bu nedenle, o hakka ilişkin bir davada davacı olma sıfatı **(aktif husumet ehliyeti)** da o hakkın sahibine aittir. Örneğin, bir alacak davasında davacı olma sıfatı o alacağın alacaklısına aittir. Alacak davası, o alacağın alacaklısından başka bir (üçüncü) kişi tarafından açılırsa, (dava konusu alacağın mevcut olmadığından dolayı değil) davacının davacı sıfatına sahip olmadığından (sıfat yokluğundan, husumetten) dolayı (esastan) reddedilir.

---

[19] Emel Hanağası, Davada "Sıfat" Kavramına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım Denemesi, (MİHDER 2015/32, s. 53-80).

Bir sübjektif hak kendisinden davalı olarak istenebilecek olan kişi (davalı sıfatına, **pasif husumet** ehliyetine sahip kişi), o hakka uymakla yükümlü (borçlu) olan kişidir. Örneğin, bir alacak davasında davalı olma sıfatı o alacağın borçlusuna aittir. Alacak davası, o alacağın borçlusundan başka bir (üçüncü) kişiye karşı açılırsa, (dava konusu alacak mevcut olmadığından dolayı değil) davalının davalı (borçlu) sıfatına sahip olmadığından (sıfat yokluğundan, husumetten) dolayı reddedilir. Yine örneğin, (A), (C)'nin taşınmazını (C)'nin izni ve bilgisi dahilinde (B)'ye kiralar ve (A) ile (B) arasında kira sözleşmesi yapılırsa, (C), (B)'ye karşı kira sözleşmesine dayalı tahliye davası açamaz; çünkü (C), kiralayan sıfatına sahip değildir.

Yukarıdaki açıklamanın gösterdiği gibi, bir sübjektif (maddî hukuktan doğan) hakkın sahibinin ve o hakka uymakla yükümlü olan kişinin kimler olduğu (yani bir davada davacı ve davalı sıfatının kimlere ait olduğu) tamamen **maddî hukuka** göre belirlenir. Bu nedenle, bir kişinin belli bir davada gerçekten davacı veya davalı sıfatına sahip olup olmadığı hususu, usul hukuku sorunu olmayıp, dava konusu (sübjektif) hakkın özüne ilişkin bir maddî hukuk sorunudur.

Sıfatın usul hukuku bakımından önemi (usul hukukunu ilgilendiren yönü) şudur: Bir davanın tarafları (veya taraflardan biri) o davada gerçekten (davacı veya davalı olarak) taraf sıfatına sahip değilse, mahkeme, dava konusu hakkın esası (mevcut olup olmadığı) hakkında inceleme yapıp karar veremez. Mahkeme, davanın sıfat (husumet) yokluğundan reddine karar verir. Bu karar, davanın dinlenemeyeceğine (mesmu) olmadığına ilişkin bir karar olmayıp, gene davanın esasına ilişkin bir karardır; yani taraf olarak gösterilenlerden birinin taraf sıfatının bulunmadığını tespit eden bir karardır.

Kuşkusuz, böyle bir karar, yalnız o davada taraf olarak gösterilmiş olan kişiler arasında kesin hüküm (m. 303) teşkil eder; dava konusu hak ve gerçekten taraf sıfatına sahip (ve fakat o davada taraf olarak gösterilmemiş) olan kişi bakımından kesin hüküm teşkil etmez.

Bir davanın tarafları o davada gerçekten taraf sıfatına sahip ise ve davanın esastan görülmesi koşulları varsa, o zaman, mahkeme dava konusu hakkın esası hakkında inceleme yapar ve karar verir. Mahkemenin bu kararı, dava konusu hak ve davanın (gerçek taraf sıfatına sahip olan) tarafları bakımından kesin hüküm teşkil eder.

Davanın taraflarının taraf sıfatına sahip olmalarının dava şartı olduğu görüşünde olanlar mevcut ise de, biz **sıfatın dava şartı olmadığı** kanısındayız (bkz. m. 114). Çünkü, yukarıda görüldüğü gibi, bir kişinin belli bir davada gerçekten davacı veya davalı sıfatına sahip olup olmadığı hususu, usul hukuku sorunu olmayıp, dava konusu (sübjektif) hakkın özüne ilişkin bir maddî hukuk sorunudur. Bu nedenle, az sonra görüleceği gibi, taraflardan birinin taraf sıfatına sahip olmaması halinde dava usulden (mesmu olmadığından) değil, esastan reddedilir ve bu karar (o davadaki) taraflar arasında maddî anlamda kesin hüküm teşkil eder.

Yargıtaya göre, mahkemenin sıfat (husumet) yokluğunu kendiliğinden gözetmesi gerekir. Bu kararlardan, Yargıtayın sıfatın dava şartı olduğu görü-

şünde bulunduğu sonucuna varılamayacağı kanısındayız. Çünkü, Yargıtay sıfatın (husumetin) mahkemece kendiliğinden gözetileceği esasını benimsemektedir. Bununla Yargıtay, sıfatın, maddî hukuk anlamında bir def'i değil, itiraz olduğunu belirtmek istemiştir, ki doğrudur. Çünkü, sıfat yokluğu, bir **def'i değil**, davada taraf olarak görünen kişiler arasında dava konusu hakkın doğumuna engel olan bir **itiraz**dır. Hâkim, kendisine sunulan dava malzemesinden (davalı veya davacının bildirdikleri vakıalardan, yani dava dosyasından) bir itiraz sebebinin varlığını (yani sıfat yokluğunu) öğrenirse, bunu kendiliğinden gözetir. İşte bu nedenle, hâkim, sıfat yokluğunu kendiliğinden gözetir.

Sıfat yokluğunun dava şartı olması ile itiraz sebebi sayılması arasında şu **esaslı fark vardır**: Sıfat yokluğu dava şartıdır denirse, hâkimin, dava dilekçesinde taraf olarak gösterilmiş olan kişilerin gerçekten taraf sıfatına sahip olup olmadıklarını kendiliğinden gözetmesi, bu konuda taraflarca ileri sürülmeyen vakıaları da araştırıp, incelemesi gerekir. Buna karşılık, sıfat yokluğu "itiraz" sayılırsa hâkim sıfat yokluğunu, ancak tarafların bildirmiş oldukları (dava dosyasındaki) vakıalara göre kendiliğinden gözetir. Dava dosyasından taraflardan birinin taraf sıfatına sahip olmadığı anlaşılamıyorsa, hâkim, o tarafın gerçekten taraf sıfatına sahip olup olmadığı hakkında kendiliğinden araştırma yapamaz; taraf sıfatının varlığını kabul zorundadır.

Sıfat yokluğu, genellikle dava dosyasından anlaşılacağından, hâkim de bunu (gene genellikle) kendiliğinden gözetir. Fakat, sıfat yokluğunun dava dosyasından anlaşılamayacağı haller de vardır. Örneğin;

(A), (B)'den olan alacağını (C)'ye devrettiği (temlik ettiği) halde, (B)'ye karşı alacak davası açmıştır. (A)'nın bu davada taraf (davacı) sıfatı yoktur. Ancak, alacağın devri vakıası dava dosyasından anlaşılamıyorsa [yani (A) bunu bildirmediği gibi, (B) de bu yolda bir savunmada bulunmamış ise], mahkeme, dava konusu alacağın devredilip edilmediği hakkında kendiliğinden bir araştırma yapamaz. Mahkeme, (A) ile (B) arasındaki davanın esasına girerek davayı esastan karara bağlar. Bu karar, (A) ile (B) arasında kesin hüküm teşkil eder (m. 303); (C)'ye karşı ise kesin hüküm teşkil etmez. Çünkü (C), gerçek davacı (alacaklı) sıfatına sahip ise de, (A) ile (B) arasındaki davada taraf değildir.

Yukarıdaki örneğin daha açık bir şekilde gösterdiği gibi, taraf sıfatı, usul hukukuna değil, maddî hukuka ilişkin bir sorundur; diğer bütün maddî hukuk sorunlarında olduğu gibi, dava şartı değildir. Taraf sıfatının (davacı bakımından, aktif husumet ehliyetinin; davalı bakımından, pasif husumet ehliyetinin) yokluğu, davada taraf olarak gözüken kişiler arasında dava konusu hakkın doğumuna engel olduğu için def'i değil bir **itirazdır**. Diğer bütün itiraz hallerinde olduğu gibi, sıfat yokluğu da, ancak dava dosyasından anlaşılabildiği ölçüde hâkim tarafından kendiliğinden gözetilir.

Sıfat yokluğu, bir davada dava şartlarından (m. 114) sonra, yani tahkikat aşamasında incelenir. Sıfat yokluğunun, mümkünse diğer itirazlardan önce incelenmesi gerekir. Çünkü, taraflardan birinin taraf sıfatı yoksa, diğer itiraz ve def'ilerin incelenmesine gerek kalmaz (m. 143).

§ 14. DAVAYA VEKÂLET

A) GİRİŞ

Dava ehliyetine sahip olan tarafın davasını bizzat açabileceğini ve takip edebileceğini veya tayin edeceği vekille dava açıp takip edebileceğini ya da kendisine karşı açılmış davayı bizzat veya tayin edeceği vekille takip edebileceğini yukarıda görmüştük. Davada tarafın temsili, özel hukukta düzenlenen temsilin usul hukukunda büründüğü şeklidir.

Davada tarafların temsili[1] iki şekilde olur: 1) Yasal temsil, 2) İradî temsil.

Yasal (kanunî) **temsil**: Dava ehliyeti olmayanların davada yasal temsilcileri tarafından temsil edileceğini yukarıda inceledik[2]. Yasal temsilin ne zaman söz konusu olacağı, içeriği, nasıl ve ne zaman sona ereceği kanunla belirlenir (m. 54).

İradî temsil: Tarafların (veya yasal temsilcilerinin) iradelerine dayanan temsildir. Dava ehliyeti olan kişi (taraf), davasını kendisi açıp takip edebileceği gibi, atadığı (seçtiği) bir temsilci (vekil) aracılığı ile de açabilir ve takip edebilir (m. 71; AK m. 35, III). Esasen yukarıda görüldüğü gibi, dava ehliyeti (m. 51), kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir temsilci (vekil) aracılığı ile bir davayı (davacı veya davalı olarak) takip etme ve usul işlemlerini yapabilme ehliyetidir.

Yasal temsil, yalnız dava ehliyeti bulunmayanlar için söz konusudur. Buna karşılık, yasal temsilci, temsilcisi olduğu kişinin taraf bulunduğu bir davayı kendisi takip edebileceği gibi, davanın takibi için bir vekil de (avukat da) atayabilir (m. 71). Vekille takip edilen davalarda bile bazı usul işlemleri, bizzat tarafın bulunması ile yapılabilir. Örneğin, tarafın sorguya çekilmesi anlamında olan isticvap (m. 169-175) bu şekilde yapılabilir.

Burada iradî temsili inceleyeceğiz. Kanun buna, **davaya vekâlet** demektedir (m. 71 vd.). Ancak, davaya vekâlet ile TBK'nda düzenlenen vekâlet sözleşmesi (TBK m. 502 vd.) bütünüyle aynı değildir. Başka bir deyişle, vekil ve müvekkili (iş sahibi) arasındaki hukukî ilişki, vekâlet sözleşmesi olabileceği gibi, başka bir ilişki (örneğin hizmet sözleşmesi) de olabilir. Bunun gibi, vekâletname ile vekâlet sözleşmesi aynı şeyler değildir[3].

Davaya vekâlet HMK'nda (m. 71-83'de) düzenlenmiştir. Bu hükümlerde açıklık olmayan hallerde, TBK'nun temsil ve vekâlete ilişkin hükümleri (TBK m. 40 vd. ve m. 502 vd.) davaya vekâlet hakkında da uygulanır (m. 72).

---

1 Bkz. Mine Akkan, Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, Ankara 2010.
2 Bkz. yuk. § 13, B, I.
3 Bkz. yuk. § 4, E; § 14.

B) DAVADA VEKİLLE (AVUKATLA) TEMSİL ZORUNLULUĞU YOKTUR

Bazı ülkelerde (örneğin Almanya'da), taraflar, sulh mahkemeleri dışındaki mahkemelerde davalarını kendileri takip edemezler; bir avukat aracılığı ile takip etmek zorundadırlar.

Türk hukukunda, bir davanın takibi için vekil (avukat) tayin etme (davayı avukat aracılığı ile takip etme) zorunluluğu yoktur[4]. Bu nedenle dava ehliyeti (m. 51) olan herkes, davayı kendisi açabilir ve takip edebilir (m. 71; AK m. 35, III). Bunun gibi, dava ehliyeti olan davalı da, davayı kendisi takip edebilir (kendisini savunabilir; karşı dava açabilir). Davacı veya davalının davayı vekil aracılığı ile takip etmeleri kendi takdirlerine (iradelerine) bırakılmıştır. Yani vekili (avukatı) temsilci olarak görevlendirme, zorunlu değil, isteğe bağlıdır.

Ancak HMK, iki durumda vekille temsil zorunluluğu öngörmektedir. İlk olarak, tarafın davasını takip edecek yeterlilikte olmadığını gören hâkim, o tarafın davasını vekil aracılığı ile takip etmesine karar verebilir. Verilen bu karara uymayan taraf hakkında, yokluğu halindeki hükümlere göre işlem yapılır (m. 80).

Hâkimin tarafı vekille temsile zorlayabileceği ikinci durum ise, davasını bizzat takip eden tarafın, duruşma disiplinini bozması ve hâkimin uyarısına rağmen bu durumun devam etmesi halinde, hâkimin tarafı, duruşma salonundan çıkarması yanında, onun davada vekille temsiline de karar vermesidir (m. 79, 2). Hâkimin bu kararına rağmen, kendisini vekille temsil ettirmeyen taraf, duruşmaya kabul edilmez, yokluğu halindeki hükümler uygulanır; yani dosya işlemden kaldırılabilir (m. 150).

Bu özel durumlar dışında, avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bir tarafın vekil (avukat) tayin etmek istemesi nedeniyle, yargılama başka bir güne bırakılamaz (m. 77, 3). Aynı şekilde avukatın istifa etmesi, azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak dosyanın incelenememiş olması kabul olunabilir bir özre dayanıyorsa, hâkim bir defalık kısa (kesin) bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile, davaya devam olunur (m. 77, 4).

Bu halde, vekil tayini için kendisine bir defalık kesin süre verilen taraf da oturuma gelmezse, tahkikat (veya yargılama) gelmeyen tarafın yokluğunda yapılır (m. 80; 144; 147; 186) veya dosya işlemden kaldırılır (m. 150).

C) DAVADA VEKİL OLABİLECEK KİŞİLER (DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİ)

Yukarıda görüldüğü gibi, Türk hukukunda davada vekille temsil zorunlu değildir; taraflar davalarını kendileri takip edebilirler. Ancak, taraflardan biri, davayı vekil (temsilci) aracılığı ile takip etmek isterse, yalnız belirli kişileri (kural olarak avukatları) vekil tayin edebilirler.

---

[4] HMK Tasarısının ön hazırlıkları sırasında, "avukatla temsil zorunluluğu" ilkesi benimsenmiş idi; ancak, TBMM'ye sunulan HMK Tasarısında, bu zorunluluk kaldırılmış ve HMK avukatla temsil zorunluluğu olmaksızın yasalaşmıştır.

I – EN AZ ÜÇ AVUKAT BULUNAN YERLER

En az üç avukat bulunan yerlerde (il ve ilçelerde), ancak baroda yazılı **avukatlar** vekil olarak dava takip edebilirler[5].

Avukatlık Kanunu'na (AK m. 35, I) göre, en az üç avukat bulunan yerlerde, baroda yazılı avukatlar vekil olarak dava takip etme bakımından bir **tekele sahiptirler**. Baroda yazılı avukat olmayan kişiler, vekil sıfatıyla mahkemeye kabul olunmaz. Baroda yazılı avukat olmadığı halde vekil sıfatıyla dava takip edenler cezalandırılır[6]. Avukatlık yapma yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak avukatlara ait yetkileri kullananlar cezalandırılır[7].

Avukatlık Kanunu ile yasaklanmış olan, avukat olmayan kişilerin vekil olarak dava takip etmeleridir. Buna karşılık, avukat olmayan bir kişiye dava açmak için yetki (vekâlet) verilebilir. Bu kişi, böyle bir yetki (vekâlet) ile vekil sıfatıyla dava açıp takip edemez; ancak, müvekkili adına bir avukata temsil yetkisi (vekâlet) verebilir.

Avukat stajyerleri, avukat yanında staja başladıktan sonra avukatın yazılı muvafakatı (izni) ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, icra mahkemeleri (İİK m. 4) ile sulh hukuk mahkemelerinde ve sulh ceza hâkimliklerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler (AK m. 26, I).

II – ÜÇ AVUKAT BULUNMAYAN YERLER

En az üç avukat bulunmayan yerlerde, avukatlardan başka, ancak o yerin bağlı bulunduğu baroda tutulan özel listeye yazılmış olan **dava takipçileri** vekil olarak dava takip edebilirler (AK geçici m. 17; AK Yönetmeliği m. 74-75). Dava takipçileri ve bunların hangi mahkemelerde görev yapabilecekleri yukarıda incelendi[8].

Bir yerde (ilçede) hiçbir avukat ve dava takipçisi olmasa bile, (az sonra görülecek kadastro işleri dışında) orada dava takibi için herhangi bir kişiye (örneğin yakın hısımlara) vekâlet verilemez. Çünkü, davaya vekâlet üstlenmesine kanunen imkân bulunmayan (avukat veya dava takipçisi olmayan) bu gibi kimseler (vekiller) mahkemeye kabul olunmaz.

Kadastro işlerinde[9], avukat ve dava takipçilerinden başka, davada menfaatleri zıt olmamak şartıyla, karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler (Kadastro K. m. 31, I).

Tüzel kişilerin davada temsili ve özellikle, kamu tüzel kişilerinin vekili olarak, Hazine avukatlarının dava takip etmesi, yukarıda tüzel kişilerin dava ehliyeti ile birlikte incelendi[10].

---

5 Bkz. AK m. 35, I; AK geçici m. 17, I.
6 Bkz. AK m. 63, I-II.
7 Bkz. AK m. 63, III.
8 Bkz. yuk. § 4, E.
9 Bkz. aşa. § 74.
10 Bkz. yuk. § 13, B, III.

D) DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİ OLMAYAN KİŞİLER DAVA TAKİP EDEMEZ

Buraya kadar, kimlerin davada vekil olabileceğini gördük. Bunun dışındaki (kural olarak avukatlardan başka) kişiler, TBK'na göre vekil tayin edilebilir (kendilerine temsil yetkisi verilebilir); ancak vekâletnamelerinde (temsil belgesinde) dava açmak ve takip etmek için açık bir yetki bulunsa bile, bu kişiler vekil sıfatıyla dava açamazlar ve takip edemezler.

Davaya vekâlet üstlenmesine imkân olmayan kişiler, vekil sıfatıyla mahkemeye kabul olunmaz. Örneğin en az üç avukat bulunan yerlerde, avukat olmayan kişiler vekil sıfatıyla mahkemeye kabul edilmez.

Davada vekil olamayacak (davaya vekâlet üstlenmelerine kanunen imkân bulunmayan) bu kişilerin davaya vekâlet ehliyeti yoktur. Davaya vekâlet ehliyeti dava şartıdır (m. 114, 1/f). Bu nedenle mahkemenin, davayı vekil olarak takip eden kişinin davaya vekâlet ehliyetinin bulunup bulunmadığını kendiliğinden gözetmesi gerekir.

Konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir:

Davaya vekâlet ehliyeti olmayan (davaya vekâlet üstlenmesine kanunen imkân bulunmayan) bir kişi (örneğin avukat olmayan bir kişi) vekil sıfatıyla dava açarsa, o kişinin (geçerli bir dava vekâletnamesi bulunsa bile) davaya vekâlet ehliyeti olmadığından mahkeme, davayı esasa girmeden (dava şartı yokluğundan) reddetmekle yükümlüdür. Ancak mahkemenin, davayı reddetmeden önce, davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişi (vekili) tarafından adına dava açılmış olan davacıya, bu davaya onay (icazet) verip vermeyeceğini bildirmesi için uygun bir süre vermesi gerekir (m. 115, 2). Bunun üzerine iki ihtimal ile karşılaşılır:

Davacı, davaya **onay verirse**, davaya devam edilir. Davacı, davaya vekâlet ehliyeti olmayan vekilinin açmış olduğu davaya iki şekilde onay verebilir: Davacı, mahkemeye gelerek davayı kendisi takip eder veya davacı, davaya vekâlet ehliyeti olan bir kişiyi (avukatı) vekil tayin ederek davasını vekil (avukat) ile takip ettirir.

Davacı, davaya vekâlet ehliyeti olmayan vekili tarafından açılmış olan davaya **onay vermezse,** mahkeme, davayı esasa girmeden dava şartı (davaya vekâlet ehliyeti) yokluğundan reddeder. Bu halde, (vekâlet ücreti dahil) yargılama giderlerinin (müvekkile, yani davacıya değil) davaya vekâlet ehliyeti olmadığı halde dava açmış olan vekile yükletilmesi gerekir (m. 77, 2).

Yukarıdaki açıklamalar, davaya vekâlet ehliyeti olmayan (örneğin avukat olmayan) bir kimsenin, vekil sıfatıyla dava açmış olması hali içindir. Buna karşılık, davanın asıl (davacı) veya avukat (davaya vekâlet ehliyeti) olan vekili tarafından açılmasından sonra, yargılama sırasında taraflardan birinin avukat (davaya vekâlet ehliyeti) olmayan bir vekil tarafından temsil edilmesinin yaptırımı (müeyyidesi), davanın reddi değildir.

Bu halde, davaya vekâlet ehliyeti olmayan (davaya vekâlet üstlenmesine kanunen imkân bulunmayan) vekil mahkemeye kabul olunmaz. Mahkemeye

kabul olunmayan böyle bir vekilin müvekkiline, bir defaya özgü olmak üzere, mahkemenin kendiliğinden durumu bildiren davetiye göndermesi uygun olur.

Davaya vekâlet ehliyeti olmayan bir kişinin, davayı vekil sıfatıyla yürütmüş olması ve bu eksikliğin daha önce fark edilmeyerek kararın bu şekilde kesinleşmiş olması, bir yargılamanın iadesi sebebi oluşturur (m. 375, 1/c).

E) VEKÂLETİN VERİLMESİ

Yukarıda belirtildiği gibi, konumuz davada iradî temsildir. Temsilcinin, temsil edilen adına dava takip edebilmesi için, temsil edilenin temsilciye davada vekâlet (temsil yetkisi) vermesi gerekir. Kanun iradî temsile, davaya vekâlet dediği için, temsil yetkisi verilmesine de vekâlet verilmesi denilmesi gerekir.

Temsil yetkisi (vekâlet) veren kişiye (temsil edilen tarafa) **müvekkil**; kendisine temsil yetkisi (vekâlet) verilen kişiye (temsilciye) de **vekil** denir.

Dava ehliyeti olmayan taraf adına, onun yasal temsilcisi tarafından vekâlet (temsil yetkisi) verilir. Dava ehliyeti bulunmayan tarafın kendisinin avukata vekâlet vermesi, halinde, bu avukatın açmış olduğu davaya yasal temsilci onay (icazet) verebilir.

I – VEKÂLETNAME[11]

Davaya vekâlet (temsil yetkisi) verilmesi, tek taraflı bir hukukî işlemdir ve vekâlet verenin (müvekkilin) tek taraflı bir irade beyanı ile olur. Davaya vekâlet verilmesi yalnız başına bir sözleşme (örneğin vekâlet veya hizmet sözleşmesi) değildir. Bu nedenle, vekâlet (temsil yetkisi) içeren belgeye vekâletname (m. 76) değil, belki **temsil belgesi** denilmesi, karışıklığa yer verilmemesi için daha doğru olur. Nitekim, bir içtihadı birleştirme kararında vekâletname yerine "**temsil belgesi**" terimi kullanılmıştır[12].

Ancak, uygulamada alışılmış olduğu için, Kanundaki gibi, "**vekâletname**" terimini kullanacağız. Vekâletname, vekil ile müvekkil arasındaki sözleşme (örneğin vekâlet veya hizmet sözleşmesi) ile aynı şey değildir. Vekâletname verilmesi, müvekkilin tek taraflı bir hukukî işlemi olup, (dışarıya, yani üçüncü kişilere ve mahkemeye karşı) vekilin müvekkilini temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir. Vekil ile müvekkil arasındaki sözleşme (vekâlet veya hizmet sözleşmesi) ise, vekil ile müvekkil arasındaki iç ilişkiyi düzenler (karş. TBK m. 42).

Avukatın onayı alınmadan, adına vekâletname (temsil belgesi) düzenlenebilir (çıkarılabilir). Vekil (avukat) ile müvekkil arasında (vekâletnamenin verilmesini gerektiren) daha önce yapılmış bir sözleşme yoksa, böyle bir vekâletnamenin vekile (avukata) verilmesi icap (iş teklifi) niteliğindedir. Vekilin bu icabı (vekâletnameyi) kabul etmesi ile vekâlet sözleşmesi yapılmış olur (TBK m. 503). Ancak avukat (vekil), vekâletnameyi (iş teklifini) kabul etmek zorunda değildir.

---

11 Bkz. Seyhan Selçuk, Medeni Usul Hukukunda Dava Vekâletnameleri, Ankara 2011.

12 Bkz. 04.02.1959 gün ve 14/06 sayılı İBK (RG 29.04.1959, sa. 10194).

Genel vekâletname, vekile dava açma veya müvekkiline karşı açılmış olan davada savunmada bulunma (kısaca, dava takip etme) yetkisini vermez. Vekilin (müvekkili adına) dava açabilmesi veya mahkemede savunmada bulunabilmesi (dava takip edebilmesi) için, ya genel vekâletnamede özel bir dava takip etme yetkisi bulunmalı veya vekile ayrı bir dava vekâletnamesi verilmelidir (TBK m. 504).

Dava vekâletnamesi de, özel veya genel verilebilir:

Özel dava vekâletnamesi: Yalnız belli bir (veya birkaç) davanın takibi için verilen vekâletnamedir. Vekil, özel dava vekâletnamesi ile müvekkilini (vekâletnamede belirtilenden) başka davalarda temsil edemez.

Genel dava vekâletnamesi: Müvekkilin açmış olduğu ve açacağı ve müvekkile karşı açılmış ve açılacak bütün davaları takip etmek için verilen vekâletnamedir (karş. AK m. 171, II). Vekil, genel dava vekâletnamesi ile, müvekkilini başka davalarda da temsil edebilir. Vekil, genel dava vekâletnamesi ile, müvekkilini davada temsil edebilirse de, müvekkili ile kendi arasındaki iç ilişki bakımından bu konuda (müvekkilini davada temsil etmesi için) müvekkilinden özel bir talimat almış olması gerekir. Vekil, genel dava vekâletnamesi ile, müvekkiline karşı açılan başka bir davada müvekkilini temsil edebilirse de, diğer (davacı) tarafça buna zorlanamaz. Yani, dava dilekçesi davalının genel vekiline tebliğ edilemez. Genel dava vekâletnamesinin, TBK m. 504, III'teki özel yetki gerektiren işlemler dışında bütün işlemleri müvekkil adına yapma yetkisini veren genel vekâletnameden farklı olduğunu da belirtmek gerekir.

Avukatlık ortaklığında vekâletname ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık, iş veya davayı yürütecek avukatlara **yetki belgesi** verir (AK m. 44/B, 2).

II – VEKÂLETNAMENİN ŞEKLİ

Kanun, vekâletnameyi onaylayacak veya düzenleyecek organı belirtmektedir; yani vekâletname için belli şekil öngörmüştür. Bu şeklin, bir geçerlilik şartı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır (m. 76). Buna göre:

Noterin onayladığı veya düzenlediği **vekâletnameler:** bütün mahkemelerdeki davalar için geçerlidir. Vekâletnamenin (temsil belgesinin) noter tarafından onaylanmış olması yeterlidir (m. 76; NK m. 90-92). Fakat, vekâletnamenin noterlikçe düzenleme biçiminde yapılması (resen düzenlenmesi) da mümkündür (NK m. 84 vd.).

Boşanma davaları için düzenlenecek vekâletnamelere, vekâlet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur (NK Yönetmeliği m. 93/k).

Kadastro işlerinde, (noterlerden başka), sulh hâkimi veya kadastro hâkimi tarafından onaylanmış vekâletnameler de geçerlidir (Kadastro K. m. 31, I).

Hazarda ve seferde silah altına çağrılan muvazzaf veya ihtiyat **eratın** kıtaya katıldıktan sonra verecekleri vekâletnameler, adlî hâkimler, bölük komutanları veya bulundukları müessese âmirleri tarafından düzenlenir ve onaylanır. Bu vekâletnameler hiçbir harca ve resme tâbi değildir. Bu vekâletnamelerin hükümleri, eratın terhisinden iki ay sonrasına kadar devam eder (Askerlik K. m. 61).

Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak temsil belgeleri (vekâletname) verilir; bunların geçerliği için ayrıca onaya gerek yoktur (m. 76, 2).

Yabancı ülkelerdeki Türk konsolosluğu tarafından onaylı vekâletnameler noter tarafından onaylı vekâletnameler gibi geçerlidir (NK m. 191).

Bir yabancı devlet makamı tarafından onaylanan vekâletnamenin, devletin yetkili makamı tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunduğunun, oradaki Türk konsolosu tarafından onaylanması gerekir (NK m. 195)[13].

F) VEKÂLETNAMENİN MAHKEMEYE VERİLMESİ

I – VEKİL, VEKÂLETNAMEYİ MAHKEMEYE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

Vekil, vekâletnamenin aslını veya kendisi tarafından onaylanmış örneğini, dava dosyasına konulmak üzere, mahkemeye vermekle yükümlüdür (m. 76, 1; 77, 1).

Vekâletname aslının veya onanmış örneğinin **her dosya için ayrı ayrı** verilmesi zorunludur[14].

Avukatların, iş sahibinin (müvekkilin) kendilerine verdikleri vekâletnamelerin örneklerini çıkarıp, bu örneklerin aslına uygunluğunu imzaları ile onaylayarak kullanabilecekleri yukarıda görüldü[15]. İşte avukat (vekil) kendi onayladığı vekâletname örneğini, dava dosyasına konulmak üzere, mahkemeye verebilir.

Dava vekil aracılığı ile açılırsa, vekâletnamenin dava dilekçesi ile birlikte (dilekçeye ekli olarak) mahkemeye verilmesi gerekir. Vekil, açılmış bir davaya vekil sıfatıyla katılırsa, vekil sıfatıyla katıldığı ilk celsede (duruşmada) vekâletnamesini mahkemeye vermekle yükümlüdür (m. 77, 1).

Vekil aracılığı ile takip edilen davalarda, **geçerli bir vekâletname** bulunması ve bunun mahkemeye verilmesi **dava şartı**dır (m. 114, 1/f). Bu nedenle mahkeme, vekilin vekâletnamesinin (temsil yetkisinin) bulunup bulunmadığını kendiliğinden araştırır ve vekilden vekâletnamesinin aslını isteyebilir. Taraflardan her biri de, diğer taraf vekilinin vekâletnamesinin mevcut olmadığı veya usulüne uygun bulunmadığı hakkında (her zaman) itirazda bulunabilir.

---

13 Bu kurala, "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" ile istisna getirilmiştir (bkz. RG 16.09.1984, sa.18517; bu sözleşmeyi onaylayan 3028 s. K. RG 29.06.1984, sa.18446). Buna göre, yabancı ülke noterinin düzenlediği vekâletnameye, noterin bulunduğu yerin en yüksek mülkî âmiri "**apostil**" şerhi verir.

14 "Vekâletname aslının veya onanmış örneğinin her dosya için ayrı ayrı verilmesi zorunludur" şeklindeki eski HUMK m. 67, IV hükmü, söz konusu hükmün (uygulamanın) işin doğası gereği yapılması zarureti bulunduğu gerekçesiyle, HMK m. 77'ye alınmamıştır (HMK m. 77 ile ilgili Hükümet gerekçesi). Dolayısıyla, bugün için de vekâletnamenin her dosya için ayrı ayrı verilmesi kuralı devam etmektedir.

15 Bkz. yuk. § 4, E, V.

II – VEKÂLETNAMENİN MAHKEMEYE VERİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Az önce görüldüğü gibi, taraflardan birinin vekili olarak taraf adına dava açan veya açılmış bir davayı takip etmek isteyen vekilin, vekâletnamesinin aslını veya onanmış örneğini mahkemeye vermesi gerekir. Vekil sıfatıyla hareket eden kişinin vekâletnamesini veya örneğini mahkemeye vermemesinin sonuçları Kanunda (m. 77) düzenlenmiştir.

Bu düzenleme konuyu ikiye ayırmaktadır:

1) Açılmış Bir Davayı Vekil Sıfatıyla Takip Etmek İsteyen Kişinin Vekâletnamesini Vermemesi

Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek isteyen kişi, vekâletnamesinin var (yapılmış) olduğunu bildirse bile, vekâletnamesinin aslını veya onanmış örneğini mahkemeye vermeden, **yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz** (m. 77, 1/c.1). Böyle bir kişi, vekil sıfatıyla oturuma (duruşmaya) da kabul olunmaz.

Aşağıda incelenecek istisna (m. 77, 1/c.2) dışında, mahkeme, vekile vekâletnamesini vermesi için bir süre veremez ve bunun için oturumu (duruşmayı) başka bir güne erteleyemez. Mahkeme, m. 77, 1/c. 2 hükmünün uygulanmasına gerek görmez (ve vekil olduğunu bildiren kişinin müvekkili olan taraf da oturumda hazır değil) ise, karşı tarafın talebiyle, o tarafın yokluğunda tahkikata veya yargılamaya devam eder (m. 186) veya dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150).

İstisna olarak mahkeme, **gecikmesinde zarar doğabilecek hal**lerde (örneğin davalının cevap süresini kaçırması ihtimali varsa), vereceği kesin bir süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermek koşuluyla, vekilin usul işlemleri yapmasına (örneğin davalı adına cevap dilekçesi vermesine) izin verebilir (m. 77, 1/c. 2). Vekil, kendisine verilen bu kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye verir ise, vekil tarafından yapılmış olan işlemler geçerli olur ve artık o vekil hazır olduğu halde (o vekilin katılımı ile) yargılamaya devam edilir.

Vekil, kendisine verilen bu kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermez ve fakat asıl (müvekkil) aynı süre içinde yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirirse, vekâletnamesiz vekil tarafından yapılmış olan işlemler yine geçerli olur (m. 77, 1).

Vekil, kendisine verilen kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermezse ve aynı süre içinde asıl (müvekkil) de yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmezse, vekâletnamesiz vekil tarafından yapılmış olan işlemler hükümsüz kalır (m. 77, 1/c.3); örneğin vekâletnamesiz vekilin yapmış olduğu zamanaşımı def'i dikkate alınmaz (yapılmamış sayılır).

Bundan başka, kendisine verilen kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermemiş olan vekil, oturum harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir (m. 77, 2/c. 1).

Kendisine verilen kesin süre içinde vekâletnameyi kötüniyetle mahkemeye vermeyen vekil aleyhine ceza takibi yapılmak ve disiplin cezası uygulanmak üzere, mahkemece, Cumhuriyet savcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro başkanlığına yazı gönderilir (m. 77, 2/c. 2).

Vekil, kendisine verilen kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermez ve asıl da, kendisine bu konuda yapılan tebligata rağmen, aynı süre içinde yapılan işlemleri kabul ettiğini mahkemeye bildirmez ve kesin süreyi izleyen oturuma da gelmezse, diğer tarafın talebi üzerine, mahkeme, tahkikata veya yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam eder (m. 186) veya dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150).

2) Vekâletnamesiz Dava Açılması

Yukarıda da görüldüğü gibi, vekâletnamenin aslını veya onaylanmış örneğini mahkemeye vermeyen vekil, **dava açamaz** (m. 77, 1/c. 1). Mahkeme, vekâletnamesiz dava açan vekilin imzasını taşıyan dava dilekçesini reddetmek (kabul etmemek) zorundadır.

İstisnaî olarak, mahkeme, **gecikmesinde zarar doğabilecek hallerde**, vereceği kesin bir süre içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla **vekilin** (vekâletnamesiz) dava açmasına izin verebilir (m. 77, 1/c. 2). Örneğin, hak düşürücü sürenin korunması veya zamanaşımının kesilmesi için müvekkil vekiline telefonla veya benzeri iletişim araçları ile dava açmasını bildirmiş olabilir. Bu hallerde, vekil, dava açmak için vekâletnamenin gelmesini beklerse, hak düşürücü sürenin veya zamanaşımı süresinin geçmesi tehlikesi olabilir. İşte bu gibi acele (gecikmesinde zarar doğabilecek) hallerde, mahkeme, vereceği kesin bir süre içinde vekâletnamesini getirmek şartıyla, vekilin dava açmasına izin verebilir.

Vekil, kendisine süre verilmesini beklemeden kendiliğinden veya kendisine verilen bu kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye verirse, dava, vekâletnamesiz açıldığı tarihte geçerli olarak açılmış sayılır.

Vekil, kendisine verilen bu kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermez ve fakat asıl (müvekkil), aynı süre içinde yapılan işlemi (kendisi adına dava açılmış olmasını) kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirirse, vekâletnamesiz vekil tarafından açılmış olan dava, vekâletnamesiz açıldığı tarihte geçerli olarak açılmış sayılır (m. 77, 1/c. 3). Yani davacı, vekâletnamesiz açılan davaya onay (icazet) vermiş olur.

Vekil, kendisine verilen kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye sunmazsa ve aynı süre içinde asıl (müvekkil) da, bu konuda yapılan tebligata rağmen, kendisi adına dava açılmış olmasını kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmezse, vekâletnamesiz vekil tarafından açılmış olan dava açılmamış sayılır (m. 77, 1/c. 3).

Bundan başka, kendisine verilen kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermemiş olan vekil, oturum harcı ile diğer yargılama giderlerini ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir (m. 77, 2/c.1). Bu halde, yargılama giderleri özellikle davalı yararına hükmedilecek vekâlet ücreti

davacıya değil, vekâletnamesiz dava açan kişiye (vekile) yükletilir. Yukarıda belirtilen m. 77, 2 hükmü burada da uygulanır.

Davacı vekilinin vekâletnamesinin dava dilekçesine ekli olmadığı fark edilmeden dava dilekçesi mahkemece kabul edilmiş (dava açılmış) ise, bunun fark edilmesi üzerine, mahkemenin, başkaca bir işlem yapmadan, vekâletnamesi olmayan vekile vekâletnamesini mahkemeye vermesi için kesin bir süre vermesi gerekir. Bu süre içinde vekâletname verilmez ve aynı süre içinde asıl, kendisi adına dava açılmış olmasını kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmezse, vekâletnamesiz açılmış olan dava açılmamış sayılır. Yani bu halde, m. 77, 1-2 hükümleri (yukarıdaki açıklamalar) kıyasen uygulanmalıdır.

G) DAVAYA VEKÂLETİN KAPSAMI

Davaya vekâletin kapsamı, vekilin hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir. Davaya vekâletin (dava vekâletnamesinin) bir kanunî kapsamı vardır; yani vekil normal (özel veya genel) bir dava vekâletnamesi ile (bu vekâletnamede ayrıca sayılmış olmasa bile) kanunda belirtilmiş olan (normal) işlemleri yapabilir (m. 73). Vekilin, kanundan dolayı yetkili olduğu bu işlemler dışında bir başka işlem yapabilmesi (örneğin sulh olabilmesi) için, vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetkinin (örnekte sulh yetkisinin) bulunması gerekir (m. 74). Buna göre, davaya vekâletin kapsamını ikiye ayırarak incelemek gerekir:

I – DAVAYA VEKÂLETİN KANUNÎ KAPSAMI (VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİRMEYEN İŞLEMLER)

Özel veya genel dava vekâletnamesinde açıkça sayılmış olmasa bile, vekil, böyle bir vekâletname ile (kanundan dolayı) HMK m. 73'teki işlemleri yapabilir. Vekilin m. 73'te belirtilen işlemleri yapabilmesi veya vekile karşı bu işlemlerin yapılabilmesi için, dava vekâletnamesinde bu hususta özel bir yetkinin bulunmasına (m. 73'te belirtilen işlemlerin dava vekâletnamesinde yazılı olmasına) gerek yoktur. Buna davaya vekâletin kanunî kapsamı denir. Buna göre, dava vekâletnamesinde açıkça yazılı olmasa bile, vekil, böyle bir vekâletname ile (kanundan dolayı) aşağıdaki işlemleri yapabilir (m. 73; karş. TBK m. 504, III):

Vekil, **hüküm kesinleşinceye kadar** davanın takibi için gerekli bütün işlemleri yapabilir; örnekler:

Vekil dava ve (karşı dava) açabilir. Vekilin davaya müdahale edebilmesi (m. 66 vd.) için vekâletnamesinde özel bir **davaya müdahale** yetkisi bulunmasına gerek yoktur. Vekil, dava ile ilgili her türlü iddia ve savunmada bulunabilir; dilekçe verebilir; ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delil tespiti isteyebilir; duruşmalarda bulunabilir; delil gösterebilir; hüküm konusunu tahsil edebilir (karş. HUMK m. 63 -ahzükabz-) vs. Bundan başka, vekilin davanın takibinden vazgeçebilmesi (m. 123), davayı kısmen ıslah edebilmesi, belli bir vakıayı ikrar edebilmesi için vekâletnamesinde bu konularda açık yetki bulunma-

sına gerek yoktur. Vekâletnamesinde kanun yolu (istinaf, temyiz) için özel bir yetki olmasa bile, vekil, hükmü (kararı) kanun yoluna götürebilir; üst mahkemelerdeki duruşmalarda hazır bulunabilir.

Kanun (m. 73) "davanın takibi için gereken bütün işlemler" demek suretiyle, usul işlemleri ile maddî hukuk işlemleri arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bu nedenle, dava vekâletnamesi, vekile özel yetki verilmesi gereken haller dışında, davanın takibi için gerekli olan (davada yapılacak) maddî hukuk işlemlerini de kapsar. Buna göre vekil, davada (dava konusu hak ile ilgili olarak) takas, sözleşmenin feshi, feshi ihbar, sözleşmeden dönme gibi beyanlarda bulunabilir; bu beyanlar vekile karşı da yapılabilir.

Vekil, vekâletnamesinde hükmün icrası için özel bir yetki yazılı olmasa bile, hükmü (ilâmı) icraya koyabilir (m. 73; İİK m. 24 vd.).

Diğer taraf da, yukarıdaki işlemleri vekile karşı yapabilir (m. 73, 1). Bu nedenle, bir davayı takip etmiş olan vekilin yetkisi bu davada verilen hükmün icrasını da kapsadığından, bu hükmün (ilâmın) icrasında (İİK m. 24 vd.), icra emri borçlunun (davalının) davayı takip etmiş olan **vekiline tebliğ edilir;** davayı takip etmiş olan vekil, usulüne uygun istifa veya azil bulunmadıkça, tebellüğden kaçınamaz.

Buraya kadar incelemiş olduğumuz davaya vekâletin kanunî kapsamını (m. 73, 1) daraltan (sınırlayan) bütün kayıtlar, diğer (karşı) taraf için geçerli değildir (m. 73, 2). Fakat, böyle bir sınırlama, vekil ile müvekkil arasındaki iç ilişki bakımından geçerlidir.

II – VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER

Vekilin bazı işlemleri yapabilmesi için, kendisine verilmiş olan dava vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetkinin bulunması gerekir. Vekile özel yetki verilmesini gerektiren işlemlerin önemli bir kısmı m. 74'te sayılmıştır. Bunun dışında, bazı özel kanun hükümlerinde vekile özel yetki verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre, vekile özel yetki verilmesini gerektiren (yani vekilin vekâletnamesinde ancak özel yetki bulunması halinde yapabileceği) işlemlere şu örnekler verilebilir[16]:

Sulh (m. 313-315) olmak (m. 74; TBK m. 504, III); **tahkim** ve hakem sözleşmesi (m. 407 vd.) yapmak (m. 74; TBK m. 504, III); karşı tarafı **ibra** etmek (m. 74); davadan ve kanun yollarından **feragat** (m. 307) etmek (m. 74); davayı **kabul** (m. 308) etmek (m. 74); **yemini teklif, kabul, iade** veya **yemini reddetmek** (m. 74, 228-230)[17]; **müvekkilinin iflâsını** istemek (m. 74); **haczi** (İİK m. 78 vd.) **kaldırmak** (m. 74); **hâkimi reddetmek** (m. 74;

---

16 HUMK m. 63'te ve ona paralel olarak HMK Tasarısı m. 79'da yer alan "Hükmolunan şeyi alma (**ahzukabz**) yetkisi", TBMM Adalet Komisyonunda "avukatların hükmün icrası esnasında karşılaştığı problemler de dikkate alınarak madde metninden çıkartılmıştır". Bu sebeple, vekâletnamede "ahzukabz" yetkisi olduğu belirtilmese dahi, vekilin ahzu kabz (alma) yetkisi, kanundan dolayı vardır.

17 Burada avukata yetki verilecek husus, avukatın karşı tarafa, müvekkili adına, yemin teklif edebilmesi, teklif edilen yemini kabul veya iade edebilmesi bakımındandır. Zira, yemin, her durumda ve mutlaka tarafça eda edilir (m. 232). Yemin davetiyesi bizzat tarafa gönderilir.

36 vd.); başkasını **tevkil** edebilmek, yani müvekkili için başka bir vekil tayin edebilmek (TBK m. 506, III; AK m. 171; HMK m. 74); **hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası** (m. 46 vd.) **açabilmek** (m. 74); **yargılamanın iadesi** (m. 74; 374 vd.) talebinde bulunabilmek; davanın tamamında **ıslah** (m. 74; 180) yapabilmek. Vekilin müvekkili adına **mirası reddedebilmesi** (TMK m. 609) için, vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetki bulunması gerekir (VVM Tüz. m. 39). Vekilin, müvekkili adına **konkordato** teklif edebilmesi (İİK m. 285) için vekâletnamesinde konkordato veya sulh için özel bir yetki bulunması gerekir (m. 74). Vekilin sermaye şirketleri ve kooperatiflerin **uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifi**nde bulunabilmesi için özel yetkisinin bulunması gerekir (m. 74). Vekilin **alternatif uyuşmazlık çözümü** yollarına başvurabilmesi özel yetkisin bulunması gerekir (m. 74)[18]. Vekil, hangileri hakkında yetki verildiğini açıklamadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları (örneğin boşanma davası) açamaz (m. 74). **İkrar** (m. 188) için, kural olarak özel bir yetkiye gerek yoktur. Ancak, vekilin ikrarının karşı tarafın ileri sürdüğü bütün vakıaları kapsaması halinde, bunun sonucu davayı kabul anlamına geleceğinden, vekilin vekâletnamesinde ikrar veya kabul için özel bir yetki bulunması gerekir.

H) DAVANIN BİRDEN FAZLA VEKİL İLE TAKİBİ

Müvekkil, bir davanın takibi için birden fazla vekil (avukat) görevlendirmiş olabilir (m. 75). Müvekkil, davanın başında birden fazla avukata vekâlet vermiş ise, bu vekillerden (avukatlardan) her biri davayı yalnız başına takip edebilir. Yani, vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir.

Buna karşılık, başlangıçta davayı yalnız bir avukata vermiş olan müvekkilin, o davada başka bir avukata da vekâlet verebilmesi için, vekili olan (ilk) avukatın yazılı muvafakatini alması gerekir. Muvafakat verilmezse, ilk avukatın vekâleti kendiliğinden sona erer. Müvekkil, ikinci avukata vekâlet verilmesine muvafakat etmeyen birinci avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür (AK m. 172).

Gerek başlangıçta gerek (ilk avukatın muvafakatı ile) sonradan bir davanın takibi için birden fazla avukata vekâlet verilmiş ise, bu vekillerden her biri, davayı yalnız başına takip edebilir (m. 75).

Mahkeme ve diğer taraf, davaya ilişkin bütün usul işlemlerini vekillerden yalnız birine karşı yapabilirler. Bunun gibi, bir tarafın birden fazla vekili varsa, tebligat bunlardan yalnız birine yapılır; diğer vekillere tebligat yapılsa bile, süreler ilk vekile yapılan tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar (Teb. K. m. 11, I).

---

[18] Bkz. 6235 s. K. m. 13.

J) DAVAYA VEKÂLETİN SONA ERMESİ

Vekil (avukat), üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile, sonuna kadar takip eder (AK m. 171, I). Başka bir deyişle, davaya vekâlet, (özellikle, özel dava vekâletnamesinde) davanın sonuçlanması (yani hükmün kesinleşmesi) ve hükmün icra edilmesi ile son bulur. Bu, davaya vekâletin normal sona erişidir.

Bundan başka davaya vekâlet, bazı nedenlerle, dava devam ederken de sona erebilir. İşte burada, dava devam ederken davaya vekâletin sona ermesi hallerini ve bunun görülmekte olan davaya etkilerini inceleyeceğiz:

I – VEKİLİN İSTİFASI

Vekilin, vekâletten istifa etmesi (çekilmesi) ile, davadaki vekâlet (vekillik) görevi son bulur; vekilin istifası ile vekâlet görevi sona erer (AK m. 41; HMK m. 81, 82; TBK m. 42 ve 512).

Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın, o işe ait vekâlet görevi, durumun müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta **süre** ile devam eder (m. 82, 1; karş. AK m. 41, I). Bu hüküm, vekil (avukat) ile müvekkili arasındaki iç ilişkiyi düzenlemektedir.

Bir tarafın istifa etmiş olan vekili ile mahkeme ve karşı taraf arasındaki dış ilişkiyi ise, HMK m. 77, 4 ve m. 81 düzenlemektedir; buna göre:

Vekilin (vekâletten) istifa etmesi sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz (m. 77, 4/c.1). Bu hükme göre:

Vekil, duruşmada vekillikten istifa ettiğini bildirirse, mahkeme oturumu (duruşmayı) başka bir güne bırakamayacak, aksine, istifa eden vekilin huzuru ile yargılama devam edecektir. Mahkeme, istifa eden vekilin müvekkilini ancak bundan sonraki duruşmaya çağıracaktır. Bu çağrıda (tebligatta), müvekkile, vekilinin istifa ettiği, bu nedenle duruşmaya çağrıldığının açıkça bildirilmesi gerekir.

Vekil, duruşmadan önce vekâletten istifa ettiğini mahkemeye yazılı olarak bildirirse, mahkeme, bu istifa nedeniyle yargılamayı başka bir güne bırakamaz (m. 77, 4/c.1). İstifa eden vekilin ya kendisinin veya müvekkilinin duruşmaya gelmesi gerekir. Her ikisi de duruşmaya (oturuma) gelmezse, mahkeme, karşı tarafın talebi üzerine tahkikata gelmeyen tarafın yokluğunda devam eder (m. 186) veya dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir; yoksa duruşmayı (yargılamayı) başka bir güne bırakmakla yetinemez. Sözlü yargılama ve hüküm için belirlenen gün ve saatte hazır bulunmaları için iki tarafa gönderilen davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir ve mahkeme buna göre hareket eder (m. 186, 1).

Bir tarafın vekilinin istifa ettiği (dilekçeyle veya tutanağa geçirtilerek) mahkemeye ve karşı tarafa (hasma) tebligat gideri peşin yatırılarak bildirilmedikçe, karşı taraf (ve mahkeme) hakkında hüküm ifade etmez; yani sonuç doğurmaz (m. 81). Buna göre:

Bir tarafın vekili istifa etmiş ve bunu müvekkiline tebliğ etmiş (ve hatta bu tebliğden itibaren m. 82, 1'deki iki haftalık süre geçmiş) olsa bile, istifa, yukarıdaki (m. 81'deki) şekilde mahkemeye ulaşıp karşı tarafa bildirilmedikçe, karşı taraf ve mahkeme için hüküm ifade etmez. Vekilin istifası mahkemeye ulaşıncaya ve karşı tarafa bildirilinceye kadar mahkeme ve taraf, istifa etmiş olan vekile karşı usul işlemlerini yapmaya devam ederler. Örneğin, aslında istifa etmiş olan vekil duruşmaya kabul edilir; bu vekile tebligat yapılır ve bu tebligat ile süreler işlemeye başlar.

Bunun gibi hüküm, istifa etmiş ve fakat istifası m. 81'e göre mahkemeye ve karşı tarafa bildirilmemiş olan vekile tebliğ edilirse, hükme karşı kanun yoluna başvurma süresi (vekil istifasını müvekkiline bildirmiş ve bundan itibaren iki hafta geçmiş olsa bile) hükmün vekile tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. Çünkü, vekilin istifası m. 81'e göre mahkemeye ve karşı tarafa bildirilmediği için, mahkeme ve karşı taraf hakkında hüküm ifade etmez; yani vekil mahkeme ve karşı taraf bakımından istifa etmiş değildir (m. 81).

II – VEKİLİN AZLİ VE DİĞER SONA ERME HALLERİ

Vekilin müvekkil tarafından azledilmesi (vekillikten çıkarılması) ile, davadaki vekâlet (vekillik) görevi son bulur.

Bir tarafın vekilini azletmesi sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz (m. 77, 4/c.1). Bu hükme göre:

Vekilini azletmiş olan taraf (müvekkil), ondan sonraki duruşma (oturum) gününü öğrenip, o gün duruşmaya gelmek zorundadır. Yoksa mahkeme, tarafın vekilini azletmesi sebebiyle yargılamayı başka bir güne bırakamaz (m. 77, 4/c.1); yani, tarafa tebligat yaparak onu yeni bir duruşmaya çağıramaz.

Vekilin azledildiğinin mahkemeye bildirilmesinden sonra, azledilen vekil duruşmaya alınmaz. Vekili azleden (vekâlet veren müvekkil) davayı takip etmez ve iki hafta içinde bir başka vekil de görevlendirmez ise, tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır (m. 83).

Bir tarafın vekilini azlettiği mahkemeye ve karşı tarafa bildirilmedikçe, azil mahkeme ve karşı taraf hakkında hüküm ifade etmez; yani hukukî sonuç doğurmaz (m. 81).

Başka bir deyişle, bir taraf vekilini azletmiş ve bunu vekiline bildirmiş olsa bile, vekilin azledildiği yukarıdaki şekilde mahkemeye bildirilmedikçe, mahkeme ve karşı taraf için hüküm ifade etmez. Mahkeme ve karşı taraf usul işlemlerini (azledilmiş olan) vekile karşı yapmaya devam ederler; örneğin vekil duruşmaya kabul edilir, tebligat vekile yapılır ve süreler bu tebligat ile işlemeye başlar.

Vekilin (avukatın) **ölümü** (TBK m. 43, I; 513, I), meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması veya geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde de vekâlet görevi son bulur.

Müvekkilin ölümü ile de vekâlet son bulur (TBK m. 43, I; 513, I). Ancak, vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek

duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür (TBK m.513, II). Müvekkilin sağlığında düzenlediği vekâletname ile yetkili kıldığı vekil (avukat), müvekkilinin ölümünden sonra dava açamaz. Müvekkilinin (vekili tarafından) dava açıldıktan sonra, ölmesi halinde de, ölüm ile vekâlet son bulur. Bu halde, mahkemenin, ölen müvekkilin mirasçılarını mirasçılık belgesi ile tespit ettirerek, mirasçıları duruşmaya davet etmesi gerekir.

Vekilin veya müvekkilin iflâsı ile, vekâlet (kural olarak) son bulur (TBK m. 43; 513; AK m. 5/f).

Vekilin veya müvekkilin medenî hakları kullanma (fiil) ehliyetini kaybetmesi ile de vekâlet son bulur (TBK m. 43, I; 513).

K) VEKİL İLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA MÜVEKKİLİN DURUMU

Vekil ile takip edilen davalarda, müvekkil, vekil tarafından temsil edilir. Kural olarak, bütün usul işlemleri vekil tarafından yapılır (AK m. 171).

Yalnız, **müvekkilin şahsına sıkı sıkıya bağlı olan işlemler**, vekil tarafından yapılamaz; sadece müvekkil tarafından yapılabilir; örnekler:

Yemin tarafa teklif edilir ve tarafça eda olunur (m. 228; 232); vekil, müvekkili adına yemin edemez.

İsticvap için müvekkilin mahkemeye gelmesi ve müvekkilin (tarafın) kendisinin isticvap edilmesi gerekir (m. 172). Vekil, isticvap edilecek müvekkilinin yanında bulunabilir (m. 173).

Bundan başka, vekâletnamesinde özel yetkisi olmayan vekil, **özel yetki verilmesini gerektiren işlemleri** (m. 74) de yapamaz. Örneğin, vekâletnamesinde özel yetkisi olmayan vekil, davadan feragat edemez; sulh olamaz; davayı kabul edemez vs.

Vekil tarafından yapılan işlemler, vekil değil müvekkil hakkında sonuç doğurur. Örneğin hüküm müvekkil hakkında verilir, verilen hüküm müvekkil bakımından kesin hüküm (m. 303) teşkil eder; hüküm müvekkile karşı icra edilir; yargılama giderlerinin alacaklı veya borçlusu müvekkildir vs. (karş. AK m. 164, V).

Karşı (diğer) taraf ve mahkeme, davaya ilişkin bütün usul işlemlerini vekile karşı yaparlar. Bu nedenle, vekilin mazereti eski hale getirme (m. 95) sebebi sayılmıştır. Tebligat müvekkile değil mutlaka vekile yapılır (Teb. K. m. 11, I).

Müvekkil, vekili ile birlikte duruşmada (oturumda) hazır bulunmak zorunda değildir; ancak isterse hazır bulunabilir. Bu durumda, vekilin duruşmada yaptığı beyanlar (örneğin, vekilin bir vakıayı ikrar etmesi, davadan feragat etmesi, davayı kabul etmesi gibi.) hazır olan müvekkil tarafından derhal tekzip edilmez (yalanlanmaz) ise (yani müvekkil bu beyanlara, örneklerde ikrara, feragata veya kabule derhal itiraz etmezse) bu beyanlar müvekkil tarafından yapılmış sayılır (m. 78).

Davanın asıl sahibi (tarafı) **müvekkildir**; bu nedenle:

Müvekkil, vekiline dava ile ilgili her türlü isteğini bildirebilir. Vekil, kural olarak müvekkilin talimatına (isteğine) uymakla yükümlüdür. Örneğin, müvekkil, vekiline (vekâletnamede özel yetkisi bulunmamasına rağmen) davadan feragat etmesini bildirebilir ve vekil buna uymakla yükümlüdür. Ancak, müvekkilin vekiline verdiği talimat, doğruluk (dürüstlük) kurallarına aykırı ise, vekil bu talimata uymakla yükümlü değildir.

Müvekkil, kendisi davadan feragat (veya davayı kabul) edebilir.

Müvekkil, (vekilini azletmeden) dava dosyasının işlemden kaldırılmasını (m. 150) isteyebilir.

Hüküm, vekile tebliğ edilmiş olsa bile, müvekkil, hüküm hakkında kendi imzasıyla kanun yoluna başvurabilir.

Müvekkil, vekilin davayı takip şeklini beğenmezse, vekilini her zaman azledebilir (karş. AK m. 174), yerine başka bir vekil tayin edebilir veya davayı kendisi takip edebilir.

L) AVUKATLIK (VEKÂLET) ÜCRETİ

Vekil (avukat), davadaki vekâlet hizmetine karşılık müvekkilinden bir vekâlet ücreti isteyebilir. Bu vekâlet ücretinin miktarı, vekil ile müvekkil arasında bir ücret sözleşmesi ile serbestçe kararlaştırılır.

Vekâlet ücreti, ileride yargılama giderleri ile birlikte incelenecektir[19].

[19] Bkz. aşa. § 67, D.

§ 15. DAVA ŞARTLARI

Dava şartları[1], bir davanın esası hakkında incelemeye geçilebilmesi (tahkikat) için gerekli olan şartlardır (koşullardır). Dava şartlarının önceden belirlenmesi, davaların daha çabuk, basit ve ekonomik bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur. HUMK, dava şartlarının müstakil (bağımsız) bir kurum olarak düzenlememişti. Buna karşılık HMK m. 114, dava şartlarının neler olduğunu belirtmiş; HMK m. 115'te dava şartlarının davanın hangi aşamasında ve nasıl inceleneceği düzenlenmiştir.

A) DAVA ŞARTLARI KAVRAMI

Mahkemenin, davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davayı esastan inceleyebilmesi) için varlığı veya yokluğu gerekli olan hallere (durumlara), dava (yargılama) şartları denir. Davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi için varlığı gerekli hallere, **olumlu dava şartları** denir. Örneğin mahkemenin görevli olması, davacı tarafın dava açmakta hukukî yararının bulunması gibi. Buna karşılık davanın esası hakkında inceleme yapılması için yokluğu aranan şartlara ise **olumsuz dava şartları** denir. Örneğin, dava konusu hakkında kesin hüküm bulunmaması, davanın derdest olmaması gibi.

Dava şartları, dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esası hakkında inceleme yapabilmesi (davanın esasına girebilmesi) için gerekli olan şartlardır. Buna davanın dinlenebilmesi (mesmu olması) şartları da denir.

Dava şartlarından biri olmadan açılan dava da açılmış (var) sayılır; yani dava derdesttir. Ancak mahkeme, dava şartlarından birinin bulunmadığını tespit edince, davanın esası hakkında inceleme yapamaz; davayı dava şartı yokluğundan (usulden, mesmu olmadığından) reddetmekle yükümlüdür.

Bu açıklamalar, geniş anlamdaki dava şartları (dava engelleri) içindir. Buna, genel olarak ilk itiraz halleri (m. 116) de girer. Ancak, yargılama engelleri, dar anlamda dava şartı değildir.

Dar ve gerçek anlamda dava şartları, davanın esastan incelenip karara bağlanabilmesi için varlığı veya yokluğu mutlaka gerekli olan hallerdir. Yani, dava şartlarının bulunup bulunmadığı davada hâkim tarafından kendiliğinden gözetilir; taraflar bir dava şartının noksan olduğu davanın görülmesine (esastan karara bağlanmasına) muvafakat etseler (onay verseler) bile, hâkim davayı usulden (mesmu olmadığından) reddetmekle yükümlüdür. Ancak mahkeme, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanma-

---

[1] Baki Kuru, Dava Şartları (Ord. Prof. Sabri Şakir Ansay'ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, s. 109-147); Ramazan Arslan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Medenî Usul Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler (Prof. Dr. Gürgân Çelebican'a Armağan, Ankara 2011, s. 439-459).

sı için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilememişse, davayı dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddeder (m. 115, 2).

B) DAVA ŞARTLARININ ÇEŞİTLERİ

Bir hususun (durumun) dava şartı olup olmadığı, onun niteliğinden anlaşılır: Kanun, bir hususun (durumun) varlığını veya yokluğunu, mahkemenin davayı esastan inceleyip karara bağlamasına engel görmüş ve hâkimi o hususu kendiliğinden gözetmekle yükümlü kılmış ise, o husus bir dava şartıdır. Bununla birlikte, dava şartlarının çeşitleri her hukuk sisteminde az veya çok değişik düzenlenmiş olabilir. Burada, dava şartları kavramına göre, hangi durumların dava şartı olduğu tespit edilecek ve bu durumlar incelenecektir.

Dava şartları, mahkemeye, taraflara ve dava konusuna ilişkin olmak üzere, üçe ayrılarak incelenebilir:

I – MAHKEMEYE İLİŞKİN DAVA ŞARTLARI

1) Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması

Mahkemenin, açılan dava bakımından yargı hakkına (yetkisine) sahip olması gerekir (m. 114, 1/a). Mahkemenin yargı yetkisi (hakkı) Devletin egemenliği ile bağlantılıdır. Yargı hakkından kasıt, Türk mahkemelerinin yargı hakkıdır (yetkisidir). Türk mahkemelerinin yargı hakkı, ülke ve kişi yönünden olmak üzere, iki bakımdan sınırlıdır:

a) Yargı Hakkının Ülke Yönünden Sınırları

Türk mahkemelerinin yargı hakkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafî sınırları ile sınırlıdır. Türk mahkemeleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında (yabancı ülkelerde) yargı hakkına sahip değildir; yargı yetkisini kullanamazlar. Bunun gibi, yabancı devlet mahkemeleri de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yargı hakkına sahip değildir; yargı yetkisini kullanamazlar

Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler, yargı hakları (yetkileri) dışında kalan hususlarda, karşılıklı olarak birbirlerine hukukî yardımda bulunurlar; yani birbirlerini istinabe ederler. Bu konu yukarıda incelendi[2].

b) Yargı Hakkının Kişi Yönünden Sınırları

Kural olarak, (yerli, yabancı) bütün gerçek ve tüzel kişiler, Türk yargısına tâbidir. Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır; yani, Türk mahkemeleri bazı kişilere karşı açılan davalara bakamazlar:

aa) Yabancı Devletlerin Yargı Muaflığı

Bir devlet, başka bir devletin mahkemeleri önünde yargılanamaz. Bu nedenle, yabancı bir devlete karşı Türk mahkemelerinde dava açılamaz. Ancak, yabancı devletlerin yargı muaflığı (bağışıklığı), yabancı devletlerin egemenlik işlemlerine ilişkin davalar hakkındadır.

---

[2] Bkz. yuk. § 12.

Buna karşılık, yabancı bir devletin özel hukuk ilişkilerinden dolayı, o devlete karşı, Türk mahkemelerinde hukuk davası açılabilir. Yani, "yabancı devlete, özel hukuk ilişkilerinden doğan hukukî uyuşmazlıklarda yargı muafiyeti tanınmaz. Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin (Türkiye'deki) diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir" (MÖHUK m. 49).

bb) Diplomatik Temsilcilerin Yargı Muafiyeti

Türkiye, 3042 sayılı Kanunla 18.04.1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine katılmıştır[3]. Buna göre:

Yabancı diplomatik temsilciler (ajanlar)[4], Türkiye'de ceza yargısından tam (mutlak) olarak muaftır (Viyana Sözleşmesi m. 31, 1).

Buna karşılık, diplomatik temsilcilerin hukuk davalarındaki yargı muafiyeti tam (mutlak) değildir. Viyana Sözleşmesi'nin 31. maddesine göre, diplomatik temsilciler aşağıdaki davalarda Türk medenî (ve idarî) yargısına tâbidir; yani **aşağıdaki davalar**, Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilere karşı **açılabilir**:

a) Diplomatik temsilcilerin Türkiye'de bulunan özel taşınmazıyla ilgili aynî hak davaları,

b) Diplomatik temsilcilerin (gönderen devlet adına değil de, bir özel kişi olarak) vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasın idarecisi, mirasçı veya vasiyet olunan kişi sıfatıyla ilgili bulunduğu mirasa ilişkin davalar.

c) Diplomatik temsilcinin, Türkiye'de resmî görevleri dışında icra ettiği herhangi bir mesleki veya ticarî faaliyet ile ilgili davalar.

Yukarıdaki hallerde, diplomatik temsilci ne hukuk davalarında ne de icra-iflâs takiplerinde yargı muafiyetine sahiptir. Bunların dışındaki hallerde yabancı temsilcilere karşı Türk mahkemelerinde dava açılamaz; açılırsa, yargı hakkı (dava şartı) yokluğundan, dava esasa girişilmeden (usulden) reddedilir.

Diplomatik temsilcinin, tanıklık yapmak zorunluluğu yoktur (Viyana Sözleşmesi m. 31, 2); ancak diplomatik temsilci, kendi isteği ile mahkemeye gelerek tanıklık yapabilir.

Yargı muafiyetinden yararlananlara, Türk mahkemeleri tarafından Türkiye'de tebligat yapılamaz. Ancak, bu kişilere, yabancı ülkelerdeki kişiler gibi, diplomatik yolla (kendi devletlerinin yetkili organları tarafından) tebligat yapılabilir.

Yargı muafiyetinden yararlananlara (diplomatik temsilcilere) karşı Türkiye'de icra takibi de yapılamaz (Viyana Sözleşmesi m. 31, 3).

Yargı muafiyetinden yararlananlar, Türk mahkemelerinde dava açabilirler ve açılmış bir davaya müdahale edebilirler. Bu şekilde dava açılması halinde, bu kişilere (muafiyet söz konusu olmadan), karşı dava açılabilir.

---

3 RG 24.12.1984, sa. 18615.

4 "**Diplomatik temsilci** (ajan)", misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir üyesidir (Viyana Sözleşmesi m. 1/c). Diplomatik temsilcinin beraberinde oturan aile üyeleri (TC vatandaşı değillerse) yargı muafiyetinden yararlanabilirler.

2) Yargı Yolunun Caiz Olması

Adlî yargı yolunun caiz olması, dava şartıdır (m. 114, 1/b). Yani, davanın adlî yargı koluna ait (adliye mahkemelerinin görevine giren) bir dava olması gerekir[5]. Yukarıda da açıklandığı üzere, idarî yargının konusuna giren bir dava, adliye mahkemelerinde (adlî yargı koluna mensup mahkemede) açılamaz; aynı şekilde, adlî yargıya ait olan bir dava idarî yargı merciinde (örneğin idare mahkemesinde) açılamaz; açılırsa, bu husus yargılamanın her aşamasında bir dava şartı olarak taraflarca ileri sürülür ve mahkeme tarafından kendiliğinden gözönüne alınır. Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünün idarî yargıya ait olduğu tespit edilirse, görevsizlik kararı değil, davanın usulden (dava şartı bulunmadığından) reddine karar verilir (m. 115, 2).

3) Mahkemenin Görevli Olması

Görev (m. 1-4) dava şartıdır. Yani, davanın açıldığı (özel veya genel) hukuk mahkemesinin, o davaya bakmaya görevli olması gerekir[6] (m. 114, 1/c).

4) Kesin Yetki Hallerinde Mahkemenin Yetkili Olması

Kesin yetki halleri (kuralları) yukarıda incelendi[7]. Bunlardan, kesin yetki kurallarının mahkemece kendiliğinden gözetileceği ve bu nedenle dava şartı olduğuna kuşku yoktur (m. 114, 1/ç)[8]. Yani, hakkında kesin yetki kuralı bulunan bir davanın, mutlaka kanunda gösterilen yer mahkemesinde açılması gerekir; aksi halde, mahkeme, kendiliğinden yetkisizlik kararı vermekle yükümlüdür.

II – TARAFLARA İLİŞKİN DAVA ŞARTLARI

Taraflara ait dava şartlarının bir kısmı, tarafın kişivarlığı hakları ile ilgilidir; bir kısmı ise, tarafın davada yapması gereken hususlarla ilgilidir. Bunlar:

1) Davada İki Tarafın Bulunması

Yukarıda görüldüğü gibi, her davada, davacı ve davalı olmak üzere daima iki taraf vardır. Dava iki tarafın bulunması dava şartıdır. Bir davada, birbiri ile uyuşmazlık (çekişme) halinde olan iki kişi (taraf) yoksa, o zaman dava değil, çekişmesiz yargı işi (m. 382) söz konusu olur[9] ve çekişmesiz yargıya ilişkin kurallar (m. 383-389) uygulanır.

2) Taraf Ehliyeti

Her iki tarafın da taraf ehliyetine sahip olması gerekir; taraf ehliyeti dava şartıdır[10] (m. 114, 1/d).

---

5 Bkz. yuk. § 2, B, III.
6 Bkz. yuk. § 9.
7 Bkz. yuk. § 10, B, III, 1.
8 Bkz. yuk. § 10, B, III, 1.
9 Bkz. aşa. § 70.
10 Bkz. yuk. § 13, A.

3) Dava Ehliyeti

Her iki tarafın da dava ehliyetine sahip olması gerekir. Dava ehliyetine sahip olmayan tarafın davada yasal temsilcisi tarafından temsil edilmesi gerekir. Dava ehliyeti, dava şartıdır[11] (m. 114, 1/d).

4) Dava Takip Yetkisi

Her iki tarafın da dava takip yetkisine sahip olması gerekir; dava takip yetkisi bulunmayan taraf, tasarruf yetkisinin bulunmaması sebebiyle dava açamaz ve usul işlemleri yapamaz. Dava açılması ve usulî işlem yapılması, bu konuda kanunen yetkilendirilmiş kişiye aittir. Dava takip yetkisi dava şartıdır[12] (m. 114, 1/e).

5) Yasal Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Olması

Davada tarafların yasal temsilci ile temsil edilmesi hallerinde, temsilci olarak hareket eden kişinin gerekli niteliklere sahip olması bir dava şartıdır (m. 54) (m. 114, 1/d).

6) Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname

Vekil veya temsilci aracılığı ile takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve geçerli bir vekâletnamesinin (temsil belgesinin) bulunması gerekir[13] (m. 114, 1/f). Vekilin davaya vekalet ehliyetine ve geçerli bir vekâletnameye sahip olması dava şartıdır.

Buna karşılık, taraf sıfatı (husumet) dava şartı değildir[14].

Aynı nedenle, dava hakkı da dava şartı değildir. Çünkü, dava hakkının bulunmaması, davanın esasına girmeye engel olmaz. Mahkeme, davanın esasına girer; davacının dava hakkının bulunmadığı sonucuna varırsa, davayı (usulden değil) esastan reddeder.

7) Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi

Aşağıda[15] görüleceği üzere, kanunların öngördüğü bazı hallerde (m. 84 vd.) Türkiye'de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşı davacının veya davacı yanında davaya müdahale edenin, davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat yatırması gerekmektedir. Hâkim tarafından verilen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, (dava şartı gerçekleşmezse) dava usulden (dava şartı eksikliğinden, m. 114, 1/ğ) reddedilir (m. 88, 1).

---

11 Bkz. yuk. § 13, B.
12 Bkz. yuk. § 13, C.
13 Bkz. yuk. § 14, D; E.
14 Bkz. yuk. § 13, D.
15 Bkz. aşa. § 46.

III – DAVA KONUSUNA İLİŞKİN DAVA ŞARTLARI

1) Davacının Yatırması Gerekli Gider Avansının[16] Yatırılmış Olması

Aşağıda[17] görüleceği üzere, davacı dava açarken (yargılama harçlarının yanı sıra), Gider Avansı Tarifesinde[18] belirlenen tutarı mahkeme veznesine yatırmak zorundadır (m. 120). Gider avansının yatırılmış olması dava şartıdır. HUMK'nda bu yönde bir düzenleme bulunmaması davanın, dürüstlük kuralına aykırı olarak, geciktirilmesine neden olabiliyordu. Bu uygulamayı önlemek için HMK'nda konu dava şartı olarak düzenlenmiştir. HMK m. 114, I/g ve m. 120'de düzenlenen **gider avansı**, m. 324'te düzenlenen **delil avansı**ndan farklıdır (karş. HMK Gider Avansı Tarifesi m. 4 ve Y m. 205).

2) Davacının, Dava Açmakta Hukukî Yararının Bulunması[19]

Davacının, bir davayı açmakta hukukî yararı (menfaati) bulunmalıdır. Buna, hukukî korunma (himaye) ihtiyacı da denir. Yani davacının mahkemeden hukukî korunma istemesinde (dava açmasında), korunmaya değer bir yararı olmalıdır (m. 114, 1/h).

Davacının dava hakkına sahip olması, dava açabilmesi için yeterli değildir. Bundan başka, davacının dava açmakta hukukî bir yararının bulunması gerekir; yani, **dava hakkı hukukî yarar ile sınırlıdır.** Dava açmakta hukukî yararı olmayan kişi, Devletin mahkemelerini (davası ile) gereksiz yere uğraştıramaz.

Davacının dava açmaktaki yararı **hukukî** olmalıdır; ideal veya ekonomik yarar yalnız başına yeterli değildir.

Davacı, hakkına kavuşmak için mahkemenin kararına muhtaç bulunmalıdır. Davacının hakkını elde edebilmek için bir mahkeme kararına ihtiyaç yoksa, hukukî yarar yok sayılır. Örneğin, geçerli bir haciz yokken açılan istihkak davasında (İİK m. 96-99) davacının hukukî yararı yoktur.

Davacının dava açmaktaki hukukî yararının, **korunmaya değer** bir yarar olması gerekir. Dava edilen alacak miktarının çok az olması halinde de, davacının dava açmakta korunmaya değer bir hukukî yararı (kural olarak) vardır.

Buna karşılık, bir alacağın küçük parçalara bölünerek, her parça için ayrı dava açılmasında, korunmaya değer bir hukukî yarar yoktur. Örneğin, davacı beş yüz liralık bir alacağı için beş liralık yüz adet dava açamaz. Çünkü, burada davacının dava açmakta hukukî yararı varsa da, bunu yüz parçaya bölerek yüz ayrı dava açmakta korunmaya değer bir hukukî yararı yoktur. Hukukumuzda kısmî dava açmak mümkün ise de (m. 109), alacağın bir bölümünün dava edilmesinde, davacının korunmaya değer hukukî yararının bulunması gerekir.

---

16 Bkz. Mustafa Serdar Özbek, Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı, Ankara 2016.
17 Bkz. aşa. § 17, B.
18 RG 29.09.2018, sa. 30550.
19 Bkz. Emel Hanağası, Davada Menfaat, Ankara 2009.

Hukukî yarar **dava açıldığı anda** var olmalıdır; gelecekteki bir yarar yeterli değildir. Bu nedenle, muaccel olmayan (vadesi gelmemiş, müeccel) alacak için dava açılamaz; açılırsa, dava hukukî yarar yokluğundan (usulden) reddedilir. Ancak, bu ret kararı, alacağın muaccel hale gelmesinden sonra yeniden dava edilmesine engel değildir. Aynı şekilde, açıldığı sırada belli olmayan (şüpheli) veya ileride doğacağı beklenen bir yarar da hukukî yarar sayılmaz.

Davanın açıldığı sırada var olmayan "hukukî yararın" dava sırasında tamamlanması, mahkemenin "hukukî yarar" eksikliğinin tamamlanmasını beklemesi söz konusu olamaz. Çünkü, hukukî yarar dava şartı eksikliği ilgili tarafa belli bir süre verilerek tamamlanabilecek bir dava şartı değildir. Hukukî yararın bulunması dava şartı, sadece dava açılırken değil, nihai karar verilinceye kadar var olmalıdır. Bu dava şartının eksikliğinin mahkemece tespiti üzerine davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.

Dava açmadaki hukukî yarar, dava çeşitlerine göre bazı özellikler gösterir:

a) Eda Davalarında Hukukî Yarar

Eda davalarında (m. 105) hukukî yararın **varlığı asıldır**. Yani, eda davalarında, davacı (kural olarak) dava açmakta hukukî yararının varlığını bildirmek ve ispat etmekle yükümlü değildir. Ancak, şüphe (kuşku) halinde, hukukî yararın olup olmadığı inceleme konusu yapılır.

Yukarıdaki açıklama (kural), dava konusu alacak veya hakkın muaccel olması hali içindir. Buna karşılık, **müeccel** (vadesi gelmemiş) **alacaklar** (örneğin, dava açılmasından sonra doğacak ayların kira bedelleri) için eda davası açılmasında kural olarak hukukî yarar yoktur.

Buna karşılık, maddî hukuka göre, özellikle **gelecekte tekrarlanacak olan edimler için,** bazı hallerde (şimdiden) eda davası açılabilir; örneğin: yoksulluk nafakası konusunu düzenleyen TMK m. 175; çocuklar bakımından ana ve babanın haklarını belirleyen hâkimin takdir hakkına ilişkin TMK m. 182; nafaka yükümlülüğüne ilişkin TMK m. 364-365; ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali ve tenkisi ile feshini düzenleyen TMK m. 615-617 hükümlerine göre açılan davalar gibi.

Davacı, mahkemeye başvurup bir ilâm almadan, başka bir yol ile de hakkına aynı güvenle kavuşabilecek ise, artık eda davası açmakta hukukî yararı yoktur; örnekler:

Bir para alacağı için **ilâmsız icra takibi** yapmış (İİK m. 58 vd.), borçlunun takibe (ödeme emrine) itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış (İİK m. 68-69) olması nedeniyle icra takibi **kesinleşmiş** olan **alacaklının**, artık aynı alacak için **eda davası açmasında hukukî yararı yoktur**. Çünkü, alacaklı, dava açsa bile, dava sonucunda alacağı ilâmı da icraya koyacak (İİK m. 32) ve borcun ödenmemesi halinde, haciz isteyebilecektir. Oysa, burada ilâmsız icra takibinin kesinleşmiş olması nedeniyle, alacaklının haciz isteme yetkisi doğmuş durumdadır (İİK m. 78). Yani alacaklı, dava ile erişebileceği amaca esasen ulaşmış durumdadır. Bu nedenle, alacaklının (buna rağmen) alacak davası açmasında, korunmaya değer hiçbir hukukî yararı yoktur.

Davacının elinde **ilâm niteliğinde bir belge** (İİK m. 38) varsa, artık davacının böyle bir belgeye bağlı alacağı için **dava açmakta hukukî yararı yoktur**. Çünkü, dava, alacaklının alacağının kesin olarak ve gerektiğinde cebri icra yolu ile elde edilmesini temin için hüküm verilmesini amaçlar. Bu nedenle, böyle ilâm niteliğindeki (gücündeki) bir belgenin varlığı halinde, artık dava açmakta hukukî yarar yoktur.

Kanunların "ayrıca bir mahkeme hükmüne lüzûm olmadığını" bildirdikleri hallerde de, davacının dava açmakta hukukî yararı yoktur. Bkz. örneğin: İİK m. 15, I; 24, IV; 25, II; 30, II; 40, II; 94, V; 118, III; 133, II; 149a, II; 356, I; 358, II; 361; Harcırah K. m. 59, VII; 6183 s. K. m. 86, 97.

b) Tespit Davalarında Hukukî Yarar

Tespit davasının (m. 106) dinlenebilmesi (esasına girilebilmesi, esastan karara bağlanabilmesi) için, davacının, tespit davası konusu hukukî ilişkinin var (mevcut) olup olmadığının mahkemece **hemen** tespit edilmesinde hukukî yararının bulunması gerekir (m. 106, 2); mahkemeden, bir hakkın veya hukukî ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talebi ile açılan tespit davalarında hukukî yarar, aşağıda incelenecektir[20].

Eda davasında, davacı dava açmakta hukukî yararı bulunduğunu (kural olarak) bildirmek ve ispat etmekle yükümlü olmadığı halde, tespit davası açılmasında hukukî yararın varlığı, davacı tarafından özellikle bildirilmeli ve ispat edilmelidir. Davacı tespit davası açmakta hukukî yararı olduğunu ispat edemezse, tespit davası dava şartı (hukukî yarar) yokluğundan (usulden) reddedilir.

Mahkemenin, her tespit davasında davacının hukukî yararın bulunup bulunmadığını kendiliğinden incelemesi gerekir: Oysa, eda davası açılmasında hukukî yarar (kural olarak) var olduğundan, mahkeme, eda davasında hukukî yarar bulunup bulunmadığını ancak şüphe (kuşku) halinde inceler.

c) Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Hukukî Yarar

HMK m. 107, I hükmü ile, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin davacıdan beklenemeyeceği veya bunun olanaksız bulunduğu hallerde, alacaklının (davacının) hukukî ilişkiyi ve asgarî bir miktarı belirterek belirsiz alacak davası ve tespit davası da açılabileceği kabul edilmiş ve bu durumda hukukî yararın olduğu var sayılmıştır. Kısmî eda davasının açılabileceği hallerde, tespit davasının da açılabileceği ve bu durumda hukukî yararın var olduğunun kabul edileceği m. 107, 3'de açıkça ifade edilmiştir.

Hâkim, açılan belirsiz alacak ve tespit davalarının, kanunun aradığı şartlara uygun olarak açıldığını tespit etmesi halinde, hukukî yararın varlığını

---

[20] Bkz. aşa. § 16, A, II, 3.

kabul ederek davayı görür; aksi takdirde, dava şartı eksiliğinden davayı usulden reddeder.

d) İnşaî Davalarda Hukukî Yarar

İnşaî davalar, kural olarak, kanunun açıkça öngördüğü hallerde açılabilir[21]. Bu nedenle, kanunun inşaî dava açılabileceğini öngördüğü hallerde, inşaî dava açılmasında (kural olarak) hukukî yararın var olduğu kabul edilir. Eda davalarında olduğu gibi (tespit davalarının aksine), davacının, inşaî dava açmakta hukukî yararı olduğunu bildirmesine ve ispat etmesine gerek yoktur.

Çok istisnaî hallerde, davacının inşaî dava açmakta hukukî yararı olmayabilir. Örneğin, boşanmaya karar verildikten sonra, artık evlenmenin butlanı davası açmakta hukukî yarar yoktur.

e) Her Talep İçin Hukukî Yarar Şarttır

Dava açılmasında olduğu gibi, mahkemeye yapılan her başvuru için, talepte bulunanın hukukî yararının varlığı şarttır. Aksi halde mahkeme, böyle bir talebi inceleyip yerine getiremez. Mahkeme, kendisine yapılan her talebin esası hakkında incelemeye geçmeden önce, talep sahibinin bu hususta hukukî yararının bulunup bulunmadığını incelemeli, soruya olumlu cevap verdikten sonra, talebi esastan incelemeye geçmelidir; aksi halde talebi hukukî yarar yokluğundan (usulden) reddetmelidir.

Dava açılmasındaki hukukî yararı dava çeşitlerine göre yukarıda inceledik. Davadan başka talepler hakkındaki hukukî yarar, burada yalnız örneklerle belirtilecektir. Örnekler:

Kanun yoluna başvurmada: Kanun yoluna (örneğin, istinaf veya temyiz yoluna) başvuran tarafın (m. 341; 361), aleyhine kanun yoluna başvurulan kararın (hükmün) kaldırılması veya (bozulmasında) hukukî yararı bulunmalıdır[22].

Fer'i müdahalede: Bir hukuk davasına müdahale etmek isteyen üçüncü kişinin (müdahilin), lehine müdahale etmek istediği tarafın davayı kazanmasında hukukî yararı bulunmalıdır (m. 66).

Delil tespitinde: Delil tespiti talebinde bulunabilmek için, delilin önceden tespit edilmesinde hukukî yarar olmalıdır (m. 400). Şimdiden tespit edilmemesi halinde ileride yok olacağı veya gösterilmesi çok güç olacağı tahmin edilen delillerin, önceden tespitinde hukukî yarar vardır.

İcra ve iflâs hukukunda, ihalenin feshini şikâyet yolu ile icra mahkemesinden isteyen ilgilinin, yapılan yolsuzluk sonucunda kendi menfaatinin ihlâl edildiğini ispat etmesi gerekir (İİK m. 134, VIII). Bunun gibi, şikâyet yoluna (İİK m. 16) başvuranın da, şikâyet konusu işlemin iptal edilmesinde veya düzeltilmesinde hukukî yararı bulunmalıdır.

---

[21] Bkz. aşa. § 16, A, III.

[22] Bkz. HMK m. 341, 361; aşa. § 54-61.

3) Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Halen Görülmekte (Derdest) Olmaması

Aşağıda[23] görüleceği üzere, davanın açılmasının usul hukuku bakımından ortaya çıkardığı sonuçlarından biri de **derdestlik**tir.

Aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak daha önce bir dava açılmış ve bu dava görülmekte (derdest) ise, aynı konunun (uyuşmazlığın) aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanarak yeni bir dava konusu yapılması mümkün değildir (**olumsuz dava şartı**). Çünkü, aynı konuda iki dava açılmasında davacının hukuken korunmaya değer bir yararı yoktur. Başka bir deyişle, açılmış ve görülmekte olan bir davanın davacısı, hukukî korunma sürecini başlatmıştır. Artık onun aynı davayı yeniden açmasında hukuken korunmaya değer bir yararı yoktur. Bundan başka, ayrı ayrı görülen davalar mahkemelerin iş yükünü artırır ve çelişik kararların verilmesi olasılığını ortaya çıkarır. Bu durumun adalet açısından sakıncalı olduğu açıktır. Daha önce, HUMK m. 187, 4'de bir ilk itiraz olarak nitelenen bu husus (derdestlik), HMK m. 114, 1/ı hükmü ile, isabetli olarak, dava şartı haline getirilmiştir.

4) Kesin Hüküm Bulunmaması

Dava konusu uyuşmazlığın, daha önce bir kesin hüküm (m. 303) ile çözümlenmemiş olması dava şartıdır (**olumsuz dava şartı**). Aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak daha önce dava açılmış ve verilen hüküm kesinleşmiş ise, artık o dava konusu hakkında kesin hüküm vardır[24]. Aynı dava (uyuşmazlık) yeni bir dava konusu yapılamaz; yapılırsa, mahkemenin, kesin hükmün varlığını kendiliğinden gözeterek, davayı esasa girmeden (usulden) reddetmesi gerekir (m. 114, 1/i).

IV – ÖZEL KANUNLARDAKİ ÖZEL DAVA ŞARTLARI

Buraya kadar incelenen dava şartları, genel dava şartlarıdır. Bundan başka, kanun hükümleri ile bazı davalar için ek (özel) dava şartları öngörülmüş olabilir. Örnekler:

İİK m. 277-284 hükümlerine göre **tasarrufun iptali davası** açabilmek için, alacaklının elinde borç ödemeden aciz belgesi (İİK m. 143; 105) bulunmalıdır (İİK m. 277, 1).

Borçtan kurtulma davasının (İİK m. 69) dinlenebilmesi için, bu davayı açan borçlunun alacağın yüzde on beşi (İİK m. 69, II) kadar bir teminatı ilk duruşma gününe kadar göstermesi şarttır.

Davalı eşe **ihtar kararı** tebliğ ettirmeden ve ihtar kararının tebliğinden itibaren iki ay geçmedikçe, terk sebebiyle **boşanma davası** açılamaz (TMK m. 164).

Bir mirasçının alacaklılarının tenkis davası açabilmesi için, saklı pay sahibi mirasçıdan alacaklarını tahsil etme imkânı bulunmadığını gösteren bir

---

[23] Bkz. aşa. § 18, B, IV.

[24] Bkz. aşa. § 62-63.

aciz belgesi (İİK m. 153; 105) almış olmaları ve ihtara rağmen mirasçının **tenkis davası** açmamış olması gerekir (TMK m. 562). Bu hükümdeki, **aciz belgesi ve ihtar** ayrı ayrı dava şartıdır.

TTK'nun "iptal davası açabilecek kimseler" başlığı altında düzenlenen 446. maddesinde, toplantıda hazır bulunup da anonim şirket genel kurul kararına olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahibinin iptal davası açabileceği hükme bağlanmıştır.

Son olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince, Kanunun belirlediği parasal sınırlar çerçevesinde, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklarda, doğrudan doğruya tüketici mahkemesine başvurulamaz. Burada tüketici hakem heyetlerine gidilmesi gerekir (6502 s. K. m. 68). Bu zorunluluk yerine getirilmeksizin mahkemeye başvurulması halinde, mahkeme, dava şartı eksikliğinden davayı usulden reddeder.

C) DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ

Dava şartları, dava açılmasından hükmün verilmesine kadar var olmalıdır. Davanın açıldığı anda var olan bir dava şartı (örneğin, hukukî yarar) **sonradan ortadan kalkarsa**, o zaman dava (esastan değil), dava şartı yokluğundan (usulden) reddedilir. Az sonra görüleceği gibi mahkeme, davanın başında dava şartlarının bulunup bulunmadığını kendiliğinden araştırmak ve incelemekle (yani gözetmekle) yükümlüdür (m. 115). Bu nedenle, davanın başında bir dava şartının noksan olduğu tespit edilirse, dava esasa girilmeden (usulden) reddedilir.

Ancak, bu ihmal edilmiş olup da, bir dava şartı noksan olmasına rağmen esasa girilmiş ve **dava sırasında o dava şartı noksanlığı ortadan kalkmış** ise, hüküm anında bütün dava şartları tamam olduğundan, davanın esası hakkında karar verilir; yani dava, dava şartlarının başlangıçta noksan olduğu gerekçesiyle usulden reddedilemez (m. 115, 3). Çünkü, hüküm anında bütün dava şartları tamamdır; örneğin:

Velayet altındaki küçüğün kendisinin açmış olduğu davanın görülmesi sırasında ergin olması halinde, davanın dava ehliyeti yokluğundan dolayı reddine karar verilemez.

Mahkeme, dava şartlarının tamam olup olmadığını **kendiliğinden gözetir**; yani araştırıp inceler; bu konuda tarafların talepleri ve beyanları ile bağlı değildir (m. 115, 1).

Taraflar (özellikle davalı) da, davanın her aşamasında (üst veya yüksek mahkemelerde de) dava şartlarının noksan olduğunu ileri sürebilirler.

Mahkeme, **ön inceleme**[25] **aşamasında** dava şartlarını inceler (m. 137, 1) ve dava şartlarının bulunmaması halinde, tamamlanabilecek olanlar hakkın-

---

[25] Kanun, mahkemenin dava şartlarını ilk iş olarak ele alması için, ön incelemede karar verilmesini istemiştir. Ancak dava şartları, davanın her aşamasında, mahkeme tarafından gözetileceği gibi, taraflar da, davanın her aşamasında dava şartı eksikliğini ileri sürebilirler. O

da bunların tamamlanmasını teminen gerekli kararları alır; tamamlanması olanağı bulunmayan dava şartı varsa, davayı usulden reddeder (m. 115, 2).

Ön inceleme aşaması ve dava şartları tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan mahkeme tahkikata geçemez, tahkikat için duruşma günü tayin edemez (m. 137, 2).

Kanun, ön inceleme aşamasında incelenecek ve yapılacak olanlar arasından dava şartlarının ve ilk itirazların incelenmesine öncelik vermiştir (m. 138, 1). Mahkeme dava şartlarını, kural olarak, dosya üzerinden karara bağlar; ancak gerekli görüyorsa, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında (m. 140) dinledikten sonra da karar verebilir.

Dava şartlarının (kendi içinde) **hangi sıra ile** inceleneceği hakkında, görüş birliği yoktur. Kanımızca, mahkeme, ön incelemeyi (m. 137-142) basitleştirmek veya kısaltmak için bazı dava şartlarını diğerlerinden önce inceleyebilmelidir. Bunun için dava şartlarını mantıklı bir sıraya tâbi tutmak gerekir. Belli bir dava şartının yokluğu halinde diğerlerinin incelenmesine gerek kalmayacak ise, o zaman ilk önce o dava şartının var olup olmadığı incelenmelidir.

Buna göre, **ilk önce mahkemeye ilişkin dava şartlarının** incelenmesi gerekir. Çünkü, mahkemeye ilişkin dava şartlarından birinin yokluğu halinde, mahkemenin bu davaya bakması ve diğer dava şartlarını incelemesi söz konusu olmayacaktır. Mahkemeye ilişkin dava şartlarının kendi arasındaki inceleme sırası da yargı hakkı, yargı yolu, görev ve kesin yetki şeklinde olmalıdır. Örneğin mahkeme yargı hakkına sahip değilse, artık mahkemenin görevli olup olmadığını incelemesine gerek yoktur. Çünkü, Türk mahkemeleri o davada yargı hakkına sahip değildir ki, hangi Türk mahkemesinin görevli olduğu tespit edilsin.

Mahkemeye ilişkin dava şartlarından **sonra taraflara** ve **en son olarak** da **dava konusu**na ilişkin olanlar inceleme konusu yapılmalıdır.

Yargıtay, yargı yolu sorununun, davacının dava ehliyetinden önce inceleneceğine, çünkü dava ehliyetinin incelenmesinin yargı yoluna ilişkin kurala göre davaya bakması gereken (görevli) mahkemeye ait olduğuna, bu nedenle yargı yolunun doğru seçilmediğine (görevsizliğine) karar veren mahkemenin, davacının dava ehliyetine sahip olup olmadığını ayrıca karara bağlamasına gerek bulunmadığına karar vermiştir. Bu karar, yukarıdaki açıklamalara uygun ve doğrudur.

Mahkeme, gerek kendiliğinden gerek tarafların itirazı üzerine yapacağı inceleme sonunda, bir dava şartının noksan olduğu kanısına varırsa, davanın esasına girmeden **davayı dava şartı yokluğundan** (usulden) **reddetmekle yükümlüdür** (m. 115)[26].

---

nedenle, ön incelemeden sonra da, davanın herhangi bir aşamasında dava şartlarına ilişkin bir karar verilebilir.

[26] Yalnız, görevsizlik ve kesin yetkinin söz konusu olduğu dava ve işlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilir (bkz. yuk. § 9, F; § 10, D, V).

Yalnız, yukarıda görüldüğü gibi, onay (icazet) verilerek noksan olan dava şartının tamamlanması mümkün ise, mahkeme, ilk önce icazet verebilecek kişiye bunun için bir süre vermeli, bu süre içinde onay verilmezse, ancak o zaman davayı dava şartı yokluğundan (usulden) reddetmelidir (bkz. m. 115, 2-3)[27].

Dava şartı yokluğundan dolayı davanın (usulden) reddi kararına karşı, nihaî karar olması nedeniyle kanun yoluna başvurulabilir (m. 341; 361). Böyle bir karar, ancak ilişkin olduğu dava şartının yokluğu hakkında kesin hüküm teşkil eder (m. 303). Bu nedenle, dava şartı yokluğundan reddedilen dava, **noksan dava şartı tamamlandıktan sonra yeniden açılabilir** ve davalı bu yeni davaya karşı kesin hüküm (m. 303) itirazında bulunamaz. Çünkü ilk karar, davanın esası hakkında verilmiş olmayıp, yalnız belli bir dava şartının yokluğuna ilişkindir. Bu dava şartı noksanlığı şimdi giderildiğine (tamamlandığına) göre, davanın esası hakkında inceleme yapılmasına bir engel kalmamış demektir.

Kanunda (m. 114) bu konu "dava şartları" başlığı altında düzenlenmiş ise de, dava şartının yargılamanın yapılabilmesi şartı olarak nitelendirilmesi mümkün olduğundan, çekişmesiz yargıda ve geçici hukukî koruma başvuruları ile takiple ilgili olarak mahkemeye yapılan başvurularda, talebin esastan incelenmesine geçilebilmesi için, dava (yargılama) şartlarının niteliğine uyduğu ölçüde, incelenip karar verilmesi gerekir.

---

[27] Bkz. yuk. § 14, D.

§ 16. DAVA ÇEŞİTLERİ[1]

Genel olarak her davanın bir ismi (adı) vardır: Alacak davası, menfi tespit davası, istihkak davası, tenkis davası, tahliye davası, müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davası, istirdat davası, iflâs davası, boşanma davası, babalık davası gibi. Buradaki dava çeşitlerinden kasıt, davaların bu şekilde isimlendirilmesi değildir. Dava çeşitlerinden (türlerinden) kasıt, davaların belli bir ölçüte göre gruplandırılmasıdır.

Davalar çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bu ölçütlerden en çok kullanılanı, mahkemeden istenen hukukî koruma (himaye) ölçütüdür. Davalar genellikle bu ölçüte göre sınıflandırılır. Bu nedenle, burada en çok kullanılandan başlayarak, değişik ölçütlere göre, dava çeşitleri inceleme konusu yapılacaktır.

HMK, dava çeşitleri başlığı altında (m. 105-113), HUMK'ndan farklı olarak, bir düzenleme yapmakla birlikte, burada belirli bir ölçütten hareket edilmemiş; uygulamada en çok rastlanılan dava türleri Kanuna alınmıştır.

A) MAHKEMEDEN İSTENEN HUKUKÎ KORUNMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ

Mahkemeden istenen hukukî korumaya göre davaların sınıflandırılması (çeşitlere ayrılması), bütün davaları kapsadığı ve dava çeşitleri arasındaki farkları ve ilişkileri en iyi şekilde düzenlediği için, en çok kullanılan ölçüttür. Davalar, mahkemeden istenen hukukî korumanın çeşidine göre, eda davaları, tespit davaları ve inşaî (yenilik doğuran) davalar biçiminde bir ayrıma tâbi tutulabilir.

I – EDA DAVALARI

1) Genel Bilgi

Eda (edim) davasında davacı; davalının bir işi yapmaya, bir şeyi vermeye veya bir işi yapmamaya mahkûm edilmesini ister (m. 105, 1). Örneğin, davalının taşınmazı tahliye etmesine (yapmak), satış bedeli olan on bin lirayı ödemesine (vermek) veya gürültü yapmamasına (yapmamak) karar verilmesini istemek gibi.

Davacının eda davası açmakta hukukî yararının bulunması gerekir. Esasen eda davalarında hukukî yararın varlığı kabul edilir. Eda davasındaki hukukî yarar yukarıda incelendi[2]. Eda davası açılmasında hukukî yarar bulunması için, davalının davacının hakkını inkâr etmiş olması şart değildir. Davalı, davacının hakkını ikrar eder (tanır) ve fakat yerine getirmezse, davacı, ic-

---

1 Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Dava Çeşitleri (Bankacılar 2012/80, s. 83-104); Baki Kuru, İcra ve İflâs Hukukunda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası, Ankara 2003; Timuçin Muşul, Medenî Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, Ankara 2009.

2 Bkz. yuk. § 15, B, III, 2, a.

raya konulabilecek bir hüküm (ilâm) elde etmek için de, davalıya karşı dava açabilir.

Eda davasının konusu, hem kişisel haklar (örneğin, satış bedelinin ödenmesi) hem de aynî haklar (örneğin, istihkak davası, TMK m. 683) olabilir. Burada, davalının olumlu (yapmak, vermek) veya olumsuz (yapmamak, yapamamak) bir edaya (edime) mahkûm edilmesi istenir. Örneğin, taşınır veya taşınmaz bir malın teslimi (karş. İİK m. 24; 26-27), bir şeyin (işin) yapılması veya yapılmaması (karş. İİK m. 30) gibi.

Davalının, davacının istediği edaya mahkûm edilebilmesi için, ilk önce dava konusu hakkın veya hukukî ilişkinin tespit edilmesi gerekir. Mahkeme, incelemesi sonucunda davacının iddia ettiği hakkın veya hukukî ilişkinin mevcut olduğu kanısına varırsa, davalıyı, davacıya belli bir edada bulunmaya mahkûm eder. Buna göre, eda davasının kabulü halinde verilen hüküm, iki hususu içerir: 1) Davanın dayandığı hakkın veya hukukî ilişkinin var olduğunun **tespit** edildiği; 2) Davacının istediği edanın yerine getirilmesi hususunda davalıya yöneltilmiş bir **emir**.

Böyle ikili bir ayrıma, eda hükümlerinde (her zaman) açıkça yer verilmez. Ancak bu, eda hükümlerinin temelini oluşturduğundan her eda hükmü, eda emrinden başka, zorunlu olarak dava konusu hakkın veya hukukî ilişkinin tespitini de kapsar.

Eda davasının kabulü halinde verilen (olumlu) hükmün tespit bölümü, bundan sonra aynı taraflar arasında aynı hukukî ilişkiye (dava sebebine) dayanarak açılan ikinci davada **kesin delil** teşkil eder.

Eda davasının kabulüne ilişkin kararda **hem tespit hem de eda hükmüne yer verilir**; yalnız tespit hükmü ile yetinilemez.

Eda davasının kabulüne ilişkin hükümler, ilâmların icrası yolu ile icra olunur (İİK m. 24-41). Bunun için eda hükmünün, tarafa veya taraflara yüklenen borç ve tanınan hakları açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde göstermesi gerekir (m. 297, 2).

Eda davasının reddine ilişkin hüküm, (eda hükmü olmayıp) **bir tespit hükmüdür**. Çünkü, bununla davacının iddia ettiği hakkın veya hukukî ilişkinin mevcut olmadığı tespit edilir. Kesinleşen bu tespit hükmü de **kesin hüküm** (m. 303) ve **kesin delil** teşkil eder.

Mahkemelerde görülen davaların büyük çoğunluğu eda davasıdır. Esasen HMK da, kural olarak, eda davalarını göz önünde bulundurarak usul kuralları koymuştur.

2) Kısmî Dava

Davacının, bir hukukî ilişkiden doğan ve aynı kişiden olan alacağının veya hakkının şimdilik belli bir kesimi (bölümü) hakkında hüküm verilmesi talebi ile açtığı davaya kısmî dava denir. Örneğin, davacının, davalıya ödünç verdiğini iddia ettiği yüz bin TL'nın, (tümünü değil) şimdilik yirmi bin TL'sını veya on ton buğday alacağının yüz kilosunu dava etmesi gibi.

İşin niteliği gereği, kısmî dava açılabilmesi için, **talep konusunun bölünebilir olması gerekir** (m. 109, 1); aksi takdirde kısmî dava açılamaz.

Bir davanın kısmî dava olarak nitelendirilebilmesi için, **alacağın tümünün aynı hukukî ilişkiden** (örneğin, ödünç veya satış sözleşmesinden) **doğmuş olması** ve bu (aynı hukukî ilişkiden doğan) alacağın şimdilik bir kesiminin dava edilmesi **gerekir**.

Dava konusu alacak, bir alacağın belli bir kesimi değil (tersine bağımsız bir alacak) ise, o zaman dava, kısmî dava olarak nitelendirilemez (tam dava olur). Örneğin, davacı davalıdan ödünç verdiği para için on bin TL; sattığı malın bedeli için de beş bin TL (toplam on beş bin TL) alacaklı olduğunu iddia ederek, bunlardan şimdilik ödünç verdiği on bin TL için dava açtığını bildirirse, böyle bir dava kısmî dava değildir (tam davadır); çünkü, ödünç alacağının tamamı dava konusu yapılmıştır.

Davacının kısmî dava mı yoksa tam dava mı açtığı, dava dilekçesinden (talep sonucundan) anlaşılır. Davacının davasını açıkça kısmî dava olarak nitelendirmesi zorunlu değildir. Dava dilekçesindeki açıklamalardan, davacının alacağının (dava edilenden) daha fazla olduğunun ve bunun yalnız **bir kesiminin** (bölümünün) **dava edildiğinin açıkça anlaşılması gerekli ve yeterlidir**. Örneğin, davacının "fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutuyorum", "alacağımın şimdilik şu kadarını dava ediyorum" gibi bir ifade kullanması, davanın kısmî dava olarak nitelendirilebilmesi için (kural olarak) yeterlidir.

Hukukumuzda kısmî dava açılması mümkündür (m. 109). Bundan başka, kısmî davanın mümkün olması, hiç kimsenin kendi lehine olan davayı (yani tam dava) açmaya zorlanamayacağı kuralına (m. 24) da uygundur. Borçlar hukuku bakımından da, alacaklının alacağının bir kısmını istemesine (dava etmesine) bir engel yoktur (TBK m. 84).

Şu halde, alacaklı, alacağının tümü için dava açmak zorunda olmayıp, alacağının şimdilik belli bir kesimini (bölümünü) dava konusu yapabilir. Ancak, alacaklının böyle bir kısmî dava açmada korumaya değer bir **hukukî yararının bulunması** gerekir.

"Talep konusunun miktarı açıkça belli ise ve taraflar arasında bu konuda herhangi bir tartışma yoksa kısmî dava açılması mümkün değildir" ifadesi ile m. 109, 2'de düzenlenen hüküm, 6444 s. K. m. 4 ile 01.04.2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, talep konusunun miktarının açıkça belli olduğu ve taraflar arasında bu konuda herhangi bir tartışma olmadığı durumda da, davacı bu davayı açmakta hukukî yararı olmak koşulu ile; kısmî dava açılabilecektir. Başka bir deyişle, m. 109, 2'nin yürürlükten kaldırılması ile, alacağın taraflar arasında tartışmasız ve belirli olup olmadığına bakılmaksızın kısmî dava açılması olanağı sağlanmıştır. Kuşkusuz, davanın görülebilmesi için davacının bu davayı açmakta hukukî yararının bulunması gerekir.

Kısmî davanın açılması mümkün olan hallerde davacının, yargılama giderlerini ödemeye mahkûm olma riskini azaltmak için kısmî dava açmasında korunmaya değer bir hukukî yararı vardır. Buna karşılık, bir **alacağın küçük parçalara bölünerek**, her parça (bölüm) için ayrı ayrı dava açılmasında, korunmaya değer bir **hukukî yarar yoktur**.

Davacının, alacağının küçük parçalara bölerek her parça için ayrı kısmî dava açmasında korunmaya değer bir hukukî yararı olmadığı gibi, böyle bir davranış **hakkın kötüye kullanılması** olarak da nitelendirilebilir (TMK m. 2). Bu nedenle, bu şekildeki kısmî davaların, esasına girilmeden, hukukî yarar yokluğu (dava şartı eksikliği) nedeniyle caiz (mesmu) olmadıklarından dolayı reddi gerekir.

HMK m. 109, 3 hükmüne göre; dava açılırken (m. 118), talep konusunun kalan kısmından **açıkça feragat edilmiş olmadıkça** kısmî dava açılması, talep konusunun **geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.** Bu yüzden, dava dilekçesinde açıkça feragat (m. 307) edilmiş olmadıkça, kısmî dava açmış olan davacının ileride ek dava açmasına engel yoktur[3].

Faiz istenmeden, yalnız asıl alacak için açılan dava, bir kısmî dava değildir; tam davadır. Çünkü faiz, asıl alacağın bir bölümü olmayıp, fer'i nitelikte (ve fakat ayrı) bir alacaktır. Asıl alacak davasında faiz istenmemiş olsa bile, davacı, faiz alacağından zımnî olarak feragat etmiş sayılmaz; daha sonra faiz için ayrı bir dava açabilir.

Mahkeme, kısmî davanın tamamen kabulüne karar vermiş ise, kısmî davada verilen hüküm, açılacak ek davada kesin delil teşkil eder[4].

Kısmî dava açılması halinde, dava konusu yapılmayan kısmın ayrı bir davanın konusu yapılması veya kısmî davada ıslah yoluna başvurularak kısmî dava konusuna eklenmesi mümkündür. Ancak, 04.02.1948 gün ve 10/3 sayılı, Yargıtay İBK'na göre, bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucu arttırılamaz. Böyle bir durumda davacı ayrı (ek) bir dava açarak alacağının geri kalan kısmını isteyebilir.

3) Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları[5]

Normal olarak, bir alacak (eda) davasında davacı, alacağının miktarını belirler ve dava dilekçesinin talep sonucu kısmına da bu miktarı, davalıdan talep ettiği miktar (tutar) olarak (m. 105) yazar.

Davacının, talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda, davanın kaybı halinde yargılama giderlerine mahkûm olma riskini azaltmak amacıyla, talep konusunun sadece bir kısmı için dava (kısmî dava) açması da mümkündür (m. 109, 1).

HMK m. 107, eda davaları (m. 105), tespit davaları (m. 106) ve kısmî davanın yanı sıra, "belirsiz alacak ve tespit davası" adı altında yeni bir eda davası türü daha kabul etmiştir: Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını veya değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu durumlarda, alacaklı, somut hukukî ilişkiyi ve tespit edebildiği asgarî bir miktarı ya da değeri belirterek belirsiz alacak davası açabilir (m. 107, 1). HMK m. 107'de bu dava türü düzenlenmeden

---

3 Bkz. madde ile ilgili Hükümet gerekçesine.

4 Bkz. aşa. § 62, 63.

5 Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2017; Hakan Pekcanıtez, Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2017; Cemil Simil, Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013; İbrahim Ercan, Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, Konya 2013.

önce, talep sonucunun objektif olarak belirlenemediği hallerde, önce bir kısmî dava açılmakta, daha sonra alacağın geri kalan kısmı, karşı tarafın izni ya da ıslah yolu ile aynı davada istenebilmekte veya davacı ek dava açmak zorunda kalmakta idi. Bu uygulamanın sakıncaları vardı. Davacının kısmî dava yerine, zamanaşımı riskini de düşünerek, muhtemel alacağını dava etmesi halinde de, talebinin reddedilen kısmı için yargılama giderine mahkûm olması söz konusu idi. Bütün bu sakıncaları gidermek (veya azaltmak) için bu dava çeşidi düzenlenmiştir. Belirsiz alacak ve tespit davası hakkındaki m. 107 düzenlemesinden sonra, talep sonucunun tam ve kesin olarak belirlenemediği durumlarda, kısmî davanın olumsuzluklarını taşımayan belirsiz alacak davası da açılabilecektir. Alacaklı, alacağının belirlenebilen kısmı için bu davayı açıp sonradan belirlenebilecek (geri kalan) kısmı için de belirsiz alacağın tespiti davası açabilir.

Belirsiz alacak davası özellikle, alacağın veya zararın baştan belirlenemediği, ancak bir incelemeden (tahkikattan) sonra tam olarak tespiti mümkün olan tazminat taleplerinde söz konusu olur Alacaklının bu tür bir dava açabilmesi için, dava açacağı miktarı ya da değeri tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği bir durum (hâl) olmalı veya belirleyebilmesi objektif olarak imkânsız olmalıdır. Yani alacaklının (davacının) dava konusu yapacağı miktarı ya da değeri tam ve kesin olarak belirleyebilmesi objektif olarak imkânsız olmalıdır[6].

Açılacak davanın miktarı **biliniyor** yahut **belirlenebiliyor**sa, belirsiz alacak ve tespit davası açılamaz. Çünkü, her davada arandığı gibi, burada da hukukî yarar (menfaat) aranacaktır. Alacak miktarının yahut dava konusunun değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilir olduğu bir durumda davacının belirsiz alacak davası açmakta hukukî yararının bulunduğundan söz edilemez. Özellikle, HMK'nun kısmî davaya ilişkin hükümleri de dikkate alınıp birlikte değerlendirildiğinde, alacağın tam ve kesin olarak baştan tespiti mümkün olan hâllerde bu yola başvurulması kabul edilemez[7]. Çünkü, bu durumda talep sonucunun dava dilekçesinde belirtilmesi, "açık bir şekilde talep sonucu"nun yazılması gerekir (m. 119, 1/g).

---

6 Madde 107'de belirtilen bu kural, işçi alacakları bakımından da geçerlidir. Buna göre, dava açıldığı tarihte işçi alacağının miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesinin davacıdan beklenememesi veya bunun imkânsız olması durumunda, bu işçi alacağı, belirsiz alacak davası olarak açılabilir. Buna karşılık, işçi alacağının miktarı belli ise veya belirlenebiliyorsa, bu işçi alacağı için belirsiz alacak davası açılamaz. Nitekim Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15.12.2017 gün ve 06/05 sayılı kararı da bunu teyit ederek, işçi alacaklarının belirsiz alacak davası olarak açılması konusunda uygulamada ortaya çıkan tereddüdü ortadan kaldırmıştır. Bu karara göre, "işçilik alacaklarının çok değişik tür ve nitelikte uyuşmazlık olarak mahkemeler önüne gelebileceği, aynı tür ve nitelikteki işçilik alacaklarında dahi her defasında alacağın belirli veya belirsiz olmasından söz edilmesinin mümkün olmadığı, her bir somut olayın özelliğine göre mahkemelerin alacağın belirli mi yoksa belirsiz alacak mı olduğunu tespit etmeleri gerektiği, alacağın türü itibariyle bir alacağın belirli veya belirsiz alacak olduğundan söz edilemeyeceği, bu hususta yapılacak içtihadı birleştirmenin, içtihadı birleştirme kararlarının soyut, genel ve her defasında geçerli normatif yapısıyla bağdaşmadığı"ndan içtihadı birleştirmeye gerek olmadığına karar vermiştir (İBK 15.12.2017, E. 2016/06, K. 2017/5, RG 29.06.2018, sa. 30463).

7 Bkz. hükümle ilgili TBMM Adalet Komisyonu gerekçesi.

Belirsiz alacak davası veya tespit davası açılması hâlinde, alacaklı, tüm miktarı belirtmese dahi, davanın başında hukukî ilişkiyi somut olarak belirtmek ve tespit edebildiği ölçüde de asgarî miktarı göstermek durumundadır.

Belirsiz alacak davasının açılmasından sonra, yargılama sırasında, karşı tarafın verdiği bilgi veya yapılan tahkikat sonucunda, alacağın miktarının veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesi (alacağın belirli hale gelmesi sonrasında) halinde (m. 107, 1), davacı **iddianın genişletilmesi yasağına** (m. 141, 319) **tâbi olmaksızın** davanın başında (dava dilekçesinde) belirtmiş olduğu talebini arttırabilir (m. 107, 2). Ancak, alacağın belirli hâle gelmesini müteakip (alacağın belirli hale gelmesi sonrasında) ileri sürülen yeni talep eksik belirtilmişse, bundan sonra yeni bir artırma isteği iddianın genişletilmesi yasağıyla karşılaşacaktır. Çünkü, bu halde belirsizlik değil; davacının kendi ihmalinden kaynaklanan bir durum söz konusu olur. Belirsiz alacak davasında alacak belirli hale gelince, davacı iddianın genişletilmesi yasağı ile karşılaşmadan ve yeni bir dava açmasına gerek olmaksızın, alacağının tamamını talep edebilir.

Belirsiz alacak davasının açılması ile alacağın (dava sırasında artırılan kısmı da dahil) tümü için zamanaşımı kesilir. Usulî bu düzenleme ile maddî hukuktan doğan hakkın (alacağın) elde edilmesi mümkün hale gelmektedir ki, bu sonuç hak arama özgürlüğünün kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak, davacı dava açarken alacağını belirlemesinin imkânsız veya objektif olarak kendisinden beklenemeyecek ölçüde güç olması koşullarından biri olmadan belirsiz alacak davası açacak olursa, bu davayı açmakta hukukî yararı bulunmadığından ve bu dava şartı eksikliğinin giderilmesi için davacıya süre verilmesi söz konusu olmayacağından ve davacının dava türünü değiştirmesine izin verilmemesi gerektiğinden, dava usulden reddedilir.

Belirsiz alacak davasının, olağan eda davasına kıyasla, davacıya sağladığı diğer bir avantaj, belirsiz alacak davasının amaçlarından biri, talep sonucunun kesin olarak belirlendiği ve davacı tarafından asgarî talebin kesin talebe dönüştürüldüğü anda (tahkikat aşamasında), kesin talep miktarı kadar zamanaşımı süresinin kesilmesidir.

Aynı şekilde, davacının alacağı hakkında faiz de, davanın açıldığı tarihten itibaren, tüm alacak bakımından işler. Belirsiz alacak ve tespit davası hakkındaki bu özel hükümler dışında, bütün davalarda uygulanan HMK hükümleri bu davada da uygulanır.

II – TESPİT DAVALARI

1) Genel Bilgi

Tespit davaları[8], bir **hakkın** veya **hukukî ilişkinin var olup olmadığı**nın yahut bir belgenin sahte olup olmadığının **tespiti**ne ilişkin davalardır. Tespit davası yolu ile, mahkemeden bir hakkın veya hukukî ilişkinin varlığı veya

[8] Bkz. Baki Kuru/Ali Cem Budak, Tespit Davaları, İstanbul 2010; Ejder Yılmaz, Tespit Davası (Sicil İş Hukuku Dergisi, 2012/26, s. s.38-49; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 2007-2023).

yokluğu yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir (m. 106, 1). Örneğin:

(A) ve (B), uzun zamandan beri bir adî ortaklığın ortağı olarak birlikte bir ticarî işletmeyi işlettikten sonra ortaklığın tasfiyesine karar veriyorlar. Bu sırada (A)'nın, birlikte kullandıkları bir aracın kendi aracı (malı) olduğunu iddia etmesi üzerine (B), aracın ortaklığın malı olduğunu iddia etmiştir. (A) ile (B) arasında çıkan bu uyuşmazlık bir eda hükmü ile çözümlenecek nitelikte değildir. Yani (A), (B)'ye karşı bir eda davası açarak aracın kendisine verilmesini isteyemez. Aynı şekilde, (A), yeni bir hukukî durumun yaratılması için (B)'ye karşı bir yenilik doğuran (inşaî) dava da açamayacaktır. (A)'nın burada mahkemeden isteyebileceği hukukî korunma, aracın mülkiyetinde olduğunun tespit edilmesidir. İşte bu istemi karşılayan dava çeşidi, tespit davasıdır.

Tespit davalarına başka bir örnek, kira bedelinin tespiti davaları[9] ve iş hukukunda söz konusu olan hizmet tespiti davalarıdır.

Tespit davası, **genel olarak** HMK m. 106'da düzenlenmiştir. Bunun dışında tespit davalarını düzenleyen bazı **özel kanun hükümleri vardır**; örneğin TMK m. 26; İİK m. 69, II; 72; 89, III; TTK m. 56, 1/a.

2) Tespit Davası Bazı Hallerde Eda Davasının Öncüsüdür

Tespit davasının işlevi, bir hukukî ilişkinin var olup olmadığının veya bir belgenin sahte olup olmadığının tespitinden ibarettir. Yukarıda görüldüğü gibi, bu tespit işlevi (bölümü) eda davalarında da (hatta bütün dava türlerinde de) vardır. Bundan başka, eda davalarının ikinci bir (eda) bölümü vardır ki, bu bölüm tespit davalarında yoktur. Bu nedenle, eda davası aynı konudaki tespit davasını (talebini) da içeren daha geniş kapsamlı bir davadır. İşte bundan dolayı, tespit davası, eda davasının öncüsüdür.

Yargıtaya göre, henüz şartları olmadığı için açılamayan eda davası için ilerideki hukukî ilişkinin belli edilmesi bakımından **kesin delil olarak kullanılmak üzere** tespit davası açılabilir. Örneğin, kira bedelinin tespiti davası, ileride açılacak ve fakat henüz şartları bulunmadığından açılamayan kira alacağı davasını hazırlamak amacını güder.

3) Tespit Davasının Şartları[10]

Tespit davasının dinlenebilmesi (esasına girilebilmesi) için, diğer genel dava şartlarından[11] başka, şu iki (ek) şartın da bulunması gerekir: 1) Tespit davasının konusu yalnız **hak** veya **hukukî ilişkiler** olabilir. 2) Davacının bir hakkın veya hukukî ilişkinin var olup olmadığının ya da bir belgenin sahte olup olmadığı **hemen tespit edilmesi**nde hukukî yararı (menfaati) bulunmalıdır.

---

9 Bkz. 18.11.1964 gün ve 02/04 sayılı; 07.07.1965 gün ve 05/05 sayılı ve 21.11.1966 gün ve 19/10 sayılı İBK (bkz. RG 27.11.1964, sa. 11867; 21.07.1965, sa. 12054; 29.12.1966, sa. 12490).

10 Kuru/Budak, s.80 vd.; Yılmaz, Tespit s. 38 vd.

11 Bkz. yuk. § 15.

a) Hak veya Hukukî İlişki Şartı

Tespit davasının konusu, yalnız hak veya hukukî ilişkiler olabilir. Hukukî ilişkiden kasıt, bir kişi ile diğer bir kişi veya bir mal (eşya) arasında somut bir olaydan doğan hukukî ilişkidir. Her çeşit hukukî ilişki, tespit davasının konusu olabilir; borç ilişkileri, aynî haklar, zilyetlik, aile hukuku ilişkileri, miras hakkı, saklı pay, fikrî haklar, isim hakkı, firma üzerindeki haklar, üyelik hakları gibi.

Buna karşılık, somut bir olaydan doğmayan, **soyut hukukî ilişkilerin tespiti** için tespit davası açılamaz. Örneğin, belediyenin kentin temizliğine ilişkin genel bir yükümlülüğünün olup olmadığının tespiti için tespit davası açılamaz.

Bir hukukî ilişki için önemli olsalar bile, **maddî vakıalar** (olay ve olgular) yalnız başına tespit davasına konu yapılamaz (m. 106, 3). Örneğin, belli bir zamanda şu veya bu şekilde bir iş kazasının meydana geldiği vakıasının tespiti için ayrı bir tespit davası açılamaz. Maddî vakıalar, ancak belli bir hak veya hukukî ilişki ile birlikte tespit davasına (veya eda davasına) konu yapılabilir. Aynı şekilde, kaybolması veya başvurulma olanağının kalmaması nedeniyle, henüz incelenme zamanı gelmeden başvurulan, bir anlamda delillerin güvence altına alınmasını amaçlayan delil tespiti (m. 400-405) ile tespit davası birbirine karıştırılmamalıdır.

b) Hukukî Yarar Şartı

Tespit davasının ikinci şartı, hukukî yarardır. Yani, davacının tespit davasına konu yapılan hukukî ilişkinin **hemen tespit edilmesi**nde hukukî yararının bulunması şarttır. HMK m. 106, 2'ye göre; tespit davasını açan davacının, davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır; kanunlarda belirtilen istisnaî durumlarda bu kural aranmaz. HMK m. 114'te düzenlenen dava şartlarından biri de davacının dava açmasında hukukî yararının bulunmasıdır.

Her davada bulunması gereken hukukî yararın önemi, kendisini özellikle tespit davasında gösterir.

Bir hakkın veya hukukî ilişkinin varlığı yahut yokluğu, tespit davası açılabilmesi için yalnız başına yeterli değildir. Bundan başka, o hukukî ilişkinin var olup olmadığının mahkemece hemen tespit edilmesinde, davacının korunmaya değer bir hukukî yararının bulunması şarttır.

Bir hukukî ilişkinin hemen tespit edilmesinde hukukî yararın bulunması, şu **üç koşulun birlikte varlığı**na bağlıdır: 1) Davacının bir hakkı veya hukukî durumu **güncel** (m. 106, 2) **bir tehlike** ile tehdit edilmiş olmalı; 2) Bu tehdit nedeniyle, davacının hukukî durumu **tereddüt** içinde olmalı ve bu husus davacıya zarar verebilecek nitelikte bulunmalı; 3) Yalnız kesin hüküm etkisine sahip olup, cebrî icraya yetki vermeyen (icraya konulamayan) tespit hükmü, bu **tehlikeyi ortadan kaldırmaya elverişli** olmalıdır.

Yukarıda gördüğümüz adî ortaklıkta kullanılan araç örneğinde, (A)'nın tespit davası açmakta (az önce belirtilen şekilde) bir hukukî yararı vardır.

Bunun gibi, kiralayanın kira bedelinin tespiti davası açmakta, kural olarak hukukî yararı vardır.

Ancak, kiralayanın kira döneminin bitiminden (yeni kira döneminin başlamasından) çok önce kira bedelinin tespiti davası açmakta güncel bir hukukî yararı yoktur:

"Davanın yeni dönemin başlamasından çok önce açılmış olması halinde, inceleme sırasında yeni dönem rayiçlerinin tayin edilmesinde imkânsızlıklar meydana gelirse, çok erken açılmış bir dava bu sebepten reddolunabilir. Bu hâl vakıalarla ilgili bir durumdur"[12].

Yalnız, uzun süreli kira sözleşmesinin son yılında, yeni dönem kira bedelinin tespiti davası açılmasında hukukî yarar vardır. Örneğin, beş yıllık bir kira sözleşmesinin beşinci yılında, kira bedelinin tespiti davası açılmasında hukukî yarar bulunduğu kabul edilebilir.

Davacının tespit davası ile istediği **hukukî koruma, diğer dava çeşitlerinden biri ile sağlanabiliyorsa**, o zaman, davacının (o konuda) tespit davası açmakta hukukî yararı yoktur. Örneğin, boşanma davası açma hakkı olan bir eşin, ilk önce yalnız boşanma hakkının tespiti için bir tespit davası açmakta hukukî yararı yoktur. Bunun gibi, **eda davası açması mümkün olan** davacının, aynı konuda **tespit davası açmakta** (kural olarak) hukukî yararı yoktur (karş. m. 107, 3).

Bir kanun hükmü ile açıkça düzenlenen tespit davalarında yukarıda incelenen hukukî yarar ve hukukî ilişki şartını aramaya (incelemeye) kural olarak gerek yoktur. İlgili kanun hükmünün öngördüğü biçimde açılan tespit davasının dinlenme şartları var sayılır ve mahkemece davanın esasının incelenmesine geçilir.

HMK m. 107, 3 hükmüne göre; kısmî eda davasının (m. 108) açılabildiği durumlarda tespit davası da açılabilir ve bu halde hukukî yararın var olduğu kabul edilir (m. 106, 2)[13]. Kanun koyucunun bu düzenlemeyi (m. 107, 3) yapmaktaki amacı, tüm kısmî dava açılabilen durumlarda, hukukî yarar bulunmasa bile tespit davasının açılmasına izin vermek değildir. Bu kural (m. 107, 3), m. 107, 1'de düzenlenen koşulların bulunduğu durumlarda uygulanabilir; yani, bu kural, her türlü eda davasında değil, belirsiz alacak davasının açılabildiği haller bakımından özel bir hükümdür.

c) Hak, Hukukî İlişki ve Hukukî Yarar Dava Şartıdır

Buraya kadar incelediğimiz, tespit davasının konusunun hak veya hukukî ilişki olması ve davacının tespit davası açmakta hukukî yararının bulunması, dava şartıdır (m. 114, 1/h). Açılan bir tespit davasında, bu iki şartın (birlikte) bulunup bulunmadığı, diğer dava şartlarında olduğu gibi, davanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden gözetilir.

Tarafların, bu iki şartın (veya bunlardan birinin) mevcut olmadığına ilişkin bir itirazda bulunmamaları ve hatta buna rıza göstermeleri halinde bile, bu iki

---

12 Bkz. 21.11.1966 gün ve 19/10 sayılı İBK (RG 29.12.1966, sa. 12490).

13 Bu konuda bkz. TBMM Adalet Komisyonu gerekçesi.

şart (ve diğer dava şartları) bulunmadıkça, tespit davası dinlenmez. Mahkemenin esas hakkında incelemeye girmeden, davayı usulden (dava şartı yokluğundan) reddetmesi gerekir.

4) Tespit Davası Çeşitleri

İki çeşit tespit davası vardır:

a) Müspet (Olumlu) **Tespit Davası**

Bir hakkın veya hukukî ilişkinin mevcut olduğunun yahut bir belgenin sahte olmadığının tespiti için açılan davaya, müspet (olumlu) tespit davası denir. Bu dava, davacının varlığını iddia ettiği hak veya hukukî ilişkinin, davalı tarafından inkâr edilmesi halinde açılır. Örneğin, sigortasız çalıştırılan veya sigortası eksik yatırılan işçinin, geçmiş sürelerini sigortalı hale getirmek için işveren ve sosyal güvenlik kurumuna karşı açtığı hizmet tespiti davası.

Müspet tespit davasının kabulü halinde verilen hüküm ile hukukî ilişkinin var olduğu; davayı esastan reddeden hüküm ile de hukukî ilişkinin yok olduğu (mevcut olmadığı) kesin olarak (m. 303) tespit edilmiş olur.

b) Menfî (Olumsuz) **Tespit Davası**

Davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hak veya hukukî ilişkinin mevcut olmadığının (yok olduğunun) yahut bir belgenin sahte olduğunun belirlenmesi için açılan davaya, menfî (olumsuz) tespit davası denir. Bir hak veya hukukî ilişkinin mevcut olmadığının tespit edilmesi hakkında menfî tespit davası açılabilmesi için, davalının daha önce o hukukî ilişkinin varlığını iddia etmiş olması gerekir. Örneğin, bir kimsenin borçlu olmadığının tespiti için açtığı menfî tespit davası gibi (İİK m. 72).

Menfî tespit davasının kabulü halinde verilen hüküm ile hukukî ilişkinin mevcut olmadığı (yok olduğu) veya bir belgenin sahte olduğu, davayı esastan reddeden hüküm ile de hukukî ilişkinin var olduğu kesin olarak (m. 303) tespit edilmiş olur.

5) Tespit Hükmü

Tespit davasında, yalnız tespit hükmü verilir; ayrıca eda hükmü de verilemez. Çünkü, mahkeme talepten fazlaya hüküm veremez (m. 26). Örneğin, kira bedelinin tespiti davasında, tespit edilen kiranın ayrıca tahsiline (ödenmesine) de karar verilemez.

Tespit hükmü, **kesin hüküm** (m. 303) ve **kesin delil** teşkil eder.

Tespit hükmünde eda emri bulunmadığı için, tespit hükmü ilâmlı icra yolu (İİK m. 24 vd.) ile icraya konamaz.

Buna karşılık, borçlunun belli bir paranın (kayıtsız şartsız) borçlusu olduğunu gösteren müspet (olumlu) tespit hükmü, İİK m. 68, I anlamında, resmî dairelerin yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge niteliğindedir. Bu nedenle alacaklı, müspet tespit hükmüne dayanarak ilâmsız icra takibi

yapabilir ve borçlu, ödeme emrine itiraz ederse, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Örneğin, açmış olduğu kira bedelinin tespiti davasını kazanan kiralayan, yeni kirayı gösteren tespit hükmü ile, kiracıya karşı ilâmsız icra takibi (İİK m. 58 vd.; 269 vd.) yapabilir ve kiracı ödeme emrine itiraz ederse icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Yukarıdaki açıklamalar, mevcut olup olmadığı tespit edilen hukukî ilişkinin kendisi hakkındadır. Müspet veya menfî tespit hükümlerinin yargılama giderlerine (m. 297, 1/ç) ilişkin olan bölümü, eda hükmü olduğundan, ilâmlı icra yolu (İİK m. 32) ile icra edilir.

III – İNŞAÎ DAVALAR (YENİLİK DOĞURAN DAVALAR)[14]

1) Genel Bilgi

İnşaî dava ile davacı, var olan bir hukukî durumun değiştirilmesini veya kaldırılmasını veya yeni bir hukukî durumun yaratılmasını ister. Bu nedenle, inşaî davalara **yenilik doğuran davalar** da denir. Bir inşaî hakkın, dava yoluyla kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde inşaî dava açılır (m. 108). Bu haller ise, genellikle maddî hukuk tarafından belirlenir. Örneğin:

Evlenmenin butlanı davası (TMK m. 145 vd.), boşanma davası (TMK m. 161 vd.), babalık davası (TMK m. 301 vd.), soybağının (nesebin) reddi davası (TMK m. 286), ölüme bağlı tasarrufların iptali davası (TMK m. 557-559), tenkis davası (TMK m. 560 vd.), cezaî şartın (cezanın) indirilmesi (TBK m. 182), kira bedelinin belirlenmesi (TBK m. 344, 345), anonim şirketlerde ve kooperatiflerde genel kurul kararlarının iptali davası[15], aşırı cezaî şartın indirilmesi davası (TBK m. 161, III).

2) İnşaî Dava Bir İnşaî Hakka Dayanır

Davacı, inşaî dava ile bir inşaî (yenilik doğuran) hakkını kullanır ve bu inşaî hakkına dayanarak mahkemeden, bir hukukî durumun değiştirilmesine veya kaldırılmasına veya yeni bir hukukî durumun yaratılmasına karar verilmesini ister. Yani, davacının dava konusu yaptığı hakkı, inşaî bir haktır. Ancak, **her inşaî hakka dayanarak açılan dava inşaî dava değildir**; şöyle ki:

Kural olarak, inşaî hak sahibinin bu hakkını tek taraflı olarak kullanmasıyla, hukukî sonuç meydana gelir; bu hukukî sonucun doğması için, karşı tarafın kabulüne veya bir mahkeme kararına (hükmüne) gerek yoktur. Örneğin, bir sözleşmenin feshedilmesinde olduğu gibi (bkz. örneğin: TBK m. 39, 328-330; 432; 512). Burada inşaî hak sahibinin bu hakkını (tek taraflı olarak) kullanmasıyla (örneğin yanılma, aldatma veya korkutma nedeniyle sözleşmeyle bağlı olmama iradesinin karşı tarafa ulaşması ile -TBK m. 39-), hukukî sonuç doğar (örnekte, sözleşme feshedilir); bunun için, karşı tarafın kabulüne veya bir mahkeme kararına (hükmüne) gerek yoktur.

---

[14] Bkz. Ergun Önen, İnşai Dava, Ankara 1981.

[15] Bkz. TTK m. 445 vd.; Kooperatifler K. m. 53.

Yukarıdaki gibi, hukukî sonucun doğması için inşaî hak sahibinin tek taraflı irade beyanının yeterli olduğu hallerde (inşaî haklarda), taraflar hukukî sonucun doğup doğmadığı (örneğin, akdin feshedilip edilmediği) hususunda uyuşmazlığa düşerler ve bu uyuşmazlık bir dava ile mahkeme önüne getirilirse, bu dava **inşaî dava değildir**; ya bir eda davasıdır ya da tespit davasıdır ve bu dava sonunda verilecek hüküm de inşaî (yenilik doğurucu) değil, tespit edici (beyan edici) niteliktedir.

Buna karşılık, bazı inşaî haklarda hak sahibinin bu hakkını **tek taraflı olarak kullanmasıyla hukukî sonuç kendiliğinden doğmaz**; bu inşai hakların kullanılması için dava açılması gerekir (m. 108, 2). Kanun koyucu, özellikle hukukî durumun kuşkusuz hale gelmesi ve kamu düzeni düşüncesi ile bazı inşaî hakların kullanılmasının dava yoluyla olmasını düzenlemiştir. Bu inşaî haklar ikiye ayrılır:

Bu inşaî hakların çoğunda **hukukî sonuç, ancak mahkeme kararı** (hükmü) **ile doğar**; örneğin boşanma (TMK m. 167) ve evlenmenin butlanı (TMK m. 146 ve 148) davası açma haklarında olduğu gibi. Bu inşaî haklarda, taraflar anlaşsalar bile yeni bir hukukî durum (inşaî tesir: boşanma, evlenmenin butlanı) yaratamazlar. Bu inşaî hakların, mutlaka mahkeme aracılığı (dava yolu) ile kullanılması gerekir (m. 108, 2).

Diğer bazı inşaî haklarda ise, inşaî hak sahibinin, bu hakkını tek taraflı olarak kullanmasıyla hukukî sonuç doğmaz ise de, hukukî sonucun doğması için, mutlaka bir mahkeme kararı alınması (dava açılması) da şart değildir. Taraflar anlaşırsa, mahkeme kararına (hükmüne) gerek kalmadan, tarafların anlaşması ile hukukî sonuç doğar; örneğin, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve cezaî şartın indirilmesi hallerinde olduğu gibi. Ancak tarafların anlaşamaması halinde, hukukî sonucun doğması için, inşaî hak sahibinin bu hakkını mahkeme aracılığı ile kullanması, yani (inşaî) dava açması gerekir.

3) İnşaî Davada Verilen Hüküm

Mahkeme, inşaî **davanın reddi**ne karar verirse, bu ret kararı inşaî bir hüküm değildir; eda ve tespit davalarında verilen hükümler gibi bir **tespit hükmü**dür. Çünkü bu ret hükmü ile, davacının varlığını iddia ettiği inşaî hakkın mevcut olmadığı tespit edilmiş olur (yeni bir hukukî durum yaratılmış olmaz).

Mahkeme, inşaî **davanın kabulü**ne karar verirse, bu kabul kararı **inşaî niteliktedir**. Çünkü bu kabul kararı ile, yeni bir hukukî durum yaratılır veya mevcut hukukî durum değiştirilir veya ortadan kaldırılır. Hükmün bu inşaî niteliğine, "**inşaî etki**" (veya yenilik doğurma etkisi) denir.

İnşaî hükümlerin icra (infaz) edilmesine gerek yoktur. İnşaî tesir, hükmün verilmesi ve kesinleşmesi ile kendiliğinden doğar (meydana gelir).

Ancak, inşaî hükmün, aynı zamanda bazı edimlere mahkûmiyeti de içermesi halinde, bu edimlerin alınması için, hükmün icraya konulması mümkündür. Örneğin, boşanma hükmünde nafakaya ve çocuğun ana babadan birine teslimine de karar verilmiş olmasında olduğu gibi (bkz. İİK m. 25, 32, 344).

Bundan başka, inşaî hükümlerin yargılama giderlerine ilişkin bölümü, bir eda hükmü olup, ilâmların icrası yolu ile (İİK m. 32) icraya konabilir.

4) İnşaî Dava Çeşitleri

İnşaî davalar, meydana getirdikleri inşaî etki (yenilik doğuran etki) bakımından ikiye ayrılır:

a) Geleceğe Etkili İnşaî Davalar

İnşaî davaların kabulü halinde verilen inşaî kararlar, kural olarak **geleceğe etkilidir**. Yani inşaî etki, kural olarak gelecek içindir; geçmişe etkili değildir. Geleceğe etkili inşaî davaların kabulü halinde verilen inşaî kararlarda, hukukî durumdaki değişiklik (yeni hukukî durum yaratılması), ancak inşaî kararın (hükmün) kesinleşmesi ile meydana gelir. Örneğin, eşler ancak boşanma kararının kesinleştiği tarihte boşanmış olurlar; geçmişteki evlilik, geçmişte geçerli olarak kalır.

Geleceğe etkili inşaî davaların başlıcaları şunlardır:

Derneklerin feshi davası (TMK m. 89), vakıfların feshi davası (TMK m. 116), evlenmenin butlanı davası (TMK m. 146 ve 156), evlenmenin feshi davası (TMK m. 148 vd.), boşanma (ve ayrılık) davası (TMK m. 148 vd.), aile malları ortaklığının feshi davası (TMK m. 380, 5), mirasın taksimi davası (TMK m. 642), paylaştırma (taksim) ve şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davaları (TMK m. 699, 703), adî şirketin feshi davası (TBK m. 639, 7), kollektif şirketin feshi davası (TTK m. 243, TBK m. 639, 7; TTK m. 249), komandit şirketin feshi davası (TTK m. 243, 328; TBK m. 639, 7; TTK m. 249), anonim şirketin feshi davası (TTK m. 530), limited şirketin feshi davası (TTK m. 636, 4; 638, 2), taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için açılan davalar, geleceğe etkili inşaî dava niteliğindedir (TMK m. 705).

b) Geçmişe Etkili İnşaî Davalar

Bazı inşaî davaların kabulü halinde verilen inşaî kararlar (hükümler), (eda ve tespit davalarında verilen hükümlerde olduğu gibi) **geçmişe de etkilidir**. İnşaî hükümlerin geçmişe etkili olması (geriye yürümesi) istisna olup, ancak özel bir sebep (neden) bulunması halinde mümkündür.

Geçmişe etkili inşaî davaların başlıcaları şunlardır:

Soybağının reddi davası (TMK m. 286), soybağının düzeltilmesine itiraz davası (TMK m. 294), evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası (TMK m. 317, 318), babalık davası (TMK m. 301), ölüme bağlı tasarrufların iptali davası (TMK m. 557 vd.), anonim şirket genel kurul kararlarının iptali davası (TTK m. 445 vd.), limited şirket genel kurul kararlarının iptali davası (TTK m. 622), kooperatif genel kurulu kararlarının iptali davası (Kooperatifler K. m. 53), tenkis davası (TMK m. 560 vd.).

B) DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ

Roma hukukunda olduğu gibi davalar, konularını teşkil eden hakkın niteliğine göre üçe ayrılabilir:

Aynî davalar (ayın davaları): Konusu aynî hak olan davalardır (örneğin, istihkak davaları, müdahalenin önlenmesi davaları gibi).

Kişisel davalar: Konusu kişisel hak olan davalardır (örneğin, alacak davaları, tahliye davaları gibi).

Karma davalar: Konusu hem aynî hem de kişisel hak olan davalardır (örneğin, müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davasının birlikte açılması gibi).

Bu ayrım, özellikle aynî-kişisel dava ayrımı, HMK'nun 12. maddesinin uygulanması bakımından önemlidir.

C) DAVA KONUSU MALA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ

Davalar (mal davaları), konularının taşınır veya taşınmaz olmasına göre de ikiye ayrılabilir:

Taşınır Davaları: Buradaki taşınır davaları terimi, taşınmaz davalarının karşıtı olarak kullanılmakta olup, konusu taşınır mal olan her dava buradaki anlamda taşınır davasıdır. Taşınır davası terimi, TMK m. 989'da düzenlenmiş olan ve doktrinde taşınır davası olarak da isimlendirilen dava ile aynı değildir. Buradaki taşınır davaları terimi, TMK m. 989'daki davalar dahil olmak üzere, konusu taşınır mal olan bütün davaları kapsar.

Taşınmaz Davaları: Konusu taşınmaz olan davalardır; istihkak davası, müdahalenin önlenmesi davası, tahliye davası vs. gibi.

Bu ayrım örneğin HMK m. 8, 12; İİK m. 24, 26-29 hükümlerinin uygulanması bakımından önemlidir.

D) DAVA KONUSUNUN AYNÎ HAK VEYA ZİLYETLİK OLMASINA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ

Davalar (mal davaları), aynî hakları veya yalnız zilyetliği korumaları bakımından da hakka dayanan davalar ve zilyetliğe dayanan davalar biçiminde ayrılabilir.

Bu ayrım, özellikle HMK m. 4, 1/c hükmünün uygulanması bakımından önemlidir.

E) TALEP SONUCUNUN SAYISINA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ

I – TERDİTLİ DAVALAR

1) Genel Bilgi

Terditli (kademeli) davada, davacı aynı davalıya karşı aralarında hukukî veya ekonomik bağlantı bulunan birden fazla talebini, **aralarında aslîlik ve fer'ilik ilişkisi kurarak** aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir (m. 111, 1). Örneğin (A)'nın bir taşınırı (B) tarafından alınmıştır ve (A) uğradığı zararın gide-

rilmesi için (B)'ye dava açmayı düşünmektedir. Ancak (B)'nin bu mala hâlâ sahip olup olmadığını bilmemekte ve dava dilekçesinin istem sonucu kısmında malı mı yoksa malın bedelini mi talep edeceğinde tereddüt etmektedir. Böyle bir durumda (A), dava dilekçesinde asıl talep olarak malın (aynen) iadesi; mal (B)'nin elinden çıkmışsa yardımcı talep olarak malın bedelinin verilmesini terditli olarak dava edebilir.

Bir davanın terditli (kademeli) dava olarak nitelendirilebilmesi için, davalıya karşı ileri sürülen birden fazla talep arasında bir aslîlik-fer'ilik ilişkisi olmalı ve dava dilekçesinde bu husus belirtilmiş olmalı; bu koşulun yanında, bu aslî ve fer'i talepler arasında hukukî veya ekonomik bir bağlantı bulunmalıdır. Bu koşullara uyulmadan, bir dava terditli olarak açılırsa, mahkeme, bu davaların ayrılmasına karar verebilir.

Terditli davadaki taleplerden biri asıl taleptir; ikincisi fer'i (yardımcı, terditli, kademeli) taleptir. Davacı, ilk önce asıl talep hakkında karar verilmesini ister; yardımcı talebini ise, asıl talebin reddedilmesi olasılığı için yapar. Mahkeme de, davacının asıl talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer'i talebi inceleyemez ve karara bağlayamaz (m. 111, 2).

2) Terditli Davaların Çeşitleri

Terditli davalar, dayandıkları vakıaların (olay ve olguların) aynı veya başka olmasına göre başlıca iki şekilde olur:

a) Taleplerin Dayandığı Vakıaların Aynı Olması

Bu halde, asıl talep ile fer'i (yardımcı) talebin dayandığı maddî vakıalar aynıdır; yalnız (bu vakıalara dayandırılan taleplerin) hukukî sebebi değişiktir.

Örneğin, bir kimse (davacı), iyiniyetle başkasının arsasına inşaat yapmıştır (TMK m. 722 vd.). Bu kimse, binanın kıymetinin arsa kıymetinden açıkça fazla olduğunu sanarak haklı bir tazminat karşılığında arsa ve binanın mülkiyetinin kendisine verilmesini, TMK m. 724 hükmüne dayanarak ve asıl talep olarak istemektedir. Ancak, mahkemece yapılacak inceleme (tahkikat) ve kıymet takdiri sonucunda, binanın kıymetinin arsanın kıymetinden daha az olduğu tespit edilirse, bu olasılıkta da TMK m. 723 hükmüne göre ve fer'i talep olarak, kullandığı malzeme karşılığı tazminat istemektedir.

Yukarıdaki örnekte, davacının dava dilekçesinde dayandığı vakıalar aynıdır. Başkasının arsasına iyiniyetle inşaat yapılmış olmasıdır. Yalnız, bu vakıaların hukukî nitelendirilmesi terditli olarak yapılmaktadır. Mahkeme, maddî vakıaları tespit ettikten sonra, o vakıalara uyan kanun hükmünü kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olduğundan (m. 33) ve bu konuda tarafların yapmış oldukları hukukî nitelendirme (hukukî sebepler) ile bağlı olmadığından, mahkeme, arsa ve binanın haklı bir tazminat karşılığında davacıya verilmesine (TMK m. 724), bu olmazsa malzemesine karşılık olmak üzere davacıya bir tazminat ödenmesine (TMK m. 723) karar verir.

b) Taleplerin Dayandığı Vakıaların Farklı Olması

Bu halde, asıl talep ile fer'i (yardımcı) talebin hem dayandıkları vakıalar hem de bunların hukukî sebepleri değişiktir.

Örneğin davacı, ölüme bağlı bir tasarrufun iptalini (TMK m. 558-560) istemekte (asıl talep); iptal sebepleri yerinde görülmezse bu ölüme bağlı tasarrufla yapılan bağışın tenkisini (TMK m. 560 vd.) istemektedir (fer'i talep). Burada, her iki talebin dayandığı vakıalar (TMK m. 558 ve 559'daki vakıalar) ile saklı paya tecavüz edilmiş olduğu vakıası başka olduğu gibi, bunların hukukî nitelendirilmesi (hukukî sebep) de (iptal, tenkis) başkadır.

3) Terditli Davanın İncelenmesi

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, terditli davanın dinlenebilmesi (mesmu olması) için, asıl talep ile fer'i talep arasında hukukî veya ekonomik bir bağlantı bulunması ve her iki talebin de hukukî ve ekonomik bakımdan aynı veya benzer amaca yönelmiş olması gerekir (m. 111, 1).

Terditli davada mahkeme, ilk önce asıl talep hakkında inceleme yapar; bunu yerinde bulursa, fer'i (yardımcı) talebin incelenmesine gerek kalmaz. Asıl talep yerinde görülmezse, o zaman yardımcı talebin incelenmesine geçilir. Fer'i talep de aynı vakıaya dayandığı veya asıl taleple bağlantılı olduğu için, mahkemenin yardımcı talebi aynı davada incelemesi (tahkikatın ortak yapılması), yardımcı talebin ayrı bir dava konusu yapılması haline oranla çok daha kolay, basit ve ucuz olur; dava, usul ekonomisi ilkesine göre görülüp karara bağlanmış olur.

II – SEÇİMLİK DAVALAR

Seçimlik (alternatif) davalar, seçimlik (seçmeli) borçlarda söz konusu olabilir. Bilindiği gibi, bir borcun (edimin) konusu iki veya daha fazla şey olur ve bunlardan birinin ifa edilmesiyle borç yerine getirilebilirse, bu gibi borçlara **seçimlik borçlar** denir. Ancak, bir borcun seçimlik borç sayılabilmesi için, seçim hakkının ya alacaklıya ya da borçluya tanınmış olması, başka bir deyişle borcun konusu olan şeylerden hangisinin yerine getirileceğinin, sadece ya alacaklı ya da borçlunun iradesine tâbi bulunması gerekir. Örneğin, borcun konusu bir buzdolabı veya bir fırın olur ve bunlardan birini yerine getirmek (vermek) veya istemek hakkı borçluya veya alacaklıya ait ise, borç seçimlik bir borçtur.

Buna karşılık, Ahmet, Mehmet'e bir buzdolabı vereceğini ve fakat Mehmet'e bir başkası tarafından buzdolabı verilmesi halinde ona bir fırın vereceğini taahhüt etmişse, bu bir seçimlik borç değildir. Çünkü, borç konusu olan şeylerden birinin veya diğerinin yerine getirilmesi hususunda Ahmet'e bir seçim hakkı tanınmamış, bu husus onun iradesine bırakılmamıştır.

Seçimlik borçlar, seçim hakkının borçluda veya alacaklıda olmasına göre ikiye ayrılır:

Seçimlik dava, ancak **seçim hakkının borçluya ait olması** halinde mümkündür. TBK'nun 87. maddesine göre, seçimlik borçlarda, hukukî ilişkiden ve

işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edimlerden birinin seçimi borçluya aittir. Bu hüküm gereğince seçim hakkı borçluda ise, alacaklının borç konusu şeylerden yalnız biri için (normal bir) dava açmasına imkân yoktur. Bu halde, alacaklı borçluya karşı açacağı davada seçimlik (alternatif) olarak talepte bulunmak zorundadır. Yukarıdaki örnekte alacaklı, davasında borçlunun seçimine göre buzdolabı veya fırını vermeye mahkûm edilmesini istemelidir.

Seçimlik borçlarda, seçim hakkı kendisine ait olan borçlu veya hukukî ilişkide kendisine seçim hakkı tanınan üçüncü kişi bu hakkı kullanmaktan kaçınırsa, alacaklı seçimlik dava açabilir (m. 112, 1).

Seçimlik davada, mahkeme talebi kabul ederse, seçimlik mahkûmiyet kararı (hüküm) verir (m. 112, 2). Alacaklı, böyle seçimlik bir mahkeme ilâmını icraya koyarken (İİK m. 24 vd.), icra takibini borç konularından birine hasretmelidir. Fakat borçlu, icra takibinin sonuçlanmasına kadar, takibe konu yapılmayan diğer seçimlik edimi yerine getirmek suretiyle kendini borçtan kurtarabilir (m. 112, 3).

Seçim hakkı alacaklıda ise (örneğin, aralarındaki hukukî ilişkiye göre alacaklı, borçludan bir buzdolabı veya fırın isteyebilecekse), bu halde alacaklı **seçimlik dava açamaz.** Alacaklının, ilk önce seçim hakkını kullanıp, seçtiği şeyin (buzdolabı veya fırının) verilmesi için (yoksa ikisinden birinin verilmesi şeklinde değil) dava açması gerekir. Buna rağmen alacaklı, seçimlik dava açarsa (veya davasında her iki edimi de birlikte isterse), mahkemenin, edimlerden (taleplerden) hangisini seçtiğini davacıdan sorması gerekir. Davacı buna rağmen seçim hakkını kullanmazsa, mahkemenin davayı reddetmesi gerekecektir.

Görüldüğü gibi, seçimlik davada birden çok dava bir arada değildir. Borcun konusu ve talep tektir.

III – DAVALARIN YIĞILMASI (Objektif Dava Birleşmesi)[16]

Davacı, davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden fazla aslî talebini (alacağını) aynı davada birleştirebilir; yani **birden fazla davasını** (birden fazla talebini) aynı dava dilekçesi ile açabilir; buna **davaların yığılması** (objektif dava birleşmesi) **denir** (m. 110). Bu halde, davada birlikte açılan dava sayısı kadar istem sonucu (talep neticesi) ve dava konusu vardır. Örneğin, davacının ödünç sözleşmesinden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan iki ayrı alacağını, bir dava ile davalıdan istemesi gibi. Bir başka deyişle, davacı birden fazla davasını aynı dava dilekçesi ile açabilir. Bu durumda davada birlikte açılan dava sayısı kadar istem (talep) sonucu ve dava konusu vardır. İşte, bu durum m. 110'da davaların yığılması olarak düzenlenmiştir.

Terditli dava ile davaların yığılmasını ayıran özellik, davaların yığılmasında ileri sürülen talepler arasında, aslîlik ve fer'ilik ilişkisinin bulunmaması, taleplerin tamamının birbirinden bağımsız olmasıdır.

---

[16] Bkz. Uğur Bulut, Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması, Ankara 2017.

Davaların yığılmasının şartlarını aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

Davaların yığılması için, birlikte açılan davalar (talepler, alacaklar) arasında herhangi bir bağlantı bulunması gerekli değildir.

Birden fazla aslî talebin ileri sürüldüğü davanın, aynı davacı (alacaklı) tarafından aynı davalıya (borçluya) karşı açılması gerekir. Birlikte ileri sürülen talepler arasında hukukî veya ekonomik bir bağın bulunması şart değildir.

Dava yığılması olarak dava edilen taleplerin (davaların) tamamının aynı yargı çeşidi içinde ve aynı yargılama usulüne tâbi görevli mahkemede ileri sürülmesi ve taleplerin tümü bakımından **ortak yetkili bir mahkeme**nin bulunması gerekir. Bu nedenle örneğin, sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu bir dava asliye hukuk mahkemesinin görevine giren dava ile birlikte görülemez; burada dava yığılması olmaz.

Dava yığılmasında, görünüşte tek bir dava dilekçesi bulunmasına karşın, aslında dava dilekçesinde belirtilen **talep sayısı kadar birbirinden ayrı bağımsız dava vardır** ve yargılamada her bir dava (talep) bağımsız olarak ayrı ayrı işlem görür ve karara bağlanır.

IV – HAKLARIN YARIŞTIĞI (MÜTELÂHİK) DAVALAR

Buraya kadar incelenen terditli davaları ve dava yığılmasını (objektif dava birleşmesini), mütelâhik (hakların yarıştığı) davalar ile karıştırmamak gerekir. Bu iki dava çeşidinde, birden fazla talep vardır. Oysa, hakların yarıştığı davada tek bir talep vardır.

Hakların yarıştığı davayı ayrı bir dava çeşidi olarak incelememizin nedeni, hem hakların yarıştığı davanın yukarıda görülen üç dava çeşidi ile karıştırılmasını önlemek hem de hakların yarıştığı davayı normal bir davadan ayıran özelliği belirtmektir.

Hakların yarıştığı davayı normal bir davadan **ayıran özellik**, bir davada talep sonucunu haklı gösteren bir hukukî sebep bulunduğu halde, hakların yarıştığı davada **birden fazla hukukî sebep vardır**. Aynı talep sonucunun, birden fazla hukukî sebebe dayanması, **hakların** yarışması (telâhuku) anlamına gelir. Örneğin, (A)'nın malik olduğu tarla, kötüniyetli zilyet (B) tarafından ekilmekte ve ürün bedelleri de (B) tarafından tahsil edilmektedir. Bunu öğrenen (A), elde edilen bedellerin tahsili için (B)'ye karşı açtığı davada, vekâletsiz iş görme ile ilgili TBK m. 530 hükmüne veya iyiniyetli olmayan zilyedin iade borcu ile ilgili TMK 995 hükmüne de dayanabilir. Yani (A), her iki kanun hükmünden de yararlanarak dava açabilir.

Hâkim, davacının bildirdiği hukukî sebeple bağlı olmayıp, davacının dayandığı vakıaya/vakıalara (dava sebebine) uygulanacak kanun hükmünü kendiliğinden araştırıp bulmak ve uygulamakla yükümlü olduğundan (m. 33), hakların yarışması halinde de davacının yarışan kanun hükümlerini (hukukî sebebi) noksan göstermiş veya hiç göstermemiş olmasının bir önemi yoktur. Hâkim davaya uygulanacak kanun hükümlerini kendiliğinden araştırıp bulmakla yükümlüdür. Burada, hâkimin yarışan kanun hükümlerinden **davacı için daha elverişli olan kanun hükmünü** (hukukî sebebi) kendiliğinden gözetip **uygulaması** gerekir.

TBK m. 60'da "sorumluluk sebeplerinin çokluğu, sebeplerin yarışması" başlığı altında özel bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre, "bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir" (TBK m. 60).

F) TALEP SONUCUNDAN YARARLANACAKLARA GÖRE DAVA ÇEŞİDİ OLARAK TOPLULUK DAVASI

Yargılama hukuku sistemimizde, dava açılabilmesi için davacının hukukî yararının bulunması gerekir ve hukukî yararın varlığı dava şartlarındadır (m. 114, 1/h). Bu husus yukarıda incelendi[17].

Bu sebeple davacı, ancak kendi hukukî yararının korunması için dava açabilir; başka birinin hukukî yararının korunması için açılan dava, hukukî yarar yokluğundan reddedilir.

Hal böyle olmakla birlikte, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda dernek, sendika veya diğer tüzel kişilerin; üyelerinin veya mensuplarının menfaatlerini korumak amacıyla dava (topluluk davası; sınıf davası; grup davası; class action) açabilip açamayacakları tartışılmış ve bu yönde mevzuatta değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Örneğin, Tüketicinin Korunması Hakkında K. m. 73, 6'da, "Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık (Ticaret Bakanlığı); haksız ticarî uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hallerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir" hükmüne yer verilmiştir. İşte, bu hüküm ve aynı maddenin 7. ve 8. fıkra hükümleri topluluk davası hakkındadır.

HMK m. 113 hükmü ile de, **topluluk davası**[18] adı verilen bir dava türü genel olarak düzenlenmiştir. Buna göre; **dernekler** ve **diğer tüzel kişiler**, statüleri (tüzükleri, anasözleşmeleri, senetleri vb.) çerçevesinde, **üyelerinin** veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin **menfaatlerini korumak amacıyla**, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlâl edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilirler.

Topluluk davası ile, ilgililerin haklarının tespit edilmesi; hukuka aykırı durumunun giderilmesi; ilgililerin gelecekteki haklarının ihlalinin önüne geçilmesi sağlanır.

Topluluk davasında verilen hükmün ilgililer hakkında kesin hüküm oluşturup oluşturmayacağı, dava sırasında derdestlik itirazına konu olup olmayacağı, bu konular hakkındaki HMK hükümlere göre belirlenir.

---

17 Bkz. yuk. § 15, III, 2.

18 Bkz. İbrahim Özbay, Grup Davaları, Ankara 2009; Melis Taşpolat Tuğsavul, Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları, İstanbul 2016; Emel Hanağası, Kollektif Menfaatin Hukuki Himayesi Biçimi Olarak Topluluk Davaları (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. II, Ankara 2009, s. 351-410).

G) SERİ DAVA

İleride[19] görüleceği üzere, dava konusu olan hak veya borcun (elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple) ortak olması, ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmeleri veya davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması hallerinde, **birden fazla kişi** isterlerse davacı sıfatıyla, **ihtiyarî dava arkadaşı** olarak tek bir dava dilekçesiyle dava açabilirler (m.57). İhtiyari dava arkadaşlığında, ortada şeklen tek bir dava dosyası olmasına rağmen, hukuken davacı sayısı kadar dava vardır; davalar birbirinden bağımsızdır ve dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız olarak hareket eder (m.58). Uygulamada taraf vekilleri bazen, birden fazla kişinin davasını ihtiyarî dava arkadaşlığı şeklinde değil de, hazırlanan aynı tip dilekçeye her bir davacının adını yazarak ayrı ayrı davalar açmakta ve bu davalar genellikle birleştirilmektedir. Özellikle iş hukukunda ortaya çıkan bu uygulamada, aynı tip dilekçe ayrı ayrı bazen yüzlerce imzalanmak suretiyle dava açılmakta ve mahkemeler de bu davaları genellikle birarada görmeyi tercih etmektedirler. Bu davalara uygulamada **seri dava** adı verilmektedir.

Seri davalar uygulamada özellikle avukatlık ücreti bakımından tartışılmış, çeşitli Yargıtay kararlarına konu olmuş ve seri dava açan avukata her bir dava için ayrı ayrı (tam) avukatlık ücreti hükmedilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu tartışmaların neticesinde konu, "seri davalarda ücret" kenar başlığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde (m.22) özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, "**İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü** olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış beş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70'i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz doksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz doksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40'ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir".

Bilirkişilik Asgarî Ücret Tarifesine (m. 9) göre, "Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır".

---

19 Bkz. aşa. § 47, B.

§ 17. DAVA AÇILMASI

A) GENEL BİLGİ

Dava, davanın tarafları, davaya vekâlet, dava şartları ve dava çeşitleri konuları incelendikten sonra hukuk davalarında asıl görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerinde uygulanan yargılama usulünün incelenmesi gerekir. Sulh hukuk mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulü ve bu usulün asliye hukuk mahkemelerinde uygulanan usule göre özellikleri ise ileride incelenecektir[1].

Asliye hukuk mahkemelerinde uygulanan usul, **yazılı yargılama usulüdür** (m. 118-315). Bu usulde, özellikle dava malzemesinin hazırlanması, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi yazılı olur. Ancak, yazılı yargılama usulünde, hâkim iki tarafı dinlemeden hüküm veremez (m. 27; 137 vd.; 143 vd.; 184 vd.). Asliye hukuk mahkemelerindeki usul, yazılı yargılama usulü olmakla beraber, yargılama yalnızca yazılı belgeler ve dosya üzerinde cereyan etmez; mahkeme tarafları duruşmada sözlü olarak da dinler.

Mahkemenin bir davaya bakabilmesi için, davacının talebi şarttır. Bu talep, **dava dilekçesi** ile dava açmak suretiyle yapılır. Hâkim, davacının talebi olmadan kendiliğinden bir davaya bakamaz[2]. Açık bir kanun hükmü[3] olmadıkça, hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamaz (m. 24, 2). Ancak, dava hakkının kullanılması da hukukî yararın bulunması şartına bağlıdır.

Bir kimsenin kendi lehine olan bir davayı açmaması, hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemez[4].

B) DAVA DİLEKÇESİ

Dava, bir dilekçe[5] ile açılır (m. 119). Burada önce dava dilekçesinin içeriği, daha sonra da sırasıyla dava dilekçesinde eksiklik bulunması, dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve davanın açılma zamanı incelenecektir.

Davacı, dava dilekçesini çok iyi bir hazırlığa dayalı olarak yazmalı, bu konuda özen göstermeli, HMK, Yazışleri Yönetmeliği ve özel kanun hükümlerine mutlak uygun hareket etmelidir. Davalı da, cevap dilekçesini hazırlarken aynı şekilde davranmalıdır. Bu sayede davanın sağlam bir temele da-

---

1 Bkz. m. 316-322; aşa. § 69.
2 Bkz. m. 24, 2; yuk. § 5, C.
3 Bir kimsenin kendi lehine olan davayı açmaya zorlandığı istisnaî bazı haller için bkz. İİK m. 33a, II; 69, III; 97, VI; 99; 228, II; 276, III; 302.
4 Bkz. yuk. § 5, N.
5 Bir dava dilekçesi örneği için, Kitabın sonuna ekli (1) no.lu örneğe (aşa. § 81) bakınız.

yanması sağlanır. Davanın, dava dilekçesi ile kazanılacağından veya kaybedileceğinden söz edilirken, dava dilekçesinin önemi vurgulanmaktadır.

I – DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ

Dava dilekçesinde nelerin yer alacağı[6], 119. maddede gösterilmiştir. Buna göre, dava dilekçesinde şu hususlar bulunur: 1) Mahkemenin adı (görevli ve yetkili mahkeme), 2) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, 3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 4) Varsa tarafların yasal temsilcileri ve davacı vekilinin ad ve soyadları ile adresleri, 5) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, 6) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların (olay ve olguların) sıra numarası altında açık özetleri (m. 194, 1), 7) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği (m. 194, 2), 8) Dayanılan hukukî sebepler (m. 33), 9) Açık bir şekilde talep sonucu, 10) Davacının, varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası.

Burada, sadece dava dilekçesine nelerin yazılması gerektiğinin sayılmasıyla yetinilmeyecek, aynı zamanda bunların geniş bir açıklaması yapılacak ve bundan başka dava açılması ile ilgili gördüğümüz, örneğin, hukukî sebep, vakıalar, dava sebebi, talep sonucu gibi ana kavramlar hakkında da açıklama yapılacaktır:

1) Mahkemenin Adı

Dava ile mahkemeden hukukî korunma istendiğinden, dava dilekçesinin başına, hangi mahkemeden hukukî korunma istendiği açıkça yazılmalıdır (m. 119, 1/a). Davacı, HMK veya varsa özel kanun hükmüne göre görevli ve yetkili olan mahkemeyi önceden belirler ve dava dilekçesinin başına yazar ve dava dilekçesini o mahkemeye verir; davayı o mahkemede açar.

Davanın açıldığı mahkeme aslında görevli veya yetkili olmasa bile, dava dilekçesi geçerlidir. Mahkeme, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verecek olursa, davacı, mahkemenin görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde görevli veya yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle (m. 20), görevsiz veya yetkisiz mahkemede açmış olduğu davaya (görevli veya yetkili) mahkemede devam edilmesini sağlayabilir[7].

Bir yerde birden fazla asliye hukuk mahkemesi varsa, o zaman, davacı, dilekçenin o yerdeki kaçıncı asliye hukuk mahkemesine gideceğini bilemeyeceğinden ve aslında bu tür bir tercih hakkı da olmadığından, dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi (dağıtım) işiyle görevli yazı işleri personeline teslim edilir (Y m. 197, 1). Davanın elektronik ortamda UYAP üzerinden açılması halinde dava dilekçesi sisteme kaydedilir ve işlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur (Y m. 197, 8).

---

6 Bkz. Ramazan Arslan, Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması ve Ön İnceleme (Bankacılar Dergisi sa. 80, Mart 2012, s. 67-82). Ayrıntılı örnekler için bkz. ayrıca, Ejder Yılmaz/Ümit Yılmaz, Hukuk Rehberi (5 Cilt), Ankara 2006.

7 Bkz. yuk. § 9-10.

2) Davacı ile Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri

Dava dilekçesine tarafların (davacı ile davalının) ad ve soyadları ile adreslerinin yazılması gerekir (m. 119, 1/b). Konunun, davacı ve davalı için ayrı ayrı incelenmesi gerekir:

a) Davacının Adı, Soyadı ve Adresi

Dava dilekçesinde davacının adı, soyadı veya adresi **yazılmamışsa**, hâkim davacıya **eksikliği tamamlaması** için bir haftalık kesin süre (m. 94) verir; eksiklik bu süre içinde tamamlanmazsa, dava açılmamış sayılır (m. 119, 2).

Buradaki adres, dava sırasında kendisine yapılacak olan tebligat adresidir. Bu adres, ev adresi, işyeri adresi veya başka bir adres de olabilir.

Davacı taraf birden çok kişiden oluşuyorsa, bu kişilerin hepsinin adı, soyadı ve adresinin yazılması gerekir. Bu isimler daha sonra değiştirilemez (m. 124). Ancak, yazım hatası (maddî hata) varsa düzeltilebilir (m. 183).

b) Davalının Adı, Soyadı ve Adresi

Dava dilekçesinde davalının adı, soyadı veya adresi **yazılmamışsa**, hâkim, davacıya **eksikliği tamamlaması** için bir haftalık kesin süre (m. 94) verir; eksiklik bu süre içinde tamamlanmazsa, dava açılmamış sayılır (m. 119, 2).

Buradaki adres, dava sırasında kendisine yapılacak olan tebligat adresidir. Bu adres, ev adresi, işyeri adresi veya başka bir adres de olabilir.

Davacının, dilekçede davalının adresini gösterme zorunluluğu, davacının, davalıya ait bir adresi bilmesi halinde geçerlidir. Buna karşılık, davacı, davalının adresini bilemiyorsa, adres araştırması yapmak, mahkemenin görev ve yetkisine girer. Bu halde varsa, davalının mahkeme tarafından tespit edilen MERNİS adresine tebligat yapılır. Davalının adres kaydı yoksa ve tüm araştırmalara rağmen, adres tespit edilememişse, dava dilekçesi, davalıya ilânen tebligat yolu ile tebliğ edilir (Teb. K. m. 28-30; Teb. Yön. m. 48-52).

3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Dava dilekçesinde gerçek kişi davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilir (m. 119, 1/c). Bu gereklilik, doğal olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içindir.

Dava dilekçesinde davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası **yazılmamışsa**, hâkim davacıya **eksiği tamamlaması** için bir haftalık kesin süre verir; eksiklik bu süre içinde tamamlanmazsa, dava açılmamış sayılır (m. 119, 2).

Buna karşın davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının davacı tarafından dilekçede bildirilmesi zorunlu değildir.

4) Varsa Tarafların Yasal Temsilcileri ve Davacı Vekilinin Ad ve Soyadları ile Adresleri

Davacı veya davalının dava ehliyetinin (m. 51) bulunmaması halinde davacı veya davalı, davada yasal temsilcileri tarafından temsil olunur. Bu nedenle, davacı veya davalının yasal temsilcisi varsa, dava dilekçesinde taraf olarak yazılı bulunan davacı veya davalı tarafın adı, soyadı ve adresinin yanı sıra, ilgili tarafın/tarafların yasal temsilcisinin adı, soyadı ile adresi de yazılır (m. 119, 1/ç).

Davacı (veya varsa yasal temsilcisi), davayı bir **vekil** (avukat) aracılığıyla da açabilir (m. 71). Bu halde dava dilekçesinde, ayrıca vekilin adı, soyadı ve adresinin de gösterilmesi gerekir (m. 119, 1/ç).

Dava açılırken davalının (o davada) vekilinin kim olacağı bilinemeyeceğinden, dava dilekçesinde davalı vekilinin isim ve adresinin yazılmasına olanak ve gerek yoktur. Nitekim, m. 119, 1/ç'de de iki tarafın vekillerinden değil, (yalnızca) "davacı vekili"nden söz edilmektedir. Davalının bir genel vekili olsa bile, dava dilekçesine genel vekilin isim ve adresi yazılarak, dava dilekçesi bu genel vekile tebliğ edilemez.

Yasal temsilci veya vekil bulunmasına rağmen dava dilekçesine yazılmamışsa veya eksik yazılmışsa, hâkim, davacıya **eksikliği tamamlaması** için bir haftalık kesin süre verir; eksiklik bu süre içinde tamamlanmazsa, dava açılmamış sayılır (m. 119, 2).

5) Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri

Dava dilekçesinin bu bölümüne, anlaşılır biçimde kısaca davanın konusunun yazılması gerekir (m. 119, 1/d); örneğin, "On bin liralık alacak davasıdır; el atmanın önlenmesi davasıdır" gibi.

Dava konusu para değil de, para ile ölçülebilmesi mümkün olan (malvarlığı haklarından doğan) bir konu ise, davacı dava dilekçesinde dava konusunun değerini, **para olarak** göstermek zorundadır. Bu husus, davanın açılması sırasında yatırılacak olan harçların hesabı bakımından da önemlidir. Dava dilekçesinde değer gösterilmemişse, bu değer (mahkemece) davacıya tespit ettirilir. Davacının mahkemece verilecek uygun süre içinde dava konusunun değerini tespit etmekten kaçınması halinde, dava dilekçesi işleme konmaz (Harçlar K. m. 16, II).

Yargılama sırasında dava konusunun değerinin (dava dilekçesinde bildirilenden) daha fazla olduğu tespit olunursa (anlaşılırsa), yalnız o oturum için davaya devam edilir. Ondan sonraki oturuma kadar eksik değer üzerinden peşin karar ve ilâm harcı **tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz**; yani dosya işlemden kaldırılır (Harçlar K. m. 16, IV; 30; HMK m. 150).

Belirsiz alacak ve tespit davası açılmışsa (m. 107), davacının, dilekçesinde, belirleyebildiği asgari miktarı veya değeri göstermesi yeterlidir.

Dava konusunun değeri ya da miktarı yabancı para olarak gösterilmiş olsa bile, alınacak harcın belirlenebilmesi için bu değer ya da miktarın Türk Lirası tutarının da dilekçeye yazılması gerekir.

Dava, niteliği itibariyle taraflar arasında geleceğe yönelik olarak çıkması olası olan uyuşmazlığın (muarazanın) da giderilmesine ilişkin ise ve çıkabilecek uyuşmazlığın miktarının (değerinin) bilinmesi mümkün değilse, bu taleple ilgili olarak, davacının dava dilekçesinde değer/miktar bildirmemiş olması m. 119, 1/d hükmüne aykırılık oluşturmaz.

6) Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri[8]

Davacı, iddiasının (davasının) dayanağı olan bütün vakıaların (olayların ve olguların) **sıra numarası altında açık özetleri**ni dava dilekçesinde yazmalıdır (m. 119, 1/e). Bunlar, dava dilekçesindeki talep sonucunun dayanağı olan ve bu talep sonucunu haklı göstermeye elverişli bulunan vakıalardır (olay ve olgulardır). Bu vakıalar, maddî bir fiil olabilir; örneğin, haksız fiil teşkil eden bir otomobil çarpması, bir iş kazası gibi; bir hukukî işlem de olabilir; örneğin, bir satış sözleşmesi, kira sözleşmesi gibi.

Vakıaların oluş tarihlerine göre bir sıra içinde (sıra numarası altında) dava dilekçesine yazılması gerekir (m. 119, 1/e); bu husus davalının cevap vermesini ve mahkemenin davayı inceleyip karara bağlamasını kolaylaştırır.

Öte yandan, m. 194'e göre de; davacı (ve davalı), dayandıkları vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdır. Kanun (m. 194) buna (vakıaları) **somutlaştırma yükü** demektedir. Bir davada, ispat faaliyetinin tam olarak yürütülebilmesi, mahkemenin uyuşmazlığı doğru tespit ederek yargılama yapabilmesi, karşı tarafın ileri sürülen vakıalara karşı kendini savunabilmesi için, iddia edilen, talep sonucunun dayandırıldığı vakıaların açık ve somut olarak ortaya konulması gerekir. Somut bir şekilde ortaya koymadan iddia veya savunma amacıyla vakıaların ileri sürülmesi durumunda, yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayacağı gibi, vakıaların anlaşılması için ayrıca bir araştırma yapılması ve zaman kaybedilmesi söz konusu olacaktır. Taraflar, haklarını dayandırdıkları hukuk kuralının aradığı koşul (şart) vakıalara uygun, somut vakıaları açıkça ortaya koymalıdırlar. Bu vakıaların somut olarak ileri sürülmesi, ilgili taraf için bir yüktür; bu yükü yerine getirmeyen davacı (taraf) sonuçlarına katlanmak durumundadır[9].

Davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıaların doğru olduğu, yargılama sırasında ispat edilirse ve bu vakıalar, davacıyı talep sonucunda haklı gösteriyorsa, mahkeme davacının davasını kabul ederek, davayı davacı lehine karara bağlar. Örneğin davacı, davalıya elli bin liraya bir mal sattığını, malı teslim ettiğini, fakat davalının satış bedelini ödemediğini bildirerek, davalının elli bin lirayı ödemeye mahkûm edilmesini istiyorsa, dava dilekçesinde, satış sözleşmesi, malın teslimi ve satış bedelinin ödenmediği vakıalarını

---

[8] Bkz. Levent Börü, Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara 2016; Taner Emre Yardımcı, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul 2017.

[9] Bkz. madde ile ilgili Hükümet gerekçesi.

açıklayacaktır. Mahkeme yapacağı inceleme (tahkikat) sonucunda bu üç vakıanın doğru olduğunu tespit ederse, davalıyı, davacıya elli bin lira ödemeye mahkûm eder.

Davacı, davasının dayanağı (temeli) olan bütün vakıaları (açık özetlerini) dava dilekçesinde bildirmekle yükümlü (m. 119, 1/e) olduğundan, davacının, dilekçeler aşamasından (dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinden) sonra (dilekçelerinde bildirmediği) **yeni vakıalar ileri sürmesi, davayı değiştirme** olur; ancak davalının rızası veya ıslah yolu ile davayı değiştirmek mümkündür (m. 141)[10].

Hâkim, davacının dava dilekçesinde göstermediği vakıaları kendiliğinden gözetemez (inceleyemez) ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz (m. 25). Fakat **hâkim**, belirsiz veya çelişik gördüğü iddia ve sebepler (vakıalar) hakkında **açıklama isteyebilir** (m. 31). Ancak, bu açıklama isteme sadece dava dilekçesinde bildirilmiş olan vakıalar içindir. Dava dilekçesinde gösterilmeyen (bildirilmeyen) bir vakıa, ikinci dilekçenin (cevaba cevap dilekçesinin) verilmesinden sonra, açıklama isteme (veya açıklama verme) gerekçesiyle (davalının rızası olmadıkça veya ıslah yoluna başvurulmadıkça) sonradan ileri sürülemez.

Az önce belirtildiği gibi, davacı, davasının dayanağı olan bütün vakıaları dava dilekçesinde bildirmekle yükümlü kılındığı için, kanunumuzun **iddiaların teksifi ilkesini** kabul ettiği kabul edilir.

Hâkim, hukukî sebepleri (kanun hükümlerini) kendiliğinden gözetir (m. 33). Yani hâkim, davacının dava dilekçesinde göstermiş olduğu hukukî sebepler ile bağlı olmayıp, davacının dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaların hukukî sebebini (hukukî niteliğini) kendisi araştırıp bulmakla yükümlüdür. Davacının, dava dilekçesinde hukukî sebebi yanlış göstermiş olmasının bir önemi yoktur.

Hâkim, davacının dava dilekçesinde bildirdiği **vakıalarla bağlı** olup, davacının bildirmediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz (m. 25). Bu nedenle, dava sebebi olan ve talep sonucunun dayandırıldığı vakıalar (olay ve olgular), açık ve somut bir şekilde dilekçede yazılmalıdır ki, ispat edilmeye uygun ve davalının savunma hakkını kullanabilmesine elverişli olsun.

Buna göre, Kanunumuz, ferdileştirme ilkesini (teorisini) değil, **vakıalara dayandırma ilkesini** (teorisini) benimsemiş bulunmaktadır. Çünkü:

Ferdileştirme ilkesine göre, dava dilekçesinde talep sonucunu haklı gösteren hukukî sebeplerin (hukukî ilişkinin) belirtilmesi gerekli ve yeterlidir; vakıaların bildirilmesi gerekli (zorunlu) değildir. HMK m. 119, 1/g uyarınca dayanılan hukukî sebeplerin dava dilekçesinde bulunması gerektiği için Kanunumuzun bu ferdileştirme ilkesini benimsediği sonucuna varılabilirse de, az sonra hukukî sebepler bölümünde ayrıntılı biçimde görüleceği gibi, hukukî sebepler dava dilekçesinin zorunlu bir unsuru olmadığından, Kanunumuzun

[10] Bkz. aşa. § 18, B, III; istisnai düzenleme için m. 139.

ağırlıkla benimsediği sistemin, ferdileştirme ilkesi olmadığını söylemek mümkündür.

Vakıalara dayandırma ilkesine göre, dava dilekçesinde talep sonucunun dayanağı olan ve bu talep sonucunu haklı göstermeye elverişli bulunan bütün vakıaların gösterilmesi gerekli ve yeterlidir. Kanunumuz, m. 119, 1/e hükmü ile, vakıalara dayandırma ilkesini benimsemiş bulunmaktadır. Bu husus, az sonra hukukî sebepleri incelerken daha belirgin bir biçimde görülecektir.

Buna göre, davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıalar **davanın temeli**dir. Çünkü, sadece bu vakıalar davanın sınırını çizmekte, hâkim ancak bu vakıalar hakkında inceleme yapabilmektedir. Bu nedenle, hukukumuzda **dava sebebi** (hukukî sebepler değil) davacının davasını dayandırmış olduğu **vakıalardır**. Yargıtay da bu görüştedir.

7) İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği

HMK m. 119, 1/f'ye göre, davacı, dava dilekçesine, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini yazmalıdır.

Bu hükmün (m. 119, 1/f) gerekçesine göre; davacı dava açarken, dayandığı vakıaların hangi delillerle ispat edileceğini de belirtmek zorundadır[11]. Delil bir ispat aracı olarak, ileri sürülen bir vakıanın doğruluğunu ispat etmeye yaradığı için, dava dilekçesinde her bir vakıa bakımından o vakıayı ispata yarayan ispat araçlarının da belirtilmesi önemlidir. Uygulamada, tarafların iddia veya savunmada bulunurken yeterli araştırma yapmadan vakıalar ileri sürdükleri veya bunların delillerini ortaya koymadan dilekçeler verdikleri görülmektedir. Özellikle taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğu davalarda, mahkemenin yargılamayı doğru yürütebilmesi ve makul bir sürede karar verebilmesi için, delillerin vakıalarla bağlantısı kurularak mahkeme önüne getirilmiş olması gerekir. Bu da tarafların dayandıkları delilleri ve her bir delilin hangi vakıanın ispatı için kullanılacağını belirtmeleriyle mümkün olabilir.

Bu hükme (m. 119, 1/f) göre davacı, dayandığı vakıaların delillerini de gösterir. Bununla dava dilekçesinde "delillerim şunlardan ibarettir" diyen ve bu şekilde delillerini hasretmiş olan **davacı, sonradan başka** (yeni) **delil gösteremez.**

Böylece, davacı, yemin dahil bütün delillerinin nelerden ibaret olduğunu dava dilekçesinde gösterir. Dava dilekçesindeki "**sair kanunî deliller**" deyiminin bir anlamı olmaz, dava dilekçesinde sair deliller denilmiş olsa bile, (dava dilekçesinde) açıkça yemin delili de yazılı değilse davacı, davalıya yemin teklif edemeyecek, dolayısıyla mahkeme de davacıya yemin teklifine hakkı olduğunu hatırlatamayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar, m. 119, 1/f'deki ifadenin yorumu ile varılan sonuçlardır. Ancak, Kanun koyucunun, bu sonuçları isteyip istemediği, gerekçeden tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle uygulamada, dava dilekçesine

---

[11] Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Davalarında Delillerin Gösterilmesi Zamanı (Av. Serdar Özersin'e Armağan, Ankara 2017, s. 11-25).

her türlü delil konulmamakta (yani başlangıçta deliller hasredilmemekte) ve "sair (kanunî) deliller" ibaresine yer verilmektedir. Bunun sonucu olarak da, mahkemenin yemin delilini hatırlatması gerektiği yönündeki uygulama devam etmekteydi. Ancak Yargıtay, HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılan davalarda, tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller", "her türlü delil ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde, tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin, ispat yükü kendisine düşen tarafa "yemin teklifinde bulunma hakkını" hatırlatamayacağına ilişkin içtihadı birleştirme kararı[12] vermiştir.

İddiasını tanıkla ispat etmek isteyen davacının, dava dilekçesinde "tanıklarım" veya "şahadet" gibi tanık göstermek istediğini belirten bir deyim kullanması yeterli olup, ayrıca tanıklarının isimlerini de bildirmesi (tanık listesini de dava dilekçesi ile birlikte vermesi) gerekli değildir.

Davacı, **yazılı delillerini dava dilekçesine eklemek zorundadır**. Çünkü, 121. maddeye göre, dava dilekçesinde sözü edilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte (harç ve vergiye tâbi olmaksızın) davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dava dilekçesine eklenerek mahkemeye verilmesi zorunludur. Bunların yanı sıra, başka yerlerden (örneğin, tapu ve nüfus dairesinden) getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dava dilekçesinde yapılması zorunludur.

Yukarıdaki açıklamalar, davacının elinde bulunan yazılı deliller (belgeler) içindir. Tanık listesi, bu anlamda (m. 121 anlamında) bir yazılı delil değildir. Bu nedenle davacının, dava dilekçesinde tanık deliline dayandığını bildirmesi yeterli olup (m. 119, 1/f), tanıkların isimlerini dava dilekçesinde bildirmek (veya tanık listesini dava dilekçesine ekli olarak vermek) zorunluluğu yoktur.

8) Dayanılan Hukukî Sebepler

Hukukî sebepler, davacının talep sonucunu haklı göstermek için dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaların (olayların) hukukî niteliğidir. Örneğin, dava dilekçesinde bildirilen bir vakıanın haksız fiil (TBK m. 49 vd.), sebepsiz zenginleşme (TBK m. 77 vd.), belli bir hukukî işlem (örneğin, hizmet, eser sözleşmesi) vs. olarak nitelendirilmesi gibi.

Davacı, dava dilekçesinde hukukî sebeplerin (kanun hükümlerinin) özetini bildirmelidir (m. 119, 1/g). Fakat bu, **dava dilekçesinin zorunlu bir unsuru değildir**. Yani, dava dilekçesinde hukukî sebeplerin gösterilmemiş olmasının bir yaptırımı yoktur (karş. m. 119, 2). Çünkü hâkim, Türk kanunlarını kendiliğinden uygulamakla yükümlüdür (m. 33). Davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıalara uygulanacak hukuk kuralını (kanun hükmünü) bulup uygulamak, başka bir deyişle bu vakıaların hukukî niteliğini (hukukî sebebini) belirlemek, Türk kanunlarını uygulamak demektir. O halde, bu husus Türk kanunlarını kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olan (m. 33) hâkimin işidir. Yargıtayın yerleşmiş uygulaması da bu şekildedir; örnek:

---

12 Bkz. RG 17.06.2017, sa. 30099.

"Davacı, dava dilekçesinde dayandığı hukukî sebepleri bildirmelidir. (HMK m. 119, 1/g). Hukukî sebepler, davacının talep sonucunu haklı göstermek için dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaların hukukî niteliğidir. Her ne kadar davacının dava dilekçesinde dayandığı hukukî sebepleri bildirmesi gerekirse de hukukî sebeplerin bildirilmesi dava dilekçesinin zorunlu unsuru değildir. Hâkim, Türk kanunlarını kendiliğinden uygulamakla yükümlü olduğu için dava dilekçesinde dayanılan hukukî sebeplerin gösterilmemiş olmasının bir müeyyidesi yoktur...".

Buna göre, hâkim, davacının dava dilekçesinde bildirdiği hukukî sebeple bağlı olmayıp, hukukî sebebi kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olduğundan, davacının m. 119, 1/g hükmüne rağmen, dava dilekçesinde hukukî sebepleri göstermemiş olması halinde, dava dilekçesinin düzenlenmesinde kanunî noksanlar bulunduğu söylenemez.

Bunun gibi, davacının dava dilekçesinde bir kanun hükmünü (hukukî sebebi) yanlış göstermiş veya hiç hukukî sebep göstermemiş olması halinde, dava dilekçesinin düzenlenmesinde kanunî noksanlık vardır denemez. Hâkim, hukukî sebebi (davada uygulanacak kanun hükmünü) kendiliğinden araştırıp uygulamakla yükümlüdür.

Buna göre, davacının dava dilekçesinde bildirdiği ve fakat hâkimi bağlamayan, hâkimin doğru olup olmadığını kendiliğinden araştırmakla yükümlü olduğu (ve davacının dava dilekçesinde göstermemiş olması halinde hâkimin kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olduğu) hukukî sebep, davanın sebebi olamaz. **Davanın gerçek sebebi**, yukarıda incelendiği gibi, davacının dava dilekçesinde bildirmiş olduğu **vakıalardır**.

9) Açık Bir Şekilde Talep Sonucu

Dava dilekçesinin talep sonucu (netice talep; istem sonucu) bölümünde (m. 119, 1/ğ) davacı mahkemeden neye karar verilmesini (davalının neye mahkûm edilmesini) istiyorsa onu (açık bir şekilde) yazar.

Esasen, talep sonucu dava dilekçesinin **en önemli unsuru**dur ve talep sonucunu içermeyen bir dilekçe, dava dilekçesi olarak nitelendirilemez.

Talep sonucu dava çeşitlerine göre değişiklik gösterir:

Eda davalarında, davacı, davalının bir şey vermeye, bir işi yapmaya veya yapmamaya mahkûm edilmesini ister[13]. **Tespit davalarında** davacı, bir hukukî ilişkinin var olup olmadığının ya da bir belgenin sahte olup olmadığının tespitine karar verilmesini ister[14]. **İnşaî davalarda** davacı, var olan bir hukukî durumun değiştirilmesine veya kaldırılmasına veya yeni bir hukukî durumun yaratılmasına karar verilmesini ister[15]. **Terditli davalarda** davacı iki ayrı talepte bulunur; ilk önce asıl talebi hakkında karar verilmesini ister; yardımcı talebini ise, asıl talebin reddedilmesi ihtimali için yapar[16]. **Seçimlik**

---

[13] Bkz. yuk. § 16, A, I.
[14] Bkz. yuk. § 16, A, II.
[15] Bkz. yuk. § 16, A, III.
[16] Bkz. yuk. § 16, E, I.

davalarda davacı, seçimlik (alternatif) olarak talepte bulunur[17]. Davacının, birden fazla davasını aynı dava dilekçesi ile açması (**davaların yığılması** - objektif dava birleşmesi-) halinde, her davaya ait talep sonucunu (davanın konusunu) açıkça (ayrı ayrı) dava dilekçesinde göstermesi gerekir[18]. **Kısmî davada,** davacının dava dilekçesinde kısmî dava açtığını açıkça bildirmesi gerekir[19].

Yukarıdaki talepler, davanın asıl kısmına ilişkin taleplerdir. Bunun yanında davacı, talep sonucu bölümünde, **fer'i** (yardımcı) **nitelikte taleplerde** de bulunabilir; örnekler:

Davacı, dava dilekçesinde **faiz** de isteyebilir. Bu durumda, davacının faiz istemini dilekçenin talep sonucu kısmında açıkça belirtmesi gerekir.

Davalı, davadan önce temerrüde düşürülmüş ve davacı, dava dilekçesinde temerrüt tarihinden itibaren faiz istiyorsa, şu şekilde hareket eder: Davacı, dava dilekçesinde davalının temerrüt tarihini gösterir ve temerrüt tarihinden dava tarihine kadar işlemiş gecikme (temerrüt) faizini hesaplar.

Davacı, dava dilekçesinde **yalnız faiz istemekle yetinmiş** (temerrüt tarihinden itibaren faiz istediğini bildirmemiş) ise, davalı önce mütemerrit duruma düşmüş olsa bile, mahkeme, **davanın açıldığı tarihten itibaren** faize hükmeder.

TBK ve TTK'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, bu ödemenin yıllık yüzde on iki üzerinden yapılacağı 3095 s. K. m. 1, I'de düzenlenmiş ise de aynı maddenin 2. fıkrası hükmünün verdiği yetki ile Bakanlar Kurulu, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olarak, bu oranı yüzde dokuz olarak belirlemiştir.

Dava, bir miktar paranın ödenmemesi (davalının temerrüde düşmesi) üzerine açılmış ise sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça davalı yukarıda açıklanan 3095 s. K. m. 1'de belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mahkûm edilir (3095 s. K. m. 2).

Davacı, dava dilekçesinde davanın açıldığı tarihe kadar yapmış olduğu giderleri de isteyebilir.

Davacı, itirazın iptali davasında (İİK m. 67) ve borçtan kurtulma davasında (İİK m. 69), asgarî yüzde yirmi **tazminat** da isteyebilir.

Davacı, boşanma davası ile birlikte tedbir nafakası (TMK m. 169), yoksulluk nafakası (TMK m. 175) ve iştirak nafakası (TMK m. 182) da isteyebilir. Buna karşılık, yargılama giderlerinin (bu arada vekâlet ücretinin) dava dilekçesinde açıkça istenmesine gerek yoktur; çünkü, mahkeme, yargılama giderleri hakkında kendiliğinden karar vermekle yükümlüdür (m. 332, 1)[20].

Talep sonucu **çok açık bir şekilde** yazılmalıdır (m. 119, 1/ğ). Talep sonucu çok açık olmalı ki, mahkeme, davayı kabul edince talep sonucunu aynen hüküm fıkrası olarak (m. 297, 1/ç) kararına alabilsin. Esasen mahkeme, davacının talep ettiğinden fazlasına hüküm veremez (m. 26). Bu nedenle

---

17 Bkz. yuk. § 16, E, II.
18 Bkz. yuk. § 16, E, III.
19 Bkz. yuk. § 16, A, I, 2.
20 Bkz. aşa. § 67.

davacı, nelerin hüküm altına alınmasını (davalının neye mahkûm edilmesini) istediğini, açık ve eksiksiz bir şekilde dava dilekçesinin talep sonucu bölümünde bildirmelidir.

Talep sonucu açık değilse, mahkeme (hâkim) **davayı aydınlatma ödevi** kapsamında, davacıya talep sonucunu açıklattırmalıdır (m. 31). Bu hükümde, "hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda maddî veya hukukî açıdan belirsiz yahut çelişki gördüğü hususlar hakkında, taraflara **açıklama yaptırabilir**; soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir" denilmekte ise de, bunu sadece hâkime tanınan bir yetki şeklinde değil, aynı zamanda hâkime verilen bir ödev olarak anlamak gerekir.

10) Davacının** (Varsa Yasal temsilcisinin veya Vekilinin) **İmzası

Dava dilekçesinin altı davacı tarafından imzalanır. Ancak, dava davacının yasal temsilcisi veya vekili tarafından açılmışsa, dava dilekçesini davacı değil, yasal temsilcisi veya vekili imzalar (m. 119, 1/h; 119, 2).

İmzanın davacının el yazısı (TBK m. 15) ile atılması gerekir.

II – DAVA DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK BULUNMASI

Kanun (m. 119, 2), dava dilekçesinin içeriğindeki eksiklikler bakımından bir ayrım yapmaktadır[21]:

Dava dilekçesindeki davacı ve davalının adında, soyadında, adresinde (m. 119, 1/b); davacının kimlik numarasında (m. 119, 1/c); varsa yasal temsilci ve vekilin ad, soyad ve adresinde (m. 119, 1/ç); açık bir şekilde talep sonucunda (m. 119, 1/ğ) ve davacının imzasında (m. 119, 1/h) eksiklik bulunması halinde, hâkim eksikliği tamamlaması için davacıya bir haftalık kesin bir süre (m. 94) verir. Davacı süresi içinde eksikliği tamamlarsa, davaya devam edilir; aksi takdirde (**eksikliği tamamlamazsa**), **dava açılmamış sayılır** (m. 150).

Diğer hususlarda eksiklik hallerinde ise, m. 119, 2 hükmü ne yapılacağını açıkça düzenlememiştir.

Mahkemenin adı (m. 119, 1/a) yazılmamışsa, davanın pratik olarak görülebilmesi, hatta açılmış sayılabilmesi mümkün değildir; çünkü, bu konuda yargılama yapıp karar verecek olan mahkeme belli değildir.

Dava konusu (m. 119, 1/b) belli edilmemiş olmasına rağmen, dava dilekçesinde talep sonucu (m. 119/1, ğ) açıkça belirtilmişse, eksiklik dolaylı olarak tamamlanmış olacağından bu eksiklik bir sorun yaratmaz. Öte yandan, bu eksiklik, "hâkimin davayı aydınlatma ödevi" (m. 31) çerçevesinde giderilebilir.

Dava konusunun değeri (m. 119, 1/b) belirtilmemişse, bu konu Harçlar Kanunu çerçevesinde çözümlenir. Çünkü, malvarlığı haklarından doğan davalarda değer belirtilmesi zorunludur. Dava dilekçesinde değer hiç belirtilmemiş veya eksik belirtilmişse; mahkeme, davacıya eksikliği tamamlaması, eksik kalan harcı yatırması için kesin bir süre verir; eksiklik tamamlanmazsa

---

[21] Dava dilekçesinin unsurlarındaki eksiklik (kanunî eksiklik), eski HUMK m. 187, 7'de bir **ilk itiraz** olarak düzenlenmiş idi.

dosya işlemden kaldırılır; üç ay içinde davacı, harcı yatırarak eksikliği tamamlamazsa, dava açılmamış sayılır (Harçlar K. m. 16; 30; HMK m. 150).

Vakıalarda eksiklik (m. 119, 1/f) varsa, bu husus, yargılamanın sonucunda davacının talebine uygun karar alamamasına neden olabilir. Ancak, dava dilekçesinde hiçbir vakıa bildirilmemişse, m. 119, 2 hükmü kıyasen uygulanabilmelidir. Davacı dilekçesinde dava sebebi olan vakıaların ispatı için gerekli delillerini bildirmemişse, m. 145'te düzenlenen istisnalar dışında daha sonra delil gösteremeyecektir; davacıya, delillerini bildirmesi için süre verilemeyecektir.

Dayanılan hukukî sebeplerde (m. 119, 1/g) eksiklik veya hukukî sebep gösterilmemesi, herhangi bir sorun yaratmaz. Çünkü m. 33 gereğince hâkim, kanunları kendiliğinden uygular.

III – DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ

Davanın tek bir davalısı olması halinde, dava dilekçesi iki adet olarak[22], tevzi bürosu, ön büro[23] veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir (Y m. 197). Dilekçe örneklerinden biri dava dosyasına konur, diğeri davalıya tebliğe gönderilir. Fiziksel ortamda gelen tüm belgeler derhal elektronik ortama aktarılır (Y m. 197, 7). Bu nedenle fiziksel ortamda teslim edilen dava dilekçesi ve eklerinin de derhal UYAP'a aktarılması gerekir.

Harca tâbi davalarda, her dava açılırken davacıdan **başvurma harcı** ile nispî harca tâbi davalarda nispî **karar ve ilâm harcının** dörtte biri (maktu harca tâbi davalarda ise karar ve ilâm harcının tamamı), peşin olarak alınır (Harçlar K. m. 27-28).

Davacı yargılama harçlarının yanı sıra, Gider Avansı Tarifesinde belirtilen **gider avansını** da mahkeme veznesine yatırmak zorundadır (m. 120).

Davanın UYAP üzerinden açılması halinde yargılama harçları ve gider avansının elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarılması gerekir.

Bu işlemden sonra dava, sisteme kaydedilir ve bu tarihte açılmış sayılır. Davacıya elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur (Y m. 197, 8-10). Dava her zaman açılabilir. Adlî tatilde de, her türlü dava açılabilir (m. 103)[24]. Dava, fiziksel ortamda mesaî saati içerisinde, elektronik ortamda ise saat 00:00'a kadar açılabilir (Y m. 197, 10).

---

22 Davalı sayısı birden fazla ise (davalı tarafta dava arkadaşlığında), dava dilekçesi davalı sayısından bir adet fazla olarak verilir (m. 118, 1).

23 **"Tevzi bürosu"**, dava ve işlerin mahkemelere gönderilmesi işleminin yapıldığı yeri; **"ön büro"**, davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili bütün işlemler ile mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle adliyelerin giriş kısımlarında bulunan ve tüm hukuk mahkemelerine hizmet veren yazı işleri birimini ifade eder (Y m. 4)

24 Bkz. yuk. § 7, A, IV.

Dava dilekçesi, dava harca tâbi ise harç ve gider avansı, harca tâbi değilse gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun[25] bir örneği başvuru sahibine verilir (Y m. 197, 2).

Tevzi işlemleri, kural olarak, UYAP ortamında yapılmaktadır. Dava fizikî ortamda açılmasa bile dava dilekçesi ve eklerinin sisteme aktarılması gerekir. Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır (Y m. 197, 6).

Dava dilekçesinde delillerin gösterilmesi ve yazılı delillerin mahkemeye verilmesi yukarıda incelendi[26].

Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise, o mahkemenin **esas kaydı**ndan[27] (Y m. 172) numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu doldurulur (Y m. 197, 3). Davanın esas kaydı (dosya) numarası, dava dosyasının üstüne yazılır. Buna göre, örneğin "Esas -Dosya- no. 2017/217" kısaltmasında, 2017 sayısı davanın 2017 yılında açıldığını, 217 sayısı ise davanın esas kaydındaki açılan davaların tarihlerine göre verilen numarasını (esas veya dosya sayısını) gösterir.

Mahkeme kalemi, posta (tebligat) giderini m. 120'ye göre yatırılan avanstan karşılayarak, dava dilekçesinin bir örneğini davalıya tebliğe gönderir.

Bu tebliğin işlevi, davalının dava dilekçesine cevap verebilmesini (cevap süresinin işlemeye başlamasını) sağlamaktır. Yoksa, davanın açılmış sayılabilmesi için, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş olması şart değildir.

IV – DAVANIN AÇILMA ZAMANI

Kanun, davanın, **dava dilekçesinin kaydedildiği tarih**te açılmış sayılacağını[28] (m. 118, 1) ve dava dilekçesinin kaydına ilişkin esas ve usullerin Yönetmelikle belirleneceğini düzenlemiştir.

Yönetmeliğin 197. maddesinde bu konuda çeşitli olasılıklar öngörülmektedir. Buna göre **dava**, dava dilekçesinin (elektronik ortamda, UYAP'ta) tevzi edilerek **kaydedildiği tarihte açılmış sayılır** (Y m. 197, 5).

Eğer herhangi bir nedenle elektronik ortamda (UYAP'ta) işlem (tevzi) yapılması mümkün değilse; işlem fizikî ortamda yapılır, bu durum (elektronik ortamda işlem yapılamaması) bir tutanakla tespit edilir; elektronik sistem açıldığında, fizikî ortamda yapılan işlemler, gecikmeksizin elektronik ortama

---

25 **Tevzi formu**, dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesidir (Y m. 197, 1).

26 Bkz. yuk. § 17, B, I, 7.

27 **Esas kaydı**, davaların aşamalarının kaydedildiği kayıttır. Esas kaydı; sıra numarası, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya merkezi tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ve düşünceler sütunlarını içerir (Y m. 172).

28 **Tahkimde davanın açılma zamanı** farklıdır (m. 426).

aktarılır ve bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır (Y m. 197, 6).

Davanın UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile açılması ve yargılama harçları ile gider avansının elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılması veya baro kartı veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla sağlanması durumunda, dava, dava dilekçesinin UYAP Sistemine kaydedildiği tarihte açılmış sayılır (Y m. 197, 8-9).

V – TENSİP TUTANAĞI

Mahkeme, davanın açılmasından (m. 118) sonra, dilekçeler aşamasının başında açılan dosya (dava) için bir tensip tutanağı düzenler (Y m. 200).

Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin takdirindedir; ancak, tensip tutanağının başına mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı, hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa yasal temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri yazılır. Ayrıca dava dilekçesinin 119. maddede düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile eksiklik bulunması halinde ne gibi işlemin yapıldığı; davanın türü ve tâbi olduğu yargılama usulü; karşılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılması, tarafların 121. madde ve 129. maddesinin 2. fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri; davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde, (basit yargılama usulüne ilişkin hükümler saklı olmak üzere) 140. maddenin 5. fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacakları; dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği; ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak taraflara bildirileceği; ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği; dosyanın durumuna göre gerek görülen diğer hususlar yazılır.

Tensip tutanağının bu şekilde düzenlenmesinden sonra, davanın ilgili her aşamasında gerekli kararlar verilir ve işlemler yapılır (Y m. 200, 2).

§ 18. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI

Dava açılmasının maddî hukuk ve usul hukuku bakımından bazı sonuçları vardır:

A) DAVA AÇILMASININ MADDÎ HUKUK BAKIMINDAN SONUÇLARI

Bu sonuçlar, maddî hukuka ilişkin kanunlarda (örneğin, TMK ve TBK'nda) düzenlenmiştir:

I – ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

Dava açılması ile, dava konusu alacak (hak) için zamanaşımı kesilir (TBK m. 154, 1-2; TTK m. 750; TMK m. 714; 777, II). Zamanaşımının kesilmesi için davanın açılması yeterlidir; bunun için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş olmasına gerek yoktur.

Dava açılması ile kesilmiş olan zamanaşımı, dava süresince iki tarafın yargılama ile ilgili her işleminden ve hâkimin her emir ve kararından sonra yeniden işlemeye başlar (TBK m. 157, 1; karş. TBK m. 158).

Alacaklının müteselsil borçlulardan (TBK m. 162 vd.) birine karşı açmış olduğu dava ile, diğer (dava edilmeyen) müteselsil borçlular hakkında zamanaşımı kesilmiş olur (TBK m. 155, 1).

Kısmî dava (m. 109) açılması ile, alacağın yalnız kısmî dava konusu yapılan kesimi için zamanaşımı kesilir; dava dışı kalan (saklı tutulan) kesimi hakkında zamanaşımı kesilmez, işlemeye devam eder.

Menfi (olumsuz) tespit davası ile zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz.

II – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KORUNMASI

Hak düşürücü süreye bağlı davalarda (örneğin, şuf'a -önalım- davasında), **dava açılması ile hak düşürücü süre korunmuş** (yani dava, süresi içinde açılmış) **olur**.

III – BAZI KİŞİVARLIĞI HAKLARININ MALVARLIĞI HAKKINA DÖNÜŞMESİ

Nafaka, manevî tazminat ve evlenmenin feshi gibi **bazı kişivarlığı hakları,** dava konusu yapılınca (dava açılması ile) **malvarlığı hakkına dönüşür.** Bu nedenle, (mirasçıların bu davaları açma hakları olmadığı halde) mirasçılar, miras bırakanın (sağlığında) açmış olduğu bu davaları, miras bırakanın küllî halefi olarak takip edebilirler.

IV – İYİNİYETİN KÖTÜNİYETE DÖNÜŞMESİ

Bazı hallerde, davanın açılması ve dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi ile, davalının iyiniyeti, kötüniyete dönüşür. Örneğin, TMK m. 995 gereğince geri vermekle yükümlü olan zilyet veya TBK m. 78'e göre sebepsiz zenginleşmede, geri vermekle yükümlü olan kişi, (daha önce iyiniyetli ise) dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesi ile iyiniyeti ortadan kalkar ve bu kişinin sorumluluğu ona (kötüniyetli olmasına) göre değerlendirilir.

V – DAVALININ MÜTEMERRİT OLMASI

Davalı daha önce mütemerrit (direngen) kılınmamış ise, dava açılması ve dava **dilekçesinin davalıya tebliği ile** davalı mütemerrit olur (TBK m. 117).

B) DAVA AÇILMASININ USUL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

Dava açılmasının usul hukuku bakımından önemli sonuçları vardır. Bunlardan derdestlik, Kanunda düzenlenmiştir (m. 114, 1/ı); diğerleri ise açıkça yazılı değildir. Kanunda açıkça yazılı olan ve kanun hükümlerinin genelinden yorum yoluyla çıkarılan, dava açılmasının usul hukuku bakımından ortaya çıkan sonuçlarını aşağıdaki gibi belirlemek ve incelemek mümkündür.

I – MAHKEMENİN DAVAYI İNCELEMESİ ZORUNLULUĞU DOĞAR

Dava açılması ile, mahkeme için, harekete geçmek ve açılmış olan davayı bir karar ile sonuçlandırmak zorunluluğu ortaya çıkar. Dava, dava şartlarını içermese (dava şartları eksik olsa) bile hâkim, davayı incelemesiz bırakamaz; davayı ya dava şartı eksikliğinden (usulden) reddetmek veya davayı esastan inceleyip karara bağlamak zorundadır. Aksi halde hâkim, hakkı yerine getirmekten kaçınmış olur ve hâkimin hukukî sorumluluğu doğar (m. 46, 1/e).

Mahkeme, davanın açılması (m. 118; 126-136) ile başlayan davada, aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, ön inceleme (m. 137-142); tahkikat (m. 143-183; 187-293); sözlü yargılama (m. 184-186) ve hüküm (m. 294 vd.) aşamalarını tamamlamak zorundadır.

II – DAVA ŞARTLARI DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE GÖRE BELİRLENİR

Dava şartları (m. 114), kural olarak davanın açıldığı tarihe göre belirlenir. Mahkeme, davanın başında (ön incelemede) dava şartlarının bulunup bulunmadığını kendiliğinden araştırmak ve incelemekle (yani gözetmekle) yükümlüdür (m. 115; 137).

Ancak, dava şartı eksikliği, mahkemece davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş olsa bile, **hüküm anında dava şartı eksikliği giderilmişse,** başlangıçtaki dava şartı eksikliğinden ötürü, dava usulden reddedilemez (m. 115, 3). Çünkü, hüküm anında bütün dava şartları tamamdır.

III – DAVA, AÇILDIĞI TARİHTEKİ DURUMA GÖRE KARARA BAĞLANIR

Mahkeme hükmünü de, kural olarak, davanın açıldığı tarihteki durumu dikkate alarak verir.

Buna göre, örneğin, davacı ancak dava açıldığı tarihte var olan (o zamana kadar gerçekleşmiş olan) alacağının hüküm altına alınmasını isteyebilir; dava tarihinden sonra doğacak haklar için (o davada) karar verilemez. Örneğin davacı, 15 Mart günü, daha önce ödenmeyen Ocak ve Şubat ayı kiralarının tahsili için dava açmış ve dava 01 Aralık'ta karara bağlanmışsa, dava açılmasından sonraki (sözgelimi Mart, Nisan ayı) kiralarına hükmedilemez (m. 26).

IV – DERDESTLİK DURUMU ORTAYA ÇIKAR

Dava açılması ile derdestlik[1] durumu doğar (m. 114, 1/ı). Bir davanın **derdest olması**, **davanın görülmekte olması**dır. Derdest (görülmekte) olan dava, yeniden (tekrar) açılamaz.

Derdestlik bir **dava şartıdır** (m. 114, 1/ı)[2]. Bir dava görülürken aynı dava (yani konusu, dava sebebi ve tarafları aynı olan dava) yeniden açılırsa, bu yeni (ikinci) dava, dava şartı eksikliği nedeniyle reddedilir.

Bir davanın derdestlik nedeniyle usulden reddedilebilmesi için, şu iki şartın birlikte bulunması gerekir: İlk açılan (birinci) dava görülmekte iken ikinci bir dava açılması ve birinci dava ile ikinci davanın aynı dava olması:

Birinci davanın görülmekte iken ikinci davanın açılmış olması: Birinci (ilk açılan) davanın görülmekte (derdest) olması demek, (ikinci davanın açıldığı tarihte) birinci davanın henüz karara bağlanmamış olması veya karara bağlanmış olmakla beraber verilen kararın henüz (şeklî anlamda) kesinleşmemiş olması demektir.

Birinci (ilk açılan) **dava ile ikinci davanın aynı dava olması**: Derdestlik için gerekli ikinci şart, birinci dava ile ikinci davanın aynı dava olmasıdır. İkinci dava, başka bir mahkemede açılmış olabileceği gibi, aynı (birinci davanın görüldüğü) mahkemede de açılmış olabilir.

İki davanın aynı dava sayılması bakımından, maddî anlamda kesin hüküm (m. 303) ile derdestlik arasında hiçbir fark yoktur. Görülmekte olan birinci dava ile yeni açılan ikinci davanın aynı dava olduğunu söyleyebilmek için, maddî anlamda kesin hükümdeki gibi, birinci dava ile ikinci davanın **tarafları**nın, **dava konusu**nun **ve dava sebepleri**nin **aynı olması gerekir**.

Derdestlik dava şartının mevcut olup olmadığının davanın hangi aşamasında incelenip karara bağlanacağı, m. 137 ve 140'da belirlenmiştir.

Derdestlik dava şartı olduğu için, birinci ve ikinci davanın **aynı mahkemede açılmış olması** halinde mahkeme, kendiliğinden iki dosyayı birlikte in-

---

1 Bkz. Süha Tanrıver, Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 2007; Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, Milletlerarası Usûl Hukukunda Paralel Davalar, Ankara 2016.

2 HUMK m. 187/4 hükmü, derdestliği bir dava şartı olarak değil, ilk itiraz olarak kabul etmekte ve bundan dolayı eleştirilmekte idi.

celeyerek, iki davanın da aynı dava olup olmadığını tespit eder. Birinci dava, **başka bir mahkemede açılmış** ve görülmekte **ise**, ikinci davanın açıldığı mahkeme, birinci davaya bakan mahkemeden, birinci davanın taraflarını, dava konusunu ve dava sebebini sorar (veya bizzat incelemek üzere dosyayı getirtir); gelecek cevaba (veya bizzat incelediği dosyaya) göre iki davanın aynı dava olup olmadığını tespit eder.

Mahkeme veya davaların ayrı mahkemelerde açılmış olması halinde ikinci davaya bakan mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda iki davanın taraflarının, dava konularının ve dava sebeplerinin aynı olduğu kanısına varırsa, derdestlik sebebiyle (dava şartı yokluğundan) ikinci davanın esasa girilmeden (usulden) reddine karar verir. Dava şartı sebebiyle verilen davanın usulden reddi kararı, nihai karar olduğundan, bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.

Mahkeme, iki davanın taraflarının, dava konularının ve dava sebeplerinin aynı (yani iki davanın, aynı dava) olmadığı kanısına varırsa, derdestlik itirazını reddederek davayı esastan incelemeye başlar. Derdestlik itirazının reddine ilişkin karar, bir ara kararı olduğundan (nihaî karar olmadığından) yalnız başına kanun yoluna götürülemez; ancak asıl hükümle birlikte kanun yoluna götürülebilir.

V – İHTİYATÎ TEDBİR VE/VEYA İHTİYATÎ HACİZ KORUNUR

Davanın açılması, dava konusu hakkında önceden (dava tarihinden önce) alınan ve uygulanan ihtiyatî haczin veya dava konusu üzerine önceden konulan ihtiyatî tedbirin korunmasını (yani, bunların ortadan kalkmamasını -düşmemesini-) sağlar. Bu sonucun ortaya çıkabilmesi için m. 397 veya İİK m. 264 hükümlerine uygun olarak davanın açılması ve gerekli işlemin yapılması gerekir.

VI – DAVAYI GERİ ALMA YASAĞI[3]

Davacı, davalının rızası olmaksızın davasını geri alamaz (m. 123).

Davayı geri almak, ileride incelenecek olan **davadan feragat etmekten** (m. 307) **farklıdır**[4]. Davayı geri alan davacı, bununla talep sonucundan, yani hakkının özünden feragat etmemekte, sadece davasını geri almakta ve onu ileride tekrar açabilme hakkını saklı tutmaktadır. Davadan feragat davalının rızasına bağlı olmadığı halde, davacının davayı geri alabilmesi için davalının rızası şarttır (m. 123).

Davayı geri alma, **davayı takipsiz** (veya müracaata) **bırakma** (m. 150) ile de karıştırılmamalıdır. Çünkü, takipsiz bırakılan dava (3 ay daha) derdest kalmakta devam eder; oysa, davanın geri alınması (ve mahkemenin bu nedenle davanın son bulduğuna karar vermesi ve bu kararın kesinleşmesi) ile dava derdest olmaktan çıkar. Davacının davasını takipsiz bırakması (takip

---

3 Bkz. Kudret Aslan, Medeni Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması, Ankara 2016.

4 Bkz. aşa. § 49.

etmemesi) davalının rızasına bağlı olmadığı halde, davalının rızası olmaksızın davacı davasını geri alamaz (m. 123).

Uygulamada, davayı geri alma ile davayı takipsiz bırakma anlamlarına gelmek üzere, **"davanın atiye terki** (geleceğe bırakılması)" kavramı da kullanılmaktadır. Özellikle davacı tarafından bu tür bir talepte bulunulduğunda, hâkimin, tarafın iradesinin davayı geri almak mı, yoksa davayı müracaata bırak mı olduğu konusunda iradesini açıklattırması gerekir.

Davacının, davalının rızası olmaksızın davayı geri alamamasına (m. 123), **davayı geri alma yasağı** denir. Davayı geri alma yasağı davanın açıldığı anda, yani kural olarak dava dilekçesinin esas defterine kaydı tarihinde başlar. Dava dilekçesi esas defterine kaydedilmiş ve fakat henüz davalıya tebliğ edilmemiş olsa bile, davacı, davalının rızası olmaksızın davayı geri alamaz.

Davacı, **davalının rızası** (muvafakatı) ile davayı geri alabilir. Davalının rızasının açık olması gerekir (m. 123); zımnî (üstü kapalı) rıza yeterli değildir.

Davalı, davacının davayı geri almasına açık bir şekilde muvafakat ederse mahkeme, davanın esası hakkında bir karar vermez; davanın, davacı tarafından geri alınma ve davalının da buna muvafakat etmesi nedeniyle son bulduğunu belirtmekle yetinir. Davanın bu şekilde (davalının muvafakatı ile) **geri alınması ile, dava hiç açılmamış sayılır** ve dava açılması ile doğan sonuçlar (geçmişe etkili olarak) hiç doğmamış sayılır (m. 150, 7); örneğin, zamanaşımı kesilmemiş sayılır.

Davalı, davanın geri alınmasına razı olmazsa davaya devam edilir. Ancak, davacı davasına devam etmezse (davasını takip etmezse), davalı, isterse dosyanın işlemden kaldırılmasını sağlar (m. 150), isterse davaya davacının yokluğunda devam edilir.

C) DAVA AÇILMASININ DİĞER SONUÇLARI

Bazı özel kanun hükümlerinde, dava açılması ile doğan başkaca sonuçlar düzenlenmiş olabilir; örnekler:

Menfî tespit davasının (İİK m. 72) açılma tarihi, icra takibinin durdurulması için ihtiyatî tedbir kararı verilip verilemeyeceği bakımından (çok) önemlidir (İİK m. 72, II-III).

Davanın açılma tarihi, hacze iştirak etme bakımından önemlidir (İİK m. 100).

Dava açılması ile, dava konusu alacak "şüpheli alacak" haline dönüşür (bkz. Vergi Usul K. m. 323/1).

§ 19. DAVAYA CEVAP

A) GENEL BİLGİ

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen (m. 122) davalı, bununla kendisine karşı dava açılmış olduğunu öğrenir.

Bunun üzerine **davalı,** Anayasa ile güvence altına alınmış olan **savunma hakkını** kullanabilir. Çünkü davalı, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı olarak, savunma ile **adil yargılanma hakkına** sahiptir (Anayasa m. 36). Mahkeme, savunmasını bildirmek için davalıyı usulüne uygun olarak bilgilendirmelidir (m. 27; 122). Buna göre, bir davada davalıya savunma hakkını kullanma imkânı verilmeden hüküm verilemez. İşte davalıya savunma hakkını kullanma imkânının verilmesi (yani taraf teşkilinin sağlanması), ona dava dilekçesinin (usulüne uygun olarak) tebliğ edilmesi ile olur.

Kendisine dava dilekçesi tebliğ edilen ve bununla savunma hakkını kullanma imkânı verilen davalı, savunma hakkını kullanmak, yani davaya cevap vermek zorunda değildir. Süresi içinde cevap vermeyen davalı, bununla davadaki hukukî durumunu zorlaştırmış (güçleştirmiş) olur.

Davalı, kendisine karşı açılan davanın haksız olduğu kanısında ise, mahkemeye başvurarak mahkemeden kendisi için hukukî korunma ister. Bu hukukî korunma talebi, davaya cevap vermek suretiyle olur. Davalı **karşı dava**[1] açmak isterse, bunu cevap dilekçesi ile de yapabilir (m. 132).

Davalı davaya cevap vermek isterse, bunu yazılı olarak yapmalıdır. Çünkü, bütün yargılama usullerinde dilekçeler aşaması (dava malzemesinin hazırlanması) yazılıdır. Davalının cevaplarını içeren dilekçeye, **cevap dilekçesi** denir.

B) DAVALININ CEVAPLARI (savunma biçimi)

Davalının, dava dilekçesinde davacının talep sonucunu dayandırdığı vakıalar (olay ve olgular) ile gösterdiği deliller ve talep sonucu hakkında cevapları olabilir. Bu cevapların neler olabileceğini ve bu cevapların verilmesi usulünü de incelemek gerekir. Davaya cevap vermek isteyen davalı, üç şekilde hareket edebilir:

I – DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ

Davalı, davayı haklı buluyorsa, onu kabul edebilir (m. 308); davalı, davacının talep sonucuna kısmen veya tamamen muvafakat ettiğini cevap dilekçesi ile açıklayabileceği gibi, daha sonra da yapabilir. Ancak, davalı, hâl ve davranışı ile kendisine karşı dava açılmasına sebebiyet vermemiş ise, cevap

---

[1] Bkz. aşa. § 44.

dilekçesinde (en geç ilk oturumda) davayı kabul etmekle yargılama giderlerine mahkûm edilmekten kurtulabilir[2] (m. 312, 2).

Davanın (davalı tarafından) tamamen kabul edilmesi ile, dava son bulur (m. 308). Davayı kabul, ilerde (§ 50'de) ayrıntılı biçimde incelenecektir.

Davalı, davayı (tamamen değil de) kısmen kabul ederse, davalının kabul etmediği bölüm için davaya devam edilir. Davalı, davanın kabul etmediği bu bölümüne karşı az sonra görülecek şekillerde savunmada bulunabilir.

II – DAVALININ DAVA DİLEKÇESİNDEKİ VAKIALARA KARŞI KOYMASI

Davalının, davacının dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıalara (olay ve olgulara) karşı koyması da iki şekilde olabilir:

1) Davalı Dava Dilekçesindeki Vakıaları İnkâr Edebilir

Davalı, davacının dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaları (olay ve olguları) inkâr edebilir. Örneğin davalı, davacının dayandığı sözleşmenin (örneğin, ödünç sözleşmesinin) varlığını inkâr edebilir. Bu inkâr da, tamamen veya kısmen olabilir.

Vakıaların tamamen inkârı halinde, başkaca savunmaya gerek kalmadan, davanın reddi istenir.

Davalı, dava dilekçesindeki vakıaları kısmen inkâr ederse, inkâr etmediği vakıaların da davacıyı talep sonucunda haklı gösterecek nitelikte olmadığını savunur.

2) Davalı Dava Dilekçesindeki Vakıaların Davayı Haklı Gösterecek Nitelikte Olmadığını Bildirebilir

Davalı, dava dilekçesindeki vakıaları inkâr etmemekle beraber, bu vakıaların davacının talep sonucunu (davasını) haklı gösterecek nitelikte olmadığını iddia edebilir. Örneğin, davacının verdiği borcun vadesinin henüz gelmediğini veya talep edilmesinin şarta bağlı olup, bu şartın gerçekleşmediğini, alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir. Bu halde davalı, davacının dava dilekçesinde yer verdiği vakıaların (m. 118, 1/e) her biri hakkında (aynı sıra numarası altında) açıklamada bulunur ve bunların hangi nedenlerle davacının talep sonucunu (davasını) haklı gösterecek nitelikte olmadığını ileri sürer.

Davalı, davacının dava dilekçesinde göstermiş olduğu **hukukî sebeplere itiraz** edebilir. Ancak davalının hukukî sebeplere itiraz etmemesi tek başına davalı aleyhine sonuç doğurmaz. Çünkü hâkim, tarafların bildirdikleri hukukî sebeplerle bağlı olmayıp, tarafların dilekçelerinde dayandıkları vakıaların hukukî sebebini (niteliğini) kendiliğinden araştırıp bulmakla yükümlüdür (m. 33).

---

[2] Bkz. aşa. § 50.

III – DAVALININ LEHİNE OLAN KARŞI VAKIALAR İLERİ SÜRMESİ (SAVUNMA ARAÇLARI)

Davalı, lehine olan, davacının dava dilekçesinde bildirmediği (yeni) vakıalara dayanarak, davanın reddini isteyebilir. Bu halde davalı, dava dilekçesinde davacı tarafından ileri sürülmüş olan vakıaları tartışma konusu yapmadan, aksine karşı (yeni) vakıalara dayanarak davacının iddia ettiği hakkın mevcut olmadığını veya davanın haksız olduğunu ileri sürer. Örneğin davalı dava konusu alacağın ödendiğini veya zamanaşımına uğradığını savunur.

Davalının ileri sürdüğü karşı (yeni) vakıalara davalının **savunma araçları** denir. Bu savunma vasıtaları da maddî hukuka ve usul hukukuna dayanan savunma vasıtaları (araçları) olmak üzere ikiye ayrılır:

1) Maddî Hukuka Dayanan Savunma Araçları

Maddî hukuka dayanan savunma araçları, def'iler ve itirazlar olmak üzere ikiye ayrılır:

a) Def'iler

Def'i, davalının (aslında) borçlu olduğu bir edimi (borcu) özel bir nedenle yerine getirmekten kaçınmasına imkân veren bir **hak**tır. Burada davalı, aslında borçludur; ancak, davalının özel bir nedenle o borcu yerine getirmekten kaçınma hakkı vardır. Def'ilere örnekler: Zamanaşımı def'i (TBK m. 161); karşılık borcun yerine getirilmediği (ödemezlik) def'i (TBK m. 97); semenin (satış bedelinin) indirilmesi def'i (TBK m. 227; 231); bağışlayanın def'i (TBK m. 296); ödünç (borç) verenin def'i (TBK m. 390); kefilin tartışma def'i (TBK m. 585); takas def'i[3] vb.

Def'iler ile itirazlar arasında önemli **nitelik farkı** vardır: "**İtiraz"da hak ya hiç doğmamıştır** (örneğin, sözleşme geçersizdir; sözleşme hükümsüzdür) veya **sözleşme ilişkisi son bulmuştur** (örneğin, borç ödenmiştir). Yani ileri sürülen vakıa nedeni ile, dava konusu hakkın mevcut olmadığı veya ortadan kalktığı bildirilir. Buna karşılık, **def'ide** hak vardır; ancak davalı, özel bir nedenle (örneğin, zamanaşımı nedeniyle) **o hakkı yerine getirmekten kaçınabilir**.

Davalının ileri sürdüğü bir vakıanın (savunmanın) def'i olup olmadığının bilinmesi, özellikle usul hukukunda (davada) çok önemlidir. Çünkü, davalının def'iyi açıkça ileri sürmesi gerekir. Davalı def'iyi açıkça ileri sürmemişse (bildirmemişse), hâkim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan def'inin varlığını öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. Örneğin, davalı **zamanaşımını** ileri sürmezse, **hâkim,** dava dosyasından (örneğin, dosyadaki borç senedinden) borcun zamanaşımına uğramış olduğunu anlasa bile, bunu **kendiliğinden gözetemez** ve bu hususta davalıya bir hatırlatmada bulunamaz (m, 25, 1; TBK m. 161).

---

[3] Davada takas konusunda bkz. Ejder Yılmaz, Davada Takas Ve Mahsup Talebi (MİHDER, 2010/2, s.247-284; Yılmaz, Makaleler, c. 2, s. 1824-1870).

b) İtirazlar

İtirazlar, bir hakkın doğumuna engel olan veya o hakkı sona erdiren vakıalardır. Buna göre, iki türlü itiraz vardır:

Bir Hakkın Doğumuna Engel Olan İtirazlar: Örneğin, sözleşmenin taraflarından birinin fiil ehliyetinin (TMK m. 9) bulunmaması; sözleşmenin geçerlilik şekline uygun (TBK m. 12 vd.; örneğin, yazılı şekilde) yapılmamış olması gibi. Bu halde, davacının iddia ettiği hakkın hiç doğmadığı ileri sürülür.

Bir Hakkı Sona Erdiren İtirazlar: Örneğin, borcun ödenmiş olduğu itirazı gibi. Burada, davacının iddia ettiği hak geçerli olarak doğmuştur (örneğin, sözleşme geçerlidir); ancak, davalının ileri sürdüğü vakıa (örneğin ödeme vakıası) nedeniyle hak sona ermiştir.

Bir vakıanın itiraz olup olmadığının bilinmesi, özellikle usul hukukunda (davada) çok önemlidir. İtirazların mutlaka davalı tarafından ileri sürülmesi gerekli değildir. **Hâkim,** kendisine (usulüne uygun biçimde) sunulan dava malzemesinden (davacı veya davalının bildirdikleri vakıalardan, yani dava dosyasından) bir **itirazın varlığını** öğrenirse, bunu (davalının ileri sürmesine gerek kalmadan) **kendiliğinden gözetir**.

2) Usul Hukukuna Dayanan Savunma Araçları

Maddî hukuk gibi usul hukuku da, davalıya bazı savunma imkânları tanımıştır. Kanun, bu savunma imkânlarına da itiraz demektedir; bkz. örneğin, m. 19; 394; 403 vb. Bu hükümlerdeki itiraz terimi (yukarıda incelediğimiz gibi) maddî hukuk anlamındaki itirazdan tamamen farklıdır. İkisi arasındaki farkı belirtmek için, HMK'ndaki itirazlara **usulî itirazlar** denilmesi uygun olur. Usulî itirazlar ikiye ayrılır:

a) İlk İtirazlar

Yukarıda[4] incelenen dava şartları dışında iki durum da davanın esasına girilmesine engel olan usulî itirazlardır; bunlar, mahkemenin yetkili olmaması ve tahkim itirazlarıdır. Davanın esasına girilmesini önleyen bu durumlara (dava engellerine) Kanun, ilk itiraz demektedir (m. 116). Bu maddede sayılanlar, dava şartı değildir; çünkü hâkim tarafından kendiliğinden gözetilemez. Davalı bu konuda bir ilk itirazda bulunursa, hâkim, bu ilk itirazı inceler, yerinde görürse ilk itirazın çeşidine göre gerekli kararı verir.

Davalı, ilk itirazlarını, ancak davanın başında **cevap dilekçesinde yapabilir** (m. 117; 129; 317); yapmazsa, bundan sonra karşı tarafın rızası ile de ileri süremez; ilk itirazda bulunulmazsa mahkeme, davanın esasına girerek esas hakkında karar vermekle yükümlüdür[5]. Görüldüğü gibi, **dava şartları ile** ilk itirazlar **arasında** başlıca şu **iki fark** vardır:

Hâkim, dava şartlarını kendiliğinden gözetmekle (araştırıp incelemekle) yükümlü olduğu halde, ilk itirazları **kendiliğinden gözetemez**; bunları ancak davalının ilk itirazı üzerine inceleyebilir.

---

4 Bkz. yuk. § 15.

5 Bkz. yuk. § 20, D.

Davalı, dava şartlarının eksik olduğunu yargılamanın her aşamasında (hatta kanun yolları aşamasında) ileri sürebildiği halde, ilk itirazlarını, ancak **cevap dilekçesinde yapabilir**; yapmazsa, bundan sonra ilk itirazda bulunma hakkını kaybeder (m. 131).

İlk itirazlar da, mahkemenin davayı esastan incelemesine engel olur; ancak, bunun için ilk itirazların cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. İleri sürülmezse, mahkeme davanın esasını incelemeye geçer ve artık tarafların ilk itirazları ileri sürmesine imkân kalmaz.

Bir davada, ilk önce dava şartlarının var olup olmadığı incelenir. İlk itirazların incelenebilmesi için, mahkemenin daha önce bütün dava şartlarının varlığını tespit etmiş olması gerekir. Örneğin, yetki itirazını görevli mahkeme inceler. İlk itirazlar da dava şartları gibi ön inceleme aşamasında incelenir (m. 138).

İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır (m. 117, 3). Yetki ilk itirazı[6] yukarıda incelendi. Tahkim ilk itirazı aşağıda incelenecektir[7].

b) Diğer Usulî İtirazlar

Bunlar, dava şartlarının (m. 114) bulunmadığına ilişkin itirazlar olup, davalı tarafından yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir ve mahkemece de kendiliğinden gözetilir[8].

Bu iki grup dışında bazı itirazlar daha vardır; örneğin, HMK m. 394, 403'deki itirazlar gibi. Bunlar, bir savunma aracı olmayıp, daha çok bazı ara kararlarına karşı tanınmış başvuru yolu niteliğindedir.

C) CEVAP DİLEKÇESİ

Davalının davaya verdiği cevapları içeren yazıya cevap dilekçesi denir[9].

I – CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ

Cevap dilekçesinde bulunması gereken kayıtlar m. 129'da gösterilmiştir. Buna göre, cevap dilekçesine şunlar yazılır:

1) Mahkemenin Adı

Cevap dilekçesi, davanın açıldığı mahkemeye verileceğinden, cevap dilekçesine yazılacak olan mahkemenin adı (m. 129, 1/a), davanın açıldığı ve dava dilekçesini davalıya tebliğ eden (m. 122) mahkemenin adıdır. Bundan başka, cevap dilekçesinin başına (sağ üst köşeye) davanın dosya (esas) numarası da yazılır.

---

6 Bkz. yuk. § 10, D.
7 Bkz. aşa. § 80.
8 Bkz. yuk. § 15, C.
9 Bir cevap dilekçesi örneği için Kitabın sonuna ekli (2) nolu örneğe bakınız (bkz. aşa. § 81).

2) Davacı ile Davalının Adı ve Soyadı ve Adresleri

Cevap dilekçesine, davacının ve davalının adı ve soyadı ile adresleri yazılır. Davalı yurt dışında oturuyorsa, açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres de yazılır (m. 129, 1/b; karş. 119, 1/b).

3) Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Cevap dilekçesinde davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilir (m. 129, 1/c). Bu gereklilik, doğal olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içindir.

4) Varsa Tarafların Yasal Temsilcileri ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri

Varsa, tarafların yasal temsilci veya vekillerinin adı, soyadı ve adresleri de cevap dilekçesine yazılır (m. 129, 1/ç). Davalı bir vekil aracılığı ile cevap veriyorsa, cevap dilekçesinde vekilin adı, soyadı ve adresi de yazılır.

5) Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri

Bu bölümde (m. 129, 1/d) davalı, (dava dilekçesindeki) bütün vakıaları inkâr ile yetinmek istemezse, ilk önce davacının dava dilekçesinde dayandığı **vakıalara** aynı sıra numarası altında **cevap verir** (m. 129, 1/d); bu konu yukarıda incelenmişti[10].

Daha sonra davalı, kendisinin dayandığı **vakıaları** sıra numarası altında bildirir (m. 129, 1/d); bunlar davalının **savunma araçları** olup, yukarıda incelenmişti[11].

Davalı, def'ileri, itiraz sebeplerini ve ilk itirazlarını süresinde vereceği bu cevap dilekçesinde bildirir (m. 141).

6) Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği

Davalı da, davacının iddiasında olduğu gibi (m. 119, 1/f), savunmasının dayanağı olarak ileri sürdüğü her bir vakıayı hangi delillerle ispat edeceğini cevap dilekçesinde göstermelidir (m. 129, 1/e).

Yukarıda dava dilekçesinde deliller konusunda davacı bakımından yapılan açıklamalar, kıyasen davalı bakımından da geçerlidir.

7) Dayanılan Hukukî Sebepler

Davalı, savunmasını dayandırdığı hukukî sebepleri (kanun hükümlerini) cevap dilekçesinde bildirmelidir (m. 129, 1/f).

Yukarıda dava dilekçesinde hukukî sebepler konusunda davacı bakımından yapılan açıklamalar, kıyasen davalı bakımından da geçerlidir.

---

[10] Bkz. yuk. § 19, B, II.
[11] Bkz. yuk. § 19, B, III.

8) Açık Bir Şekilde Talep Sonucu

Davalı, cevap dilekçesinin talep sonucu bölümünde, açıkladığı savunma araçlarına dayanarak ve kural olarak, davanın reddini ister. Davalının talep sonucunun da gerektiğinde gerçek iradesine (genel yorum kurallarına) göre yorumlanması gerekir.

9) Davalının Veya Varsa Yasal Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası

Cevap dilekçesinin altı, davalı veya vekili ya da yasal temsilcisi tarafından imzalanır.

II – CEVAP DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK BULUNMASI

Kanun (m. 130, 2; karş. m. 119, 2) cevap dilekçesinin içeriğindeki eksiklikler bakımından bir ayırım yapmaktadır:

Cevap dilekçesindeki mahkemenin adında (m. 129/1,a; karş. m. 119, 2); davacı ve davalının ad, soyad ve adresinde ya da yurt dışında yaşayan davalının yurt içinde bir adres göstermemesi halinde (m. 129, 1/b); davalının kimlik numarasında (m. 129, 1/c); varsa yasal temsilci ve vekilin ad, soyad adresinde (m. 129, 1/ç) ve davacının imzasında (m. 129, 1/ğ) eksiklik bulunması halinde, hâkim eksikliği tamamlaması için davalıya bir haftalık (karş. m. 119, 2) süre verir. Davalı süresi içinde eksikliği tamamlarsa herhangi bir sorun kalmaz; aksi takdirde (eksikliği tamamlamazsa), **cevap dilekçesi verilmemiş sayılır** (m. 130). Bu durumda davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr ettiği varsayılır (m. 128, 1).

Diğer eksiklik hallerinde ise, m. 128, 1 hükmü ne yapılacağını açıkça düzenlememiştir. Kanımızca, bunların eksik kalması halinde mahkeme, davayı görmeye devam edecek ve cevap dilekçesini davalı bakımından mevcut haliyle değerlendirecektir.

III – CEVAP DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ

Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi (m. 126), kural olarak dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi gibidir. Bu nedenle, burada cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesine ilişkin özellikler üzerinde durulacak, bunun dışındaki hallerde dava dilekçesi bölümüne yollama yapılmakla yetinilecektir.

Cevap dilekçesine, davacı sayısı kadar örnek eklenir. Buna göre, davacı bir (tek) kişi ise, cevap dilekçesi **iki nüsha** (davacı üç kişi ise, cevap dilekçesi dört adet) olarak verilir (m. 126, 2).

Cevap dilekçesi, başvurma harcına ve başka bir **harca tâbi değildir**; yani cevap dilekçesini verirken davalıdan harç alınmaz.

Cevap dilekçesinde delillerin gösterilmesi ve yazılı delillerin mahkemeye verilmesi yukarıda incelendi[12].

Davalı, adlî tatil sırasında da cevap dilekçesi verebilir (m. 103, 3).

---

[12] Bkz. yuk. § 19, C, I, 6.

Cevap dilekçesi hâkim veya yazıişleri müdürüne havale ettirilir (m. 159, 1). Cevap dilekçesi mahkeme kaleminde, **esas defterine kaydedilir**.

Cevap dilekçesi hâkim veya yazıişleri müdürü tarafından havale edildikten sonra (davalının eline verilmeyip) bir mahkeme görevlisi ile mahkeme kalemine gönderilirse bu halde, cevap dilekçesi, **hâkimin havale ettiği** tarihte verilmiş sayılır (m. 126, 3).

Buna karşılık, (uygulamada genellikle yapıldığı gibi) cevap dilekçesi havale edildikten sonra davalıya geri verilirse, bu durumda, cevap dilekçesinin davalı tarafından mahkeme kalemine, havale tarihinden sonraki bir tarihte verildiği, mahkeme kalemince belgelendirilmeli ve bu belgede iş sahibinin de (davalının da) imzası bulunmalıdır; aksi takdirde, esas deftere kayıt işleminin mahkeme kaleminde geciktirildiği kabul edilir ve cevap dilekçesi hâkimin cevap dilekçesini havale tarihinde verilmiş sayılır. Davalının cevap dilekçesini, hâkimin havale gününden sonraki bir günde kaleme verdiği yukarıda belirtildiği gibi belgelenirse, cevap dilekçesi o tarihte (yani, dilekçenin fiilen kaleme verildiği tarihte) verilmiş sayılır.

Mahkeme kalemi, posta giderini davalıdan aldıktan sonra, cevap dilekçesinin bir örneğini davacıya tebliğe gönderir (m. 126/4).

Davalı, **karşı dava** açmak istiyorsa, karşı davasını cevap dilekçesinde açmak zorunda değildir; esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe ile de açabilir (m. 133, 1)[13].

Davalı, cevap dilekçesinde (ilk itirazlar dahil) bütün iddia ve savunmasını bildirir (karş. m. 141)[14].

D) CEVAP SÜRESİ

Davaya cevap bir süreye tâbidir. Davalı bu süre içinde cevap dilekçesini vermelidir; aksi halde kendisi bazı yaptırımlarla karşılaşır.

I – CEVAP SÜRESİ

Yazılı yargılama usulünde[15], cevap süresi kural olarak **iki hafta** olup, Kanun tarafından belirlenmiştir (m. 127, 1/ c.1; ayrıca bkz. m. 122, 1). Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliği (m. 122, 1) tarihinden başlar. İki haftalık cevap süresi, tebliğ edildiği güne iki hafta sonra karşılık gelen günün çalışma saatinin sonunda (tatil saatinde) sona erer (m. 92, 2). Örneğin, 15 Aralık **Perşembe günü** başlayan iki haftalık cevap süresi, 29 Aralık **Perşembe günü** çalışma saati bitiminde sona erer.

---

13 Bkz. aşa. § 44.

14 Bkz. yuk. § 19, C, I, 5.

15 Basit yargılama usulünde de cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır (m. 317, 2).

II – CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI

Bazı durumlarda cevap dilekçesinin iki haftalık süre içinde hazırlanması çok zor veya olanaksız olabilir. Örneğin, cevap vermek için büyük bir ticarî işletmenin hesaplarının incelenmesi gerekiyorsa veya davalı tüzel kişiliğin kendi iç birimleriyle yazışma yapması ihtiyacı varsa, iki haftalık yasal süresi içinde cevap dilekçesinin hazırlanması zor veya imkânsız olabilir.

Bu gibi hallerde, davalı, iki haftalık cevap süresi içinde mahkemeye başvurarak ek cevap süresi isteyebilir. Mahkeme, **iki haftalık süre içinde başvurulmuş olması kaydıyla**, ileri sürülen gerekçeleri uygun görürse, davalıya, **bir defaya özgü** olmak üzere, **bir ayı geçmemek üzere ek bir süre** verebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar, taraflara derhal bildirilir (m. 127, 1/c. 2-3).

Kanuna (m. 127, 1/c. 2-3) göre, bir ayı geçmemek üzere ek süre, iki haftalık süreye eklenerek verileceğinden, cevap süresi en çok, "iki hafta + bir ay" olabilir.

E) CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMESİNİN SONUCU

Davalının süresinde usulüne göre hazırlanmış cevap dilekçesini mahkemeye vermesinin usulî sonucu, cevap süresi henüz geçmemiş (dolmamış) olsa bile, cevap dilekçesi vermiş olan davalının, cevap süresi içinde vereceği ikinci bir dilekçe ile ilk itirazda bulunamamasıdır (m. 131); çünkü cevap dilekçesi ile esasa girilmiştir ve esasa girişildikten sonra yapılan ilk itirazlar dinlenmez (m. 117). Bu vesile ile tekrar belirtelim ki, davalı, davacının açık muvafakatı veya ıslah ile de ilk itirazda bulunamaz.

F) SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN SONUÇLARI

Davalının cevap süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olmasının da bazı sonuçları vardır:

Cevap süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü **vakıaların tamamını** (davayı) **inkâr etmiş sayılır** (m. 128).

Süresinde cevap dilekçesi vermediği için davayı inkâr etmiş sayılan davalı, davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıaların doğru olmadığını, m. 191 uyarınca ispat etmeye ve bunun için karşı ispat faaliyetinde bulunmaya ve delil göstermeye yetkilidir ve bu karşı delillerle davacının iddiasının doğru olmadığını ispat edebilir. Yani davalı, sadece davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıaların doğru olmadığını (inkârı) ispat için karşı delil gösterebilir; vakıalar ileri süremez. Bu halde mahkeme, davacının iddiasının doğru olmadığını ispat için davalının göstereceği delilleri inceleyip, davacının delilleri ile birlikte değerlendirerek, varacağı sonuca göre hüküm verir. Ancak Yargıtay, kanımızca hatalı olarak, cevap dilekçesi vermeyen davalıya hiçbir şekilde delil sunma hakkı tanımamaktadır[16].

---

[16] Yargıtay HGK'nun bu yöndeki kararı ve ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, Usul-Pratik, s. 215-221.

§ 20. CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ve İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ
(TARAFLARIN İKİNCİ DİLEKÇELERİ)

Davacı dava dilekçesi ile iddiasını ileri sürer ve mahkemeden kendi lehine karar verilmesi talebinde bulunur; davalı da cevap dilekçesi ile savunmasını yapar ve davacının davasının (iddiasının) reddini ister.

Kanun, taraflara birer dilekçe daha verme olanağı tanımaktadır (m. 136). Bu dilekçeler, m. 136'da, "tarafların ikinci dilekçeleri" şeklinde belirtilmiştir.

A) CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ

Davacı, davalının dava dilekçesine karşı verdiği (ve savunmasını yaptığı) cevap dilekçesinin (m. 126-131) kendisine tebliğinden itibaren **iki hafta** içinde **cevaba cevap** (replik) **dilekçesi** verebilir (m. 136, 1).

Davacının cevaba cevap dilekçesi hakkında, dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümler (m. 118-122; 126-131), niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasen uygulanır (m. 136, 2).

Durum ve koşullara göre cevaba cevap dilekçesinin iki haftalık süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olduğu durumlarda, bir defaya özgü ve bir ayı geçmemek üzere mahkemece davacıya **ek süre** verilebilir. Ancak bunun için, davacının aynı iki haftalık süre içinde mahkemeye başvurmuş olması şarttır (m. 136, 1; 127). İki haftalık cevaba cevap süresi (veya hâkim tarafından verilen ek süre) geçtikten sonra verilen cevaba cevap dilekçesi, davayı genişletme ve değiştirme olur, ancak davalının açık onayı veya ıslah üzerine mahkemece kabul edilebilir (m. 141).

Davacı, cevaba cevap dilekçesi ile, davalının cevap dilekçesinde bildirdiği savunma sebeplerine (vakıalara, def'ilere ve itirazlara) cevap verir. Örneğin, davalı cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunmuş ise, davacı cevaba cevap dilekçesi ile zamanaşımının kesildiğini ve bunu haklı gösteren vakıaları bildirebilir. Davacı cevaba cevap dilekçesinde, davalının cevap dilekçesindeki savunmasına karşı def'i veya itiraz da ileri sürebilir. Örneğin, davalı cevap dilekçesinde davacıdan alacaklı olduğunu bildirerek takas savunmasında bulunmuş ise, davacı, takas edilen karşılık alacağın zamanaşımına uğradığını (veya ödendiğini) ileri sürebilir.

Davacı, cevaba cevap dilekçesinde, daha önce vermiş bulunduğu dava dilekçesindeki iddiaları ile bağlı değildir; iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağına tâbi olmaksızın, **dava dilekçesindeki iddialarını serbestçe değiştirip genişletebilir** (m. 141, 1). Yani, cevaba cevap dilekçesinde; talep sonucunu arttırılabilir; değiştirilebilir; yeni vakıalar ileri sürülebilir vb.

Buna karşılık davacı, cevaba cevap dilekçesini verdikten sonra veya bunun için öngörülen iki haftalık süre geçtikten sonra (ve ön inceleme aşamasının m. 141, 1/c.3 hükümleri de gözetilerek tamamlanmasından sonra), ce-

vaba cevap dilekçesinde bildirilmesi gereken ve fakat bildirilmemiş olan hususları ileri süremez; yani, cevaba cevap dilekçesindeki iddiasını (daha sonra) genişletemez, değiştiremez. Başka bir deyişle iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, bu cevaba cevap dilekçesinin verilmesi ile başlar. İddianın en geç bu aşamaya kadar teksif edilmesi gerekir. Yukarıdaki zamanaşımı örneğinde, davacı, (davalının cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunması üzerine) cevaba cevap dilekçesinde zamanaşımının kesildiğini ileri sürmemişse, davalı açık onay vermedikçe (veya ıslah yoluna başvurmadıkça), sonradan zamanaşımının kesildiğini bildiremez (m. 141).

Cevaba cevap dilekçesi, dava ve cevap dilekçesine benzer şekilde düzenlenir; davacı, cevaba cevap dilekçesinde sözü edilen ve elinde bulunan belgelerini, cevaba cevap dilekçesine ekli olarak mahkemeye vermek zorundadır (m. 136; 119; 129).

Cevaba cevap dilekçesi, derhal davalıya tebliğ edilir.

B) İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ ve DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI[1]

I – GENEL BİLGİ

Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesinden sonra, davacı bakımından iddiayı (davayı) genişletmesi ve değiştirmesi yasağı başlar. Bu çerçevede davacı, davalının rızası olmaksızın iddiasını genişletemez veya (niteliğini) değiştiremez (m. 141). Uygulamada buna **iddiayı** (davayı) **genişletme ve değiştirme yasağı** denilir.

HUMK m. 185/1, bu yasağı davanın açılması (m. 118) anından başlatırken, HMK m. 141, 1, **yasağın başlangıcını** farklı düzenlemiştir[2]. Buna göre:

Davacı, davalının cevap dilekçesine (m. 126) karşı verdiği **cevaba cevap dilekçesinde** (m. 136), dava dilekçesinde ileri sürdüğü **iddialarını** (davasını) **serbestçe genişletebilir veya değiştirebilir** (m. 141, 1/c. 1); cevaba cevap dilekçesinde yapılan genişletme veya değiştirme, yasak kapsamına girmez. Yani, (karşılıklı ikişer dilekçeden oluşan) dilekçeler aşamasında "ya-

---

1 Bkz. Saim Üstündağ, İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967; Ejder Yılmaz, Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2013.

2 "(Maddenin birinci fıkrası ile), tarafların karşılıklı dilekçelerini verdikleri aşamada, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan uyuşmazlığın genel çerçevesi içinde iddia ve savunmalarını değiştirebilecekleri kabul edilmiştir. Zira, daha uyuşmazlığın başında, karşı tarafın açıklamasını, iddia ve savunmasını tam olarak görmeden, sağlıklı ve tam bir iddia ve savunma örgüsü kurmak her zaman mümkün ve gerçekçi değildir. Karşı tarafın beyanına göre, daha önce ortaya konulmayan bir iddia veya savunmayı ileri sürmek zorunlu olabilir. Ayrıca, yeni düzenlemeyle ön inceleme aşamasında, uyuşmazlığın tam olarak tespit edilmesi de gereklidir. Bu hususlar gözetilerek, tarafların, dilekçelerinde rahat, doğru ve sağlıklı bir iddia ve savunma bütünü oluşturmalarını, maddî ve hukukî nitelendirmeleri uyuşmazlığı çözecek doğrulukta ortaya koymalarını sağlamak amacıyla, dilekçelerin verilmesi aşamasında, yani **yargılamanın ilk kesitinde, iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı uygulanmayacaktır**. Şüphesiz bu imkân, sadece cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için söz konusudur. İkişer dilekçeden sonra, hangi ad altında olursa olsun verilecek dilekçeler, sınırlama ve yasak kapsamında kabul edilmelidir" (Hükümet gerekçesi).

sak" söz konusu değildir; ancak, ikişer dilekçeden sonra, hangi ad altında olursa olsun verilecek dilekçeler, yasak kapsamındadır.

Ancak, (dilekçeler aşamasından sonraki) ön inceleme (m. 137 vd.) aşamasında da, **davalı** mazeretsiz olarak **ön inceleme duruşmasına** (m. 140) **gelmezse**, davacı, davalının muvafakatine gerek kalmaksızın, iddiasını (davasını) serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir (m. 141, 1/ c.2); bu istisnaî durumda da "yasak"tan bahsedilemez.

O halde, iddianın (davanın) genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, davanın başlangıcındaki **dilekçeler aşamasının** (ve istisnaî olarak, davalının ön inceleme duruşmasına gelmemesi halinde ön inceleme aşamasının) **tamamlanmasından sonra başlar** (m. 141, 1/c. 3). Davalının cevap dilekçesine süresi içinde cevap vermeyen davacı için, cevaba cevap süresinin dolması ile, iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı başlar.

Ayrıca, açılmış bulunan **belirsiz alacak davası**nda, alacağın miktarının veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı ile karşılaşmaksızın, davanın başında belirtmiş olduğu talebini arttırabilir (m. 107, 2).

Basit yargılama usulünde iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının başlangıcı, m. 141'den farklı olarak, **davanın açıldığı** (m. 118; 322) **andır** (m. 319)[3].

II – İDDİAYI GENİŞLETME veya DEĞİŞTİRME SAYILAN HALLER

Talep sonucunun ve dava sebebinin (vakıaların) genişletilmesi veya değiştirilmesi m. 141 anlamında iddiayı (davayı) genişletme veya değiştirmedir. Buna göre, konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir:

1) Talep Sonucunu Genişletmek veya Değiştirmek

Davacı, davalının rızası olmaksızın talep sonucunu genişletemez; davalı taraf **açık muvafakat** ederse genişletebilir (m. 141, 2). Talep sonucunu genişletmek de iki şekilde olur:

Dava konusunun arttırılması, talep sonucunu genişletmektir (karş. m. 107, 2). Davacı, ıslah yolu ile veya davalının açık muvafakati ile aynı davada dava konusunu arttırabilir. Örneğin, dava konusunun miktarı on bin liradan yirmi beş bin liraya çıkartılması, iddianın genişletilmesidir. Ancak, davalı açıkça bu artırmaya muvafakat ettiğini bildirirse dava bu miktar hakkında görülür.

Dava dilekçesinde yer alan talep sonucuna, sonradan **yeni bir talebin eklenmesi** halinde de, talep sonucu (dava) genişletilmiş olur. Örneğin, davacı üç tarla için tescil davası (TMK m. 713) açmış, keşif sırasında dördüncü tarlanın da tescilini istemiştir; davalı davanın bu şekildeki genişletilmesine açıkça onay verdiğini belirttiği takdirde mahkeme dördüncü tarla hakkında da tescil kararı verebilir.

---

[3] Bkz. aşa. § 69.

HMK m. 141 hükmü, talep sonucunun genişletilmesi veya değiştirilmesi ile ilgilidir. Bu hüküm, **talep sonucunun daraltılması** (azaltılması) hali için uygulanmaz. Talep sonucunun daraltılması (örneğin, dava konusunun on beş bin liradan on bin liraya indirilmesi), ya kısmî feragat veya davayı kısmî geri alma şeklinde olur ve bu nedenle (m. 141 hükmüne değil) davadan feragat (m. 307) veya davayı geri alma (m. 123) hakkındaki hükümlere tâbidir.

Davacı, davalının **açık muvafakati olmaksızın** (veya ıslah yoluna başvurmaksızın), **talep sonucunu değiştiremez**; davalı açıkça razı olursa değiştirebilir (m. 141, 2). Örneğin, davacı, dava dilekçesinde dava konusu olarak gösterdiği taşınmaz yerine, sonradan başka bir taşınmazı dava konusu yapmak isterse, talep sonucunu değiştirmiş olur.

Davacı, dava dilekçesinde belli bir malın aynen teslimini istediği halde, daha sonra o malın bedelinin ödenmesini isterse, talep sonucunu değiştirmiş olur.

Mahkemenin talep edilenden **başka bir şeye de hüküm vermesinin caiz olduğu hallerde**[4] davacının talep sonucunu değiştirmesi, m. 141 anlamında yasak bir dava değiştirme olarak nitelendirilemez. Yani bu hallerde, talep sonucunu değiştirmek davalının muvafakatine (rızasına) bağlı değildir. Çünkü, bu hallerde hâkim, davacının değiştirme hakkında bir talebi olmasa bile, kendiliğinden talep edilenden başka bir şeye hüküm verebilmektedir. Örneğin, boşanma yerine ayrılığa karar verilmesi gibi (TMK m. 170, III).

2) Dava Sebebini Genişletmek veya Değiştirmek

Dava sebebi (yani, vakıalar) davanın ve talep sonucunun dayandırıldığı vakıalar (olay ve olgular) olduğu için, dava sebebinin değiştirilmesi (bazen genişletilmesi) de, m. 141 anlamında (yasak olan) bir dava değiştirme olur.

Dava sebebinin, hukukî sebepler değil[5], aksine dava dilekçesinde gösterilen **vakıalar**[6] olduğunu yukarıda görmüştük. Burada, konuyu dava değiştirme bakımından tekrar incelemek gerekir.

Davacının, dava dilekçesinde bildirdiği **hukukî sebepleri** sonradan değiştirmesi (veya genişletmesi) m. 141 anlamında (yasak olan) bir **dava değiştirme değildir**. Çünkü, yukarıda ayrıntılı biçimde incelendiği gibi, davacı dava dilekçesinde hukukî sebebi gösterecek ise de, davacının dava dilekçesinde gösterdiği hukukî sebep hâkim tarafından kendiliğinden değiştirebilir ve davanın gerçek hukukî sebebi hâkim tarafından araştırılıp bulunur (m. 33). O halde davacı, dava dilekçesinde göstermiş olduğu hukukî sebebi (vakıalar aynı kalmak koşulu ile) sonradan değiştirir veya genişletirse, bununla sadece hâkime (görevini yapmada) yardım etmiş olur; yoksa, bununla davasını değiştirmiş veya genişletmiş olmaz. Bu nedenle, davacı, dava dilekçesindeki hukukî sebepleri değiştirebilmek veya genişletebilmek için davalının iznini almak zorunda değildir. Yani, bu halde davanın değiştirilmesi yasağı (m. 141) uygulanmaz.

---

4 Bkz. HMK m. 26; TMK m. 170, III; TBK m. 227, 2; TTK m. 202, 1/b; 531.
5 Bkz. yuk. § 17, B, I, 8.
6 Bkz. yuk. § 17, B, I, 6.

Buna karşılık, **davacının**, dava dilekçesinde bildirmiş olduğu **vakıaları sonradan değiştirmesi**, m. 141 anlamında bir **dava değiştirmedir**. Çünkü yukarıda görüldüğü[7] gibi, hâkim, davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıalar ile bağlı olup, davacının dilekçesinde bildirmediği vakıaları kendiliğinden gözetemez (m. 25, 1). Aynı şekilde yukarıda görüldüğü gibi, davacı dava dilekçesinde davasının dayanağı olan bütün vakıaları göstermek zorundadır (m. 119, 1/e). Buna göre, HMK iddiaların teksifi ilkesini kabul ettiğinden[8], davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıalardan (dava sebebinden) başka vakıalar ileri sürmesi, dava sebebini ve bununla davasını değiştirmesi demektir. Örneğin, davacının tapulu tarlasına davalının müdahale ettiğini bildirerek, açtığı müdahalenin (elatmanın) önlenmesi davasında mahkemece yapılan keşif sonucunda davalının müdahale ettiği yerin davacının tapusu dışında kaldığının anlaşılması, bunun üzerine davacı, bu yere yirmi yıldan fazla bir zamandan beri zilyet bulunduğunu (TMK m. 713); bu nedenle yerin maliki olduğunu ileri sürerek müdahalenin önlenmesi hakkındaki talep sonucunu (davasını) haklı göstermeye çalışabilir. Davacının sonradan ileri sürdüğü zilyetlik vakıası, davayı genişletme sayılır, davalı da buna açıkça rıza göstermezse, zilyetlik vakıasının (iddiasının) incelenmesi mümkün olmaz.

Bu **olayda** davacının (her iki halde) dayandığı hukukî sebep aynıdır. Yani mülkiyettir. Buna karşılık, mülkiyet hukukî sebebini haklı göstermek için davacının ileri sürdüğü vakıalar değişiktir: Dava dilekçesinde mülkiyet tapuya dayandırılmış iken, sonradan, o yere yirmi yıldan fazla bir zamandan beri zilyet olma vakıasına dayandırılmıştır. Dava sebebi olarak hukukî sebep kabul edilse idi, bu olayda sonradan ileri sürülen zilyetlik vakıası ile dava dilekçesinde bildirilen hukukî sebep değişmediği gerekçesiyle davalının davanın değiştirildiği itirazı yerinde görülmeyecek, yani zilyetlik vakıası (iddiası) incelenebilecekti. Oysa, davanın gerçek sebebi vakıalar olarak kabul edildiğinden ve olayda sonradan ileri sürülen zilyetlik vakıası yeni olduğundan, Yargıtay doğru olarak, bununla dava sebebinin (yani davanın) değiştirildiğine karar vermiştir.

III – İDDİAYI GENİŞLETME VEYA DEĞİŞTİRMENİN YASAK OLMADIĞI HALLER

Buraya kadar, iddiayı değiştirmenin veya genişletmenin yasak olduğu halleri ve bunun (m. 141, 2'deki) istisnalarını inceledik. Şimdi inceleyeceğimiz haller ise, davayı değiştirme yasağının (bir bakıma) istisnasıdır. Ancak, bu istisnalar mutlaktır. Yani bu hallerde, davanın değiştirilebilmesi için, davalının rızasına veya ıslah yoluna başvurmaya gerek yoktur.

1) Talep Edilenden Başka Bir Şeye de Hüküm Verilebilen Haller

Mahkemenin talep edilenden başka bir şeye de hüküm vermesinin caiz olduğu hallerde, davayı değiştirmenin yasak olmadığı yukarıda kısaca belirtilmişti.

---

7 Bkz. yuk. § 17, B, I, 6.
8 Bkz. yuk. § 5, H.

2) Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalar

Kamu düzeni düşüncesi ile (mahkemece) kendiliğinden araştırma ilkesinin[9] uygulandığı davalarda, hâkim belli vakıaları kendiliğinden araştırma yetkisine (ve yükümlülüğüne) sahip olduğu için, davacının, bu vakıaları sonradan ileri sürmesi (m. 141, 2 anlamında) iddiayı değiştirme sayılmaz. Yani davacı, bu vakıaları davalı açık muvafakat etmese de ıslah yapmaya da gerek kalmadan ileri sürebilir; örneğin, **evlilik birliğinin korunması** (TMK m. 195 vd.) kamu düzenini ilgilendirdiği için mahkeme her çeşit delili kendiliğinden toplayabilir. Bu itibarla bu tür davalarda iddianın genişletilmesi söz konusu olamaz. Onun için davacının başlangıçta kocanın ayrı evinin bulunmadığını ileri sürmemiş olması, sonradan (kocasına karşı nafaka davası açmış olan karının) bunu ileri sürmesine engel değildir.

Bir babalık davasında, TMK m. 304 gereğince velayetin ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi, iştirak nafakasının takdiri hususları kendiliğinden gözetilecek yönlerden olup, iddianın genişletilmesi söz konusu olamaz.

Babalık davası devam ettiği sürece, manevî tazminat talep şartları mevcut ise tazminata hükmolunabilir. Bu konuda m. 141 hükümleri uygulanmaz.

3) Dava Açılmasından Sonra Doğan Olaylar

Davayı değiştirme yasağı, dava açılırken mevcut ve bu nedenle dava dilekçesinde ileri sürülmesi mümkün olan vakıalar için söz konusu olabilir. Buna karşılık, **dava açılmasından sonra doğan** ve dava sebebi olarak gösterilen **vakıalar**la ilgili olan (ayrı bir dava sebebi olacak nitelikte ve kapsamda olmayan) olayların ileri sürülmesi, davayı değiştirme sayılmamalıdır. Çünkü, dava açıldığı zaman henüz doğmamış olan bu olayların dava açılırken öngörülmesi ve dava dilekçesinde bildirilmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle, davacı, (davalının rızası aranmaksızın ve ıslah yoluna başvurmaksızın) bu yeni olayları ileri sürebilmelidir. Örneğin, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK m. 162) yahut evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166) sebebiyle, açılan boşanma davasında dayanılan vakıalara benzer veya davanın sebebi olarak gösterilen vakıaların tekrarı niteliğindeki yeni vakıalar (davanın açılmasından sonra) doğarsa, bunlar davayı değiştirme yasağına tâbi olmaksızın ileri sürülebilirler.

4) Belirsiz Alacak Davası Bakımından Kabul Edilen Özel Durum

Yukarıda da belirtildiği üzere, belirsiz alacak davası (m. 107) dava açılırken belirlenebilen asgarî bir miktar veya değer üzerinden açıldıktan sonra, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucunda, alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmasının ardından, davacı, davanın başında (dava dilekçesinde) bildirdiği **talebini arttırabilir**. Bu artırma iddianın genişletilmesi yasağına tâbi değildir (m. 107, 2).

---

[9] Bkz. yuk. § 5, E.

5) Tarafta İradî Değişiklik[10]

Kanunlarda yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın izni ile mümkündür. Ancak, **maddî bir hatadan kaynaklanan** veya **dürüstlük kuralına aykırı olmayan** taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilebilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim **karşı tarafın rızasını aramaksızın** taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder (m. 124).

Dava sırasında yapılan bazı değişiklikler, m. 141, 2 anlamında davayı değiştirme sayılmaz; bu nedenle, bu değişikliklerin yapılması davalının açık muvafakatına veya ıslaha bağlı değildir:

Hukukî sebeplerin değiştirilmesi, iddiayı değiştirme değildir; bunu yukarıda inceledik.

Talep sonucunun daraltılması (azaltılması), m. 141 anlamında iddiayı değiştirme sayılmaz; bu konuya da yukarıda değinildi.

Ayrı bir dava sebebi oluşturacak nitelikte bulunmayan, **asıl vakıaya zımnen dahil olan vakıaların** ileri sürülmesi, dava sebebinin (iddianın) genişletilmesi sayılmaz.

Davacının sonradan ileri sürdüğü vakıa, **dava dilekçesinde bildirdiği vakıaların delili niteliğinde** ise, bu halde de dava sebebinin (iddianın) genişletilmesinden söz edilemez. Çünkü, sonradan ileri sürülen husus, dava dilekçesinde dayanılan vakıayı hükümden düşürmemekte, aksine onu ispata yaramaktadır. O halde, bu husus delili olduğu vakıadan ayrı olarak davaya dayanak teşkil edemez ve bu nedenle de davanın sebebi sayılamaz; örneğin:

Davacı, dava dilekçesinde davalının müdahalesinin (el atmasının) önlenmesini istediği taşınmazın tapulu mülkü olduğunu bildirmiş ise, bu iddiasına (talebine) ilk dayanak gösterdiği tapudan başka bir tapu senedi ile ispat edebilir. Çünkü, burada hukukî sebep mülkiyet, dava sebebi ise taşınmaza tapu ile malik olunması vakıasıdır. Davacı, bu dava sebebini ispat için gösterdiği ikinci tapu senedi ile dava sebebini değiştirmemektedir; bu husus ikinci (bağımsız) bir vakıa değil, sadece aynı cinsten ikinci bir delildir.

Buna karşılık, davacı o taşınmaz üzerindeki mülkiyet iddiasını tapu yerine, yirmi yıldan fazla olan zilyetlik vakıasına (TMK m. 713) dayandırmış olsa idi, olayda hukukî sebep (mülkiyet) aynı kalmakla beraber, bunun dayanağı olan vakıalar değişik olacağından, yukarıda görüldüğü gibi, dava (sebebi) değiştirilmiş olurdu.

---

[10] Bkz. Hülya Taş Korkmaz, Medenî Usul Hukukunda İradî Taraf Değişikliği, Ankara 2014.

IV– İDDİAYI GENİŞLETME veya DEĞİŞTİRME YASAĞININ İSTİSNALARI

Buraya kadar, m. 141 anlamında davayı değiştirmenin (veya genişletmenin) yasak olduğu halleri inceledik. Bundan sonraki (IV numaralı başlık altında) davayı değiştirme yasağına tâbi olmayan haller incelenecektir. Burada ise, davayı değiştirmenin yasak olduğu hallerde, **dava değiştirmenin nasıl mümkün olduğu** inceleme konusu yapılacaktır. Davayı değiştirme yasağının istisnaları da, m. 141, 2 hükmünde belirtilmiştir: Davalının açık muvafakatı (rızası), ıslah ve davalının mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına gelmemesi.

Davalının Açık Muvafakatı: Yukarıda davayı değiştirmenin yasak olduğunu gördüğümüz hallerde, davalı buna (iddiayı genişletme veya değiştirmeye açıkça) muvafakat ederse (rıza gösterirse), davacı davayı değiştirebilir veya genişletebilir (m. 141).

Davalının (davayı değiştirmeye) muvafakatının **açık olması**[11] **gerekir** (m. 141, 2). Kanun (m. 141, 2), kullandığı "açık" ifadeyle zımnî muvafakatın yeterli olmadığını belirtmiştir.

Islah: Davalı, davanın değiştirilmesine muvafakat etmezse davacı, davasını ıslah ederek (m. 176 vd.) davayı değiştirebilir (m. 141, 2). Örneğin, davacı, ıslah yolu ile dava konusunu (müddeabihi) arttırabilir.

Davacı, (davalının açık rızası veya ıslah yolu ile) ancak yargılamanın bitimine (hüküm verilinceye) kadar davasını değiştirebilir.

Davalının Mazeretsiz Olarak Ön İnceleme Duruşmasına Gelmemesi: Kanun koyucu, ön inceleme duruşmasına tarafların katılımını sağlamak, özellikle hâkimin tahkikat için yol haritasını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için bir anlamda ödül-ceza düzenlemesi yapmıştır. Buna göre, davalı, usulüne uygun uyarılı bir davetiye ile davet edildiği ön inceleme duruşmasına mazeretsiz katılmazsa, davacı serbestçe, dava ve cevaba cevap dilekçelerindeki iddialarını değiştirip genişletebilir. Bu durum, diğer genişletme veya değiştirme hallerinden farklı olarak yalnızca ön inceleme aşamasında söz konusu olur.

Davalı, davayı değiştirmeye açık muvafakat ederse veya dava ıslah edilirse, mahkeme, davayı değiştirilmiş (veya genişletilmiş) olarak (yani, yeni şekli ile), inceleyip karara bağlar.

Davalı, davayı değiştirmeye açık muvafakat etmezse ve davacı davasını ıslah da etmezse, mahkeme, davacının davayı değiştirme talebini dikkate almadan, davayı eski hali ile inceleyip karar bağlar.

Davalı, davayı değiştirmeye açık muvafakat etmezse ve davacı davasını ıslah da etmezse, davacı, o davada mahkemece inceleme konusu yapılmayan davayı değiştirme talebini yeni bir dava konusu yapabilir; yani yeni (ayrı) bir dava açabilir.

---

[11] Karş. HUMK m. 185/2.

C) İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ

Davalı, davacının verdiği cevaba cevap dilekçesinin (m. 136, 1) kendisine tebliğinden itibaren **iki hafta** içinde bu dilekçeye cevap verebilir.

Kanun (m. 136, 1), davalının vereceği bu dilekçeye (davalının, dava dilekçesine karşı verdiği cevap dilekçesini birinci cevap dilekçesi olarak kabul ederek), **ikinci cevap dilekçesi** (düplik) demektedir.

Dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümler (m. 118-122; 126-131), davalının ikinci cevap dilekçesi hakkında da kıyasen uygulanır (m. 136, 2).

Durum ve koşullara göre ikinci cevap dilekçesinin iki haftalık süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olduğu durumlarda, bir defaya özgü olmak ve bir ayı geçmemek üzere, mahkemece davalıya ek süre verilebilir. Ancak bunun için, davalının aynı iki haftalık süre içinde mahkemeye başvurmuş olması şarttır (m. 136, 1; 127).

İki haftalık ikinci cevap dilekçesi süresi (veya hâkim tarafından verilen ek süre) geçtikten sonra verilen ikinci cevap dilekçesi, savunmayı genişletme ve değiştirme olur, ancak, davacının açık muvafakati veya ıslah üzerine mahkemece kabul edilebilir (m. 141).

Davalı, ikinci cevap dilekçesi ile, davacının cevaba cevap dilekçesinde bildirdiği yeni, değiştirilmiş veya genişletilmiş iddia sebeplerine (vakıalara, def'ilere ve itirazlara) cevap verir. Örneğin, davacı cevaba cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunmuş ise, davalı ikinci cevap dilekçesi ile zamanaşımının kesildiğini ve bunu (zamanaşımı kesilmesini) haklı gösteren vakıaları bildirebilir.

Örneğin, davalı cevap dilekçesinde davacıdan alacaklı olduğunu bildirerek takas savunmasında bulunmuş ise, davacı, cevaba cevap dilekçesinde takas edilen karşılık alacağın zamanaşımına uğradığını (veya ödendiğini) ileri sürebilir. Davalı ikinci cevap dilekçesinde, davacının cevaba cevap dilekçesindeki savunmasına karşı def'i (veya itiraz da) ileri sürebilir.

Davalı, ikinci cevap dilekçesinde, daha önce vermiş bulunduğu cevap dilekçesindeki savunmaları ile bağlı değildir; savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağına tâbi olmaksızın, cevap dilekçesindeki savunmalarını serbestçe değiştirip genişletebilir (m. 141, 1). Yani, davalı ikinci cevap dilekçesinde, savunma sebeplerini değiştirebilir; yeni vakıalar ileri sürebilir vb. Ancak, daha önce ileri sürmediği (yeni) ilk itirazda bulunamaz (m. 117, 1; 131).

Buna karşılık davalı, ikinci cevap dilekçesini verdikten sonra veya bunun için öngörülen iki haftalık sürenin geçmesinden ve ön inceleme aşamasının (m. 141, 1/c. 3) tamamlanmasından sonra, ikinci cevap dilekçesi ile bildirilmesi gereken ve fakat bildirilmemiş olan hususları ileri süremez; yani, ikinci cevap dilekçesindeki iddia ve savunmasını genişletemez. Yukarıdaki zamanaşımı örneğinde, davalı, (davacının cevaba cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunması üzerine) ikinci cevap dilekçesinde zamanaşımının kesildiğini ileri sürmemişse, davacı açık muvafakat etmedikçe (veya davalı ıslah yoluna başvurmadıkça), sonradan zamanaşımının kesildiğini bildiremez

(m. 141). Çünkü, savunmayı genişletme ve değiştirme yasağı, ikinci cevap dilekçesinin verilmesiyle başlamıştır.

İkinci cevap dilekçesi, dava ve cevap dilekçesine benzer şekilde düzenlenir; davalı, ikinci cevap dilekçesinde sözü edilen ve elinde bulunan belgelerini, cevaba cevap dilekçesine ekli olarak mahkemeye vermek zorundadır (m. 136; 119; 129).

İkinci cevap dilekçesi, derhal davacıya tebliğ edilir.

İkinci cevap dilekçesinin verilmesi ile (veya ikinci cevap dilekçesi verilmemişse, iki haftalık sürenin geçmesi ile) davanın dilekçeler aşaması sona erer; bundan sonra ön inceleme (m. 137) yapılır.

Davalı ikinci cevap dilekçesini süresi içinde vermemişse, davalı, sadece davacının cevaba cevap dilekçesinde bildirdiği vakıaların doğru olmadığını ispat için delil göstermekle yetinebilir. Bu durumda davalı, davayı inkârının karşı delilini göstermek bahanesiyle yeni vakıalar, (örneğin zamanaşımı) ileri sürerse, savunmasını genişletmiş olur; bu ise, kural olarak yasaktır (m. 141).

D) SAVUNMAYI GENİŞLETME VE DEĞİŞTİRME YASAĞI

I – GENEL BİLGİ

İkinci cevap dilekçesi verilmesinin en önemli sonucu, davalının, davanın bu aşamasından sonra, savunmasını genişletmesinin ve değiştirmesinin yasak olmasıdır. Bu çerçevede davalı, davacının açık izni olmaksızın savunmasını genişletemez veya değiştiremez (m. 141). Uygulamada buna (davacı bakımından geçerli bulunan, "iddiayı genişletme ve değiştirme yasağı"na paralel olarak) "**savunmayı genişletme ve değiştirme yasağı**" denilir.

HUMK m. 202, bu yasağı, cevap dilekçesinin davacıya tebliği tarihinden başlatmakta idi; HMK m. 141, 1, **yasağın başlangıcını** ikinci cevap dilekçesinin verilmesi olarak belirlemiştir. Ancak, Kanun istisnai olarak, ön inceleme aşamasının tamamlanması ile yasağın başlamasının mümkün olduğunu da düzenlemiştir (m. 140)[12]. Buna göre:

Davalı, davacının cevaba cevap dilekçesine karşı verdiği ikinci cevap dilekçesinde (m. 136), cevap dilekçesinde ileri sürdüğü **savunmalarını ser-**

---

[12] "Maddenin birinci fıkrası ile, tarafların karşılıklı dilekçelerini verdikleri aşamada, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan uyuşmazlığın genel çerçevesi içinde iddia ve savunmalarını değiştirebilecekleri kabul edilmiştir. Zira, daha uyuşmazlığın başında, **karşı tarafın açıklamasını, iddia ve savunmasını tam olarak görmeden, sağlıklı ve tam bir iddia ve savunma örgüsü kurmak her zaman mümkün ve gerçekçi değildir.** Karşı tarafın beyanına göre, daha önce ortaya konulmayan bir iddia veya savunmayı ileri sürmek zorunlu olabilir. Ayrıca, yeni düzenlemeyle ön inceleme aşamasında, uyuşmazlığın tam olarak tespit edilmesi de gereklidir. Bu hususlar gözetilerek, tarafların, dilekçelerinde rahat, doğru ve sağlıklı bir iddia ve savunma bütünü oluşturmalarını, maddî ve hukukî nitelendirmeleri uyuşmazlığı çözecek doğrulukta ortaya koymalarını sağlamak amacıyla, dilekçelerin verilmesi aşamasında, yani **yargılamanın ilk kesitinde, iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı uygulanmayacaktır.** Şüphesiz bu imkân, sadece cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için söz konusudur. **İkişer dilekçeden sonra, hangi ad altında olursa olsun verilecek dilekçeler, sınırlama ve yasak kapsamında kabul edilmelidir**" (Hükümet gerekçesi).

bestçe genişletebilir veya değiştirebilir (m. 141, 1/c.1). Örneğin, ilk dilekçesinde zamanaşımı defini ileri sürmemiş olan davalı, ikinci cevap dilekçesinde zamanaşımı definde bulunabilir. İkinci cevap dilekçesinde yapılan genişletme veya değiştirme, yasak kapsamına girmez. Yani, karşılıklı ikişer dilekçeden oluşan dilekçeler aşamasında "yasak" söz konusu değildir; ancak, ikişer dilekçeden sonra, hangi ad altında olursa olsun verilecek dilekçeler sınırlama ve yasak kapsamında kabul edilir.

Dilekçeler aşamasından sonraki ön inceleme (m. 137 vd.) aşamasında da, **davacı** mazeretsiz olarak **ön inceleme duruşmasına** (m. 140) **gelmezse**, davalı, davacının iznine gerek kalmaksızın, savunmasını serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir (m. 141, 1/c. 2); bu istisnaî durumda da "yasak"tan bahsedilemez.

O halde, savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, davanın başlangıcındaki dilekçeler aşamasından (ve istisnaî olarak, davacının ön inceleme duruşmasına gelmemesi halinde ön inceleme aşamasının tamamlanmasından) sonra (m. 141, 1/c. 3) başlar.

Basit yargılama usulünde savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının başlangıcı, m. 141'den farklı olarak, **cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi** (m. 126; 322) **tarihi**dir (m. 319)[13].

II – SAVUNMAYI GENİŞLETME SAYILAN HALLER
(Savunmayı Genişletme Yasağına Tâbi Olan Haller)

1) Def'iler

Davalı, cevap dilekçesinde bildirmediği def'ileri (yasağın başlamasından, m. 141; 319) sonra ileri sürerse, bununla savunmasını genişletmiş olur. Örneğin, cevap veya ikinci cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunmamış olan davalı, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra (m. 141, 1/c. 3) zamanaşımını ileri sürerse, bununla savunmasını genişletmiş olur.

2) Vakıaların Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Savunmayı Genişletmedir

Yukarıda görüldüğü gibi, davalı, savunmasını dayandırdığı bütün vakıaları cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde göstermek zorundadır[14]. Hâkim, davalının cevap dilekçesinde bildirdiği vakıalar ile bağlı olup, davalının cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde bildirmediği vakıaları kendiliğinden gözetemez (m. 25, 1). Bu nedenle, davalının, cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde savunmasını dayandırdığı vakıaları genişletmesi veya değiştirmesi, savunmayı genişletmedir. Örneğin, cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde davacının kendisine verdiğini iddia ettiği parayı almadığını bildiren davalının, sonradan bu parayı nişan hediyesi olarak aldığını bildirmesi savunmayı genişletmedir.

---

[13] Bkz. aşa. § 69.
[14] Bkz. HUMK m. 201/1.

Cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde dava konusu bononun bedelsiz olduğunu bildiren davalının, sonradan bono bedelini ödediğini ileri sürmesi savunmayı genişletmedir.

Cevap dilekçesinde veya ikinci cevap dilekçesinde dava konusu senetteki imzayı inkâr eden davalının, sonradan (senetteki imzanın kendisine ait olduğunun anlaşılması üzerine) senedi boş imzalı olarak davacıya verdiğini ileri sürmesi savunmayı genişletmedir.

Davalının, savunmasını cevap veya ikinci cevap dilekçesinde tapu kaydına dayandırması, sonradan (örneğin, tahkikat aşamasında) dava konusu yere yirmi yıldan fazla bir zamandan beri zilyet bulunması nedeniyle malik olduğunu (TMK m. 713) ileri sürmesi savunmayı genişletmedir.

3) İtirazların İleri Sürülmesi ve Savunmayı Genişletme

Maddî hukuk anlamındaki itirazlar yukarıda incelendi[15]. Şimdi, itirazların davalı tarafından sonradan ileri sürülmesinin savunmayı genişletme olup olmadığı incelenecektir.

Dava dosyasından anlaşılabilen itiraz sebeplerinin cevap dilekçelerinin verilmesinden sonra ileri sürülmesi m. 141 anlamında (yasak olan) savunmayı genişletme değildir. Çünkü hâkim, dava dosyasından anlaşılan itiraz sebeplerini kendiliğinden gözetmekle yükümlüdür.

Buna karşılık, davacının dilekçelerinden anlaşılamayan itiraz sebepleri, davalı tarafından süresi içinde verilmiş olan cevap dilekçelerinde bildirilmemiş ise, bu itiraz sebeplerinin sonradan ileri sürülmesi savunmayı genişletme yasağına (m. 141) tâbidir. Çünkü, bu itiraz sebeplerinin sonradan ileri sürülmesi yeni vakıaların bildirilmesi demektir; vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi ise, savunmayı genişletmedir.

Davacının dilekçelerinden (ve davalının süresinde verdiği cevap dilekçelerinden) anlaşılamayan itiraz sebeplerinin davalı tarafından yasağın başlamasından sonra ileri sürülmesi halinde, davacı savunmanın genişletilmesine izin vermez ve davalı ıslaha da başvurmazsa, davalının sonradan bildirdiği itiraz sebepleri (vakıalar) mahkemeye usulüne uygun biçimde bildirilmiş sayılamaz. Bu nedenle, hâkim, sonradan bildirilen bu itiraz sebeplerini (vakıaları) kendiliğinden gözetemez; yani, bu vakıalara dayanarak hüküm veremez. O halde, davalının bu itiraz sebeplerini sonradan ileri sürmesi, m. 141 anlamında (yasak olan) savunmayı genişletmedir.

Yargıtay, bütün itiraz halleri için savunmanın genişletilmesi yasağının uygulanmayacağı görüşündedir.

III – SAVUNMAYI GENİŞLETME YASAĞININ İSTİSNALARI

Buraya kadar, m. 141'de düzenlenen, savunmayı genişletmenin yasak olduğu haller incelendi. Bundan sonraki (IV numaralı) başlık altında savunmayı genişletme yasağına tâbi olmayan haller incelenecektir. Burada ise,

---

15 Bkz. yuk. § 19, B, III.

savunmayı genişletmenin yasak olduğu hallerde, savunmayı genişletmenin nasıl mümkün olduğu inceleme konusu yapılacaktır.

Savunmayı genişletme yasağının istisnaları da, aynı hükümde (m. 141'de) belirtilmiştir. Buna göre davacının açık izni ve ıslah ile davacının mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına gelmemesi halinde davalı, savunmasını değiştirip genişletebilir.

Davacının Açık Muvafakati: Yukarıda savunmayı genişletmenin yasak olduğunu gördüğümüz hallerde, davacı buna açık muvafakat ederse, davalı savunmasını genişletebilir (m. 141, 2).

Davacının savunmayı değiştirmeye muvafakatinin açık olması gerekir (m. 141, 2). Kanunda kullanılan "açık" ifadesi, örtülü muvafakatin yeterli olmadığını göstermektedir.

Islah: Davacı savunmayı genişletmeye açık bir şekilde muvafakat vermezse, davalı, cevap dilekçesini ıslah ederek (m. 176 vd.) savunmasını genişletebilir (m. 141, 2).

Örneğin davalı, verdiği cevap ve ikinci cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunmayı unutmuş veya alacağın zamanaşımına uğradığını daha sonra (m. 141, 1'de belirtilen yasağın başlamasından sonra) fark etmiştir; davalı sonradan zamanaşımı def'inde bulunmuş ise de, davacı bu savunmanın genişletilmesine açıkça muvafakat vermemiştir. Bunun üzerine, davalı, savunmasını ıslah ederek (düzelterek) zamanaşımı def'inde bulunabilir (m. 141, 2)[16].

Davalı, davacının muvafakati veya ıslah yolu ile yargılamanın bitimine (hüküm verilinceye) kadar savunmasını genişletebilir.

Davacının Mazeretsiz Olarak Ön İnceleme Duruşmasına Gelmemesi: Kanun koyucu, ön inceleme duruşmasına taraflarını katılımını sağlamak, özellikle hâkimin tahkikat için yol haritasını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için bir anlamda ödül-ceza düzenlemesi yapmıştır. Buna göre, davacı, usulüne uygun uyarılı bir davetiye ile davet edildiği ön inceleme duruşmasına mazeretsiz katılmazsa, davalı, serbestçe cevap ve ikinci cevap dilekçelerindeki savunmalarını değiştirip genişletebilir. Bu durum, diğer genişletme veya değiştirme hallerinden farklı olarak yalnızca ön inceleme aşamasında söz konusu olur.

Davacı savunmayı genişletmeye açıkça muvafakat verir; davalı savunmasını ıslah eder veya davacı mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına katılmazsa, davalı savunmayı genişletebilir ve mahkeme, davalının savunmasını genişletilmiş (yani yeni) şekli ile inceleyip karara bağlar; örneğin, davalının zamanaşımı savunmasını inceler.

Buna karşılık, davacı davalının savunmasını genişletmesine açık muvafakat vermezse (ve davalı savunmasını ıslah da etmezse), mahkeme, davalının savunmasını, genişletilmiş şekli ile değil, eski hali ile inceler; örneğin, davalının (sonradan ileri sürdüğü) zamanaşımı savunmasını inceleme konusu yapamaz.

---

[16] Bkz. m. 176 ile ilgili Hükümet gerekçesi.

IV – SAVUNMAYI GENİŞLETMENİN YASAK OLMADIĞI HALLER

Buraya kadar, savunmayı genişletmenin yasak olduğu haller ve bunun (m. 141, 1-2) istisnaları incelendi. Şimdi incelenecek haller de savunmayı genişletme yasağının (bir anlamda) istisnasıdır. Fakat, bu istisnalar mutlaktır. Yani bu hallerde, savunmayı genişletebilmek için, davacının açık muvafakatine veya ıslah yoluna başvurmaya gerek yoktur.

1) Mahkemenin Kendiliğinden İncelemesi Gereken Hususlar

Davalı, mahkemenin kendiliğinden incelemesi (gözetmesi) gereken hususları, cevap dilekçesinden ve ikinci cevap dilekçesinden sonra da ileri sürebilir ve bu (m. 141, 1 anlamında) yasak olan bir savunmayı genişletme değildir; yani, bunun için davacının açık muvafakatine ihtiyaç yoktur; örnekler:

Davalı, dava şartlarından (m. 114) birinin bulunmadığı itirazını her zaman yapabilir (m. 115, 1)[17].

Davalı, davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığı itirazını her zaman yapabilir.

Davalı, dava dosyasına usulüne uygun biçimde girmiş dava malzemesinden (davacının her türlü dilekçesi ile davalının cevap süresi içinde verdiği cevap dilekçesinden) anlaşılabilen itiraz sebeplerini de sonradan ileri sürebilir[18].

2) Sonradan Doğan Savunma Sebeplerinin İleri Sürülmesi

Savunmayı genişletme yasağı, cevap ve ikinci cevap dilekçesi verildiği zaman var olan ve bu nedenle cevap dilekçelerinde bildirilmesi mümkün olan savunma sebepleri (vakıalar, def'iler ve itirazlar) için söz konusu olabilir.

Buna karşılık, cevap veya ikinci cevap dilekçesinin verilmesinden sonra doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi, savunmayı genişletme yasağına tâbi değildir. Çünkü, cevap veya ikinci cevap dilekçesi verildiği zaman henüz doğmamış olan savunma sebeplerinin, daha önceki cevap dilekçeleri verilirken öngörülmesi ve bildirilmesi imkânsızdır. Bu nedenle, davalı, (davacının açık muvafakatine ihtiyaç duymaksızın) bu yeni savunma sebeplerini sonradan ileri sürebilmelidir; örnekler:

Davalı, dava edilen alacağı dava sırasında davacıya ödemiş ise, davacının rızasına ihtiyaç olmaksızın, borcu ödediğini ileri sürebilir. Bu halde mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına karar verir.

Dava devam ederken, davalıya takas etme yetkisi (TBK m. 139) gelirse davalı, davacının açık muvafakatına ihtiyaç duymaksızın, dava sırasında takası ileri sürebilir.

Aşağıdaki haller, m. 141 anlamında savunmayı genişletme ve değiştirme sayılmaz; bu nedenle, davalının açık izni gerekmez.

---

17 Bkz. yuk. § 15, C.

18 Bkz. yuk. § 19, B, III.

Davalının, cevap veya ikinci cevap dilekçesinde bildirdiği **hukukî sebepleri** sonradan değiştirmesi veya genişletmesi, m. 141 anlamında (yasak olan) bir savunmayı genişletme değildir. Çünkü, davalı cevap veya ikinci cevap dilekçesinde hukukî sebep gösterecek ise de bu hukukî sebep mahkeme tarafından kendiliğinden değiştirilebilir ve gerçek hukukî sebep hâkim tarafından araştırılıp bulunur (m. 33).

O halde davalı, cevap veya ikinci cevap dilekçesinde göstermiş olduğu hukukî sebebi (vakıalar aynı kalmak şartı ile) sonradan değiştirir veya genişletirse, bununla sadece hâkime (görevini yapmada) yardım etmiş olur; yoksa, bununla savunmasını genişletmiş olmaz. Bu nedenle, davalı, cevap dilekçesindeki hukukî sebepleri değiştirebilmek veya genişletebilmek için davacının muvafakatını almak zorunda değildir. Yani, bu halde savunmayı genişletme yasağı (m. 141, 1) uygulanmaz.

Cevap veya ikinci cevap dilekçesinde belirtilen vakıalara **zımnen dahil olan vakıaların** sonradan ileri sürülmesi de, savunmayı genişletme sayılmaz.

Davalının sonradan ileri sürdüğü husus, cevap veya ikinci cevap dilekçesinde bildirdiği vakıaların **delili** niteliğinde ise, bu halde savunmayı genişletmeden söz edilemez. Örneğin;

Davalı, cevap veya ikinci cevap dilekçesinde dava konusu yerin tapulu mülkü olduğunu bildirmişse, bu savunmasını ilk dayandığı tapudan başka bir tapu senedi ile ispat edebilir. Buna karşılık davalı, sonradan zilyetlik vakıasına (TMK m. 713) dayanırsa, savunmayı genişletme yasağına tâbi olur.

Yukarıda incelenen savunmayı genişletme yasağı ve istisnaları, maddî hukuka dayanan savunma araçları içindir. İlk itirazlar, savunmayı genişletme yasağına (özellikle bu yasağın istisnalarına) tâbi değildir. İlk itirazlar, davacı açık muvafakat etse bile, cevap süresi geçtikten (veya cevap dilekçesi verildikten) sonra (bir daha) ileri sürülemez; bu konuda ıslah da olmaz.

Yukarıda incelenmiş olan savunmayı genişletme yasağı ve istisnaları, süresinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı hakkında da uygulanır. Bu konuda, süresinde cevap dilekçesi veren davalı ile vermeyen davalı arasında bir fark yoktur.

Çünkü, süresinde verdiği cevap dilekçesinde, davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıaları inkâr eden davalı ile, süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalı arasında fark yoktur; o da davayı inkâr etmiş sayılır. O halde, her iki durumda da davalının inkâr savunmasını genişletmesi, savunmayı genişletme yasağına (m. 141) tâbidir.

Buna göre, süresinde cevap dilekçesi vermemiş olan (veya süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi veren) davalının sonradan bir def'i veya vakıa ileri sürmesi, savunmayı genişletme yasağına tâbidir.

Örneğin, süresinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, sonradan zamanaşımı def'inde bulunursa, bununla (inkâr) savunmasını genişletmiş olur. Davacı buna açıkça izin vermez (ve davalı inkâr savunmasını ıslah da etmez) ise, mahkeme zamanaşımı savunmasını inceleme konusu yapamaz.

Buna karşılık, davacı, süresinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının sonradan ileri sürdüğü zamanaşımı def'ine açıkça muvafakat ederse veya davalı ıslah yoluna başvurursa bu halde mahkeme, zamanaşımı savunmasını inceleme konusu yapar.

YARGILAMA
(ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)

§ 21. ÖN İNCELEME

A) GENEL BİLGİ

HMK, ilk derece mahkemesinde açılan bir davanın görülmesi ve karara bağlanması sürecinin beş aşamadan oluşmasına göre kurallar koymuştur. Bu aşamalardan biri olan "Ön İnceleme" ilk defa ayrı başlık altında Yazılı Yargılama Usulü başlıklı Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm'de m. 137'de düzenlenmiştir[1]. Bu düzenleme HMK'nun getirdiği en önemli yeniliklerden biridir.

Ön inceleme müessesesinin kabulünün gerekçesi, şöyle belirtilmektedir[2]:

"Uygulamada en çok şikâyet edilen ve yargılamanın gecikmesi sebebi olarak gösterilen önemli bir husus, mahkemelerce **tam hazırlık yapılmadan tahkikata başlanmasıdır**. Çoğu kez, taraflar delillerini tam olarak göstermeden ve dilekçelerine eklemeden, mahkeme de delilleri tam olarak toplamadan tahkikata başlamaktadır. Delillerin ve hukukî uyuşmazlığın tartışılması için yeterli hazırlık yapılmadan tahkikata başlandığında, istenen sonuç elde edilememekte; tahkikat, delillerin toplanması için gereksiz yere uzamaktadır. Bunun yanında, mahkemelerce, yeterli hazırlık yapılıp dosyalar incelenmediğinden ve taraflar da bu konuda gerekli açıklamaları tam olarak yapmadıklarından, yargılamanın başında karar verilmesi gereken, usule ilişkin dava şartları ve ilk itirazlar hakkında davanın sonunda karar verilebilmektedir. Örneğin, iki yıl süren bir davanın sonunda, bazen mahkemenin görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verdiği veya zamanaşımı gerekçesiyle davayı reddettiği görülebilmektedir. Dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan ve tarafların elinde bulunan delillerin mahkemeye sunulmasından, elde ol-

---

1 HUMK'nda bu aşamada yapılması gereken usul işlemleri hakkında ayrı başlık altında ve "ön inceleme" adı verilerek ayrıntılı bir düzenleme bulunmamakta idi. Uygulamada mahkemeler, dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi (dava açılması) üzerine, hemen bir tensip tutanağı düzenlemekte ve bu tensip tutanağında, davada yapılacak olan hususlarla ilgili kararların yanı sıra, duruşma günü de tayin etmekte idiler. Bunun sonucunda; bir yandan taraflar arasında dilekçeler alınıp verilirken (teati edilirken), diğer yandan duruşmalar yapılmakta idi. Her iki tarafın dilekçeleri toplanıp iddia ve savunmalarının ne olduğu anlaşılmadan ve bu konuda gerekli bazı kararlar alınmadan yapılan duruşmalar, çoğu zaman gereksiz duruşmalar haline dönüşmekteydi. Bu hususun hem mahkeme hem davanın tarafları için, zaman ve emek kaybı ve boş yere masraf yapılması anlamına geldiği kuşkusuzdur. HUMK, esas itibariyle, dilekçeler aşaması ile tahkikat aşamasını birbirinden ayırmış olmasına rağmen, uygulamada, her iki aşama, karışıklığa yol açar şekilde birbirinin içerisine girmişti. Bu sebeple, yargılamalar gereksiz yere uzamakta ve bu durum çeşitli yakınmalara ve eleştirilere neden olmaktaydı. Bu hususu dikkate alan kanunkoyucu, HUMK'nda yeni bir müessese olarak "ön inceleme"yi kabul etmiştir.

2 Bkz. "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu" (TBMM Dönem: 23, Yasama Yılı:3, S. Sayısı 393).

mayanların ise masrafları ödendikten ve nereden getirtileceğine ilişkin bilgiler verildikten sonra, tahkikatın başlatılması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak, tahkikatın, amacına uygun olarak, sadece uyuşmazlığın ve uyuşmazlığa ilişkin delillerin incelendiği ve tartışıldığı bir aşama hâline getirilmesi; bunun için de tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tahkikat başlamadan tam tespiti gereklidir. Ayrıca, işin esasına girilmesi gerekli olmayan, usule ilişkin kararlarla sürelere ilişkin kararların da başlangıçta verilmesi, birçok uyuşmazlığın baştan hâlli sonucunu doğuracaktır. Bu aşamada, uyuşmazlık konuları tam ve açık olarak tespit edilmiş olacağından, tarafların durumlarını gözden geçirerek sulh olmaları da daha kolay hâle gelebilecektir. Bu aşamanın diğer bir olumlu yönü ise uyuşmazlık noktaları kesin olarak tespit edildiğinden, inceleme ve hukukî tartışma da bu noktalara münhasır olarak yapılacak, gereksiz işlemlerin ve zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktır. Ön incelemenin amacına uygun yapılması, taraflar arasında sulh imkânını artıracak, hatta yargılama dışı uyuşmazlık çözüm yollarıyla da bağlantılı olarak tarafların doğrudan ya da arabulucu yardımıyla uyuşmazlığı çözmelerinin yolunu açacaktır. Taraflar sulh olmadıklarında ise tahkikat için tüm hazırlıklar yapılmış olduğundan, tahkikatta sadece tanık dinlenmesi, bilirkişiye başvurulması ve keşif gibi usul işlemleri gerçekleştirilecek, tahkikatın arka arkaya yapılacak birkaç oturumda da tamamlanması mümkün olabilecektir. Bu aşamanın, ön inceleme olarak ifade edilmesinin sebebi, dilekçelerden sonra, mahkemece yapılacak ilk inceleme aşaması olması, ancak işin henüz esasına tam olarak girilmemesidir. Bu aşama, tahkikat olmadığından tahkikat ifadesi de kullanılmamıştır. Çünkü, bu aşamada bir ön tahkikat ve benzeri işlemlerden daha çok, tahkikattan önce yapılması gereken işlemler tamamlanmaktadır. Bu bölüm, yeni olmakla birlikte, hukukumuza tamamen yabancı da değildir. Nitekim istinaf aşamasında ön inceleme kabul edilmiştir. Yine temyiz aşamasında da işin esasına girilmeden ön inceleme yapılmaktadır".

B) ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI

Davacı ve davalının verdikleri ikişer dilekçenin ardından, tahkikat aşamasından önce, mahkeme bu dilekçeler üzerinde ön inceleme yapar (m. 137, 1/c. 1).

Ön inceleme tamamlanmadan ve bu aşamada alınması gerekli kararlar alınmadan **tahkikat aşamasına geçilemez** ve tahkikat için duruşma (m. 143) günü verilemez (m. 137, 2). Başka bir deyişle, HMK, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden, tarafların delillerini göstermelerinden veya nereden getirtileceklerini bildirmelerinden ve tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespitinden sonra tahkikat aşamasına geçilebileceğini öngörmüştür. Kanımızca, bu hüküm 6100 sayılı Kanunla getirilmiş bulunan "ön inceleme" aşamasının başarı ile tamamlanabilmesi (uygulanabilmesi) için çok önemlidir. Eğer, ön inceleme aşamasında yapılması gereken hususlar karara bağlanıp, gereği yerine getirilmez ve böylece tahkikat aşa-

masına geçilirse, yeni dönemde de HUMK dönemindeki sakıncalar devam edecek ve kanun değişikliği amacına ulaşamayacaktır[3].

Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, 137, 2 hükmü ön inceleme aşamasının işlevini yerine getirmesi ve beklenen sonucun gerçekleştirilebilmesi için açık bir emir içermektedir. Bu hükme aykırı davranış, **hâkimin sorumluluğunu doğurabilir.**

Ön inceleme aşamasında mahkemenin neler yapacağı 137. maddede gösterilmektedir:

Mahkeme **öncelikle dava şartlarını** (m. 114) inceler (m. 138). Dava şartları, mahkemenin kendiliğinden araştırması gereken hususlardandır (m. 115). Dava şartlarının hangi sırayla inceleneceğine dair açık bir kural bulunmamakla birlikte, mahkemenin 114. maddedeki sırayı izlemesi uygun olur.

Mahkeme dava şartı eksikliğini tespit ederse, bu dava şartı eksikliğinin giderilmesinin mümkün olup olmadığına bakılır. Eksikliğin giderilmesinin mümkün olmaması halinde davanın usulden reddine karar verilir. Eksikliğin tamamlanması mümkün ise, ilgili tarafa Kanunun öngördüğü kesin veya hâkimin takdir ettiği kesin ve uygun bir süre verilir; eksiklik süresi içinde giderilmezse davanın usulden reddine karar verilir (m. 115, 2).

Dava şartlarının incelenmesinden ve eksikliğin bulunmadığının tespitinden **sonra varsa ilk itirazlar** (m. 116) **incelenir** (m. 117, 2). İlk itirazlar mahkemece kendiliğinden gözönüne alınacak hususlardan değildir; davalı tarafından (m. 117, 1) ileri sürmedikçe dikkate alınamaz.

Dava şartları ve ilk itirazlar duruşma yapmaya gerek kalmadan **dosya üzerinden** karara bağlanabilir (m. 140). Ancak mahkeme gerek görürse, tarafları ön inceleme duruşmasına (m. 140) çağırıp dinledikten sonra da karar verebilir (m. 138).

Mahkeme, tarafların dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaları inceleyerek, tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşmadıkları konuları tespit eder.

Ön inceleme, tahkikat aşamasına (m. 143 vd.) hazırlık niteliğinde olduğundan mahkeme bu aşamada, hazırlık işlemlerini ve tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gerekli işlemleri yapar.

Ön inceleme aşamasında hâkim ayrıca, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda, tarafları ön inceleme duruşmasında sulhe (m. 313) veya arabuluculuğa teşvik eder. Kanun, ön inceleme aşamasında tarafların sulhe teşvik edilmesine ve arabuluculuğa yönelmelerine özel bir önem vermektedir.

Bu hususlar, ön inceleme aşamasının sonunda düzenlenen tutanağa yazılır.

Ön inceleme duruşmasından önce, yapılacak incelemelerin ne kadar süre içinde tamamlanacağına dair Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından, bu süre uyuşmazlığın niteliğine göre mahkeme tarafından belirlenir.

---

[3] Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanununda Ön İnceleme Aşaması (Güncel Hukuk, 2012, s.16-19; Yılmaz, Makaleler c. 2, s. 1999-2006).

C) ÖN İNCELEME DURUŞMASI

I – ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET

Mahkeme, dilekçelerin verilmesinden sonra yapacağı incelemede, dava şartlarını dosya üzerinden inceleyerek davanın usulden reddi veya ilk itirazı/itirazları kabul edip davadan elini çekme kararı vermezse (m. 138), ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara tebliğ eder (m. 139, 1/c. 1).

Taraflara gönderilecek olan duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve gelen tarafın, gelmeyen tarafın muvafakati olmadan iddia veya savunmasını genişletip değiştirebileceği (m. 141, 1) ayrıca ihtar edilir (m. 139, 1/c. 2).

II – ÖN İNCELEME DURUŞMASININ YAPILMASI

Kanun (m. 140), ön incelemede sırasıyla ne gibi işlemlerin yapılacağını düzenlemiştir. Bu hüküm yol gösterici bir hükümdür. Mahkeme, işin gereğine göre diğer işlemleri de yapar. Ancak mahkeme bu aşamada, dava şartlarına ve ilk itirazlara ilişkin olanlar hariç, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görüşü alma, keşif yapma ve yemin teklif etme gibi tahkikat işlemleri kesinlikle yapamaz[4].

Mahkeme, daha önce dosya üzerinden karar vermediyse (m. 138) ön inceleme duruşmasında, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında **karar** verebilmek için (m. 138) tarafların görüşlerini alır (m. 140, 1, ilk yarım cümle).

Mahkeme, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, **anlaştıkları ve anlaşmadıkları vakıaları** tek tek tespit eder (m. 140, 1/ikinci yarım cümle). Bunun için, mahkemenin ön inceleme duruşmasından önce dosya üzerinde yapacağı çalışmada (değerlendirmede) dilekçeler üzerinden gerekli tespiti yapması ve duruşmada bunlar hakkında tarafları dinlemesi uygun olur.

Mahkeme, taraflar arasındaki uyuşmazlık konularının tespitinden sonra, üzerinde tasarruf edebilecekleri konuda tarafları **sulhe** veya **arabuluculuğa teşvik** eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya özgü olmak üzere, yeni bir duruşma günü tayin eder (m. 140, 2). Sulhe veya arabuluculuğa teşvik, hâkim için **zorunlu bir görev**dir. Tarafların sulhe teşviki hususu, HMK'ndan önce de mevzuatımızda yer almakta ve ancak mahkemeler bu hükümlerin uygulanması konusunda etkin olarak faaliyet göstermemekte idiler. Oysa sulh konusu, hem mahkemelerin kısa sürede karar vermesi hem de tarafların sulh yoluyla aralarındaki uyuşmazlığı kendilerinin çözmesi sonucunda toplumsal barışı sağlaması bakımından büyük önem göstermektedir. HMK m. 140, 2 hükmünün bu konuyu vurgulamakta oluşu, ka-

---

[4] Bkz. madde ile ilgili Hükümet gerekçesi; ayrıca, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk K. m. 13, I.

nımızca çok önemlidir ve mahkemelerin sulh (veya arabuluculuğa teşvik) konusunda etkin çaba göstermeleri gerekir.

Ön inceleme duruşması sırasında taraflar **sulh olurlarsa**, bu husus tutanağa geçirilir (m. 137, 1; 140, 3).

Sulh olmazlarsa, ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu, açık bir şekilde tutanağa (m. 154) yazılır. Tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflar ve hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır (m. 140, 3).

Ön inceleme aşamasının sonunda ön inceleme tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmadığı, ön inceleme duruşmalı yapılıyorsa duruşmaya taraflardan hangisinin katıldığı ya da mazeretinin bulunup bulunmadığı; dava şartlarının mevcut olup olmadığı, eksiklik varsa ne tür işlem yapıldığı; ilk itiraz bulunup bulunmadığı ve varsa ne tür işlem yapıldığı; davacının iddialarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu; davalının savunmalarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu; tarafların uyuşmazlık noktalarının ana başlıklarıyla nelerden ibaret bulunduğu; tarafların sunmadıkları belgelerin neler olduğu, dilekçelerinde belirttikleri tüm belgeleri sunup sunmadıkları, ayrıca başka yerden getirilecek delillere ilişkin bilgi vermedikleri bir hususun bulunup bulunmadığı ve bu konuda ne şekilde işlem yapıldığı, bu aşamada karar verilmişse gerekli delil avansını yatırmaları; ön incelemede yapılması gereken diğer işlemlerin yapılıp yapılmadığı; iddiasını ya da savunmasını genişleten taraf olup olmadığı, bu konuda karşı tarafın açık muvafakatinin bulunup bulunmadığı; tarafların sulhe veya arabuluculuğa teşvik edildikleri ve sonuçlarının ne olduğu; eğer ön inceleme duruşması sonunda tahkikat için duruşma günü verilebiliyor ise duruşma günü, duruşma günü verilemiyor ise tahkikat için duruşma gününün sonradan bildirileceği ya da duruşma günü vermeden tahkikata geçileceği hususlarına yer verilir.

Hâkim, Yönetmeliğe ekli "ön inceleme kontrol formu"nu kullanarak ön inceleme tutanağı düzenleyebileceği gibi ön inceleme tutanağını resen de düzenlenebilir. Yönetmeliğin ekinde yer alan veya hâkim tarafından resen oluşturulan form, elektronik ortamda doldurulup güvenli elektronik imza ile imzalanarak kaydedilir ve ön inceleme tutanağına eklenir (Y m. 201).

Tahkikat, bu tutanak esas alınarak yürütülür (m. 140, 3/c. 3).

Ön inceleme, kural olarak, **tek duruşma**da tamamlanır; bununla birlikte zorunlu olan durumlarda (örneğin m. 140, 2), bir defaya özgü yeni bir duruşma günü tayin edilir (m. 140, 4).

Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri (m. 119, 1/f; 119, 1/e), ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanılmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir (m. 140, 5).

Ön inceleme duruşması (m. 140) tamamlandıktan sonra, hâkim tahkikata (m. 143 vd.) başlamadan önce, hak düşürücü süreler ve zamanaşımı hak-

kındaki itiraz ve def'ileri inceleyerek karara bağlar (m. 142). Bu hükümle, mahkemenin zamanaşımı def'i ve hak düşürücü süre itirazı hakkında, tahkikattan önce karar vermesi sağlanmıştır. Ancak, maddî hukuka ilişkin olan hak düşürücü süre ve zamanaşımı süreleri, esasen tahkikat aşamasında ele alınacak konulardandır. Buna rağmen, kanun koyucu tahkikata geçmeden usule ilişkin olmayan süreler konusunda karar verilebileceğini değerlendirerek, m. 142'yi düzenlemiştir. Örneğin, dava malzemesinden hak düşürücü sürenin veya zamanaşımı süresinin dolmuş (geçmiş) olduğu açıkça görülüyorsa hâkim, ön inceleme tamamlanır tamamlanmaz, asıl tahkikata geçmeden, bu hususu da tutanağa yazarak ve konu hakkında tarafların görüşünü alarak, hak düşürücü sürenin veya zamanaşımının geçmiş olduğu gerekçesi ile davayı reddedebilir (m. 142).

§ 22. YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

A) GENEL BİLGİ

Tarafların dilekçelerini (dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve ikinci dilekçelerini) vermesinden sonra, ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasında yapılacak işlemler yapılıp, alınacak kararlar alındıktan ve tutanak düzenlendikten sonra, tahkikat aşamasına geçilir. Yukarıda görüldüğü üzere[1], ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez (m. 137, 2).

Ön inceleme aşamasında, öncelikle usulî konular hakkında kararlar alınır; taraflar arasındaki uyuşmazlık konuları belirlenerek tutanağa bağlanır ve bu tutanak esas alınarak tahkikat yürütülür.

Tahkikat aşamasında, tarafların ileri sürdükleri vakıaların doğru olup olmadığı başvurulan (gösterilen) delillere göre araştırılır ve tespit edilir. Davanın en uzun süren aşaması, tahkikat aşamasıdır.

Tahkikat aşamasının tamamlanmasından sonra, sözlü yargılamaya (sözlü yargılama aşamasına) geçilir (m. 186)[2]. Sözlü yargılamada, taraflar, tahkikat aşamasının sonucuna göre iddia ve savunmalarını gözden geçirirler ve bu hususlaki son sözlerini söylerler.

Ondan sonra da (son aşamada da), mahkeme hükmünü verir (m. 294 vd.)[3].

Yargılama (ön inceleme ve tahkikat) hâkim tarafından, bu iş için belirlenen duruşmalarda (oturumlarda; celselerde) yapılır. Bu nedenle, yargılamanın (tahkikatın) nasıl yapıldığını incelemeye başlamadan önce, yapılış biçimi olan oturumları, oturumlarda düzenlenen tutanakları ve yargılama sırasında (ve bununla genel olarak) hâkimin durumunu (yetkilerini) incelemek uygun olur.

B) YARGILAMANIN YAPILIŞ BİÇİMİ

Yargılama, bunun için belirli olan duruşmalarda (oturumlarda) yapılır. Bu duruşmalarda yargılamanın yapılış biçimini gösteren bir tutanak düzenlenir (m. 154). Bundan başka, mahkemede dava için açılan dosyaya yargılama ile ilgili her türlü belge konulur.

I – DURUŞMA

1) Genel Bilgi

Duruşma (oturum; celse), mahkeme önünde yapılacak ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri için önceden belirlenmiş olan zaman bölümüdür.

---

1 Bkz. yuk. § 21.
2 Bkz. aşa. § 36, B.
3 Bkz. aşa. § 36, C.

Duruşma terimi, hem yapılacak tahkikat işlemleri hem de bunun için belirlenen gün ve saat anlamındadır.

Duruşmada, hâkim ile zabıt kâtibi hazır bulunur. Hâkim, zabıt kâtibi hazır olmadan duruşma yapamaz. Duruşmada taraflar, vekilleri ya da yasal temsilcileri de hazır bulunur.

Duruşmalar, kural olarak, alenî (açık) olarak yapılır (Anayasa m. 141, I; HMK m. 28; 154). Duruşmanın yönetimi ve disiplininin sağlanması hâkime aittir (m. 151). **Duruşmanın alenîliği** (açıklığı) ve **disiplini** yukarıda incelendi[4].

Mahkeme, tarafların izni olmak şartıyla, mahkemeye (duruşmaya) gelmeyerek kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda **ses ve görüntü nakledilmesi** (SEGBİS, ses ve görüntü bilişim sistemi) **yoluyla** bulundukları yerden **duruşmaya katılmalarına** ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir (m. 149, 1). Benzeri şekilde, tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme; tanığın (m. 240 vd.), bilirkişinin (m. 266 vd.), uzmanın (m. 293) veya tarafın dinlenmesi esnasında başka bir yerde bulunmasına izin verebilir. Bu dinleme; ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir (m. 154, 5; Y m. 218).

Yönetmeliğe (m. 218, 5-8) göre; SEGBİS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve görüntü verileri de, m. 199'a göre **elektronik belge** hükmündedir. Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta, dinlenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin başlangıç ve bitiş zamanı, dinlemenin süresi, hazır bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir. Elektronik ortamdaki tutanak aynen; fizikî olarak tutulan tutanak ise taranıp, elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden gönderilir. Belge asılları mahallinde saklanır. SEGBİS veya benzeri sistemlerle duruşmaya katılan tarafların beyanlarının imzalanması gerektiğinde, dinlemenin yapıldığı yer mahkemesince talepte bulunan mahkemece tutulan tutanağın bir çıktısı alınarak imzalatılır; imzalanan tutanak tekrar elektronik ortama aktarılır ve tutanağın aslı mahkemesine gönderilir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır (Y m. 218, 8).

Duruşma sırasında **fotoğraf çekilemez** ve hiçbir şekilde **ses ve görüntü kaydı yapılamaz**; bu yasak, yargılamanın zorunlu kıldığı durumlarda mahkemece yaptırılabilecek kayıtlar ve çekimler halinde uygulanmaz (m. 153).

Kural olarak, her davada duruşma yapılması ve **tarafların bu duruşmaya** usulüne uygun biçimde **çağrılmaları** (davet edilmeleri) zorunludur (m. 27).

---

4 Bkz. yuk. § 5, A, III; § 5, J.

2) Duruşma Yapılması Zorunludur

Kural olarak, her davada duruşma yapılması zorunludur. Yani hâkim duruşma yapmadan (tarafları usulüne uygun biçimde duruşmaya çağırmadan) hükmünü veremez (m. 27). Başka bir deyişle, hâkim Kanunda açıkça gösterilmedikçe dosya üzerinde karar veremez.

Bazı hallerde duruşma yapılması **zorunlu değildir**; hâkim, **dosya üzerinde** de karar verebilir. Bu istisnaî haller, kanunla belirlenir. Duruşma yapılması zorunlu olmayan haller daha çok acele ve geçici nitelikteki işlerde söz konusu olur. Örneğin mahkeme, ön incelemede dava şartları ve ilk itirazlar hakkında (m. 138) duruşma yapmadan karar verebilir. Mahkemenin ihtiyatî tedbirlere (m. 390, 2), delillerin tespitine (m. 403) ve ihtiyatî hacize (İİK m. 258, II) duruşma yapmadan da (karşı tarafı dinlemeden de) karar vermesi mümkündür.

Aynı şekilde, hâkimin reddi istemine ilişkin karar, duruşma yapılmaksızın verilebilir (m. 42, 1).

Mahkemeye ilişkin dava şartlarından birinin yokluğu halinde, mahkeme, duruşma yapmadan da davayı usulden (dava şartı yokluğundan) reddedebilir. Örneğin mahkeme, duruşma yapmadan, yani taraflara tebligat yapıp onları dinlemeden, dosya üzerinden de görevsizlik kararı verebilir; yargı yolunun caiz olmadığına (örneğin davanın idare mahkemesinin görevine girdiğine) karar verebilir (m. 138). Yargıtay bu görüşte olmayıp duruşma yapılması gerekliği düşüncesindedir.

3) Tarafların Duruşmaya Çağrılması

Yukarıda görüldüğü gibi, kural olarak duruşma yapılması **zorunludur**. İşte bu hallerde, tarafların duruşmaya çağrılması da (davet edilmesi de) zorunludur. Hâkim, iddia ve savunma haklarını (Anayasa m. 36; HMK m. 27) kullanabilmeleri için tarafları duruşmaya çağırmak zorundadır.

Bunun üzerine, **iki taraf da duruşmaya gelirse** yargılamaya başlanır.

Bundan sonra bir tarafın kendisinin veya vekilinin dosyayı incelememiş bulunması sebebiyle, yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenememesi kabul olunabilir bir özüre dayanıyorsa, hâkim bir defalık kısa bir (kesin) süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenememiş olsa bile (yeni bir süre verilmeden) davaya devam olunur (m. 77, 3-4).

Usulüne uygun olarak davet edilen **her iki taraf da duruşmaya gelmezse**, mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150)[5].

Taraflardan biri duruşmaya gelir diğeri **gelmezse**, bakılır: Duruşmaya gelmiş olan taraf davayı takip etmeyeceğini bildirirse, mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150, 1).

Duruşmaya gelmiş olan taraf davayı takip edeceğini bildirirse, davaya (tahkikata), gelmeyen (karşı) tarafın yokluğunda devam edilir. Ancak bunun için, bu hususun (tahkikata yokluğunda devam edileceğinin) duruşmaya gelmeyen tarafa gönderilen davetiyede (çağrı kâğıdında) **bildirilmiş** (yazılmış)

[5] Bkz. aşa. § 48.

olması gerekir. Çünkü, tahkikat sırasında taraflara çıkartılacak (ilk) çağrı kâğıtlarında (davetiyelerde), tarafların belli edilen günde mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, tahkikata yokluklarında devam edileceği bildirilir (m. 147, 2). Bu davetiyeye, bir çeşit **meşruhatlı** (açıklamalı; uyarılı) **davetiye** diyebiliriz. Bu davetiyeyi alan taraflardan biri çağrıldığı duruşmaya gelmezse; gelen taraf davayı takip edeceğini bildirirse, tahkikata gelmeyen (karşı) tarafın yokluğunda devam edilir[6].

Duruşmaya gelmeyen ve bu nedenle tahkikata yokluğunda devam edilmiş olan taraf, ondan sonraki veya daha sonraki duruşmaya gelirse[7], duruşmaya taraf olarak kabul edilir[8]. Ancak, geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmemiş olan taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez (m. 147, 2). Duruşmaya gelmemiş olan taraf, geçerli bir özür (örneğin ağır hastalık) nedeniyle duruşmaya gelemediğini ispat ederse, yokluğunda yapılmış olan işlemlere itiraz edebilir.

4) Duruşma Gününün ve Saatinin Belirlenmesi

Duruşma gün ve saati[9] **hâkim tarafından belirlenir** (Y m. 201, 1/ı). Hâkim, duruşma gün ve saatini belirlerken, tarafların ve vekillerinin bu hususlaki isteklerini de imkân ölçüsünde gözetir. Örneğin, vekilin hâkimin duruşma koymak istediği günde ve saatte başka bir yerde duruşması varsa, hâkim, vekile uygun düşen başka bir duruşma günü ve saati belirleyebilir.

Hâkim, bir güne ancak bakabileceği kadar davanın duruşmasını koyar. Bir günde bakılacak davalar için **ayrı ayrı duruşma saatleri belirlenir** ve bir duruşma listesi düzenlenir:

Bir günde görülecek davalar için sırasıyla okunaklı şekilde tarafların ve vekillerinin adları ve duruşma saati yazılmak suretiyle bir **"duruşma listesi"** düzenlenir; bu listenin baş tarafına hangi mahkemenin hangi gününe ait olduğu da yazılır ve duruşmadan önce mahkeme (duruşma) salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır (Y m. 204).

Hâkimin, duruşmada yapılacak işin önemine göre, her dava için değişik duruşma saatleri belirlemesi gerekir; örneğin, ilk dava saat 9.30'da, ikinci dava 10.00'da, üçüncü dava 10.15'te vs. gibi.

---

6 Duruşmaya gelmemiş olan tarafa gönderilen davetiyede (gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği) ihtarı yoksa, yargılamaya o tarafın yokluğunda devam edilemez.

7 Yokluğunda yargılamaya devam edilen tarafa, ondan sonraki duruşmaya gelmesi için davetiye gönderilmez. Yalnız, sözlü yargılama için kendisine yeni bir (uyarılı- meşruhatlı) davetiye gönderilmesi gerekir (m. 186, 1).

8 Yalnız HMK m. 79 ile 80'deki hallerde, taraf sonraki duruşmalara da kabul edilmez.

9 HMK m. 147, 2'de; HUMK m. 231, II'den farklı olarak, "gün" ibaresinin yanısıra "**saat**" ibaresine de yer verilmiştir (ayrıca bkz. Y m. 204). TBMM Adalet Komisyonu gerekçesine göre bunun nedeni, "duruşma zamanındaki belirsizliğin giderilerek zaman diliminin netleştirilmesidir".

II – TUTANAKLAR

Oturumda (duruşmada) yapılan tahkikat ve yargılama işlemleri hakkında zabıt kâtibi tarafından hâkimin gözetimi altında bir tutanak (zabıt varakası, zabıtname) düzenlenir (m. 154).

Tutanağa mahkemenin ve hâkimin/hâkimlerin isimleri, tahkikat ve yargılamanın yapıldığı yer, duruşmanın açıldığı gün ve saat, iki tarafın ve vekillerinin isimleri, yapılan yargılama işlemleri ile iki tarafın ne gibi belgeleri verdikleri, yargılamanın alenî (açık) yapıldığı veya aleniliğin kısmen kaldırılmasını gerektiren sebepler, ikrar, sulh, tamamen veya kısmen feragat, iddia ve savunmaların özeti, tanık ve bilirkişilerin beyanları, ihtilâf konusunun keşfi ve muayenesi halinde rapor özeti ve verilen karar ile bunun nasıl tefhim edildiği yazılır (m. 154, 3).

Hâkim, tarafların, tanık ve bilirkişi gibi kimselerin ifadelerini **özet halinde** (alenen) söyleyerek tutanağa yazdırır. **Taraflar** veya diğer ilgililer, sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilirler. Duruşmaya katılan taraf vekili (avukat), tanıklara, bilirkişilere ve mahkemece duruşmaya çağrılmış diğer kişilere doğrudan soru sorabilir. Taraflar ise bu kişilere yönelik sorularını hâkim aracılığı ile sorabilir (m. 152).

Yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa (m. 149; 153, I), bu durum bir tutanakla tespit olunur.

Tutanağın tanık ile bilirkişi ifadelerine ve iki tarafın ikrar, sulh ve feragatine (ve kabulüne) ilişkin kısımları ve diğer ilgililerin beyanları bunların önünde okunarak kendilerine imza ettirilir (m. 154, 3/ç).

Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır; bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya özel işaret kullanabilir (m. 155, 2).

Oturumun sonunda tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhal imza olunur (m. 155, 1).

Yargılama işlemleri, ancak tutanak ile ispat edilebilir (m. 156). Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması; duruşma tutanaklarının tahrif edilmiş ve buna göre hüküm verilmiş olması halinde, hâkimlerin bu şekildeki yargılama faaliyetinden dolayı Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir (m. 46, 1/c-d).

Talep edilmesi halinde, tutanakların tamamı veya bir kısmının örnekleri taraflara veya fer'i müdahile verilir. Bu örneklere mahkemenin mührü basılır ve aslına uygun olduğu yazı işleri müdürü tarafından imza olunarak onaylanır. Tutanağın eki niteliğindeki gizlilik kararı kapsamında kalan belgelerin örneği, ancak hâkimin izni ile verilebilir (m. 158).

Uygulamada avukat ile takip edilen davalarda, mahkeme tutanaklarının onaysız örnekleri avukat sayısı kadar çoğaltılarak, hemen duruşmanın bitiminde avukatlara verilmektedir. Bu usul, uygulamada avukatların ve mahkeme kalemlerinin işini çok kolaylaştırmaktadır.

Taraflar duruşmada belge ibraz edince, bu husus tutanağa geçirilir. Tutanağa geçirilen ve tutanakta sözü edilen belgeler, tutanağın eki sayılır (m. 154, 4).

III – DAVA DOSYASI

Her dava için, mahkeme kaleminde ayrı bir dosya tutulur. Bu dosyaya o dava ile ilgili bütün belgeler bir sıra dahilinde konur ve **dizi listesi** düzenlenir. Dosyaya konulan ve çıkarılan belgeler hemen bu listeye yazılır (m. 160; Y m. 203). Dosyanın dizi listesine bağlanması, içeriğinin daha iyi saklanması bakımından önem taşımaktadır.

Mahkemeye verilen kıymetli evrak ve diğer belgeler ile mühürlerin teslim alındığına ilişki yazı ve berat, yazı işleri müdürlerinin sorumluluğunda mahkemenin kasasında saklanır (Y m. 255).

Dava dosyası, zabıt kâtibi tarafından duruşma gününden önce hâkime verilir. Zabıt kâtibi, gerektiğinde dava dosyasını incelenmek için hâkime vermek ve zamanında eksiksiz almak ile görevlidir (m. 162).

Davanın hiçbir evrakı taraflardan, vekillerinden ve davaya müdahil olandan **gizlenemez**; taraflar, müdahil veya vekilleri dava evrakını istedikleri zaman, kuralları çerçevesinde inceler. Kanuna göre, taraflar, vekilleri veya müdahil, zabıt kâtibinin yanında dava dosyasını inceleyebilir. Ayrıca, dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla ve hâkimin izni ile dosyayı inceleyebilirler (m. 161, 1; Y m. 202).

Gizli olarak saklanmasına karar verilen **belge** ve tutanakların **incelenebilmesi, hâkimin açık iznine bağlı**dır (m. 161, 2). Bunun nedeni, dava evrakı arasına getirilen veya konulan belgelerin kapsamı davanın konusu ile doğrudan ilgili olmayan başka konuları da içerebilir ve gizlilik kararının alınmasına sebep olmuş olabilir. Bu yüzden dava dosyası içinde yer alan fakat dava ile doğrudan ilgisi olmayan belgelerin hangilerinin hangi kapsamda taraflar, vekilleri veya müdahil tarafından hâkimin kararı ile incelenebileceğinin tespiti, gizlilik dereceli resmî belgelerin ve ticarî sırların korunması bakımından önemlidir.

§ 23. TAHKİKAT

A) GENEL OLARAK

Dilekçelerin verilmesinden veya bunlara ilişkin sürelerin geçmesinden sonra yapılan ön inceleme aşamasında çeşitli ihtimallerle karşılaşılabilir:

İlk itirazlar veya dava şartları üzerinde yapılan incelemede (m. 138) mahkeme, yapılan ilk itirazın haklı veya dava şartlarının eksik olduğunu tespit edebilir ve bu konuda duruşma yapmaya da gerek görmeden (dosya üzerinden) davanın reddine karar verebilir. Böyle bir durumda, tahkikat (soruşturma) aşamasına gerek kalmadan mahkeme nihaî kararını vermiş olur.

Davacı ve davalı dilekçeleri ve beyanları ile bütün vakıaları bildirmiş ve ekli olarak gerekli bütün delilleri (senetleri, belgeleri) vermiş ve başkaca delilleri olmadığını bildirmiş olabilirler. Bu hususu, yani talep sonucunun karara bağlanabilmesi için önemli olan bütün vakıaların aydınlanmış ve ispatlanmış olduğunu ön inceleme aşamasında tespit eden mahkeme, davada ileri sürülen maddî vakıaların incelenmesine (tahkikine) gerek kalmadığından, onları sözlü yargılama için duruşmaya davet eder; tarafları dinledikten sonra nihaî kararını verebilir (m. 186). Çünkü, tahkikat, incelenmesi gereken bir husus (vakıa, delil) varsa yapılır; yoksa yapılmaz.

B) TAHKİKATIN YAPILMASI

Yukarıdaki ihtimallerin ortaya çıkmaması halinde tahkikat (m. 143-183) aşamasına geçilir. Hâkim tahkikatı, ön inceleme aşamasında belirlediği ve tutanağa geçirdiği hususlar üzerinden (m. 137) yapar. Yani, tahkikat, bu tutanak esas alınarak yürütülür (m. 140, 3/c. 3). Yargılamanın temel ilkelerine uygun, düzenli ve sağlıklı bir tahkikat için Kanun hükümlerine uygun bir ön incelemenin yapılmış olması ön koşuldur. Özellikle, hangi vakıaların uyuşmazlık konusu olduğu, delillerinin neler olduğu tam ve somut olarak ön inceleme tutanağında gösterilmelidir ki, doğru bir tahkikat yapılabilsin. Hükmün gerekçesindeki ifadeyle "Bu belge (tutanak), yargılamanın yolunu gösteren bir yol haritasıdır; tutanakta yer almayan hususlar, tahkikatın konusu olmayacaktır".

Tahkikat sırasında tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar, kural olarak, birlikte incelenir (m. 143; 144; 147). Ancak hâkim, yargılamayı basitleştirmek veya kısaltmak (usul ekonomisi) için kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine tahkikatın her aşamasında iddia ve savunmalardan birinin veya bir kısmının diğerinden önce incelenmesine karar verebilir (m. 30; 143).

Genellikle görüldüğü gibi, dilekçelerin incelenmesi ile dava sözlü yargılama ve hüküm için gereği gibi aydınlanmaz. Bu durumda hâkim, davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinlemek üzere tarafları duruşmaya çağırır

(m. 144). Dinlenilmek üzere mahkemeye gelmeleri için taraflara verilecek süre, kural olarak, iki haftadan az olamaz; ancak gerekli durumlarda bu süre, talep üzerine veya kendiliğinden uzatılıp kısaltılabilir (m. 144).

Tahkikat aşaması delillerin toplandığı değil, dilekçelerin verilmesi ve ön inceleme aşamalarında toplanan delillerin incelendiği, tartışıldığı ve değerlendirildiği bir aşamadır. Bu çerçevede sözgelimi varsa belgenin/senedin sahteliği iddiası incelenir; tanıklar dinlenir; bilirkişi raporu alınır; keşif yapılır; yemin ettirilir vb.

Mahkeme tahkikat aşamasını ve özellikle delillerin değerlendirilmesini, tarafların da davet edilip dinlenildiği, duruşmalar şeklinde gerçekleştirir (m. 147 vd).

Tahkikat sırasında, davaya ilişkin olarak ortaya çıkan ön sorunlar (m. 163-164) ve bekletici sorunlar (m. 165) hakkında gerekli kararlar alınır. Gerekirse isticvaba başvurulur.

Hâkim, tarafların iddia ve savunmaları ile toplanan delilleri inceleyip değerlendirdikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir (m. 184, 1).

Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, gerekirse, eksik kalan tahkikatın tamamlanmasını sağlamak için gerekli işlemleri yapar (tahkikata devam eder) veya tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder (m. 184, 2; ayrıca bkz. m. 185)

Mahkeme bütün delillerin incelenmesinden sonra, davanın sözlü yargılama ve hüküm için yeteri derecede aydınlandığını (mevcut delillerle davanın aydınlandığını) anlarsa, tahkikatın bittiğini taraflara bildirir (m. 146) ve sözlü yargılama ve hüküm için tayin edilecek gün ve saatte mahkemede bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafa davetiye gönderir (m. 186).

Hâkimin, tahkikat ve yargılama işlemlerinin nasıl yapıldığı, tarafların (ve diğer ilgililerin) sözlü açıklamalarını tutanağa kaydettireceği yukarıda[1] incelendi. Deliller, incelenmesi ve değerlendirilmesi konusu ise aşağıda[2] incelenecektir.

---

1 Bkz. yuk. § 22, B.
2 Bkz. aşa. § 25-35.

§ 24. İSTİCVAP
(tarafın sorguya çekilmesi)

A) GENEL BİLGİ

İsticvap[1], bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir vakıa veya vakıalar hakkında (mahkeme tarafından) **sorguya çekilmesi** (dinlenilmesi) demektir. Bu anlamda isticvap, teknik bir terim olup, bir tarafın **ancak** m. 169-175'de **düzenlenen usule** göre sorguya çekilmesine (dinlenilmesine) verilen bir isimdir.

Bununla, tarafların hâkim tarafından her dinlenilmesinin teknik anlamda bir isticvap olmadığını belirtmek istiyoruz. İsticvap, bir tarafın ancak m. 169-175 hükümlerine göre dinlenilmesi (sorguya çekilmesi) halinde söz konusu olur. Bunun dışındaki tarafların hâkim tarafından dinlenmesi, teknik anlamda bir isticvap değil, sadece taraflardan bilgi alınmasıdır. Öğreti ve Yargıtay uygulamasında isticvabın amaçlarından birinin hâkimin vakıalar ve delilleri hakkında bilgi edinmesi ve kanaat oluşturması olduğu kabul edilmektedir (m. 140; 144).

Yukarıda da görüldüğü gibi, hâkim, davanın her halinde, tarafları (veya vekillerini) çağırarak (davet ederek) dava konusu vakıalar hakkında tarafları dinleyebilir (m. 140; 144). Böylece, davacının davasının veya davalının savunmasının açıklanmasına çalışılır.

Bunun gibi, hâkim, aydınlatma ödevi gereğince, belirsiz veya çelişik gördüğü iddia ve sebepler (vakıalar) hakkında taraflardan açıklama isteyebilir (m. 31); yani tarafları dinleyebilir.

Tarafların (m. 140; 144'e göre) sadece **dinlenilmesi ile** m. 169-175'e göre **isticvabı arasında önemli nitelik farkları** vardır. Ancak taraf çağrıldığı oturuma gelerek sorulanlara cevap verirse, sonuç bakımından hangi usule göre çağrılmış olduğunun bir önemi yoktur. Buna karşılık, taraf çağrıldığı oturuma gelmezse, o zaman m. 171'de yer alan yaptırımın (isticvap konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı) uygulanabilmesi için, tarafın isticvap için m. 169-175'e göre çağrılmış olması gerekir.

İsticvap, taraflarca getirilme ilkesine (m. 25) tâbi olan davalarda uygulanır. Buna karşılık, kendiliğinden araştırma ilkesine tâbi olan davalarda, isticvap hükümleri uygulanmaz; çünkü tarafların ikrarı hâkimi bağlamaz. Bu nedenle, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda taraflar, m. 169-175 hükümlerine göre değil; m. 144 hükmüne (ve m. 31 hükmüne) göre dinlenir.

Hâkim, dinlenilmek üzere huzuruna gelen tarafın kimliğini titizlikle tespit etmelidir. Dinlenilmesine karar verilen taraftan başka birinin hâkim huzuruna

---

1 Bkz. Erdal Tercan, Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001.

gelmesi ve dinlenmesi halinde, bunu yapanlar hâkimi yanıltarak ona sahte tutanak düzenlettirmiş olur ve TCK'nun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. Bu husus, ayrıca bir yargılamanın iadesi sebebi teşkil eder (m. 375, 1/h)[2].

Dava ile ilgili vakıaları en iyi taraflar bilebileceklerinden, isticvabın davanın aydınlanması için iyi bir usul olduğu söylenebilirse de, taraflar kendi davalarında en şüpheli tanık durumunda olduklarından, **isticvap başlı başına bir ispat aracı** (delil) **olarak kabul edilmemiştir**. Ancak, isticvap ile delil (özellikle ikrar) elde edilebilir ve bazı hallerde isticvap davanın aydınlanmasına hizmet edebilir.

Başka bir deyişle, isticvabın asıl amacı ikrar elde edebilmek ise de, isticvaba yalnız ikrar elde amacı ile başvurulmaz, davanın (vakıaların) aydınlatılması, takdirî delillerin daha isabetle değerlendirilmesi için de başvurulabilir. Yargıtay bazı kararlarında, bu amacın gerçekleşmesi için, her iki tarafın isticvap edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle takdirî delillerle ispat söz konusu olduğunda, hâkimin, ispatı gereken vakıanın ispatlanmış olup olmadığı konusunda bir kanıya varmasında isticvap önemli olabilir.

B) İSTİCVABIN KONUSU

İsticvabın konusu, dava ile ilgili **belli** (davanın temelini oluşturan) **vakıalar** ve onunla ilişkisi bulunun hususlardır (m. 169, 2). Mahkeme, gerçeğe ulaşmak için kendiliğinden veya talep üzerine tarafların her ikisinin veya birinin isticvabına karar verebilir (m. 169, 1). İsticvap, isticvap edilecek tarafı bir ikrarda (m. 188) bulunmaya götürebileceğinden ve tarafın gelmemesi halinde taraf isticvap konusu vakıayı ikrar etmiş sayılacağından (m. 171), bir **taraf, ancak kendi aleyhine olan vakıalar hakkında isticvap edilebilir**; yoksa, kendi lehine olan vakıalar için isticvap edilemez. Yani, davacının iddiasını dayandırdığı vakıa hakkında davalı; davalının savunmasını dayandırdığı vakıalar hakkında davacı isticvap olunur.

Bir taraf, kendi lehine olan vakıalar hakkında ancak m. 144'e (veya m. 31'e) göre dinlenebilir.

C) İSTİCVAP USULÜ

Hâkim, bir tarafın isticvabına (belli bir vakıa hakkında sorguya çekilmesine) **kendiliğinden karar verebilir** (m. 169, 1). **Taraflardan biri de**, diğer tarafın (belli bir vakıa hakkında) isticvap edilmesini **isteyebilir** (m. 169, 1). Fakat hâkim, bir tarafın isticvap talebini kabul etmek zorunda değildir; gerekli görürse isticvap kararı verir.

İsticvap edilecek kişi, isticvap konusu vakıa aleyhine olan ve bu nedenle isticvabına karar verilmiş olan tarafın (bizzat) kendisidir (m. 171, 1/c. 1; 172).

Bu nedenle tarafın **vekili**, taraf adına **isticvap edilemez**. Taraf, davayı vekil aracılığı ile takip etse bile, isticvap davetiyesinin tarafın kendisine tebliğ edilmesi gerekir.

---

[2] Bkz. aşa. § 58, 61.

Ergin olmayan küçük veya kısıtlı adına yapılan işlemle ilgili olarak ise, yasal temsilcisi (**veli**si veya **vasi**si) isticvap olunur (m. 170, 2). Buna karşılık, ergin olmayan veya kısıtlı kişilere bizzat dava ehliyeti tanınan hallerde, yasal temsilcisi değil, ergin olmayan küçük veya kısıtlının kendisi isticvap olunur (m. 170, 3).

İsticvabına karar verilen taraf bir **tüzel kişi** ise, tüzel kişinin organı isticvap olunur (m. 170, 1). Örneğin, bir derneğin yönetim kurulu üyeleri isticvap olunur.

Bir davada ancak taraflar isticvap edilebilir. Taraflar dışındaki üçüncü kişilerin isticvap edilmesine imkân yoktur; onların bilgisinden tanık olarak yararlanılır (m. 240 vd.).

İsticvabına karar verilen taraf, bizzat kendisine gönderilen (karş. Teb. K. m. 11) davetiye ile belirlenen gün ve saatte isticvap olunmak üzere mahkemeye çağrılır (m. 171). Buna **isticvap davetiyesi** denir.

Bu davetiyede, isticvabına karar verilen tarafa geçerli özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de sorulan sorulara cevap vermediği takdirde sorulan soruları ikrar etmiş sayılacağı uyarısı yapılır (m. 171, 1/c.2). Çağrılan taraf gelmez veya gelip de sorulara cevap vermezse, mahkeme, sorulan (isticvap davetiyesinde bildirilen) vakıaları ikrar (m. 188) edilmiş sayar (m. 171, 2).

Örneğin, davacının dayandığı senet altındaki imzanın davalıya ait olup olmadığını bildirmesi için hâkim davalının isticvabına karar verir (m. 211, 1/a) ve davalıya isticvap davetiyesi gönderir. Davalı, bunun üzerine geçerli bir özrü olmaksızın oturuma gelmezse veya gelip de imzanın kendisine ait olup olmadığı hakkındaki soruya cevap vermezse, davacının dayandığı senet altındaki imzanın kendisine (davalıya) ait olduğunu ikrar etmiş sayılır (m. 171).

İsticvabına karar verilen taraf, aynı mahkemede isticvap olunur.

Ancak, taraf davaya bakan mahkemenin bulunduğu **il dışında** (karş. "yargı çevresi") oturmakta ve bulunduğu yerde aynı anda **ses ve görüntü nakledilmesi** (SEGBİS) yolu ile isticvap olunması mümkün ise, bu yolla; mümkün değilse, **istinabe** yolu ile isticvap olunur (m. 172, 1/c. 2). Madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere, isticvap olunacak kişi, mahkemenin bulunduğu il dahilinde oturuyorsa, (mahkemenin yargı çevresi dışındaki bir ilçede bulunsa bile) gerçeğin ortaya çıkması bakımından, hüküm verecek hâkimle yüz yüze gelmesinde fayda bulunduğundan, isticvap için davet edilen mahkemeye gelme zorunluluğu vardır.

Hastalık, engellilik veya benzeri sebeplerle mahkemeye bizzat gelemeyecek durumda olanlar, bulundukları yerde isticvap olunur (m. 172, 2; m. 175'in atfıyla m. 259, 3).

İsticvap davetiyesine uyarak gelen taraf mahkemede isticvap olunur.

İsticvap sırasında tanıklar hazır bulunamaz. Mahkeme, gerekirse tarafı isticvaptan sonra tanıklarla yüzleştirebilir.

İsticvap olunan tarafın vekili ile diğer taraf ve vekili isticvap sırasında hazır bulunabilir (m. 173, 3). Zabıt kâtibinin ise isticvap sırasında bulunması zorunludur (m. 157, 1).

Hâkim isticvaba başlamadan önce, isticvap olunan tarafa gerçeği (m. 29) söylemesi gerektiği hususunu hatırlatır (m. 173, 2).

İsticvap olunan taraf, mahkemenin izni olmadıkça, yazılı notlar kullanamaz (m. 173, 4).

İsticvap bitince bir **tutanak düzenlenir**. İsticvap olunan tarafça yapılan açıklamalar, sorulan sorular ve verilen cevaplar tutanağa yazılır. Tutanak alenen her iki taraf önünde okunduktan sonra altı, isticvap olunan kişi tarafından imza olunur. Taraf haklı bir gerekçe göstermeden, tutanağı imza etmekten kaçınırsa, durum imzadan kaçınma için gösterilen sebep ile birlikte tutanağa yazılarak hâkim tarafından tespit olunur (m. 174).

Kanun koyucu, isticvabı, doğrudan doğruya delil olarak değil de, tarafın kendi davasında tanıklığına yakın gördüğü için, tanıklıkla ilgili; sır saklama nedeniyle çekinme (m. 249), menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle çekinme (m. 250), mahkemede dinlenilme (m. 259), bilgilendirilme (m. 260), dinlenilme şekli (m. 261), tarafların yapmalarının yasak olduğu davranışlar (m. 262) ve tercüman kullanılması (m. 263) ile ilgili hükümler, niteliğine aykırı düşmedikçe, isticvapta da uygulanır (m. 175).

Taraf isticvabı sırasında ikrarda bulunursa, hâkim bu ikrar ile bağlıdır (m. 236). Bunun dışında hâkim, isticvap olunan tarafın beyanlarını serbestçe takdir eder (karş. m. 198).

İSPAT VE DELİLLER[1]

Genel anlamı ile **ispat**, bir iddianın doğru olduğu konusunda muhatabı inandırma (ikna) çabasıdır. Davada ispat ise, tarafın/tarafların talebinin (talep sonucunun) dayanağını oluşturan vakıaların (olay ve olguların) doğru olduğu konusunda hâkimi inandırma faaliyetidir (çabasıdır). İspat faaliyeti sonucunda dava konusu iddia ve savunmaların gerçekliği konusunda hâkimde bir kanaat oluşturulması, hâkimin uygun hukukî sebebi tespit edip uygulayarak adlî (yargısal) gerçeği yansıtan karar vermesi sonucunu doğuracak; adlî gerçeğin (hâkimin kararının) maddî gerçeğe (ispatlanan, talep sonucunun dayandırıldığı vakıalara) uygun olması sağlanacaktır. Bu bölümde önce, ispat ve delillere ilişkin genel hükümler, arkasından ispata ilişkin hususlar ve ispat araçları (deliller) incelenecektir.

Genel anlamda delil (kanıt), bir iddianın doğru olduğu konusunda muhatabı ikna etmek için kullanılan araçtır. Tahkikat aşamasındaki ispat faaliyetinde başvurulan araç olan delil ise, talep sonucunun dayandırıldığı (talep sonucunu haklı gösteren) vakıaların doğru olduğu konusunda hâkimi ikna etmek (inandırmak) için başvurulan ispat araçlarıdır.

§ 25. GENEL HÜKÜMLER

Bu bölümde, ispat ve delillerle ilgili genel hükümler (m. 187-198), özellikle ispatın konusu, delillerin niteliği, ispat hakkı, ispat yükü ve delillerin gösterilmesi incelenecektir. Delil çeşitleri (senet, tanık, bilirkişi vs.) ise bundan sonraki paragraflarda ayrı ayrı inceleme konusu yapılacaktır.

A) İSPATIN KONUSU ve DELİL

Dava konusu yapılan hakkın (örneğin alacağın) gerçekten var olup olmadığının anlaşılması; maddî hukukun o hakkın doğumunu veya sona ermesini kendisine bağladığı vakıaların doğru olup olmadığının tespit edilmesi sonucunda mümkün olur. İşte, dava konusu hakkın ve (hak iddiasının) buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıaların doğru (var) olup olmadıkları hakkında mahkemeye kanaat verilmesi (mahkemenin inandırılması, ikna edilmesi) işlemine ispat denir.

---

[1] Bkz. Halûk Konuralp, Medenî Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999; Yavuz Alangoya, Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979; M. Kamil Yıldırım, Medenî Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990; Sema Taşpınar, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001; Aziz Serkan Arslan, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2013; Nur Bolayır, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2013; Pınar Çiftçi, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Ankara 2018; S. Hilal Üçüncü, Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilen ve Sırların Korunması, İstanbul 2019.

İspatın konusunu, tarafların üzerinde anlaşamadıkları (m. 140, 3) ve fakat uyuşmazlığın çözümünde (talep sonucunun karara bağlanmasında) etkili olabilecek **çekişmeli vakıalar** oluşturur (m. 187, 1/c. 1).

Bir taraf, ancak kendisinin dayandığı vakıaların doğru olduğunu veya karşı tarafın dayandığı vakıaların doğru olmadığını ispat ederek, davayı kazanır veya davanın reddini sağlayabilir. Davacı, davasında ne kadar haklı olursa olsun, davasını dayandırdığı vakıaları ispat edemez veya ispat eder de davalı bunların aksini ispat ederse, davayı kaybeder. Bu nedenle, davada ispat çok önem taşır. Bir vakıanın ispatı için yapılan işlemlere ispat faaliyeti denir. Yani **ispat faaliyeti,** soyut (koşul) vakıalardan hareketle ileri sürülen, talep sonucunu haklı kılan somut vakıaların (olay ve olguların) doğru olduğu konusunda hâkimin bir kanıya ulaşmasını sağlama çalışmasıdır. Bu ispat faaliyeti sonucunda hâkimin vakıanın doğru (gerçek) olduğu konusunda tam (ve vicdanî) bir kanıya ulaşması, vakıanın tam ispat edildiği anlamına gelir. Geçici hukukî koruma tedbirlerinin talep edildiği bazı hallerde ise, ispat faaliyeti ile hâkimde bir kanaat uyandırılması (yaklaşık ispat) yeterli olur.

İşte, talep sonucunun dayandırıldığı (taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan) bu çekişmeli vakıanın ispatı için başvurulan araçlara **delil** (kanıt) denir (m. 187, 1/c. 2).

Başka bir deyişle delil, "davanın çözümünü etkileyebilecek çekişmeli hususların ispatı için başvurulan araç" şeklinde tanımlanabilir[2].

B) DELİLİN KONUSU

Delilin konusu, maddî **vakıalardır** (olay ve olgulardır). Bu vakıalar, yukarıda da görüldüğü gibi, davanın ve savunmanın esasını (temelini) oluşturan, bunların dayandıkları, taraflarca ileri sürülen vakıalardır. Bu vakıalar olumlu veya olumsuz olabilir.

Maddî hukuk, bir hakkın doğumunu veya son bulmasını, belli vakıaların (koşul vakıaların) varlığına bağlı tutmuştur. İşte delilin konusu bu maddî vakıalardır; bu vakıalar hakkında delil gösterilir. Gösterilen delil ile örneğin, davacının talebini dayandırdığı maddî vakıa (örneğin satış sözleşmesi) ispat edilirse, (davalı karşı bir vakıayı, örneğin satış bedelini ödediğini ispat ederek davacının iddiasını çürütmedikçe), artık mahkeme o vakıanın hukukî niteliğini (hukukî sebebi) belirleyerek, yani hukuk kurallarını o maddî vakıaya uygulayarak (m. 33) davacı lehine hüküm verir.

Bununla, hukuk kurallarının delilin konusunu teşkil edemeyeceğine de işaret etmek istiyoruz. Hukuk kurallarının ispatına gerek yoktur; çünkü hukuk kuralları, hâkim tarafından kendiliğinden araştırılır ve uygulanır (m. 33). İspat edilen bir maddî vakıanın hukukî niteliğini belirlemek, ona uygulanacak hukuk kurallarını bulup uygulamak, hâkime aittir[3].

---

2 Bkz. HUMK m. 238, I.

3 Bkz. yuk. § 5, M.

Bir davada, o **davanın çözümünü etkileyebilecek** (davanın konusu olan uyuşmazlığın çözümü için gerekli) olan vakıalar hakkında delil gösterilir ve ancak bu deliller, inceleme konusu yapılır.

Yukarıda belirtildiği gibi, hâkim, ön incelemede tarafların bildirdikleri ve fakat davanın çözümü için gerekli (dava ile ilgili olmayan) vakıaları ayırır ve bunları tahkikat konusu yapamaz (m. 140). Dava ile ilgili olmayan vakıalar için delil gösterilemez; gösterilmiş ise incelenemez. Çünkü, bu vakıaların (ilgili olmadıkları o davada) ispat edilmesi ile edilmemesi arasında, o davanın çözümü (halli) bakımından hiçbir fark yoktur.

Bundan başka, taraflar arasında **çekişmeli olmayan vakıalar** için de delil gösterilmesine gerek yoktur. Taraflar arasında çekişmeli olmayan vakıalar, tarafların üzerinde anlaştıkları ve özellikle ikrar edilen (m. 187, 2; 188) vakıalardır.

Bunun gibi, **herkesçe bilinen vakıalar** çekişmeli sayılmaz (m. 187, 2). Yani, herkesçe bilinen bir vakıaya dayanan taraf, bunu ispat etmek için delil gösterme (ispat) yükü altında değildir. Bu vakıalar, genel olarak herkesin bildiği veya öğrenmesinin mümkün olduğu vakıalardır. Bunlar daha çok, önemli tarihî olaylardır: Gölcük depremi, en son genel seçimlerin yapıldığı gün, belli bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığı gibi.

C) İSPAT HAKKI[4]

Hak arama özgürlüğü, dava açmayı (iddia etmeyi) ve savunmayı kapsayan genel ve soyut bir kavramdır. Davada tarafların (ve hatta dava ile ilgili üçüncü kişilerin) iddia ve savunma haklarını fiilen kullanabilmeleri, kendilerine, ispat etme hakkının verilmesiyle sağlanabilir; bu şekilde hak arama özgürlüğü somutlaşır ve fiilen gerçekleşir.

Hukukî dinlenilme hakkının (m. 27, 2/b) bir unsuru olarak taraflar, kanunda belirtilen **süre ve usule uygun olarak ispat hakkı**na sahiptir (m. 189, 1).

İspat hakkı her iki tarafa da ait olduğu için ispat, Kanunda (m. 189) taraflar bakımından sadece bir yük olmanın ötesinde aynı zamanda bir hak olarak düzenlenmiştir.

İspat hakkı, tarafların Kanunun belirlediği süre içinde ve Kanunun düzenlediği usule uygun olarak ortaya koyduğu delillerle sağlanır. Ancak ispat hakkı pahasına, **hukuka aykırı olarak elde edilen delil**lerin kullanımına izin verilemez. Bu nedenle, hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin, bir vakıanın ispatında mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı Kanunda açıkça düzenlenmiştir (m. 189, 2). Bu düzenlemede, yargılama sırasında taraflarca sunulan delillerin elde ediliş biçiminin mahkeme tarafından kendiliğinden gözönüne alınması ve delilin her ne surette olursa olsun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin tespit edilmesi halinde, diğer tarafça bir itiraz ileri sürülmese dahi mahkemece caiz olmadığına karar verilerek, dosya kapsamında değerlendi-

---

[4] Pınar Çiftçi, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Ankara 2018.

rilmemesi ilkesi benimsenmiştir[5]. Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkeme tarafından karar verilir (m. 189, 4).

Hâkim, tarafların ispat hakkı çerçevesinde ibraz ettikleri (toplanan) bütün delilleri kararında tartışır, değerlendirir ve bundan çıkan sonucu kararına yazar (m. 297, 1/c). Aslında bu hüküm, Anayasanın öngördüğü, (m. 141, III), "bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektiği" ilkesine uygundur.

Mahkeme kararında delillerin hiç değerlendirilmemesi, istinaf mahkemesinin duruşma yapmadan, kararın kaldırılması ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın gönderilmesi kararı vereceği hallerden biridir (m. 353). Keza, taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanunî bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi, temyizde bozma sebepleri arasında sayılmıştır (m. 371). Bu düzenlemeler de, hâkimin delillerin tümünü değerlendirip bunu kararın gerekçesine yazmasının önemini ve gereğini vurgulamaktadır.

Delil sistemleri, geneli itibariyle; hâkimin bütün delilleri serbestçe değerlendirdiği "**takdirî delil sistemi**" ile delillerin (kısmen veya tamamen) hâkimi bağladığı "**kesin** (kanunî) **delil sistemi**" olarak ikiye ayrılır. "Kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar başka delillerle ispat olunamaz" şeklindeki m. 189, 3 hükmü, HMK'nun da HUMK'nun kabul ettiği "kesin delil" sistemini benimsediğini göstermektedir.

D) İSPAT YÜKÜ[6]

I – GENEL BİLGİ

Hâkim, davada hangi (çekişmeli) vakıaların ispat edilmesi gerektiğini tespit edip ön inceleme tutanağına yazdıktan sonra, bu vakıaların kimin tarafından ispat edilmesi gerektiği konusunu inceler ve karara bağlar. İşte, bir davada talep sonucunun karara bağlanması için önemli olan ve taraflar arasında anlaşmazlık konusu olmaya devam eden vakıaların ispatının kime (hangi tarafa) düştüğü hâkim tarafından karara bağlanır. Hâkimin kararında gösterdiği bu kişiye (tarafa) verilen yüke, ispat yükü denir.

Kendisine ispat yükü düşen taraf için, bu bir yükümlülük değil, sadece bir yüktür. Taraf kendisi tarafından ispatı gereken bir vakıayı ispat edemezse, karşı taraf (ve mahkeme) onun mutlaka ispat etmesini isteyemez (yükümlülük). Tam tersi (aksine), kendisine ispat yükü düşen taraf, o vakıayı ispat edememiş sayılır; örneğin, kendisine ispat yükü düşen ve fakat bunu yerine getiremeyen taraf davacı ise, davasını (iddiasını) ispat edememiş sayılır ve dava bu nedenle reddedilir.

---

5 Hukuka aykırı yolla elde edilen deliller konusu aşağıda (§ 26, B) incelenecektir.

6 Bkz. Bilge Umar/Ejder Yılmaz, İsbat Yükü, İstanbul 1980; Oğuz Atalay, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001.

II – İSPAT YÜKÜ, ZAMANI ve ÖNEMİ

Her iki taraf da, ispat yükünün kime düştüğünü gözetmeden (m. 119, 1/f; 129, 1/e hükümleri gereğince) delil göstermişler ise, bu halde hâkimin ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü araştırmasına gerek yoktur. Çünkü hâkim, ilk önce tarafların gösterdikleri delilleri incelemekle yükümlüdür.

Örneğin, bir trafik kazasından dolayı açılan tazminat davasında, her iki taraf da kazanın oluş biçimi hakkında tanık göstermiş ise, hâkim, bu tanıkların hepsini dinleyerek kazanın oluş biçimini öğrenmeye (tespit etmeye) çalışır. Yoksa, burada hâkim, ilk önce ispat yükünün kime düştüğünü araştırıp, yalnız o tarafın tanıklarını dinlemekle yetinemez.

İki tarafın (veya bir tarafın) gösterdiği deliller ile davaya ilişkin bütün çekişmeli vakıalar aydınlanmış ise, gene ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü araştırmakta bir yarar yoktur.

Yukarıdaki örnekte hâkim iki tarafın (veya bir tarafın) gösterdiği tanıkların ifadesinden kazayı yapan şoförün (davalının) trafik kurallarına aykırı hareket ettiğini tespit ederse, buna göre hükmünü verir (davalıyı mahkûm eder). Hâkimin, bu sonuca davalının gösterdiği tanıkların ifadesi üzerine de varması mümkündür.

Buna karşılık, gösterilen delillerin hâkime dava hakkında tam bir kanaat vermemesi halinde, ispat yükünün hangi tarafa düştüğünün tespit edilmesi gerekli olur. İşte ispat yükü, bu hal (durum) için önemlidir; çünkü:

Hâkim, gösterilen delillerin davayı karara bağlamak için yeterli olmadığı hallerde de esas hakkında bir karar vermekle yükümlüdür. Ceza usulündeki "davalının (sanığın) delil yetersizliğinden dolayı beraat ettirilmesine" benzeyen bir kurum, medenî usul hukukunda yoktur. Bu halde, hâkimin ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü tespit etmesi ve o taraftan uyuşmazlık konusu vakıayı ispat etmesini istemesi gerekir.

Hâkimin kendisine ispat yükü düştüğünü bildirdiği taraf, uyuşmazlık konusu vakıayı ispat edemezse, **davayı kaybeder**. O taraf, davacı ise davası reddedilir, davalı ise mahkûm edilir.

Yalnız bu halde, kendisine ispat yükü düşen ve fakat bunu yerine getirememiş olan tarafın, karşı tarafa yemin teklif etme hakkı vardır (m. 225 vd.). Örneğin, ispat yükü kendisine düşen davacı, davasını ispat edememiş ise, hemen davanın reddine karar verilmez; davacının, dilekçelerinde dayanmış olması koşuluyla, karşı tarafa (davalıya) bir yemin teklif etmesine izin verilir. Bu konu, ileride yemin bölümünde incelenecektir[7].

İspat yükünün zamanı ve önemi hakkındaki bu açıklamalardan sonra, şimdi ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü belirten genel kural ve istisnaları incelenecektir:

---

7 Bkz. aşa. § 29.

III – İSPAT YÜKÜ KONUSUNDA GENEL KURAL

Türk Medenî Kanununa (m. 6) göre, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK m. 6). HMK m. 190, 1 ise, bu (TMK m. 6) kuralı, "ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir" şeklinde ifade etmektedir. Bu iki kurala göre;

İspat yükü, ilk önce **kural olarak davacıya** düşer; yani, davacı davasını dayandırdığı vakıaları (olguları) ispat etmelidir. Örneğin, davacı, davalıya on bin lira ödünç verdiğini iddia ederek, davalının bu parayı ödemeye mahkûm edilmesini istiyorsa, ilk önce bu ödünç verme vakıasını ispat etmelidir. Davacı bunu ispat ederse, ödünç aldığı parayı ödediğini iddia eden davalının, ödeme vakıasını ispat etmesi gerekir.

Yukarıdaki örneğin de gösterdiği gibi, ispat yükünün tarafların rolü ile bir ilgisi yoktur. İspat yükü davacıya düşebileceği gibi, davalıya da düşebilir. Bu konudaki genel kurala (TMK m. 6; HMK m. 190, 1) göre, "**hakkını bir vakıaya dayandıran taraf** (iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf) **o vakıayı ispat etmelidir**". Bu taraf davacı olabileceği gibi, davalı da olabilir.

IV – GENEL KURALIN İSTİSNALARI

Yukarıda incelenmiş olan genel kuralın bazı istisnaları vardır. Genel kuralı düzenleyen TMK m. 6 ve HMK m. 190, 1'den, genel kuralın bazı istisnalarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre; aşağıdaki hallerde, istisna olarak, ispat yükü hakkını bir vakıaya dayandıran tarafa değil, o vakıa aleyhine olan (karşı) tarafa aittir:

1) Normal Durumun Aksinin İspatı

Normal bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını ispat etmesi gerekmez; tam tersi, ispat yükü **normal durumun aksi**ni iddia eden tarafa düşer. Her olayda normal olarak var olan bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını ispat etmesine gerek yoktur. Tam tersi, normal durumun aksini, yani istisnaî bir durumu iddia eden taraf, bu istisnaî durumu ispat etmelidir. Örneğin, bir sözleşmeye dayanarak dava açan davacının, bu sözleşme yapılırken (imzalanırken) gerek kendisinin gerek davalının fiil ehliyetinin bulunduğunu ispat etmesine gerek yoktur. İddiası, bu sözleşmenin geçerlilik şartlarından olan fiil ehliyetinin varlığını da kapsayan davacı, bunu ispat etmekle yükümlü tutulamaz; çünkü, bu normal bir durumdur. Normal olmayan (istisna), sözleşmeyi yapanların fiil ehliyetinin bulunmamasıdır. Davalı bunu iddia ederse, bu iddiasını kendisi (davalı) ispat etmelidir.

Bir hakkın doğumu için kanunen iyiniyet şart kılınan hallerde normal (asıl) olan, iyiniyetin varlığıdır (TMK m. 3, I). Bu nedenle, karşı tarafın (iyiniyetli olmadığını iddia edenin) kötüniyeti ispat etmesi gerekir. Ancak, başkasının arsasına iyiniyetle inşaat yaptığını iddia eden kimse (TMK m. 724), iyi-

niyet, kural olarak, asıl olmakla (TMK m. 3, I) beraber, iyiniyetini ispat etmelidir. Çünkü, başkasının arsasına inşaat yapan bir kimse, normal olarak o arsanın başkasına ait olduğunu bilir; yani (normal olarak) iyiniyetli değildir. Şu halde, normal olmayan durumu, yani iyiniyetini ispat etmelidir.

Davalı, kendi imzasını taşıyan bir senedi davacıya sadece bir imza (beyaza imza) ile verdiğini senet metninin davacı tarafından doldurulduğunu ve bunun anlaşmalarına (gerçeğe) aykırı olduğunu iddia ederse, bu iddia normal duruma aykırı olduğundan, senet metninin doğru olduğunu davacı değil, tam tersi (aksine) senedin doğru olmadığını davalı ispat etmelidir.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, normal durumun aksini iddia eden ve bu nedenle ispat yükü kendisine düşen taraf, davacı veya davalı olabilir.

2) İspat Yükünün Kanunla Belirlendiği Haller

Bazı hallerde bir vakıayı kimin ispat etmesi gerektiği (ispat yükünün kime düştüğü), bir kanun hükmü ile belirlenmiş olabilir. Kanun (TMK m. 6; HMK m. 190, 1) bu halleri saklı tutmuştur. Bu hallerde, ispat yükünün (genel kurala göre) kime düştüğü araştırılmaz; ispat yükü, özel kanun hükümlerinde yazılı olan kimseye düşer.

İspat yükünün özel kanun hükümleri ile belirlendiği hallere örnekler:

Evlendikten en az yüz seksen gün sonra doğan çocuğu reddeden kocanın, çocuğun kendisinden olması ihtimali bulunmadığını (yani menfî bir vakıayı) ispat etmesi gerekir (TMK m. 287).

Soybağının düzeltilmesine itiraz davasında, çocuğun o ana ve babadan olmadığını ispat, davacılara aittir (TMK m. 294).

Haksız fiilde zararı ispat etmek davacıya düşer (TBK m. 50).

Adam çalıştıranın, sorumluluktan kurtulabilmesi için, zararın meydana gelmemesi (doğmaması) için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmesi gerekir (TBK m. 66).

Bunun gibi, araç sahibinin sorumluluktan kurtulabilmesi için, zararın mücbir sebepten veya kazaya uğrayanın veya üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini veya kendisinin veya fiil ve hareketlerinden sorumlu olduğu kimselerin kusurunun bulunmadığını ispat etmesi gerekir (Karayolları Trafik K. m. 86, I).

Hayvan bulunduranın hayvanın verdiği zarardan sorumlu olmaması için, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmesi gerekir (TBK m. 67).

Sözleşmeyi yerine getirmeyen borçlunun, bundan doğan zararı ödemekten kurtulabilmesi için, kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat etmesi gerekir (TBK m. 112).

Ancak, cezaî şartta, alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa, alacaklı, borçlunun kusuru bulunduğunu ispat etmedikçe aşan miktarı isteyemeyeceğinden, borçlunun kusurlu olduğunu ispat yükü alacaklıya düşer (TBK m. 180, 2).

Kıymetli evrakta, ihbarı yapmakla mükellef olan kimse, bunu belli süre içinde yaptığını ispat etmek zorundadır (TTK m. 723, 6).

3) Karineler

Karine[8], belli bir olaydan, belli olmayan diğer bir olay için çıkarılan sonuçtur. Karineler ikiye ayrılır: Fiilî karineler ve kanunî karineler.

a) Fiilî Karineler[9]

Bunlar belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için **hâkim tarafından** çıkarılan sonuçlardır. Fiilî karinelere, yaşam deneyimi (hayat tecrübesi) kuralları da denir. Başka bir deyişle, fiili karineler yaşam deneyimi (tecrübe) kuralları temeline dayanır. Yargıtay, kararlarında bu durum hayatın olağan akışı veya normal durum olarak da belirtmektedir.

Fiilî karine (yaşam deneyimi kuralı) lehine olan taraf, o hususu (vakıayı) ispat etmiş sayılır. Ancak, fiili karineye dayanan tarafın karineye temel olan vakıayı (karine temelini) ispat etmesi gerekir. Karine temelini (örneğin, alacaklının senedi geri verdiğini) ispat eden borçlu taraf, karine sonucunu (borcun ödendiğini) ispat yükünden kurtulur. Örneğin, alacaklı tarafından borç senedinin borçluya geri verilmesi, borcun ödendiğine karine sayılır.

Destekten yoksun kalma tazminatıyla ilgili davalarda, yaşam deneyimi kurallarına (fiilî karineye) göre desteklik durumunun ispat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kural olarak, fiilî karinenin aksini karşı taraf ispat edebilir.

b) Kanunî Karineler

Bunlar, belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için kanun tarafından çıkarılan sonuçlardır. Kanunî karineler, ispat yüküne gerçek bir istisnadır. Çünkü, karine lehine olan taraf o olayı ispat etmekle yükümlü değildir. Kanunî karineler de, kesin ve adî (kesin olmayan) kanunî karineler olarak ikiye ayrılır:

Kesin Kanunî Karineler: Bazı kanunî karineler kesindir; karşı taraf, bunların aksini ispat edemez (m. 190, 2). Daha doğrusu, bu karinelerin aksinin ispatı caiz değildir. Örneğin, kimse, tapu sicilinde kayıtlı olan bir durumun kendisince bilinmediği yolunda bir iddia ileri süremez (TMK m. 1020, III).

İrade bozukluğuna uğrayan kimse, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmezse sözleşmeye onay vermiş sayılır (TBK m. 39). Bu kimse bir yıl geçtikten sonra, gerçek iradesinin onay verme olmadığını ispat edemez.

---

[8] Bkz. Gökçen Topuz, Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012; Ahmet Başözen, Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010; Hakan Albayrak, Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

[9] Bkz. Sema Taşpınar, Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü (AÜHFD, C. 45, sa. 1-4, 1996, s. 533-572).

İİK m. 44'e göre, ticareti terk eden tacir mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay süresince tasarruf işlemi yapamaz. Üçüncü kişilerin iyiniyetle elde ettiği haklar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru arasındaki kazanımlarda iyiniyet iddiasında bulunulamaz; yani bu kişiler kötüniyetli sayılır.

İİK m. 278'de sayılan tasarruflar iptal davası bakımından, bağışlama ile bir tutulmuştur; ilgililer, bu tasarrufların bağışlama olmadığını (ivazlı olduğunu) iddia ve ispat edemezler.

Adî Kanunî Karineler: Adî kanunî karineler, aksi ispat edilebilen karinelerdir. Bunlar, aksi ispat edilinceye kadar delil teşkil eder. Ancak, karine aleyhine olan taraf, karinenin aksini ispat edebilir. Kanunî bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanunî karinenin aksini ispat edebilir. Örnekler:

İyiniyet karinesi (TMK m. 3, I). Ancak, duruma göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse, iyiniyet iddiasında bulunamaz (TMK m. 3, II); yani TMK m. 3, I'deki iyiniyet karinesine dayanamaz.

Resmî sicil ve senetlerin, doğru olmadığı ispat edilinceye kadar, doğru olduğu kabul olunur (TMK m. 7).

Hangisinin önce veya sonra öldüğünü tayin mümkün olmaksızın ölenler, aynı anda ölmüş sayılırlar (TMK m. 29, II).

Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile ölmüş sayılır (ölüm karinesi, TMK m. 31).

Soybağının reddine ilişkin karineler (TMK m. 288); babalık karinesi (TMK m. 285) de yine bir adî kanuni karinedir.

Taşınır bir malın zilyedi onun maliki sayılır (İİK m. 97/a; TMK m. 985). Taşınmazlarda, tescil mülkiyete karinedir (TMK m. 992; İİK m. 97/a). Hacizdeki istihkak davalarında da, bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır.

Faiz ve kira bedeli gibi belirli zamanlarda ödenmesi gereken sair borçlardan, çekince (ihtirazî kayıt) ileri sürmeksizin, bir taksit için makbuz veren alacaklı ondan önceki taksitleri de almış sayılır (TBK m. 104).

V – KARŞI İSPAT

Yukarıdaki kurallara göre kendisine ispat yükü düşmeyen taraf, karşı (kendisine ispat yükü düşen) tarafın iddiasını (vakıayı) ispat etmesini bekleyebilir. Kendisine ispat yükü düşen taraf iddiasını ispat edemezse, diğer (kendisine ispat yükü düşmeyen) tarafın onun iddiasının aksini ispat etmesine gerek olmaz; o vakıa ispat edilmemiş sayılır.

Fakat, kendisine ispat yükü düşmeyen taraf, ispat yükü kendisinde olan (diğer) tarafın iddiasını ispat etmesini beklemeden, onun iddiasının aksini ispat için delil gösterebilir. İşte bu delile, karşı (mukabil) delil denir. Ancak, ispat yükü kendisinde olmayan taraf, karşı delil göstermekle, ispat yükünü kendi üzerine almış sayılmaz (m. 191).

Karşı delil gösteren taraf, bununla sadece kendisi bakımından diğer (ispat yükü düşen) tarafın iddiasını çürütmeye çalışır ve böylece diğer tarafın iddiasını ispat etmesini güçleştirir veya imkânsız hale getirir. Sonuçta, ispat yükü kendisinde olan taraf, iddiasını ispat edemezse, o vakıadan kendi lehine hak (sonuç) çıkarılmasını isteyemez. Örneğin, iş davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda, ispat hukukunun genel esaslarına uygun olarak, iş sözleşmesinin haklı olarak bozulduğunun ve bir emek karşılığı olmayan hafta ve genel tatil ücretlerinin ödenmiş bulunduğunun ispatı yükü, işverene düşer. Nitekim Yargıtayın kökleşmiş içtihatları da bu yoldadır. Ancak işçinin de aynı konuda delil gösterme hakkı vardır. Ancak davacı işçi, delil gösterme talebiyle ispat yükünün kendisine düştüğünü kabul etmiş sayılmaz; bu hususların ispatı, davalı işverene düşer.

Yukarıda, ancak iki tarafın getirdikleri delillerle davanın aydınlanamaması halinde, ispat yükünün kime düştüğünü belirlemenin önem kazanacağı belirtilmişti. Şu halde, karşı ispat faaliyetiyle gösterilen karşı delile rağmen durum aydınlanamamışsa, o zaman hâkim, ispat yükü kendine düşen tarafı belirlemeli ve bu tarafa iddiasını ispat etmesi gerektiğini bildirmelidir. Taraf, iddiasını, lehine sonuç (hak) çıkardığı vakıaların doğru olduğunu ispat edemezse davayı kaybeder; örneğin, ispat yükü kendinde olan taraf davacı ise, davası reddedilir.

Bir kez daha belirtmek gerekirse, **karşı delil**, ispat yükü kendine düşmeyen tarafın gösterdiği delile denir. İspat yükü kendisine düşen taraf bir vakıayı ispat ettikten sonra, artık ispat yükü karşı tarafa geçer. Bunun üzerine karşı tarafın o vakıanın doğru olmadığını veya başka bir vakıa nedeniyle hükümsüz kaldığını ispat etmesi gerekir; aksi halde, karşı taraf davayı kaybeder; örneğin davalı ise mahkûm olur. İşte bu halde, karşı tarafın (ispat yükü başlangıçta kendisine düşen tarafın ispat ettiği vakıanın aksini ispat için) gösterdiği delil, m. 191 anlamında karşı delil değildir; çünkü, (ispat yükü kendine düşen tarafın iddiasını ispat etmesi ile) artık ispat yükü karşı tarafa geçmiştir.

İspat yükü ile yakından ilgili olan ikrar aşağıda incelenecektir[10].

[10] Bkz. aşa. § 27.

§ 26. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE DELİL ÇEŞİTLERİ

A) DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ

I – GENEL BİLGİ

Davacı, dava dilekçesinde, iddia ettiği her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini belirtir (m. 119, 1/f) ve dilekçesinde gösterilen ve elinde bulunan belgelerin asıllarını veya örneklerini dava dilekçesine ekleyerek mahkemeye verir (m. 121). Davalı da, cevap dilekçesinde savunmasının dayanağı olan her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini belirtir (m. 129, 1/e).

Mahkeme, ikinci dilekçelerin de karşılıklı verilmesinden sonra yapacağı ön inceleme duruşmasında; tespit ettiği uyuşmazlık konuları ile ilgili olarak taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ve ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmaları için iki haftalık kesin süre verir. Bu hususların verilen iki haftalık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir (m. 140, 5).

Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak belli şartlarda mahkeme, bir delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir (m. 145).

Deliller, kural olarak taraflarca gösterilebilir. Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmeleri zorunludur (m. 194). Bu maddenin gerekçesine göre: "Bu madde yeni bir düzenlemedir. Maddenin amacı, bir yandan ispatın genel hükümleri çerçevesinde temel bir kavrama yer vermek iken, diğer yandan da uygulamada genel geçer ifadelerle somut vakıalara dayanmadan davaların açılıp yürütülmesinin önüne geçmektir. - Birinci fıkrada, somutlaştırma yükü düzenlenmiştir. Bir davada, ispat faaliyetinin tam olarak yürütülebilmesi, mahkemenin uyuşmazlığı doğru tespit ederek yargılama yapabilmesi, karşı tarafın ileri sürülen vakıalara karşı kendini savunabilmesi için, iddia edilen vakıaların açık ve somut olarak ortaya konulması gerekir. Genel geçer ifadelerle, somut bir şekilde ortaya koymadan iddia veya savunma amacıyla vakıaların ileri sürülmesi durumunda, yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayacağı gibi, vakıaların anlaşılması için ayrıca bir araştırma yapılması ve zaman kaybedilmesi söz konusu olacaktır. Taraflar, haklarını dayandırdıkları hukuk kuralının aradığı koşul vakıalara uygun, somut vakıaları açıkça ortaya koymalıdırlar. Bu vakıaların somut olarak ileri sürülmesi, ilgili taraf için bir yüktür; bu yükü yerine getirmeyen sonuçlarına katlanacaktır. - İkinci fıkrada, somutlaştırma yükünün delillerle ilişkisi ortaya konulmuştur. Dava açılırken ve cevap dilekçesi verilirken taraflar, dayandıkları vakıaların hangi delillerle ispat edileceğini de belirtmek zorundadırlar. Delil bir ispat aracı olarak, ileri sürülen bir vakıanın doğruluğunu ispat etmeye yarar. Dolayısıyla her bir va-

kıa bakımından o vakıayı ispata yarayan ispat araçlarının da belirtilmesi önemlidir. Uygulamada, tarafların iddia veya savunmada bulunurken yeterli araştırma yapmadan vakıalar ileri sürdükleri veya bunların delillerini ortaya koymadan dilekçeler verdikleri görülmektedir. Özellikle taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda, mahkemenin yargılamayı doğru yürütebilmesi ve makul bir sürede karar verebilmesi için, delillerin vakıalarla bağlantısı kurularak mahkeme önüne getirilmiş olması gerekir. Bu da tarafların dayandıkları delilleri ve her bir delilin hangi vakıanın ispatı için kullanılacağını belirtmeleriyle mümkündür".

Delillerin nasıl gösterileceği, ileride her delil için ayrı ayrı incelenecektir[1]. Burada, delillerin gösterilmesi hakkında genel bir açıklama yapılmakla yetinilecektir.

Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda hâkim, davanın ispatı için gereken bütün delillere kendiliğinden başvurur; yine bu tür davalarda taraflar da yargılama bitinceye kadar delil gösterebilirler.

Taraflarca getirilme ilkesinin (m. 25) uygulandığı davalarda ise, deliller kural olarak taraflarca gösterilir; hâkim delillere kendiliğinden başvuramaz. Hâkim, taraflarca gösterilen delillerin hangisinin ispat için caiz (geçerli) olacağına karar verir (m. 189, 4). Örneğin, senetle (kesin delille) ispatın söz konusu olduğu ve senetle ispat zorunluluğunun istisnalarının bulunmadığı bir durumda, tarafın gösterdiği tanık delili geçerli delil sayılmaz.

Ancak hâkim, bilirkişi ve keşif delillerine kendiliğinden de başvurabilir (m. 266; 288). Hâkim, isticvaba da kendiliğinden karar verebilir (m. 169, 1). Bundan başka hâkim, davanın her aşamasında, iki tarafın iddiaları sınırı içinde olmak üzere, tarafları dinleyebilir ve gerekli olan delillerin gösterilmesini ve verilmesini emredebilir (m. 31).

Delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan vazgeçemez (m. 196).

II – DELİLLERİN HASREDİLMESİ

Bir tarafın, ispat yükü altında olduğu bir vakıayı ispat için bütün delillerini göstermesine ve bundan **başka delili olmadığını bildirmesi**ne delillerini hasretmesi denir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, taraflar dilekçeleri ile delillerini gösterirler (m. 119, 1/f; 129, 1/e); hâkim de, ön inceleme duruşmasının sonunda, taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir (m. 140, 5; karş. m. 145). Yani, taraflar delillerini, esasen dilekçelerinde hasrederler; ancak sunulmayan bazı bilgi ve belgelerin sağlanması için iki haftalık kesin bir süre verilebilir. Tarafların tanığa başvuracaklarını belirtmeleri yeterli olup, tanıkla-

[1] Bkz. aşa. § 26 vd.

rının isim ve adreslerini içeren listeyi hâkim tarafından verilen süre içinde ibraz etmeleri mümkündür.

III – DELİLLERİN İNCELENMESİ

Yukarıda görüldüğü gibi, deliller hasredildikten ve delillerini göstermeleri için taraflara gerekli süre verildikten sonra (m. 140, 5), belirlenen duruşmada delillerin incelenmesine geçilir.

Deliller, kural olarak mahkeme huzurunda (mahkemede) incelenir ve değerlendirilir (m. 197, 1). Bazı hallerde, mahkeme dışında da incelenebilir; örneğin m. 195; 235; 259; 288; 290'da düzenlenen hallerde olduğu gibi.

Başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde istinabe yoluyla toplanabilir (m. 195; 197, 2). Delillerin incelenmesi ve beyanların dinlenmesi sırasında taraflar, istinabe olunan mahkemede hazır bulunabilirler ve delillerle ilgili açıklama haklarını kullanabilirler. Bu durum, hukukî dinlenilme hakkının bir sonucudur. Bunun için, taraflara delil incelemesinin yapılacağı tarih ve yer bildirilir. Bu davet üzerine taraflar istinabe olunan mahkemede hazır bulunmasalar dahi deliller incelenir ve beyanlar dinlenir (m. 197, 3).

Gerek mahkemede gerek mahkeme dışında yapılan delil incelemesi ve işlemler ayrıntılı biçimde tutanağa yazılır (m. 154, 3).

Deliller hep birlikte ve mümkün olduğu kadar aynı duruşmada incelenir (m. 197, 1/c. 1). Delillerin incelenmesinin aynı duruşmada mümkün olmaması halinde yeni duruşmalar yapılabilir (m. 197, 1/c. 2). Bu konu ayrıntısı ile aşağıda, deliller kısmında incelenecektir.

IV – DELİLLERİN İNCELENMESİNDEN SONRA YENİ DELİL GÖSTERİLMESİ

Mahkemenin verdiği iki haftalık kesin süreden sonra, delil ileri sürülmesi, kural olarak mümkün değilse (m. 140, 5) de, yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ileri süren tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme, o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir (m. 145, 1; ayrıca bkz. m. 185).

Mahkemenin sonradan yeni delil gösterme taleplerine karşı tutumu, davanın makul sürede veya geç bitirilmesi hususunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle, m. 145'in hâkime tanıdığı takdir yetkisi, iyi değerlendirilmeli, hâkim bu yeni delil gösterme talebini kabul yetkisini çok dikkatli kullanmalıdır. Önceden gösterilmesi mümkün olan bir delilin, sırf davayı uzatmak için gösterilmemiş olması halinde hâkim, bu delilin sonradan gösterilmesine izin vermemelidir. Burada, ancak daha önce gösterilmesi mümkün olmayan veya ancak diğer delillerin incelenmesinden sonra gösterilmesinin yararlı olacağı anlaşılan delillerin sonradan gösterilmesine izin verilmelidir.

HMK m. 145, 1 hükmü, m. 140, 5 hükmü ile ilgili bir istisnadır. Buna karşılık bir taraf, hâkimin izni ile dahi (aynı vakıa için), ikinci (yeni) bir tanık listesi veremez (m. 240, 2).

B) HUKUKA AYKIRI YOLLARDAN ELDE EDİLEN DELİLLER

İspat hakkı, Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen bir temel hak olarak, m. 189 hükümlerine uygun olarak kullanılır. Bu hak, hukuka aykırı olmayan yollarla elde edilmiş ve yukarıda incelediğimiz gibi yargılamanın belli aşamasında mahkemeye sunulmuş delillerle kullanılabilir. Bu husus, ispat hakkı başlıklı m. 189'un gerekçesinde vurgulanmaktadır:

"Bu maddenin birinci fıkrası ile, ispat hakkı kavramı, kanunî sınırları belirtilmek suretiyle, bir davanın her iki tarafına da tanınmış olmaktadır. Böylece ispat, bu maddede taraflar bakımından sadece bir yük olmanın ötesinde aynı zamanda kanunî bir hak olarak düzenlenmiştir. - İkinci fıkra ile, ispat hakkının delillere ilişkin yönünün hukukî çerçevesi çizilmiş, bir davada ileri sürülebilecek her türlü delilin mutlaka hukuka uygun yollardan elde edilmiş deliller olması esası getirilmiştir. Fıkrada öngörülen düzenlemeye göre, hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşılan delillerin, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamayacağı düzenlenmek suretiyle, yargılama sırasında taraflarca sunulan delillerin elde ediliş biçiminin mahkeme tarafından re'sen göz önüne alınması ve delilin her ne surette olursa olsun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin tespit edilmesi hâlinde, diğer tarafça bir itiraz ileri sürülmese dahi mahkemece caiz olmadığına karar verilerek, dosya kapsamında değerlendirilmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bu hususta mahkemece re'sen karar verilebileceği hususu dördüncü fıkra ile öngörülmüştür".

İspat hakkının hukuka uygun yöntemlerle kullanılması gerekir. Günümüzde, özellikle teknolojinin hızla gelişmesi, sahte veya hukuka aykırı delil üretilmesi ya da mevcut delillerin hukuka aykırı yollardan elde edilerek kullanılmaya teşebbüs edilmesi biçiminde önemli sorunlar yaratmaktadır. Nitekim, izinsiz ses veya görüntü kaydı alınması ya da fotoğraf çekimi veya şifre kırmak suretiyle özel bilgilerin elde edilmesi gibi haller, hukuka aykırılığın görünüm biçimlerindendir. Hukuka aykırılık (örneğin bir delilin çalınması, gizli ve izinsiz kayıt yapılması gibi) çoğu kez suç da oluşturur.

Bir delilin hukuka aykırı yollardan elde edilip edilmediğini tespit etmek, ilk bakışta kolay görünmekle birlikte; burada sorun, hangi hallerde hukuka uygunluk sebebinin oluşacağı konusundadır. Bu ise, çoğunlukla özel hayatın söz konusu olduğu özel hukuk ilişkilerinde kolay olmamaktadır. Örneğin, Yargıtay, bir boşanma davasında kocanın evde bulduğu ve karısının bir başkasına yönelik duygularını anlattığı günlüğün hukuka uygun elde edilmiş delil olduğunu; çünkü karının bunu ortak yaşam alanı olan evde tuttuğunu ifade etmiştir. Yargıtay, bir başka olayda ise, karısına telefon hediye eden kocanın, telefon içerisine yerleştirdiği "casus" bir yazılım programıyla karısının tüm konuşmalarını dinleyip, kendisine yönelttiği hakaretleri bu kayıtla ispat etmesinde hukuka aykırılık görmemiştir. Bir başka kararda da Yargıtay, karısının bilgisi dışında eve ses tertibatı yerleştirerek karısını izleyen ve bu yolla delil elde eden kocanın, bu eyleminin hukuka aykırı olmadığı; çünkü, evlilik birliğinin getirdiği sadakat ve özen yükümlülüğünün, özel hayattan daha önce geldiğini ifade etmiştir. Buna karşılık Yargıtay, kendisine basın yoluyla hakaret edildiği iddiasıyla bir tazminat davası açan davacının dayandığı ses

kayıtlarının, hukuka aykırı yollarla elde edildiği gerekçesiyle davayı reddetmiş; yani hukuka aykırı yolla elde edilen ses kayıtlarını delil olarak dikkate almamıştır.

Bu kural uygulanırken, gösterilen delilin uyuşmazlık konusu olan vakıa/vakıalarla sınırlı olması gerektiği; delilin hukuka aykırı bir şekilde (yöntemle) elde edilmiş delil olmaması gerektiği; delilin hukuka aykırı olarak elde edilmiş bir delil olmadığının belirlenmesinde mahkemenin dürüstlük kuralına (m. 29) başvurabileceği, kişilik haklarının çiğnenmesi sonucu veya özel hayata müdahale ile elde edilen delilin hukuka aykırı yolla elde edilen delil olarak kabul edilmesi gerektiği; mahkemenin hukuka aykırı yolla elde edildiği kanısına vararak değerlendirmediği delili neden bu şekilde nitelendirdiğini, hükmünün gerekçesinde açıklaması gerektiği; Anayasanın 38, VI ve HMK m. 189, 2 hükümlerinden anlaşılır.

C) DELİL ÇEŞİTLERİ

Deliller, kesin ve takdirî deliller olmak üzere ikiye ayrılır:

I – KESİN DELİLLER

Kesin deliller; ikrar (m. 188), kesin hüküm (m. 303), senet (m. 199 vd.) ve yemin (m. 225 vd.) olmak üzere dört tanedir.

Kanunda unsurları, başvurulması usulü ve sonuçları ayrıntılı olarak düzenlenen delillere kesin delil denilmesinin nedeni, bu delillerin hâkimi bağlayıcı nitelikte olmalarıdır. Hâkim, kesin delillerden biri ile doğrulanan bir vakıayı, ispat edilmiş (doğru) olarak kabul etmek zorundadır; yani, hâkimin bu delilleri takdir yetkisi yoktur. Ancak, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda, hâkim, kural olarak, kesin deliller ile dahi bağlı değildir; örneğin, soybağına ilişkin davalarda hâkim resen araştırma yetkisine sahiptir ve delilleri serbestçe takdir eder (TMK m. 284/1)[2].

Bu gibi istisnalar dışında, özellikle taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalarda hâkim, kesin delillerle bağlıdır. Bundan başka, belli tutardan (sınırdan) yukarı hukukî işlemler (m. 200, 1) ve senede karşı olan iddialar (m. 201) kural olarak, tanıkla ispat edilemez; yalnız kesin delil ile ispat edilebilir.

Az önce de belirtildiği gibi, bu delillere kesin delil denilmesinin nedeni, bu delillerin hâkimi bağlayıcı nitelikte olmasıdır. Hâkim, kesin delillerden biri ile ispat edilen bir vakıayı, ispat edilmiş (doğru) olarak kabul etmek zorundadır; yani, hâkimin kesin delilleri takdir yetkisi yoktur.

Buna göre, kesin deliller terimini, takdirî deliller teriminin karşıtı olarak kullanıyoruz.

---

[2] Boşanma davalarında vakıalar bakımından taraflarca getirilme ilkesi geçerliyken; hâkim delilleri serbestçe takdir eder; bu davalarda yemin teklif edilemez; ikrar hâkimi bağlamaz (TMK m. 184; karş. TMK 166, III).

Kesin delillere kanunî deliller de denilmektedir[3]. "**Kanunî delil**" terimi, ilk bakışta yanlış anlaşılmaya elverişli olduğundan, "kesin delil" terimini kullanmayı tercih ediyoruz.

Kesin delillerin hukukumuzda önemi çok büyüktür. Çünkü, belli parasal tutardan (sınırdan) yukarı değer veya miktara ilişkin hukukî işlemler (m. 200) ve senede karşı olan iddialar (m. 202), kural olarak yalnız kesin delillerle ispat edilebilir (tanıkla ispat edilemez).

Yukarıda da belirtildiği üzere, kesin deliller dört tanedir: 1) ikrar (m. 188), 2) senet (m. 199 vd.), 3) yemin (m. 225 vd.) ve 4) kesin hüküm (m. 303).

Burada ilk üç kesin delil incelenecek, kesin hükmün kesin delil teşkil etmesi ise, ileride kesin hüküm bölümünde görülecektir[4].

II – TAKDİRÎ DELİLLER

Takdirî deliller; tanık (m. 240 vd.), bilirkişi (m. 266 vd.), keşif (m. 288 vd.) ve kanunda düzenlenmemiş diğer delillerdir (m. 192). HMK m. 293'te düzenlenmiş bulunan uzman görüşü de takdirî delil olarak değerlendirilebilir.

Kural olarak (istisnalar dışında) hukukî işlemler hakkında başvurulamayan, hukukî fiillerin ispatında başvurulan bu delillere takdirî delil denilmesinin nedeni, hâkimin bu delilleri serbestçe takdir (değerlendirme) yetkisine sahip olmasıdır (m. 198; 282). Yani hâkim, (kesin delillerin aksine) kanunda belirtilen istisnalar dışında, kural olarak, bu delilleri serbestçe takdir eder (değerlendirir). Bu delillerden önce kesin deliller incelenecek, arkasından takdiri delillerle ilgili açıklamalar yapılacaktır.

---

3 Nitekim, ispat hakkını düzenleyen m. 189'un 3. fıkrası hakkındaki hükümet gerekçesinde, "mevcut uygulama ve öğretideki görüş birliğinden hareketle, senetle ispat zorunluluğunun temel dayanağı olan kanuni delil sistemi esası muhafaza edilmiştir" denilmektedir.

4 Bkz. aşa. § 62, 63.

§ 27. İKRAR

A) İKRARIN NİTELİĞİ ve KONUSU

İkrar[1] bir tarafın, diğer tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu bildirmesidir. Davalı davacının ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebileceği gibi, davacı da davalının ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebilir.

Bir tarafın (kendi lehine) ileri sürdüğü vakıaların doğru olduğunu bildirmesi, ikrar değildir. İkrardan söz edilebilmesi için, bir tarafın (lehine ikrar yapılacak tarafın) bir vakıa ileri sürmüş olması, diğer tarafın da bu vakıanın doğru olduğunu bildirmesi gerekir. Örneğin, davacı davalıya beş bin lira ödünç verdiğini iddia eder, davalı da bu parayı (davacıdan) ödünç olarak aldığını bildirirse, ödünç para verilmiş olduğu vakıasını ikrar etmiş olur.

İkrar, bunu yapan tarafın tek taraflı açık bir irade beyanı ile olur.

Susma (sükût) **ikrar sayılmaz**. Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır (bkz. m. 171, 2; 220; 229 gibi).

İkrarın konusu, ancak karşı tarafın ileri sürdüğü **vakıalar** olabilir. Karşı tarafın ileri sürdüğü hukukî sebepler, ikrara konu teşkil etmez.

Sadece tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları maddî vakıalar ikrara konu teşkil edebilir. Ancak, herkesin kullandığı ve anlamı herkesçe bilinen hukukî terimler, bunların dayanağı olan vakıaları da kapsamak üzere ikrar olunabilir; örneğin, bir tarafın aralarında kira, satış, mülkiyet, vekâlet gibi bir sözleşmenin varlığı iddiasını diğer taraf ikrar edebilir.

İkrar, tek tek vakıalar hakkında olur; ikrar, talep sonucunun kabulünden farklıdır. Bir tarafın talep sonucunun diğer tarafça kabul edilmesi, davayı sona erdiren bir taraf işlemi olup, (davayı) **kabul** ismini alır (m. 308). Kabulde, karşı tarafın ileri sürdüğü vakıalara değil, onlardan çıkardığı talep sonucuna rıza gösterilmektedir.

İkrarda ise, talep sonucunun doğruluğu (haklılığı) değil, sadece ileri sürülen şu veya bu vakıanın doğru olduğu bildirilmektedir. Kabul ile, kabul edilen miktar hakkında dava sona erdiği halde, ikrarda sadece ikrar edilen vakıa doğru olarak kabul edilir ve diğer vakıalarla ilgili tahkikata devam olunur.

Her iki taraf da aleyhine olan bir vakıanın doğruluğunu bildirebilirken; kabul, yalnızca davalı tarafça gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

Bir vakıayı ikrar için, vekilin özel yetkiye ihtiyacı yokken, kabul bakımından vekilin vekâletnamesinde bu konuda özel yetkisinin bulunması gerekir (m. 74).

İkrar başlıklı m. 188, 1'de "tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı gerekmez" hükmü

---

[1] Bkz. Taylan Özgür Kiraz, Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Ankara 2013.

yer almaktadır. Bu hükümle, ikrarla doğrulanan bir vakıa için başka bir delile ihtiyaç olmadığı, ikrarın kesin delil gücünde bir beyan olduğu anlatılmaktadır.

B) İKRARIN YAPILIŞ ŞEKLİ

İkrar, **yapıldığı yere göre** ikiye ayrılır. Yani ikrar, ya mahkeme dışında veya mahkeme önünde yapılır:

I – MAHKEME DIŞI İKRAR

Taraf, mahkeme dışında ikrarda bulunabilir; örneğin, karşı tarafa yazdığı bir mektupta veya başka kişiler (tanıklar) önünde, karşı tarafın iddia ettiği bir vakıayı ikrar edebilir. Mahkeme dışı ikrar, kesin bir delil değildir. Hâkim, mahkeme dışı ikrarı doğrulayacak (teyit edecek) delilin veya belirtinin (emarenin) bulunması halinde, bu ikrara dayanarak hüküm verebilir. Buna göre, mahkeme dışı ikrar bir **takdirî delil**dir ve bununla ancak takdirî delillerle (örneğin tanıkla) ispat edilebilen hususlar ispat edilebilir. Bu bakımdan, kesin delille ispatı gereken bir hukukî işlemin varlığı, mahkeme dışı ikrarla ispat edilemez. Kuşkusuz mahkeme dışı ikrar, bir belge ile ispat edilirse, kesin delil hükmünde olur.

Yargıtay kararlarına göre, savcılıkta, haciz sırasında veya polis önünde yapılan ikrar, mahkeme dışı ikrardır; o nedenle buradaki ikrarlar da ancak takdirî delil olarak kabul edilir.

Buna karşılık, az sonra incelenecek olan mahkeme içi ikrar, kesin delildir. Esasen, bundan sonraki açıklamalar sadece mahkeme içi ikrar hakkındadır.

II – MAHKEME İÇİ İKRAR

Mahkemeye karşı yapılan (mahkemeye yönelik) ikrara **mahkeme içi ikrar** (adlî ikrar) denir. İkrar, bunu yapan tarafın (mahkemeye karşı) tek taraflı açık bir irade beyanı ile olur. İkrarın karşı tarafça kabulü gerekli değildir; bu nedenle, karşı tarafın yokluğunda da yapılabilir. Mahkeme içi ikrar, mahkeme önünde sözlü olarak yapılabilir (m. 188, 1). Tarafın ikrarı tutanağa yazılır; ikrar eden tarafın önünde okunarak imza ettirilir (m. 154, 3/ç). Bu husus, ikrar için geçerlilik şartıdır. Taraf, sözlü ikrarda bulunabilmenin yanı sıra, bir dilekçe veya dava dosyasına girmiş beyan ile de bir vakıayı ikrar edebilir. Yetkisiz veya görevsiz mahkemede yapılan ikrar da geçerlidir. Bir davada yapılan (mahkeme içi) ikrar, başka bir davada da geçerlidir; yani kesin delil teşkil eder. Ancak, sulh müzakeresi (m. 313 vd.) sırasında yapılan ikrar geçerli değildir (m. 188, 3).

III – İKRARDAN DÖNME

İkrar eden, kural olarak ondan dönemez (rücu edemez, cayamaz); yani, ikrarı ile bağlıdır. Yalnız, ikrar eden, ikrarın maddî bir hatadan (TBK m. 30) doğduğunu ispat ederek ikrarından dönebilir (m. 188, 2).

Hukukî bir hata (yani, ikrarın hukukî sonucunu bilmede hata) ikrardan dönme için yeterli değildir.

İkrardan ancak maddî hatadan doğduğu gerekçesiyle dönülebilir. Ancak, maddî hata halinde de, ikrar eden ikrardan dönebilmek için iki hususu birlikte ispat etmek durumundadır: 1) İkrar edilen vakıanın gerçeğe uygun olmadığı (gerçeğe aykırı olduğu); 2) İkrarın maddî bir hata sonucunda yapıldığı. Bu nedenle taraf, gerçeğe uygun olmayan bir vakıayı bilerek ikrar etmiş ise bundan dönemez.

C) İKRARIN ETKİSİ

İkrar olunan vakıalar (hususlar), çekişmeli sayılmaz ve ispatı gerekmez (m. 172, 2;188, 1). Yani mahkeme içi ikrar, bunu yapan (ikrar eden) taraf aleyhine **kesin delil** teşkil eder.

İkrar, bir kesin delildir. Yani, lehine ikrar yapılan taraf, ikrar edilen vakıa için artık delil göstermek ve o vakıanın doğruluğunu ispat etmek zorunda değildir. Hâkim de ikrar ile bağlıdır; ikrarın doğru olup olmadığı hakkında delil dinleyemez, bu hususta delil gösterilmesini isteyemez; ikrar edilmiş olan vakıanın doğru olduğunu kabul etmek zorundadır.

Sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar tarafları bağlamaz (m. 188, 3; ayrıca bkz. Arabuluculuk Yön. m. 7, 1/c).

Yukarıdaki açıklamalar, taraflarca getirilme ilkesinin (m. 25) uygulandığı davalar içindir. Buna karşılık, kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda, hâkim ikrar ile kural olarak bağlı değildir; yani bu halde ikrar bir takdirî delildir. Ancak, TMK m. 166, III hükmü ile bu kurala istisna getirildiği gibi[2], evlenmenin feshi davasında, davalı kadının TMK m. 149, II anlamındaki önemli bir niteliğin kendisinde bulunmadığını ikrar etmesi, TMK m. 184, III'de "hâkimi bağlamaz" diye tarif edilen ikrarlardan değildir.

D) İKRARIN ÇEŞİTLERİ VE BÖLÜNMESİ

İkrar, ikrar beyanının **içeriğine göre üçe ayrılır**. Bu ayrım, özellikle ikrarın bölünüp bölünememesi bakımından önemlidir.

Az sonra görüleceği gibi, bazı hallerde (özellikle vasıflı ikrarda) ikrar bölünemez. İkrarın bölünememesi, sadece mahkeme içi ikrar hakkında olup, mahkeme dışı ikrarda söz konusu değildir.

I – BASİT İKRAR

Karşı tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu kayıtsız şartsız bildirmeye basit ikrar (adî ikrar) denir. Örneğin davacı davalıya on bin lira ödünç verdiğini bildirir ve davalı da "evet bu parayı ödünç olarak aldım" derse, bu bir basit ikrardır.

---

[2] Bu kuralın Anayasaya aykırı olmadığı hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 15.05.2008 gün ve 26/105 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 101-103.

Basit ikrarın bölünmesi söz konusu olmaz. Yani, yukarıdaki örnekte ikrar edilmiş olan ödünç para verme vakıası, çekişmeli sayılmaz (m. 188, 1); kesin delille ispat edilmiş olur.

II – NİTELİKLİ (VASIFLI) İKRAR

Nitelikli (vasıflı) ikrarda, ikrar eden, karşı tarafın ileri sürdüğü vakıanın doğru olduğunu bildirir; ancak, bunun hukukî niteliğinin iddia edildiğinden başka olduğunu ifade eder. Yukarıdaki on bin liralık örnekte, davalı, davacıdan on bin lira aldığını ikrar eder, fakat bu parayı ödünç (karz) olarak değil de bağışlama (hibe) olarak aldığını bildirirse, davalının ikrarına vasıflı ikrar denir. Burada davacının ileri sürdüğü vakıa ikrar edilmekte, fakat onun iddia ettiği hukukî nitelik (ödünç) inkâr edilmektedir. Bu nedenle, nitelikli ikrara gerekçeli inkâr da denir.

Acaba, burada davalı on bin lirayı aldığını ikrar etti diye, davalının bu parayı ödünç olarak değil bağışlama olarak aldığını mı ispat etmesi, yoksa davacının bu parayı ödünç olarak verdiğini mi ispat etmesi gerekir? Davalı parayı bağışlama olarak aldığını ispat etsin denirse, onun ikrarı bölünmüş olur; aksi halde (davacı ödünç verdiğini ispat etsin denirse) ikrar bölünmemiş olur.

Hukukumuzda nitelikli (vasıflı) ikrarın bölünemeyeceği, yani, vasıflı ikrarın ikrar eden aleyhine delil teşkil etmeyeceği, aksine o vakıayı ileri sürenin onu ispat etmesi gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. Yani, vasıflı ikrarda ispat yükü (m. 190; TMK m. 6), vakıayı ileri süren tarafta olup o vakıayı vasıflı olarak ikrar eden (gerekçeli olarak inkâr eden) tarafta değildir. Yargıtay da aynı görüştedir. Örneğin;

Yukarıda ödünç-bağışlama örneğinde, davacı, davalıya ödünç (para) verdiğini ispat etmelidir; yani, ispat yükü davacıdadır.

Davacı, otomobilini davalıya emanet olarak (TBK m. 561 vd.) verdiğini iddia etmiş, davalı ise otomobili emanet olarak değil rehin olarak aldığını bildirmiştir; davacının emanet (vedia) sözleşmesini ispat etmesi gerekir.

Davacı, davalıdan ödünç aldığı on bin liranın teminatı olmak üzere davalıya ineğini rehin verdiğini iddia etmiş, davalı ise bu ineği on bin liraya davacıdan satın aldığını bildirmiştir; davacının ineği rehin olarak verdiğini ispat etmesi gerekir.

III – BİLEŞİK İKRAR

Bileşik (mürekkep veya karmaşık) ikrarda bulunan taraf, diğer tarafın ileri sürdüğü vakıayı ikrar eder; fakat ikrarına, bu vakıadan çıkan hukukî sonucu hükümden düşüren (ortadan kaldıran) ve bu (ikrar edilen) vakıanın doğumu ile ilgili bulunmayan başka bir vakıa (veya vakıalar) ekler. Örneğin davalı "davacının bana verdiği on bin lirayı ödünç olarak aldım, fakat bu parayı kendisine ödedim" diyebilir. Yahut davalı, "bu on bin lirayı davacıdan ödünç olarak aldım, fakat ben de davacıdan on bin lira alacaklıyım, bu alacağım ile borcumu takas ediyorum" diyebilir.

Her iki örnekte de davalı, ödünç verme vakıasını tam olarak ikrar etmektedir; ancak ikrarına, bundan (ikrardan) çıkan hukukî sonucu hükümden düşüren ve ödünç vermenin (karz sözleşmesinin) doğumu ile ilgili olmayan bir vakıa (ödeme veya karşılık bir alacağın varlığı vakıasını) eklemektedir.

Bileşik ikrar da (kendi arasında) bağlantılı ve bağlantısız bileşik ikrar olmak üzere ikiye ayrılabilir:

1) Bağlantılı Bileşik İkrar

Bağlantılı bileşik ikrarda, ikrar edenin ikrarına eklediği vakıa ile ikrar edilen vakıa arasında doğal bir bağlantı vardır; ikrara eklenen vakıa, ikrar olunan vakıanın doğal bir sonucudur. Yukarıdaki, "ödünç aldım, fakat ödedim" örneğinde olduğu gibi.

Bağlantılı bileşik ikrarın bölünüp bölünemeyeceği tartışmalıdır:

Doktrinde bağlantılı bileşik ikrarın da (nitelikli ikrar gibi) bölünemeyeceği görüşünü savunanlar olduğu gibi Yargıtayın da bu yönde kararları vardır. Buna göre, "ödünç aldım, fakat ödedim" örneğinde, davacı on bin lirayı davalıya ödünç olarak verdiğini ispat etmelidir; yoksa davalının, bu parayı ödemiş olduğunu ispat etmesi gerekmez. Bu görüşe göre, bağlantılı bileşik ikrarın bölünememesi gerekir. Çünkü, karşı görüşün (Yargıtayın bazı kararlarında benimsenen görüşün) kabulü, ikrar eden tarafı, iddia edilen vakıayı inkâra sevk eder. O taraf, inkâr etmeyip, dürüst davranarak, borcun doğduğunu (ödünç aldığını) ve fakat bunu ödediğini iddia etmekte ise, onun ikrarının karşı tarafın işine gelen kısmını (ödünç alma vakıasını) ikrar edilmiş sayıp, diğer kısmını (ödeme vakıasını) kendisine ispat ettirmenin mantıki bir çözüm biçimi olmaz.

Doktrinde ve uygulamada bağlantılı bileşik ikrarın bölünmesi gerektiği görüşünün ağırlıklı olduğu söylenebilir. Bu görüşe göre, bağlantılı bileşik ikrarın bölünmesi gerekir. Çünkü ikrarla çekişmeli olmaktan çıkmış bir vakıanın ispatına ihtiyaç yoktur. İkrar edenin dürüst davranmış olması doğruyu söyleme ödevinin gereğidir. Davalının "ödünç aldım, fakat ödedim" demesinden sonra, davacının verdiğini ispat etmesinin anlamı olmaz; davacının ödüncü (parayı) davalıya verdiği hususu taraflar arasında çekişmeli olmaktan çıkmıştır. Artık çekişmeli olan husus davalının ödediği iddiasıdır; bunu da davalı ispat etmelidir. Kanımızca, bu gerekçe daha inandırıcıdır. Bu nedenle, bağlantılı bileşik ikrarın bölünmesi gerektiği kanısındayız.

Bağlantılı bileşik ikrar ve bunun bölünememesi, karşı (ispat yükü kendine düşen) tarafın (ödünç verme ve ödeme örneğinde davacının) o vakıayı (örnekte ödünç vermeyi) ispat etmesinden önce söz konusu olur. Karşı taraf (örnekte davacı) ödünç verme vakıasını usulüne uygun biçimde (örneğin senetle) ispat ettikten sonra, davalının "ödünç aldım, fakat ödedim" demesi, artık bir ikrar değildir. Çünkü, ödünç verme vakıası başka bir kesin delille (örnekte, senetle) ispat edilmiştir; bu nedenle, ödünç verme vakıasının ikrar edilmeye ihtiyacı yoktur. Bu halde, davalının ödünç aldığı parayı ödediğini ispat etmesi gerekir. Ancak, bunun nedeni, davalının ikrarının bölünmesi değil, m. 190 ve TMK m. 6'da düzenlenen genel kuraldır. Davacı ödünç verdi-

ğini ispat ettiğine göre, bunun ödendiğini ispat yükü (ödeme iddiasında bulunan) davalıya düşer.

2) Bağlantısız Bileşik İkrar

Bağlantısız bileşik ikrarda, ikrar edenin ikrarına eklediği vakıa ile ikrar edilen vakıa arasında hiçbir bağlantı yoktur; yani ikinci (ikrara eklenen) vakıa, ikrar edilen vakıa olmadan da mevcuttur. Örneğin, davalının "dava konusu on bin lirayı davacıdan ödünç olarak aldım, fakat ben de davacıdan on bin lira alacaklıyım, bu alacağım ile borcumu takas ediyorum" şeklindeki beyanı, bağlantısız bileşik ikrardır. Çünkü, davalının karşılık alacağı ile, davacının alacağı arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Doktrinde çoğunluk, bağlantısız bileşik ikrarın bölünebileceği görüşündedir. Kanımızca da, bağlantısız bileşik ikrar bölünebilmelidir; çünkü:

Burada ikrar edenin ikrarına eklediği vakıanın, diğer tarafın iddia ettiği vakıa ile bir ilgisi (bağlantısı) yoktur. İkrara eklenen vakıa, tamamen diğer tarafın savunmasının dayandığı bir vakıadır ve bunu da o taraf ispat etmelidir (m. 190; TMK m. 6). Aksi halde, diğer taraf olumsuz bir durumu ispat zorunda bırakılmış olur; bu ise güçtür.

Yukarıdaki takas örneğinde, davalının ikrarı bölünemez denirse, alacağının varlığı davalı tarafından ikrar edilmiş olan davacı, davalının ileri sürdüğü karşı alacağın mevcut olmadığını ispat etmek zorunda olacak, ispat edemezse yeni baştan davalının ikrar etmiş olduğu alacağını ispat edecektir. Davalının bir karşı alacağı gerçekten yok ise, davacı bunun yok olduğunu nasıl ispat edecektir? İlk önce davalı karşı alacağının varlığını ispat etmelidir ki, bundan sonra davacı buna karşı koyabilsin!

§ 28. SENET VE BELGE

A) KAVRAM

Senet, bir kimsenin vücuda getirdiği (veya getirttiği) ve kendi aleyhinde delil teşkil eden **yazılı belge**dir.

HMK, bir üst kavram olarak, "belge"yi, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plân, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları[1] (m. 199) olarak tanımlamıştır. HMK m. 199'un hükümet gerekçesinde, "...Belge konusunda sınırlayıcı bir tanım yapmak yerine, belgenin ne olduğunu belirten bir çerçeve çizilmiştir. Maddedeki belge tanımında, iki unsur önemlidir. Belge bir bilgi taşıyıcısıdır. Ancak, her bilgi taşıyıcısı değil, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli olanlar yargılama hukuku anlamında belge sayılmıştır. Tüm belgeler bu sayılanlardan ibaret değildir" ifadelerine yer verilmiştir.

Belge kavramına dahil olan verilerin ortak özelliği ispatı gereken vakıa/vakıalar hakkında bir bilgi taşıyıcısı olmasıdır. Ancak, her bilgi taşıyıcısı değil, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli olanlar, yargılama hukuku anlamında belge sayılmıştır. Tanımda belge sayılacak bilgi taşıyıcılarının bir kısmı örnek olarak sayılmış olmakla beraber, belge kavramına giren veriler bu sayılanlardan ibaret değildir.

Kanun (m. 199) belge kavramını, senet kavramı yerine kullanmamıştır. Aşağıda görüleceği üzere, HUMK'ndaki senet kavramı ve ispat gücü, HMK'nda da aynen korunmuştur. Bu anlamda, senetle ispat kuralları, belge ile ispat kuralları haline gelmemiştir.

Belgenin ispat gücü, onun senet olup olmamasına göre değişir; buna göre belge, kesin delil olabileceği gibi hâkimin takdirinde rol oynayan (takdirini etkileyen) bir bilgi gücünde de olabilir.

Senet, yazılı bir belgede açıklanan irade beyanıdır. Ancak, senedi vücuda getirenin (düzenleyenin) onu kendi aleyhine delil teşkil etmek iradesiyle düzenlemiş/düzenletmiş olması şart değildir. Çünkü, senedi düzenleyenin onun kendi aleyhine delil teşkil etmesini düşünmediği hallerde de, yazılı belge senet sayılır; örneğin, bir tarafın diğer tarafa yazdığı bir mektubun "tesadüfî senet" olarak değerlendirilmesi gibi.

Senet genel olarak, kâğıt üzerine yazılır; ancak, kâğıttan başka malzeme (örneğin kumaş, tahta, metal, taş vs.) üzerine yazılan yazılar da senet olabilir.

Aşağıda, senet çeşitleri incelenirken görüleceği gibi, senedin onu düzenleyenin (vücuda getirenin veya getirtenin), yani aleyhine delil teşkil edecek

---

[1] Bkz. Bilgi Edinme Hakkı K. m. 3

kişinin imzasını, mührünü veya el ile yapılmış bir işaretini taşıması gerekir. Ayrıca, usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler[2] de senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar (m. 205, 2-3).

Medenî usul hukukunda senet bir (kesin) delil, yani ispat aracıdır. Bunu, bir hukukî işlemin **geçerlilik şartı olan yazılı şekil** (TBK m. 12 vd.) **ile karıştırmamak gerekir**.

Bir hukukî işlemin, örneğin, sözleşmelerin geçerli olması için kural olarak yazılı şekilde yapılması şart değildir. Bu anlamda örneğin, ödünç (karz) sözleşmesi yazılı şekle tâbi değildir. Ancak, bu hukukî işlemin ispatı için senet düzenlenebilir. Senet düzenlenmemişse, hukukî işlem (örnekte, ödünç sözleşmesi) gene geçerlidir; ancak, bunun varlığını ispat etmek zordur. Ödünç sözleşmesinin konusu (ödünç verilen para) m. 200'de belirtilen parasal sınırdan fazla ise, ancak senet (veya diğer kesin delillerle) ispat edilebilir; ispat edilemezse, dava, ödünç sözleşmesinin geçersiz olduğundan (mevcut olmadığından) dolayı değil, ispat edilemediğinden dolayı reddedilir.

Buna karşılık, şekle tâbi bir hukukî işlem, kanunun öngördüğü yazılı şekilde yapılmamışsa geçerli değildir (çünkü, geçerlilik şartı yerine getirilmemiştir); böyle (kanunun öngördüğü yazılı şekilde yapılmamış olan) bir hukukî işlemin varlığı, diğer kesin deliller (ikrar ve yemin) ile de ispat edilemez; örneğin;

Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz (TBK m. 583). Bu hükme göre, Kanun (m. 203, 1/a) gereğince tanık dinlenmesi caiz olan eşler arasında yapılmış olsa bile, yazılı şekilde yapılmadıkça kefalet geçerli değildir. Geçerli olmayan bir sözleşmenin varlığı ise hiçbir şekilde ispatlanamaz.

Senet, en önemli kesin delildir. Çünkü, hukukumuzda kesin delil (senet) ile ispatı gereken (zorunlu olan) hukukî işlemlerin uygulama alanı çok geniştir (m. 220; 202); senetle ispat zorunluluğu ileride incelenecektir.

Gerçi kesin delil ile ispat zorunluluğu olan hallerde, senet dışındaki (diğer) kesin delillerle de ispat mümkündür. Ancak ikrar ve yemin delili, karşı tarafın iradesine (arzusuna) bağlı olduğundan ve kesin hüküm delili ise, aslında genellikle başka kesin delillere dayandığından, hukukumuzda senet, en önemli kesin delildir. Bunun nedeni, senet delilinin emin ve doğru bir ispat aracı olmasıdır.

B) SENET ÇEŞİTLERİ

Senetler, düzenleyen kişilere ve ispat güçlerine göre, **adî senetler** ve **resmî senetler** olmak üzere ikiye ayrılır:

---

2 Bkz. Mine Erturgut, Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 2004; Mustafa Göksu, Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, Ankara 2011; Ayşe Ece Acar, Medenî Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği, İstanbul 2013.

I – ADÎ SENETLER

1) Kavram ve İçeriği

Resmî bir makam veya memurun katılımı olmaksızın düzenlenen senetlere adî (özel) senetler denir. Bu nedenle, adî senetlere, resmî olmayan senetler de denir.

Adî senet, genellikle taraflarca düzenlenir. Fakat taraflar, senedi bir başkasına yazdırarak altını imza etmekle de yetinebilirler.

Usulüne uygun **güvenli elektronik imza**[3] ile oluşturulan elektronik veriler de, adî senet hükmündedir (m. 205, 2). Bu hükmün gerekçesinde belirtildiği üzere; "Elektronik imzalı belgelerden sadece, güvenli elektronik imza ile oluşturulanlar adî senet kuvvetinde sayılmış, diğer elektronik belgeler ya da güvenli elektronik imza dışında imzalanarak oluşturulmuş elektronik belgeler adî senet olarak kabul edilmemiştir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler için doğrudan adî senettir ifadesi yerine, adî senet hükmündedir ifadesi tercih edilmiştir. Zira, güvenli elektronik imza, dar ve teknik anlamda adî senet değildir. Bu tür belgelerin oluşturulması ve ibrazı adî senetlerden farklılık gösterdiği gibi, inkârı hâlinde uygulanacak hükümler de farklıdır. Bu sebeple, adî senetle aynı ispat gücüne sahip olmakla birlikte, doğrudan adî senet olarak kabulü doğru görülmemiştir. Nitekim, adî senetlerin inkârı ile elektronik belgelerin inkârı hâlinde uygulanacak usul ayrı maddelerde düzenlenmiştir. Elektronik imzalı belgelerin güvenli elektronik imza ile oluşturulup oluşturulmadığını hâkim kendiliğinden inceler. Zira, bir elektronik belge, ancak güvenli elektronik imza ile oluşturulması hâlinde adî senet kuvvetinde delil olma niteliğine sahiptir".

Senette (senedin içeriğinde) nelerin bulunması ve senedin şeklinin nasıl olması gerektiği, HMK'nda tam olarak belirtilmemiş ise de, senet metninin, belgelendirdiği husus (hukukî işlem) hakkında tam bir bilgiyi içermesi ve senedin altının, senet aleyhine delil teşkil edecek kimse tarafından imza edilmesi veya usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulması (m. 205) gerekir (TBK m. 14-15). Buna göre, imzalı bir mektup da senet olabilir.

Alacaklı, kendi lehine olan bir senet üzerine alacağını tamamen veya kısmen aldığını yazıp (veya yazdırıp) bu beyanını imza ederse, bu beyan alacaklı aleyhine senet (delil) teşkil eder (bkz. TBK m. 103).

2) Adî Senetlerin İspat Gücü

a) Adî Senet Kesin Delildir

Yukarıda da belirtildiği gibi, senet kesin delildir. Ancak, bir senedin kesin delil teşkil edebilmesi, her şeyden önce onun doğru olmasına (sahte olmamasına) bağlıdır.

Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkâr edenden sadır olduğu (çıktığı) kabul edilen adî senetler, kesin delil sayılır. Başka bir deyiş-

---

[3] Bkz. Elektronik İmza K. m. 4 vd.

le, bir adî senet, senet altında imzası bulunan (senedi düzenleyen, senet kendisine karşı delil teşkil edecek olan) kimse tarafından ikrar edilirse, o senet kesin delil teşkil eder (m. 205, 1).

Taraflardan biri, kendisi tarafından düzenlendiği iddia edilen belgedeki yazı veya imzayı inkâr etmek isterse, sahtelik iddiasında bulunmalıdır; aksi halde belge, aleyhine delil olarak kullanılır (m. 208, 1). Bir belgenin sahteliği iddia edildiğinde, belgenin mahkemeye verildiği tarih yazılıp mühürlenerek, saklanması için mahkemece gerekli tedbirler alınır (m. 208, 2).

Adî senedin sahteliği (yazı veya imza inkârı), aynı mahkemede sahtelik iddiası (ön sorun) olarak ileri sürülebilir (m. 163) veya bu konuda ayrı bir sahtelik davası açılabilir (m. 208, 2).

b) Sahtelik İddiası

Belge altındaki imzanın kendisine ait olduğu ileri sürülen taraf (örneğin davalı), senetteki yazı veya imzayı yahut güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi (m. 205, 2); görülmekte olan davada (aynı mahkemede) inkâr ederse (ön sorun olarak sahtelik iddiasında bulunursa; m. 208 veya menfî tespit davası niteliğinde olan bir sahtelik davası açarsa ya da adî senette sahtecilik suçunun işlendiği iddiası ile ceza davası açılırsa) bu konuda bir karar verilinceye (senetteki imzanın veya yazının bu kimseye, örnekte davalıya ait olduğu anlaşılıncaya) kadar, senet herhangi bir işleme esas alınamaz ve delil olarak kullanılamaz (m. 209, 1; karş. m. 209, 2). Bu halde mahkemenin araştırma yaparak, senetteki imzanın gerçekten davalıya ait olup olmadığını tespit etmesi gerekir. Madde 209'da ifade edilen sahtelik iddiası (veya sahtelik davası) adî senette ifade edilen borcun doğumunu engelleyen tüm iddiaları kapsayacak biçimde anlaşılmamalıdır. Bu madde hükmünün kötüniyetli borçlular tarafından haksız kullanılmasına izin verilmemesi gerekir.

Bir icra takibine dayanak olan adî senet hakkında sahtelik iddiasında bulunulmasının sonuçları ise aynı değildir. Şöyle ki: HMK m. 209, 1 hükmündeki "adî bir senetteki imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas alınamaz" hükmü, icra takipleri hakkında uygulanmaz. Çünkü, İİK, imzaya itirazı ayrıca düzenlemiştir (bkz. İİK m. 68/a; 72; 170). İİK'nun bu hükümleri, HMK m. 209, 1 hükmüne oranla daha özel hüküm niteliğinde olduğundan HMK m. 209, 1 hükmü icra ve iflâs takiplerinde kendiliğinden uygulanmaz. Bu halde, adî bir senetteki imzanın sahte olduğundan bahisle açılan bir sahtelik davası İİK m. 72 anlamında menfî tespit davası olduğundan, icra takibi, ancak menfî tespit davasına bakan mahkeme tarafından İİK'nun 72. maddesine göre verilecek bir ihtiyatî tedbir kararı ile durdurulabilir. Yoksa mücerret adî senetteki imzanın sahte olduğundan bahisle açılmış olan bir sahtelik davası, m. 209, 1 hükmüne göre icra takibini kendiliğinden durdurmaz.

Senede (belgeye) dayanılarak verilmiş olan ihtiyatî tedbir, o senet hakkındaki sahtelik iddiasından etkilenmez ve gerektiğinde senet sahibi, haklarının korunması için yeni tedbirler talep edebilir (m. 209, 3).

c) Sahtelik Davası

Bir adî senedin kendisi tarafından düzenlendiği iddia edilen (örneğin senette borçlu gözüken) kişi, yukarıda incelendiği gibi, kendisine karşı adî senede dayanarak dava açılmasını bekleyebilir ve bu davada, senet altındaki imzayı inkâr etmekle (sahtelik iddiasında bulunmakla) yetinebilir.

Ancak, bir adî senedi düzenlediği iddia edilen kişi (borçlu), bu adî senede dayanarak dava açılmasını beklemeden, senetteki imzanın kendisine ait olmadığının (yani senedin sahte olduğunun) tespiti için ayrı bir sahtelik davası da açabilir (m. 106, 1; 208, 3). Bu sahtelik davası, hukukî niteliği bakımından bir menfî tespit davasıdır. Madde 208'in gerekçesinde, yazı veya imza inkârı (her iki husus) uygulamada **sahtelik iddiası** olarak adlandırılan durumu ifade etmektedir; açıklaması yapılmaktadır.

Açılmış bir davada adî senedin sahteliği ön sorun (m. 208, 3) şeklinde (m. 163 vd.) iddia edilmiş ve bu sahtelik iddiası incelenmekte ise, artık, adî senedin sahteliğinin tespiti için ayrı bir sahtelik davası açmakta hukukî yarar yoktur.

Şu halde, ayrı bir sahtelik davası, senedin sahteliğinin daha önce bir davada ileri sürülmemiş olması halinde açılabilir. Ancak, bu halde de, ayrı bir sahtelik davası açılmasında, kural olarak, hukukî yarar yoktur. Çünkü, borçlu kendisine karşı açılmış veya açılacak olan davada (örneğin alacak davasında), adî senetteki imzayı inkâr etmekle (senedin sahteliğini iddia etmekle) yetinebilir. Bir davada savunma olarak ileri sürülmesi mümkün olan bir husus ise, ayrı bir dava konusu yapılamaz.

Ancak, sahte bir adî senede dayanarak kendisine karşı icra takibi yapılan borçlunun, bu senedin sahteliğinin tespiti için sahtelik davası açmakta hukukî yararı olabilir; şöyle ki:

Borçlu, ödeme emrine itiraz ederken imzaya itirazını ayrıca ve açıkça bildirmeyi ihmal etmiş veya ödeme emrine hiç itiraz etmemişse, hakkındaki icra takibini ancak sahtelik davası açmakla durdurabilir ve önleyebilir. Bilindiği gibi, böyle bir sahtelik davası aynı zamanda İİK m. 72'de düzenlenmiş olan menfî tespit davasıdır.

Buradaki sahtelik davası (ve iddiası) da HMK m. 211 hükümlerine göre incelenir. Çünkü, sahtelik iddiası ve davasını düzenleyen HMK m. 211 vd. hükümleri hem adî senetler hem de resmî senetler içindir.

Bir belgenin sahteliği ayrı bir dava şeklinde de açılabilir. Sahtelik iddiası veya sahtelik davasında mahkeme, karşı tarafın açıklamalarını da dinler ve **aşağıdaki sıra** ile inceleme yaparak öncelikle karar verir:

aa) Hâkim, ilk önce yazı veya imzayı inkâr eden tarafı **isticvap** ederek (m. 169) tarafların gösterdikleri delillerle bir kanaat edinmeye çalışır; bu şekilde yeterli kanaat sahibi olursa, senedin kabulüne (sahtelik iddiasının reddine) veya reddine (sahtelik iddiasının kabulüne) karar verir (m. 211, 1/a/c. 1).

bb) Hâkim isticvapta, tarafların dinlenilmesi sonucunda yazı veya imzanın davalıya ait olup olmadığı hakkında yeterli kanaat edinemezse, mahkeme yazı veya imzayı inkâr eden kişiye, huzurda (önünde) **yazı yazdırıp imza**

attırır (istiktap). Bu yolla elde ettiği yazı ve imza ile inkâr edilen belgedeki **yazı ve imzayı karşılaştırır** ve değerlendirir. Hâkim, sahtelik konusunda başka bir incelemeye gerek duymadan karar verebilecek durumda ise, gerekçesini belirtmek suretiyle, belgenin sahteliği hakkında bir karar verir (m. 211, 1/a/c. 2). Yazı veya imza kendisine ait olduğu ileri sürülen taraf (örnekte davalı), isticvap hükümlerine göre usulüne uygun olarak çağrıldığı (m. 211, 1/a; 171) halde mahkemeye gelmezse, kendisine ait olduğu bildirilen senetteki imzayı ikrar etmiş sayılır; bu konu yukarıda incelendi[4].

cc) Hâkim, yukarıda belirtilen inceleme ve değerlendirmelerden kesin bir kanaate ulaşamazsa, **bilirkişi incelemesi** yaptırır. İnkâr edilen imza ile karşılaştırılacak imza arasında ilk bakışta görülebilecek derecede bir uygunluk ve benzerlik veya farklılık **yoksa** veya inkâr edilen imzanın taklit edilmesi kolay ise, hâkim, imza karşılaştırması için uzman bir bilirkişiye başvurur. Bilirkişi, imza uygulamasını (incelemesini), inkâr edilen imza ile bu imzayı inkâr eden tarafa (örnekte davalıya) ait olduğu muhakkak olan başka bir imzayı karşılaştırmak suretiyle yapar. Bilirkişi incelemesinden önce, varsa, o tarafa ait olan karşılaştırma yapmaya elverişli (tatbike medar) yazı ve imzalar ilgili yerlerden getirtilir (m. 211, 1/b/c. 3). Bilirkişi, bu yazı ve imzalarla, o mahkemede elde edilen yazı ve imzaları esas alarak inceleme yapar.

Güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş verinin inkârı halinde, hâkim tarafından veriyi inkâr eden taraf dinlendikten sonra bir kanata varılamamışsa bilirkişi incelemesine başvurulur (m. 210; 211, 1/b).

Yukarıdaki şekilde yapılacak incelemeler sonucunda hâkim, inkâr edilen imzanın inkâr eden tarafa (örnekte davalıya) ait olduğu kanısına varırsa, adî senedin kabulüne karar verir. Bu halde, adî senet o davada kesin delil olarak işlem görür.

Senedin (belgenin) sahte olmadığına dair verilen kararın kesinleşmesinden sonra, söz konusu senet hakkında ceza mahkemesinde de sahtelik iddiası dinlenmez (m. 214, 1). Yani, hukuk mahkemesinin kararı, (kesinleşmesi şartı ile) ceza mahkemesi bakımından da bağlayıcıdır (karş. TBK m. 74). Buna karşın, ceza mahkemesince belgeyi düzenleyen hakkında ceza verilmesine yer olmadığı ya da beraat kararı verilmiş olması, hukuk mahkemesinin belgenin sahteliğini incelemesini etkilemez (m. 214, 2).

Sahtelik iddiası sonunda haksız çıkan taraf **kötüniyetli** ise, bu sebeple ertelenen her bir duruşma için celse harcına[5] ve talep halinde bu sebeple diğer tarafın uğradığı zararları tazmin etmeye mahkûm olunur (m. 213, 1). Sahtelik iddiasından bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesinden önce vazgeçilirse, hâkim tazminattan indirim yapabileceği gibi tazminata hükmetmeyebilir (m. 213, 3).

Hâkim, adî senetteki imzanın, senette ismi yazılı olana (inkâr eden tarafa) ait olmadığı kanısına varırsa, adî senedin reddine karar verir. Bu halde, davada o adî senet yok sayılır (delil olarak değerlendirilemez). Bir senedin

---

4 Bkz. yuk. § 24.

5 Harçlar K. m. 12.

sahte olduğuna ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra, senedin altına sahte olduğu yazılarak senet iptal olunur (m. 212, 1/c.1).

3) Adî Senetlerin Üçüncü Kişiler Hakkında İspat Gücü

Buraya kadar görüldüğü şekilde imzası ikrar edilen veya mahkemece imzanın senette ismi yazılı olan kişiye ait olduğuna karar verilen adî senetteki tarih, imza eden (sahibi) ile halefleri hakkında geçerlidir; üçüncü (yani senette taraf olmayan) kişiler hakkında hüküm ifade etmez (m. 215, 1). Aynı sonuç belge hakkında da geçerlidir. Yani, bir kimsenin aleyhine delil olarak kullanılacak belgeler, o kimsenin halefleri aleyhine de delil olur; üçüncü kişiler aleyhine delil teşkil etmez.

II – RESMÎ SENETLER

1) Genel Bilgi

Resmî bir makam (organ) veya memurun katılması ile düzenlenen senetlere resmî senetler denir. Burada resmî senet terimi, **ispat şekli** (şartı) **olan resmî senet** anlamında kullanılmaktadır. Buna göre, resmî bir makam veya memurun senedin düzenlenmesine herhangi bir şekilde (yalnız imza ve tarihin onaylanması suretiyle de olsa) katılmış olması halinde, senet ispat hukuku anlamında bir resmî senettir.

Buna karşılık geçerlilik şartı olan resmî senet veya resmî şekil, ispat şeklinden başkadır; örneğin TMK m. 105; 205; 315; 374; 532; 545; 731; 856, II; TBK m. 237; 288; 612; Noterlik K. m. 89'da olduğu gibi. Bu anlamdaki resmî senet, az sonra incelenecek olan resen düzenlenmiş (düzenleme biçiminde yapılmış) olan senet demektir. Bu resmî senedin tümü resmî memur (organ) tarafından düzenlenir. Resmî şekle tâbi bir hukukî işlem için kendiliğinden bir senet (belge) düzenlenmezse, o işlem geçerli olmaz. Örneğin, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, noterlikçe düzenleme biçiminde yapılmadıkça geçerli olmaz (TBK m. 237; Noterlik K. m. 60, 3; 89).

Resmî şekle bağlı hukukî işlemlerin değiştirilmesi de, kural olarak aynı (resmî) şekilde yapılmalıdır; çünkü resmî şekil (o işlemler için), geçerlilik şartıdır.

Oysa usul hukukunda, senetle ispatı gereken (m. 200-201) bir hukukî işlemin ispatı için mutlaka resmî senet düzenlenmesi gerekmez. Bu hukukî işlem için adî senet düzenlenmekle yetinilebileceği gibi, daha güçlü bir delil elde etmek için de resmî senet düzenlenebilir. Ancak bazı hallerde ispat koşulu olarak resmî senet öngörülmüş olabilir. Örneğin, **imza atamayan**ların parmak izi (veya mühür, alet) kullanmak suretiyle yapacakları hukukî işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için, noter tarafından **düzenleme** şeklinde oluşturulması gerekir (m. 206, 1)

Geçerlilik şartı olarak resmî senet şeklinde yapılması gereken bir hukukî işlem, düzenleme biçiminde yapılmamış ise geçersizdir; fakat bu geçersiz şekil (belge), geçerlilik şartına tâbi olmayan (ispat şartı olan) hususlar hakkında, ispat şartı olarak resmî senet teşkil edebilir. Örneğin, taşınmaz satış

vaadi (düzenleme biçiminde değil de) yalnız imza onaylaması biçiminde yapılırsa geçersizdir. Ancak, onaylama biçiminde yapılan noter senedinde alıcının satış bedelini aldığı yazılı ise, senet bu konuda (satış bedelinin alındığı hususunda) resmî senet (dolayısıyla kesin delil) teşkil eder.

Buradaki (usul hukukundaki) resmî senet kavramı, az önceki örneğin de gösterdiği gibi geçerlilik şartı olan resmî senet kavramından daha geniştir. Örneğin, yalnız imza ve tarihi resmî bir memur veya makam (örneğin noter) tarafından onaylanmış olan senetler de, usul hukukunda resmî senet sayılır.

Resmî senetler, kural olarak noterler tarafından düzenlenir (bkz. Noterlik K. m. 60; 82; 84 vd.). Ancak, kanunla, başka bir makam, merci veya kişiye de resmî senet düzenleme yetkisi verilebilir (Noterlik K. m. 60, 1-2); örneğin Tapu K. m. 26 veya TMK m. 532'de olduğu gibi.

Burada önce, medenî usul hukuku bakımından ispat şekli olan resmî senetlerin çeşitleri, sonra da resmî senetlerin ispat gücü inceleme konusu yapılacaktır:

2) Noter Senetleri

Noter senetleri Noterlik Kanunu'na göre belgelendirilir (düzenlenir) ve resmî senet sayılır. Çünkü, Noterlik Kanunu hükümlerine göre belgelendirilen işlemler, resmî sayılır (Noterlik K. m. 82, I).

Hukukî işlemler, noter tarafından düzenleme ve onaylama şeklinde yapılabilir:

a) Düzenleme Biçimindeki Noter Senetleri

Bu senetlere 1512 sayılı Noterlik Kanunundan önce **resen düzenlenen noter senetleri** denilirdi. Noterlik Kanunu, bunun yerine "düzenleme" terimini kullanmaktadır (bkz. Noterlik K. m. 84-89). Düzenleme biçimi, aslında kendiliğinden düzenleme anlamındadır.

Düzenleme biçimindeki noter senetleri, bizzat noter tarafından bir tutanak şeklinde yapılır (bkz. Noterlik K. m. 84-89; 60, 1;72; 82, I-II). İlgili (örneğin borçlu), notere başvurarak, ondan bir senet düzenlemesini ister. Noter, ilgilinin bu isteğini "hakiki arzusu hakkındaki beyanını" bir tutanağa yazar ve tutanağı okuması için ilgiliye verir. İlgili tutanağı okur, içindekiler gerçek isteğine uygun ise, bu husus da yazılarak altını imzalar. Bundan sonra, noter de tutanağı imza eder ve mühürler. Bu tutanağın aslı noterlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine (örnekte borçluya) verilir (Noterlik K. m. 84-89).

İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukukî işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noter tarafından düzenleme biçiminde oluşturulmasına bağlıdır (m. 206, 1)[6].

---

[6] HMK m. 206, 1 hükmü ile, okuma yazma bilmeyenlerin düzenledikleri senetlerin geçerliliği bakımından ihtiyar heyeti ve iki tanık huzurunda işlem yapılmasını öngören HUMK m. 297'deki usul yürürlükten kaldırılmıştır. Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Türk Borçlar Kanu-

Düzenleme biçimindeki noter senetleri, **kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içerirse**, İİK m. 38'e göre **ilâm** hükmünde sayılır. Bu nedenle, kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senedine dayanarak bir alacak davası açılmasında hukukî yarar yoktur[7]. Alacaklı düzenleme biçimindeki böyle bir noter senedi ile doğruca ilâmlı icra yoluna başvurabilir (İİK m. 32).

b) Onaylama Biçimindeki Noter Senetleri

Noterlik Kanunu m. 90, "hukukî işlemlerin altındaki imzanın onaylanması, imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır", hükmünü taşımaktadır. Bu senetler, noter önünde (noterlik dairesinde) değil, dışarıda düzenlenir ve yalnız imza onaylaması için notere getirilir (verilir, ibraz edilir). Noter, kendisine verilen (getirilen) böyle bir (adî) senedi huzurunda ilgiliye (örneğin borçluya) imzalatır ve imzanın kendi (noter) önünde atıldığını ve imzayı atan kişiye (örnekte borçluya) ait olduğunu şerh vererek imzayı onaylar (bkz. Noterlik K. m. 60, 4; 90-93).

c) Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Noter Senetleri

Yabancı ülkelerdeki Türklerin noterlik işleri oradaki **Türk konsolosları** tarafından görüldüğünden (Noterlik K. m. 191-195), yabancı ülkelerdeki Türk konsolosları tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olan noter senetleri, az önce incelenmiş olan (Türk) noter senetleri gibi işlem görür.

Yabancı bir ülkedeki devlet makamlarınca (örneğin bir Alman noteri) tarafından düzenlenen veya onaylanan resmî belgelerin (senetlerin), usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunduğu oradaki (örnekte Almanya'daki) Türk konsolosu veya ilgili makamı tarafından onaylanmış[8] ise, bu senetler de Türkiye'de resmî senet hükmündedir (m. 224, 1); yani kesin delil teşkil eder.

Türk konsolosluğu veya o ülkenin yetkili makamı tarafından bu şekilde onaylanmamış olan bir yabancı resmî senedin delil (senet) teşkil edip etmeyeceği, mahkemece takdir olunur. Mahkeme böyle bir senedin resmî senet olduğunu kabul etmezse, senede dayanan taraf, bu senedin o yabancı ülkenin yetkili makamı tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunduğunu ispat edebilir.

3) Resmî Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usulüne Uygun Olarak Düzenledikleri Belgeler

Resmî senetler, noter senetlerinden ibaret değildir. Kanunlar, çeşitli resmî makamlara (örn. tapu dairesi, nüfus dairesi, icra ve iflâs dairesi vb) da resmî belge düzenleme yetkisi vermiş ve bu belgelerin nasıl düzenleneceğini

---

nu (TBK) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) İmza Atamayanlarla İlgili Yeni Düzenlemesine Eleştirel Bir Bakış (AÜHFD, 2013/1, s. 351-382).

7 Bkz. yuk. § 15, B, III, 2.

8 "**apostil şerhi**" verilmiş.

de hükme bağlamıştır (tapu senedi, nüfus cüzdanı, aciz belgesi gibi). Bunlar da, resmî senet niteliğini taşırlar.

4) Resmî Senetlerin İspat Gücü

a) Genel Bilgi

Resmî senetler (ve ilâmlar), kesin delil teşkil eder. Kanun bunu, "düzenleme şeklindeki noter senetleri" (m. 204, 1) ve "ilgililerin beyanına dayanılarak noterlerin onayladıkları senetler" ile "diğer yetkili memurların görevleri içinde usulüne uygun olarak düzenledikleri belgeler"in, aksi ispatlanıncaya kadar kesin delil sayılacağı şeklinde ifade etmiştir.

Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, mahkeme önünde yapılan **sulhler**, resmî vasiyetname düzenlenmesi ve tereke tespiti gibi resmî belgeler de resmî senet gücüne sahiptir.

Resmî senetler de adî senetler gibi kesin delildir; ancak resmî senetler, adî senetlerden daha güçlüdür. Çünkü, bir resmî senede dayanan taraf bunun doğru (borçluya ait) olduğunu ispat zorunda değildir. Bundan başka, bir resmî senedin doğru olmadığını ileri süren borçlu, resmî senedi (örneğin senetteki imzayı) inkâr etmekle yetinemez; az sonra görüleceği gibi, resmî senedi kabul etmeyen borçlunun, senedin sahteliğini ileri sürmesi ve bu konuda **ayrı bir sahtelik davası** açması gerekir (m. 208, 3). Buna göre, resmî senetler, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil eder (m. 204). Resmî senetlerdeki yazı veya imza inkâr edildiğinde, senetteki yazı veya imzanın sahteliği, ancak mahkeme kararıyla sabit olursa, bu senet herhangi bir işleme esas alınamaz (m. 209, 2).

b) Resmî Senetlerin Sahteliği ve Sahtelik Davası[9]

Resmî senetlerin sahteliğinden kasıt, senedi düzenleyen (veya onaylayan) noterin veya resmî kişinin, tamamen sahte bir senet düzenlemiş (veya onaylamış) olması veya resmî senet düzenlenmesi sırasında (veya sonradan) senede gerçeğe uygun olmayan kayıtlar (bölümler) koymuş olması demektir (karş. TCK m. 204-205). Örneğin, resmî senette borçlu gözüken kişinin, böyle bir senet için resmî memur (örneğin noter) önüne gitmediğini, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını (sahte olduğunu), noter senedinde noterin senet metnini kendisine okuduğu yazılı olduğu halde, aslında noterin senedi kendisine okumadan imza ettirdiğini, noter senedinde alacaklının kendisine noter önünde yüz bin lirayı ödediği yazılı olduğu halde aslında noterde böyle bir ödeme yapılmadığını ileri sürmesi birer sahtelik iddiasıdır.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, resmî senedin sahte olduğu iddiası, senedin taraflarına (örneğin alacaklıya karşı) değil, senedi düzenleyen resmî kişiye (örneğin notere) karşıdır (ona yöneliktir). Bununla, noterin bir **haksız fiil işlediği** (sahtecilik yaptığı) iddia edilir. Bu nedenle, sahtelik iddia-

[9] Bkz. Mustafa S. Özbek, Noter Senetlerinde Sahtelik, Ankara 2018.

sı, resmî senedin ancak resmî memur tarafından düzenlenen bölümleri hakkında mümkündür. Buna göre:

Düzenleme biçimindeki noter senetleri, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil eder (m. 204; Noterlik K. m. 82, II). Bu senetlerin tümü noter tarafından düzenlendiği için, hem senedin (içeriğinin) hem de imza ve tarihin sahteliği ileri sürülebilir.

İmzası noterlikçe onaylanan noter senetlerindeki **imza onaylaması**, onaylanan imzanın ilgiliye ait olduğunu belgelendirme niteliğinde olup, senedin içindekileri kapsamaz. Bu senetlerdeki imza ve tarih, sahteliği ispat edilinceye kadar geçerlidir (Noterlik K. m. 82, III). Bu senetlerde noterin onaylaması imza ve tarih hakkında olduğu için, sahtelik iddiasının konusu da yalnız **imza** veya **tarih** olabilir.

Buna karşılık, imzası noterlikçe onaylanan senetlerdeki onaylama, senedin içindekileri kapsamadığı için, bu gibi senetlerin içindekiler hakkında buradaki anlamda bir sahtelik iddiası yapılamaz. Bu senetlerin içindekilerin doğru olmadığı, normal ispat hükümlerine (hukukî işlemler bakımından m. 201 hükmüne) tâbidir.

Tekrar belirtmek gerekirse, yetkili memurların yetkileri içinde usulüne uygun olarak düzenledikleri veya ilgililerin beyanına dayanarak onayladıkları belgeler (resmî senetler), aksi ispat olununcaya kadar kesin delil teşkil eder (m. 204, 2).

Yukarıda da belirtildiği üzere, adî senetler bakımından yazı veya imzanın inkârı (sahte olduğu hususu), ön sorun veya ayrı bir sahtelik davası biçimde ileri sürülebilir iken (m. 208, 3), resmî senetlerin sahteliği, ön sorun olarak ileri sürülemez; sahtelik konusunda **ayrı bir sahtelik davası** açılması gerekir.

Kanuna (m. 208, 4/c.1) göre; resmî bir senetteki (belgedeki) yazı veya imza inkâr edilirse, bu iddia ancak ilgili evraka resmiyet kazandıran kişiyi de taraf göstererek açacağı ayrı bir davada incelenip karara bağlanır. Asıl davaya bakan hâkim, gerekirse bu konuda imza veya yazıyı inkâr eden tarafa, **dava açması için iki haftalık kesin süre** (m. 94) verir (m. 165; 209).

Bu hükmün gerekçesine göre: "Resmî senetlerde sahtelik iddiası söz konusu olduğunda, bu iddianın nasıl ileri sürüleceği ve inceleneceği uygulamada tereddüt doğurabilmektedir. Bu konudaki tereddütleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, resmî senetteki yazı veya imzayı inkâr eden tarafın bu iddiasını, ancak ilgili evraka resmiyet kazandıran kişiyi de taraf göstererek açacağı ayrı bir davada ileri sürmesi kabul edilmiştir. Zira, resmî senedin düzenlenmesinden sonra, resmî senede benzetilerek sahte belge düzenleme dışında, evraka resmiyet kazandıran kişi dahil olmadan bir resmî senette sahtelik yapılması kural olarak mümkün değildir. Sahtelik iddiasının sadece karşı tarafa ya da sadece evrakı düzenleyene yöneltilmesi veya bunlara karşı farklı zamanlarda ayrı davaların açılması çelişik kararların ortaya çıkmasına sebep olabilecek, resmî senedin niteliği ile bağdaşmayan bir durumla karşı karşıya kalınabilecektir. Ayrıca, sadece karşı tarafa veya sadece evrakı düzenleyene dava açılması, bu yolun kötüye kullanılarak yargılamaların uzatılması sonucunu doğurabilecektir. Resmî senetlerin güvenilirliği de dikkate

alındığında, bu konudaki iddianın, evrakı düzenleyene de yöneltilerek bir an önce aydınlatılması önem taşımaktadır. Mevcut dava içinde de böyle bir sahtelik iddiasının karara bağlanması mümkün değildir. Zira, mevcut davanın tarafları dışında, evrakı düzenleyenin de asıl uyuşmazlıkla ilgisi olmadığı hâlde taraf gösterilerek, dava içinde tarafları farklı yeni bir davanın görülmesi şeklinde bir usul, yargılama hukukumuzda mümkün değildir. Belirtilen sebeplerle, resmî senetlerdeki sahtelik iddiasının, evrakı düzenleyen ve senetten lehine sonuç çıkarana karşı açılacak ayrı bir davada görülerek, karara bağlanması düzenlenmiştir. Sahtelik iddiasını ileri süren taraf, bu şekilde ayrı bir dava açmamışsa, yargılamanın uzamaması ve bu imkânın kötüye kullanılmaması için, asıl davaya bakan hâkimin, gerekirse bu konuda yazı veya imzayı inkâr eden tarafa, dava açması için onbeş günlük kesin bir süre vermesi de maddede ayrıca düzenlenmiştir".

Bir belgenin sahteliği ileri sürülürse, belgenin mahkemeye verildiği tarih, yazılıp mühürlenerek, saklanması için mahkemece gerekli tedbirler alınır (m. 208, 2).

Mahkeme, sahtelik incelemesini, m. 211 vd. hükümlerine göre yapar.

Mahkeme, **resmî senedin sahte olduğu kanısına varırsa**, resmî senedin iptaline karar verir. Bu iptal kararı kesinleşince hâkim, resmî senedin altına iptal kararının özetini yazarak senedi iptal eder; yani senede iptal şerhi verir. Resmî senedin ilgili dairedeki aslı da bu yolla iptal olunur (m. 212).

Mahkeme, **sahtelik iddiasını reddederse**, haksız çıkan taraf kötüniyetli ise, bu sebeple ertelenen her bir duruşma için iki katı celse harcına (Harçlar K. m. 12) ve talep edilmek kaydıyla diğer tarafın maddi ve manevi zararları mahkemece takdir edilerek tazminine hükmolunur (m. 213, 1-2). Bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesinden önce, sahtelik iddiasından vazgeçilmesi halinde hâkim tazminattan indirim yapabileceği gibi tazminata hükmetmeyebilir (m. 213, 3).

Senedin sahte olmadığına dair olarak verilen kararın kesinleşmesinden sonra, söz konusu senet hakkında ceza mahkemesinde de sahtelik iddiası dinlenmez (m. 214, 1). Yani, hukuk mahkemesinin kararı, (kesinleşmesi şartı ile) ceza mahkemesi bakımından da bağlayıcıdır (karş. TBK m. 74). Hukuk mahkemesince, belgenin sahte olmadığına kesin olarak karar verilirse, bu belge konusunda ceza mahkemesince de inceleme yapılmayacağı kabul edilerek, aynı hususların tekrar incelenmesinin ve çelişkili kararların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Buna karşın, ceza mahkemesi tarafından, belgeyi düzenleyen hakkında ceza verilmesine yer olmadığı ya da beraat kararı verilmiş olması, hukuk mahkemesinin belgenin sahteliğini incelemesini etkilemez (m. 214, 2).

III – SENETLERDEKİ ÇIKINTILAR VE SİLİNTİLER

Bir senet düzenlendikten sonra, senette bazı noksanlar bulunduğunun veya bazı yanlışlar yapılmış olduğunun farkına varılınca, çıkıntı yapılarak veya silinerek (veya kazınarak) bu eksiklik giderilebilir veya yanlışlar düzelti-

lebilir. Ancak, bu çıkıntıların veya silintilerin (senet gibi) **ayrıca imza edilmesi** (onaylanması) gerekir.

Bir senetteki bu gibi çıkıntı, kazıntı veya senedin metnindeki ve eklentisindeki kazıntı ve silinti, ayrıca imza edilmemiş (onaylanmamış) ise, inkâr halinde bunlar gözönünde tutulmaz (m. 207, 1/c.1).

Yalnız, bu gibi çıkıntı, kazıntı veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine veya anlamına etkili olacak nitelikte görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz (yok) sayılabilir (m. 207, 1/c.2).

HMK m. 207 hükmü hem adî senetler hem de resmî senetler (belgeler) hakkında uygulanır. Yalnız, noter senetleri hakkında, Noterlik K. m. 81, I hükmü uygulanır. Buna göre, noter senetlerindeki ilgilinin imzasını ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz.

İlgililerin elindeki noter senetlerindeki (ilgililerin imzasını taşımayan) çıkıntılar, mahkemece noter senedinin geçerliliğine veya anlamına etkili olabilecek nitelikte görülürse, noter senedi kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir; yani bu halde m. 207, 1/c. 1 hükmü uygulanır. Buna karşılık resmî senedin noterdeki aslındaki veya örneğindeki ilgililerin imzasını taşımayan çıkıntılar hakkında m. 207, 1/c. 2 hükmü uygulanamaz.

İspat şekli olarak düzenlenmiş olan noter senetlerindeki (özellikle bu senetlerin ilgililerin elindeki örnekler üzerindeki) çıkıntıların, el yazısı ile de yapılabileceği kanısındayız. Noterlik K. m. 81, I hükmü, geçerlilik şekli olan noter senetleri ve senedin noterde kalan aslı veya örneği içindir.

C) BELGELERİN MAHKEMEYE VERİLMESİ

I – GENEL BİLGİ

Buraya kadar, senet kavramı ve çeşitleri incelendi. Bundan sonraki başlık altında senetle ispat zorunluluğu incelenecektir. Burada ise, bir davada delil olarak dayanılan belgenin mahkemeye nasıl verileceği (ibraz edileceği) açıklanacaktır. HMK, belge kavramını son derece geniş bir şekilde düzenlemiş ve her türlü bilgi taşıyıcısını belge olarak nitelemiştir (m. 199). Bu bakımdan HMK da, HUMK'ndan farklı olarak senetlerin değil, belgelerin mahkemeye verilmesi konusunu düzenlemiştir (m. 216 vd.).

Davacının ve davalının, ellerinde bulunan belgeleri, dava dilekçesi ve cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye vermek durumunda oldukları ve ancak dilekçeleri ile (henüz) sunmadıkları belgeleri de, ön inceleme aşamasında kendilerine verilen **iki haftalık kesin süre** içinde sunmaları gerektiği yukarıda görüldü[10].

Taraflardan her biri, davada delil olarak dayandığı bütün belgeleri dizi pusulası ile birlikte mahkeme kalemine verir. Bunlardan hâkim tarafından (o dava için) incelemeye değer görülen belgeler dava dosyasına konur; diğer belgeler (yani hâkim tarafından o dava için incelemeye değer görülmeyenler) o tarafa geri verilir.

---

[10] Bkz. HMK m. 119, 1/f; 129, 1/e; yuk. § 17, B, II; § 19, C, II.

Taraf **belgenin aslını** mahkemeye verirse, sorun yoktur. Buna karşılık, taraf belgenin aslını elinde tutarak (saklayarak) yalnız **örneğini** mahkemeye verirse, bakılır:

Karşı taraf belgenin örneğine itiraz etmezse, yani örneğin aslına uygun olmadığını ileri sürmezse, mahkeme bununla yetinebilir. Ancak mahkeme, belgenin aslının verilmesini kendiliğinden de isteyebilir (m. 216, 1).

Belgeye dayanan taraf, belgenin aslını (zayi veya telef olduğu için) mahkemeye veremezse, noterlikçe onaylı olmayan adî senet örnekleri delil teşkil etmez. Örneğin, noterlikçe onaylı olmayan adî senet **fotokopisi delil teşkil etmez.**

Belgenin aslı resmî bir dairede (veya noterde) olduğu için bunu mahkemeye veremeyen taraf, belge aslının bu daireden getirtilmesini isteyebilir (m. 121). Belgenin aslını saklayan taraf, noter veya sair memurlar, hâkimin kararı üzerine bunları mahkemeye vermek zorundadır (m. 216, 1).

Yabancı dilde yazılmış bir belgeye dayanan taraf, bunu tercümesi ile birlikte mahkemeye vermek zorundadır. Hâkim veya diğer taraf verilen tercümeyi kabule değer görmezse, belgenin resmen (bir bilirkişiye) tercüme ettirilmesine karar verilebilir (m. 223).

Mahkemeye verilen senetler veya kıymetli evrak, dava dosyasında bırakılmayarak, bu işe ayrılan sağlam ve güvenli yerlerde (örneğin kasada) yazı işleri müdürü tarafından saklanır. Hâkim, bu senetlerin gerektiğinde yeniden verilmek üzere sahiplerine geri verilmesine de karar verebilir (m. 216, 2).

II – BELGELERİN MAHKEMEYE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU[11]

Taraflardan hiçbiri, karşı tarafın davayı kazanması için kendi aleyhine ve onun lehine olan bir delil göstermekle yükümlü tutulamaz. Her iki taraf da, dayandıkları delilleri kendileri göstermekle yükümlüdürler. Fakat, kanun belgeler bakımından bu kurala bazı istisnalar getirmiştir. Bir taraf, kanunda sayılan belgeleri, kendi aleyhine olsa bile, mahkemeye vermekle yükümlüdür (m. 219).

1) Mahkemeye Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler

Mahkemece istenmesi halinde, taraflar kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar (m. 219, 1/c. 1).

Mahkeme, ticarî davalarda tarafların **ticarî defterlerinin ibrazı**na kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir (m. 222, 1). Ticarî defterlerin delil olarak kabul edilebilmesi için eksiksiz ve usulüne uygun tutulmaları, onaylatılmış olmaları ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır (m. 222, 2)[12].

---

[11] Bkz. Güray Erdönmez, Medenî Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, İstanbul 2014.

[12] Bkz. Ejder Yılmaz, Ticarî Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler (Bankacılar D. 2013 özel sayı s. 28-41; Yılmaz, Makaleler c. 2, 2043-2058); Sema Taşpınar Ayvaz, Ticari Defterlerin İbrazı ve İspat, Ticaret

Elektronik belgeler, belgenin çıktısı alınarak ve talep edildiğinde incelemeye elverişli şekilde elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilir (m. 219, 1/c. 2). Elektronik belgelerin ibrazı, diğer belgelerin ibrazından farklıdır. Bu sebeple, elektronik belgenin kâğıt üzerine çıktısı alınarak ve talep edildiğinde de incelemeye elverişli şekilde elektronik ortama kaydı yapılmak suretiyle mahkemeye ibrazı gereklidir. İncelemeye elverişli şeklin ne olduğu, o günkü teknik imkânlara uygun olarak tespit edilecektir. Burada ibraz edilecek elektronik belgenin, güvenli veya basit elektronik imza ile imzalanmış olup olmaması önemsizdir. Güvenli elektronik imza ile imzalanmamış olan ya da hiç elektronik imza taşımayan bir elektronik belgenin de delil olarak ibrazı gerekebilir. Belgenin ibrazı ile onun delil değeri ayrı değerlendirildiğinden Kanun (m. 218, 1/c. 2) böyle bir ayrıma gitmemiştir.

Ticarî defterler (TTK m. 64 vd.) gibi devamlı kullanılan belgelerin (gerekli olmadıkça tümü değil) sadece ilgili kısımlarının onaylı örnekleri mahkemeye ibraz edilir (m. 219, 2). Çünkü ticarî defterler gibi hacimli belgelerin sadece belirli bir sayfası ya da bölümü uyuşmazlıkla ilgili olabileceğinden, kullanılan bu tür belgelerin tamamının ibrazını istemek, hem ibraz eden taraf için bazı zorluklar ortaya çıkarabilir hem de uyuşmazlık dışındaki bölümlerinin ibrazı sebebiyle mahkeme dosyasında gereksiz yer işgal eder.

2) Belgeyi Vermek Zorunda Olan Kişiler

Yukarıda sayılan belgeleri mahkemeye vermek (ibraz etmek) zorunda olan kişiler, üç gruba ayrılır:

a) Bir **belge, ona dayanan tarafın elinde ise**, bu belgeyi o tarafın kendisinin mahkemeye vermesi gerekir; vermezse, belge elinde bulunan taraf iddiasını ispat edememiş sayılır. Karşı taraf, o belgenin mahkemeye verilmesini (ibraz edilmesini) istemedikçe, burada belgenin mahkemeye verilmesi zorunluluğu söz konusu olmaz.

b) Bir tarafın dayandığı ve mahkemeye verilmesini istediği **belge karşı tarafın elinde ise**, belirli şartların gerçekleşmesi halinde, karşı tarafın bu belgeyi mahkemeye vermesi zorunludur:

Hâkim, ilk önce mahkemeye verilmesi istenen belge ile ispat edilmek istenen hususun, davanın (iddianın veya savunmanın) ispatı için gerekli olup olmadığını inceler. Hâkim, bu belgenin davanın ispatı için gerekli olmadığı (belgenin davayı ilgilendirmediği veya o hususun esasen, kesin olarak ispat edilmiş olduğu) kanısına varırsa, o zaman belgenin mahkemeye verilmesini istemeye gerek kalmaz.

Buna karşılık, hâkim, mahkemeye verilmesi istenen belgenin davanın ispatı için gerekli olduğu kanısına varırsa, o zaman mahkeme, taraftan o belgeyi mahkemeye vermesini (ibraz etmesini) ister (m. 220, 1; 222).

Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu Bildirileri (15-16 Mayıs 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayını, s. 140-155); Önder Topal, Ticari Defterlerin Delil Niteliği, Ankara 2015.

Karşı taraf, istenen belgenin elinde olduğunu **ikrar ederse** veya ileri sürülen talep üzerine susarsa yahut belgenin elinde var olduğu resmî bir kayıtla anlaşılır veyahut başka bir belgede ikrar olunursa, mahkeme, karşı tarafa elinde olduğunu kabul (ikrar) ettiği belgeyi mahkemeye vermesini ister; bunun için ona kesin bir süre verir (m. 220, 1).

Karşı taraf, bu süre içinde belgeyi süresi içinde mahkemeye vermez ve aynı sürede verememesinin nedeninin gerçek bir özre dayandığını (örneğin, senedin yandığını) ispat edemezse ya da belgenin elinde bulunduğunu **inkâr ederse,** mahkeme, diğer (belgenin mahkemeye verilmesini isteyen) tarafın **belge içeriği** hakkındaki beyanını **gerçek kabul edebilir**; mahkeme örneğin, diğer tarafın vermiş olduğu onaysız senet örneğinin (veya fotokopinin) aslına uygun olduğunu kabul edebilir. Ancak bunun için, o tarafın kendisine teklif edilen yemini kabul edip etmemesi veya yerine getirip getirmemesi önem arz eder (m. 220, 3).

HMK m. 220, 3'e göre yapılan bu yemin teklifi üzerine karşı (belgenin elinde olduğunu inkâr eden) taraf **yemin ederse**, artık belgeyi mahkemeye verme zorunluluğu olmaz.

Buna karşılık, karşı taraf **yemin etmezse**, mahkeme, diğer (belgenin verilmesini isteyen) tarafın belge içeriği hakkındaki sözlerini gerçek kabul edebilir (m. 220, 3).

Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticarî defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf (ticarî) defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf, iddiasını ispat etmiş sayılır (m. 222, 5).

c) Davada dayanılan ve mahkemeye verilmesi istenen belge taraflar dışında bir **üçüncü kişinin elinde** olabilir. Bu durumda, belgeye dayanan taraf, üçüncü kişinin o belgeyi mahkemeye vermesini isteyebilir; tarafın, üçüncü kişideki belgenin içeriğini belirtmesi ve açıklaması gerekir. Bunun üzerine, hâkim bu talep hakkında bir karar verir.

Mahkeme, üçüncü kişinin (veya kurumun) elinde bulunan bir belgenin taraflarca ileri sürülen hususun (davanın) ispatı için zorunlu olduğuna karar verirse, bu belgenin ibrazına, yani üçüncü kişinin o belgeyi mahkemeye vermesine karar verir (m. 221, 1).

Üçüncü kişi, başkaları arasındaki bir davanın ispatı için gerekli olan ve elinde bulunan bir belgeyi mahkemeye vermek veya belgenin nerede olduğunu bildirmek için tanık sıfatıyla mahkemeye çağrılabilir (m. 221, 2). Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 247 vd.) olmayan üçüncü kişi, hâkimin bu kararına uymak zorundadır; aksi halde, tanıklar gibi cezalandırılır ve mahkemeye zorla getirilir (m. 221; 245).

Bir senedin aslı kendilerinde olan üçüncü kişi (örneğin, noter) ile resmî makamlar senet aslını mahkemeye vermek zorundadırlar (m. 216, 2).

D) SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU[13] (tanıkla ispat yasağı)

I – GENEL BİLGİ

Yukarıda incelendiği gibi, senet en önemli kesin delildir. Medenî usul hukukunda senet delilinin önemi çok büyüktür. Çünkü, hukukî işlemler, kural olarak, yalnız senet (kesin delil) ile ispat edilebilir; tanık (takdirî delil) ile ispat edilemez. Gerçekten, Kanunda ispat sınırı olarak gösterilen (parasal) **belli tutarı** (m. 200, 1) **aşan hukukî işlemler** ve senede karşı olan iddialar (m. 201) kural olarak yalnız **senet** (kesin delil) **ile ispat edilebilir**; tanık (takdirî delil) ile ispat edilemez. Bu iki ana kuralın, bazı istisnaları vardır (m. 200, 2; 202; 203). Senetle ispat zorunluluğuna ilişkin iki ana kural ile istisnaları, bundan sonraki başlıklar altında ayrıntılı biçimde incelenecektir.

Burada, senetle ispat zorunluluğu hakkında genel bir açıklama yapmakla yetinilecektir:

Senetle ispat zorunluluğu yerine aslında "**kesin delille ispat zorunluluğu**" denilmesi daha doğrudur. Çünkü, senetle ispatı zorunlu olan bir hukukî işlem, örneğin yüz bin liralık bir satış sözleşmesi, başka kesin deliller (ikrar, yemin veya kesin hüküm) ile de ispat edilebilir. Ancak, senet ispat yükü kendisine düşen tedbirli bir tarafın hukukî işlemin yapıldığı sırada sağlayabileceği bir delil olduğu için, kesin delillerin en önemlisi olduğu kabul edilir. Bu özelliğinden dolayı bu kural, "**senetle ispat zorunluluğu**" olarak ifade edilmektedir. Ancak, senetle ispat zorunluluğu hakkındaki açıklamaların, diğer kesin deliller için de geçerli olduğunu tekrar belirtmek gerekir.

Senetle ispat zorunluluğu, "**tanıkla ispat yasağı**" olarak da ifade edilir. Bu ifade ile aslında "**takdirî delille ispat yasağı**" anlatılmaktadır. Ancak, tanık en çok başvurulan önemli bir takdirî delil olduğundan, buna "tanıkla ispat yasağı" denilmektedir. Tanıkla ispatı yasak (kesin delille ispatı zorunlu) olan bir hukukî işlem, diğer takdirî delillerle de ispat edilemez.

Senet (kesin delil) ile ispat zorunluluğuna ilişkin kanun hükümleri (m. 200-201), başka bir deyişle tanıkla ispat yasağı, kamu düzeni düşüncesiyle kanunda düzenlenmiş değildir[14]. Bu nedenle, bunun aksine sözleşme (delil sözleşmesi) yapılabilir. Delil sözleşmesi (m. 193; 200, 2) ileride incelenecektir[15].

Senetle ispat zorunluluğu bakımından, senedin (yazılı şeklin) bir ispat şartı olduğu, bunun geçerlilik şartı olan yazılı şekil ile karıştırılmaması gerektiği yukarıda incelendi[16].

---

[13] Bkz. İlhan Postacıoğlu, Şahadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, İstanbul 1964; Murat Yavaş, Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, Ankara 2009.

[14] Senetle ispat kuralının kamu düzeninden olmadığına ilişkin 1959 tarihli İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 160-161.

[15] Bkz. aşa. § 35.

[16] Bkz. yuk. § 28, A.

II – KANUNDAKİ İSPAT SINIRINDAN FAZLA HUKUKÎ İŞLEMLERİN SENETLE İSPATI ZORUNLUDUR

1) Birinci Ana Kural

Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrar ve itfası amacıyla yapılan hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değeri m. 200, 1'deki parasal sınırı (2019 yılı için: 3.360 TL'nı) **geçtiği takdirde** senetle ispat olunması gerekir (m. 200, 1). Buna göre; HMK m. 200, 1'de açıkça belirtildiği gibi, senetle ispat zorunluluğu, yalnız **hukukî işlemler** içindir.

Buna karşılık, hukukî fiillerin senetle ispatına olanak ve gerek yoktur; yani, **hukukî fiiller tanıkla** (takdiri delillerle) **ispat edilebilir**. Hukukî fiillerin tanıkla ispatı konusu, bu başlığın sonunda (birinci ana kuralın istisnalarından sonra) ayrıca incelenecektir.

Hukukî işlem, belli bir hukukî sonuç (bir hakkın veya hukukî ilişkinin doğumu, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasını) meydana getirmeye yönelmiş bir irade beyanıdır (açıklamasıdır). Bu irade açıklaması, tek taraflı (örneğin borç ikrarı), iki taraflı (sözleşme) veya çok taraflı (örneğin karar) olabilir.

İşte bu hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değeri m. 200, 1'de belirlenen parasal sınırı geçtiği takdirde, senetle ispat olunması gerekir. Bu bakımdan, hukukî işlemin borçlandırıcı işlem (taahhüt işlemi) veya tasarruf işlemi olması arasında fark yoktur. Maddede (m. 200, 1) tanımlanan her türlü hukukî işlemin, kural olarak senetle (kesin delille) ispat olunması gerekir.

Kanunda belirlenen parasal sınırı geçen hukukî işlemlerin senetle ispat edilmesi gerektiğine (tanıkla ispat edilemeyeceğine) örnekler: Ödünç verildiği iddia edilen (TBK m. 379) para m. 200, 1'de belirlenen miktardan fazla ise, bu iddia senetle (kesin delille) ispat edilebilir. Ödendiği iddia edilen tutar, m. 200, 1'de belirlenen miktardan fazla ise, bu iddia senetle (kesin delille) ispat edilebilir. HMK m. 200, 1 hükmündeki tutardan fazla bir taşınır satış sözleşmesinin senetle ispat edilmesi gerekir; tanıkla ispat edilemez. Yıllık kira tutarı m. 200, 1 hükmündeki tutardan fazla bir kira sözleşmesi, tanıkla ispat edilemez; ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir. Yine bu tutardan fazla bir saklama sözleşmesinin (TBK m. 561 vd.), senet (kesin delil) ile ispatı gerekir; tanıkla ispatı mümkün değildir. Aynı şekilde bu tutardan çok bir vekâlet sözleşmesinin (TBK m. 502 vd.) senetle (yazılı delille) ispatı gerektiği gibi, müvekkilinin vekiline (200, 1 hükmündeki tutardan fazla bir) talimat verdiğinin de yazılı delille ispatı gerekir. Bir adî şirket (ortaklık) sözleşmesinin (TBK m. 620 vd.) değeri/miktarı m. 200, 1'de belirlenen tutardan çok ise bu sözleşmenin senet (yazılı delil) ile ispat edilmesi gerekir; tanıkla ispatı mümkün değildir.

Senetle ispat zorunluluğunun alt sınırı m. 200, 1'deki tutardır. Yani, yapıldıkları zamanki miktar veya değeri söz konusu tutarı geçen hukukî işlemlerin senetle ispat olunması gerekir (m. 200, 1).

Maddede açıkça yazılı olduğu gibi, hukukî işlemin miktar veya değerinin m. 200, 1'deki sınırı geçip geçmediği, hukukî işlemin yapıldığı zamanki du-

rumuna göre belirlenir. Buna göre, bir hukukî işlemin yapıldığı zamanki değeri m. 200, 1'deki sınırdan az ise, davanın açıldığı andaki değeri m. 200, 1'deki sınırdan fazla olsa bile, o hukukî işlem tanıkla ispat olunabilir.

Bir hukukî işlemin senetle ispatının gerekip gerekmediği (başka bir deyişle, tanıkla ispatının mümkün olup olmadığı), o hukukî işlemin tümünün değerine göre belirlenir. Örneğin, m. 200, 1'de belirlenen tutardan fazla bir alacağın, m. 200, 1 hükmündeki miktardan az bir bölümünün dava edilmesi (kısmî dava) halinde, dava edilen alacak, m. 200, 1 hükmündeki tutardan az olduğu halde, senet (kesin delil) ile ispat edilmelidir, tanıkla ispat edilemez.

Bir hukukî işlemin yapıldığı zamanki miktar veya değeri m. 200, 1'de belirlenen miktar ya da değerden fazla ise, bu hukukî işlemin miktar ya da değeri ödeme veya borçtan kurtulma (ibra) gibi herhangi bir nedenle m. 200, 1'deki tutardan aşağı düşse bile, hukukî işlem senetsiz (tanıkla) ispat olunamaz (m. 200, 1/c. 2).

Bunun gibi, aslı m. 200, 1 hükmündeki tutardan fazla olan bir alacağın ödenmesinde, ödendiği ileri sürülen para m. 200, 1 hükmündeki tutardan az olsa bile, bu ödemenin senetle ispatı gerekir.

2) Birinci Ana Kuralın İstisnaları

Senet alınmasının imkânsız olduğu bazı hallerde, değeri veya miktarı m. 200, 1'de belirlenen tutardan fazla olan hukukî işlemlerin tanıkla ispat edilebileceği (istisna olarak) kabul edilmiştir (m. 202-203).

Senet alınmasındaki bu imkânsızlık, **maddî** bir **imkânsızlık** olabilir; örneğin bir su baskını veya deprem sırasında yapılan hukukî işlemler için senet düzenlenmesi ve alınmasında maddî imkânsızlık vardır (m. 203, 1/c).

Senet alınmasındaki imkânsızlık, **manevî** bir **imkânsızlık** da olabilir; örneğin, bir baba ile oğlu arasındaki hukukî işlemlerde, bu kişilerin birbirinden senet istemesi uygun düşmeyeceğinden (toplumsal değerler açısından hoş karşılanmayacağından), senet alınmasında manevî bir imkânsızlık vardır (m. 203, 1/a).

Kanun, senet alınmasında imkânsızlık olduğu için, tanıkla ispatın mümkün olduğu istisnaî halleri, sınırlı olarak saymıştır (m. 202-203); bunlar dışındaki haller istisna olarak kabul edilemez; yani bunlar dışındaki hallerde m. 200'de düzenlenen ana kural uygulanır.

Bu genel açıklamadan sonra, senetle ispat zorunluluğu hakkındaki m. 200, 1'deki birinci ana kuralın istisnalarını (m. 202-203) inceleyebiliriz. Bu istisnalar, yani, miktar veya değerine bakılmaksızın (her halde) tanıkla ispat edilebilecek olan hukukî işlemler şunlardır:

a) Yakın Hısımlar Arasındaki Hukukî İşlemler Tanıkla İspat Edilebilir

HMK m. 203, 1/a'da yazılı olan yakın hısımlar arasındaki hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir. Bu istisna, m. 203, 1/a'da yazılı olan yakın hısımlar arasında senet alınması **manevî bakımdan imkânsız** bulunduğu için kabul edilmiştir.

HMK m. 203, 1/a'daki sayma sınırlıdır; yani, m. 203, 1/a'da sayılı olmayan hısımlar arasındaki hukukî işlemler (m. 203, 1/a'ya göre) tanıkla ispat edilemez; şartları varsa m. 203, 1/b'ye göre tanıkla ispat edilebilir.

Bu genel açıklamadan sonra, şimdi m. 203, 1/a'daki **yakın hısımları** ayrı ayrı incelemek gerekir:

Alt ve üst soy (füru ve usul; örneğin oğul ile baba) arasındaki hukukî işlemler, her halde (yani miktar veya değerine bakılmaksızın) tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/a).

Kardeşler arasındaki hukukî işlemler, her halde (yani miktar veya değerine bakılmaksızın) tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/a).

Eşler (karı ve koca) arasındaki hukukî işlemler, her halde (yani miktar veya değerine bakılmaksızın) tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/a). Tanıkla ispatı mümkün olan hukukî işlemler, eşler arasındaki **evlilik birliği mevcut iken yapılmış olan hukukî işlemler**dir. Taraflar sonradan boşanmış olsalar bile, evlilik sırasında yaptıkları hukukî işlemleri tanıkla ispat edebilirler.

Kayınpeder veya kayınvalide ile damat veya gelin arasındaki hukukî işlemler, her halde (yani miktar veya değerine bakılmaksızın) tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/a).

Yukarıda incelenmiş olan m. 203, 1/a hükmü, yalnızca m. 200, 1'deki ana kuralın istisnasıdır. Buna karşılık, m. 203, 1/a hükmü, m. 201, 1'deki (senede karşı senetle ispata ilişkin) ikinci ana kuralın istisnası değildir. Yani, m. 203, 1/a'daki yakın hısımlar arasındaki bir hukukî işlem senede bağlanmış ise, bu senede karşı ileri sürülecek savunmalar (örneğin ödeme savunması) tanıkla ispat edilemez, ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir.

b) Senede Bağlanmaması Gelenek (Teamül) Olan Hukukî İşlemler Tanıkla İspat Edilebilir

İşin niteliğine ve iki tarafın durumlarına göre senede bağlanmaması **gelenek** (teamül) olarak yerleşmiş bulunan hukukî işlemler, miktar veya değerine bakılmaksızın tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/b). Burada senet alınmasında **manevî imkânsızlık** olduğu için, tanıkla ispata izin verilmiştir.

Ancak taraflar, böyle bir manevî imkânsızlığa rağmen, aralarındaki hukukî işlemi senede bağlamışlarsa, artık o senede karşı olan iddialarını m. 203, 1/b'ye göre tanıkla ispat edemezler (m. 201). Çünkü taraflar aralarında (asıl) hukukî işlemi bir defa senede bağlamakla böyle bir geleneğin (manevî imkânsızlığın) olmadığını veya bu geleneğin aksine hareket ettiklerini kabul etmiş sayılırlar.

Gelenek nedeniyle m. 203, 1/b hükmüne göre tanık dinlenebilmesi için, dava konusu hukukî işlemlerin devamlı olarak senede bağlanmamasının gelenek haline gelmiş olması, bu hususun istikrarlı (kararlı) bulunması ve aynı zamanda ilgili kamuoyu tarafından bu geleneğe inanılmış olması gerekir.

Yukarıdaki açıklamalara uygun olarak, m. 200, 1/b hükmüne göre tanıkla ispat edilebilen hukukî işlemlere şu örnekler verilebilir:

Köylüler arasında (köylerde) yapılan bazı hukukî işlemler (örneğin kira sözleşmesi), tanıkla ispat edilebilir.

Birlikte oturan ve kendisine yeğeni tarafından bakılan hasta teyze ile yeğen arasında yapılan hukukî işlemler, tanıkla ispat edilebilir.

Yolcu taşıma sözleşmesi bakımından, yolcunun otobüste eşyasının kaybolduğu m. 203, 1/b hükmüne göre tanıkla ispat edilebilir.

Avukat, müvekkilinden icra takibi yapmak üzere aldığı borç senedini, icra takibi sonuçsuz kalınca, müvekkiline geri vermiş olduğunu tanıkla ispat edebilir.

Evlat edinen ile evlatlık arasındaki hukukî işlemler, m. 203, 1/b hükmüne göre tanıkla ispat edilebilir.

Nişan hediyelerinin geri verilmesi davasında, verilen hediyeler (ve başlık parası) tanıkla ispat edilebilir.

HMK m. 203, 1/b hükmünün uygulama alanı, özellikle ticarî işlemlerde daha geniştir. Gerçekten, ticarî geleneğe ve iki tarafın durumuna göre senede bağlanması veya ticarî defterlere geçirilmesi usulden olmayan ticarî işlemler tanıkla ispat edilebilir. Örneğin hâkim, ticarî alım satım işlerinde senet düzenlenmesi hakkında bir geleneğin bulunmadığı hallerde tanık dinleyebilir.

Hâkim, bir ticarî işlem hakkında senet düzenlenmesinin gelenek gereği olup olmadığını, ticaret veya sanayi odasından sorabilir (bkz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar K. m. 12/f, g).

c) Senet Alınması Mümkün Olmayan Haller

Yangın, deniz kazası, sel ve deprem gibi senet alınması mümkün olmayan (senet alınmasında maddi imkânsızlık olan) veya çok güç olan hallerde yapılan hukukî işlemler, miktar veya değerine bakılmaksızın tanık ile ispat edilebilir (m. 203, 1/c; maddî imkânsızlık).

d) Hukukî İşlemlerdeki İrade Bozukluğu veya Aşırı Yararlanma Halleri Tanıkla İspat Edilebilir

Hukukî işlemlerde hata (yanılma), hile (aldatma) ve ikrah (korkutma) iddiaları (TBK m. 30 vd) ile aşırı yararlanma (gabin; TBK m. 28) durumu; hukukî işlemin konusunun miktar veya değerine bakılmaksızın, tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/ç). Yanılma, aldatma, korkutma ve aşırı yararlanma iddialarının senede bağlanmasında **maddî imkânsızlık** olduğu için, bu iddiaların tanıkla ispat edilebilmesi doğaldır.

HMK m. 203, 1/ç hükmünün uygulaması, daha çok yazılı sözleşmelerdeki yanılma, aldatma, korkutma ve aşırı yararlanma iddiaları hakkında olduğundan, bu hüküm, m. 201'deki (senede karşı senetle ispat hakkındaki) ikinci ana kuralın istisnaları görülürken de incelenecektir. Bu nedenle, burada aldatma ile ilgili bazı örnekler verilmekle yetinilecektir.

Gerçekten, m. 203, 1/ç hükmünün uygulanmasına daha **çok aldatma** (hile) **iddialarında** rastlanmaktadır: Aldatma (TBK m. 36'da), "taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa

bile, sözleşme ile bağlı değildir. Üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf, sözleşmenin yapıldığı sırada karşı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması halinde, sözleşmeyle bağlı değildir" şeklinde düzenlenmiştir. Sözlük anlamı ile hile, bir kimsenin gerçeği bilmesi halinde yapılmasına razı olmayacağı bir işleme rızasını elde etmek için yapılan fiil ve davranışlarla, bu doğrultuda kullanılan sözler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda aldatma (hile) iddiası tanıkla ispat edilebilir.

Alacaklı, borçlunun kendisine (alacaklıya) vermiş olduğu borç senedini aldatma (hile) ile geri aldığını tanıkla ispat edebilir.

Yazılı sözleşmelerdeki (belgelerdeki) **aldatma** (hile) **iddiaları** ile sözleşmelerdeki yanılma (hata) ve korkutma (ikrah) iddialarının tanıkla ispat edilmesine ilişkin örnekler ileride görülecektir.

e) Hukukî İşlemlere ve Senetlere Karşı Üçüncü Kişilerin Muvazaa İddiaları Tanıkla İspat Edilebilir

İki taraf arasında yapılan muvazaalı işlemden zarar gören üçüncü kişi, kendi aleyhine kullanılan hukukî işlemin veya senedin aksini, ancak tanıkla ispat edebilir (m. 203, 1/d). Çünkü, üçüncü kişinin hukukî işlemin taraflarından bir belge alabilmesi fiilen mümkün değildir.

f) Senedin Beklenmeyen Bir Olay veya Zorlayıcı Nedenle Kaybolduğu Tanıkla İspat Edilebilir

Bir senedin, sahibinin elinde beklenmedik bir olay veya zorlayıcı bir sebeple veya usulüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte herhangi bir şekilde kaybolduğu kanısını kuvvetlendirecek delil veya emarelerin bulunması halinde tanık dinlenebilir (m. 203, 1/e). Çünkü bu gibi hallerin de bir belgeye bağlanabilmesi fiilen imkânsızdır.

Senedin kaybolması halinde, m. 203, 1/e'deki şartlar varsa, senet konusu olan hukukî işlem tanıkla ispat edilebilir. Burada başlangıçta bir senet alınmıştır; fakat **sonradan senet kaybolmuştur**. Kaybolan her senet hakkında tanık dinlenemez; ancak, m. 203, 1/e'deki şartların varlığı halinde tanık dinlenebilir. Burada da iki ihtimal (olasılık) vardır:

Ani bir olay veya mücbir bir sebep ile senedin sahibi elinde kaybolması halinde, senedin bundan dolayı kaybolduğu hakkında kanaat verici delil ve belirtiler (emareler) varsa, kaybolan senedin konusu olan hukukî işlem tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/e).

Burada, ilk önce senet sahibinin elinde senet bulunduğu, sonra da bu senedin ani (beklenmedik) bir olaydan sonra mücbir sebepten dolayı kaybolduğu hususu kanaat verici delil ve belirtilerle (yani takdirî delillerle, bu arada tanık ile de) ispat edilmelidir. Ancak senedin bu şekilde kaybolduğu hakkında kanaat verici delil ve belirtilerin bulunması halinde, senet konusu hukukî işlem (miktar veya değerine bakılmaksızın) tanık ile ispat edilebilir (m. 203, 1/e).

Senet sahibi senedini usulüne uygun olarak bir resmî memura (daireye) vermiş ve senet bu resmî memur elinde (resmî dairede) kaybolmuş ise, bu hususta kanaat verici delil ve belirtilerin bulunması halinde, senet konusu hukukî işlem tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/e).

Burada, senedin ani (beklenmedik) bir olay veya mücbir sebepten dolayı kaybolmuş olması şartı aranmaz. Senedin usulüne uygun olarak bir resmî memura verilmiş ve bu resmî memur elinde kaybolmuş olması ve bunun kanaat verici delil ve belirtilerle ispat edilmesi yeterlidir. Örneğin;

Vergi dairesi bir kimsenin (mükellefin) bütün belgelerini incelemek için alır ve bu belgeler arasındaki bir senet vergi dairesinde kaybolursa, senet sahibi bunu ve senet konusu hukukî işlemi tanıkla ispat edebilir.

Borçlu borcunu alacaklıya ödediğini bildirerek makbuz ibraz etmiş ve taşıdığı imzanın incelenmesine karar verilmiş olduğu halde bu işlemler yapılmadan belge (makbuz) icra mahkemesi dosyasından kaybolmuş ise, belge resmî mercide ve borçluya isnat edilebilecek bir kusur olmaksızın kaybolduğuna göre ödemenin tanıkla ispatı mümkündür.

Yangın, deprem, su baskını veya toprak kayması (heyelân) afetlerinden biri nedeniyle mahkeme ve adliye dairelerinde kaybolan (zıyaa uğrayan) belgeler (senetler) hakkında da bu konudaki 4473 sayılı Kanunun 11 ve 30. maddelerine göre tanık dinlenebilir.

g) Haksız Fiilden Doğan Tazminat Alacakları Tanıkla İspat Edilebilir

Haksız fiil (TBK m. 49 vd.), bir hukukî işlem olmadığından ve haksız fiilden doğan tazminat alacakları için senet almak (sağlamak) imkânsız bulunduğundan, haksız fiilden doğan tazminat alacaklarının, senetle ispat zorunluluğu kuralının dışında kalması doğaldır. Haksız fiiller, diğer bütün hukukî fiiller gibi, tanıkla ispat edilebilir.

Bu istisna, HUMK m. 293/2'de açık bir şekilde yer almakta idi; ancak haksız fiilin, HMK m. 200'de sözü edilen hukukî işlemlerden olmaması sebebiyle, bu hususun istisnalar arasında sayılmasının fazladan bir düzenleme olduğu gerekçesiyle HMK m. 203'deki istisnalar arasına alınmamıştır.

h) Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dinlenebilir

Senet (kesin delil) ile ispatı gereken (m. 200, 1) bir hukukî işlem, bunun hakkında bir **delil başlangıcı** varsa, tanıkla ispat edilebilir (m. 202, 1).

Delil başlangıcı[17], m. 202, 2'de tarif edilmiştir. Buna göre, "delil başlangıcı, iddia konusu hukukî işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukukî işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya kendisine gönderilmiş **belge**dir"[18].

---

[17] Bkz. Halûk Konuralp, Medenî Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı, Ankara 1988.

[18] "...Öte yandan, haberleşmenin önemli bir türünü oluşturan faks mesajlarının delil değerini, delil başlangıcı olarak benimseyen içtihatlarla uyum sağlanması amacıyla, 'verilmiş' sözcüğünün yanısıra 'gönderilmiş' sözcüğünün de ilâve edilmesi kabul edilmiştir. Böylece, faks

HMK m. 202'de, (HUMK m. 292'den farklı olarak), "yazılı delil başlangıcı" ibaresinde yer alan "yazılı" sözcüğüne yer verilmemiş; "delil başlangıcı" ibaresi kullanılmıştır. Yani, delil başlangıcının yazılı olma koşulu kaldırılmıştır. Bu sebeple, bir belgenin delil başlangıcı olabilmesi için, yazılı olması şart değildir[19].

Kanunda yapılan düzenlemeye göre, m. 199'da yapılan tanıma uygun bir belgenin delil başlangıcı sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın birlikte bulunması gerekir.

aa) Bu belgenin **aleyhine ileri sürülen kimse** veya temsilcisi **tarafından verilmesi** veya gönderilmesi (onun tarafından verilmiş veya gönderilmiş olması) gerekir. Ancak, delil başlangıcı olan belgenin mutlaka karşı tarafa yöneltilmiş bir irade açıklamasını taşıyan bir belge olması gerekli değildir.

bb) Bu belgenin, varlığı iddia edilen hukukî işlemi **tam olarak ispata yeterli olmamakla beraber**, o hukukî işlemin varlığını muhtemel kılması gerekir.

Buna göre, m. 202, 2'deki iki şarta da uygun olduğu için delil başlangıcı sayılan belgelere şu örnekler verilebilir:

Borçlu tarafından el ile yazılmış ve fakat imzasız olan bir senet veya mektup, delil başlangıcı sayılır.

Bunun gibi, borçlunun alacaklının defterine el ile yazıp da imzalamadığı yazılar, delil başlangıcı sayılır.

Makine (örneğin, bilgisayar) ile yazılmış olup da karşı tarafın (borçlunun) parafını (veya el ile yazılı adını veya soyadını) taşıyan belge de, delil başlangıcı sayılır.

Bir fotoğraf, film, görüntü, ses kaydı veya elektronik posta, bilgi taşıyıcı olarak, aleyhine ileri sürülen kişi tarafından verilmiş veya gönderilmiş ise ve bu bilgi taşıyıcısı iddia edilen hukukî işlemi (örneğin, sözleşmenin varlığını) muhtemel gösteriyorsa, bu fotoğraf, film, görüntü, ses kaydı veya elektronik posta da delil başlangıcı sayılır.

Örneğin, bir elektronik postanın işyerinde iç yazışmalarda kullanılması ve çalışana ait olması halinde bu bir belge ve delil başlangıcı olabilir. Yine taraflar elektronik ortamda yazışma suretiyle mutabakata varmış, ancak bu hususu ıslak imza ile belgelemedikleri halde dahi, bu yazışmaların taraflardan kaynaklandığı ispat edilmek koşuluyla belgenin varlığı kabul edilmelidir. Aynı şekilde davanın taraflarından gönderilen SMS kaydı veya sosyal medya (fa-

---

mesajı ve bu konudaki benzer yollarla göndermenin, bir belgenin verilip verilmemesi sayılmasına ilişkin tereddüt ve tartışmaların önüne geçilebilecek, teknik araçlarla gönderilen belgeler de delil başlangıcı sayılabilecektir" (m. 202 gerekçesinden).

19 Farklı görüş için bkz. Baki Kuru, Yazılı Delil Başlangıcı (HMK m. 202), (Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, c. 2, s. 1383-1391). Kuru'ya göre HMK m. 199 anlamında senet dışındaki bir belgenin kendisi, senetle ispat zorunluluğunun istisnası olmadığından, böyle bir belgenin başlangıcı öncelikle HMK m. 202 anlamında senetle ispat zorunluluğunun istisnası olan bir delil başlangıcı değildir. Bu nedenlerle, Kuru, senede karşı ileri sürülen delil başlangıcının yazılı olmasının gerekli olduğu; HMK m. 199'daki senet dışındaki belgelere karşı ileri sürülen delil başlangıcının yazılı olmasına gerek olmadığı görüşündedir. Yargıtay kararları ağırlıklı olarak bu yönde olmakla birlikte farklı kararlar da vardır.

cebook mesajı vs.) mesajları da m. 199 anlamında belge olduğu için delil başlangıcı sayılır.

Bu söz edilen belgelerin delil değeri taşıması için hukuka aykırı olarak elde edilmemiş olması da gerekir; hâkim bu hususu da resen dikkate alır (m. 189, 2, 4).

TTK m. 749'a göre **zamanaşımına uğramış olan bonolar** ve **çekler**, asıl borç ilişkisine (örneğin ödünç sözleşmesine) dayanarak TBK m. 146'daki on yıl içinde açılan alacak davasında (asıl borç ilişkisi hakkında) delil başlangıcı sayılır.

Bir kişinin (vergi mükellefinin) vergi beyannamesindeki veya mal beyannamesindeki gelirleri, borçları vs. ile ilgili yazılar kendi aleyhine delil başlangıcı sayılır.

Bir hukukî işlem hakkında, m. 202, 2'deki şartlara uygun bir **delil başlangıcı varsa** (yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi), o hukukî işlem hakkında **tanık dinlenebilir** (m. 202, 1). Böylece, delil başlangıcı, senetle ispat zorunluluğuna ilişkin m. 200, 1'deki birinci ana kuralın (ve ileride görüleceği gibi senede karşı senetle ispat hakkındaki ikinci ana kuralın) istisnalarından biridir.

i) Delil Sözleşmesi Varsa

Kanundaki (m. 200, 1'deki) tutardan fazla değeri veya miktarı olan bir hukukî işlemin tanıkla ispat edilebileceği hakkında taraflar arasında bir delil sözleşmesi (m. 193; 201, 2) varsa, bu hukukî işlem tanıkla ispat edilebilir. Örneğin, davalı, davacı ile kendisinden yüz bin lira alacaklı olduğunu iddia eden davacının bu alacağını tanıkla ispat etmesine izin veren bir delil sözleşmesi yapmışlarsa veya davalı, davacının alacağını tanıkla ispat etmesine açıkça izin verirse, davacı, davalıdan yüz bin lira alacaklı olduğunu (örneğin ona yüz bin lira ödünç verdiğini) tanıkla ispat edebilir (m. 202). Bu hüküm (ve m. 193 hükmü) delil sözleşmesi başlığı altında ilerde incelenecektir[20].

j) Kadastro Davaları

Kadastro ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesinde her türlü delile (bu arada tanık deliline de) dayanılarak hüküm verilebilir (Kadastro K. m. 30).

3) İstisnalar Dışında Birinci Ana Kural Uygulanır

Yukarıda incelenmiş olan istisnalar dışında, m. 200, 1'de belirlenen tutardan fazla değerli veya miktarlı hukukî işlemlerin tanıkla ispatı mümkün değildir; senetle (kesin delille) ispat olunması gerekir (m. 202, 2).

Yukarıda sıkça belirtildiği gibi, buradaki "senet" terimini, "kesin delil" olarak anlamak gerekir. Yani, m. 200, 1'deki tutardan fazla işlemlerin senetle ispatı zorunluluğu, aslında kesin delille ispat zorunluluğudur. Çünkü, m. 200, 1'deki tutardan fazla bir hukukî işlemi senetle ispat edemeyen taraf, bu hu-

---

[20] Bkz. aşa. § 35.

kukî işlemi başka bir kesin delille ispat edebilir. Şöyle ki: HMK m. 200, 1'de belirlenen tutardan (değer ya da miktardan) fazla bir hukukî işlem (örneğin ödünç sözleşmesi) hakkında senedi olmayan (ve yukarıdaki istisnalardan birine de dayanmayan) taraf, bu hukukî işlemi (örnekte ödünç sözleşmesini), tanıkla ispat edemezse de, karşı tarafın ikrarı (m. 188) ile ispat edebilir.

Aynı şekilde m. 200, 1'de belirlenen tutardan fazla bir hukukî işlemi (örnekte ödünç sözleşmesini) senet ve ikrar ile de ispat edemeyen (ve m. 200, 1 gereğince bunu tanıkla ispat etmesi yasak olan) taraf, kesin delil olan yemine başvurabilir; yani, karşı tarafa yemin teklif edebilir (m. 225 vd.). Yemin teklifi üzerine, karşı taraf yemin ederse, m. 200, 1'deki tutardan fazla hukukî işlem (örnekte ödünç sözleşmesi) ispat edilememiş sayılır. Yemin teklifi üzerine, karşı taraf, yeminden kaçınırsa, m. 200, 1'deki tutardan fazla hukukî işlemi (örnekte ödünç sözleşmesini) ikrar etmiş sayılır (m. 229); yani, ödünç sözleşmesi (diğer bir kesin delil olan) yemin (veya ikrar) delili ile ispat edilmiş olur.

4) Hukukî Fiiller Tanıkla İspat Edilir

Senetle ispat zorunluluğuna (tanıkla ispat yasağına) ilişkin olan buraya kadarki açıklamalar, birçok defalar belirtildiği gibi, hukukî işlemler içindir. Buna karşılık, **hukukî fiiller** (maddî vakıalar) **tanıkla ispat edilebilir.**

Hukukî fiil de, hukukî işlem gibi hukukî sonuçlar doğurur. Bu bakımdan hukukî fiil hukuken önemli olmayan diğer fiillerden ayrılır ve hukukî işleme yaklaşır (benzer).

Ancak, hukukî fiil, hukukî işlemden ayrıdır: Hukukî fiiller, genellikle bir irade beyanını içermez. İstisna olarak, hukukî fiil bir irade beyanını içerse bile, bu irade beyanı (hukukî işlemdeki gibi) belli bir hukukî sonuç doğurmaya yönelmiş değildir. Yani hukukî fiiller, bir hukukî sonuç doğurmakla birlikte, o hukukî sonucu doğurmak iradesiyle (amacıyla) yapılmaz.

İşte, hukukî fiiller belli bir hukukî sonuç doğurmak iradesiyle yapılmadıkları ve bu irade beyanının karşı tarafa ulaşması şart olmadığı için hukukî fiil (örneğin haksız fiil) hakkında senet alınması (düzenlenmesi) imkânsızdır. Bu nedenle, hukukî fiiller m. 200, 1'in (ve m. 201'in) kapsamı dışında kalır; yani tanıkla ispat edilebilir:

Kiralayanın kendisine ödenmek istenen kira bedelini reddetmesi (almaması), bir hukukî işlem değil hukukî fiil olduğundan tanık ile ispat edilebilir[21].

Bir işçinin fazla çalışma (mesai) yaptığı ve bayram ve pazar günleri de çalıştığı vakıası, tanık ile ispat edilebilir.

Zamanaşımının başlangıcı öğrenmeye bağlı ise, öğrenme hususu her türlü delil (bu arada tanık) ile ispat edilebilir.

Zilyetlik durumu, yalnız başına bir hukukî fiildir ve bu nedenle tanıkla ispat edilebilir.

---

[21] Bkz. 11.03.1959 gün ve 23/20 sayılı İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 159-160.

Bir tapusuz taşınmaz, davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir (TMK m. 713, 1). İşte, bu hükme dayanılarak açılan davada davacı, zilyetliğinin davasız ve aralıksız ve en az yirmi yıl sürdüğünü (TMK m. 713), tanık beyanlarıyla da ispat edilebilir (bkz. ayrıca Kadastro Kanunu m. 14, I; TMK m. 713, V).

Ancak, tapusuz taşınmazların (zilyetliğinin) başkasına devrinin bir hukukî işlem olduğu, bu nedenle senet (kesin delil) ile ispat edilebileceği kanısındayız; fakat, Yargıtay karşı görüştedir (tanıkla ispat edilebileceği görüşündedir).

III – SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU (SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI)

1) İkinci Ana Kural

Senetle ispat zorunluluğu hakkındaki ikinci ana kural, senede karşı senetle ispat zorunluluğudur (senede karşı tanıkla ispat yasağıdır; m. 201). Buna göre, senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı def'i (savunma) olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler, m. 200, 1'deki tutardan az bir miktara ilişkin olsa bile tanıkla ispat olunamaz (m. 201); ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir.

Senede karşı senetle ispat zorunluluğu da, m. 201'de açıkça yazılı olduğu gibi, ancak ispat edilecek iddianın hukukî işlem olması halinde uygulanır. Buna karşılık, senede karşı ileri sürülen iddia (savunma) bir hukukî fiil ise, bu hukukî fiil tanıkla ispat olunabilir. Bu konuya ileride tekrar dönülecektir.

Senede karşı senetle ispat kuralına aşağıdaki durumlar örnek gösterilebilir:

Taraflar arasında yazılı bir ödünç sözleşmesi (senedi) varsa, borçlu ödünç almış olduğu parayı ödediğini senet (kesin delil) ile ispat edebilir; tanıkla ispat edemez. Ödünç alınan para veya ödendiği bildirilen para m. 200, 1'de belirlenen tutardan az olsa bile, ödünç sözleşmesi senede bağlı olduğu için, ödemenin de ancak senet (kesin delil) ile ispat edilmesi gerekir; tanıkla ispat olunamaz (m. 201).

Taraflar arasındaki yazılı kira sözleşmesinde kapı, pencere, vitrin, lavabo, elektrik tesisatı ve saati ve camlar ile kapıların sağlam olarak teslim edildiği yazılmış olmasına karşısında, davalı (kiracı), taşınmazı tam ve sözleşmeye uygun şekilde almadığını tanıkla ispat edemez. Çünkü m. 201'e göre, yazılı delile karşı tanık dinlenemez.

Bononun bedelsiz (karşılıksız) olduğu ve hatır için veya kredi temini için verildiği (veya böyle bir kambiyo senedine karşı muvazaa) iddiaları, tanıkla ispat edilemez; senede karşı senetle ispat kuralına göre, senet (kesin delil) ile ispat edilmelidir.

"Bedeli malen alındı" kaydını taşıyan bir bonoda, borçlu bunun aksini, yani malın teslim edilmediğini ancak yazılı (kesin) delil ile ispat edilebilir; tanıkla ispat edemez.

Tamamen doldurulmadan (beyaza imza ile) verilen bir kambiyo senedinin (örneğin bononun) anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu da tanıkla ispat edilemez; ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir.

Yazılı sözleşmenin değiştirildiği tanıkla ispat edilemez. Örneğin, yazılı bir sözleşmenin sonradan anlaşma ile feshedildiği (m. 201'e göre) tanıkla ispat edilemez; ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir. Bunun gibi, yazılı bir sözleşmenin ikinci bir sözleşme ile son bulduğu tanıkla ispat edilemez (m. 201); ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir.

Yazılı bir sözleşmenin tarafları, o sözleşmeye ilişkin muvazaa (TBK m. 19) iddialarını ancak yazılı (kesin) delil ile ispat edebilirler; tanıkla ispat edemezler (m. 201)[22].

Senede karşı ileri sürülen iddianın ispatı için (m. 201'e göre) gerekli olan senedin (yani her iki belgenin aynı çeşit belge) olmasına gerek yoktur. İkinci ana kurala göre, senede karşı ileri sürülen iddialar tanık (takdirî delil) ile ispat edilemez (m. 201); yalnız kesin delil ile ispat edilebilir. Senedin ise kesin delil teşkil etmesi bakımından, resmî senet ile adî senet arasında fark yoktur. Buna göre:

Bir adî senede karşı ileri sürülen iddia resmî senetle de ispat edilebilir. Bunun gibi, bir resmî senede karşı ileri sürülen iddia (imzası inkâr edilmemiş veya inkâr edilmiş olup da imzanın inkâr edene ait olduğuna mahkemece karar verilmiş olan) adî senetle de ispat edilebilir.

Senede karşı senetle ispat zorunluluğu, yalnız senedin tarafları içindir.

Buna karşılık, senedin taraflarından olmayan üçüncü kişiler, senede karşı olan iddialarını senetle ispat etmek zorunda değildirler. Çünkü üçüncü kişiler, senette taraf olmadıklarından senede karşı olan bir iddia (def'i) için senedin taraflarından senet almak imkânından yoksundurlar. Bu nedenle, üçüncü kişiler (taraf olmadıkları bir) senede karşı olan iddialarını tanıkla ispat edebilirler.

Buna göre, üçüncü kişiler (tarafı olmadıkları) bir sözleşmenin muvazaalı (TBK m. 19) olduğunu tanıkla ispat edebilirler (m. 203, 1/d).

Önalım davasında, davacı paydaş, pay satışı sözleşmesinde taraf olmadığından (üçüncü kişi olduğundan), satış bedelinin tapu dairesinde yapılan satış sözleşmesinde yazılı olan miktardan daha az olduğunu (bedelde muvazaayı) tanıkla ispat edebilir.

Senedin taraflarının mirasçıları (küllî halefiyet nedeniyle) kural olarak taraf kavramına dahildir. Bu nedenle, mirasçı, miras bırakanın taraf bulunduğu bir senede karşı ileri sürdüğü iddiayı (savunmayı) tanıkla ispat edemez (m. 201); ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir.

---

[22] Buna karşılık, üçüncü kişiler, sözleşmenin muvazaalı olduğunu tanıkla ispat edebilirler (m. 203, 1/d).

Buna karşılık mirasçı, miras bırakanın halefi olarak değil de, yalnız kendi hakkına (saklı payına) dayanmakta ise, o zaman miras bırakan ile bir üçüncü kişi arasındaki senede (sözleşmeye) karşı olan iddiasını senet (kesin delil) ile ispat zorunda değildir; tanıkla ispat edebilir. Çünkü, bu halde mirasçı yalnız kendi hakkına dayandığı (miras bırakanın halefi olarak hareket etmediği) için, miras bırakanı ile bir üçüncü kişi arasındaki hukukî işlem karşısında üçüncü kişi durumundadır. Mirasçının, miras bırakanı ile üçüncü kişi arasındaki bir hukukî işleme karşı olan iddiasını tanıkla ispat edebilmesi, daha çok miras bırakan ile bir üçüncü kişi arasında yapılan ve mirasçının saklı payına (mahfuz hissesine) tecavüz eden muvazaalı işlemler (yani mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla yapılan hukukî işlemler) için söz konusu olabilir. İşte mirasçı, bu gibi işlemlerin muvazaalı (TBK m. 19) olduğunu tanıkla ispat edebilir (m. 203, 1/d).

TMK'nun 7. maddesine göre, resmî sicil ve senetlerin "doğru olmadığını ispat, herhangi bir şekle bağlı değildir". Oysa, yukarıda görüldüğü gibi, HMK m. 201'e göre, resmî olsun olmasın bütün senetlere karşı olan iddialar, tanıkla ispat edilemez; ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir. Bu iki hükmün birbiriyle çelişmediği kanısındayız. Şöyle ki;

Resmî sicil ve senetlerin konusu bir hukukî işlem ise, bunun aksi tanıkla ispat edilemez; ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir (m. 201). Örneğin tapu dairelerinde düzenlenen resmî senetler ile tapu sicilinin konusu genellikle bir hukukî işlem olduğundan, bunların aksinin (örneğin yukarıda görüldüğü gibi muvazaa iddialarının m. 201'e göre senetle ispat edilmesi gerekir.

Buna karşılık, resmî sicil ve senetlerin konusu bir hukukî fiil ise, bunların aksi tanıkla ispat edilebilir (TMK m. 7); örneğin nüfus kayıtlarının aksi her türlü delil (ve bu arada tanık ile) ispat edilebilir[23].

2) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları

Senede karşı senetle ispat zorunluluğu kuralının, senede karşı tanıkla ispatın mümkün olduğu haller olarak da ifade edilebilen istisnaları vardır. Bunlar:

a) İkinci Ana Kuralın İstisnaları Daha Azdır

Birinci ana kuralda (m. 200, 1) olduğu gibi, senede karşı senetle ispat zorunluluğuna ilişkin ikinci ana kuralın (m. 201) da bazı istisnaları vardır. Ancak, ikinci ana kuralın istisnaları, birinci ana kuralın istisnalarından daha azdır. Çünkü, burada asıl hukukî işlem senede bağlandığı için, artık tarafların (birbirinden) senet almalarında (istemelerinde) manevî imkânsızlık bulunduğundan söz edilemez. Bu nedenle;

HMK m. 203, 1/a'da düzenlenen, yakın hısımlar arasındaki **hukukî işlem senede bağlanmış ise**, artık bu yakın hısımların birbirlerinden senet almalarında (istemelerinde) **manevî imkânsızlık bulunduğundan söz edilemez**.

---

[23] Nüfus kayıtlarının aksini ispatın bir şekle bağlı olmadığına ilişkin 1965 tarihli İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 162.

Bu nedenle, yakın hısımlar arasındaki senede karşı ileri sürülecek savunmalar tanıkla ispat edilemez; ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir. Örneğin, bir kimse (kendi) kardeşine borç verirken ondan bir senet almışsa, bu senedin aksi (örneğin, senetle alınmış bulunan bu borcun ödendiği vakıası) tanıkla ispat edilemez (karş. m. 203, 1/a); çünkü, bir kimsenin kendi kardeşine borç verirken ondan senet almış olması halinde, olağan şartlarda kardeşler arasında borç verirken, manevî nedenlerle, senet alınmama olgusu (manevî imkânsızlık) bu olay bakımından ortadan kalmış demektir. Bu nedenle, senede karşı tanık dinlenmesi ile ilgili m. 203, 1/a hükmündeki istisna, senede karşı senetle ispat kuralının istisnası olarak uygulanamaz.

Senede karşı def'i olarak ileri sürülen hukukî işlemin senede bağlanmamasının gelenek (teamül) olduğu (m. 203, 1/b) gerekçesiyle, senede karşı ileri sürülen bu hukukî işlem tanıkla ispat edilemez. Çünkü taraflar, aralarında (asıl) hukukî işlemi bir defa senede bağlamakla böyle bir geleneğin olmadığını veya bu geleneğin aksine hareket ettiklerini kabul etmiş sayılırlar.

Böylece, birinci ana kuralın (m. 200, 1) istisnası olup da senede karşı senetle ispat zorunluluğuna ilişkin ikinci ana kuralın (m. 201) istisnası sayılmayan durumları inceledikten sonra, ikinci ana kuralın istisnaları incelenebilir:

b) Senet Alınması Mümkün Olmayan Haller

Senede karşı def'i olarak ileri sürülen (karşılık) hukukî işlem (örneğin ödeme) yangın, deniz kazası, düşman istilâsı gibi senet alınması mümkün olmayan veya çok güç olan hallerde yapılmış ise, bu (karşılık) hukukî işlem (örnekte ödeme) tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/c).

c) Hukukî İşlemlerdeki İrade Bozukluğu veya Aşırı Yararlanma Halleri Tanıkla İspat Edilebilir

Yazılı sözleşmeye karşı ileri sürülecek irade bozukluğu (örneğin yanılma, hata) iddiasının tanıkla ispat edilmesinde çok titiz davranmak gerekir. Çünkü, her yanılma (TBK m. 31-35) iddiasının tanıkla ispat edilmesi yoluna gidilirse, m. 201'deki ikinci ana kural kolayca ihlâl edilebilir. Burada önce irade bozukluğunun varlığını makul gösteren objektif sebepler ayrıca ortaya konulmalı, ondan sonra yanılmanın (hatanın) ispatı için tanık dinlenmesine izin verilmelidir.

Örneğin, tapu dairesinde yapılan satış konusu taşınmazın parsel numarasını beyanda hata edildiğine ilişkin iddialar tanıkla ispatlanabilir.

Buna karşılık, borçlu senedi okumadan imza ettiğini bildirerek yanılma (veya aldatma) nedeniyle senedin iptalini isteyemez.

Bunun gibi, borçlu alacaklıya boş kâğıt (beyaza imza) verdiğini, alacaklının senedi anlaşmaya aykırı doldurduğunu ve bu nedenle kendisini hataya düşürdüğünü bildirerek, senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunu tanıkla ispat edemez.

Yazılı sözleşmeye karşı aldatma (hile) iddiası tanıkla ispat edilebilir. Örneğin, dededen kalan bir parça tarlanın miras yolu ile mirasçılara (taraflara)

geçmesinden sonra taraflar arasında tahsis anlaşması yapılmış ve sonunda davalının belli bir bedel ödemesi karşılığında, yerin ona verilmesi öngörülmüştür. Bedelin hemen ödeneceği mutabakatı üzerine düzenlenen belge imzalanıp davalıya verilmiş, davalı belgeyi cebine koyduktan sonra hileli davranışla parayı ödemeden toplantıyı terk etmiştir. Bu olay, borçlar hukuku anlamında hiledir (aldatmadır). Bu durumda davacının davada ileri sürdüğü hileye ilişkin olayları m. 201 hükmüne uygun biçimde tanıkla ispat edebilir.

Az sonra görüleceği gibi, bir kimsenin anlaştıkları gibi doldurması için güvenerek başkasına verdiği imzalı boş kâğıdın anlaşmaya aykırı doldurulması halinde aldatma (hile) söz konusu olmaz ve senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu tanıkla ispat edilemez. Fakat imzalı boş kâğıt o kimseden hile ile alınmışsa, bu husus (hile) tanıkla ispat edilebilir.

Bir kimseye güvenilerek o kimse tarafından anlaştıkları gibi doldurulmak (yazılmak) üzere verilmiş imzalı boş kâğıt (beyaz veya açık imza) o kimse tarafından anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulmuş ise, beyaz (açık) imzayı (imzalı boş kâğıdı) veren kişi (örneğin senet borçlusu), bu senedin (kâğıdın) aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu tanıkla ispat edemez; yani bu halde m. 203, 1/ç anlamında bir hile (aldatma) söz konusu değildir. Çünkü, bu halde imzalı boş kâğıt o kişiden (örnekte borçludan) hile ile alınmış değildir. İmzalı boş kâğıdı veren kişi, onun karşı tarafça doldurulacağını bilmekte ve ona güvenmektedir. Bu güvenin kötüye kullanılması hile teşkil etmez. İmzalı boş kâğıdı veren kişi, karşı taraftan bu kâğıdın ne için kullanılacağına ilişkin (yani aralarındaki anlaşma) senet (belge) almak (istemek) imkânına sahip olduğu için senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunu tanıkla ispat edemez (m. 201).

Yazılı bir sözleşmeye (belgeye) karşı ileri sürülen korkutma (tehdit, ikrah, TBK m. 37-38) iddiası tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/ç).

Yazılı bir sözleşmeye karşı ileri sürülen aşırı yararlanma (gabin-TBK m. 28) iddiası tanıkla ispat edilebilir (m. 203, 1/ç).

d) Hukukî İşlemlere ve Senetlere Karşı Üçüncü Kişilerin Muvazaa İddiaları Tanıkla İspat Edilebilir

İki taraf arasında yapılan muvazaalı (danışıklı) işlemden zarar gören üçüncü kişi, kendi aleyhine kullanılan hukukî işlemin veya senedin aksini, ancak tanıkla ispat edebilir (m. 203, 1/d).

e) Senedin Beklenmeyen Bir Olay Veya Zorlayıcı Nedenle Kaybolduğu Tanıkla İspat Edilebilir

Senede karşı def'i olarak ileri sürülen (karşılık) hukukî işlem, örneğin yapılan ödeme nedeniyle alınmış olan karşılık senet (makbuz) kaybolmuş (örneğin yanmış) ise, bu karşılık hukukî işlem (örnekte ödeme), m. 203, 1/e'deki şartların varlığı halinde tanıkla ispat edilebilir.

f) Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dinlenebilir

Senede karşı def'i olarak ileri sürülen (karşılık) hukukî işlem hakkında bir delil başlangıcı varsa, karşılık hukukî işlem bu delil başlangıcı ve tanık ile ispat edilebilir (m. 202).

g) Delil Sözleşmesi Varsa

Senede karşı def'i olarak ileri sürülen (karşılık) hukukî işlemin tanık ile ispat edilebileceği hakkında taraflar arasında bir delil sözleşmesi (m. 193; 200, 2) varsa, bu karşılık hukukî işlem tanıkla ispat edilebilir. Ayrı bir delil sözleşmesi yapılabileceği gibi, örneğin, senede bağlı olan borcunu ödediğini iddia eden davalının, bu ödemeyi tanıkla ispat etmesine davacı, açıkça izin verirse, davalı senede bağlı olan borcunu ödediğini tanıkla ispat edebilir (m. 200, 2). Bu hüküm (ve m. 193 hükmü) delil sözleşmesi başlığı altında aşağıda incelenecektir[24].

h) Senede Karşı Haksız Fiil İddiası Varsa

Senede karşı ileri sürülen haksız fiil iddiası tanıkla ispat edilebilir. Çünkü, haksız fiil m. 201'in düzenlediği (öngördüğü) anlamda bir hukukî işlem değildir.

3) İstisnalar Dışında Senede Karşı Senetle İspat Kuralı Uygulanır

Yukarıda incelenmiş olan istisnalar dışında, senede karşı def'i olarak ileri sürülen hukukî işlemlerin tanıkla ispatı mümkün değildir (m. 201); senetle (kesin delille) ispat olunması gerekir.

Birçok defa belirtildiği gibi, buradaki "senet" terimini, "kesin delil" olarak anlamak gerekir. Yani, senede karşı ispat zorunluluğu, aslında senede karşı kesin delille ispat zorunluluğudur. Çünkü, senede karşı olan iddiasını senetle ispat edemeyen taraf, bu iddiasını başka bir kesin delille ispat edebilir. Buna göre:

Senede karşı def'i olarak ileri sürdüğü bir hukukî işlem (örneğin ödeme) hakkında senedi olmayan (ve yukarıdaki istisnalardan birine de dayanmayan) taraf, bu karşılık hukukî işlemi, tanıkla ispat edemezse de, karşı tarafın ikrarı (m. 188) ile ispat edebilir.

Senede karşı olan iddiasını (örneğin ödeme iddiasını) senet ve ikrar ile de ispat edemeyen (ve m. 201 gereğince bu iddiasını tanıkla ispat etmesi yasak olan) taraf, son kesin delil olan yemine başvurabilir; yani, karşı tarafa yemin teklif edebilir (m. 225 vd.).

Bu yemin teklifi üzerine, karşı taraf yemin ederse, senede karşı olan iddia (örnekte ödeme iddiası) ispat edilememiş sayılır.

Yemin teklifi üzerine, karşı taraf yeminden kaçınırsa, senede karşı olan iddiayı (örnekte ödeme iddiasını) ikrar etmiş sayılır (m. 229); yani, ödeme iddiası (diğer bir kesin delil olan) yemin (veya ikrar) delili ile ispat edilmiş olur.

---

[24] Bkz. aşa. § 35.

Buraya kadar görüldüğü gibi, senede karşı senetle ispat zorunluluğu, senede karşı ileri sürülen iddianın hukukî işlem olması hali içindir. Buna karşılık, senede karşı ileri sürülen iddia hukukî fiil ise, bu hukukî fiil kuşkusuz tanıkla ispat edilebilir.

§ 29. YEMİN[1]

A) GENEL BİLGİ

Yemin (m. 225-239), taraflardan birinin, bir vakıanın doğru olup olmadığı hakkında "namusu, şerefi ve kutsal saydığı bütün inanç ve değerleri" üzerine beyanda bulunmasıdır. Bir vakıanın doğru olup olmadığına yemin edilirse, artık o vakıa hakkında başka delil gösterilmesine gerek yoktur; o vakıanın doğru olup olmadığı davada kesin olarak ispat edilmiş olur (**kesin delil**). Örneğin;

Davacı, davalıya on bin lira ödünç verdiğini bildirir; ancak bu iddiasını başka hiçbir delil (örneğin senet) ile ispat edemezse, davalıya, kendisinden (davacıdan) on bin lira ödünç almadığına dair yemin teklif eder. Davalı, davacıdan on bin lira ödünç almadığına yemin ederse, artık davalının davacıdan on bin lira ödünç almadığı kesin olarak ispat edilmiş olur. Buna karşılık davalı, davacıdan on bin lira ödünç almadığına yemin etmezse (yeminden kaçınırsa) davacıdan on bin lira ödünç almış olduğunu ikrar etmiş sayılır (m. 229); davalının davacıdan on bin lira ödünç aldığı hususu çekişmeli olmaktan çıkar. Yani bu ikrar bir kesin delildir (m. 188).

HMK, bir tarafın diğer tarafa teklif ettiği "taraf yemini"ni (m. 225-239) düzenlemiş; HUMK'nda yer alan "**tamamlayıcı yemin**"**e yer vermemiştir**. Yani, tamamlayıcı yemine başvurulması artık söz konusu değildir.

B) YEMİN TEKLİFİ

Bir vakıayı ispat yükü kendisine düşen taraf (örneğin, davacı), o vakıayı başka delillerle ispat edemezse, diğer tarafa (örnekte davalıya) yemin teklif eder. Yani, **yemin teklifini ispat yükü kendisine düşen** (ve fakat bunu yerine getirememiş olan) **taraf yapar.**

Yemin teklifi karşı (ispat yükü kendisine düşmeyen) **tarafa yapılır**. Kendisine yemin teklif edilen tarafa yemin davetiyesi gönderilmesi ve tarafın yemin teklifine karşı davranışı aşağıda incelenecektir.

Yemin deliline başvurulması halinde, yeminin delil gücü tamamen karşı tarafın yeminden korkup korkmamasına (yemine verdiği öneme) ve onun ahlâkî ve dinî (kutsal) inançlarına bağlı bulunduğundan, ispat yükü kendisine düşen taraf, diğer bütün delillerle iddiasını veya savunmasını ispata çalışıp bunu başaramadığı takdirde, **son çare** olarak yemin deliline başvurur (yemin teklif eder).

Davacı yemin deliline başvuracağını dava dilekçesinde açıkça belirtir (m. 119, 1/f). Bunun gibi, davalı da, karşı delil olarak yemin deliline başvurmak istiyorsa, bunu cevap dilekçesinde bildirir (m. 129, 1/e).

---

1 Bkz. Ejder Yılmaz, Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 2012.

Diğer deliller ile birlikte yemin teklifinde de bulunulması (m. 227, 1) halinde ilk önce diğer deliller incelenir; bunlar ile iddia (veya savunma) ispat edilirse, yemin teklifine gerek kalmaz (yani yemin teklif edilmemiş sayılır).

Kesin delil ile ispatı zorunlu olan bir vakıa (m. 200, 1 ve m. 201), kesin delillerle ispat edilemezse, ispat yükü kendisine düşen taraf takdirî delil (örneğin tanık) gösteremez; sadece karşı tarafa bir yemin teklif etme hakkına sahiptir.

Buna karşılık, kesin delil ile ispat zorunluluğu bulunmayan hallerde (örneğin m. 203'de düzenlenen istisnalarda), ispat yükü kendine düşen taraf, o vakıayı (kesin, takdirî) her türlü delille ispat etmeye çalıştığı halde ispat edemezse, o zaman karşı tarafa yemin teklif edebilir.

Başka bir deyişle, her halde yemin deliline en son (çare) olarak başvurulur.

Davacı dava dilekçesinde, davalı ise cevap dilekçesinde yemin deliline başvuracağını bildirmek zorunda olduğundan (m. 119, 1/f; 129, 1/e; 136), mahkemenin ancak bu durumda (dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde ya da ikinci dilekçelerinde, yemin deliline dayanıldığının bildirilmesi halinde) **yemin teklifini hatırlatmakla yükümlü** olduğu kanısındayız. Nitekim Yargıtay da bu yönde içtihatların birleştirilmesine karar vermiştir[2].

Kendisine yemin teklif etme hakkı hatırlatılan taraf, bunun üzerine karşı tarafa **yemin teklif ederse**, bundan sonra (aşağıda) incelenecek olan hükümler uygulanır. Yani karşı taraf yemin eder, yeminden kaçınır veya yemini (teklif edene) iade eder.

İspat yükü kendisine düşen taraf, yemin teklif etme hakkı bulunduğunun mahkemece kendisine hatırlatılması üzerine, **yemin teklif etmeyeceğini bildirirse**, artık bundan sonra yemin teklif etme hakkı kalmaz.

Kendisine ispat yükü düşmeyen tarafa belli bir vakıa hakkında yemin teklif edebilmek için, **vakıanın kişinin kendisinden kaynaklanması** (kendisine ilişkin olması) gerekir (m. 225, 1):

Örneğin davacı, kendisinden onbin lira ödünç alıp almadığı hakkında davalıya yemin teklif edebilir; çünkü ödünç alma vakıası davalının kendisinden kaynaklanmıştır (onunla ilgilidir).

Buna karşılık, ispat edilecek vakıa karşı tarafın kendisinden kaynaklanmıyorsa karşı tarafa yemin teklif edilemez.

Bir kimsenin bir şeyi bilmesi, onun kendisinden kaynaklanan vakıa (fiil) sayılır (m. 225, 1/c.2); yani o kimseye o vakıayı bilip bilmediği hakkında yemin teklif edilebilir. Örneğin;

Mirasçılara, miras bırakanları tarafından yapılan bir hukukî işlemi (veya vakıayı) bilip bilmedikleri hakkında yemin teklif edilebilir.

Evli kadın, kiracısına karşı kira bedelinin ödenmesi için bir alacak davası açar ve davalı (kiracı) da kirayı kadının kocasına ödediğini iddia ederse, kocasıyla bir arada yaşayan davacı **kadın kiranın kocasına ödenip ödenmediğini bilecek durumda olduğundan**, davalı kiracı, davacı kadına (m. 225/ c. 2'ye göre) kiranın ödenip ödenmediği hakkında yemin teklif edebilir.

---

[2] Bkz. yuk. § 17. B, I, 7.

Yeminin konusu davanın (iddianın) veya savunmanın dayanağını oluşturan ve **davanın halline** (çözümlenmesine) **etkili** olan belirli vakıalardır (m. 225/ c. 1).

Hukukî sebepler, yemin konusu olamaz. Yani, hukukî sebepler (kanun hükümleri) hakkında yemin teklif edilemez. Çünkü, hâkim hukukî sebepleri kendiliğinden araştırıp uygulamakla yükümlüdür (m. 33).

Yemin teklif eden taraf, kendisine yemin teklif olunan (karşı) taraf yemin etmeye hazır olduğunu (mahkemeye) bildirinceye kadar, yemin teklifinden vazgeçebilir ve başka delil gösterebilir (m. 227).

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri vakıalar hakkında; kendiliğinden harekete geçme ve araştırma ilkeleri uygulanan davalarda yemin teklif edilemez (m. 226, 1/a; TMK m. 184/2).

Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği haller de yemine konu olmaz (m. 226, 1/b).

Bundan başka, yemin edecek tarafın (kimsenin) namus ve haysiyetini etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar hakkında yemin teklif edilemez (m. 226, 1/c). Örneğin, dava konusu senet altındaki imzanın kendisine ait olmaması hali (sahtecilik suçuna) suça vücut verebileceğinden, imzanın aidiyeti konusunda yemin teklif edilemez.

Burada incelenen yemin bir delildir. Bu nedenle, yemin ancak delillerle ispat edilebilen hususlar hakkında teklif olunabilir. Geçerliliği şekle tâbi olan bir sözleşme, kanunun aradığı şekilde yapılmamış ise, bu sözleşmenin varlığı başka delillerle ispat edilemeyeceği için, bu konuda karşı tarafa yemin de teklif edilemez[3].

C) KENDİSİNE YEMİN TEKLİF EDİLEN TARAFIN YEMİN İÇİN DAVET EDİLMESİ VE BUNA KARŞI DAVRANIŞI

Kendisine yemin teklif edilen (karşı) taraf davasını kendisi takip etmekte ve yemin teklif edilen duruşmada (oturumda) hazır ise, yemin için bir oturum belirlenmesine ve kendisinin yemin için çağrılmasına gerek yoktur.

Buna karşılık, kendisine yemin teklif edilen taraf davasını bir vekil aracılığı ile takip etmekte veya tahkikata yokluğunda devam edilmekte (m. 147), yani yemin teklif edilen duruşmada hazır değilse, yemin için bir gün ve saat belirlenerek taraf bu duruşmaya davet edilir (m. 228, 1). Bu çağrı karşı tarafa çıkarılacak (gönderilecek) yemin davetiyesi ile olur. Yemin davetiyesine, yemine konu hususlar (vakıalar) ile yemin için çağrılacak tarafın, geçerli bir özrü olmaksızın yemin için belirlenen günde (mahkemeye) bizzat gelmediği takdirde yeminden kaçınmış ve yemin edeceği vakıaların sabit olmuş sayılacağına karar verileceği bildirilir (m. 228, 2)[4].

---

[3] Bkz. yuk. 29, B.

[4] Kendisine yemin teklif edilen (karşı) taraf davayı bir vekil aracılığı ile takip etmekte olsa bile, yemin davetiyesi (karşı) tarafın (vekiline değil) bizzat kendisine tebliğ edilmelidir (gönderilmelidir) (karş. Teb. K. m. 11).

Tahkikat karşı tarafın yokluğunda yapılmakta olsa bile, kendisine (karşı tarafa) yemin teklif edilebilir ve yemin davetiyesi gönderilebilir. Bu halde, yemin için gelen taraf, yemini kabul veya ret ile yetinebileceği gibi, başka bir def'i de ileri sürebilir; yani, tahkikatın bundan sonraki aşamasında hazır bulunabilir.

Kendisine yemin teklif edilen tarafa yemin davetiyesinin tebliğinden sonra, iki ihtimal (olasılık) ile karşılaşılır:

I – YEMİN TEKLİF EDİLEN TARAF ÇAĞRILDIĞI OTURUMA GELMEZSE

Kendisine yemin teklif edilen taraf, geçerli bir özrü olmaksızın yemin davetiyesi ile çağrıldığı oturuma gelmezse, o tarafın yeminden kaçınmış ve yemin edeceği vakıaların da ikrar edilmiş (sabit olmuş) sayılmasına karar verilir (m. 229).

II – YEMİN TEKLİF EDİLEN TARAF ÇAĞRILDIĞI OTURUMA GELİRSE

Kendisine yemin teklif edilen taraf, yemin davetiyesi üzerine çağrıldığı oturuma gelirse, üç şekilde davranabilir:

1) Yemin Teklifinin Kabulü ve Yemin Edilmesi

Yemin için çağrıldığı oturuma gelen veya yemin teklif edilen oturumda hazır bulunan taraf, yemin etmeye hazır olduğunu bildirebilir; buna **yemin teklifinin kabulü** denir.

Tarafın yemin için çağrıldığı oturuma gelmiş olması, yemin teklifini zımnen kabul ettiği anlamına gelir.

Kendisine yemin teklif edilen taraf, yemin etmeye hazır olduğunu (yemini kabul ettiğini) bildirdikten sonra, artık yemin teklif eden, yemin teklifinden vazgeçip, başka delil gösteremez (m. 227, 2).

Taraf, yemin teklifinin kabulünden sonra, usulüne (m. 233) uygun biçimde yemin ederse, yemin teklif eden tarafın iddia ettiği vakıanın mevcut olmadığı ispat edilmiş olur (kesin delil).

Kendisine yemin teklif edilen taraf yemin ettikten sonra, yemin teklif eden taraf, yemin ile mevcut olmadığı kesin olarak ispat edilmiş olan vakıayı ispat etmek için başka delil gösteremez.

Yemin eden tarafın yemin beyanının bir bütün halinde kabul edilmesi ve buna göre hüküm verilmesi gerekir. Aynı nedenle, kanımızca yemin eden, mahkemenin hazırladığı yeminli ifade metnini aynen tekrarlamak zorunda olmayıp, kendisine sorulan sorulara metin dışı bazı açıklamalar yapmak suretiyle cevap verebilir; bu halde mahkemenin, yemin edenin sözlerini bölmeden tüm olarak değerlendirmesi gerekir.

Yemin eden, yalan yere yemin etmiş olabilir. Ancak, yemin teklif eden taraf, yeminin yalan yere olduğunu artık hukuk mahkemesinde (aynı davada) ileri süremez ve mahkeme yeminin yalan yere olduğunu kabul ederek yemin teklif eden tarafın başka delil göstermesine izin veremez.

Yalan yere yemin edilmiş olması bir suçtur (TCK m. 275)[5]. Bu nedenle, yeminin yalan yere edilmiş olduğu hakkında, yalan yere yemin ettiği iddia edilen tarafa karşı, ancak (Cumhuriyet Savcısı tarafından) ceza davası açılabilir.

Yalan yere yeminden dolayı açılan ceza davası, görülmekte olan (yalan olduğu iddia edilen yeminin edildiği) hukuk davasının ertelenmesini gerektirmez (m. 239).

Ceza davasında yeminin yalan olduğuna karar verilirse, yemin teklif eden davada verilen hükmün kesinleşmiş olması halinde yargılamanın iadesi yoluna başvurabilir (m. 375, 1/g).

Yalan yere yemin ettiği ileri sürülen taraf hakkında, delil yokluğundan başka bir sebeple ceza kovuşturmasına başlanamamış veya karar verilememiş ise, ilgili taraf, doğruca hukuk mahkemesinde yargılamanın iadesi davası açabilir; bunun için ayrı bir tespit davası açamaz (m. 375, 2).

2) Yeminden Kaçınma

Yemin için çağrıldığı oturuma gelen taraf, yemin etmez ve yemini (onu teklif eden tarafa) reddetmezse yeminden kaçınmış (çekinmiş) ve böylece yemin konusunu teşkil eden vakıayı **ikrar** (m. 188) **etmiş sayılır** (m. 229, 1).

3) Yeminin İadesi

Kendisine yemin teklif edilen taraf, bu yemini teklif eden tarafa **iade edebilir** (reddedebilir); yani, "ben yemin etmiyorum, karşı taraf yemin etsin" diyebilir (m. 229, 1).

Kendisine yemin teklif edilen tarafın, yemini teklif edene iade (ret) edebilmesi için, yemin konusu vakıanın (fiilin) aynı zamanda yemin teklif edenin kendisinden kaynaklanması, yani, ispatı söz konusu olan **vakıanın iki taraf arasında ortak olması** gerekir (m. 230). Örneğin davacı, davalının kendisinden on bin lira ödünç almadığına yemin etmesini teklif ederse, davalı "bana on bin lira ödünç verdiğine davacı kendisi yemin etsin" diyerek, yemini onu teklif eden davacıya iade edebilir.

Buna karşılık, bir önalım davasında, davalının davacıya satışı daha önce öğrenmemiş olduğu hakkında yemin teklif etmesi üzerine, davacı, "satışı daha önce öğrendiğime davalı yemin etsin" diyerek yemini davalıya iade edemez. Çünkü davacının satışı öğrenmesi vakıası, davalıdan (kendisinden) kaynaklanmamıştır.

Kendisine yemin iade edilen taraf, yemin ederse, o vakıanın mevcut olduğu (kesin delille) ispat edilmiş sayılır; yeminden kaçınırsa, yemin konusu vakıanın mevcut olmadığını ikrar etmiş sayılır (m. 229, 2).

---

[5] Bu nedenle, hâkim, yeminden önce, yalan yere yeminin sonuçları hakkında yemin edecek tarafın dikkatini çeker (m. 233, 2).

D) YEMİN TARAFLARCA EDİLİR

Yukarıda da görüldüğü gibi, yemin ancak taraflarca teklif edilebilir ve tarafların kendilerine iade edilebilir. Yemin, ancak kendisine yemin teklif edilen veya yemin kendisine iade edilen **tarafın kendisi tarafından** edilir; yani eda olunur (m. 232, 1). **Vekil**, müvekkili adına **yemin edemez.**

Yemin edecek taraf kısıtlı veya ergin olmayan (on sekiz yaşından küçük) kişi ise, yemin velisine veya yasal temsilcisine (vasisine) teklif veya iade olunabilir (m. 232, 2). Yasal temsilci, ancak kendisinden kaynaklanan (kendisine ilişkin olan veya kişisel olarak öğrendiği) vakıalar hakkında yemin edebilir. Yemin konusu vakıa kısıtlının, kısıtlanmasından önceki döneme ait ise (kısıtlıdan kaynaklanmışsa), bunu vasi bilemeyeceğinden, bu konuda vasiye yemin teklif edilemez veya yemin vasiye iade olunamaz.

Tüzel kişilerin taraf olduğu davalarda, tüzel kişiye teklif edilen yemin tüzel kişinin organı (yasal temsilcisi, TMK m. 50) tarafından eda edilir.

E) USUL HÜKÜMLERİ

Yemin, **mahkeme huzurunda** icra olunur (m. 233, 1). Bu mahkeme, davaya bakan mahkemedir.

Ancak, yemin edecek taraf, davaya bakan mahkemenin yargı çevresi dışında oturmakta ise, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorunda değildir; bulunduğu yerdeki Türk mahkemesi veya yabancı mahkeme huzurunda **istinabe yolu ile yemin** etmesi istenebilir (m. 236).

Yemin ettirilmesi aşağıdaki sıraya göre olur:

Hâkim, ilk önce **yemin şeklini** (formülünü, sorusunu) **tespit** eder. Yukarıda görüldüğü gibi, yemin teklif eden taraf hangi vakıa hakkında yemin teklif ettiğini bildirir; yemin şeklini (sorusunu) ise mahkeme tespit eder. Hâkimin tespit ettiği yemin şeklinin yemin teklif eden tarafın teklifine uygun düşüp düşmediğini denetlemek için ve yemin teklifinin taraflar bakımından olan öneminden dolayı, yemin şeklinin duruşma tutanağına yazılması ve okunarak yemin teklif edene imza ettirilmesi uygun olur (m. 154, 3/ç kıyasen).

Bundan sonra, hâkim hazırladığı yemin şeklini (sorusunu) okuyup durumun önemi ve yalan yere yeminin sonuçları (TCK m. 287) hakkında yemin edecek tarafın dikkatini çeker (m. 233, 2).

Yemin edecek kimse, yemin konusunun yeterli açıklıkta olmadığını ileri sürerse, hâkim karşı tarafın görüşünü aldıktan sonra derhal bu konuda karar verir ve gerekirse yemin konusunu yeniden belirler.

Daha sonra hâkim, yemin edecek tarafa "size sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?" diye sorar ve yemin edecek taraf da "Namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyorum" der (m. 233, 4). Bu hükme göre, yemin, yemin edecek tarafın cevabına (ifadesine) başlamadan önce ettirilir.

Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler, yemin hakkındaki beyanlarını yazıp imzalayarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır ve dilsizler ise, işaretlerinden anlayan bir bilirkişi aracılığıyla yemin ederler (m. 234).

Yemin eda ettirilirken, hâkim de dahil olmak üzere hazır bulunan herkes ayağa kalkar (m. 233, 5).

Mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya engelli tarafın yeminini, hâkim, onun bulunduğu yerde yaptırır; isterlerse, taraf vekilleri veya karşı taraf da yemin sırasında hazır bulunabilirler (m. 235).

Yemin edecek olan taraf, mahkemenin yargı çevresi dışında oturuyorsa, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorundadır. Ancak yemin edecek taraf, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkün değil ise istinabe yolu ile yemin ettirilir (m. 236; 197). Görüldüğü gibi Kanun, yeminin olabildiğince davaya bakan hâkimle yüz yüze gelerek yapılmasına önem vermektedir. Yeminin istinabe ile yapılma alanı daraltılmıştır.

Hâkim, yemin eden tarafın ifadesini[6] dinleyip aynen tutanağa geçirdikten (m. 154) ve yazılanları yüksek sesle huzurunda okuduktan ve yemin eden tarafa bu ifadesinde ısrar edip etmediğini sorduktan sonra cevabı tutanağa kaydeder (m. 238). Hâkimin sorusu üzerine, yemin eden ifadesinde ısrar etmediğini bildirirse, yeminin hükmü kalmaz. Hâkimin sorusu üzerine, yemin eden ifadesinde ısrar ettiğini bildirirse, bu husus da tutanağa yazılır ve tutanağın altı yemin edene imza ettirilir; bununla yemin tamam olur.

Hâkim, eksik olan noktaları tamamlamak veya açık olmayan hususları aydınlatmak için yemin konusu (m. 225) ile bağlantılı gördüğü soruları yemin eden kimseye sorar (m. 237).

Yemin eda edildikten sonra, yalan yere yemin nedeniyle açılan ceza davası (TCK m. 275), esas dava bakımından bekletici sorun yapılamaz (m. 239).

---

[6] Kanımızca, yemin edecek taraf, ifadesinde mahkemenin hazırlamış olduğu yemin şekli dışında bazı ek açıklamalar yapabilir.

TAKDİRÎ DELİLLER

Takdirî deliller kavramı yukarıda kısaca incelenmişti. Orada da belirtildiği gibi, "takdirî deliller" kavramı, şimdiye kadar incelenmiş olan "kesin deliller" kavramının karşıtıdır.

Kesin deliller, hâkimi bağlayıcı niteliktedir. Buna karşılık, hâkim, takdirî delilleri **serbestçe takdir** eder. Özellikle, tanık ve bilirkişilerin beyanları hâkimi bağlamaz (m. 198; 282). Keşifte ise, delil, esasen hâkimin kendi hisleri (duyu organı) ile saptadığı hususlardır.

Hukukumuzda, m. 200, 1'de belirlenen sınırdan yukarı hukukî işlemler (m. 201, 1) ve senede karşı iddialar (m. 201) kural olarak sadece senet (kesin delil) ile ispat edilebileceğinden, takdirî delillerin önemi, kesin delillere oranla daha azdır. Esasen, takdirî delillerin ispat gücü de kesin delillere oranla daha azdır; yani, hâkimin takdirine bağlıdır.

Ancak, kesin delille ispat zorunluluğuna istisna teşkil eden hallerde (m. 193; 201, 2; 202; 203) ve hukukî fiillerde, takdirî delillere başvurulacaktır.

HMK'nda takdirî deliller tanık (m. 240-265); bilirkişi incelemesi (m. 266-287); keşif (m. 288-292) ve kanunda düzenlenmemiş diğer deliller (m. 192) olarak düzenlenmiştir. HMK'nda ilk defa yer alan uzman görüşü (m. 293) de takdirî deliller arasında sayılabilir.

§ 30. TANIK

A) GENEL BİLGİ

Tanıklık[1] (şahitlik) üçüncü kişilerin (davanın tarafları dışındaki kişilerin), dava ile ilgili bir vakıa hakkında, dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiyi mahkemeye bildirmeleridir. Örneğin, haksız fiilden dolayı tazminat davasında, haksız fiilin meydana geldiği anda (örneğin trafik kazası anında) tesadüfen orada bulunan bir kimsenin, kazanın oluşu hakkındaki bilgisini mahkemeye anlatması gibi.

Tanıklık yapan kişiye tanık (şahit) denir. Tanık, davanın taraflarından başka biridir; **üçüncü kişi**dir. Taraflar kendi davalarında tanık olamazlar. Tarafların dava hakkındaki bilgisinden isticvap yolu (m. 169 vd.) ile yararlanılır.

Ancak, ergin olmayan veya kısıtlı olmaları nedeniyle isticvap yolu ile dinlenemeyen taraflar (m. 170), tanık olarak dinlenip, belli bir vakıa (örneğin haksız fiil) hakkında onların bilgilerinden de yararlanılabilmelidir.

Taraflardan birinin vekili (avukatı), üçüncü kişi olduğundan, tanık olarak dinlenebilir. Buna karşılık, tarafların yasal temsilcileri tanık olamaz. Yasal temsilcilerin bilgisinden de isticvap yolu ile yararlanılabilir (m. 170).

Tüzel kişinin taraf olduğu bir davada, o **tüzel kişinin organı** (yasal temsilcisi) durumundaki kişiler tanık olarak dinlenemez.

Köy orta mallarını ilgilendiren davalarda, davanın tarafı köy halkından olanların, orta mallarından yararlanmaları doğal olduğundan davada hukukî yararları vardır (karş. m. 255); bu nedenle, bu kişiler mensup oldukları köyün taraf bulunduğu davalarda tanık olamazlar. Tanıkların, davada taraf olan köylere mensup olmayan kişilerden gösterilmesi gerekir.

B) TANIK İLE İSPATIN MÜMKÜN OLDUĞU HALLER

Tanık ifadesi, çok güvenilir, güçlü (sağlam) bir delil değildir. Tanığın bir vakıayı/vakıaları tamamen hatırında tutması ve gerçeği olduğu gibi anlatması zor olabileceği gibi; tanığın eğitimi, entelektüel birikimi, duyu organlarının (görme, işitme, duyma vb.), belleğinin güçlü olup olmaması da tanığın verdiği bilgilerin güvenilirliğini etkiler. Bundan başka, ahlâk, din, şeref ve namus gibi manevî değerlere fazla önem vermeyen kişilerin, bilerek gerçeğe aykırı tanıklık yapmaları da mümkündür. Bundan dolayı, tanıklık ancak küçük tutarlı hukukî işlemler ve senede bağlanması imkânsız olan hukukî işlemler ile hukukî fiiller için başvurulabilen bir delildir.

Hangi hukukî işlemlerin senet (kesin delil) ile ispat edilmesinin zorunlu olduğu yukarıda incelendi[2]; bu hukukî işlemler tanıkla ispat edilemez.

---

1 Bkz. Mesut Ertanhan, Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Ankara 2005.

2 Bkz. m. 200 ve m. 201; yuk. § 28, D.

Bunların dışındaki hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir. Buna göre, m. 200, 1'de belirlenen sınırı geçmeyen hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir. Bundan başka, senetle ispat zorunluluğuna ilişkin ana kuralın (m. 201) istisnalarında da tanık dinlenebilir. Bu haller de yukarıda incelendi[3]. Bütün **hukukî fiiller** tanıkla ispat edilebilir. Bu konu da yukarıda incelendi[4].

C) TANIKLARIN GÖSTERİLMESİ

Davada, tanıklar **taraflarca** gösterilir (m. 240, 1). Mahkeme, tarafların tanık olarak göstermedikleri kişileri kendiliğinden tanık olarak dinleyemez.

İddia veya savunmasını tanıkla ispat etmek isteyen taraf (kural olarak ispat yükü kendisine düşen taraf), ilk önce tanıkların hangi husus hakkında dinleneceklerini mahkemeye bildirir ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebligata elverişli adreslerini içeren **tanık listesi**ni mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kişiler tanık olarak dinlenemez; **ikinci** bir **tanık listesi de verilemez** (m. 240, 2).

Tarafın mahkemeye verdiği tanık listesinde adres gösterilmemiş veya tanık gösterilen adreste bulunmamışsa, mahkeme tarafa adres (duruma göre, tebligata elverişli yeni adres) göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin bir süre (m. 94) verir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adreste tebligat yapılamazsa (bu adres de doğru adres değilse), bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır (m. 240, 3)[5].

Tarafın tanık dinletme talebi üzerine mahkeme, o hususun tanıkla ispat edilmesinin mümkün olup olmadığını inceler ve bu konuda bir karar verir. Örneğin, davacı m. 200, 1'deki tutardan fazla bir hukukî işlemi tanıkla ispat etmek isterse; ancak, ispat edilecek vakıa (konu), tanık dinlenilmesi mümkün olan istisnalardan birine uygun değilse, mahkeme, o hukukî işlemin tanıkla ispat edilemeyeceğine (yani tanık gösterme talebinin reddine) karar verir. Ancak, mahkemenin, bu halde tanık gösterme talebinin reddine karar vermeden önce, karşı taraftan (örnekte davalıdan) tanık dinletilmesine izni olup olmadığını sorması gerekir (m. 200, 2)

Tarafın dinlenilmesini istediği çok sayıda tanık varsa, mahkeme, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeterli derecede bilgi edinirse, usul ekonomisi (m. 30) çerçevesinde, geri kalan tanıkların dinlenilmemesine karar verebilir (m. 241).

İkinci tanık listesi verme yasağı, **kamu düzenine ilişkin**dir. Çünkü bu yasak, yargılamanın sürüncemede bırakılmasını önlemek ve mahkemelerin işini azaltmak amacıyla konulmuştur. Bu nedenle, karşı taraf ikinci tanık listesi verilmesine razı olsa bile, mahkeme ikinci tanık listesindeki tanıkları dinleyemez. İkinci tanık listesi verme yasağı, yalnız tarafların dilekçelerinde, gösterdikleri vakıalar ve bu vakıaların ispatı için başvuracaklarını bildirdikleri tanık-

---

3 Bkz. m. 202, 203; yuk. § 28, D, II, 2.

4 Bkz. yuk. § 28, D, II, 4.

5 Bu hükmün Anayasaya aykırı olmadığına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 11.10.2010 gün ve 69/149 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası- Usul Pratik, s. 126-127.

lar içindir. Buna karşılık, taraf, ispat etmek istediği başka **(yeni) bir vakıa hakkında** (davanın veya savunmanın genişletilmesi yasağı sınırları içinde) **yeni bir tanık listesi verebilir.**

Buraya kadarki açıklamalar, taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalar içindir. Buna karşılık, **kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda ikinci bir tanık listesi verilebilir**. Örneğin;

Velayetin kaldırılması işlerinde, ikinci tanık listesi verilebilir.

Boşanma davalarında, TMK m. 184 hükmü gereğince, tanık listesi dışında (ikinci tanık listesi ile) gösterilen tanıklar dinlenebilir.

Bir taraf, tanık listesinde göstermiş olduğu tanıkların (bir kısmının veya tümünün) dinlenmesinden vazgeçebilir; bunun için karşı tarafın izni gerekli değildir (karş. m. 196). Ancak, karşı taraf, tanık listesini veren tarafın dinlenmesinden vazgeçmiş olduğu tanıkların dinlenmesini kendisi isteyebilir.

D) TANIKLARIN MAHKEMEYE DAVET EDİLMESİ

Tanıklar, usulüne (Teb. K. m. 9) göre tebliğ olunacak davetiye ile mahkemeye çağrılır (m. 243, 1/c. 1).

Bu davetiyede tarafların isimleri, tanıklık konusu (tanığın hangi hususu - vakıayı- ispat için mahkemeye çağrıldığı) ve hangi gün ve saatte hazır bulunacağı, gelmemesinin veya gelmesine karşın tanıklıktan ya da yemin etmekten çekinmesinin hukukî ve cezaî sonuçları ve kendisine Tarife uyarınca ücret ödeneceği yazılır (m. 244).

Tanık davetiyesinin duruşma gününden en az bir hafta önce tebliğ edilmesi gerekir; acele hallerde bu süre kısaltılabilir (m. 243, 2). Davet, gerektiğinde telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla da yapılabilir; ancak, bu gibi durumlarda, davete rağmen gelmemeye bağlanan sonuçlar (m. 245) uygulanmaz (m. 243, 3).

Yukarıda belirtildiği üzere, tanığın dinlenilmesi için, usulüne göre davet edilmesi gerekir ise de; tarafın, davetiye tebliğ edilmeden de gösterdiği tanıkları mahkemede hazır bulundurması mümkün olup, mahkeme bu tanıkları da dinler (m. 243, 1/c.2). Tanık listesi için kesin süre verilen ve dinlenme günü belirlenen durumlarda, tanık listesi verilmemiş olsa dahi, taraf, tanıkları o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir (m. 243, 1).

Hâkim gerekli görülen durumlarda, sözlü olarak dinlenmek yerine, belirlenecek süre içinde cevaplarını yazılı olarak bildirmesi için **tanığa soru kâğıdı gönderilmesi**ne karar verebilir. Böyle durumlarda verilen cevabın yeterli görülmemesi halinde, tanık mahkemeye davet edilir (m. 246).

E) TANIKLIK ETMEK ZORUNLUDUR

Kural olarak, Türk yargısına tâbi olmak şartı ile herkes tanıklık etmek zorundadır (m. 245). Bu zorunluluk, tanık olarak yapılan davet üzerine mahkemeye gelmeyi, tanıklık etmeyi ve yemin etmeyi kapsar.

Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek,

kamu alacakları gibi ödettirilir. Mazeret bildirmeden gelmeyen tanık ayrıca disiplin para cezasına mahkûm edilir. Zorla getirilen tanık gelmemesini haklı gösterecek nedenleri sonradan bildirirse, aleyhine takdir edilen (hükmedilen) giderler ve disiplin para cezası kaldırılır; ödettirilmez veya geri verilir (m. 243).

Mahkemeye gelip de tanıklıktan veya yeminden kaçınan tanığın bu yüzden doğacak giderleri ödemesine ve ayrıca disiplin para cezasına çarptırılmasına karar verilir (m. 253, 1). Tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemekte direnirse, mahkemece iki haftayı geçmemek üzere, disiplin hapsine mahkûm edilir (m. 253, 2).

Tanık olarak mahkemeye gelmek zorunluluğuna karşılık, tanığa, Adalet Bakanlığınca hazırlanan Tarifeye[6] göre, kaybettiği zaman ile orantılı bir ücret verilir. Tanık mahkeme önünde hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, tanığın yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Bu ücret ve giderler herhangi bir vergi, resim ve harca tâbi değildir (m. 265).

F) TANIKLIKTAN ÇEKİNME

Bazı kişiler için tanıklık etmek zorunlu değildir. Bu kişiler, isterlerse tanıklık etmeyebilir, yani tanıklıktan çekinebilirler (m. 247).

I – KİŞİSEL NEDENLERLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME

Kişisel nedenlerle (genel olarak, yakınlık/hısımlık sebepleriyle) tanıklıktan çekinme hakkı olanlar, m. 248'de **sınırlı olarak sayılmıştır**:

İki tarafın birinin nişanlısı (m. 248, 1/a); aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile iki taraftan birinin (karı veya kocası) eşi (m. 248, 1/b); kendisi veya eşinin altsoyu veya üstsoyu (m. 248, 1/c); taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar (m. 248, 1/ç); üçüncü dereceye kadar (bu derece de dahil olmak üzere), iki taraftan birinin kan veya (kendisiyle kayınlık -sıhriyet- hasıl olan evlilik bağı kalkmış olsa bile) kayın hısımları (m. 248, 1/d); koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk[7] (m. 248, 1/e) bakımından tanıklıktan çekinme hakkı vardır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, m. 248'deki sayma sınırlıdır. Bu maddede sayılmayanların ve sayılanlardan daha uzak derecedeki yakınların (hısımların) tanıklıktan çekinme hakkı yoktur.

II – SIR NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME

Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgilere sahip olanlar tanıklıktan çekinebilirler; ancak o kimse (sırrı bilinen) izin verirse, tanıklıktan çekinemezler (m. 249).

Örneğin, avukatların, görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır; bu hususlarda tanıklık edebilmeleri için, iş sahibinin iznini

---

6 Bkz. HMK Tanık Ücret Tarifesi (RG 29.09.2018, sa. 30550).

7 Bkz. Çocuk Koruma K. m. 5 vd.

almış olmaları gerekir (AK m. 36). Ancak, bu halde (iş sahibinin iznini almış olması halinde) dahi, avukat tanıklıktan çekinebilir (AK m. 36, II/c.2).

III – MENFAAT İHLÂLİ TEHLİKESİ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME

Tanık, kendisinin veya yakınlarının menfaatinin söz konusu olduğu aşağıdaki hallerde tanıklıktan çekinebilir (m. 250):

Tanığın beyanı, tanığın kendisine veya m. 248'de sayılan yakınlarından birine doğrudan doğruya maddî (malî) bir zarar verecek nitelikte ise (m. 250, 1/a); tanıklık etmesi, tanığın kendisinin veya m. 248'deki yakınlarından birinin şeref ve itibarlarını (saygınlıklarını) ihlâl edecek veya haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılmasına neden olacak ise (m. 250, 1/b) veya tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkması sonucunu doğuracaksa (m. 250, 1/c), menfaat ihlâli nedeniyle tanıklıktan çekinmek mümkündür.

IV – TANIKLIKTAN ÇEKİNMENİN CAİZ OLMADIĞI HALLER

Yukarıda üç grup altında sayılan kişiler için tanıklık etmek zorunlu değildir. Bu kişiler, isterlerse tanıklık etmeyebilirler; yani tanıklıktan çekinebilirler. Ancak 248 ve 249. maddeler ile 250. maddenin (a) bendi hükümlerine göre tanıklıktan çekinme hakkı olan bir kimsenin, tanığı bulunduğu ve onun tanıklığından başka bir delille ispatı imkânsız veya çok güç olan aşağıdaki hallerde tanıklıktan çekinilemez:

Hukukî bir işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan kimse, bu işlemin esası ve içeriği hakkında tanıklıktan çekinemez (m. 251, 1/a).

Aile bireylerinin arasındaki doğum, ölüm ve evlenme olayları hakkında tanıklıktan çekinilemez (m. 251, 1/b).

Aile bağlarından doğan malî anlaşmazlıklar hakkında tanıklıktan çekinilemez (m. 251, 1/c).

İki taraftan birinin hukuken selefi (önce geleni) veya temsilcisi sıfatıyla tanığın kendisinin yaptığı işler hakkında tanıklıktan çekinilemez (m. 251, 1/ç).

V – TANIKLIKTAN ÇEKİNME USULÜ

Az önce belirtilen (m. 251'deki) istisnalar dışında, m. 248 ve 249'daki kişiler, tanıklıktan çekinebilirler.

Hâkim, kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kişilere (m. 246), çekinme hakkı bulunduğunu önceden hatırlatır (m. 247, 2).

Tanıklıktan çekinen kimse, çekinme sebebini ve delilini dinleneceği günden önce, zabıt kâtibine yazdırmak suretiyle sözlü olarak veya yazılı olarak mahkemeye bildirmek zorundadır (m. 252, 1). Bu şekilde önceden bildirimde bulunan tanık, belli günde mahkemeye gelmek zorunda değildir.

Tanığı göstermiş olan taraf çekinme beyanını kabul ederse, o tanığı dinletmekten vazgeçmiş sayılır. Bu halde, mahkemenin tanığın çekinme isteği hakkında ayrıca karar vermesine gerek yoktur.

Tanığı göstermiş olan taraf, onun çekinme beyanını kabul etmezse, hâkim, iki tarafı da dinleyip bu konudaki delili inceledikten sonra, tanığın çekinme isteği hakkında karar verir (m. 252, 3).

G) TANIKLARIN DİNLENMESİ

Tanıklar, kural olarak, davaya bakan mahkemede dinlenir (m. 197; 259).

Hastalığı veya engelli olması nedeniyle mahkemeye gelemeyen tanık, bulunduğu yerde (örneğin evinde, hastanede) dinlenir (m. 259, 3).

Tanıkların dava ile ilgili bir yeri (veya şeyi) göstermeleri suretiyle dinlenmelerinin gerçeği daha iyi aydınlatacağı umulan hallerde, tanıkların yerinde dinlenmesine karar verilebilir (m. 259, 2). Özellikle taşınmaza ilişkin davalarda tanıkların **taşınmazın olduğu yerde** dinlenmesi gerekir.

Davaya bakan mahkemenin yargı çevresi dışında oturan tanıkların, istinabe suretiyle dinlenmesine de karar verilebilir (m. 259, 4).

Bu halde, tanık istinabe olunan mahkeme tarafından çağrılır (davet edilir). İstinabe olunan mahkemenin, tanığın dinleneceği duruşma günü ve saatini taraflara bildirmesi gerekir (m. 259, 4).

Tanıklar, birbirinden etkilenmemeleri amacıyla ayrı ayrı dinlenir (m. 261); hepsi birlikte dinlenemez. Tanıklardan biri dinlenirken, henüz dinlenmemiş olan diğer tanıklar, huzurda (salonda) bulunamazlar. Ayrı ayrı dinlenmiş olan tanıklar, gerekli görülürse yüzleştirilebilir (m. 261, 1/c.2).

Hâkim, tanıkları bizzat (kendisi) sorguya çeker (m. 259, 1); bu işi başkasına (örneğin bilirkişilere) bırakamaz.

Tanığın dinlenmesi sırasında, ilk önce tanıktan, adı, soyadı ve yaşı, sanatı, oturduğu yer, iki tarafa yakınlığı olup olmadığı, varsa derecesi ve tanıklığına güveni sarsabilecek veya yok edebilecek bütün ilişkiler sorulur (m. 254). Bundan sonra hâkim, tanığı gerçek durumu ve doğruyu söylemeye teşvik eder; doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceğini belirtir ve hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği ve gerekli görülürse, diğer tanıklarla yüzleştirilebileceğini anlatır (m. 256).

Hâkim, dinlenilmesinden önce tanığa **yemin ettirir** (m. 258, 1).

Tanığa şu şekilde yemin ettirilir: Hâkim tanığa; "Tanık sıfatıyla sorulan sorulara verdiğiniz cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bilginizden hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyor musunuz?" der ve tanık da cevaben, "Sorulacak sorulara, hiçbir şey saklamadan doğru cevap vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum" der (m. 258, 3).

Bazı kimseler (tanıklar) **yeminsiz** dinlenir; buna göre, dinlendiği sırada on beş yaşını tamamlamamış olanlar ile yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayacak derecede ayırt etme gücüne sahip olmayanlar (m. 257) yeminsiz olarak tanıklık eder.

Tanık bildiğini (hâkime) **sözlü olarak** anlatır. Tanığın yazılı notlar kullanması (kural olarak) yasaktır (m. 261, 2). Ancak, tanık, tarihleri ve sayıları

belirlemek veya bazı konuları açıklamak veya belleğini toparlamak için yazılarına bakmak zorunda olduğunu hâkime söylerse, hâkim derhal yazılarına bakmasına veya belirleyeceği oturumda yeniden dinlenmesine karar verebilir (m. 261, 2).

Türkçe bilmeyen tanık, tercüman aracılığı ile bildiklerini anlatır. Sağır ve dilsiz tanık okuma ve yazma biliyorsa, sorular kendisine yazılı olarak bildirilir ve cevapları yazdırılır. Sağır ve dilsiz tanık okuma yazma bilmiyorsa, hâkim, kendisini işaret dilinden anlayan bilirkişi yardımı ile dinler (m. 263).

Tanığın ifadesi tutanağa yazılır, önünde okunur ve ifadesinin altı, tanığa imza ettirilir (m. 261; 154, 3/d).

Hâkim, tanıklık sırasında tanığın yalan söylediği veya menfaat sağlayarak tanıklık yaptığı hakkında güçlü delil ve belirtiler görürse, derhal bir tutanak düzenler ve bunu Cumhuriyet Savcılığına gönderir. Hâkim, tanığın ve bu suçta ortakları varsa onların tutuklanmasına da karar verebilir ve onları haklarında ceza davası (TCK m. 272) açılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderir (m. 264).

Yalan tanıklıkta bulunmak suçtur (TCK m. 272 vd.). Tanık hakkında yalan tanıklıktan dolayı ceza kovuşturması yapılması, hukuk davasının görülmesine ve sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

İfadesi karara esas alınan tanığın yalan tanıklıktan mahkûm edilmiş olması **yargılamanın iadesi sebebi**dir (m. 375, 1/e).

Yalan tanıklık yaptığı ileri sürülen kişi hakkında, delil yokluğundan başka bir sebeple ceza kovuşturmasına başlanamamış veya karar verilememiş ise, ilgili taraf doğruca hukuk mahkemesinde yargılamanın iadesi davası açabilir; bunun için ayrı bir tespit davası açamaz (m. 375, 2).

H) HÂKİM TANIK İFADELERİNİ SERBESTÇE TAKDİR EDER

Tanıklık takdirî bir delildir (m. 198). Bu nedenle hâkim, tanıkların ifadeleri (verdiği bilgileri) ile bağlı değildir; tanığın doğru söylemediğini başka delil ve belirtilerle anlarsa, tanık ifadelerinin aksi yönde de karar verebilir. Ancak hâkimin, tanık ifadelerini serbestçe takdir edip (değerlendirip) vicdani kanaatini oluşturması yeterli olmayıp, hükümde bir tanığın ifadesinin neden kabul edildiğini veya edilmediğini belirtmesi gerekir.

Taraflardan her biri de tanığın davada (tanıklık etmekte) hukukî yararı bulunduğu gibi bir nedenle doğru söylemediğini iddia ve ispat edebilir (m. 255). Ancak bu durum, o tanığın dinlenmesine engel olmayıp, yalnızca hâkimin tanık ifadelerini takdirinde önem taşır.

§ 31. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

A) BİLİRKİŞİ KAVRAMI ve TANIKTAN FARKI

Bir davada çözümü hukuk dışında **özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde,** taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, mahkemenin oy ve görüşüne başvurulmasına karar verdiği üçüncü kişiye (veya kişilere) bilirkişi (ehlivukuf, ehlihibre) denir[1] (m. 266, 287).

Bilirkişi, görüşüne başvurulan husus hakkında, hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgisine dayanarak inceleme yapar ve vardığı sonuçları (görüşünü) mahkemeye bildirir. Başka bir deyişle, bilirkişi, hâkimin özel ve teknik bilgisinin bulunmadığı veya yeterli olmadığı hallerde, hâkime yardım eder. Bu nedenle;

Bilirkişiye başvurulmasına gerek olup olmadığına hâkim karar verir (m. 266). Bilirkişi seçiminde son söz hâkimindir (m. 267-268). Bilirkişilerin tarafsızlığını sağlamak için (hâkimler gibi) bilirkişiler de reddedilebilir (m. 272).

Bilirkişi, bilgisine başvurulan vakıaya tanık olmuş değildir. Bilirkişiye böyle bir vakıa/vakıalar bildirilerek, o vakıa/vakıalar hakkında görüşünü bildirmesi istenir. Oysa tanık, bilgisine başvurulan vakıanın nasıl olduğunu kendisi görmüş veya duymuştur. Tanık, ancak gördüğünü ve duyduğunu nakleder, bunlar hakkında oy ve mütalâa bildiremez.

Tanık geçmişteki gözlemlerini anlattığı halde, bilirkişi şimdiki gözlemlerini, özel ve teknik bilgisine dayanarak mahkemeye bildirir.

Bilirkişilik özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği için, herkes bilirkişi olamaz ve bu nedenle, kural olarak, herkes bilirkişiliği kabul etmeye zorlanamaz. Oysa, tanıklık, istisnalar dışında, zorunludur.

Bilirkişilik, yalnızca hukuk davalarına özgü bir müessese değildir; bütün yargı alanlarında da uygulanır ve bilirkişilik konusunda, yargılama usulü kanunlarında özel düzenlemeler vardır. Bunların dışında, bilirkişilerin nitelikleri, seçimi ve denetimi usul ve esaslarını gösteren Bilirkişilik Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanun, bilirkişilerle ilgili **temel ilkeler** getirmiştir. Buna göre; bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir. Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bil-

---

[1] Bkz. Ramazan Arslan, Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtayın Etkisi (YKD 1989/1-4, s. 156-183); Ejder Yılmaz, Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu (Yaklaşım 1996/42 s. 26-31; Yılmaz, Makaleler c. 1, s. 803-810); Ejder Yılmaz, Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları (Malî Hukuk 1996/62 s.12-31; Yılmaz, Makaleler c. 1, s. 811-828); Ejder Yılmaz, Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Alman, İsviçre ve Avusturya Hukuklarında Bilirkişilik (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, Ankara 2000, s.3-27; Yılmaz, Makaleler c. 1, s. 1129-1144); Ejder Yılmaz, Bilirkişiliğin Kurumsallaştırılması Hakkında Bir Kanun Taslağı (Bilirkişilik Sempozyumu, Samsun 9-10 Kasım 2001, Ankara 2002, s.538-550; Yılmaz, Makaleler c. 2, s. 1223-1230); Sema Taşpınar Ayvaz, Hukuk Yargısında Bir Kördüğüm: Bilirkişilik (Güncel Hukuk, Şubat 2007, sa. 10, s. 71-79); Süha Tanrıver, Medenî Yargıda Bilirkişilik, Ankara 2016.

giyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez. Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder. Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez. Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır; ancak rapordaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile bu sisteme entegre bilişim sistemleri veya yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz (Bilirkişilik K. m. 3).

Uygulamada taşınmaz davalarında, taşınmazın durumunu bilen genellikle yaşlı kişiler dinlenmekte ve bu kişilere **mahalli** (yerel) **bilirkişi** denilmektedir.

B) BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİ GEREKTİREN HALLER

Yukarıda da değinildiği gibi, ancak, çözümü **hâkim tarafından bilinemeyen** (hukuk dışında) **özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde** bilirkişiye başvurulur. Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında, ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez (m. 266). Hâkim tarafından bilinemeyen özel ve teknik bilgiye gerek olup olmadığını hâkim takdir eder. Ancak kanun, bazı hallerde bilirkişiye başvurulmasını zorunlu kılmıştır. Buna göre, konuyu, zorunlu durumdan başlamak üzere ikiye ayırarak incelemek gerekir:

1) **Bazı hallerde** kanun, bilirkişiye başvurulması gerektiğini açıkça öngörmüştür; bu hallerde, **hâkim bilirkişiye başvurmak zorundadır**. Örneğin;

Akıl hastalığına dayanarak açılan boşanma davasında, davalı eşin akıl hastası olup olmadığının; akıl hastası ise hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu (bilirkişi) raporuyla tespit edilmesi gerekir (TMK m. 165).

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlılık kararı, ancak bilirkişi raporu üzerine verilebilir (TMK m. 409).

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle verilmiş olan kısıtlılık kararının kaldırılması, kısıtlılık için bir neden kalmadığını gösteren bilirkişi raporuna bağlıdır (TMK m. 474).

Hayvan alım satımında hayvanın ayıplı olduğunun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir (TBK m. 224).

Yayım sözleşmesinde, yazarlık ücretinin miktarı, bilirkişinin görüşü alındıktan sonra, hâkim tarafından takdir olunur (TBK m. 496, 2).

Kamulaştırma bedelinin tespiti işlerinde kamulaştırılan taşınmazın kıymeti bilirkişiler tarafından takdir edilir (bkz. Kamulaştırma K. m. 15; Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik m. 5 vd.).

2) Yukarıdaki örneklerdeki gibi açık bir kanun hükmü ile bilirkişiye başvurmak zorunlu kılınmış değilse, hâkim, dava ile ilgili bir husus hakkında (kendisinin bilmediği) özel ve teknik bilginin gerekli olduğu hallerde bilirkişiye başvurur (m. 266). Özel bir kanun hükmü ile bilirkişiye başvurmak zorunlu kılınmış değilse, hâkim, her davada başkasının özel ve teknik bilgisine (dolayısıyla bilirkişiye başvurulmasına) gerek olup olmadığına kendisi karar verir. Başka bir deyişle, hâkim, her davada özel ve teknik bilgisinin yeterli olup olmadığını, yani bilirkişiye başvurulmasına gerek bulunup bulunmadığını kendisi takdir eder.

Ancak, uygulamada Yargıtay, "çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde" (m. 266) ibaresinden yola çıkarak, hemen her konuda hâkimin bilirkişiye başvurmak zorunda olduğuna karar vermektedir. Kanımızca, bugün uygulamada yapıldığı gibi, "çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren haller" deyimi çok geniş biçimde yorumlanmamalı ve hâkim hemen her davada bilirkişiye başvurmak zorunda olmamalıdır. Hâkim, ilk önce davanın karara bağlanabilmesi için gerçekten özel ve teknik bilginin gerekli olup olmadığını, gerekli ise kendi özel ve teknik bilgisinin o davada yeterli olup olmadığını kendisi takdir eder.

Hâkim, davanın karara bağlanabilmesi için özel ve teknik bilgiye gerek olmadığı kanısına varırsa, bilirkişiye başvurmaz. Hâkim, davanın karara bağlanabilmesi için özel ve teknik bilginin gerekli olduğu, fakat kendisinin o konudaki özel ve teknik bilgisinin yeterli olduğu kanısına varırsa, gene bilirkişiye başvurmayabilir.

Buna karşılık, hâkim davanın karara bağlanabilmesi için özel ve teknik bilgiye ihtiyaç olduğu ve bu özel ve teknik bilgiye sahip olmadığı kanısına varırsa, işte o zaman bilirkişiye başvurmak zorundadır.

Hâkimin mesleği nedeniyle bilmesi doğal olan hukukî sorunlar için (m. 33) bilirkişiye başvurulamaz. Başka bir deyişle, "**genel bilgi veya tecrübe**yle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği **hukukî bilgi** ile çözümlenmesi mümkün olan konularda **bilirkişiye başvurulamaz**" (m. 266, 1/c. 2). Örneğin;

Sigortacının TTK m. 1440 vd. gereğince cayma hakkının doğup doğmadığının tayini, hukukî bir sorundur. Bir hakkın doğumunu bildirmesi için bilirkişiden hukukî görüş alınması doğru değildir; pozitif hukuku resen uygulayacak olan hâkimdir.

TTK m. 1472'deki halefiyet prensibi mal ve sorumluluk sigortalarına münhasırdır. Bu hükmün can sigortalarında uygulanıp uygulanmayacağını tespit için bilirkişiye başvurulamaz. Çünkü, kanun hükümlerinin uygulanmasında bilirkişiden görüş alınması HMK'nun 33. maddesi hükmüne aykırıdır.

Ceza koşulundan indirme yapılması TBK'nun 182/son ve TMK'nun 4. maddesince hâkimin takdirine bağlıdır. Kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hâkimin hakkaniyetle hükmetmesi zorunludur. Hukukla ilgili bir konuda bilirkişi düşüncesine başvurulamaz.

Manevî tazminatın miktarının takdiri mahkemeye ait olup, bunun için bilirkişiye başvurulmasına gerek yoktur.

Taraflar arasındaki sözleşmenin bir maddesinin anlamını anlayabilmek için özel ve teknik bilgiye ihtiyaç bulunmadığından ve maddenin yorumu mahkemenin yetki ve görevi içinde olduğundan, bilirkişi görüşüne başvurulmasına gerek yoktur.

Bir olayın iş kazası niteliğinde bulunup bulunmadığının saptanması, bilirkişi görüşüne başvurulmasını gerektiren teknik bir konu ise de varılacak sonuca hangi kuralın uygulanacağı bir hukukî sorundur. Hukukî sorunların halli ise, bilirkişiye değil, hâkime ait bir görevdir.

Bir olayda, davacı, davalının kendisini memuriyet görevini kötüye kullandığından söz ederek şikâyeti üzerine açılan ceza davasında beraat ettiğini ileri sürerek manevî tazminat talep etmiştir. Mahkeme, şikâyet hakkının kötüye kullanılmak suretiyle davacının kişilik hakkının saldırıya uğradığını kabul etmiş ve davalıyı manevî tazminata mahkûm etmiştir. Ne var ki, mahkeme, davaya konu olan şikâyet hakkının kullanılması olayında sorumluluğun belirlenmesi için bilirkişiye başvurmuştur. Yargıtay ise, davada sorumluluk yönünden ulaşılacak sonucun tamamen bir yargı görevi olduğu; hâkimin, hukukî sonucu yargı ödevi gereği olarak kendisinin değerlendireceğini vurgulayarak kişilik hakkı, hak arama özgürlüğü kavramları ile kişilik hakkının zarar görmesi halinde bunun sonuçlarını düzenleyen kuralların, hâkimlik mesleğinin gereği olarak bilinmesi gerekli bilgiler kapsamı içinde olduğunu belirterek olayda bilirkişiye başvurulmasını yanlış bulmuş ve kararı bu nedenle bozmuştur.

C) BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE KARAR VERİLMESİ

Buraya kadar incelendiği gibi, hâkim, bir davada özel ve teknik bilgiye gerek bulunup bulunmadığını; gerekli ise kendi özel ve teknik bilgisinin o davada yeterli olup olmadığını, başka bir deyişle o davada bilirkişiye başvurulmasının gerekli olup olmadığını kendisi takdir eder ve karara bağlar.

Hâkim, bilirkişi incelemesi yaptırılmasına kendiliğinden karar verebileceği gibi, taraflardan birinin talebi üzerine de karar verebilir. Hâkimin kendiliğinden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar vermiş olmasının, bilirkişi giderlerinin (özellikle bilirkişi ücretinin) taraflarca yatırılmaması hali için büyük önemi vardır.

Bir taraf, iddia veya savunmasını ispat için bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyebilir. Bu halde tarafın, hangi husus hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasını istediğini bildirmesi gerekir (m. 119, 1/f; 129, 1/e).

Hâkim, tarafın bilirkişi incelemesi yapılmasına ilişkin talebini kabul ederse, yani bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verirse, bu kararında, bilirkişi incelemesi isteyen tarafa, bilirkişi giderlerini (özellikle bilirkişi ücretini **delil**

avansı olarak) ödemesi için iki haftalık kesin süre verir (m. 324). Taraf bu süre içinde bilirkişi giderlerini ödemezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir; aksi halde bilirkişi incelemesi yapılması talebinden vazgeçmiş sayılır (m. 324, 2). Bu halde dosyada mevcut diğer delillerle bir karar verilemiyorsa ve bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyen taraf davacı ise, iddiasını ispat edemediği için davanın reddi gerekecektir.

D) BİLİRKİŞİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ

Hâkim, önce kaç adet bilirkişi seçileceğine karar verir. Hâkim kural olarak yalnızca bir kişiyi bilirkişi olarak seçer; ancak, gerekçesi açıkça gösterilerek tek sayıda (üç veya beş gibi) olmak şartıyla birden fazla kişiden oluşan bir kurulu da görevlendirmesi mümkündür (m. 267).

İstinabe yoluyla bilirkişi incelemesi yaptırılması halinde, bilirkişinin hangi uzmanlık alanından seçileceğine istinabe eden mahkeme karar verir.

Bilirkişiler, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle **bilirkişilik bölge kurulu** (bkz. Bilirkişilik K. m. 7) **tarafından hazırlanan liste**de[2] yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir (m. 268, 1). Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının listelerinden; burada da bulunmaması hâlinde, kural olarak, listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir (m. 268, 2).

Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara görevlendirildikleri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili dava ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez (m.268,3).

UYAP Bilirkişi Sistemi üzerinden bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi listesinde yer alan bilirkişi, tespit ve teslim tutanağını, dosyanın iş listesine düşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde güvenli elektronik imzayla imzalayarak mahkemeye göndermek ya da m. 275, 1'e göre haber vermek zorundadır (Y m. 220, 2).

UYAP Bilirkişi Sistemi üzerinden bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi listesinde yer alan bilirkişi, tespit ve teslim tutanağını, dosyanın iş listesine düş-

---

2 Bilirkişilik Kanunu, bilirkişiliğe kabul ve bu görevin ifası bakımından bilirkişilik eğitimi, bilirkişi listeleri ve bilirkişilik sicili uygulaması getirmiş; bu amaçla Adalet Bakanlığı nezdinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bilirkişilerin bu listeye ve sicile kabulü, Bilirkişilik K. Geçici Madde 1 uyarınca Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre gerçekleşecektir. Bu yönetmelik yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir (Bkz. RG 03.08.2017, sa. 30143). Ancak Bilirkişilik K. geçici madde 1 uyarınca Yönetmeliğin yayımından itibaren (yani 03.08.2017 tarihinden itibaren) altı ay içinde bu Kanunun öngördüğü bilirkişilik sicili ve listeleri oluşturulur. Bilirkişilik sicil ve listelerinin oluşturulmasını müteakip Bakanlık tarafından ilân yapılır. Bu ilân yapılıncaya kadar mevcut bilirkişi listelerinden görevlendirme yapılır ve bu bilirkişiler görevlerini tamamlarlar.

mesinden itibaren en geç bir hafta içinde güvenli elektronik imzayla imzalayarak mahkemeye göndermek ya da m. 275, 1'e göre haber vermek zorundadır (Y m. 220, 2).

Mahkeme, bilirkişinin görevlendirilmesine ilişkin kararında; **inceleme konusunun bütün sınırlarını**, bilirkişinin cevaplandırması gereken soruları ve raporun verilme süresini (m. 274) **açıkça belirler**. Bu belirlemede mahkeme, tarafların görüşünü de alır (m. 273, 1)

HMK'nun 273. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere; "Bu düzenleme ile mahkeme, tarafların da görüşünü almak suretiyle, inceleme konusunu, bilirkişinin cevaplandırması gereken soruları belirlemeli, bunlara görevlendirme yazısında açıkça işaret etmeli ve raporun verilme süresini de bu yazıda göstermelidir. Uygulamada, bu hususlara gereken özen gösterilmemekte; son derece genel, soyut ve hatta hukukî konularda da görevlendirmeyi kapsar bir biçimde 'dosyanın bilirkişiye tevdiine', 'dosya ve eklerinin bilirkişiye havalesine', 'tarafların iddia ve savunması karşısında bilirkişi görüşünün alınmasına' gibi ifadelerle, bilirkişiye başvurulmaktadır. Bu şekilde yapılan bir görevlendirme sonucunda, bilirkişi, görevinin ne olduğunu tam olarak bilemediği veya kavrayamadığı için, hâkime ya hiç yardımcı olamamakta ya da işlevinin sınırlarını aşıp hukukî değerlendirmelere girişerek, gerçekte hükmü veren konumuna geçmektedir. Bu durum ise hâkimin, bilirkişi karşısında bağımsızlığını koruyamamasına; hâkimin bilirkişinin oy ve görüşünü serbestçe takdir edeceği yönündeki düzenlemenin amacını ve işlevselliğini yitirmesine ve toplumda yargıya olan güvenin tümüyle sarsılıp, kararın fiilen bilirkişi tarafından verildiği yönündeki çarpık anlayışın yerleşmesine ve kökleşmesine neden olmaktadır. İşaret edilen sakınca nedeniyle, hâkim, dava dosyasına tümüyle egemen olduktan sonra, maddî sorunlarla hukukî sorunları kesin çizgileriyle birbirinden ayırmalı, hangi maddî vakıa veya vakıaların özel ve teknik bilgilere dayalı olarak aydınlatılmasını ya da tespit edilmesini istiyorsa, somut sorular hâlinde bu konudaki iradesini herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak bir biçimde bilirkişinin görevlendirilmesine ilişkin kararda açıklamalıdır. Raporun sağlıklı ve eksiksiz olmasının temini ile taraflarca yapılması muhtemel itirazların daha işin başında bertaraf edilmesi ve dolayısıyla usul ekonomisine uygunluğunun sağlanması açısından, inceleme konusu ile bilirkişiye yöneltilecek soruların tayini sürecinde, tarafların da görüşü alınmalıdır".

Başka bir ifade ile, bilirkişiyi görevlendiren mahkeme kararında, tarafların da görüşünü alarak inceleme konusunu açıkça belirlemeli; bilirkişinin cevaplamasını istediği soruları açıkça yazmak ve raporun (görüşün) verilmesi süresini belirtmelidir (m. 273).

Bilirkişiye gönderilecek **görevlendirme yazısının** ekinde, inceleyeceği şeyler, dizi pusulasına bağlı olarak ve gerekirse mühürlenmiş şekilde teslim edilir, bu husus ayrıca tutanakta gösterilir (m. 273, 2).

Bilirkişilik görevi, mahkemece belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmayı; bilirkişi listesine kaydedilmemiş olanlar bakımından yemin etmeyi (m. 271, 2) ve oy ve görüşünü süresi içinde (m. 273, 1/c) bildirmeyi kapsar

(m. 269, 1). Bu görevlerini, geçerli bir özre dayanmaksızın yerine getirmeyen bilirkişilere, tanıklar hakkındaki disiplin hükümleri (m. 245 vd.) uygulanır ve durum, bilirkişilik bölge kurullarına bildirilir (m. 269, 2).

Mahkemenin seçtiği (ve kendisine görevlendirme yazısı gönderilen/verilen) bilirkişi; verilen görev kendi uzmanlık alanına girmiyorsa veya inceleme konusu maddî vakıaların açıklığa kavuşturulması ve tespiti için uzman başka bir bilirkişi ile işbirliği ihtiyacı hissediyorsa yahut görevi kabul etmemek için haklı bir özrü varsa, bu durumu bir hafta içinde mahkemeye bildirir (m. 275, 1). Listelerden bilirkişi seçimi halinde, bilirkişiler il adlî yargı adalet komisyonları huzurunda yemin etmiş olduklarından, bu bilirkişilere görevlendirildikleri her dava veya işte **ayrıca yemin verdirilmez**; ancak görevlendirme yazısında, önceden ettikleri yemine bağlı kalarak oy ve görüş bildirmek zorunda oldukları hususu kendilerine **hatırlatılır** (m. 271, 1). **Bilirkişi listesinin dışından seçilen** bilirkişiler ise (m. 268, 1), göreve başlamadan önce, mahkeme huzurunda, "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim" sözleri tekrarlattırılarak **yemin ettirilir** (m. 271, 2).

E) BİLİRKİŞİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ

Bilirkişiler, görevlerini, dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir (Bilirkişilik K. m. 3, 1). Bilirkişinin tarafsızlığını sağlamak için, **hâkimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar** (m. 34 vd.), bilirkişiler bakımından da uygulanır (m. 272, 1).

Hâkimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden (m. 34) biri bilirkişi bakımından gerçekleşirse; mahkeme, hüküm verilinceye kadar her zaman, bilirkişiyi kendiliğinden görevden alabilir veya bilirkişi de görevden alınmasını mahkemeden isteyebilir (m. 272, 2).

Hâkimler hakkındaki ret sebeplerinden (m. 36) biri, bilirkişi bakımından gerçekleşirse, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren bir hafta içinde taraflar, bilirkişinin reddini isteyebilir veya bilirkişi de kendi kendini reddedebilir (m. 272, 3/c. 1-2). Ret sebebinden dolayı yemin teklif olunamaz (m. 272, 3/c. 3).

Görevden alınma, ret ve bilirkişinin kendisini reddetmesine yönelik talep, bilirkişiyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Mahkemenin, görevden alınma ve ret talebinin kabulüne ilişkin kararları kesindir ve bunlar aleyhine kanun yoluna başvurulamaz. Buna karşın görevden alınma veya ret talebinin uygun görülmemesine ilişkin kararlara karşı ise, esas hakkındaki kararla birlikte kanun yoluna (m. 341 vd.) başvurulabilir (m. 272, 4).

F) BİLİRKİŞİLİK YAPMAK KURAL OLARAK ZORUNLU DEĞİLDİR

Bilirkişilik yapmak, kural olarak, zorunlu değildir. Ancak, resmî bilirkişiler; bilirkişi listesinde (m. 268) yer alanlar; bilgisine başvurulan konuyu bilmeksizin meslek ve zanaatlarını icra etmesine olanak bulunmayanlar ile bilgisine

başvurulan konu hakkında meslek veya zanaat (sanat) icrasına resmen yetkili kılınmış olanlar (örneğin doktorlar, ebeler, mühendisler gibi) bilirkişilik yapmak zorundadırlar (m. 270, 1/a-c).

Bilirkişilik yapmak zorunda olan bu kişiler, tanıklıktan çekinme hakkındaki sebeplere veya mahkemece kabul edilebilir diğer bir sebebe dayanarak, bilirkişilik yapmaktan çekinebilirler (m. 270, 2).

G) BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE SONUCUNUN SUNULMASI

Bilirkişi, kendisine verilen görevi (m. 273), mahkemenin sevk ve idaresi altında yürütür (m. 278, 1). Bilirkişilik görevi, seçilen kişi tarafından bizzat yerine getirilir; görev, kısmen veya tamamen başka birine bırakılamaz (m. 276).

Bilirkişi, kendisine verilen görevin alanı ve sınırları hakkında (m. 273, 1/a-b) tereddüde düşerse, bu tereddüdün giderilmesini, mahkemeden her zaman isteyebilir (m. 278, 2).

İncelemenin gerçekleştirebilmesi için, bazı belge ve bilgilerin getirtilmesine ihtiyaç duyulursa, bilirkişi, bunun sağlanmasını, görev alma tarihinden itibaren bir hafta içinde, kendisini görevlendiren mahkemeden ister (m. 275, 2). Ayrıca bilirkişinin, incelemesini yaparken ihtiyaç duyması halinde, tarafların bilgisine başvurması mümkündür; ancak bunun için bilirkişinin taraflarla görüşmeden önce mahkemeden izin alması gerekir. Taraflardan birinin bilgisine başvurulacağı hallerde, taraflardan biri bulunmaksızın diğerinin dinlenemeyeceği hususu (önceden) bilirkişiye mahkemece hatırlatılır (m. 278, 3).

Bilirkişinin, görev konusu ile ilgili olarak bir şey (örneğin dava konusu taşınmaz veya su kaynağı vb.) üzerinde inceleme yapması zorunlu ise, mahkemeden bu konuda karar alması gerekir; bu işlemin icrası sırasında taraflar da hazır bulunabilirler (m. 278, 4).

Bilirkişi yaptığı **incelemelerin sonucunu**, mahkemenin kararına göre (m. 279, 2), **yazılı** veya **sözlü olarak** mahkemeye **bildirir**.

Bilirkişiler UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de işlem yapabilirler. Bunun için bilirkişilerin elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Bilirkişi dosyayı inceledikten sonra elektronik ortamda düzenlediği raporunu güvenli elektronik imzayla imzalayarak mahkemesine gönderir. Birden fazla bilirkişi görevli ise düzenlenen rapor tüm bilirkişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra mahkemeye gönderilir. Bilirkişi listesinde yer almayan bilirkişilerin bu işlemleri yapabilmeleri için öncelikle mahkeme huzurunda yemin etmeleri gerekir (Y m. 220, 1-2).

Mahkemenin kararına göre bilirkişi görüşü, **bilirkişi raporu** şeklinde yazılı olarak verilecekse, raporda; tarafların ad ve soyadları, bilirkişinin görevlendirildiği hususlar, gözlem ve inceleme konusu yapılan maddî vakıalar, gerekçe ve varılan sonuçlar ile bilirkişiler arasında görüş ayrılığı varsa bunun sebebi, raporun düzenlenme tarihi ve bilirkişilerin imzaları yer alır (m. 279, 2).

Kurul halinde görevlendirme söz konusu ise, bilirkişilerin, bilgilerine başvurulan hususu, bir araya gelerek, **aralarında müzakere etmeleri zorunludur**. Bilirkişi kurulunun bir araya gelmeden rapor hazırlaması, sağlıklı bir

sonuca varılabilmesi açısından doğru bir usul olmadığı gibi, 279. madde hükümlerine de aykırı olur.

Bilirkişiler oy çokluğuyla da bir sonuca varabilirler. Bu durumda, azınlıkta kalan bilirkişi, oy ve görüşünü (muhalefet şerhini) ayrı bir rapor halinde de mahkemeye sunabilir.

Mahkeme, bilirkişinin oy ve görüşünün sözlü olarak açıklanmasına karar verirse, bilirkişinin açıklamaları tutanağa (m. 154, 2/d) geçirilir ve altı bilirkişiye imzalatılır. Eğer bilirkişi birden çok ise (kurul halinde görev yapmışsa), kendi aralarında hemen müzakere etmelerine olanak tanınır ve müzakere sonunda açıklanan oy ve görüş, tutanakla tespit edilir ve altı tüm bilirkişilere imzalatılır (m. 279, 3).

Bilirkişi, mahkemece tespit edilmiş olan vakıalar hakkında görüş bildirir. Bilirkişinin delilleri takdir yetkisi yoktur; delillerin takdiri yetkisi (doğal olarak) yalnız hâkime (mahkemeye) aittir.

Bilirkişi, yalnız maddî vakıalar hakkında görüş bildirir. Bilirkişi raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken **hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz** (m. 279, 4; Bilirkişilik K. m. 3).

Bilirkişi oy ve görüşünün (raporunun) hazırlanması için verilecek **süre üç ayı geçemez**; ancak bilirkişinin talebi halinde mahkeme, gerekçesini göstererek, üç ayı geçmemek üzere yeni süre verebilir (m. 274, 1).

Bilirkişi, mahkeme tarafından belirlenen **süre içinde raporunu vermezse**, mahkeme onu görevden alıp yerine **başka bir kişiyi bilirkişi olarak atayabilir**. Bu durumda mahkeme, görevden alınan bilirkişiden o ana kadar yaptığı işlemler hakkında açıklama yapmasını ister ve ayrıca kendisine teslim edilen evrakı mahkemeye iade etmesini talep eder. Mahkeme ayrıca, hukukî ve cezaî sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, sözü edilen bilirkişiye **ücret ve gider ödenmemesi**ne karar verebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını bilirkişilik bölge kurulundan talep eder (m. 274, 2).

Bilirkişi raporu ve varsa kendisine teslim olunan evrakı ve şeyleri, dizi pusulasına bağlı olarak, **mahkemeye verir**. Mahkeme, verildiği tarihi rapora yazar ve raporun birer örneğini (yargılamadan önce) taraflara tebliğ eder (m. 280).

H) BİLİRKİŞİ OY VE GÖRÜŞÜNE İTİRAZ

Mahkeme kendiliğinden, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanmasını veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiye yeni sorular sorarak ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada bilirkişinin sözlü açıklamalarda bulunmasını da isteyebilir (m. 281, 2). Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse yeni bilirkişi seçerek tekrar inceleme de yaptırabilir (m. 281, 3).

Taraflar, bilirkişi raporunun kendilerine **tebliği tarihinden** (m. 280) **itibaren iki hafta** içinde raporda eksik gördükleri hususların bilirkişiye tamamlattırılmasını veya belirsiz olan hususların açıklattırılmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler (m. 281, 1). Buna **bilirkişi raporuna itiraz** (tarafların bilirkişi raporuna itiraz etmesi) diyoruz.

Taraflar (veya bir taraf), bu **iki haftalık (kesin) süre**[3] içinde bilirkişi raporuna itiraz etmezse, bilirkişi raporunun taraflar (veya itiraz etmeyen taraf) bakımından kesinleşmiş sayılması gerektiği kanısındayız.

Ancak, bu kesinleşme mahkeme bakımından söz konusu olamaz. Mahkeme, bilirkişilerden tamamlayıcı bilgi alma, açıklama isteme ve yeni bilirkişi incelemesi yaptırma yetkisini (m. 281, 2) her zaman (hüküm verilinceye kadar) kullanabilir.

Taraflar da, mahkemeden bu yetkisini kullanmasını (her zaman) isteyebilirler. Ancak, iki hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz etmemiş olan tarafların, bu şekildeki (bilirkişiden tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgi alınmasına ilişkin) taleplerinin kabul edilip edilmemesi mahkemenin takdirine kalmış bir husustur. Yani mahkemenin, tarafların bu şekildeki taleplerini nazara almamış (ve taraflar bakımından kesinleşmiş olan bilirkişi raporuna göre hüküm vermiş) olması, kanun yoluna başvurma sebebi teşkil etmemelidir.

Hâkim, bilirkişinin raporu (görüşü, mütalâası) ile bağlı değildir (m. 282). Bu nedenle, hâkim, bilirkişi raporu (ve alınmışsa ek rapor) ile durumun gereği gibi aydınlanmadığı kanısına varırsa, **yeni** (ikinci) **bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar** verebilir.

İ) HÂKİM BİLİRKİŞİ OY VE GÖRÜŞÜNÜ SERBESTÇE DEĞERLENDİRİR

Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir (m. 282); **bilirkişinin oy ve görüşü (raporu) hâkimi bağlamaz**. Bu hüküm, "hâkim delilleri serbestçe değerlendirir" biçimindeki genel kuralın (m. 198), özel olarak vurgulanmasından başka bir şey değildir.

Kanımızca, "bilirkişi oy ve görüşünün hâkimi bağlamaması" ilkesinin anlamı şudur: Hâkim, bilirkişi oy ve görüşünü serbestçe değerlendirir; bilirkişi oy ve görüşünü yeter derecede kanaat verici bulmazsa, bilirkişiden ek görüş (rapor) isteyebilir veya yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırabilir (m. 281). Ancak, hâkim, bilirkişi raporunda yazılı olan özel ve teknik açıklamalardan, bilirkişi raporunda varılan sonucun yanlış olduğunu takdir edebilecek derecede bilgi sahibi olduğu kanısına varabiliyorsa, yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırmadan, bilirkişi raporunun aksine de karar (hüküm) verebilmelidir. Ancak hâkim, bilirkişi raporunun aksine karar verirken, bilirkişi raporundaki sonucun

---

[3] 281. maddenin Hükümet gerekçesinde, bu iki haftalık sürenin **kesin süre** olduğu açıkça belirtilmiştir: "Rapora itiraz için taraflara tanınmış bulunan 15 günlük (iki haftalık) süre kesin süredir; hak düşürücü nitelik taşır. Dolayısıyla taraflar, bu süre içinde, itirazlarını dile getirmez ise, bilirkişi raporu onlar bakımından kesinleşir; yani taraflar rapora itiraz olanağını tümüyle kaybederler".

neden dolayı yanlış olduğunu (kabul edilemeyeceğini) hükümde gerekçesiyle birlikte inceleyip belirtmelidir.

Ancak, Yargıtay, hâkimin bilirkişinin oy ve görüşü ile bağlı olmadığı hakkındaki kanun hükmünü (m. 282), hâkimin, bilirkişi raporunu yeterli görmezse, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırması (m. 281) gerektiği şeklinde anlamaktadır. Yargıtayın, kanun hükmünü, hâkimin bilirkişi raporunu yeterli görmezse, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiği, yoksa bilirkişi raporunun aksine karar veremeyeceği şeklinde anlamasına; bu yöndeki görüşüne katılamıyoruz. Çünkü:

HMK m. 282'de yer alan "bilirkişi oy ve görüşünün hâkimi bağlamaması" ilkesi, hâkimin, bilirkişi raporunu yetersiz bulması halinde, aynı bilirkişiden ek rapor alması veya yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiği şeklinde anlaşılamaz. Çünkü, ek rapor alınması ve yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması esasen hâkimin takdirine bırakılmıştır (m. 281); yani, bunlar hâkimin yetkilerine dahildir. Hâkimin bu yetkilere sahip olduğunu belirtmek veya "hâkimi benimsemediği bir görüşe uyarak karar vermek zorunluluğundan kurtarmak" için Kanuna bir hüküm (m. 282 hükmünü) koymaya gerek olmazdı.

Şu hâlde, m. 282'deki "bilirkişi oy ve görüşünün hâkimi bağlamaması" ilkesinin (m. 281'de yazılı yetkilerden) başka bir anlamı vardır: Hâkim, bilirkişi raporunu yeterli görmemekle beraber, raporda yazılı olan özel ve teknik bilginin, kendisinde başlangıçta noksan olan özel ve teknik bilgiyi sağladığı, yani dava için gerekli özel ve teknik bilgiye şimdi sahip olduğu kanısına varırsa, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırmadan, bilirkişi raporunun (sonucunun) aksine de karar verebilir.

HMK m. 282'nin gerekçesinde de ifade edildiği üzere; "Anılan hüküm çerçevesinde, hâkim, bilirkişi raporunu yeterli görmemekle beraber, raporda yazılı olan özel ve teknik bilgilerden hareketle, bilirkişinin raporunda varmış olduğu sonucun yanlış olduğu kanısına ulaşacak olursa, bunun gerekçelerini açıkça ortaya koymak suretiyle, bilirkişi raporunun aksine de karar verebilecektir. Tersine bir anlayış, hâkimi, bilirkişi raporuyla, hüküm arasında bir aracı hâline getirir ki; bunun hukuk devleti ve onun bir görünüm biçimi olan yargı bağımsızlığı (Anayasanın 2 nci ve 138 inci maddeleri) ile bağdaştırılamayacak olması sebebiyle kabulü mümkün değildir. Öte yandan, bu kural, hâkim, bilirkişi raporunu yeterli görmezse, bilirkişiden ek rapor almak yahut yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırtmak zorundadır şeklinde de anlaşılamaz".

Yargıtayın yukarıda belirtilen (ve eleştirilen) uygulaması (görüşü), hâkimin takdir yetkisini daraltmakta ve bu yolla hâkimlik yetkilerini önemli ölçüde kısıtlamakta, hâkimi adeta bilirkişi raporu ile hüküm arasında bir araç veya aracı durumuna sokmaktadır. Çünkü, yukarıda görüldüğü gibi, hâkim hemen her davada (örneğin kira bedelinin tespiti davalarında) bilirkişiye başvurmak zorunda bırakılır ve hâkimin, bilirkişi raporunu serbestçe takdir edemeyeceği, raporu yetersiz bulursa ikinci, hatta üçüncü, dördüncü ve beşinci defa bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiği; ancak mutlaka bir bilirkişi raporuna göre karar vermek zorunda olduğu kabul edilirse o zaman, hüküm, aslında hâkim ta-

rafından değil, bilirkişi tarafından hazırlanmış olur. Oysa, hâkim, isminden de anlaşıldığı gibi, "davanın hâkimi" ve en iyi bilirkişisidir.

Kanımızca, gerek bilirkişiye başvurulmasında (m. 266), gerek bilirkişi raporunun değerlendirilmesinde (m. 282) hâkimin takdir hakkının bulunması demek, hâkime bilirkişiye başvurmanın gerekli olup olmadığını belirlemek yetkisini vermek ve bilirkişi raporundan edineceği özel ve teknik bilgiye göre, gerekçesini göstermek şartıyla, gerektiğinde bilirkişi raporunun aksine de karar verme yetkisinin tanınması demektir. HMK m. 282'nin gerekçesi de bu görüşümüzü doğrulamaktadır[4].

Hâkim, bilirkişi hakkında UYAP'ta yer alan performans değerlendirme formu doldurabilir (Y m. 220, 4).

J) BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ[5]

Bilirkişiye harcadığı emek ve gördüğü hizmete karşılık bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir (m. 283, 1/c.1) Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılan Tarife[6] esas alınır (m. 283, 1/ c. 2).

K) BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU[7]

HMK'nun 285. maddesi, bilirkişinin hukukî sorumluluğunu düzenlemektedir. Kanun, bilirkişiyi hâkimin yardımcısı olarak kabul ettiği için, bilirkişinin hukukî sorumluluğunu da hâkimin sorumluluğuna paralel düzenlemiştir.

Bu düzenlemeye göre, bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun mahkemece hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararlarının tazmini için, doğrudan doğruya bilirkişiye karşı değil **Devlete karşı** tazminat davası açabilirler (m. 285, 1).

---

4 "Maddede yer alan düzenlemeyle, bilirkişinin, raporunda yahut sözlü açıklamalarında işaret ettiği oy ve görüşünü, hâkimin, diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendireceği hususu hüküm altına alınmış; bu suretle bilirkişinin belirteceği oy ve görüşünün, bir takdiri delil niteliği taşıdığına açıkça işaret edilmiştir. Anılan hüküm çerçevesinde, hâkim, bilirkişi raporunu yeterli görmemekle beraber, raporda yazılı olan özel ve teknik bilgilerden hareketle, bilirkişinin raporunda varmış olduğu sonucun yanlış olduğu kanısına ulaşacak olursa, bunun gerekçelerini açıkça ortaya koymak suretiyle, bilirkişi raporunun aksine de karar verebilecektir. Tersine bir anlayış, hâkimi, bilirkişi raporuyla, hüküm arasında bir aracı hâline getirir ki; bunun hukuk devleti ve onun bir görünüm biçimi olan yargı bağımsızlığı (Anayasanın 2 nci ve 138 inci maddeleri) ile bağdaştırılamayacak olması sebebiyle kabulü mümkün değildir. Öte yandan, bu kural, hâkim, bilirkişi raporunu yeterli görmezse, bilirkişiden ek rapor almak yahut yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırtmak zorundadır şeklinde de anlaşılamaz. Çünkü, bilirkişiden ek rapor almak yahut yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırtmak, "Bilirkişi raporuna itiraz" başlıklı 285 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan düzenlemeler uyarınca, zaten hâkimin sahip olduğu doğal yetkiler arasında bulunmaktadır" (HMK m. 282 gerekçesi).

5 Bkz. Sema Taşpınar, Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Bilirkişi Ücreti (Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, İstanbul 2003, s. 373-416).

6 Bkz. 2019 Yılı Bilirkişilik Asgarî Ücret Tarifesi (30.05.2019, sa. 30789).

7 Bkz. Süha Tanrıver, Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, Ankara 2002.

Devlet, davanın kaybı halinde ödediği tazminat için **sorumlu bilirkişiye rücu eder** (m. 285, 2).

Tazminat davası, bilirkişi raporunun; ilk derece mahkemesi kararına esas alınması halinde bu mahkemenin yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinde, bölge adliyle mahkemesi kararına esas alınması halinde ise Yargıtay ilgili hukuk dairesinde açılır (m. 286, 1).

Devletin sorumlu bilirkişiye açacağı rücu davası (m. 285, 2), tazminat davasını karara bağlayan mahkemede açılır (m. 286, 2).

Rücu davasının zamanaşımı, kural olarak, ödeme tarihinden itibaren bir yıldır. Ancak bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi halinde, ceza zamanaşımı süresi uygulanır (m. 287).

Bilirkişi, TCK anlamında **kamu görevlisi**dir (m. 284).

L) KASTEN GERÇEĞE AYKIRI RAPORUN YARGILAMANIN İADESİ NEDENİ OLMASI

Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı rapor düzenlemiş olduğunun ceza mahkemesince tespit edilmiş olması, yargılamanın iadesi sebebidir (m. 375, 1/f).

Kasten gerçeğe aykırı rapor düzenlemiş olduğu ileri sürülen bilirkişi hakkında, delil yokluğundan başka bir sebeple ceza kovuşturmasına başlanamamış veya karar verilememiş ise, ilgili taraf, doğruca hukuk mahkemesinde yargılamanın iadesi davası açabilir; bunun için ayrı bir tespit davası açamaz (m. 375, 2).

§ 32. KEŞİF[1]

Hâkimin uyuşmazlık konusu şeyi[2] bizzat inceleyerek onun hakkında bütün duyu organlarıyla bilgi edinmesine **keşif** denir.

HMK m. 288-292 hükümleri, uyuşmazlık konusu şeyin taşınmaz olup olmadığına bakılmaksızın her türlü uyuşmazlık hakkında uygulanır. HMK, "özel hüküm sebepleri" başlığını taşıyan HUMK m. 367 hükmü yerine "kanunda düzenlenmemiş deliller" başlığını taşıyan m. 192 hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme ile HUMK'nda bulunan "özel hüküm sebepleri" kavramının terk edildiği, madde gerekçesinde ifade edilmiştir.

Keşifle ilgili bu düzenlemelere uyan örnekler vermek gerekirse;

Sınırları çekişmeli olan bir taşınmaz (hâkim tarafından) yerinde görülür ve gerçek sınırların nereden geçtiği ve taşınmazın yüzölçümünün ne kadar olduğu tespit edilir.

Bir trafik kazasının meydana geldiği yere gidilerek, yol durumu ve kazanın nasıl olduğu incelenir ve tespit olunur.

Trafik kazasına katılan aracı, iş kazasını yapan makineyi, kusurlu (ayıplı) olduğu iddia edilen malları hâkim bizzat görüp inceleyerek sonuca varabilir.

Hâkim, dava konusu yiyecek maddesinin bozuk olup olmadığını, bunları koklayarak, rengine bakarak onlar hakkında bilgi edinir.

Bu gibi durumlarda uyuşmazlık konusu şeyin durumunu anlayabilmek için bilirkişiye de başvurulabilir.

Hâkim, keşfe kendiliğinden karar verebileceği gibi, iki taraftan birinin talebi üzerine de karar verebilir (m. 288, 2). Tarafların keşif talebini sözlü yargılama aşamasından (m. 186) önce yapmaları gerekir.

Keşif isteyen taraf, hâkim tarafından tespit edilecek keşif gideri için gereken delil avansını, keşif gününden önce mahkeme veznesine yatırmalıdır (m. 324, 1). Dava açılırken m. 120'ye göre yatırılan gider avansı yeterli olmaz, hâkim tarafından belirlenen kesin süre içinde keşif gideri yatırılmazsa ve diğer taraf da ödemezse, keşif isteyen taraf talebinden vazgeçmiş sayılır (m. 324, 2). Ancak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işler hakkındaki hükümler (m. 325) saklıdır.

Keşif, (davaya bakan) hâkim tarafından yapılır (m. 289, 1/c.1). Hâkimin, keşif yerine gitmeden; keşif konusu şeyi görmeden, dosyayı bilirkişiye veya zabıt kâtibine vermek suretiyle keşif yaptırması söz konusu olamaz.

Ancak, her yargılama işleminin yapılmasında olduğu gibi, zabıt kâtibinin de keşifte hazır bulunması zorunludur (m. 157).

---

1 İbrahim Aşık, Medeni Usul Hukukunda Keşif, Ankara 2019.

2 HUMK m. 363, HMK m. 288'den farklı olarak, "uyuşmazlık konusu yer (münazaalı mahal)"den söz ettiği için, eskiden (HUMK döneminde) keşif denilince sadece taşınmazların hâkim tarafından yerinde görülüp incelenmesi anlaşılmakta; hâkimin taşınmaz mallar dışındaki çekişmeli şeyler, hakkında bütün duyularıyla bilgi edinmesi ise, HUMK m. 367'de düzenlenen "hususi (özel) hüküm sebepleri" altında incelenmekte idi.

Keşif konusu, davaya bakan mahkemenin yargı çevresi dışında ise, davaya bakan mahkeme, keşfi kendisi (kendi hâkimi aracılığıyla) yapamaz; keşif konusu şeyin (örneğin taşınmazın) yargı çevresi içinde bulunduğu mahkemeyi **istinabe** eder (m. 289, 1/c. 2); yani keşfin o mahkeme tarafından yapılmasını bir istinabe talebi ile (o mahkemeden) ister. Keşif konusu, **büyükşehir belediyesi** sınırları içerisinde ise inceleme davaya bakan mahkeme tarafından da yerine getirilebilir (m. 289, 2).

Mahkeme, bir olayın nasıl gelişmiş olabileceğini tespit bakımından **temsilî uygulama** da yapabilir. Bu uygulama mahallinde olabileceği gibi duruşma salonunda da yapılabilir (m. 290, 3).

Keşif yeri, günü ve saati mahkeme tarafından tespit edilir (m. 290, 1). Resmî çalışma saatleri dışında, resmî tatil günlerinde ve adlî tatil sırasında da keşif yapılabilir (m. 148; 103, 1/f).

Keşif taraflar hazır iseler huzurlarında, aksi takdirde yokluklarında yapılır (m. 290, 1/c. 2). Hükmün Gerekçesine göre: "Davayı takip edenler mahkeme kararıyla keşfin yeri ve zamanı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Davanın oturumlarının başında yapılan tebligatla davayı takip etmeyen kişiye, bulunmadığı oturumlarda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğ edildiğinden, keşif yeri ve zamanının bulunmayanlara ayrıca tebliğine gerek görülmemiştir". Mahkeme, **keşifte tanık** ve **bilirkişi dinleyebilir** (m. 290, 2/c.1). Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, tanığın olayın gerçekleştiği veya şeyin bulunduğu yerde dinlenilmesine karar verebilir (m. 259, 2).

Keşif, genellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir iş olduğundan, hâkim keşif sırasında bilirkişi incelemesi de yaptırabilir (m. 290, 2). Bilirkişi, raporunu hemen keşif yerinde dinlenmek suretiyle (sözlü olarak) verebileceği gibi, ölçü, hesap ve inceleme yapması gereken hallerde sonra (yazılı olarak) da verebilir.

Taraflar ve üçüncü kişiler, keşif kararının gereğine uymak ve engelleyici tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadırlar (m. 291, 1).

Uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti (TMK m. 284) amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır (m. 291). Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir (m. 292, 1).

Keşif yapılmasına taraflardan birinin karşı koyması halinde, o kimse ispat yükü kendisine düşen taraf ise bu delilden vazgeçmiş; diğer taraf ise iddia edilen vakıayı kabul (**ikrar**) etmiş sayılır. Şu kadar ki, hâkim duruma ve karşı koyma sebebine göre bu hükmü uygulamayabilir (m. 291, 2).

Yukarıda da belirtildiği üzere, keşfe uyma zorunluluğu yalnızca davanın tarafları için değil, üçüncü kişiler bakımından da vardır. Ancak Kanun üçüncü kişiler bakımından bazı özel düzenlemeler getirmiştir. Buna göre, keşif, üçüncü kişi için uygun olan zamanda yapılır. Keşif zamanı ve yeri, üçüncü kişiye bildirilir (karş. m. 290, 1). Gecikmesinde zarar doğabilecek hallerde bildirim yapılmaksızın keşif icra edilir. Keşfe karşı koyma halinde hâkim, üçün-

cü kişiyi karşı koymanın sebep olduğu giderlere ve disiplin para cezasına mahkûm eder; gerektiğinde zor kullanılmasına karar verebilir. Ancak, üçüncü kişinin (m. 292, 1'de düzenlenen soybağı tespiti incelemesi hariç) tanıklıktan çekinme sebeplerine dayanarak keşfe katlanma yükümlülüğünden kaçınabilme hakkı vardır (m. 292, 2).

Keşif bitince (keşif yerinde) keşifte yapılan işlemleri içeren bir tutanak (**keşif tutanağı**) düzenlenir; plan, çizim, fotoğraf gibi belgeler de bu tutanağa eklenir (m. 290, 2).

Hâkim, keşif sonucunda edindiği bilgileri (ve varsa bilirkişi raporunu) serbestçe takdir eder (değerlendirir); çünkü, keşif bir **takdirî delil**dir (m. 198). Hâkim, keşif sonucunda davanın gereği gibi aydınlanmadığı kanısına varırsa, yeniden keşif yapabilir. Bu iki keşif arasında aykırılık (çelişki) olursa, bu aykırılığın (çelişkinin) giderilmesi için üçüncü bir keşif de yapılabilir.

§ 33. UZMAN GÖRÜŞÜ

HMK, yeni bir kurum düzenlemiştir: "uzman görüşü" (m. 293; karş. CMK m. 67/6). Aslında, HMK öncesinde (HUMK'nda bir hüküm bulunmamasına karşın) taraflar, uzmanlarından görüş alarak mahkemeye sunabilmekte idiler. Ancak, açık yasal bir dayanağının bulunmaması sebebiyle bu konuda bazı tereddütler vardı.

Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere bu düzenleme, Anglo-Sakson hukukundaki "taraf bilirkişisi" veya "uzman tanık" (expert witness) kurumuna paraleldir.

Uzman görüşü, bilirkişi (m. 266-287) kurumundan (bilirkişinin oy ve görüşünden) farklıdır. Bu hükme (m. 293) uygun olarak tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli görüş almaları ve böylelikle, özel ve teknik konularda da tarafların uzman görüşünden yararlanmaları ve iddia veya savunmalarını bu görüşlerle desteklemeleri ve bu görüşü mahkemeye sunmaları mümkün olacaktır.

Ancak, uzman görüşü alınacağı gerekçesiyle mahkemeden ayrıca süre istenemez (m. 293, 1/c. 2).

Uzman görüşü için yapılan giderler, yargılama giderlerinden (bkz. m. 323) sayılmadığından, bu giderler mahkemeyi ve karşı tarafı ilgilendirmez ve başvuran tarafça karşılanır.

Hâkim, dosyaya sunulan uzman görüşü ile bağlı değildir; bu görüşü serbestçe takdir eder; değerlendirir. Hâkim, talep üzerine veya kendiliğinden, kendisinden rapor alınan uzman kişiyi mahkemeye davet ederek (m. 149, 2) dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada, hâkim ve taraflar, uzman kişiye gerekli soruları sorabilir (m. 293, 2). Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirilmez (m. 293, 3). Bu hükümden hareketle uzman görüşü takdirî delil olarak kabul edilebilir.

Uzman kişinin mahkemece dinlenmesi, hâkim ve tarafların sorularına cevap vermesi usulünün, uzman görüşünün tarafsızlığının ve bilimselliğinin ortaya çıkması bakımından çok önemli olduğu kanısındayız.

§ 34. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DİĞER DELİLLER

Deliller ile ilgili olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan da görüldüğü üzere, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, delilleri; ikrar (m. 188), kesin hüküm (m. 303), belge ve senet (m. 199-224), yemin (m. 225-239), tanık (m. 240-265), bilirkişi incelemesi (m. 266-287), keşif (m. 288-292) uzman görüşü (m. 288) olarak saymış ve bunları ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Bu delilleri yukarıda ayrı ayrı inceledik.

Esasında "belge" (m. 199) kavramı her türlü bilgi taşıyıcısını delil olarak kabule elverişli hale getirmiştir. Ancak kanun koyucu, delillerin sınırlandırılmamış olduğunu ifade etmek üzere ve gelecekte belki de "belge" kavramına dahil olamayacak bir delilin de kullanılabilmesinin önünü açmak üzere, m. 192 hükmünü düzenlemiştir[1].

"Kanunda düzenlenmemiş deliller" başlığını taşıyan m. 192, "Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği hallerde, Kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir" hükmünü getirmiştir.

Hükmün Gerekçesine göre: "1086 sayılı Kanunun 367 nci maddesine karşılık gelen bu maddeyle, kanunda düzenlenmemiş olan delillerin hukukî çerçevesi çizilmiştir. Bu düzenleme, 1086 sayılı Kanundaki anlayışı muhafaza etmekte ve delilleri tek tek sayarak sınırlamamaktadır. Her ne kadar tanık beyanı, bilirkişi görüşü, senet ve yemin ayrı ayrı düzenlenmişse de amaç, sadece düzenlenmiş olan bu unsurların delil olabilmesi değildir. Maddeyle, kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği hâllerde, kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabileceği açıkça düzenlenmiş; böylece, senetsiz ispatı caiz olan davalarda aklî, mantıkî ve hukuka uygun yollardan elde edilmiş olmak koşuluyla davayı aydınlatabilecek ve davanın dayanağı olan vakıaları ispatlayabilecek her türlü unsurun delil olarak değerlendirilebileceği esası tereddüde yer vermeyecek bir biçimde düzenlenmiştir. Böylece, aslında eski HUMK'nun mehazında da bulunmayan ve uygulanmasında daima tereddütle karşılaşılan özel hüküm sebepleri kavramı da terk edilmiştir".

---

[1] HMK'ndan önce, bu konu, "**özel hüküm sebepleri** (hususî esbabı hüküm)" başlığı altında, HUMK m. 367'de düzenlenmişti. HUMK m. 367 hükmü, kanunda hüküm bulunmayan diğer deliller bakımından da değer ifade etmekte idi.

§ 35. DELİL SÖZLEŞMESİ[1]

A) GENEL BİLGİ

Buraya kadar kesin ve takdirî deliller incelendi. Bunun gibi, hangi hususların (hukukî işlemlerin) senet (kesin delil) ile ispat edilmesinin zorunlu olduğu da yukarıda "senetle ispat zorunluluğu" bölümünde incelendi. O bölümde kısaca değinildiği gibi delil sözleşmesi, senet (kesin delil) ile ispat zorunluluğuna ilişkin her iki **ana kuralın** (m. 200-201) da **istisnasıdır.**

Delil sözleşmesi, bir hususun (vakıanın veya hukukî işlemin) belli bir delil (örneğin tanık) ile ispat edileceği (veya diğer deliller yanında o delil, örnekte tanık ile de ispat edilebileceği) hakkında yapılan sözleşmenin adıdır.

Hukukumuzda delil sözleşmesinin geçerli olduğu, m. 193'de açıkça düzenlenmiştir. Bundan başka, tanıkla (takdirî delillerle) ispat edilemeyen hukukî işlemlerin (m. 200-201) tanıkla ispat edilebileceği hakkında delil sözleşmesi yapılabileceği m. 200, 2 hükmünde açıkça belirtilmiştir. Buna göre, delil sözleşmesinin konusu **her çeşit delil** olabilir.

Delil sözleşmesi ile hangi delile başvurularak, ispatı gereken vakıanın ispatlanabileceği belirlendiği için delil sözleşmesinin konusunun, ispat olduğu da söylenebilir. Bu nedenle, delil sözleşmesi ile ispat şartı olarak yazılı şekil öngörülebilir veya ispat şartı olan yazılı şekil (senet) ile ispat zorunluluğuna istisna getirilebilir (örneğin, senetle ispatı gereken bir hukukî işlemin tanıkla ispat edilebileceği kabul edilebilir). Buna karşılık, delil sözleşmesi ile geçerlilik şartı olan yazılı şekil yerine başka bir delil veya şekil kararlaştırılamaz.

Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını olanaksız hale getiren veya olağanüstü bir şekilde güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir (m. 193, 2). Özellikle güçlü olan tarafın, diğer tarafın ispat hakkını tamamen ortadan kaldıracak veya güçleştirecek nitelikte, onu, delil sözleşmesi yapmaya zorlaması halinde bu tür delil sözleşmeleri geçerli olmaz.

B) DELİL SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ

Kanun (m. 193), tarafların delil sözleşmesini yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilen imzalı beyanları ile iki tür yapabileceklerini düzenlemiştir. Buna göre, taraflar;

Kanunda belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece belirli delil veya delillerle ispatını (münhasır delil sözleşmesi) kabul edebilirler.

Kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle de ispatını kararlaştırabilirler (münhasır olmayan delil sözleşmesi).

---

[1] Bkz. Ramazan Arslan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Delil Sözleşmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler (Bankacılar Dergisi, Ocak 2013, Özel sayı, s. 67-71); Sema Taşpınar, İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001.

I – MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ

Bir davanın tarafları, dava açılmadan önce veya dava görülürken, delillerin incelenmesine kadar bir hususun (vakıanın, hukukî işlemin) **yalnız belli bir delil ile ispat** edileceği hakkında bir sözleşme yaparlarsa, buna münhasır delil sözleşmesi denir. Yani bu halde, o husus (vakıa) yalnız delil sözleşmesi ile kabul edilmiş olan delil ile ispat edilebilir; **başka bir delil ile ispat edilemez**. Örneğin;

Taraflar, miktar veya değeri m. 200, 1'de belirlenen sınırdan az olan bir hukukî işlemin (tanıkla ispatı mümkün olmasına rağmen) yalnız senetle ispat edilebileceği hakkında bir delil sözleşmesi yapabilirler.

Bunun gibi, miktar veya değeri m. 200, 1'de belirlenen sınırdan fazla olmakla birlikte, istisnai olarak tanık ile ispatı mümkün olan hukukî işlemlerin (m. 203), yalnız senetle ispat edilebileceği hakkında bir delil sözleşmesi yapılabilir.

Taraflar, aslında senet (kesin delil) ile ispat edilmesi zorunlu olan bir hukukî işlemin (m. 200-201), yalnız tanıkla ispat edilebileceği hakkında (münhasır) bir delil sözleşmesi yapabilirler.

Taraflar, bir vakıanın veya hukukî işlemin yalnız yemin ile ispat edilebileceği hakkında bir delil sözleşmesi de yapabilirler.

Delil sözleşmesi ile kararlaştırılan delil çeşidi birden fazla da olabilir. Örneğin, bir hukukî işlemin yalnız tanık ve yemin ile ispat edileceği hakkında yapılan delil sözleşmesi de geçerlidir.

HMK m. 193, 1'de açıkça "delil veya deliller" denildiği için, delil sözleşmesi ile birden fazla delil ile ispat kararlaştırılabilir. Ancak delil sözleşmesi ile kararlaştırılan **delillerin belirli olması gerekir**. Bu nedenle, bir hukukî işlemin "her türlü delil ile ispat edilebileceği" hakkındaki bir delil sözleşmesinin geçerli olmadığı kanısındayız.

Bir hususun belli delil/delillerle ispatı için delil sözleşmesi yapılmış ise, taraflar, delil sözleşmesi ile aynı zamanda delillerini hasretmiş olurlar. Yani taraflar, delil sözleşmesinde kararlaştırdıkları deliller dışında başka delil gösteremezler. İşte bundan dolayı, bu (birinci çeşit) delil sözleşmesine münhasır delil sözleşmesi diyoruz.

Münhasır delil sözleşmesinin en önemli örneği, "**hakem-bilirkişi sözleşmesi**"dir: Hakem-bilirkişi sözleşmesi (anlaşması) ile **taraflar**, aralarındaki belli bir uyuşmazlık konusunun miktarının veya niteliklerinin belirli kişiler veya kurullar (hakem-bilirkişiler) tarafından tespit edileceğini ve hakem-bilirkişilerce yapılacak tespiti kabul edeceklerini kararlaştırırlar.

Bu şekildeki, hakem-bilirkişi atanmasına ve onların verecekleri raporların taraflarca kabul edileceğine ilişkin anlaşmalar, hukukî nitelikçe m. 193, 1'e uygun bir münhasır delil sözleşmesidir. Bu nedenle, hakem-bilirkişi **raporları**, normal bilirkişilerin (m. 266-287) raporlarından farklı olarak (m. 282), gerek tarafları gerek mahkemeyi **bağlayıcı niteliktedir.** Örneğin;

Bir inşaat (eser) sözleşmesinde, yapılacak inşaatın metrajının ve karşılığı olan paranın nasıl tespit edileceği gösterilir ve seçilecek hakem-bilirkişi-

lerin bu hususta yapacakları tespiti tarafların kabul edecekleri kararlaştırılabilir.

Sigorta poliçelerinde, hasarın seçilecek olan hakem-bilirkişiler tarafından tespit edileceği ve tespitin tarafları bağlayacağı kararlaştırılabilir.

Hakem-bilirkişilerin işlevi, sadece kendilerinden isteneni (örneğin hasarı) tespit etmekten ibarettir.

Hakem-bilirkişiler, bu tespitlerini bir raporda belirtirler. Hakem-bilirkişiler, tespit ettikleri husus hakkında (mahkeme veya hakem gibi) ayrıca karar veremezler; örneğin sigortalı malın hasarını tespit ettikten sonra, bu hasarı kimin ödeyeceğine karar veremezler.

Hakem-bilirkişilerin raporu, mahkemede açılan davada hâkimin hükmüne esas teşkil eder; yani mahkeme, normal bilirkişi raporundan (m. 282) farklı olarak, hakem-bilirkişi raporu ile bağlıdır.

II – MÜNHASIR OLMAYAN DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, delil sözleşmesi ile delillerini hasretmez, aksine bir hususun başka bir delil ile de ispat edilebileceğini kararlaştırırlarsa, böyle bir delil sözleşmesine, münhasır olmayan (başvurulacak delil sınırlandırılmamış) delil sözleşmesi denir[2].

Münhasır olmayan delil sözleşmesinin en önemli örneği, senetle ispatı zorunlu olan bir hukukî işlemin (m. 200-201), tanıkla da (takdiri delille de) ispat edilebileceği hakkında yapılan delil sözleşmesidir (m. 200, 2). Bu halde taraflardan biri (örneğin davacı) iddia ettiği hukukî işlemin tanıkla da ispat edilebileceği hakkında bir delil sözleşmesi (m. 193) bulunmasına rağmen, hukukî işlemi senetle de ispat edebilir; senetle ispat edemezse, tanıkla ispat edebileceği gibi, hiç tanık dinletmeden davalıya yemin de teklif edebilir. Tanık dinletilmesine ilişkin delil sözleşmesinin nasıl yapılacağı az sonra delil sözleşmesinin şekli incelenirken görülecektir.

Delil sözleşmesinin açık (anlaşılır) olmaması nedeniyle ne tür delil sözleşmesi olduğunda bir tereddüt olursa, bu delil sözleşmesinin münhasır olmayan delil sözleşmesi olarak yorumlanması, tarafların haklarını daha kolay kullanabilmeleri açısından, daha doğru olur.

C) DELİL SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

Delil sözleşmesi yazılı olarak yapılabilir (m. 193, 1). Bunun için imzalı adî yazılı şekil yeterlidir.

Hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere, delil sözleşmesi açık bir şekilde yapılabilir; üstü kapalı yapılması mümkün değildir.

Taraflar, delil sözleşmesini mahkeme önünde, tutanağa geçirilen imzalı beyan (m. 154) şeklinde de, sözlü olarak yapabilirler (m. 193, 1). Bu şekil, daha çok bir tarafın tanık dinletmek istemesine, karşı tarafın (açık olarak)

---

[2] Şüphe (tereddüt) halinde bir delil sözleşmesinin münhasır olmayan delil sözleşmesi olarak yorumlanması gerekir.

muvafakat etmesi (razı olması) yolu ile olacağı için, burada bu örnek (m. 200, 2) üzerinde durulacaktır. Ancak, yapılacak açıklamalar, başka deliller (örneğin hakem-bilirkişi) hakkında mahkeme önünde (sözlü olarak) delil sözleşmesi yapılması hali için de (niteliğine aykırı düşmedikçe) geçerlidir.

Aslında senetle ispatı gereken hususlarda (m. 200-201) bu husus (m. 200 veya m. 201 hükmü) hatırlatılarak, karşı tarafın açık muvafakatı halinde tanık dinlenebilir (m. 200, 2). Bu halde, aslında senetle ispatı gereken bir hususun tanıkla ispat edilebileceği hakkında, mahkeme önünde yapılan bir sözleşmeden çok, mahkemeye yöneltilmiş, aynı doğrultuda beyanlar söz konusudur.

Bir taraf aslında senetle ispatı gereken (m. 200-201) bir hukukî işlemi tanık ile ispat etmek isterse, hâkim, kanuna (m. 200-201 hükmüne) göre bu hukukî işlemin senet (kesin delil) ile ispat edilmesi gerektiğini (tanıkla ispat edilemeyeceğini), ancak izin verirse tanık dinlenebileceğini karşı tarafa hatırlatır ve karşı taraftan tanık dinlenmesine muvafakat edip etmediğini (razı olup olmadığını) sorar (m. 200, 2). Hâkimin yukarıdaki şekilde hatırlatması ve sorması üzerine karşı taraf tanık dinlenmesine muvafakat ettiğini açık bir şekilde mahkemeye bildirirse, (aslında senetle ispat gereken) o hukukî işlem tanık ile ispat edilebilir (m. 200, 2).

YARGILAMA ve HÜKÜM

Yukarıda incelemiş olduğumuz gibi delillerin incelenmesi tamamlanınca, davanın tahkikat (soruşturma) aşaması son bulur. Bundan sonra, sözlü yargılama aşamasına geçilir. Sözlü yargılamanın bitiminde de hüküm (nihai karar) verilir. Bu bölümde, tahkikatın bitmesi, sözlü yargılama ve hüküm konularını inceleyeceğiz.

§ 36. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKMÜN VERİLMESİ

HMK'nun 184. maddesinde, tek hâkimli mahkemede hâkimin; 185. maddesinde, toplu mahkemede tahkikatı yapmakla görevlendirilen hâkimin görevini tamamlaması üzerine toplu mahkemenin; tarafların iddia ve savunmaları ile toplanan delilleri inceleyip, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın (soruşturmanın) tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verdikten sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını gördüğünde **tahkikatın bittiğini tefhim edeceği**; 186. maddede ise, sözlü yargılamanın nasıl yapılacağı ve mahkemenin taraflara son sözlerini sorup hükmünü vereceği belirtilmiştir.

Hükmün anlamı, verilmesi ve tefhimi, kapsamı, yazılması, imza edilmesi, korunması ve ilâmın alınması ise, Kanunun 294-302. maddelerinde düzenlenmiştir.

A) TAHKİKATIN SONA ERMESİ

Tahkikatın (soruşturmanın) nasıl yapılacağı yukarıda (tahkikat bölümünde) incelendi. Hâkim, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasından sonra, yapıp tamamlayacağı ön inceleme aşamasını (m. 137 vd.) takiben, başladığı tahkikat aşamasında (m. 143 vd.) tarafların dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaları ve bunların ispatı için gösterilen delilleri inceleyip bitirince, tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için duruşmada hazır bulunan taraflara söz verip, onları dinledikten sonra, tahkikatı gerektiren bir hususun kalmadığı anlaşılınca tahkikat aşamasının sona ermiş olduğunu taraflara tefhim eder (m. 184) ve sözlü yargılama aşamasına geçilir (m. 186).

HMK m. 184 hükmünün gerekçesine göre; "hâkim, taraflara öncelikle tahkikat hakkında sözlü açıklama yapabilmeleri için imkân hazırlamakta olup, taraf tahkikat hakkında açıklamalarda bulunmak durumundadır. Hâkim dosyadaki tüm delilleri inceledikten sonra taraflara tahkikat hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. Yapılan sözlü açıklamalardan sonra mahkeme gerekli görürse tahkikatı sürdürür. Aksi hâlde tahkikatın tamamlandığını açıklayarak sözlü yargılama safhasına geçer".

B) SÖZLÜ YARGILAMA

Yazılı yargılama usulüne göre yürütülen yargılamada da tarafların, hükmün verilmesinden önce, sözlü olarak görüş ve değerlendirmelerini açıklamaları, doğru bir karar verilmesi bakımından önemlidir.

Sözlü yargılama aşaması, hükümden önceki son yargılama aşamasıdır.

Kanun, bunun için **ayrı bir duruşma günü tayini**ni öngörmüştür (m. 186, 1). Bu sebeple sözlü yargılama aşamasının, bunun için ayrı bir duruşma günü belirlemeden, tahkikatın sona erdiğinin bildirildiği (aynı) duruşmada (m. 184) yapılmaması gerekir.

Mahkeme, tahkikatın sona ermesinden (m. 184) sonra, sözlü yargılama ve hükmün açıklanması için bir oturum gün ve saati belirleyerek tarafları davet eder (m. 186, 1/c. 1). Sözlü yargılama duruşması davetiyesinde; taraflara belirlenen gün ve saatte hazır bulunmazlar ise yokluklarında hüküm verileceği bildirilir (m. 186, 1/c. 2).

Sözlü yargılama duruşmasında mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü (m. 294) verir (m. 186).

Bu hükmün (m. 186) uygulanmasının şöyle olması gerektiği kanısındayız:

Hâkimin tahkikatın sona erdiğini bildirdiği duruşmada (oturumda) her iki taraf da hazır ise, taraflara sözlü yargılama duruşması davetiyesi çıkarılmasına (tebliğ edilmesine) gerek yoktur. Hâkimin, sözlü yargılama ve hüküm (verilmesi) için belirlenen duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceğini ve hüküm verileceğini duruşmada taraflara bildirmesi ve duruşma tutanağına yazdırması yeterlidir.

Buna karşılık, tahkikatın sona erdiğini bildirdiği duruşmada **taraflardan biri hazır değilse** hâkimin oturumda hazır bulunmayan (tahkikat yokluğunda bitirilmiş olan) tarafa, m. 186 hükmüne uygun biçimde davetiye gönderilmesi gerekir.

Yukarıdaki hallerde, taraflardan biri sözlü yargılama ve hüküm (verilmesi) için belirlenecek duruşmaya (oturuma) gelmezse, sözlü yargılama (m. 186) gelmeyen tarafın yokluğunda yapılır ve hüküm de gelmeyen tarafın yokluğunda (aynı duruşmada) verilir. Belirlenen gün ve saatte **iki taraf da** duruşmada **hazır bulunmazsa** (dosyanın işlemden kaldırılması-m. 150- söz konusu olmaz) hüküm, **yokluklarında verilir**.

Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların kesinleşme kaydı (m. 302, 4) ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılır (m. 302, 5). Örneğin, boşanma kararının kesinleşmesi üzerine nüfus müdürlüğüne yapılması gereken bildirimi, ilk derece mahkeme yapar.

C) HÜKMÜN VERİLMESİ

Sözlü yargılamanın bitmesi üzerine, hükmün (nihaî kararın), sözlü olarak verileceği (tefhim edileceği) yukarıda incelendi. Bu nedenle hükmün verilmesini hemen sözlü yargılama aşamasından sonra inceliyoruz. Burada, hük-

mün (nihaî kararın) verilmesini yalnız şekil (usul) bakımından inceliyoruz. Yani hükmün tefhimini (bildirilmesini) inceliyoruz. Hükmün çeşitleri, içeriği, doğurduğu sonuçlar ve taraflara verilmesi (tebliği) ise, bundan sonraki paragrafta inceleme konusu yapılacaktır.

Mahkeme, sözlü yargılama ve hüküm için belirlenen günde (oturumda, m. 186) hazır olan tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarını ve kendi iddia ve savunmalarının haklılığı yönündeki değerlendirmelerini dinledikten sonra, dava hakkındaki yargılamanın (davanın) sona erdiğini bildirerek hükmünü verir (m. 186, 2; 294, 2; karş. m. 321).

Hükmün tefhimi, 297. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen, hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur (m. 294, 3). Buna göre, mahkemenin davacının istek (talep) sonuçlarından her biri hakkında verdiği hükmü, taraflara yüklenen borç ve hakları (mümkünse sıra numarası altında birer birer) açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde duruşma tutanağına (m. 154) yazdırması ve bunu duruşmada okuması gerekir (m. 294, 3; 297, 2).

Mahkeme, daha önce hükmünü gerekçesiyle birlikte tam olarak yazmış (ve imzalamış) olsa bile, yukarıdaki gibi, en azından hüküm sonucunun (hüküm fıkrasının) duruşma tutanağına (m. 154) tam olarak (açık biçimde) yazdırılması ve okunması gerekir.

Mahkeme zorunlu nedenlerle, kararını gerekçesi ile birlikte (tam olarak) yazmadan, **yalnız hüküm sonucunu tefhim** etmekle yetinebilir. Bu halde de, tefhim edilen hüküm sonucunun açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde duruşma tutanağına geçirilmesi ve okunması gerekir (m. 294, 3; 297, 2). Tefhim edilen bu hüküm sonucuna (fıkrasına) **kısa karar** denir. Kısa kararın tefhimi ile hüküm, hukukî varlık kazanır.

Bu halde, yani zorunlu nedenlerle yalnız hüküm sonucunun (kısa kararın) tefhim edildiği hallerde, **gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir** (m. 294, 4).

Sonradan yazılan gerekçeli kararın, tefhim edilen kısa karara (hüküm sonucuna) uygun olması gerekir (m. 298, 2). Aksi halde bu durum, kanun yolunda hükmün kaldırılması veya bozma sebebi oluşturur.

§ 37. HÜKÜM (KARAR)

Bundan önceki paragrafta, hükmün (nihaî kararın) verilmesi ve tefhimi, yalnız şekil (veriliş biçimi) bakımından incelendi. Bu paragrafta ise genel olarak kararların çeşitleri (ve bu arada, hüküm; nihaî karar) ile hükmün (kararın) içeriği ve doğurduğu sonuçlar incelenecektir.

Hüküm, yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihaî karardır (m. 294-303). Başka bir deyişle hüküm, davayı (uyuşmazlığı) esastan çözen, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren bir (nihaî) karardır. Ancak, mahkemenin verdiği her karar, bir nihai karar olmadığı gibi, hüküm de olmayabilir. Bu nedenle, ilk önce mahkeme kararlarının çeşitleri ve hükmün bu karar çeşitleri içindeki yeri incelenecektir.

A) KARAR ÇEŞİTLERİ

Kararlar, ara kararları ve nihaî kararlar olmak üzere iki şekilde (türde) verilebilir.

I – ARA KARARLARI

Ara kararları yargılamaya (davaya) son vermeyen, aksine onu yürütmeye, ilerletmeye yarayan kararlardır. Hâkim, yargılamayı yürütmek (ilerletmek) için, davada birçok ara kararı verir. Bütün bu kararların ortak özelliği, hâkimin ara kararı ile **davadan** (işten) **elini çekmeyip**, aksine **davaya devam etmesidir**. Örneğin;

Mahkemenin görev itirazının reddine, yetki (ilk) itirazının reddine, bir delilin gösterilmesinin caiz olmadığına ilişkin kararı birer ara karardır.

Hâkimin, davaya ilişkin bir işin yapılması, örneğin delil gösterilmesi (m. 31), okunamayan veya uygunsuz yahut ilgisiz olan dilekçenin yeniden düzenlenmesi için tarafa uygun bir süre verilmesi (m. 32, 2) bir ara kararıdır.

Zamanaşımı def'inin reddine (ve davanın esasının incelenmesine) ilişkin karar da, bir ara kararıdır.

Mahkemenin üst mahkemenin bozma kararına uyması, bir ara kararıdır.

Yargılamanın iadesi sebebinin sabit görülerek yeniden yargılama yapılması hakkındaki karar (m. 380, 1), bir ara kararıdır.

Ara kararı gereğince yapılması gerekli işlemler derhal yerine getirilir. Ara kararının yerine getirildiği veya yerine getirilmeme nedeni zabıt kâtibi tarafından tarih belirtilerek şerh verilir.

Kural olarak, mahkeme (hâkim), **verdiği ara kararından** (dava veya yargılama sonuçlanmadan önce) **dönebilir** (rücu edebilir). Çünkü, ara kararları ile, kural olarak, taraflardan biri lehine usulî kazanılmış hak doğmaz.

Mahkemenin ara kararından dönebileceğine ilişkin bu kuralın bir istisnası vardır: O da **usulî** (usule ilişkin) **kazanılmış hak**tır. Yani, mahkemenin ara kararı ile, taraflardan biri yararına (lehine) **usulî kazanılmış hak** doğmuş ise,

artık mahkeme bu ara kararından dönemez; ara kararına göre işlem yapmakla yükümlüdür. Örneğin;

Yargıtayın bozma kararına uyan mahkeme (m. 373, 3; HUMK m. 429), uyma ara kararı ile bağlıdır; sonradan bozmaya uyma kararından dönerek direnme kararı veremez. Çünkü bozmaya uyma ara kararı ile, bozma yararına olan taraf için usulî kazanılmış hak doğmuştur.

Ara kararı, davayı sona erdirmediği (nihaî karar olmadığı) için, **yalnız başına kanun yoluna götürülemez**; ancak asıl hüküm (nihaî karar) ile birlikte kanun yoluna götürülebilir.

Hukukumuzda, ara kararları için kabul edilmiş genel bir kanun yolu yoktur; yalnız bazı ara kararları için aynı mahkemeye itiraz imkânı (m. 394 gibi) tanınmıştır.

Bunun dışında bir taraf, karşı taraf yararına usulî kazanılmış hak doğurmamış olan ara kararından dönülmesini, mahkemeden isteyebilir.

II – NİHAÎ KARARLAR

Yargılamaya son veren ve **hâkimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran kararlar**a nihaî karar denir. Örneğin, yetkisizlik kararı, görevsizlik kararı, davalının dava konusu parayı ödemeye mahkûm edilmesi kararı, boşanma kararı, aylık kiranın belirli bir rakam olarak tespiti kararı, dava sırasında (dava konusu) borcun ödenmiş olması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı gibi.

Hâkim nihaî karar ile davadan elini çeker; verdiği nihai **karardan dönemez** ve onu **değiştiremez**. Ancak, (ara kararlardakinin aksine) **nihaî kararlar** kural olarak **kanun yoluna götürülebilir**. İşte, nihaî kararlar kanun yoluna götürülüp üst (veya yüksek) mahkemece bozulup geri gönderilmedikçe hâkimin, nihaî kararla sonuçlandırmış olduğu davaya tekrar bakması (el koyması) caiz değildir[1].

Nihaî kararlar, esasa ilişkin (hükümler), usule ilişkin ve davanın konusuz kalması halinde verilen nihaî kararlar olmak üzere üçe ayrılır:

1) Hükümler (Esasa İlişkin Nihaî Kararlar)

Hükümler, **davayı esastan çözümleyen**, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren nihaî kararlardır (m. 294, 1). Başka bir deyişle, hükümler davanın esası (esas) hakkında verilen nihaî kararlardır. Hüküm ile taraflar arasındaki uyuşmazlık (esastan) sona erer ve hüküm kesinleşince (kesin hüküm ortaya çıkınca), artık o uyuşmazlık (dava konusu) hakkında, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak yeni bir dava açılamaz; yani, aynı dava tekrar açılamaz; açılırsa, kesin hüküm dava şartı (m. 114, 1/i) eksikliği nedeniyle reddedilir (m. 303).

---

[1] Karş. Ejder Yılmaz, Dosyadan El Çeken Mahkemenin Kanunyolu Aşamasında Bulunan Davada İhtiyatî Tedbir Kararı Verme Yetkisi (MİHDER 2009/2, s. 213-220; Yılmaz-Makaleler, s. 1797-1804).

Örneğin, davalının davacıya beş bin lira ödemesine, el atmanın önlenmesine, aylık kira miktarının tespitine veya boşanmaya ilişkin nihaî kararlar, taraflar arasındaki uyuşmazlığı esastan sona erdirdikleri için, birer hükümdür.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, **hükümler**, dava çeşitlerine paralel biçimde **üçe ayrılır:**

a) **Eda Hükümleri:** Eda davasının kabulü halinde verilen hükümlere, eda hükümleri denir; örneğin davalının, davacıya beş bin lira ödemeye mahkûm edilmesi hakkındaki hüküm, bir eda hükmüdür. Davacının dava açtığı sırada dava konusu yapacağı para alacağının miktarını belirlemesinin objektif olarak imkânsız olduğu hallerde açacağı belirsiz alacak davasının (m. 107) kabul edilmesi sonucunda verilen hüküm de eda hükmüdür. Topluluk davasında (m. 113), hukuka aykırı durumun giderilmesi veya ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi yönünde verilen esasa ilişkin nihai karar da bir eda hükmüdür.

b) **Tespit Hükümleri:** Tespit hükümleri, her (üç) çeşit davada da söz konusu olabilir:

Tespit davasının kabulüne veya reddine ilişkin hükümler tespit hükümleridir. Çünkü, bu hükümlerle bir hukukî ilişkinin var olup olmadığı tespit edilir; ayrıca eda hükmü (mahkûmiyete karar) verilmez[2]. Topluluk davasında (m. 113) ilgililerin haklarının tespiti talep edilmişse, bu davada verilecek hüküm, tespit hükmü olacaktır

Eda davasının reddine ilişkin hüküm de, eda hükmü olmayıp bir tespit hükmüdür[3].

İnşaî davanın reddine ilişkin hüküm de inşaî hüküm olmayıp bir tespit hükmüdür[4].

c) **İnşaî hükümler** (yenilik doğuran hükümler): İnşaî davanın kabulü halinde verilen hükümlere, inşaî (yenilik doğuran) hükümler denir. Örneğin, boşanma davasında verilen boşanma hükmü, bir yenilik doğuran hükümdür.

Tespit davası ve inşaî dava sonucunda, yargılama giderlerine ilişkin kısım ise her durumda eda hükmüdür ve icra edilebilir niteliktedir.

2) Usule İlişkin Nihaî Kararlar

Usule ilişkin nihaî kararlar ile de yargılama sona erer ve davaya bakmakta olan hâkim, o davadan elini çeker. Ancak bu kararlar ile taraflar arasındaki uyuşmazlık (dava) çözümlenmiş olmaz; yani taraflar arasındaki uyuşmazlık sona ermiş olmaz. Başka bir deyişle, usule ilişkin nihaî kararlar ile dava konusu (talep sonucu) hakkında bir karar verilmez. Bu kararlar ile usule ilişkin sorunlar çözülür; bu nedenle, bu kararlara usule ilişkin nihaî kararlar denir.

---

2 Bkz. yuk. § 16, A, II, 4.
3 Bkz. yuk. § 16, A, II, 5.
4 Bkz. yuk. § 16, A, III, 3.

Usule ilişkin nihaî kararlara aşağıdaki örnekler verilebilir:

Görevsizlik kararı (m. 20), **yetkisizlik** kararı (m. 19), **davanın açılmamış sayılmasına** ilişkin karar (m. 150), usule ilişkin nihaî kararlardandır. **Dava şartlarından birinin bulunmaması** nedeniyle **davanın usulden reddine** ilişkin kararlar da (m. 115; 117; 138) usule ilişkin nihaî kararlardandır.

Davacının, hüküm kesinleşinceye kadar, davalının açık rızası ile **davayı geri alması** (m. 123) nedeniyle davanın son bulduğunu belirten karar da usule ilişkin nihaî karardır.

Usule ilişkin nihaî kararlar, gerek yazılması ve içeriği (m. 297) gerek kanun yolları bakımından, hükümler gibi işlem görür. Bu nedenle, ilerideki hükümlere ilişkin açıklamalar, niteliğine aykırı düşmedikçe, usule ilişkin nihaî kararlar hakkında da uygulanır (m. 294, 6).

3) Davanın Konusuz Kalması Halinde Verilen Kararlar

Bazı hallerde dava devam ederken, dava konusu alacağın ödenmesi, taşınır malın davacıya teslim edilmesi, taşınmazın tahliye edilmesi gibi bir nedenle, dava konusuz kalabilir (dava konusu ortadan kalkabilir).

Davanın konusuz kalması halinde, artık dava (esas talep) hakkında yargılama yapılmasına ve hüküm verilmesine gerek kalmaz. Bu halde mahkeme, **dava** (esas) **hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına** karar verir. Böyle bir karar, yukarıda gördüğümüz her iki çeşit nihaî karardan farklı nitelikte olduğundan, davanın konusuz kalması halinde verilen kararları, üçüncü bir karar çeşidi olarak, ayrı bir başlık altında inceleme uygun olacaktır. Örneğin;

Dava sırasında (dava devam ederken) dava konusu alacak (davacıya) ödenirse dava konusuz kalır. Dava devam ederken dava konusu taşınır mal (davalı tarafından) davacıya teslim edilirse, dava konusuz kalır. Tahliye davası devam ederken davalı (kiracı) kiralananı tahliye ederse, tahliye davası konusuz kalır. Müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davasında davalı, dava konusu taşınmaza el atmaya son verirse (taşınmazdan elini çekerse veya taşınmazı davacıya teslim ederse) dava konusuz kalır. Boşanma davası devam ederken, taraflardan biri ölürse ve onun mirasçısı bulunmazsa veya mirasçısı davaya devam etmek istemezse boşanma davası konusuz kalır (TMK m. 181, II).

Davanın (asıl talebin) konusuz kaldığını tespit eden mahkemenin, bunun üzerine, "dava konusuz kaldığından esas (asıl talep) hakkında karar verilmesine yer olmadığına" karar vermesi gerekir.

Davanın konusuz kalması halinde, mahkemenin, yargılamaya devam ederek, dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip, o tarafı **yargılama giderlerine** (bu arada vekâlet ücretine de) **mahkûm etmesi gerekir** (m. 331, 1).

B) HÜKÜM

Karar çeşitleri incelendikten sonra, burada karar çeşitlerinden (türlerinden) en önemlisi olan hüküm, daha yakından inceleme konusu yapılacaktır. Buradaki açıklamalar, niteliğine aykırı düşmedikçe, diğer karar çeşitleri için de kıyasen geçerlidir (m. 294, 6).

Hükmün verilmesi ve tefhim edilmesi (bildirilmesi), yukarıda incelendi[5].

Burada hükmün içeriği, yazılması, saklanması, taraflara verilmesi ve doğurduğu sonuçlar incelenecektir:

Hükmün neleri içermesi gerektiği, HMK'nun 297. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında, "hüküm, Türk Milleti adına verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar" ifadesi yer almaktadır.

HMK m. 297'ye göre **hükmün aşağıdaki hususları içermesi gerekir**: Başka bir deyişle, hükümde;

1) Hükmü veren mahkeme ile hâkim, zabıt kâtibinin ad ve soyadları ve sicil numaraları; mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa, hükmün hangi sıfatla verildiği yazılır (m. 297, 1/a). Bu husus, özellikle mahkemenin sıfatına göre yargılama usullerinin değişik olduğu haller için çok önemlidir. Örneğin, iş davalarına bakmakla da görevli bir asliye hukuk mahkemesi, bir iş davasına, iş mahkemesi sıfatıyla baktığını kararında açıkça belirtmemişse, davada yazılı yargılama usulü hükümlerinin uygulanması söz konusu olacak ve verilen karar, asliye hukuk mahkemesi kararı kabul edilecektir. Yargıtay, bir mahkemenin başka bir mahkeme sıfatıyla davaya baktığını belirtmemesi halini, mutlak temyiz sebebi saymaktadır.

2) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerinin hükümde yazılması gerekir (m. 297, 1/b).

3) İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakıalarla, bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebepleri gösterilmelidir (m. 297, 1/c). Bu kısım, hükmün gerekçe bölümüdür.

Gerekçe, hâkimin (mahkemenin) tespit etmiş olduğu maddî vakıalar ile hüküm fıkrası arasında bir köprü görevi yapar. Gerekçe bölümünde hükmün dayandığı hukukî esaslar açıklanır. Hâkim, tarafların kendisine sundukları maddî vakıaların hukukî niteliğini (hukukî sebepleri) kendiliğinden araştırıp bularak (m. 33), hükmünü dayandırdığı hukuk kurallarını ve bunun nedenlerini gerekçede açıklar.

Hâkim, gerekçe sayesinde verdiği hükmün doğru olup olmadığını, yani yargılamanın usul kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını; bir anlamda, kendi kendini denetler. Üst mahkeme de, bir hükmün hukuka uygun olup olmadığını ancak gerekçe sayesinde denetleyebilir. Taraflar da ancak gerekçe

---

[5] Bkz. yuk. § 36, C.

sayesinde haklı olup olmadıklarını daha iyi anlayabilirler. Bir hüküm, ne kadar haklı (isabetli) olursa olsun, gerekçesiz ise tarafları doyurmaz.

Hâkim hükmün gerekçesini hazırlarken yargı kararlarından (içtihatlarından) ve bilimsel görüşlerden yararlanır (TMK m. 1, III).

Gerekçe çok önemli olduğundan, **Anayasaya,** "bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılacağı" hakkında **açık hüküm konulmuştur** (Anayasa m. 141, III). Bu hükme uygun olarak hukukî dinlenilme hakkının içeriğinde de kararın somut ve açık olarak gerekçelendirilmesi hususuna yer verilmiş olup (m. 27, 2/c), mahkeme kararlarının gerekçeli olması adil yargılanma hakkının da gereğidir (Anayasa m. 36; AİHS m. 6).

4) Hükmün sonuç kısmında (hüküm sonucunda; **hüküm fıkrası**nda), gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan haklar, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir (m. 297, 2).

Hüküm sonucu, davacı ve davalının talep sonuçlarına mahkemenin vermiş olduğu cevaptır. Mahkeme, davacının talep sonucunu tamamen haklı bulursa, bunu aynen, hüküm sonucuna alır; kısmen haklı bulursa, bu halde iki tarafın talep sonuçlarına da hüküm fıkrasında (kısmen) yer (cevap) verir. Örneğin: "dava konusu yapılan beş bin liralık alacağın yalnız üç bin lirası için davacı haklı görüldüğünden, davalının davacıya üç bin lira ödemeye mahkûm edilmesine ve davanın kalan iki bin liralık kısmının reddine karar verildi" gibi.

Dava dilekçesinin talep sonucunun çok açık olması gerektiği, yukarıda incelendi[6]. Bunun gibi, **hüküm sonucunun da çok açık olması gerekir.** Yani, hüküm sonucunda taraflara yükletilen borç ve tanınan haklar, hiç bir şüphe ve tereddüdü gerektirmeyecek biçimde çok açık olarak yazılmalıdır (m. 297, 2). Çünkü bu husus aynı zamanda hükmün icrası bakımından da önem taşır (İİK m. 24-32).

Hâkim, kural olarak, iki tarafın iddia ve savunmaları ile bağlı olup, **talepten fazlasına veya başka bir şeye hüküm veremez** (m. 26, 1). Örneğin;

Davacı, açtığı elatılan (tecavüz edilen) metrekare başına yüz lira ödenmesine karar verilmesini talep ettiği davada, davalının metrekare başına iki yüz lira ödemesine hüküm verilirse HMK m. 26 hükmüne aykırı davranılmış olur.

Davacının dava tarihinden sonrası için faiz istemediği bir davada mahkemenin faize de hükmetmesi, talepten fazlaya karar vermek olur. Bu ise HMK m. 26 hükmüne aykırıdır.

Davacının, davalının haksız feshettiği sözleşmenin yerine getirilmesi için fesihten önce yaptığı giderlerin karşılığı olarak davalıdan yüz bin lira talep etmiş olmasına karşın, bilirkişi raporuna dayanılarak davacı lehine yüz elli bin liraya hükmedilmesi HMK m. 26'ya aykırı olur.

---

[6] Bkz. yuk. § 17, B, I, 9.

Davada talep (A)'nın yaşının düzeltilmesine ilişkin olduğu için onun yaşının düzeltilmesi ile yetinmek gerekirken ana ve babasının evlenme tarihlerinin dahi değiştirilmesine karar verilmesi HMK'nun 26. maddesine aykırıdır.

Davacının yalnız ayrılık davası açmış olması halinde, mahkeme boşanmaya karar veremez (TMK m. 170, 2).

Mahkeme, yukarıda görüldüğü gibi, talepten fazlaya veya başka bir şeye hüküm veremez ise de, tahkikat sonunda gerçekleşecek duruma göre **talepten noksanına** (azına) **hüküm verebilir** (m. 26, 1); örnekler:

On bin liralık bir alacak davasında, mahkeme, alacağın beş bin lirasının ödenmiş olduğunu tespit ederse, davalıyı beş bin lira ödemeye mahkûm eder (davanın beş bin liralık bölümünün reddine karar verir).

Haksız fiilden dolayı açılan beş bin liralık bir manevî tazminat davasında mahkeme, davacının uğradığı zararın üç bin lira olduğu kanısına varırsa, davalıyı üç bin lira ödemeye mahkûm eder. Davanın iki bin liralık bölümünün reddine karar verir.

Özel kanun hükümlerine dayanan (kanunun açıkça öngördüğü) istisnaî hallerde hâkim, davacının isteğinden başka bir şeye de hüküm verebilir (m. 26, 2). Örneğin;

Boşanma davasında (dava, boşanma için açılmış olup da) karı kocanın barışmaları ihtimali varsa, mahkeme (bu yönde talep olmasa bile) ayrılığa hüküm verebilir (TMK m. 170, 2).

Haksız fiilden doğan manevî tazminat davasında, hâkim, manevî tazminat yerine veya manevî tazminata ek olarak, başka bir tazmin şekline karar verebilir (TBK m. 58).

Taşınır satışında, satılanın ayıplı olması halinde, alıcının açtığı satılanı ret (satımın feshi) davası üzerine, hâkim, durum satımın feshini haklı göstermiyorsa, satış parasının (semenin) indirilmesi ile yetinebilir (TBK m. 227).

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi davasında hâkim, sözleşmeyi feshedeceği yerde, bakım borçlusunu hak sahiplerine nafaka ödemeye mahkûm edebilir (TBK m. 615).

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi davasında hâkim, sözleşmeyi feshetmek yerine, iki taraftan birinin talebi ile veya kendiliğinden, tarafların artık birlikte yaşamalarına son verip, buna karşılık, alacaklıya ömür boyunca bir gelir bağlanmasına karar verebilir (TBK m. 617; ayrıca bkz. TTK m. 202, 1/b; TTK m. 531).

5) Bunlardan başka, **hükümde**, hüküm sonucu, yargılama giderleri (m. 323 vd.) ile taraflardan alınan avansın (m. 120) harcanmayan kısmının iadesi, **varsa kanun yolları ve süresi** (m. 341 vd.); hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzaları ile gerekçeli **kararın yazıldığı tarihin gösterilmesi gerekir** (m. 297, 1/ç-e).

Hüküm sonucunda, kanun yolları ile ilgili açıklama yapılmasının adil yargılanma hakkının sağlanması bakımından özel bir önemi vardır. Buna göre, eğer verilen hükme (karara) karşı kanun yolu açık değilse (yani hüküm verildiği anda kesinse) hüküm sonucunda kanun yolunun bulunmadığı (yani, hükmün kesin olarak verildiği) belirtilir. Buna karşılık kanun yolu açıksa, bu

yolun ne olduğunun ve ayrıca süresinin de bildirilmesi gerekir. Mahkemenin bu konuda yanlış karar vermesi (yani, kanun yolunun bulunmaması halinde, buna karşı kanun yoluna gidilebileceğini veya kanun yolunun bulunmasına rağmen hükmün kesin olarak verildiğini bildirmesi yahut kanun yolu süresini yanlış bildirmesi) halinde ne olacağı konusu tereddütlere yol açmıştır. Yargıtay bu konuda, hükmün değil kanun maddelerinin esas olduğundan hareketle kararlar vermiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru ile ilgili olarak verdiği 09.06.2016 tarihli ve 2014/819 başvuru numaralı kararında; isabetli olarak, temyiz süresinin kanuna göre on gün olduğu bir olayda, mahkemenin süreyi on beş gün olarak yazdığı ve tarafın (on beş günlük süre içinde ve fakat) on gün geçtikten sonra yaptığı temyiz talebinin Yargıtayca reddini adil yargılanma (mahkemeye erişim) hakkının ihlâli olarak değerlendirmiştir.

Hüküm yazılıp imzalandıktan ve mühürlendikten sonra, örnekleri, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine verilir ve bir örneği de gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir (tebliğe çıkarılır). Hükmün bir örneği de, dosyasında saklanır (m. 301, 1). Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan hâkim/hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri tabanında saklanır. Ayrıca, hükmün çıktısı hükme katılan hâkim/hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından imzalanıp mahkeme mührüyle mühürlenerek karar kartonunda muhafaza edilir (Y m. 214). Tarafların elindeki hüküm örneklerinin farklı olması halinde dosyada (karar kartonunda) saklanan esas alınır (m. 301, 3).

Taraflardan her birine verilen hüküm örneğine (suretine-nüshasına), ilâm denir (m. 301, 2).

Bu hükümden de anlaşılacağı gibi, kanun hüküm terimini, kararın yalnız aslı için kullanmaktadır. Hükmün örneği (sureti-nüshası) için ise ilâm terimi kullanılmaktadır.

Taraflar, ilâmı, harcının ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın her zaman alabilirler (m. 302, 1). İlâmın resen tebliği söz konusu olmayıp, ilâm ancak taraflardan birisinin talebi üzerine verilir. Karar ve ilâm harcının bir kısmı ödenmemiş olsa bile hüküm, taraflara tebliğ edilebilir; icra takibine konulabilir ve hüküm hakkında kanun yollarına başvurulabilir (m. 302, 2; Harçlar K. m. 28/a, c.3).

İlâmın usulen taraflardan her birine **tebliği ile, kanun yoluna başvuru süresi işlemeye başlar** (m. 345). Yani, kanun yoluna başvuru süresi ilâmın taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren, her bir taraf için ayrı tarihte işlemeye başlar (m. 345; 361).

İlâm, hükmün verilmesi (tefhimi) tarihinden itibaren, kural olarak, **on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar** (TBK m. 156, 2). Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman on yıldır. İlâma dayanan takip, son işlem üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (İİK m. 39, 1). Hüküm, zamanaşımına uğramayan (örneğin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı) bir hakla ilgili ise ilâm zamanaşımına uğramaz.

Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların, kesinleşme kaydı (m. 302, 4) ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler ve ilk derece mahkemesince yapılır (m. 302, 5)[7]. Örneğin, boşanma kararının kesinleşmesi üzerine nüfus müdürlüğüne yapılması gereken bildirimi ilk derece mahkemesi yapar.

Yukarıda belirtildiği (§ 3, D) üzere, **toplu mahkeme**ler, kanunda aksine açık hüküm bulunmadıkça **bütün üyelerin** (yani, asliye ticaret mahkemeleri ve istinaf mahkemeleri üç; Yargıtay daireleri beş üyenin) **hazır bulunması ile oluşur**; bütün üyelerin hazır bulunmasıyla müzakerede bulunulur; işlem yapılır ve karar (ara karar, nihaî karar) verilir. Bu sebeple, **eksik üye ile müzakere ve işlem yapılamaz; karar verilemez.** Aksi halde yapılan müzakere, işlem ve karar yok hükmündedir. Bununla birlikte, üyelerin tamamının bir araya gelmesi halinde oy çokluğuyla işlem yapılabilmesi ve karar verilebilmesi mümkündür.

C) HÜKMÜN DOĞURDUĞU SONUÇLAR

Hâkim, verdiği ve bildirdiği (tefhim ettiği) hüküm ile bağlıdır; sonradan hükmün yanlış olduğu kanısına varsa bile, artık hükmünü değiştiremez; yani mahkeme davayı tekrar ele alıp, yeni (başka) bir karar veremez. Hükme karşı kanun yoluna başvurulur ve hüküm üst mahkeme (istinaf mahkemesi) tarafından kaldırılır veya Yargıtay tarafından bozulursa, mahkeme ancak o zaman davayı tekrar ele alabilir.

İleride görüleceği gibi, istisna olarak, bazı nihaî kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz[8]. Bunun dışındaki nihaî kararlara karşı kanun yoluna başvurulabilir.

Bir ilâmın (hükmün) icraya konulabilmesi (İİK m. 24 vd.) için, hükmün **kesinleşmesi** kural olarak **şart değildir**; yani ilâmlar, kural olarak kesinleşmeden icraya konulabilir. İstisna olarak, kanunda sınırlı biçimde sayılmış olan davalara ilişkin ilâmlar kesinleşmedikçe icra olunamaz (m. 350).

Daha kısa zamanaşımına tâbi olan bir borç (bkz. TBK m. 72, 82, 147), bir hüküm ile tespit edilince yeni zamanaşımı süresi on yıla çıkar (TBK m. 156).

Aksi belirtilmediği takdirde, ihtiyatî tedbir kararının etkisi, nihaî kararın kesinleşmesine kadar devam eder (m. 397, 2).

---

7 7035 s.K. ile m. 302'ye 5. fıkra olarak eklenmiştir.

8 Bkz. aşa. § 55, C; § 56, C; § 59, C.

DAVADA ÖZEL DURUMLAR

Yukarıda, davanın açılmasıyla başlayan **dilekçeler aşaması**, mahkemenin yaptığı **ön inceleme ve tahkikat aşaması** ile davanın son aşaması olan sözlü yargılama ve **hüküm aşamaları** incelendi. Bu aşamalar, yazılı yargılama usulünün, her davada ortaya çıkan olağan aşamalarıdır. Davada bundan sonraki aşama, **kanun yolları aşamasıdır.**

Kanun yolları aşamasına geçmeden önce, öğretim ve anlama kolaylığı açısından, Kitabımızın bu bölümünde büyük bir parantez açarak, her davada değil de, bazı davalarda ortaya çıkan ve "**özel durumlar**" diye adlandırılan bazı usul müesseseleri incelenecektir. Örneğin:

Davada, davacı ve davalı tarafta, normal olarak birer kişi bulunur. Ancak, bazı durumlarda davacı ve davalı tarafta birden fazla kişi de yer alabilir. Tarafın birden fazla kişiden oluşması, **dava arkadaşlığı** (m. 57) olarak adlandırılır. Aşağıda görüleceği üzere, bazı hallerde dava arkadaşlığı zorunludur; bu sebeple, dava dilekçesinde bütün dava arkadaşlarının (davacı, davalı olarak) ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde, (eksikliğin tamamlanmaması halinde) davanın reddi yoluna gidilir. Ayrıca, yargılamanın devamı sırasında yapılacak işlemlerin de bütün zorunlu dava arkadaşları tarafından birlikte yapılması esastır. Bazı hallerde ise, dava arkadaşlığı ihtiyarîdir. Kanun, dava arkadaşlığını özel olarak düzenleme ihtiyacını hissetmiştir.

Dava, davacı ve davalı arasında görülmesine rağmen, bazı durumlarda üçüncü kişilerin **davaya katılması** (davaya müdahale etmesi; m. 65 vd.) mümkündür. Davaya katılmanın aslî veya fer'i olmasının, önemli sonuçları vardır.

Bir davanın görülmesi sırasında, bu davanın başka bir dava ile yakından ilgisi bulunduğu (başka bir ifade ile ilgili davalarda biri hakkında verilecek olan hükmün diğerini etkileyebileceği) anlaşılırsa ve iki davanın ayrı ayrı olarak görülmesinin, usul ekonomisine (m. 30) aykırı olacağı yahut bu davalarda zıt (çelişik) kararların çıkmasının sakınca yaratacağı gibi bir sonuca varılırsa, davanın diğer davanın sonucunun beklenmesi (m. 165) veya her iki davaların birleştirilerek bir arada görülmesi (m. 166) ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu yüzden, davayı gören mahkeme (duruma göre) diğer davanın sonucunun beklenmesine karar verirse (bekletici sorun kararı alırsa), yargılama, diğer davanın sonucuna kadar ertelenir; mahkeme, davaların birleştirilmesine karar verirse, davalar ilk açılan dava dosyası üzerinde birleştirileceğinden, ikinci davayı gören mahkeme elindeki dava dosyasını diğer mahkemeye gönderir.

Bazı hallerde, iki kişi arasında görülmekte olan davaya, menfaatinin varlığı halinde üçüncü kişinin katılması (**davaya müdahale**; m. 65) gündeme gelebilir ve mahkeme, bu aşamadan itibaren davayı üçüncü kişi birlikte görmeye devam eder.

Davacı veya davalı, başlangıçtaki iddialarını yahut savunmalarını **ıslah** ederek (m. 176 vd.) değiştirirlerse, mahkeme, yargılamayı bu değişiklikler üzerinden devam ettirir.

Yukarıda verilen örneklerin de gösterdiği gibi, davada ortaya çıkan bu tür özel durumlar, yargılamanın yürütülmesi ve sona erdirilmesinde önemli sonuçlar doğurmaktadırlar.

Bu genel açıklamadan sonra, "özel durumlar"ı incelemeye geçebiliriz.

§ 38. ÖN SORUN[1]

A) KAVRAM

Önüne getirilen davada (uyuşmazlıkta) mahkemenin esas olarak yapacağı iş, taraflardan hangisinin ne oranda haklı olduğunu belirleyerek, taraflar arasındaki uyuşmazlığı esastan vereceği nihaî kararla (hükümle) sona erdirmektir. Bu husus, esasen yargılamanın da amacını oluşturur.

Bazı hallerde, görülmekte olan davada, uyuşmazlığın esasının karara bağlanmasından önce çözümlenmesi gereken, bazı ikincil (yan) sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, hukuken ayrı birer dava olmayıp, asıl dava üzerine aşılanmış **küçük davacık**lar niteliğindedir.

Mahkemenin, davanın esası hakkında karar verebilmesi için önce bu sorunların çözülmesi (bunların karara bağlanması) gerekir. Bu tür sorunlara, "**ön sorun**" ("ara sorun"; "hâdise"; "meselei mukaddime") denir (m. 163).

Ön sorun, aşağıda[2] görülecek olan "bekletici sorun"dan farklı bir müessesedir.

Ön soruna bazı örnekler verilecek olursa:

Taraflardan biri **hâkimi reddederse** veya çekilmeye davet ederse (m. 36 vd.), reddi istenen hâkim, ret hakkında karar verecek olan yetkili ve görevli mahkeme (merci) karar verinceye kadar o davaya bakamaz (m. 32, 2). Hâkimin davaya bakabilmesi, önce, hâkimi ret talebinin incelenerek reddine bağlıdır; eğer ret talebi yerinde ise, hâkim davaya bakamayacaktır. Görüldüğü üzere, hâkimin reddi halinde, önce bu sorunun çözümlenmesi gerekmektedir.

Davada taraflar için öngörülen yasal süreler veya hâkimin kesin olarak verdiği süreler hak düşürücü niteliktedir. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar (m. 94). Görülmekte olan bir davada, tarafın kesin süre içinde yapması gereken bir işlemi yapmadığını (örneğin, delil listesini sunmadığını) varsayalım. Mahkeme bu durumda diğer tarafın gösterdiği deliller üzerinden yargılamaya devam edecektir. Yargılamanın bu çerçevede ilerleyen bir aşamasında (sözgelimi, hüküm verme aşamasında), kesin süre içinde işlem yapmamış ve hakkı düşmüş olan taraf, mahkemeye gelerek altı aydır hastanede yattığına dair usulüne uygun bir rapor getirerek **eski hale getirme** (m. 95 vd.) talebinde bulunursa, mahkeme, esas hakkında karar vermeden önce, eski hale getirme talebini inceleyerek karara bağlamak zorundadır (m. 100, 1). Mahkemenin eski hale getirme talebini inceleyip karara bağlamadan (yani, yalnızca bir tarafın

---

1 Seda Özmumcu, Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Ön Sorun, İstanbul 2019.

2 Bkz. aşa. § 39.

delillerini dikkate alarak ve diğer tarafın delillerini değerlendirmeden) esas hakkında vereceği karar, hukuka aykırı olur.

Davada, mahkemeye delil olarak sunulan bir belgenin sahte olduğu ileri sürülürse (m. 298, 3), mahkeme, önce bu sahtelik iddiasının doğru olup olmadığını inceleyip (m. 211) karara bağlamak zorundadır.

Duruşmada, aleniyet (kamuya -halka- açıklık) esastır. Ancak, genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme, gizli (kamuya kapalı) duruşma yapılıp yapılmamasını bir ön sorun olarak inceleyip karara bağlar (m. 28, 3).

B) ÖN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Yargılama sırasında, davaya ilişkin bir ön sorun ortaya çıkarsa, ilgili taraf, bunu dilekçe ile veya duruşma sırasında tutanağa geçirtmek ve altı imzalamak suretiyle sözlü olarak talep eder (m. 163).

Mahkemenin kendiliğinden gözönüne alması gereken konularda, talep olmadan da bir husus ön sorun incelenerek karara bağlanabilir (örneğin, gizli duruşma ile ilgili m. 28, 3).

Ön sorun, esas olarak, davayı gören mahkeme içinde (o mahkeme tarafından) incelenip karara bağlanır. Ancak, yukarıda hâkimin reddi konusunda olduğu üzere, istisna olarak, kanunen ön sorunu başka bir mahkeme (hâkim) karara bağlar.

Hâkim, ilk önce ön sorun talebinin incelemeye değer olup olmadığına karar verir (m. 164, 1). Hâkim, ön sorun talebini incelemeye değer bulursa, bu talebi, vereceği süre içinde varsa delilleriyle birlikte cevap verebilmesi için, talebin sözlü veya yazılı olmasına (m. 163) göre, karşı tarafa tefhim veya tebliğ eder (m. 164, 1).

Ön sorun hakkında iki taraf arasında uyuşmazlık varsa, hâkim ön sorun talebini, tarafları davet edip dinledikten sonra, karara bağlar (m. 164, 2) ve verdiği kararı, taraflara tefhim veya tebliğ eder (m. 164, 3).

Ön sorun hakkındaki karar, mahkemenin davadan el çekmesi sonucunu doğuruyorsa (örneğin mahkeme, yetkisizlik kararı vermişse), bu bir nihaî karar olduğundan bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir. Buna karşılık, mahkemenin ön sorun hakkındaki kararı, yargılamaya son vermiyorsa, (mahkemenin davadan el çekmesini gerektirmiyorsa), bu karar bir ara kararıdır; yalnız başına kanun yoluna gidilemez; ancak esas hakkındaki kararla birlikte kanun yoluna gidilebilir.

§ 39. BEKLETİCİ SORUN[1]

A) GENEL BİLGİ

Bir davada ön sorun (m. 163-164) olarak incelenebilecek olan bir husus, **ayrı** (başka) **bir dava konusu yapılmış** ise ne olacaktır? Burada iki ihtimal vardır:

Her iki dava **aynı mahkemede açılmış ise**, davalar arasında bağlantı bulunması durumunda, mahkeme, iki **davanın birleştirilmesine** (m. 167) karar verir ve davalardan birini diğerinden önce inceleyip karara bağlayabilir. Örneğin, bir senet için açılan **ayrı sahtelik** (menfî tespit) **davası** ile o senedin delil olarak gösterildiği dava (örneğin alacak davası) **aynı mahkemede** görülmekte ise, mahkeme, bu iki davanın bağlantı nedeniyle birleştirilmesine karar verir ve önce ön sorun olarak sahtelik davasını inceleyip karara bağlar. Bu örnekte mahkeme, birleştirilen davalardan birini diğerinden önce inceleyip karara bağlamak zorunda değildir. Birleştirilen davaların birlikte incelenip karara bağlanması, davalardan birinin ön sorun yapılmasına oranla daha çok emek, zaman ve gider kaybına neden olmayacaksa, birleştirilen davaların birlikte incelenmesi usul ekonomisine (m. 30) daha uygun düşer. Örneğin mahkeme, birleştirilen kısmî dava (m. 109) ile ek davayı birlikte inceleyip karara bağlar.

Bir davada **ön sorun olarak incelenebilecek olan bir husus hakkında** aynı yargı çevresindeki aynı düzey ve sıfattaki **başka bir hukuk mahkemesinde** dava açılmış ise, ikinci davanın açıldığı mahkeme, davanın her aşamasında, taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden bu iki davanın ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilmesine karar verebilir (m. 166). Bu durumda, yukarıdaki gibi işlem yapılır ve mahkeme, davalardan birinin sonuçlanmasını diğeri için ön sorun yapabileceği gibi, iki davayı birlikte de inceleyip karara bağlayabilir.

Buna karşılık, iki davanın birleştirilmesi (m. 166) mümkün olmazsa, bu halde **iki davaya da ayrı ayrı mahkemelerde** bakılması gerekir. Fakat, bu davalardan biri hakkında hüküm verilmesini, diğer davanın sonucuna bağlı gören mahkemenin, o davanın sonuçlanmasını beklemesi, yani o davanın sonuçlanmasını kendi baktığı dava için **bekletici sorun** (meselei müstehire) yapması gerekir (m. 165).

B) BEKLETİCİ SORUN ÇEŞİTLERİ

Yukarıdaki örnek, ön sorunun bekletici soruna dönüşmesini, başka bir deyişle ön sorun ile bekletici sorun arasındaki terim farkını da açıkça göstermektedir. Geniş anlamda ön sorun terimi, bekletici sorunu da içerir. Bu

---

[1] Bkz. İbrahim Aşık, Medenî Usul Hukukunda Bekletici Sorun, Ankara 2012.

nedenle, uygulamada ön sorun, aynı zamanda bekletici sorun anlamında da kullanılmaktadır. Fakat, dar ve gerçek anlamda **ön sorun**, bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için **aynı mahkeme tarafından** (aynı davada) daha önce **karara bağlanması gereken sorun**lardır.

Yukarıdaki, aralarında bağlantı bulunmasına rağmen **ayrı ayrı mahkemelerde görülmeleri gereken davalar** örneğinde olduğu gibi, bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun, **başka bir mahkeme tarafından** (başka bir davada) **karara bağlanması gereken** hallerde artık ön sorun değil, **bekletici sorun** söz konusu olur.

Bazı durumlarda kanunlar, hukuk mahkemesinin, başka bir mahkemede görülmekte olan bir davayı bekletici sorun yapmasını zorunlu kılmaktadır (**zorunlu bekletici sorun**). Bu istisnaî haller dışında, mahkemenin, başka bir mahkemede görülmekte olan bir davanın sonuçlanmasını bekletici sorun yapması, **ihtiyarîdir**; mahkeme, bekletici sorun yapıp yapmamayı kendisi takdir eder.

Bekletici sorun yapılmasının **yararı** vardır. Bu yolla, aynı sorun hakkında iki mahkemeden farklı (çelişik) karar çıkmasını önlenmiş olur ve bekletici sorun yapan mahkeme, diğer davada verilen karardan yararlanarak karar verir. Böylece, bekletici sorun yapılması, iki davaya da aynı zamanda devam edilmesi halinde sarf edilecek olan fazla zamandan, giderlerden ve emekten tasarruf sağladığı için usul ekonomisine (m. 30) de uygun düşer.

Bekletici sorun yapılması, **sakınca** da yaratabilir ve özellikle, başka bir mahkemenin kararının sonucunun beklenmesi (bekletici sorun yapılması), eldeki davanın uzamasına neden olabilir. Davayı uzatmak isteyen davalı, gereksiz bir dava açarak bunun sonucunun beklenmesini isteyebilir. Fakat, bekletici sorun yapmak mahkemenin takdirine bağlı olduğundan, mahkeme bu sakıncayı her zaman önleyebilir. Yani bir mahkeme, görmekte olduğu bir davada savunma yolu ile ileri sürülmesi mümkün olan bir sorunun sonradan ayrı dava konusu yapılmış olması halinde, o (ikinci) davanın sonuçlanmasını beklemeden, o sorunu ön sorun olarak kendisi inceleyip karara bağlayabilir.

Mahkeme, bekletici sorun konusunda her somut olayın özelliğine göre, bekletici sorunun yararını ve sakıncasını değerlendirerek karar verir. Bu açıdan, mahkemenin özellikle, başka bir mahkemede görülmekte olan davada verilecek hükmün kendi bakmakta olduğu davayı etkileyeceğini kuvvetle tahmin ettiği halleri bekletici sorun yapması uygun olur.

HMK'nun 165. maddesinin birinci fıkrasında, "Bir davada hüküm verilebilmesi, görülmekte olan başka bir davaya, idarî makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, davayı gören mahkemenin bekleyeceği husus, başka bir mahkemede görülmekte olan bir davanın sonucu veya idari makamın vereceği kararıdır.

Hukuk mahkemesi, görmekte olduğu davanın incelenmesi ve sonuçlandırılmasını, henüz açılmamış başka bir davanın sonucuna bağlı görürse, ilgili tarafa görevli mahkemeye başvurması için uygun bir süre verir. Kendisine süre verilen taraf, bu süre içinde mahkemeye başvurmazsa, o taraf bu hususlaki iddiasından vazgeçmiş sayılır ve mahkeme esas hakkında kararını verir (m. 165, 2). Kendisine süre verilen taraf dava açarsa, bu davanın sonucunu mahkeme bekleyecektir.

Bu açıklamalardan sonra, bekletici sorun kararı almanın şartlarını incelemeye geçebiliriz. Bunu da, bekletici sorunun zorunlu veya ihtiyarî olmasına göre ikiye ayırarak yapmak gerekir:

I – ZORUNLU BEKLETİCİ SORUN

Aşağıdaki hallerde, hukuk mahkemesi, başka bir mahkemede görülmekte veya görülecek olan işi, kendi bakmakta olduğu dava için bekletici sorun yapmak zorundadır:

1) Anayasa Mahkemesi Kararının Beklenmesi

Bir davaya bakmakta olan hukuk mahkemesi, o davada uygulanacak bir kanun hükmünü Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü **Anayasaya aykırılık** iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır; yani Anayasa Mahkemesinin kararını bekletici sorun yapar (Anayasa m. 152). Anayasa Mahkemesi, **beş ay** içinde karar verir ve açıklarsa, mahkeme bu karara göre hareket eder. Anayasa Mahkemesi beş ay içinde karar vermezse, mahkeme, daha fazla beklemeyerek elindeki davayı, yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır (Anayasa m. 152, III).

2) Uyuşmazlık Mahkemesi Kararının Beklenmesi

Hukuk mahkemesi ile idarî mahkeme arasında olumlu görev (yargı yolu) uyuşmazlığı çıkması halinde, hukuk mahkemesi, görev konusunda Uyuşmazlık Mahkemesince bir karar verilinceye kadar davanın görülmesini geri bırakır; yani Uyuşmazlık Mahkemesinin kararını bekletici sorun yapar. Mahkeme, **altı ay** içinde Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı gelmezse, beklettiği davayı görmeye devam eder (UMK m. 18)[2].

3) İcra Mahkemesinin Bekletici Sorun Yapması

Borçlu, mirasbırakanına (murisine) ait bir alacak için takip edilmekte olup da mirasbırakanının ödemeden aczinin açıkça belli olduğunu veya resmen tespit edilmiş olduğunu (terekenin borca batık olduğunu) (TMK m. 605) ileri sürerse, itirazın kesin kaldırılması talebini inceleyen icra mahkemesi, terekenin borca batık olduğunun tespiti davası açması için borçluya uygun bir süre verir (İİK m. 68, IV).

---

2 Bkz. yuk. § 2, B, IV.

Borçlu bu süre içinde terekenin borca batık olduğunun tespiti için dava açarsa, icra mahkemesi, bu tespit davasının sonuçlanmasına kadar itirazın kaldırılması hakkındaki incelemesini erteler; yani, bekletici sorun kararı alarak, tespit davasının sonucunu bekler.

II – İHTİYARÎ BEKLETİCİ SORUN

Yukarıda örneklerini gördüğümüz zorunlu bekletici sorun dışındaki hallerde, hukuk mahkemesi, başka bir mahkemede görülmekte veya görülecek olan davayı, kendi bakmakta olduğu dava için bekletici sorun yapmak zorunda değildir; yani, bekletici sorun yapıp yapmamak hukuk mahkemesinin takdirine kalmıştır. Ancak belirli şartların varlığı halinde, hukuk mahkemesi, başka bir mahkemede görülen (veya görülecek olan) bir davayı bekletici sorun yapabilir. Bu şartları, bekletici sorun yapılacak davanın açılmış (ve görülmekte) olup olmamasına göre ikiye ayırarak incelemek gerekir:

1) Görülmekte Olan Bir Davanın Bekletici Sorun Yapılması

Görülmekte (derdest) olan bir davanın sonuçlanmasının, başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için, her iki dava arasında **bağlantı bulunması** (m. 166, 4) gerekir.

Bir davada, başka bir davanın sonuçlanmasının bekletici sorun yapılabilmesi için, o davanın başka bir mahkemede açılmış olması gerekir. Her iki dava, aynı hukuk mahkemesinde açılmışsa, mahkeme davanın her halinde kendiliğinden de iki davanın birleştirilmesine karar verip iki davayı birlikte inceleyip karara bağlayabilir (m. 166).

İki dava aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ve davalar ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilmiş ise (m. 166, 1), bu halde de, bekletici sorun değil; belki, ön sorun söz konusu olabilir.

Buna karşılık, ayrı yargı çevrelerinde olan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış olan davalar birleştirilmemiş ise (m. 166, 2), bu halde, davalardan birinin sonuçlanması, diğer dava için bekletici sorun yapılabilir. Fakat bunun için, iki dava arasında bağlantı bulunmalıdır. Bu halde, hangi hukuk mahkemesinin bekletici sorun yapacağı (diğerini bekleyeceği) konusunda, genel bir kural konulamaz. Ancak, **hangi mahkemedeki tahkikat daha ileri bir aşamada** ise, diğerinin onu beklemesi usul ekonomisine uygun düşer. Ancak, davalardan biri sonuçlanmadıkça, diğerinin karara bağlanması mümkün görülmüyorsa, o zaman daha önce sonuçlanması gereken davanın, (diğer mahkeme tarafından) bekletici sorun yapılması gerekir.

Her **iki davanın taraflarının aynı kişiler olması şart değildir**. Bekletici sorun yapılacak davanın tarafları (özellikle bir tarafı) başka kişiler de olabilir.

Bekletici sorun yapılacak davanın diğerinden (bekletilecek davadan) daha önce açılmış olması şart değildir. Ancak davalı, sırf bekletici sorun yaratabilmek için sonradan bir dava açmış ise, ilk davaya bakan mahkeme, sonradan açılan davayı bekletici sorun yapmamalı, sonradan dava konusu edilen sorunu da kendisi (ön sorun olarak) incelemelidir.

Hukuk mahkemesinin, başka bir mahkemede görülmekte olan davanın sonuçlanmasını bekletici sorun yapabilmesi için, bu iki dava arasında **bağlantı bulunması** gerekir. Davaların temelini oluşturan vakıaların (dava sebebinin) ve hukukî sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması (m. 57, 1/c); yani davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması veya biri hakkında verilecek kararın (hükmün) diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, iki dava arasında bağlantı var sayılır (m. 166, 4). Fakat, buradaki (bekletici sorundaki) bağlantı terimini, davaların birleştirilmesindekinin aksine, dar biçimde yorumlamak gerekir.

Bir davada hüküm verilmesi, başka bir davada incelenmekte ve kesin karara bağlanacak olan bir hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise, iki dava arasında bağlantı var sayılır. Diğer davada toplanan delillerin sonucunun, bekletilmesi (bekletici sorun yapılması) düşünülen davaya etkili olması (bağlantı için) yeterli değildir. Bağlantının mevcut olup olmadığı, diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukukî ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilecek davaya etkili olması, başka bir deyişle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilecek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.

Bir hukuk mahkemesinde görülmekte olan dava ile başka bir hukuk mahkemesinde görülmekte olan dava arasında, yukarıdaki anlamda bağlantı varsa, hukuk mahkemesi, diğer hukuk mahkemesinde görülmekte olan davanın sonuçlanmasını (kendi baktığı dava için) bekletici sorun yapabilir.

İki dava arasında bağlantı yoksa veya bağlantı olmakla beraber, hukuk mahkemesi kendi baktığı davada diğer dava konusu olan sorunu, ön sorun olarak inceleme yetkisine sahip ise, hukuk mahkemesi, başka bir hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir davanın sonuçlanmasını bekletici sorun yapamaz; davayı incelemeye devam eder.

Hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile **idarî yargıda görülmekte olan** bir dava arasında bağlantı varsa, hukuk mahkemesi, idarî yargıda görülmekte olan davanın sonuçlanmasını (kendi baktığı dava için) bekletici sorun yapabilir.

Hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir dava (hukuk davası) ile **ceza mahkemesinde görülmekte olan** bir dava (ceza davası) arasında bağlantı varsa, hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını (hukuk davası için) bekletici sorun yapabilir. Fakat bu halde hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını mutlaka bekletici sorun yapmak zorunda değildir. Hukuk mahkemesindeki tahkikat (ceza davasına oranla) daha ileri bir aşamada ise, hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını beklemeden davaya devam eder. Buna karşılık, ceza mahkemesindeki tahkikat (hukuk davasına oranla) daha ileri bir aşamada ise ve ceza davasında verilecek kararın hukuk mahkemesini bağlaması ihtimali varsa, hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını (hukuk davası için) bekletici sorun yapmalıdır.

Hukuk mahkemesi, başka bir mahkemede görülmekte olan bir davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği kanısına varırsa, o davanın sonuçlanmasını bekletici sorun yaptığını, ara kararında açıkça belirtmelidir. Bunun-

la hukuk mahkemesinin bekletici sorun yaptığı davanın **şeklî anlamda kesin hükümle sonuçlanmasına kadar** yargılamayı ertelemesi gerekir.

UMK m. 18, l'deki istisna dışında, hukuk mahkemesinin bekleme kararı, zamanaşımını durduran sebeplerden (TBK m. 153) değildir.

Bu nedenle ve bekletici sorun yapmaya ilişkin ara kararın, dosyanın işlemden kaldırılması kararı (m. 150) niteliğinde olmaması nedeniyle, hukuk mahkemesinin, bekletici sorun yapma kararı ile birlikte yeni bir duruşma günü de belirlemesi (yani duruşmayı başka bir güne ertelemesi) gerekir. Bu yapılırken, bekletici sorun yapılan davanın kesin olarak, sonuçlanmasına kadar geçecek tahmini süre dikkate alınarak, ona göre uzunca bir zaman için duruşma ertelenmelidir.

Mahkemenin bekletici sorun yapma kararı, bir ara kararı olduğundan, bu karara karşı, **yalnız başına kanun yoluna başvurulamaz.** Fakat hukuk mahkemesi, şartları (özellikle iki dava arasında bağlantı) olmadığı halde, başka bir mahkemede görülmekte olan davayı bekletici sorun yapmış ise, taraflara buna karşı bir kanun yoluna başvurma hakkı tanınması uygun olur.

Davacı, bekletici sorun yapma kararına her zaman itiraz edebilir. Bunun üzerine, mahkeme, bekletici sorun yapma kararından, bu kararın hukukî niteliği bir ara kararı olduğundan dönebilir ve davaya devam edilmesine karar verebilir.

Bekletici sorun yapma kararından dönülmesine gerek bulunmadığına ilişkin mahkeme kararının, yalnız başına kanun yoluna götürülemeyeceği kabul edilirse, hâkimin davaya bakmasını sağlamak için aşağıdaki şekilde hareket edilebilir: Şartları (iki dava arasında bağlantı) mevcut olmadığı halde, bir davanın başka bir davanın sonuçlanmasına kadar bekletilmesi, hakkı yerine getirmeden kaçınma niteliğinde sayılabilir. Bu nedenle davacı, Devlet aleyhine tazminat davası açabilir (m. 46, 1/e ve 46, 3).

Hukuk mahkemesinin başka bir mahkemede görülmekte olan davayı bekletici sorun yapmasından sonra, sonucu beklenilen dava, gereği gibi takip edilmez, yani uzatılır veya sürüncemede bırakılır ise, hukuk mahkemesi, taraflardan birinin (özellikle davacının) talebi üzerine bekletici sorun yapma ara kararını kaldırarak davaya devam edebilir.

Sonucu beklenilen (başka mahkemedeki) dava, işlemden kaldırılırsa (m. 150, 1), bekletici sorun yapan (bekleme kararı alan) mahkeme, sonucu beklenilen davanın yenilenmesi (m. 150, 4) için taraflara uygun bir süre vermeli, dava bu süre içinde yenilenmezse, bekletici sorun yapma kararını kaldırarak davaya devam etmelidir.

Zorunlu bekletici sorun bulunan hallerde hukuk mahkemesi, sonuçlanmasını beklediği dava (veya iş) hakkında verilecek **karar ile bağlıdır.**

Bekletici sorun yapmanın ihtiyarî olduğu hallerde de, sonuçlanması beklenilen davada verilen hüküm, **bekletici sorun yapılan davayı**, kural olarak **etkiler**; çünkü, hukuk mahkemesi başka mahkemedeki davayı kendi baktığı davaya etkili gördüğü için bekletici sorun yapmıştır. Buna göre; sonuçlanması beklenilen davada verilen hüküm, bekletici sorun yapılan davada **kesin hüküm** (m. 303) teşkil etmekte ise, hukuk mahkemesi, beklettiği davayı ke-

sin hüküm nedeniyle reddeder. Sonuçlanması beklenilen davada verilen hüküm, bekletici sorun yapılan davada **kesin delil** teşkil etmekte ise, hukuk mahkemesi, baktığı davada bu hükmü, kesin delil olarak kabul etmek zorundadır. Bunun dışındaki hallerde de, hukuk mahkemesi, bekletici sorun yaptığı konu (hukukî ilişki) hakkında, o davada verilen hükümle kural olarak bağlı olmalıdır. Örneğin, hukuk mahkemesi, bekletici sorun yaptığı ceza davasında verilen mahkûmiyet kararı ile bağlıdır. Buna karşılık, hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir.

Bu açıklamalar (kurallar), bir hukuk mahkemesinde görülmekte olan davada hüküm verilebilmesinin bir idarî makamın tespitine bağlı olduğu durumlarda mahkeme tarafından verilecek bekletici sorun kararı (m. 165, 1) için de kıyasen uygulanır.

2) Yeni Açılacak Bir Davanın Bekletici Sorun Yapılması

Buraya kadar, başka bir mahkemede görülmekte olan bir davanın hukuk mahkemesi tarafından (kendi baktığı dava için) bekletici sorun yapılması incelendi. Şimdi ise, henüz açılmamış veya yeni açılacak olan bir davanın bekletici sorun yapılması incelenecektir.

Hukuk mahkemesindeki bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması, başka bir mahkemenin (hukuk mahkemesi veya idare mahkemesinin) görevine giren veya ayrı bir dava konusu yapılması gereken bir hususun çözümüne bağlı ise, mahkeme, ilgili tarafa o konuda ayrı bir dava açması için uygun bir süre verir (m. 165, 2). Örneğin, resmî senette sahtelik iddiası varsa, hâkim, bu iddiada bulunan tarafa, ayrı bir sahtelik davası açmak üzere iki haftalık süre verebilir (m. 208, 4).

İlgili tarafa verilen bu süre, sadece ayrı bir dava açması içindir. Yoksa, ilgili tarafa ayrı bir dava açıp o mahkemeden hüküm getirmesi için süre verilemez. Çünkü verilen süre içinde mahkemeden hüküm getirmek ilgilinin elinde olan bir şey değildir.

İlgili taraf bu süre içinde ayrı bir dava açarsa, birinci davaya bakan hukuk mahkemesi, bu (ikinci) davanın sonuçlanmasını (kendi baktığı dava için) bekletici sorun yapar. İlgili taraf bu süre içinde görevli mahkemeye başvurmazsa, ilgili taraf bu iddiasından vazgeçmiş sayılır ve esas dava hakkında karar verilir (m. 165, 2).

Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılmasının bir idarî makamın çözümüne bağlı olduğu durumlarda da, mahkeme ilgili tarafa idarî makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde idarî makama başvurulursa, mahkeme bekletici sorun kararı verir. Süresi içinde ilgili taraf idarî makama başvurmazsa, ilgili taraf bu hususiaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak, esas dava hakkında mevcut duruma dayalı olarak karar verilir (m. 165, 2).

§ 40. DAVANIN İHBARI[1]

A) KAVRAM

Dava, kural olarak, davacı ile davalı arasında görülür ve mahkemenin yargılamanın sonucunda verdiği hüküm, davacı ve davalı bakımından hüküm ifade eder. Buna bağlı olarak, bir davanın kaybı, normal olarak, davayı kaybeden tarafın zarara (kayba) uğraması ve bu zarara kendisinin katlanması sonucunu doğurur. Bununla birlikte, bazı durumlarda davayı kaybedenin, uğradığı zararı üçüncü kişiden alabilmesi (ona rücu edebilmesi) olanağı vardır. Örneğin (B), on bin lira vererek (C)'den bir inek satın almıştır. Ancak (A), bu ineğin kendisine ait olduğu, ineği (C)'ye geçici olarak bakması için verdiği, (C)'nin malik olmadığından bu ineği (B)'ye satamayacağı, (B)'nin bu ineğin mülkiyetini kazanamayacağı iddiasıyla, ineğin kendisine verilmesi için (B)'ye karşı bir dava açmıştır. (B); (A) ile (C) arasındaki ilişkiyi bilmediği için, (A)'nın iddialarına karşı kendini gereği gibi savunamayabilir ve ineği kendisine satan (C)'nin bu konuda yardımına ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, (A) ile (B) arasındaki bu davanın ileride (A) lehine [(B) aleyhine] sonuçlanması halinde, (B), ineği (A)'ya verecektir. Bu durumda (B)'nin, ineğin bedeli olan on bin lira için (C)'ye rücu etme amacıyla tazminat davası açma olanağı vardır. Dolayısıyla, (A) ile (B) arasındaki davanın sonucu, (bu dava bakımından -dava dışı- üçüncü kişi konumundaki) (C)'yi de ilgilendirmektir ve (B)'nin bu davayı kazanmasında (C)'nin de hukukî menfaati vardır. Bütün bunlar dikkate alındığında, üçüncü kişi (C)'nin (A) ile (B) arasındaki davaya katılması (müdahalesi) önem kazanmaktadır. (C)'nin bu davaya katılabilmesi (müdahale edebilmesi) için, davanın (C)'ye duyurulması ihtiyacı vardır. Kanun (m. 61 vd.) buna, "**davanın ihbarı**" (davanın duyurulması) demektedir.

Kanuna göre; davanın taraflarını oluşturan davacı veya davalıdan biri, davayı kaybettiği takdirde üçüncü kişiye rücu etme (dönme; uğradığı zararı ondan isteme) düşüncesi varsa veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğinden endişe ediyorsa, açılan (görülmekte olan) davayı üçüncü kişiye bildirme ihtiyacında olabilir (m. 61, 1). Bu sebeple, davacı veya davalı durumu, üçüncü kişiye duyurabilir (ihbar edebilir); böylece, tarafı olduğu davadan onun da haberdar (bilgi sahibi) olmasını sağlayabilir.

HMK m. 61-64 dışında, diğer bazı kanunlarda da davayı ihbar ile ilgili özel hükümler yer almaktadır. Örneğin, **satıcının** "**zapttan** (el koymaya karşı garanti) **sorumluluğu**" ile ilgili TBK m. 214, I hükmüne göre, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak dolayısıyla, satılanın tamamı veya bir kısmı bir üçüncü kişi tarafından alıcının elinden alınırsa satıcı, bundan dolayı alıcıya karşı sorumlu olur. Aynı Kanunun, "yargılama usulü/davanın bildirimi adlı 215. maddesine göre de, satılanın elinden alınması tehlikesi ile karşıla-

---

[1] Bkz. Murat Atalı, Medenî Usul Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007.

şan alıcı, kendisine karşı açılan davayı satıcıya bildirdiği zaman satıcı, alıcının yanında davaya katılmak zorundadır[2]. Bildirme, davaya katılmaya ve savunmaya elverişli bir zamanda yapılmışsa, alıcının aleyhinde verilen hüküm, onun ağır kusuru yüzünden verildiği ispat edilmedikçe, satıcı için de sonuç doğurur. Dava, kendisine yüklenilemeyen sebeplerden dolayı satıcıya bildirilmemişse satıcı, zamanında bildirilmiş olsaydı daha elverişli bir hüküm elde edilebileceğini ispatladığı ölçüde sorumluluktan kurtulur.

B) DAVAYI İHBAR USULÜ

Davayı ihbar edecek olan taraf, ihbarda **hukukî menfaati** bulunan taraftır. Davanın her iki tarafının da davayı ihbar etmesi mümkündür. Ancak istisnaen hâkimin de davayı resen ihbarı (m. 46 vd.) öngörülmüş olabilir.

Davayı ihbar eden, üçüncü kişinin **kendi yanında davaya katılmasını** bildirir. Bu sebeple taraflardan birinin, davaya karşı tarafın yanında katılması için ihbarda bulunulmasını istemesinde hukukî menfaati yoktur.

Davanın kendisine ihbar edileceği kişi, davanın kaybı halinde kendisine rücu edilecek olan veya davayı kaybeden kişiye rücu edecek olan **ilgili üçüncü kişi**dir. Eğer kanunlarda kime ihbar yapılacağı hakkında açıkça düzenleme varsa, ihbar o kişiye yapılır. Örneğin TMK'na (m. 301, III) göre, babalık davası; Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Mirasçısız ölen kimsenin mirası Devlete intikal edeceğinden, bu gibi durumlarda davanın Hazineye ihbar edilmesi gerekir.

Davanın ihbarı, **üçüncü kişinin** davacı veya davalı yanına, **taraf olarak katılması** (dahili dava; davanın teşmili) **sonucuna yol açmaz**; bu sebeple dava kendisine ihbar edilen kişi hakkında hüküm kurulamaz.

Dava kendisine ihbar edilen kişi hakkında (taraf olarak) hüküm kurulmaması gerekirken; bunun aksine olarak dava ihbar olunan hakkında (taraf olarak) hüküm tesis edilirse, ihbar olunan kişi, hükmün kendisiyle ilgili kısmına karşı kanun yoluna gidebilir.

HMK m. 62, 1'e göre davanın ihbarı, **tahkikat** (m. 143 vd.) **sonuçlanıncaya kadar** yapılabilir. Bunun nedeni, ihbarın tahkikatın aşamasından sonra yapılmasının, (ihbar ile) amaçlanan sonucu tam olarak gerçekleştiremeyeceği ve yargılamayı uzatacağı düşüncesidir.

---

[2] TBK m. 215, I hükmünde, satıcının, **alıcı yerine geçerek** üçüncü kişiye karşı davayı takip etmek ve savunmak zorunluluğundan söz ediliyorsa da, bu hüküm, 1086 sayılı HUMK'nun, "İki taraftan biri davayı kaybettiği takdirde üçüncü şahsa rücu hakkı olduğu mülahazasında bulunursa **makamına kaim olarak davayı takip** veya davada üçüncü şahıs sıfatıyla kendisine iltihak etmesi lüzumunu o şahsa ihbar edebilir" şeklindeki 49. maddesine (ayrıca bkz. HUMK m. 50) paralel bir hükümdür. Oysa, 6100 sayılı HMK m. 63, HUMK m. 49'dan farklı olarak, ferî müdahilin, taraf yerine geçerek davayı takip etme halini düzenlememiştir. Bu sebeple, HMK m. 63, TBK m. 215, I hükmünü üstü örtülü olarak, "Satılanın elinden alınması tehlikesi ile karşılaşan alıcı, kendisine karşı açılan davayı satıcıya bildirdiği zaman satıcı, alıcının yanında davaya katılmak zorundadır" şeklinde değiştirmiştir.

Kanun yolu aşamasında davanın ihbarı kural olarak mümkün değildir. Ancak, üst mahkeme kararı sonrasında tahkikat yeniden yapılacak ise davanın ihbarı bu aşamada mümkün olmalıdır.

Dava kendisine ihbar edilen **üçüncü kişi** de, başka bir kişiye rücu etmesi olanağının veya üçüncü kişinin kendisine rücu etmesi olasılığının bulunduğunu düşünüyorsa; o da **davayı başkasına** (dördüncü kişiye) **ihbar edebilir** (m. 61, 2). Kendisine dava ihbar edilen dördüncü kişinin de aynı şekilde davayı bir diğer kişiye (beşinci kişiye) ihbar etmesi olanağı vardır. İhbarlar bu şekilde, ard arda (tevali edebilir) gelebilir (m. 61, 2).

HMK'nda (m. 61 vd.) düzenlenen davanın ihbarı hükümleri, idarî yargıda da uygulanır.

Davanın ihbarı, **tek taraflı usul işlemi**dir; karşı tarafın iznine veya mahkemenin onayı bağlı değildir. Taraf isterse, davanın ihbar edilmesini mahkemeden talep edebileceği gibi, isterse mahkemeye başvurmadan doğrudan doğruya kendisi de davayı ihbar edebilir.

Tarafın, ihbarın yapılmasını mahkemeden talep etmesi, ihbar sebebinin gerekçelerini bildiren bir **dilekçe** ile mahkemeye başvurması suretiyle olur. Talebin mahkemece kabulü halinde, mahkeme tarafın dilekçesinin bir örneğini ekleyerek, üçüncü kişiye usulüne uygun şekilde tebligat çıkartır. Mahkeme, davanın ihbarı talebini kabul etmezse, davanın ihbarı bizzat (doğrudan doğruya) ilgili tarafça yapılır; çünkü, mahkemenin ihbar talebini kabul etmemesi, hukukî menfaati bulunan tarafın ihbarda bulunmasına engel değildir.

Davanın ihbarı sebebiyle yargılama başka güne bırakılamaz ve ihbarın tevalisi (m. 61, 2) dışında ihbarda bulunana süre verilmez (m. 62, 2). Başka güne bırakmama ve süre verilmemesinin gerekçesi, yargılamanın gereksiz uzamasının ve kötüniyetli ihbarın önüne geçilmesidir.

Tarafın bizzat davayı ihbarı, **yazılı şekilde olur**; ihbar eden üçüncü kişiye göndereceği yazılı ihtarnamede, ihbar sebebinin gerekçelerini açıklar ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunu belirtir (m. 62, 1).

C) DAVAYI İHBARIN SONUÇLARI

Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukukî yararı olan taraf yanında davaya katılabilir (m. 63). Hükümde (m. 63) yer alan "**davayı kazanmasında hukukî yararı bulunan** taraf yanında" ibaresi, 61. madde ile birlikte düşünülerek yorumlanmalıdır. Buna göre üçüncü kişi; davayı kaybeden tarafın kendisine rücu edeceğini veya bizzat üçüncü kişinin davaya kaybedene rücu edeceğini düşünerek, kendi (üçüncü kişi) açısından hangi tarafın davayı kazanması gerekiyorsa, o taraf yanında davaya katılacaktır.

Hükmün gerekçesinde yer alan, "bu düzenlemeye göre, kendisine ihbarda bulunulan üçüncü kişi, mutlaka ihbarda bulunan tarafın değil, hukukî yararı bulunuyorsa diğer tarafın da yanında yer alabilecektir" ifadesinden, üçüncü kişiye bu konuda bir takdir hakkı verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, yukarıda (m. 61) yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere, taraflardan birinin, karşı tarafın yanında katılması için üçüncü kişiye ihbarda bulunulmasını iste-

mesinde hukukî menfaati yoktur. Bu nedenle, hükmün gerekçesinde yer alan ifade yadırgatıcıdır. Çünkü kimse, kendi aleyhine (diğer taraf lehine) olarak, üçüncü kişinin davaya katılması için davanın ihbarında bulunmaz. Kaldı ki davanın ihbarının, ihbar eden tarafa etkisini düzenleyen 64. maddenin gerekçesinde yer alan, "... dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişinin ihbar eden yanında davaya ferî müdahil olarak katılmadığı hallerde, aralarındaki rücu bakımından ihbar alan kişi, asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verilmiş olduğunu ileri süremeyecektir" ifadesi de, burada varılan sonucun doğruluğunu güçlendirmektedir.

Davanın ihbarı üzerine **üçüncü kişi**, davaya **ferî müdahil olarak katılır** ve katıldığı tarafa (davayı kazanması için) yardım eder (m. 68). Davanın sonunda, fer'i müdahilin yanına katıldığı taraf, (dava, sulh, davanın açılmamış sayılması veya davanın konusuz kalması gibi başka nedenlerle sona ermediği takdirde) davayı ya kaybedecek ya da kazanacaktır. Bu durumda verilen hükmün, davayı ihbar eden tarafa etkisi, "ferî müdahalenin etkisi"ni düzenleyen 69. maddeye yollama yapılarak düzenlenmiştir.

Bu husus özellikle, davayı ihbar eden tarafın davayı kaybı halinde üçüncü kişiye karşı açacağı rücu (dönme) davasında kendisini gösterir. Dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişinin (ihbar eden yanında) davaya **fer'i müdahil olarak katılmadığı hallerde**, aralarındaki rücu bakımından ihbar alan kişi, asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verilmiş olduğunu ileri süremeyecektir. Bununla birlikte, ihbar alan kişi, ihbar eden tarafın ihbarı zamanında yapmamış olduğunu yahut iddia ve savunma imkânlarının asıl davada ihbar eden tarafından ağır kusurlu olarak değerlendirilebilecek surette kullanmadığını; davayı hatalı yürüttüğünü ileri sürebilecektir. Kanunun benimsemiş olduğu bu çözüm tarzı, ihbarı alan kişinin ihbar eden taraf yanında davaya fer'i müdahil olarak katılmaması durumu için ağır bir yaptırım getirmek yoluyla davanın ihbarı kurumunu etkin ve anlamlı kılmaktadır.

§ 41. DAVAYA MÜDAHALE

Yukarıda davanın ihbarı müessesesi hakkındaki açıklamalardan da görüldüğü üzere, derdest bir davaya, üçüncü kişilerin katılması mümkündür. Üçüncü kişinin davaya müdahalesi için, mutlaka davanın ihbar edilmesi gerekmez.

Öte yandan, davanın ihbarında üçüncü kişinin davaya (yalnızca) ferî müdahalesi söz konusu olur. Oysa, davaya müdahale, yalnızca ferî müdahaleden ibaret değildir. Davaya aslî müdahale de mümkündür.

Davaya ferî müdahale ile aslî müdahale, şartları, usulleri ve doğurdukları sonuçlar itibariyle birbirinden farklı müesseselerdir.

A) FERÎ MÜDAHALE[1]

I – KAVRAM

Görülmekte olan bir davanın sonucunda hakkı veya borcu etkilenecek olan **üçüncü kişinin**, (aslî müdahaleden farklı olarak) **taraflardan birinin yanında,** onun davayı kazanması amacıyla **davaya katılması mümkündür.** Bu durum, iki kişi arasında görülen davada verilecek olan hükmün, doğrudan doğruya o davanın tarafları ile ilgili sonuçları olmasına rağmen; bu davada aleyhine karar verilecek olan tarafın, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin davayı kaybeden tarafa rücu etmesi (başvurması) sonucunu ortaya çıkarabileceğinden (m. 61, 1), üçüncü kişinin taraflardan birinin davayı kazanması için ona yardım etmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Davaya katılmanın (müdahalenin) bu türüne, **ferî müdahale**, davaya katılana da **ferî müdahil** denir.

Bir davaya ferî müdahil olarak davaya katılacak olan kişinin, davaya katılmasında, hukukî yararının bulunması gerekir (m. 66, 1).

Örneğin (B), beş bin lira vererek (S)'den bir bilgisayar satın almıştır; bundan sonra (A), (B)'ye karşı bir dava açmış ve bu davada söz konusu bilgisayarın kendisine ait iken çalındığı gerekçesiyle, bilgisayarın kendisine verilmesini istemiştir.

(B), bu davayı kaybederse ödediği beş bin lirayı (satıcının, satış konusu mal nedeniyle garanti -tekeffül- borcu nedeniyle -TBK m. 214-) (S)'den isteme hakkına sahiptir. O halde, (B)'nin davayı kazanmasında (S)'nin hukukî yararı bulunmaktadır.

Üçüncü kişinin, aynı zamanda hem davacının hem de davalının yanında katılması, ilke olarak, hukukî yarar yokluğu sebebiyle mümkün değildir.

Davada, davacı veya davalı tarafta birden fazla kişinin bulunması (dava arkadaşlığının varlığı) halinde, üçüncü kişi, dava arkadaşlarından yalnızca birinin veya birkaçının yanında da davaya katılabilir.

---

[1] Bkz. Hakan Pekcanıtez, Medenî Usul Hukukunda Fer'i Müdahale, Ankara 1992.

Davaya katılma, taraflardan birinin ihbarı (m. 61 vd.) üzerine olabileceği gibi, hukukî menfaatinin varlığı şartıyla, üçüncü kişinin böyle bir ihbarı beklemeden de olabilir.

Örneğin, vakıf tüzel kişiliğine karşı açılan, vakıf yöneticilerinin görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davada, bu davanın vakıf aleyhine sonuçlanması halinde vakıf yöneticilerinin bundan böyle hiçbir vakıfta görev almalarının mümkün olamayacağı sebebiyle, vakıf yöneticilerinin bu davaya (ferî) müdahil olarak katılmalarında hukukî yararları vardır.

Ferî müdahil (aslî müdahilden farklı olarak), aşağıda (m. 68) görüleceği üzere, davada taraf değildir; **katıldığı tarafın yardımcısı**dır (m. 66, 1).

II – FER'Î MÜDAHALE USULÜ ve MÜDAHALENİN SONUÇLARI

Yukarıda gördüğümüz davayı ihbar ile ilgili 61. maddede, davanın taraflarından birinin davayı üçüncü kişiye ihbar etmesi üzerine üçüncü kişinin davaya fer'i müdahil olarak katılmayı kabul etmesi halinde, yargılamaya gelerek kendisine ihbar eden kimse yanında, davaya katılmasını düzenlemektedir. 67. maddedeki düzenleme ise, kanımızca, **üçüncü kişinin kendiliğinden** davaya ferî müdahil olarak **katılması talebi** ile ilgilidir. Çünkü, m. 67, 1 hükmü, davaya ferî müdahil olarak katılmak isteyen üçüncü kişinin, bir dilekçe vererek müdahale talebinde bulunması şartını aramaktadır. Oysa davanın ihbarında, üçüncü kişi, kendi yanında davaya katılmak üzere çağrıldığı için, davanın ihbar edilen üçüncü kişinin ayrı bir dilekçe vermesine gerek yoktur; bu durumda üçüncü kişi davete uyarsa, dilekçe vermesine gerek olmaksızın, yargılamaya katılır.

Üçüncü kişi, ferî müdahale dilekçesinde, davaya hangi taraf yanında (m. 66) katılmak istediğini, neden müdahale talebinde bulunduğunu ve bunun gerekçelerini (dayanaklarını, delillerini) davayı görmekte olan mahkemeye bildirir (m. 67, 1).

Yargılama hukukunda bütün taleplerde hukukî yararın bulunması şartı nedeniyle, üçüncü kişinin davaya müdahale talebinde de aynı esas geçerlidir (m. 66).

Ferî müdahaleden söz edebilmek için katılan kişinin bu yönde talebinin (m. 67, 1) bulunması gerekir. Hâkimin kendiliğinden üçüncü kişiye bildirimde bulunması, üçüncü kişinin bu konuda usulüne uygun bir talebi bulunmadıkça ferî müdahale olarak değerlendirilemez.

Müdahale dilekçesi, mahkemece davacı ve davalıya **tebliğ edilir** (m. 67, 2/c. 1). Tebliğin amacı, mahkemenin talep hakkında vereceği karar hakkında her iki tarafın görüşlerini almaktır.

Kanunda (m. 67, 2/c. 2) kullanılan "gelmeseler dahi" ifadesinden, inceleme için tarafların (ve gerekirse üçüncü kişinin) **duruşmaya davet** edileceği anlaşılmaktadır. Tarafların (ve çağrılmışsa üçüncü kişinin) duruşmaya gelmemeleri halinde, karar verilebilmesi için, mahkemenin taraflara göndereceği davetiye, **uyarılı davetiye** olmalı ve "gelmemeleri halinde karar verileceği" yazılmalıdır.

Davaya ferî müdahale talebi, **tahkikat bitinceye kadar** (m. 184-185) yapılabilir (m. 66, 1). Bu sebeple; ister taraf, üçüncü kişinin davaya katılmasını istesin (m. 61), isterse üçüncü kişinin kendisi kendiliğinden (m. 66 vd.) davaya katılmak istesin, bu talebin, tahkikat sona erinceye kadar yapılması gerekir.

Tahkikatın bitmesinden sonra, hüküm verilmeden ve hüküm verildikten sonra ve kanun yolu aşamasında davaya müdahale mümkün değildir (m. 357, 1).

Davaya müdahale etmek isteyenin talebi ferî müdahale bile olsa, eğer katılmak isteyen ayrıca harç yatırmış ve davacı olarak dilekçe vererek, görülmekte olan davadaki tarafları davalı olarak göstermişse; bu talep ferî müdahil değil, aslî müdahil olarak nitelenerek işleme alınmalıdır. Çünkü usul işlemlerini yorumlamak, hâkime ait bir görevdir (m. 33).

Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşının davaya davacı yanında ferî müdahil olarak katılabilmesi için davalı tarafın muhtemel giderlerini karşılayacak uygun bir **teminat** göstermesi gerekir (m. 84, 1/a). Benzer şekilde, Türk vatandaşı olmayan kişilerin de davaya müdahil olmaları, yargılama giderleriyle karşı tarafın zararlarına karşı teminat yatırmalarına bağlıdır (MÖHUK m. 48).

Mahkeme, müdahale talebinin kabulü veya reddi hakkında karar vermek durumundadır. Hâkim, müdahale talebini ve itirazları ön sorun (m. 163-164) olarak inceleyip karara bağlar.

Bu karar, bir ara kararı olması sebebiyle karara karşı, tek başına kanun yoluna başvurulamaz, ancak nihai karar ile birlikte kanun yoluna gidilebilir. Kanun yoluna başvurma hakkı, tarafa ait olduğundan asıl tarafı talepte bulunmazsa, müdahil olmak isteyen kişinin tek başına kanun yoluna başvurma hakkı yoktur.

Davaya müdahale eden (ferî müdahil), katıldığı davayı, dava hangi halde (aşamada) ise o andan itibaren takip eder. Bu sebeple müdahil, müdahale talebinin karara bağlanmasından önceki işlemlere karşı itiraz edemez veya onların yenilenmesini isteyemez. Aksinin kabulü halinde, bu husus davanın gecikmesine neden olabilir.

Müdahil, yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia ve savunma araçlarını ileri sürebilir; onun işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemlerini yapabilir (m. 68, 2/c. 2). Bu hüküm, ferî müdahilin, katıldığı taraf lehine olmak üzere, katıldığı taraftan ayrı işlem yapabilmesine olanak tanımaktadır. Bu sebeple örneğin, davalı zamanaşımı def'inde bulunmasa bile, (davalı yanına katılan kişinin, katıldığı taraf lehine olduğu için) zamanaşımı def'inde bulunması olanağı bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Ferî müdahil, lehine katıldığı taraf yetki vermedikçe **dava konusu üzerinde tasarrufta bulunamaz.** Bu yüzden, davadan feragat edemez; davayı kabul edemez; sulh olamaz; dava konusunu başkasına devredemez. Ferî müdahil, yalnız başına karşı tarafa yemin teklif edemez; ferî müdahile yemin teklif edilemez.

Kanun (m. 68, 2), ferî müdahilin, yanına katıldığı tarafın yardımcısı olarak üzerine düşeni tam olarak gerçekleştirebilmesi için, **katıldığı andan iti-**

baren yargılama işlemlerinden haberdar olmasını teminen, **taraflara bildirilen işlemlerin müdahile de tebliği** şartını getirmiştir. Hükmün gerekçesine göre, bu husus hukukî dinlenilme hakkının bir gereğidir. Zira, yargılamanın süjeleri, yargılamadaki durumlarıyla bağlantılı şekilde hukukî dinlenilme hakkına sahiptirler. Şüphesiz ferî müdahilin hukukî dinlenilme hakkı; özellikle açıklama ve ispat hakkı, taraflar kadar geniş değildir. Ancak, ferî müdahilin yargılama faaliyetinden, taraf ve mahkeme işlemlerinden bilgi sahibi olması konusundaki hakkı taraflara yakındır.

Dava, iki taraftan oluşur ve dava sonundaki hüküm de tarafa yönelik olarak verilir. Davaya üçüncü kişinin ferî müdahil olarak katılması bu durumu değiştirmez. Bu davalarda da **hüküm**, ferî müdahile yönelik olarak değil, yanında müdahale edilen **tarafa yönelik olarak verilir** (m. 69, 1).

Hüküm, tarafa yönelik olarak verildiğinden, kanun yoluna başvurma hakkı da, kural olarak, ferî müdahile değil tarafa aittir. Bu sebeple müdahil, kural olarak hükmü tek başına kanun yoluna götüremez. Bu kurala rağmen, mahkeme, ferî müdahile yönelik hüküm tesis ederse (hükmü yalnızca müdahile yönelik olarak veya tarafla birlikte müdahile yönelik olarak verirse), müdahilin bu durumda kanun yoluna başvurma hakkının bulunduğu kabul edilmelidir. Ferî müdahil bu hakkını, yanına katıldığı tarafla birlikte kullanabileceği gibi, ondan bağımsız olarak da kullanabilir.

Müdahilin kanun yoluna başvuru hakkı bakımından hükmün müdahile de tebliğ edilmesi gerekir (m. 68, 2).

Ferî müdahalenin; davayı kaybeden tarafın, üçüncü kişiye karşı açacağı rücu davası veya üçüncü kişinin (davayı kaybeden) asıl tarafa karşı açacağı dava (m. 61) bakımından çeşitli etkileri vardır.

Davayı kaybeden taraf ile ferî müdahil arasında görülecek olan dava (ikinci dava), müdahale edilen davanın (ilk davanın) sonucundan etkilenmek durumundadır. Çünkü, ferî müdahil ile taraf arasında görülecek ikinci davada ortaya çıkacak olan bazı sorunlar, (ferî müdahilin katıldığı) ilk davada çözümlenmiş ve karara bağlanmış olabilir. İlk davada karara bağlanan sorunların, ikinci davada (bu davanın taraflarınca) ileri sürülüp sürülmeyeceği ve mahkemenin ilk davada verilen ve kesin hale gelen hükümle (kesin hükümle) bağlı olup olmadığı (daha genel bir ifadeyle ilk davanın ikinci davaya etkisi) önemli usulî sorunlar teşkil etmektedir. İşte ortaya çıkan bu etkiye, **ferî müdahalenin etkisi** denilmektedir. Bu etki, **kesin hükümden farklı**dır; çünkü kesin hüküm, yalnızca davanın tarafları bakımından ortaya çıkar, ferî müdahil ise taraf değildir.

Ferî müdahalenin etkisi, önceki davada verilen hükmün sadece sonuç kısmıyla (hüküm fıkrasıyla) değil, hükmün dayandığı maddî ve hukukî unsurlarla da geçerli olacağından, ferî müdahalenin etkisinin kesin hükme oranla daha geniş olduğu kabul edilmektedir.

Hüküm, taraflara yönelik olarak verildiğinden (yani, ferî müdahil hakkında herhangi bir şekilde hüküm verilmesi hukuken mümkün olmadığından) davayı kazanan taraf elde ettiği ilâmı, ferî müdahile karşı değil davayı kaybeden taraf aleyhine icraya koyar.

Buna karşılık ferî müdahalenin etkisi, **müdahil ile yanına katıldığı** (davayı kaybeden) **taraf arasında** ortaya çıkar. İlk dava sonucunda ortaya çıkan kesin hüküm, davada taraf olmasa bile, ister istemez ferî müdahilin durumunu etkiler.

Her somut olayın özelliği dikkate alındığında, ferî müdahalenin etkisi, müdahilin aleyhine olduğu gibi, lehine de ortaya çıkabilir.

Yukarıda verilen satıcının ayıba karşı garanti (tekeffül) borcu (TBK m. 214) ile ilgili örnekte; (A), [(S)'den mal satın alan] (B)'ye karşı açtığı davayı kazanmış ve hüküm kesinleşmiştir. Malın gerçek malikinin (A) olduğu anlaşılmış, mal ona teslim edilmiş ve böylece (S)'nin malı satma hakkının bulunmadığı vakıası, tarafları (A) ve (B) olan davada kesin hükümle anlaşılmıştır. (A) ile (B) arasında görülen ilk davada, (S)'nin malı satma hakkının bulunmadığı yolunda ortaya çıkan bu kesin hüküm, (B)'nin, satın aldığı mal için ödemiş bulunduğu beş bin liralık zararının tazmini için (S)'ye karşı açtığı rücu davasında (ikinci davada), (ilk davanın tarafı olmadığı için kesin hüküm değil) **kesin delil** teşkil edecektir.

Ferî müdahalenin etkisi, kesin hükmün aksine, mutlak değildir. Ferî müdahil, ilk davada verilen kesin hükmün kesin delil değeri ile bağlı olduğundan, ilk davada verilen **hükmün yanlış olduğunu** ve bu bağlamda, hükmün dayandığı vakıaların da yanlış olduğunu, ikinci davada **kural olarak, ileri süremez** (ve kendisine karşı da benzeri iddiada bulunulamaz). Kural bu olmakla birlikte, ilk davada hükümde bulunması gerekmeyen, yani tarafların talep etmediği ve dava ile ilgisi bulunmayan hususlar hakkında karar verilmişse, bu tespitler ikinci davada bağlayıcı olmayabilir.

Bu husus özellikle, **ferî müdahilin**, katıldığı **ilk davada ne kadar etkili olduğu** ile de yakından ilgilidir. Sözgelimi, davanın başında yapılan ihbar (m. 61 vd.) üzerine davaya ferî müdahil olarak katılan üçüncü kişinin durumu ile davayı tesadüfen öğrenmesi üzerine tahkikatın bitmesinden (m. 66, 1) hemen önce ferî müdahil olarak katılan üçüncü kişinin durumu birbirinden farklıdır. Davanın başından beri davayı ferî müdahil olarak takip eden üçüncü kişi, yanına katıldığı tarafın yardımcısı olarak (m. 66, 1) hareket etmiş ve ancak yanına katıldığı taraf davayı kaybetmiştir. Buna karşılık, tahkikatın hemen bitiminden önce davadan haberdar olan ferî müdahil ise, davaya katıldığı andan itibaren davayı takip etmiş (m. 68, 1/c. 1) ve daha önceki işlemler hakkında herhangi bir katkısı olmamıştır/olamamıştır.

Eğer ferî müdahil, davanın kendisine çok sonra (geç) ihbar edilmesi (veya kendisinin bizzat öğrenmesi) nedeniyle davaya geç katılmışsa, davayı kaybeden taraf ile kendi (ilk davanın ferî müdahili) arasında görülen ikinci davada, geç katılmasının davayı kaybeden taraftan kaynaklandığını, asıl tarafın davayı iyi yürütemediğini, eksik veya yanlış iddia ve savunmada bulunduğunu, bu nedenle davanın kısmen veya tamamen kaybedilmesine neden olduğunu ve zamanında dava ihbar edilse idi, davanın kaybedilmeyeceğini ileri sürebilir. Bu suretle kendisine karşı açılan tazminat davasının reddini isteyebilir. Bu husus özellikle, davanın kendisine hiç ihbar edilmemiş olması durumunda, daha da önemli sonuç doğurur.

Buna karşılık dava, daha başlangıcında üçüncü kişiye ihbar edilmiş ve fakat üçüncü kişi, davaya hemen değil de çok geç müdahale etmişse, bu husus, ikinci davanın davacısı olan ferî müdahil aleyhine değerlendirilir.

Taraflar arasında görülen ilk davada, ferî müdahil, katıldığı taraf yararına bazı işlemler yapmak istemiş (m. 68, 1/c. 2) ve fakat yanına katıldığı taraf, buna izin vermemiş ise; davayı kaybeden taraf ile ferî müdahil arasındaki ikinci davada, ilk davanın ferî müdahili olan taraf bu hususa dayanabilir. Örneğin, ferî müdahil, asıl tarafın ikrarı sebebiyle bazı savunma araçlarını ileri sürememişse veya ileri sürdüğü işlem geçersiz ise ferî müdahalenin etkisinin (m. 69, 2) buna göre sınırlandırılmasını ve davanın tamamen veya kısmen reddini talep edebilir.

Keza, asıl taraf, ferî müdahilin bilmediği iddia ve savunma araçlarını ve delilleri kasten veya ağır kusuru ile ileri sürmemişse, ferî müdahil, ikinci davada yanına katıldığı tarafça ilk davanın iyi yürütülüp yönetilmediğini ileri sürebilir. Ferî müdahil bunu ispat edebildiği ölçüde, ferî müdahalenin etkisinden (m. 69, 2) kurtulur. Örneğin ferî müdahilin bilmediği zamanaşımı def'ini, asıl taraf bilmesine rağmen kasten ileri sürmemişse ve bu sebeple dava asıl tarafın aleyhine sonuçlanmışsa, müdahil için bu hükmün bir etkisi olmamalıdır.

Hükmün gerekçesine göre, ferî müdahalenin etkisi, mahkeme tarafından **kendiliğinden gözönünde tutulur**. Çünkü bu etki, çelişik kararların verilmesini önlemek, bu sayede tarafların mahkeme kararlarına güvenini sağlamak yanında, usul ekonomisi yönünden de önem taşır.

B) DAVAYA ASLÎ MÜDAHALE (ASLÎ MÜDAHALE DAVASI)[2]

I – KAVRAM

HMK, HUMK'nda düzenlenmemesine rağmen, gerek öğretide gerek Yargıtay uygulamasında kabul edilen aslî müdahaleyi (aslî müdahale davasını) açıkça düzenlemiştir (m. 65).

Bunun dışında, eskiden beri bazı kanunlarda (örneğin, Kadastro K. m. 26/D) aslî müdahale kavramı açıkça yer almaktadır.

Aslî müdahale, bir ihtiyaçtır. Çünkü, görülmekte olan bir davanın konusunun üçüncü kişiyi de ilgilendirmesi halinde, üçüncü kişinin (taraf olarak) bu davaya katılmasına izin verilmesi ve bu üçüncü kişi hakkında hüküm kurulmasının sağlanması ihtiyacı vardır. Ferî müdahil hakkında (taraf olarak) hüküm kurulamaması sebebiyle (m. 69/c. 1), ferî müdahale hükümleri bu ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir.

Aslî müdahaleye duyulan ihtiyacı daha iyi bir şekilde açıklayabilmek için şöyle bir örnek verilebilir: (A), (B)'ye karşı bir dava açmış ve bu davaya konu ettiği taşınırın kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Mahkeme davanın sonunda bu taşınırın (A)'ya veya (B)'ye ait olduğuna karar verecektir. Ancak bu davanın tarafı olmayan (C), bu malın (A) veya (B)'ye değil kendisine [(C)'ye]

---

[2] Muhammet Özekes, Medenî Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995; Mehmet Kodakoğlu, Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale, Ankara 2018.

ait olduğu iddiasındadır. Eğer aslî müdahaleye izin verilmeseydi, önce (A) ile (B) arasındaki dava görülecek, karara bağlanacak ve (C)'nin daha sonra davayı kazanan tarafa karşı dava açması söz konusu olacaktı. Oysa aslî müdahale sayesinde, üçüncü kişi (C)'nin de taraf olarak (A) ile (B) arasındaki davaya katılmasına izin verildiği için, mahkeme, (A) ile (B) arasındaki davanın yargılaması ile (C)'nin [(A) ve (B)'yi hasım göstererek] açtığı **bağımsız aslî müdahale davası**nın yargılamasını birlikte yürüterek, malın üç kişiden hangisine ait olduğuna daha çabuk bir şekilde (usul ekonomisine uygun olarak) karar verecek ve gerçekliğe ulaşma olanağı elde edilmiş olacaktır.

Aslî müdahale davası açan (aslî müdahale talebinde bulunan) kişiye, **aslî müdahil** denir.

II – ASLÎ MÜDAHALE USULÜ ve MÜDAHALENİN SONUÇLARI

HMK m. 65 uyarınca, üçüncü kişi, iki kişi arasında görülmekte olan bir davada, yargılamanın konusu olan hak ve şey üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia ederek, hüküm verilinceye kadar, davanın taraflarına karşı, aynı mahkemede dava açabilir.

Aslî müdahale davası açma olanağı, üçüncü kişiye tanınan bir haktır; bu hakkın kullanılıp kullanılmaması, ona ait bir hususdur. Yukarıdaki örnekte (C) isterse, (A) ile (B) arasındaki derdest davanın sonuçlanmasını bekleyip, o davada hüküm lehine verilen kişiye karşı, ileride dava açma yolunu da tercih edebilir. Bu durumda, (A) ile (B) arasında verilen hüküm, yalnızca davanın tarafları [(A) ile (B)] hakkında kesin hüküm teşkil eder.

Üçüncü kişinin bir davaya aslî müdahalesinden söz edebilmek için, her şeyden önce, (iki kişi arasında) derdest bir dava bulunmalıdır ki, aslî müdahil, derdest davanın davacısı ile davalısına karşı davacı sıfatıyla aslî müdahale davasını açabilsin! Eğer ortada derdest bir dava yoksa, aslî müdahale söz konusu olamaz. Yukarıdaki örnekte, (A) ile (B) arasında derdest bir dava yoksa, (C)'nin malın kendisine ait olduğu iddiasıyla (A)'ya ve/veya (B)'ye karşı açacağı dava, aslî müdahale (davası) değil, herhangi bir geri alım (istirdat, istihkak) davası olurdu.

Aslî müdahil, davacı sıfatıyla **derdest davanın taraflarını** (bu davanın davacısı ve davalısını) **birlikte davalı göstererek** bir dava açmalıdır. Aslî müdahalede, davalılar (asıl davanın davacısı ve davalısı) arasında, **şeklî zorunlu dava arkadaşlığı** ilişkisi (m. 59-60) vardır. Çünkü mahkeme, aslî müdahale davasını reddedecek olursa, mal üzerinde (C)'nin herhangi bir hakkının olmadığını tespit edecek ve dava konusu malın bu davalılardan birine (asıl davanın davacısına veya davalısına) ait olduğuna karar vermiş olacaktır.

Aslî müdahale, derdest (asıl) davanın görülmekte olduğu (**görevli ve yetkili**) mahkemeye verilen dava dilekçesiyle olur (m. 65, 1). Çünkü, hem derdest davanın hem de aslî müdahale davasının yargılamasının birlikte yürütülebilmesi (m. 65, 2) için, **aynı mahkemede** açılması şarttır.

Aslî müdahale davasından bahsedebilmek için aslî müdahilin, açtığı davada, **harç yatırılması** gerekir. Harç yatırılmadan aslî müdahale talebinde

bulunulursa, mahkeme bu konuda harç yatırılmasına olanak tanımalı ve kendisine süre vermelidir; çünkü harç hususu, kamu düzeni uyarınca hâkimin kendiliğinden gözeteceği bir hususturur.

Görülmekte olan bir davada üçüncü kişinin harç yatırarak müdahale talebinde bulunması, tek başına müdahale talebinin aslî müdahale olduğu anlamına gelmez.

Aslî müdahale talebi, asıl davada davacı ile davalı arasında görülmekte olan bir davada, **hüküm verilinceye kadar** (m. 294 vd.) yapılabilir (m. 65, 1). Bu hüküm sayesinde, üçüncü kişilerin, iki kişi arasında görülen davadan haberdar olabilme süresi uzatılarak, aynı konuda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, farklı davalarda çelişik kararlar verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Aslî müdahale talebi üzerine, mahkeme, bu talep hakkında bir karar vermek zorundadır. Aksi takdirde aslî müdahil, taraf sıfatıyla kanun yoluna başvurabilir.

Derdest davayı gören mahkeme, usulüne uygun harç da yatırılarak açılan aslî müdahale davasını, asıl dava ile **birlikte yürütür**. Ancak, mahkeme, uyuşmazlığın özelliğine göre, asıl davadaki yargılama ile aslî müdahale davasındaki yargılamanın ayrı ayrı yürütülmesine veya bu davalardan birinin diğeri için bekletici sorun yapılmasına da karar verebilir.

Aslî müdahil, doğrudan doğruya aslî müdahale davasının davacısı (yani, taraf) olduğu için, (ferî müdahilden farklı olarak) bağımsız hareket etme yetkisine sahiptir. Örneğin:

Aslî müdahil, açtığı aslî müdahale davasından kısmen veya tamamen feragat edebilir (m. 327); davasını geri alabilir (m. 123); dava konusunu devredebilir (m. 125); görevsizlik kararı üzerine dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini isteyebilir vb.

Asıl dava ile aslî müdahale davası, birbirinden bağımsız davalar olduğu için, örneğin, davadan feragat, davanın kabulü veya sulh gibi işlemler her bir davanın kendi içinde hüküm ve sonuç doğurur. Bu sebeple, örneğin asıl davanın, kabul, feragat veya sulh nedeniyle sona ermesi, aslî müdahale davasını sona erdirmez; mahkeme, aslî müdahale davasını yürütür ve karara bağlar.

Mahkeme, yapacağı yargılamanın sonucunda, hem asıl dava hem de aslî müdahale davası hakkında karar verir. Yukarıda verilen taşınır malın teslimi davası örneğinde, mahkeme, her iki davanın yargılaması sonucunda; malın (A)'ya mı, (B)'ye mi, yoksa (C)'ye mi ait olduğunu tespit edeceği için, malın ona teslimi yönünde karar verir.

Mahkeme, yalnızca asıl dava veya yalnızca aslî müdahale davası hakkında hüküm vermekle yetinemez, her iki dava hakkında ayrı ayrı hüküm vermek zorundadır. Çünkü ortada, birbirinden bağımsız iki ayrı dava bulunmaktadır. Aslî müdahalede hüküm, (lehe veya aleyhe olarak) aslî müdahile yönelik olarak verileceğinden (karş. m. 69, 1), aslî müdahil, hükme karşı tek başına kanun yoluna başvurabilir.

Aslî müdahalede verilen hüküm, aslî müdahil bakımından da (hem şeklî hem maddî anlamda) kesin hüküm (m. 303) teşkil eder.

§ 42. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ve AYRILMASI[1]

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın gerçek duruma ve geniş anlamda adalete uygun şekilde çözümlenmesi amacı ve bu amaca ulaşmak için geçerli olan ilkeler dikkate alındığında, bazı hallerde, birden fazla davanın bir arada görülmesi veya bir davanın birden çok dava haline getirilerek ayrı ayrı görülmesi gerekebilir. Birinci halde, davaların birleştirilmesi (m. 166), ikinci halde davaların ayrılması (m. 167) söz konusu olur.

Davaların birleştirilmesi sayesinde, birden fazla dava birlikte görüleceğinden, öncelikle birbiriyle bağlantılı davalarda çelişik kararların ortaya çıkmasındaki sakınca önlenmiş olur. Davaların birleştirilmesi, aynı zamanda usul ekonomisine de (m. 30) hizmet eder.

Davaların ayrılması sayesinde de, birbiriyle bağlantısı bulunmayan birden fazla talebin aynı davada görülmesinden doğan sakınca ortadan kaldırılmış olur. Her ne kadar davaların ayrılması ile mahkemeler, birden çok davayı ayrı ayrı görme durumunda kalır iseler de, aslında davaların ayrılması, uyuşmazlığın karmaşıklığını gidererek basitleştirmesinin yanı sıra, dava arkadaşlığında (sözgelimi, arkadaşlardan birine tebligatta ortaya zorluk sebebiyle) verilen ayırma kararı sayesinde, davalardan biri daha kolay ve çabuk karara bağlanacağından davaların ayrılması da, hem yargılamanın amacı hem de usul ekonomisine hizmet etmektedir.

A) DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

I – KAVRAM

Aynı düzey ve aynı sıfattaki hukuk mahkemelerinde (ayrı ayrı) açılmış ve görülmekte bulunan (derdest) davaların, aralarında bağlantı bulunması halinde, birleştirilerek aynı dava dosyası üzerinden birlikte görülmeleri mümkündür. Buna, "**davaların birleştirilmesi**" adı verilir (m. 166).

Burada aranan, "aynı düzey ve aynı sıfattaki mahkemeler"den[2] kasıt, her iki davanın da görüldüğü mahkemenin, kendi aralarında, asliye hukuk mahkemesi veya sulh hukuk mahkemesi yahut iş mahkemesi veyahut aile mahkemesi olmalarıdır. Aynı düzey ve aynı sıfatta olmayan mahkemelerde görülen davaların birleştirilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle örneğin, asliye hukuk mahkemesinde görülen dava ile sulh hukuk mahkemesinde görülen dava; iş mahkemesinde görülen dava ile aile mahkemesinde görülen dava birleştirilemez.

---

1 Bkz. İbrahim Ermenek, Medenî Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014.

2 HMK m. 166, 1/c.1'de yer alan "...aynı düzey ve sıfattaki..." ifadesi, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunmamıştır (Anayasa Mahkemesinin 27.03.2014 gün ve 127/64 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 147.

Davaların birleştirilmesi, ilk derece mahkemeleri önünde görülen davalarda söz konusu olup, istinaf mahkemelerinde görülen davalarda kural olarak birleştirme olmaz (m. 357, 1). Ancak aynı istinaf mahkemesinin dairelerinde görülmekte olan davalar oranında bağlantı bulunması durumunda talep üzerine veya kendiliğinden ilk istinaf, incelemesini yapan dairede davalar birleştirilebilir (m. 166, 1).

II – DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ USULÜ

Davaların birleştirilmesi kararı verilebilmesi için, davalar arasında **bağlantı bulunması** gerekir.

Buradaki bağlantıdan kasıt, davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması veya biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olmasıdır.

Örneğin aşağıdaki hallerde, davalar arasında bağlantı vardır:

Kısmî alacak davası görülürken açılan ek dava ile kısmî dava (veya kısmî davalar; m. 109) arasında bağlantı vardır. Çünkü, kısmî davanın kabulü veya reddi hakkında verilecek olan hüküm, ek davayı etkileyecek niteliktedir. Örneğin kısmî davada, davacı ile davalı arasında herhangi bir hukukî ilişki bulunmadığından davanın reddi halinde verilecek olan karar, ek davada da benzer hüküm verilmesi sonucuna yol açar. Benzeri şekilde, kısmî davanın kabulü, davacı ile davalı arasında alacak ilişkisinin bulunduğunu göstereceğinden (davacının ek davasında davalıdan kısmî alacak dışında alacağının bulunması halinde), kısmî davanın kabulü, ek davayı da etkileyecektir.

Kadastro yazımı sırasında tapuda Hazine adına kaydedilen, aynı yerde ve aynı özelliklerine sahip çok sayıda parselle ilgili olarak hak sahiplerinin Hazineye karşı ayrı ayrı açtıkları tapu iptali ve tescil davalarında, biri hakkında verilecek olan hüküm, diğer davaları da etkileyeceğinden, bu davalar arasında bağlantı vardır.

Eşin, diğer eşe karşı açtığı terk nedeniyle boşanma davası (TMK m. 164) görülürken, aynı eşin diğer eşe karşı açtığı zina sebebiyle boşanma davası (TMK m. 161) arasında bağlantı vardır. Benzer şekilde, kadının, kocasına karşı açtığı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası (TMK m. 166) görülürken, kocanın daha sonra eşine karşı açtığı hayata kasta dayalı boşanma davası (TMK m. 162) arasında bağlantı vardır.

Buna karşılık, örneğin aşağıdaki hallerde davalar arasında bağlantı yoktur.

Eşlerden birinin diğerine karşı açtığı alacak davası ile boşanma davası arasında bağlantı yoktur.

Tapuda isim düzeltme ile tapuda eksik yazılan hissenin düzetilmesi davası arasında bağlantı yoktur.

Davaların birleştirilmesi kararını verecek olan mahkeme, **ikinci** (tarih itibariyle daha sonra açılan) **davanın açıldığı mahkeme**dir. Mahkeme, davaların birleştirilmesi kararı vermeden önce, elindeki dava ile diğer mahkemede görülen davanın aynı veya benzer sebeplerden doğup doğmadığını veya

davaların birbirini etkileyecek nitelikte bulunup bulunmadığını tespit edebilmek için, diğer mahkemedeki **dosyayı getirterek** inceler.

Davaların birleştirilmesi kararını vermek için, tarafın talebinin gerekli olup olmadığı ve en geç hangi ana kadar birleştirme kararı verilmesi gerektiği konusunda bir ayırım yapmak gerekir:

Ayrı ayrı açılan davalar, **aynı mahkeme**de (örneğin Ankara 150. Asliye Hukuk Mahkemesinde) görülmekte ise, taraflardan birinin yapacağı **talep üzerine** veya mahkemece (talep gerekmeksizin bizzat) **kendiliğinden** birleştirme kararı verilir. **Hüküm verilinceye kadar** her aşamada birleştirme kararı verilmesi mümkündür (m. 166, 1/c. 1; bkz. Y m. 219).

Davaların (ayrı ayrı) görüldüğü mahkemeler, fiilen aynı mahkeme (Ankara 150. Asliye Hukuk Mahkemesi) olmamakla birlikte **aynı yargı çevresinde iseler** (örneğin davalardan biri Ankara 149. Asliye Hukuk Mahkemesinde, diğeri Ankara 150. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte ise), bu mahkemeler de, davaların birleştirilmesi açısından, (hukuken) **aynı mahkeme** sayılır[3].

Ayrı mahkemede görülen davaların birleştirilmesi kararı, ilk davanın açıldığı (diğer) mahkemeyi bağlar[4]. Bu nedenle, birleştirme kararı nedeniyle dosyanın kendisine gönderildiği mahkeme, birleştirme kararı çerçevesinde yargılamaya devam etmek zorundadır. Buradaki davaların birleştirilmesi kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz (m. 168). Çünkü, aynı yargı çevresindeki aynı düzey ve aynı sıfattaki mahkemeler, tek (aynı) mahkeme sayıldıklarından bunların verdiği birleştirme kararı, nihaî karar değildir; ara kararıdır.

Davaların (ayrı ayrı) görüldüğü (aynı düzey ve sıfattaki) mahkemeler, **farklı yargı çevrelerinde iseler**, davaların birleştirilmesi, ikinci davanın açıldığı davada **talep üzerine** olur (m. 166, 2/c. 1). Davaların farklı yargı çevrelerindeki mahkemelerde görülmekte olması halinde de davaların birleştirilmesi talebi, ikinci davanın her aşamasında yapılabilir. Farklı yargı yerlerinde gö-

---

3 "Yasa ile gereken yerlerde aynı düzeyde, aynı sıfat ve görevle birden fazla mahkeme kurulacağına cevaz veren bir düzenleme getirilmiştir. Gerçekten nüfus arttıkça bir yargı çevresinde kurulan bir sulh mahkemesi, asliye hukuk veya asliye ticaret veya iş mahkemesi yeterli olmamakla; ihtiyaca yetecek kadar aynı düzeyde mahkeme kurulmakla ve asliye birinci, ikinci, üçüncü hukuk mahkemesi gibi adlarla adlandırılmaktadır. Bunlar tamamen aynı nitelikte mahkemeler olup hiçbir zaman asliye birinci veya ikinci hukuk mahkemesine hitaben dava açılamamaktadır. Dava doğrudan doğruya asliye hukuk mahkemesine hitaben açılmakla ancak iş bölümü esasına göre dosyalar bu mahkemelere dağıtılmaktadır. Bu mahkemelerin hepsi görevli oldukları davaların tümüne bakmaya yetkilidirler. Ne var ki iş çokluğu, görevli oldukları davalar açısından iş bölümünü doğurmuştur. Aralarında hiçbir zaman bir görev ilişkisi mevcut değildir. Gene bu şekilde kurulan mahkemelerden bir veya birkaçı kaldırılırsa baktıkları işler aynı sıfat ve görevle kurulan diğer mahkemelere devredilmektedir. Yasa ile sağlanan bu olanak tamamen işlerin süratle çıkmasını kolaylaştırma amacına yönelik bulunmaktadır. **Yasa koyucunun amacı** mevcut olandan farklı, **ayrı bir mahkeme kurmak olmayıp** mevcudun sayısını artırmaktır. Bu sebeplerle **bir yargı çevresinde aynı düzeyde aynı sıfat ve görevle kurulmuş bulunan mahkemeler davaların birleştirilmesi açısından aynı mahkeme sayılmalıdır**" (İBK 14.02.1999, 3/2).

4 HMK m. 166, 1/cümle 2'de yer alan "...bu karar, diğer mahkemeyi bağlar" ifadesi, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunmamıştır (Anayasa Mahkemesi, 27.03.2014 gün ve 05/65 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 146-147).

rülmekte olan davalar yönünden mahkeme, taraflardan birinin talebi bulunmadıkça, davaların birleştirilmesine kendiliğinden karar veremez (karş. m. 166, 1/c. 1). İkinci davanın açıldığı mahkeme, birleştirme talebini yerinde görürse, elindeki davanın ilk dava dosyasında birleştirilmesine karar verir ve dosyadan el çeker. İkinci davanın açıldığı mahkemenin verdiği bu birleştirme kararı, ikinci davayı gören mahkeme bakımından **nihaî bir karardır**; bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir. Birleştirme kararının ilk davanın açıldığı mahkemeyi bağlaması için, bu yöndeki kararın kesinleşmesi şarttır (m. 166, 2/c.2).

Birleştirilmelerine karar verilmiş olan davaların esas kayıtlarında bu durum belirtilir. Başka bir dava ile birleştirilmesine karar verilen davanın karar numarası birleştirme kararına yazılır ve bu durum mahkemede verilen son kararda gösterilir (Y m. 219, 1).

Kanun (m. 166, 3), ikinci davanın açıldığı mahkemenin verdiği birleştirme kararının, ilk davanın açıldığı mahkemeye hemen bildirileceğini belirtmektedir. Bu hüküm, m. 166, 1 ve 2'de yapılan "aynı yargı çevresine giren veya girmeyen mahkeme" ayrımına uygun olarak kaleme alınmamıştır ve yeterince açık değildir. Kanımızca, aynı yargı çevresinde yer alan mahkemeler arasındaki birleştirme kararı, kesin olduğundan ve ilk davanın açıldığı mahkemeyi (hemen) bağladığından, bu halde ikinci dava dosyası, birleştirme kararı ile birlikte derhal ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir ve dava dosyası da ilk davanın açıldığı mahkemeye gönderilir. Buna karşılık, farklı yargı çevrelerindeki mahkemeler arasındaki birleştirme kararı, kesinleşmesinden itibaren birinci davanın açıldığı mahkemeyi bağlayacağından, birleştirme kararının verilmesini takiben ilk davanın açıldığı mahkemeye derhal gönderilmesinin bir anlamı bulunmadığından, bildirimin, birleştirme kararının kesinleşmesinden hemen sonra yapılması gerekir.

Davaların birleştirilmesine ilişkin hükümlerin (m. 166) uygulanabilmesi için, birleştirme konusunda usulüne uygun şekilde bir karar verilmiş olması gerekir. Birleştirme kararı verilmeden iki davanın birlikte görülmesi usule aykırıdır.

Birleştirilen davalar, **bağımsızlıklarını kaybetmezler**. Yani, davaların birleştirilmesine rağmen, ortada, birleştirilen dosya kadar bağımsız dava var olmaya devam eder.

Birleştirilen davalar, birleştiği (içine girdiği) ilk dava dosyasıyla birlikte incelenip karara bağlanır. Yani, her iki davanın **tahkikat aşaması ortak**tır. Tahkikat aşaması birlikte yapılacağından, yapılacak keşif de birleşen dosya üzerinden yapılır ve esas numarası kapatılan dosyalar için ayrı ayrı keşif gideri yatırılmaz. Çünkü, davaların birleştirilmesi usul ekonomisine hizmet eder.

Mahkeme, birleştirilen (ilk) davanın hüküm sonucunda, her iki dava için herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde, ayrı ayrı karar verir.

Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme kararına karşı, tek başına kanun yoluna gidilemez; ancak esas hakkındaki hükümle birlikte gidilebilir (m. 168, 1/c. 1). Davaların birleştirilmesi kararı (başka bir kanun yolu nedeni bulunmadıkça), tek başına, istinaf mahkemesinde hükmün kaldırı-

larak esastan incelenme, Yargıtayda ise bozma sebebi teşkil etmez (m. 168, 1/c. 2).

Kanun yolu ile ilgili m. 168 hükmü, ayrı (farklı) yargı çevresindeki mahkemelerin verdiği kararlar hakkında uygulanmaz. Bunlar hakkında gerek kanun yolu hükümleri uygulama alanı bulur (m. 341 vd.)

B) DAVALARIN AYRILMASI

I – KAVRAM

Görülmekte olan (derdest) davada birden fazla talebin yer alması (davaların yığılması, m. 110); davacı veya davalı tarafın birden çok kişiden oluşması (m. 57 vd.); birden çok davanın birleştirme suretiyle bir araya getirilmiş olması (m. 166) veya karşı dava (m. 132) açılması gibi hallerde, davayı gören mahkemenin, yargılamanın usulen daha iyi yürütülmesi amacıyla, davada ayırma kararı vermesi mümkündür. Bu müesseseye "**davaların ayrılması**" denir.

Bununla ilgili örnekler verilecek olursa:

Davacı (A) açtığı davada, tapuda davalı (B)'nin mülkiyetinde görünen bir ev ve bir tarla hakkında yolsuz tescilin iptali ile bunların kendi adına yazılmasını talep etmiştir. Yargılama sırasında tarla üzerinde üçüncü kişi (C) de hak iddia etmiş ve hatta aslî müdahale davası (m. 65) açarak davaya katılmıştır. Bu durumda, mahkeme (A)'nın tarla ile ilgili talebi hakkında davaların ayrılması (kısaca "ayırma") kararı verebilir. Bu durumda, ayrılan dava için ayrı bir dosya açılır ve bu dava başka bir esasa kaydedilir (bkz. Y m. 219).

Davacı (A), müteselsil borçlu (sorumlu) (B) ve (C)'ye karşı (ihtiyarî dava arkadaşı olarak), aynı dava dilekçesiyle bir alacak davası açmıştır. Dava sırasında, (C)'nin uzun zamandan beri "gaip" (TMK m. 32-35) olduğu anlaşılmış ve bu yüzden kendisine tebligat yapılamamıştır. TMK m. 33'e göre, gaiplik kararı verilebilmesi için en az beş yıllık sürenin geçmesi gerekmektedir. Her ne kadar gaip kişi bakımından davada kayyım tayini mümkün ise de, bütün bu işlemlerin yapılması halinde, (A)'nın açtığı dava uzayacaktır. Bu durumda, (A)'nın açtığı davada, (C) hakkında ayırma kararı verilirse, (A)'nın açtığı dava, "(B)'ye karşı açılan dava" ve "(C)'ye karşı açılan dava" diye ikiye ayrılacak; bu sayede (B)'ye karşı açılan davanın yürümesi sağlanmış olacaktır.

Zorunlu dava arkadaşlığında davaların ayrılmasına karar verilemez. Çünkü, bu davanın zorunlu dava arkadaşları arasında yürütülmesi ve hükme bağlanması mecburiyeti vardır (m. 59-60).

Yukarıda verilen örnekler, başlangıçta bir (tek) olarak açılmış bulunan davanın, birden fazla davaya ayrılması içindir. Bunun dışında, açılan bir davanın, yargılama sırasında, başka dava (davalar) ile birleştirilerek (m. 166) beraberce görülmesi aşamasında da, birleşen davaların, yargılamanın daha iyi yürütülebilmesi için daha sonra ayrılmasına karar verilebilir.

II – DAVALARIN AYRILMASI USULÜ

Ayırma kararı, **davanın her aşamasında** (hüküm vermeden önce) taraflardan birinin talebi üzerine veya mahkemece kendiliğinden verilebilir.

Birden fazla davalının bulunduğu davalarda, bütün davalılara karşı, davalılardan herhangi birinin yerleşim yerinin bulunduğu mahkemede dava açılabilir. Ancak kanunda ortak yetkinin belirtildiği hallerde ve sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açılan davalarda mahkeme, davada ayırma kararı vermek ve buna bağlı olarak yetkisizlik kararı vermek zorundadır (m. 7, 2).

Açılma şartları bulunmamasına rağmen **karşı dava** (m. 132) açılmış ise, bu durumda karşı davanın reddi değil, davaların ayrılmasına karar verilmesi daha uygun olur.

Davanın açıldığı mahkeme, önündeki davadaki bazı talepler bakımından görevsiz ise, davada ayırma kararı verip bu kısım için görevsizlik kararı verir.

Mahkeme, yukarıdaki hallerde, birlikte açılmış (veya sonradan birleştirilmiş) davaların ayrılması gerektiği kanısına varırsa, sadece davaların ayrılmasına karar vermekle yetinmez; mahkeme, ayrılmasına karar verdiği davalara ayrı davalar olarak bakmaya devam eder[5] (m. 167, 1/son cümle; Y m. 219).

Mahkemenin ayrılmasına karar verdiği (ayrı dosya açarak ayrı esas numarası verdiği) davalar, **davanın birlikte açılmış olduğu tarihte açılmış sayılır**.

Ayırma kararı verildiğinde, ayrılan dava veya davalar o mahkemenin esasına ayrıca kaydedilir ve eski kayıt ile yeni kayıt birbiriyle ilişkilendirilir. İlk kayıt, o dosyada kalan kısma münhasır olur. Ayrılan davanın dosyası ilk dosyada bu kısımlara ait yazıların tamamının onaylı örnekleri konularak yeniden oluşturulur. Ayrılan davalar bakımından daha önce tek karar ve ilâm harcı alınmış ise her biri için ayrıca harç alınır; daha önce alınan harç ayrılmış davaları da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılan yeni esas numarası alan her dava için başvuru harcı alınır (Y m. 219, 2).

Ayırma işlemleri için yapılan masraflar ile ayrılan dosyanın duruşma gününün tebliği için gerekli olan masraf ana dosyanın gider avansından karşılanır. Gerektiğinde gider avansı tamamlatılır (Y m. 219, 3).

Davaların ayrılması kararı, taraflar arasındaki uyuşmazlığı esastan çözümleyen (esasa ilişkin) bir karar olmadığından, bu kararda taraflar (özellikle gerekmediği halde birlikte dava açan davacılar) **yargılama giderlerine** ve bu arada vekâlet ücretine **mahkûm edilemez**.

Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen ayırma kararına karşı, tek başına kanun yoluna gidilemez; ancak esas hakkındaki hükümle birlikte gidilebilir (m. 168, 1/c. 1). Davaların ayrılması kararı başka bir kanun yolu nede-

---

[5] HMK m. 167, 1, son cümlenin Anayasaya aykırılığı ileri sürülmüşse de Anayasa Mahkemesi bu iddiayı reddetmiştir (Anayasa Mahkemesinin 22.06.2016 gün ve 09/125 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 153-154).

ni bulunmadıkça, tek başına istinaf mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtayda ise bozma sebebi teşkil etmez (m. 168, 1/c. 2).

§ 43. DAVA KONUSUNUN DEVRİ[1]

A) GENEL OLARAK

Davacı dava dilekçesinde, genellikle eda davalarında, davalının dava konusu edime mahkûm edilmesini, örneğin, davalının elinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kendisine verilmesini ister. Bu örnekte davacının dava açmaktaki amacı, dava konusu yaptığı mala (tekrar) kavuşmaktır. Davalı ise, cevap dilekçesinde, dava konusu şeyin kendisine ait olduğunu savunarak davanın reddini ister. Bu örnekte; dava kabul edilirse, mahkeme, davalının elinde bulunan malı davacıya vermesine hükmeder. Sonuçta davalı, elinde bulunan dava konusu malı kendi rızası ile davacıya teslim eder; aksi takdirde davacı, alacaklı sıfatıyla icra dairesine başvurur ve mahkeme hükmünün (ilâmın) gereği, icra dairesince zorla yerine getirilir (İİK m. 24 vd.). Böylece, uyuşmazlık çözümlenmiş, davacı amacına ulaşmış, dava konusu mala ulaşmış ve adalet yerini bulmuş olur.

Bu sonucun ortaya çıkabilmesi, dava konusu malın davanın (yargılamanın) sonunda davalının elinde bulunmasına bağlıdır. Buna karşılık, dava konusu mal, davanın sonundan önce, iyiniyetli üçüncü kişiye devredilirse, davacı davayı kazansa dahi, malın davalıdan alınıp davacıya verilebilmesi fiilen imkânsız hale gelir. Bu durumda, dava da amacına ulaşamaz.

Böyle bir sakıncaya yol açmamak ve dava konusunun üçüncü kişiye devrini önlemek için, davacının talebiyle, mal üzerine mahkeme kararıyla ihtiyatî tedbir (m. 389) konulması mümkündür. Ancak, ihtiyatî tedbir talebinde bulunulmaması, yapılan talebin reddi veya konulmuş olan ihtiyatî tedbirin dava sırasında kalkması/kaldırılması halinde dava konusu devredilirse ne olacağı, Kanunun 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Uyuşmazlık konusu mal, alacak veya hak, **henüz dava açılmadan önce devredilirse**, 125. madde uygulanmaz. Çünkü, malını, alacağını veya hakkını devreden kişinin, devrettiği mal, alacak veya hak konusu üzerinde (alacaklı, borçlu, malik, zilyet vb.) sıfatı kalmaz. Dolayısıyla, devreden kişi devirden sonra açılacak olan bir davada davacı veya davalı olarak gösterilemez; gösterilirse, açılan dava sıfat yokluğundan reddedilir[2].

Dava konusu yapılmış olan mal, alacak veya hakkın başkasına devredilmesi ile, o mal, alacak veya hakka bağlı olan dava hakkı da birlikte devredilmiş sayılır. Çünkü dava hakkı, asıl haktan ayrı bir hak değildir ve bu nedenle yalnız başına başkasına devredilemez.

Dava konusunun devri, davanın değiştirilmesi yasağının (m. 141) istisnalarından biridir. Çünkü, aşağıda görüleceği üzere, dava konusunun devri halinde, davacı, başlangıçtaki talebinde veya tarafta değişiklik yapabilmektedir.

---

1 Bkz. Levent Börü, Dava Konusunun Devri, Ankara 2012.

2 Bkz. yuk. § 13, D.

Bu genel açıklamalardan sonra, dava konusunun davacı veya davalı tarafından devri halinde uygulanacak olan hükümleri incelemeye geçebiliriz.

B) DAVA KONUSUNUN DAVALI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

Davacının, davalıya karşı açtığı davada, onun elinde bulunan bir taşınır malın mülkiyetinin kendisine (davacıya) verilmesini talep ettiği örneği üzerinden devam edelim. Dava sırasında davalı, elindeki taşınır malı üçüncü kişiye satıp teslim edecek olursa; davacının, **seçimlik hakkı** vardır (m. 125, 1).

Davacı bu seçimlik hakkını **kendiliğinden kullanırsa**, seçimine göre hareket edilir.

Davacı seçimlik hakkını **kendiliğinden kullanmazsa**, dava konusunun devredildiğini öğrenen **mahkemenin**, davacıya seçimlik hakkı bulunduğunu **hatırlatması**, davaya hangi kişi hakkında devam edeceğini sorması, süre vermesi ve ona göre işlem yapması **gerekir**. HMK m. 125'teki seçimlik hakkın hatırlatılması kuralı, kamu düzenine ilişkindir ve kanun yolu dahil yargılamanın her aşamasında yapılır. Kesin süre verilerek kendisine tercih hakkı sorulan davacı, süre içinde cevap vermez ve seçim hakkını kullanmaz ise, davanın takipsiz bırakılmak istendiği varsayılarak **dosya işlemden kaldırılır** (m. 150).

Dava konusunun davalı tarafından üçüncü kişiye devri halinde, davacının sahip olduğu seçimlik hakka gelince:

I – DAVACI İSTERSE, DAVALIYA KARŞI AÇTIĞI DAVADAN VAZGEÇEREK DAVAYI DAVA KONUSUNU DEVİR ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVAM ETTİRİR

Davalının dava konusunu üçüncü kişiye devretmesi halinde, davacının, davasını üçüncü kişiye karşı devam ettirmeyi (m. 125, 1/a) tercih etmesine bağlı olarak, dava üçüncü kişiye karşı devam eder. Kanun (m. 125, 1/a), açıkça "vazgeçme" sözcüğünü kullandığından, davacının (devreden eski davalıya karşı) açmış olduğu davasından **feragat etmesi değil**, **davasından vazgeçmesi** söz konusudur. Davacının, bilinçli olarak, açık bir biçimde, davadan feragat etmedikçe davadan feragat ettiğini belirtmesinin hukukî değeri yoktur; burada asıl olan davacının gerçek iradesinin ne olduğunun mahkeme tarafından araştırılmasıdır.

Davalının dava konusunu devretmesi halinde, davacının davayı, dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı sürdürme yolunu tercih etmesi, eski davalı ile arasındaki mevcut uyuşmazlığı ortadan kaldırmaz. Diğer bir ifadeyle davacının bu tercihi, eski davalıyı ibra ettiği anlamına da gelmez. Bu sebeple davayı, dava konusunu devralana karşı sürdüren ve kaybeden davacı, eski davalıya karşı dava (örneğin, tazminat davası) açma hakkını korumaktadır.

Dava sırasında dava konusunu devralan üçüncü kişi hakkında hüküm kurulabilmesi için, kendisine usulüne uygun olarak davetiye gönderilerek da-

valı taraf sıfatıyla davaya dahil edilmiş olması gerekir. Bu işlem yapılmadan onun hakkında hüküm kurulamaz.

Dava konusunu devreden davalının yerine geçen yeni davalı, eski davalının hak ve yükümlülükleri ile, **davayı kaldığı yerden** devam ettirir. Bu sebeple, eski davalı tarafından veya ona karşı yapılmış olan usul işlemleri geçerliliği sürdürmekte olup, yeni davalı bu usul işlemlerinin tekrarlanmasını isteyemez.

Davacı ile yeni davalı arasında görülen bu dava, yeni bir dava değildir; davacı ile dava konusunu devretmiş olan eski davalı arasındaki **davanın devamı**dır. Buna bağlı olarak, davasını üçüncü kişiye yöneltmiş olan davacıdan **yeniden harç alınmaz**. Eski davalıya karşı dava açılması ile meydana gelen sonuçlar devam eder. Buna göre, dava konusu hakkın **zamanaşımı**na uğrayıp uğramadığı veya davanın **hak düşürücü süre** içinde açılıp açılmadığı, eski davalıya karşı dava açıldığı tarihe göre belirlenir.

Eski davalı için başlamış olan savunmayı genişletme yasağı, yeni davalı için de devam eder. Fakat, yeni davalı varsa, kişisel savunma sebeplerini ileri sürebilir; örneğin, dava konusu malı iyiniyetle edindiğini ileri sürebilir. Davalının kötüniyetli olduğunu ispat yükü, davacıya düşer.

Davacı, dava konusunu devralmış olan üçüncü kişiye yöneltmiş olduğu davayı kazanırsa, yeni davalı aleyhine hüküm verilir; eski davalı aleyhine hüküm verilemez. Buna rağmen, dava konusunu devretmiş olan eski davalı, üçüncü kişi, yani yeni davalı ile birlikte yargılama giderlerini müteselsilen ödemeye mahkûm edilir (m. 125, 1/a).

Davacının üçüncü kişiye karşı devam ettirdiği dava, üçüncü kişinin dava konusunu iyiniyetle iktisap etmiş olması (TMK m. 988; 1023) nedeniyle reddolunursa, davacı, dava konusunu devretmiş olan eski davalıya karşı yeni bir dava açarak eski davalıdan m. 125, 1/b hükmüne göre tazminat isteyebilir. Çünkü, davacının, dava konusunu devreden eski davalı hakkındaki davasından vazgeçmesi, eski davalıya karşı açılmış olan davadan feragat edilmesi veya bir ibra niteliğinde değildir.

Dava konusunu devralan yeni (ikinci) davalı da, onu dava sırasında bir başkasına devrederse, davacı, m. 125'deki seçim hakkını tekrar kullanılabilir.

II – DAVACI, İSTERSE DAVALIYA KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVASINI TAZMİNAT DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜR

Davalının dava konusunu üçüncü kişiye devretmesi halinde, davacı isterse, davayı üçüncü kişiye karşı (m. 125, 1/a) devam ettirmez; mevcut davasını, davalıya karşı **tazminat davasına dönüştürerek** devam ettirir.

Bu durum özellikle dava konusunu devir alan üçüncü kişinin iyiniyetli (TMK m. 3) olması halinde karşımıza (tek seçenek olarak) çıkar. Dava sırasında davalı, dava konusunu **iyiniyetli üçüncü kişiye devrederse**, davacının dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı devam ettirmesinin pratik bir anlamı yoktur. Zira üçüncü kişi, iyiniyetli olduğu için, devraldığı malın mülkiyetini usulüne uygun olarak kazanacağından ve kazanımı (iktisabı) hukuken korunacağından, davacının, mevcut (örneğin, mal istirdadı) davasını

(aynen) dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı devam ettirip mala kavuşabilmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla, üçüncü kişinin iyiniyetli olması halinde **davacı**, davasını üçüncü kişiye (m. 125, 1/a) yöneltmeyip, **tazminat davasına çevirme yolunu** (m. 125, 1/b) tercih edecektir.

Bu durumda davacının davalıdan talep ettiği tazminat, esas itibariyle, davacının davayı kazandığı takdirde elde edeceği menfaattir. Örneğin dava konusunun değeri yirmi bin TL ise dava, tazminat davası olarak yirmi bin TL üzerinden devam eder.

Harca esas değeri örneğin beş bin TL olarak belirtilerek açılmış bulunan malın iadesi davası bakımından, davacı m. 125 hükmü çerçevesinde davasını malın bedeline çevirir ve malın o andaki değeri de yirmi bin TL ise, davacı şimdi beş bin TL değil, yirmi bin TL tazminat isteyebilir. Bu istem, iddianın (davanın) genişletilmesi anlamına gelmez. Ancak, davacının şimdi istediği yirmi bin TL ile davanın açıldığı tarihte harcın yatırıldığı beş bin TL arasındaki farkın harcını yatırması gerekir.

C) DAVA KONUSUNUN DAVACI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

Davacının, davalıya karşı bir dava açarak, (davacının kendi) elinde bulunan bir taşınır malın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve davalının bu mal üzerinde herhangi bir hakkının bulunmadığının tespitini talep ettiğini (tespit davası açtığını; uygulamadaki adıyla: sataşmanın önlenmesi davası-muarazanın men'i davası- açtığını) yahut davacının, yüz bin liralık alacak davası açtığını düşünelim.

Dava konusunun davacı tarafından üçüncü bir kişiye devredilmesi halini düzenleyen, m. 125, 2 hükmü, "devralan üçüncü kişinin, hukuk gereği (ipso iure) davacı sıfatı ve buna bağlı olarak dava takip yetkisi kazanacağı ve davanın yeni davacı ile süreceği" gerekçesiyle, davalıya HMK m. 125, 1/a'dakine benzer seçimlik haklar tanımamış ve devralan kişinin, kendiliğinden davacı yerine geçerek, davaya kaldığı yerden itibaren devam olunacağı esasını getirmiştir.

Bu hükme göre, davacının dava konusunu üçüncü kişiye devretmesi halinde, davaya üçüncü kişi ile davalı arasında devam edilecektir. Bunun için, davalının bu konuda bir karar vermesi veya devralan üçüncü kişinin davacı yerine geçmesi için onayı aranmaz.

Dava konusunu devralan üçüncü kişi (yeni davacı), davaya, katıldığı yerden devam eder; daha önce yapılmış olan işlemlerin tekrarlanmasını isteyemez ve devreden davacının sahip bulunmadığı yetkileri kullanamaz.

Bu sebeple; örneğin, eski davacı davasını bir kere ıslah etmişse, yeni davacının artık ıslah hakkı yoktur (m. 176, 2). Eski davacı tanık listesi vermişse, yeni davacı ikinci bir tanık listesi veremez (m. 240, 2); yeni davacı da, davalının rızası olmadıkça, davayı geri alamaz (m. 123); davalı, eski davacıya karşı olduğu gibi, yeni davacının rızası olmadan savunmasını genişletemez; daha önce ileri sürmediği zamanaşımı def'ini yeni davacıya karşı da

yeni davacının rızası olmadıkça veya ıslah yoluna başvurmadıkça ileri süremez.

Fakat, davalı, yeni davacıya karşı (varsa) kişisel savunma sebeplerini ileri sürebilir. Örneğin, davalı, yeni davacıdan alacaklı ise yeni davacıya karşı takas def'ini ileri sürebilir. Çünkü, davalının yeni davacıya karşı kişisel savunma sebeplerini (örnekte, takas def'ini) bu davada ileri sürme yetkisi dava devam ederken (dava konusunun davacı tarafından yeni davacıya devredilmesinden sonra) doğmuştur.

§ 44. KARŞI DAVA[1]

A) GENEL BİLGİ

Açılmış ve görülmekte olan bir davada davalının, aynı mahkemede (ve aynı dosyada) davacıya karşı, cevap dilekçesiyle veya cevap süresi içinde, ayrı bir dilekçe ile açtığı davaya, **karşı dava** (karşılık dava; mukabil dava) denir (m. 132; 133).

Açılmış ve görülmekte olan davada, cevap dilekçesiyle veya cevap süresi (m. 127) içinde ayrı bir dilekçe ile karşı dava açılabilir (m. 133).

Karşı davaya bir örnek vermek gerekirse; (A), (B)'ye karşı yüz bin liralık bir alacak davası açmıştır (asıl dava). (B), bu (asıl) davaya karşı verdiği cevap dilekçesinde, kendisinin de (A)'dan yüz elli bin lira alacaklı olduğunu bunun yüz bin lirasını asıl davacı (A)'ya olan borcu ile takas ettiğini bildirerek, kalan elli bin liranın (A)'dan alınarak kendisine [(B)'ye] ödenmesine karar verilmesini isterse, (B), asıl davacı (A)'ya karşı yüz elli bin liralık bir karşı dava açmış olur. Bu halde, (A)'ya "**asıl davacı-karşı davalı,** (B)'ye "**asıl davalı-karşı davacı**"[2] denir.

Başka bir deyişle, davalı, kendisine yönelik olarak açılan davaya karşı, sadece savunmada bulunmakla yetinmeyip, aynı zamanda davacıdan olan bir hakkının da hüküm altına alınmasını isterse, (asıl) davacıyı, davalı göstererek bir karşı dava açar.

Aşağıda görüleceği gibi mahkeme, karşı davayı, **asıl dava ile birlikte inceleyip** karara bağlar. Bu nedenle mahkeme, her iki davanın konusunu teşkil eden uyuşmazlık (veya uyuşmazlıklar) hakkında tam bir görüş sahibi olur; mahkemenin vereceği karar, daha isabetli olur ve birbirleriyle bağlantılı olan uyuşmazlıklar hakkında çelişik hükümler verilmesi önlenir. İki davanın ayrı ayrı görülmesine oranla, karşı davanın, asıl dava ile birlikte incelenmesinde tahkikat ve yargılama daha çabuk ve kolaydır ve yargılama giderleri daha azdır. Yani karşı dava, usul ekonomisine (m. 30) de uygundur.

Ancak, davalının karşı dava olarak açtığı davanın, bu sayılan **yararları** sağlayabilmesi için, Kanunun (m. 132-133) aradığı şartlara uygun bir dava olması gerekir:

B) KARŞI DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI

Davalının, davacıyı karşı taraf (davalı) göstererek açtığı davanın, teknik anlamda bir **karşı dava sayılabilmesi için**, aşağıdaki şartlara uygun açılması gerekir:

---

1 Bkz. Tuğçe Arslanpınar, Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava, Ankara 2017.

2 Uygulamadaki genel kullanılışı ile: "Davacı/karşı davalı", "davalı/karşı davacı".

I – ASIL DAVANIN GÖRÜLMEKTE OLMASI GEREKİR

Karşı dava, asıl dava üzerine (ona mukabil) açılır. Bu nedenle, karşı davanın açıldığı anda, asıl davanın mevcut ve görülmekte (derdest) olması gerekir.

Buna karşılık, asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel değildir (m. 134).

Karşı dava, asıl davanın görülmekte (derdest) olduğu mahkemede açılır. Karşı davanın cevap dilekçesi ile veya cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe ile açılması gerekir.

II – ASIL DAVA İLE KARŞI DAVA ARASINDA YAKIN İLİŞKİ BULUNMASI GEREKİR

Bir davaya yönelik olarak açılan her dava, (aynı yargılama usulüne tâbi olsa bile) teknik anlamda bir karşı dava değildir. Bir davaya yönelik açılan davanın, teknik anlamda karşı dava sayılabilmesi için, asıl dava ile karşı dava arasında **yakın ilişki** (bağlantı) bulunmalıdır. Bu da **iki şekilde olabilir**:

1) Takas veya Mahsup İlişkisi Bulunması[3]

Davalı, kendisinin de (asıl) davacıdan alacaklı olduğunu bildirerek, bu alacağı ile (davacıya olan) borcunun **takas** edilmesini, açacağı bir karşı dava ile isteyebilir (m. 132, 1/b).

Ancak, davalı takas için mutlaka karşı dava açmak zorunda değildir. Bilindiği gibi, takas için ayrı bir dava açılmasına gerek yoktur. Takas, borçlunun (davalının) takas etme iradesini alacaklıya bildirmesiyle gerçekleşir (TBK m. 143, 1). Bu nedenle, davalının karşılık alacağını takas etmesi için, mutlaka bir karşı dava açması zorunlu değildir. Davalı, karşı dava açmadan, **sadece takas savunmasında** (def'inde) **bulunmakla yetinir**. Çünkü, savunma çerçevesinde ileri sürülebilecek bir hususun ayrı dava konusu yapılmasında, dava şartı olan hukukî yararın bulunduğu söylenemez.

Eğer, davalının takas etmek istediği karşılık alacağın miktarı, **asıl davada istenen alacak kadar** veya **ondan daha az ise**, davalının, bir karşı dava açmakta hukukî yararı yoktur; takas savunmasında bulunması yeterlidir.

Buna karşılık, eğer davalının takas etmek istediği **karşılık alacağın miktarı**, asıl davada istenen alacaktan (davacının alacağından) **daha fazla ve davalı bu fazlayı hüküm altına aldırmak istiyorsa**, o zaman, davalının takas ve fazla alacağının davacıdan tahsili için bir karşı dava açması gerekir.

Bu halde, davalının cevap dilekçesinde veya süresi içinde ayrı bir dilekçede (m. 133, 1) takas için karşı dava açtığını açıkça bildirmesi ve karşı dava için ayrıca başvurma harcı ve peşin karar harcı ile ilâm harcı yatırması gerekir. Davalı, açıkça karşı dava açtığını bildirmez ve takas nedeniyle davanın reddini isterse, karşılık alacağı asıl davada istenen alacaktan fazla olsa bile, bununla davalının talebi, bir karşı dava olarak kabul edilemez.

---

[3] Davada takas ve mahsup talebi için bkz.: Ejder Yılmaz, Davada Takas ve Mahsup Talebi (MİHDER 2010/2, s.247-284).

Takas için karşı dava açılmış olması halinde mahkeme, asıl dava konusu alacağın ve karşılık alacağın mevcut olduğu sonucuna varırsa, asıl davayı takas nedeniyle reddeder ve davalının fazla alacağının (asıl) davacıdan alınmasına karar verir.

Takas gibi, mahsup (örneğin, TBK m. 80; 309; 408) talebi için de, hukukî yararın varlığı halinde, karşı dava açılabilir (m. 132, 1/b).

Uygulamada mahsup kavramı bazen takas kavramı anlamında da kullanılmaktadır. Ancak, bu iki kavramın anlamı aynı değil, ayrıdır. Takasta karşılıklı iki alacağın varlığı gerektiği halde, mahsupta ayrı bir varlığı olan bir karşı alacak ileri sürülmemekte, asıl alacağın miktarının belirlenmesini etkileyen ek koşullar ileri sürülmektedir. Örneğin, sebepsiz olarak zenginleşilen şeyin (miktarın) iadesinde, iade borçlusu, yapmış olduğu giderleri mahsup etme hakkına sahip olur (bkz. TMK m. 994; 995; TBK m. 80; 309; 408). Davacının açtığı tazminat davasında, davalı tazminat alacağının belirlenmesi için yapılan hesapta, davacının zarar verici olaydan elde ettiği yararların, zarardan mahsup edilmesini (indirilmesini) talep edebilir.

2) Asıl Dava ile Karşı Dava Arasında Bağlantı Bulunması

Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi, takas veya mahsup halinde, davalının takas veya mahsup ettiği karşılık alacağı ile asıl davanın konusu olan alacak (davacının alacağı) arasında bağlantı bulunmasa bile, takas veya mahsup için karşı dava açabilir.

Buna karşılık, takas veya mahsup talebi dışındaki hallerde ise, karşı dava ile asıl dava arasında bağlantı bulunmalıdır (m. 132, 1/b). Aksi halde, davalının asıl davacıya karşı açtığı dava, teknik anlamda bir karşı dava (yani, karşı dava olarak dinlenebilir bir dava) değildir.

Asıl dava ile karşı davanın aynı veya benzer sebepten doğması veya asıl dava ile karşı davadan biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek nitelikte bulunması halinde, iki dava arasında bağlantı var sayılır (m. 166, 4); örnekler:

(B), (A)'nın arsası üzerine onun [(A)'nın] rızası olmaksızın bir bina yapmıştır. (A), (B)'yi davalı olarak gösterip bir dava açarak, (B)'nin arsaya müdahalesinin (el atmasının) önlenmesine ve yaptığı binanın sökülmesine (TMK m. 722, 2) karar verilmesini istemiştir (asıl dava). Davalı (B), asıl davaya yönelik olarak açacağı bir karşı dava ile, bu binayı iyiniyetle yaptığını ve binanın kıymetinin arsa kıymetinden açıkça fazla olduğunu bildirerek, arsanın mülkiyetinin uygun bir tazminat karşılığında kendisine [(B)'ye] verilmesini isteyebilir (TMK m. 724). Çünkü, bu iki davadan biri hakkında verilecek karar, diğerini etkileyecek niteliktedir.

Davacının açmış olduğu müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davasına karşı, davalı, asıl davacının müdahalesinin (el atmasının) önlenmesi için bir karşı dava açabilir.

Davacının bir taşınır mal hakkında açmış olduğu istihkak davasına (TMK m. 683) karşı davalı, o mal üzerinde rehin hakkı bulunduğunu bildirerek bu rehin hakkının tanınması için bir karşı dava açabilir.

Davacının açmış olduğu kira bedelinin tespiti (artırılması) davasına yönelik olarak, davalı kiracı, kira bedelinin indirilmesi için bir karşı dava açabilir.

Davacının (kiralayanın) açmış olduğu ihtiyaç sebebiyle tahliye davasına yönelik olarak, davalı kiracı, kiralanan taşınmazda yaptığı tamirat bedelinin tahsili için karşı dava açabilir.

Eşlerden birinin açtığı evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle boşanma davasına yönelik, diğer eş de zina sebebine dayalı bir karşı boşanma davası açabilir.

Hacizde (ve iflâsta) üçüncü kişinin icra mahkemesinde açmış olduğu istihkak davasına yönelik, davalı alacaklı (veya iflâs idaresi), İİK m. 277-284'teki iptal davasını, karşı dava olarak açabilir (İİK m. 97, XVII).

III – KARŞI DAVANIN CAİZ OLMAMASI

Asıl dava ile arasında bağlantı bulunmayan ve takas veya mahsup ilişkisini (talebini) de içermeyen ve cevap dilekçesi ile veya cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe ile asıl davayı gören mahkemede açılmayan bir dava, (asıl davaya yönelik olarak) karşı dava şeklinde açılamaz (m. 132, 1/b); yani bu durumda, karşı dava caiz (mesmu; kabule şayan) değildir.

Davacının açmış olduğu alacak davasına karşı davalı; davacının da kendi (davalının) taşınmazına el attığını bildirerek davacıya yönelik olarak (karşı dava şeklinde) müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davası açamaz. Çünkü, bu iki dava arasında bağlantı yoktur.

Asıl dava ile bağlantılı olmayan ve takas veya mahsup talebini de içermeyen bir davayı, davalı, karşı dava olarak açarsa, mahkeme, davacının talebi üzerine yahut kendiliğinden karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa (yani, mahkemenin ayırdığı davayı görevli olmadığı için kendisinin görmesi mümkün değilse), dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir (m. 132, 2). Başka bir deyişle, mahkeme, davacının talebi üzerine veya kendiliğinden, karşı davanın caiz (kabule şayan) olmadığı gerekçesi ile, karşı davanın bu nedenle reddine değil, aksine karşı davanın (asıl davadan) ayrılmasına (m. 167) karar verir (karş. m. 412-413).

İstinaf aşamasında karşı dava açılamaz (m. 357).

C) KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

Karşı dava, asıl davada verilen **cevap dilekçesi**yle veya cevap süresi içinde **ayrı bir dilekçe** verilmek suretiyle açılır (m. 133, 1)[4]. Yani, yazılı yargılama usulüne göre görülen (m. 127, 1/c. 1) ve basit yargılama usulünün uygulandığı (m. 317, 2/c. 1) davalarda, kural olarak, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta olan cevap süresi içinde, verilecek cevap di-

---

[4] Karşı davanın cevap süresi içinde cevap dilekçesiyle birlikte veya ayrı bir dilekçe ile açılması mümkündür. Her ne kadar Kanun, "esasa cevap süresi"nde karşı dava açılmasından söz etmekteyse de, Kanun, davaya cevap vermek bakımından genel olarak böyle bir ayrım yapmamıştır. Ancak m. 131'de, ilk itirazların cevap dilekçesinde yapılması gerektiği, cevap süresi dolmamış olsa bile, ikinci bir cevap dilekçesi verilemeyeceği ifade edilmektedir.

lekçesiyle veya bu süre içinde verilecek ayrı bir dilekçeyle karşı dava açılabilecektir. Cevap süresi uzatılmışsa (m. 127; 317, 2), karşı dava, uzatılan süre içinde açılabilir.

Karşı dava, cevap süresi geçtikten sonra açılırsa, mahkeme, talep üzerine veya kendiliğinden davaların ayrılmasına karar verir (m. 133, 2; 167).

Cevap süresi içinde karşı dava açmamış olan davalı, karşı dava açma hakkını kaybeder. Böyle bir durumda davalı, **davasını, ayrı** (bağımsız, müstakil) **bir dava olarak** (her zaman) **açabilir**. Bu halde, davacının açtığı (ilk) dava ile davalının ayrıca açtığı (ikinci) dava arasında bağlantı varsa (m. 166, 4), bu **iki davanın birleştirilme**sine karar verilebilir (m. 166, 1-2).

D) KARŞI DAVANIN AÇILMASI

Karşı dava, süresi içinde asıl davanın görülmekte (derdest) olduğu mahkemede açılır. Karşı dava, **davalı** (karşı davacı) **tarafından asıl davacıya** (karşı davalıya) **yönelik olarak**, asıl davanın davacısı, karşı davanın davalısı olarak gösterilerek **açılır**.

Yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda, karşı dava, cevap dilekçesiyle veya dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta olan cevap dilekçesini verme süresi (m. 127) içinde ayrı bir dilekçeyle açılır (m. 133).

Basit yargılama usulüne göre görülen davalarda da cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta olduğundan (m. 317, 2), karşı dava, cevap dilekçesiyle veya bu süre içinde verilecek (başka) bir dilekçeyle açılır.

Açılan karşı davaya yönelik olarak, karşı dava açılamaz (m. 132, 3).

Karşı dava, her ne kadar asıl davaya yönelik olarak aynı mahkemede açılıyorsa da, ayrı bir davadır. Bu nedenle **karşı davalar**, ayrı davalar gibi **harca tâbidir** (Harçlar K. m. 6, I); harç yatırılmadan karşı dava açılmış sayılmaz ve karşı dava hükümleri uygulanmaz.

E) KARŞI DAVAYA CEVAP

Yazılı yargılama usulünde davacı (karşı davalı), karşı dava dilekçesi üzerine, cevap dilekçesi verebilir (m. 126, 135). Asıl davanın davacısı (karşı davalı), bu cevap dilekçesini asıl dava için vereceği cevaba cevap dilekçesi ile verir. Davacı da dilekçesini asıl dava bakımından cevaba cevap; karşı dava bakımından ise, cevap dilekçesi olarak düzenler. Bu dilekçeyi verme süresi ise, asıl davadaki cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftadır (m. 136, 1) .

Basit yargılama usulüne tâbi bir davaya yönelik olarak açılan karşı davaya, HMK'nun 317, 2 ve 3 ile 135. maddeleri hükümlerine göre, iki haftalık süre içinde (veya hâkim tarafından uzatılan cevap süresi içinde), asıl davanın davacısı (karşı davalı) tarafından cevap verilebilir.

Yukarıda görüldüğü gibi, karşı dava, asıl davanın görüldüğü mahkemede açılır. Bu mahkemede, her iki dava için yalnız bir dava dosyası (asıl dava

dosyası) düzenlenir. Karşı dava da, bu (asıl davanın) dosya (esas) numarası ile anılır; yani, karşı dava için **ayrı bir esas** (dosya) **numarası verilmez.**

Mahkeme, asıl dava ile karşı davayı **birlikte inceler ve karara bağlar**; yani iki davanın ön inceleme ve **tahkikat aşamaları ortaktır**. Her iki davanın delilleri, birlikte incelenir ve davalar birlikte karara bağlanır.

Asıl dava ile birlikte incelenirse de, karşı dava, asıl davaya oranla müstakil (ayrı) bir davadır. Buna göre:

Dava şartları, asıl dava ve karşı dava için, ayrı ayrı incelenir.

Karşı dava, bağımsız davalar gibi **harca tâbidir**.

Karşı dava ayrı bir dava olduğundan, asıl dava ve karşı dava için ayrı ayrı **vekâlet ücreti** takdir edilir.

Asıl davanın herhangi bir nedenle **son bulması, karşı davanın görülmesine engel olmaz** (m. 134). Bunun gibi, karşı davanın herhangi bir nedenle son bulması, asıl davanın görülmesine engel olmaz.

Kanun yoluna başvuru sınırı (m. 341, 2; 362), yani hükmün kanun yoluna götürülüp götürülemeyeceği asıl dava ve karşı dava için **ayrı ayrı belirlenir**; yoksa, her iki davanın dava konularının değer veya miktarlarının toplamına göre belirlenmez.

F) KARŞI DAVADA HÜKÜM

Mahkeme, asıl dava ve karşı dava hakkında tek bir hüküm (karar) verir. Ancak, hükümde, asıl dava ve karşı dava hakkında verilen kararlar ayrı ayrı gösterilir.

Mahkeme, hükmünde asıl dava için **ayrı**, karşı dava için **ayrı karar** ve **ilâm harcı** alınmasına karar verir.

Karşı dava, ayrı bir dava olduğundan, mahkemenin, asıl dava ve karşı dava için **ayrı ayrı vekâlet ücreti** takdir etmesi gerekir.

Kanun yoluna başvuru bakımından söz konusu olan parasal sınırı, asıl dava ve karşı dava için ayrı ayrı belirlenir. Bunun gibi, asıl dava ile karşı dava, **kanun yolu**na götürülme bakımından da birbirinden bağımsız davalardır. Yani, bu davalardan biri hakkındaki hüküm yalnız başına kanun yoluna götürülebilir; diğeri hakkındaki hüküm ise süresinde kanun yoluna götürülmediği için kesinleşebilir. Kanun yoluna götürülen (asıl davaya yönelik olarak açılan karşı davaya ilişkin) hüküm, üst mahkemece kaldırılır veya bozulursa, bu kaldırma veya bozmanın, süresinde kanun yoluna götürülmediği için kesinleşmiş olan diğer davaya ilişkin hükme bir etkisi olmaz.

§ 45. ISLAH[1]

A) GENEL OLARAK

Yukarıda görüldüğü üzere, hukuk yargılaması düzenimizde (hukuk davalarında), iddianın ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı vardır ve karşı tarafın açık muvafakati bulunmadıkça her iki taraf da, davanın belli bir aşamasından sonra, yaptıkları usul işlemlerini, kural olarak, değiştiremezler (m. 141; 319).

Taraflar, iddianın ve savunmanın değiştirilmesi yasağının başlamasından sonra, iddia ve savunmalarında değişiklik yapma ihtiyacı hissedebilirler. Bu ihtiyaç, genellikle, daha önceki **usul işlemlerinde yapılan bir hata**dan, **unutma**dan veya yargılama sırasında ortaya çıkan gelişmelerden kaynaklanır; yargılamanın ilerleyen aşamalarında bu hatayı, unutmayı ve gelişmeleri fark eden **taraf**, **yaptığı usul işlemini düzeltmek** (değiştirmek) **isteyebilir**. Bu düzeltmeye izin verilmeyecek olursa, hatalı usul işlemine dayalı olarak yapılan yargılamanın sonucu da yanlış olacak ve yargılamanın amacı olan maddî gerçekliğe (adalete) ulaşılamayacaktır. Kanunumuzun, 176 vd. maddelerinde düzenlediği ıslah kurumu, bu sakıncayı önlemek için kabul edilmiştir.

Islah kurumu, iddianın ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağının katılığından ileri gelen sakıncaları önleyen ve kurala getirilen istisnalardan biridir (m. 141, 2).

Islah, istisnaî nitelik taşıdığından, her usul işleminin değiştirilmesi için ıslaha gitmeye gerek yoktur. **Islah** sadece, **iddianın ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının kapsamına giren konularda olur**. Tarafın davada yapmak istediği değişiklik, eğer yasak kapsamına girmiyorsa, ıslah yoluna gitmeye gerek yoktur. Örneğin yazılı yargılama usulünde, değişiklik, ikinci cevap dilekçelerinde (davacı bakımından cevaba cevap dilekçesinde; davalı bakımından ikinci cevap dilekçesinde) yapılıyorsa, ıslaha gitmeye gerek yoktur (m. 141, 1). Benzeri şekilde, yasak kapsamına girmeyen bir değişiklik yapılıyorsa (örneğin, dilekçede dayanılan kanun maddesi değiştiriliyorsa), ıslaha gerek yoktur.

Ayrıca, iddianın veya savunmanın değiştirilmesine veya genişletilmesine **karşı taraf izin verirse**, ıslah yoluna gitmeye gerek yoktur.

Aşağıdaki hallerde, davanın (iddianın) veya savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi için, bunu yapmak isteyen tarafın ıslah yoluna başvurmasına gerek yoktur.

Bazı durumlarda mahkeme, taleple bağlı değildir (karş. m. 26); kendiliğinden davacının dava dilekçesinde talep ettiği şeyden başka bir şeye de hüküm verebilir. Bu hallerde davayı değiştirme yasağı (m. 141, 2) uygulanma-

---

[1] Bkz. Ejder Yılmaz, Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2013; Adnan Deynekli, Medeni Usul Hukukunda Islah, Ankara 2013.

dığından, davacının, talep edilenden başka bir şeye hüküm verilmesini isteyebilmesi için davasını ıslah etmesine de gerek yoktur.

Mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken hususların sonradan ileri sürülmesi, davayı değiştirme veya savunmayı genişletme yasağına tâbi olmadığından, bir tarafın, mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken hususları ileri sürebilmesi için, ıslah yoluna başvurmasına gerek yoktur.

Dava açılmasından sonra doğan olayların ileri sürülmesi, davayı değiştirme yasağına (m. 141, 2) tâbi değildir. Bu nedenle, davacının, dava açılmasından sonra doğan olayları ileri sürebilmesi için, davalının açık rızasına ihtiyacı olmadığı gibi, ıslah yoluna da başvurmasına gerek yoktur.

Bunun gibi, cevap dilekçelerinin verilmesinden (veya cevap süresinin geçmesinden) sonra doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi, savunmayı genişletme yasağına (m. 141, 2) tâbi değildir. Bu nedenle davalının, sonradan doğan savunma sebeplerini ileri sürebilmesi için, davacının açık rızasına ihtiyacı olmadığı gibi, ıslah yoluna başvurmasına da gerek yoktur.

Hukukî sebeplerin değiştirilmesi (veya genişletilmesi) davayı veya savunmayı değiştirme (veya genişletme) niteliğinde olmadığından, bir tarafın, bildirmiş olduğu hukukî sebebi değiştirebilmesi (veya genişletebilmesi) için, karşı tarafın rızasına ihtiyacı olmadığı gibi, ıslah yoluna başvurmasına da gerek yoktur.

Şimdi gelelim, ıslahla yapılabileceklere:

Islahla **dava konusu** değiştirilebilir. Dava dilekçesinde istenilen dava konusunun ıslahla değiştirilebilmesi mümkündür. Örneğin:

Dava konusu olan mal (ayın) talebi (malın aynen verilmesi istemi), ıslahla bedel talebine dönüştürülebilir.

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası, ıslahla müdahalenin önlenmesi davasına dönüştürülebilir.

İtirazın iptali davası, ıslahla alacağın tahsili davasına dönüştürülebilir.

Mirasta iade davası, ıslahla tenkis davasına dönüştürülebilir.

Islahla dava konusu arttırılabilir[2]. Örneğin, davacı dava dilekçesinin istem (talep) sonucu kısmında davalının on bin liraya mahkûm edilmesini is-

---

[2] 1086 sayılı HUMK'nun 87/son cümlesi, dava konusunun ıslahla arttırılamayacağını düzenlemekte idi. Anayasa Mahkemesi, 20.07.1999 tarihli ve 1-33 sayılı kararı ile, bu hükmü iptal etmiştir. HMK m. 176 vd. hükümlerinde ıslahla dava konusunun arttırılamayacağı şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin anılan kararına göre: "Hukuk devleti temel hak ve özgürlüklere saygı gösteren, onların korunup güçlenmelerine olanak sağlayan, adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olan devlettir. Hukuk devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği, kişilerin, hukuk düzeninin koruması altındaki haklarını elde edilebilmeleri için her türlü önlemin alınmasını zorunlu kılar. Dava açıldıktan sonra davacının müddeabihi ıslah yoluyla artırmasını önleyen itiraz konusu kural, **bir hakkın elde edilmesini zorlaştırdığından, hukuk devleti ilkesine aykırıdır**. Ayrıca, ... hak arama özgürlüğünün en önemli iki ögesini oluşturan **sav ve savunma haklarının kısıtlanması**, bu hakların noksansız kullanımının ve **âdil yargılanmanın engellenmesi Anayasa'nın 36. maddesine aykırılık oluşturur**".

temesine rağmen, daha sonra yapacağı ıslahla, talebini yüz bin liraya çıkartabilir.

Dava konusunun azaltılması için ıslaha gidilmez. Çünkü, iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı, karşı tarafın aleyhine olan genişletme veya değiştirme için söz konusu olabilir. Oysa, dava konusunun azaltılması (örneğin, davacının dava dilekçesindeki yüz bin liralık alacak talebini otuz bin liraya indirmesi), davalının aleyhine değil, lehine olan bir değişikliktir. Dava konusunun azaltılması, (tek taraflı bir işlem olan) davadan **kısmen feragat** (m. 307 vd.) veya karşı tarafın izni halinde **davanın kısmen geri alınması** (m. 123) şeklinde olur.

Dava konusunun değiştirilmesi halinde, bu talep karşı tarafa tebliğ edilir ve davacının yeni talebine karşı, davalının m. 126 vd. hükümlerine göre cevap verme hakkı vardır.

Dava konusu değişikliği, istem sonucunun tamamen değiştirilmesi şeklinde olabileceği gibi, istem sonucuna yeni bir talep eklenmesi şeklinde de ortaya çıkabilir.

Dava konusunun ıslahla arttırılması halinde, arttırılan miktara **uygulanacak olan faizin başlangıcı bakımından**, eğer önceden temerrüt var idiyse o tarih esastır. Buna karşılık, ıslahla arttırılan kısım için daha önce temerrüt yoksa, ıslahla arttırılan kısım için faiz hesaplanacak tarih, davanın açıldığı tarih değil, ıslahın yapıldığı (harca tâbi işlerde ıslahla artırılan miktara ilişkin ek harcın yatırıldığı) tarihtir.

Islahla, **dava sebebi (vakıalar)** değiştirilebilir. Davacı veya davalı, ıslah yoluyla dayandıkları vakıaları değiştirebilirler. Örneğin:

Doktorluk hizmetinden doğan alacak davası, ıslah yoluyla, ortaklıktan doğan kâr payı alacağı şekline dönüştürülebilir.

Islahla **tarafın değiştirilebilip değiştirilemeyeceği** tartışmalıdır. Taraf değişikliğinden kasıt, davacı veya davalı tarafta (iradî olarak) değişiklik yapılmasıdır. Değişiklik, taraflardan birinin tamamen değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, davacı veya davalı tarafta birden çok kişinin bulunması halinde bu kişiler bakımından yapılan değişiklikleri, bunların yanına başka kişilerin eklenmesini veya çıkartılmasını da kapsar. HMK m. 124'e göre, iradî taraf değişikliği, kural olarak, karşı tarafın açık onayı ile olabilir. Ayrıca, maddî hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kurallarına aykırı olmayan iradî taraf değişiklikleri, karşı tarafın onayına gerek kalmaksızın hâkim tarafından kabul edilebilir. Bunun dışındaki hallerde, ıslahla da tarafta değişiklik yapılabileceği kanısındayız. Ancak Yargıtayın yerleşik kararları, ıslahla tarafın değiştirilemeyeceği yönündedir.

Islahla **zamanaşımı**nın ileri sürülüp sürülemeyeceği çeşitli tartışmalara yol açmış ve Yargıtay çelişik kararlar vermişti. HMK m. 176'nın gerekçesinde açıkça, "zamanaşımı ilk itiraz olmayıp, ıslah yolu ile de ileri sürülebileceğine tereddüt etmemek gerekir" denilerek, bu konudaki tartışmalara son verilmiştir.

Buna karşılık, bazı konularda ıslah yapılamaz. Örneğin:

Bir taraf, (aynı davada ve aynı vakıa hakkında) yanlış bir tanık listesi verdiğini bildirerek, ıslahla **ikinci bir tanık listesi veremez** (m. 240, 2).

Tarafların usul işlemlerinin içinde maddî hukuk işlemlerinin yapılması da mümkündür; örneğin davadan feragat, davayı kabul, sulh, bir sözleşmenin feshi, takas beyanı gibi. Bu maddî hukuk işlemleri, usul işlemi içinde yapılmış olmakla beraber içerik bakımından maddî hukuk işlemi niteliğini korurlar. Çünkü, bu işlemlerin şart ve etkileri maddî hukuk tarafından düzenlenmektedir. Bu nedenle, bir usul işlemi içinde yapılmış olan bu gibi **maddî hukuk işlemlerinin** ıslah yolu ile düzeltilmesine imkân yoktur.

Islah, **tamamen ıslah** ve **kısmen ıslah** şeklinde ikiye ayrılır. Tamamen ıslahta, ıslah yoluyla dava en baştan (dava dilekçesinden) itibaren değiştirilir (m. 180). Tamamen ıslah, davacı tarafından yapılabilir. Kısmen ıslah, davacının veya davalının, yaptıkları usul işlemlerinden bazılarını ıslah etmeleri anlamına gelir (m. 181).

B) ISLAHIN YAPILMASI USULÜ

Islah, tükenebilen bir haktır. Davacı veya davalı, aynı davada yalnızca **bir kez** ıslah hakkını kullanabilirler (m. 176, 2). Tarafın yaptığı ıslahın, tamamen (m. 180) veya kısmen (m. 181) olması, durumu değiştirmez. Hangi ıslah türüne gidilmiş olduğuna bakılmaksızın, ıslah hakkını kullanan tarafın ikinci kez ıslah yoluna gidebilmesi mümkün değildir. Islah hakkının tüketilmemesi bakımından, ıslah hakkının kullanımında bu hususa dikkat edilmesi, tarafın kendi menfaatinedir. İleride ihtiyaç duyulabilecek önemli bir konunun ıslahına engel çıkmaması bakımından, ıslah hakkı, basit konularda kullanılarak tüketilmemelidir.

Islah belli bir zaman kesiti içerisinde yapılabilir. Islahın yapılabilmesinin başlangıç anı, iddianın ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının başladığı andır (m. 141; karş. m. 319). Bundan önce, iddia ve savunma serbestçe değiştirilebileceğinden ıslah yoluna gitmeye gerek yoktur. Islah halinde, görülmekte olan davada değişiklik ortaya çıktığı içindir ki, ıslahın davanın son aşamasında yapılması, hem diğer taraf hem de mahkeme bakımından doğru değildir. Bu sebeple Kanun, ıslah bakımından sınır getirmiştir. Islah, **tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir** (m. 177, 1). Mahkemenin, duruşmada hazır bulunan tarafların (o ana kadar yapılan) tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görmesi üzerine tahkikatın bittiğini taraflara tefhim etmesi (m. 184, 2) anından sonra ıslah yapılamaz.

Yargıtay, 04.02.1948 tarihli ve 10/03 sayılı İBK ile bozmadan sonra ıslaha izin vermemektedir. HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra bu İBK'nın değiştirilmesi için yapılan başvuru üzerine Yargıtay, bozma kararı sonrasında ıslah yapılamayacağına ve önceki İBK'nın değiştirilmesinin gerekmediğine karar vermiştir[3].

İstinaf aşamasında ıslah yapılamaz (m. 357, 1).

---

[3] 06.05.2016 gün ve E. 2015/01 ve K. 2016/01 sayılı İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 184-201.

Islah, **sözlü** olarak yapılabileceği gibi **yazılı da yapılabilir** (m. 177/c. 1). Sözlü yapılan ıslah talebi, tutanağa geçirilir ve tutanağın altı ıslah eden tarafından imzalanır (m. 154). Islahın sözlü yapıldığı duruşmada karşı taraf hazır değilse, tutanağın bir örneği, haber vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir (m. 177, 2/c. 2).

Kanunun, ıslahın karşı tarafa tebliğ edilmesindeki amacı, karşı tarafın ıslah talebine karşı savunmada bulunma olanağı vermesini, yeni bir dava açılması halinde davalıya verilen savunma olanağı ile paralel olarak düşünmek gerekir.

Davalının savunması, özellikle zamanaşımına uğramış bir alacağın ıslahla davaya dahil edilmesi bakımından önem arz eder. Şöyle ki:

Belirsiz alacak davası hariç, zamanaşımına uğrayan bir alacağın dava edilmesi halinde davalının zamanaşımı def'inde bulunma hakkı gibi, zamanaşımına uğrayan bir alacağın ıslahla davaya dahil edilmesinde de diğer tarafın zamanaşımı def'inde bulunma hakkı vardır. Bunu bir örnekle açıklayalım: (A), 01.03.2017'de ortaya çıkan bir haksız fiilden doğan alacağı için (iki yıllık zamanaşımı dolmadan) 01.02.2019 tarihinde, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, on bin liralık bir tazminat davası açmıştır (böylece, haksız fiilden doğan alacağının, yalnızca on bin liralık kısmı için zamanaşımı kesilmiştir). Dava sırasında alınan bilirkişi raporunda (A)'nın haksız fiilden doğan alacağının otuz bin lira olduğu anlaşılmıştır. (A), bunun üzerine davasını 01.03.2018 tarihinde ıslah ederek, davanın konusunu on bin liradan otuz bin liraya çıkartırsa, davalı, yirmi bin liralık alacağın zamanaşımına uğradığı def'ini ileri sürebilir. Çünkü, haksız fiilden doğan alacağın iki yıllık zamanaşımı, on bin lira için dava tarihinde kesilmiş olmakla birlikte, geriye kalan yirmi bin lira için zamanaşımı kesilmemiştir; ıslah tarihi itibariyle aradan üç yıl geçmiştir.

Islahtan sonra karşı taraf, zamanaşımı def'ini, ıslah dilekçesinin tebliği izleyen ilk oturuma kadar ileri sürer. Islahla arttırılan kısım için zamanaşımının dolup dolmadığına bakarken, olayda uzatılmış ceza zamanaşımının bulunup bulunmadığına da dikkat etmek gerekir.

Kanunun aradığı şartlara ve usulüne uygun olarak yapılan ıslah, **tek taraflı bir irade beyanı** ile kullanılan ve sonuç doğuran bir usulî işlemdir; mahkemenin veya karşı tarafın rızasına bağlı değildir.

Bununla birlikte, mahkeme, mevcut delillere ve belirtilere bakarak, ıslahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi **kötüniyetli** düşüncelerle yapıldığı sonucuna varırsa, davayı ıslahı dikkate almadan (ıslah edilmeden önceki haliyle) hükme bağlar (m. 182, 1/c. 1). Böyle bir durumda hâkim, ayrıca, kötüniyetle (örneğin sırf davayı uzatmak amacıyla) ıslaha başvuranı, karşı tarafın bu yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve disiplin para cezasına mahkûm eder (m. 181, 1/c. 2).

Kanun, ıslah üzerine tarafın yapması gereken işlemleri, tamamen ıslah ve kısmen ıslahı ayrı ayrı öngörerek düzenlemiştir.

I – TAMAMEN ISLAH

Davasını tamamen ıslah etmek isteyen davacı; ıslah edilmiş haliyle yeni bir dava dilekçesi hazırlayıp bunu mahkemeye sunarak ıslah yoluna gidebileceği gibi, henüz ıslah dilekçesi hazırlamadan da, mahkemeye davasını tamamen ıslah ettiğini bildirebilir. Bu ikinci halde, davacı, bildiriminden itibaren bir hafta içinde **yeni bir dava dilekçesi** vermek zorundadır (m. 180, 1/c. 1).

Davasını tamamen ıslah eden davacı, yukarıda belirtildiği gibi, bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi verirse veya ıslah dilekçesi aynı zamanda yeni bir dava dilekçesi niteliğinde ise **mahkeme**, m. 178'e göre yargılama giderleri ve davalının zararını karşılamak üzere takdir edilen teminatın da mahkeme veznesine yatırılmasından sonra, **davayı yeni şekline** (yeni dava dilekçesine) **göre yürütür** (görür). Kanun (m. 180), "bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır" demekte ise de burada, davacının vermiş olduğu yeni dava dilekçesi ile **yeni bir dava açılmış olmaz**. Davanın tamamen ıslahı üzerine (yeni şekline göre) bakılan dava da eski (ilk açılan) davanın bir devamı niteliğindedir; bu nedenle m. 180'deki bir hafta içinde yeni dava dilekçesini veren davacıdan **yeniden başvurma harcı** ile **peşin karar** ve **ilâm harcı alınmaz**. Davanın açıldığı tarihte ortaya çıkan **zamanaşımı kesilmesi sonucu devam eder**; davanın tamamen ıslahı, bu konuda bir değişiklik ortaya çıkarmaz.

Davacının bir hafta içinde verdiği yeni dava dilekçesinin bir örneği, davalıya tebliğ edilir. Davalı, bu yeni dava dilekçesine karşı (cevap süresi içinde) yeni bir cevap dilekçesi verebilir.

Davasını tamamen ıslah ettiğini (edeceğini) bildiren ve aynı anda yeni dava dilekçesi vermeyen davacı, **yeni dava dilekçesini bir hafta içinde vermezse**, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya (mevcut haliyle) devam edilir. Ancak bu halde dahi, ıslah hakkı kullanılmış olur (m. 180, 1/c. 2) ve bundan sonra davacı (artık) ıslah yoluna gidemez (m. 176, 1); çünkü ıslah hakkı bir kez kullanılabilen haktır (m. 176, 2).

Islah hakkını kullanmış olan davacı, isterse (kendi iradesine bağlı olarak) yeni talebi için başka bir dava açacaktır. Davacının açacağı yeni dava ile, (duruma göre) ilk davanın istem sonuçları veya vakıaları farklı olacağından derdestlik söz konusu olmaz.

II – KISMEN ISLAH

Kısmen ıslahta, davadaki bir veya birkaç usul işlemi ıslah edilir. Kısmen ıslahı, davacı da davalı da yapabilir. Dava konusunun arttırılması, kısmen ıslahtır. Yukarıda (m. 180) tamamen ıslahta açıklandığı gibi, taraf, daha önceden (kısmen ıslah etmeyi düşündüğü işlemi yapmadan) mahkemeye yöneltileceği yazılı veya sözlü bir irade beyanı (m. 177, 2) ile kısmen ıslah yoluna gideceğini bildirmiş olabilir. Bu durumda mahkeme, ıslah edilen işlemini yapması için, tarafa bir haftalık süre verir (m. 181, 1/c. 1).

Taraf, kısmen ıslah talebini ayrı yapmak ve ıslah edilmiş haliyle yeni işlemini de ayrıca vermek zorunda değildir; taraf, ıslah talebi ile birlikte ıslah

edilmiş haliyle yeni işlemini de, aynı anda, mahkemeye verebilir. Bu durumda, mahkemenin tarafa bir haftalık süre vermesine ve tarafın da bir hafta içinde yeni bir dilekçe vermesine gerek yoktur. Davasını kısmen ıslah ettiğini (edeceğini) bildiren ve aynı anda ıslah edilmiş haliyle yeni işlemini vermeyen taraf, ıslah edilen işlemini bir hafta içinde yapmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya (mevcut haliyle) devam edilir (m. 181, 1/c. 2). Ancak bu halde dahi, ıslah hakkı kullanılmış olur (m. 180, 1/c. 2) ve bundan sonra taraf, aynı davada artık ıslah yoluna gidemez (m. 176, 1).

C) ISLAHIN ETKİSİ

Islah eden taraf, yargılamada o ana kadar yapılmış olan bazı usul işlemlerini değiştirmekte veya düzeltmektedir. Hatta tamamen ıslahta, yargılamanın başına kadar dönülebilmekte ve böylece, o ana kadar yapılan işlemlerin yapılmamış sayılması gibi bir durum ortaya çıkmakta ve böylece gerek mahkemenin gerek karşı tarafın yaptığı işlemler (deyiş yerinde ise) boş yere yapılmış olmaktadır. Bu sonucun, ıslaha başvuran taraf bakımından bir yaptırımı olmalıdır. Kanuna (m. 178) göre; ıslah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hale gelen işlemler için **yapılan yargılama giderlerini** ve karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hâkimin belirleyeceği **teminatı** (m. 84 vd.), bir hafta içinde, mahkeme veznesine yatırmak zorundadır (m. 178, 1/c. 1). Yatırılacak olan teminat için, karşı tarafın talebi gerekmez; mahkeme buna kendiliğinden karar verir. Hâkimin yatırılacak olan teminatın miktarını belirlerken, ıslah sonucunda geçersiz hale gelen işlemler bakımından yapacağı tespit kolaydır. Örneğin, yargılama sırasında keşfe gidilmiş ve bunun için çeşitli yargılama giderleri yapılmıştır. Oysa, taraflardan birinin ıslah talebi üzerine bu keşif, gereksiz ve anlamsız hale gelmiştir. Islah eden taraf, gereksiz ve anlamsız hale gelen bu keşif giderleri için teminat vermek zorundadır. Buna karşılık, "karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zarar"ın belirlenebilmesi bazı durumlarda zorluk gösterebilir. Mahkemenin tam bir tespit yapmasının zor olduğu hallerde, mahkeme yaklaşık bir miktar belirlemeyle yetinmeli ve ıslah işleminin bir an önce tamamlanmasını sağlamalıdır. Mahkemenin yatırılmasını istediği teminatın, bir haftalık süresi içinde yatırılmaması halinde ıslah yapılmamış sayılır (m. 178, 1/c. 2). Karşı tarafın zararının kesin olarak tespit edilmesinden sonra, daha önce yatırılmış bulunan teminat eksikse tamamlatılır, fazla ise iade edilir (m. 178, 2).

Islahla davada düzeltme (değiştirme) yapıldığından; ıslah yapan tarafın ıslahı anından **geriye doğru olan işlemler**, kural olarak, **yapılmamış sayılır** (m. 179, 1). Bu hükmün amacı, ıslahtan önceki işlemleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Davacı, taşınmaz üzerindeki kişisel hakka dayanarak, İİK m. 277 vd. hükümlerine dayanarak davalılardan birinin yerleşim yerinde (m. 7, 1), tasarrufun iptali davası açmış iken, yargılama sırasında davasını ıslah ederek, TBK m. 19 uyarınca taşınmazın aynı ile ilgili muvazaaya dayalı tapu iptali ve tescil davası olarak değiştirirse, dava, taşınmazın aynı hakkında açılan dava (m. 12) haline geldiğinden, mahkemenin, yetkisizlik kararı vermesi gerekir.

Kural olarak ıslahtan önceki işlemler yapılmamış sayılmakla birlikte, ikrar (m. 188); tanık ifadeleri (m. 240 vd.); bilirkişi rapor ve beyanları (m. 279); keşif tutanakları (m. 290); isticvap tutanakları (m. 174); yerine getirilmiş olan veya henüz yerine getirilmemekle birlikte karşı tarafın yerine getireceğini ıslahtan önce bildirmiş olması şartıyla yeminin teklifi veya iadesi, ıslah sonucunda geçersiz kılınamayıp, bunlar geçerliliklerini sürdürürler (m. 179, 2). Ancak, ıslahtan sonraki tahkikatın sonucunda bu işlemlerin değeri kalmamışsa, bunlar da yapılmamış sayılır (m. 179, 3).

D) MADDÎ HATALARIN DÜZELTİLMESİ

Tarafların, dava dosyasında bulunan belgelerde yaptığı açık yazı ve hesap hataları, **ıslah yoluna gitmeye gerek kalmadan**, hüküm verilinceye kadar düzeltilebilir (m. 183, 1/c. 1). Örneğin:

Davacının dilekçesine, maliki bulunduğu parselin numarasını yanlış yazmış olması ve bu maddî hatanın dava dilekçesindeki açıklamalardan anlaşılması halinde parsel numarası düzeltilebilir. Tarafların dilekçelerindeki maddî hatanın düzeltilmesi iddianın veya savunmanın değiştirilmesi anlamına gelmez.

Tarafın, yazı veya hesap hatasını düzeltmesi, yargılamanın uzamasını neden olmuşsa, yargılama giderlerinin (m. 323) belirlenmesinde bu durum da dikkate alınır (m. 183, 1/c. 2; ayrıca bkz. m. 327).

Mahkemenin, dava dosyasında bulunan belgelerde yaptığı açık yazı ve hesap hataları da hüküm verilinceye kadar düzeltilebilir (m. 183, 1/c. 1). Örneğin, mahkeme, maddî hata sonucunda "davacı" yerine "davalı" demişse veya yüz bin lira alacağın yüzde dokuz üzerinden bir yıllık faizini hesaplaması sonucu bu faizi beş bin lira olarak bularak yazarsa, bu tür hatalar düzeltilebilir.

§ 46. DAVADA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ[1]

A) GENEL OLARAK

Herkes (Türk vatandaşları, yabancılar ve vatansızlar) Türk mahkemeleri önünde serbestçe dava açabilir veya davaya katılabilirler. Bu husus hak arama özgürlüğünün sonucudur.

Hal böyle olmakla birlikte, kanunlar bazı hallerde, davanın açılmasını, davaya müdahale edilmesini veya takip yapılmasını teminat gösterilmesi şartına bağlayabilmektedir. Bunun gerekçesi, hakkında (aleyhine) dava açılan veya takip yapılan kişinin (ki, bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığının herhangi bir önemi yoktur), davayı veya takibi kazanması halinde, davacının ödemek zorunda kalacağı (davalının ve/veya Hazinenin) yargılama giderlerinin tahsilini sağlamaya yöneliktir. Davacının, onun yanında davaya katılan ferî müdahilin veya alacaklının Türkiye'de oturması (Türkiye'de en azından mutad meskeninin bulunması) halinde, davalının yargılama giderlerini tahsilinde (olağan şartlarda) büyük bir zorluk ortaya çıkmaz. Buna karşılık davacının, onun yanında davaya katılan ferî müdahilin veya alacaklının Türkiye'de oturmaması halinde ise, davayı veya takibi kazanan davalı yargılama giderlerini tahsil edememe tehlikesi ile karşı karşıyadır. İşte bunun için, anılan kişilerin teminat yatırması şartı aranmaktadır.

Hukukumuzda bu hususu düzenleyen iki ayrı kanun vardır. Bunlardan biri HMK m. 84 vd.; diğeri, MÖHUK m. 48'dir.

Bu arada belirtelim ki, mevzuatımızda teminat gösterilmesini gerektiren haller, aşağıda göreceğimiz HMK m. 84 vd. ile MÖHUK m. 48'deki düzenlemeden ibaret değildir. Mevzuatımızda teminat gösterilmesini gerektiren diğer haller (örneğin, geçici hukukî himaye tedbirlerinde, icranın durdurulmasında, ıslahta, eski hale getirmede vb.) hakkında çok sayıda özel düzenleme vardır.

B) HMK'NA GÖRE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ

Aşağıdaki durumlarda, davacının veya davacı yanında davaya katılanın (ferî müdahale edenin) yahut icra takibi yapan kişinin, davalı tarafın -icra takibinde borçlunun- muhtemel yargılama ve takip giderlerini karşılayacak uygun bir teminat göstermesi gerekir (m. 84, 1).

---

[1] Bkz. Ejder Yılmaz, Davada İnanca (HUMK m. 96 vd. EHVK m. 3), (AÜ Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı, Ankara 1977; s. 382-410; Yılmaz, Makaleler c.1, s. 177-200); Mustafa Okur, Davada Teminat, Ankara 2011; Zeynep Çalışkan, Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat, İstanbul 2013.

I – TÜRKİYE'DE MUTAD MESKENİ BULUNMAYAN TÜRK VATANDAŞININ TEMİNAT GÖSTERMESİ

Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşı olan (gerçek) kişi, Türkiye'de **dava açarsa** veya Türkiye'de açılmış ve derdest bulunan bir davada, davacı yanında **ferî müdahil olarak katılırsa** (m. 66 vd.) veya Türkiye'de **takip yaparsa** teminat yatırır (m. 84, 1/a).

Burada (m. 84, 1/a) önemli olan, davacının veya ferî müdahilin Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de mutad meskeninin bulunmamasıdır. Davacının Türkiye'de mutad meskeni varsa (m. 84, 1/a'ya göre) dava açarken teminat göstermesi gerekmez. Buna karşılık, bu davacının açtığı davaya ferî müdahil olarak katılmak isteyen kişinin Türkiye'de mutad meskeni yoksa, (m. 84, 1/a'ya göre) teminat göstermesi gerekir.

Aslî müdahale hukukî niteliği itibariyle bir dava olduğundan, Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşı aslî müdahil de (aslî müdahale davasının davacısı) teminat yatırmak zorundadır.

Zorunlu dava (m. 59-60) ve **takip arkadaşlığı**nda teminat gösterme zorunluluğu, bu zorunluluğun tüm davacılar bakımından mevcut olması halinde doğar (m. 84, 3). **İhtiyarî dava arkadaşlığı**nda (m. 57) ise, teminat gösterme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, her bir dava arkadaşı için ayrı ayrı değerlendirilir (m. 58).

Maddedeki (m. 84, 1/a) teminat konusu, **sadece Türk vatandaşları** bakımındandır. Çünkü yabancıların, Türkiye'de dava açması, davacı yanında davaya ferî müdahil sıfatıyla katılması ve Türkiye'de takip yapması halinde, teminat göstermesi hakkında (HMK m. 84 değil) MÖHUK m. 48 uygulanır.

Hukuken "mutad mesken" tabiri, gerçek kişiler bakımından kullanıldığından m. 84, 1/a hükmü, (Türk vatandaşı) **gerçek kişiler** hakkında uygulanır. Tüzel kişiler bakımından ise hukuken (mesken, mutad mesken gibi tabirler değil) "merkez" (veya şube) gibi terimler kullanıldığından m. 84, 1/a hükmünün Türk vatandaşı tüzel kişiler hakkında uygulanması düşünülemez.

"**Mutad mesken**", herkesçe bilinen (alışılmış) mesken (oturulan yer) anlamındadır. HMK'nun 84. maddesinin gerekçesinde, mutad meskenin, "tüm hayat ilişkilerinin belirli bir coğrafî alanda yoğunlaşması" şeklindeki tanımına yollama yapılmaktadır.

HMK m. 84'te "yerleşim yeri" değil, "mutad mesken" şartı aranmaktadır[2]. Buna göre, yerleşim yeri yabancı ülkelerde olan Türk vatandaşlarının Türkiye'de mutad meskenlerinin bulunması halinde teminat göstermelerine gerek yoktur.

Davanın veya takibin Türk vatandaşı vekil aracılığıyla yapılması, teminat gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan ferî müdahil açısından teminat gösterme zorunluluğu, davalının yanında değil, **davacının yanında davaya katılması** durumuna özgüdür.

---

[2] Mutad mesken terimi, **"yerleşim yeri" kavramından daha dar bir anlam taşımakta**dır. HUMK m. 97, Türkiye'de yerleşim yeri olmayanların teminat yatırması şartını aramakta idi.

II – ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNANIN TEMİNAT GÖSTERMESİ

Ödeme güçlüğü içinde bulunan davacı da teminat yatırmak zorundadır (m. 84, 1/b). Çünkü, ödeme güçlüğü içinde bulunan kişi, açtığı davayı kaybederse, davalı yararına hükmedilen yargılama giderlerini de ödeyememe tehlikesi vardır. Bu sebeple, ödeme güçlüğü içinde bulunan kişinin, davalının muhtemel yargılama giderlerine karşılık teminat yatırması gerekir

Ödeme güçlüğü bulunan kişi bakımından kabul edilen bu halin, m. 84, 1/a'daki hal (Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti gerçek vatandaşları) ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu halde, davacının Türk vatandaşı olup olmamasının, Türkiye'de yerleşim yerinin veya mutad meskeninin bulunup bulunmamasının herhangi bir önemi yoktur. Aynı şekilde, davacının gerçek kişi veya tüzel kişi olması da fark etmez. Ödeme güçlüğü içinde bulunan herkes, bu madde kapsamında teminat yatırmak durumundadır.

Ödeme güçlüğünün hangi hallerde olacağı ise Kanunda örnek niteliğinde yer almıştır. Buna göre, davacının daha önceden iflâsına karar verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış bulunması; borç ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi halleri, davacının teminat yatıracağı haller olarak ifade edilmiştir (m. 84, 1/b).

Hüküm (m. 84, 1/b), m. 84, 1/a'daki düzenlemeden farklı olarak, (yalnızca) "**davacı**"dan söz etmektedir. Başka bir ifade ile, m. 84, 1/b'de "davacı yanına davaya müdahil olan kişi"den söz edilmemiştir. Bu sebeple, ferî müdahil ödeme güçlüğü içinde ise, m. 84, 1/b hükmüne tâbi olup olmayacağı akla gelmektedir. Hükmün gerekçesinde kullanılan, "(ödeme güçlüğü ile ilgili) bu hallerin davacı yanında ferî müdahil sıfatıyla yer alan kişinin şahsında gerçekleşmiş olması, ferî müdahil açısından da müdahale giderleriyle sınırlı olarak teminat gösterme zorunluluğunun doğması sonucunu ortaya çıkarır" ibaresinden, kanun koyucunun ödeme güçlüğü içindeki ferî müdahilin de teminat göstermesi şartını aradığı sonucuna vardırmaktadır.

Davada teminat gösterilmesi, başka bir deyişle, teminat hakkındaki kararın yerine getirilmesi gereği, bir **dava şartıdır** (m. 114, 1/ğ).

Türkiye'de mutad meskeninin mevcut olması ve ödeme güçlüğü içinde bulunmaması halinde, teminat göstermeye gerek kalmadan, davacı davayı açmış veya ferî müdahil, davaya katılmış olabilir. Eğer davacı veya ferî müdahil, (dava açıldıktan sonra) **dava** (takip) **sırasında** Türkiye'de mutad meskenini terk ederse yahut ilgili kişi (davacı veya ferî müdahil) hakkında ödeme güçlüğü sebeplerinden biri (m. 84, 1/a-b) **ortaya çıkarsa**, mahkeme, teminat gösterilmesine karar verir (m. 84, 2; 86).

III – TEMİNAT GÖSTERİLMESİNİN İSTİSNALARI

Bazı hallerde teminat gösterilmesi gerekmez (m. 85). Buna göre:

1) 84. maddeye göre teminat göstermek zorunda olan taraf veya ferî müdahil (Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşı yahut öde-

me güçlüğü içindeki kişi, Türk mahkemesinde açtığı/açacağı (müdahale ettiği/edeceği) dava veya Türk icra dairesinde başlattığı/başlatacağı icra takibi bakımından **adlî yardımdan** (m. 334 vd.) yararlanıyorsa, teminat yatırmak zorunda değildir (m. 85, 1/a). Bu istisna, adlî yardımdan yararlanacak olan kişilerin malî durumlarının yerinde olmamasından kaynaklanmaktadır.

2) 84. maddeye göre teminat yatırmak zorunda olan tarafın veya ferî müdahilin, **Türkiye'de** istenen teminatı karşılamaya **yeterli taşınmaz malının** veya aynî teminatla güvence altına alınmış bir **alacağının bulunması** halinde, teminat göstermesi gerekmez (m. 85, 1/b). Çünkü böyle bir durumda, davayı kazanan davalının yargılama giderlerini Türkiye'de tahsil edebilme olanağının bulunduğu kabul edilir. Bu sebeple bu istisnanın uygulanmasında, ilgilinin Türkiye'de bulunan taşınmaz malının veya alacağının üzerinde, üçüncü kişilerin öncelikle gelen (imtiyazlı) alacakları varsa ve bunun sonucunda bunlar üzerinden geriye bir şey kalmayacaksa, bu husus dikkate alınmalıdır.

3) 84. maddeye göre teminat göstermek zorunda olan tarafın sırf **küçüğün** (on sekiz yaşını doldurmamış çocuğun**) menfaatlerini koruma**ya yönelik bir dava açması (veya ferî müdahilin böyle bir davaya katılması) halinde teminat göstermesi gerekmez (m. 85, 1/c). Bu istisna, küçüğü korumaya yöneliktir. Küçüğün menfaati hem millî, hem de milletlerarası planda en çok korunmaya değer (himayeye mahzar) menfaat olarak kabul edilmiştir.

4) 84. maddeye göre teminat yatırmak zorunda olan taraf, **ilâma bağlı alacak** için ilâmlı icra takibi yaparsa, teminat göstermesi gerekmez (m. 85, 1/d). Çünkü, elde bir ilâm (ve hatta ilâm niteliğinde belge) varsa, alacaklının alacağı, kural olarak, belli hale gelmiştir.

Hayatın olağan akışı çerçevesinde, mahkemenin (Türk vatandaşı olan) davacının (veya ferî müdahilin) Türkiye'de mutad meskeninin bulunup bulunmadığını veya ödeme güçlüğü içinde olup olmadığını (m. 84), kendiliğinden bilebilmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle, teminat hususu genellikle, karşı tarafın yapacağı itirazla gündeme gelir. Böyle bir itirazın doğru olup olmadığı, konuyla ilgili bazı incelemelerin yapılmasını ve delil toplanmasını gerektirebilir. Mahkemenin bu konuda karar almadan önce, sağlıklı ve doğru bir değerlendirme yapabilmesini mümkün kılmak amacıyla tarafları ve müdahale isteminde bulunanı dinleyebileceği hususu hüküm (m. 86) altına alınmıştır.

Mahkeme, kendiliğinden (veya karşı tarafın talebi -uyarısı- üzerine) yapacağı inceleme sonucunda teminat gösterilmesi gereken bir halin olduğunu anlarsa, teminatın miktarını ve cinsini belirleyerek tarafa veya ferî müdahile uygun ve kesin (m. 88, 1) bir süre verir.

Kanundan (m. 87, 1/c. 2) anlaşıldığı üzere, teminat konusunda tarafların anlaşma yapabilmelerine olanak tanınmıştır. Buna göre, taraflar sözleşme ile aksini kararlaştırmamışlarsa, mahkeme, teminatın tutarını ve şeklini serbestçe takdir eder (m. 87, 1).

Mahkemenin, teminat konusunda aldığı kararını (m. 87, 1), durum ve şartlarda zamanla ortaya çıkan ihtiyaca göre değiştirmesi mümkündür. Örneğin, teminat gösterilmesini gerektiren şart sonradan ortadan kalkarsa (söz-

gelimi, Türkiye'de mutad meskeni bulunmayan kişi Türkiye'ye yerleşirse) teminat kaldırılabilir veya diğer gelişmelere göre azaltılabilir, arttırılabilir (m. 87, 2); teminat gösterilmesini gerektiren hal dava sırasında ortaya çıkarsa, başlangıçta teminat istenmemesine rağmen, şimdi teminat istenebilir (m. 84, 2).

87. madde hükmü, yalnızca m. 84'te teminat gösterilmesini gerektiren hallerle sınırlı değildir, genel olarak davada gösterilecek diğer teminat hallerini de kapsamaktadır. Bu sebeple mahkeme, teminat yatırılmasını gerektiren her bir olayın özelliklerini dikkate alarak takdir yetkisini kullanır. Örneğin, ihtiyatî tedbirdeki teminat uygulamasında (m. 392) mahkemeler, genellikle alacağın yüzde on-on beşi oranında teminat istemektedirler; kira alacağı ve tahliye davalarında icranın durdurulması için üç aylık kira bedeli teminat alınmaktadır vb.

IV – TEMİNAT TUTARI

HMK'nun 84. maddesine göre gösterilecek teminat tutarına gelince:

HMK m. 84'deki haller bakımından gösterilecek teminat, **"davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak** uygun bir teminat"tır.

Teminat göstermesine karar verilen davacı, mahkeme kararı (m. 86) ile tespit edilen teminatı, mahkemece belirlenen kesin süre içinde yatırmazsa, açtığı dava usulden reddedilir (m. 88, 1). Teminat gösterecek olan kişi; ferî müdahil ise, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, müdahale talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir (m. 88, 2).

İcra takipleri bakımından, icra dairesinin vereceği kesin süre içinde gerekli teminat yatırılmazsa, icra dairesi, takipten vazgeçilmiş sayılmasına karar verir (m. 88'e kıyasen). İcra dairesinin bu kararına karşı şikâyet yolu açıktır (İİK m. 16).

Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir. Burada kullanılan "teminat gösterilmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması"nın takdiri, mahkemeye (icra takiplerinde, icra dairesine) ait bir konudur.

İhtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz taleplerinde teminat olarak yatırılan para, banka mektubu, tahvil veya benzeri evrakın iadesinin istenmesi halinde yazı işleri müdürü teminatın iadesi için şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırıp bu hususu belgelendirerek görüşü ile birlikte dosyayı hâkim ya da daire başkanına sunar. Teminat gösterilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığının anlaşılması halinde mahkemece, teminatın iadesine karar verilir (Y m. 217).

C) TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLARIN (YABANCILARIN) TEMİNAT GÖSTERMESİ (MÖHUK m. 48)

Yukarıda gördüğümüz üzere, HMK (m. 84 vd.), Türk vatandaşlarının teminat gösterme yükümlülüğü bakımından, "Türkiye'de mutad meskenin bulunup bulunmadığı" ölçütünü benimsemiştir.

Teminat gösterme ile ilgili diğer düzenleme olan MÖHUK m. 48 ise, (Türkiye'de mutad meskenin bulunup bulunmadığını değil) **yabancılık** (Türk vatandaşı olmama) **ölçütü**nü benimsemiştir.

Bu hükme göre; Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzelkişiler, **yargılama ve takip giderleri** ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar (MÖHUK m. 48, 1). Mahkeme, dava açanı, davaya katılanı veya takip yapanı **karşılıklılık esasına** göre teminat göstermekten muaf tutabilir (MÖHUK m. 48, 2).

Türkiye'de dava açan, icra veya iflâs takibi yapan yabancı kişi, teminat tutarını **döviz** olarak Merkez Bankasına depo eder. Türkiye'de dava açan yabancı davacının, istenilen teminatı döviz olarak nakit bir şekilde yatırması şart olmayıp, **döviz üzerinden** (hâkimin kabul edeceği) **banka teminat mektubu** şeklinde de yatırabilir. Önemli olan döviz üzerinden teminat yatırılmış olmasıdır.

Teminattan muafiyet için açık bir **uluslararası sözleşme**nin bulunup bulunmadığı veya **karşılıklılık** ilkesi çerçevesinde yabancı davacının **teminattan muafiyeti** için, mahkemenin davacının hangi devletin uyruğunda olduğunu kendiliğinden araştırarak sonuca varması gerekir.

§ 47. DAVA ARKADAŞLIĞI[1]

A) DAVA ARKADAŞLIĞI KAVRAMI

Yukarıda, dava çeşitlerini incelerken davacının, davalıya karşı birden çok talebini aynı dava dilekçesiyle dava edebileceğini "**davaların yığılması**" (m. 110) başlığı altında görmüştük. Birden fazla konu ("obje") bir arada dava edildiği için, davaların yığılmasına, "**objektif dava birleşmesi**" de denilmektedir.

Bazı durumlarda davada, (birden fazla konunun değil de) birden fazla kişinin ("süje"nin) de bir araya gelmesi mümkündür. Örneğin, müteselsil alacaklılıkta, birden fazla kişi (davacı sıfatıyla) birlikte dava açabilirler veya müteselsil borçlulara karşı (davalı sıfatıyla) birlikte dava açılabilir. Bu gibi durumlarda, aynı tarafta bulunan birden fazla kişi arasındaki ilişkiye, (objektif dava birleşmesinin karşıtı olarak) "**sübjektif dava birleşmesi**" denir. Sübjektif dava birleşmesi, daha çok **dava arkadaşlığı** olarak anılmaktadır. Buna paralel olarak, dava arkadaşlığı durumunda, aynı tarafta yer alan kişilere, **dava arkadaşı** (arkadaşları) denilmektedir.

Dava arkadaşlığı, davacı tarafında olabildiği gibi (aktif dava arkadaşlığı), davalı tarafında (pasif dava arkadaşlığı) da olabilir. Hatta, aynı dava her iki tarafta da birden çok dava arkadaşı bulunabilir.

Kanun, bazı şartların varlığı halinde, birden çok kişinin aynı dava dilekçesiyle birlikte dava açmasına ve birden çok kişiye karşı da aynı dava dilekçesiyle dava açılabilmesine olanak tanımaktadır (m. 57 vd.). Bu olanağın kullanılarak dava açılması, **ihtiyarî dava arkadaşlığı**dır (m. 57-58).

İhtiyarî dava arkadaşlığında, şeklen yalnızca bir (tek) dava dilekçesi bulunmasına ve yalnızca (tek, bir) yargılama yapılıyormuş gibi gözükmesine rağmen, aslında ortada, dava arkadaşı sayısı kadar bağımsız dava vardır; çünkü, yargılama sırasında her bir dava arkadaşı ayrı ayrı iddia ve savunmada bulunabilir ve mahkeme, yargılamanın sonunda verdiği hükümde (nihaî kararda) her bir dava arkadaşı için ayrı ayrı karar vermek durumundadır.

Dava arkadaşlığı, bazı hallerde zorunludur. Davacılar arasında zorunlu (mecburî) dava arkadaşlığı (m. 59-60) söz konusu ise, bütün arkadaşların (aynı dava dilekçesiyle) birlikte dava açması; davalılar arasındaki zorunlu dava arkadaşlığında, bütün arkadaşların aynı dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeleri gerekir.

---

[1] Bkz. Yavuz Alangoya, Medenî Usul Hukukunda Dava Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1999; Ömer Ulukapı, Dava Arkadaşlığı, Konya 1992.

B) İHTİYARÎ DAVA ARKADAŞLIĞI

Birden çok kişinin, davacı sıfatıyla hareket ederek aynı dava dilekçesiyle birlikte dava açabilmeleri veya birden çok kişinin davalı olarak gösterilerek bunlara karşı aynı dava dilekçesi ile dava açılabilmesi (ihtiyarî dava arkadaşlığının oluşabilmesi), Kanunda (m. 57, 1) gösterilen sebeplerin varlığına bağlıdır.

I – İHTİYARÎ DAVA ARKADAŞLIĞININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER

1) Davacılar veya Davalılar Arasında Dava Konusu Olan Hak veya Borcun, Elbirliği İle Mülkiyet Dışındaki Bir Sebeple Ortak Olması

TMK'na (m. 683 vd.) göre, şey (mal) üzerinde bir kişinin mülkiyet hakkı olabileceği gibi o şeye birden çok kişi de malik olabilir. Kanun buna, "**birlikte mülkiyet**" demektedir (TMK m. 688-703). Birlikte mülkiyet, kendi arasında ikiye ayrılır: 1) "**Paylı mülkiyet**" (müşterek -ortak- mülkiyet; TMK m. 688-700); 2) "**Elbirliği mülkiyeti**" (iştirak halinde mülkiyet; TMK m. 701-703).

Paylı mülkiyette birden çok kişi, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Paylı mal üzerinde yapılacak tasarruflar konusunda Kanundaki hükümler geçerlidir (TMK m. 689 vd.). Buna göre, kural olarak, her ortak kendi payı üzerinde, serbestçe tasarruf edebilir.

Buna karşılık, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla, mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. **Elbirliği mülkiyetinde**, paylı mülkiyetten farklı olarak, **ortakların** belirlenmiş payları bulunmayıp her birinin **hakkı, ortaklığa giren malların tamamı üzerindedir** (TMK m. 701); bütün ortaklar, ortak malın her bir zerreciği üzerinde (hakları oranında) birlikte maliktirler. Elbirliği mülkiyetinde, kanunda veya sözleşmede, aksine bir düzenleme bulunmadıkça, gerek yönetim gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir ve topluluk devam ettiği sürece pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz (TMK m. 702; karş. TMK m. 689 vd.).

Üzerinde, sözgelimi (A) ve (B)'nin yarı yarıya mülkiyet hakkı bulunduğu mala (paylı -müşterek- mülkiyet konusu ortak mala), üçüncü kişi (C) tarafından müdahale edilirse, müdahalenin önlenmesi için (A) ve (B), birlikte dava açabilecekleri gibi; (C)'nin, fiilen (A)'nın payına isabet eden kısmına müdahalesi halinde yalnızca (A)'nın dava açabilmesi mümkündür. Şayet (C), bu malın gerçekte kendisine ait olduğunu (babasından kaldığını) ileri sürerek bir tespit davası açmak isterse, (A) ve (B)'yi birlikte davalı göstererek aynı dava dilekçesiyle dava açabilir. Birinci halde davacılar arasında; ikinci halde ise, davalılar arasında ihtiyarî dava arkadaşlığı vardır.

Yukarıda verilen örnekte (A) ve (B)'nin ortak olduğu mal üzerinde, paylı mülkiyet değil de elbirliği ortaklığı bulunsa idi, o zaman ihtiyarî dava arkadaşlığı (m. 57-58) değil, zorunlu dava arkadaşlığı (m. 59-60) söz konusu olurdu.

2) Ortak Bir İşlemle, Davacıların veya Davalıların Hepsinin Yararına Bir Hak Doğmuş Olması veya Kendilerinin Bu Şekilde Yükümlülük Altına Girmeleri

Birden çok kişinin, birlikte yaptıkları ortak işlem sonucunda hak (alacak) sahibi olabilmeleri veya borç (yükümlülük) altına girebilmeleri mümkündür.

Örneğin (A)'nın bankadan aldığı borç karşılığı düzenlenen kredi sözleşmesini, (A) asıl borçlu; (B) ve (C) de, müteselsil kefil olarak imzalamışlardır. Böylece (A), (B) ve (C); ortak bir işlem yaparak alacaklı banka lehine yükümlülük (borç) altına girmişlerdir. Asıl borçlu (A)'nın, aldığı kredi borcunu bankaya ödememesi halinde, banka isterse, her üç kişiyi de davalı göstererek bir alacak davası açabilir veya banka isterse, bunlardan yalnızca birini veya ikisini de dava edebilir. İkisini veya üçünü birden davalı olarak göstermesi halinde, davalılar arasında ihtiyarî dava arkadaşlığı ilişkisi vardır.

Başka bir örnek: (A) ve (B), birlikte müteselsil alacaklı sıfatı ile (C)'ye (yarı yarıya karşılayarak) on bin lira borç vermişler; (C) de, aldığı borcu vadesinde (A) ve (B)'ye ödemeyi taahhüt etmiştir. (C)'nin borcunu vadesinde ödememesi üzerine (A) ve (B) birlikte, davacı sıfatıyla (C)'ye karşı bir dava açmışlardır. Bu örnekte, (A) ile (B) arasında ihtiyarî dava arkadaşlığı ilişkisi vardır.

Yukarıdaki örneklerin gösterdiği üzere; davacı veya davalı hanesinde gösterilen **müteselsil alacaklı**lar (TBK m. 169) ve **müteselsil borçlu**lar (TBK m. 163) arasındaki ilişki, **ihtiyarî dava arkadaşlığı** ilişkisidir.

3) Davaların Temelini Oluşturan Vakıaların ve Hukukî Sebeplerin Aynı Veya Birbirine Benzer Olması

İhtiyarî dava arkadaşlığının bu üçüncü hali, davaların temelini (sebebini) oluşturan vakıaların ve hukukî sebeplerin, aynı veya birbirine benzer olmasıdır.

(B) ve (C), trafikte önlerinde aniden duran (A)'ya kızarak onu [(A)'yı] birlikte dövmüşler ve kolunu kırmışlardır. (A), bu şekilde uğradığı maddî ve manevî zararın tazmini için, aynı dava dilekçesinde (B) ve (C)'yi davalı olarak göstererek ikisine karşı birlikte dava açabilir. Çünkü, her iki davalı bakımından da dava sebebi olan "dövme vakıası", "aynı"dır.

Gazeteci (A), köşesinde yayınladığı makalede, adını verdiği bir siyasal partinin bütün milletvekillerine, "onların hepsi de hırsızdır" diyerek hakaret etmiştir. Adı geçen partiye mensup 120 milletvekili, tek bir dava dilekçesiyle (A)'yı davalı göstererek her biri için beşer bin lira manevî tazminat talebiyle davası açabilirler. Çünkü, 120 milletvekili için de davanın temelini oluşturan vakıa "aynı"dır.

Kanunda üç bent halinde gösterilen bu sebepler (m. 57), **sınırlı sayı**dadır (numerus clausus). Belirtilen bu sebeplerin dışında ihtiyarî dava arkadaşlığı olmaz. Örneğin:

Değişik zamanlarda ayrı ayrı işverenlerin işyerlerinde çalışan bir işçi, aynı dava dilekçesiyle bu işverenlerin tümünü davalı göstererek, onların işyerlerinde hizmet (iş) sözleşmesiyle çalıştığının tespiti davası açamaz.

Bir borçlunun borcu için, birden fazla üçüncü kişinin mallarının haczedilmesi halinde, malları haczedilen üçüncü kişiler, ihtiyarî dava arkadaşı olarak birlikte (aynı dava dilekçesiyle) istihkak davası (İİK m. 96 vd.) açamazlar.

İş sözleşmesi sona erdirilen birden fazla işçi, aynı dava dilekçesiyle feshin geçersizliği ve işe iade davası açamazlar. Çünkü, her işçinin durumu, iş hukuku bakımından birbirinden farklılık gösterebilir.

Ayrı ayrı şirketlere tescilli aynı marka ve endüstriyel tasarıma tecavüz halinde, hakları haleldar edilen iki ayrı şirket aynı dilekçe ile dava arkadaşı olarak dava açamazlar.

II – İHTİYARÎ DAVA ARKADAŞLIĞINDA USUL

İhtiyarî dava arkadaşlığı oluşturup oluşturmamak, esas itibariyle **davacı tarafın tercihine bağlı** bir hususturu. Davacı tarafı oluşturan birden çok kişi, 57. maddenin gösterdiği hallerde, bir araya gelerek davacı (davacılar) sıfatıyla birlikte dava açmaya karar verebilirler veya yine davacı taraf (tek davacı veya birden çok davacılar), açılacak olan davada, birden çok kişiyi davalı (dava arkadaşı) olarak göstermeyi tercih edebilirler.

Görüldüğü üzere, davacı ve davalı tarafta ihtiyarî dava arkadaşlığı oluşturmaya karar verecek olan taraf, davacıdır ve davacı, bu yola gidip gitmemekte serbesttir. Daha değişik bir ifadeyle, bu husus onun ihtiyarındadır. Çünkü, dava açma ve kimin davacı kimin davalı olarak gösterileceği hakkı davacı tarafa aittir. Davalı, kendi yanında kimlerin dava arkadaşı olarak yer alacağını belirleme durumunda değildir; davalı taraf, olsa olsa, davada ihtiyarî dava arkadaşlığı hükümlerinin (m. 57-58) uygulanamayacağını veya dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen kişilerin taraf ehliyetine yahut davalı sıfatına sahip olmadığını ileri sürebilir.

İhtiyarî dava arkadaşlığında dava, tek bir dava dilekçesi ile açılır ve dava dilekçesinde, davacı veya davalı olarak gösterilen dava arkadaşlarının tamamının adı, soyadı ve adresleri ile diğer bilgiler mutlaka yer alır. Dava arkadaşlarının yalnızca bazılarının adı ve soyadının yazılarak, diğerlerin yazılmaması ve adı soyadı yazılmayan kişilerin örneğin, ("diğer dava arkadaşları" veya "arkadaşları") şeklinde anılması, usule (m. 119, 1/b) aykırı olur (m. 119, 2).

Yetkili mahkemenin, davalının yerleşim yerine göre belirlenmesi hallerinde, dava arkadaşlarından birinin yerleşim yerinde de dava açılabilir (m. 7, 1).

İhtiyarî dava arkadaşlığında dava, her ne kadar (şeklen) tek bir dilekçeyle açılmakta ise de, hukuken, ihtiyarî dava arkadaşlığı oluşturan taraftaki her davalı veya davacı sayısı kadar dava vardır. Yukarıda m. 57'de verilen, "makalesinde kullandığı bir ifadesiyle çok sayıda kişiye birden hakaret eden Gazeteci (A)'ya karşı (onu, davalı; kendilerini, davacı olarak gösteren) 120 kişinin tek bir dava dilekçesiyle açtığı tazminat davası örneğinde, 120 ayrı dava

vardır. Başka bir ifadeyle, ortada şeklen tek dava dilekçesi var gibi gözükmesine rağmen, hukuken birbirinden bağımsız 120 ayrı dava söz konusudur.

İhtiyarî dava arkadaşlığındaki davalar, **birbirinden bağımsızdır** ve dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız hareket edebilir (m. 58). Örneğin, kendi serbest iradelerine bağlı olarak; bazı davacılar davadan feragat edebilir; bazı davalılar davayı kabul edebilir; davada hazır bulunmayabilir, delil sunmayabilir; her bir davacı veya davalı dava arkadaşı (diğer davada arkadaşlarından farklı olarak) iddia veya savunmayı kendisine göre yapabilir; bir kısmı yetki ilk itirazında bulunabilir veya zamanaşımı def'i ileri sürebilir; mahkemenin verdiği hükmü, bazı dava arkadaşları kanun yoluna götürmeyerek, kendileri açısından hükmün kesinleşmesine neden olabilirler vb.

Dava arkadaşlarının farklı usul işlemi veya iddia/savunma yapmaları, kural olarak, yalnızca kendileri bakımından sonuç doğurur, **diğer dava arkadaşlarının durumunu etkilemez**. Buna bağlı olarak örneğin, bir dava arkadaşının yaptığı **yetki ilk itirazı**nın kabulü halinde, mahkeme, yalnızca o kişi bakımından yetkisizlik kararı verir, diğerleri için davaya devam eder. Çünkü, yetki ilk itirazında bulunmayanlar, itiraz etmemekle, yetkisiz mahkemesinin yetkisini kabul etmişler ve Kanun gereği, süresi içinde yetki itirazı yapılmadığı için o mahkeme yetkili hale gelmiştir (m. 19, 4). Benzer şekilde, mahkeme, dava arkadaşlarından birinin yaptığı **zamanaşımı def'i**ni kabul ederse, onun açısından davanın zamanaşımına uğradığını tespitle, davayı onun açısından reddeder; diğer davalı dava arkadaşları, zamanaşımı def'inden yararlanamaz.

Buna karşılık, herhangi bir dava arkadaşının ileri sürdüğü, "borcun doğmadığı", "ödeme nedeniyle sona erdiği" gibi **itiraz sebepleri**nden, bunu ileri sürmeyen diğer dava arkadaşları da yararlanır. Dava şartları mahkemece kendiliğinden dikkate alınacağından, bir dava arkadaşının ileri sürdüğü dava şartı eksikliği iddiası, bütün dava arkadaşları için sonuç doğurur.

Mahkeme, yapacağı yargılama sonucunda her bir dava arkadaşı için ayrı ayrı karar verir; verilen hükümde, her bir dava arkadaşının durumu teker teker değerlendirilerek sonuca varılır.

Mahkemenin verdiği karar, (ortak avukatları bulunmadıkça Teb. K. m. 11) her bir dava arkadaşına ayrı ayrı tebliğe çıkartılır.

Dava arkadaşlarının hep birlikte kanun yollarına başvurmaları şart değildir.

Hal böyle olmakla birlikte, uygulamadan da gözlemlendiği üzere, ihtiyarî dava arkadaşları, genellikle, aynı avukata vekâlet vererek kendilerini temsil ettirmekte olduklarından, yargılama hepsi için genellikle aynı doğrultuda devam etmekte ve hâkim de hepsi için ayrı ayrı da olsa genellikle aynı yönde kararı vermekte ve karar, ortak avukat tarafından kanun yoluna götürülmektedir.

İhtiyarî dava arkadaşlığında, davacı, birden fazla kişiyi davalı gösterip dava açabilmekte ve böylece (davada haklı görülmesi şartına bağlı olarak), birden çok kişiyi aynı anda mahkûm ettirebilmektedir. Davacının, dava dilekçesinde birden çok kişiyi davalı olarak gösterip dava açmasından sonra, yargılama sırasında, dava dilekçesinde göstermeyi unuttuğu diğer kişiyi/kişileri

de davalı olarak gösterebilmesine, uygulamada "**dahili dava**" (teşmil; husumetin yaygınlaştırılması) denilmektedir. Tarafta iradî değişikliğe izin veren **HMK m. 124 hükmü**nün şartlarının gerçekleşmesine bağlı olan istisnaî durum **dışında** ihtiyarî dava arkadaşlığı bakımından, **dahili dava olanağı bulunmamaktadır.**

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü üzere, ihtiyarî dava arkadaşlarının münferit şekilde, ayrı ayrı davalar açmaları yerine tek bir dava dilekçesiyle, ihtiyarî dava arkadaşı olarak dava açmaları (veya benzer şekilde birden fazla kişiye karşı ayrı ayrı davalar açılması yerine tek bir dilekçeyle hepsine karşı ihtiyarî dava arkadaşı olarak dava açılması) usul ekonomisi (m. 33) bakımından büyük kolaylıktır. Bu yolla, birden fazla dava dilekçesi hazırlama yerine tek bir dilekçeyle yetinilmesi, davacı için büyük kolaylıktır. Benzeri kolaylık mahkeme için de vardır. Mahkeme böylece, çok sayıda davayı ayrı ayrı duruşmalar yaparak görmeyip tek bir dava dosyası üzerinden yargılamayı sürdürerek zaman ve emek tasarrufu yapmış olmaktadır.

İhtiyarî dava arkadaşlığının diğer bir yararı; aynı şekildeki davalar bakımından çelişik karar verme riskini ortadan kaldırmasıdır.

C) ZORUNLU (MECBURÎ) DAVA ARKADAŞLIĞI

Bazı durumlarda, açılacak davalar bakımından, birden çok kişinin, davacı sıfatıyla hareket ederek aynı (tek) dava dilekçesiyle birlikte dava açmaları veya davalı olarak birden çok kişinin gösterilerek, bunlara karşı aynı dava dilekçesi ile dava açılması zorunluluğu vardır. Bu gibi durumlarda, bir kişinin yalnız başına açtığı (veya sadece bir kişiye karşı açılan) dava, reddedilir.

HMK'na göre, maddî hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hallerde zorunlu (mecburî) dava arkadaşlığı vardır (m. 59).

Kanun, "maddî hukuk"tan söz etmesine rağmen, usul hukuku bakımından da bazı durumlarda zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

I – ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞININ ÇEŞİTLERİ

Hüküm ve sonuçları açısından zorunlu dava arkadaşlığı; **maddî zorunlu dava arkadaşlığı** ve **şeklî zorunlu dava arkadaşlığı** olarak ikiye ayrılır.

1) Maddî Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Maddî hukuk hükümleri (TMK, TBK, TTK vb.), bazı hakların birden çok kişi tarafından birlikte kullanılması veya birden çok kişiye karşı birlikte ileri sürülmesi zorunluluğu getirmiştir.

Örneğin, **elbirliği mülkiyeti**nde (iştirak halinde mülkiyette) Kanunda veya sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim gerek tasarruf işlemleri için **ortakların** (paydaşların) **oybirliğiyle** karar vermeleri gerekir (TMK m. 702, II). Dava açılması da, bu anlamda bir tasarruf işlemidir. Bu yüzden, elbirliği mülkiyetinin bulunduğu davalarda, kural olarak, bütün ortak-

ların davacı olarak birlikte dava açmaları (veya kendilerine karşı birlikte dava açılması) gerekir. Bu husus özellikle, ortaklık konusunun bölünemez olmasında geçerlidir. Buna karşılık, örneğin terekenin para borçları bakımından mirasçıların müteselsil sorumluluklarının bulunması sebebiyle, tereke alacaklısı, bütün mirasçılara karşı birlikte dava açmak zorunda değildir; istisnaî olarak, mirasçılardan bazılarına karşı dava açabilir.

Benzer şekilde, üzerinde elbirliği mülkiyeti bulunan bir malla ilgili hakların korunması bakımından her bir ortağın dava açma hakkı vardır ve bu korumadan bütün ortaklar yararlanır (TMK m. 702, IV). Bu sebeple, paydaşlardan birinin tek başına müdahalenin önlenmesi davası açabilmesi mümkündür; ancak, bu davanın sürdürülebilmesi için, diğer ortakların izninin (icazetinin) alınması (veya terekeye bir temsilci atanmasının sağlaması) gerekir[2].

Kanunda açıkça yer almamasına rağmen, bir taşınmazda birden fazla kiracı varsa, (örneğin, ihtiyaç sebebiyle) **tahliye davası**nın, kiracılardan birinin veya birkaçının aleyhine açılamayacağı, bütün kiracılara karşı açılması gerektiği kabul edilmektedir. Çünkü, (dava sonunda) taşınmazı bir veya birkaç kiracının tahliye etmesi, istenilen amacı sağlayamaz. Bu yüzden, tahliye davalarında, zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

Buna karşılık, kira bedelinin tahsili davasının bütün kiracılara karşı açılması zorunluluğu yoktur; zira, kira borcu bölünebilen bir borçtur. Kira bedelinin tahsili davasında davalılar arasındaki ilişki, ihtiyarî dava arkadaşlığı ilişkisidir.

Mirasçıların açacağı kamulaştırmasız el atma nedeniyle taşınmaz bedelinin tahsili davasında mirasçılar arasındaki ilişki, zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisidir.

Murisin nüfus kaydının düzeltilmesi ile ilgili davada, mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisi vardır.

Aşağıda (II) belirtileceği üzere, maddî zorunlu dava arkadaşlığında mahkeme, bütün dava arkadaşları hakkında **aynı yönde hüküm vermek zorundadır.**

2) Şeklî Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Maddî hukuk bakımından bir zorunluluk olmamasına karşılık, gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve taraflar arasındaki hukukî ilişkinin doğru bir şekilde karara bağlanmasını gerekli gördüğü bazı durumlarda da dava arkadaşlığı zorunludur. Maddî hukuktan kaynaklanmayan ve ancak kanunlardaki hüküm-

---

[2] "İştirak halinde mülkiyette paylaştırmadan önce ortağın belli bir pay üzerinde aynî bir hakkı bulunmamaktadır. Ortakların hepsi birlikte maliktirler. Bu itibarla iştirak halinde mülkiyet durumunda olan bir taşınmaza üçüncü bir kişi tarafından elatılması halinde bir ortağın MK'nun 618. maddesine dayanarak **dava açması mümkün ise de bunu sürdürebilmesi, diğer ortakların muvafakatını almak** veya **terekeye bir mümessil atanmasını sağlaması ile mümkün olacaktır.** Öte yandan, ortada bir hakkın kaybı da söz konusu değildir. Zira, mirastan doğan ve iştirak halinde mülkiyet durumunda olan bir taşınmaza elatılması halinde zilyet olan ortaklardan her birinin zilyetliğin korunmasına ilişkin MK'nun 894, 895 ve 896. (şimdi: TMK'nun 981, 982 ve 983.) maddelerinden yararlanmaları mümkündür" (11.10.1982 gün ve 03/02 sayılı İBK gerekçesi).

ler nedeniyle zorunlu olan bu dava arkadaşlığına, **şeklî zorunlu dava arkadaşlığı** denir. Örneğin:

Aslî müdahalede davacı üçüncü kişi, davasını, asıl davanın davacısı ve davalısını hasım (davalı) göstererek açar (m. 65); asıl davanın yalnızca davacısına veya yalnızca davalısına karşı dava açılamaz. Açılırsa ve sonra düzeltilmezse, bu dava, aslî müdahale davası olarak nitelenemez. Aslî müdahale davasında davalı tarafta bulunanlar arasındaki ilişki, şeklî zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisidir.

İşe iade davalarında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda, davalı taraf yönünden şeklî (usulî) bakımdan zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

Hacizdeki **tasarrufun iptali davası**nda davalı; borçlu ve borçlu ile işlem yapan yahut borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kişiler ile bunların mirasçılarıdır (İİK m. 282). Davalılar arasındaki ilişki, şeklî zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisidir.

Kanun (İİK m. 282), tasarrufun iptal davasındaki şeklî zorunlu dava arkadaşlığını, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki ilişki bakımından kabul etmiştir. Buna karşılık, **üçüncü kişi ile** ondan sonraki **dördüncü ve beşinci kişiler arasındaki ilişki**, zorunlu dava arkadaşlığı değil, **ihtiyarî dava arkadaşlığıdır**.

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanımı davası, Hazine ile ilgili kamu tüzel kişilerine (veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına) karşı açılır (TMK m. 713, III). Davalılar arasındaki ilişki, şeklî zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisidir.

Orman olarak Hazine adına tescil edilen taşınmazın tapusunun iptali davasında, Hazine ile Orman İdaresi arasındaki ilişki, zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisidir.

Soybağının reddi davası, baba (koca) tarafından, ana ve çocuğa karşı açılır (TMK m. 286, I). Soybağının reddi davasını çocuk açarsa bu dava ana ve babaya karşı açılır (TMK m. 286, II). Her iki durumda da davalılar arasındaki ilişki, şeklî zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisidir.

Aşağıda (II) belirtileceği üzere, şeklî zorunlu dava arkadaşlığında **mahkeme**, bütün dava arkadaşları hakkında (aynı yönde hüküm vermek zorunda değildir) ayrı ayrı karar verebilir.

II – ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞINDA USUL

Zorunlu dava arkadaşlarının birlikte dava açma (**aktif dava arkadaşlığı**); zorunlu dava arkadaşlarına birlikte dava açılma (**pasif dava arkadaşlığı**) zorunluluğu vardır (m. 60, 1/c. 1).

Zorunlu dava arkadaşlığında, dava arkadaşlarının tamamının davacı veya davalı tarafta mutlaka gösterilmesi gerekir (m. 60, 1/c. 1). Aksi takdirde taraf eksikliği sebebiyle davanın reddi söz konusu olur. Ancak, böyle bir durumda eksikliğin giderilmesi için, mahkemece davacıya, diğer dava arkadaşlarının da davaya dahil edilmesi için uygun bir süre verilmesi gerekir. Verilen süre içinde eksiklik giderilirse davaya devam olunur; aksi takdirde, taraf (eh-

liyeti eksikliği) sebebiyle dava reddedilir. Yukarıda, ihtiyarî dava arkadaşlığında dahili dava müessesinin bulunmadığı belirtilmişti. Buna karşılık, **zorunlu dava arkadaşlığında dahili dava mümkündür.**

Murislerinden kalan taşınmazın iki haklı ihtar sebebiyle tahliyesi davasında mirasçılar arasındaki ilişki zorunlu dava arkadaşlığı ilişkisi olmakla birlikte dava arkadaşlığı eksikliği halinde bu eksiklik dava sırasında tamamlanabilir. Ancak bir mirasçının çektiği ihtarnamedeki eksikliğin sonradan tamamlanabilmesi mümkün değildir.

Kanun (m. 60, 1/c. 2), zorunlu dava arkadaşlığında, dava arkadaşlarının **birlikte hareket etmelerinin zorunlu olduğu**nu belirtmektedir.

Hükümde yer alan bu ifadeden hareket edildiğinde, her türlü (yani, maddî zorunlu ve şeklî zorunlu) dava arkadaşlığında, kuralın geçerli olduğu düşünülebilir. Ancak, hükmün gerekçesinde, 60. maddenin yalnızca "maddî mecburî dava arkadaşlığı" bakımından geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, yukarıda (m. 59) belirtildiği üzere, HMK m. 59 da maddî zorunlu dava arkadaşlığını düzenlemektedir. Dolayısıyla, m. 60 hükmündeki birlikte hareket etme zorunluluğu şeklî zorunlu dava arkadaşlığı için uygulanmaz.

Bu nedenle, zorunlu dava arkadaşları arasındaki ilişki bakımından konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir:

1) Maddî Zorunlu Dava Arkadaşları Birlikte Hareket Etmek Zorundadır

Maddî zorunlu dava arkadaşlığının, özellikle elbirliği ortaklığı veya bölünemeyen hak veya borç üzerinde birden fazla kişinin tasarrufta bulunması bakımından ortaya çıktığı dikkate alındığında, dava arkadaşlarının, yargılama işlemleri bakımından da kural olarak, hep birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Dava arkadaşlarından bazılarının yaptığı işlemler, diğeri (veya diğerleri) katılmadığı takdirde, geçersizdir.

Bu sebeple, maddî zorunlu dava arkadaşları iddia ve savunmalarını hep birlikte (aynı yönde) yaparlar. Örneğin, bütün dava arkadaşlarının hepsi beraber yetki ilk itirazında bulunur, zamanaşımı def'i ileri sürer; hep birlikte davayı kabul edebilirler veya davadan feragat edebilirler; kanun yoluna hep birlikte gidebilirler vs.

Ana kural bu olmakla birlikte, maddî zorunlu dava arkadaşlarından bir ya da bir kaçının kötüniyetli olarak veya hukuken geçerli olmayan (kabul edilemeyen) başka sebeplerle **diğer dava arkadaşlarıyla birlikte hareket etmemeleri**, örneğin duruşmalara gelmemeleri veya yapılacak usulî işlemlere yanaşmamaları halinde, diğer dava arkadaşları bundan zarar gördükleri gibi, bu tür tutum ve davranışlar davaların gecikmesine de sebep olabilmektedir. Bu durum gözönüne alınarak, m. 60, 1/c.3'te, **duruşmaya gelmiş** olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usul işlemlerinin, usulüne uygun olarak davet edildikleri halde **duruşmaya gelmemiş** olan dava arkadaşları bakımından da hüküm ifade edeceği açıkça belirtilmiştir. Maddedeki, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usul işlemlerini, hem tarafın

duruşmaya gelmemesi, hem de duruşma dışında süreye tâbi işlemlerde hareketsiz kalınması durumunda yapılan işlemler olarak anlamak uygun olur.

Maddî zorunlu dava arkadaşlığında mahkeme, **bütün dava arkadaşları bakımından aynı yönde** karar verir. Mahkemenin bazı arkadaşlar bakımından farklı karar verebilmesi (örneğin, bir kısmı için davayı kabul edip diğerleri yönünden reddetmesi), kural olarak, mümkün değildir.

2) Şeklî Zorunlu Dava Arkadaşları Birlikte Hareket Etmek Zorunda Değildir

Yukarıda belirtildiği üzere, şeklî zorunlu dava arkadaşlığında maddî hukuk bakımından bir gereklilik yoktur (m. 59); ancak kanunlar, gerçeğin ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki hukukî ilişkinin doğru bir şekilde karara bağlanması amacıyla dava arkadaşlığını şeklen zorunlu görmüştür. Bu sebeple, şeklî zorunlu dava arkadaşlığında mahkeme, **bütün dava arkadaşları bakımından aynı yönde karar vermek zorunda değildir**; dava arkadaşları arasında farklı sonuca varabilir ve davayı birinin lehine, diğerinin aleyhine sona erdirebilir.

Örneğin, (A)'nın (B)'ye karşı açtığı malın kendisine verilmesi (istirdat veya istihkak) davası üzerine; malın (A)'ya veya (B)'ye ait olmayıp kendine ait olduğu iddiasıyla, (C)'nin (A) ve (B)'yi birlikte şeklî zorunlu dava arkadaşı - davalı- göstererek) açtığı aslî müdahale davasının sonunda mahkeme, yaptığı yargılamaya göre, malın mülkiyetinin (A)'ya ait olduğu sonucuna varırsa, aslî müdahale davasını, (C)'nin ve (şeklî zorunlu dava arkadaşlarından) (B)'nin aleyhine karara bağlar.

Şeklî zorunlu dava arkadaşlığında, arkadaşların her birinin kişisel menfaatleri ön planda olduğundan birlikte hareket etmek zorunda değildirler. Her biri iddia ve savunmasında tek başına hareket edebilir. Bu açıdan şeklî zorunlu dava arkadaşlarının durumu, ihtiyarî dava arkadaşlarının durumu (m. 58) gibidir.

§ 48. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI

A) GENEL OLARAK

Yukarıda, medenî yargılamaya egemen ilkeleri[1] incelerken de görüldüğü üzere, yargılamada **tasarruf ilkesi** egemendir ve mahkeme, iki taraftan birinin talebi olmaksızın bir davayı kendiliğinden inceleyemez (m. 24). Davacının dava açmasıyla başlayan yargılama, normal olarak, çeşitli taraf ve mahkeme usul işlemleri ile devam eder ve hükmün kesinleşmesiyle sona erer. Mahkeme, önüne gelen davayı görmek ve davayı usul veya esas hakkında hükümle sona erdirmek zorundadır. Mahkemenin, kural olarak, yargılamada işlem yapmaması ve bu sebeple davayı durdurması mümkün değildir. Aksine davranış, hakkın (adaletin) yerine getirilmesinden kaçınma (ihkakı haktan istinkaf) anlamına gelir ve hâkimin sorumluluğunu gerektirir (m. 46, 1/e).

Ancak, aşağıda göreceğimiz bazı durumlarda, **dava dosyasının işlemden kaldırılması**na karar verilir (m. 150). Bunun sonucunda mahkeme, dava (yargılama) ile ilgili işlemleri durdurur ve dava dosyası taraflarca yenilenmedikçe, dosyada yargılama ile ilgili işlem yapılmaz.

B) DAVA DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINI GEREKTİREN HALLER

Davada duruşma yapılması, hukukî dinlenilme hakkının (m. 27) doğal bir sonucudur. Mahkeme, kanunun açıkça gösterdiği istisnaî haller dışında duruşma yapmadan (dosya -evrak- üzerinden) karar veremez. Yukarıda, görüldüğü üzere, **davanın tarafları**, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra, tahkikat için, mahkeme tarafından, **duruşmaya davet edilir**.

Duruşma tayini mahkemeye ait bir görevdir ve mahkeme duruşma gününü kendiliğinden belirler; duruşma gününün belirlenmesi için, kural olarak, **tarafların talebi gerekmez**. Yukarıda, tahkikat (m. 143 vd.) konusunu incelerken görüldüğü üzere, yargılama, duruşmalar yapılarak sürdürülür. Mahkeme, ilk duruşma günü dahil olmak üzere, yargılama sırasında daha sonraki duruşma günlerini de, her bir duruşmanın sonunda kendiliğinden belirler.

Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir (m. 147, 2).

Bu şekilde davet edilmelerine rağmen, **taraflardan ikisi de duruşmaya gelmezse** veya ikisi de duruşmaya gelmelerine rağmen, ikisi de davayı takip etmeyeceklerini bildirirlerse, dava dosyası (dava yenileninceye kadar) işlemden kaldırılır (m. 150, 1).

---

[1] Bkz. yuk. § 5, B.

Duruşmaya gelmeyen taraflardan biri veya her ikisi, mahkemeye bir **mazeret** (özür) **dilekçesi** göndermiş ise bakılır: Mahkeme, özrü yerine görerek kabulüne karar verirse, mahkeme, yeni bir duruşma günü belirleyerek tarafların bu duruşmaya davet edilmelerine karar verir; yani, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar veremez. Mahkeme duruşmaya gelmeyen tarafların özrünü kabul etmezse, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150, 2).

Usulüne uygun biçimde çağrılmış (davet edilmiş) olan **taraflardan yalnız biri duruşmaya** gelir, diğer taraf geçerli bir mazereti olmaksızın **gelmezse**, duruşmaya gelmiş olan taraf, davaya devam edilmesini isterse, mahkeme, gelmeyen tarafın yokluğunda yargılamaya devam eder. Bu durumda dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilemez. Buna karşılık, gelen taraf da, davayı takip etmeyeceğini açıkça bildirirse (veya açıkça dosyanın işlemden kaldırılmasını isterse), mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150, 2).

Duruşmaya gelen taraf, davayı takip etmeyeceğini açıkça bildirmemekle beraber, tahkikata gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilmesini de (açıkça) istemezse, mahkemenin m. 31 hükmü çerçevesinde açıklama yapılmasını istemesi ve ona göre karar vermesi gerekir.

Yukarıda görülen haller, tarafların mahkemece belirlenen duruşmalara gelmemeleri ile ilgilidir. Bunun dışında, bazı hallerde duruşma gününün tayini, **tarafların başvurmasına bağlıdır**. Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde, **taraflardan biri mahkemeye başvurarak gün tespit ettirmemişse**, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır (m. 150, 3). Örnekler:

Üst mahkemenin yargı yerini belirten kararının (m. 22-23) mahkemeye gelmesinden itibaren bir ay içinde taraflardan hiçbiri yargı yeri olarak belirlenen mahkemeden duruşma günü belirlenmesini istemezse, dosyanın işlemden kaldırılması gerekir (m. 150, 3).

Davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin, davaya bakmasına herhangi bir engel çıkması halinde, bu engelin çıktığı tarihten itibaren bir ay içinde yargı yerinin belirlenmesi istenmezse, dosya işlemden kaldırılmalıdır (m. 150, 3).

Dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin bu sonuç, tasarruf ilkesinin gereğidir. Mahkeme, önüne gelen davada iki tarafın da davayı takip etmeyeceklerini anlaması üzerine, elindeki davanın dosyasını işlemden kaldırmakta ve aşağıda görüleceği üzere, üç ay sonra da, davanın açılmamış sayılmasına karar vermektedir (m. 150, 5)[2].

---

[2] HMK m. 150, 2, 4, 5 - 6 hükümlerinin Anayasaya aykırılığı ileri sürülmüşse de, Anayasa Mahkemesi, bu iddiayı reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, hukuk davalarında, tarafları ve özellikle davacıyı, davasını takip etmede özenli davranmaya zorlamak ve tarafların davalarını takibe niyetli olmadığı durumlarda yargılamanın sürüncemede kalmasını ve gereksiz uzamasını engellemek amacıyla bu tür bir kurumun kabul edildiği, bunun da usul ekonomisine hizmet ettiğini ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesinin 10.02.2016 gün ve 96/09 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 150-151.

C) DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI ve SONUÇLARI

Yukarıda görüldüğü ve m. 150'de açıkça belirtildiği gibi, dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren hallerden birinin varlığını (gerçekleştiğini) tespit eden mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir (m. 150).

Mahkeme bu konuda bir karar vermemiş olsa bile, dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren yukarıdaki hallerden birinin gerçekleştiği anda, **dosya işlemden kaldırılmış sayılır**. Örneğin, iki tarafın da gelmediği veya taraflardan birinin gelip de davayı takip etmeyeceğini bildirdiği duruşma tarihi, dosyanın işlemden kaldırılmış olduğu tarihtir. Mahkemenin dosyanın işlemden kaldırılmasına daha sonra karar vermiş veya işlemden kaldırma kararını daha sonra yazmış olması halinde, karar tarihi, dosyanın işlemden kaldırılması tarihi olarak kabul edilemez.

Örneğin, iki taraf da, 02 Aralık 2019'daki duruşmaya (mazeretsiz olarak) gelmemişse, mahkeme 02 Aralık 2019 tarihindeki duruşmada dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir; mahkeme, dosyasının işlemden kaldırılması kararını, herhangi bir nedenle (sözgelimi, unutma sebebiyle) 02 Aralık 2019'da değil de, başka bir tarihte vermiş olsa dahi, mahkeme dosyanın işlemden kaldırılması kararını 02 Aralık 2019 tarihi itibariyle verir (02 Aralık 2019 tarihinde verilmiş sayılır). İşte bu örnekte olduğu üzere, üç ay içinde yenilenmemesi halinde davanın, 02 Mart 2020 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına karar verilir. Yani, davanın açılmamış sayılması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar da bu tarihten (02 Mart 2020'den) itibaren başlar.

Dosyanın işlemden kaldırılması (kararı) ile dava açılmamış sayılmaz. Dava, üç aylık süre (m. 150, 4) için durur ve dava açılması ile meydana gelen sonuçlar devam eder. Buna göre:

Dosyanın işlemden kaldırılması kararı ile dava açılmamış sayılmadığından, dava (dosyanın işlemden kaldırılmasından itibaren) **üç ay süre ile derdest kalmakta devam eder**. Dosyanın işlemden kaldırılması tarihinden itibaren bir ay geçmiş olsa bile, dava (m. 150, 4'teki üç ay içinde), iki ay daha derdest kalmaya devam eder.

İşlemden kaldırılmış olan dava, derdest kalmakta devam ettiğinden, davacı **aynı davayı yeniden açarsa**, davalı derdestlik dava şartı (m. 114, 1/ı) noksanlığını her zaman ileri sürebilir; ayrıca mahkeme de kendiliğinden, bu noksanlığı tespit edebilir. Bu durumda, mahkeme (yeni) davayı **dava şartı yokluğundan** usulden **reddeder** (m. 115).

İşlemden kaldırılmış olan dava derdest kalmakta devam ettiğinden, dava açılması ile meydana gelmiş olan zamanaşımı kesilmesi, dosyanın işlemden kaldırılması kararına rağmen devam eder. Daha doğrusu, dosyanın işlemden kaldırılması (kararı) ile de **zamanaşımı kesilir**.

İşlemden kaldırılmış olan dava, üç ay süre ile, derdest kaldığından ve bu nedenle dava açılması ile meydana gelen sonuçlar devam ettiğinden, dava açılması ile meydana gelmiş olan hak düşürücü sürenin korunmuş olması sonucu da devam eder. Zamanaşımının aksine, hak düşürücü sürelerin kesilmesi söz konusu olmadığından, **davacının**, davasını dosyanın işlemden

kaldırılması tarihinden itibaren, **davanın tâbi bulunduğu hak düşürücü süre içinde yenilemesi** (m. 150, 4-5) **şart değildir**. Davacı (veya davalı), dosyanın işlemden kaldırılmasından itibaren ancak üç ay içinde yenileme talebinde bulunabilir (m. 150, 4).

D) DAVANIN YENİLENMESİ

Taraflardan biri, dosyası işlemden kaldırılmış olan davayı, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak **üç ay içinde yenileyebilir** (m. 150, 4); bu konudaki talebe, **yenileme talebi** denir. Yenileme talebi ile, dosyası işlemden kaldırılmasına rağmen derdest kalmakta devam eden davanın, mahkemece yeniden ele alınarak incelenip sonuçlandırılması (hükme bağlanması) istenir.

Üç aylık süre içinde yenilenmeyen davalar, **sürenin dolduğu gün itibariyle** açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır (m. 150, 5). Başka bir deyişle, üç aylık yenileme talebi süresi, **hak düşürücü** niteliktedir. Bu nedenle, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay geçtikten sonra yenilenen (ve fakat, hâkimin iş çokluğu nedeniyle açılmamış sayılması hakkında henüz bir karar vermediği) bir dava da açılmamış sayılır; yani, üç ay geçtikten sonra yapılan yenileme talebi geçersizdir.

Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren **bir ay içinde** yenileme talebinde bulunan taraftan hiç bir **harç alınmaz**. Buna karşılık, dava, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak **bir ay geçtikten sonra** yenilenirse, yeniden **harç alınır** (m. 150, 4; Harçlar K. m. 7).Yenileme talebinde bulunanın ödeyeceği bu harç, dava açılırken ödenmiş olan karar ve ilâm harcının peşin ödenen bölümü (dörtte biri) ile başvurma harcıdır. Bu harç, (bir ay geçtikten sonra) yenileme talebinde bulunan davacı veya davalı tarafından ödenir ve **karşı tarafa yükletilemez** (m. 150, 4). Buna göre, yenileme talebinde bulunan davalı ise, harç davalı tarafından ödenir ve (davacı sonradan davayı kaybetse bile) davacıya yükletilemez.

Bu şekilde harç ödenerek yenilenen dava, **yeni bir dava sayılmaz**; eski (işlemden kaldırılmış olan) davanın devamıdır. Bu nedenle, dava bu yeni harcın ödendiği tarihte değil, ilk defa harç ödendiği (ve davanın açıldığı) tarihte açılmış sayılır

Yenileme talebinde bulunan tarafın verdiği yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir (m. 150, 4). Dosyanın işlemden kaldırılmasından önce, duruşmaya gelmediği için tahkikat ve yargılama yokluğunda devam etmekte olan taraf da, yenileme talebinden sonraki duruşmaya çağrılır (m. 150, 4). Taraf, çağrıldığı bu duruşmaya da gelmezse, yargılamaya yokluğunda devam olunur (m. 147, 2).

Bu şekilde yenilenmiş olan davanın görülmesi sırasında dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, dosyanın yeniden işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Yenilenen dava (yeniden harç ödenerek yenilenmiş olsa bile), yeni bir dava olmayıp, eski davanın devamı olduğu için (m. 150), taraflar, dosyanın işlemden kaldırılmasından önceki dönemde yapamadıkları bir işlemi, davanın yenilenmesinden sonra da yapamazlar. Örneğin, daha önce tanık listesi

vermiş olan taraf, davanın yenilenmesinden sonra da aynı vakıa hakkında ikinci bir tanık listesi veremez (m. 240, 2). Keza, dosyanın işlemden kaldırılmasından önce başlamış olan davayı değiştirme yasağı ve savunmayı genişletme yasağı aynen devam eder. Yani, bir taraf karşı tarafın açık izni olmadıkça (veya ıslah yoluna başvurmadıkça) davasını değiştiremez veya savunmasını genişletemez (karş. m. 107).

Davanın açılması ile hak düşürücü süre korunduğundan ve yenilenen dava eski (işlemden kaldırılmış olan) davanın devamı olduğundan, dosyanın işlemden kaldırılması tarihi ile davanın yenilenmesi tarihi arasında davanın tâbi bulunduğu hak düşürücü süre geçmiş ise, davalı hak düşürücü sürenin geçirildiğini ileri süremeyeceği gibi, mahkeme de hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması nedeniyle davanın reddine karar veremez.

E) DOSYANIN YENİDEN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Yenilenmiş olan dava dosyasının yeniden işlemden kaldırılması mümkündür. Yani, yenileme talebi üzerine davaya yeniden bakıldığı sırada, dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren hallerden (m. 150, 2-3) birinin gerçekleşmesi halinde, dava dosyasının **yeniden işlemden kaldırılmasına karar** verilir.

Bu şekilde yeniden işlemden kaldırılan dava, bu yeni işlemden kaldırma kararından itibaren üç ay içinde (m. 150, 4) **tekrar yenilenebilir** (m. 150, 6). Dosyanın işlemden kaldırılması ve yenilenmesi, **bir defa daha tekrarlanabilir** (m. 150, 6; karş. m. 320, 4). Yani, ilk defa işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, (bu) ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz (işlemden kaldırılamaz), aksi halde dava açılmamış sayılır (m. 150, 6). Bu hükmün aşağıdaki gibi anlaşılması ve uygulanması gerekir:

Hükümde, "ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz" denildiği için, bir dava **iki defa takipsiz bırakılabilir** (işlemden kaldırılabilir) ve **iki defa yenilenebilir**. Buna göre, bir davanın (birinci dahil) iki defa (veya birinci hariç bir defa) takipsiz bırakılması halinde mahkeme, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir (davanın açılmamış sayılmasına karar veremez). Böyle bir dava, ikinci (ve son defa) yenilenebilir. Ancak, ikinci yenilemeden sonra davanın tekrar **(üçüncü defa) takipsiz bırakılması halinde,** (dosyanın işlemden kaldırılmasına değil) **davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.**

Buna göre örneğin, 01.03.2019 tarihli duruşmaya her iki taraf da gelmemiş (veya biri gelip diğeri gelmediği ve gelen taraf da davaya devam etmeyeceğini bildirdiği için) hâkim, dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar vermiştir (m. 150, 1) (**1. işlemden kaldırma**). Taraflardan biri 15.03.2019 tarihinde yenileme talebinde bulunmuş (m. 150, 4) ve yeni bir duruşma günü tayin edilmiştir (**1. yenileme**). Taraflar bu yeni duruşma gününe gelmişler ve dava yeniden yürümeye başlamıştır. Daha sonra, tarafların her ikisi de 01.07.2019 tarihli duruşmaya gelmemiş (veya biri gelip diğeri gelmediği ve gelen taraf da davaya devam etmeyeceğini bildirdiği için) hâkim dava dosya-

sının tekrar işlemden kaldırılmasına karar vermiştir (m. 150, 1) (**2. işlemden kaldırma**). Böylece, dava dosyası hakkında ikinci kez işlemden kaldırılması kararı verilmiştir. Bundan sonra taraflardan biri (m. 150, 4 hükmü uyarınca üç ay içinde) 16.09.2019 tarihinde yenileme talebinde bulunmuş ve yeni bir duruşma günü tayin edilmiştir (**2. yenileme**). Taraflar bu yeni duruşma gününe gelmişler ve dava yeniden yürümeye başlamıştır. Tarafların her ikisi de 02.03.2020 tarihli duruşmaya gelmemiştir (veya biri gelip diğeri gelmediği ve gelen taraf da davaya devam etmeyeceğini bildirmiştir). Bu durumda dosyanın işlemden kaldırılması kararı değil, **davanın açılmamış sayılmasına** karar verilerek kayıt kapatılır (m. 150, 6). Zira, **somut olayda dava iki defa takipsiz bırakılmış ve iki defa yenilenmiştir**. Buna göre, bir davanın (birinci dahil) iki defa (veya birinci hariç bir defa) takipsiz bırakılması halinde mahkeme dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Davanın ikinci yenilemeden sonra, tekrar (**üçüncü kez**) **takipsiz bırakılması** halinde ise, dosyasının işlemden kaldırılmasına değil **davanın açılmamış sayılmasına karar verilir** (m. 150, 6; karş. m. 320, 4).

Belirtelim ki, bu iki yenileme talebinin de, dosyanın ilk olarak işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılması şart değildir. HMK m. 150, 5'teki üç aylık süre, dosyanın her (en çok iki defa) işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

F) İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ve SONUÇLARI[3]

Yukarıda incelendiği gibi mahkeme, iki halde, işlemden kaldırılmış olan davanın açılmamış sayılmasına karar verir:

Dosyası işlemden kaldırılan bir dava, işlemden kaldırılma tarihinden itibaren **üç ay içinde yenilenmezse** veya ikinci yenilemeden sonra davanın **üçüncü defa takipsiz bırakılırsa**, mahkeme, kendiliğinden **davanın açılmamış sayılmasına karar vererek** dosya kaydını kapatır (m. 150, 5-6).

Mahkemenin, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gereken tarihte (üç aylık yenileme süresinin bittiği veya dosyanın üçüncü defa takipsiz bırakıldığı tarihte) böyle bir karar vermeyi ihmal etmiş olması, taraflara bu tarihten sonra davayı yenileme hakkı vermez. Çünkü dava, üç aylık yenileme süresinin bittiği veya dosyanın üçüncü defa takipsiz bırakıldığı tarihte kanundan dolayı açılmamış sayılmıştır. Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına üç aylık süre geçtikten çok sonra karar verebilirse de bu karar, davanın üç aylık yenileme süresinin bittiği veya dosyanın üçüncü defa takipsiz bırakıldığı tarihte açılmamış sayıldığını tespit edici nitelikte bir karardır.

Bu iki halde, mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi gerekir; mahkeme, **davanın reddine karar veremez**.

Üç ay içinde yenilenmeyen (m. 150, 5) veya üçüncü defa takipsiz bırakılan bir dava, terk edilmiş bir dava olduğundan, mahkemenin, davanın açıl-

---

[3] Bkz. Emel Şeyda Elgün, Medenî Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları, Ankara 2011.

mamış sayılması kararında, davacıyı, davalı lehine yargılama giderlerine (bu arada, vekâlet ücretine) mahkûm etmesi gerekir (m. 331, 3; AK Ücret Tarifesi m. 7, I-II).

Mahkeme davanın açılmamış sayılması kararı ile davadan elini çektiğinden davanın açılmamış sayılması kararı, usule ilişkin bir **nihaî karar**dır; bu nedenle kanun yoluna götürülebilir.

Davanın açılmamış sayılması ile, davacı, davasından **feragat etmiş** (m. 307) **olmaz**; sadece davasını **takipten vazgeçmiş** (m. 123) ve terk etmiş (m. 331) **sayılır**. Bu nedenle, davacı, açılmamış sayılan davasını, yeniden harç ödemek suretiyle tekrar açabilir.

Davanın açılmamış sayılması (kararı) ile, **dava açılması ile meydana gelmiş olan sonuçlar ortadan kalkar**. Yani, yeniden harç verilerek yeni dava açılsa bile, eski (açılmamış sayılan) davanın açılması ile meydana gelmiş olan sonuçlar devam etmez.

Davanın açılmamış sayılması hangi sebepten olursa olsun, **açılmamış sayılan davadaki talep de yapılmamış sayılır** (m. 150, 7). Bu hükümle, açılmamış sayılan davada verilen dava dilekçesindeki talebin, sonradan açılacak davalar bakımından önleyici veya sonuç doğurucu etki yaratmaması hedeflenmektedir.

DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

Davanın (yargılamanın) normal seyrinin, mahkemenin vereceği nihaî kararla (hükümle) sona ereceğini yukarıda gördük[1]. Bunun yanı sıra, davanın; görevsizlik (veya yetkisizlik kararı) verilmesi üzerine, süresinde görevli (veya yetkili) mahkemeye gönderilmesinin talep edilmemesi (m. 20) veya davalının izni ile davacı tarafından geri alınması (m. 123) yahut iki tarafın da duruşmaya gelmemesi gibi bazı hallerin gerçekleşmesi sonucunda dava dosyasının işlemden kaldırılan davanın yenilenmemesi sonucunda da dava sona ermektedir.

Davanın sona erme halleri bunlardan ibaret değildir. Kanunumuzun **"davaya son veren taraf işlemleri"** başlığını taşıyan 307-319. maddelerinde, birbirine benzeyen üç kurum düzenlenmiştir. Bunlar; davadan feragat, davayı kabul ve sulhtür.

Aşağıda görüleceği üzere; **davadan feragat**te, davacı, davasından (davasının talep sonucundan) bir daha hak talep etmemek (dava açmamak, icra iflâs takibi yapmamak vb.) üzere kısmen veya tamamen vazgeçmektedir. **Davayı kabul**de davalı, davacının davasını, kısmen veya tamamen kabul etmektedir.

Sulh ise, iki tarafın aralarında diledikleri şartlarla anlaşıp uzlaşarak mevcut davayı sona erdirmeleridir.

Tarafların bu şekilde davaya son verebilmeleri, çekişmeli yargıda geçerli olan **"tasarruf ilkesi"**nin (m. 24) bir sonucudur. Davanın başlamasının, taraf usul işlemi olan bir dava dilekçesiyle olması gibi, davanın taraf usul işlemiyle de son bulması doğal olarak kabul edilmelidir.

Kamu düzeni ile ilgili bazı istisnaî durumlar hariç, her davadan feragat edilebilir, her dava kabul edilebilir ve her davada sulh yapılabilir ve bunların sonucunda mahkemenin görmekte olduğu dava (yargılama) sona erer.

Davadan feragat ve davayı kabul **tek taraflı usul işlemi**dir; bu nedenle karşı tarafın izni ve mahkemenin onayına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder. Sulh ise, bir sözleşmedir, iki taraflıdır ve yapılabilmesi için her iki tarafın iradesinin birbiri ile uyuşmasını gerektirir. Sulh de mahkemenin onayına bağlı olmayan bir işlem olarak hukukî sonuç doğurur.

Davadan feragat, davayı kabul ve sulhün önemi, bu işlemlerin sonucu, mahkemenin verdiği nihaî karara benzer sonuçlar doğurmasıdır. Bu yüzden, davadan feragat, davayı kabul ve mahkeme önünde yapılan sulh, ilâm niteliğinde belgelerden sayılır (İİK m. 38).

---

[1] Bkz. yuk. § 36-37.

§ 49. DAVADAN FERAGAT[1]

A) GENEL OLARAK

Davadan feragat, davacının, **talep sonucundan** (m. 119, 1/ğ) kısmen veya tamamen **vazgeçmesidir** (m. 307). Davadan feragat eden davacı, bununla dava dilekçesinin talep sonucu bölümünde istemiş olduğu haktan talepten (haktan)) tamamen veya kısmen vazgeçer.

Hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi (m. 24, 2), davacı da, açmış olduğu bir davayı sonuna kadar takip etmeye zorlanamaz. Bunun doğal bir sonucu olarak, davacı, feragat etmek suretiyle açmış olduğu davayı sona erdirebilir (m. 24, 3).

Davayı feragat ile **davayı geri alma** (davayı takipten vazgeçme; davayı âtiye bırakma) (m. 123) müessesesini birbiri ile karıştırmamak gerekir. Davayı geri almada, davacı, karşı tarafın açık onayı ile davasını **şimdilik takipten vazgeçmekte** (geri almakta) ve aynı **davasını** (talebini) **ileride yeniden açma hakkını saklı tutmaktadır**. Oysa davadan feragatte davacı, davasında talep ettiği haktan (hakkın özünden), ileride hiçbir şekilde talep etmemek üzere tamamen vazgeçmektedir.

Davadan feragat ile kanun yolundan (m. 349; 366) feragat de, birbirinden farklı hususlardır. Kanun yolundan feragatta, davadan değil, yalnızca kanun yolu hakkının kullanılmasından vazgeçilirken, davadan feragat daha geniştir ve dava hakkından vazgeçilmektedir.

B) DAVADAN FERAGAT USULÜ ve DAVADAN FERAGATIN SONUÇLARI

Davadan feragat, davacının mahkemeye karşı yapacağı **tek taraflı** ve açık bir **irade beyanı** ile olur. Feragatın geçerliliği için, bunun davalı ve mahkeme tarafından kabul edilmesine veya davalının izin vermesine gerek yoktur (m. 309, 2). Davadan feragatın tamamlanması için, davacının feragat beyanının **mahkemeye ulaşması yeterli**dir; bu feragat beyanının ayrıca davalıya da ulaşması (davalı tarafından da öğrenilmesi) feragatın tamamlanması için şart değildir. Çünkü davacı, davadan feragat etmekle, yalnız davasını geri almakla yetinmemekte, aksine dava konusu yapmış olduğu haktan vazgeçmektedir.

Hüküm kesinleşinceye kadar davacı davasından (dava, kanun yolları aşamasında iken dahil) her zaman feragat edilebilir (m. 310).

Henüz açılmamış (ileride açılabilecek) olan bir davadan feragat söz konusu olamaz. Dava açılmadan yapılan feragat, davadan feragat değil, esas

---

[1] Bkz. Leyla Akyol Aslan, Medenî Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

haktan feragat olarak nitelendirilir. Ancak, bilindiği üzere, henüz doğmamış olan bir haktan önceden vazgeçme (feragat), hukuken geçerli değildir.

Dava vekil (avukat) aracılığıyla takip edilmekte ise, vekil de davadan feragat edebilir. Ancak bunun için, vekilin vekâletnamesinde davadan feragat yetkisinin bulunması gerekir. Çünkü, davadan feragat özel yetki verilmesini gerektiren hallerdendir (m. 74). Vekâletnamesinde davadan feragat yetkisi bulunmayan vekilin, davadan feragati, asıl (müvekkil) sonradan onay (icazet) vermedikçe geçersizdir.

Vasinin davadan feragat edebilmesi için, vesayet makamının izni gerekir.

Tüzel kişinin temsilcisinin davadan feragat veya davayı kabul edebilmesi için bu konuda yetkili olması gerekir. Özel olarak yetkilendirilmedikçe, belediye başkanının ve köy muhtarının davadan feragat yetkisi yoktur.

Davadan feragat şekle tâbidir (m. 309). Kanunun öngördüğü bu şekil, **geçerlilik şartı**dır. Davadan feragat, sözlü veya yazılı şekilde olabilir: Davacı, yargılama sırasında (duruşmada) davasından **sözlü** olarak feragat edebilir (m. 309, 1). Bu halde, davacının (kısmen veya tamamen) feragat beyanı duruşma **tutanağına yazılır** (m. 154, 1/ç). Bu şekle uygun olmayan feragat beyanı geçersizdir. **Keşif sırasında** yapılan, keşif tutanağına yazılan ve davacıya okunarak imza ettirilen feragat geçerlidir. Davacı, mahkemeye vereceği bir **dilekçe ile** (yazılı olarak) de davasından feragat edebilir. Bu halde, davacının dilekçe ile yaptığı davadan feragatın geçerli olabilmesi için, dilekçedeki feragat beyanının ayrıca duruşma tutanağına geçirilmesine ve kendisine imza ettirilmesine gerek yoktur. Böyle bir feragat dilekçesinin mahkemeye verildiğinin tutanağa yazılması yeterlidir.

Mahkemenin hüküm (nihaî karar) verip dosyadan el çekmesinden sonra, davacı davadan feragat ederse; mahkeme davadan el çekmiş olmasına rağmen, feragatin tek taraflı olarak davaya son veren bir işlem olması sebebiyle dosyayı istinaf mahkemesine göndermeyerek, davadan feragat sebebiyle davanın reddine karar verebilmelidir. Feragat talebi davanın istinaf aşamasında yapılırsa, gerektiğinde hüküm mahkemesi olarak karar verme yetkisine sahip olan istinaf mahkemesi, dosyayı geri göndermeyerek talep doğrultusunda davanın reddine karar verebilmesi gerekir. Bu kararın şekli konusunda bkz. Y m. 215[2].

Davadan feragat, temyiz aşamasında yapılırsa Yargıtay, davadan feragat konusunda bizzat karar vermez; bu konuda karar vermesi için dosyayı ilgili alt mahkemeye geri gönderir.

Zorunlu dava arkadaşlığında davadan feragat beyanının hüküm ifade edebilmesi için bütün zorunlu dava arkadaşlarının da bu konudaki beyanları gerekir. İhtiyarî dava arkadaşlarından her biri bağımsız olarak davadan feragat edebilir ve bu feragat sadece onun açısından hüküm ifade eder.

---

[2] Bu konuda Yönetmelik hükmü ile düzenleme yapılmışsa da, bu husus Kanunla açıkça düzenlenmelidir. Zira yargılama usulüne ilişkin kuralların kanunla getirilmesi gerekir (Anayasa m. 142). Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, HMK Yönetmeliği İle Usul Hükmü Getirilemez (Güncel Hukuk Dergisi, 2013/3, s. 552-555).

Davadan feragat, davayı sona erdirmektedir. Bu nedenle, feragat eden davacının kimliğinin mahkemece tespiti, bunun için gerekirse beyanda bulunanın mahkemeye davet edilmesi ve tespit işleminin tutanağa geçirilmesi gerekir. Bu husus özellikle, feragat beyanının (duruşma dışında) dilekçe ile yapılması halinde önem gösterir.

Kanunun öngördüğü (sözlü veya yazılı) şekilde yapılmamış olan feragat, geçerli değildir; aynı şekilde, kısmen feragatte feragat edilen kısmın dilekçede veya tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir. Bu şekilde yapılmayan bir feragat ile dava sona ermez.

Feragat, tek taraflı irade beyanı olduğundan geçerli olabilmesi ve hüküm doğurabilmesi için, yukarıda da belirtildiği gibi, mahkemenin onayına gerek yoktur. Ancak mahkemenin, somut olayın feragatle sona erdirilebilecek davalardan olup olmadığını, davacının feragat beyanının gerçekten feragat olup olmadığını ve kanunun öngördüğü şekilde yapılıp yapılmadığını inceleme yetkisi vardır. Mahkeme, davacının beyanının gerçekten feragat olduğunu ve kanunun öngördüğü şekilde yapıldığını tespit ederse, davanın feragat nedeniyle reddine karar verir.

Davadan feragat, davanın istem sonucundan tümüyle (tamamen) vazgeçme şeklinde olabileceği gibi, talebin yalnızca bir kısmından (kısmî) feragat şeklinde de olabilir.

Davacının davasından **tamamen feragat** etmesi üzerine, (bu feragatın geçerli olduğu ve bununla dava konusu uyuşmazlığın son bulduğu kanısına varan) **mahkeme**, **davanın feragat nedeniyle reddi**ne karar verir. Mahkeme, ancak feragat nedeniyle davanın reddine ilişkin kararı ile davadan elini çeker.

Davadan **kısmî feragat** halinde, dava, feragat edilen kısım açısından sona erer; feragat edilmeyen geriye kalan kısım için devam eder. Örneğin:

Davacı, dava yığılmasında (objektif dava birleşmesinde, m. 119) taleplerinden (kalemlerden) birinden feragat ederse, dava, feragat edilen talep edilen kısım için sona erer ve fakat diğer talepler bakımından devam eder.

Davacı açtığı alacak davasında, davalının yüz bin liraya mahkûm edilmesini istemiş ve dava sırasında bunun on bin lirasından feragat etmişse, dava doksan bin lira için devam eder.

Davadan feragat ile dava konusu uyuşmazlık (ve bununla dava), esastan sona erdiğinden, **şarta bağlı feragat yapılamaz** (m. 309, 4); şarta bağlı feragat ile dava sona ermez.

Davalının dava konusunun devri (m. 125) halinde, davacı davayı, dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı devam ettirmek ister ve davayı ilk davacıya karşı takip etmeyeceğini bildirirse, bu beyan davadan feragat anlamına gelmez.

Davasından feragat eden **davacı**, davada aleyhine hüküm verilmiş (davayı kaybetmiş) gibi **yargılama giderlerini ödemek zorundadır** (m. 312, 1). Feragat kısmî ise, yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.

Davadan feragat, ön inceleme tutanağının imzalanmasından önce yapılırsa, Tarife hükümleriyle belirlenen **avukatlık ücreti**nin yarısına; daha sonra yapılırsa tamamına hükmedilir (AK Ücret Tarifesi m. 6).

Davadan feragat eden davacı, davasının reddi halinde ödeyeceği **karar ve ilâm harcı**nın; ilk duruşmada (ön inceleme duruşmasında) yapılırsa üçte birini, daha sonra yapılırsa üçte ikisini ödemeye mahkûm edilir (Harçlar K. m. 22).

Davadan feragat bir usul işlemi ise de, içeriği bakımından bir maddî hukuk işlemidir. Başka bir deyişle, davadan feragat, karma nitelikli bir işlemdir.

Davadan feragatın içeriği olan maddî hukuk işlemi (haktan vazgeçme), ile taraflar arasındaki dava konusu yapılan uyuşmazlık son bulur. Burada dava, mahkemenin kararı ile değil, davacının feragat iradesi ile sona erdiğinden, feragatın içeriği olan bu maddî hukuk işlemine karşı usul hukuku kurallarına göre, kural olarak, kanun yoluna başvurulamaz. Çünkü, mahkemenin, dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında vermiş olduğu bir karar yoktur. Kanun yolu ise, ancak mahkeme kararlarına karşı başvurulacak yoldur. Davadan feragatın içeriği olan maddî hukuk işlemi ancak maddî hukuk kurallarına göre iptal ettirilebilir (m. 311, 1/ son cümle). Fakat, feragat aynı zamanda bir usul işlemi olduğundan, feragatın yapılışı, usul hukukuna tâbidir. Mahkemenin davanın feragat nedeniyle reddine ilişkin bu kararı, usul hukukuna aykırı olduğu iddiasıyla, kanun yoluna götürülebilir. Buna göre, davanın feragat nedeniyle reddine ilişkin mahkeme kararı, **yalnız usul hukukuna dayanan sebeplerden dolayı** kanun yoluna götürülebilir.

Davadan feragat, **kesin hüküm gibi** hukukî sonuç doğurur (m. 311, 1/ilk cümle). Bu maddedeki kesin hükümden kasıt, şeklî anlamda kesin hüküm değildir. Çünkü dava, feragat ile kendiliğinden son bulmamakta, ancak mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine ilişkin kararının kesinleşmesi ile son bulmaktadır. Bu nedenle m. 311, 1 hükmünde açık biçimde belirtildiği gibi, davadan feragat, **maddî anlamda kesin hüküm** (m. 303) gibi sonuç doğurur. Feragat nedeniyle reddedilen dava, aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanarak yeniden açılamaz; açılırsa, kesin hüküm nedeniyle reddedilir.

Davacının davasından feragat etmesi ile, dava konusu uyuşmazlık sona erer. Bu nedenle, mahkeme henüz feragat nedeniyle davanın reddine karar vermemiş olsa bile, davacı, **feragattan dönemez**; feragatı ile bağlıdır. Fakat davacı, feragatın **irade bozukluğu nedeniyle geçersiz olduğu**nu aynı davada ileri sürebilir veya feragatın iptali için ayrı bir dava açabilir (m. 311, 1/c. 2).

Kural olarak her davadan feragat edilebilir. Çünkü, hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi, açmış olduğu davayı da sonuna kadar takip etmeye zorlanamaz. Dava konusu üzerinde tarafların tasarruf yetkisi bulunmasa bile (yani tasarruf ilkesinin tam olarak uygulanmadığı davalarda da), davacı davasından feragat edebilir. Örneğin boşanma davasının kabul edilmesi kesin hükmün (m. 303) hukukî sonuçlarını doğurmadığı halde davacı, **boşanma davasından feragat edebilir** ve bununla boşanma davası son bulur.

Buna karşılık, bazı **istisnaî hallerde**, feragat, **davayı sona erdirmez.** Örneğin:

Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi (izalei şüyû) davası (m. 4, 1/b) **çift taraflı** bir **dava** (actio dublex) olduğundan, davacının davadan feragat etmesi halinde, davalı (veya davalılardan biri) davaya devam edilmesini isterse, mahkeme paydaşlığın giderilmesi davasına devam etmekle yükümlüdür.

Sosyal güvenlik hakkından vazgeçilemeyeceğinden, sosyal güvenlik hakkı tanınması sonucunu doğuran davadan feragat edilemez.

Tapuda isim düzeltilmesi isteğine ilişkin davalar sicillerin doğru tutulmamasından kaynaklandığından ve sicillerin doğru tutulması kamu düzenine ilişkin bulunduğundan bu yöndeki davadan feragat edilemez.

İflâs kararı verildikten sonra iflâs davasından feragat edilemez (İİK m. 165, II).

§ 50. DAVAYI KABUL[1]

A) GENEL OLARAK

Davalının, davacının dava ile kendisinden istediğini (kısmen veya tamamen) kabul etmesine "davayı kabul" denir. Kanunun (m. 308. I) ifadesiyle, davayı kabul, **davacının talep sonucuna**, **davalının** kısmen veya tamamen **muvafakat etmesidir** (m. 308, 1).

Davayı kabul eden davalı, bu şekilde, davacının talep sonucu bölümünde istemiş olduğu hakkı (talebi), tamamen veya kısmen kabul eder (talep sonucuna muvafakat eder; m. 308, 1).

Davayı kabul, **tek taraflı irade beyanı**dır; ve mahkemeye verildiği andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Davayı kabulün geçerliliği için, davacının rızasına ve mahkemenin onayına gerek yoktur.

Davayı kabul ve **ikrar** (m. 188)[2], hukukî nitelikleri ve doğurdukları sonuçlar itibariyle, birbirinden farklı müesseselerdir. Şöyle ki:

İkrarın konusu, **vakıa**lardır (iddia ve savunmanın dayandığı -davanın ve savunmanın sebebi olan- olaylardır). Oysa davayı kabul, davalının dava dilekçesinin **talep sonucu**na ilişkindir. İkrar ile bir vakıanın doğru olduğu bildirilir; davayı kabulde ise, davacının dava dilekçesindeki talep sonucuna, yani davacının ileri sürdüğü bütün vakıalardan çıkarmış olduğu sonuca rıza gösterilir. İkrar ile dava sona ermez, sadece ikrar edilen vakıa doğru olarak kabul edilir, o vakıanın ispatına gerek kalmaz (m. 187, 2); fakat tahkikata (davaya) devam edilir. Oysa kabul ile, dava tamamen veya (kısmî kabulde) kısmen sona erer. İkrar, (diğer tarafın ileri sürdüğü olaylar açısından) her iki tarafça da yapılabildiği halde; davayı sadece davalı (karşı davanın da davalısı) kabul edebilir. Kabul için vekilin vekâletnamesinde özel yetkinin bulunması gerektiği halde (m. 74), ikrar için bu gerekli değildir.

B) DAVAYI KABUL USULÜ ve DAVAYI KABULÜN SONUÇLARI

Davayı kabul, davalının **mahkemeye karşı** yapacağı **tek taraflı ve** açık bir **irade beyanı** ile olur.

Davalının vekilinin, bir vakıayı ikrar edebilmesi için, vekâletnamesinde özel bir "ikrar etme" veya "karşı tarafın ikrarını kabul etme" yetkisinin bulunmasına gerek yoktur. Buna karşılık, vekilin davayı kabul edebilmesi için, vekâletnamesinde **özel "kabul yetkisi"**nin bulunması şarttır (m. 74).

Tüzel kişinin temsilcisinin davayı kabul edebilmesi için bu konuda yetkili olması gerekir. Özel olarak yetkilendirilmedikçe, belediye başkanının veya köy muhtarının davayı kabul yetkisi yoktur.

---

1 Bkz. İbrahim Ermenek, Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul, Ankara 2009.

2 Bkz. yuk. § 27.

Zorunlu dava arkadaşlığında davayı kabul beyanının hüküm ifade edebilmesi için bütün zorunlu dava arkadaşlarının da bu konudaki beyanları gerekir. Buna karşılık, ihtiyarî dava arkadaşlığında, her bir dava arkadaşı tek başına davayı kabul edebilir; ancak bu kabul yalnızca kendisini bağlar.

Davalı, davanın açılmasından dava hakkında verilen **hükmün** (şeklen) **kesinleşmesine kadar davayı** kabul edebilir. Kanun yolları aşamasında da, davanın kabulü mümkündür.

Mahkemenin hüküm (nihaî karar) verip dosyadan el çekmesinden sonra, davalı davayı kabul ederse; mahkeme davadan el çekmiş olmasına rağmen, kabulün tek taraflı olarak davaya son veren bir işlem olması sebebiyle dosyayı istinaf mahkemesine göndermeyerek, davanın kabul sebebiyle kabulüne karar verebilmelidir. Kabul beyanı davanın **istinaf aşamasında yapılırsa**, gerektiğinde hüküm mahkemesi olarak karar verme yetkisine sahip olan istinaf mahkemesi dosyayı geri göndermeyerek, beyan doğrultusunda davanın kabulüne karar verebilmelidir[3].

Davayı kabul, **temyiz aşamasında yapılırsa** Yargıtay, davayı kabul konusunda bizzat karar vermez; bu konuda karar vermesi için dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderir.

Davalı, davacının talep sonucunun tamamını kabul edebileceği gibi bir kısmını da (kısmî) kabul edebilir. Davanın kısmen kabulünde, kabul edilen kısmın, dilekçede yahut mahkeme (duruşma) tutanağında açıkça gösterilmesi gerekir (m. 309, 3). Davalının davacının talep sonucunun bir kısmını kabul etmesi (**kısmî kabul**) halinde, talep sonucunun (davanın) kabul edilmeyen (diğer) kısmı hakkındaki uyuşmazlık son bulmuş olmaz. Dava bu (kabul edilmeyen) kısım hakkında devam eder.

Davayı kabul ile dava konusu uyuşmazlık ve bununla dava, esastan sona erer. **Şarta bağlı kabul geçerli değildir** (m. 309, 4). Örneğin, davalının yaptığı "Davacı taraf, faiz talebinden vazgeçerse (veya dava dışı olan malı bana verirse, davayı kabul ediyorum" derse, bu, şarta bağlı kabuldür ve geçersizdir. Mahkeme de, şarta bağlı kabul çerçevesinde davanın kabulüne karar veremez.

Davayı kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında (duruşmada) sözlü olarak yapılır (m. 309, 1). Davayı kabul için Kanunun öngördüğü bu şekil, geçerlilik şartıdır. Başka bir deyişle, davayı kabul, davalının mahkemeye karşı yaptığı yazılı veya sözlü tek taraflı bir irade beyanı ile olur ve tamamlanır. Bu kabul beyanının ayrıca davacıya da ulaşması (davacı tarafından öğrenilmesi), kabulün tamamlanması için şart değildir. Davayı kabul, davalının tek taraflı (açık) bir irade beyanı ile yapıldığından ve tamamlandığından, kabulün geçerliliği için, bunun davacı tarafından onaylanmasına (davacının kabule rıza göstermesine) gerek yoktur.

Davayı kabul, yazılı (dilekçe ile) veya sözlü olarak yapılabilir. Davalının, yargılama sırasında (duruşmada veya keşif sırasına vb.) **sözlü** olarak yaptığı kabul beyanı (m. 309, 1) mahkeme (duruşma) tutanağına yazılır (m. 154,

---

[3] Bu kararın şekli konusunda bkz. Y m. 215.

3/ç). Tutanağın kabule ilişkin bölümü, davalının önünde okunarak davalıya **imza ettirilir**. Kabul beyanının davalıya okunduğunun ve ondan sonra imza ettirildiğinin de tutanağa yazılması zorunludur (m. 154, 3/ç). Bu şekil şartlarına uygun olmayan kabul beyanı geçersizdir.

Davalı, duruşmada mahkemeye vereceği bir **dilekçe** ile de davayı kabul edebilir. Bu halde, davalının dilekçe ile yaptığı davayı kabulün geçerli olabilmesi için, dilekçedeki kabul beyanının ayrıca mahkeme tutanağına geçirilmesine ve kendisine (davalıya) okunarak imza ettirilmesine gerek yoktur. Böyle bir kabul dilekçesinin mahkemeye verildiğinin tutanağa yazılması yeterlidir. Davalı, duruşma dışında da davayı kabul etmek isterse, mahkemeye vereceği bir dilekçe ile davayı kabul edebilir (m. 309, 1).

Davayı kabul, davayı sona erdirmektedir. Bu nedenle, davayı kabul eden davalının kimliğinin mahkemece tespiti, bunun için gerekirse beyanda bulunanın mahkemeye davet edilmesi ve tespit işleminin tutanağa geçirilmesi gerekir. Bu husus özellikle, kabul beyanının (duruşma dışında) dilekçe ile yapılması halinde önemli olur.

Davalının davayı **tamamen kabul** etmesi üzerine, kabulün geçerli olduğu ve bununla dava konusu uyuşmazlığın son bulduğu kanısına varan mahkeme, kabul nedeniyle davanın kabulüne karar verir. Davalının davayı tamamen kabul etmesi üzerine, mahkemenin, davalının o zamana kadar yapmış olduğu savunmaları ve o zamana kadarki tahkikat sonucunu dikkate almadan, kabul gereğince davanın kabulüne karar vermekle yetinmesi gerekir. Bunun gibi, mahkeme, davalının davayı kabul ettikten sonra yaptığı savunmayı dikkate alamaz.

Davanın kısmen (kısmî) kabulü halinde, davanın kabul edilmeyen kısmı için yargılamanın devamına karar verilir.

Davayı kabul eden **davalı**, kural olarak, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi **yargılama giderleri**ni ödemeye mahkûm edilir (m. 312, 1). Kabul, talep sonucunun bir kısmına ilişkin ise, yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir (m. 309, 1). Davalı, dava açılmasına kendi hal ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilemez (m. 312, 2).

Davayı kabul eden davalı, davayı kaybetmesi halinde ödeyeceği **karar ve ilâm harcı**nın üçte ikisini ödemeye mahkûm edilir (Harçlar K. m. 22). Davalı ilk oturumda davayı kabul ederse, kendisinden karar ve ilâm harcının üçte biri alınır (Harçlar K. m. 22). Yargılamanın ilk duruşmasında davayı kabul eden davalının, yargılama giderlerinden kurtulabilmesi için, hal ve davranışı ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş olması gerekir (m. 312, 2). Vekâlet ücreti de yargılama giderlerinden olduğundan, davacı, ilk oturumda davayı kabul eden ve hal ve davranışı ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş ve kendini vekil ile temsil ettirmiş olan davalıya **vekâlet** (avukatlık) **ücreti** ödemeye de mahkûm edilmelidir. İlk oturumda davayı kabul eden davalı, hal ve durumu ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermiş

ise, m. 312, 2 hükmünden yararlanamaz. Yani bu halde, davalı, davayı kaybetmiş gibi yargılama giderlerini ödemekle yükümlü olur.

Davayı kabul, ön inceleme tutanağının imzalanmasından önce yapılırsa, Tarife hükümleriyle belirlenen **avukatlık ücreti**nin yarısına; daha sonra yapılırsa tamamına hükmedilir (AK Ücret Tarifesi m. 6).

Davayı kabulün içeriği olan maddî hukuk işlemi (hakkın varlığını kabul etme) ile, taraflar arasında dava konusu yapılan uyuşmazlık son bulur. Burada dava mahkemenin kararı ile değil, davalının iradesi (maddî hukuk işlemi) ile son bulduğundan, kabulün içeriği olan bu maddî hukuk işlemine karşı, usul hukuku kurallarına göre kanun yoluna başvurulamaz. Fakat, davayı kabul, aynı zamanda bir usul işlemi olduğundan, kabulün yapılışı, usul hukukuna tâbidir. Bu nedenle mahkeme, kabulün usul hukuku kurallarına uygun bir biçimde yapılıp yapılmadığını araştırır; kabulün usulüne uygun biçimde yapıldığı ve bununla dava konusu uyuşmazlığın son bulduğu kanısına varırsa, kabul nedeniyle davanın kabulüne karar verir. Mahkemenin, kabul nedeniyle davanın kabulüne ilişkin bu kararı, usul hukuku kurallarına aykırı olabileceğinden, kararın bu kısmı kanun yoluna götürülebilir.

Davayı kabul, maddî anlamda **kesin hüküm** gibi hukukî sonuç doğurur (m. 303). Yani, kabul nedeniyle kabul edilen dava, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanarak yeniden açılamaz; açılırsa, kesin hüküm nedeniyle reddedilir.

Yukarıda görüldüğü gibi, davalının davayı kabul etmesi ile, dava konusu uyuşmazlık sona erer. Bu nedenle, mahkeme henüz kabul nedeniyle davanın kabulüne karar vermemiş olsa bile, **davalı kabulden dönemez** (rücu edemez); kabulü ile bağlıdır. Fakat, diğer maddî hukuk işlemlerinde olduğu gibi irade bozukluğu hallerinde (yanılma, aldatma, korkutma -hata, hile, ikrah-; TBK m. 30), kabulün iptali (feshi) için dava açılabilir (m. 311). Davalı, mahkemenin kabul nedeniyle davanın kabulüne karar vermesinden önce aynı dava içinde, kabulün hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürebilir; bunun için ayrı bir kabulün feshi davası açması şart değildir.

Kabul, **ilâm niteliğinde** olup, ilâmların icrası yolu ile icra edilir (İİK m. 38).

Özellikle kamu düzeninin gerekli kıldığı bazı istisnaî hallerde, tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkileri yoktur veya sınırlıdır. Bu tür davalarda davalının davayı kabul etmesi, davayı sona erdirmez (m. 308, 2); bu davalarda, mahkeme, davalının kabulü ile bağlı olmayıp, davaya devam eder. Örneğin:

Babalık davası kamu düzeni ile ilgili olduğundan davalının davayı kabul etmesi hukukî sonuç doğurmaz.

İmar kurallarına aykırı olan konularda açılan bir dava, davanın kabulü suretiyle sona ermez.

Boşanma davasında kabul hâkimi bağlamaz; ancak boşanma davası açılmaksızın tedbir nafakası talep edilmişse, bu, kamu düzeninden olmadığından davanın kabulü hüküm ifade eder.

§ 51. SULH[1]

A) GENEL OLARAK

Sulh, görülmekte olan bir davanın taraflarının, **karşılıklı anlaşma** (fedakârlık, özveri) **ile** (yani, bir sözleşme ile), dava konusu **uyuşmazlığa son vermeleri**dir (m. 313).

Sulhte, genellikle, davacı talep sonucunun bir kısmından feragat eder ve davalı da, davacının talep sonucunun diğer (kalan) kısmını kabul eder ve böylece (yani kısmî feragat ve kısmî davayı kabul ile) sulh sözleşmesi (anlaşması) meydana gelir; örnek:

Yüz bin liralık bir alacak davasında, davalı, (davacının kalan yetmiş bin liradan feragat etmesi şartı ile) davanın otuz bin lirasını kabul etmeyi teklif eder ve davacı da bu teklifi (aynen) kabul ederek alacağının (davasının) yetmiş bin liralık kısmından feragat ederse, taraflar arasında otuz bin lira üzerinden bir sulh sözleşmesi meydana gelmiş olur.

Sulh, HMK'nun 313-315. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun m. 313, 1'de "sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir" ifadesi ile sulhü tanımlamaktadır.

Sulh, taraflar arasındaki uyuşmazlığı onların rızası (uzlaşması) ile gidermeye yaradığından ve böylece uyuşmazlığa daha çabuk, ucuz ve basit bir şekilde son verdiğinden, davanın mahkemece esastan karara bağlanmasına oranla çok daha iyi bir çözüm şeklidir. Bu açıdan, uyuşmazlığın sulhen çözümlenmesinin özellikle **toplumsal barış** yönünden bir ideal olduğu da kolaylıkla söylenebilir. Eski bir deyişle, "**en kötü sulh, mahkemenin dava sonucunda vereceği en iyi hükme tercih edilmelidir**".

Bu nedenle **hâkim**, daha davanın başında **(ön inceleme aşamasında) iki tarafı sulh olmaya** (uzlaşmaya) **teşvik eder** (m. 137, 139, 140); davanın ilerleyen aşamalarında da sulh yapılabilir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda yapılabilen sulh, davanın ön inceleme sonrası aşamalarında da hüküm kesinleşinceye kadar (m. 314) yapılabilir.

Her ne kadar Kanun ve gerekçesi, mahkemenin tarafların sulhe teşvik edilmesi hususunu önemle ve defaatle vurgulamakta ise de, gözlemlediğimiz kadarıyla uygulamada, mahkemelerin esas itibariyle aşırı iş yükü nedeniyle sulhe teşvik ile ilgili gerekli zamanı ayıramadıklarından sulh amacına ulaşılamamakta ve sulhe teşvik, yalnızca şekle uyularak kararlar vermekten ibaret kalmaktadır.

---

[1] Bkz. Ergun Önen, Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972.

B) SULH USULÜ ve SULHÜN SONUÇLARI

Sulh, hukukî niteliği gereği, bir sözleşme olduğundan, ancak davacı ve davalının iradelerinin uyuşması ile yapılabilir.

Vekilin (karşı tarafla) sulh anlaşması yapabilmesi için, vekâletnamesinde açık bir sulh yetkisinin bulunması gerekir (m. 74).

Sulh sözleşmesi, genellikle kısmî feragat ve kısmî kabul ile meydana gelir. Fakat sulh, her zaman kısmî feragat ve kısmî kabul sonucunda meydana gelmez. Taraflardan birinin dava dışındaki bir hakkı da sulh sözleşmesine (anlaşmasına) dahil edilebilir (m. 313, 3); örnek:

Yukarıda verilen yüz bin liralık örnekte davacı bu yüz bin liralık davayı kısmî dava olarak açmış ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş olsun. Davalı, bu yüz bin liralık davayı, aralarındaki uyuşmazlığın tamamen çözümlenmiş olması şartı ile kabul etmeyi teklif eder ve davacı da bu teklifi benimseyerek, saklı tutmuş olduğu fazlaya ilişkin haklarından vazgeçerse (feragat ederse), taraflar arasında, yüz bin lira üzerinden bir sulh anlaşması meydana gelmiş olur. Böylece taraflar arasındaki uyuşmazlık, sulhen sona erer.

Şarta bağlı feragat ve kabul mümkün olmadığı halde, **taraflar**, mahkeme önünde **şarta bağlı** (bazı şartları içeren) **sulh sözleşmesi yapabilirler** ve böyle bir sulh ile de davanın son bulmasını sağlayabilirler (m. 313, 4).

Mahkeme önünde sulh şekle tâbidir (m. 154, 3/ç). Kanunun öngördüğü bu şekil, sulh için geçerlilik şartıdır. Taraflar, **duruşma** sırasında sulh olmak istediklerini hâkime bildirince, tarafların mahkeme önünde yaptıkları sulh anlaşması duruşma tutanağına yazılır (m. 154, 1). Tutanağın sulhe ilişkin bölümü, tarafların önünde okunarak kendilerine imza ettirilir (m. 154, 3/ç). Tutanağa yazılan sulh anlaşmasının taraflara okunduğunun ve ondan sonra imza ettirildiğinin de tutanağa yazılması zorunludur. Bu şartlara uygun olmayan sulh anlaşması geçersizdir.

Taraflar, **mahkeme** (duruşma) **dışında** yapmış oldukları yazılı bir sulh sözleşmesini mahkemeye verirler ve buna göre davada sulh olduklarını bildirirlerse, bu yazılı sulh sözleşmesinin mahkemeye verildiği duruşma tutanağına yazılır (m. 154, 3/f). Bu halde, mahkemeye verilen yazılı sulh sözleşmesinin ayrıca tutanağa geçirilmesine gerek yoktur. Çünkü, duruşma tutanağında eklendiği yazılı olan belgelerin içeriği de tutanak metni hükmündedir (m. 154, 4). Ancak bu halde, mahkemeye verilen yazılı sulh sözleşmesinin duruşmada tarafların önünde okunması, okunduğunun da duruşma tutanağına yazılması ve ondan sonra tutanağın (m. 154, 3/ç'ye göre) taraflara imza ettirilmesi gerekir. Böylece, mahkeme dışı sulh, mahkeme içi sulhe dönüşür.

Keşif sırasında yapılan, keşif tutanağına yazılan ve taraflara okunarak imza ettirilen sulh de mahkeme önünde yapılmış sayılır ve geçerlidir.

Sulh üzerine mahkemenin vereceği kararı çeşitli ihtimallere göre ayrı ayrı incelemek uygun olur:

Sulh sözleşmesi **şarta bağlı olarak yapılmışsa**, mahkemenin, böyle bir sulh sözleşmesine dayanarak esas hakkında karar (hüküm) vermesi imkânsızdır. Çünkü şarta bağlı sulh yapılabilmesine karşılık mahkemece **şarta**

bağlı hüküm verilemez. Taraflar şarta bağlı şekilde sulh olmakla, davaya son vermek istediklerinden, başka bir deyişle davanın takibinden vazgeçtiklerinden (m. 123), bu halde mahkemenin "**karar verilmesine yer olmadığına**" biçiminde bir kararla davayı sonuçlandırması gerekir (m. 315, 1).

Sulh **şarta bağlı değilse**, sulh üzerine mahkemenin vereceği karar, tarafların talebine göre iki şekilde olabilir:

Taraflar, mahkemenin, **sulhe** (sulh sözleşmesine) **göre** bir **karar vermesini istemezlerse**, mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına karar verir (m. 315, 1). Taraflar, sulhün mahkeme tarafından tespit etmesini isterlerse, o zaman mahkeme, sulhü m. 154, 3/ç'ye, göre tutanağa geçirir ve "karar verilmesine yer olmadığı" (m. 315, 1/c. 2) biçiminde bir kararla davanın son bulduğunu tespit etmekle yetinir. Çünkü, davanın sahibi taraflardır ve hâkim onların talebinden fazlaya karar veremez (m. 26). Bundan başka, tarafların sadece sulhün tespit edilmesini ve bununla davanın sona erdirilmesini istemeleri, davayı takipten vazgeçmeye (m. 123) benzetilebilir.

Taraflar, **sulhe göre karar verilmesini isterlerse**, mahkeme, sulh sözleşmesine göre bir karar (hüküm) vermek zorundadır. Özellikle tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın esaslı noktalarında sulh olmaları halinde, bunun bütün ayrıntıları ile birlikte bir mahkeme hükmünde belirtilmesini istemelerinde hukukî yararları vardır.

Taraflar sulh olurken aynı zamanda yargılama giderleri hakkında da bir anlaşmaya varmışlarsa, mahkeme, tarafların ödeyecekleri yargılama giderlerini tarafların anlaşmasına çerçevesinde belirler. Taraflar, sulh sözleşmesinde yargılama giderlerinden söz etmemişlerse mahkeme, yargılama giderleri üzerinde de bir anlaşmaya varmaları için taraflara bir imkân verir. Taraflar, yargılama giderleri hakkında bir anlaşmaya varamazlarsa mahkeme, yargılama giderlerini, sulh sözleşmesindeki (kısmî) kabul ve feragat edilen miktarlar oranında taraflar arasında paylaştırır (m. 326, 2); yani taraflardan birini, o oranda yargılama gideri ödemeye mahkûm eder.

Taraflardan biri veya her ikisi davayı bir vekille (avukatla), vasıtasıyla takip etmiş ise, mahkeme, karşı tarafı veya her iki tarafı sulh sözleşmesindeki kabul ve feragat oranında vekâlet (avukatlık) ücreti ödemeye mahkûm eder (m. 323, 1/ğ; 326, 2). Bu vekâlet ücretine, Ücret Tarifesine göre hükmedilir.

Anlaşmazlık sulhen, ön inceleme tutanağı imzalanmasından önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur (AK Ücret Tarifesi m. 6).

Davanın sulh ile sonuçlanması halinde, mahkemenin sulh olmadan davayı karara bağlaması halinde ödenecek olan **karar ve ilâm harcı**nın üçte ikisi alınır (Harçlar K. m. 22). Taraflar ilk oturumda sulh olurlarsa bu halde, karar ve ilâm harcının üçte biri alınır (Harçlar K. m. 22).

Mahkeme önünde sulh, bir usul işlemi olduğundan, bu usul işleminin yapılışı, usul hukukuna tâbidir. Bu nedenle mahkeme, sulh halinde, önce sulhün usul hukuku kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır; sulhün usulüne uygun biçimde yapıldığı kanısına varırsa, bir kararla davayı so-

na erdirir. Mahkemenin sulh üzerine vereceği kararlar yukarıda incelendi. Mahkemenin sulh üzerine vereceği karar, usul hukukuna aykırı olabileceğinden, kanun yoluna götürülebilir.

Şarta bağlı olan sulh ile dava kendiliğinden sona erecek ve mahkeme de sulh nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığını tespit ile yargılamayı (davayı) sona erdirecektir. Mahkemenin bu durumda vereceği karar, maddî anlamda kesin hüküm (m. 303) teşkil etmez. Çünkü, şarta bağlı bir sulh ve mahkeme kararı ile, taraflar arasındaki uyuşmazlık, (esastan) son bulmuş değildir. Buna karşılık, şarta bağlı olmayan sulh ve böyle bir sulh üzerine verilen mahkeme kararı, kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğurur (m. 303). Çünkü, böyle bir sulh ve mahkeme kararı ile, taraflar arasındaki uyuşmazlık, esastan son bulmaktadır.

Yukarıda görüldüğü gibi, mahkeme önünde sulh, bir sözleşmedir ve taraflar bu sözleşme ile bağlıdır. Bu nedenle, mahkeme henüz sulh üzerine bir karar vermemiş olsa bile, taraflardan birinin tek taraflı olarak sulhten dönememesi (rücu edememesi) esastır. Fakat, feragat ve kabulde olduğu gibi, diğer maddî hukuk işlemlerinin iptaline ilişkin hükümlere (TBK m. 30 vd.) göre, irade bozukluğu hallerinin (yanılma, aldatma veya korkutma) varlığı nedeniyle sulh sözleşmesinin feshi (iptali) için dava açılabilir. Gabin (aşırı yararlanma, TBK m. 29) halinde de, sulhün iptali istenebilir (m. 315, 2).

Mahkeme önünde yapılan sulhler, ilâmların icrası hakkındaki hükümlere tâbidir (İİK m. 38); yani bu sulhler ilâm niteliğinde olup, ilâmlar gibi icra edilir. Yalnız şarta bağlı sulh, mahkeme ilâmları gibi icra edilemez.

Sulh ile ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalar, tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkilerinin bulunduğu haller içindir. Çünkü sulh, ancak tarafların konusu üzerinde serbestçe tasarruf yetkilerinin bulunduğu davalarda mümkündür. Örneğin, alacak, taşınır, taşınmaz ve tahliye davalarında taraflar sulh olabilirler.

Buna karşılık, kamu düzeniyle ilgili bazı istisnaî davalarda, tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkileri yoktur veya kısıtlıdır. İşte, istisna olarak tarafların dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf yetkilerinin bulunmadığı davalarda, sulh ile dava sona erdirilemez; örnekler:

Boşanma davası, sulh ile sona erdirilemez. Fakat, boşanmanın ferî (yan) sonuçlarına ilişkin bir sulh anlaşması, hâkimin tasdiki ile geçerli olur (TMK m. 184/5).

Babalık davası, sulh ile sona erdirilemez. Fakat, babalık davasında, çocuğun menfaatlerine dokunmamak şartıyla nafaka hakkında sulh yapılabilir.

Belediye sınırları içindeki bir taşınmazın tarafların rızasıyla paylaşılması (bölüşülmesi), belediye encümeni veya il idare kurulunca kabul ve tasdik edilmedikçe, (imar kurallarının genellikle kamu düzeni ile ilgili olması sebebiyle) tapuca tescil edilemez (İmar K. m. 16).

Bu hükme göre, paylaştırılması mümkün olmayan bir taşınmazın paylaştırılmasını içeren mahkeme önündeki sulh sözleşmesi de geçersizdir. Çünkü, az önce görüldüğü gibi, tarafların böyle bir paylaştırma (tasarruf) yetkileri yoktur.

Buraya kadarki açıklamalar, davanın görüldüğü mahkeme önünde yapılan (mahkeme içi) sulh içindir.

Sulh, bir sözleşme olarak mahkeme dışında da yapılabilir; buna **mahkeme dışı sulh** denir. **Mahkeme dışı sulh**, diğer sözleşmeler gibi tamamen **maddî hukuk hükümlerine tâbidir.**

Mahkeme dışı sulh sözleşmesi dava devam ederken yapılsa bile, görülmekte olan davayı kendiliğinden etkilemez. Burada iki ihtimal vardır:

Taraflar mahkeme dışında yapmış oldukları sulh sözleşmesini mahkemeye birlikte verirler ve buna göre sulh olduklarını bildirirlerse, bu husus tutanağa geçirilir, taraflara okunur ve imza ettirilir. Bu halde mahkeme dışı sulh, mahkeme içi sulhe dönüşür.

Taraflar, mahkeme dışında sulh olduklarını davaya bakan mahkemeye birlikte bildirmezlerse ve taraflardan biri böyle bir sulh sözleşmesini inkâr ederse, mahkeme dışındaki sulh sözleşmesine dayanan taraf, bunu mahkemede ispat etmekle yükümlüdür.

Mahkeme dışında yapılan sulh sözleşmesinin mahkemede (davada) ispatı için, m. 154'teki şekil şartı aranmaz. Mahkeme dışı sulh sözleşmesine dayanan taraf, bunu kanunen caiz olan her türlü delil ile ispat edebilir. Mahkeme dışı sulh sözleşmesi ile sona erdirilen uyuşmazlığın miktar veya değeri m. 200'de belirtilen sınırdan az (veya söz konusu sınırdan fazla olmakla beraber tanık dinlenilmesi mümkün olan bir istisna söz konusu) ise, mahkeme dışı sulh sözleşmesi, tanıkla da ispat edilebilir. Buna karşılık, mahkeme dışı sulh sözleşmesi ile sona erdirilen uyuşmazlığın miktar veya değeri m. 200'deki sınırdan fazla (ve tanık dinlenmesi mümkün olan bir istisna da söz konusu değil) ise, mahkeme dışı sulh sözleşmesi ancak senet (kesin delil) ile ispat edilebilir; çünkü, mahkeme dışı sulh sözleşmesi, iki taraflı bir hukukî işlemdir.

Öte yandan, sulh görüşmeleri sırasında gerçekleşen ikrar bağlayıcı olmaz (m. 188, 3).

GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR[1]

Hakkı çiğnenen veya çiğnenme tehlikesinde bulunan kişiler, mahkemeye başvurarak açtıkları davada, mahkemenin, yapacağı yargılama sonucunda kendi lehlerine karar (hüküm) vermesini ve çiğnenen haklarının geri verilmesini veya çiğnenme tehlikesinde bulunan haklarının korunmasını beklerler. Ancak yargılama, belli bir zaman alır ve hatta bazen uzun yıllar devam eder. Oysa, bazı durumlarda davanın sonuna kadar beklenilmesi halinde, hakların yargılama sırasında (zamanla) kaybolması veya uğranılan zararın daha da büyümesi ihtimali bulunabilir; bu amaçla da davanın sonu beklenmeden, yargılama sırasında da alınması gereken bazı geçici tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin:

Taşınmazın tapudaki yolsuz kaydın (tescilin) düzeltilmesi davası yargılamasının devamı sırasında, taşınmazın iyiniyetli üçüncü kişiye devri halinde, davanın sonunda davacı lehine verilen kararın pratik bir yararı olmayacaktır; çünkü, taşınmaz iyiniyetli üçüncü kişiye satıldığından ve davacı, davayı kazansa dahi, taşınmaza kavuşamayacaktır. Bu nedenle, taşınmazın, dava sırasında üçüncü kişilere devrinin önlenmesi ihtiyacı vardır.

Boşanma davası açan kadın, aynı zamanda nafaka da talep etmişse, davanın sonuna kadar beklenmesi halinde, kadının yaşamını sürdürebilmesinde büyük zorluklar ortaya çıkabilir; bu sebeple dava sırasında geçici tedbir olarak kadın lehine nafakaya karar verilmesi önemli bir ihtiyaçtır.

Bir basın organı, tamamen haksız ve rekabet kurallarını ihlâl eder şekilde bir üretici firma aleyhine dizi yayın yapmaya başlamıştır; bu haksız yayının önlenmesi için dava açmak isteyen firma, yayının hemen (dava açmayı dahi beklemeden) durdurulması ihtiyacını duyacaktır. Çünkü yayın durdurulamaması halinde, büyük ekonomik zararlara uğrama tehlikesi içerindedir.

Yargılama öğretisinde, normal bir davanın sonunda mahkemenin (uyuşmazlığı esastan çözen) kararına, **"kesin hukukî koruma"** (himaye) denildiği dikkate alınarak; dava sırasında veya hatta dava öncesinde alınması gereken ve yukarıda bazı örnekleri verilen geçici kararlara ise, bir üst kavram olarak, **"geçici hukukî koruma"** (geçici hukukî himaye tedbirleri) denilmektedir.

Geçici hukukî koruma, yalnızca medenî usul hukukuna özgü değildir. İcra hukukundaki ihtiyatî haciz; ceza yargısındaki tutuklama veya emniyet tedbirleri; idarî yargıdaki yürütmenin durdurulması ve anayasa yargısında yürürlüğün durdurulması kararı da, geçici hukukî korumalara birer örnektir.

HMK'nun 10. kısmı, "geçici hukukî koruma" üst başlığını taşımaktadır. Bu kısım altındaki birinci bölümde **"ihtiyatî tedbir"** (m. 389-399), ikinci bölümde

---

[1] Bkz. Ejder Yılmaz, Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri (2 Cilt) Ankara 2001; Ramazan Arslan, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici Hukuki Korumalar Konusunda Getirdiği Yenilikler (Bankacılar D. 2013 özel sayı, s. 7-27); Evrim Erişir, Geçici Hukukî Korunmanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, İstanbul 2013.

"**delil tespiti**" (m. 400-405) ve "**diğer geçici hukukî korumalar**" (m. 406) düzenlenmiştir.

Bundan sonraki paragraflar, ihtiyatî tedbirler ve delillerin tespiti konularına ayrılmıştır.

HMK, ihtiyatî tedbir ve delil tespiti müesseselerini ayrı ayrı düzenledikten sonra, 406. maddesinde "**diğer geçici hukukî korumalar**" başlığı altında yaptığı düzenlemeye göre; mahkeme, gerekli hallerde, mal ve haklarla ilgili defter tutulmasına (m. 382, 2/c.8) ya da mühürleme işleminin (m. 382, 2/g, 1) yapılmasına karar verir (m. 406, 1).

Kanunlarımızda, ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delil tespiti gibi klâsik denilebilecek geçici hukukî korumalar yanında; geçici tedbirler, ihtiyatî önlemler, muhafaza tedbirleri, koruma tedbirleri vb. adlar altında, farklı verilme şartları bulunan ve değişik sonuçlar doğuran, çok çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Hatta bu tür düzenlemeler, bazen teknik anlamda ihtiyatî tedbirlerle karıştırılabilmekte ve bunlara (teknik anlamda) ihtiyatî tedbirlerle ilgili kuralların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda hukukî tereddütler yaşanmaktadır[2]. Aslında bu tür düzenlemelerin hepsi, genel olarak, "geçici hukukî koruma" kavramı altında ifade edilebilecek olan hükümlerdir. İşte bu yüzden, m. 406, 2, bunlara yollama yaparak, "ihtiyatî haciz, muhafaza tedbirleri ve geçici düzenleme niteliğindeki diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır" şeklinde bir düzenleme getirme ihtiyacı hissetmiştir.

Geçici hukukî koruma hakkındaki bu genel açıklamalardan sonra, şimdi HMK'nun özel olarak düzenlediği ihtiyatî tedbirleri ve delillerin tespiti müesseselerini (geçici hukukî koruma örneklerini) incelemeye geçebiliriz.

---

[2] Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanunda Yer Alan Tedbirlerin Medenî Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (EMU-CWS 4th International Conference on Women's Studies, Gender Equality and the Law, Eastern Mediterranean University Press, 2013, Volume I, s. 27-49).

§ 52. İHTİYATÎ TEDBİRLER

A) GENEL OLARAK

Bir dava uzun sürebilir. Dava sırasında davalının, dava konusunu başkasına devretmesi mümkün olduğundan, davacının davayı kazanması halinde dava konusu şeye kavuşması tehlikeye girebilir. İşte, davacının davayı kazanması halinde dava konusuna kavuşmasını, daha dava sırasında (hatta davadan bile önce) güvence altına almaya yarayan geçici hukukî korumalara (tedbirlere), **ihtiyatî tedbirler** denir.

Bundan başka, davanın devamı süresince diğer bazı geçici tedbirler alınması zorunlu olabilir. Örneğin, boşanma davası devam ederken, kocanın karısının ve çocuğunun geçimleri için onlara bir miktar nafaka ödemesine (mahkemece) karar verilebilir.

Bazı hallerde, dava sonucunun beklenmesi halinde, davanın sonunda verilecek olan hükmün yerine getirilememesi tehlikesi veya önemli bir zarar ortaya çıkabilir. Örneğin, dava konusu bozulmaya elverişli bir mal olup, bunun dava sonuna kadar beklemesi halinde bozulması tehlikesi varsa, ihtiyatî tedbir olarak, o malın satılmasına ve bedelinin dava sonuna kadar saklanmasına karar verilebilir.

İhtiyatî tedbir, dava açılmasından önce veya sonra istenebilir. Bunun için tedbir isteyen, mahkemeye başvurur; talebi haklı görülürse (mahkemece) ihtiyatî tedbir kararı verilir. Bunun üzerine, ihtiyatî tedbirin çeşidine göre ihtiyatî tedbir kararı icra edilir (uygulanır). Örneğin, dava konusu taşınır mal bir yediemine (güvenilir üçüncü kişiye) teslim edilir; bozulmak üzere olan mallar satılır ve bedeli saklanır; kadın ve çocuklar için takdir edilen tedbir nafakası kocadan zorla (cebrî icra yolu ile) tahsil edilir vs.

B) İHTİYATÎ TEDBİR KARARI VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI

Kanun (m. 389); ihtiyatî tedbir talebinin yapıldığı sıradaki (mevcut) durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından, hakkın elde edilmesinin tamamen imkânsız hale geleceğinden, hakkın elde edilmesinde gecikme nedeniyle bir sakıncanın yahut ciddî bir zararın doğacağından endişe ediliyorsa, ihtiyat tedbir şartlarının var olduğunun kabul edileceğini belirtmektedir. Başka bir deyişle, bu hallerde mahkeme, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyatî tedbir kararı verebilir (m. 389, 1).

İhtiyatî tedbir şartlarını belirleyen bu hüküm, niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır (m. 389, 2).

İhtiyatî tedbirde asıl olan, hakkında ihtiyatî tedbir kararı alınacak hakkın bulunması ve yukarıda açıklanan (m. 389'da düzenlenen) bir ihtiyatî tedbir şartının (sebebinin) ortaya çıkmasıdır.

Bazı özel kanunlarda, konuları ile ilgili hususlarda verilebilecek ihtiyatî tedbir kararının şartları (ve çeşitleri) ayrıca düzenlenmiştir. Bu hallerde, mahkeme, ihtiyatî tedbirin HMK'nun aradığı şartlara uygun veya dava konusu uyuşmazlığın esasını çözümleyecek veya böyle bir sonuç doğuracak nitelikte olup olmadığını araştırmadan, özel kanunlarda öngörülmüş olan şartlar varsa, o ihtiyatî tedbirlere karar vermekle yükümlüdür; bkz. örneğin: TMK m. 420; TTK m. 61, 128 son fıkra, 449, 530, 575, 978, 976; İİK m. 92, II-III; Maden K. m. 40; FSEK m. 77; TBK m. 113.

C) İHTİYATÎ TEDBİR USULÜ

İhtiyatî tedbire karar verilmesi ancak mahkemeden istenebilir. **Dava açılmadan önce** ihtiyatî tedbir, davanın esası bakımından (davaya bakmaya) **görevli mahkeme**den istenir. Dava açıldıktan **sonra**, ihtiyatî tedbir için görevli mahkeme, **davanın görüldüğü mahkeme**dir (m. 390, 1)[1].

Dava açılmadan önce ihtiyatî tedbir, esas (dava) hakkında **yetkili olan mahkeme**den (birden fazla mahkeme varsa, bunlardan birisinden) istenir (m. 390, 1). Davanın açılmasından önce ihtiyatî tedbir isteyenin, ihtiyatî tedbir kararının verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasını talep etmesi zorunludur. Bu kurala uyulmazsa, kanunun öngördüğü süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar (m. 393, 1). Dava açıldıktan sonra, her türlü ihtiyatî tedbir yalnız asıl davaya bakmakta olan mahkemeden istenir (m. 390, 1). Dava açıldıktan **sonra**, davaya bakan mahkemeden başka bir mahkeme, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak ihtiyatî tedbir kararı veremez; davaya bakan mahkemeden başka bir mahkemenin vermiş olduğu ihtiyatî tedbir kararı geçersizdir.

İhtiyatî tedbir, görevli ve yetkili mahkemeden dilekçe ile istenir (m. 390, 3). Bu dilekçeye, (mahkemenin adı, tarafların kimlikleri ve adresleri gibi) diğer dilekçelerde de bulunan hususlardan başka, ihtiyatî tedbir talebinin hangi hakka dayanarak ve hangi uyuşmazlık (konusu) için istendiği, bu talebi haklı kılan sebepler ve istenen ihtiyatî tedbir türü yazılır.

Dava açılmadan önce ihtiyatî tedbir talebinde bulunandan, başvurma harcı ve karar harcı (peşin olarak) alınır. Davacı, dava dilekçesi ile hem ihtiyatî tedbir isteyebilir hem de esas hakkındaki davasını açabilir. Bu halde, davacıdan bir (tek) başvurma harcı ile bir (dava açılırken ödenmesi gereken) karar ve ilâm harcı alınır.

Mahkeme, kural olarak iki tarafı davet edip dinledikten sonra, ihtiyatî tedbir talebi hakkındaki kararını verir. Fakat, taraflar veya karşı taraf mahkemeye (ihtiyatî tedbir duruşmasına) gelmese bile, mahkeme, acele olarak ihtiyatî tedbir talebi hakkındaki kararını verir.

---

[1] İç (millî) tahkimde hakemler de ihtiyatî tedbir kararı verebilirler (m. 414, 1). Hakemlerin verdiği ihtiyatî tedbir kararının icra edilebilirliğine karar verme görevi (yetkisi) mahkemeye aittir (m. 414, 2). Milletlerarası Tahkim Kanununa (m. 6) göre de, hakemler ihtiyatî tedbir kararı verebilirler.

İhtiyatî tedbir talep edenin haklarının derhal korunmasında zorunluluk bulunan hallerde, (örneğin aleyhine ihtiyatî tedbir talep edilenin uyuşmazlık konusu taşınır malı kaçırması, taşınmazı başkasına devretmesi ihtimali olan hallerde) hâkim karşı tarafı dinlemeden de (duruşma yapmadan da) dosya üzerinden ihtiyatî tedbire karar verebilir (m. 390, 2).

İhtiyatî tedbir isteyen taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve ihtiyatî tedbir türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden de haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır (m. 390, 3). Buradaki "**yaklaşık ispat**", tam ispat değildir. Geçici hukukî koruma yargılamasını, asıl hukukî korumadan ayıran diğer bir özellik **ispat ölçüsü** bakımındadır. Kanunda açıkça öngörülmemişse ya da işin niteliği gerekli kılmıyorsa, bir davada (normal bir yargılamada) yaklaşık ispat değil, tam ispat aranır. Çünkü, hâkim, mevcut ispat ve delil kuralları çerçevesinde, tarafların iddia ettiği bir vakıa konusunda tam bir kanaate varmadan o vakıayı doğru kabul edemez. Örneğin, bir alacak davasında taraflardan biri bir sözleşmenin varlığına dayanıyorsa, hâkim bu sözleşmenin varlığı konusunda (mevcut ispat yükü ve delil kuralları çerçevesinde) tam bir kanaate sahip olmalıdır. Yani, zayıf veya kuvvetli bir ihtimal, karar vermek için yeterli değildir. Sözleşmenin varlığı konusunda tam kanaat uyanmazsa, o zaman, ispat yükü kendine düşen tarafın aleyhine bir karar verilmesi gerekir. Ancak, kanun koyucu, bazen ya doğrudan kendisi düzenleme yaparak ya da işin niteliği ve olayın özelliği gereği hâkime, bu durumu belirterek, ispat ölçüsünü düşürme imkânı vermiştir. Bu düşürülmüş ispat ölçüsü çerçevesinde, tam kanaat değil, kuvvetle muhtemel, **yaklaşık bir kanaat** yeterli görülmektedir. Yaklaşık ispatla yetinilmiş olması, ispatın aranmayacağı ya da ispat kurallarının tamamen dışına çıkılacağı anlamına gelmez. Bir taraf iddiasını mahkeme önüne ne kadar inandırıcı şekilde getirirse getirsin, bu sadece bir iddiadan ibarettir. İddia edilen vakıanın sabit yani doğru kabul edilebilmesi için, ispat yükü üzerine düşen tarafın, bunu kanundaki delil sistemi içinde yine kanunun aradığı ispat ölçüsü çerçevesinde ispat etmesi gerekir. Tam ispatın arandığı durumlarda, bu ölçü tereddütsüz ortaya konmalıdır. Yaklaşık ispat durumunda ise hâkim o iddianın ağırlıklı ihtimal olarak doğru olduğunu kabul etmekle birlikte, zayıf bir ihtimal de olsa, aksinin mümkün olduğu ihtimalini göz ardı etmez. Bu sebepledir ki, genelde geçici hukukî korumalara, özelde ihtiyatî tedbire ve ihtiyatî hacze karar verilirken, haksız olma ihtimali de dikkate alınarak talepte bulunandan **teminat** alınması öngörülmüştür. Geçici hukukî korumalarda, bazen karşı tarafın dinlenmemesi, tüm delillerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesine yeterli zamanın olmaması gibi sebeplerle, yaklaşık ispat yeterli görülmüştür.

İhtiyatî tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık **teminat** göstermek zorundadır. İhtiyatî tedbir talebi, resmî belgeye, başka bir kesin delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek koşuluyla teminat alınmamasına da karar verebilir (m. 392, 1). Örneğin nafaka davalarında, ihtiyatî tedbir olarak nafaka ödenmesine teminatsız karar verilebilir. İhtiyatî tedbir isteyen, adlî yardımdan istifade eden bir

kişi ise, ihtiyatî tedbir için teminat göstermesi gerekmez (m. 392, 1). Teminat olarak gösterilen para, banka mektubu, tahvil vb. iadesinin istenmesi halinde yazı işleri müdürü iade için gerekli şartları araştırır ve belgeleri ile görüşünü hâkime sunar. Bu konuda gerekli karar hâkim tarafından verilir (Y m. 217).

Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyatî tedbir kararının kalkmasından (m. 393, 1; 397) itibaren, bir ay içinde tazminat davasının (m. 399) açılmaması üzerine teminat iade edilir (m. 392, 2; Y m. 217).

Mahkeme ihtiyatî tedbir talebini haklı görürse, talebi kabul eder ve ihtiyatî tedbir kararı verir. Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir (m. 391, 1). Mahkeme, bu örnekler dışında da, her somut olayda ihtiyati tedbir kararı verilmesi şartlarının varlığını tespit edince, gerekli her türlü tedbiri alabilecektir. Bununla birlikte, hâkim, her kararında olduğu gibi, ihtiyatî tedbir kararı verirken de taraflar arasındaki menfaat dengesini ve tedbir kararı ile ulaşılmak istenen amacı gözönünde tutmak zorundadır.

Mahkeme, kural olarak, asıl uyuşmazlığı çözecek nitelikte, **esası çözer şekilde** ihtiyatî tedbir kararı veremez. Örneğin (A), (B)'nin elinde bulunan traktörünün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ileri sürerek dava açmış ve ihtiyatî tedbir alarak traktörün kendisine teslimini istemişse, mahkeme dava bitmeden, ihtiyatî tedbir talebini kabul ederek traktörü (A)'ya verirse, esası çözer tarzda karar vermiş olur. Bu durumda, ihtiyatî tedbir davanın yerine geçmiş olur. Böyle bir karar verilmesi ise ihtiyatî tedbire ilişkin hükümlerin ihlâl edilmesi sonucunu doğurur.

İhtiyatî tedbir kararında; ihtiyatî tedbir isteyenin ve karşı tarafın kimlikleri ve yerleşim yeri, tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı, tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerine ve ne tür bir tedbire karar verildiği, talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde teminat göstereceği yazılır (m. 391, 2; karş. İİK m. 260). Bu düzenleme emredici niteliktedir. Bu hükümle, genel birtakım ifadelerle ve somut gerekçeler olmadan ihtiyatî kararı verilmesi suretiyle hem karşı taraf haklarının ihlâl edilmesinin engellenmiş, hem de kararın uygulanması kolaylaştırılmıştır.

İhtiyatî tedbir talebinin **reddi halinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir** (m. 391, 3). Bu karara karşı **temyiz yolu kapalıdır** (m. 362, 1/f).

Mahkeme, ihtiyatî tedbir talebini haklı görürse, verilen ihtiyatî tedbir kararına karşı itiraz edilebileceğinden (m. 394) ve ihtiyatî tedbir kararı durum ve koşulların değişmesi halinde değiştirilebileceğinden, ihtiyatî tedbir talebinin kabulü kararına karşı, doğrudan kanun yoluna başvurulamaz. Ancak, **ihtiyatî tedbir kararına itiraz hakkında verilen karara karşı, istinaf yoluna başvurulabilir**. Öncelikle incelenip kesin olarak karara bağlanması gereken bu başvuru, tedbirin uygulanmasını durdurmaz (m. 394, 5).

D) İHTİYATÎ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI

İhtiyati tedbir kararı alan tarafın, bu kararın, kararın **verildiği tarihten itibaren bir hafta** içinde uygulanmasını talep etmesi gerekir. Aksi halde, yasal süresi (m. 397, 1) içinde dava açılmış dahi olsa, ihtiyatî tedbir (uygulanması talep edilmediğinden) kendiliğinden kalkar (m.393, 1).

İhtiyatî tedbir kararı, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer **icra dairesi tarafından** uygulanır (m. 393, 2). İcra müdürü, hacizdeki hükümlere (İİK m. 80) göre ihtiyatî tedbir kararını uygular (yerine getirir); gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilir (m. 393, 3; İİK m. 81).

Taşınmazın başkasına devrinin yasaklanmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararının icrası için, icra dairesine başvurulmasına gerek yoktur. Bu karar, mahkeme tarafından kendiliğinden tapu idaresine bildirilir ve tapu idaresi ihtiyatî tedbiri hacizler siciline kaydeder.

İhtiyatî tedbir kararını veren mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbir kararının mahkeme yazı işleri müdürü tarafından uygulanmasına da karar verebilir (m. 393, 2).

İhtiyatî tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenler. Bu tutanakta, tedbir konusu ve bulunduğu yer gösterilir; tedbir konusu ile ilgili her türlü iddia bu tutanağa geçirilir. Tedbiri uygulayan memur, tutanağın bir örneğini tedbirin icrası sırasında hazır bulunmayan taraflara ve gerekiyorsa üçüncü kişiye tebliğ eder (m. 393, 4)[2].

E) İHTİYATÎ TEDBİRİN KALKMASI

İhtiyatî tedbir kararı, geçici bir karardır ve bu nedenle er veya geç sona erer (kalkar). Bu da çeşitli şekillerde olur:

I) İhtiyatî tedbirin kalkması (kaldırılması) yollarından biri, itirazdır. İtiraz, başvurma harcına tâbi değildir. Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen karşı taraf, kendisi dinlenmeden verilmiş olan ihtiyatî tedbir kararına **itiraz edilebilir**. Tedbire itiraz edilmesi, aksine karar verilmedikçe, tedbirin icrasını (uygulanmasını) durdurmaz (m. 394, 1).

İhtiyatî tedbire itiraz süreye tâbidir. Aleyhine ihtiyatî tedbir verilen karşı taraf, ihtiyatî tedbirin uygulanması sırasında hazır bulunmuş ise, tedbirin uygulanması tarihinden itibaren; hazır değilse (yokluğunda uygulama yapılmış ise) tedbirin uygulandığını gösteren tutanağın tebliğinden itibaren **bir hafta** içinde yapılabilir. İhtiyatî tedbirin uygulanması yüzünden menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de, tedbiri öğrenmelerinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir (m. 394, 3).

İhtiyatî tedbire **itiraz sebepleri sınırlıdır** (m. 394, 2). İtiraz; ihtiyatî tedbirin şartlarına (m. 389), mahkemenin yetkisine (m. 390, 1) ve teminata (m. 392) ilişkin olabilir. Bunun dışındaki sebeplerle itiraz edilemez. Örneğin, lehi-

---

[2] İhtiyatî tedbire uymama (muhalefet) halinde disiplin hapsini öngören m. 398 hükmü, Anayasa Mahkemesinin 11.07.2018 gün ve 09/83 sayılı kararı ile iptal edilmiştir (RG 20.02.2019, sa. 30692). .

ne ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin haklı olmadığı, bu anlamda bir itiraz sebebi oluşturmaz; bu husus, olsa olsa dava (yargılama) sırasında ileri sürülebilir.

İtiraz, ihtiyatî tedbir kararını veren mahkemeye dilekçe ile yapılır (m. 394, 2). İtiraz eden, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazını dayandırdığı tüm delilleri dilekçesine eklemek zorundadır (m. 394, 4).

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, lehine ihtiyatî tedbir verilen kişi ile itiraz edeni duruşmaya davet edip dinledikten sonra, itirazı karara bağlar. Taraflardan biri veya ikisi gelmezse, mahkeme, dosya (evrak) üzerinde inceleme yaparak karar verir. Mahkeme itirazı haklı görürse, ihtiyatî tedbir kararını değiştirebileceği gibi, tamamen de kaldırabilir (m. 394, 4). Mahkeme itirazı haklı görmezse, itirazın reddine karar verir. Mahkemenin itiraz hakkında verdiği kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Tedbirin uygulanmasını durdurmayan bu başvuru, öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır (m. 394, 5; karş. İİK m. 265, V). İstinaf mahkemesinin verdiği karar kesindir. Çünkü, m. 362, 1/f hükmüne göre, geçici hukukî korumalar hakkında verilen kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

II) İhtiyatî tedbirin kalkmaması için, karar dava açılmadan önce verilmiş ise, tedbir isteyen, ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren **iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak** ve dava açtığını gösteren belgeyi dosyaya ibraz etmek **zorunda**dır (m. 397, 1). İhtiyatî tedbir kararı dava açıldıktan sonra verilmişse, m. 397, 1 hükmü uygulanmaz; zira, zaten dava açılmış durumdadır.

İki haftalık dava açma süresi, **ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasının talep edildiği tarihten** itibaren işlemeye başlar. Yani, iki haftalık sürenin işlemeye başlayabilmesi için ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasını beklemeye gerek yoktur. İhtiyatî tedbir kararı uygulanmışsa, iki haftalık süre, tedbir kararının uygulandığı tarihten itibaren değil, tedbir talep edenin ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasını talep ettiği (m. 393, 1) tarihten itibaren işlemeye başlar.

İhtiyatî tedbir isteyenin, bu iki hafta içinde davasını açmış olması yetmez, **dava açtığına ilişkin** (mahkemeden alacağı) **belgeyi**, aynı iki haftalık süre içinde ihtiyatî tedbir kararını uygulayan memura verip **ihtiyatî tedbir dosyasına koydurtması** ve karşılığında (dava açtığını gösteren belgeyi dosyaya koydurduğuna ilişkin) bir belge alması **zorunludur** (m. 397, 1).

İhtiyatî tedbir isteyen, ihtiyatî tedbir kararının verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde (m. 393, 1) kararın uygulanmasını talep etmezse veya kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmazsa veya açtığı halde dava açtığına ilişkin belgeyi aynı süre içinde ihtiyatî tedbir kararını icra eden memura (icra müdürü veya mahkeme yazı işleri müdürü) verip ihtiyatî tedbir dosyasına koydurtmazsa, ihtiyatî tedbir, hiç bir merasime (işleme) gerek kalmaksızın, **kendiliğinden** kalkar (m. 393, 1; 397, 1).

Uygulanmış olan ihtiyatî tedbirin fiilen kaldırılması ise, ancak ihtiyatî tedbir kararını uygulamış olan memur tarafından yapılabilir. Bu nedenle, aleyhi-

ne ihtiyatî tedbir kararı uygulanmış olan kişi (taraf), uygulanmış olan ihtiyatî tedbirin fiilen kaldırılmasını ihtiyatî tedbir kararını uygulamış olan memurdan isteyebilir. Bunun üzerine, ihtiyatî tedbir kararını uygulamış olan memur, ihtiyatî tedbirin fiilen kaldırılması için gerekli işlemleri yapar; örneğin ihtiyatî tedbir kararı üzerine mal kendisine teslim edilen yediemine, malı karşı tarafa vermesini bildirir veya taşınmaz üzerindeki ihtiyatî tedbir kaydının silinmesini tapu idaresinden ister vs. (m. 397, 3).

İhtiyatî tedbir isteyen, ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açarsa, ihtiyatî tedbir dava süresince (mahkemenin yeni bir kararı ile kaldırılmadıkça) devam eder. Bunun için, dava dilekçesinin aynı iki hafta içinde davalıya tebliğ edilmiş olması (ihtiyatî tedbirin devamını sağlamak için) şart değildir.

III) İhtiyatî tedbirin kaldırılmasının bir diğer yolu, **teminat** göstererek talepte bulunmaktır. Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilmiş olan taraf veya hakkında bu tedbir kararı uygulanan kişi, mahkeme tarafından kabul edilecek teminat (m. 87) gösterirse, mahkeme, duruma göre ihtiyatî tedbiri değiştirebilir veya kaldırabilir (m. 395, 1; karş. İİK m. 266). Mahkemenin bu kararına karşı istinaf yolu açık değildir. Bu halde ihtiyatî tedbir, teminat karşılığında kaldırılmakta ise de, aslında teminat üzerinde devam etmektedir.

IV) Davanın görülmesi sırasında, ihtiyatî tedbir kararı verilmesini gerektiren **durum ve koşullar değişirse**, davaya bakan mahkeme, talep üzerine, teminatsız olarak ihtiyatî tedbiri değiştirebilir veya kaldırabilir (m. 396).

V) Mahkemece aksi belirtilmiş (aksine karar verilmiş) olmadıkça, ihtiyatî tedbir kararının etkisi, **hükmün** (nihaî kararın) **kesinleşmesine kadar** devam eder (m. 397, 2)[3]. Kural böyle olmakla birlikte mahkeme, ihtiyatî tedbirin (kesinleşmeden önce) kalkacağına (örneğin, nihaî kararında, ihtiyatî tedbirin bu kararla birlikte kaldırıldığına) karar verirse, ihtiyatî tedbir kararının etkisi, bu kararla birlikte ortadan kalkacaktır.

İhtiyatî tedbir kendiliğinden kalkmış (m. 393, 1; 397, 1) veya mahkemenin kararı ile kaldırılmış ise bu husus ilgili yerlere bildirilir (m. 397, 3).

F) HAKSIZ İHTİYATÎ TEDBİRDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI

Yukarıda, ihtiyatî tedbir kararı verilirken, bunu isteyenin sonuçta haksız çıkması nedeniyle karşı tarafın veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararı karşılamak için bir teminat göstermek zorunda olduğunu görmüştük. İhtiyatî tedbir isteyen tarafın ihtiyatî tedbir talebinde bulunduğu anda haksız olduğu anlaşılırsa yahut ihtiyatî tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kaldırılırsa, karşı taraf veya üçüncü kişi, bu haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle uğradıkları zararın ödenmesini, ihtiyatî tedbir koydurmuş olan taraftan ayrı bir tazminat davası ile isteyebilir (m. 399, 1).

---

[3] HMK m. 397, 2 hükmü, HUMK m. 112'deki kuralı terse çevirmiştir. HUMK m. 112'deki kural, (mahkeme aksine karar vermedikçe) esas hakkındaki hüküm verilmesi (tefhim veya tebliğ edilmesi) anında, ihtiyatî tedbirin kalkmasını düzenlemekte ve eleştirilmekte idi.

Haksız olarak ihtiyatî tedbir koydurmuş olan tarafın sorumluluğu, haksız fiil sorumluluğuna (TBK m. 49 vd.) çok benzer; bu nedenle, kural olarak haksız fiil hakkındaki hükümlere tâbidir.

Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı açılacak olan tazminat davasının şartları, haksız fiil hakkındaki hükümlerden (TBK m. 49 vd.) de yararlanarak belirlenmektedir.

1) İhtiyatî tedbir kararı **uygulanmış olmalı**dır: Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası açılabilmesi için, ihtiyatî tedbir kararının verilmiş olması yeterli değildir; ihtiyatî tedbir kararının uygulanmış olması da gerekir. Çünkü, ihtiyatî tedbir kararı icra olunmadan, karşı tarafın veya üçüncü kişinin bundan bir zarar görmesi mümkün değildir.

2) İhtiyatî tedbir kararı **haksız olmalı**dır: İhtiyatî tedbir isteyenin bundan doğan zarardan sorumlu tutulabilmesi için, dava sonunda, ihtiyatî tedbirin haksız olduğunun anlaşılması gerekir. Örneğin:

Davacı, bir taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia ederek açtığı tescil ve müdahalenin önlenmesi davasında, davalının o taşınmaz üzerinde yaptırmakta olduğu inşaatın durdurulması için bir ihtiyatî tedbir kararı almış; fakat mahkeme, o taşınmazın davacıya değil bilâkis davalıya ait olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiş (ve bu ret kararı kesinleşmiş) ise, davacının koydurmuş olduğu ihtiyatî tedbir haksız demektir.

Davacı, dava konusu olan otomobil için ihtiyatî tedbir kararı almış ve otomobil bir yediemine teslim edilmiş; fakat mahkeme, dava konusu otomobilin davacıya değil, aksine davalıya ait olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiş (ve bu ret kararı kesinleşmiş) ise, davacının koydurmuş olduğu ihtiyatî tedbir haksız demektir.

3) Uygulanan ihtiyatî tedbir kararı sonucunda bir **zarar** ortaya çıkmalıdır: Aleyhine ihtiyatî tedbir kararı alınmış ve icra edilmiş olan tarafın veya üçüncü kişinin, bu haksız ihtiyatî tedbirden dolayı bir zarar görmüş olması gerekir; yukarıda (2) verilen ilk örnekte, inşaatın gecikmesinden dolayı uğranılan zararda olduğu gibi.

4) Zarar ile ihtiyatî tedbir arasında **uygun illiyet** (nedensellik) bağı bulunmalıdır: Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası açan davacının ödenmesini istediği zararı ile haksız ihtiyatî tedbir arasında uygun illiyet bağı (sebep-sonuç ilişkisi) bulunması gerekir. Yukarıdaki (2) örneklerde, zarar ile haksız ihtiyatî tedbir arasında uygun illiyet bağı vardır.

Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı olan sorumluluk davası için, haksız fiiller için aranan kusur şartı burada aranmaz. Burada, **kusursuz sorumluluk** hali vardır. Yani, haksız ihtiyatî tedbir koydurtmuş olan tarafın bundan doğan zararla sorumlu tutulabilmesi için, ihtiyatî tedbiri kötüniyetle istemiş ve koydurtmuş olması veya bunda herhangi bir ihmalinin bulunması şart değildir. İhtiyatî tedbir haksız ve bundan da bir zarar doğmuş ise, bu haksız ihtiyatî tedbiri koydurtmuş olan taraf, kusurlu olmasa bile bundan zarar gören karşı tarafa veya üçüncü kişiye tazminat ödemekle yükümlüdür.

Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası, aleyhine haksız olarak ihtiyatî tedbir konulmuş olan taraf veya bu haksız ihtiyatî tedbirden zarar

görmüş olan üçüncü kişi tarafından açılır (m. 399, 1). Yukarıdaki inşaatın durdurulması örneğinde, aleyhine haksız ihtiyatî tedbir konulmuş olan davalının iş ortağı da, bu haksız ihtiyatî tedbirden zarar göreceğinden tazminat davası açabilir.

Bu dava, haksız ihtiyatî tedbir kararı alarak uygulatan tarafa karşı açılır.

Dava, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılır. Başka bir deyişle, haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davasında yetkili ve görevli mahkeme, asıl davayı görüp karara bağlayan mahkemedir. (m. 399, 2)

Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası, **bir yıllık** (karş. TBK m. 72) **zamanaşımı**na tâbidir. Bu zamanaşımının başlangıcı, esas hükmün kesinleştiği veya ihtiyati tedbir kararının kalktığı tarihtir (m. 399, 3).

Bu tazminat davası sonucunda, haksız ihtiyatî tedbir koydurtmuş olan taraf (tazminat davalısı), davacıya tazminat ödemeye mahkûm edilirse davacı, bu tazminatını öncelikle davalının ihtiyatî tedbir kararı alırken göstermiş olduğu teminattan (m. 392) alır.

§ 53. DELİL TESPİTİ[1]

A) GENEL BİLGİ

Delil tespiti (tespiti delâil; kanıtların saptanması), ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delilin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet güvence altına alınmasını sağlamak için kabul edilen geçici hukukî koruma müessesesidir; örnekler:

İleride davada tanık olarak dinlenecek olan bir kişi ağır hastadır ve yakında öleceğinden korkulmaktadır. Bu kişi, henüz tanık dinleme aşaması gelmediği halde, delil tespiti yolu ile (mahkemece) daha önce dinlenir; ileride davada delillerin incelenmesine sıra gelince, tanığın (önceden tespit edilen) bu ifadesi, delil olarak değerlendirilir.

Trafik kazasında otomobili hasara uğrayan bir kişi, otomobilini, davanın sonuna (davada, bu hasarın -tahkikat aşamasında- tespitine sıra gelinceye) kadar, o şekilde bekletemez. Bunun için, delil tespiti yolu ile otomobilindeki hasarı (önceden) tespit ettirir ve bundan sonra otomobilini tamir ettirerek kullanmaya devam eder. Bu kişiye, "davada otomobilindeki hasarın tespitine sıra gelinceye kadar otomobilini tamir ettirmeden bekle" denemez; otomobil tamir edilince de, ileride dava sırasında bu hasarı tespit etmek çok zor olur. İşte bu sakıncayı önlemek için, otomobilindeki hasarın (delil tespiti yolu ile) hemen tespitinde hukukî yarar vardır.

Delil tespiti bir dava olmayıp, deliller hakkında, geçici bir hukukî korumadır; genel olarak, bir çeşit ihtiyatî tedbir gibidir. Ancak ihtiyatî tedbirde, dava konusu olan malın veya hakkın güvence altına alınması için o mal veya hakka tedbir konulduğu halde delil tespitinde, davanın karara bağlanmasına yardımcı olacak delilin kaybolmasını önlemek için tedbir alınmaktadır; delil, önceden tespit edilmektedir (m. 400).

Delil tespiti (talebi), uygulamada bazen hatalı olarak söylendiği üzere, **dava değildir**; aksine, ilişkin olduğu (açılacak veya açılmış) davaya bağlı bir işlemdir. Delil tespiti, ayrı (yalnız başına) bir dava konusu da olamaz. Çünkü delil tespitinin konusu, **maddî vakıalar**dır (olay ve olgulardır) ve maddî vakıalar ise yalnız başına tespit davasına konu yapılamaz (m. 106, 3).

Delil tespiti (talebi), **tespit davasından da farklı**dır. Çünkü delil tespiti, geçici hukukî koruma olduğu halde; tespit davası, kesin hukukî koruma sağlar. Bu nedenle, delil tespiti yoluna bir tespit davasının ispatına yarayacak delil tespiti için de başvurulabilir. Tespit davasının konusu sadece hukukî ilişkiler olduğu halde, delil tespitinin konusu maddî vakıalardır.

---

[1] Bkz. Leyla Akyol Aslan, Medenî Usul Hukukunda Delil Tespiti (Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre), Ankara 2011.

B) DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HALLER

Delil tespiti yoluna, **henüz inceleme sırası gelmemiş** yahut ileride açılması söz konusu olacak davada başvurulacak deliller için başvurulabilir (m. 400, 1). Yani delil tespiti, dava açılmadan önce de, sonra da istenebilir. Özellikle dava açıldıktan sonra, ancak kendisine inceleme sırası gelmemiş olan delillerin tespiti istenebilir (m. 400, 1). Dava açılmasından önce ise, ileride açılacak olan davada ileri sürülecek hususların (vakıaların) ispatı amacıyla tanık ifadesinin alınması, keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması gibi işlemlerin yapılması delil tespiti ile mümkün olur (m. 400, 1).

Buna göre, her türlü delilin tespiti istenebilir. Ancak, tespiti istenen deliller, ileride açılacağı bildirilen veya açılmış olan dava ile ilgili olmalıdır. Bu nedenle, dava açmadan önce delil tespiti isteyen kişi, delil tespiti talebinde, ileride açacağı davayı somut olarak belirtmelidir.

Delil tespitini isteyenin, delilin önceden (sırası gelmeden) tespit edilmesinde **hukukî yararı** bulunmalıdır. Kanunda açıkça öngörülen haller dışında, delilin hemen (şimdiden) tespit edilmemesi halinde ileride kaybolacağı (yok olacağı) veya gösterilmesinin çok güç olacağı ihtimal dahilinde (olası) olan delillerin, önceden tespit edilmesinde hukukî yarar vardır (m. 400, 2). Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi; ileride davada tanık olarak dinlenecek kişinin ağır hasta olması, uzun bir yolculuğa çıkmak üzere bulunması veya zamanla karşı tarafın etkisinde kalarak bildiğini söylemeyeceği veya yanlış söyleyeceğinden korkulan hallerde, o kişinin (tanığın) ifadesinin şimdiden (delil tespiti yolu ile) tespit edilmesinde hukukî yarar vardır. Trafik kazasında hasara uğrayan bir otomobilin durumunun (otomobilindeki hasarın) şimdiden (hemen) tespit edilmesinde hukukî yarar vardır. Çünkü, otomobil tamir edildikten sonra dava sırasında bu hasarın tespiti çok güç ve belki de imkânsız olabilir.

C) DELİL TESPİTİ USULÜ

Dava açılmadan önce talep edilecek delil tespitinde yetkili ve görevli mahkeme; **esas davaya bakacak olan mahkeme** veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer **sulh hukuk mahkemesi**dir (m. 401, 1).

Dava açıldıktan sonra delil tespiti için yetkili ve görevli mahkeme, yalnız **davaya bakan mahkeme**dir (m. 401, 4). Davaya bakan mahkemeden başka bir mahkeme, o davaya ilişkin delil tespiti için yetkili ve görevli değildir. Bu sebeple dava açıldıktan sonra, davaya bakan mahkemeden başka bir mahkeme, o davaya ilişkin delillerin tespitine karar veremez ve delil tespiti yapamaz; yaparsa, böyle bir delil tespiti geçersizdir.

Davaya bakan mahkeme tarafından tespitine karar verilen delil, davaya bakan mahkemenin yargı çevresi dışında ise, davaya bakan mahkeme, o delilin tespiti (örneğin tanığın ifadesinin alınması) için o delilin (örnekte tanığın) bulunduğu yer mahkemesini istinabe eder.

Delil tespiti, mahkemeden dilekçe ile istenir. Bu dilekçeye, tespiti istenen vakıa (olay veya olgu), tanıklara veya bilirkişilere sorulması istenilen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler yazılır. Dilekçede ayrıca, aleyhine delil tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresinin yer alması da gerekir. Ancak, tespit talebinde bulunan, durum ve koşulların imkân vermemesi nedeniyle, aleyhine tespit yapılacak kişiyi gösteremiyorsa delil tespiti talebi geçerli sayılır (m. 402, 1).

Delil tespiti dilekçesi, kural olarak, üç nüsha olarak verilir. Bunlardan birincisi mahkemede kalır, ikincisi karşı tarafa gönderilir, üçüncüsü de varsa bilirkişiye verilir.

Dava açılmadan önce delil tespiti isteyenden, başvurma harcı ve karar harcı (peşin olarak) alınır (m. 402, 2).

Davacı, aynı dilekçe ile hem delil tespiti isteyebilir hem de esas hakkındaki davasını açabilir. Bu halde, davacıdan yalnız bir (tek) başvurma harcı alınır. Delil tespiti isteyen, tespit için gerekli giderleri (ezcümle, tanık ve bilirkişi ücretleri ile keşif giderlerini) peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Bu giderler, ilerde açılacak olan davanın yargılama giderlerine dahildir. Mahkeme tarafından tespit edilen tespit giderleri, avans olarak mahkeme veznesine yatırılmadıkça, sonraki işlemler yapılmaz (m. 402, 2).

Delil tespiti isteyenin, mahkemeye delil tespiti şartlarının varlığı hakkında delil (delil tespiti talebini haklı kılan sebepleri) göstermesi gerekir. Fakat, buradaki **ispat tam bir ispat değildir**. Mahkemenin, delil tespiti şartlarının mevcut olduğuna kanaat getirmesi (onu kuvvetle muhtemel görmesi) yeterlidir.

Mahkeme, delil tespiti talebini yerinde (kabule şayan) görürse delilin tespitine karar verir. Delil tespiti kararına, tarafların kimlikleri ve adresleri, tespitine karar verilen deliller, vakıalar, dinlenecek olan tanıkların ve bilirkişilerin isimleri ve onlardan sorulacak hususlar yazılmalıdır.

Delil tespiti kararı, nihaî karar olmadığından **kanun yoluna götürülemez**. Fakat karşı taraf, delil tespiti kararına (delil tespiti şartlarının bulunmadığı gerekçesiyle) tebliğden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir (m. 403/son cümle). Bu itiraz, delil tespiti kararını vermiş olan hâkim tarafından incelenip karara bağlanır.

Mahkeme, delil tespiti talebini yerinde görmezse, yani delil tespiti şartlarının bulunmadığı kanısına varırsa, delil tespiti talebinin reddine karar verir. Bu ret kararı da kanun yoluna götürülemez. Ancak, aynı taraf, durum ve şartların değiştiğini bildirerek yeniden delil tespiti talebinde bulunabilir.

Mahkemenin delil tespiti kararının bir örneği (delil tespiti isteyenin dilekçesinin bir örneği ile birlikte) karşı tarafa tebliğ olunur. Kararda ayrıca, delil tespitinin nasıl ve ne zaman yapılacağı, tespitin yapılması sırasında karşı tarafın da hazır bulunabileceği, varsa itiraz ve ilâve soruların bir hafta içinde bildirilmesi istenir (m. 402, 3).

Buna göre delil tespiti, kural olarak, karşı taraf da hazır olduğu halde (her iki tarafın huzurunda) yapılır. Fakat, karşı taraf, usulüne uygun biçimde davet edildiği halde gelmezse delil tespiti yokluğunda yapılır. Delil tespiti isteyen ta-

rafın haklarını korumak için zorunluluk varsa veya acele hallerde, istisna olarak, mahkeme, karşı tarafa tebligat yapmadan (karşı tarafın yokluğunda) da delil tespiti yapabilir (m. 403, 1/c.1). Örneğin, keşif yapılacağını öğrenen karşı tarafın çekişmeli şeyin durumunu değiştirmesinden korkuluyor veya (bir mağazanın camlarının kırılmış olması nedeniyle uğranılan zararın tespitinde olduğu gibi) tespit edilecek şeyin olduğu gibi uzun süre bekletilmesi mümkün değilse, karşı tarafa tebligat yapılmadan (onun yokluğunda) delil tespiti yapılabilir. Fakat bu halde, yani delil tespitinin karşı tarafın yokluğunda yapılmış olması halinde, mahkeme, tespit dilekçesini, tespit kararını, tespit tutanağını ve varsa bilirkişi raporunun bir örneğini kendiliğinden ve derhal, karşı tarafa tebliğ etmek zorundadır (m. 403, 1/c. 2). Aksi halde, karşı tarafa tebliğ edilmemiş olan delil tespiti tutanağı, davada delil olarak kullanılamaz. Karşı taraf, tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına ve yapılan tespite itiraz edebilir (m. 403, 1/c. 3).

Deliller, (mahkemece) her delil hakkında geçerli olan usul hükümlerine göre tespit edilir (m. 404).

Delil tespiti ayrı bir dava olmayıp, ilişkin olduğu (açılacak veya açılmış) davaya bağlı bir işlem olduğundan, delil tespiti dosyası (delillerin tespiti için yapılmış ve düzenlenmiş bütün işlemler ve belgeler) esas dava dosyasının eki sayılır ve onunla birleştirilir (m. 405).

Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki sayıldığından, delil tespiti giderleri de asıl davanın yargılama giderlerine dahildir[2]. Bu nedenle istenmemiş olsa bile, mahkeme, diğer yargılama giderleri gibi, delil tespiti giderlerini de kendiliğinden hüküm altına almak zorundadır. Diğer yargılama giderlerinde olduğu gibi, delil tespiti giderleri de, ancak asıl davanın yargılama giderleri ile birlikte hüküm altına alınır; ayrı bir dava ile istenemez.

Delil tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan davada (sırası geldiğinde) kullanılmak üzere yaptırılır. Bu nedenle, yaptırılmış olan bir delil tespitine, taraflardan her biri, davada (sırası geldiğinde) dayanabilir; yani delil tespiti yolu ile tespit edilen delile dayanarak iddiasını veya savunmasını ispat edebilir. Bu husus, delil tespiti dosyasının esas dava dosyasının eki sayılmasının da doğal bir sonucudur.

Delil tespiti yolu ile tespit edilen delil takdirî delil ise, hâkim bu takdirî delili, asıl davada takdir etme yetkisine sahip olduğu gibi, taraflar da böyle bir takdirî delilin, delil değerini davada tartışma konusu yapabilirler. Bir dava sırasında alınmış olan bilirkişi raporunda olduğu gibi, taraflar, delil tespiti yolu ile alınmış olan bilirkişi raporuna karşı da m. 281, 1'deki iki haftalık süre içinde itiraz etmezlerse bilirkişi raporu (taraflar bakımından) kesinleşmiş olur. Artık taraflar, asıl dava sırasında, delil tespiti aşamasında, itiraz edilmemek suretiyle kesinleşmiş olan bu bilirkişi raporuna itiraz edemezler.

---

2 Bkz. 22.03.1976 gün ve 01/01 sayılı İBK (RG 28.04.1976, sa. 15572).

KANUN YOLLARI

§ 54. KANUN YOLU KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ

A) KANUN YOLU KAVRAMI

Mahkemelerin, önlerine gelen davaları (hukukî uyuşmazlıkları) kanuna, usule, en geniş anlamda hukuka (adalete) uygun ve tarafları tatmin edecek (tarafların güven duyacağı) şekilde, doğru olarak karara bağlamaları esastır. Bu husus, hukukun ve onun bir parçası olan yargılama hukukunun amacı ile de örtüşmektedir. Ancak, mahkemeleri oluşturan hâkimler de insandır ve yanılmamaları düşünülemez. İşte bu nedenle, mahkemenin verdiği kararı doğru bulmayan (bu karardan tatmin olmayan) tarafa, verilen kararı (genellikle) üst dereceli mahkemenin denetimine götürebilme ve bu mahkemede yeniden incelenmesini sağlama hakkının tanınması, hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir.

İlk derece (hüküm) mahkemesinin verdiği kararın yeniden incelenerek değerlendirilmesini sağlamak üzere, tarafa tanınan bir üst ve/veya yüksek mahkemeye başvuru olanağına, **kanun** (yasa) **yolu** denir.

Başka bir tanımla; kanun yolu, davanın taraflarına tanınan bir hukukî yoldur ki, bununla yanlış olan mahkeme kararlarının (daha doğrusu, yanlış olduğu iddia edilen kararların) tekrar incelenmesi ve değiştirilmesi sağlanır.

Kanun yollarına başvurma olanakları sonsuz değildir. Bir nihaî kararın kesinleşmesi için, kural olarak, iki kanun yolu kabul edilmiştir. Kararın bu kanun yollarından geçmesinden sonra veya bu kanun yollarına başvurma sürelerinin geçirilmesi ile karar kesinleşir; artık o karara karşı normal (olağan) bir kanun yoluna gidilemez. Kanun yoluna başvurmanın sınırlı olmasının nedeni, davada verilen kararın belli bir aşamada kesinleşmesinin ve böylece uyuşmazlığın sona ermesinin sağlanmasıdır. Aksi halde, uyuşmazlığın bir türlü sona erdirilmeyerek belirsiz halde bırakılması, toplumda huzursuzluğa neden olur ve adalete olan güven sarsılırdı.

Medenî usul hukukundaki kanun yolları, nihaî kararlar için kabul edilmiştir. Mahkemelerin nihaî olmayan kararlarına (ara kararlarına)[1] karşı gidilebilecek kabul edilmiş genel bir kanun yolu yoktur. Buna karşılık, **nihaî** (hâkimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran) **kararlara karşı**, kural olarak, kanun yolu açıktır.

Medenî usul hukukumuzdaki kanun yolları, 5235 sayılı Adlî Mahkemeler Kanunu ile HUMK'nu değiştiren 5236 sayılı Kanundan önce, **temyiz** (HUMK m. 427-439, 443); **karar düzeltme** (HUMK m. 440-442) ve **yargılamanın iadesi** (HUMK m. 445-454) olarak düzenlenmişti.

---

[1] Bunun istisnası ihtiyatî tedbir kararlarıdır (m. 391, 3; 394, 5).

5235 ve 5236 sayılı Kanunlarla, ilk derece mahkemeleri kararlarına karşı başvurulabilecek ilk kanun yolu olarak istinaf müessesesi (kanun yolu) kabul edilmiş; karar düzeltme yolu kaldırılmış ve (istinaftan sonraki ikinci kanun yolu olan) temyiz müessesesi (kanun yolu) yeniden düzenlenmiştir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK, 5235 ve 5236 sayılı kanunlarla kanun yolu konusunda yapılan değişiklikleri birkaç istisna dışında aynen benimsemiştir.

İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri, **20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete başlamıştır**. Bu nedenle, Hukuk Muhakemeleri Kanununun istinafa ilişkin hükümleri (m.341-360) ile temyize ilişkin hükümleri (m. 361-373) 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

HMK'nun Geçici 3. maddesine göre, **20 Temmuz 2016 tarihinden önce** (yani, 19 Temmuz 2016 tarihi ve bu tarihten önce) verilmiş bulunan[2] kararlar hakkında, bu kararlar kesinleşinceye kadar, 1086 sayılı **HUMK'nun 427 ilâ 454. madde hükümleri** uygulanmaya devam olunacaktır.

Geçici 3. maddede (1086 sayılı) HUMK'nun 427 ilâ 454. maddelerine yollama yapılmış olması sebebiyle, **20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş bulunan kararlar hakkında,** HUMK tarafından düzenlenen **temyiz, karar düzeltme** ve **yargılamanın iadesi yolları geçerli olacaktır.** Geçici 3. maddede yer alan, "kesinleşinceye kadar" ibaresi ve HUMK'ndaki temyiz ve karar düzeltme ile HUMK'nun 445-454. madde hükümlerine atıf yapılmış olması nedeniyle yargılamanın iadesi hükümlerinin uzun bir süre daha yürürlükte kalacağı açıktır. Ülkemizde mahkeme kararlarının kesinleşmesi süreçleri oldukça uzun sürmektedir. Buna göre, aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, örneğin 19 Temmuz 2016 tarihinde verilen (veya ondan önceki tarihli) karara karşı, istinaf yoluna değil, HUMK m. 427 vd. hükümlerine göre temyiz yoluna başvurulacaktır. Daha önce temyiz (karar düzeltme) aşamasında bulunanlar hakkındaki temyiz (karar düzeltme) incelemesi de HUMK m. 427 vd. hükümlerine göre yapılmaya devam olunacaktır. Bu kararların Yargıtayca bozulması halinde dosya, ilk derece mahkemesine gönderilecek, ilk derece mahkemesi bozma kararını taraflara tebliğ edecek, karar düzeltme yolu açık olanlar için karar düzeltme yolu söz konusu olacak, diğer kararlarda mahkeme bozmaya uyarsa bu çerçevede yapacağı yargılama sonunda vereceği kararlara (direnirse direnme kararlarına) karşı HUMK m. 427 vd. hükümlerine göre temyiz (ve karar düzeltme) yoluna başvurulacak ve bu durum, bu kararlar şeklen kesin hüküm haline gelinceye kadar devam edecektir.

Benzer şekilde, 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş bulunan kararlara karşı gidilecek olan yargılamanın iadesi yolunda da, HUMK'nun yargılamanın iadesine ilişkin hükümler (HUMK m. 445-454) uygulanacak ve bu şekilde açılan/açılacak yargılamanın iadesi davasında verilen kararlar hakkında da, bunlar kesinleşinceye kadar, HUMK'nun temyiz ve karar düzeltme hükümlerinin tatbikine devam olunacaktır.

---

[2] HMK'nun Geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, **"aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan"** ibaresi, 6723 sayılı Kanunla (m. 34) **"verilen"** olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle HMK'nun kabulünden (04.02.2011'den) sonra, fakat yürürlüğe girmesinden (01.10.2011'den) önce, 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun ile HMK'na Geçici Madde 3 eklenmiştir. Bu madde fıkra (1)'e göre, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek olan göreve başlama tarihine[3] kadar, 1086 sayılı HUMK'nun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Aynı madde (Geçici Madde) 3 fıkra (2)'ye göre, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce, verilen[4] kararlar hakkında, **kesinleşinceye kadar** 1086 sayılı HUMK'nun (5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki) 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.

HMK'nda istinaf (bölge adliye) mahkemelerine görev verilen hallerde, bu mahkemelerin göreve başlama tarihine 20.07.2016'ya kadar 1086 sayılı HUMK'nun bu Kanuna (HMK'na) aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle, Kitabımızın bu (kanun yolları) bölümünde, uygulanmaya devam edilecek olan kanun maddeleri önüne (HUMK), istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlamasından sonra, uygulanacak olan kanun maddeleri önüne (HMK) adı konulmuştur.

Bu son düzenlemeye göre kanun yollarını aşağıdaki gibi iki grup altında toplamak (ve incelemek) mümkündür:

B) KANUN YOLU ÇEŞİTLERİ

I – OLAĞAN KANUN YOLLARI

Nihaî kararların kesinleşmesine engel olan kanun yollarına, **olağan** (normal, adi) **kanun yolları** denir. Olağan kanun yollarına başvurulması halinde, hakkında kanun yoluna başvurulan nihaî karar bu yollardan geçmeden (bu kanun yolları denetimi tamamlanmadan) kesinleşmiş olmaz. Başka bir deyişle, olağan kanun yolu, **henüz kesinleşmemiş** olan nihaî kararlar için tanınmış bir yoldur. Bir nihaî karara karşı üst mahkemeye başvurulursa, yani olağan kanun yoluna gidilirse, o kararın kesinleşmesi önlenmiş ve böylece kesinleşme, kanun yoluna başvurunun sonucuna kadar ertelenmiş olur.

---

3 20.07.2016 tarihine kadar (RG 07.11.2015, sa. 29525).

4 "...6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan' ibaresi 'verilen' şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 'Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez" (6723 s. K. m. 34; RG 23.07.2016, sa. 29779 2. Mükerrer). 6723 s. K. ile yapılan değişiklik 23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, istinaf mahkemelerinin göreve başladığı 20 Temmuz 2016 günü itibariyle bu değişikliğin uygulanması gerektiği kanısındayız. Kanun koyucunun amacı, istinaf mahkemelerinin göreve başlamasından önce verilen kararlara karşı temyiz yoluna gidilmesi olup, bu dosyaların bölge adliye mahkemelerine gönderilemeyeceğini özellikle vurgulamıştır.

Olağan kanun yolu açık olan nihaî kararlara karşı süresi içinde, bu yola gidilmezse veya gidilir de verilen karar usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunursa ve başka bir olağan kanun yolu da yok ise, karar kesinleşir.

HMK'na göre, genel olarak, **istinaf** ve **temyiz** olmak üzere iki çeşit olağan kanun yolu vardır.

Hukukumuzda istinaf yolunun kabulünden önce mevcut olan ve aşağıda belirtileceği üzere, HMK'nun yürürlüğünden sonra bir süre daha uygulanacak olan **karar düzeltme** yolu da bir kanun yoludur.

II – OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

Kesinleşmiş hükümlere karşı başvurulabilecek kanun yoluna, **olağanüstü** (fevkalâde) **kanun yolu** denir. Burada hüküm, olağan kanun yollarından geçerek veya süresi içinde bu yollara gidilmeyerek kesinleşmiştir (şeklî anlamda kesin hüküm). Bu kesinleşmeden sonra, kural olarak aynı konuda, aynı dava sebebine dayanarak, aynı taraflar arasında bir dava açılamaz; açılırsa dava şartı gerçekleşmediğinden dinlenmez (maddî anlamda kesin hüküm; m. 303). Ancak, bazı ağır usul hataları yapılarak verilmiş olan yanlış hükümlerin kaldırılmasını veya değiştirilmesini sağlamak için, olağan olmayan, olağanüstü bir kanun yolu kabul edilmiştir ki, buna **yargılamanın iadesi** (yenilenmesi) denir (m. 374 vd.). Yargılamanın iadesi yolu, aşağıda, kesin hükümden sonra incelenecektir.

Kanun yararına temyiz (m. 363; HUMK m. 427,VI-VIII) de, bazı özellikleri dikkate alındığında, bir olağanüstü kanun yoludur.

C) GENEL OLARAK KANUN YOLLARINA BAŞVURU USULÜ

Bir karara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı, Kanun tarafından belirlenir. Mahkemenin, kanuna göre kanun yolu kapalı olan bir kararın kanun yoluna götürülebileceğini, örneğin, temyiz edilebileceğini kararında göstermiş olması o kararın (hükmün) temyiz incelemesinin yapılmasını sağlamaz; mahkemenin temyizi mümkün bir kararın temyiz edilemeyeceğini hükmünde bildirmiş olmasının da hukukî bir değeri yoktur. Çünkü, bir karara karşı kanun yolunun, örneğin temyiz yolunun açık olup olmamasında esas olan, mahkemenin kararı değil, kanun hükmüdür.

Dava açmakta olduğu gibi kanun yoluna başvurmada da, başvuran tarafın **hukukî yararının** bulunması şarttır. Başka bir deyişle, kanun yoluna başvuranın, aleyhine kanun yoluna başvurduğu kararın kaldırılması veya değiştirilmesinde, hukuken korunmaya değer (hukukî) yararının bulunması gerekir.

Buna göre davacı, kural olarak, lehine verilmiş bir hükmü (nihaî kararı) kanun yoluna götüremez. Bunun gibi davalı da, kural olarak kendisine karşı açılmış olan davanın reddine ilişkin hükme karşı kanun yoluna başvuramaz. Ancak bunun için, hükmün, onu kanun yoluna götürmek isteyen tarafın talep sonucuna tamamen uygun bulunması gerekir. Mahkemenin hükmü ile hüküm lehine olan tarafın talep sonucu arasında fark varsa, o tarafın hükmü kanun yoluna götürmekte hukukî yararı vardır. Örneğin, davası kısmen ka-

bul, kısmen reddedilen davacının hükmü kanun yoluna götürme hakkı vardır; bunun gibi kendisine karşı açılan dava tamamen reddedilen ve fakat buna rağmen yargılama giderlerine mahkûm edilen davalı da hükme (yargılama giderlerine ilişkin bölümüne) karşı kanun yoluna gidebilir.

Buna karşılık, hüküm bir tarafın talep sonucuna tamamen uymakta ve fakat gerekçesi o tarafın ileri sürdüğü gerekçeye aykırı ise, o tarafın, kural olarak hükmü kanun yoluna götürme hakkı (yetkisi) yoktur. Çünkü, kanun yolu ile ancak hüküm sonucunun kaldırılması veya değiştirilmesi istenebilir. Ancak, hüküm sonucuna zorunlu bir şekilde bağlı olan ve bu nedenle kesin hüküm teşkil eden gerekçeye karşı hüküm lehine olan taraf kanun yoluna başvurabilir. Bundan başka, karşı tarafın (davada haksız çıkan tarafın) kanun yoluna gitmesi üzerine hükmün kaldırılması veya bozulması halinde karşı taraf lehine ve hüküm lehine olan taraf aleyhine usulî kazanılmış hak doğacak ise, hüküm lehine olan tarafın bunu önlemek için (lehine olan) hükmü kanun yoluna götürmekte hukukî yararı vardır. İşte bu amaçla, "davada haklı çıkmış olan taraf da, hukukî yararı bulunmak şartıyla, temyiz yoluna başvurabilir" hükmü (m. 361, 2; HUMK m. 427, II) kabul edilmiştir.

Hukukî yararları varsa, her iki taraf da bir kararı kanun yoluna götürebilir; örneğin davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine ilişkin hükümlerde olduğu gibi.

Kanun yoluna başvurmada aranan, burada genel olarak açıklanan hukukî yararın her bir kanun yolunda gösterdiği özellikler, aşağıda ayrıca incelenecektir.

Her kanun yoluna başvurma, **belli bir süreye tâbi**dir (bkz., m. 345; 361; 377; HUMK m. 432; 440; I; 447). Bu süre içinde, bir nihaî karara karşı kanun yoluna başvurulmazsa, kanun yoluna başvurma hakkı düşer. Geçirilen süre olağan kanun yolu süresi ise, karar (şeklî anlamda) kesinleşir.

Kanun yoluna başvurma hakkından **feragat edilebilir**. Ancak, feragatin geçerli olabilmesi için, somut olayda, kanun yoluna başvurma hakkının doğmuş ve ilâmın tebliğ edilmiş olması gerekir (m. 349, 1; 366). Örneğin, mahkemenin verdiği nihaî karar, 01 Mart 2018 tarihinde tarafa tebliğ edilmişse, hüküm aleyhine olan taraf, tebliğ anından itibaren istinaf yoluna gitmekten feragat ettiğini bildirebilir; buna karşılık, 01 Mart 2018 tarihinden önce istinaf yoluna gitmekten feragat edilemez; edilirse, bu feragat geçersizdir.

Kanun yoluna gitmekten feragat, genellikle, hükmün bir an önce kesinleşmesini sağlamak amacıyla yapılır. Aksi takdirde hükmün kesinleşmesi için, kanun yolu süresinin sonunun beklenmesi gerekir.

Kanun yoluna başvurduktan sonra da kanun yolu talebinden feragat edilebilir. Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya istinaf mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya, istinaf mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamışsa başvuru feragat nedeniyle reddedilir (m. 349). Bu hükümler temyiz yolunda da uygulanır (m. 366).

Asıl kanun yoluna başvuran, kanun yolu talebinden feragat ederse, katılma yoluyla kanun yoluna başvuranın istemi de reddedilir (m. 348, 2; 366).

Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli personele teslim edilir. Kanun yoluna başvuru dilekçesi, harca tâbi değilse hemen, harca tâbi ise harç ödendikten sonra kaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir. **Kanun yolu başvurusu**, kanun yolu dilekçesinin **kaydedildiği tarihte** yapılmış sayılır. Başka yer mahkemesine verilen kanun yoluna başvuru dilekçelerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fiziki ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır. Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesaî saatleri içinde yapılır (Y m. 208, 1-7).

Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için, elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler, elektronik ortamda yapacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur (Yönetmelik m. 208, 8).

Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile, kanun yolu başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur. Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu, başvuru için son gün saat 00:00'a kadar yapılabilir (Y m. 208, 9-10).

Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir (Y m. 208, 11).

D) UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ

Yukarıda açıklandığı üzere; HMK'nun 6217 s. K. ile eklenen Geçici 3. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre; istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlama tarihine (20.07.2016) kadar, 1086 sayılı HUMK'nun (5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki) temyize ilişkin hükümleri uygulanmıştır (HMK Geçici Madde 3, 1). Bu vesile ile belirtelim ki, HUMK'nun temyize ilişkin hükümleri, HUMK'nun "üçüncü bab"ının birinci faslının, "temyiz" üst başlığı altındaki 427 ilâ 444. madde hükümleridir. Bu hükümlerin içe-

risine, hem temyiz hem de karar düzeltme ile ilgili hükümler girdiğinden, HUMK'nun temyize ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin faaliyete başlamasına kadar uygulanmıştır.

Aynı şekilde, HMK Geçici 3. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre ise; istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen[5] kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı HUMK'nun (5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki) 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır. Bu hükümlerin içerisine, hem **temyiz** hem **karar düzeltme** ve hem de **yargılamanın yenilenmesi** (iadei muhakeme) hükümleri girdiğine göre, HUMK'nun kanun yollarına ilişkin hükümleri; 20.07.2016 tarihinden önce verilmiş olan kararlar bakımından, hükmün şeklen kesinleşmesine kadar ve daha sonra söz konusu olabilecek yargılamanın yenilenmesi talepleri hakkında da uygulanacaktır. 20.07.2016 tarihinden önce verilmiş bulunan bu kararlara ilişkin dosyalar istinaf (bölge adliye) mahkemelerine gönderilmeyecektir (6723 s. K. m. 34).

HMK Geçici m. 3 hükmünde yer alan bu düzenleme; HMK'nun 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve HUMK'nun da, kural olarak, aynı tarih itibariyle tümüyle ortadan kaldırılacağını belirten 450. maddesinin önemli bir istisnasını oluşturmaktadır.

Önemle belirtelim ki; Geçici Madde 3, 2'deki "**kesinleşinceye kadar**" ibaresi; bir hükmün (şeklen) kesinleşme usulleri ve ülkemizdeki fiilî uygulamanın bilinen durumu dikkate alındığında ortalama sekiz-on yıllık (ve istisnaî hallerde çok daha uzun) bir dönemi ifade etmektedir.

Bu nedenle, Kitabımızın bu bölümünü, yukarıda belirtilenlere uygun olarak, iki alt bölüme ayırarak açıklamalar yapmayı uygun bulduk:

Birinci alt bölümde, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlamasından sonraki (**HMK hükümlerine göre**) kanun yolları (istinaf, temyiz ve yargılamanın yenilenmesi); **ikinci alt bölüm**de ise, istinaf mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar (ve o tarihte mevcut davalar kesinleşinceye kadar) **HUMK hükümlerine göre uygulanacak** olan kanun yolları (temyiz, karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi) anlatılacaktır.

---

[5] Bkz. yuk. dn. 2.

§ 55. İSTİNAF[1]

A) NİTELİĞİ

İstinaf[2], sözlük anlamıyla, "yeniden başlama" demektir. Teknik ve **klâsik** (en eski) **anlamda istinaf**ta, uyuşmazlık, ilk derece mahkemesinin önünde cereyan etmiş yargılamadan tamamen bağımsız olarak, yeni ortaya çıkan değişiklikler ve bir sınırlamaya tâbi olmaksızın ileri sürülebilen yeni delil ve olayları da gözönünde tutarak, istinaf (bölge adliye) mahkemesi tarafından aynen yeniden (tekraren) ele alınmakta ve uyuşmazlık hakkında karar verilmektedir. Yani, bu (geniş) anlamdaki istinaf anlayışında, ilk derece mahkemesinin incelediği ve değerlendirdiği vakıalar, ondan bağımsız olarak ikinci derecede görev yapan istinaf mahkemesinde de incelenir ve değerlendirilir. Vakıaların (yeniden) incelenmesi sebebiyledir ki, **istinaf mahkemeleri**ne (hukukî denetim makamı olan temyiz mahkemesinin yaptığı işin aksine), **vakıa** (olay) **mahkemesi** de denir.

Dar anlamda istinafta ise, ilk derece mahkemesinde tamamlanmış olan yargılama, istinaf mahkemesinin önünde baştan sona aynen tekrarlanmaz ve maddî vakıalar, yalnızca gereken hususlarda (sınırlı olarak) yeniden incelenerek karara varılır. Bugün için genel eğilimin, dar anlamda istinaftan yana olduğu söylenebilir. Bu eğilimde (anlayışta) olanlara göre, ilk yargılamayı baştan sona tekrarlamak, davaların istenmeyecek şekilde uzamasına, usul ekonomisi ilkesinin ihlâline neden olabilir. Nitekim, kanun koyucu da HMK'nun istinafa ilişkin kurallarını dar anlamda istinaf anlayışına uygun düzenlemiştir.

Kanun koyucu, doktrinde istinaf lehine ve aleyhine olan görüşlerden istinaf lehine olan görüşü tercih etmiş ve incelemekte olduğumuz düzenlemeleri yapmıştır.

5236 sayılı Kanunun Genel Gerekçesine göre: "İlk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, maddî hukuka ve usul hükümlerine uygunluğunu denetlemek üzere bölge adliye (istinaf) mahkemeleri kurulmuş ve **Yargıtaya da** temyiz olunan kararların yalnızca hukuka uygunluğunu denetleme ve **içtihat mahkemesi** olma **görevi verilmiş olduğundan,** istinaf yoluna başvuru ve bu mahkemelerce uygulanacak usul hükümlerinin Hukuk Usulü

---

1 **İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016 TARİHİNDEN) SONRA VERİLEN KARARLAR HAKKINDA UYGULANAN HÜKÜMLER**

2 Bkz. Ejder Yılmaz, İstinaf, Ankara 2005; Tolga Akkaya, Medenî Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009; Cenk Âkil, İstinaf Kavramı, Ankara 2010; Deniz Meraklı Yayla, Medenî Usul Hukukunda İstinaf Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014; Muhammet Özekes, 100 Soruda Medenî Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz Ankara 2016; Halûk Konuralp/Emel Hanağası, Fransız Hukukunda İptal Amaçlı İstinaf Yolu (LEGAL Hukuk Dergisi, Haziran 2007, s. 1795-1818); Emel Hanağası, Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri (Açık Sayfa 2005/60, s. 38-43); Emel Hanağası, Hukuk Davalarında İstinaf Usulü (Açık Sayfa 2005/60, s. 44-56).

Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ve Kanunun ilgili hükümlerinde gerekli değişikliğin yapılması" gerekmiştir.

İstinaf, henüz kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen ve üst mahkemeye başvurulmasını gerektiren bir yol olması nedeniyle, olağan (normal) kanun yollarından biridir.

B) İSTİNAF SİSTEMİNE EGEMEN OLAN İLKELER

5236 sayılı Kanunun Genel Gerekçesinden de görüleceği üzere, 5236 sayılı Kanunla kabul edilen ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri içine alınan istinaf yolu, klasik istinaf değil, **dar anlamda istinaf** yoludur. Yani, istinaf (bölge adliye) mahkemesi, her olayda, mutlaka ilk derece mahkemesinin yaptığı tüm yargılamayı tekrarlamayacaktır. Bunun pratik anlamı şudur: **İstinaf mahkemesi bazı davalarda,** aynen bugünkü Yargıtay gibi **hukukî denetim mahkemesi,** (adeta temyiz derecesi) olarak görev yapacaktır.

5236 sayılı Kanunun Genel Gerekçesinden, kanun koyucunun istinaf yolunun işleyişinde aşağıdaki ilkelerden hareket ettiği anlaşılmaktadır:

1) İlk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygunluğunun tespiti halinde, **yeniden yargılama yapılmaksızın**, istinaf başvurusunun **esastan reddine karar** verilecektir.

2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edildiği saptandığında, bu durum **yeniden yargılama yapılmasını gerektirmiyorsa** veya sadece kararın gerekçesinde hata yapıldığı tespit edildiğinde istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararının bu hatalarını düzelterek **esas hakkında yeniden karar** verecektir.

3) Yargılamada bulunan **eksikliklerin duruşma yapılmaksızın tamamlanabilecek nitelikte bulunması** durumunda, istinaf mahkemesi bunların tamamlanmasını takiben **esas hakkında yeniden karar verecektir**.

Temyiz uygulamasında ise, yargılamada tespit olunan bu tür eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte bulunsa dahi Yargıtayın temyiz denetimi yapması nedeniyle, bunlar tamamlanamamakta, bu eksikliklerin giderilmesi bozma sebebi yapılarak dosya mahkemesine gönderilmektedir. Bu durum yargılamanın uzamasına sebep olmaktadır.

4) İstinaf mahkemelerinin **miktar veya değeri, temyiz sınırı**nı (m. 362[3], 1/I, a) **geçmeyen davalar**da vereceği kararlar kesindir; yani istinaf mahkemesinin verdiği bazı kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır. Bu husus Yargıtayın gerçek işlevine kavuşmasını temin bakımından önemlidir. Eğer böyle bir hüküm olmasa idi, Yargıtay yine aşırı iş yükü altında kalmaya devam eder ve bu durum, işlevini yerine getirmesine engel olurdu.

5) İstinaf mahkemesi, ancak maddî hukuk veya usul hukukunda yer alan kamu düzenine ilişkin hükümlere aykırılık oluşturan bazı hallerde (m. 355),

---

[3] 2019 yılı için 58.800 TL'nı geçmeyen kararlar kesindir. 6763 s. K ile HMK'na eklenen Ek Madde 1 uyarınca parasal sınırlar, her takvim yılı itibariyle yeniden değerleme oranında güncellenecektir.

ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yargı çevresinde uygun göreceği başka bir mahkemeye ya da görevli ve yetkili mahkemeye (mahkemesine) gönderecektir.

6) İstinaf mahkemesi, **yeniden yargılama yapılmadan** sonuca ulaşılmasına olanak bulunmayan durumlarda, kuşkusuz davaya başından itibaren bakarak karar verebilecektir.

7) İstinaf mahkemelerinde bazı işlemlerin yapılması söz konusu olmayacaktır. Bu çerçevede istinaf mahkemesinde karşı dava açılamayacak, davaya müdahale isteminde bulunulamayacak, ıslah ve davaların birleştirilmesi istenemeyecek, yeni delil ileri sürülemeyecek, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenmeyecek, bu mahkemeler için yetki sözleşmesi yapılamayacaktır.

Bu ilkelerden de görüleceği üzere, kanunumuzun kabul ettiği istinaf yolu, (yineleyerek belirtirsek) **dar anlamda istinaf** yoludur. Bunun nedeni, davaların uzamasının önüne geçilmesi düşüncesidir. Kabul edilen bu yöntemle yargılamanın "maddî gerçeğin ortaya çıkarılması" şeklindeki amacı ile "yargılamanın makul sürede bitirilmesi" ilkesi dengelenmek istenmiştir.

C) ALEYHİNE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR

HMK'nun, "İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar" kenar başlığını taşıyan 341. maddesinde, hangi mahkeme kararları aleyhine istinaf yoluna gidilebileceği belirlenmektedir. Anılan m. 341 hükmü, bu konuda bazı koşullar koymaktadır:

I – İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI OLMASI ŞARTI

Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilecek olan kararlar (m. 341), herşeyden önce, ilk derece mahkemesi kararlarıdır. İlk derece mahkemesi kararları, kanunlara göre, bir uyuşmazlığın çözümü için tarafların ilk olarak başvurdukları (genel ve özel görevli) mahkemelerin kararlarıdır.

II – NİHAÎ KARAR ŞARTI

İlk derece mahkemelerinin her türlü kararlarına karşı istinaf yolu açık değildir. İstinaf yoluna gidilebilecek olan kararlar, kural olarak nihaî kararlardır[4]. Bu nihaî kararların dayanağı, davacının esastan haklı bulunması sebebiyle davanın kabulü, davanın zamanaşımından dolayı reddi kararlarında olduğu gibi maddî hukuk olabilir veya görevsizlikten veya başka bir dava şartı bulunmamasından reddi kararlarında olduğu gibi usul hukuku kuralları da olabilir.

---

[4] İlk derece mahkemelerinden verilen ancak nihaî karar niteliğinde olmayan ihtiyatî tedbir kararlarına karşı da istinaf yolu açıktır (m. 391, 3; 394, 5)

III – BELLİ PARASAL SINIRI (İSTİNAF SINIRINI) GEÇME ŞARTI

Kanun koyucu, ilk derece mahkemelerinin her türlü nihaî kararına karşı istinaf yolunu açmamıştır. Miktar veya değeri, Kanunun (m. 341, 2) aradığı belirli bir tutarı (sınırı-2019 yılı için: 4.400TL'nı) geçmeyen **malvarlığı davalarına ilişkin kararlar** kesin olup, bunlara karşı (karş. İİK m. 363) istinaf yoluna başvurulamaz.

İstinaf yoluna başvurulabilmesi için böyle bir sınırın getirilmesinin, hak arama özgürlüğü bakımından yerindeliği tartışılabilir. Ancak böyle bir sınırın getirilmemesi ve miktar veya değeri ne olursa olsun ilk derece mahkemesinin her türlü nihaî kararına karşı istinafa gidilmesi, istinaf mahkemelerinin işlerini çok artırabilirdi. Nitekim, temyiz sistemimiz (HMK m. 362, 1/a; HUMK m. 427) bakımından da mevcut bulunan benzeri hükmün, Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi, 20.01.1986 günlü ve 23/02 sayılı kararında "bu sınırın konulmasıyla davaların hızlandırılması ve Yargıtay'ın iş yükünün bir ölçüde azaltılmasının amaçlandığı; bu sınırlamanın kamu yararına yönelik olduğu ve hak arama hürriyetinin de kamu yararı dikkate alınarak sınırlanabileceği" gerekçesiyle, anılan hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir[5].

Kanunun (m. 341, 2) belirlediği parasal **sınır, "malvarlığı davaları" içindir.** "Malvarlığı davaları" terimi, taşınır ve taşınmaz mal davalarıyla her türlü alacak davasını da kapsar. Bu hüküm, temyizdeki sınır ile ilgili olan HUMK m. 427, 2 hükmünden daha geniş, HMK m. 362, 1/a hükmünden ise daha dardır. Ancak **manevî tazminat davalarında** verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir (m. 341, 2/2).

İstinaf yoluna başvurabilmek için belirlenen sınır, doğrudan doğruya o davanın konusu bakımından değil, istinaf yoluna başvuran kimsenin **hukukî yararı** açısındandır. Bu sebeple, istinaf için aranan sınır bakımından; alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kesinlik sınırı, alacağın tamamına göre belirlenir (m. 341, 3). Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü m. 341, 2'deki sınırı geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz (m. 341, 4).

Buna göre: Davacı (A), (B)'ye karşı altı bin liralık bir dava açmış olsa ve mahkeme bu davanın üç bin liralık kısmının kabul, üç bin liralık kısmının reddine karar verirse, bu hükme karşı tarafların hiçbirisi istinaf yoluna başvuramaz. Çünkü her ikisinin de hukukî yararı m. 341, 2'deki sınırı geçmemektedir. Buna karşılık, aynı davada mahkeme beş bin liralık kısmı kabul, bin liralık kısmı reddetmiş ise, bu hükme karşı yalnızca davalı istinaf yoluna gidebilir; davacı bu hükmü istinaf edemez. Çünkü, bu ihtimalde davalının aleyhine olan tutar, m. 341, 2'deki sınırdan fazladır ve hükmü istinaf yoluna götürmekte hukukî yararı vardır. Oysa, davacının talebinin reddedilen kısmı m. 341, 2'deki sınırı aşmadığından, davacı istinaf yoluna başvuramaz.

---

[5] Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu (TBB Dergisi, 1988/1 s.131-155; Yılmaz, Makaleler C. 1, s. 607-526). Karar için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 90-94.

İstinaf yoluna başvurma hakkı olanlar, davanın taraflarıdır. Ferî müdahil (m. 66 vd.) kural olarak, tek başına istinaf yoluna başvurma hakkı olmadığından, ancak davaya katıldığı tarafla birlikte hükme karşı istinaf yoluna gidebilir. Buna karşılık, aslî müdahalede (m. 65) aslî müdahil, davanın tarafı olduğundan, tek başına istinaf yoluna gidebilir.

HMK'nun 341. maddesinin 5. fıkrası, geçiş dönemi bakımından önemli bir hüküm daha içermektedir. Buna göre: İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da istinaf mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihaî kararlarına karşı istinaf mahkemelerine başvurulabilir. Eğer özel bir kanun hükmü, bir hususta verilen nihaî kararın kesin olduğunu veya yalnız başına temyiz edilemeyeceğini belirtmekte ise, söz konusu olan "temyiz" tabiri, kanun yolu (istinaf) anlamına geldiği sürece, bu kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

D) İSTİNAF SEBEPLERİ

Kanun koyucu, istinaf sebeplerini saymamış; istinaf sebepleri şunlardır şeklinde bir düzenleme yapmamış; temyiz sebeplerinin tek tek gösterilmesinin (m. 371; HUMK m. 428) aksine, istinaf yolunun niteliğine uygun olarak, genel bir sebep göstermiştir (m. 353/6, 1; 342, 2/e).

Kanunumuzun özellikle özel bazı istinaf sebeplerinin yer aldığı m. 353 hükmüne bakılarak; istinaf sebebinin, "ilk derece mahkemesi kararının **usul ve esas yönünden hukuka uygun olmadığı**" şeklinde düzenlendiği söylenebilir. *İstinaf sebepleri bu haliyle, temyiz sebeplerinden* (m. 371; HUMK m. 428) çok daha geniş bir çerçeve çizmektedir.

E) İSTİNAF SÜRESİ

İstinaf yoluna başvuru süresi **iki haftadır**. Bu süre, ilâmın (nihaî kararın) usulen taraflardan her birine **tebliğiyle işlemeye başlar**. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır (m. 345); yani, eğer özel kanunlarda sürenin tefhim (sözle bildirim) ile başlayacağı belirtilmişse, istinaf süresi tefhim ile başlayacaktır. Örneğin icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi, tefhim veya tebliğle işlemeye başlar (İİK m. 363, I).

F) İSTİNAF DİLEKÇESİ

İstinaf kanun yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır (m. 342; 24). Kanun yollarına ve bunlardan biri olan istinaf yoluna, ancak davanın, bu yola başvurmakta hukukî yararı olan tarafları başvurabilir. Maddî bakımdan zorunlu dava arkadaşları birlikte istinaf yoluna başvurabilirler (m. 60). İhtiyarî dava arkadaşlarının her biri kanun yoluna başvurabilir (m. 58). Fer'î müdahil tek başına hükme karşı kanun yoluna başvuramaz (m. 66-69).

I – İSTİNAF DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI

"İstinaf dilekçesi" kenar başlıklı HMK'nun 342. maddesine göre; istinaf yoluna başvuru için hazırlanan dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 1) Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri; 2) Varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri; 3) Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı; 4) Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih; 5) Kararın özeti; 6) Başvuru sebepleri ve gerekçesi; 7) Talep sonucu; 8) Başvuranın veya varsa yasal temsilcisinin yahut vekilinin imzası (m. 342, 2). Dilekçede **başvuru sebepleri**nin ile **gerekçesi**nin ve **talep sonucu**nun **çok iyi, açık ve anlaşılır şekilde** açıklanması gerekir. Çünkü **istinaf incelemesi, kural olarak gösterilen sebeplerle sınırlı yapılır.**

Kanunda (m. 342), istinaf dilekçesinin hangi yerdeki bölge adliye (istinaf) mahkemesine hitaben yazılması gerektiği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak bu bir eksiklik değildir. Bu mahkeme "**yetkili istinaf mahkemesi**"dir. Hangi ilk derece mahkemesi bakımından hangi yerdeki istinaf mahkemesinin yetkili olduğu ("yetkili istinaf mahkemesi"), 5235 s. K. m. 25'e göre, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenip ilân edilmiştir.

Bölge adliye (istinaf) mahkemeleri için **yetki sözleşmesi yapılamaz** (m. 357, 2). Bu düzenlemeden hareket edildiğinde, istinaf mahkemesinin yetkisinin kesin ve kamu düzeninden olduğu sonucuna varmak gerekir. Ancak, HMK hükümlerine uygun olarak yapılacak yetki sözleşmesiyle yetkili ilk derece mahkemesi belirlenerek, yetkili bölge adliye (istinaf) mahkemesini dolaylı olarak belirlemek (değiştirmek) mümkün olabilir.

İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, m. 355 madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır. (m. 342, 3) Bu hüküm ile, istinaf dilekçesindeki bir usul eksikliği sebebiyle hak kaybının önlenmesi amaçlanmıştır.

II – İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ

İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya (kararı veren mahkemeye gönderilmek üzere) başka bir yer mahkemesine verilebilir.

İstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, istinaf mahkemesi başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi (makbuz) verilir (m. 343, 1). Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece m. 343, 1'e göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durum derhal mahkemesine bildirilir.

Dosya, kararı veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen istinaf mahkemesi (daire) ile bağlı kalınmaksızın, yetkili istinaf mahkemesine gön-

derilir (m. 343, 4). Yani, istinaf yoluna başvuran, istinaf dilekçesini yetkili olmayan yerdeki istinaf mahkemesine hitaben yazmış olsa dahi, kararın verildiği mahkeme, istinaf talebinde bulunanın yazdığı yer ile bağlı olmaksızın kendiliğinden yetkili istinaf mahkemesini tespit ederek, dosyayı o mahkemeye gönderir. İstinaf dilekçesinin yanlışlık sonucunda yetkili olmayan istinaf mahkemesine hitaben yazılması ve kararın verildiği mahkemenin de buna dikkat etmemesi halinde, dosya yetkisiz istinaf mahkemesine gideceğinden ve dosyanın yetkili istinaf mahkemesine intikalinde zaman kaybı olacağından, istinaf başvurusunda bulunan tarafın ve/veya kararı veren mahkemenin gerekli dikkati göstermesi gerekmektedir.

İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 118. madde hükmü uygulanır (m. 343, 3). Kendisine atıf yapılan 118. madde hükmü şöyledir: "Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır".

Kanımızca, Kanunun (m. 343, 3'ün) 118. maddeye yaptığı atıf, Yargıtayın 06.02.1984 tarihli ve 07/03 sayılı "Harca tâbi olmayan davalarda, hâkimin dava dilekçesini havale tarihinde; harca tâbi davalarda ise, harcın ödendiği tarihte dava açılmış sayılacağına; ancak, dava dilekçesinin ilgilisi tarafından daha sonraki bir tarihte mahkeme kalemine verildiğinin kalemce belgelendirilmiş olması halinde, davanın o tarihte açıldığının kabulü gerekir" ifadelerini taşıyan içtihadı birleştirme kararı ile birlikte değerlendirilmelidir.

III – GEREKLİ HARÇ VE GİDERLERİN ÖDENMESİ

İstinaf dilekçesi verilirken, tebliğ giderleri de dahil olmak üzere gerekli harç[6] ve giderler ödenir[7]. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen **kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir**. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması halinde, istinaf dilekçesinin reddi hakkındaki 346. maddenin 2. fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır (m. 344, 1).

İstinaf (bölge adliye) mahkemelerine yapılan istinaf başvurusu, başvurma harcına tâbidir; ayrıca istinaf mahkemeleri kararları duruma göre, nispî veya maktu karar ve ilâm harcına tâbidir[8].

---

6 HMK m. 344'te yer alan "istinaf kanun yoluna başvuru harcı" ibaresi, 474 s. KHK ile "kanun yoluna" başvuru için gerekli harçlar" biçiminde değiştirilmiştir (RG 01.09.2016, sa. 29818 ikinci mükerrer).

7 Ayrıca bkz. Harçlar K. (1) sayılı Tarife A, I/3; Tebligat K. m. 3.

8 5235 sayılı K. (m. 52) ile Harçlar K.'nda yapılan değişiklikle, Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarifenin "(A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün "I- Başvurma harcı" başlıklı bendinin (3) numaralı alt bendinin girişine, "III-Karar ve ilâm harcı" başlıklı bendinin nisbî harçla ilgili (e) alt bendindeki "Yukardaki nispetler" ibaresinden sonra gelmek üzere ve maktu harçla ilgili (c) alt bendinin girişine "Bölge Adliye Mahkemeleri" ibaresi eklenmiştir.

IV – İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KARARI VEREN MAHKEME TARAFINDAN USULDEN REDDİ

İstinaf **dilekçesi**, yasal **süresi geçtikten sonra** verilir veya **kesin olan** (yani, istinaf yolu kapalı bulunan) **bir karara ilişkin olursa**, kararı veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve 344. maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (m. 346, 1).

Bu ret kararına karşı, tebliği tarihinden itibaren **bir hafta** içinde istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvurulduğu ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya, kararı veren mahkemece yetkili istinaf (bölge adliye) mahkemesine gönderilir. İstinaf (bölge adliye) mahkemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmezse, ilk istinaf dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar (m. 346, 2).

G) İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP

İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkeme tarafından karşı tarafa tebliğ edilir (m. 347, 1).

Karşı taraf, istinaf dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren, **iki hafta içinde cevap verebilir**. Cevap dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilebilir (m. 347, 2).

Kararı veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten sonra, dosyayı dizi listesine bağlı olarak yetkili istinaf (bölge adliye) mahkemesine gönderir (m. 347, 3).

Cevap dilekçesinin de, istinaf dilekçesi gibi (benzer biçim ve içerikte) hazırlanması (m. 342) istinaf incelemesinin daha sağlıklı yapılabilmesine katkıda bulunur.

H) KATILMA YOLUYLA İSTİNAFA BAŞVURMA

Katılma yolu ile istinafa başvurmak da mümkündür (m. 348). İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, istinaf yoluna başvurma hakkı bulunmasa veya istinaf hakkı bulunmasına rağmen başvuru süresini geçirmiş olsa bile, süresi (iki hafta) içinde cevap vermekle yetinmeyip bu cevap dilekçesiyle kendine özgü nedenler ileri sürerek istinaf yoluna başvurabilir.

Katılma yoluyla istinaf dilekçesi, karşı tarafa (yani, asıl istinaf başvurusunda bulunan tarafa) tebliğ edilir; asıl istinaf yoluna başvuranın katılma yoluyla istinaf dilekçesine iki hafta içinde cevap verme hakkı vardır (m. 348, 1).

Bu başvuru, asıl başvuruya bağımlı bir istinaf yolu başvurusudur. Bu nedenle istinaf yoluna başvuran, başvurusundan feragat eder veya istemi esasa girilmeden önce reddedilirse, katılma yolu ile başvuranın talebi de reddedilir. Çünkü kural olarak, asıl istem incelenmezse, ona bağlı olan istemin de incelenememesi gerekir. Fakat **istinaf yoluna başvuran tarafın istemi esa-**

sa girildikten sonra reddedilirse bu durum katılan tarafın isteminin incelenmesine engel olmaz.

Aynı gerekçeyle, taraflar istinaf mahkemesindeki uyuşmazlığı sona erdirirlerse, katılma yolu ile istinaf yoluna başvuru da etkisini kaybeder. Asıl istinaf yoluna başvuru isteminin esasına girilip inceleme yapılmadan, katılan tarafın istemi hakkında bir inceleme yapılamaz[9].

İ) İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT

HMK'nun 349. maddesinde, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edilmesi ve feragatın sonuçları düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, taraflar, ilâmın kendilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemez. Bu hükümle, ilk derece mahkemesinde görülmüş olan davanın taraflarının istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edebilmeleri için ilâmın kendilerine tebliğ edilmiş olması koşulu öngörülmüş olup, bir hak doğmadan ondan feragat edilemeyeceği kabul edilmiştir.

Başvuru yapıldıktan sonra, fakat dosya istinaf (bölge adliye) mahkemesine gönderilmeden önce istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edilirse, dosya istinaf (bölge adliye) mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya istinaf mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise, başvuru, istinaftan feragat nedeniyle reddolunur (m. 349, 1-2).

J) İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMANIN İCRAYA ETKİSİ

HMK'nun 350. maddesi hükmü ile, istinaf yoluna başvurmanın ilk derece mahkemesinin kararı üzerindeki etkisi düzenlenmektedir.

Buna göre, hukuk mahkemeleri kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulması, **kararın icrasını durdurmaz**; ilk derece mahkemesi kararının icra edilebilir niteliğini ortadan kaldırmaz. Başka bir deyişle, ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olması, ilke olarak, kararın icrasını durdurmayacaktır. Böylece, getirilen düzenlemeyle, hem mevcut sistemimizdeki ilk derece mahkeme kararlarının kesinleşmeden icra edilebilmesine ilişkin ilke korunmakta, hem de istinaf yoluna başvurulmasının kendiliğinden hakkın yerine getirilmesini geciktirici bir etki doğurması önlenmektedir.

Maddenin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde, İİK'nun 36. maddesine yapılan yollamayla, istinaf yoluna başvurulması nedeniyle **icranın geri bırakılmasına karar verme yetkisi, istinaf mahkemesi**ne tanınmıştır. Böylece, istinaf yoluna başvurulmasının bütünüyle haksız olduğunun anlaşıldığı durumlarda icranın geri bırakılması isteminin reddedilmesi olanağı istinaf mahkemesine verilmiştir. Buna karşılık, 350. maddenin 1. fıkrasının son cümlesiyle, nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin ilke muhafaza edilmiştir.

---

[9] Bkz. m. 348 Hükümet gerekçesi.

Aynı şekilde 350. maddenin 2. fıkrasında, kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mal ile ilgili aynî haklara ilişkin kararların kesinleşmedikçe icra edilemeyeceğine ilişkin ilkenin istinaf yolu bakımından da geçerli olduğu vurgulanmaktadır (m. 350, 1-2).

K) KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

İstinaf başvurusunun kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa, istinaf (bölge adliye) mahkemesince 329. madde hükümleri uygulanır (m. 351). Bu kural, dürüstlük kuralının (TMK m. 2) yargılama hukukunda da uygulandığını gösteren örneklerden biridir.

Bu hüküm gereğince, istinaf sebebi olmadığı halde kötüniyetli istinaf başvurusunda bulunan taraf, istinaf yargılama giderlerinden başka diğer tarafın vekili ile kararlaştırdığı (vekiline ödeyeceği) vekâlet ücretini veya bir kısmını ödemeye mahkum edilebileceği gibi, disiplin para cezasına da çarptırılabilir. Bu duruma vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para cezası vekile verilir.

L) İSTİNAF MAHKEMESİNİN ÖN İNCELEME YAPMASI

İstinaf başvurusu üzerine, bölge adliye (istinaf) mahkemesi hukuk dairesince dosya üzerinde bir **ön inceleme**[10] yapılır.

Bu ön incelemenin sonucunda; incelemenin başka bir dairece yapılması gerektiği, kararın kesin olduğu, başvurunun süresi içinde yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine getirilmediği, başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli karar verilir. Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır (m. 352).

Anılan hükmün gerekçesi şöyledir: "Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine, dosya üzerinde yapılacak bir ön inceleme ile kolaylıkla tespit edilebilecek bazı temel hususların eksikliği halinde, davanın süratle sonuçlandırılması için, hemen gerekli kararı vermesine olanak tanınmak istenmiştir. Dosyanın incelenmesinin başka bir dairenin iş alanına girmesi, ilk derece mahkeme kararının kesin olması, istinaf yoluna başvurunun süresi içinde yapılmamış olması ve asgarî başvuru şartlarının yerine getirilmemesi, örneğin başvuru dilekçesinin başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşımaması halleri zaten açıklanmaya muhtaç değildir. Kaldı ki bu hâllerden bir kısmında, örneğin başvurunun yasal süre geçtikten sonra yapılması veya kesin olan bir ilk derece mahkemesi kararına ilişkin olması durumunda, bunu ilk derece mahkemesi de 346 ncı maddesi hükmü uyarınca göz önüne alarak başvuru dilekçesini reddedebilecektir. Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin başvuru dilekçesinde hiç gösterilmemiş olması hâlinde ise, bölge adliye mahkemesi 355 inci maddesinin ikinci cümlesi uyarınca sadece **kamu düzeni** yönünden bir inceleme yapıp gerekli kararı bu incelemenin sonucuna göre hemen verecektir".

---

[10] Burada söz edilen ön inceleme, ilk derece mahkemeleri önünde gerçekleşen ön inceleme aşamasından (m. 137 vd.) tümüyle farklıdır.

Ön inceleme heyetçe (kurulca) veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır ve ön inceleme sonunda karar heyetçe verilir (7035 s. K. ile değişik m. 352, 3).

M) İSTİNAF MAHKEMESİNDE ESASTAN İNCELEME (TAHKİKAT)

I – GENEL OLARAK

Kanunumuzun kabul ettiği sistemde istinaf (bölge adliye) mahkemesi, kural olarak, bütün vakıaları yeniden incelemeyip bir hukukî denetim mahkemesi gibi görev yapabilecektir.

İstinaf mahkemesince inceleme (ki, buna yukarıda belirtilen "ön inceleme"nin karşıtı olarak, "**asıl** (esas) **inceleme**" de denilebilir), davanın özelliğine göre heyet (kurul) tarafından veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır (m. 354, 1).

İnceleme sırasında gereken hallerde, **başka bir istinaf mahkemesi** veya **ilk derece mahkemesi** istinabe edilebilir (m. 354, 2). Ancak, incelemenin mümkün olduğu sürece (tahkikatın) ilgili dairece yapılması, doğrudanlık ve sözlülük ilkeleri ile adil yargılanma hakkına daha uygun olacaktır.

Burada, "inceleme" sözcüğü ile kast edileni, HMK anlamında tahkikat (m. 143 vd.) olarak nitelendirmek mümkündür. Madde, bu anlamda incelenen konunun önemine ve kapsamına göre, incelemenin bizzat istinaf mahkemesi heyeti tarafından yapılmasına veya heyetçe görevlendirilecek bir üye tarafından yürütülmesine olanak sağlamaktadır.

İstinaf mahkemeleri birden fazla ili kapsayan belirli bölgelerde kurulmuştur. Böyle olunca, ortaya çıkan sorun; keşif, bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi gibi, mahallinde yapılması gereken işlemlerde, işlemin yapılacağı yerin, istinaf mahkemesinin yargı çevresinde bulunmakla beraber onun faaliyet gösterdiği il merkezinde olmaması halinde ne gibi bir yöntem izleneceğidir. Nitekim, istinaf mahkemelerine yöneltilen eleştirilerin en başında bu gibi hâllerde istinaf mahkemesinin bu işlemleri heyet olarak veya naip üye tayin ederek yapmasının çok büyük zaman ve emek kaybına neden olacağı yer almaktadır. Oysa, halen sadece ilk derece mahkemeleri arasında uygulanabilen istinabe özde, bu tür ihtiyaçlara cevap vermek içindir. İstinabenin istinaf mahkemeleri nezdinde de uygulanabilmesine olanak tanımak suretiyle, bu mahkemelerin birden fazla ili kapsayan bir yargı çevresine sahip olmalarından doğabilecek güçlükler kolaylıkla aşılabilecektir.

Böylece, bir istinaf mahkemesi kendi yargı çevresi içindeki işlemler için aynı yargı çevresindeki bir ilk derece mahkemesini istinabe edebileceği gibi başka bir istinaf mahkemesi veya başka bir istinaf mahkemesinin yargı çevresinde kalan ilk derece mahkemesini doğrudan istinabe edebilecektir.

II – İNCELEMENİN KAPSAMI

İstinaf incelemesinin kapsamının ne olacağı, 355. maddede düzenlenmiştir. Buna göre: **İnceleme**, istinaf dilekçesinde **belirtilen sebeplerle sınırlı** olarak yapılır. Ancak, istinaf mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu kendiliğinden gözetir.

Kamu düzenine aykırılık geniş bir kavramdır ve bunların içine öncelikle dava şartları girer.

Bu husus maddeye ilişkin Hükümet gerekçesinde şöyle açıklanmaktadır: "Bölge adliye mahkemesi, incelemesini istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapacaktır. Temyiz incelemesinden farklı olarak, bölge adliye mahkemesinde yapılacak incelemede tarafların ileri sürdüğü sebeplerle bağlı kalınmasının nedeni, bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararının kanuna aykırılığını tespit etmesi hâlinde, çoğu zaman yeniden yargılama yaparak yeni bir karar verebilmesidir. Bununla beraber, kamu düzenini ilgilendiren hususlarda bölge adliye mahkemesi istemle bağlı olmaksızın re'sen inceleme yapar. Örneğin, kamu düzenini ilgilendiren görev kuralına aykırılık bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir. Yine dava şartlarının var olup olmadığı bölge adliye mahkemesince re'sen araştırılır. Bunun gibi, re'sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda bölge adliye mahkemesi tarafların istemiyle bağlı olmaksızın ilk derece mahkemesinin kararını inceler".

III – DURUŞMA

Aşağıda belirtileceği gibi, istinaf (bölge adliye) mahkemesinde asıl olan, incelemenin **duruşmalı** yapılmasıdır. İncelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilince belirlenen duruşma günü taraflara tebliğ edilir (m. 356). Ancak bazı hallerde, duruşma yapılması gerekli görülmemektedir:

a) Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar

Kanunun 353. maddesinin "Duruşma yapılmadan verilecek kararlar" kenar başlıklı hükmüne göre:

Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa;

İstinaf mahkemesi aşağıdaki durumlarda, esası incelemeden **kararın kaldırılmasına** ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği **başka bir** yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili **mahkemeye** gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak karar verir. Bu hükümde belirtilen sebepler, usul ve esas açısından ikiye ayrılmıştır.

Usulden dolayı:

1) Davaya bakması yasak olan hâkimin (m. 34) karar vermiş olması;

2) İleri sürülen haklı ret istemine rağmen reddedilen hâkimin (m. 36) davaya bakmış olması;

3) Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması[11];

4) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması;

5) Mahkemece usule aykırı olarak, davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına[12] karar verilmiş olması;

6) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri **delillerin hiçbiri toplanmadan** veya gösterilen **deliller hiç değerlendirilmeden** karar verilmiş olması

hallerinde duruşma yapılmadan ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve mahkemeye gönderilmesine **kesin** olarak **karar** verilir. Gönderme kararına karşı direnme kararı verilemez[13]. Görüldüğü üzere bu (m. 353) hükümle; istinaf mahkemesinin iki halde duruşma yapmadan karar verebileceği düzenlenmiştir. İlk olarak özellikle bazı önemli usul eksikliklerinin bulunması halinde istinaf mahkemesine, duruşma yapmadan, davayı yeniden görmek üzere, dosyayı ilk derece mahkemesine gönderme yetkisi tanınmıştır. Burada ilk derece mahkemesi kararında ağır usul hatalarının varlığı nedeniyle, istinaf mahkemesi, kararın esasına girmemekte, kararı kaldırarak dosyayı geri göndermektedir. İlk derece mahkemesi, istinaf mahkemesinin belirttiği eksikliği tamamlayıp yeniden bir karar vermek zorundadır.

Esastan dolayı:

1) İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun **esastan reddine**;

2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde (örneğin, mahkemenin yargılama giderleri hakkında karar vermemesi halinde) veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek **yeniden esas hakkında**;

3) Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise (örneğin, resmî veya özel bir kurumdan getirtilmesi gereken bir belgenin dosyada bulunmaması halinde) bunların tamamlanmasından sonra **yeniden esas hakkında**,

duruşma yapılmadan karar verilir.

İkinci durumda ise, üç olasılık öngörülmüştür; Buna göre ilk derece mahkemesinin kararı usul veya esas yönünden hukuka uygun ise istinaf başvu-

---

11 "Mahkemenin istinaf mahkemesinin yargı çevresi dışında kalmış olması" ibaresi 7035 s. K. ile madde (m. 353) metninden çıkarılmıştır.

12 Maddede yer alan "merci tayinine" ifadesi 7035 s. K. ile metinden çıkarılmıştır. Çünkü ilk derece mahkemelerin bu konuda karar verme yetkisi bulunmadığından (karş. m. 22, 1) maddenin bu hükmü uygulanma kabiliyeti bulunmayan bir düzenlemeydi.

13 Anayasa Mahkemesi, istinaf mahkemesinin m. 353, 1/a'da öngörülen durumlarda "kesin" karar vermesi ve bu karara karşı ilk derece mahkemesi hâkiminin direnememesine ilişkin kuralın Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 28.03.2018 tarih ve E. 2017/120, K. 2018/33 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 154-156.

rusu esastan reddedilir. Bu halde ilk derece mahkemesi kararının doğru olduğu sonucuna ulaşılır. Diğer iki olasılık ise yargılamanın süratlendirilmesi düşüncesiyle, kanuna uymayan hususun duruşma yapılmaksızın giderilmesine olanak bulunması veya karar esas yönünden doğru olmakla birlikte gerekçesinde hata edilmiş olması ya da yargılamadaki eksikliğin duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte bulunması halinde, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan (yapmadan) yeniden esas hakkında karar vermesi olanağı sağlanmaktadır.

b) Duruşma Yapılmasına Karar Verilecek Olan Durumlar

Yukarıda belirtilen duruşma yapılmadan karar verilecek (m. 353) haller dışında istinaf mahkemesi incelemesini, duruşmalı olarak yapar (m. 356). Çünkü yargılamada (incelemede) aslolan, duruşma yapılmasıdır.

Duruşma yapılacak olan hallerde, duruşma günü taraflara tebliğ edilir (m. 356).

Bu hükümden, kanun koyucunun, istinaf mahkemesindeki incelemenin (tahkikatın) ilke olarak, duruşmalar yoluyla yapılmasını gerekli gördüğü anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, tahkikat ilk derece mahkemelerinde de duruşmalar yapılarak yürütülmektedir.

c) Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi

Duruşmalı olarak incelenen işlerde taraflara çıkartılan davetiyelerde (çağrı kâğıtlarında), duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde tahkikatın yokluklarında yapılarak karar verileceği hususu ile başvuran tarafa çıkartılacak davetiyede, ayrıca, yapılacak tahkikatla ilgili olarak istinaf mahkemesince belirlenen gideri duruşma gününe kadar avans olarak yatırması gerektiği açıkça belirtilir.

Başvuran, kabul edilebilir bir mazerete dayanarak duruşmaya gelemediğini bildirdiği takdirde, yeni bir duruşma günü tayin edilerek taraflara bildirilir. Başvuran, mazeretsiz olarak duruşmalara katılmadığı veya tahkikatla ilgili giderler süresi içinde yatırılmadığı takdirde, **dosyanın mevcut durumuna göre karar verilir**. Başka bir deyişle, **istinaf mahkemesinde dosyanın işlemden kaldırılması** ve **buna bağlı sonuçlar ortaya çıkmaz** (m. 150; karş. m. 360). Şu kadar ki, öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hallerde istinaf başvurusu reddedilir (m. 358).

N) İSTİNAF MAHKEMESİNDE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER

HMK, dar anlamda istinafa göre düzenleme içerdiğinden, istinafta yapılamayacak olan işlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

HMK m. 357'de bu hususlar (işlemler) şöyle belirtilmektedir:

İstinaf mahkemesinde; **dava açılamaz**; davaya **müdahale** isteminde bulunulamaz; dava **ıslah edilemez**; 166. maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere **davaların birleştirilmesi istenemez**; istinaf mahkemesince

resen gözönünde tutulacaklar dışında, **ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez**; **yeni delillere** dayanılamaz; istinaf mahkemeleri için **yetki sözleşmesi** yapılamaz.

Ancak, İlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak gösterildiği halde incelenmeden reddedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan deliller, istinaf mahkemesince incelenebilir.

Bu hükmün nasıl anlaşılması gerektiğini belirlemede, hükmün konuluş gerekçesi önem arz etmektedir: "Bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesi olarak davaya baktığı sınırlı haller dışında, bu mahkemeye doğrudan dava açılamayacağından karşılık dava da açılamayacaktır. Davaya katılma, hakkı veya borcu bir davanın sonucuna bağlı olan üçüncü kişinin taraflardan birisine katılması ve ona yardım etmesi olduğundan, müessese niteliği itibarıyla ancak ilk derece mahkemesinde yarar sağlayacağı öngörülerek bölge adliye mahkemesinde davaya katılma olanağı tanınmamıştır. Bölge adliye mahkemesi ancak ilk derece mahkemesince karara bağlanan davalara bakabileceğinden, başka ilk derece mahkemesinde henüz karara bağlanmamış dava ile birleştirme söz konusu olamayacak, bölge adliye mahkemesinde davaların birleştirilmesi istenemeyecektir. İstinaf mahkemelerinin yetkisi kesin ve kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bu konuda yetki sözleşmesi yapılamayacaktır. Islah ilk derece mahkemesinde hüküm ifade edeceğinden, istinaf mahkemesinde **ıslah kabul edilmemiş**, buna uygun olarak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmaların karşı tarafın muvafakatiyle dahi bölge adliye mahkemesinde ileri sürülememesi esası benimsenmiştir. Bölge adliye mahkemesi iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına aykırılığı kendiliğinden gözetecektir. Tarafların ilk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak ileri sürmediği deliller de bölge adliye mahkemesinde incelenemeyecektir. Ancak ilk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak ileri sürüldüğü hâlde, haksız olarak reddedilip incelenmeyen veya ilk derece mahkemesinde mücbir bir sebeple gösterilebilme olanağı bulunmayan ya da tarafın geç ileri sürmesinde bir kusurun bulunmadığı deliller bölge adliye mahkemesinde incelenebilecektir. Bunun gibi, bölge adliye mahkemesince kendiliğinden incelenecek hususlar, şüphesiz taraflarca da ileri sürülebilecektir".

Aslında yapılamayacak işlerin belirlenmesinin nedeni, istinaf yolunun kabulünün, davaları uzatma sonucunu (sakıncasını) doğurmasını önlemektir.

O) İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI

İstinaf mahkemesi, yapacağı ön inceleme sonucunda duruşma yapıp yapmayacağını belirleyebilir. İstinaf mahkemesinin duruşma yaparak karar vermesi, genel kuraldır (m. 356). Ancak Kanun, istisnaî olarak usul veya esasa ilişkin bazı konularda istinaf mahkemesinin duruşma yapmadan (yani tarafları davet etmeden, dosya üzerinden) karar verebilmesine olanak tanımıştır.

I – DURUŞMA YAPMADAN VERİLEN KARARLAR

İstinaf mahkemesi, yukarıda da belirtildiği üzere, yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden karar verebileceği sonucuna ulaşırsa, yukarıda incelediğimiz gibi, duruşma yapmadan istinaf başvurusu hakkında usule veya esasa ilişkin bir karar verir.

Buna göre m. 353, 1/a'da altı bent olarak düzenlenen durumdan birinin varlığını tespit eden istinaf mahkemesi, esası incelemeden **kararın kaldırılmasına** ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye **gönderilmesine** duruşma yapmadan **kesin olarak karar verir** (m. 353, 1/a). Bu kararlar, **usule ilişkin**dir. Bu halde, istinaf mahkemesi, kararın esasına girmez; karardaki usulî hataların giderilmesi amacıyla kararı kaldırıp, dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bu kararların kesin olması nedeniyle, dosya kendisine gönderilen ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesinin kaldırma kararına uymak zorundadır; yani ilk derece mahkemesinin **istinaf mahkemesinin kararına direnme yetkisi yok**tur.

İstinaf mahkemesinin, duruşmasız (dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda) vereceği kararların ikinci çeşidi ise esasa ilişkin olabilir. Bu kararlar Kanunda üç bent olarak sayılmıştır (m. 353, 1/b). Buna göre:

1) İlk derece mahkemesinin kararı usule uygun veya esas açısından doğru ise, istinaf mahkemesince **istinaf talebinin esastan reddine** karar verilir (m. 353, 1/b, 1). Böylece istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hiç değiştirmeden veya kararı kaldırmadan, kararı doğru bulduğunu belirtmiş olur.

İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar, temyiz edilebilen kararlardan değilse, hüküm **istinaf talebinin reddi** ile **şeklen kesinleşir**; bu karara karşı temyiz yolu açık ise, kesinleşme, süresinde temyiz yoluna gidilmemesi üzerine, gidilmişse temyiz incelemesi sonucuna göre ortaya çıkar. Belirtelim ki, HMK, Yargıtay kararlarına karşı gidilen karar düzeltme kanun yolunu yürürlükten kaldırmıştır.

2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, Kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasına rağmen, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmazsa veya kararın gerekçesi hatalı bulunursa, istinaf mahkemesince hata ve/veya gerekçe düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilir (m. 353, 1/b, 2). Burada ilk derece mahkemesi kararındaki hatayı düzeltme ihtiyacı bulunmakla birlikte, bu hata, yeniden yargılama/inceleme yapılmasını gerektirmeyen türden olduğu için, istinaf mahkemesi, **dosya üzerinden kararı düzeltir** ve **esas hakkında yeniden bir karar verir.** Bu da, ilk derece mahkemesi kararındaki hukukî sebebin değiştirilmesi veya gerekçenin düzeltilmesi şeklinde olur.

3) Son olarak, istinaf mahkemesince tespit edilen eksiklikler duruşma yapılmadan tamamlanabiliyorsa, bu eksikler tamamlandıktan sonra **yeniden esas hakkında** karar verilir (m. 353, 1/b, 3). Burada da ilk derece mahkemesi kararındaki eksikliğin duruşma yapılmasını ve kararın kaldırılıp ilk derece

mahkemesine geri gönderilmesini gerektirmeyecek düzeyde olması halinde, istinaf mahkemesinin bu eksikliği kendisinin tamamlayıp yeniden esas hakkında bir karar vermesi söz konusudur.

II – DURUŞMALI VERİLEN KARARLAR

İstinaf mahkemesi, yukarıda belirtilen ve istisna olarak ortaya çıkacak durumlar dışında m. 356 uyarınca, incelemesini **duruşmalı** yapacaktır. İstinaf mahkemesinin, aynı zamanda bir vakıa mahkemesi olması sebebiyle , temyiz incelemesinden farklı olarak duruşma yapması esastır.

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararı hakkında m. 353'te belirtilen sebeplerle usule veya esasa ilişkin bir karar vermez; ancak duruşmalı yapacağı inceleme sonucunda ilk derece mahkemesi kararını usul ve esasa uygun bulmazsa ilk derece mahkemesi kararını kaldırıp yeniden esas hakkında iki şekilde karar verebilir:

Bu kararlar: a) davanın kısmen veya tamamen kabulü kararı, b) davanın reddi kararı olabilir.

a) İstinaf başvurusunu dinlenebilir bulup, ilk derece mahkemesinin davayı reddeden kararını esastan inceleyen istinaf mahkemesi, incelediği kararı **hukuka uygun bulmazsa**, yani ileri sürülen istinaf sebeplerinin yerinde olduğu kanısına ulaşırsa, ilk derece mahkemesi **kararını kaldırarak** yeniden yargılama yapar ve **yeni bir karar verir**. Bu karar, ilk derece mahkemesinde açılan davanın kısmen veya tamamen kabulü kararı olabilir (m. 353, 3).

b) Davanın kısmen veya tamamen kabulüne ilişkin olan ilk derece mahkemesi kararının, istinaf sebeplerinin varlığı kabul edilerek, isabetli bulunmaması halinde, istinaf mahkemesi yeniden yapacağı yargılama (inceleme) sonucunda (ilk derece mahkemesinin yerine geçerek) davanın kısmen veya tamamen reddine karar verir.

İstinaf mahkemesinin söz edilen bu durumlarda verdiği kararlar **temyiz edilebilen kararlardan değilse**, verilen hüküm kesindir; yok eğer temyiz yolu açık ise, kesinleşme, süresi içinde temyiz talebinde bulunulmaması üzerine veya temyiz talebinin sonucuna göre ortaya çıkar.

İstinaf mahkemesi, duruşmasız verebileceği bir kararı vermemiş ve duruşma yapmış ise, karar mutlaka yukarıda belirtilen şekilde davanın kabulü veya reddi biçiminde olmayabilir. Örneğin, istinaf mahkemesi, duruşma yaptıktan sonra, ilk derece mahkemesinin görevli olmadığı veya başka bir dava şartının bulunmadığı kanısına varırsa, davanın kabulü veya reddi kararı değil; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılıp görevli mahkemeye gönderilmesine ya da ilk derece mahkemesi kararını kaldırıp, gerekli kararın verilmesi için dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verir. Bu halde (olasılıkta), istinaf mahkemesi, esasa ilişkin olarak kendisi bir karar vermez.

İstinaf mahkemesi, yukarıda belirtildiği üzere, farklı kararlar verebilmekle birlikte, **verdiği kararın türü ne olursa olsun**, kararın içeriğinin nasıl olacağı ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, **istinaf mahkemesinin kararı aşağıdaki hususları kapsar** (m. 359):

1) Kararı veren istinaf (bölge adliye) mahkemesi hukuk dairesi ile başkan, üyeler ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları, sicil numaraları; 2) Tarafların ve davaya ilk derece mahkemesinde katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri; 3) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti; 4) İlk derece mahkemesi kararının özeti; 5) İleri sürülen istinaf sebepleri; 6) Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara ilişkin delillerin tartışması, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen olaylarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebep; 7) Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi; 8) Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler ile zabıt kâtibinin imzaları (m. 359, 1).

Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istem sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç veya tanınan hakların, tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gereklidir (m. 359, 2).

İstinaf mahkemesinin verdiği kararlardan bazıları kesindir (m. 362). Bunun dışındaki kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz yolu aşağıda ayrıca incelenecektir.

Ö) İSTİNAF MAHKEMESİNDE UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

"Uygulanacak diğer hükümler" kenar başlıklı **m. 360** hükmüne göre: "Bu bölümde (m. 341-360) aksine hüküm bulunmayan hâllerde ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usulü, istinaf mahkemesinde de uygulanır". Yani, bu bölümde aksi belirtilmediği takdirde bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını inceledikten sonra duruşma yapılmasına karar verirse, bundan sonraki incelemesini, ilk derece mahkemesinde uygulanmış olan yargılama usulüne göre yapacaktır. Örneğin ilk derece mahkemesinde yazılı yargılama usulü uygulanmış ise, istinaf mahkemesinde de yeniden yapılacak incelemede, yazılı yargılama usulü uygulanacaktır.

§ 56. TEMYİZ[1]

A) NİTELİĞİ

Temyiz, istinaf (bölge adliye) mahkemelerince verilen konusunun değer veya miktarı belli meblağı aşan nihaî kararlara ve hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı Yargıtay nezdinde gidilen, olağan (normal) kanun yoludur (m. 361 vd.; 407 vd.).

Aleyhine temyiz yoluna gidilen istinaf (bölge adliye) mahkemesi kararı, Yargıtay ilgili (özel) dairesi tarafından[2] yalnız hukuka uygunluk açısından incelenerek değerlendirilir[3]. Yani temyiz mercii (temyiz incelemesini yapan yüksek mahkeme -Yargıtay-), esas itibariyle istinaf mahkemesi gibi bir vakıa, tahkikat ve yargılama mahkemesi değildir. Temyiz yolunda, (alt derece) mahkemesine usulüne uygun olarak bildirilmiş olan vakıaların usulüne uygun bir şekilde incelenip incelenmediği, özellikle o vakıalara kanunların (hukukun) doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir.

Hal böyle olmakla birlikte, genel olarak (istinaf yolunda olduğu gibi) temyiz yolunun da geniş ve dar anlamları vardır. Bir ülkede benimsenen sisteme göre, temyiz yolunda bazen vakıaların da incelenebildiği görülmektedir. Nitekim ülkemizde 5235 sayılı Adlî Mahkemeler Teşkilâtı Kanununa kadar istinaf derecesinin bulunmaması sebebiyle, istinaf mahkemeleri kurulduktan sonra da bu mahkemeler göreve başlayıncaya (20.07.2016'ya) kadar ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan doğruya temyiz yoluna (Yargıtaya) başvurulduğu için, Yargıtay, istinaf derecesinin bulunmamasından doğan sakıncaları bertaraf edebilmek için zaman zaman vakıaları da incelemek ihtiyacını hissetmiştir.

Bugün, 5235 sayılı Kanun hükümleri gereğince bölge adliye (istinaf) mahkemeleri kurulmuş ve buna uygun olarak, HMK ile istinaf ve temyiz usullerine dair yeni hükümler getirilmiştir.

HMK ile düzenlenen ve istinaf mahkemelerinin faaliyete geçerek istinaf incelemesi üzerine kararlar vermesinden sonra **(20.07.2016 tarihinden itibaren)** uygulanan temyiz kanun yoluna ilişkin hükümler (m. 361 vd.), ilk derece mahkemesi kararlarına karşı gidilen temyizi düzenleyen HUMK hükümlerinden (HUMK m. 427 vd.) farklılıklar göstermektedir:

---

1 **İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA VERİLEN NİHAİ KARARLAR HAKKINDA UYGULANAN TEMYİZ HÜKÜMLERİ**

2 Bkz. 30.01.2019 gün ve 2019/01 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı (RG 31.01.2019, sa. 30672).

3 Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, İstinaftan Sonraki Temyiz İncelemesi ve Sonuçları, Medenî Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı (VI. Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı, İzmir 2007, TBB yayını, Ankara 2008, s. 151-207).

B) TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR

"Temyiz edilebilen kararlar" ile ilgili HMK'nun 361. maddesine göre:

Bölge adliye (**istinaf**) **mahkemesi** hukuk dairelerinden **verilen** temyiz edilebilir **nihaî kararlar** ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir (karş. HUMK m. 427).

Görüldüğü üzere, (ülkemizde uygulanan istinaf sisteminde) ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı doğrudan temyiz yoluna gidilemez; yukarda açıklandığı üzere, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı sadece istinaf yolu açıktır. Ancak istisnaî olarak, ilk derece mahkemesi kararının temyize konu olması mümkündür. İstinaf mahkemesinin istinaf başvurusunu esastan reddetmesi (m. 353, 1/b, 1) ve bu kararın temyiz edilmesi üzerine, dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir (m. 373, 1). İlk derece mahkemesinin bozmaya uygun olarak verdiği karar ise istinaf yoluna değil, temyize tâbidir (m. 373, 4).

Kanun (m. 361, 1), istinaf mahkemesi tarafından (m. 439, 1) verilen **hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara** karşı da temyiz yoluna gidilebileceğini düzenlemektedir. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda yapılan düzenlemeye paralel olarak, HMK'nda da (m. 439), hakem kararlarına karşı (doğrudan doğruya temyiz kanun yolu değil) iptal davası yolu düzenlendiğinden, bu iptal davasında mahkemece verilen kararlara karşı doğrudan temyiz yoluna başvurulabilir (karş. HUMK m. 533).

Davada haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir (m. 361, 2).

C) TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

İstinaf mahkemesinin **nihaî kararlarına** karşı temyiz yolunun açık olması kural ise de, bu kuralın istisnaları vardır ve istinaf mahkemesinin bazı kararlarına karşı temyiz yolu kapalıdır.

HMK'nun 362. maddesine göre, istinaf mahkemelerinin aşağıdaki **nihaî kararları** hakkında temyiz yoluna gidilemez:

1) Miktar veya değeri belli **parasal temyiz sınırını** (2019 yılı için: 58.800 TL) geçmeyen davalara ilişkin kararlar temyiz edilemez (m. 362, 1/a). Bu hüküm sebebiyle, istinaf mahkemesinin verdiği kararlardan belli tutarın altında kalanlar kesin olacak ve bu hükümlere karşı temyiz yoluna gidilemeyecektir. Hükümle böyle bir sınırın getirilmesinin nedeni, miktar veya değeri söz konusu sınırı Türk Lirasını geçmeyen davaların uzamasının önüne geçilmesi düşüncesidir. Maddede dava konusunun iki dereceli yargılamadan geçmiş bulunduğu göz önüne alınarak, istinaf mahkemesinin bazı kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği öngörülmüş ve böylece Yargıtayın iş yükünün hafifletilmesi de amaçlanmıştır.

2) Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değer itibariyle temyiz edilebilen alacak davaları hariç olmak üzere[4] sulh hukuk mahkemelerinin görevi başlık-

[4] 7035 s. K. ile değişik m. 362, 1/b.

lı **HMK'nun 4. maddesi**nde gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez (m. 362, 1/b). Bu hüküm nedeniyle, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin davalarda verilen kararlar dışında, sulh mahkemesi kararları istinaf aşaması tamamlanınca kesinleşecektir.

3) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine (yargı yeri belirlenmesine -m. 21) ilişkin kararlar temyiz edilemez (m. 362, 1/c).

4) **Çekişmesiz yargı işleri**nde (m. 382 vd.) verilen kararlar temyiz edilemez (m. 362, 1/d).

5) Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar (TMK m. 284) hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez (m. 362, 1/d).

6) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar temyiz edilemez (m. 362, 1/e).

7) **Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar** (m. 389 vd.; İİK m. 257 vd.) temyiz edilemez (m. 362, 1/e).

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan davalara ilişkin kararlarda, alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü kesinlik sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da (temyiz hakkı olmayan da) düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir (m. 362, 2). Görüldüğü gibi, 362.maddenin ikinci fıkrasına göre, hukukî yararın varlığı için, temyiz edenin yararının belli bir parasal sınırı geçmesi şartı aranmaktadır. HMK m. 361, 2'deki, "Davada haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir" hükmünü de, bu hükümle (m. 362, 2 hükmü ile) birlikte (paralel bir şekilde) değerlendirmek gerekir.

Dava konusu, para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen davalarda verilen hükümler de (nihaî kararlar da), aksine bir düzenleme olmadığından, temyiz edilebilir.

D) TEMYİZ SEBEPLERİ

HMK'nun 371. maddesinin kenar başlığı, "**bozma sebepleri**"dir. Yani, bu maddede sayılan hallerden biri veya birkaçı varsa, istinaf mahkemesinin kararı (Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda) bozulur.

Bozma sebepleri, aynı zamanda, temyiz yoluna gidilmesi için aranan sebepler (**temyiz sebepleri**) anlamındadır.

HMK m. 371'e göre, (karş. HUMK m. 428) Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:

1) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması (m. 371, 1/a).

2) Dava şartlarına (m. 114) aykırılık bulunması (m. 371, 1/b).

3) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanunî bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi (m. 371, 1/c).

4) Kararı etkileyen yargılama hatası veya eksikliklerin bulunması (m. 371, 1/ç; karş. HUMK m. 428, II) .

Yargıtay, hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması, dava şartlarına aykırılık bulunması, taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin yasal bir sebep olmadan kabul edilmemesi, durumunda, temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar.

Bozma sebebi **nispî** nitelikte (m. 371, 1/ç) ise, tespit edilen bozma sebebinin hükmü etkilemesi gerekir. Başka bir deyişle, Yargıtay, kararı etkileyebilecek ağırlıkta yargılama hatası veya eksikliklerin mevcut olduğunu tespit ederse, bunların hükmün sonucunu etkilemiş olup olmadığına bakar. Etkilediğini tespit ederse bozma kararı verir.

Buna karşılık, dava şartlarının bulunmaması veya taraflardan birinin iddiasını ispat için dayandığı delillerin yasal bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halleri **mutlak** bozma sebeplerinden olup, bu hataların hükmün sonucunu etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerekli değildir. Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması da hükmün sonucunu etkileyeceğinden mutlak bozma sebebi olarak değerlendirilir.

E) TEMYİZ SÜRESİ

Temyiz süresi, **iki hafta**dır[5]. Süre, istinaf (bölge adliye) mahkemesi hukuk dairesinden verilen nihaî kararın veya hakem kararına karşı açılan iptal davasında verilen kararın tarafa tebliği tarihinden itibaren başlar (m. 361, 1).

İstinaf mahkemesi kararının kimin tarafından tebliğ edileceği de 7035 s. K. değişikliği ile açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, "Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk derece mahkemesi tarafından temyizi kabil olan kararlar ise bölge adliye mahkemesi tarafından tebliğe çıkarılır" (m. 359,2).

F) TEMYİZ DİLEKÇESİ

I – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI

HMK'nun 364. maddesi, istinaf yolunun kabulüne paralel (istinaf yolunun açılmasının sonucu) olarak temyiz dilekçesi konusunu yeniden düzenlemiş-

---

[5] Bir ay olan temyiz süresi 7035 s. K. ile değişikliğe uğramış ve iki haftaya indirilmiştir (7035 s. K. değişik m. 361, 1). Bu değişiklik, Kanunun yürürlüğe girdiği ve sonrasında (05.08.2017'den sonra) verilen kararlar hakkında uygulanır (7035 s. K. Geçici Madde 1).

tir. Buna göre: Temyiz, **dilekçe**yle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir (m. 364, 1).

Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 1) Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresleri; 2) Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri; 3) Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı; 4) Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı; 5) İlâmın temyiz edene tebliğ edildiği tarih; 6) Kararın özeti; 7) Temyiz sebepleri ve gerekçesi; 8) Duruşma istenmesi hâlinde bu istek; 9) Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası (m. 364, 1).

Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması hâlinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır (m. 364, 3).

II – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ

Temyiz dilekçesi, kararı veren istinaf mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer istinaf (bölge adliye) mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir (m. 365, 1).

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhal kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir. Temyiz edene, ücretsiz bir alındı belgesi verilir (m. 365, 2-3).

HMK m. 366 hükmünün 343. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, istinafla ilgili 343. madde hükmü temyiz bakımından da kıyasen uygulanacağından, temyiz dilekçesi, kararı veren istinaf mahkemesinden başka bir mahkemeye verilmiş ise, bu mahkeme temyiz dilekçesini temyiz mahkemesi başvuru defterine kaydeder ve ekleriyle birlikte kararı veren istinaf mahkemesine gönderir.

Kararı veren istinaf mahkemesi, temyiz dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalınmaksızın, dava dosyasını ilgili Yargıtay Dairesine gönderir.

Temyiz başvurusunun sonuçları ve icraya etkisi bakımından, istinaf başvurusu sonuçlarına (m. 343-350) paralel bir düzenleme yapılmıştır (m. 367).

III – TEMYİZ DİLEKÇESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

HMK'nun 366. maddesinin 344. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, 344. madde hükmü temyiz konusunda da kıyasen uygulanacağından; temyiz dilekçesi verilirken, tebliğ giderleri de dahil olmak üzere gerekli harç ve giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu

başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde, 346. maddenin 2. fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır (m. 344).

HMK m. 366'nın, 346. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, 346. madde hükmü temyiz konusunda da kıyasen uygulanacağından; temyiz dilekçesi, yasal süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara karşı temyiz talebinde bulunulursa, kararı veren istinaf mahkemesi hukuk dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve 344. maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (m. 346).

Bu ret kararının tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz yoluna başvurulduğu ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya, kararı veren istinaf mahkemesince Yargıtaya gönderilir. Yargıtayın ilgili dairesi temyiz dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmezse, ilk temyiz dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar (m. 346, 2).

HMK'nun 366. maddesinin 347. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, m. 347 hükmü temyiz konusunda da kıyasen uygulanacağından; temyiz dilekçesi, kararı veren istinaf mahkemesince karşı tarafa tebliğ olunur (m. 347).

G) TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP

Temyiz dilekçesini tebellüğ eden (temyiz dilekçesi kendisine tebliğ edilen) karşı taraf, temyiz dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren **iki hafta** içinde cevap dilekçesi verebilir. Cevap dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilebilir (m. 347, 2; 366).

Kararı veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten sonra, dosyayı dizi listesine bağlı olarak **Yargıtaya gönderir** (m. 347, 3; 366).

Cevap dilekçesinin de, temyiz dilekçesi formatında (m. 342) yazılması uygun olur.

H) KATILMA YOLUYLA TEMYİZE BAŞVURMA

HMK m. 366'nın 348. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, 348. madde hükmü temyiz konusunda da kıyasen uygulanacağından; istinafta olduğu gibi, **katılma yolu ile temyize** başvurma da mümkündür (m. 348). Temyiz dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile temyiz dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren, süresi (iki hafta) içinde cevap vermekle yetinmeyip bu cevap dilekçesiyle kendine özgü nedenler ileri sürerek temyiz yoluna başvurabilir.

Bu **başvuru, asıl başvuruya bağımlı** bir **temyiz yolu başvurusu**dur. Bu nedenle katılma yolu ile temyiz yoluna başvuru; asıl başvuran taraf, başvurusundan feragat eder veya istemi esasa girilmeden önce reddedilirse, hüküm doğurmaz. Çünkü kural olarak asıl istem incelenmezse, ona bağlı olan istemin de incelenmemesi gerekir. Ancak temyiz yoluna başvuran tara-

fın istemi esasa girildikten sonra reddedilirse, bu durum katılan tarafın isteminin incelenmesine engel olmaz. Bunun gibi, taraflar temyiz aşamasında uyuşmazlığı sona erdirirlerse, katılma yolu ile temyiz yoluna başvuru da etkisini kaybeder. Asıl temyiz başvurusunun esasına girilip inceleme yapılmadan, katılan tarafın istemi hakkında bir inceleme yapılamaz.

İ) TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT

HMK'nun 366. maddesinin 349. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, 349. madde hükmü temyiz konusunda da kıyasen uygulanacaktır.

HMK'nun 349. maddesi hükmü ile temyiz yoluna başvurma hakkından feragat edilmesi ve feragatın sonuçları düzenlenmiştir. Hükme göre, taraflar, ilâmın kendilerine tebliğinden önce, temyiz yoluna başvurma hakkından feragat edemez. Böylece istinaf mahkemesinde görülmüş olan davanın taraflarının temyiz yoluna başvurma hakkından feragat edebilmeleri için ilâmın kendilerine tebliğ edilmiş olması koşulu öngörülmüştür. Bu hüküm, bir hak doğmadan ondan feragat edilemeyeceği şeklinde ifade edilen genel ilkeye uygundur.

Başvuru yapıldıktan sonra temyizden feragat edilirse, dosya Yargıtaya gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya Yargıtaya gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise başvuru, Yargıtay ilgili dairesi tarafından feragat nedeniyle reddolunur (m. 349, 2).

J) YARGITAYIN ÖN İNCELEME YAPMASI

HMK'nun 366. maddesinin 352. maddeye yaptığı yollama nedeniyle, m. 352 hükmü temyiz konusunda da kıyasen uygulanacaktır. Bu madde hükmü gereğince, temyiz başvurusu üzerine; Yargıtay ilgili hukuk dairesince dosya üzerinde bir ay içinde bir ön inceleme yapılır (bkz. 2797 s. K. m. 60, III).

Bu ön incelemenin sonucunda; incelemenin başka bir dairece yapılması gerektiği, kararın kesin olduğu, başvurunun süresi içinde yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine getirilmediği, başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli karar verilir. Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır (m. 352, 1).

K) TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMANIN İCRAYA ETKİSİ

Temyiz, **kararın icrasını durdurmaz**; İİK'nun, icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36. maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez (m. 367, 1).

Kişiler ve aile hukukuna ve taşınmaz mal ile ilgili aynî haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez (m. 367, 2).

Buna göre bir karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kural olarak onun yerine getirilmesini (icraya konulmasını; İİK m. 24 vd.) durdurmaz. Yani kural olarak, kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez.

Öteden beri, gerek usul ve gerekse icra ve iflâs hukukumuzda benimsenmiş olan bu ilke, 367. maddenin ilk fıkrasının birinci cümlesinde açıkça ifade edilmiştir.

Her ne kadar kararın temyiz edilmesi, onun yerine getirilmesini durdurmazsa da, İİK'nun 36. maddesinde öngörüldüğü üzere, kararı temyiz eden borçlu, teminat göstermek suretiyle Yargıtaydan "icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı" getirebilir. Bu suretle borçlu, Yargıtayca verilecek karara kadar, kararın yerine getirilmesini durdurmuş olur.

Hukukumuzda eskiden beri bazı kararların kesinleşmedikçe yerine getirilmemesi de (icraya konulmaması da) benimsenmiştir (örneğin, MÖHUK'un 60., Sayıştay K.'nun 53. maddesinde olduğu gibi). Kişiler ve (nafaka alacakları hariç) aile hukukuna[6], taşınmaz mal ile ilgili aynî haklara ilişkin kararların kesinleşmedikçe yerine getirilemeyeceği, HMK'nun 367. maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanmıştır[7].

L) KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI

Temyiz başvurusunun kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa, Yargıtayca, kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçlarını düzenleyen m. 329 hükümleri uygulanır (m. 368). HMK m. 329 hükmü temyize uygulandığında, kötüniyetli veya hiçbir hakkı olmadığı halde temyiz yoluna başvuran taraf yargılama giderlerinden başka diğer tarafın vekili ile kararlaştırdığı vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebileceği gibi, disiplin para cezasına da çarptırılır. Kötüniyetle temyiz başvurusu yapan vekil ise, disiplin para cezası, vekil hakkında uygulanır. Bu düzenleme, dürüstlük kuralının (TMK m. 2) yargılama hukukunda da uygulandığının bir örneğidir. Ancak, itiraf etmek gerekir ki, kötüniyetin ispatı oldukça zor bir hususdur. Düzenleme isabetli ise de hak arama özgürlüğünün sınırlanması sonucunu doğuran bir uygulamadan da kaçınılmalıdır.

M) YARGITAYDA ASIL İNCELEME

Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir (m. 369, 1). Çünkü, Yargıtayın yaptığı temyiz incelemesi kararın hukuka uygun olup olmadığına ilişkin bir incelemedir. Başka bir deyişle, Yargıtayın temyiz merci olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlı olacaktır.

---

6 Kişiler ve aile hukukuna ilişkin kararların derhal icra edilmeyip kesinleşmesinin beklenmesinin Anayasaya aykırılığı ileri sürülmüşse de Anayasa Mahkemesi m. 367'de yer alan düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 16.03.2016 tarih ve E. 2015/104 ve K. 2016/20 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 151-153.

7 Uygulamada Yargıtay, bazı kararların da kesinleşmeden icra edilemeyeceğini kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası, İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2019, § 44, B.

Yargıtay, temyiz incelemesini kural olarak, dosya üzerinden yapar (m. 369, 2). Ancak, tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya iptaline, boşanma veya ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri **belli bir parasal sınırı aşan** (2019 yılı için: 88.210 TL'nı aşan) alacak ve ayın davalarında taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemiş ise, Yargıtay ilgili dairesince bir gün belli edilerek taraflara usulen çağrı kağıdı (davetiye) gönderilir. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az iki hafta bulunması gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gideri verilmemişse duruşma istemi dikkate alınmaz. Duruşma giderinin eksik ödenmiş olduğu anlaşılırsa, dairenin başkanı tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde duruşma isteminden vazgeçilmiş sayılacağı, duruşma isteyene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde giderler tamamlanmadığı takdirde, Yargıtay incelemesini dosya üzerinde yapar (m. 369, 2).

Duruşma sınırının belirlenmesinde 362. maddenin ikinci fıkrası, kıyas yoluyla uygulanır (m. 369, 3).

Yargıtay, 369. maddenin ikinci fıkrası hükmü ile bağlı olmaksızın, bilgi almak üzere resen de duruşma yapılmasına karar verebilir (m. 369, 4).

Duruşma günü belli edilen hallerde Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararını verir (m. 369, 5).

Duruşma gününde kararı verilemeyen işlerin, en geç bir ay içinde karara bağlanması zorunludur (m. 369, 6).

Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapılır (m. 369, 7; CMK m. 299).

N) YARGITAY KARARI

Yargıtay, temyiz talebi üzerine, dosya üzerinde veya duruşmalı olarak yapacağı inceleme sonunda üç tür karar verebilir: Hükmü ya bozar, ya onar ya da düzelterek onar[8].

Yargıtay kararlarının da, diğer bütün mahkeme kararları gibi mutlaka **gerekçeli** olması gerekir. Bu bir **Anayasa emri**dir (Anayasa m. 141, III). Yargıtayın kararının gerekçeli olması, istinaf mahkemesinin kararında direnip direnmeyeceğini belirleyebilmesi için özellikle faydalıdır. Bundan başka, tarafların da kararın gerekçesini bilmeleri, onların karara karşı olan güvenini artırır. İstinaf mahkemesi bozmaya uyarsa, gerekçe mahkemenin işini önemli ölçüde kolaylaştırır; çünkü, ancak gerekçe sayesinde Yargıtay kararının anlaşılması mümkündür. Nihayet, kararın gerekçeli olması, o karar üzerinde faydalı bilimsel tartışmalar yapılmasına imkân verir ki, bu da sağlıklı bir hukukî gelişmeye yol açar.

---

[8] Bkz. CMK m. 302-303.

I – BOZMA KARARI

HMK'nun 371. maddesine göre Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar: 1) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin **yanlış uygulanmış olması**; 2) **Dava şartlarına aykırılık** bulunması; 3) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı **delillerin kanunî bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi**; 4) Kararı etkileyen **yargılama hatası** veya eksiklikleri bulunması (karş. HUMK m. 428, II).

Yargıtay, temyiz talebinde bulunan taraf veya taraflarca ileri sürülen veya kendiliğinden (resen) tespit ettiği yukarıdaki temyiz sebeplerinin mevcut olduğunu görürse, temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar.

Yargıtayın incelediği karar, kural olarak[9], istinaf mahkemesinin kararıdır. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını doğru bulduğu için başvurunun esastan reddi kararı verir (m. 353, 1/b-1) veya ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak düzelterek ya da yargılama yaparak **yeniden esas hakkında bir karar verir** (m. 353, 1/b-1.2; 356; 359). İşte **Yargıtayın incelediği karar da, istinaf mahkemesinin bu kararlarıdır**.

Yargıtay, temyiz (bozma) sebebini (veya sebeplerini) yerinde görürse, istinaf mahkemesinin kararını tamamen veya kısmen bozar. Yargıtay, tarafların bildirmiş oldukları temyiz sebepleri ile bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir (m. 369, 1). Yargıtay, istinaf mahkemesi kararını kanuna (hukuka) uygun bulmazsa, hükmü yalnız bozmakla yetinir; yoksa o davayı kendisi karara bağlayamaz.

İstinaf mahkemesi kararına karşı taraflardan birisinin temyiz talebi olmadan Yargıtayın kendiliğinden temyiz incelemesi yapması mümkün değildir. Başka bir deyişle tasarruf ilkesi (m. 24) burada da geçerlidir. O nedenle hükmün davanın taraflarından **yalnız biri tarafından temyiz edilmesi hali**nde Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz eden tarafın aleyhine olarak bozamaz; buna, "**aleyhe bozma yasağı**" (reformatio in peius) denir[10]. Bu yasak taleple bağlılık ilkesine paraleldir ve temyiz talebi bulunmayan kişi lehine karar verilemez. Buna karşılık, bir hüküm tarafların her ikisi tarafından da temyiz edilmişse, bu halde Yargıtay, hükmü temyiz eden taraf aleyhine de bozabilir; yani, bu halde aleyhe bozma yasağı uygulanmaz. Örnek:

Bir alacak davasında istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve alacak davasının kabulüne, ancak davacının faiz isteğinin reddine karar vermiştir. Hüküm yalnız davalı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay, hükmün faiz isteğinin reddine ilişkin kısmını kanuna aykırı bulsa bile, hükmü (davacı lehine faize de karar verilmesi gerekçesiyle) bozamaz. Çünkü, davacı hükmü temyiz etmemiştir; yani kararı benimsemiş ve doğru bulmuştur; faize ilişkin talebini ileri sürmemiştir; faize de hüküm verilmesi gerektiğine ilişkin böyle bir bozma, temyiz eden davalının aleyhine olur (aleyhe bozma yasağı).

---

9 Bu konudaki istisnalar için bkz. yuk. § 56. B.

10 Bkz. Murat Atalı, Medenî Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, Ankara 2014.

Taraflardan yalnız birinin temyizi halinde, Yargıtayın (temyiz eden tarafın lehine olarak) verdiği bozma kararına uyan istinaf mahkemesi (ve m. 373, 4'te düzenlenen istisnai halde ilk derece mahkemesi) de artık, temyiz eden tarafın, önceki (bozulan) karara oranla aleyhine olan bir hüküm veremez. Buna da, "**aleyhe hüküm verme yasağı**" denir; örnek:

"Davacı N yararına ilk kararla beş bin liraya hükmedilmiştir. Bu kararı davacı taraf temyiz etmemiştir. Davalının temyiz isteği üzerine karar bozulmuştur. İkinci kararla bu davacı lehine on bin liraya hüküm verilmiştir. İlk kararı davacı temyiz etmediğine göre diğer taraf lehine usule ilişkin müktesep hak doğmuştur. O halde, bundan fazlaya hüküm verilmesi usule ve yasaya aykırıdır".

Yargıtay, bir kararı bozunca, dava dosyasını kural olarak kararı vermiş olan mahkemeye (veya m. 373, 1 ve 4'te belirtilen mahkemelerden birisine) gönderir. Yargıtayın bozma kararına uyan mahkeme, artık bozma kararı gereğince işlem yapmak ve hüküm vermek zorundadır. Çünkü, mahkemenin bozma kararına uyması ile, bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usulî müktesep hak (usule ilişkin kazanılmış hak) doğmuştur[11].

Usulî müktesep hak, HUMK'nda düzenlenmediği gibi HMK'nda da yer almamaktadır. Bununla beraber Yargıtay, bu müesseseyi kararlarıyla ortaya çıkarmış, geliştirmiş ve en iyi (anlaşılır) şekilde 09.05.1960 günlü içtihadı birleştirme kararında açıklamıştır. Bu içtihadı birleştirme kararına göre:

"Bir mahkemenin Yargıtay dairesince verilen **bozma kararına uyması** sonunda, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak yine o kararda belirtilen hukukî esaslar gereğince karar verme mükellefiyeti meydana gelir ve bu itibarla mahkemenin sonraki hükmünün bozmada gösterilen esaslara aykırı bulunması, usule uygun sayılmaz ve bozma sebebidir; meğerki bu aykırılık sadece bozma kararında gösterilen bir usul kaidesine ilişkin bulunsun ve son kararın neticesini değiştirecek bir mahiyet arzetmesin. Mahkemenin bozma kararına **uymasiyle meydana gelen** bozma gereğince muamele yapma ve hüküm verme durumu, taraflardan **biri lehine ve diğeri aleyhine** hüküm verme neticesini doğuracak bir durumdur ve buna **usulî müktesep hak** yahut usule ait müktesep hak denilmektedir. Usul kanunumuzda bu şekildeki usule ait müktesep hakka ilişkin açık bir hüküm konulmuş değilse de temyizin bozma kararının hakka ve usule uygun karar verilmesini sağlamaktan ibaret olan gayesi ve muhakeme usulünün hakka varma, hakkı bulma maksadıyla kabul edilmiş olması yanında hukukî alanda istikrar gayesine dahi ermek üzere kabul edilmiş bulunması bakımından usule ait müktesep hak müessesesi, Usul Kanununun dayandığı ana esaslardandır ve âmme intizamı ile ilgilidir. Gerçekten, mahkemenin doğru bularak uyduğu veyahut kanun gereğince uymak zorunda olduğu bozma kararı ile dava, usul ve kanuna uygun bir çığıra sokulmuş demektir. Buna aykırı karar verilmesi, usul ve kanuna uygunluktan uzaklaşılması manasına gelir ki, böyle bir netice asla kabul edilemez".

---

[11] 09.05.1960 gün ve 21/09 sayılı İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 158-159.

Bu İBK'ndan sonraki Yargıtay kararları, hep bu İBK'na uygun olarak ve ona atıf yaparak, usulî kazanılmış hakkı çeşitli olaylara aynı şekilde uygulamıştır; örnekler:

"Mahkemenin hükmü, Yargıtay özel dairesince incelenerek (... davalıların mukabil dava dilekçelerinde hüküm altına alınmasını istedikleri 2750 lira ile ayrıca 1000 liralık istekleri şahadetle sabit olmadığına göre, davalıların bu hususta davacı tarafa bir yemin teklifine hakları olduğu hatırlatılarak neticesine göre karar verilmesi gerektiği) nedeniyle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulmuş ve bu suretle davacı bakımından usulî kazanılmış hak meydana gelmiş olduğuna göre, HUMK m. 339 hükmü gözönünde tutularak hâkim tarafından tespit edilecek yeminin, davacıya aynen eda ettirilmesi gerekmektedir. Davacının ve vekilinin ısrarlı isteklerine rağmen yalnız 1.000 lira hakkında davacıya yemin verilmesi ve 2750 liralık kısım hakkında hükmüne uyulan bozma ilâmına aykırı olarak yemin ettirilmemesi ve bu paranın da davacıdan tahsiline hüküm olunması isabetsizdir".

Yukarıda görüldüğü üzere, Yargıtayın bozma kararına uymuş olan mahkeme, bozma kararı gereğince inceleme yapıp karar vermek zorunda olduğu gibi, mahkemenin kararını bozmuş olan Yargıtay dairesi de, sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara (usulî kazanılmış hakka) aykırı şekilde ikinci bir bozma kararı veremez. Çünkü aksi halde, usul hükümleri ile hedef tutulan istikrar zedelenir ve hatta mahkeme kararlarına karşı genel güven sarsılır (karş. HUMK m. 429, IV). .

Buraya kadar incelemiş olduğumuz mahkemenin bozma kararına uyması ile meydana gelen usulî kazanılmış hak, usulî kazanılmış hakkın birinci çeşididir. Bundan başka, usulî kazanılmış hakkın ikinci bir çeşidi daha vardır ki, bu da bazı konuların **bozma kararının kapsamı dışında kalarak kesinleşmesi** ile meydana gelir:

Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün, bozma kararının (sebeplerinin) kapsamı dışında kalmış olan kısımları (konuları, cihetleri) kesinleşir. Bozma kararına uyan mahkeme, (bozma kararının kapsamı dışında kalmış olması nedeniyle) kesinleşen bu kısımlar hakkında yeniden inceleme yaparak karar veremez. Yani, kesinleşmiş olan bu kısımlar, o kısımlar lehine olan taraf yararına bir usulî kazanılmış hak teşkil eder.

Buna göre, bir hususun bozma kararının kapsamı dışında kalarak kesinleşmesi iki şekilde olabilir: 1) O husus açıkça bir temyiz sebebi olarak ileri sürülmüş, fakat Yargıtayca reddedilmiştir. 2) Veya o hususta hem bir temyiz itirazı ileri sürülmemiş, hem de dosyanın Yargıtay dairesince incelendiği sırada dosyada bulunan yazılardan onun bir bozma sebebi sayılması mümkün olduğu halde o cihet Yargıtayca bozma sayılmamıştır; örnekler:

Davalı lehine hüküm verildiği halde, davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi unutulmuştur. Hüküm, yalnız davacı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay hükmü bozmuş, mahkeme bozmaya uyarak verdiği yeni hükümde davalı lehine vekâlet ücretine de hükmetmiştir. Yargıtay, davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemesi hususunun kesinleştiği ve bunun davacı lehine

usulî müktesep hak doğurduğu gerekçesiyle davalı lehine vekâlet ücretine hükmolunamayacağına karar vermiştir.

Buraya kadar görmüş olduğumuz usulî kazanılmış hak müessesesinin, (özellikle kamu düzeni düşüncesiyle kabul edilmiş) bazı **istisnaları** vardır. Bu istisnalara bazı örnekler:

Mahkemenin bozmaya uymasından (usulî kazanılmış hakkın doğmasından) sonra, bir içtihadı birleştirme kararı verilirse, bu yeni İBK'nın mahkemelerde ve Yargıtayda görülmekte olan bütün işlere uygulanması gerekir; yani sonradan verilen İBK'na karşı usulî kazanılmış hak iddiasında (ve itirazında) bulunulamaz. Buna göre, usulî kazanılmış hakka aykırı bir İBK çıkınca, Yargıtay daireleri İBK'na aykırı ve fakat usulî kazanılmış hakka uygun olan kararları bozacaklardır. Daha önce verilmiş bozma kararları üzerine davayı incelemekte olan diğer mahkemeler de yeni İBK'nı öğrenince bozma kararı ile gösterilen yolu bırakarak, İBK gereğince inceleme yapmaya başlayacak ve o karar gereğince hüküm vereceklerdir.

Bunun gibi, bozmadan sonra, o konuda yürürlüğe giren bir **yeni kanun** uygulanması gerekir. **Görev** konusu, usulî kazanılmış hakkın istisnasıdır[12]. Yani Yargıtay, görevsiz mahkemenin vermiş olduğu bir hükmü, görevsizlikten dolayı değil de, başka bir sebepten bozmuş ise, taraflar mahkemede görev itirazında bulunabilecekleri gibi Yargıtay da ikinci temyiz incelemesinde mahkemenin hükmünü görevsizlikten dolayı bozabilir.

Yargıtayın bozma kararı, tartışmasız ve çok açık bir **maddî hata**ya dayanıyorsa, yani, bozma kararı bir maddî hata nedeniyle verilmişse, usulî kazanılmış hak kuralına dayanılamaz. Bu nedenle, maddî hatayı, usulî kazanılmış hakkın istisnalarından biri olarak kabul etmek gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir.

Kesin hükmün de usulî kazanılmış hakkın istisnalarından biri olduğu kabul edilmektedir.

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın temyizi üzerine dosya kendisine gelen Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını doğru bulmayarak bozarsa, **bozma kararı üzerine Yargıtayca ne karar verileceği ve dosyanın hangi mahkemeye gönderileceği** konusunda Kanun (m. 373, 1-2) bir ayrım yapmıştır.

Temyizen incelenen karar, istinaf mahkemesinin, ilk derece mahkemesi kararını doğru bulması sebebiyle, **istinaf talebinin esastan reddi kararına ilişkin ise** (m. 353, 1/b-1) Yargıtay, **istinaf mahkemesi kararının** kaldırılmasını ve dosyanın, kararı veren **ilk derece mahkemesine** (veya duruma göre gerekiyorsa başka bir ilk derece mahkemesine) **gönderilmesi**ne karar verir (m. 373, 1). Dikkat edilirse kanun koyucu bu hükümle, istinaf mahkemesinin, ilk derece mahkemesi kararını doğru bulması sebebiyle istinaf talebini esastan reddi halinde, dosyanın **istinaf mahkemesine değil** de ilk de-

---

[12] Görev kurallarının usulî kazanılmış hakkın istisnası olduğu hakkında 1959 tarihli İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 158.

rece mahkemesine gönderilmesi ve istinaf mahkemesi kararının kaldırılması esasını benimsemiştir.

Buna karşılık, temyizen incelenen karar, istinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesi kararını doğru bulmadığı için bu kararı **düzelterek verdiği bir kararın** (m. 353, 1/b-2) veya **ilk derece mahkemesi kararını kaldırıp verdiği yeni bir kararın** (m. 353, 1/b-3) bozulması kararı ise, Yargıtay, dosyanın, kararı veren **istinaf mahkemesine** (veya duruma göre gerekiyorsa, başka bir istinaf mahkemesine) gönderilmesine karar verir (m. 373, 1). Dikkat edilirse bu ihtimalde istinaf mahkemesi kararı kaldırılmamakta ve bozma ile yetinilmektedir.

II – ONAMA KARARI

Yargıtay, temyizen incelediği kararı usul ve esas açısından doğru bulursa (yani, bozmayı gerektiren bir sebebin bulunmadığını saptarsa) kararı onar.

Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır (m. 370, 1).

III – DÜZELTEREK ONAMA KARARI

Yargıtay, temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı kanısına varırsa, temyiz olunan kararı düzelterek onayabilir. **Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında düzelterek onama kararı verilemez** (m. 370, 2). Fakat karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek onanır (m. 370, 4).

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu (m. 370) hüküm uygulanır.

IV – YARGITAY KARARININ TEBLİĞİ

Yargıtayın temyiz incelemesi üzerine verdiği karar, dosyanın mahkemeye geri gönderilmesi üzerine (m. 373), mahkeme yazı işleri müdürü tarafından derhal taraflara tebliğ edilir. Tebliğ giderleri, temyiz dilekçesiyle birlikte, temyiz isteminde bulunandan peşin olarak alınır. Bu giderlerin ödenmemesi halinde 344. madde hükmü uygulanır (m. 372).

O) BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME

Yargıtayın bozma kararı üzerine dosya kendisine gelen mahkeme (duruma göre), ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi, bozmaya uyabileceği gibi, bozma kararına karşı direnebilir.

Dosya kendisine gelen **istinaf mahkemesi**, istinaf talebi sırasında peşin alınan gideri (m. 344) kullanarak, kendiliğinden tarafları duruşmaya çağırır, dinler ve bozmaya uyulup uyulmayacağına karar verir. **Bozmaya uyarsa**,

bozma çerçevesinde yargılamaya devam ederek, yeni bir nihaî karar (hüküm) verir. Bu karara karşı temyiz yolu açıktır. İstinaf mahkemesi, bozmaya karşı **direnme kararı** verirse ve bu karara karşı temyiz yoluna başvurulmazsa, bu karar kesinleşir. Direnme kararına karşı temyiz yoluna başvurulursa, temyiz incelemesini önce, bozma kararı veren daire inceler ve direnme kararını yerinde bulursa, bozma kararını değiştirir; direnme kararını yerinde görmezse, dosyayı karar vermek üzere Hukuk Genel Kuruluna gönderir (m. 373, 3-4).

Dosya kendisine gelen **ilk derece mahkemesi**, kendiliğinden tarafları duruşmaya çağırır, dinler ve bozmaya uyulup uyulmayacağına karar verir. **Bozmaya uyarsa**, bozma çerçevesinde yargılamaya devam ederek, yeni bir nihaî karar (hüküm) verir. **Bu karara karşı** istinaf yolu açık olmayıp **doğrudan temyiz yolu açıktır**. İlk derece mahkemesi bozmaya karşı **direnme kararı verirse** ve bu karara karşı (doğrudan) temyiz yoluna başvurulmazsa, bu karar kesinleşir. Temyiz yoluna başvurulursa, temyiz incelemesini, önce bozma kararı veren daire inceler ve direnme kararını yerinde bulursa, bozma kararını değiştirir; direnme kararını yerinde görmezse, dosyayı karar vermek üzere Hukuk Genel Kuruluna gönderir (m. 373, 3-4).

Yukarıda verilen hallerde davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak verilen kararın, önceki bozmayı kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine, alt dereceli mahkeme tarafından verilen kararın temyiz incelemesi, bozma kararı veren Yargıtay dairesi tarafından değil Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılır (m. 373, 6).

§ 57. KANUN YARARINA TEMYİZ[1]

HMK'na göre, temyiz yolu, kesin olmayan istinaf (bölge adliye) mahkemesinin nihaî kararlarına karşı başvurulan olağan bir kanun yoludur (m. 361). Yukarıda HMK hükümleri çerçevesinde tarafların bu kanun yoluna nasıl başvuracakları ve başvuru üzerine temyiz incelemesinin nasıl yapılacağı ve sonuçları incelendi.

Tarafların başvurusu üzerine yapılan temyiz incelemesinden başka, ilk derece mahkemelerinin ve istinaf mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı (karş. HUMK m. 427,VI) veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulabilir. Bu (kanun yararına temyiz başvurusu) başvuru üzerine de Yargıtay ilgili dairesince temyiz incelemesi yapılır (m. 363, 1).

Kanun yararına temyiz edilebilecek olan kesin nihaî kararlar iki çeşittir: (m. 363, 1):

1) **Verildikleri anda kesin** olan ilk derece mahkemesi kararları ile **istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşen** ilk derece mahkemesi kararları. Bunlar, istinaf yoluna götürülemeyen (yani verildikleri anda kesin olan) kararlardır. Bunlar dışında istinaf yolu açık olmasına rağmen taraflardan hiç birinin bu yola gitmemesi üzerine kesinleşen ilk derece mahkemesi kararları da kanun yararına temyize konu olabilir.

2) İstinaf mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan nihaî kararlar[2] (m. 363, 1)[3].

Görüldüğü gibi her iki halde de, nihaî karar, bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesinden veya Yargıtayın temyiz denetiminden geçmemiştir ve bu hükümler verilirken, hukuk kuralları yanlış uygulanmıştır. İşte bu hallerde, hukukun yanlış uygulandığını tespit edip, mahkemelerin bundan sonraki benzer olaylarda aynı yanlışı yapmalarını önlemek için bu gibi nihaî kararlar, Adalet Bakanlığının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyizi üzerine, Yargıtay ilgili dairesince incelenir. Yargıtay, temyiz tale-

---

1 **İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA VERİLEN KARARLAR HAKKINDA UYGULANAN HÜKÜMLER**

2 Kanun (m. 363, 1) Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümlerin kanun yararına temyiz edilebilmesi için, bu hükümlerin "niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade etmesini" şart kılmakta ve Yargıtayın HUMK'nun 427. maddesinin uygulandığı dönemdeki bazı kararları da hükmü bu şekilde uygulamaktadır.

3 İstinaf mahkemelerinin verdiği kesin kararlar ile tarafların temyiz yoluna başvurmaması nedeniyle kesinleşen bütün kararlara karşı, kanun yararına temyiz yolu açık iken, 7035 s. K. ile m. 363, 1'de yapılan değişiklik sonucu bu imkân kaldırılmıştır. Bundan böyle sadece istinaf mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı, kesin olan veya temyiz yoluna gidilmediği için kesinleşen davalar bakımından (bkz. m. 286) kanun yararına temyize gidilebilecektir.

bini yerinde görürse; yani gerçekten hukukun yanlış uygulanmış oluğu kanısına varırsa, kararı kanun yararına bozar.

Bu bozma, **kararın hukukî sonuçlarını ortadan kaldırmaz** (m. 363, 2). Başka bir deyişle, kanun yararına bozma üzerine, mahkeme tekrar yargılama yapamaz ve bozmaya uygun olarak yeni bir hüküm veremez; verirse, bu hüküm geçersizdir. Mahkeme, kanun yararına bozma kararına karşı direnme kararı da veremez; mahkeme, kanun yararına bozma kararı üzerine hiç bir işlem yapamaz. Çünkü, kanun yararına bozma, hükmün hukukî sonuçlarını kaldırmaz (m. 363, 2).

Yargıtay tarafından bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça **Resmî Gazete**de yayımlanarak (m. 363, 3), kanunların yurdun her yerinde aynı şekilde, hukuka uygun olarak, uygulanması sağlanır. İşte, kanun yararına temyizin faydası buradadır.

§ 58. YARGILAMANIN İADESİ[1]

A) KONUSU

Yargılamanın iadesi (yenilenmesi)[2], olağanüstü bir kanun yoludur; çünkü, yargılamanın iadesi yoluna ancak kesinleşmiş veya kesin olarak verilmiş olan kararlara (hükümlere) karşı başvurulabilir (m. 374). Bir karar (hüküm) henüz kesinleşmemişse, HMK m. 375'teki sebeplerden biri mevcut olsa bile, hüküm kesinleşmeden önce yargılamanın iadesi yoluna gidilemez.

Yargılamanın iadesi sebepleri, henüz kesinleşmemiş durumdaki kararlar bakımından, evleviyetle (öncelikle) olağan kanun yolu (istinaf ve temyiz) sebebi oluşturur. Yani, yargılamanın iadesi sebepleri de, esas itibariyle, hukuka (kanuna) aykırılık oluşturduklarından, genel istinaf ve temyiz sebebi (HUMK m. 428, I/1) olarak da değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle, yargılamanın iadesi sebebi olarak öngörülmüş olan bir durum (m. 375), henüz derdest (yani, kesin hükümle sonuçlanmamış) olan davada ortaya çıkarsa, bu sebep, hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin olağan kanun yolu sebebi olarak ileri sürülür ve kaldırma veya bozma nedeni oluşturur.

Yargılamanın iadesi sebebinin kanun yolları aşamasında ortaya çıkması ve kanun yolu aşamasında ileri sürülmesi halinde, istinaf mahkemesi bu hususu dikkate alabilmeli ve gereken kararı verebilmelidir (m. 355). Temyiz aşamasında ise, bu hususu ciddî görmesine bağlı olarak Yargıtayın, dosyayı istinaf mahkemesine veya (m. 373, 4'te düzenlenen durum söz konusu ise) ilk derece mahkemesine iade etmesi gerektiği kanısındayız. Aksi halde, istinaf mahkemesinin veya Yargıtayın bu hususu dikkate almayıp hükmün kesinleşmesinin beklenerek yargılamanın iadesi yoluna gidilmesi düşüncesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzamasına yol açacağı gibi usul ekonomisine de aykırılık oluşturur.

Maddî anlamda kesin hüküm gücü olmayan kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamayacağına tekrar işaret etmek isteriz.

Şeklî anlamda kesinleşmiş ve maddi anlamda Kesin hükme bağlanmış olan bir davaya yeniden bakılamayacağına ilişkin kuralın en önemli istisnası, yargılamanın iadesi (yenilenmesi) yoludur[3].

---

1 **İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA VERİLEN KARARLAR HAKKINDA HMK GEÇİCİ MADDE 3 GEREĞİ UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER**

2 Yargılamanın iadesi (yenilenmesi) konusunda geniş bilgi için bkz. Ramazan Arslan, Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977; Mert Namlı, Türk ve Fransız Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014. Yargılamanın iadesi için, HUMK (m. 445-454) **"iadei muhakeme"** terimini kullanmaktadır. Buna karşılık, İdarî Yargılama Usulü Kanunu (m. 53) **"Yargılamanın yenilenmesi"**, Sayıştay Kanunu (m. 74) **"yargılamanın iadesi"** terimini kullanmaktadır. Bundan başka, yargılamanın iadesi için, **"yargılamanın tekrarı"** terimini de kullanılmaktadır. Bir Yargıtay kararında, yargılamanın iadesi için, **"yargılamanın geri çevrilmesi"** denilmektedir. HMK ise, yargılamanın iadesi terimini tercih etmiştir.

3 HUMK'na göre yargılamanın iadesi hakkında bkz. aşa. § 61.

Yargılamanın iadesi, bazı ağır yargılama hatalarından ve eksikliklerinden dolayı, maddî anlamda kesin hükmün ortadan kaldırılmasını ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur.

O halde yargılamanın iadesi (yenilenmesi), bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından dolayı, maddî anlamda kesin hükmün ortadan kaldırılmasını ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden inceleme ve yargılama yapılarak yeni bir karar verilmesini sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur.

Yargılamanın iadesi yolu, ancak maddî anlamda kesin hüküm teşkil eden kararlar için açıktır. Kendilerine karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamayacak olan kararlar bu paragrafın son bölümünde incelenecektir.

B) YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ

Yargılamanın iadesi sebepleri, m. 375'te **sınırlı** (numerus clausus) olarak sayılmıştır. Kanunda sayılmayan bir sebep yargılamanın iadesi nedeni olmaz. Buna paralel olarak, Kanunun saydığı iade sebeplerinin kıyas yoluyla genişletilebilmesi mümkün değildir. Çünkü, yargılama hukukunun amaçlarından birisi de, taraflar arasındaki uyuşmazlığı kesin hükümle sona erdirmektir. Kesin hükmün bu özelliği (kesin hüküm elde etme amacı), kesin hükmün olabildiğince ayakta tutulmasını gerektirir. Öte yandan, yargılamanın iadesinin olağanüstü bir kanun yolu olarak kabul edilmesi de bundandır. Bu nedenlerle yalnız aşağıdaki sebeplere dayanılarak yargılamanın iadesi talep edilebilir (m. 375):

I – MAHKEMENİN KANUNA UYGUN OLARAK TEŞEKKÜL ETMEMİŞ OLMASI (m. 375, 1/a)

Mahkemelerin kanuna uygun olarak oluşması (kurulması) adil yargılanma hakkının (tabiî hâkim ilkesinin)[4] bir gereğidir. HMK, ilk defa açıkça bir yargılamanın iadesi sebebi olarak bu hususu düzenlemiştir.

Anayasa m. 142 hükmüne göre, mahkemeler kanunla kurulur. Burada sözü edilen kanun (bugün için) 5235 sayılı Kanun ve özel görevli mahkemelerin kurulmasına ilişkin kanunlardır. Mahkeme, bu Kanuna (veya kanunlara) uygun kurulmamışsa, bu (Kanun hükümlerine uygun olarak oluşturulmamış olan) mahkemenin kesinleşen kararı yargılamanın iadesi (yenilenmesi) yolu ile iptal edilir.

Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olduğunun **öğrenildiği tarihten** itibaren **üç ay** içinde bu sebeple yargılamanın iadesi talep edilmelidir (m. 377, 1/a). Yargılamanın iadesinin istenebileceği üst sınır (süre), iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl olarak kabul edilmekte ise de (m. 377, 1, son c.), kanımızca, kanuna uygun teşekkül etmemiş bir mahkemenin kararının kesinleşmesinden söz edilemeyeceği için, on yıllık sürenin burada geçerli olmaması gerekir.

---

[4] Bkz. yuk. § 5 A.

II – DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN YAHUT HAKKINDAKİ RET TALEBİ, MERCİİNCE KESİN OLARAK KABUL EDİLEN HÂKİMİN KARAR VERMİŞ VEYA KARARA KATILMIŞ BULUNMASI (m. 375, 1/b)

Bu hükme göre;

1) Davaya bakması yasak olan (m. 34-35) hâkimin davaya görüp karar vermiş olması, başka bir koşul veya kayıt aranmaksızın, yargılamanın iadesi sebebidir.

2) Davaya bakan hâkim hakkındaki ret talebi, merci hâkimi tarafından verilen kesin kararla kabul edilmişse (m. 36) ve buna rağmen hâkim davayı görüp karar vermişse veya karara katılmışsa, bu durum, yargılamanın iadesi sebebidir.

Bu hükme göre yargılamanın iadesini isteme süresi, hükmün aleyhine karar verilen tarafa tebliğinden itibaren **üç ay** ve her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren **on yıl**dır.

III – VEKİL VEYA TEMSİLCİ OLMAYAN KİMSELERİN HUZURUYLA DAVANIN GÖRÜLMÜŞ VE KARARA BAĞLANMIŞ OLMASI (m. 375, 1/c)

Dava ehliyetine (medenî hakları kullanma ehliyetine) sahip olmayanlar, davada yasal temsilcileri (TMK m. 335 vd., 396 vd.); tüzel kişiler ise, yetkili organları (TMK m. 49-50) tarafından temsil olunurlar (m. 52). Yasal temsilciler, davanın açılıp yürütülmesi belli bir makamın iznine bağlı olduğu hallerde (TMK m. 462/5) izin belgelerini; tüzel kişilerin organları ise temsil belgelerini dava veya cevap dilekçesiyle mahkemeye vermek zorundadırlar (m. 54). Dava ehliyetine sahip olanlar da, isterlerse davalarını vekil (avukat) eliyle takip edebilirler (m. 71). Vekil (avukat), açtığı veya takip ettiği davada vekâletnamesini mahkemeye vermek zorundadır (m. 76).

Davanın yasal temsilci ve vekil (avukat) eliyle takip edilmesi halinde, taraf, temsil edilen kişidir ve mahkeme onun hakkında hüküm tesis eder; bunun sonucunda, aleyhine hüküm verilen de, tarafın bizzat kendisidir.

Eğer bir davaya, taraflardan birinin gerçekten vekili veya temsilcisi olmayan bir kimsenin huzuru ile bakılır ve hüküm verilirse, bu husus, yargılamanın iadesi sebebidir (m. 375, 1/c). Örnekler:

Davada taraflardan birinin vekili (veya temsilcisi) olarak hareket etmiş olan kişinin (örneğin avukatın), o tarafı temsil yetkisinin (örneğin vekâletnamesinin) bulunmaması (m. 76) veya hiç avukatlık yapma hak veya yetkisine sahip olmayan birisinin davada vekil sıfatıyla hareket etmiş olması, yargılamanın iadesi sebebidir.

Evlilik dışı doğan bir çocuğa kayyım tayin edilmediği ve mahkeme velayeti ana ve babadan birine vermediği halde, çocuğun anası çocuk adına dava açmış ve davaya bakılmış ise, ana, yasal temsilci olmadığından, bu husus bir yargılamanın iadesi sebebi oluşturur.

Bu sebebe dayanarak yargılamanın iadesini talep etme hakkı, davada vekili veya yasal temsilcisi tarafından temsil edilmemiş olan tarafa aittir. Bu temsil eksikliğinin kararı (hükmü) etkileyip etkilemediğinin önemi yoktur (m. 380, 1). Çünkü, usulüne göre taraf teşkili sağlanmadan yargılama yapılıp karar verilmesi söz konusu olamayacağından, şeklen verilmiş olan kararı, tarafı temsil eksikliğinin etkileyip etkilemediğini araştırmak anlamsız olur. Burada, yargılamanın iadesini isteme süresi, hükmün, aleyhine hüküm verilen tarafa veya onun gerçek vekil veya temsilcisine **tebliği** veya alacaklı ya da davalı yerine geçenlerin karardan usulen haberdar olduğu **tarihinden itibaren üç ay** (m. 377, 1/b) ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

IV – YARGILAMA SIRASINDA, ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFIN ELİNDE OLMAYAN NEDENLERLE ELDE EDİLEMEYEN (BULUNAMAYAN) BİR BELGENİN, KARARIN VERİLMESİNDEN SONRA ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI (m. 375, 1/ç)

Burada öncelikle belirtilmesi gereken husus, Kanunun "senet" yerine "belge" kavramını tercih etmiş olmasıdır. Gerçekten HUMK m. 445/1'de "senet veya vesika" denilmiş olmasına rağmen HMK, yalnızca "belge"den söz etmiştir. "Belge", "senet"i de kapsayan daha geniş bir kavramdır (m. 199).

Kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş bir belgeye dayanarak yargılamanın iadesinin (yenilenmesinin) istenebilmesi için dört koşulun bir arada bulunması gerekir. Bunlar;

1) Kesinleşmiş bulunan kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olan belgenin, davanın görüldüğü sırada mevcut olması gerekir.

2) Ele geçirilen belgenin, kararı (hükmü) etkileyecek nitelikte olması gerekir. Yani, bu belge dava sırasında mahkemeye sunulabilmiş olsaydı, yargılamanın iadesi talebinde bulunanın lehine karar verilmesine neden olacak bir belge olmalıdır.

3) Bu belgenin, aleyhine karar (hüküm) verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle, davanın görülmesi sırasında elde edilememiş olması gerekir.

4) Bu belgenin, kararın (hükmün) verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması gerekir. Bu nitelikte bir belgenin, karar verildikten sonra bulunması yeterlidir; kararın kesinleşmesinden sonra bulunması gerekli değildir. Ancak, karar kesinleşmeden bu belgeye dayanarak yargılamanın yenilenmesi talep edilemez.

Yargıtayın HUMK'nun benzer hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak, aşağıdaki şekilde kararlar verdiği görülmektedir:

"Mahkemece; bu belgenin elde edilememesinin hükmü etkileyecek nitelikte olmadığı, yargılamanın yenilenmesini isteyen taraf senedin resmi bir dairede bulunduğunu biliyorsa senedin muhtevasını bilmiyor olmasının senedin yeni bulunduğu anlamına gelmeyeceği, diğer tarafa atfı kabil bir kusur ve hile ile değil de davacının veya yargıcın bir hatası yüzünden elde edilemeyen senet veya vesikanın yargılamanın iadesi sebebi olamayacağı; kaldı ki kadastro tespitine itiraz davasında verilen kararın yalnız yerinde uygulanamayan

hava fotoğrafı değil tüm dosya kapsamına dayalı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi" yerindedir.

"Somut olayda mahkemece Bağ Kur'dan davacının sigortalılık süreleri istenildiğinde Bağ Kur yeni bir araştırma yapmadan davacının dosyasındaki mevcut bilgilere göre hizmetlerini bildirmiş ise de davacının 08.02.1991 - 14.02.1999 tarihleri arasında kendi nam ve hesabına nakliyecilik işi ile uğraştığına dair vergi kaydının yargılama devam ederken dosyaya girdiğinin anlaşılmasına göre; SSK artık bu ticari faaliyetin varlığından haberdar olmakla, bu bilgiler ışığında Bağ Kur'dan gerekli bilgileri tekrar istemesinin mümkün olduğunun, oda kayıtlarının davacıdan değil ilgili odalardan istenebileceğinin kabulü gerekir. SSK.ca bu oda kayıtların istenilmemiş olmasına göre, SSK.'nun ulaşması ve temin etmesinde engel bulunmayan bu bilgilere yargılama sona erdikten sonra ancak Bağ-Kur A. il Müdürlüğü'nün 11.03.2005 tarihli yazısıyla ulaştığı iddiasına H.U.M.K 445.maddesi kapsamındaki yargılamanın yenilenmesi koşulları açısından itibar edilemeyeceğinden ve koşulları bulunmadığından mahkemece yargılamanın iadesi isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir".

"Yargılama sırasında alınan N. Valiliği Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 20.10.1999 tarihli cevabi yazısında kat irtifaklarının projelerinde yerleşim planı ve vaziyet planı bulunmadığı bildirilmiştir. Ayrıca davalı A.E. hakkında açılan ceza davasında alınan ifadesinde binanın vaziyet planının bulunmadığı açıklanmıştır. Dosyada mevcut SS. H. Konut Yapı Kooperatifi vaziyet planında C ve D Bloklarında yerleşim şekli gösterilmiş, bu belgede 'Blok' kelimesinin sonradan eklendiği davacı tarafından karardan sonra ele geçirildiği iddia edilen her iki belge arasında farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Belediyeden ibrazı gereken belgenin elde edilememiş olmasında davacıya bir kusur yükletilemeyeceğinden bu hususun 'mücbir sebep' olarak kabulü gerekir".

Bu halde (m. 375, 1/ç), yargılamanın iadesini isteme süresi, yeni belgenin **elde edildiği tarihten itibaren üç ay** (m. 377, 1/c) ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

Son olarak belirtmek gerekir ki, Yargıtay, özellikle teknolojik gelişmeler sonucu babalık davaları bakımından önem taşıyan gen incelemesi gibi yöntemlerin kullanılması suretiyle, önceki hükümlerin iptaline izin vermemektedir. Çünkü, Yargıtay, yukarıda belirtilen ölçütleri sıkı bir şekilde uygulamakta ve kararın verildiği tarihte var olan, ancak elde edilemeyen belgelere yönelik iade taleplerini kabul etmektedir.

V – KARARA ESAS ALINAN SENEDİN SAHTELİĞİNE KARAR VERİLMİŞ VEYA SENEDİN SAHTE OLDUĞUNUN MAHKEME VEYA RESMÎ MAKAM ÖNÜNDE İKRAR EDİLMİŞ OLMASI (m. 375, 1/d)

Bu madde hükmüne göre;

1) Kararın verilmesinden sonra, karara (hükme) esas alınan (hükmün o şekilde verilmesine neden olan) senedin sahte olduğuna mahkemece karar

verilmesi ve bu kararın kesinleşmiş olması üzerine yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir.

2) Karara esas alınmış olan senedin sahte olduğunun, lehine karar verilmiş bulunan tarafça, mahkeme veya resmî bir makam önünde ikrar edilmiş olması da, bir yargılamanın iadesi sebebi olur.

Sahtelik hakkındaki mahkeme kararının (yargılamanın iadesi istenilen) hükümden önce verilmiş (veya lehine karar verilen tarafın ikrarının hükümden önce yapılmış) olması halinde, eğer iade talebinde bulunan taraf, hüküm sırasında bunu öğrenmemişse, bu da iade sebebi olabilir.

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, ceza mahkûmiyetine ilişkin hükmün kesinleştiği veya hüküm lehine olan tarafın senedin sahte olduğunu mahkeme veya resmi makam huzurunda ikrar etmiş bulunduğunu öğrenme tarihten itibaren **üç ay** (m. 377, 1/ç) ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

VI – İFADESİ KARARA ESAS ALINAN TANIĞIN, KARARDAN SONRA YALAN TANIKLIK YAPTIĞININ SABİT OLMASI (m. 375, 1/e)

Davayı karara bağlayan mahkeme, dinlediği tanık ifadesini (m. 240 vd.) esas alarak sonuca varmış ve kararının (hükmünün) gerekçesini de bu tanığın ifadesine dayandırmış olabilir. Ancak, ifadesi (tanıklığı) hükme esas alınan tanığın, yalan yere tanıklık ettiği (m. 264) anlaşılırsa, kararın temeli çökmüş olur ve yargılamanın yenilenmesi gerekir.

Tanığın yalan tanıklık yapıp yapmadığı, bu konuda verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararına bağlıdır (TCK m. 272). Ancak, delil yokluğundan başka bir sebeple ceza yargılamasına başlanamamış veya mahkûmiyet kararı verilememişse, tanığın ifadesinin yalan olduğunun yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispatı gerekir (m. 375, 2).

Her yalan tanıklık (m. 264; TCK m. 272), yargılamanın iadesi sebebi oluşturmaz. Yalan tanıklığın, yargılamanın iadesi nedeni olabilmesi için, yalan tanıklık yapan kişinin ifadesinin **hükme esas alınmış olması** gerekir. Eğer mahkeme, tanığın ifadesine itibar etmemiş ve kararına gerekçe olarak da almamışsa, bu tanığın yalan tanıklıktan dolayı mahkûm edilmesi, yargılamanın iadesi nedeni olmaz.

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, tanığı yalan tanıklıktan dolayı cezaya mahkûm eden **ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren üç ay** (m. 377, 1/e) ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

VII – BİLİRKİŞİ VEYA TERCÜMANIN, HÜKME ESAS ALINAN HUSUS HAKKINDA KASTEN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞUNUN SABİT OLMASI (m. 375, 1/f)

Davayı karara bağlayan mahkeme, başvurduğu bilirkişi görüşünü (sözlü veya yazılı raporunu; m. 266 vd.) esas alarak sonuca varmış ve kararının (hükmünün) gerekçesini de bu bilirkişi görüşüne dayandırmış olabilir. Ancak,

görüşü hükme esas alınan bilirkişinin, kasıtlı olarak (bile bile) gerçeğe aykırı rapor verdiği (TCK m. 276), kesin ceza mahkemesi kararıyla anlaşılırsa, kararın temeli çökmüş olur ve yargılamanın yenilenmesi gerekir.

Bu sebebin varlığının da kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararı ile sabit olması gerekir. Yani, bilirkişinin mahkemece hükme esas alınan husus hakkındaki raporunu kasten gerçeğe aykırı olarak vermiş olduğunun hükme bağlanmış olması gerekir. Delil yokluğundan başka bir sebeple ceza yargılamasına başlanamamış veya mahkûmiyet kararı verilememişse, ceza mahkemesi kararı aranmaz; bilirkişi görüşünün kasten gerçeğe aykırı verildiğinin yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispatı gerekir (m. 375, 2).

Belirtilen hususlar, davada kendisine çeşitli nedenlerle başvurulan tercüman bakımından da geçerlidir. Örneğin, Türkçe bilmeyen tanık, tercüman aracılığıyla dinlenir (m. 154, 3/b; 263). Yine davada tarafların getirdiği yabancı dildeki belgelerin tercümelerinin de mahkemeye sunulması gerekir; ancak mahkeme, belgenin resmî tercümesini de isteyebilir (m. 223). İşte söz konusu durumlarda, tercümanın kasten geçeğe aykırı bir tercüme yaptığı ve bunun da hükmün esasını etkilediği ortaya çıkarsa, bu da bir yargılamanın iadesi sebebi olur. Yukarıda yalan tanıklığa ilişkin açıklamalar burası için de kıyasen geçerlidir.

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, bilirkişi veya tercümanı, hükme esas alınan husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan dolayı cezaya mahkûm eden **ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren üç ay** (m. 377, 1/f) ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

VIII – LEHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN, KARARA ESAS ALINAN YEMİNİ YALAN YERE ETTİĞİNİN, İKRAR VEYA YAZILI DELİLLE SABİT OLMASI (m. 375, 1/g)

HMK, kesin delil olarak taraf yeminine yer vermiştir (m. 225 vd.). Yemin, kesin delil olduğu için yemin üzerine hâkim, takdir yetkisi kullanamayıp, yemine göre davayı sona erdirir. Ancak karara esas alınan yeminin yalan olduğu ortaya çıkarsa, hükmün temeli de sarsılır.

Lehine karar verilen tarafın karara esas alınan yemini yalan yere ettiği hakkında ceza mahkemesinde bir dava açılabileceği gibi (m. 239; TCK 275); bu husus, yemin eden tarafın başka bir yerde bulunan ikrarı veya yazılı delille ortaya çıkabilir.

Yalan yere yemin eden tarafın bu hususu ceza mahkemesinde ikrar etmesi veya ceza mahkemesinin yazılı bir delile dayanarak verdiği ve kesinleşen mahkûmiyet kararı, yargılamanın iadesi talebi için gereklidir.

Delil yokluğundan başka bir sebeple ceza yargılamasına başlanamamış veya mahkûmiyet kararı verilememişse, ceza mahkemesi kararı aranmaz; lehine karar verilen tarafın yemininin yalan olduğunun yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispatı gerekir (m. 375, 2).

Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin, kesinleşmiş **ceza mahkemesi kararı**yla tespitinden (ikrar veya yazılı de-

lille sabit olmasından) **itibaren üç ay** (m. 377, 1/g) ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

IX – KARARA ESAS ALINAN BİR HÜKMÜN, KESİNLEŞMİŞ BAŞKA BİR HÜKÜMLE ORTADAN KALKMIŞ OLMASI (m. 375, 1/ğ)

Kesin hüküm halini almış kararın (hükmün) verildiği davada, kesin delil olarak bir kesin hükme dayanılmış ve mahkeme de bu kesin hükme göre karar vermişse, bu kesin hükmün (kesin delilin) kesinleşmiş bir hükümle (yargılamanın yenilenmesi yoluyla) ortadan kalkması durumunda, temeli kalmamış kesin hüküm hakkında yargılamanın yenilenmesi sebebi ortaya çıkar.

Bu sebebe dayalı olarak yargılamanın iadesi, karara esas alınan ilâmın bozularak kesin hüküm şeklinde tamamen ortadan kalkmasından **haberdar olunduğu tarihten itibaren** (m. 377, 1/d) **üç ay ve** her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

X – LEHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN, KARARA TESİR EDEN HİLELİ BİR DAVRANIŞTA BULUNMUŞ OLMASI (m. 375, 1/h)

Lehine karar (hüküm) verilen tarafın veya bilgisi dahilinde vekilinin, kararın o şekilde verilmesinde etkisi olan her türlü yanıltıcı, dürüstlük kuralına, hukuka aykırı davranışı yargılamanın iadesi sebebi olabilir. Buradaki hileyi, diğer kanunlarda düzenlenen veya tanımlanan "hile"den daha geniş bir şekilde anlamak gerekir. Örneğin, lehine karar verilen tarafın, bilirkişiyi, tanığı yanıltması, karşı tarafın vekili ile gizli anlaşması, tebligat hilesi yaparak karşı tarafın davada hazır bulunmasını veya iddia ve savunma yapmasını engellemesi ya da bir boşanma davasında davacı kocanın duruşmaya başka bir kadını getirerek davalı kadın gibi göstermesi ve böylece anlaşmalı boşanmanın sağlanması vb.

Hileli davranışın bir ceza mahkemesi mahkûmiyet kararına konu olması gerekli değildir. Yargılamanın iadesi talebinde bulunan taraf, karşı tarafa yönelik hile iddiasını davaya bakacak mahkemede ileri sürerek, iddiasını, HMK hükümlerine göre ispat edebilir.

Bu sebebe dayalı olarak yargılamanın iadesi, **hilenin farkına varıldığı tarihten itibaren** (m. 377, 1/c) **üç ay ve** her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıl**dır (m. 377, 1, son c.).

XI – BİR DAVA SONUNDA VERİLEN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA TARAFLARI, KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN İKİNCİ DAVADA, ÖNCEKİNE AYKIRI BİR HÜKÜM VERİLMİŞ VE BU HÜKMÜN DE KESİNLEŞMİŞ OLMASI (m. 375, 1/ı)

Tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynı olan bir dava hakkında verilen hükme aykırı yeni bir hüküm verilmesi için neden yokken, aynı mahkeme veya başka bir mahkeme tarafından, önceki (birinci) hükme aykırı ikinci bir hüküm verilmiş bulunması, yargılamanın iadesi sebebidir. Bu sebebe dayanarak yargılamanın iadesi yoluna gidebilmek için, her iki hükmün de kesin-

leşmiş olması gerekir (m. 375, 1/ı). Eğer ikinci hüküm henüz kesinleşmemişse (yani, ikinci dava derdest ise), yargılamanın iadesi yoluna değil, ikinci hükme karşı kanun yoluna başvurulur. Çünkü, yargılamanın iadesinin istenebilmesi için hükmün kesinleşmiş olması gerekir. Hükmün henüz kesinleşmemiş olması durumunda, yargılamanın iadesi sebepleri, (yukarıda da belirtildiği üzere) aynı zamanda ve öncelikle kanun yoluna başvurma sebebi oluşturur. Kaldı ki, kesin hüküm bulunmaması bir dava şartı olduğu için davanın her aşamasında dikkate alınır (m. 114, 1/i; 371, 1/b).

Tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynı olan uyuşmazlık hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması halinde, birinci hüküm lehine olan taraf, kesin hükümden yararlanır (m. 114, 1/i). Bu nedenle yargılamanın iadesi talebi üzerine, ikinci hükmün iptaline karar verilir (m. 380, 1).

İlk kesin hükümle bu hükme aykırı olarak verilmiş ikinci kesin hükmün, sulh, asliye veya özel görevli hukuk mahkemelerinden verilmiş olması halinde, ikinci kesin hükme karşı, yargılamanın iadesi istenebilir. Ancak, ikinci hükmün yargılamanın iadesi yolu ile iptal edilebilmesi için, bu ikinci kararı vermiş olan mahkemenin, bu kararı verdiği yargılama sırasında, ilk hükümden bilgisi olmaması, ilk hükme dayanarak kesin hüküm itirazında bulunulmamış olması gerekir. Yargılama sırasında mahkeme, ilk kesin hükümden haberdar olmuşsa ve kanun yolunda da kesin hüküm itirazı yerinde bulunmamışsa, ikinci hükmün iptalini gerektiren bir iade sebebinin varlığından söz edilemez.

Burada yargılamanın iadesini isteme süresi, ilâma ilişkin zamanaşımı süresi kadardır (m. 377,2): yani **on yıldır** (TBK m. 156; İİK m. 39). Bu süre, **ikinci hükmün kesinleşmesinden itibaren** işlemeye başlar.

XII – KARARIN, İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN VEYA EKİ PROTOKOLLERİN İHLÂLİ SURETİYLE VERİLDİĞİNİN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARI İLE TESPİT EDİLMİŞ OLMASI VEYA DOSTANE ÇÖZÜM YA DA TEK TARAFLI DEKLARASYON SONUCU DÜŞME KARARI VERİLMESİ (m. 375, 1/i)

Mahkemece verilen hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması[5] veya karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi[6] de bir yargılamanın iadesi (m. 375, 1/i) nedenidir.

Burada yargılamanın iadesini isteme süresi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş **kararının tebliğinden itibaren** (m. 377, 1/e) **üç ay** ve her halde iade talebine konu olan **hükmün kesinleşmesinden itibaren**

---

5 Bireysel başvuru yolları hakkında bkz. aşa. § 78.

6 Bu iade sebebi HMK m. 375, 1/i'ye 7145 s. K. ile eklenmiştir. Bkz. RG 31.07.2018, sa. 30495.

on yıldır (m. 377, 1, son c). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm, ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi durumunda ise yargılamanın iadesini isteme süresinin ne olduğuna ilişkin HMK'nun 377. maddesinde bir düzenleme öngörülmemiştir. Bununla birlikte söz konusu kararın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı olduğu ve HMK'nun ilgili hükmünde (m. 377, 1/e) herhangi bir değişiklik yapılmadığı dikkate alındığında kanımızca m. 377, 1/e hükmünün kıyasen uygulanması mümkündür[7].

XIII- Yargılamanın iadesi sebepleri sınırlı olmakla birlikte ve esasen yargılamanın iadesi kurumunun tüm özelliklerini barındırmamakla birlikte, **bireysel başvuru** üzerine[8], Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama yapılması için dava dosyasını ilgili mahkemeye göndermesi de, bir yargılamanın iadesi sebebi olarak nitelenebilir. Çünkü, mahkeme, Anayasa Mahkemesinin kararı gereğince, yeniden yargılama yapmak ve Anayasa Mahkemesinin ihlâl kararında açıklanan temel hak ihlâli ile sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar vermek zorundadır (AYMK m. 50, 2).

Tüm yargılamanın iadesi sebepleri incelendikten sonra, tekrar vurgulamak gerekirse, m. 375 fıkra (1) bent (e), (f) ve (g)'de düzenlenen hallerde yargılamanın iadesinin istenebilmesi, bu sebeplerin kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması şartına bağlıdır. Bu hallerde delil yokluğundan başka bir sebeple **ceza kovuşturmasına başlanamamış** veya **mahkûmiyet kararı verilememiş** ise ceza mahkemesi kararı aranmaz. Bu takdirde dayanılan yargılamanın iadesi sebebinin, yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir (m. 375, 2).

C) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ

Davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler, borçluları veya yerine geçmiş oldukları kimselerin aralarında anlaşarak, kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle hükmün iptalini isteyebilirler (m. 376. 1).

İki kişi, alacaklılara veya kendi yerlerine geçecek olan haleflere zarar vermek üzere, hileli bir anlaşma yaparak, davacı ve davalı olurlar, hüküm elde ederler ve bu hüküm kesinleşir ise, hüküm aleyhine olan tarafın alacaklıları ve aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler ile iadesi talep edilen yargılamada verilen ve kesinleşen hüküm kendilerine karşı ileri sürülebilecek olanlar (yani, dava dışı üçüncü kişiler) yargılamanın iadesi yoluna gidebilirler (m. 376).

Bunun için hükmün (davanın) taraflarının, hüküm aleyhine olan tarafın alacaklılarına veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenlere zarar vermek için, anlaşarak hile ile o taraf aleyhine hüküm verilmesini sağlamış olması şartının gerçekleşmesi gerekir. Örnekler:

---

7 Ayrıca bkz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü m. 56, 2.

8 Bireysel başvuru yolları hakkında bkz. aşa. § 78.

Mirasçılarından mal kaçırmak isteyen bir kişi, üçüncü bir kişi ile anlaşarak, bu üçüncü kişiye, kendisi aleyhine uydurma bir alacak davası açtırmıştır; davada kendini savunmayarak (tersine, davacı üçüncü kişiye yardım ederek), kendi aleyhine hüküm verilmesini sağlamıştır. Böylece malvarlığının tamamen veya kısmen elinden çıkmasına sebebiyet vermiştir. Aleyhine hüküm verilen davalının ölümünden sonra, bundan zarar gören mirasçılar (halefler), miras bırakanları (murisleri) aleyhine olan bu hükme karşı, yargılamanın iadesi yoluna başvurabilirler.

Alacaklılarının, kendisine karşı yapacakları takibin sonuçlarından (haciz, satış) kurtularak mal kaçırmak isteyen bir borçlu, üçüncü bir kişi ile anlaşarak, bu üçüncü kişiye kendisi aleyhine uydurma bir dava açtırmıştır ve aleyhine hüküm verilmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda alacaklı, alacağına kavuşamama hali ile karşılaşmıştır. Zarar gören alacaklı, bu hükme karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurabilir. Örneğin: Beş bin lira net aylık ücret alan bir borçlu, ücretine haciz konulmasını önlemek için, karısına ve çocuklarına, kendisi aleyhine nafaka davası açtırır; dört bin lira nafaka ödeyeceğini bildirir ve kendisini aylık dört bin lira nafaka ödemeye mahkûm ettirerek, alacaklılarının ücreti üzerine yeterli haciz koymalarını önlerse, borçlunun alacaklısı, bu nafaka hükmüne karşı yargılamanın iadesi yoluna giderek nafakanın dört bin liradan, iki bin liraya indirilmesini sağlayabilir (bkz. İİK m. 101, III).

Aynı şekilde borçlu kocanın alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla karısıyla anlaşmalı boşanma yoluna gitmesi ve mal paylaşımı yapması halinde, boşanma hükmü ile mal paylaşımı kararı bir bütün olduğundan bu boşanma kararının iptali için alacaklı, dava açabilir.

Kanunun üçüncü kişilere tanıdığı yargılamanın iadesi davası, m. 376'daki şartların gerçekleşmesi halinde açılan özel bir davadır. Haleflerin ayrıca, küllî halefiyet kuralları çerçevesinde, miras bırakanları (murisleri) yerine geçerek m. 375'te sayılan yargılamanın iadesi sebebiyle dava açma (veya miras bırakan, ölümünden önce yargılamanın iadesi davası açmışsa bu davayı takip etme) hakları da elbette vardır.

D) YARGILAMANIN İADESİ SÜRESİ

Yukarıda her yargılamanın iadesi sebebi incelenmiş ve her sebep için bu yola başvuru süresi belirtilmişti. Buna rağmen, burada bütün sebepler için yargılamanın iadesi süresini toplu olarak ifade etmekte yarar vardır.

Yargılamanın iadesi süresi; a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olduğunun öğrenildiği (m. 377, 1/a); b) 375. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörülen hallerde, kararın davalıya veya gerçek vekil veya temsilciye tebliğ edildiği; alacaklı veya davalı yerine geçenlerin karardan usulen haberdar olduğu (m. 377, 1/b); yeni belgenin elde edildiği veya hilenin farkına varıldığı (m. 377, 1/c); 375. maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki hallerde, ceza mahkûmiyetine ilişkin hükmün kesinleştiği veya ceza kovuşturmasına başlanamadığı yahut soruşturmanın sonuçsuz kaldığı (m. 377, 1/ç); karara esas alınan ilâmın bozularak kesin hü-

küm şeklinde tamamen ortadan kalkmasından haberdar olunduğu (m. 377, 1/d); 375. maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde yazılı sebepten dolayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararının tebliğ edildiği (m. 377, 1/e)[9] tarihten itibaren üç ay ve her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır (m. 377, 1).

Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de kesinleşmiş olması (m. 375, 1/ı) sebebinden dolayı yargılamanın yenilenmesi süresi ilâma ilişkin zamanaşımı süresi kadardır (m. 377, 2).

E) YARGILAMANIN İADESİ USULÜ

Yargılamanın iadesi yoluna, kural olarak, ancak davanın tarafları (davanın davacısı ve davalısı) başvurabilir; m. 375'te sayılan hallerde durum böyledir. Ancak istisnaî olarak, m. 376'da belirtilen yargılamanın iadesini ise, üçüncü kişiler (alacaklılar ve aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler) isteyebilirler.

Diğer kanun yollarında olduğu gibi, yargılamanın iadesine başvuracak olan tarafın bu başvuruda hukukî yararının bulunması gerekir. Bu sebeple, hüküm lehine olan tarafın, yargılamanın iadesi yoluna başvurmakta hukukî yararı yoktur; bu yola, ancak hüküm aleyhine olan taraf başvurabilir. Birbirine aykırı iki hüküm bulunması halinde (m. 375, 1/ı), ikinci hüküm ile birinci hüküm lehine olan tarafa zarar verildiğinden, yargılamanın iadesine isteme hakkı, birinci hüküm lehine ve fakat ikinci hüküm aleyhine olan tarafındır.

Yargılamanın iadesi talebi, süresi içinde bir **dava olarak açılır** ve incelenir. Yargılamanın iadesini isteme süreleri ile bu sürelerin başlangıcı, daha kolay anlaşılması amacıyla yukarıda ayrı ayrı açıklanmıştır. **Yargılamanın iadesini isteme süreleri**, zamanaşımı süresi olmayıp **hak düşürücü süre**lerdir. Bu nedenle, hâkim tarafından kendiliğinden gözetilir.

Süresinde talep edilmiş olmak kaydıyla, hüküm (ilâm) icra edildikten sonra da, yargılamanın iadesi istenebilir.

Yargılamanın iadesi davası, **kararı veren mahkemede açılır** ve o mahkeme tarafından incelenip karara bağlanır (m. 378, 1). Dava dosyası o mahkemede olduğu ve hükmü vermiş olan mahkeme, davayı en iyi bildiği için, yargılamanın iadesi davasının, hükmü vermiş olan mahkemede açılacağı ve inceleneceği hakkındaki m. 378, 1 hükmünü mutlak bir şekilde anlamak gerekir. Bu nedenle, yargılamanın iadesi davasının, o yerdeki aynı derecedeki başka bir mahkemede (örneğin hükmü vermiş olan asliye mahkemesinden başka bir asliye mahkemesinde) açılamayacağı kanısındayız.

---

[9] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucu düşme kararı verilmesi durumunda da, kanımızca m. 377, 1/e hükmünün kıyasen uygulanması mümkündür.

Yargılamanın iadesi davası, diğer davalarda olduğu gibi, bir dava dilekçesi (m. 119) ile açılır. Bu dava dilekçesinde, özellikle yargılamanın iadesini haklı gösteren sebebin (m. 375'teki sebeplerden birinin) yazılması ve açıklanması gerekir.

Vekilin (avukatın) yargılamanın iadesi davası açabilmesi için, vekâletnamesinde bir yargılamanın iadesini isteme yetkisinin açık bir biçimde bulunması gerekir (m. 74).

Mahkeme, dayanılan sebebin niteliğine göre yargılamanın iadesi talebinde bulunandan karşı tarafın olası zarar ve ziyanını karşılayacak uygun bir miktar **teminat göstermesini** isteyebilir (m. 378, 1).

Yargılamanın iadesi davası, **hükmün icrasını durdurmaz**. Ancak dava veya hükmün niteliğine ve diğer hallere göre talep üzerine icranın durdurulmasına ihtiyaç duyulursa, yargılamanın iadesi talebinde bulunan kimseden teminat alınmak şartıyla iade talebini inceleyen mahkemece **icranın durdurulması kararı** verilebilir (İİK m. 24, II; 32, I). Yargılamanın iadesi sebebi bir mahkeme kararına dayanıyorsa bu takdirde teminat istenmez (m. 381).

Yargılamanın iadesi talebi üzerine mahkeme, **ön inceleme** yapmak amacıyla tarafları davet edip dinledikten sonra, talebin kanuni süre içinde yapılmış olup olmadığını, yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılması istenen hükmün kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş olup olmadığını ve ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin kanunda yazılı sebeplerden olup olmadığını kendiliğinden inceler (m. 379, 1). Bu koşullardan biri **yoksa** ise hâkim davayı esasa girmeden reddeder (m. 379, 2).

Mahkeme, yargılamanın iadesi davasının görülebilmesi için bir usul eksikliği olmadığı kanısına varırsa, esasa girerek, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olup olmadığını araştırır.

Yargılamanın iadesi davası, mutlaka **duruşma yapılarak** incelenir. Mahkemenin dosya üzerinde **inceleme** yaparak yargılamanın iadesi talebini karara bağlaması (yargılamanın iadesi sebeplerinden birinin mevcut olmaması halinde bile) caiz değildir[10].

Mahkeme, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olmadığı kanısına varırsa, yargılamanın iadesi davasını reddeder. Buna karşılık, mahkeme, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olduğu kanısına varırsa, **yeniden yargılama yapılarak** ortaya çıkacak duruma göre verilmiş olan karar **onanır** veya kısmen yahut tamamen **değiştirilir**. Ancak, davacının açık veya zımni muvafakati olmaksızın vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması (m. 375, 1/c) yahut 375. maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine dayalı olarak yargılamanın iadesi dilekçesinin kabul olunması halinde, **başka bir inceleme yapılmaksızın hüküm iptal edilir.** Bu husus, iade yoluyla incelenmesi istenen hükmün bütün nüshalarında gösterilir (m. 380, 1-2).

---

[10] Bkz. 23.05.1956 gün ve 08/09 sayılı İBK (RG 11.08.1956, sa. 9379)

O halde mahkemenin vereceği karar bakımından yargılamanın iadesi sebeplerine göre bir ayrım yapmak gerekir:

1) HMK'nun **375. maddesinin 1. fıkrasının c ve ı bentleri dışında** yazılı sebeplerden birine dayalı yargılamanın iadesi:

Bu sebeplerle yargılamanın iadesi talebini kabul eden mahkeme, hükmün iptali ile yetinemez. Mahkemenin yeniden yargılama yaparak, ortaya çıkacak duruma göre verilmiş olan **kararı onaması** veya kısmen yahut tamamen **değiştirmesi** gerekir (m. 380, I).

Yeniden yapılacak olan bu yargılama, iadesi istenen yargılamanın (asıl davanın) devamı niteliğindedir. Taraflar, burada yeni delil gösterebilirler; fakat, asıl davadaki davayı değiştirme ve savunmayı genişletme yasağı (m. 141), yargılamanın iadesi davasında da geçerlidir. Yani taraflar, kural olarak, asıl dava sırasında yapmış oldukları iddia ve savunmaları ile bağlıdır.

Bu halde, yargılamanın iadesi sebebine göre, yapılacak yeni yargılamanın şekli de değişir. Örneğin, yeni bir senedin ele geçirilmiş olmasına dayanarak yargılamanın iadesi istenmişse, mahkeme, bu senedin hükme etkisi olup olmadığını inceler. Tanığın yalan söylediğine dayanarak yargılamanın iadesi istenmiş ise, bu tanığın ifadesi dikkate alınmadan hüküm verilir. Tebligat hilesi ile bir tarafın yokluğunda hüküm verilmiş ise, o tarafın delilleri de sorulup, bütün deliller birlikte incelenerek hüküm verilir.

Mahkeme, bu şekilde yapacağı tahkikat ve yargılama sonucunda; yargılamanın iadesi sebebinin doğru olmasına rağmen, eski hükmünü doğru bulabilir; yani, yargılamanın iadesi sebebini hükme etkili bulmayabilir. Bu halde mahkeme, eski kararını onar (tekrarlar). Buna karşılık mahkeme, eski hükmün kısmen veya tamamen değiştirilmesi gerektiği kanısına varırsa, eski hükmünü kısmen veya tamamen değiştirir (m. 380, 1).

2) HMK'nun **375. maddesinin 1. fıkrasının c ve ı bentlerinde** yazılı sebeplerden birine dayalı yargılamanın iadesi:

HMK m. 380, 1 uyarınca, iki halde hükmün mahkeme tarafından iptal edilmesi öngörülmüştür. Buna göre, davacının açık veya zımni muvafakati olmaksızın vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması yahut 375. maddenin 1. fıkrasının (ı) bendine dayalı olarak yargılamanın iadesi dilekçesi kabul olunursa, **başka bir inceleme yapılmaksızın hüküm iptal edilir.** Bu husus, iade yoluyla incelenmesi istenen hükmün bütün nüshalarında gösterilir (m. 380, 2).

Yargılamanın iadesi davası sonucunda, eski hükmün kısmen veya tamamen değiştirilmesine karar verilmiş ise bu karar, eski hükmün yerine geçer, yani geçmişe etkilidir. Eski hüküm daha önce icra edilmiş ise, icra eski haline iade olunur (İİK m. 40). Ancak, bir boşanma hükmünün kesinleşmesi ile bu hükme karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulması arasındaki dönemde, taraflardan biri, başka biri ile evlenmişse, bu yeni evlenme geçerli kalmakta devam etmesi gerektiği kanısındayız.

F) YARGILAMANIN İADESİNE KONU OLMAYAN KARARLAR

Yukarıda, bazı kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamayacağına kısaca değinilmişti. Bazı kararlara karşı, yargılamanın iadesi davası açılamaz (açılmasına gerek yoktur). Örnekler:

Çekişmesiz yargıda verilen kararlar, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmadıklarından (m. 388), bu kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurmaya gerek yoktur. Çünkü, HMK m. 375'teki sebeplerden birinin mevcut olması halinde, kararın sonradan haksız görülmesi veya sonradan meydana gelen değişiklikler nedeniyle, çekişmesiz yargıda her zaman kararın değiştirilmesini istemek mümkündür.

İcra mahkemesinin (İİK m. 4), örneğin, ödeme emrine itirazın kaldırılması taleplerinin ret veya kabulüne ilişkin **kararları** (İİK m. 68-68a), maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, bu icra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. Buna karşılık, icra mahkemesinin, istihkak davaları (İİK m. 96 vd.) ve ihalenin feshi davasının (talebinin; İİK m. 134) reddine ilişkin kararları, maddî anlamda kesin hüküm oluşturduğundan[11], bu kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir.

---

[11] Yargıtay, son yıllarda hem ihalenin feshi talebinin reddi kararı hem de istihkak davasında verilen kararlar bakımından, bu kararların maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceği biçiminde kararlar vermektedir.

§ 59. TEMYİZ (HUMK m. 427-439, 443-444'e Göre)[1,2]

A) GENEL OLARAK

Yukarıda da belirtildiği üzere, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin Resmî Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihine (20.07.2016'ya) kadar, HUMK'nun temyize ilişkin hükümleri (HUMK m. 427-444) uygulanmıştır (HMK geçici m. 3, 1).

*Yine, **istinaf mahkemelerinin göreve başlama** (faaliyete geçme) **tarihinden** (20.07.2016'dan) **önce verilen**[3] **kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar**, HUMK'nun 5236 s.K.'la yapılan değişiklikten önceki **427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır** (HMK geçici m. 3, 2).*

Bu sebeple, Kitabımızın bu kısmında, HUMK'nda yer alan temyiz ve karar düzeltme (kanun yollarına) hükümlerine de yer verdik.

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, yukarıda gördüğümüz HMK'nda düzenlenen temyiz yolu ile HUMK'ndaki temyiz yolunun en önemli farkı; HMK'ndaki temyiz yolu (ilk derece mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı değil) istinaf mahkemesinin nihaî kararlarına karşı gidilen bir yol iken; HUMK'ndaki temyiz yolu, ilk derece mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı gidilen yol olmasıdır.

B) TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR

Kural olarak, ilk derece mahkemelerinin vermiş oldukları bütün nihaî kararlar (hükümler) temyiz edilebilir (HUMK m. 427, I/c.1). Ara kararları, yalnız başına temyiz edilemez; ancak, asıl hükümle birlikte temyiz edilebilir. İstisnaî olarak, bazı nihaî kararların temyiz edilemeyeceği kabul edilmiştir.

Temyizi mümkün olan nihaî kararlar, üç gruba ayrılabilir:

***Hükümler**, kural olarak, temyiz edilebilir. Feragat, kabul ve sulh halinde verilen (nihaî) kararlar da usul hükümlerine uyulmadığı gerekçesi ile temyiz edilebilir.*

***Usule ilişkin nihaî kararlar** da, kural olarak temyiz edilebilir. Bu husus, yukarıda (ilgili bölümlerde) görüldü. Bu nedenle, burada ilgili bölümlere yollama yaparak, temyiz edilebilecek usule ilişkin nihaî kararlara bazı örnekler verilmekle yetinilecektir.*

---

1 **İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) ÖNCE VERİLEN KARARLAR HAKKINDA UYGULANAN VE HMK GEÇİCİ MADDE 3 UYARINCA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

2 Bkz. Burhan Gürdoğan, Yargıcın Takdir Hakkının Yargıtay'ca Denetlenmesi, Ankara 1967; Ömer Sivrihisarlı, Hukuk Yargılamasında Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri ve Yargıtay Denetiminin Kapsamı, İstanbul 1978; Recep Akcan, Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Ankara 1999.

3 Bkz. yuk. § 54, A, dn. 3.

Görevsizlik kararı, yetkisizlik kararı, dosyanın yeni mahkemeye devri kararı, hâkimin çekinmesi kararı, hâkimin reddi talebinin reddine veya kabulüne ilişkin merci kararı, başka mahkemelerde açılmış olan davaların birleştirilmesi kararı, davanın açılmamış sayılması kararı, dosyanın işlemden kaldırılması kararı, ilk itirazın kabulüne ilişkin nihaî kararlar vb. temyiz edilebilir.

***Davanın konusuz kalması** halinde verilen nihaî kararlar da temyiz edilebilir.*

Yargıtay, esas itibariyle denetim (kanun yolu) mahkemesidir; ancak istisnaî olarak bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak bakar (örneğin m. 47, 1). Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların da temyizi mümkündür.

Mahkemelerin nihaî kararlarının kural olarak temyiz edilebileceği kuralı, bazı istisnalar hariç, asliye hukuk mahkemeleri ve özel görevli mahkemeler için mutlaktır. Buna karşılık, sulh hukuk mahkemelerinin nihaî kararları için bir ayrım yapılması gerekir: Sulh hukuk mahkemelerinin nihaî kararları da kural olarak temyiz edilebilir. Ancak, sulh mahkemesinin nihaî kararına karşı asliye mahkemesine itiraz etme imkânı varsa, o zaman sulh mahkemesinin kararı (sulh mahkemesi bu kararla işten el çektiğinden) nihaî karar olmakla beraber, temyiz yolundan önce arada bir itiraz yolu bulunduğundan, doğrudan doğruya temyiz edilemez. İlgilinin, sulh hukuk mahkemesi kararına karşı asliye hukuk mahkemesinde itiraz etmesi (örneğin TMK m. 397; 422, III; 461, II; 463; 488) ve asliye hukuk mahkemesinin itiraz üzerine vereceği karara karşı temyiz yoluna başvurması gerekir; yoksa, doğrudan temyiz yoluna başvurulamaz.

C) TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

Nihaî kararların temyiz edilebileceği kuralı mutlak değildir. Yani, istisnaî olarak bazı nihaî kararların temyiz edilemeyeceği kabul edilmiştir. Temyiz edilemeyen nihaî kararlar şunlardır:

*1) Miktar veya değeri HUMK m. 427, II'deki parasal **temyiz sınırını** (2019 yılı için: 3.200TL; icra mahkemelerinde: 9.260 TL) **geçmeyen** taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihaî kararlar (verildikleri anda) kesindir (HUMK m. 427, II). Bu fıkranın uygulanmasında, hükmün sulh veya asliye mahkemesinden veya bir özel görevli mahkemeden (örneğin iş mahkemesinden) verilmiş olması arasında fark yoktur[4]. Bu yüzden, miktar veya değeri HUMK m. 427, II'deki sınırı geçmeyen taşınır ve alacak davalarına ilişkin her çeşit hukuk mahkemesi nihaî kararları kesindir; temyiz edilemez. Kanundaki sınır (HUMK m. 427, II), yalnızca taşınır mal ve alacak davalarıyla ilgilidir. Buna karşılık örneğin taşınmaz davaları bu hükme tâbi değildir.*

Delil tespiti (m. 400-405) giderleri, dava konusuna dahil olmadığından, HUMK m. 427, II'deki temyiz sınırının belirlenmesinde nazara alınmaz; birleştirilen davalarda, HUMK m. 427, II'deki temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.

---

[4] Bkz. ayrıca, aşa. § 73.

İhtiyarî dava arkadaşlığında (m. 57-58), HUMK m. 427, II'deki temyiz sınırı, her dava arkadaşının davası birbirinden bağımsız olduğu için, ayrı ayrı belirlenir.

Karşı davada (m. 132), HUMK m. 427, II'deki temyiz sınırı, asıl dava ve karşı dava için ayrı ayrı belirlenir.

Tespit davalarında (m. 106; İİK m. 72), HUMK m. 427, II'deki temyiz sınırı, tespit davasının öncüsü olduğu eda davasının miktar veya değerine göre belirlenir.

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması (m. 107) halinde, (HUMK m. 427, II'deki) kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir (HUMK m. 427, III).

Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü, m. 427, II'deki ***parasal sınırı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur*** *(HUMK m. 427, IV/c.1); örnekler:*

a) 6.000 liralık bir alacak davasında, mahkeme, davanın 3.000 lirasını kabul, 3.000 lirasını reddederse, taraflardan hiç birisi hükmü temyiz edemez. Çünkü, hem davacının hem davalının temyizdeki menfaati, temyiz sınırının altındadır.

b) 6.000 liralık bir alacak davasında, mahkeme, davanın 1.000 lirasını kabul, 5.000 lirasını reddederse, davalı bu hükmü temyiz edemez (davacı temyiz edebilir).

c) Yukarıda örnekte mahkeme, davanın 5.000 lirasını kabul, 1.000 lirasını reddederse, davacı bu hükmü temyiz edemez (davalı temyiz edebilir).

Kural bu olmakla birlikte; temyiz etme hakkı bulunan tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde, temyiz hakkı olmayan tarafın düzenleyeceği cevap dilekçesinde (HUMK m. 433, II) temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi (yani hükmü temyiz etmesi) mümkündür (HUMK m. 427, IV/ c. 2); buna ***katılma yolu ile temyiz*** *denir; örnekler:*

Yukarıdaki 2. (b) örnekte, davacı, davasının 5.000 lirasının reddine ilişkin hükmü süresinde temyiz ederse; davalı da, buna karşı on gün içinde vereceği cevap dilekçesinde (HUMK m. 433, II) hükmün 1.000 lira ödemeye mahkûm edilmesine ilişkin bölümünü (katılma yolu ile) temyiz edebilir (HUMK m. 427, IV/c.2).

Yukarıdaki 3. (c) örnekte, davalı, aleyhine verilen 5.000 liralık hükmü süresinde temyiz ederse; davacı da, buna karşı on gün içinde vereceği cevap dilekçesinde (HUMK m. 433, II), davasının 1.000 liralık kısmının reddine ilişkin hükmü (katılma yolu ile) temyiz edebilir (HUMK m. 427, IV/c. 2).

2) ***Özel bir kanun hükmü ile*** *bazı nihaî kararların* ***kesin*** *olduğu veya yalnız başına temyiz edilemeyeceği kabul edilmiş olabilir. Örneğin: TTK m. 310, 2; Kooperatifler K. m. 21, IV; Kadastro K. m. 4, VIII; 4081 s. K. m. 26; 195 s .K. m. 49; bkz. ayrıca: Yargıtay K. m. 17, 3.*

Kesin (temyiz edilemeyen, temyizi mümkün olmayan) kararlara karşı temyiz yoluna başvurulursa, kararı veren mahkeme, temyiz isteminin (talebinin) reddine kendisi karar verir (HUMK m. 432, III).

D) TEMYİZ (BOZMA) SEBEPLERİ

Temyiz sebebinden kasıt, tarafın hükmü hangi gerekçeye dayanarak temyiz edebileceği; yani, temyiz talebinin dayanağının ne olacağıdır. Tarafın temyize gidebilmesi için öngörülen ***temyiz sebebi****, kabulü halinde, Yargıtay açısından da bir* ***bozma nedeni****dir; yani, bozma kararının gerekçesidir.*

Aşağıda göreceğimiz temyiz sebepleri, esas itibariyle, bir ***hukuk kuralının yanlış uygulanmış olması*** *nedenine dayanır. Her ne kadar HUMK m. 428, I/1'de "kanun" kelimesi kullanılmış olsa da, buradaki "kanun" ibaresini, "hukuk" olarak anlamak gerekir. Buradaki hukuk kuralı terimi, (Anayasa dahil) tüm kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, örf ve âdet hukuku vb hukuk kurallarını kapsar. Tarafların kendi aralarında yapmış oldukları sözleşmeler de (tarafların kanunu olmaları hasebiyle), buradaki anlamda hukuk kuralı terimine dahildir; bu* ***sözleşmelerin yanlış uygulanmış*** *olması da temyiz (bozma) sebebidir (HUMK m. 428/1).*

Bir ***hukuk kuralının yanlış uygulanmasından kasıt****, o hukuk kuralının hiç uygulanmamış veya eksik uygulanmış olmasıdır. Bir hukuk kuralının yanlış uygulanmış olmasının temyiz sebebi sayılması için verilen kararın hukukun bu yanlış uygulanmasına dayanması (yanlış uygulanmanın sonucu olması) gerekir. Başka bir ifadeyle, hukuk kuralının yanlış uygulanmış olması ile, verilen karar arasında uygun bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Buna göre; hukuk kuralı yanlış uygulanmamış olsa idi, verilen karar başka türlü olacak idiyse, uygun nedensellik bağı var demektir.*

Bu hususun tespiti, maddî hukukta ve usul hukukunda başka başka olduğundan, her iki hukuka göre olan temyiz sebepleri arasında bir ayrım yaparak, kanunun saydığı temyiz (bozma) sebeplerini (HUMK m. 428) bu ayrıma göre incelemek uygun olur:

I – MADDÎ HUKUKA DAYANAN TEMYİZ (BOZMA) SEBEPLERİ

Maddî hukuka (örneğin TMK, TBK, TTK'na) ilişkin bir hukuk kuralının yanlış uygulanmış olması halinde, bu yanlış uygulama ile verilen karar arasındaki illiyet bağını tespit etmek kolaydır. Burada, verilen kararı etkilemiş olan ***maddî hukuk kuralları****nın yanlış uygulandığı bütün haller, temyiz sebebidir. Örnekler:*

Haksız fiilden dolayı açılan bir tazminat davasında, mahkeme, haksız fiilin unsurları (TBK m. 49), örneğin kusur mevcut olmadığı halde, davalıyı tazminata mahkûm etmiştir. Mahkeme, eğer TBK m. 49 hükmünü yanlış uygulamamış olsa idi karar başka türlü olacak, dava reddedilecektir; o halde bu bir temyiz sebebidir (karş. HUMK m. 428/1).

Mahkeme, ***maddî vakıaları yanlış değerlendirmiş****, taraflar arasındaki hukukî ilişkiyi, satış sözleşmesi yerine, eser (istisna) sözleşmesi olarak nitelendirmiştir. Satış sözleşmesi hakkındaki hükümlerin uygulanması halinde karar başka türlü olacak (değişecek) idi ise, bu durum bir bozma sebebidir.*

*Kanun, maddî hukuka dayanan temyiz sebeplerinin bu ikinci çeşidini, "**meselei maddîyenin takdirinde hata edilmesi**" (maddî konunun değerlendirilmesinde hataya düşülmesi) şeklinde ifade etmektedir (HUMK m. 428/5). Uygulamada (istinaf yolunun açılmasından önce) Yargıtay, maddî meselenin takdirinde hata edilmiş olması şeklindeki bu temyiz sebebine dayanarak, delillerin takdirinin doğru yapılmış olup olmadığını da incelemiş; böylece istinaf derecesinin (mahkemesinin) boşluğunu kısmen doldurmaya çalışmıştır.*

II – USUL HUKUKUNA DAYANAN TEMYİZ (BOZMA) SEBEPLERİ

Mahkemenin usul kurallarının uygulanmasında hata yapması da, temyiz (bozma) sebebi olabilir. Ancak, her usul kuralı ihlâli, başlı başına temyiz sebebi oluşturmaz. Bir usul kuralı ihlâlinin temyiz sebebi olabilmesi için, ihlâl edilen usul kuralının, hükmü etkileyecek derecede önemli olması gerekir. Eğer ihlâl edilen usul kuralı doğru uygulansa (usul kuralının uygulanmasında yanlışlık yapılmasa) idi, farklı bir karar verilecek idiyse, o usul kuralı, bozma açısından önemli bir usul kuralıdır. Başka bir deyişle, hiç uygulanmayan veya yanlış uygulanan usul kuralı ile verilen hüküm arasında uygun nedensellik bağı (doğrudan bir ilişki) varsa, bu husus bir temyiz (bozma) sebebi oluşturur.

Ancak, usul kuralının hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması ile verilen karar arasında bir nedensellik bağının mevcut olup olmadığını tespit etmek, yani o kural yanlış uygulanmamış olsa idi verilen kararın başka türlü olacağını söylemek zordur.

Bu yüzden Kanun (HUMK m. 428), usul hukukuna dayanan temyiz (bozma) sebeplerini, "mutlak temyiz sebepleri ve "nispî temyiz sebepleri" olarak ikiye ayırmayı gerektiren bir düzenleme getirmiştir.

1) Mutlak Temyiz (Bozma) Sebepleri

Öyle usul kuralları vardır ki, bunların yanlış uygulanması halinde, bu yanlış uygulamanın verilen kararı mutlaka etkilediği var sayılır. Bu hallere mutlak temyiz (bozma) sebebi denir. Bu hallerde, usul hukuku kuralının yanlış uygulanması ile hüküm arasında bir nedensellik bağının bulunup bulunmadığı araştırılmaz ve bu bağ var sayılarak hüküm bozulur. Mutlak temyiz sebepleri şunlardır:

*a) Mahkemenin **görevsiz olması** (HUMK m. 428/2). Görev (m. 1-4) kamu düzenine ilişkin olduğundan, buna uyulmaması mutlak bir temyiz sebebidir.*

*b) **Yargı yolunun caiz olmaması** (örneğin, hukuk mahkemesinin değil, idarî mahkemenin görevli olması gibi) da mutlak bir temyiz sebebidir[5].*

*c) Tarafları, dava sebebi (davada dayanılan vakıaları) ve konusu aynı olan bir (aslında iki) dava hakkında **birbiriyle çelişik kararlar** verilmiş olması (HUMK m. 428/3). Bu iki dava sonucunda verilen hükümlerin çelişik olması halinde, temyiz yolu ile bu hükümlerden birinin bozulması gerekir. İki hüküm de henüz kesinleşmemişse Yargıtay, bunlardan doğru bulduğunu onar,*

---

5 HUMK m. 428/2 hükmüne kıyasen.

diğerini bozar. Hükümlerden biri kesinleşmiş ise, ikinci hüküm mutlaka bozulur. Hükümlerden her ikisi de kesinleşmiş ise, bu halde yargılamanın iadesi yoluna (HUMK m. 455/10) gidilir.

*ç) İki taraftan birinin davasını ispat için gösterdiği **delillerin kanunî sebep olmaksızın reddedilmiş olması** (HUMK m. 428/6). Bundan maksat, hâkimin delilleri takdir yetkisini yerinde kullanıp kullanmadığının denetlenmesi değildir. Bundan kasıt, hâkimin kesin delille (senet, ikrar, yemin, kesin hüküm) ispatı gerekmeyen bir husus hakkında gösterilen bir takdirî delili (örneğin tanık dinletme isteğini) o hususun kesin delille ispatı gerektiği kanısı ile reddetmiş olmasıdır.*

*d) Bir davaya bakması **yasak olan hâkimin** (m. 34) yargılamaya ve karara iştirak etmiş olması. Bir yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilen (HUMK m. 445/9) bu halin, öncelikle mutlak bir temyiz sebebi teşkil etmesi gerekir.*

*e) **Vekil ve mümessil olmayan kişiler** huzuruyla davaya bakılmış ve hüküm verilmiş olması. Bir yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilen (HUMK m. 445/8) bu halin de, öncelikle mutlak temyiz sebebi teşkil etmesi gerekir. Vekilin davaya vekâlet ehliyetinin bulunmaması da mutlak bir temyiz nedenidir.*

*f) Hüküm mahkemesinde davanın görülmesi sırasında taraflardan biri tarafından bir **usul kuralının yanlış uygulandığını** ispat edecek derecede **itiraz** edildiği halde, mahkemenin bu itirazı incelememiş olması (HUMK m. 428, II/son yarım cümle). Örneğin, taraflardan biri zamanında hâkimi reddettiği halde, hâkim bu itirazı dikkate almadan yargılamaya devam etmiş ve karar vermiştir.*

*g) Kanımızca, **hükmün gerekçesiz olması** (Anayasa m. 141, III) da bir mutlak temyiz sebebi sayılmalıdır.*

*ğ) Bütün **dava şartlarının** (m. 114) **bulunmaması** hallerini de mutlak temyiz sebebi olarak kabul etmek gerekir.*

Mutlak temyiz sebeplerinde Yargıtayın incelemesi, bu sebeplerin bulunup bulunmadığını tespit etmekle sınırlı olur. Yargıtay, bu sebeplerden birinin mevcut olduğu sonucuna varırsa, bu sebep ile verilen karar arasında bir nedensellik bağının mevcut olup olmadığını, yani bu sebebin varlığının hükmü değiştirecek nitelikte bulunup bulunmadığını araştırmaksızın, kararı bozar.

2) Nispî Temyiz** (Bozma) **Sebepleri

*Mutlak temyiz sebepleri dışında kalan hallerde, **bir usul hukuku kuralının yanlış uygulanmış olmasının**, temyiz (bozma) sebebi oluşturabilmesi için, hukukun bu yanlış uygulamasının, **verilen kararı değiştirebilecek nitelikte olması** gerekir (HUMK m. 428/4 ve fıkra II/ilk yarım cümle). Yani, o usul hukuku kuralı yanlış uygulanmasaydı karar başka türlü verilecek idi ise, bu hal temyiz sebebi olarak kabul edilebilir ki, bunlara (mutlak temyiz sebeplerinin karşıtı olarak) nispî temyiz sebepleri denir.*

Nispî temyiz sebeplerinde, hukukun yanlış uygulanmış olması ile verilen karar arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekir. Yukarıda da belirtildiği üzere, usul hukukunda bu bağı tespit etmek, maddî hukuktaki gibi kolay değildir. Bu yüzden burada, böyle bir bağ bulunmasının ihtimal dahilinde olması ile yetinilmelidir.

Maddî hukuka dayanan temyiz sebeplerinde olduğu gibi, nispî temyiz sebeplerini de ayrı ayrı saymaya imkân yoktur. Usul hükümlerinin yanlış uygulanmış olması ile verilen karar arasında hangi hallerde nedensellik bağı bulunduğu, her olayın özelliğine göre, Yargıtay tarafından takdir edilir. Sonuç üzerine etkisi olan ve bu nedenle temyiz (bozma) sebebi teşkil eden usul yanlışlığına iki örnek:

Gerekli olduğu halde bilirkişi incelemesi yaptırılmadan hüküm verilmiş olması, genellikle hükmün sonucuna etkili bir usul yanlışlığı olduğundan bozma sebebi oluşturur.

Aralarında bağlantı bulunmamasına (karş. m. 166, 4) rağmen davaların birleştirilmesine karar verilmiş ve davaların birlikte inceleyip hükme bağlamış olması, davaların daha iyi incelenmesini önlemiş ise, sonuca etkili bir usul yanlışlığıdır; bu nedenle bozma sebebidir.

*Buna karşılık, mahkemenin yapmış olduğu usul yanlışlığı, **sonuç üzerine etkili değilse** temyiz (bozma) sebebi teşkil etmez. Yani, yanlış uygulanan usul kuralı doğru kullanılmış olsa idi dahi, verilen hüküm aynı kalacak idi ise, bu usul yanlışlığı bozma sebebi olmaz.*

Hükmün sonucunu etkilemeyen (önemsiz) usul yanlışlıkları bozma sebebi sayılamaz (HUMK m. 428/son). Aksi halde, sırf şekle dayalı ve hükmü değiştirmeyen usul yanlışlığı yüzünden kararın bozulması, davaları (uyuşmazlıkları) uzatmaktan başka işe yaramaz. Eğer, her usul hatası temyiz sebebi olsa idi, o zaman gereksiz ve haksız olarak şekil, hakka tercih edilmiş olurdu. Örnek:

Kanun koyucu bu amaçla, davanın gereksiz uzamasını önlemek için, bu tür usul eksikliğini bozma sebebi kabul etmemiştir. Örneğin, bir olayda Yargıtay, son oturumda davacıya söz verilmeden duruşmanın bitirilmesini (kararın verilmesini) önemli bir usul hatası olarak görmemiştir Yargıtay, bu eksiklik olmasa idi, temyize konu olandan başka bir hüküm verilmesi mümkün olacak idiyse, bu takdirde, usul yanlışlığı sebebiyle hükmün bozulması gerekirdi. Oysa, dosyadaki deliller, özellikle doyurucu ve ayrıntılı raporlar karşısında davacı tarafa son oturumda söz verilmiş olsaydı bile, davanın reddi gerekeceği için bu konudaki temyiz başvurusunu reddetmiştir.

E) TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI

Temyiz yoluna, ancak davanın tarafları başvurabilir. Maddî bakımdan zorunlu dava arkadaşları, verilen hükmü ancak birlikte temyiz edebilirler (m. 60). Buna karşılık, ihtiyarî dava arkadaşlarından (ve şeklî bakımından zorunlu dava arkadaşlarından) her biri hükmü yalnız başına temyiz edebilir (m. 58). Ferî müdahil (m. 66-69), yalnız başına hükmü temyiz edemez.

Çekişmesiz yargı işlerinde (m. 382), bir kararı temyiz etmekte hukukî yararı bulunan bütün ilgililer temyiz yoluna başvurabilirler.

Daha önce de belirtildiği üzere, bir kararı temyiz etmek isteyen kişinin, o kararı temyiz etmekte hukukî yararının bulunması gerekir.

I – TEMYİZ SÜRESİ

***Asliye hukuk mahkemesi** kararlarına karşı temyiz süresi, **on beş gün**dür. Temyiz süresi, ilâmın usulen taraflardan her birine tebliği ile işlemeye başlar (HUMK m. 432).*

***Sulh hukuk mahkemesi** kararlarına karşı temyiz süresi, **sekiz gün**dür. Bu süre de, ilâmın (kararın) usulen taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar (HUMK m. 437, I).*

Paydaşlığın (şüyuun) satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilen şikâyetler hakkındaki sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi, tebliğden itibaren sekiz gündür.

Bir tarafın davayı vekil aracılığı ile takip etmesi halinde, hüküm (karar) vekile tebliğ edilir (Teb. K. m. 11) ve temyiz süresi vekile yapılan tebligat ile işlemeye başlar.

Yukarıda belirtilen kanunî temyiz süresi (HUMK m. 432, I; 437, I) geçtikten sonra temyiz yoluna başvurulamaz; başvurulursa, kararı veren mahkeme temyiz talebinin (isteminin) reddine kendisi karar verir (HUMK m. 432, III).

*Temyiz süresi geçtikten sonra temyiz yoluna başvurulamayacağı kuralının bir istisnası vardır: Temyiz süresini elde olmayan sebeplerle kaçırmış olan taraf, **eski hale getirme** yoluna (m. 95 vd.) **başvurmak** (ve aynı zamanda hükmü temyiz etmek) suretiyle hükmün temyizen incelenmesini sağlayabilir. Bundan başka, temyiz süresini geçirmiş olan taraf, diğer tarafın süresinde yaptığı temyiz talebi üzerine, cevap süresi içinde hükmü **katılma yoluyla temyiz** edebilir (HUMK m. 433, II).*

II – TEMYİZ TALEBİ

*Tasarruf ilkesi (m. 24) gereği, bir kararın temyizen incelenebilmesi için **taraflardan birin**in kararını temyiz etmiş olması gerekir. Yargılama yokluğunda yapılmış ve hüküm yokluğunda verilmiş (m. 147) olan taraf da, yokluğunda verilmiş olan hükmün temyizini talep edebilir. Talep olmadıkça, mahkeme dava dosyasını kendiliğinden Yargıtaya gönderemeyeceği gibi, Yargıtay da bir kararı kendiliğinden temyizen inceleyemez.*

1) Temyiz Dilekçesi

Temyiz talebi dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye aleyhine temyiz edilenlerin (karşı taraf) sayısı kadar suret eklenir (HUMK m. 431; Y m. 208, 1-3).

Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur (HUMK m. 435, I):

Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı soyadı ve adresleri; bunların kanunî temsilci veya vekillerinin adı, soyadı ve adresleri; temyiz edilen hükmün hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı; ilâmın

temyiz edene tebliğ edildiği tarih; hükmün özeti; temyiz sebepleri; duruşma istenmesi (HUMK m. 438) halinde bu istek; temyiz edenin veya varsa kanunî temsilci yahut vekilinin imzası.

Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla, temyiz olunan hükmü yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde diğer şartlar bulunmasa bile, reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır (HUMK m. 435, II).

Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir (HUMK m. 432, II). Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse, o mahkemece (az sonra incelenecek olan) HUMK'nun 434. maddesine göre işlem yapıldıktan sonra örnekleriyle (HUMK m. 321/c.2) birlikte kararı veren mahkemeye gönderilir (HUMK m. 432, III).

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderin[6] tamamı (karş. m. 302, 2) (temyiz eden tarafından) ödenir (HUMK m. 434, III/c.1).

Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse o mahkemece kaydolunur ve temyiz edene ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir (HUMK m. 434, I).

Temyiz isteği (talebi), temyiz dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış (karar temyiz edilmiş) sayılır.

2) Temyiz Dilekçesine Cevap

Temyiz dilekçesi, hükmü veren mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ olunur. Tebliğ tarihi temyiz dilekçesinin dosyada kalan aslına işaret edilir (HUMK m. 433, I).

*Karşı (aleyhine temyiz olunan) taraf, bu tebliğ gününden başlayarak **on gün içinde,** hükmü veren mahkemeye (veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir mahkemeye) **cevap** dilekçesi **verebilir** (HUMK m. 433, II/c.1). Karşı taraf, bu cevap dilekçesinde duruşma talebinde de bulunabilir. (HUMK m. 438,I).*

*Temyize cevap veren karşı taraf, hükmü süresinde temyiz etmemiş olsa bile, cevap dilekçesinde hükme ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde de bulunabilir (HUMK m. 433, II/c.2); yani hükmü temyiz edebilir (**katılma yolu ile temyiz**). Temyiz hakkı bulunmayan taraf da, diğer tarafın (süresinde) hükmü temyiz etmesi halinde, on gün içinde vereceği cevap dilekçesinde hükmü temyiz edebilir[7]. Ancak bu temyizin geçerli olması için, katılma yolu ile temyizde bulunan taraf, aynı zamanda temyiz için gereken harç ve giderleri de ödemelidir; aksi halde, yalnızca cevap vermiş olur.*

---

6 Temyiz yoluna başvuran taraftan başvurma harcı alınır. Temyiz yoluna başvurandan maktu harca tâbi kararlardan maktu ilâm harcının tümünün peşin ve nispî harca tâbi kararlarda ise, mahkemece alınmasına karar verilen nispî ilâm harcının dörtte birinin peşin olarak alınması gerekir (bkz. 10.05.1965 gün ve 01/01 sayılı İBK: RG 07.07.1965, sa. 12042). Giderler ise, dosyanın Yargıtaya gönderilmesi için gerekli posta ücretidir. Bundan başka, Yargıtayın temyiz edilen kararı bozması halinde mahkemenin tarafları (kendiliğinden) duruşmaya davet edebilmesi için gerekli giderler de, temyiz edenden peşin olarak alınır (HUMK m. 429, II). Nihayet, Yargıtay kararının taraflara tebliği veya bildirilmesi için gerekli giderler de, temyiz edenden peşin olarak alınır (HUMK m. 442/A, III).

7 Bkz. HUMK m. 427, IV/c. 2.

HUMK m. 433 hükmü, sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyizi halinde de uygulanır (HUMK m. 437, II).

3) Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesi

Hükmü veren mahkeme, cevap verildikten veya bunun için belli süre geçtikten (ve temyiz harç ve giderleri de ödendikten) sonra, dosyayı üç gün içinde dizi listesine bağlı olarak (Yargıtayın görevli dairesine)[8] gönderir (HUMK m. 433, III; Yargıtay K. m. 60).

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmesi gerektiği yukarıda belirtilmişti. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hâkim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde bu eksiğin tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir (HUMK m. 434, III; ayrıca m. 442/A, III)[9]. Kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar veren mahkeme, dosyanın Yargıtaya gönderilmesi için yatırılan parayı kullanarak, ret kararını kendiliğinden temyiz eden ilgiliye tebliğ eder (HUMK m. 434, III; 432, IV). Temyiz eden, mahkemenin kararının temyiz edilmemiş sayılmasına ilişkin bu kararını, kararın kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz edebilir; temyiz edildiği ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya kararı veren mahkemece Yargıtaya yollanır. Yargıtayın ilgili dairesi mahkemenin kararın temyiz edilmemiş sayılmasına ilişkin kararını bozarsa, ilk temyiz dilekçesine göre temyiz talebini inceler (HUMK m. 434, III/ c.4; 432, V).

Temyiz talebini reddetme yetkisi, Yargıtaya aittir. Ancak, aşağıdaki iki halde, kararı veren mahkeme temyiz talebinin reddine karar verir:

Temyiz, kanunî süre (HUMK m. 432, I; 437, I) geçtikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmayan bir karara (HUMK m. 427, II-IV) ilişkin olursa, kararı veren mahkeme, temyiz isteminin reddine karar verir ve dosyanın Yargıtaya gönderilmesi için yatırılan parayı kullanarak ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (HUMK m. 432, IV).

Bu ret kararı, tebliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir. Temyiz edildiği ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde, dosya kararı veren mahkemece Yargıtaya yollanır. Yargıtayın ilgili dairesi, temyiz isteminin reddine ilişkin kararı bozarsa, ilk temyiz dilekçesine göre temyiz istemini inceler (HUMK m. 432, V).

---

8 Bkz. Yargıtay K. m. 14.

9 24.02.1941 gün ve 9/32 sayılı İBK (RG 20.04.1942, sa. 5088); Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu hiç temyiz harcı ödenmemiş olması halinde de HUMK m. 434, III hükmünün (ilke olarak) benzetme (kıyas) yoluyla uygulanacağına karar vermiştir (21.05.1985 gün ve 05/01 sayılı İBK: RG 16.04.1985, sa. 18727). Yani, harca tâbi olduğu halde temyiz dilekçesinin hiç harç alınmadan temyiz defterine kaydedilmiş olması halinde, temyiz harcı HUMK m. 434, III uyarınca verilen yedi günlük kesin süre içinde ödenirse, temyiz talebi, temyiz dilekçesinin temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılacak, yatırılmazsa, temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilecektir.

Temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapılması veya temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olması durumunda hükmü veren mahkemenin, temyiz isteminin reddine karar vermeden, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtaya göndermesi halinde, Yargıtay da temyiz isteminin reddine karar verebilir[10].

III – TEMYİZE BAŞVURMANIN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ

Bir hüküm aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olması, kural olarak hükmün icrasını (yani ilâmın icraya konulmasını, İİK m. 24 vd.) durdurmaz (HUMK m. 443, I/ c.1). Konusu para veya taşınır mal olan hükümlerde durum böyledir. Örneğin, (A)'nın, (B)'ye karşı açtığı yüz bin liralık alacak davası mahkemece kabul edilmiş ve mahkeme, (B)'yi yüz bin lira ödemeyle mahkûm etmiştir. (A), bu kararı (ilâmı), aldığı günden itibaren hemen icraya koyarak, (B)'den bu parayı cebrî icra yoluyla [(B)'nin mallarını haczettirip sattırarak] tahsil edebilir. (B)'nin bu hükmü temyiz etmiş olması, icrayı durdurmaz. (B)'nin icrayı durdurabilmesi, teminat göstermesine ve Yargıtaydan icranın geri bırakılması kararı almasına bağlıdır (HUMK m. 443, I; İİK m. 36).

Bazı hükümler ise kesinleşmedikçe icra edilemez. Örneğin, taşınmaza ve buna ilişkin aynî haklara ve aile[11] *ve şahsın hukukuna dair hükümler, kesinleşmedikçe (HUMK m. 443, IV) icra edilemez. Dolayısıyla, bu hükümlerin temyiz edilmesi, kendiliğinden icrayı durdurur; bunun için teminat gösterilmesine ve Yargıtaydan icranın geri bırakılması kararı alınmasına gerek yoktur.*

F) TEMYİZ İNCELEMESİ

Temyiz incelemesi için Yargıtaya (dairelere) gelen dosyalar, bekletilmeksizin görev ve iş bölümü, temyiz kabiliyetinin bulunup bulunmadığı, temyiz is-

---

10 Yargıtay da 01.06.1990 gün ve 03/04 sayılı İBK ile aynı görüşü benimsemiştir: "Asliye hukuk mahkemelerince verilen kararların yasal süre geçtikten sonra temyiz edilmesi veya temyiz kabiliyetinin bulunmaması halinde, yerel mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi durumunda, Yargıtay'ca da inceleme yapılabileceğine ve HUMK'nun 2494 s. K. ile değişik 432/4. maddesine göre bu konuda bir karar verilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmeden doğrudan doğruya Yargıtay'ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir" (RG 14.07.1990, sa. 20754).

11 Anayasa Mahkemesi aile hukukuna ilişkin ilâmların icra edilebilmesi için kesinleşmesinin gerekli olduğuna ilişkin hükmü Anayasaya aykırı bulmamıştır: "Bazı ilâmların kesinleşmeden icra edilmesi halinde, daha sonra üst mahkemece kanun yoluna başvuru sonucu ilâm bozulduğunda, icranın iadesi, mümkün olamayabilir. Bu durum özellikle aile hukukunda daha da belirgindir. Kanun koyucu bu nedenle, kamu düzenine olan etkilerini de dikkate alarak, aile hukukuna ilişkin ilâmların kesinleştikten sonra icra edilmelerini kabul etmiştir. Bununla birlikte ilâmın kesinleşmesinin beklenmesi halinde taraflardan birinin çok zor durumda kalabileceği nafaka gibi bazı durumlar genel kuraldan istisna tutulmuştur. Kanun koyucunun, itiraz konusu kuralla aile hukukuna ilişkin ilâmların kesinleşmeden icra edilmemelerini öngörmesi takdir yetkisi kapsamındadır. İtiraz konusu kuralın, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve çocuğun ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına aykırı bir düzenleme olduğu söylenemez". (Anayasa Mahkemesinin 16.03.2016 gün ve 2015/104 E. ve 2016/20 K. sayılı kararı için bkz. RG 08.04.2016, sa. 26698. Ancak Anayasa Mahkemesi burada kanımızca hatalı olarak 5236 s. K. ile değişik HUMK m. 433, II'yi itiraz konusu kural olarak ele almıştır. Oysa burada uygulanacak kural HUMK m. 443, IV'tür).

teminin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönlerinden ön incelemeye tâbi tutulur. ***Ön inceleme*** *sırasında temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz kabiliyetinin bulunmadığı, temyiz isteminin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği veya diğer usul eksiklikleri bulunduğu saptanan dosyalar, dairede öncelikle karara bağlanır (Yargıtay K. m. 40, III-IV). Buna göre:*

Temyiz incelemesi için dava dosyası kendisine gelen görevli hukuk dairesi başkanı, ön inceleme için bir tetkik hâkimini[12] görevlendirir. Bu tetkik hâkimi, dosyayı aidiyet[13], kararın temyiz kabiliyetinin bulunup bulunmadığı (temyizinin mümkün olup olmadığı), temyiz talebinin süresi içinde olup olmadığı ve diğer usulî eksiklikler yönlerinden bir ön incelemeye tâbi tutar (Yargıtay K. m. 40, III; Yargıtay İç Yönetmeliği m. 18, I).

Tetkik hâkimi yapacağı ön inceleme sonucunda, temyiz incelemesi görevinin başka bir daireye ait olduğu[14], kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığı (temyiz edilemeyeceği), temyiz talebinin süresi içinde olmadığı veya diğer usulî eksiklikler bulunduğu (örneğin temyiz harç ve masraflarının ödenmemiş olduğu veya temyiz edenin kararı temyiz etmekte hukukî yararının bulunmadığı) kanısına varırsa, durumu hemen daire başkanına bildirir. Böyle bir dosya, daire kurulunda öncelikle incelenir ve karara bağlanır (Yargıtay K. m. 40, IV; Yargıtay İç Yönetmeliği m. 16, II).

Daire kurulu, işbölümü dışında kalan diğer sebeplerden herhangi birisiyle dosyanın ön inceleme sonucu, temyiz incelemesi yapılamayacağı kanısına varırsa (yani yukarıda belirtilen ön şartlardan birinin mevcut olmadığı kanısına varırsa), esas hakkında temyiz incelemesi yapmadan, temyiz talebini usulden, görülemeyeceği gerekçesiyle reddeder[15].

Buna karşılık daire kurulu, az önce belirtilen ön şartların mevcut olduğu (yani temyiz talebinin incelenebileceği) kanısına varırsa, esas hakkında temyiz incelemesi yapılmasına karar verir. Bunun üzerine daire başkanı, temyiz dilekçesini, karşı tarafın cevabını ve dava dosyasını, esas bakımından, incelemek ve bir rapor hazırlamak üzere, o dairedeki Yargıtay üyelerinden[16] veya tetkik hâkimlerinden birine havale eder. Bu üye veya tetkik hâkimi, dosyayı

---

12 **Tetkik hâkimleri,** kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı süresinde inceleyerek bir rapor düzenlerler. Kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini rapora yazıp kurullara açıklamakla yetinirler (Yargıtay K. m. 26; bkz. ayrıca; Yargıtay K. m. 36).

13 Yani, o dosya hakkındaki temyiz incelemesinin dairenin görevine (işbölümüne, Yargıtay K. m. 14) girip girmediği.

14 Daireler arasında ortaya çıkabilecek işbölümü uyuşmazlıklarını çözmek üzere **Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu** oluşturulmuştur. Buna göre dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise, gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonucunda verilen işbölümüne ilişkin karar kesindir (Yargıtay Kanunu m. 60, 3).

15 Yargıtayın temyizin süre geçtikten sonra yapılması ve temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olması hallerinde, nasıl karar vereceği az önce açıklandı. Eğer dosyada eksik var ise, eksiklerin tamamlanıp, yeniden Yargıtaya gönderilmesi için dosya geri çevrilir.

16 Bkz. HUMK m. 436; Yargıtay K. m. 25, 1; Yargıtay İç Yönetmeliği m. 4/D, 18, 19.

esastan inceleyerek, bir hafta içinde etraflı ve yazılı bir rapor düzenleyip, bu raporunu daire başkanına verir[17].

Bunun üzerine daire kurulu, temyiz talebini esastan incelemeye başlar. Temyiz talebinin esastan incelemesinde, temyiz edilen karar, yalnız hukuka uygunluk bakımından inceleme konusu yapılır.

İncelenen dosyada, örneğin bazı belgelerin (tebligat parçası, birleştirilen dosya vb.) dosyada bulunmadığı görülürse; dosyanın tamamlanabilmesini teminen dava dosyası ilk derece mahkemesine geri gönderilir (geri çevrilir; nevakısa gönderilir). Dosyanın tamamlanıp Yargıtaya (yeniden) gönderilmesinden sonra, temyiz incelemesine devam edilir.

Yargıtay, temyiz incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar (HUMK m. 438, I/c.1). Ancak istisnaî olarak taraflar, bazı davalara ilişkin kararların temyiz incelemesinin ***duruşmalı*** *(murafaalı) olarak yapılmasını isteyebilirler (HUMK m. 438, I).*

Tarafların Yargıtayda duruşma yapılmasını isteyebilecekleri davalar şunlardır: 1) Tüzel kişiliğin feshine veya tüzel kişilerin genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalar; 2) Evlenmenin butlanına (TMK m. 145-147) veya evlenmenin feshine (TMK m. 148 vd.) ilişkin davalar; 3) Boşanma veya ayrılık davaları (TMK m. 161 vd.); 4) Velayete (TMK m. 335 vd.), nesebe (TMK m. 285 vd.) ve kısıtlamaya (TMK m. 405 vd.) ilişkin davalar; 5) Miktar veya değeri HUMK m. 438, I'deki sınırı (2019 yılı için: 32.920 TL) aşan alacak ve ayın (taşınır ve taşınmaz mal) davalarında verilen hükümlerin temyiz incelemesinin, duruşmalı olarak yapılması istenebilir (HUMK m. 438, I). Ancak, alacak ve ayın davalarına ilişkin hükümlerde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü HUMK m. 438, I'deki parasal sınırı geçmeyen tarafın duruşma isteme hakkı yoktur (HUMK m. 427, V).

Yukarıdaki hallerde duruşma istenmesi bakımından, hükmün sulh veya asliye hukuk mahkemesi veya bir özel görevli mahkemeden (örneğin iş mahkemesinden) verilmiş olması arasında fark yoktur.

Kanunda (HUMK m. 438, I) sayılan yukarıdaki haller sınırlıdır (numerus clausus). Bunun dışındaki hallerde, Yargıtayda duruşma istenemez. Bundan başka, yukarıda sayılan davalara ilişkin olsa bile, görevsizlik, yetkisizlik, hâkimin reddi, dava veya karşı davanın açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi ile direnme kararlarının (HUMK m. 429, III) temyiz incelemesinde duruşma yapılmaz (HUMK m. 438, II). Taraflardan biri, temyiz dilekçesinde veya süresinde verilen cevap dilekçesinde Yargıtayda duruşma yapılmasını isteyebilir (HUMK m. 438, I). Duruşma isteğinin, dilekçede açıkça belirtilmesi gerekir.

Yargıtay, tarafların duruşma istemedikleri veya duruşma istemek haklarının bulunmadığı hallerde, taraflardan bilgi almak üzere, kendiliğinden de duruşma yapılmasına karar verebilir (HUMK m. 438, III). Yargıtay, bir duruşma günü ve saati belli ederek, tarafları duruşmaya davet eder. Yargıtay, yargılama yokluğunda yapılmış (HMK m. 147, 2) olan tarafı da duruşmaya

---

[17] Bkz. HUMK m. 436; Yargıtay K. m. 25, 1; 26; Yargıtay İç Yönetmeliği m. 50.

davet eder. Bu duruşma davetiyesinin taraflara tebliği ile duruşma günü arasında en az on beş gün bulunması gerekir; taraflar duruşmaya gelmişlerse, bu süreye bakılmaz (HUMK m. 438, I). Tebligat gideri verilmemişse, duruşma isteği dikkate alınmaz (HUMK m. 438, I son cümle); yani duruşma yapılmaz. Duruşma için belli edilen gün ve saatte taraflar (veya vekilleri) gelmişlerse dinlenir. Taraflardan yalnız biri gelmişse, sadece o taraf dinlenir. İki taraf da gelmemişse, Yargıtay dosya üzerinde inceleme yapar.

Yargıtay, kararını duruşmanın yapıldığı gün verebilirse kararı o gün taraflara tefhim eder (HUMK m. 438, IV). Genellikle, kararın duruşma gününde verilmesi mümkün olmaz. Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin en geç yirmi gün içinde karara bağlanması zorunludur (HUMK m. 438, V). Karar, herhalde duruşmada bulunmuş olan başkan ve üyeler tarafından verilir ve imzalanır.

Yargıtaydaki duruşmada haklı çıkan taraf, duruşmada kendini bir vekil (avukat) ile temsil ettirmişse, karşı taraf, duruşma için Yargıtayca ayrıca vekâlet ücretine mahkûm edilir[18] *ve bu vekâlet ücreti (hükmün kesinleşmesi beklenmeden) ayrıca icraya konabilir.*

Duruşma talebi dikkate alınmadan, dosya üzerinde inceleme yapılmış olması, bir karar düzeltme (HUMK m. 440, I) sebebidir.

Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapılır (HUMK m. 438, VI).

G) YARGITAY KARARI

Yargıtayın, temyiz talebinin ilk önce usul açısından dinlenebilir olup olmadığını inceleyeceğini (ön inceleme), dinlenebilir olmadığı sonucuna varırsa temyiz talebini esasa girmeden reddedeceğini, ancak dinlenebilir kabul ettiği temyiz talepleri hakkında esasa girerek inceleme yapacağını yukarıda görmüştük. Burada Yargıtayın esas hakkındaki incelemesi sonucunda vereceği kararı inceleyeceğiz.

Yargıtay, temyiz incelemesi sırasında, iki tarafın temyiz dilekçesinde ve cevap dilekçesinde ileri sürdükleri bütün itiraz ve savunmaları göz önünde bulundurur ve vereceği kararda her temyiz ve savunma sebebinin neden dolayı ret veya kabul edildiğini gerekçesiyle birlikte bildirir. Bildirmemiş olması, bir karar düzeltme sebebi teşkil eder (HUMK m. 440, I/1).

Bundan başka Yargıtay, tarafların dilekçelerindeki iddia ve savunmaları ile bağlı olmayıp, kanuna (hukuka) aykırı bulduğu diğer sebeplerden dolayı da, temyiz edilen kararı bozabilir (HUMK m. 439, II).

Yargıtayın kararı, daire başkanı veya belli edeceği üye tarafından yazılır (Yargıtay K. m. 24, 1; 25, 1). Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adları, mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy (muhalefet) yazısı, kararın asıl ve örneklerinde gösterilir (Yargıtay K. m. 40, II).

---

[18] Bkz. AK Ücret Tarifesi m. 3, II; İkinci kısım, 2. bölüm No. 14.

*Yargıtay kararını **gerekçeli** olarak vermek zorundadır (HUMK m. 439,I; HUMK m 440, II; Anayasa m. 141 ,III). Yargıtayın kararının gerekçeli olması, hüküm mahkemesinin kararında direnip direnmeyeceğini belirleyebilmesi için özellikle faydalıdır. Bundan başka, tarafların da kararın gerekçesini bilmeleri, onların karara karşı olan güvenini artırır. Hüküm mahkemesi bozmaya uyarsa, gerekçe mahkemenin işini önemli ölçüde kolaylaştırır; çünkü, ancak gerekçe sayesinde Yargıtay kararının anlaşılması mümkündür. Nihayet, kararın gerekçeli olması, o karar üzerinde faydalı bilimsel tartışmalar yapılmasına imkân verir ki, bu da sağlıklı bir hukukî gelişmeye yol açar.*

Yargıtay kararı[19] başlıca üç şekilde olabilir: Bozma kararı; onama kararı; düzelterek onama kararı.

I – BOZMA KARARI

Yargıtay, temyiz (bozma) sebebini (veya sebeplerini) yerinde görürse, hüküm mahkemesinin kararını tamamen veya kısmen bozar. Yargıtayın tarafların bildirmiş oldukları temyiz sebepleri ile bağlı olmadığını, hüküm mahkemesi kararını dosyada mevcut olan başka sebeplerden dolayı da bozabileceğini yukarıda görmüştük (HUMK m. 439, II).

Yargıtay, hüküm mahkemesi kararını kanuna (hukuka) uygun bulmazsa, hükmü yalnız bozmakla yetinir; yoksa o davayı kendisi karara bağlayamaz.

*Bir hüküm, davanın taraflarından **yalnız biri** tarafından temyiz edilirse Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz eden tarafın aleyhine olarak bozamaz[20]; buna, "**aleyhe bozma yasağı**" (reformatio in peius) denir[21].*

*Taraflardan yalnız birinin temyizi halinde, Yargıtayın (temyiz eden tarafın lehine olarak) verdiği bozma kararına uyan mahalli mahkeme de artık, temyiz eden tarafın, önceki (bozulan) karara oranla aleyhine olan bir hüküm veremez. Buna da, "**aleyhe hüküm verme yasağı**" denir[22].*

Yargıtay, bir kararı bozunca, dava dosyasını kural olarak kararı vermiş olan mahkemeye gönderir. Fakat Yargıtay, davayı (dava dosyasını) uygun göreceği başka bir mahkemeye (örneğin davanın, daha iyi bakılacağı umulan başka bir mahkemeye) de gönderebilir (HUMK m. 429, I).

Yargıtayın bozma kararı üzerine dava dosyası kendisine gönderilen mahkeme, aşağıdaki ihtimallere göre işlem yapar:

*Yargıtayın bozma kararına karşı, **karar düzeltme yolu kapalı** ise (HUMK m. 440, III), mahkeme, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir (HUMK m. 429, II).*

---

19 Yukarıda belirtilen, **dosyanın eksikliklerin tamamlanması için geri gönderilmesi** ("nevakısa gönderilmesi") dışında.

20 Buna karşılık, bir hüküm tarafların her ikisi tarafından da temyiz edilmişse, bu halde Yargıtay, hükmü temyiz eden taraf aleyhine de bozabilir; yani, bu halde aleyhe bozma yasağı uygulanmaz.

21 Bkz. Murat Atalı, Medenî Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, Ankara 2014; örnekler ve ayrıntılı açıklama için bkz. yuk. § 56, N, I.

22 Örnekler ve ayrıntılı açıklama için bkz. yuk. § 56, N, I.

*Yargıtayın bozma kararına karşı, **karar düzeltme yolu açık** ise (HUMK m. 440), bu bozma kararı, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından on beş gün içinde kendiliğinden taraflara tebliğ edilir (HUMK m. 442/A, I ve III). Bunun üzerine iki ihtimal ile karşılaşılır:*

Bozma kararının tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde (HUMK m. 440, I) karar düzeltme yoluna gidilmezse, mahkeme, kendiliğinden tarafları (on beş günlük karar düzeltme süresinin bitmesinden sonra) hemen duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir (HUMK m. 424, II).

Taraflardan biri, bozma kararının tebliğinden (HUMK m. 442/A, I) itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yoluna başvurursa, mahkemenin tarafları (kendiliğinden) duruşmaya davet (HUMK m. 429, II) edebilmesi için, karar düzeltme incelemesinin sonuçlanmasını beklemesi gerekir.

Yargıtay karar düzeltme talebini reddederse[23], bu ret kararının mahkemeye gelmesi üzerine mahkeme[24], kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir (HUMK m. 429, II).

Bozma kararı üzerine yapılan duruşmada davacı davasından feragat ederse, davalı davayı kabul ederse veya taraflar sulh olursa, mahkeme, davayı feragat, kabul veya sulh gereğince sonuçlandırır.

Yukarıdaki şekilde, Yargıtayın bozma kararı üzerine kendiliğinden tarafları duruşmaya davet eden mahkeme, bu duruşmada tarafları dinledikten sonra, iki şekilde karar verebilir: 1) Mahkeme, Yargıtayın bozma kararına uyar veya 2) Mahkeme, (Yargıtayın bozma kararına uymaz) kendi kararında direnir (ısrar eder) (HUMK m. 429, II-III):

1) Mahkemenin Bozma Kararına Uyması

*Mahkeme, bozmadan sonraki ilk duruşmada tarafları dinledikten sonra, bozmaya uyulup uyulmayacağına karar verir (HUMK m. 429, II). Mahkeme, bozma kararına uyduğunu bildirirse, artık bu kararı ile **bağlıdır**; bozmaya uyma kararından dönerek, direnme (ısrar) kararı veremez.*

Bozma kararına uyulması üzerine, yargılamaya devam edilir. Uyma kararından sonra, taraflara ne diyecekleri sorulur. Yoksa, hem bozmaya uyup hem de taraflara ne diyecekleri sorulmadan, esas hakkında hüküm verilemez. Taraflar, bozma kararına uyulmasından sonra devam edilen yargılama sırasında yeni iddia ve savunmada bulunabilirler ve karşı tarafın rıza göstermesi halinde, bu iddia ve savunmanın incelenmesi gerekir.

Bozma kararından yalnız kararı temyiz etmiş olan taraf istifade eder (yararlanır). İhtiyarî dava arkadaşlarından (m. 57-58) bazıları kararı temyiz et-

---

[23] Yargıtay karar düzeltme talebini kabul ederek (temyiz incelemesi üzerine bozduğu) hükmü onarsa, bu halde hüküm kesinleşir. Bu nedenle, artık ilk derece mahkemede (yeniden) duruşma yapılması söz konusu olmaz.

[24] Temyiz edenden HUMK 434. madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle.

memişlerse, diğerlerinin temyizi üzerine kararın bozulmasından yararlanamazlar.

Bir karar, yargılama usulüne aykırı hareket edilmiş olması nedeniyle bozulursa, yargılama usulüne aykırı hareket edilme anından sonraki işlem ve kararlar, bozmanın kapsamına dahil iseler, geçersiz sayılır (HUMK m. 430). Buna göre, bir karar görevsizlikten dolayı bozulursa görevsiz mahkemenin yaptığı bütün işlemler ve verdiği kararlar geçersiz olur.

Buna karşılık, örneğin, karar mahkemenin gösterilen tanıkları dinlememiş olması nedeniyle bozulmuş ise, ondan önceki işlemler geçerlidir. Bundan sonraki işlemler de sadece bozmanın kapsamına dahil oldukları oranda geçersizdir. Şu halde, mahkemenin tanık dinlememesi üzerine keşif yapılmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış ise bunlar geçerlidir. Yalnız tanık dinlenmemesi ile ilgili işlemler geçersizdir. Hâkim tanıkları dinler, tarafların görüşlerini alır ve bundan sonra hükmünü verir.

Fakat, mahkeme tanıkla ispatı caiz olmayan bir olayda tanık dinlemiş ve hüküm de bu sebeple bozulmuş ise, bundan sonraki keşif ve bilirkişi delilleri de geçersizdir; çünkü bunlar ancak senetsiz ispatı caiz olan hallerde delil olabilir.

Yargıtayın bozma kararına uyan mahkeme, artık bozma kararı gereğince işlem yapmak ve hüküm vermek zorundadır. Çünkü, mahkemenin bozma kararına uyması ile, bozma kararı lehine olan taraf yararına bir ***usulî müktesep hak*** *(usule ilişkin kazanılmış hak) doğmuştur*[25]*.*

Bozma kararına uyan mahkeme, yukarıdaki esaslara göre (bozma kararı uyarınca) inceleme yaparak, yeni bir karar (hüküm) verir. Taraflar, mahkemenin bu (yeni) kararına karşı da temyiz yoluna başvurabilirler.

Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyma olarak tesis olunan kararın ***önceki bozmayı kaldıracak şekilde yeniden bozulması*** *üzerine alt dereceli mahkemece verilen kararın temyizi halinde, temyiz incelemesi* ***Hukuk Genel Kuruluna yapılır*** *(m. 429, IV).*

2) Mahkemenin Kendi Kararında Direnmesi

*Mahkeme, Yargıtayın bozma kararını doğru bulmuyorsa (bozma kararına uymak istemezse), kendi kararında direnebilir (****ısrar*** *edebilir) (HUMK m. 429, II).*

Mahkeme, direnme kararı ile davadan elini çeker; yani davayı yeniden sona erdirmiş olur. Direnme kararı, nihaî karar olduğundan temyiz edilebilir (HUMK m. 429, III). Ancak, birinci kararı temyiz etmemiş olan tarafın, direnme kararını temyiz etmek hakkı yoktur. Şu halde, ancak önceki karara karşı temyiz yoluna başvurmuş (ve karar lehine olarak bozulmuş) olan taraf, direnme kararını temyiz edebilir.

Direnme kararı temyiz edilince, temyiz incelemesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda (HGK) yapılır (HUMK m. 429, III; Yargıtay K. m. 15, 1). Ancak istinaf mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili

---

[25] Usulî kazanılmış hak kavramı ve istisnaları hakkında bkz. yuk. § 56, N, I.

Yargıtay hukuk daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, ***kararına direnilen daire****ye gönderilir (HMK Geçici Madde 4). Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı* ***HGK****'na gönderir. HGK, direnme kararını ya doğru bulur, bu halde direnme kararını onar veya Yargıtay özel dairesinin bozma kararını doğru bulur, bu halde ise direnme kararını bozar. HUMK m. 438, I'deki şartları taşısa bile, direnme kararlarının temyiz incelemesinde (HGK'nda) duruşma yapılmaz (HUMK m. 438, II).*

Taraflar, HGK'nun onama veya bozma kararına karşı, HUMK m. 440'a göre karar düzeltme yoluna başvurabilirler.

Mahkeme, HGK'nun verdiği karara uymak zorundadır (HUMK m. 429, IV); yani artık kararında direnemez.

İlk derece mahkemesi kararı, Yargıtay özel dairesince esastan değil de usulî bir hatadan dolayı bozulur, bunun üzerine ilk derece mahkemesi kararında direnir ve HGK direnme kararını haklı bulursa, hükmün esası hakkında Yargıtay özel dairesince henüz bir inceleme yapılmamış olduğundan, HGK'nun vereceği karar direnme kararının onanması kararı olmayıp, direnme kararının doğru olduğu ve diğer yönlerin (esasın) incelenmesi için dosyanın özel daireye gönderilmesi kararıdır.

Örneğin, ilk derece mahkemesi, bir hukukî işlem hakkında tanık dinlemiş ve tanık beyanına göre hükmünü vermiş, özel daire olayda tanık dinlenmesinin caiz olmadığından hükmü bozmuş ve mahkeme de kararında direnmişse, HGK, olayda tanık dinlenebileceğine ve bu nedenle mahkeme kararının doğru olduğuna karar verirse, bununla mahkeme kararını hemen onamaz; dosyanın diğer hususların (esasın) incelenmesi için özel daireye gönderilmesine karar verir.

Mahkeme, Yargıtayın bozma kararının bir kısmına uyar, diğer kısmına ise uymayabilir; yani, mahkemenin kısmî direnme (ve dolayısıyla kısmî uyma) kararında, bozma kararının hangi kısmına uyduğunu ve hangi kısmına karşı direndiğini açıkça belirtmesi gerekir. Örneğin mahkeme, Yargıtayın bozma kararında gösterdiği birinci bozma sebebine uyar, ikinci bozma sebebine karşı ise direnebilir. Bu halde mahkeme, böyle bir kısmî uyma ve kısmî direnme kararı ile davadan elini çekmediğinden, verdiği karar bir ara kararıdır. Bu nedenle taraflar, mahkemenin kısmî direnme kararını yalnız başına temyiz edemezler.

Kısmî uyma ve kısmî direnme kararı vermiş olan mahkeme, ilk önce, kısmî uyma kararı gereğince inceleme yapar (yani, uyduğu bozma sebepleriyle ilgili soruşturmasını bitirir). Bundan sonra mahkeme, uyduğu ve direndiği kısımların tümü hakkındaki gerekçeli nihaî kararını yazıp, taraflara tefhim veya tebliğ eder. İşte, taraflar ancak bu nihaî kararı temyiz edebilirler.

Kısmî uyma ve kısmî direnme üzerine verilen nihaî karar temyiz edilince, bu temyiz incelemesinin nerede yapılacağı konusunda iki ihtimal akla gelebilir:

Mahkemenin direnmiş olduğu bozma sebepleri, mahkemenin kabulüne göre (yani terditli olarak) sevk edilmiş ve bu nedenle mahkemenin bozmaya kısmî uyması üzerine vermiş olduğu hükmün Yargıtayca onanması halinde, diğer (kısmî olarak direnilen) bozma sebeplerinin incelenmesine gerek kalmayacak ise, o zaman, mahkemenin kısmî uyma ve kısmî direnme üzerine vermiş olduğu nihaî hüküm, ilk önce bozma kararını vermiş olan Yargıtay özel dairesince temyizen incelenir.

Bunun dışındaki hallerde temyiz incelemesi, ilk önce HGK'nda, ondan sonra Yargıtay özel dairesinde yapılır.

*Mahkemeler, aşağıdaki hallerde **direnme kararı veremezler**:*

Mahkemenin, yargı yeri belirlenmesi (m. 21-23) hakkındaki Yargıtay kararına karşı direnme hakkı yoktur.

Mahkemelerin, 4308 sayılı K. m. 2'ye göre verdikleri tehir (erteleme) kararları hakkındaki Yargıtay kararına karşı direnme hakları yoktur (bkz. 4308 sayılı K. m. 2 son fıkra).

İki taraf da Yargıtayın bozma kararına uyulmasını isterse, mahkeme bozma kararına uymak zorundadır, direnme kararı veremez.

Mahkeme, Yargıtayın kanun yararına bozma kararına (HUMK m. 427, III-V) karşı direnemez.

Yargıtaya göre, hakemler, Yargıtayın bozma kararına karşı direnemezler.

II – ONAMA KARARI

Yargıtay, temyiz edilen kararın usul ve kanuna uygun olduğu kanısına varırsa, hüküm mahkemesinin kararını onar[26]*.*

*Yargıtayın onama ve onamaya karşı başvurulan karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararlarının sonucu, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından on beş gün içinde **kendiliğinden** taraflara bildirilir (HUMK m. 442/A, II-III)*[27]*.*

Yargıtayın kararına karşı karar düzeltme yolunun kapalı olduğu hallerde (HUMK m. 440, II), Yargıtayın onama kararı ile, mahkeme hükmü (şeklî anlamda) kesinleşir.

Yargıtayın kararına karşı karar düzeltme yolunun açık olduğu hallerde (HUMK m. 440) ise, Yargıtayın onama kararı ile hüküm hemen kesinleşmiş olmaz. Bu halde hükmün kesinleşebilmesi için, Yargıtayın onama kararına karşı on beş gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulmamış olması ve başvurulmuş olup da, karar düzeltme talebinin Yargıtayca reddedilmiş olması gerekir.

Yargıtay hükmü onarken, temyiz edenin kötüniyetle temyiz yoluna başvurduğu kanısına varırsa, temyiz edeni para cezasına mahkûm eder. Kötüni-

---

[26] Yargıtay, temyiz edilen kararı kısmen de onayabilir. Bu halde, Yargıtayın kısmen onama kararı, kısmî bozma kararı gibi işlem görür.

[27] "Burada şu hususu da açıklamakta yarar vardır; başkâtibin (yazı işleri müdürünün) taraflara tebliğe gönderdiği şey, Yargıtay kararı olmayıp onun sonucundan ibarettir. Bu sebeple harcın tahsili bakımından bu yöne dikkat edilmesi gerekir" (Hükümet gerekçesi).

yetle temyiz eden vekil ise, para cezasına vekil mahkûm edilir (bkz. HUMK m. 444, 422).

III – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

Temyiz olunan hükmün kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerekmekte olup da kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, hükmü düzelterek onayabilir (HUMK m. 438, VII/c.1). Ancak, esas yönünden kanuna uymayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu hüküm uygulanmaz (HUMK m. 438, VII/c.2). Örneğin, temyiz edilen hüküm esas yönünden kanuna uygundur; ancak harç, vekâlet ücreti veya faiz konularında veya hesaplanmasında yanlışlık yapılmıştır (hata edilmiştir). Bu halde Yargıtay, yapılan yanlışlığı düzelterek hükmü onayabilir.

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla yazı, hesap ve diğer açık ifade yanlışlıklarından dolayı da, esas yönünden kanuna uygun olan hüküm bozulamaz; hüküm bu yanlışlar düzeltilmek suretiyle onanır (HUMK m. 438, VIII).

Hükmün sonucu esas bakımından usul ve kanuna uygun olup da, gösterilen gerekçe doğru görülmezse, Yargıtay dairesi, gerekçeyi değiştirerek ve düzelterek hükmü onar (HUMK m. 438, IX).

HGK da, direnme kararlarını düzelterek onayabilir.

Karar düzeltme yoluna başvurulması üzerine de, Yargıtay ilk derece mahkeme hükmünü düzelterek onayabilir.

Buraya kadar incelemiş olduğumuz bozma, onama ve düzelterek onama kararları, Yargıtayın esas hakkında vermiş olduğu kararlardır.

Temyiz talebinin mesmu (dinlenebilir) olmaması halinde, Yargıtayın esasa girmeden temyiz talebini reddedeceğini yukarıda görmüştük. Bundan başka, temyiz eden sonradan temyiz talebinden feragat ederse Yargıtay, gene esas hakkında temyiz incelemesi yapamaz; temyiz incelemesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı mahkemeye gönderir.

H) KANUN YARARINA TEMYİZ[28]

Yukarıda[29] *istinaf mahkemelerinin göreve başlamasından sonraki kanun yolları arasında, "kanun yararına temyiz" müessesesini (m. 363) de inceledik. Kanun yararına temyiz müessesesi, HUMK'nda da düzenlenmiştir (HUMK m. 427, VI-VIII).*

HMK'nun Geçici 3. maddesi uyarınca; istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlama tarihine (20.07.2016'ya) kadar, HUMK'nun (diğer temyiz hükümleri arasında) kanun yararına temyiz hükümleri de uygulanmaya devam olunacaktır. Bu sebeple, istinaf mahkemelerinin göreve başlamasın-

---

[28] Bkz. Ejder Yılmaz, Olağanüstü Temyiz (Kanun Yararına Bozma, Yazılı Emirle Bozma), Ankara 2003.

[29] Bkz. yuk. § 57.

dan önceki kanun yolları konusunda, HUMK'nun kanun yararına temyiz ile ilgili hükümlerine de değinmek gerekir.

Mahkemelerce kesin olarak verilen hükümlerle, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı sonucu ifade eden ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler, Adalet Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur (HUMK m. 427, VI; karş. HMK m. 363, 1).

Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan kanun yararına temyiz isteğini yerinde görürse, hüküm, kanun yararına bozulur. Ancak bu bozma, davanın taraflarının (davadaki ilgililerin) yaptığı (normal) temyiz başvurularındaki bozmadan (HUMK m. 429 vd.) farklı olarak, hükmün sonuçlarını ortadan kaldırmaz (HUMK m. 427, VII; HMK m. 363, 2). Yani, kesin hüküm haline gelen karar ne ise, bu kararın hüküm ve sonuçları, aynen devam eder. Çünkü, kanun yararına temyiz, kesin hale gelmiş kararlara karşı başvurulan bir yoldur ve amacı, kesin hale gelen hükmün ortadan kaldırılarak yeni bir karar verilmesi değil, kesin olarak verilmiş bulunan veya tarafların aleyhine kanun yoluna başvurma olanağı bulunmasına rağmen, kanun yoluna gidilmemiş olması sebebiyle kesin hale gelen ve fakat hukuka (kanuna) aykırı kararların kamuoyuna duyurulması için kabul edilen bir kanun yoludur.

Kanun yararına bozma kararının bir örneği, Yargıtay tarafından, Adalet Bakanlığına gönderilir ve bakanlıkça Resmî Gazetede yayınlanır (HUMK m. 427, VIII; HMK m. 363, 3).

§ 60. KARAR DÜZELTME[1]

Karar düzeltme, hukukumuzda istinaf yolunun bulunmadığı dönemde kabul edilmiş bulunan bir kanun yoludur. 5235 sayılı Adlî Mahkemeler Kanunu ile istinaf yolunun kabulünün sonucu olarak, HMK, karar düzeltme ile ilgili hükümlere (HUMK m. 440-444) yer vermemiştir. Ancak, HMK Geçici m. 3'e göre, bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin göreve başlama tarihine (20.07.2016'ya) kadar HUMK'nun temyize ilişkin hükümleri (HUMK m. 427-444) ve bu arada, karar düzeltme hükümleri (m. 440-442) uygulanmaya devam edilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş kararlar ve 20.07.2016'dan önce verilmiş ilk derece mahkemesi kararları hakkında ***kesinleşinceye kadar****, HUMK'nun 427-454. maddeleri hükümleri* ***uygulanmaya devam edilecektir****. Hükümde yer alan "kesinleşinceye kadar" ibaresi, HUMK'na göre yapılan temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı sonrasındaki aşamalar düşünüldüğünde, karar düzeltme müessesesinin hukukumuzda çok uzun bir süre daha yaşayacağını göstermektedir.*

İstinaf mahkemeleri göreve başladıktan sonra, istinaf mahkemelerin kararlarına karşı başvurulan temyiz yolunda verilecek Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacaktır.

Karar düzeltme, Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlarına karşı tanınmış, ***olağan*** *bir* ***kanun yolu****dur. Yani, bir hüküm hakkında Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme yolu açık ise (HUMK m. 440), o hüküm, ancak karar düzeltme yoluna başvurulmaması veya başvurunun reddi ile (şeklî anlamda) kesinleşebilir.*

Yukarıda görüldüğü üzere temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesinin (hüküm mahkemesinin; mahallî-yerel- mahkemenin) kararı, yüksek mahkeme olan Yargıtay tarafından temyizen incelenmektedir. Bölge adliye (istinaf) mahkemeleri faaliyete geçtikten ***(20.07.2016'dan) sonra da*** *ilk derece mahkemesi kararına karşı (ikinci derece mahkemesinde) istinaf incelemesi yoluna gidilebilmekte ve bu mahkemenin kararına karşı da kanunda düzenlenen hallerde üçüncü derece olan Yargıtayda temyiz kanun yolu açık bulunmaktadır. Yani, olağan kanun yolunda esas olan, alt dereceli mahkemenin kararına karşı üst dereceli mahkemeye başvurulmasıdır. Karar düzeltme yolunda ise karar düzeltme talebi, bir üst mahkemece değil, temyiz incelemesi sonucunda kararını veren aynı mahkeme (Yargıtay) tarafından incelenir.*

Karar düzeltme talebi, temyiz incelemesi yaparak karar vermiş olan aynı Yargıtay dairesinde (veya aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan karar - temyiz kararı- HGK kararı ise, HGK'nda) incelenip karara bağlanır.

---

[1] Bkz. Necip Bilge, Medenî Yargılama Hukukunda Karar Düzeltme, Ankara 1973.

Karar düzeltme yolunun amacı, temyiz incelemesini yapan Yargıtay üyelerinin de bu aşamada bir hata yapmış olması ihtimalidir. Karar düzeltme yolu ile, yanlış bir karar verilmesinin önüne geçilerek, yargılamanın amacına uygun olarak, maddî gerçeklere ve hukuka uygun adaletli karar verilmesi sağlanmak istenmiştir.

Özetle, karar düzeltme yolu, Yargıtayın temyiz incelemesi sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan, kendine özgü bir kanun yoludur.

Ayrıca belirtelim ki, karar düzeltme (esas itibariyle) ülkemize özgü bir kanun yoludur.

A) DÜZELTİLMESİ İSTENEBİLECEK KARARLAR

Karar düzeltme, ancak, Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara (yani, Yargıtayın bozma, onama ve düzelterek onama kararları ile temyiz talebinin usule uygun olmamasından dolayı reddine ilişkin kararlarına) karşı tanınmış olan, kendine özgü bir kanun yoludur.

*Karar düzeltme, ancak temyiz yoluna gidildikten sonra başvurulabilecek bir kanun yolu olduğundan ve temyizde verilen kararın yeniden (bir kez daha) incelenmesini amaçladığından, **temyiz yolunun devamı niteliğinde**dir. Bu açıdan karar düzeltme, aşağıda görülecek bazı sebeplerin (HUMK m. 440, I/1-4) varlığı halinde başvurulabilen (adeta) ikinci bir temyiz yolu diye de değerlendirilebilir.*

*Bir hükme karşı süresi içinde **temyiz yoluna başvurulmamış** ve bu nedenle karar kesinleşmiş **ise**, artık o karara karşı **karar düzeltme yoluna da başvurulamaz**. Aynı şekilde, temyiz edilemeyen (yani verildikleri anda kesin olan) kararlara karşı, temyiz yoluna gidilemeyeceği gibi, karar düzeltme yoluna da gidilemez. Çünkü bu iki halde de, Yargıtayın temyiz ile ilgili bir kararı bulunmadığından, mevcut olmayan bir kararın, karar düzeltme yoluyla değiştirilmesi de söz konusu olamaz.*

Yargıtayın her kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Başka bir deyişle, düzeltilmesi istenemeyecek Yargıtay kararları da vardır. Az sonra görülecek olan bu istisnalar dışındaki bütün Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

*Aşağıdaki Yargıtay kararlarına karşı **karar düzeltme yoluna gidilemez**:*

*1) **Sulh hukuk mahkemesi kararlarının** (HUMK m. 8; HMK m. 4) temyiz edilmesi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı, kural olarak, karar düzeltme yoluna başvurulamaz (HUMK m. 440, III/1). Ancak bu kuralın istisnaları vardır:*

a) Sulh hukuk mahkemesinin mirasçılık belgesi (veraset ilâmı) verilmesi hakkındaki isteklerle bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları hakkındaki kararlarının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir (HUMK m. 440, III/2). Bu isteklerin veya davaların, miktar veya değeri belli olmadığından, HUMK m. 440, III/1'deki karar düzeltme sınırı bu işler ve davalar için uygulanmaz.

b) Kira ilişkisine dayanan davalara ilişkin olmak üzere sulh hukuk mahkemesinden verilen kararların (HMK m. 4, 1/a) temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir; yalnız bunun için, taşınmazın bir yıllık kira bedeli toplamının, HUMK m. 440, III/1'deki parasal sınırdan (2019 yılı için: 19.680 TL'ndan) az olmaması gerekir (HUMK m. 440,III/2).

c) Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalarda sulh hukuk mahkemesinden verilen kararların temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir; yalnız bunun için, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davanın miktar veya değerinin HUMK m. 440, III/1'deki sınırdan az olmaması gerekir (HUMK m. 440, III/2).

Şu halde kural olarak, yalnız asliye hukuk mahkemesi[2] kararlarının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilebilir. Fakat, bu kural da mutlak değildir. Yani, aşağıdaki istisnaî hallerde, asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yolu kapalıdır:

2) Miktar veya değeri, HUMK m. 440, III/1'deki ***karar düzeltme sınırı ile ilgili parasal tutardan az*** *olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı,* ***karar düzeltme yoluna gidilemez*** *(HUMK m. 440, III)[3].*

Bundan başka, miktar veya değeri, HUMK m. 440, III/1'deki sınırdan fazla olan alacak ve ayın (mal) davalarına ilişkin hükümlerde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü HUMK m. 440, III/1'deki sınırdan az olan taraf karar düzeltme yoluna başvuramaz (HUMK m. 427, V).

3) ***Görevsizlik, yetkisizlik****, hâkimin reddi, dava veya karşı davanın açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi kararlarına ilişkin Yargıtay kararları ile yargı yeri belirlenmesi hakkındaki Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez (HUMK m. 440, III/3).*

4) ***Tavzih*** *kararının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.*

5) ***Hakemler****in verdiği hükümlerin ve HUMK'nun tahkim hükümlerine göre mahkemece verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez (HUMK m. 440, III/4).*

6) Aynı Yargıtay kararı aleyhine ***bir defadan fazla karar düzeltme yoluna başvurulamaz*** *(HUMK m. 442, I). Bu hükme göre:*

a) Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu (düzeltilmesi istenebilecek) bir karara karşı yapılan karar düzeltme talebi, Yargıtay tarafından usulî şartları (süre vb.) taşımadığından (mesmu olmadığından) dolayı

---

2 Yani, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemesi kararları. Bundan başka, kadastro mahkemesi ve icra mahkemesi (İİK m. 366,III) kararlarının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı da (aşağıdaki istisnaî haller dışında) karar düzeltme yoluna gidilebilir.

3 Sulh mahkemesinde görülen miktar veya değeri HUMK m. 440, III/1'deki sınırdan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı da karar düzeltme yoluna gidilemez (HUMK m. 440, III/1; m. 8,I).

veya esastan reddedilmişse, artık Yargıtayın bu ret kararına karşı yeniden karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Ancak Yargıtay, karar düzeltme talebini süre aşımından dolayı reddetmiş ve bunu yaparken karar düzeltme süresinin hesaplanmasında açık bir hataya düşmüş ise, bu ret kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi ve bu defa karar düzeltme talebinin esası hakkında inceleme yapılması mümkün olmalıdır.

Bundan başka, bir hüküm taraflardan her ikisince de temyiz edildiği halde, yalnız bir tarafın temyiz talebi hakkında karar verilir, diğer tarafın ismi temyiz edenler arasında görülmediğinden, onun temyiz itirazları Yargıtay kararında cevapsız bırakılır ise bunun üzerine temyiz itirazları hiç incelenmemiş olan taraf HUMK m. 440, I/1'e göre karar düzeltme yoluna başvurduğunu bildirse bile, bu halde, karar düzeltme incelemesi değil, temyiz incelemesi yapılır[4]*. Bu nedenle, bu defa yapılan temyiz incelemesi üzerine verilen Yargıtay kararına karşı, karar düzeltme yoluna başvurulabilir.*

Bunun gibi bir tarafın temyiz talebi, süre aşımı veya kararın temyiz edilemeyeceği gibi bir nedenle, esasa girilmeden reddedilmiş olup da, karar düzeltme talebi üzerine bu yanlışlığın farkına varılmış ise, Yargıtayın bu defa esas hakkında yapacağı inceleme, karar düzeltme incelemesi değil, temyiz incelemesi niteliğindedir. Bu nedenle, ilk defa yapılan esasa ilişkin bu temyiz incelemesi üzerine verilen Yargıtay kararına karşı, karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

b) Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu bir karara karşı yapılan karar düzeltme talebi, Yargıtay tarafından kabul edilerek karar düzeltilmiş ise, Yargıtayın bu son kararına karşı artık karar düzeltme yoluna gidilemez (HUMK m. 442, I).

Yargıtayın karar düzeltme talebini ret veya kabul etmesi sonucunda, ilk derece mahkemesi hükmü bozulmuş[5]*, mahkeme bu bozmaya uyarak yeni bir hüküm vermiş ve bu hüküm temyiz edilmişse, Yargıtayın bu temyiz üzerine vereceği karara karşı, karar düzeltme yoluna başvurulabilir. Çünkü, bu yeni karar düzeltme talebi aynı Yargıtay kararına karşı değildir.*

Burada belirtilen istisnalar dışında, Yargıtayın (dairelerin veya HGK'nun) asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi üzerine vermiş olduğu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

Yukarıda, bazı istisnaî durumlarda Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak davalara bakabileceği belirtilmişti. Bir Yargıtay dairesinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği karara karşı, HGK'nda temyiz yolu açık ise, HGK'nun temyiz üzerine vereceği karara karşı, HGK'nda karar düzeltme yoluna başvurulabilir. Buna karşılık, bir Yargıtay dairesinin (veya HGK'nun) ilk derece mahkemesi olarak verdiği karar kesin ise (temyiz yolu kapalı ise), böyle bir

---

4 Bkz. 16.10.1940 gün ve 48/85 sayılı İBK (RG 21.02.1941, sa. 4740).

5 Bu bozma iki şekilde olabilir: 1) Yargıtay, temyiz incelemesi üzerine mahkeme kararını bozmuş ve bu bozma kararına karşı yapılan karar düzeltme talebini reddetmiştir. 2) Yargıtay, temyiz incelemesi üzerine mahkeme kararını onamış, bu onama kararına karşı yapılan karar düzeltme talebini kabul ederek, mahkeme kararını bozmuştur.

karara karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği gibi, onun bir devamı olan karar düzeltme yoluna da başvurulamaz.

B) KARAR DÜZELTME SEBEPLERİ

Karar düzeltme sebepleri, HUMK m. 440, I'de ***sınırlı*** *(numerus clausus)* ***olarak*** *gösterilmiş olup,* ***dört tane****dir. Bunun dışındaki bir sebepten dolayı, karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Bununla birlikte, HUMK m. 440, I/4'de yer alan "usul ve kanuna aykırılık" şeklindeki genel karar düzeltme sebebinden dolayı, bütün temyiz sebeplerinin, karar düzeltme sebebi olarak tekrarlanması mümkün olabilmektedir.*

Karar düzeltme sebepleri şunlardır:

1) Temyiz dilekçesi ve (süresi içinde verilmiş olması koşuluyla) karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan ***itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması*** *(HUMK m. 440, I/1). Bu durum, uygulamada özellikle, "ileri sürülen temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden" şeklindeki formül onama kararlarında ortaya çıkmaktadır.*

Kanımızca bu tür "formül onama" kararları, gerekçesiz kararlardır. Oysa Anayasaya (m. 141, III) göre, bütün mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerekir. Öte yandan, gerekçesiz karar, AİHM'nin yerleşik kararlarına göre, adil yargılanma hakkı"na (AİHS m. 6) aykırıdır.

Temyiz sırasında ileri sürülmüş olan itirazların cevapsız bırakılmış olması halinde, Yargıtayın karar düzeltme talebini kabul edip esas hakkında incelemeye geçmesi gerekir.

Yargıtay, karar düzeltme talebinin esası hakkında yapacağı bu incelemede, temyiz incelemesi sırasında cevapsız bırakmış olduğu itirazlarını (iddiasını), kararını etkileyecek nitelikte bulmazsa, karar düzeltme talebini reddeder. Ancak Yargıtay, bu ret kararında evvelce cevapsız bırakmış olduğu ve şimdi reddettiği itirazların her biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır (HUMK m. 440, II). Aksine davranış, yukarıda temyiz için belirttiğimiz üzere, Anayasaya (m. 141, III) ve adil yargılanma hakkına (AİHS m. 6) aykırılık oluşturur.

Tarafın yaptığı temyiz talebi fark edilmediği (gözden kaçtığı) için, temyiz itirazları tamamen cevapsız bırakılan tarafın başvuracağı yolun, karar düzeltme yolu değil, temyiz yolu olduğunu yukarıda görmüştük.

2) ***Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması*** *(HUMK m. 440, I/2): Yargıtayın temyiz üzerine verdiği kararda, birbirine aykırı (çelişen) fıkralar (bölümler) varsa, bunlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için karar düzeltme yoluna başvurulur.*

3) ***Yargıtayda temyiz incelemesi sırasında*** *hükmün esasını etkileyen belgelerde bir* ***hile veya sahteliğin ortaya çıkması*** *(HUMK m. 440, I/3). Örneğin, dosya Yargıtayda iken, dosyadaki belgelerde (ezcümle duruşma tutanaklarında) sahtekârlık yapılmış, mevcut bazı belgeler dosyadan düşmüş (çıkartılmış, çalınmış) veya aslında dosyada olmayan bir belge gizlice dosyaya konulmuş ise, bu durum bir karar düzeltme sebebidir. Ancak, Yargıtayın ka-*

rar düzeltme talebini esastan kabul edebilmesi için, bu hile veya sahteliğin hükmün esasını etkileyecek nitelikte olması gerekir.

*4) **Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması** (HUMK m. 440, I/4): Bu sebep, oldukça geniş bir şekilde kaleme alınmıştır. Buradaki aykırılığı da, (eğer bu aykırılık yapılmasa idi, kararın başka türlü olacağı hallerle sınırlı olarak) "hükmü etkileyecek ölçüde aykırılık" şeklinde ele almak gerekir.*

Buraya ilk olarak, Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararın kendisinin (yani Yargıtayın kararının) usul ve kanuna aykırı olması girer; örnekler:

Temyiz incelemesi duruşmalı olarak yapılmış ve hüküm temyiz eden lehine bozulduğu halde, temyiz eden lehine duruşma vekâlet ücretine hükmedilmesi unutulmuştur. Bu halde hüküm lehine bozulmuş olan taraf, Yargıtay kararının vekâlet ücreti bakımından kanuna aykırı olduğu sebebine dayanarak, karar düzeltme talebinde bulunabilir.

Temyiz eden temyiz talebinden feragat ettiği halde, Yargıtay, bu feragatı dikkate almadan temyiz incelemesi yapmış ve hükmü bozmuş ise, bu bozma kararı usul ve kanuna aykırıdır; buna karşı, taraflar karar düzeltme talebinde bulunabilirler.

Bundan başka Yargıtay, temyiz edilen hüküm usul ve kanuna uygun olduğu halde onu bozmuş veya usul ve kanuna aykırı olan bir hükmü onamış ise, Yargıtayın böyle bir kararı (HUMK m. 440,I/4 anlamında) usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle, böyle bir Yargıtay kararına karşı da, karar düzeltme yoluna gidilebilir.

Yargıtay, aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan kararının yanlış olduğu kanısına varırsa, usul ve kanuna aykırılık sebebine dayanarak, karar düzeltme talebini kabul edip, eski kararını değiştirebilmektedir. Oysa, o sebep temyiz incelemesi sırasında ileri sürülmüş ve Yargıtay'ca reddedilmiştir. Bu hali ile, karar düzeltme yolu uygulamada sanki ikinci bir temyiz yolu olmaktadır.

C) KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULMASI

Karar düzeltme yoluna da, ancak davanın tarafları gidebilir. Ferî müdahil, yalnız başına karar düzeltme yoluna başvuramaz.

Bir Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna başvuran tarafın, karar düzeltme yoluna başvurmakta hukukî yararının bulunması gerekir. Kendi temyizi üzerine hüküm bozulmuş olan taraf, kural olarak karar düzeltme yoluna gidemez; fakat, hukukî yararı varsa gidebilir (karş. HUMK m. 427,I/c. 2).

*Bir tarafın **karar düzeltme yoluna başvurabilmesi için**, hükmü **temyiz etmiş olmasına gerek yoktur**. Hüküm lehine olan taraf, hükmü temyiz etmemiş ve fakat hüküm karşı tarafın temyizi üzerine bozulmuş ise, bozma kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurarak, mahkemenin hükmünün onanmasını isteyebilir.*

*Karar düzeltme süresi, **on beş gün**dür (HUMK m. 440). Bu süre hak düşürücü süredir; süre geçtikten sonra karar düzeltme yoluna başvurulamaz.*

On beş günlük karar düzeltme süresi, Yargıtay kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Temyiz incelemesi duruşmalı olarak yapılmış ve Yargıtay, kararını duruşmada tarafın yüzüne karşı sözle bildirmiş (tefhim etmiş) ise, karar düzeltme süresi sözle bildirim tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Taraflardan biri süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunursa diğer taraf, (asıl karar düzeltme süresini geçirmiş olsa bile) karar düzeltme dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde vereceği ayrı bir dilekçe veya cevap dilekçesi ile, karar düzeltme talebinde bulunabilir (HUMK m. 442, II); buna ***katılma yoluyla karar düzeltme*** *denir.*

Karar düzeltme talebi bir ***dilekçe*** *ile yapılır. Bu dilekçeye, karşı tarafta bulunan kişilerin sayısı kadar suret eklenir (Y m. 208, 1-3).*

Karşı taraf, karar düzeltme dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde bir ***cevap dilekçesi*** *verebilir. Bu cevap dilekçesinde, karar düzeltme talebine karşı cevap verilebileceği gibi, başka sebeplere dayanarak karar düzeltme de istenebilir (HUMK m. 442, II).*

Karar düzeltme yoluna başvurulması, ***hükmün icrasını durdurmaz*** *(HUMK m. 442 son cümle); ayrıca (temyizdekinden -HUMK m. 443, I-III; İİK m. 36- farklı olarak), karar düzeltme yolunda Yargıtay, teminat karşılığı da olsa icranın durdurulmasına karar veremez. Temyiz incelemesi sırasında verilmiş olan icranın durdurulması kararı, karar düzeltme aşaması için geçerli değildir. Bu kural, kesinleşmeden icraya konabilecek hükümler içindir. Kesinleşmeden icra edilemeyecek olan hükümlerin (HUMK m. 443, IV) onanmasına ilişkin Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulması halinde, hüküm henüz kesinleşmemiş durumda olduğundan, icranın başlaması gündemde değildir.*

D) KARAR DÜZELTME TALEBİNİN İNCELENMESİ

Karar düzeltme talebinin incelenmesi de, kural olarak temyiz incelemesi gibidir. Burada, yalnız karar düzeltme incelemesinin özellikleri üzerinde durulacaktır.

Karar düzeltme talebi, aynı Yargıtay dairesinde (temyiz incelemesini yaparak karara bağlamış olan Yargıtay dairesinde) veya HGK'nda incelenir. Yargıtay, karar düzeltme incelemesini ***dosya üzerinde*** *yapar. Temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması mümkün olan hallerde (HUMK m. 438, I) dahi, karar düzeltme aşamasında* ***duruşma yapılamaz.***

Karar düzeltme incelemesi, aşağıdaki gibi üç aşamalı olabilir:

İlk önce, karar düzeltme talebinin usulî şartları taşıyıp taşımadığı (usulen görülüp görülemeyeceği; mesmu olup olmadığı) incelenir: Karar düzeltme talebi, düzeltilmesi istenebilecek bir karara karşı karar düzeltme yoluna başvurmakta hukukî yararı olan tarafça, karar düzeltme süresi içinde yapılmış ise usule uygun sayılır. Bu şartlardan biri eksik ise (örneğin karar düzeltme süresi geçtikten sonra bu yola başvurulmuşsa) Yargıtay, bundan sonraki aşamaya geçmeden, karar düzeltme talebini mesmu olmadığı (dinlenemeye-

ceği) gerekçesiyle reddeder[6]*. Bu halde Yargıtay, karar düzeltme talebinde bulunan tarafı para cezasına mahkûm eder (bkz. m. 442, III).*

Yapılan ön incelemede usulî şartların mevcut olduğu anlaşılırsa Yargıtay, karar düzeltme talebinin, ***kanunun saydığı sebeplere*** *(HUMK m .440)* ***uygun olup olmadığını*** *araştırır. Yargıtayın bu araştırmayı yapması için, karar düzeltme dilekçesinde hangi karar düzeltme sebep veya sebeplerine dayanıldığının* ***açıkça gösterilmesine gerek yoktur****. Yargıtay, Kanunun saydığı karar düzeltme sebeplerinin (HUMK m. 440, I/1-4) olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Yargıtay, yapacağı araştırma ve incelemede karar düzeltme talebini kanunda (HUMK m. 440) gösterilen sebeplere uygun bulmazsa, karar düzeltme talebini reddeder*[7] *ve karar düzeltme talebinde bulunan tarafı para cezasına mahkûm eder (HUMK m. 442, III).*

Yargıtay, karar düzeltme talebini, kanunun saydığı sebeplerden birine (veya bir kaçına) uygun bulursa, ***esas hakkında incelemeye başlar****. Bu durumda, yalnız karar düzeltme dilekçesinin kabulüne karar verilmekte olup, bunun anlamı* ***esas hakkında incelemeye geçilebilmesidir****. Yoksa, Yargıtay bununla karar düzeltme talebini esastan kabul etmiş olmadığı gibi, bu husus, mutlaka düzeltilmesi istenen kararın aksine bir karar verileceği anlamına da gelmez (m. 442, III/c.2).*

Örneğin, temyiz incelemesi sırasında bazı temyiz itirazları cevapsız bırakılmışsa (HUMK m. 440, I/1), karar düzeltme talebinde bulunulması üzerine, Yargıtay, m. 440, I/1 gereğince düzeltme dilekçesini kabul etmeye mecburdur. Ancak bu dilekçenin kabulü, Yargıtayın, mutlaka temyiz üzerine verdiği kararın aksine bir karar vereceği anlamına gelmez. Çünkü Yargıtay, temyiz incelemesi sırasında cevapsız bırakmış olduğu itirazları kendi görüşüne göre hükmü etkileyebilecek nitelikte bulmazsa, karar düzeltme talebini esastan reddeder; fakat, reddettiği her temyiz itirazı için gerekçe göstermek zorundadır (HUMK m. 440, II).

Yargıtay, esastan inceleme sonucunda iki şekilde karar verir.

I – KARAR DÜZELTME TALEBİNİN ESASTAN REDDEDİLMESİ

Yargıtay, (ikinci aşamada) mevcut olduğu kanısına vardığı karar düzeltme sebebini (veya sebeplerini), temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu (onama, düzelterek onama veya bozma) kararının esasını etkileyecek nitelikte bulmazsa, karar düzeltme talebini esastan reddeder. Yani bu halde, Yargıtay, temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu onama, düzelterek onama veya bozma[8] *kararını doğru bulur.*

---

6 Yargıtayın aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan kararı onama veya düzelterek onama kararı ise, bu defa karar düzeltme talebinin mesmu olmadığından dolayı reddedilmesi ile, onanan mahkeme hükmü (şeklî anlamda) kesinleşir.

7 Yargıtayın aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan kararı onama veya düzelterek onama kararı ise, bu defa karar düzeltme talebinin kanunun saydığı sebeplere uygun olmaması nedeniyle reddedilmesi ile, onanan mahalli mahkeme hükmü (şeklî anlamda) kesinleşir.

8 Yargıtayın onama kararına karşı başvurulan karar düzeltme talebinin reddedildiği tarihte, onanan mahkeme hükmü (şeklî anlamda) kesinleşir. Yargıtayın onamaya karşı başvurulan

Bu halde, Yargıtayın da (ikinci aşamada) kabul ettiği gibi, ortada bir karar düzeltme sebebi vardır. Karar düzeltme talebinde bulunan taraf, bu sebebin hükme etkili olup olmadığını kendisi takdir edemeyeceğinden, karar düzeltme isteme yetkisini kötüye kullanmış ve Yargıtayı gereksiz yere işgal etmiş sayılamaz; yani talebinde haklıdır. Bu nedenle, karar düzeltme isteyen tarafa (talebi esastan reddedildiği halde, m. 442, III/c.1) para cezası verilemez. Esasen, m. 442, III/c.1 hükmü, bu hükümde de açıkça ifade edildiği gibi, ikinci aşama ile ilgilidir ve buradaki üçüncü aşamaya kıyasen uygulanamaz.

II – KARAR DÜZELTME TALEBİNİN ESASTAN KABUL EDİLMESİ

Yargıtay, karar düzeltme talebini esastan kabul ederse (yani, karar düzeltme sebebini, temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararı etkileyici nitelikte bulursa), temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu eski kararını düzeltir. Bu düzeltme, Yargıtayın kendi kararına ilişkin olabileceği gibi, yerel mahkemenin (ilk derece mahkemesinin) hükmüne ilişkin de olabilir:

Yargıtay, temyiz üzerine vermiş olduğu kararın bazı yönlerden usul ve kanuna aykırı olduğu kanısına varırsa, bunları düzeltir.

Karar düzeltme talebini esastan kabul eden Yargıtay, bunun üzerine, daha önceki kararının, yerel mahkemenin hükmüne ilişkin olan kısmında değişiklik (düzeltme) yapılması gerektiği kanısına varırsa, aşağıdaki gibi üç şekilde karar verebilir:

Yargıtay, temyiz incelemesi sonucunda bozmuş olduğu bir hükmü, karar düzeltme talebi üzerine bu defa onayabilir; yani eski bozma kararını kaldırabilir.

Bu onama kararının verildiği tarihte, onanan mahkeme hükmü (şeklî anlamda) kesinleşir.

Yargıtay, karar düzeltme talebi üzerine, HUMK m. 438, VII-IX hükümlerine göre, mahkeme hükmünü düzelterek de onayabilir. Örneğin, Yargıtay bir hükmü temyiz incelemesi sonucunda onamıştır. Fakat, daha önceki bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan bir alacak kesimi bu onama kararında hüküm dışı bırakılmıştır. Karar düzeltme talebi üzerine, kesinleşmiş olan alacak kesiminin hüküm dışı bırakılması usule aykırı bulunur; fakat bunun için yeniden duruşma ve tahkikat yapılmasına gerek olmadığından, hüküm fıkrasına bu alacak kesimi de eklenerek, hüküm düzeltilerek onanır. Bu düzelterek onama kararının verildiği tarihte, onanan mahkeme hükmü (şeklî anlamda) kesinleşir.

Yargıtay, temyiz incelemesi sonucunda onamış olduğu (onama kararı verdiği) bir hükmü, karar düzeltme talebi üzerine bu defa bozabilir. Ancak, taraflardan yalnız biri karar düzeltme yoluna başvurmuşsa, Yargıtay, "aleyhe bozma yasağı" kuralı sebebiyle mahkeme hükmünü o taraf aleyhine olarak bozamaz.

---

karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararlarının sonucu, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından on beş gün içinde kendiliğinden taraflara bildirilir (HUMK m. 442/A, II-III).

§ 61. YARGILAMANIN İADESİ[1] (YENİLENMESİ)[2]

Kesin hükme bağlanmış olan bir davaya yeniden bakılamayacağına ilişkin kuralın, en önemli istisnasının, yargılamanın iadesi yolu olduğu yukarıda görüldü.

Buna göre yargılamanın iadesi (yargılamanın yenilenmesi; muhakemenin iadesi; iadei muhakeme), bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından dolayı, maddî anlamda kesin hükmün ortadan kaldırılmasını ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden inceleme ve yargılama yapılarak yeni bir karar verilmesini sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur.

Yargılamanın iadesi, olağanüstü bir kanun yoludur; çünkü, yargılamanın iadesi yoluna ancak kesinleşmiş olan kararlara (hükümlere) karşı başvurulabilir (bkz. HUMK m. 445 ilk cümle). Bir karar (hüküm) henüz kesinleşmemişse, HUMK m. 445'te düzenlenen sebeplerden biri mevcut olsa bile, hüküm kesinleşmeden önce yargılamanın iadesi yoluna gidilemez.

Yargılamanın iadesi sebepleri, henüz kesinleşmemiş durumdaki kararlar bakımından, evleviyetle (öncelikle) olağan kanun yolu (temyiz ve karar düzeltme) sebebi oluştururlar. Kaldı ki, yargılamanın iadesi sebepleri de, esas itibariyle, hukuka (kanuna) aykırılık oluşturduklarından, genel temyiz sebebi (HUMK m. 428, I/1) olarak da değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle, yargılamanın iadesi sebebi olarak öngörülmüş olan bir durum ortaya çıkınca (HUMK m. 445), dava henüz derdest (yani, kesin hükümle sonuçlanmamış) ise, bu durum, hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin olağan kanun yolu (temyiz) sebebi olarak ileri sürülür ve bozma nedeni oluşturur.

Yargılamanın iadesi sebebinin olağan kanun yolu aşamasında ortaya çıkması ve bu aşamada ileri sürülmesi halinde, Yargıtayın bu sebebi ciddî görmesine bağlı olarak bozma kararı vererek, dosyayı ilk derece mahkemesine iade etmesi uygun olur. Aksi halde, Yargıtayın bu sebebi dikkate almayıp hükmün kesinleşmesinin beklenerek yargılamanın iadesi yoluna gidilmesi düşüncesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzamasına neden olabilir.

Maddî anlamda kesin hüküm niteliği olmayan kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz.

A) YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ

Yargılamanın iadesi sebepleri, HUMK m. 445'te sınırlı (numerus clausus) olarak sayılmıştır. Kanunda sayılmayan bir sebep yargılamanın iadesi nedeni olmaz. Buna paralel olarak, Kanunun saydığı iade sebeplerinin kıyas yo-

---

1 **İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016'DAN) ÖNCE VERİLEN KARARLAR HAKKINDA HMK GEÇİCİ MADDE 3 GEREĞİ UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER (HUMK m. 445-454).**

2 Yargılamanın iadesi (yenilenmesi) konusunda bkz. Ramazan Arslan, Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977.

luyla genişletilebilmesi mümkün değildir. Çünkü, yargılama hukuku açısından asıl olan kesin hükmün elde edilmesidir ve kesin hükmün amacı, kesin hükmün olabildiğince ayakta tutulmasını gerektirir. Bu yüzden, yargılamanın iadesi olağanüstü bir kanun yolu olarak nitelendirilir.

Yargılamanın iadesi sebepleri şunlardır (HUMK m. 445):

I – YENİ BİR SENET veya BELGENİN ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI

Yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmiş olmasının yargılamanın iadesi sebebi oluşturabilmesi için, aşağıdaki şartların (hep birlikte) bulunması gerekir:

*1) Bu senet veya belge, **davaya bakıldığı sırada** (yargılama esnasında) **mevcut olmalı**dır. Bu sebeple, hüküm verildikten sonra düzenlenmiş olan bir belgeye dayanılarak yargılamanın iadesi istenemez.*

*2) Yeni ele geçirilmiş olan senet veya belgenin, **hükmü etkileyecek** (karara müessir) **nitelikte olması** gerekir. Yani, yargılama sırasında mahkemeye sunulmuş olsaydı, başka bir hüküm verilmesine neden olabilecek bir belge olmalıdır. Hükmü etkilemesi mümkün olmayan yeni senet ve belge, yargılamanın iadesi sebebi oluşturmaz.*

*3) Bu yeni senet veya belgenin, **hükmün verilmesinden sonra** elde edilmiş olması gerekir.*

*4) Bu yeni senet veya belgenin, yargılama sırasında (hükümden önce), **zorlayıcı** (mücbir) **bir sebep**ten dolayı veya lehine hüküm verilen **karşı tarafın eylemi**nden dolayı elde edilememiş olması gerekir. Maddede (m. 445/I) belirtilen zorlayıcı nedenden anlaşılması gereken, yargılamanın iadesini isteyen tarafın söz konusu belgeyi dava sırasında elde edememesinin kendi kusuruna dayanmamasıdır. Eğer bu senet veya belge, davayı kaybeden tarafın elinde bulunmasına rağmen, iyice araştırıp bulamamasından dolayı mahkemeye sunulmamışsa, bu durum, yargılamanın iadesi nedeni oluşturmaz.*

Buna göre aşağıdaki örneklerde, yukarıda anılan dört şartın hepsi de mevcut olduğundan, yargılamanın iadesi talebinin kabulüne karar verilmiştir:

*"Davacı Başbakanlık arşivinde dava konusu yaylanın köylerine tahsis edilmiş olduğuna dair bir vesika olup olmadığı hakkında müracaat ettiğini ve bu müracaata rağmen yine böyle bir vesika elde edemediğini ve sonradan tarih ve numarasını başkasından öğrenmesi üzerine bu **fermanı** bulabildiğini beyan etmiştir. Filhakika Başbakanlık Müsteşarlığının 14.8.1959 tarihli yazısında, davacının böyle bir müracaat yaptığı ve yüz senelik kayıtların arandığı, daha evvelki senelere ait kayıt isteniyorsa, kaydının bulunabilmesi için tarihinin bildirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Binaenaleyh, davacı kendisine terettüp eden işleri yapmış ve elinde olmayan bir sebepten dolayı kayıt bulunamamıştır. Bu itibarla davacının evvelce böyle bir fermanın mevcudiyetini bilememiş olmasına ve Başbakanlığa müracaat etmesine rağmen ferman elde edilememiş olmasına göre, hadisede mücbir sebebin mevcut olmadığının ve davacının ihmaliyle vesikanın bulunmadığının kabulünde isabet yoktur. Binaenaleyh, iadei muhakeme talebinin kabulü ile (sonradan ele geçirilen) fermanın nizalı yaylaya mahallen tatbiki...gerekir".*

İlgili tapu memurlarının dahi "mevcudiyetinden haberdar olmadığı sicildeki yanlışlıkla sabit bulunan ve bu davadan 30 sene önce düzenlenmiş olup bir dosya içerisinde tapu idareleri arşiv depolarına atılmış bulunan tescilin dayanağı belgeleri, davacıların araştırmamış olmaları onlar için kusurlu bir hareket sayılamayacağı, aksine olarak bu şekilde saklanmış olan belgelerin davacılar bakımından zorlayıcı bir sebep tahtında elde edilemediğinin (ve bu belgelere dayanarak açılan yargılamanın iadesi davasının) kabulü gerekir".

Buna karşılık, "tapu kayıtları herkese açık olup alâkalısının münderecatını öğrenmesi her zaman mümkündür" gerekçesiyle, hükümden sonra ele geçen (bulunan) tapu kaydı, HUMK m. 445/1 anlamında bir belge ve mücbir sebep sayılmamıştır.

Yalnız bir tarafın tapu dairesinden alıp mahkemeye verdiği tapu kayıt örneğinin doğru olmadığı, sonradan tapu memurunun yazdığı resmî yazı ile anlaşılırsa, yarılamanın iadesi yoluna gidilebilir; örnek: "Resmî dairenin gerçeğe uygun olmayacak şekilde kayıt çıkarması, doğru kaydı mahkemeye getirememe bakımından davalı için mücbir sebep sayılır. Mahkemece bu durum göz önünde tutularak yargılamanın iadesi isteği kabul edilmek ve işin esasına girilip kütük üzerinde bilirkişi incelemesi yapılıp gerçek pay miktarına göre karar verilmek gerekir".

*Bu halde (HUMK m. 445/1), yargılamanın iadesini isteme süresi, yeni senet veya belgenin **elde edildiği tarihten itibaren üç aydır** (HUMK m. 447, I).*

II – HÜKME ESAS ALINAN SENEDİN SAHTE OLDUĞUNUN SONRADAN ANLAŞILMASI

Hükme esas olarak alınmış olan bir senedin sahte olduğunun sonradan anlaşılması bir iade sebebidir. Kanuna göre bu iade sebebi iki şekilde ortaya çıkabilir:

1) Hükümden sonra verilen bir mahkeme kararı ile, hükme esas alınmış olan senedin sahteliğine karar verilmiş olmalıdır.

2) Hükme esas alınmış olan senedin sahte olduğunun, hüküm lehine olan tarafça, mahkeme veya resmî bir makam huzurunda ikrar edilmiş olmalıdır.

Sahtelik hakkındaki mahkeme kararının (yargılamanın iadesi istenilen) hükümden önce verilmiş (veya lehine karar verilen tarafın ikrarının hükümden önce yapılmış) olması halinde, eğer iade talebinde bulunan taraf, hüküm sırasında bunu öğrenmemişse, bu da iade sebebi olur.

*Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, sahtelik hakkındaki hükmün kesinleştiği veya hüküm lehine olan tarafın senedin sahte olduğunu mahkeme veya resmi makam huzurunda ikrar etmiş bulunduğunu öğrenme tarihten itibaren **üç aydır** (HUMK m. 447,I).*

III – HÜKME ESAS ALINAN BİR İLÂMIN KESİN BİR HÜKÜMLE ORTADAN KALKMIŞ OLMASI

Dava görülürken taraflardan biri, mahkemeye kesin delil olarak bir ilâm (mahkeme kararı) sunmuş ve mahkeme de, bu ilâmı esas alarak (ona itibar ederek) hüküm vermiş olabilir.

Eğer, kesin delil olarak hükme temel alınan bu ilâm, kesin hüküm halini alan başka bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkarsa, bu durum, yargılamanın iadesi sebebi olur (HUMK m. 445/3). Çünkü, mahkemenin verdiği kararın (hükmün) temeli çökmüş ve gerekçesi ortadan kalkmıştır. Bu durumda yargılamanın yeniden yapılması ve yeni bir hüküm verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, bunu isteyenin, ilâmın kesin bir hükümle ***ortadan kalktığını öğrendiği tarihten itibaren üç aydır*** *(HUMK m. 447, I).*

IV – İFADESİ HÜKME ESAS ALINAN BİR TANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA YALAN TANIKLIKTAN MAHKÛM EDİLMİŞ OLMASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, dinlediği tanık ifadesini (m. 240 vd.) esas alarak sonuca varmış ve kararının (hükmünün) gerekçesini de bu tanık ifadesine dayandırmış olabilir. Ancak, ifadesi (şahadeti, tanıklığı) hükme esas alınan tanığın, yalan yere tanıklık ettiği (m. 264) anlaşılırsa, kararın (kesin hükmün) temeli çökmüş olur ve yargılamanın yenilenmesi gerekir.

Tanığın yalan tanıklık yapıp yapmadığı, bu konuda verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararına bağlıdır (TCK m. 272).

Her yalan (yere) tanıklık (m. 264; TCK m. 272), yargılamanın iadesi sebebi oluşturmaz. Yalan tanıklığın, yargılamanın iadesi nedeni olabilmesi için, yalan tanıklık yapan kişinin ifadesinin ***hükme esas alınmış olması*** *gerekir. Eğer mahkeme, yalan tanığın ifadesine itibar etmemiş ve kararının gerekçesi olarak da bu ifadeyi değerlendirmemişse, bu tanığın yalan tanıklıktan dolayı mahkûm edilmesi, yargılamanın iadesi nedeni olmaz.*

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, tanığı yalan tanıklıktan dolayı cezaya mahkûm eden ***ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren üç ay****dır (HUMK m. 447,I).*

V – BİLİRKİŞİNİN KASTEN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞUNUN BİR MAHKEME HÜKMÜ İLE SABİT OLMASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, başvurduğu bilirkişi görüşünü (sözlü veya yazılı raporunu; m. 266 vd.) esas alarak sonuca varmış ve kararının (hükmünün) gerekçesini de bu bilirkişi görüşüne dayandırmış olabilir. Ancak, görüşü hükme esas alınan bilirkişinin, kasıtlı olarak (bile bile) gerçeğe aykırı rapor verdiği (TCK m. 276), ***kesin ceza mahkemesi kararıyla*** *anlaşılırsa, kararın temeli çökmüş olur ve yargılamanın yenilenmesi gerekir.*

Yukarıdaki yalan tanıklığa ilişkin açıklamalar (HUMK m. 445/4), burası için de kıyasen geçerlidir.

VI – LEHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFIN, YALAN YERE YEMİN ETTİĞİNİN KENDİ İKRARI veya YAZILI DELİL ile SABİT OLMASI

Davada son çare olarak, yemin deliline (m. 225) başvurulmuş ve mahkeme de, yemin deliline dayanarak karar (hüküm) vermiş ve böylece yemini kararına esas almış olabilir. Ancak, hükme esas alınan yeminin, yalan yere yapıldığı (m. 239; TCK m. 275), yalan (yere) yemin edenin kendi ikrarı veya yazılı belge ile anlaşılırsa, hükmün temeli çökmüş olur ve yargılamanın yenilenmesi gerekir.

Lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin bir ceza mahkemesi kararıyla (TCK m. 275) sabit olması veya o tarafın hukuk davasında yalan yere yemin ettiğini ikrar etmesi yahut yalan yere yeminin yazılı delile dayanması halleri, yargılamanın iadesi sebebi oluşturur.

Ancak ceza mahkemesinin yalan yere yeminden dolayı mahkûmiyet kararı, tanık ifadelerine dayanarak verilmişse, HUMK m. 445/6 anlamında bir yargılamanın iadesi sebebi oluşturmaz.

Yukarıda belirtildiği gibi, yalan tanıklık, kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunarak bilirkişilik ve yalan yere yemin hallerinde (yani 445. maddenin 4, 5 ve 6. bentlerindeki hallerde) hukuk mahkemesinden yargılamanın iadesinin istenebilmesi, bu sebeplerin kesinleşmiş bir ceza (mahkemesi) mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması şartına bağlıdır. Fakat, delil yokluğundan başka bir sebeple (örneğin af veya ölüm gibi bir nedenle) ceza kovuşturmasına başlanamamış veya karar verilememiş ise, ceza mahkemesi kararı aranmaz. Bu takdirde hukuk mahkemesinde yargılamanın iadesi davası açılır ve yargılamanın iadesi sebeplerinin varlığının (tanığın yalan söylemiş, bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş veya karşı tarafın yalan yere yemin etmiş olduğunun), yargılamanın iadesi davasında, yani bu davaya bakan hukuk mahkemesinde öncelikle ispat edilmesi gerekir (HUMK m. 445 son fıkra). Bu halde, yargılamanın iadesi davasına bakan hukuk mahkemesi, (ön sorun olarak; m. 163) tanığın veya bilirkişinin beyanının veya karşı tarafın yemininin yalan olduğunu tespit ederse, o zaman yargılamanın iadesi davasının esasına girerek davayı esastan karara bağlar. Bundan başka, tanığın veya bilirkişinin beyanının veya karşı tarafın yemininin yalan olduğunun (HUMK m. 445 son fıkraya göre) yargılamanın iadesi davasında tespit ettirme imkânı olan davacının, yargılamanın iadesi davasından ayrı olarak bir tespit davası açmakta korunmaya değer hukukî yarar da yoktur.

Burada yargılamanın iadesini isteme süresi, ***ceza mahkemesi hükmünün kesinleşmesinden itibaren üç aydır*** *(HUMK m. 447, I).*

VII – LEHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFIN HÜKME ETKİSİ OLAN BİR HİLE KULLANMIŞ OLMASI

Taraflardan biri, davada, mahkemenin ve diğer tarafın fark etmediği bazı hileler kullanmış, lehine karar (hüküm) almış ve bu karar kesinleşmiş olabilir. Davada böyle bir hile kullanılmış olması, yargılamanın iadesi sebebidir.

Buradaki hileyi, diğer kanunlarda düzenlenen hileden daha geniş bir şekilde anlamak gerekir. Örnekler:

Lehine "hüküm verilen tarafın, karşı tarafın vekili ile gizlice anlaşma yoluna gitmesi, bilirkişi ve tanıkları hatalı beyanda bulunmaya sevketmiş olması ve karşı tarafın kendi vekili ile olan muhaberelerini ele geçirerek onları kendi lehine kullanmış olması".

Tebligat hilesi yapmak: Koca, karısına karşı açtığı boşanma davasında karısının adresini yanlış gösterip, karısı bu yanlış adreste bulunamadığı için ilânla tebligat yaptırarak, karısının yokluğunda devam edilen davada boşanma kararı alıyor; veya koca, boşanma davası dilekçesini, karısının yerine hile ile başka bir kadına tebliğ ettiriyor; karısı davadan haberi olmadığı için duruşmaya gelemiyor; koca, karısının yokluğunda boşanma kararı alıyor. İşte, bu gibi hileli tebligat ile elde edilen boşanma kararına karşı kadın, boşanma kararını öğrendiği tarihten itibaren üç ay içinde, kocasına karşı yargılamanın iadesi davası açabilir.

Bir boşanma davasında davacı kocanın, karısı yerine başka bir kadını mahkemeye getirmesi ve onu hâkime karısı gibi tanıtıp dinletmesi de, HUMK m. 445/7 anlamında bir hile olup, yargılamanın iadesi sebebidir.

Burada hilenin bir ceza mahkemesi kararı ile sabit olmasına gerek yoktur. Hile iddiası, doğruca yargılamanın iadesi davası ile birlikte, bu davaya bakacak olan mahkemeye (hukuk mahkemesine) bildirilir ve o mahkeme tarafından incelenir.

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, hilenin ***öğrenildiği tarihten itibaren üç ay****dır (HUMK m. 447, I).*

VIII – VEKİL veya TEMSİLCİ OLMAYAN KİŞİLER HUZURU ile DAVANIN GÖRÜLÜP HÜKME BAĞLANMIŞ BULUNMASI

Bir davaya, taraflardan birinin gerçekten vekili veya temsilcisi olmayan bir kimsenin huzuru ile bakılır ve hüküm verilirse, bu husus, yargılamanın iadesi sebebidir (HUMK m. 445/8). Örnekler:

Davada taraflardan birinin vekili (veya temsilcisi) olarak hareket etmiş olan kişinin (örneğin avukatın), o tarafı temsil yetkisinin (örneğin vekâletnamesinin) olmaması (m. 76), yargılamanın iadesi sebebidir.

Evlilik dışı doğan bir çocuğa kayyım tayin edilmediği ve mahkeme velayeti ana ve babadan birine vermediği halde, çocuğun anası çocuk adına dava açmış ve davaya bakılmış ise, burada ana yasal temsilci olmadığından, bu husus bir yargılamanın iadesi sebebi oluşturur.

Bu halde, sadece davanın vekil veya temsilci olmayan bir kişinin huzuru ile görülmüş olması yeterli olup, bu temsil eksikliğinin hükmü etkileyip etkilemediğini araştırmaya gerek yoktur.

Burada, yargılamanın iadesini isteme süresi, hükmün, aleyhine hüküm verilen tarafa veya onun gerçek vekil veya mümessiline ***tebliği tarihinden itibaren üç aydır*** *(HUMK m. 447/I).*

IX – DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN BİR HÂKİM TARAFINDAN DAVAYA BAKILMIŞ ve HÜKÜM VERİLMİŞ OLMASI

Davaya bakması yasak olan bir hâkimin (m. 34), davaya bakmış ve hüküm vermiş olması, yargılamanın iadesi sebebidir. Bu halde de, davaya bakması yasak olan hâkimin davaya bakmış ve hüküm vermiş olmasının, hükmü etkileyip etkilemediğini araştırmaya gerek yoktur. Böyle bir durumun varlığı, mutlak yargılamanın iadesi sebebi kabul edilir.

Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, hükmün, aleyhine hüküm verilen tarafa ***tebliğ edildiği tarihten itibaren üç aydır*** *(HUMK m. 447,I).*

X – TARAFLARI, DAVA SEBEBİ ve KONUSU AYNI OLAN BİR DAVA HAKKINDA BİRBİRİNE AYKIRI KESİNLEŞMİŞ İKİ HÜKÜM BULUNMASI

Tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynı olan bir dava hakkında verilen hükme aykırı yeni bir hüküm verilmesi için neden yokken, aynı mahkeme veya başka bir mahkeme tarafından, önceki (birinci) hükme aykırı ikinci bir hüküm verilmiş bulunması, yargılamanın iadesi sebebidir. Bu sebebe dayanarak yargılamanın iadesi yoluna gidebilmek için, her iki hükmün de kesinleşmiş olması gerekir (HUMK m. 445/10). Eğer ikinci hüküm henüz kesinleşmemişse (yani, ikinci dava derdest ise), yargılamanın iadesi yoluna değil, ikinci hükme karşı temyiz yoluna başvurulur. Çünkü, yargılamanın iadesinin istenebilmesi için hükmün kesinleşmiş olması gerekir. Hükmün henüz kesinleşmemiş olması durumunda, yargılamanın iadesi sebepleri, (yukarıda da belirtildiği üzere) aynı zamanda ve öncelikle temyiz sebebi oluşturur.

Tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynı olan uyuşmazlık hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması halinde, birinci hüküm lehine olan taraf, kesin hükümden yararlanır (m. 114, 1/i). Bu nedenle yargılamanın iadesi talebi üzerine, ikinci hükmün iptaline karar verilir (HUMK m. 450, II). Fakat, bunun için (ikinci hükmün yargılamanın iadesi yolu ile iptal edilebilmesi için), ikinci hükmü veren mahkemenin, ikinci hükmü verirken, birinci hükümden haberdar bulunmamış olması gerekir. Eğer, ikinci davanın görüldüğü sırada, birinci hükme dayanılarak kesin hüküm itirazında bulunulmuş, yani gerek mahkeme, gerek Yargıtay, birinci hükmün varlığını öğrenmişler ve bu hükmü ikinci davaya etkili saymayarak, kesin hüküm itirazını reddetmişlerse, artık HUMK m. 445/10 hükmüne dayanarak yargılamanın iadesi istenemez. Çünkü kanun, ikinci davanın görülmesi sırasında mahkemenin kesin hükümden haberdar bulunmuş olması halinde, bunu ancak temyiz sebebi olarak ileri sürülebileceğini öngörmüş (HUMK m. 428/3) ve böylece bu hususun yargılamanın iadesi sebebi yapılmasına izin vermemiştir. Şu halde tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynı olan bir dava hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması sebebine dayanarak yargılamanın iadesi yoluna başvurabilmek için, ikinci hükmün verildiği davanın görülmesi sırasında, mahkemenin, birinci hükümden haberdar bulunmamış olması gerekir.

Bu halde (HUMK m. 445/10) yargılamanın iadesini isteme süresi, zamanaşımı süresi kadardır (HUMK m. 447, II): yani ***on yıldır*** *(TBK m. 156; İİK m. 39). Bu süre,* ***ikinci hükmün kesinleşmesinden itibaren*** *işlemeye başlar.*

XI – AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARI

Mahkemece verilen hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması da bir yargılamanın iadesi nedenidir[3]*.*

XII – LEHİNE HÜKÜM VERİLEN ile ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN ARASINDA HİLE YAPILMIŞ OLMASI

İki kişi, alacaklılara veya kendi yerlerine geçecek olanlara zarar vermek üzere, hileli bir anlaşma yaparak, davacı ve davalı olurlar, hüküm elde ederler ve bu hüküm kesinleşir ise, hüküm aleyhine olan tarafın alacaklıları ve halefleri (yani, dava dışı üçüncü kişiler) yargılamanın iadesi yoluna gidebilirler (HUMK m. 446).

Bunun için şu şartın gerçekleşmesi yani, hükmün (davanın) taraflarının, hüküm aleyhine olan tarafın alacaklılarına veya haleflerine zarar vermek için, anlaşarak hile ile o taraf aleyhine hüküm verilmesini sağlamış olması gerekir. Örnekler:

Mirasçılarından mal kaçırmak isteyen bir kişi, üçüncü bir kişi ile anlaşarak, bu üçüncü kişiye, kendisi aleyhine uydurma bir alacak davası açtırmıştır; davada kendini savunmayarak (tersine, davacı üçüncü kişiye yardım ederek), kendi aleyhine hüküm verilmesini sağlamıştır. Böylece malvarlığının tamamen veya kısmen elinden çıkmasına sebebiyet vermiştir. Aleyhine hüküm verilen davalının ölümünden sonra, bundan zarar gören mirasçılar (halefler), miras bırakanları (murisleri) aleyhine olan bu hükme karşı, yargılamanın iadesi yoluna başvurabilirler.

Alacaklılarının, kendisine karşı yapacakları takibin sonuçlarından (haciz, satış) kurtularak mal kaçırmak isteyen bir borçlu, üçüncü bir kişi ile anlaşarak, bu üçüncü kişiye kendisi aleyhine uydurma bir dava açtırmıştır ve aleyhine hüküm verilmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda alacaklı, alacağına kavuşamama hali ile karşılaşmıştır. Zarar gören alacaklı, bu hükme karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurabilir. Örneğin: Beş bin lira net aylık ücret alan bir borçlu, ücretine alacaklı tarafından haciz konulmasını önlemek için, karısına ve çocuklarına, kendisi aleyhine nafaka davası açtırır; dört bin lira nafaka ödeyeceğini bildirir ve kendisini aylık dört bin lira nafaka ödemeye

---

[3] 23.01.2003 gün ve 4793 s. K. m. 1 ile eklenen 11. bent hükmü ile ilgili Geçici m. 1 şöyledir: "Bu Kanunun (1 nci maddesi), bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (yani, 04.02.2003'te) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin muhakemenin iadesi istemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır" (4793 s. K. Geçici m. 1).

mahkûm ettirerek, alacaklılarının ücreti üzerine yeterli haciz koymalarını önlerse borçlunun alacaklısı, bu nafaka hükmüne karşı yargılamanın iadesi yoluna giderek nafakanın dört bin liradan, iki bin liraya indirilmesini sağlayabilir.

Kanunun (HUMK m. 446) haleflere açma hakkı tanıdığı yargılamanın iadesi davası, m. 446'daki şartların gerçekleşmesi halinde açılan özel bir davadır. Haleflerin ayrıca, küllî halefiyet kuralları çerçevesinde, miras bırakanları (murisleri) yerine geçerek HUMK m. 445/1-11'de sayılan yargılamanın iadesi sebebiyle açma (veya miras bırakan, ölümünden önce yargılamanın iadesi davası açmışsa bu davayı takip etme) hakları da elbette vardır.

***XIII** – Yargılamanın iadesi sebepleri sınırlı olmakla birlikte ve esasen yargılamanın iadesi kurumunun tüm özelliklerini barındırmamakla birlikte, **bireysel başvuru** üzerine[4], Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama yapılması için dava dosyasını ilgili mahkemeye göndermesi de, kendine özgü bir yargılamanın iadesi sebebi olarak nitelenebilir. Çünkü, mahkeme, Anayasa Mahkemesinin kararı gereğince, yeniden yargılama yapmak ve Anayasa Mahkemesinin ihlâl kararında açıklanan temel hak ihlâli ile sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar vermek zorundadır (AYMK m. 50, 2).*

B) YARGILAMANIN İADESİ USULÜ

Yargılamanın iadesi yoluna, kural olarak, ancak davanın tarafları (davanın davacısı ve davalısı) başvurabilir; HUMK m. 445'de sayılan hallerde durum böyledir. Ancak istisnaî olarak, m. 446'da belirtilen yargılamanın iadesi halinde, davada dışı üçüncü kişiler (alacaklılar, halefler ve iadesi talep edilen davada verilen ve kesinleşen hüküm kendilerine karşı ileri sürülebilecek olanlar) yargılamanın iadesi davası açabilirler.

Diğer kanun yollarında olduğu gibi, yargılamanın iadesine başvuracak olan tarafın bu başvuruda hukukî yararının bulunması gerekir. Bu sebeple, hüküm lehine olan tarafın, yargılamanın iadesi yoluna başvurmakta hukukî yararı yoktur; bu yola, ancak hüküm aleyhine olan taraf başvurabilir. Birbirine aykırı iki kesin hüküm bulunması halinde (m. 445/10), ikinci hüküm ile birinci hüküm lehine olan tarafa zarar verildiğinden, yargılamanın iadesine isteme hakkı, birinci hüküm lehine ve fakat ikinci hüküm aleyhine olan tarafındır.

*Bu halde yargılamanın iadesini isteme süresi, aleyhine hüküm verilen tarafın alacaklıları ve haleflerinin (üçüncü kişilerin), **hükümden usulen haberdar oldukları** (hükmü öğrendikleri) **günden itibaren bir aydır** (HUMK m. 447,I).*

*Yargılamanın iadesi talebi, **süresi içinde** bir **dava olarak açılır** ve incelenir. Yargılamanın iadesini isteme sürelerini ve bu sürelerin başlangıcını, daha kolay anlaşılır düşüncesi ile, yargılamanın iadesi sebeplerini incelerken yukarıda ayrı ayrı açıklanmıştır. Yargılamanın iadesini isteme sürelerinin hepsi **hak düşürücü süreler**dir. Bu nedenle, hâkim tarafından kendiliğinden gözetilir. HUMK yalnız bir çeşit süre koymuş, bunu azamî (objektif) bir süre ile sınırlandırmamıştır. Buna göre, örneğin vekil olmayan kişi huzuru ile da-*

---

[4] Bireysel başvuru yolları hakkında bkz. aşa. § 78.

vaya bakılmış olması sebebine (HUMK m. 445/8) dayanarak, hükmün aleyhine hüküm verilen tarafa veya gerçek vekiline örneğin yirmi yıl sonra tebliğ edilmesi halinde, üç aylık yargılamanın iadesi süresi, bu tebliğ tarihinden itibaren (yani örnekte yirmi yıl sonra) işlemeye başlar (karş. HMK m. 377, 1/sonu).

HUMK m. 447'de yazılı süreler içinde olmak şartı ile, hüküm (ilâm) icra edildikten sonra da, yargılamanın iadesi istenebilir.

*Yargılamanın iadesi davası, **hükmü vermiş olan mahkemeye açılır** ve o mahkeme tarafından incelenip karara bağlanır (HUMK m. 448, I). Dava dosyası o mahkemede olduğu ve davayı en iyi o mahkeme bildiği için, yargılamanın iadesi davasının, hükmü vermiş olan mahkemede açılması hükme bağlanmıştır. O nedenle bu hükmü (HUMK m. 448, I hükmünü) mutlak bir şekilde anlamak gerekir. Bu nedenle, yargılamanın iadesi davasının, o yerdeki aynı derecedeki başka bir mahkemede (örneğin hükmü vermiş olan asliye mahkemesinden başka bir asliye mahkemesinde) açılamayacağı kanısındayız.*

Yargılamanın iadesi davası, diğer davalarda olduğu gibi, bir dava dilekçesi (m. 119) ile açılır. Bu dava dilekçesinde, özellikle yargılamanın iadesini haklı gösteren sebebin (HUMK m. 445'teki sebeplerden birinin) yazılması ve açıklanması gerekir.

Yargılamanın iadesi davacısı, karşı tarafın zarar ve ziyanını ödeyeceğine dair mahkemece takdir olunacak teminatı göstermek zorundadır (HUMK m. 453, c.1). Teminatın miktarını takdir etmek davaya bakan mahkemeye aittir; bu takdir, temyiz denetimine tâbi değildir. Devletin ve adlî yardımdan yararlananların teminat göstermek zorunluluğu yoktur (HUMK m. 453, c.2).

Yargılamanın iadesi davası, (aleyhine başvurulan kesin) hükmün icrasını (İİK m. 24 vd.) kendiliğinden durdurmaz. Ancak mahkeme, davacıdan teminat alarak, hükmün icrasının durdurulmasına karar verebilir (HUMK m. 449).

Vekilin (avukatın) yargılamanın iadesi davası açabilmesi için, vekâletnamesinde bir yargılamanın iadesini isteme yetkisinin açık bir biçimde bulunması gerekir (m. 74).

*Yargılamanın iadesi davası, mutlaka **duruşma yapılarak** incelenir. Mahkemenin dosya üzerinde **inceleme** yaparak yargılamanın iadesi talebini karara bağlaması caiz değildir*[5]*.*

Mahkeme, ilk önce yargılamanın iadesi davasının usulen görülüp görülemeyeceğini (mesmu olup olmadığını) kendiliğinden araştırır. Mahkeme, burada genel dava şartlarından (m. 114) başka, yargılamanın iadesi davasının süresi içinde (HUMK m. 447) açıp açılmadığını, teminat gösterilip gösterilmediğini ve Kanunda yazılı (m. 445) bir yargılamanın iadesi sebebine dayanıp dayanmadığını kendiliğinden inceler. Mahkeme, bu şartların birinin mevcut olmadığı kanısına varırsa, yargılamanın iadesini davasını usulden (esasa girmeden) reddeder.

---

5 Bkz. 23.05.1956 gün ve 08/09 sayılı İBK (RG 11.08.1956, sa. 9379)

Mahkeme yargılamanın iadesi davasının usulden görülebilir olduğu kanısına varırsa, esasa girerek, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olup olmadığını araştırır.

Mahkeme, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olmadığı kanısına varırsa, yargılamanın iadesi davasını reddeder. Bu ret kararı ile birlikte, yargılamanın iadesini istemiş olan taraf, para cezasına mahkûm edilir (HUMK m. 454). Buna karşılık, mahkeme, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olduğu kanısına varırsa, yargılamanın iadesi talebini kabul ederek (kesin hükmü ortadan kaldırarak/iptal ederek), asıl dava hakkında yeni bir karar verir (HUMK m. 450). Burada yargılamanın iadesi sebeplerine göre bir ayrım yapmak gerekir:

*1) HUMK'nun **445. maddesinin 1 ilâ 7.** ve **11. bentleri**nde yazılı sebeplerden birine dayalı yargılamanın iadesi:*

Bu sebeplerle yargılamanın iadesi talebini kabul eden mahkeme, hükmün iptali ile yetinemez. Mahkemenin yeniden yargılama yaparak, belirecek hale göre yeni bir karar (hüküm) vermesi gerekir (HUMK m. 450, I).

Yeniden yapılacak olan bu yargılama, iadesi istenen yargılamanın (asıl davanın) devamı niteliğindedir. Taraflar, burada yeni delil gösterebilirler; fakat, asıl davadaki davayı değiştirme ve savunmayı genişletme yasağı (m. 141), yargılamanın iadesi davasında da geçerlidir. Yani taraflar, kural olarak, asıl dava sırasında yapmış oldukları iddia ve savunmaları ile bağlıdır.

Bu halde, yargılamanın iadesi sebebine göre, yapılacak yeni yargılamanın şekli de değişir. Örneğin, yeni bir senedin ele geçirilmiş olmasına dayanarak yargılamanın iadesi istenmişse, mahkeme, bu senedin hükme etkisi olup olmadığını inceler. Tanığın yalan söylediğine dayanarak yargılamanın iadesi istenmiş ise, bu tanığın ifadesi nazara alınmadan hüküm verilir. Tebligat hilesi ile bir tarafın yokluğunda hüküm verilmiş ise, o tarafın delilleri de sorulup, bütün deliler birlikte incelenerek hüküm verilir.

Mahkeme, bu şekilde yapacağı tahkikat ve yargılama sonucunda; yargılamanın iadesi sebebini doğru bulmasına rağmen, eski hükmünü doğru bulur; yani, yargılamanın iadesi sebebini hükme etkili bulmazsa mahkeme, eski kararını tekrar verir (tasdik eder). Buna karşılık mahkeme, eski hükmün kısmen veya tamamen değiştirilmesi gerektiği kanısına varırsa, eski hükmünü kısmen veya tamamen değiştirir (HUMK m. 450, I).

*2) HUMK'nun **445. maddesinin 8, 9 ve 10. bentleri**nde yazılı sebeplerden birine dayalı yargılamanın iadesi:*

Hükmün 8. ve 9. bentlerdeki sebeplerle (yani vekil veya temsilci olmayan kişiler huzuru ve yasaklı olan hâkim tarafından davaya bakılmış olması ve birbirine aykırı iki hüküm bulunması sebeplerine dayalı olarak) yargılamanın iadesi talebini kabul eden mahkeme, başkaca tahkikat yapmadan, hakkında yargılamanın iadesi istenen hükmün iptaline karar verir (HUMK m. 450, II).

Buna karşılık, HUMK m. 450, II'deki çözüm şekli, HUMK m. 445/9'da yazılı sebep (davaya bakması yasak olan hâkimin davaya bakıp hüküm vermiş olması) için mahkemenin hükmün iptali ile yetinmesi ve böylece davanın hiç açılmamış sayılması, menfaatler dengesine uygun düşmez. Bu halde, usu-

lüne uygun olarak açılmış bir dava vardır. Yalnız bu dava, davaya bakması yasak olan bir hâkim tarafından hükme bağlanmıştır. Fakat, bunda tarafların bir kusuru yoktur. Şu halde, burada yargılamanın iadesi talebini kabul eden mahkemenin, hükmün iptali ile yetinmemesi, tersine, bunun üzerine, davayı yeni baştan inceleyerek hükme bağlaması gerekir kanısındayız.

Mahkemenin yargılamanın iadesi davası sonucunda verdiği karar, eski hükmün aslının altına yazılır (HUMK m. 451).

Bu karara karşı kanun yoluna gidilebilir (HUMK m. 452, c. 2). Fakat, yargılamanın iadesi davası sonucunda verilen karara karşı, yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz (HUMK m. 452, c.1).

Yargılamanın iadesi davası sonucunda, eski hükmün kısmen veya tamamen değiştirilmesine karar verilmiş ise (HUMK m. 450, I) bu karar, eski hükmün yerine geçer, yani geçmişe etkilidir. Eski hüküm daha önce icra edilmiş ise, icra eski haline iade olunur (İİK m. 40). Ancak, bir boşanma hükmünün kesinleşmesi ile bu hükme karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulması arasındaki dönemde, taraflardan biri, başka biri ile evlenmişse, bu yeni evlenmenin geçerli kalmakta devam edeceği kanısındayız.

C) YARGILAMANIN İADESİ İSTENEMEYECEK OLAN KARARLAR

Yukarıda, bazı kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamayacağına kısaca değinilmişti. Bu (bazı) kararlara karşı, yargılamanın iadesi davası açılamaz (açılmasına gerek yoktur). Örnekler:

***Çekişmesiz yargıda verilen kararlar**, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmadıklarından, bu kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurmaya gerek yoktur. Çünkü, HUMK m. 445'teki sebeplerden birinin mevcut olması halinde, kararın sonradan haksız görülmesi veya sonradan meydana gelen değişiklikler nedeniyle, çekişmesiz yargıda her zaman kararın değiştirilmesini istemek mümkündür.*

***İcra mahkemesinin** (İİK m. 4), ödeme emrine itirazın kaldırılması taleplerinin ret veya kabulüne ilişkin **kararları** (İİK m. 68-68a), maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, bu icra mahkemesi kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. Buna karşılık, icra mahkemesinin, istihkak davaları (İİK m. 96 vd.) ve **ihalenin feshi davası**nın (talebinin; İİK m. 134) reddine ilişkin kararları, maddî anlamda kesin hüküm oluşturduğundan, bu kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir[6].*

Konkordatonun onanması veya reddi kararları (İİK m. 298) da maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz; bu nedenle, bu kararlara karşı da yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz.

---

[6] Yargıtay son yıllarda, icra mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddi ile istihkak davasında verdiği kararların maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmediği yolunda kararlar vermektedir.

KESİN HÜKÜM[1]

İlk derece mahkemesinin verdiği nihaî kararın (hükmün; belli şartlar çerçevesinde ve belli kanun yolları aşamalarına tâbi olarak) kesinleşmesi halinde, "kesin hüküm" (muhkem kaziye; kaziyei muhkeme) ortaya çıkar. Davanın konusu uyuşmazlık da, böylece (kesinleşen mahkeme kararıyla) son bulur.

Kesin hükmün amacı, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin biçimde hem kesinleşme anı (içinde bulunulan zaman kesimi) hem de gelecek için çözümlenmesidir. Bu amacın gerçekleşmesinde, hem davanın taraflarının hem Devlet'in ve hem de toplumun yararı vardır. Çünkü kişiler, aralarındaki uyuşmazlığın kesin biçimde sonuçlanması için dava sırasında bütün iddia savunma olanaklarını kullanarak davanın sonucunda verilecek kararla bu uyuşmazlığın artık (sonsuza kadar) son bulmasını isterler. Devlet'in de bunda yararı vardır. Çünkü Devlet, mahkemelerinin sınırsız (süresiz) bir şekilde aynı uyuşmazlık (dava) ile tekrar tekrar meşgul edilmesini istemez. Toplumsal barış da, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların sonsuza kadar gitmemesini (devam etmemesini) gerektirir. Bunun içindir ki davaların uzaması haline, "geciken adalet, adalet değildir" özdeyişi ifade edilir.

Kesin hüküm, hem kişiler hem de Devlet için hukukî durumda istikrar yaratır. Hukukî güvenlik ve Devlet'in üç temel işlevinden biri olan yargıya (mahkemelere), daha doğru bir ifadeyle, "**adalete güven**", kesin hüküm müessesesi ile sağlanır.

Kesin hükmün bu amacı, iki şekilde gerçekleşir:

1) Bir mahkeme hükmüne, evrensel hukuk devleti ilkesinin gereklerine uygun olarak, ancak bir dereceye kadar itiraz edilebilmesi, sonsuz kanun yolunun olmaması, yani gidilebilecek kanun yolunun belli bir aşamada bitmesi ve bu şekilde **şeklî anlamda kesin hükmün ortaya çıkması.**

2) Davanın tarafları arasındaki hukukî ilişkinin, bütün bir gelecek için kesin olarak tespiti veya düzenlenmesi ve aynı davanın, hükmün kesinleşmesinden sonra yeniden açılamaması; **maddî anlamda kesin hükmün ortaya çıkması.**

---

[1] Bkz. Burhan Gürdoğan, Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960; Hayri Domaniç, Hukukta Kaziyei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti, İstanbul 1964; Ramazan Arslan, Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Gerçeği (ABD 1988/5-6, s.722-737); Nevhis Deren Yıldırım, Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996; Hamide Özden Özkaya-Ferendeci, Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009; Ersin Erdoğan, Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi, Ankara 2017.

§ 62. ŞEKLÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM

A) GENEL OLARAK

Bir kararın şeklî (biçimsel) anlamda kesinliği ile, o karara karşı, belli bir aşamadan sonra olağan kanun yollarına başvurulamayacağı; başka bir deyişle, karara karşı **kanun yolunun bulunmaması** veya **var olanların tüketilmesi** anlaşılır.

Şeklî anlamda kesin hükmün amacı, bir davanın sona ermesine hizmet etmektir. Bir karar şeklî anlamda kesinleşince, tarafların o davadaki amaçları gerçekleşmiş olur; fakat bu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın değil, ancak görülmekte olan davanın sona ermesi demektir. Bundan sonra da taraflar arasında aynı uyuşmazlığın yeni bir dava konusu yapılamaması için bir başka müesseseye (kuruma), yani maddî anlamda kesin hüküm müessesesine (kurumuna) ihtiyaç vardır.

B) ŞEKLÎ ANLAMDA KESİNLİĞİN MEYDANA GELMESİ

Yukarıda yeri geldikçe görüldüğü üzere, bazı kararlar (hükümler), verildikleri anda (şeklî anlamda) kesindir. Bunlar, **istinaf yoluna götürülemeyen** (HMK m. 341; 362; HUMK m. 427) **kararlardır**.

Kanun yoluna tâbi olan (yani verildikleri anda kesin olmayan) kararlar, **kanun yoluna başvurma süresinin** (HMK m. 345; HUMK m. 432; 437) **geçmesi ile** (şeklî anlamda) kesinleşir.

Kanun yoluna başvurmaktan feragat edilmesi ile de, verilen karar şeklî anlamda kesinleşir.

C) ŞEKLÎ ANLAMDA KESİNLİĞİN SONUÇLARI

Şeklî anlamda kesinlik aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarır:

Şeklî anlamda kesinleşen karara karşı, artık olağan kanun yollarına gidilemez.

Bir karar hakkında maddî anlamda kesinlikten bahsedebilmek için, o kararın şeklî anlamda kesinleşmiş olması gerekir. Yani şeklî anlamda kesinlik, maddî anlamda kesinliğin şartıdır (m. 303, 1).

Bir hükmün icraya konabilmesi için, onun kural olarak şeklî anlamda kesinleşmiş olması gerekmez. Ancak, bazı istisnaî hallerde hükmün icra olunabilmesi için, şeklî anlamda kesinleşmiş olması gerekir.

D) ŞEKLÎ ANLAMDA KESİNLİĞİN SONA ERMESİ

Şeklî anlamda kesin hüküm, kural olarak sona ermez. Bunun istisnası, olağan kanun yolu süresinin geçirilmiş olmasına karşı eski hale getirme talebinde (m. 95-101) bulunulması ve bu talebin yerinde görülerek kabul edilme-

sidir. Eski hale getirme talebinin kabul edilmesi şeklî anlamda kesinliği ortadan kaldırır. Yani, eski hale getirme talebinin kabulü halinde, karar şeklen kesinleşmemiş gibi kanun yolu incelemesi yapılır.

§ 63. MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM

A) GENEL OLARAK

Hukukumuzda maddî anlamda kesin hükmü düzenleyen kurallara, HMK'nun 303. maddesinde yer verilmiştir. "Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddî anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir".

Maddî anlamda kesin hüküm (ya da maddî anlamda kesinlik), yargısal kararlara kanun tarafından tanınan gerçeklik niteliğidir. Tanım, üç unsuru kapsamaktadır: 1) Maddî anlamda kesinlik, ancak yargısal kararlara (mahkeme kararlarına) tanınan bir niteliktir. 2) Bu nitelik kanun tarafından tanınmaktadır. 3) Bu nitelik yargısal kararın gerçek olarak kabul edilmesini zorunlu kılar. Buna göre, taraflar arasındaki davada verilen ve şeklen kesinleşen bir mahkeme kararı ne yönde ise, "gerçek" odur. Başka bir deyişle, kesinleşen mahkeme kararı yanlış dahi olsa, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde yapılan incelemede "doğru olan", mahkemenin vardığı sonuçtur. Örneğin, (A)'nın, (B)'ye karşı açtığı on bin liralık alacak davası, (A)'nın elinde kesin delil (senet, ikrar, yemin) bulunmadığından dolayı reddedilirse, (A), (B)'ye gerçekten, elden -senet almaksızın- on bin lira borç vermiş olsa dahi), mahkemenin kesin kararı sonucu, (A)'nın (B)'den alacaklı olmadığı hususu, (maddî anlamda kesin hükmün sonucu) "gerçek" olarak kabul edilecektir!

Yargısal kararlara tanınan bu yasal gerçeklik niteliğinden dolayı, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak, aynı dava konusu hakkında yeni bir dava açılamaz; açılırsa bu dava dinlenmez.

Maddî anlamda kesin hükmün amacı, taraflar arasındaki uyuşmazlığın bütün bir gelecek için son bulmasına hizmet etmek; çelişik kararların ortaya çıkmasını engellemek toplum hayatı için zorunlu olan hukukî istikrarı ve güveni sağlamaktır.

Şeklî anlamda kesinlik, bir davanın sona ermesini sağlar ve maddi anlamda kesinliğin de ön şartıdır.

B) MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN ŞARTLARI

Maddî anlamda kesin hükmün şartları, m. 303'de sayıldığı gibi üç tanedir. Buna göre, bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddî anlamda **kesin hüküm** oluşturabilmesi için: 1) Her iki davanın taraflarının, 2) Her iki davanın dava sebeplerinin ve 3) İlk davanın hüküm fıkrası (sonucu) ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir[1].

---

[1] Bu üç şartın derdestlik bakımından da geçerli olduğu yukarıda § (18, B, IV) incelenmiştir.

I – TARAFLARIN AYNI OLMASI

Kesin hükme bağlanmış bir (ilk) davadan sonra, aynı dava konusu hakkında ve aynı dava sebebine dayanarak açılan yeni (ikinci) davanın kesin hükümden dolayı reddedilebilmesi için, ilk (esas) dava ile yeni davanın taraflarının aynı olması gerekir (m. 303, 1). Bunun için, tarafların her iki davada da aynı sıfatla (davacı veya davalı sıfatıyla) hareket etmiş olmaları gerekmez. Birinci davada davalı olan taraf, ikinci davada davacı olarak hareket etse ve böylece birinci davada davacı olan taraf, ikinci davada davalı olarak gösterilse bile, ikinci davanın dava konusu ve dava sebebi aynı ise, birinci davada verilen karar, ikinci dava için kesin hüküm teşkil eder; yani ikinci dava kesin hükümden dolayı reddedilir.

Kesin hüküm, taraflardan başka tarafların **küllî halefleri**, örneğin tarafların mirasçıları hakkında da geçerlidir (m. 303, 3). Yalnız, bir tarafın hasım ile yaptığı hileli bir anlaşma sonucunda davasını kaybetmesi halinde, HMK m. 376 hükmü ile (HUMK m. 446), alacaklılar ve mirasçılara yargılamanın iadesi yoluna başvurma yetkisini tanımıştır.

Kesin hükmün **cüz'î haleflere etkisi**ne gelince: Daha sonra dava konusu edilen şey, dava açılmasından önce üçüncü kişiye devredilmişse, davanın devralan üçüncü kişiye karşı açılması gerekir. Devreden kişi, açılan davada davalı olarak gösterilemez; çünkü, artık davalı sıfatı yoktur. Dava buna rağmen, dava, devralan üçüncü kişiye değil de, devredene karşı açılırsa, o davada verilecek hüküm, (taraf olmadığı için) devralanın lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmaz. Dava konusu, davanın açılmasından sonra ve fakat kesin hükmün ortaya çıkmasından önce devredilirse, 125. madde hükmü, kesin hükmün devralanı etkilemesini kabul etmemektedir. Şeklî anlamda kesin hükmün ortaya çıkmasından sonra dava konusunun devri halinde, kesin hüküm halef tarafından ve halefe karşı da ileri sürülebilir (m. 303, 3).

Bir dava dolayısıyla ortaya çıkan kesin hüküm, o hükmün kesinleşmesinden sonra dava konusu şeyin mülkiyetini tarafların birisinden devralan yahut dava konusu şey üzerinde sınırlı bir aynî hak veya ferî zilyetlik kazanan kişiler hakkında da geçerlidir. Ancak TMK'nun 3. maddesinin iyiniyetle mal edinmeye ait hükümleri saklıdır (m. 303, 4).

Müteselsil borçlulardan biri veya birkaçı ile alacaklı arasında yahut müteselsil alacaklılardan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan kesin hüküm, diğerleri hakkında geçerli değildir (m. 303, 5).

Kesin hükmün ancak tarafları ve haleflerini etkilediğine ilişkin buraya kadarki açıklamalar, eda ve tespit davaları sonucunda verilen hükümlerle, yenilik doğurucu (inşaî) davaların reddine ilişkin hükümler içindir. Buna karşılık inşaî hükümler, yalnız taraflara değil üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder.

II – DAVA SEBEPLERİNİN AYNI OLMASI

Dava sebebinden kast edilenin, hukukî sebepler değil, davanın dayanağı olan **vakıalar** (olay ve olgular) olduğunu, dava dilekçesi (m. 119, 1/e) hakkındaki açıklamalar sırasında görmüştük[2].

Kesin hüküm bakımından da, dava sebebi (hukukî sebep olarak değil) vakıalardır. Çünkü, davacı mahkemeye hukukî sebep bildirmek zorunda olmayıp, sadece kendisini talep sonucunda haklı gösterdiğini tahmin ettiği vakıaları bildirmekle yetinebilir ve bununla yükümlüdür (m. 119, 1/e). Mahkeme, incelemesini davacının kendisine sunmuş olduğu bu vakıalar (olay ve olgular) üzerinde yapar; davacının bildirmediği vakıaları kendiliğinden gözetemez ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz (m. 25; 31). Buna karşılık, davacının bildirdiği bu vakıalara uygulanacak hukuk kuralını bulmak ve uygulamak, başka bir deyişle bu vakıaların hukukî niteliğini (yani, hukukî sebebini) belirlemek, Türk hukukunu kendiliğinden uygulamakla yükümlü olan (m. 33) hâkime düşen bir ödevdir. İşte bu nedenle, mahkeme (eğer bildirmişse) davacının kendisine bildirdiği hukukî sebeple bağlı olmayıp, dava dilekçesinde gösterilen vakıaların hukukî niteliğini (sebebini) kendisi doğru olarak belirler. Hal böyle olunca, davacının mahkemeye bildirdiği ve fakat mahkemenin bununla bağlı olmadığı hatta doğru olup olmadığını kendiliğinden araştırıp incelemekle yükümlü olduğu hukukî sebep, davanın sebebi olamaz.

Mahkeme, tarafların bildirdiği vakıalarla bağlı olduğu ve bunlar dışındaki vakıaları kendiliğinden göz önüne alamadığı için, birinci davada yalnız o vakıalar hakkında inceleme yapmış ve yalnız o vakıalara dayanarak kararını vermiştir. Şu halde, kesin hüküm de yalnız o vakıalar bakımından mevcuttur. Aynı vakıalara dayanarak (aynı taraflar arasında ve aynı konuda) bu defa ikinci (yeni) bir dava açılırsa, iki davanın dava sebebi aynı olacağından, diğer şartların da varlığı halinde, ikinci dava kesin hüküm nedeniyle reddedilir. Buna karşılık aynı taraflar arasında, aynı konuda açılan bu ikinci davanın dayandığı vakıalar, birinci davada ileri sürülen vakıalardan farklı ise, birinci dava sonucunda alınan hüküm, ikinci davada kesin hüküm teşkil etmez ve ikinci dava dinlenir; çünkü, iki dava arasında sebep birliği mevcut değildir.

Buna karşılık, mahkeme davacının bildirdiği hukukî sebeple bağlı olmadığından, birinci davada davacının bildirdiği vakıaların hukukî sebebini hâkim kendiliğinden araştırmış, bu hususta mümkün olan bütün ihtimalleri düşünmüş ve ondan sonra kararını vermiş olacağından, artık aynı vakıalara dayanarak, yeni bir hukukî sebep ileri sürmek suretiyle yeni bir dava açılamaz. Çünkü, bu yeni hukukî sebep doğru olsa idi, mahkeme, ilk dava sırasında onu tarafların bildirmemiş olmalarına rağmen kendiliğinden gözetirdi. Bu yeni ileri sürülen hukukî sebep doğru bulunmadığı için, ilk davada mahkeme tarafından gözetilmemiştir. Şu halde, bu yeni hukukî sebep de ilk dava sırasında incelenmiş ve reddedilmiş demektir; şimdi, aynı vakıalara dayanarak yeni bir dava sebebi yapılamaz. Açılan ikinci dava, kesin hüküm nedeniyle (dava

---

2 Bkz. yuk. § 17, B, I, 6.

şartı -m. 114, 1/i- eksikliğinden) esasa girmeden (usulden -mesmu olmadığından- dolayı) reddedilir.

Yargıtay da, kesin hükümdeki dava sebebini, "vakıalar" (olaylar, olgular) şeklinde anlamaktadır:

Örneğin, bir boşanma davası evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik) hukukî sebebine (TMK m. 166) dayanılarak açılmış, bu davada aile birliğinin sarsılmasını doğurduğu ileri sürülen vakıalar (davanın gerçek sebebi) doğru görülmediğinden, boşanma davası reddedilmiştir. Davacı, bundan sonra yeni bir boşanma davası daha açmış, bu davasını da evlilik birliğinin sarsılması hukukî sebebine dayandırmış ve evlilik birliğini sarsan vakıalar olarak gene aynı (birinci davada bildirdiği) vakıaları ileri sürmüştür. Yargıtay, haklı olarak yeni vakıalara dayanmayan ikinci boşanma davasının kesin hükümden dolayı reddine karar vermiştir. Eğer davacı, ikinci boşanma davasında evlilik birliğini sarsan yeni vakıalar ileri sürmüş olsa idi, ikinci boşanma davası dinlenecek; birinci dava sonucunda verilmiş olan kesin hüküm buna engel olamayacaktı. Oysa, bu ikinci boşanma davasında da hukukî sebep (TMK m. 166) aynı kalacak, değişen ise sadece vakıalar (davanın gerçek sebebi) olacaktı.

Nitekim başka bir olayda, ikinci boşanma davası, birinci davanın reddinden sonraki dönemde çıkan evlilik birliğini sarsan yeni vakıalara dayandırılmış ve Yargıtay aşağıdaki gerekçe ile ikinci boşanma davasının dinlenmesine karar vermiştir: "... yeni devrede çıkan olayların ve bunlarla ilgili delillerin araştırılması, taraflar arasında boşanmayı gerektirecek şekilde şiddetli geçimsizlik çıkıp çıkmadığının belirtilmesi gerekir. Kaldı ki, (ilk) boşanma davasının görüldüğü sırada meydana gelip, o davada gözönünde tutulmayan olaylar, ikinci defa açılan davada yeni olay olarak inceleme konusu yapılır... o halde, evvelki davadan sonra açılan bu davanın aynı olduğu kabul edilemeyeceğinden" ikinci davaya bakılması gerekir.

Buna göre, ikinci davanın dayandığı vakıalar (ilk davadan önce veya sonra doğmuş olsun), ilk davada incelenmemiş ise, iki davanın sebepleri farklıdır ve ikinci davada kesin hüküm itirazında bulunulamaz. Bu örneklerin de gösterdiği üzere, **dava sebebinden kasıt**, hukukî sebep değil, **vakıalardır**. Çünkü, bu son örnekte iki davanın hukukî sebebi aynı kaldığı halde (TMK m. 166), vakıalar değişiktir ve vakıaların değişik olması nedeniyle davaların aynı olmadığı kabul edilmiştir.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere Yargıtay çoğu kararında, dava sebebi yerine hukukî sebep deyimini kullanmaktan titizlikle sakınmakta ve sorunu, (açık veya üstü kapalı olarak münhasıran) "kesin hükümdeki dava sebebinden maksat vakıalardır" ölçütüne göre çözümlemektedir.

Buna karşılık Yargıtay bazı kararlarında, dava sebebi yerine bazen vakıalar ve hukukî sebep terimlerini birlikte kullanmakta, bazen de sadece hukukî sebep ölçütüne göre karar verdiği kanısını uyandırmaktadır. Fakat, bütün bu kararlarda Yargıtayın ön planda tuttuğu hususun, "vakıalar" ölçütü olduğu kanısındayız; bazı örnekler:

Bir olayda, davacı (kiralayan) oğlunun ihtiyacı için kiracıya karşı tahliye davası açmış, ihtiyaç sabit görülmediğinden davası reddedilmiştir. Davacı, üç sene sonra birinci dava sırasında ileri sürdüğü ve fakat mahkemece o zaman doğru görülmeyen vakıalara dayanarak, yine oğlunun ihtiyacından bahisle kiracısına karşı ikinci bir tahliye davası açmıştır. HGK, "Davacı şimdiki davasında yeni bir sebep ileri sürmüş değildir. Her iki davanın tarafları, olayları ve hukukî sebepleri aynıdır. Mahkemenin bu yönden kesin hükme dayanarak, davayı reddetmiş olması Usulün (HUMK'nun) 237. maddesi (şimdi: HMK m. 303) hükmüne uygundur" gerekçesiyle, olayda kesin hüküm bulunduğuna karar vermiştir. Karardaki, "olayların aynı olması" deyimi ile HGK, her iki davadaki dava sebeplerinin aynı olduğunu tespit etmiş, iki davanın hukukî sebeplerinin (TBK m. 350) aynı olmasını da ek bir gerekçe olarak kararara eklemiştir. Oysa kararda hukukî sebeplerin aynı olduğunun belirtilmesine gerek yoktu. Çünkü, ikinci davada dayanılan vakıalar başka olsa idi, hukukî sebebin aynı kalmasına rağmen, Yargıtayın olayda kesin hüküm bulunmadığına karar vereceği kuşkusuzdu.

Nitekim başka bir olayda, ilk önce ihtiyaç hukukî sebebine dayanılarak açılan ve reddedilen tahliye davasından sonra meydana gelen vakıalara dayanılarak, gene ihtiyaç (hukukî) sebebine müsteniden ikinci bir tahliye davası açılmış, bu davaya karşı yapılan kesin hüküm itirazı, ikinci bir tahliye davası sebebinin dayanağı olan vakıaların birinci davadan sonra doğduğu gerekçesiyle reddedilmiş ve davaya bakılmıştır. Bu karardan anlaşıldığına göre, iki davanın hukukî sebepleri (TBK m. 350) aynı kaldığı halde, dayanılan vakıalar değişik olduğundan ortada kesin hüküm yoktur. O halde kesin hükümde dava sebebinden maksat, hukukî sebep değil, vakıalardır.

Başka bir olayda davacı, önce TMK m. 724'e göre, temlik davası açmış; bu davası reddedilince, aynı davalıya karşı aynı taşınmaz için tenkis davası (TMK m. 565) açmış; Yargıtay, iki davanın hukukî sebepleri ayrı olduğundan, olayda kesin hükümden bahsedilemeyeceğine karar vermiştir. Bu karardaki hukukî sebep deyiminin, aynı zamanda vakıaları da kapsar şekilde kullanıldığına şüphe yoktur. Çünkü, olayda iki davanın hem hukukî sebepleri hem de vakıaları değişiktir.

Yukarıdaki örneklerin bazısında görüldüğü gibi, kesin hükümden (önceki hükmün verilmesinden) sonra ortaya çıkan vakıalara dayanarak yeni bir dava açılması halinde, iki davanın dava sebepleri aynı değildir (farklıdır). Çünkü kesin hüküm, ancak hüküm anındaki durumu tespit eder, hükümden sonraki döneme (geleceğe) etkili değildir. Bu nedenle, yeni vakıalara (olay ve olgulara) dayanarak açılan ikinci dava, birinci davadaki kesin hükme aykırı düşmez; davanın usulden dinlenmesi gerekir.

III – DAVA KONULARININ AYNI OLMASI

Dava konusu yapılmış olan hak, yani dava ile elde edilmek istenen talep sonucu (istem; netice-i talep) (m. 119, 1/ğ) aynı olmalıdır; örneğin, bir alacağın ödenmesi, taşınır veya taşınmaz bir malın teslimi gibi.

Eski (ilk) dava ile yeni (ikinci) davanın konularının aynı olup olmadığını anlamak için mahkemenin, eski (ilk) davada verilen kararın **hüküm sonucu** (fıkrası) (m. 297, 1/ç; 297, 2) **ile**, yeni açılan (ikinci) davanın **talep sonucunu karşılaştırması** gerekir. İkisi aynı ise, dava konularının aynı olduğu sonucuna varılır (m. 303, 1).

Örneğin, bir istihkak davası sonucunda verilen kararın hüküm sonucunda, bir taşınmazın mülkiyetinin (B)'ye değil, (A)'ya ait olduğuna karar verilmiş ve bu karar şeklî anlamda kesinleşmişse, (B)'nin aynı taşınmaz için açacağı istihkak (veya müdahalenin önlenmesi) davası kesin hüküm itirazı ile karşılaşır. Bir malın ilk davada aynen teslimi, ikinci davada ise bedelinin ödenmesi dava edilse, dava konuları gene aynı demektir.

Bir olayda davacı, ormandan kesmiş ve işlemiş olduğu ağaçlar üzerindeki mülkiyet hakkının tanınması ve davalı Orman İdaresinin ağaçlara müdahalesinin önlenmesini istemiş, mahkeme, davayı reddetmiş ve satılmış olan ağaçların satış bedeli olan beş bin liranın davalı Orman İdaresine verilmesine karar vermiş ve bu hüküm kesinleşmişti. Bundan sonra davacı, gene aynı Orman İdaresine karşı bir dava açıp, aynı ağaçların işlenmesi masrafı olarak dört bin liranın kendisine ödenmesini istemiştir. Bunun üzerine, Yargıtay haklı olarak şu kararı vermiştir: "Ağaçların işlenmesi masraflarını da içine alan ve dolayısiyle bu davanın müddeabihini de kapsayan bu beş bin liranın davalı idarenin olduğu hususundaki (ilk hükümle meydana gelen) bu muhkem kaziye (kesin hüküm) karşısında, aynı miktar paranın ağaçların işlenmesi masrafı olarak bu kere davacı lehine hüküm edilmesi hiçbir bakımdan kanuna uymaz".

Buna karşılık, aşağıdaki örneklerde, eski dava ile yeni davanın dava konuları aynı değildir:

"Davacı, ilk davada **manevî tazminat**; bu (ikinci) davada ise, **maddî tazminat** istemiştir. İlk dava ile bu davadaki tazminat isteği aynı olmadığı için olayda kesin hükümden söz edilemez".

"Davacı tarafından davalı aleyhine evvelce açılan dava sonunda taraflara ait taşınmaz malları ayıran ortak sınır tespit edilmiş ve bu hususta hüküm kesinleşmiştir. Davacı bu kez açtığı davada, davalının bu sınırı aşarak duvar yapmak suretiyle bahçesine müdahalede bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddiaya göre evvelki davadaki müddeabih (dava konusu) ile bu davadaki müddeabih aynı değildir".

Buraya kadarki açıklamalar, birinci davanın, davayı esastan çözen bir hükümle sonuçlanmış olması hali içindir. Birinci dava bir hükümle değil de, usule ilişkin bir nihaî kararla (örneğin görevsizlik kararı ile) sonuçlanmış ise, ikinci (örnekte görevli mahkemede açılan) dava ile birinci davanın dava konuları aynı olmakla beraber, birinci davada o dava konusunun esası hakkında karar verilmediği için birinci davada verilen karar, ikinci davada kesin hüküm teşkil etmez.

C) MADDÎ ANLAMDA KESİNLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI

Yukarıda şeklî anlamda kesin hükmün, maddî anlamda kesinliğin (ön) şartı olduğu belirtilmişti (m. 303, 1). Bir karar şeklî bakımdan kesinleşmeden, o kararın maddî anlamda kesin hüküm gücüne sahip olduğu iddia edilemeyeceği gibi, açılan yeni bir davada kesin hüküm itirazında da bulunulamaz. Bu halde ancak derdestlik itirazında bulunulabilir ki, derdestlik de hukukumuza göre bir dava şartıdır (m. 114, 1/ı).

Maddî anlamda kesinlik, şeklî anlamda kesinlikle birlikte başlamakla beraber, kural olarak hüküm ve sonuçlarını (etkisini) aynı zamanda doğurmaz. Burada hüküm çeşitlerine paralel olarak şöyle bir ayrımda bulunmak gerekir.

Eda ve tespit hükümlerinde kesin hüküm, **hale ve geçmişe etkilidir**. Kesin hüküm, hüküm tarihine kadar olan hukukî durumu kapsar; bu tarihten sonrası için etkisi yoktur. Şu halde burada, maddî anlamda kesin hüküm, geçmişe etkilidir.

Yenilik doğuran (inşaî) kararlar ise, kural olarak, **geleceğe yöneliktir**. Yenilik doğuran karar, kural olarak hükmün şeklî bakımdan kesinleşmesinden sonrası için etkisini göstermeye başlar. Yenilik doğuran kararın etkisinin kural olarak geleceğe yönelik olması ancak, birinci çeşit (yani, geleceğe etkili) yenilik doğuran davalar sonucunda verilen inşaî hükümler için söz konusudur. Buna karşılık, geçmişe etkili inşaî davalar sonucunda verilen hükümler, diğer davalarda olduğu gibi, geçmişe de etkilidir.

D) MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN UYGULAMA ALANI

Mahkemelerin bütün kararları maddî anlamda kesin hükme elverişli değildir. Bazı kararlar, maddî anlamda kesinleşmezler. Dolayısıyla, bu tür kararlarda, aynı konuda yeniden dava açılması (talepte bulunulabilmesi) mümkündür).

Ayrıca, maddî anlamda kesinliğe elverişli kararların da belli bölümleri kesinlik kapsamındadır.

I – KARARLARIN ÇEŞİDİ BAKIMINDAN

1) Maddî Anlamda Kesinliğe Elverişli Olmayan Kararlar

Çekişmesiz yargıda verilen kararlar, kural olarak şeklî bakımdan kesinleşmeye elverişli oldukları halde, bu kararlar maddî anlamda kesin hüküm gücüne sahip değildir (m. 388). Çünkü çekişmesiz yargı kararları, kararı veren mahkemece kararın sonradan haksız görülmesi veya kararın verilmesinden sonra meydana gelen değişiklikler nedeniyle her zaman değiştirilebilir; örneğin, mirasçılık belgelerinde olduğu gibi.

2) Maddî Anlamda Kesinliğe Elverişli Olan Kararlar

Aşağıdaki kararlar, maddî anlamda kesinliğe elverişlidir; yani maddî anlamda kesin hüküm teşkil eder:

Mahkemelerin **çekişmeli yargı**ya ilişkin bütün nihaî kararları. Nihaî kararlar da ikiye ayrılır:

Esasa ilişkin nihaî kararlar (davayı esasından halleden hükümler), maddî anlamda kesin hüküm teşkil eder. Esasen, buraya kadarki açıklamalar, daha çok hükümler içindir. Feragat, kabul ve sulh halinde verilen kararlar da maddî anlamda kesin hüküm oluşturur.

Usule ilişkin nihaî kararlar da, maddî anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bir nihaî karar (hüküm), davada veya karşı davada ileri sürülen taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm teşkil eder (m. 303, 2). Bu kural, usule ilişkin nihaî kararlar hakkında da geçerlidir. Yani bu kararlar, sadece ilişkin oldukları usulî sorun hakkında kesin hüküm teşkil eder; yoksa dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında kesin hüküm teşkil etmez.

Hakem kararları da (m. 436), maddî anlamda kesin hüküm gücüne sahiptir.

İcra mahkemesinin (İİK m. 4) takip (icra-iflâs) hukukuna ilişkin kararları, kural olarak, takip hukuku (ilâmsız icra) bakımından kesin hüküm teşkil eder. Yani bu kararlar, yalnız verilmiş oldukları icra takibinde veya daha sonra yapılacak yeni bir icra takibinde kesin hüküm teşkil eder. Buna karşılık, icra mahkemesinin takip hukukuna ilişkin kararları, mahkemelerde açılan davalarda, esas hak bakımından kural olarak maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmez.

II – KARARIN İÇERİĞİ BAKIMINDAN MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN UYGULAMA ALANI

1) Hüküm Sonucu

Maddî anlamda kesinlik, kararın yalnız hüküm sonucu (fıkrası) (m. 297, 1/ç) hakkında ortaya çıkar. Hüküm sonucu, davada (veya karşı davada) istenen hususlar (talep sonucu) hakkında mahkemece verilen kararı (hükmü) gösterir (m. 297, 2).

Maddî anlamda kesinlik, yalnız hüküm sonucuna ilişkin olduğundan, hükümde tarafların talep sonuçları (veya talep sonuçlarının bazı kalemleri) hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemişse, hakkında karar verilmemiş olan bu hususlar bakımından maddî anlamda kesin hüküm söz konusu olmaz. Örneğin, talep sonucundaki kalemlerden (taleplerden) biri hakkında karar verilmesi unutulmuş ve hüküm bu şekilde kesinleşmişse, unutulan bu kalem (talep) için sonradan açılan davada, birinci davada verilmiş olan hüküm, kesin hüküm teşkil etmez.

2) Gerekçe

Maddî anlamda kesinlik, yalnız hüküm sonucu için söz konusudur; hükmün gerekçesinin kesin hüküm gücü yoktur.

Bununla beraber gerekçe, maddî anlamda kesinlikten tamamen soyutlanmış da değildir. Özellikle aşağıdaki üç halde, gerekçe de, maddî anlamda kesinlikle ilgilidir:

a) **Hüküm sonucu açık değilse**, gerekçe hüküm fıkrasını açıklamaya ve kesin hükmün kapsamını belirlemeye yardım eder.

b) Bir davanın **usulden reddedilip edilmediğini** (dolayısıyla davanın esası hakkında kesin hüküm bulunup bulunmadığını) **anlamak için**, yine gerekçeye başvurmak zorunluluğu vardır.

Örneğin, vadesi gelmemiş bir alacak için açılan dava, vade gelmediğinden dolayı reddedilince, alacağın muaccel olmasından sonra tekrar açılabilir. Birinci kararın hüküm sonucunda, sadece "alacak davasının reddine" denilmişse davanın esastan değil; yalnız alacağın muaccel olmadığı nedeniyle reddedildiği kararın gerekçesinden anlaşılabilir.

c) **Hüküm sonucuna sıkı sıkıya bağlı olan gerekçe**, kesin hüküm teşkil eder. Hangi gerekçelerin hüküm sonucuna sıkı sıkıya bağlı bulunduğu, her olayın (davanın) özelliğine göre belirlenir; örnekler:

Bir kişi, kefil sıfatıyla bir borcu ödemeye mahkûm edildikten sonra, bu kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğundan bahisle, sebepsiz zenginleşmeye (TBK m. 77 vd.) dayanarak dava açamaz. Çünkü, kefalet sözleşmesinin geçerli bir sözleşme olduğu, birinci kararın hüküm sonucuna sıkı sıkıya bağlı bir gerekçedir.

Bir kişi tarafından açılan bir alacak davası, davalının karşı alacağına dayanarak takas def'inde bulunması üzerine reddedilirse, hüküm sonucunda, sadece alacaklının alacak davasının reddedildiği bildirilir. Karşılık alacağın sona erdiği ise, ancak hükmün gerekçesinden anlaşılabilir. Fakat takas zorunlu olarak, alacağı ve karşı alacağı sona erdirdiğinden, bu hükmün bağlayıcılığı, yalnız dava edilmiş olan alacağın sona ermesi ile sınırlı kalmayıp, takas edilen alacağın sona ermiş olduğunu da kapsar. Aksi halde, davalı takas etmiş olduğu (ve bu nedenle sona ermiş olan) karşı alacağı için yeni bir dava açabilirdi.

E) MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN ETKİLERİ

I – KESİN HÜKMÜN BAĞLAYICI OLMASI

Kesin hüküm, hükmü veren mahkeme de dahil bütün mahkemeleri bağlar. Yani mahkemeler, aynı konuda aynı dava sebebine dayanarak, aynı taraflar hakkında verilmiş olan bir kesin hüküm ile bağlıdır; aynı davayı bir daha (yeniden) inceleyemezler ve aynı konuya ilişkin yeni bir davada, önceki davada verilmiş olan kesin hüküm ile bağlıdırlar.

Yasama ve yürütme organları ile idare, kesin hükme uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını (kesin hükmü) hiçbir suretle değiştiremezler (Anayasa m. 138, IV)[3]. Buna göre kesin hüküm, sonradan çıkarılan bir kanunla da değiştirilemez, ortadan kaldırılamaz.

Yürütme organı, yani idare de, kesin hükme uymak zorunda olup, kesin hükme aykırı idarî işlem yapamaz veya idarî eylemde bulunamaz. Aynı nedenle, kesin hükme bağlanmış bir konunun, Danıştaydan görüş isteme yolu ile incelenmesi de istenemez.

---

[3] Mahkeme kararlarına uyulması kuralı ve mahkeme kararlarının bağlayıcılığı, hiç şüphesiz karar, kesin hüküm halini almadan önce de mevcuttur.

II – KESİN HÜKMÜN OLUMSUZ DAVA ŞARTI OLMASI

Bir dava karara bağlanıp verilen hüküm kesinleştikten (maddî anlamda kesin hüküm ortaya çıktıktan) sonra, aynı taraflar arasında, aynı konuda, aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir dava açılamaz (m. 303, 1); açılırsa, ikinci dava, kesin hüküm itirazı ile karşılaşır ve esasa girilmeden kesin hükümden dolayı reddedilir (m. 114, 1/i). Örnekler:

(A), (B)'ye karşı bir alacak davası açmış, dava reddedilmiş ve bu ret hükmü kesinleşmiştir. Bundan sonra, (A), aynı alacak davasını (B)'ye karşı tekrar açmışsa, mahkeme, tarafları, dava konusu ve dava sebebi (birinci davadakinin) aynı olan bu ikinci davayı kesin hükümden dolayı reddedecektir.

(A), (B)'ye karşı beş bin liralık bir alacak davası açmış, mahkeme (B)'yi [(A)'ya] beş bin lira ödemeye mahkûm etmiş ve bu hüküm kesinleşmiştir. Bundan sonra (B), (A)'ya karşı bir dava açarak, "(A)'ya borçlu olmadığı halde onun açtığı dava sonunda kendisinden beş bin lira alınmasına karar verildiği, oysa böyle bir borcu olmadığı için ödeme zorunluluğu bulunmadığı iddiasıyla bu yönün tespitini" istemişse (menfî tespit davası açmışsa), mahkeme, ikinci davayı kesin hükümden dolayı reddedecektir.

Buna göre, **kesin hüküm itirazını** şu şekilde tarif etmek mümkündür: Kesin hüküm itirazı, bir davanın konusunu oluşturan uyuşmazlığın, daha önce kesin bir hükümle çözümlenmiş olması nedeniyle, mahkemece yeniden inceleme konusu yapılamayacağına ilişkin usulî bir itirazdır.

Açılan bir dava hakkında kesin hüküm bulunmaması, dava şartlarındandır (m. 114, 1/i). Yani bir davanın usulden dinlenebilmesi (mesmu olabilmesi) için aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak verilmiş bir kesin hüküm bulunmamalıdır. Şu halde, davanın her aşamasında (ilk defa kanun yolu aşamasında veya hükmün bozulmasından sonra da) yapılabilen kesin hüküm itirazı ile, dava şartlarından birinin bulunmadığı ileri sürülür (m. 114, 1/i). Bu nedenle, dava konusu hakkında bir kesin hüküm bulunduğu (diğer dava şartlarında olduğu gibi) mahkemece, her zaman kendiliğinden gözetilir.

Kesin hüküm kamu düzenine ilişkin (dava şartı) olduğundan, taraflar kesin hüküm itirazını ileri sürmekten feragat etseler bile, mahkeme, kesin hükmü öğrenince davaya bakamaz ve davayı dinlenebilir olmadığından reddeder. Çünkü, uyuşmazlıkların bir sonu gelmelidir; bu, toplum düzeninin bir isteği ve kamu düzeninin bir gereğidir.

Mahkeme, kesin hüküm itirazını kabul ederse (veya kendiliğinden olayda kesin hüküm bulunduğu sonucuna varırsa), dava şartlarından biri eksik olduğundan, davayı dinlenebilir olmadığından dolayı usulden reddetmekle yükümlüdür. Mahkeme, kesin hüküm itirazını reddederse, davanın esasına girer ve davayı esastan hükme bağlar.

III – KESİN HÜKMÜN KESİN DELİL OLMASI

Kesin hüküm (mahkeme ilâmları), **kesin delil** teşkil eder (m. 204, 1). Şöyle ki:

Birinci davada verilmiş olan hüküm, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak, aynı konuya ilişkin olarak açılan ikinci bir davada, birinci davada kesin hükme bağlanmış olan husus (m. 303, 1-2) hakkında kesin delil teşkil eder; örnekler:

Bir kira bedelinin tespiti davası sonucunda verilmiş olan (kesin) hüküm, daha sonra kira alacağının ödenmesi için açılan eda davasında kesin delil teşkil eder. Yani davalı kiracı, kiranın birinci davada tespit edilenden daha az olduğunu iddia edemeyeceği gibi, davacı kiralayan da, (birinci davada) tespit edilenden daha yüksek bir kira isteyemez.

Taraflar arasındaki birinci davada, bir taşınmazın mülkiyetinin davacıya ait olduğuna karar verilmişse, bu davada verilen (kesin) hüküm, davacının aynı davalıya karşı açacağı müdahalenin men'i (el atmanın önlenmesi) davasında kesin delil teşkil eder.

Aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak ve aynı hukukî ilişki hakkında açılan ikinci davanın konusu, birinci davadakinden farklı olsa bile, iki davanın da temelini oluşturan aynı hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığı hakkında (birinci davada) verilmiş olan (kesin) hüküm, ikinci davada **kesin delil** teşkil eder; örnekler:

Bir satış sözleşmesi ile, satıcı alıcıya iki adet mal satmıştır. Alıcının bu mallardan birinin teslimi için satıcıya karşı açmış olduğu davada satıcı muvazaa iddiasında (TBK m. 19) bulunmuş; mahkeme muvazaa iddiasını doğru görmeyerek reddetmiş ve malın teslimine karar vermiş, hüküm kesinleşmiştir. Alıcının, ikinci malın teslimi için açtığı davada, davalı satıcı yeniden muvazaa iddiasında bulunursa, bu iddiasının aksine kesin delil vardır. Çünkü, birinci davada verilen (kesin) hüküm, satış sözleşmesinin muvazaalı olmadığı hakkında kesin delil teşkil eder. Bununla birlikte, haksız fiilden dolayı açılan bir kısmî tazminat davasında, davalının tazminat ödemesine ilişkin hüküm, önceki kısmî davada saklı tutulan alacak kesimi hakkında açılacak tazminat davası için kesin hüküm teşkil etmez. Ancak, birinci davada verilen hükmün, "davalının kusurlu olduğu ve bu nedenle davacıya tazminat ödemekle sorumlu bulunduğuna" ilişkin kısmı, ikinci davada kesin delil teşkil eder. Yani, davalı ikinci tazminat davasında, kusurlu olmadığını ve tazminat ödemekle sorumlu bulunmadığını ileri süremez ve mahkeme böyle bir iddiayı yeniden inceleme konusu yapamaz.

Bir davada verilen kesin hüküm, bu davanın taraflarından biri tarafından başka birine (üçüncü kişiye) karşı açılan (veya üçüncü kişi tarafından birinci davanın taraflarından birine karşı açılan) ve konusu ile dava sebebi (vakialar) aynı olan ikinci bir davada kesin delil teşkil etmez; çünkü **iki davanın tarafları farklıdır**. Fakat, birinci davada verilen kesin hüküm, ikinci davada güçlü bir **takdirî delil** oluşturur.

Bunun gibi, bir taşınmazın hissedarlarından (paydaşlardan) birinin taraf olduğu bir dava kesin hükme bağlandıktan sonra, diğer hissedarlar tarafından (veya diğer hissedarlara karşı) açılan ve konusu ile dava sebebi aynı olan ikinci davada, birinci hüküm kesin delil teşkil etmezse de, güçlü bir takdirî delil oluşturur.

F) MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ve YENİLİK DOĞURAN ETKİ

Yukarıda hukukumuzda alışılmış olan usule uygun olarak, yenilik doğurucu (inşaî) davaları olumlu biçimde sonuçlandıran yenilik doğurucu kararlar da maddî anlamda kesin hüküm kavramına dahil olarak incelendi. Oysa yenilik doğuran kararlar, maddî anlamda kesin hükümden dolayı değil, yenilik **doğuran etki**ye (inşaî tesir) sahip oldukları için değiştirilemez ve ilişkin oldukları işler hakkında yeniden dava açılamaz. Yenilik doğurucu etki, ise maddî anlamda kesin hükümden başkadır.

Hükümlerin yenilik doğuran etkiye sahip olmaları, maddî anlamda kesin hüküm ile birlikte incelenmekte olup, sadece kesin hükmün taraflara etkisi incelenirken, yenilik doğuran hükümlerin yalnız tarafları değil üçüncü kişileri de etkileyeceği belirtilmekle yetinilmektedir. Maddî anlamda kesin hüküm ile yenilik doğuran etki, hükmün konusunu teşkil eden şeyin kesin olarak karara bağlandığı, onun bundan sonra başka bir dava konusu yapılamayacağı ve bundan sonraki davalarda o hükme aykırı bir sonuca varılamayacağında birleşirlerse de, her iki müessese nitelik bakımından birbirinden farklıdır: Maddî anlamda kesin hüküm terimi, sadece eda ve tespit hükümleri içindir.

Maddî anlamda kesin hüküm ile yenilik doğuran etki arasındaki farklar şunlardır:

Kesin hüküm, beyan edici niteliktedir (mevcut bir hukukî durumun olumlu veya olumsuz biçimde tespitidir). Oysa yenilik doğuran etki, yapıcı (kurucu-yenilik doğurucu) niteliktedir ve yenilik doğuran hükümde yeni bir hukukî durum yaratılır. Örneğin, boşanma davası sonunda verilen hüküm, davacı ile davalı arasında o ana kadar var olan evlilik ilişkisini sona erdirir. Babalık davasının kabulü ile, çocuk ile baba arasında, soybağı (babalık) hukukî ilişkisi doğar.

Kesin hüküm, hale ve geçmişe etkilidir. Oysa yenilik doğuran etki, kural olarak, geleceğe etkilidir.

Kesin hüküm, sadece tarafları ve haleflerini etkiler. Oysa yenilik doğuran etki, herkese karşı ileri sürülebilir.

§ 64. HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI ile CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ[1]

A) GENEL OLARAK

Hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemeleri, birbirinden farklı nitelikte davaları (uyuşmazlıkları) görerek karara bağlarlar. Hukuk mahkemeleri, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkları; ceza mahkemeleri ise, ceza kanunlarının (hükümlerinin) ihlâli halinde Devletin cezalandırma yetkisinden ileri gelen uyuşmazlıkları çözmekle görevlidirler.

Hukuk ve ceza davalarının konularının değişikliği; bu davaların, tarafları, açılmaları ve mahkemelerin uyguladıkları yargılama usulleri açısından da farklılık göstermektedir. Bu bağlamda; örneğin, ceza davaları, Cumhuriyet savcısının düzenlediği bir iddianame (CMK m. 170) ile açılırken, özel hukuk davalarının davacısı, hukukî menfaati (yararı) olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Ceza davası açılması, Cumhuriyet savcısı için bir yükümlülük (görev) olmasına rağmen, hukuk davası açıp açmamak hakkı, ihlâl edilmiş (çiğnenmiş) olan sahibine tanınan bir olanaktan ibarettir. Bu kişi davayı açıp açmamakta veya açtıysa bundan feragat etmekte serbesttir.

Hukuk yargılamasında tasarruf ilkesi, taraflarca getirilme ilkesi ve taleple bağlılık ilkesi gibi kurallar (m. 24 vd.) geçerli iken, ceza yargılamasında kendiliğinden harekete geçme ve araştırma ilkesi, delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi gibi kurallar geçerlidir.

Bu sebeple, ceza mahkemesi kararı, hukuk mahkemesi kararını; hukuk mahkemesi kararı da ceza mahkemesi kararını, kural olarak etkilemez. Başka bir anlatımla, ceza mahkemesi kararı hukuk mahkemesi için, hukuk mahkemesi kararı da ceza mahkemesi için, kural olarak bağlayıcı değildir.

Bununla birlikte, **hukuk mahkemesi ve ceza mahkemesi kararlarının birbirini etkilediği** (bağladığı) **istisnaî durumlar da var**dır.

B) HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ

I – HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNDE KESİN HÜKÜM OLUŞTURMASI

Hukuk mahkemesi kararı, kural olarak, **ceza davası için kesin hüküm** (m. 303) **oluşturmaz.** Ancak, aslında medenî yargıya tâbi olan, fakat özel kanun hükümleri ile ceza mahkemelerinde de görüleceği (veya görülebilece-

---

[1] Bkz. Bahattin Aras, Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Ankara 2014; Derya Belgin Güneş, Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Bakımından Etkileri, İstanbul 2019.

ği) kabul edilmiş olan davalarda, hukuk mahkemesi kararı, ceza mahkemesinde de kesin hüküm oluşturur. Örnekler:

Hukuk mahkemesinde açılan, bir senet hakkındaki **sahtelik davası** (veya sahtelik iddiası, m. 214) üzerine hukuk mahkemesi, **senedin sahte olmadığına** (sahtelik iddiasının veya davasının reddine) karar verir ve bu karar kesinleşirse, bu karar ceza mahkemesi için **kesin hüküm** teşkil eder (m. 214, 1). Yani, hukuk mahkemesinin bu kararı, ceza mahkemesini de bağlar. Ceza mahkemesi tarafından, belgeyi düzenleyen kişi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı ya da beraat kararı (CMK m. 223) verilmiş olması, hukuk mahkemesinin belgenin sahteliğini incelemesini ve senedin sahte olduğu yönünde karar vermesini engellemez (m. 214, 2).

Ceza davası açılmadan önce hukuk mahkemesince verilmiş ve kesinleşmiş olan **yaş düzeltme kararı**, ceza mahkemesi için **kesin hüküm** oluşturur. Bu sebeple, ceza mahkemesi aynı kişinin yaşının düzeltilmesi isteğini yeniden inceleyip karara bağlayamaz. Hukuk mahkemesi yaş düzeltme talebinin (davasının) reddine karar vermiş olsa bile, bu ret kararı da ceza mahkemesinde **kesin hüküm** teşkil eder.

II – HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNDE KESİN DELİL OLUŞTURMASI

Hukuk davasında verilmiş olan kesin hüküm, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak ve aynı konuya ilişkin olarak açılan ikinci hukuk davasında kesin delil teşkil eder. Buna karşın hukuk ve ceza davalarının konuları ve tarafları farklı olduğundan, hukuk mahkemesi kararı, kural olarak ceza mahkemesinde kesin delil oluşturmaz. Ancak, istisnaî bazı durumlarda o hukuk mahkemesi kararı ceza mahkemesinde **kesin delil** oluşturur. Örnekler:

Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin hüküm oluşturduğu ve bağladığı (yukarıda I'de açıklanan) durumlarda, hukuk mahkemesi kararı, ceza mahkemesinde **kesin delil** de oluşturur. Çünkü, bu iki halde, hukuk mahkemesinden verilmiş olan kesin hüküm ile, ceza davasının tarafları, dava sebebi ve konusu aynıdır (veya özel bir kanun hükmü ile aynı sayılmıştır). Bunun sonucunda;

Hukuk mahkemesi bir **senedin sahte olmadığına** karar vermişse aynı senet hakkındaki sahtecilik davasına bakmakta olan ceza mahkemesinde, hukuk mahkemesi kararı kesin delil oluşturur ve ceza mahkemesi, buna dayanarak sanığın beraatine karar vermek zorundadır. Hukuk mahkemesinin bir kişinin **yaşının düzeltilmesi** davası hakkında vermiş olduğu karar da, ceza mahkemesinde kesin delil oluşturur.

Ceza mahkemesi, bir hukuk davasının sonuçlanmasını (ceza davası için) **bekletici sorun** yapmış ise (CMK m. 218), bununla, hukuk mahkemesinin vereceği kararı dikkate alacağını kabul etmiş demektir. Bu nedenle, bekletici sorun yapılan (sonucu beklenilen) hukuk davası hakkında verilen karar, (bekletilen) ceza davasında **delil** olarak değerlendirilmelidir.

Hukuk mahkemesi kararının, ceza mahkemesinde kesin delil oluşturmadığı (başka bir ifadeyle, bağlayıcılığı bulunmayan) durumlarda, hukuk mahkemesinin kararı, ceza davasında takdirî delil olarak değerlendirilebilir.

C) CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ

Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine (davasına) etkisi, hukukumuzda TBK m. 74'te düzenlenmiştir. Ancak bu hüküm, konuyu tümü ile düzenlemiş olmadığı gibi, yalnız haksız fiilden doğan tazminat davalarına ilişkindir. Bu nedenle, genel olarak konuyu, kesin hüküm ve kesin delil müesseselerine göre ele alıp incelemek gerekir:

I – CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDE KESİN HÜKÜM OLUŞTURMASI

Hukuk ve ceza davalarının konuları, tarafları, uygulanan yargılama usulü ve amaçları farklı olduğundan, ceza mahkemesi kararı da, hukuk mahkemesi (davası) için kural olarak kesin hüküm oluşturmaz. Ancak, aslında medenî yargıya tâbi olan ve fakat özel kanun hükümleri ile ceza yargısında (mahkemelerinde) görülebileceği kabul edilmiş olan davalarda ceza mahkemesi kararı, hukuk mahkemesinde istisnaî olarak **kesin hüküm** oluşturur. Örnekler:

Ceza mahkemesi, sahtecilik suçu (TCK m. 199 vd.) nedeniyle önüne gelen davada, bir senedin sahte olduğunu tespit ederek sahtecilik suçunu işleyenleri cezaya mahkûm ederse, senedin sahte olduğuna ilişkin olan bu karar, hukuk mahkemesinde görülen davada kesin hüküm oluşturur; hukuk mahkemesini bağlar. Buna karşılık, ceza mahkemesince belgeyi düzenleyen hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ya da beraatine kararı verilmiş olması hukuk mahkemesinin belgenin sahteliğini incelemesini engellemez (m. 214, 2).

II – CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDE KESİN DELİL OLUŞTURMASI

Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturması, yalnız kesin hüküm (m. 303; 204) nedeniyle değil, aynı zamanda TBK m. 74 hükmü nedeniyle de mümkündür.

1) Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm Oluşturduğu Hallerde Kesin Delil Oluşturması

Ceza mahkemesi kararının, hukuk mahkemesini bağladığı ve kesin hüküm oluşturduğu durumlarda, ceza mahkemesi kararı, hukuk mahkemesinde **kesin delil** de oluşturur. Çünkü yukarıda örnek verilen halde, ceza mahkemesinden verilmiş olan kesin hüküm ile hukuk davasının tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynıdır (veya özel bir kanun hükmü ile aynı sayılmıştır).

Buna göre: Ceza mahkemesinin bir senedin sahte olduğuna ilişkin kararı, hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturur.

2) Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil Oluşturması

Aynı zamanda suç olarak düzenlenmiş bir haksız fiil hakkında verilmiş ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde açılan haksız fiilden doğan tazminat davasında kesin delil oluşturup oluşturmayacağına gelince:

Ceza mahkemesince cezaya mahkûm edilmiş olan sanığa karşı, hukuk mahkemesinde açılan haksız fiile dayalı tazminat davasında, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararının kesin delil oluşturup oluşturmadığı, TBK m. 74'de düzenlenmiştir. Bu hükümde, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararının, haksız fiil sorumluluğunun diğer iki şartı olan haksız fiil ve uygun nedensellik (illiyet) bağı bakımından hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturup oluşturmadığı (hukuk mahkemesini bağlayıp bağlamayacağı) açıkça belirtilmiş değildir. Bu sebeple, değişik halleri gözönüne alarak bir sonuca varılması gerekmektedir.

Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararının, **haksız fiilin** (yani haksız fiilin varlığı ve o kişi tarafından işlendiği vakıasının) **tespiti**ne ilişkin bölümünün, hukuk mahkemesinde (tazminat davasında) da kesin delil olarak değerlendirilmesi gerekir. TBK'nun az önce anılan 74. maddesinin son cümlesinden, aksi ile kanıt yolu ile bu sonuca varılabileceği gibi, kesin hükmün (m. 303) kesin delil oluşturması (m. 204) ilkesi de bu görüşü haklı kılar. Bu yüzden **hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararının aksine, haksız fiilin olmadığı veya olsa bile mahkûm olan kişi tarafından işlenmediği sonucuna varamaz.**

Buna karşılık, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararı, hukuk mahkemesinde (tazminat davasında) **kusurun takdiri** bakımından kesin delil oluşturmaz. Yani ceza mahkemesinin kararı, kusurun takdiri hususunda hukuk mahkemesini bağlamaz (TBK m. 74, 2).

Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararı, hukuk mahkemesinde (tazminat davasında) **zararın miktarının tayini** hususunda da kesin delil oluşturmaz ve hukuk mahkemesini bağlamaz (TBK m. 74, 2).

Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararı, hukuk mahkemesinde (tazminat davasında) kusur ile zarar arasında uygun **nedensellik** (illiyet) **bağı**nın mevcut olup olmadığı hususunda da kesin delil oluşturmaz. Çünkü, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararında kusur ve zarar unsuru kesin biçimde tespit edilmiş değildir.

TBK'nun 74. maddesinin 1. fıkrasına göre hukuk mahkemesi, "ceza mahkemesinden verilen beraat kararıyla bağlı değildir". Bu hükmün mutlak gözükmesine rağmen, beraat kararının hukuk mahkemesini bağladığı haller de vardır. Bu nedenle, bu hükümlerden yararlanılarak, konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir:

Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararında olduğu gibi, beraat kararı da, kusurun takdiri bakımından hukuk mahkemesini bağlamaz; yani hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturmaz. Çünkü, ceza davasındaki ve hukuk davasındaki kusur kavramlarının anlamı değişiktir.

Beraat kararının haksız fiil vakıasına ilişkin tespit bölümü, hukuk mahkemesinde (tazminat davasında) kesin delil oluşturur. Çünkü, ceza mahkemesi bu tespiti (hukuk mahkemesine oranla) daha geniş bir soruşturma ve inceleme yetkisine sahip olarak yapmış durumdadır. Buna göre:

Haksız fiilin işlenmediğini veya sanık tarafından işlenmediğini tespit eden beraat kararı, hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturur. Bunun gibi, bir vakıayı tespit eden beraat kararı da hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturur. Bir fiilin hukuka aykırı bulunmadığını tespit eden beraat kararı, hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturur.

Yukarıda görüldüğü gibi beraat kararının, tespit ettiği vakıa bakımından kesin delil oluşturabilmesi için, beraat kararında o vakıanın mevcut olup olmadığının delillerle kesin biçimde tespit edilmiş olması gerekir. Buna karşılık, delil yetersizliğinden dolayı verilmiş olan beraat kararı, konusu olan vakıanın mevcut olup olmadığını delillerle kesin biçimde tespit etmediği için, hukuk mahkemesinde (tazminat davasında) kesin delil oluşturmaz. Ceza mahkemesinin mahkûmiyet için yeterli görmediği delilleri, hukuk mahkemesi tazminat için yeterli görebilir.

3) Boşanma Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının Kesin Delil Oluşturması

Ceza mahkemesinin aynı zamanda boşanma sebebi olan bir suçtan dolayı (örneğin, cana kast gibi; TMK m. 161-163) verdiği **mahkûmiyet kararı**, bu mahkûmiyet kararında tespit edilmiş olan vakıa (olay) bakımından boşanma davasında **kesin delil** oluşturur.

Buna karşılık ceza mahkemesinin **beraat kararı**, boşanma davasında (kural olarak) kesin delil teşkil etmez. Ancak, ceza mahkemesinin beraat kararında fiilin işlenmediği (veya sanık eş tarafından işlenmediği) kesin biçimde tespit edilmişse, beraat kararı, boşanma davasında **kesin delil** teşkil eder.

4) Yargılamanın İadesinde Ceza Mahkemesi Kararının Kesin Delil Oluşturması

Yalan tanıklık, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık ile yalan yere yeminden dolayı yargılamanın iadesinin istenebilmesi için, bu sebeplerin kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması gerekir (m. 375, 1/d, e, f, g; 377, 1/ç; HUMK m. 445, I/4-6). İşte bu hallerde, ceza mahkemesinin yalan tanıklık, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlığa veya yalan yere yeminden dolayı mahkûmiyet kararı, yargılamanın iadesi davasında ilişkin olduğu yargılamanın iadesi sebebinin ispatı bakımından **kesin delil** oluşturur.

5) Bekletici Sorun Yapılan Hallerde Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil Oluşturması

Hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ceza davasının sonuçlanmasını (hukuk davası için) bekletici sorun yapabilir (m. 165). Bu halde hukuk mahkemesi, ceza mahkemesi kararını (hukuk davası için), yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde, bekletici sorun yapmakla, ceza mahkemesinin bu konuda vereceği kararı kabul etmiş sayılmalıdır. Bu nedenle, bekletici sorun yapılan ceza davası hakkında verilen karar, yukarıda belirtilen ve hukuk mahkemesini bağlayan durumlardan birisine ilişkinse (bekletilen) hukuk davasında **kesin delil** oluşturur.

III – HUKUK MAHKEMESİNDE KESİN DELİL OLUŞTURAN CEZA MAHKEMESİ KARARININ AKSİNİN İSPATI

Yukarıda incelenmiş olan ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturduğu hallerde, ceza mahkemesi kararı (kesin delil) aleyhine olan taraf, hukuk mahkemesinde **ceza mahkemesi kararının** (yani kesin delilin) **aksini**, ceza mahkemesi kararından sonra oluşan **bir kesin delil** (senet, ikrar veya yemin) **ile ispat** edebilir.

§ 65. MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN SONA ERMESİ

Yukarıda görüldüğü üzere, bir kesin hükmün varlığına rağmen, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak aynı dava konusu hakkında açılacak yeni bir dava, kesin hüküm itirazı (m. 303) ile karşılaşır ve redde uğrar. Çünkü, **kesin hükmün bulunmaması dava şartlarından biri**dir (m. 114, 1/i); mahkeme, önüne gelen davada, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın (yargılamanın) her aşamasında kendiliğinden araştırır ve taraflar da, dava şartı eksikliğini her zaman ileri sürebilirler (m. 115).

Maddî anlamda kesin hüküm, kural olarak, sona ermez. Ancak, aşağıdaki istisnaî hallerde, kesin hükme bağlanmış olan **davaya tekrar bakılması** mümkündür:

A) YARGILAMANIN İADESİ

Yukarıda yargılamanın iadesi (yenilenmesi) başlığı altında HMK m. 374-381 ve HUMK m. 445-454 hükümlerini inceledik. Bu hükümlere göre yargılamada ağır hataların veya önemli eksiklerin olması, bir adlî hata (yargısal yanılgı) ortaya çıkarabilir. Ortaya çıkan adlî hatanın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırabilmesi amacıyla Kanun, sınırlı olarak saydığı bazı ağır yargılama yanlışlıklarından dolayı, kesin hükmün tekrar gözden geçirilmesine ve aynı dava hakkında yeni bir hüküm verilmesine istisnaî olarak olanak tanımaktadır.

B) DEĞİŞİKLİK DAVASI[1]

Bazı hallerde, hükmün verilip (şeklen) kesinleşmesinden sonra, hükmün verildiği sırada ona temel (esas) olan şartlar değişebilir. Bu değişiklik, önceki şartlara göre verilmiş olan hükmün de değişmesini zorunlu kılabilir. İşte bu gibi hallerde, maddî anlamda kesin hüküm gücünü kazanmış olan bir hüküm, tekrar gözden geçirilebilmesi ve hükmün yeni şartlara göre değiştirilmesi mümkündür. Buna, **değişiklik davası** denir.

Değişiklik davası, ancak kanunun açıkça öngördüğü hallerde açılabilir. Yoksa, genel olarak şartların değişmiş olduğundan bahisle, her hükmün değiştirilmesi için dava açılamaz.

Değişiklik davası ile ilgili örnekler:

Nafaka verilmesi hakkındaki kararlar, tarafların malî durumlarındaki değişikliğe uygun olarak değiştirilebilir. Örneğin, mahkeme babayı iki yaşındaki çocuğuna aylık iki yüz lira nafaka ödemeye mahkûm etmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Aradan geçen zaman içerisinde, çocuk büyümüş ve okula başlamıştır ve aylık iki yüz lira nafaka onun masraflarını karşılamaya yet-

---

[1] Bkz. S. Serhat Kırtıloğlu, Medenî Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası, Ankara 2014.

memektedir. Bunun üzerine, çocuk adına annesi babaya karşı dava açarak, nafakanın aylık beş yüz liraya çıkartılmasını isteyebilir (TMK m. 176, IV). Kanunda açıklık bulunmamakla beraber, TMK m. 364, 365'e göre üstsoy, altsoy ve kardeşler lehine verilen nafaka kararları da, şartların önemli bir şekilde değişmesi halinde, değiştirilebilmeli veya tamamen kaldırılabilmelidir.

Boşanma halinde mahkeme, maddî tazminat ve yoksulluk nafakasını (toptan ödeme şeklinde değil de) irat (gelir) şeklinde karara bağlamışsa; mahkeme, daha sonra alacaklı tarafın fiilen evli gibi yaşaması, haysiyetsiz hayat sürmesi veya yoksulluğunun ortadan kalkması hallerinde, irat şeklindeki nafakayı kaldırabilir (TMK m. 176, III). Taraflarının malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde, mahkeme daha önce karar verdiği irat şeklindeki nafakanın arttırılması veya azaltılması şeklinde değiştirebilir (TMK m. 176, IV).

Haksız fiilden dolayı tazminat davalarında zararın sonuçlarını **tayin** etmek mümkün değilse, hâkim davayı yeniden inceleme ve tazminat hükmünü değiştirme yetkisini (kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde) saklı tutabilir (TBK m. 75).

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 22 ve m. 25 hükümlerine göre, iş göremezliğin veya malûliyetin artması gibi hallerde değişiklik davası açılabilir.

Çekişmesiz yargı kararları, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmadığı için (m. 388), değişiklik davası açılmasına gerek yoktur. Bu sebeple, çekişmesiz yargı kararının verilmesinden sonra ortaya çıkan değişiklikler veya kararın sonradan haksız görülmesi nedeniyle karar her zaman değiştirilebilir.

Şeklî anlamda kesinliğin sona ermesi halinde, maddî anlamda kesinlikten de söz edilemez.

§ 66. HÜKMÜN TASHİHİ ve HÜKMÜN TAVZİHİ

Mahkeme, yargılama sonunda verdiği hükümde, her iki tarafın hak ve yükümlülükleri ile vardığı sonucun ne olduğunu açıkça gösterir. Hüküm, özellikle icrasında herhangi bir tereddüde yol açmayacak şekilde açık bir biçimde yazılır. Ancak, hükümde bazı yazı ve hesap hataları yapılmış olabileceği gibi, hüküm yeterince açık olmayabilir veya birbiri ile çelişik fıkralar içerebilir. Bu durum, genellikle hükmün (ilâmın) icrası aşamasında (İİK m. 24 vd) anlaşılır.

Her ne kadar mahkeme, hükmünü vermekle, dosyadan elini çektiği için mahkemenin dosya hakkında herhangi bir işlem yapamaması ve hükmü değiştirmemesi esas ise de, Kanunun gösterdiği "hükmün tashihi" ve "hükmün tavzihi" hallerinde mahkeme, gösterilen sınırlar içerisinde, hükümdeki açık yazı ve hesap hatalarını düzeltebilir (tashih edebilir) ve hükmü açıklayabilir (tavzih edebilir).

A) HÜKMÜN TASHİHİ

Hükmün tashihinden kasıt, hükümdeki **maddî hataların düzeltilmesi**dir. Hükümde, yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri hatalar, mahkemece kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi halinde düzeltilebilir (tashih edilebilir) (m. 304).

Örneğin, tamamen yazma (yazım) hatası sonucunda; davacı yerine davalı denilmişse veya davacının talebi "on bin" lira olmasına ve dava aynen kabul edilmesine rağmen, bu rakam hüküm sonucunda (m. 297, 1/ç) "bin lira" olarak yazılmışsa, ortada açık bir yazı hatası bulunduğu kabul edilir. Bunun gibi, haksız fiilden kaynaklanan ve davacının yüz bin lira tazminat talep ettiği bir davada, bilirkişinin davacının yüzde otuz kusurlu olduğunu belirtmesi üzerine, mahkemenin yüz bin liranın yüzde otuzu üzerinden yaptığı hesaplamada, altmış bin lira sonucuna varması açık bir hesap hatasıdır. Bu iki örnekte de mahkemenin hükümdeki maddî hatayı, tarafların talebi üzerine veya talebe gerek kalmaksızın kendiliğinden düzeltebilmesi mümkündür.

Eğer hüküm tebliğ edilmişse, bu hataların düzeltilmesi için **tarafların dinlenmesi** gerekir. Bunun için mahkeme taraflara davetiye çıkartır ve davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilebilir (m. 304, 1/ c. 2-3).

Tashih kararı verilirse, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar (m. 301, 1) ile verilmiş suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir (m. 304, 2).

Kanunun izin verdiği hükmü **tashih** etme olanağı, **hükümdeki yazı ve hesap hatası gibi açık maddî hatalarla sınırlıdır**. Mahkeme, maddî hataların düzeltilmesi gerekçesi ile hükmünü değiştiremez. Bu sebeple mahkeme,

örneğin, hükmünde tamamen reddettiği talep hakkında yeni bir hüküm veremez veya eksik bıraktığı iddia hakkında ek bir karar tesis edemez.

Burada (m. 304'de) söz konusu olan düzeltme (tashih), hüküm verildikten sonraki dönemde, hükümdeki maddî hataların düzeltilmesidir. Hükümden önceki dönemde mahkemenin dava dosyasında yapmış olduğu açık yazı ve hesap hatalarının (maddî hataların), karar (hüküm) verilinceye kadar düzeltilmesi ise m. 183'de düzenlenmiştir.

B) HÜKMÜN TAVZİHİ

Hükmün tavzihinden kasıt, hükümdeki **belirsizliğin** (tereddüdün) **giderilmesi** (açıklığa kavuşturulması) veya hükmün içerdiği **çelişik sonuçların** (çelişkilerin) **ortadan kaldırılması**dır.

I – TAVZİHİ GEREKTİREN HALLER

Hangi hallerde bir hükmün tavzihinin istenebileceği Kanunun 305. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, **yeterince açık olmayan** veya **icrasının nasıl olacağı** (yapılacağı) konusunda **tereddüt edilen** yahut fıkraları birbirine aykırı (**çelişkili**) olan hükümlerin tavzihi (açıklanması) istenebilir (m. 305, 1); örnekler:

"Olayda davacıya verilen 17 dönümlük kısma ilişkin hüküm kesinleşmiş ise de, bu kısım ile miktar fazlası olarak Hazineye ayrılıp verilmesi gereken kısım arasındaki sınırın nereden geçeceği belirsiz ve açık değildir. Bu itibarla hükmün tavzihi suretiyle vuzuha kavuşturulmasına kanunî bir engel yoktur".

"Davacının iştirak nafakasının artırılmasına ait karar dava gününden itibaren lüzum ifade eder. Esasen mahkeme kararlarının infazda da güçlük doğurmayacak şekilde olması, tarafların hak ve borçlarının sınırını açıkça belirtmesi lâzımdır. Nafakanın artırılması ile ilgili hükmün hangi tarihten itibaren geçerli olacağının kararda yazılmamış bulunması bir noksanlıktır. Bunun giderilmesi, Usulün 455. (şimdi: HMK'nun 305) maddesine uygun düşer. Bu kanunî durumun izahından ibaret bulunan mahkeme kararı hükmü değiştiren yeni bir karar niteliğinde değildir".

"Taraflar davada sulh olmuşlar ve bir sulhname düzenlemişlerdir. Bunun üzerine mahkeme, 'sulhname gereğince karar verilmesine' şeklinde bir hüküm tesis etmiş, fakat sulhname içeriği karar yerine yazılmamıştır. Bu hali ile verilen hüküm açık değildir. Tavzih yolu ile, sulhname içeriğinin karar yerine açık bir şekilde yazılması gerekir".

Tavzih, kural olarak, yalnız **hüküm sonucu** (fıkrası; m. 297, 1/ç) hakkında olur; ancak, hüküm sonucunda taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar tavzih yolu ile sınırlandırılamayacağı gibi değiştirilemez ve genişletilemez (m. 305, 2). Hükmün gerekçesinin açıklanması için, tavzih yoluna başvurulamaz. Ancak, **hüküm sonucu ile gerekçe** (m. 297, 1/c) **arasında bir çelişki** varsa, bu çelişkinin giderilmesi için tavzih yoluna başvurulabilir. Örneğin:

"Tavzihi istenen paydaşlığın giderilmesine şüyuun izalesine (paydaşlığın giderilmesine) ilişkin ilâmın gerekçe kısmında, Asliye Hukuk Mahkemesinin

... günlü tapu iptali ve tescil davasına ait ilâmının esas alındığı yazılmış, bu ilâmın özeti doğru olarak belirtilmiş ve netice kısmında da bu ilâma atıf yapılarak satış parasının hissedarlar E, Z ve N'ye hisseleri nispetinde tevzii suretiyle şüyuun giderilmesine karar verilmiş ve hisseleri iptal edilen hissedarların paylaştırılmadan hariç tutulduğu kabul edilmiş iken, şüyuun izalesine dair hüküm fıkrası, Asliye Hukuk Mahkemesi ilâmına uygun olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tapu iptali ve tescil ilâmı esas alınacak olursa hüküm fıkrası ihmal olunacaktır. Hüküm fıkrası esas alınacak olursa, tapu iptali ve tescil ilâmı uygulanmamış olacaktır. Şu halde son ilâmda giderilmesi gereken tenakuz ve mübayenet vardır. Olayda Usulün 455 (şimdi: HMK'nun 305) inci maddesinde söz konusu edilen mütenakız fıkraları ihtiva etmek hali mevcuttur. Tavzih talebinin kabulü ile tenakuzun izalesi (çelişkinin ortadan kaldırılması) cihetine gidilmesi lâzımdır".

Hükmün gerekçesinde, yargılama masraflarına davacının katlanması gerektiği açıkça belirtildiği halde, hüküm sonucunda yargılama giderlerinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmiştir. Bu halde, yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceğini anlamak zordur. Bu çelişkinin, tavzih yolu ile giderilmesi gerekir.

Yalnız ilk derece (hüküm) mahkemesi kararları için değil, **üst dereceli mahkeme kararları** hakkında da tavzih yoluna başvurulabilir[1].

Tavzih yoluna başvurabilmek için **hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur**; kesinleşmemiş olan kararlar hakkında da tavzih istenebilir. Ancak, tavzih talebinde bulunmakla kanun yolu süresinin işlemesi durmaz. Bu nedenle, bir taraf yalnız tavzih talebinde bulunur, kanun yolu süresini kaçırırsa, hüküm kesinleşmiş sayılır.

II – TAVZİH USULÜ

Hükmün tavzihini istemek bir süreye tâbi değildir. Hükmün, **icrası tamamlanıncaya kadar** tavzihi istenebilir (m. 305, 1). İlâmın icraya konulmasından (İİK m. 24 vd.) sonra da (ilâm tamamen icra edilinceye kadar) hükmün tavzihi istenebilir. Esasen, hükmün tavzihine, genellikle, hüküm icra edilirken ihtiyaç duyulur; örnek:

"Bir taşınmazın teslimi hakkındaki bir ilâmın icrası sırasında (İİK m. 26-29) hükümde taşınmazın sınırı olarak gösterilen (cebel -dağ- ve tepe) gibi sınırlara göre taşınmazın yüzölçümü 76 dönüm olarak bulunur, oysa ilâmda yazılı yüzölçümü 44 dönüm ise, taşınmazın tesliminde yazılı sınırların mı, yoksa yüzölçümünün mü geçerli tutulacağının açıklanması için tavzih yoluna başvurulur".

Bu halde, icra müdürünün veya icra hâkiminin hükmü yorumlamak (tavzih etmek) yetkisi yoktur. Hüküm, ancak onu vermiş olan **mahkeme tarafından tavzih** edilir.

---

[1] Bkz. 07.06.1944 gün ve 40/22 sayılı İBK (RG 23.11.1944, sa. 5864). Bir İBK'nın başka bir İBK ile tavzih edilmesine bir örnek için bkz. 21.03.1960 gün ve 19/06 sayılı İBK (RG 30.05.1960, sa. 10515).

Hüküm tamamen icra edildikten sonra, artık hükmün tavzihi istenemez. Bu nedenle, bir ilâm icraya konulduktan sonra hükmün tavzihi istenirse, mahkemenin, hükmün tamamen icra edilip edilmediğini icra dairesinden sorması gerekir.

Tavzih talebi, hükmü vermiş olan mahkemeye yapılır ve bu mahkeme tarafından incelenir (m. 306). Bu madde hükmü çok yerindedir. Çünkü, bir hükmün tavzihi (açıklanması), ancak (ve en iyi bir şekilde) onu vermiş olan mahkeme tarafından yapılabilir. Bu nedenle, bazı yabancı usul kanunları, tavzihin ancak hükmü vermiş olan hâkimlerce, bu hâkimler mahkemeden ayrılmışlarsa onların davet edilmesi suretiyle yapılacağını hükme bağlamaktadır.

Tavzih, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle istenebilir. Dilekçenin bir örneği (mahkemenin belirleyeceği uygun bir cevap süresi ile birlikte) karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf, cevap süresi içinde, tarafların sayısı kadar örnek dilekçe ile tavzih talebine cevap verebilir. Bu cevabın bir örneği tavzih talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur (m. 306, 1).

Mahkeme, (tavzih talebine cevap verilmemiş olsa bile) tavzih talebini kural olarak dosya üzerinde inceler. Fakat mahkeme, taraflardan sözlü açıklama alınmasına lüzum görebilir ve tarafları dinlemek için duruşmaya davet edebilir (m. 306, 2).

Mahkeme, tavzih talebini incelemesi sonucunda, hükmün yeterince açık olmadığı veya çelişik fıkralar içerdiği yahut icrasında tereddüt edilmesinin haklı olduğu kanısına varırsa, hükmü tavzih eder ve bu hususu mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına yazar (m. 306, 3; 304).

Mahkeme, yukarıda gördüğümüz şekilde, hükmü yalnız tavzih edebilir; yoksa, **tavzih bahanesi ile hükmünü değiştiremez**; örnekler:

"Usulün 455 (şimdi: HMK'nun 305) ve müteakip maddelerine göre hüküm müphem veya gayrivazıh olur mütenakız fıkraları ihtiva ederse, ipham ın tavzihi ve tenakuzun ref'i istenebilir. Tavzih yoluyla, esas hüküm değiştirilemez".

"Boşanma kararı ile velâyet anaya tevdi edilmiş, fakat MK m. 148 (şimdi: TMK m. 182) gereğince iştirak nafakası hususu açık bırakılmıştır. Kararı taraflar nafaka dışındaki sebeplerle temyiz etmişler, hüküm onanmıştır. Şu durumda, mahkemenin tavzih suretiyle ilâma iştirak nafakası hakkında bir hüküm fıkrası ilave etmesi, Usulün 455 (şimdi: HMK'nun 305) inci ve sonraki maddelerinin sevk amacına aykırıdır".

"Kararın verilmesinden sonra ileriye sürülecek açıklama dileklerinin hangi konulara ilişkin bulunabileceği Usulün 455. (şimdi: HMK'nun 305.) maddesinde gösterilmiştir. Bu yol ile dava edilen veya verilen hükümde, hüküm edilmeyenin yeni bir karar ile hükme katılabilmesi olanaksızdır. Esas kararda hükmedilmesi unutulan faiz kalemi, tavzih yolu ile hüküm altına alınamaz. Bu yanlışlığın giderilmesi ancak üst mahkeme tarafından hükmün bozulması yoluyla sağlanabilir".

"Hükümde, davalı borçluları müteselsil sorumluluk altına sokan bir kayıt bulunmadığı ve bu husus kesinleştiği halde, tavzih yoluyla esas hükmü değiştirir ve borçluları müteselsil sorumluluk altına sokar nitelikte yeni bir hü-

küm tesis edilmesi, HUMK'nun 455 (HMK m. 305) ve müteakip maddeleri hükümlerine aykırıdır".

Tavzih talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlara karşı, **kanun yolu açıktır**. Böylece, tavzih bahanesi ile hükmün değiştirilip değiştirilmediği üst mahkemece denetlenmiş olur. Başka bir deyişle, bu kanun yolu denetiminde yalnız tavzih kararı hakkında inceleme yapılır; esas karar (hüküm) hakkında kanun yolu incelemesi yapılamaz.

YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM

§ 67. YARGILAMA HARÇLARI VE GİDERLERİ[1]

Taraflar, davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar (dava sebebiyle) çeşitli harcamalar yapmak durumundadırlar. Bu harcamalar, "yargılama harçları" ve "yargılama giderleri" olarak iki ana başlık altında toplanabilir.

A) YARGILAMA HARÇLARI

Yargılama harcı, mahkemelerin gördüğü hizmete karşılık olarak, bu hizmetten yararlananlardan Devletin aldığı paradır. Mahkemelerin gördüğü hizmet parasız değildir. Devlet, mahkemeleri sürekli görev yapar bir şekilde hak arayanların hizmetinde tutabilmek için, bazı giderler yapar (hâkim ve adlîye memurlarının maaşları, bina kirası, kırtasiye, demirbaş ücreti vb.). Bu giderlerden bir kısmı, mahkemelerin faaliyetinden yararlananlardan harç olarak alınır. Alınan harç, Devletin bu hususdaki giderinin tam karşılığı değildir. Tam karşılığı olsa idi, bu, hak arayanlar için ağır bir yük olurdu. Bu yük, kişilerin hak aramaktan kaçınmalarına da yol açabilirdi.

Devletin gördüğü kamu hizmeti kural olarak parasızdır. Fakat, davada kişilere özel hukuk alanındaki haklarına (alacaklarına) kavuşmaları için yardım edildiğinden, yapılan giderin bir kısmının mahkemelerin hizmetinden yararlananlardan alınması uygun görülmüştür ki, kişilerden makbuz karşılığı alınan (Harçlar K. m. 25, 137) bu paraya, **yargılama harcı** denir[2].

Bir sosyal hukuk devletinde davanın taraflarının, Devletin sunduğu yargı hizmeti giderine hangi ölçüde katılmaları gerektiği, kanun koyucu için karar verilmesi güç olan sorunlardan biridir. Harçlar, hak arayanların hak arama özgürlüklerini fiilen, serbestçe ve kolaylıkla kullanabilmelerini temin etmek üzere, adil ve ödenebilir bir ölçüde olmalıdır.

Anayasa Mahkemesinin kararlarında belirtildiği üzere, kanun koyucunun, yargı hizmetlerinin verilmesi karşılığında harç alınması biçiminde düzenleme yapma yetkisi bulunmakla birlikte, bunun, Anayasanın 36. maddesi kapsamında bulunan mahkemeye erişim hakkını engellememesi için "harcın miktarının makul olması", "harcın alınmasında haklı bir amacın olması", "ulaşılmak istenen amaç ile harç miktarı arasında orantı olması" ve "ödeme gücü olmayanlar bakımından etkili adlî yardım sisteminin olması" ölçütlerine uyulması gerekir.

---

1 Bkz. Ejder Yılmaz, Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti (ABD, 1984/2, s. 200-224; Yılmaz, Makaleler C. 1, s. 383-404).

2 "Harç özel ve tüzel kişilerin, özel çıkarlarına ilişkin olarak kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında yaptıkları ödemelerdir" (bkz. 07.12.1964 gün ve 03/05 sayılı İBK: RG 12.12.1964, sa. 11880).

Harçlar, kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır (Anayasa m. 73, III). Bu sebeple, bir davada alınacak harçların (yargı harçlarının) neler olduğu ve oranları 492 sayılı Harçlar Kanununda (Harçlar K. m. 2-31) ve bu Kanuna bağlı (1) sayılı Tarifede gösterilmiştir.

Yargı harçlarını, davayı açan (davacı) veya harca konu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle yükümlüdür (Harçlar K m. 11, I). Mahkeme tarafından, herhangi bir istek olmaksızın kendiliğinden yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır (Harçlar K m. 11, III).

Dava açılması, davaya katılma, tevdi mahalli tayini, ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delil tespiti talepleri, **başvurma harcı**na tâbidir. Başvurma harcının miktarı, maktu (götürü; sabit) olarak belirlenmiştir (Harçlar K. 1 sayılı Tarife, A, I) ve peşin olarak ödenir (Harçlar K. m. 27).

Duruşma (celse) **harcı**: Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden, konusu belli bir değerle ilgili davalarda nisbî; belli bir değeri bulunmayan davalarda maktu duruşma harcı alınır (m. 323, 1/a; Harçlar K. m. 12).

Karar ve ilâm harcı: Bu harç iki çeşittir:

1) **Maktu karar ve ilâm harcı**: Konusu para ile değerlendirilemeyen bir şey (kişivarlığı hakları) olan (başka bir deyişle, konusu belli bir miktar veya değerle tespit edilmemiş olan) davalarda maktu karar ve ilâm harcı alınır (Harçlar K., 1 Sayılı Tarife, A, III, 2).

Örneğin, boşanma davasında, karar ve ilâm harcı maktudur. Fakat, boşanma davasında eşya ve ziynetler veya tazminat da istenmişse, bu istem nispî harca tâbidir

Tapuda isim düzeltme talebinde harç, maktudur.

Maktu karar ve ilâm harcının tamamı (başvurma harcında olduğu gibi), dava açarken davacıdan peşin olarak alınır (bkz. Harçlar K. m. 27; HMK m. 323, 1/a).

2) **Nispî** (oransal) **karar ve ilâm harcı** (m. 323, 1/a): Konusu, para olan (örneğin yüz bin liralık alacak davası) veya para ile değerlendirilebilen bir malvarlığı hakkı olan davalarda (örneğin, elli bin lira değerindeki bir arabanın verilmesi davasında) karar ve ilâm harcı, nispîdir. Bu harcın oranı, hüküm altına alınan **miktarın veya malın değerinin** (bugün için) **binde 68.31**'idir. Bu miktar, maktu karar ve ilâm harcından az olamaz (Harçlar K., 1 Sayılı Tarife, A, III, 1).

Müdahalenin önlenmesi, tescil ve tapu kayıt iptali gibi taşınmazın aynına ilişkin olan davalarda taşınmazın değeri üzerinden nispî harç alınır (Harçlar K. m. 16, I).

Davada, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil talep ediliyorsa (yani, dava yığılması varsa) harç, elatılmasının önlenilmesini istenen taşınmazın değeri ile ecrimisil toplamı üzerinden alınır (Harçlar K. m. 16, II).

Dava taşınmazın tümü ile değil, taşınmaz üzerinde belli bir pay ile ilgili ise, taşınmazın tüm değeri üzerinden değil, yalnızca dava konusu edilen pay bedeli üzerinden harç alınır. Örneğin: İİK'nun 277 vd. hükümlerine göre açı-

lan iptal davalarında harç, iptali istenen taşınmazın değeri ile yapılan takipteki alacaktan hangisi az ise onun üzerinden alınır. Bunun nedeni, iptal davasının açılmasını engellememektir. Örneğin: (A), (B)'den olan on bin lira alacağını alamamış ve ancak (B)'nin bir milyon liralık malını üçüncü kişiye devrettiğini öğrenirse, açacağı iptal davasında onu bir milyon lira üzerinden dava açmaya zorlamak, yüksek harç nedeniyle onun iptal davasını açamaması sonucunu doğururdu. Buna paralel şekilde, on bin liralık alacağını almamış bulunan (A)'nın (B)'nin beş bin liralık malı başkasına devrine ilişkin tasarrufun iptali için açacağı davada, onu on bin lira üzerinden harç ödetmeye zorlamak adalet duygularına aykırı olurdu. Aynı şekilde, İİK'ndaki istihkak davalarında da (İİK m. 96 vd.; 228), alacak tutarı ile haczedilen dava konusu malın değerinden hangisi az ise onun üzerinden harç alınır.

Davanın nispî harca mı yoksa maktu harca mı tâbi olduğu hususu, kamu düzenine ilişkindir. Çünkü, burada Hazinenin alacağı harç miktarı değişecektir. Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde (m. 119) değer gösterilmesi zorunludur. Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde, dava dilekçesi işleme konmaz (Harçlar K. m. 16, III).

Nispî karar ve ilâm harcının dörtte biri, dava açarken davacıdan **peşin olarak alınır**; geriye kalanı, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir[3]. Peşin olarak ödenecek olan bu dörtte bir karar ve ilâm harcı, dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanır (m. 302).

Davanın reddi halinde, karar ve ilâm harcı maktudur. Bu sebeple, başlangıçta alınmış olan nispî harcın geriye kalan kısmı geri verilir.

Bu harçlar dışında bir de **keşif harcı** bulunmaktadır[4]. Bu harç da **maktu**dur.

Noksan tespit edilen değerler hakkında, 30. madde hükmü uygulanır (Harçlar K. m. 16, IV).

Taşınmazın tahliyesi davalarında, yazılı sözleşme olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır (Harçlar K. m. 17).

Kira tespit davalarında harç, **aylık kira farkı** üzerinden alınır.

Hakem kararlarının icrasında hakem kararının niteliğine göre **karar ve ilâm harcı alınır** (Harçlar K. m. 3, I).

Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince zorunlu tahkim yolu ile çözülecek davalardan da aynı şekilde harç alınır (Harçlar K. m. 3, II).

Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilâmların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilâmlarda hükmolunmuş şeyin değeri, türü ve niteliğine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır (Harçlar K. m. 4).

Karşı davalar, ayrı davalar gibi harca tâbidir (Harçlar K. m. 6).

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşması üzerine düzenlenen **anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi** için mahkemeye yapı-

---

[3] Ölüm ve cismanî zarar sebebiyle açılan maddî ve manevî tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır (bkz. Harçlar K. m. 28, I/a).

[4] Anayasa Mahkemesi, keşif harcının Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 22.03.2012 gün ve 13/45 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 121-122.

lacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır (Arabuluculuk K. m.18, 3)

Bazı dava ve işler harçtan müstesnadır. Harçtan müstesna olan dava ve işlerin bazıları Harçlar Kanununda, bazıları da özel kanunlarda gösterilmiştir (Harçlar K. m. 123, I).

Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin çekilmesine ait kararlar harçtan müstesnadır (Harçlar K. m. 13/b).

Ayda yüz lirayı geçmeyen her çeşit nafaka davaları harçtan müstesnadır (Harçlar K. m. 13/c). Yüz lira, hükmedilen nafaka miktarı olduğundan, nafaka davalarında başlangıçta peşin harç alınmaz. Birden fazla kişi lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilâmlarda her kişi lehine hükmedilen nafaka miktarı (yüz liralık istisnanın hesaplanmasında) ayrı olarak nazara alınır (Harçlar K. m. 13/c).

Kamu hukuku adına Cumhuriyet savcıları tarafından hukuk mahkemelerinde açılan davalar harçtan müstesnadır (Harçlar K. m. 131/i).

Bazı dava ve işler ise harçtan muaftır: Erler, onbaşılar ve kıta çavuşlarının (hizmetlerinin ve bu sıfatlarının devamı süresince) açacakları davalar (o davalar aslında harca tâbi olsa bile) harçtan muaftır (Harçlar K. m. 14).

Tüketici mahkemelerinde Ticaret Bakanlığı, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar harçtan muaftır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün açacağı ve bu Genel Müdürlüğe karşı açılacak davalar harçtan muaftır (6200 s. K. m. 49).

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan kooperatifler ile bölge ve merkez birliklerinin açacakları davalar harçtan muaftır (Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri K. m. 19/B/a).

İş Kanununa tâbi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki davalarda harçtan muafiyet, gündelikleri veya aylık ücretleri, on altı yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır (Harçlar K. m. 123, II).

Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe, ondan sonraki işlemler yapılmaz (Harçlar K. m. 32; 27, III). Bunun gibi, davanın başında alınmış olan peşin karar ve ilâm harcının eksik olduğu anlaşılırsa, noksan karar ve ilâm harcı tamamlanıncaya kadar davaya devam olunmaz; HMK m. 150'de gösterilen süre içinde dosyanın işleme konulması, eksik harcın ödenmesine bağlıdır (Harçlar K. m. 30).

B) YARGILAMA GİDERLERİ

Tarafların, davanın görülmesi ve sonuçlanması için ödedikleri paraların tümüne yargılama giderleri denir. Bizde yargılama giderleri geniş anlamda kullanılmakta ve buna harçlar da dahil sayılmaktadır (m. 323). Harçlar yukarıda görüldüğü için, burada dar anlamda yargılama giderleri incelenecektir. Dar anlamda yargılama giderleri, **dava için gerekli olan bir iş** veya **hizmetin gerektirdiği giderlere** denir.

Yargılama giderlerinin neler olduğu m. 323'de gösterilmiştir. Buna göre, **yargılama giderleri şunlardır**:

1) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri (m. 323, 1/b). Dava (yargılama) sırasında çeşitli tebliğ giderleri (Teb. K. m. 3-5) ile posta giderleri yapılır. Örneğin: dava dilekçesinden başlayarak tarafların verdikleri dilekçeler, diğer tarafa tebliğ edilir; mahkemenin çeşitli yerlerle yaptığı yazışmalar posta ile yapıldığında posta giderleri yapılır; hüküm taraflara tebliğ edilir vb. Yapılan tebliğ ve posta giderleri, yargılama giderlerindendir

2) Dosya ve sair evrak giderleri (m. 323, 1/c),

3) Geçici hukukî koruma tedbirleri (m. 388 vd.) ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler (m. 323, 1/ç),

4) Keşif giderleri (m. 323, 1/d),

5) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler (m. 323, 1/e),

6) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler (m. 323, 1/f),

7) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu halde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri (m. 323, 1/g). Buna karşılık, taraf vekillerinin seyahat ve ikamet giderleri, yargılama giderlerine dahil değildir.

8) Yargılama sırasında yapılan (yargılamanın gerekli kıldığı) başka giderler de olabilir. Bunlar da yargılama giderlerine dahildir (m. 323, 1/h).

9) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak **vekâlet ücreti** (m. 323, 1/ğ; AK m. 164 vd.). Vekâlet ücreti, öneminden dolayı aşağıda ayrı bir başlık altında incelenecektir. Vekâlet ücretinin yargılama giderlerinden olması, davada tarafların (özellikle davayı kısmen veya tamamen kazanan ve bu nedenle lehine yargılama gideri hükmedilecek olan tarafın) davayı (bizzat değil) vekil (avukat) aracılığıyla takip etmiş olmaları hali içindir. Bir taraf davasını bizzat takip etmiş ve davayı kazanmış ise, (karşı taraf davayı bir vekil aracılığıyla takip etmiş olsa bile) davayı kazanan taraf lehine yargılama gideri olarak vekâlet ücretine hükmedilemez.

Davacı, yargılama harçları ile Gider Avansı Tarifesinde belirlenen tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. **Gider avansı**, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade eder (Y m. 205, 1). Adlî yardım talebiyle (m. 334 vd.) açılan dava ve işlerde adlî yardım konusunda bir karar verilinceye kadar harç, gider ve delil avansı alınmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır (Y m. 205, 2). Gider avansının yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Dava şartı olan gider avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması halinde, dava, dava şartı yokluğundan reddedilir (Y m. 205, 3).

Davacı bakımından getirilen ve dava şartı olan gider avansı yanında, taraflardan her birinin incelenmesini talep ettiği delil için avans yatırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu ise, **delil avansı**dır. Buna göre, taraflar mahkemece belirlenen avansı, (örneğin, davacı bilirkişi incelemesini talep etmişse buna ilişkin; davalı keşif istemişse buna ilişkin gideri delil avansı olarak), verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır (m. 324, 1/c. 1). Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler (m. 324, 1/c. 2).Taraflardan birisi avans yükümlülüğünü (m. 324, 1) yerine getirmezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir. Aksi halde talep olunan delilin ikamesinden vazgeçilmiş sayılır (m. 324, 2). Burada vazgeçildiği varsayılan husus, kural olarak dava değil, tanık dinletmek, bilirkişi raporu istemek gibi taleptir. Hâkim ara kararında, yatırılmasını istediği yargılama giderlerinin ne olduğunu taraflara açıklamalı ve vereceği kesin sürenin hukuksal sonuçlarını belirtmeli ve bunları tutanağa geçirtmelidir. Delil avansının yatırılmaması halinde, talep edilen delilden vazgeçme kuralı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde uygulanmaz (m. 324, 3). Çünkü, bu tür davalarda giderler hakkında farklı düzenleme (m. 325) vardır.

Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde (talep olmaksızın) kendiliğinden de delile başvurabilir. Örneğin, bilirkişi incelemesi veya keşif yapılmasına karar verebilir. Hâkim bu gibi durumlarda, işlemin gerektirdiği giderlerin iki taraftan biri veya her iki tarafça da belirlenen oranda bir hafta içinde ödenmesine karar verir (m. 325, 1/c. 1). Bu karar çerçevesinde yatırılacak olan avans yatırılmazsa, hâkim ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere Hazineden ödenmesine karar verir (m. 325, 1/c. 2; karş. m. 324, 2). Bu hüküm özellikle kamu düzeni ile ilgili davalar bakımından önem taşımaktadır. Bu tür davalarda hâkim gerçeğe ulaşmak için, tarafların talebine gerek kalmaksızın, bilirkişi ve keşif gibi delillere başvurabilir. Hâkim kamu düzeni ile ilgili olmayan davalarda da, örneğin dava şartı gibi resen dikkate alması gereken hususların araştırılması için de bu yola gidebilir.

Mahkeme, bir işlemin (örneğin keşfin, m. 288) yapılmasına kendiliğinden karar verirse, bu işlem için gerekli giderin taraflardan biri veya her ikisi tarafından ödenmesine karar verebilir ve bu giderin mahkeme kalemine ödenmesi için bir haftalık süre belirler. Bu süre içinde mahkemenin istediği delil avansı ödenmezse, mahkeme, ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınması şartı ile giderin Devlet hazinesinden ödenmesine karar verebilir (m. 325). Ancak bu durum, hâkimin resen keşfe başvurabildiği her halde (m. 288, 2) değil, yalnızca m. 325 uyarınca kendiliğinden başvurmaya karar verdiği keşifler için geçerlidir.

Delil avansının ödenmesine, hâkim tarafından dilekçelerin verilmesi, ön inceleme aşaması veya tahkikatın başında karar verilir (Y m. 205, 5).

Harç, HMK'na göre tahsil edilmesi gereken avans ve para cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilir. Tahsil işlemi bankalar aracılığıyla olabileceği gibi Barokart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilir (Y m. 205, 6).

Gider ve delil avansı olarak tahsil edilen paraların, mutat ödemeler dikkate alınarak belirlenecek olan günlük ihtiyaçtan fazlası Bakanlıkça belirlenen bankaya yatırılır (Y m. 205, 7).

Yargılama gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra yazı işleri müdürü tarafından ilgilisine iade edilir. Hesap numarası bildirilmiş ise iade, elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise, masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir (Y m. 207, 1). Geçici hukukî koruma talebi için alınan yargılama giderinin kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir (Y m. 207, 2).

C) YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK

Bazı harç ve giderlerin bununla ilgili işlemlerin yapılmasını isteyen (bazen de Devlet hazinesi, m. 325) tarafından peşin olarak ödeneceğini (m. 114, 1/g;120; 324) gördük. Acaba, davanın sonunda bu giderler kime yükletilecektir? Başka bir deyişle, bu giderlerden sonuçta kim sorumlu olacaktır? İşte burada, bu sorunun cevabı üzerinde durulacaktır.

Yargılama giderleri, kural olarak, **davada haksız çıkan** yani aleyhine hüküm verilen **tarafa yükletilir** (m. 326, 1). Davada haksız çıkan tarafa yükletilecek olan yargılama giderleri, hem davayı kazanan tarafın daha önce avans olarak ödediği (m. 114, 1/g; 120; 324, 1) hem de Devlet hazinesince peşin olarak ödenen giderlerdir. Bundan başka, davayı kazanan taraf davasını bir vekil vasıtasıyla takip etmiş ise, haksız çıkan (davayı kaybeden) taraf yargılama gideri olarak vekâlet ücretine de mahkûm edilir (m. 323, 1/ğ).

Davada her iki taraf da kısmen haklı (dolayısıyla, kısmen haksız) çıkarsa, mahkeme, yargılama harç ve giderlerini, haklı çıkma oranına göre taraflar arasında paylaştırır (m. 326, 2).

Davada haksız çıkan (aleyhine hüküm verilen) tarafta birden fazla kişi (dava arkadaşı) varsa, mahkeme, yargılama harç ve giderlerini, davadaki ilgilerine göre bu dava arkadaşları arasında paylaştırır. Mahkeme, haksız çıkan (davayı kaybeden) dava arkadaşlarının yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olduklarına da karar verebilir (m. 326, 3).

Mahkeme, haksız çıkan dava arkadaşlarının yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olduklarına karar vermemişse, her dava arkadaşı yargılama giderlerinden kendi payına düşen kısımdan sorumludur. İcra dairesi veya icra mahkemesi, dava arkadaşlarını müteselsilen sorumlu sayamayacağı gibi hükmü vermiş olan mahkeme de, sonradan tavzih yolu ile, dava arkadaşlarının yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olduklarına karar veremez.

Yargılama harç ve giderlerinin davada haksız çıkmış olan tarafa yükletilmesine ilişkin **ana kuralın** (m. 326, 1) bazı **istisnaları** vardır:

1) Davanın açılmasına kendi tutum ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş olan davalı, yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilemez (m. 312, 2).

2) Davada haklı çıkmış (lehine hüküm verilmiş) olan taraf için, aşağıdaki hallerden biri söz konusu ise, (davayı kazanmış olmasına rağmen) karar ve ilâm harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir (m. 327): (a) Gereksiz yere davanın uzamasına sebep olmak; (b) gereksiz gider yapılmasına sebebiyet vermiş olmak.

3) Bir kişi davada sıfatı olmadığı halde, davacıyı, davalı sıfatı kendine aitmiş gibi yanıltıp, kendisine karşı dava açılmasına sebebiyet verirse, davanın sıfat (husumet) yokluğu nedeniyle reddi hâlinde, davalı yararına yargılama giderlerine hükmedilemez (m. 327, 2). Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluğu düzenleyen bu hükümler, dürüstlük kuralının usul hukukunda da geçerli olduğunu gösteren örneklerdir.

4) Arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak öngörüldüğü durumlarda, taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halinde toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır (Arabuluculuk K. m. 18/A, 11).

5) Davada haksız çıkılmış olup olmadığına bakılmaksızın, kanunun yargılama giderlerinin kime ait olacağını belirlediği diğer haller için bkz: m. 182, 101, 253, 213.

Mahkeme, **kötüniyetli davalı**yı veya dava açma hakkı olmadığı halde dava açan **davacı**yı, yargılama giderlerinden (m. 323) başka diğer tarafın kendi avukatıyla aralarında kararlaştırdıkları ücretin tamamına veya bir kısmına da mahkûm edebilir (m. 329, 1/c. 1). Bu hüküm, kötüniyetle açılmış bulunan bir dava içinde talep edilmiş olmasına bağlıdır; uğranılan zarar, ayrı bir dava şeklinde istenemez. Tarafın mahkûm edileceği (yani, diğer taraf ile vekili arasında kararlaştırılan) vekâlet ücreti (m. 329, 1/c. 1) konusunda uyuşmazlık ortaya çıkarsa veya bu miktar mahkemece aşırı görülürse, bunun miktarını mahkeme kendiliğinden takdir eder (m. 329, 1/c. 2). Mahkeme, kötüniyetli davalıyı veya dava açma hakkı olmadığı halde dava açan davacıyı (m. 329, 1 hükmünün yanı sıra) disiplin para cezasına (m .446) da mahkûm edebilir (m. 329, 2/c. 1). Kötüniyetli hareketi vekil yapmışsa, para cezası (m. 329, 1/c. 1) vekil hakkında uygulanır (m. 329, 2/c. 2).

Ferî müdahil (m. 66) olarak davada yer alan kimse, yanında katıldığı taraf mahkûm olursa (haksız çıkarsa), yalnız müdahale giderinden sorumlu tutulur, aksi halde bu giderler diğer tarafa yükletilir. Ancak, hüküm üçüncü kişinin katıldığı taraf lehine verilmiş olsa bile, lehine hükmolunan tarafın tutum ve davranışı, üçüncü kişinin davaya katılmasını (müdahale etmesini) gerektirmişse, müdahale giderinin tamamı veya bir kısmı, lehine hüküm verilen tarafa yükletilebilir (m. 328).

Yargılama harç ve giderlerinin kime yükletildiği ve bunun miktarı hükümde (hüküm sonucunda) açıkça gösterilir (m. 332). Taraflardan her biri, mah-

kemeye kendi ödemiş olduğu yargılama (harç ve) giderlerini gösterir bir belgeleri verir. Mahkeme, bunun dışındaki yargılama giderlerini (örneğin karar ve ilâm harcını, celse harcını, vekâlet ücretini), kendisi hesap ve takdir ederek, bütün yargılama giderlerini ve bunun kim (veya kimler) tarafından ödeneceğini hükümde açık bir şekilde gösterir (m. 332).

Mahkeme, davada haksız çıkan (veya yukarıda saydığımız istisnaî hallerde haklı çıkan) tarafı kendiliğinden yargılama (harç ve) giderlerini ödemeye mahkûm eder; bunun için, haklı çıkan tarafın bir talepte bulunmuş olmasına gerek yoktur (m. 332, 1)[5].

Mahkeme hükmünde yargılama giderlerini tamamen veya kısmen unutmuş ve hüküm bu şekilde kesinleşmiş ise, davayı kazanan taraf yargılama giderleri için ayrı bir dava açamaz; yargılama giderlerine asıl davada kendiliğinden karar verilir.

İhtiyatî tedbir ve delil tespiti giderleri de yargılama giderlerine dahil olduğundan, bu giderler de mahkemece kendiliğinden hüküm altına alınır ve ayrı bir dava konusu yapılamaz.

Yargılama giderlerinden sorumluluk, ancak davanın sonunda söz konusu olur. Bu nedenle kural olarak, ancak esas hakkında verilen hüküm ile birlikte yargılama giderlerine de hükmolunur. Hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, mahkemece ilâmın altına yazılır (m. 332, 3).

İstisnaî olarak usule ilişkin nihaî kararlarda da, yargılama giderlerine hükmedilir. Bu konuda şöyle bir ayrım yapmak gerekir:

Eğer, usule ilişkin nihaî kararla dava sona eriyor, yani dava dosyası başka bir mahkemeye gönderilmiyorsa, mahkemenin, nihaî kararla birlikte, yargılama giderlerine kimin katlanacağı hakkında da bir karar vermesi gerekir. Örneğin, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar veya davanın açılmamış sayılması kararında (m. 20, 1; 150, 5) olduğu gibi. **Davanın konusuz kalması** halinde **mahkeme, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre** yargılama giderlerini takdir ve halleder (m. 331, 1). Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hallerde davacıya yükletilir (m. 331, 3).

Buna karşılık, usule ilişkin nihaî kararla dava sona ermiyor, aksine devam ediyorsa, mahkemenin, böyle bir nihaî kararda, yargılama harç ve giderlerine kimin katlanacağını belirtmesine gerek yoktur; çünkü, dava henüz devam etmektedir (sonuçlanmamıştır); örnekler: Mahkemenin **görevsizlik** veya **yetkisizlik kararı** vermesi halinde, mahkeme, bu kararla davacıyı yargılama giderlerine mahkûm etmez. Çünkü, bu davanın taraflardan biri, 20. maddede gösterilen süre içinde, bu maddede öngörülen usule göre, davanın görevli veya yetkili mahkemede devam edilmesini sağlayabilir. Devam edilen dava, yeni bir dava olmayıp, önceki davanın devamı olduğundan, dava sonucunda verilecek nihai kararla yargılama giderlerine karar verilecektir (m. 331, 2).

---

[5] 29.05.1957 gün ve 04/16 sayılı İBK (RG 04.09.1957, sa. 9697).

Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya görevli veya yetkili mahkemede devam edilememiş ise, talep üzerine davanın açıldığı mahkeme davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder (m. 331, 2). Bu olasılıkta, süresi içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemeye başvuru yapılmadığından, mahkeme, esasında davanın açılmamış sayılmasına resen karar verir (m. 20, 1).

Yalnız davanın tarafları yargılama giderlerinden sorumlu tutulabilir. Tarafların vekilleri şahsen yargılama giderlerine mahkûm edilemez. Hatta bir olayda, avukatı şahsen yargılama giderlerine mahkûm eden hâkim, avukata tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.

Buna karşılık, vekâletnamesiz dava açmasına veya usul işlemi yapmasına izin verilen vekil, mahkemenin verdiği kesin süre içinde vekâletnamesini mahkemeye vermezse, celse harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir (m. 77, 2).

D) AVUKATLIK (VEKÂLET) ÜCRETİ

Avukatlık (vekâlet) ücreti de yargılama giderlerindendir. Davada haklı çıkan taraf, davayı bizzat değil de bir vekil (avukat) vasıtasıyla takip etmiş ise, avukatına bir vekâlet ücreti ödemek zorundadır ki, bu ücret de davanın gerektirdiği bir gider olmaktadır. Yalnız dava (yargılama) gideri olarak karşı (aleyhine hüküm verilen) tarafa yükletilecek olan vekâlet ücreti, haklı çıkan tarafın vekili (avukatı) ile kararlaştırılmış olduğu vekâlet ücreti olmayıp, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak olan, objektif bir vekâlet ücretidir[6].

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, iki çeşit vekâlet (avukatlık) ücreti vardır: 1) Müvekkil (vekâlet veren taraf; iş sahibi) ile vekili (avukatı) arasındaki vekâlet ücreti (avukatlık ücreti), 2) Yargılama gideri olan vekâlet ücreti (m. 323, 1/ğ).

I – MÜVEKKİL İLE VEKİL ARASINDAKİ AVUKATLIK ÜCRETİ

Bir taraf (müvekkil), davada kendini vekil vasıtasıyla temsil ettirmiş, yani davasını vekil (avukat) ile takip ettirmişse, vekiline bir vekâlet ücreti ödeyecektir. İşte, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblağ veya değere, avukatlık (vekâlet) ücreti denir (AK m. 164, I).

Müvekkilin vekiline ödeyeceği bu vekâlet ücreti, az sonra görülecek yargılama gideri olan vekâlet ücretine esas teşkil edemez. Buradaki vekâlet (avukatlık) ücreti, tamamen vekil ile müvekkil arasındaki bir ücrettir. Bu vekâlet ücretinin miktarı, vekil ile müvekkil arasında yapılacak bir ücret sözleşmesi ile kararlaştırılır. Bazen de hiçbir ücret sözleşmesi yapılmaz. Bu iki ihtimali ayrı ayrı inceleyelim:

---

6 Avukatlık Kanunu, vekâlet ücretine "avukatlık ücreti" demektedir (bkz. AK m. 163 vd.). Bu terimi, daha çok müvekkilin vekile (avukata) ödemek zorunda olduğu (yani az sonra görülecek olan birinci çeşit) vekâlet ücreti için anlamak doğru olur.

1) Ücret Sözleşmesi Yapılmış İse

Bu ücret sözleşmesi, vekil ile müvekkil arasında yapılır ve TBK'nun sözleşme serbestisi hakkındaki hükümlerine (karş. TBK m. 26) tâbidir. Yani vekâlet ücreti, vekil ile müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır (AK m. 164, II). Yalnız, bu ücret sözleşmesinde kararlaştırılacak olan vekâlet ücreti, Ücret Tarifesindeki asgarî miktarın altında olamaz. Çünkü, Ücret Tarifesindeki asgarî miktarın altında kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve dava kabulü yasak olup, aksine hareket, avukat için disiplin cezasını gerektirir (AK m. 164, IV).

Avukat, ücretsiz dava alabilir; örneğin yakın bir akrabasının davasını ücretsiz olarak takip edebilir. Bu halde avukat, ücretsiz olarak aldığı davayı baro yönetim kuruluna bildirir. İşte bu halde, ücret sözleşmesi söz konusu olmayacağından, yukarıda belirtilen Ücret Tarifesindeki asgarî miktarın altında avukatlık ücreti alma yasağı da uygulanmaz (AK m. 164, IV).

Ücret sözleşmesi, normal bir sözleşme olmakla beraber, Avukatlık Kanunu, bu sözleşmeyi bazı hükümlere tâbi tutmuştur (AK m. 163 vd.). Buna göre:

Vekâlet ücreti sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir (AK m. 163, I).

Avukatlık (vekâlet) ücreti sözleşmesinin, kural olarak belli bir miktarı kapsaması (içermesi) gereklidir (AK m. 164, I). Örneğin, "vekâlet ücreti olarak beş bin lira kararlaştırılmıştır" gibi.

Taraflar, yüzde yirmi beşini aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın belli bir yüzdesini avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilirler. Çünkü, bu halde kararlaştırılan vekâlet ücretinin miktarı bellidir.

Örneğin, dava konusunun dava dilekçesinde gösterilen değeri yüz bin lira ve dava konusunun değerinin yüzde yirmisi oranında vekâlet ücreti kararlaştırılmış ise, kararlaştırılan vekâlet ücretinin miktarı belli olup (100.000 X %20 =) 20.000 liradır.

Kanun, davada gösterilen başarıya göre değişmek ve yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir yüzdesinin vekâlet ücreti olarak kararlaştırılmasına izin vermektedir (AK m. 164, II). Bu hüküm, dava olunan şeyin değeri üzerinden vekâlet ücreti sözleşmesi yapılması hali için yerindedir ve yukarıda gördüğümüz "belli bir miktar şartı"nın bir teyidîdir (doğrulanmasıdır). Çünkü, burada da kararlaştırılan vekâlet ücreti önceden bellidir.

Örneğin, dava olunan şeyin değeri iki yüz bin lira ve taraflar, "davanın kazanılması halinde dava olunan şeyin değerinin yüzde yirmisi, kaybedilmesi halinde yüzde onu vekâlet ücreti olarak ödenecektir" şeklinde bir ücret sözleşmesi yapmışlarsa, burada her iki ihtimal için kararlaştırılan vekâlet ücreti bellidir: kırk bin ve yirmi bin lira.

Buna karşılık, yapılacak avukatlık ücreti sözleşmesi, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz (AK m. 164, III). Kanun koyucu, bu hükümle eskiden **"hasılı davaya** (dava sonucuna) **iştirak yasağı"** denilen müesseseyi benimsemek ve yeniden düzenlemek istemiştir. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, hükmolunacak şeyin belli bir yüzdesinin (yüzde yirmi beşi aşmamak üzere) vekâlet ücreti olarak kararlaştırılmasına izin verilmesi ile (AK m. 164, II), hasılı davaya iştirak yasağı bir hayli yumuşatılmıştır.

Bir ücret sözleşmesi hasılı davaya iştirak yasağına aykırı olması nedeniyle batıl sayılınca (AK m. 164, III) hiç ücret sözleşmesi yapılmamış gibi, vekâlet ücreti, Ücret Tarifesine göre hesaplanır.

Mahkemenin Ücret Tarifesine dayanılarak yargılama gideri olarak karşı tarafa yükleteceği (az sonra II'de incelenecek olan) vekâlet ücreti, yani **yargılama gideri olan vekâlet ücreti avukata aittir** (AK m. 164, V). Ancak AK m. 164, V hükmü emredici olmayıp, aksi kararlaştırılabilir ve yargılama gideri olan vekâlet ücretinin müvekkile ait olacağı yolunda sözleşme yapılabilir[7]. Şu halde, davayı kazanmış olan tarafın avukatı, iki adet avukatlık (vekâlet) ücreti almaktadır: 1) Ücret sözleşmesinde kararlaştırılmış olan vekâlet ücreti; 2) Mahkemenin yargılama gideri olarak hükmetmiş olduğu vekâlet ücreti.

2) Ücret Sözleşmesi Yapılmamış İse

Avukat ile müvekkili (iş sahibi) arasında ayrı bir vekâlet ücreti sözleşmesi yapılmamış ise, davayı takip eden avukat, müvekkilinden Ücret Tarifesindeki asgarî vekâlet ücretini isteyebilir.

Bu halde de, davayı kazanan tarafın avukatı, iki adet vekâlet ücreti alacaktır: 1) Ücret sözleşmesi yapılmadığı için, Ücret Tarifesindeki asgarî vekâlet ücreti; 2) Mahkemenin yargılama gideri olarak Ücret Tarifesine göre hükmetmiş olduğu vekâlet ücreti.

II – YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKÂLET ÜCRETİ

Davada haklı çıktığı için lehine yargılama gideri hükmedilen taraf, davasını bir vekil (avukat) aracılığıyla takip etmiş ise, lehine, diğer yargılama giderlerinden başka bir de (Ücret Tarifesine göre hesaplanacak) vekâlet ücreti hükmedilir (m. 323, 1/ğ).

Davada haklı çıkan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilebilmesi için, o tarafın davanın başından sonuna kadar vekil (avukat) tarafından temsil edilmiş olması şart değildir. "Hangi aşamada olursa olsun, dava kabul ve takip eden avukat Tarife hükümleriyle belirli ücretin tümüne hak kazanır" (AK Ücret Tarifesi m. 5).

Davayı kazanan taraf, davanın yalnız bir oturumunda vekille temsil edilmiş olsa bile lehine vekâlet ücreti hükmedilmesi gerekir.

---

7 Anayasa Mahkemesi, söz konus hükmün Anayasaya aykırı olmadığına bu tür gerekçelerle karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 10.04.2019 gün ve E. 2017/154 ve K. 2019/18 sayılı kararı için bkz. RG 16.05.2019, sa. 30776.

Vekâlet ücreti yargılama giderlerindendir (m. 323, 1/ğ). Davada haklı çıkan tarafın peşin olarak ödediği diğer yargılama giderleri (m. 324) gibi, vekâlet ücretinin de, haksız çıkan taraftan alınarak, haklı çıkan tarafa verilmesine hükmolunur (m. 326).

Yargılama gideri olan vekâlet ücreti, Ücret Tarifesine göre hesaplanır (m. 323, 1/ğ; AK m. 169; AK Ücret Tarifesi m. 1). Bu ücret, Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz[8]. Bu ücretin takdirinde, avukatın emeği, gayreti, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur (AK Ücret Tarifesi m. 3). Bundan başka, karşı tarafın davadaki tutumunun da ücret takdir ederken göz önünde tutulması gerekir. Örneğin, kasten davayı uzatıcı davranışlarda bulunmuş olan davalı taraf, asgari vekâlet ücretinin üç mislini ödemeye mahkûm edilebilir.

Yargılama gideri olan vekâlet ücretinin hesaplanmasında, vekil ile müvekkilin kendi aralarında yazılı ücret sözleşmesi ile kararlaştırmış oldukları vekâlet ücretine bakılmaz. Buradaki vekâlet ücreti, az önce belirtilen esaslar gereğince Ücret Tarifesine göre belirlenir.

Ancak, istisnaî olarak vekil ile müvekkil arasında kararlaştırılmış olan vekâlet ücreti, yargılama gideri olan vekâlet ücretine esas teşkil edebilir (m. 421). Buna göre mahkeme, kötüniyet sahibi olan davalıyı veya hiç bir hakkı olmadığı halde dava açan davacıyı, diğer kanunî yargılama harç ve giderlerinden başka, karşı tarafın (birinci halde davacının, ikinci halde davalının) vekili ile arasında kararlaştırdığı vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmı ile de mahkûm edebilir (m. 327, 1). Kötüniyetli davalının veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan tarafın, yargılama giderlerinden (vekâlet ücreti dahil) sorumlu tutulması ve idarî para cezasını çarptırılması da mümkündür (m. 329).

AK m. 164, V'e göre; "Dava sonunda, kararla Tarifeye dayanılarak karşı tarafa yükletilecek vekâlet ücreti avukata aittir". Ancak yargılama giderleri, davanın tarafları lehine veya aleyhine yükletildiğinden, mahkemenin davada üçüncü kişi konumundaki avukat lehine avukatlık ücreti hükmetmesi mümkün değildir; mahkeme vekâlet ücreti ile ilgili kararını yine taraf lehine (veya aleyhine) verecektir. Nitekim HMK'nun 330. maddesinde, "Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir" hükmüne yer verilmiştir. Ancak AK m. 164, V hükmü sebebiyle, karşı tarafa yükletilecek vekâlet ücreti (davayı kazanan tarafça) avukata verilecektir. Bu hükmün adil olmadığı ve genel yargılama giderleri sistemimize aykırı düştüğü kanısındayız. Ancak Anayasa Mahkemesi AK m. 164, V düzenlemesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir[9].

Mahkeme, davada haksız çıkan tarafı kendiliğinden vekâlet ücreti ödemeye mahkûm eder; bunun için, haklı çıkan tarafın bir talepte bulunmuş ol-

---

[8] Bkz. AK m. 169; AK Ücret Tarifesi m. 3, I. Müteselsilen sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek; ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur (AK Ücret Tarifesi m. 3, II).

[9] Anayasa Mahkemesinin 03.03.2004 gün ve 126/127 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 97-98. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 10.04.2019 gün ve E. 2017/154 ve K. 2019/18 sayılı kararı için bkz. RG 16.05.2019, sa. 30776.

masına gerek yoktur. Yargılama gideri olarak haksız çıkan tarafa yükletilmesi gereken vekâlet ücreti, ayrı bir dava konusu yapılamaz.

Aynı davanın birden çok vekil tarafından takip edilmesi halinde, karşı tarafa bir vekâlet ücretinden fazlası yükletilemez (AK Ücret Tarifesi m. 4).

Yargılama gideri olan vekâlet ücretinin nasıl hesaplanacağı, az sonra, Ücret Tarifesi incelenirken görülecektir.

III – AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ[10]

Ülkemizde, hukukî yardımlardan alınacak avukatlık (vekâlet) ücretinin asgarî haddini gösteren Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi kabul edilmiştir (AK m. 168).

Ücret Tarifesi, avukatların yapacakları bütün hukukî yardımlar için hesaplanacak vekâlet (avukatlık) ücretini tespit etmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Ücret Tarifesi, konumuz için özellikle iki bakımdan önemlidir: 1) Yargılama gideri olarak karşı tarafa yükletilecek vekâlet ücreti bu Tarifeye göre hesaplanır. 2) Vekil (avukat) ile müvekkil (iş sahibi) arasında hukuken geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde, avukatın müvekkili iş sahibinden isteyebileceği vekâlet ücreti de bu Tarifeye göre belirlenir.

Ücret Tarifesi, 24 maddelik bir metin kısmı ile, avukatlık ücret tarifesi kısmından ibarettir. Ücret Tarifesinin metin kısmına, yukarıda yeri geldikçe değinilmiştir. Burada, daha çok ücret tarifesi kısmının hukuk davalarına ilişkin hükümleri kısaca inceleme konusu yapılacaktır:

Davalar için, duruma göre, nispî (oransal) vekâlet ücreti veya maktu (rakamı sabit; götürü) vekâlet ücreti hesaplanır.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir şey olan davalarda vekâlet ücreti, nispî tarifeye göre hesaplanır. Nispî tarifeye göre (bugün için:) 35.000 liraya kadar olan davalarda **%12**'dir. 35.000 liranın üstündeki kısımlara ilişkin oranlar, her grup için değişiktir (%11, 8, 6, 4, 3, 1.50 ve 1).

Davanın tamamen kazanılması veya reddedilmesi halinde, nispî vekâlet ücreti, dava konusunun değeri üzerinden hesaplanır. Örneğin 10.000 liralık bir davanın tamamen kazanılması halinde davacı yararına, tamamen reddi halinde ise davalı yararına 1.200 lira asgarî vekâlet ücreti takdir edilir.

Davanın kısmen reddi halinde, kabul edilen miktar için davacı, reddedilen miktar için de davalı yararına vekâlet ücreti takdir edilir (m. 326). Örneğin 10.000 liralık bir davanın 6.000 lirası kabul, 4.000 lirası reddedilirse, davacı yararına 720, davalı yararına da 480 lira asgarî vekâlet ücreti takdir edilir.

Konusu para ile değerlendirilemeyen bir şey olan davalarda (örneğin boşanma davalarında) vekâlet ücreti, **maktu** tarifeye göre takdir edilir. 2019 yılı için maktu vekâlet ücreti, örneğin sulh hukuk mahkemelerinde 1.162 TL, asliye hukuk mahkemelerinde 2.750 TL'dır. Yargılama gideri olarak karşı tarafa yükletilecek vekâlet ücretinin, Ücret Tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamayacağını yukarıda görmüştük. Buna göre örneğin asliye hukuk mahkemesi, 10.000 liralık bir alacak davasının tamamen kazanılması

[10] Bkz. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, (RG 02.01.2019, sa. 30643).

halinde, davalıyı yargılama gideri olarak 1.200 ilâ 3.600 lira arasında bir vekâlet ücreti ödemeye mahkûm eder. Bunun gibi, aile mahkemesi, bir boşanma hükmünde davalıyı yargılama gideri olarak 2.750 ilâ 8.250 TL arasında bir vekâlet ücreti ödemeye mahkûm eder.

Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Ücret Tarifesi esas alınır (AK m. 168, III).

IV – ORTAK HÜKÜMLER

Avukatlık ücreti sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan vekâlet ücreti yalnız avukatın üzerine almış olduğu işin (davanın) karşılığı olup, karşılık dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya başka her türlü hukukî yardımlar ayrı ücrete tâbidir (AK m. 173)[11].

Avukat, üzerine aldığı işi (davayı) kanun hükümlerine ve yazılı sözleşme şartlarına göre sonuna kadar takip eder (AK m. 171). Avukatın, vekâlet ücretine hak kazanabilmesi için, davayı sonuna (hüküm kesinleşinceye) kadar yürütmesi gerekir. Bu nedenle, ücret sözleşmesinde aksi yazılı değil ise, vekâlet ücreti davanın sonunda (bitiminde) muaccel olur.

Vekil, dava müvekkil yararına sonuçlanmış olsun veya olmasın, hizmetin karşılığı olan vekâlet ücretini istemekte haklıdır.

Üzerine aldığı işi (davayı) haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen (istifa eden) avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin almış olduğu vekâlet ücretini geri vermek zorundadır (AK m. 174, I). Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez (AK m. 174, II).

Avukat, kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa teklifi reddetmek zorundadır (AK m. 38/a). Bu nedenle avukat, Kanunun açık hükmüne rağmen kazanamayacağını bildiği bir davayı kazanacağı iddiası ile almış ve kaybetmiş ise, almış olduğu vekâlet ücreti kendisinden geri istenebilir.

Avukat, müvekkil tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, vekâlet ücreti ve giderlerin ödenmesine kadar, kendi alacağı oranında elinde tutabilir (hapis hakkı). Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hâkim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilâm gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkını haizdir (AK m. 166).

---

[11] Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez. Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir (bkz. AK Ücret Tarifesi m. 2).

§ 68. ADLÎ YARDIM[1]

A) KAVRAM

Mahkemeye başvurulması ve hukukî himaye talebinde bulunulması sonucunda, pek çok gider yapılması gerektiği yukarıda incelendi. Buna göre Devlet, yargı hizmeti sunması karşılığında harç adı altında para almakta, öte yandan yargılamanın yürütülmesi için yapılması gereken tebligat, keşif veya bilirkişi, tanık ücreti gibi giderlerin karşılanması gerekmektedir. Nitekim Kanun da, davacının, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak Gider Avansı Tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olduğunu (m. 120, 1) düzenlemektedir. Bunun yanında ayrıca tahkikat sırasında tarafların, gösterdikleri delillerin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere delil avansı (m. 324) yatırmaları şarttır.

Her ne kadar, davacı bakımından gider avansı yatırılması bir dava şartı olarak kabul edilmişse de (m. 114, 1/h), bu hüküm, HMK m. 120 ile birlikte değerlendirildiğinde, harç ve gider avansını ödeyemeyen kişinin dava açması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, yargılamada yapılması gereken giderler, tarafları caydırıcı veya engelleyici bir düzeye ulaşabilir. Hak arama özgürlüğünün ve adil yargılanma hakkının sağlanması, bireylerin hak ararken malî veya ekonomik engellerle karşılaşmaması, bu konuda Devletin gerekli önlemleri almasını da içerir. Özellikle sosyal hukuk Devletinin, hak aramayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapması önem taşımaktadır.

HMK da, bu amaçla "adlî yardım" başlığı altında düzenleme yapmış ve yargılama giderlerini karşılama konusunda zorluk yaşayan hak arayanlara bir kolaylık getirmeyi amaçlamıştır (m. 334-340).

B) TALEPTE BULUNABİLECEKLER VE ADLÎ YARDIMIN KOŞULLARI

Kural olarak, Türk vatandaşı olan gerçek kişiler adlî yardım talebinde bulunabilirler. Kamuya yararlı dernek ve vakıflar da, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve malî açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adlî yardımdan yararlanabilirler. Yabancıların adlî yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır (m. 334).

Adlî yardım talebinde bulunabilmek için, **yargılama giderlerini karşılama gücünden** kısmen veya tamamen **yoksun olmak** gerekir. Adlî yardım talebinde bulunmak için söz konusu olan "yoksun"luk, "yoksulluk" olmayıp, **"ekonomik yetersizlik"**tir. Çünkü kanun koyucu burada, kişinin yalnızca kendi ekonomik durumunu değil, ailesini de düşünerek, yargılama giderlerini

---

[1] Bkz. Ayşe Kılınç, Medenî Usul Hukukunda Adlî Yardım, Ankara 2013.

karşıladığı takdirde kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürecek olmasını yeterli görmüştür (m. 334, 1). Kanunda söz edilen bu zor durum, her zaman "yoksulluk" anlamına gelmez.

Adlî yardım talebinde bulunan kişinin mutlaka davacı olması gerekmez, davalı da adlî yardım talebinde bulunabilir. Öte yandan, yalnızca dava açarken değil, geçici hukukî korunma taleplerinde veya icra takibi yaparken de adlî yardım istenebilir (m. 334, 1).

Adlî yardım talep edilebilmesinin ilk koşulu, **talepte bulunanın kısmen veya tamamen yargılama giderlerini karşılamaktan yoksun olması**; yani yargılama giderlerini ödemesinin onun ve ailesinin geçimini zora sokacak olmasıdır.

İkinci koşul ise, yardım talep eden tarafın **"taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması"**dır.

HMK, m. 334, I'de adlî yardım talep edebilmek, talepte bulunanın "haklı oldukları yolunda kanaat uyandırma"sı gerektiği biçiminde iken; 6459 sayılı Kanunla m. 334'te yapılan değişiklikle, yukarıda belirtilen ifade, "taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması" şeklinde değiştirilmiştir[2]. Değişiklikte AİHM'in haklılık değil, dayanaktan yoksun olmama gibi bir ölçütü tavsiye ettiği vurgulanmaktadır. Böylece adlî yardımdan yararlandırmanın daha geniş ölçekte sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, adlî yardım talep eden kişinin asıl davadaki haklılığını kanıtlaması gerekmeyip, yalnızca talebinin dayanaklarını en azından ilk bakışta ispat etmesi yeterlidir. Burada ileri sürülen iddia ve savunmanın başarı ihtimali (ümidi) belirleyicidir. Bir başka deyişle, talepte bulunanın davayı kaybetme riskinin kazanma olasılığına göre daha düşük olduğu konusunda bir kanaat uyanmalıdır.

Adlî yardım talebinde bulunulurken talebin kabulünü sağlamak bakımından "haklılık" kavramından yola çıkılması bazı güçlükleri de beraberinde getirmekte ve adlî yardım kararı verilmesini zorlaştırıcı bir hüküm olarak görülmekte idi. Gerçekten maddede geçen haklı olma ifadesi, sanki davanın esası bakımından bir inceleme yapılacakmış gibi bir izlenim uyandırdığı için, kanun koyucu, bunu daha objektif görünen bir ifadeyle değiştirme gereğini duymuş ve **"talebin açıkça dayanaktan yoksun olmaması"**nı aramıştır. Mahkeme, adlî yardım talebinde bulunan tarafın dava konusu yapacağı hususla ilgili yeterli ve ikna edici delil veya belge arayacak; örneğin, dava konusu 3.360 TL'nın üzerinde olan bir konuda, talepte bulunan davacının elinde alacağını kanıtlayacak kesin delillerden birisine sahip olup olmadığına bakacaktır.

İşte adlî yardım kurumunun temelinde de, ödeme gücünden yoksun olmakla birlikte, talepte bulunan herkesin değil, davadaki talepleri (davacı veya davalı olarak) "açıkça dayanaktan yoksun olmayan" kişilerin bu tür bir olanaktan yararlanması yatmaktadır. Çünkü eğer adlî yardım talebinde bulunan ve kendisine adlî yardım sağlanan taraf davada haklı çıkarsa, yargılama gi-

---

[2] Yalnızca m. 334, 1'de değişiklik yapıldığı için tüzel kişiler bakımından **"iddia ve savunmalarında haklı görünme"** ölçütü korunmuştur.

derlerinden nihaî olarak karşı taraf sorumlu olur. Bu anlamda kanun koyucu, adlî yardım talebinde bulunanların ödeme güçleri yanında, davadaki talepleri bakımından, deyiş yerindeyse, ellerinin güçlü olup olmadığına da bakma ihtiyacı duymaktadır. O halde, adlî yardım sağlanmasında bu iki koşul birlikte aranır.

C) ADLÎ YARDIMIN KAPSAMI

Yukarıda da belirtildiği gibi, adlî yardım, yargılama giderlerini karşılama gücünden yoksun olan kişilere bir kolaylık, bir muafiyet sağlamaktadır. Ancak bu muafiyet, geçicidir.

Yargılama giderleri, harç ve diğer giderleri kapsayan bir üst kavramdır (m. 323). Adlî yardım da esasen hem harç ödenmesi hem de yapılması gereken giderlerden **geçici bir muafiyet** sağlar. Şöyle ki, adlî yardım talebi kabul edilen taraf, yargılama harçlarını ödemekten muaf olur; buna karşılık, yargılama sırasında yapılacak tebligat gideri, delil avansı veya davacı bakımından gider avansı gibi masraf kalemlerinden muafiyet değil; bunların Devlet hazinesinden avans olarak ödenmesi söz konusudur.

Adlî yardımın kapsamı kural olarak, yargılama harç ve giderlerinden[3] ve teminat gösterilmesi gerekiyorsa[4] bundan geçici bir muafiyet veya ödenmesi gereken masrafın Devlet hazinesinden karşılanması olarak tespit edilmiştir (m. 335). Buna karşılık, adlî yardım talebinin kabulü, bu kişiye aynı zamanda bir vekil tayinini sağlamaz; dolayısıyla mahkeme tarafından bu konuda ayrıca bir karar verilmedikçe, adlî yardım kararı vekil tayinini kapsamaz. Nitekim Kanunda, "davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini"nin de adlî yardım kapsamında olabileceği (m. 335, 1/ç), düzenlemesi yer almaktadır.

Mahkeme, adlî yardım talebini kabul ederse adlî yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder (m. 335, 3).

D) ADLÎ YARDIM TALEBİ, İNCELEME, KARAR VE SONUÇLARI

Adlî yardım, **asıl talep bakımından görevli ve yetkili mahkeme**den istenir (m. 336, 1). Kanun yollarına başvuru sırasında adlî yardım talebi istinaf (bölge adliye) mahkemesine veya Yargıtaya yapılır (m. 336, 3).

---

[3] Yargılama giderleri, harçlar, giderler ve vekâlet ücreti olarak sayılabilir. HMK m. 323'te tüm bu hususlar birlikte düzenlenmiş ve burada harçlar, giderler ve vekâlet ücreti yer almıştır.

[4] HMK, gerek dava açarken gerekse takip yaparken bazı durumlarda dava (takip) şartı olarak teminat gösterilmesini aramaktadır (m. 114, 1/ğ; 84 vd.). Buna göre örneğin, mutad meskeni Türkiye'de bulunmayan Türk vatandaşı davacı, dava açarken, yargılama giderlerini karşılayacak ölçüde bir teminat göstermelidir. Yine ödeme güçlüğü içinde bulunan, hakkında aciz belgesi düzenlenen bir kimse ya da iflâsına karar verilmiş olan kimse, Türkiye'de yerleşim yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın dava açarken teminat göstermek zorundadır. Ancak bunların dışında da, Kanun çeşitli gerekçelerle teminat gösterilmesini aramaktadır. Örneğin, geçici hukuki korumalarda, ihtiyati tedbir veya ihtiyati hacizde teminat gösterilmesi gerektiği gibi, eski hale getirme, ıslah vb. bazı durumlarda da teminat gösterilmesi şarttır. İşte bu hallerde, bu yükümlülüğü yerine getiremeyecek kişiler de adlî yardım talep edebilirler.

Adlî yardım talebi, dava açmadan önce veya davayla birlikte talep edilebilir. Bu talep, dava ile birlikte veya tek başına yapılmış olsa bile, her türlü harç ve vergiden muaftır (m. 336, 4). O nedenle bu talepte bulunan kişiden gider avansı, başvurma harcı vb. gibi ödeme talep edilemez.

Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren malî durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır (m. 336, 2). Uygulamada genellikle Sosyal Güvenlik Kurumundan bağlanmış bir gelirin bulunmadığına veya taşınmaz ya da taşınır mallarının olmadığına ilişkin, örneğin, tapu ya da trafik sicilinden alınan belgeler ibraz edilmektedir. Talebin açıkça dayanaktan yoksun olup olmadığı konusunda ise, hâkim bir inceleme yapar, ancak bu inceleme genel olarak davada gerçekleşecek tahkikat gibi değildir. Kuşkusuz, talebin açıkça dayanaktan yoksun olmaması şartının gerçekleştiği konusunda, yaklaşık ispat ölçüsünde de olsa, hâkimde bir kanaatin oluşması gerekir.

Mahkeme, adlî yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir. Ancak, talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adlî yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir (m. 337, 1).

Adlî yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adlî yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adlî yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir. Adlî yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir (m. 337, 2).

Adlî yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz, dolayısıyla talebin kabul edildiği tarihten sonra yapılacak giderler bakımından bir muafiyet söz konusu olur (m. 337, 3).

Öte yandan, adlî yardımdan yararlanan kişinin malî durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan malî durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adlî yardım kararı kaldırılır (m. 338).

E) ADLÎ YARDIMLA ERTELENEN YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ

Adlî yardım kararının, yararlanan bakımından geçici bir muafiyet sağladığı yukarıda belirtilmişti. Burada iddiasında veya talebinde haklılık payı olduğu düşünülen tarafın, sırf ekonomik nedenlerle dava açamaması veya savunma yapamaması gibi bir durumla karşılaşmaması için Devletin bir yardımı veya katkısı söz konusu olmaktadır. Sonuçta, adlî yardımdan yararlanan taraf, iddia veya savunmasında haklı çıkarsa, onun aleyhine yargılama gide-

rine hükmedilmez; Devlet tarafından onun adına avans olarak ödenen paralar veya yatırılmayan harçlar, davada haksız çıkan karşı taraftan tahsil edilir (m. 339, 1).

Buna karşılık, sorun, adlî yardımdan yararlanan tarafın haksız çıkması durumunda olacaktır. Zira, bu olasılıkta, adlî yardımdan yararlanan taraf, yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Bu durumda geçici olarak muaf olduğu yargılama harçları ile Devlet tarafından avans olarak ödenen paraların kendisinden tahsil edilip edilmeyeceği gündeme gelir. Bu konuda Kanunumuz, kural olarak, "adlî yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar verilebilir" düzenlemesini getirmiştir (m. 339, 1). Buna göre, adlî yardımdan yararlanan, ancak haksız çıkan taraf, Devlete geri ödeme yapmak zorundadır. Ancak kanun koyucu bu düzenlemeyi yumuşatan bir hükümle, bu kuralın uygulanmayabileceğini de belirtmektedir. Buna göre, "adlî yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adlî yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir" (m. 339, 2).

Mahkemenin adlî yardım kararının, bir avukatla temsili de içermesi halinde, avukata ödenecek ücret de yargılama gideri olmakla birlikte, bu avukatın ücretinin doğrudan doğruya Hazine tarafından ödeneceği de hükme bağlanmıştır (m. 340). Böylece, avukat ücretinin geciktirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

Buraya kadar incelediğimiz HMK m. 334-340 hükümlerinden başka, **Avukatlık Kanunu**nda da adlî yardım müessesesi yalnız avukatlar bakımından ayrıca düzenlenmiştir (AK m. 95, 11; 176-181). Buna göre, asliye mahkemesi bulunan ve avukat sayısı beşten fazla olan her yerde, bir adlî yardım bürosu kurulur (AK m. 176).

Bu adlî yardım bürosu, hem mahkemece kendisine avukat tayin edilmesine karar verilmiş olan (m. 335, 1/ç) kimseye bir avukat tayin eder, hem de doğrudan adlî yardım talebi ile bu büroya başvuran ve talebinde haklı görülenler için yetkili mahkemeden adlî yardım kararının alınması için gerekli işlemleri yapar (AK m. 178). Bundan başka, bu adlî yardım bürosu, adlî yardım talebi ile doğrudan büroya başvuranlara, bir avukat tayin edilmesine de karar verebilir (AK m. 178-179).

HMK'nun adlî yardıma ilişkin hükümleri (m. 334-340), idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştayda da, uygulanır[5].

---

[5] Bkz. Ejder Yılmaz, Adlî Yardım Kurumunun İdarî Yargıda Uygulanması (Mali Hukuk, 1987/7, s. 12-23; Yılmaz, Makaleler C. 1, s. 565-576).

BASİT YARGILAMA USULÜ ve ÇEKİŞMESİZ YARGI

§ 69. BASİT YARGILAMA USULÜ

Basit yargılama usulü (m. 316-322), kanunlarda açıkça belirtilen bazı davalar ve işler (örneğin, İİK m. 18-19, 158, 271; MÖHUK m. 55; Kadastro K. m. 29) ile HMK'nun 316. maddesinde yer alan dava ve işlerde uygulanan ve yazılı yargılama usulünden (m. 118-186) daha basit ve çabuk işleyen bir yargılama usulüdür.

A) BASİT YARGILAMA USULÜNE TÂBİ DAVA ve İŞLER

Basit yargılama usulü, genel usul olan yazılı yargılama usulünün aksine, istisnaî bir usuldür; yalnızca, kanunların açıkça gösterdiği dava ve işler hakkında uygulanır.

Aşağıda örnek olarak gösterilen dava ve işler, basit yargılama usulüne tâbidir.

1) **Sulh hukuk mahkemeleri**nin görevine giren dava ve işler (m. 316, 1/a);

2) Duruşma yapmadan doğrudan **dosya üzerinden karar** vermek konusunda kanunun **mahkemeye takdir hakkı tanıdığı dava ve işler**;

3) **İhtiyatî tedbir** (m. 389 vd.), ihtiyatî haciz (İİK m. 257 vd.), delil tespiti (m. 400-405) gibi **geçici hukukî koruma talepleri** ile deniz raporlarının alınması (TTK m. 1098), dispeççi atanması (TTK m. 1280 vd.) talepleri ve bunlara karşı yapılacak itirazlar (m. 316, 1/c);

4) **Her çeşit nafaka davaları**[1] ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler (m. 316, 1/ç);

5) **İş davaları** (İş Mahk. K. m. 7, 1) ve **hizmet ilişkisinden** (TBK m. 393 vd.) doğan davalar (m. 316, 1/d),

6) İcra mahkemesine yapılan başvurular (İİK m. 18),

7) **Konkordato** ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin **uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılma**sına ilişkin açılacak davalar (m. 316, 1/e),

8) **Tahkim** hükümlerine göre mahkemenin görevine giren dava ve işler[2] (m. 316, 1/f),

9) **Özel bir kanun hükmü** ile yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işler (m. 316, 1/g).

Örneğin miktar ve değeri **yüz bin lirayı geçmeyen ticarî davalar**da basit yargılama usulü uygulanır (TTK m. 4, 2). Ayrıca bkz. İİK m. 156, 158-166, 173, 174, 177-179, 181, 182, 235, 254, 296, 298-302, 307-309, 309a vd., 309m vd.; TTK m. 207, 1209, 1212, 1460; Kamulaştırma K. m. 37; Koop. K.

---

1 Bkz. TMK m. 169, 175, 182; 197, II; 364-365 gibi.

2 Bkz. HMK m. 407 vd.

m. 99, 2) yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işlerde basit yargılama usulü uygulanır (m. 316, 1/g).

Öte yandan, HUMK'nun düzenlediği sözlü yargılama usulü ile seri yargılama usulü, HMK'na alınmamıştır. Ancak, HUMK'nun yürürlükte olduğu dönemde, çeşitli kanunlarda, sözlü yargılama usulüne ve seri yargılama usulüne atıflar yapılmış bulunmaktadır. HMK m. 447, 1 hükmüne göre, diğer kanunların, **sözlü yargılama usulü**ne veya **seri yargılama usulü**ne (yani HUMK hükümlerine) atıf yaptığı hallerde HMK'nun basit yargılama usulü hükümleri (m. 316-322) uygulanır (m. 447, 1).

B) YARGILAMA USULÜ

Basit yargılama usulünde, **dava açılması** ve davaya **cevap verilmesi, dilekçe ile** olur (m. 317, 1). Dava ve cevap dilekçeleri, Yönetmelikte belirlenecek **formun doldurulması** suretiyle de verilebilir (m. 317, 4; Y m. 198).

Dava veya cevap dilekçesi formu, fizikî ortamda tevzi bürosu ya da ön bürodan temin edilerek doldurulması suretiyle verilebilir. Dava ve cevap dilekçesi formlarının elektronik ortamda verilebilmesi için, güvenli elektronik imza sahibi olunması gerekir. Aksi halde, dava ve cevap dilekçesi formları elektronik ortamda doldurulduktan sonra alınacak çıktısı el ile imzalanır (Y m. 198, 5-6).

Basit yargılama usulüne göre görülen davada taraflar; **dilekçeleriyle birlikte, tüm delillerini** açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de, bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadırlar (m. 318, 1). Çünkü, delillerin dilekçeyle birlikte verilmesi ve ilgili yerlerden getirtilmesi, yargılamada önemli bir aşamayı oluşturur; yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve uzayıp uzamaması bakımından önem taşır. 318. madde hükmü, basit yargılama usulünün amacına uygun olarak, kısa sürede tüm delillerin toplanarak incelenmesi gerekçesiyle kabul edilmiştir.

Dava dilekçesi formunda, mahkemenin adı; davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davacının T.C. kimlik numarası ile varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik numarası; varsa tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri; davanın konusu; davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri; iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği; dayanılan hukukî sebepler; açık bir şekilde talep sonucu ile davacının varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin imzası bulunur (Y m. 198, 1-3).

Davalı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren **iki hafta içinde cevap dilekçesi** verebilir. Ancak, mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre dolmadan mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve **iki haftayı geçmemek üzere** ek bir süre verebilir ve bu konudaki karar derhal taraflara bildirilir (m. 317, 2).

Cevap dilekçesi formunda, mahkemenin adı; davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres; davalının T.C. kimlik numarası ile varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik numarası; varsa, tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri; davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri; savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği; dayanılan hukukî sebepler; açık bir şekilde talep sonucu ile davalının veya varsa kanunî temsilcisinin yahut vekilinin imzası bulunur (Y m. 198, 4).

Basit yargılama usulünün uygulandığı dava ve işlerde (yazılı yargılama usulünden farklı olarak -m. 136-) taraflara, **cevaba cevap** ve **ikinci cevap verme hakkı tanınmamıştır** (m. 317, 3)[3].

Dava dilekçesini alan mahkeme, mümkün olan hallerde, tarafları duruşmaya davet etmeden **dosya üzerinden** karar verir (m. 320, 1). Bu hüküm, yazılı yargılama usulünden farklı olarak, hâkimin, işin niteliği elverdiği ölçüde, duruşma yapmadan, esasa yönelik de karar verebilmesini sağlar. Ancak, Yargıtay, duruşma yapmadan esasa yönelik karar verilemeyeceği görüşündedir.

Dosya üzerinden karar verilemeyen hallerde ise mahkeme, bir duruşma günü tayin ederek tarafları bir davetiye ile ilk duruşmaya davet eder. Bu duruşma davetiyesi de, tamamen m. 144 ve 147 hükümlerine göre düzenlenir. Başka bir deyişle, basit yargılama usulünde tarafların duruşmaya çağrılması, ön inceleme ve tahkikata (yargılamaya) gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilmesi, tamamen yazılı yargılama usulünde olduğu gibidir.

Basit yargılama usulünde mahkeme, (yazılı yargılama usulünde olduğu gibi -m. 140- ayrı bir ön inceleme duruşması yapmaz) **ilk duruşma, ön inceleme amaçlı yapılır.** Mahkeme, ilk duruşmada diğerlerinin yanı sıra, öncelikle dava şartları (m. 114) ve ilk itirazlarla (m. 116), hak düşürücü süre ve zamanaşımı (TBK m. 146 vd.) hakkında tarafları dinler; anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, iddia ve savunmaları çerçevesinde, tek tek tespit eder; tarafları sulhe (m. 313 vd.) teşvik eder ve sulh olamazlarsa anlaşamadıkları hususları tutanağa yazar.

Tahkikat, bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür (m. 320, 2; karş. m. 137 vd.). Başka bir anlatımla, ilk duruşma tutanağı, yapılacak tahkikat bakımından bir yol haritası niteliğindedir. Basit yargılama usulünde, kural olarak, ön inceleme ve tahkikat duruşması birlikte yapılır; yani, yazılı yargılama usulünde olduğu gibi, mutlaka ayrı bir **ön inceleme duruşması öngörülmemiştir.**

Mahkeme, **tahkikatı** ilk duruşma hariç, kural olarak, **iki duruşmada tamamlar** ve duruşmalar arasındaki süre, **bir ay**dan uzun olamaz (m. 320, 3/c. 1-2). Ancak, işin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması, istinabe yo-

---

[3] Anayasa Mahkemesi bu hükmün hak arama özgürlüğünü sınırlayıcı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 22.03.2012 gün ve 125/46 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 127-130.

luyla tahkikat yapılması gibi, istisnaî zorunlu durumlarda, gerekçesi belirtilmek suretiyle, ikiden fazla duruşma yapılabilir ve duruşma araları bir aydan fazla olabilir (m. 320, 3/c. 3). Kanımızca, buradaki istisnanın çok sınırlı hallerde uygulanması, HMK'nun amacına ulaşması bakımından çok önemlidir.

İki taraf da, usulüne göre davet edildikleri duruşmaya gelmezlerse, **dosyanın işlemden kaldırılması**na karar verilir (m. 150) Bu dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır (m. 320, 4). Görüldüğü gibi, basit yargılama usulünde, dava dosyası yalnızca **bir kez** (karş. m. 150, 6) **yenilenebilir**.

İddianın ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı, basit yargılama usulünde de geçerlidir. Ancak yasağın başlangıcı, basit yargılama usulünde farklı düzenlenmiştir. Basit yargılama usulüne tâbi davalarda **davacı, dava açılması** (m. 322'in yollama yaptığı m. 118) anından itibaren davasını (iddiasını); **davalı, cevap dilekçesini mahkemeye verdiği** (322'in yollama yaptığı m. 126, 2) **andan itibaren savunmasını genişletemez veya değiştiremez** (m. 319). Oysa yazılı yargılama usulünde taraflar, dava ve cevap dilekçelerinde söylediklerini ikinci dilekçe (m. 136) ile değiştirebilirler; basit yargılama usulünde ikinci dilekçe verme olanağı bulunmadığından (m. 317, 3), yasak, dava dilekçesi ve cevap dilekçesi ile başlamaktadır. Keza, yazılı yargılama usulünde, taraflardan birinin mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına gelmemesi halinde diğer tarafın iddia veya savunmasını değiştirebilmesi olanağı var ise de (m. 141, 1/c. 2), basit yargılama usulünde (m. 319) tarafa bu tür bir olanak verilmemiştir. Bu sebeple, basit yargılama usulüne tâbi dava ve işlerde taraflar daha dikkatli davranmalı, talep ve savunmaları konusunda daha titiz olmalıdırlar.

Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme. tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder (yüzlerine sözlü olarak bildirir; m. 321, 1/c. 1; m. 294; karş. m. 184, 186). Yani, yazılı yargılama usulünde olduğu gibi, ayrı bir sözlü yargılama aşaması yoktur. Ayrıca taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez (m. 322, 1/c. 2).

Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçeli olarak açıklanması ile yapılır. Ancak, zorunlu hallerde, gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir (m. 321, 2).

Yukarıda incelenen özel hükümler dışında, basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler hakkında da yazılı yargılama usulü kuralları (m. 118 vd.) uygulanır (m. 322, 1).

§ 70. ÇEKİŞMESİZ YARGI[1]

A) GENEL BİLGİ

Yukarıda da görüldüğü üzere, çekişmesiz yargı (nizasız kaza), çekişmeli yargıdan farklı özellikleri bulunan bir yargı çeşididir. Bu sebeple bazı ülkelerde (örneğin, Avusturya, Almanya), çekişmesiz yargı işleri için, ayrı (özel) bir yasal düzenleme bulunmaktadır. Ülkemizde çekişmesiz yargı konusunda ayrı bir kanun bulunmadığı gibi, HUMK da çekişmesiz yargıyı düzenlememekte idi. Buna karşılık, çeşitli kanunlarımızda çekişmesiz yargı ile ilgili dağınık bazı hükümler ve yetersiz usulî hükümler vardı.

Yeterli (ve ayrı) bir düzenleme bulunmaması sebebiyle uygulamada çekişmesiz yargı işleri de bir dava gibi algılanmış ve çekişmesiz yargı işlerine de HUMK hükümleri uygulanagelmiştir. Ancak, bu durum sebebiyle çekişmesiz yargı, uygulamada gereği gibi anlaşılamamış ve çeşitli karışıklıklara da sebebiyet vermiştir.

Bu eksikliği gidermek amacıyla, HMK'nun, "çekişmesiz yargı" başlığını taşıyan dokuzuncu kısım hükümleri (m. 382-388) kabul edilmiştir.

B) ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ

Bir işin çekişmesiz yargı işi sayılabilmesi için, şu **üç temel ölçütten** birinin veya birkaçının varlığı gerekir: a) İlgililer arası bir **uyuşmazlığın** (ihtilâfın) **bulunmaması**; b) **Başka birine** (bir muhataba) **karşı ileri sürebilecek** ve onun aleyhine (kendi lehine) karar verilmesini gerektiren herhangi bir **hakkın olmaması**; c) Hâkimin **kendiliğinden** (resen) **harekete geçtiği bir halin varlığı** (m. 382, 1).

Kanun (m. 382, 2), birinci fıkradaki genel çerçevenin dışında; kolaylık sağlamak üzere, öğreti ve Yargıtay kararlarında kabul edilen çeşitli çekişmesiz yargı işlerini; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra-iflâs hukuku ve çeşitli kanunlar kategorileri çerçevesinde örnek olarak saymıştır. Örneğin, ergin kılınma (TMK m. 12), gaiplik kararı (TMK m. 32), henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin verme (TMK m. 126-128), konutu terk eden eşe davet (TMK m. 188), velayetin kaldırılması (TMK m. 348), vesayet işleri (TMK m. 396 vd.), mirasçılık belgesi verilmesi (TMK m. 598), terekenin resmî defterinin tutulması (TMK m. 619 vd.), taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini, tevdi mahalli belirlenmesi (TBK m. 124), komisyoncu elindeki malın açık artırma ile satışına izin verilmesi (TBK m. 648), ticari defterlerin ziyaı halinde belge verilmesi, kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini (TTK m. 333), kıymetli evrakın iptali (TTK m. 739-741), iflasın kaldırılması (İİK m. 182), kon-

---

[1] Bkz. Baki Kuru, Nizasız Kaza, Ankara 1961.

kordato mühleti verilmesi ve komiser atanması (İİK m. 287), nüfus kütüklerinin sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahkemesince mühürlenmesi, noterlerin göreve başlarken mahkemede yemin ettirilmesi gibi.

Çekişmesiz yargı işleri, HMK m. 382, 2'de belirtilen hallerden ibaret (numerus clausus) olmayıp, burada yer alanlar yalnızca örnek olarak belirtilen hallerdendir. HMK m. 382, 2'de sayılmasa dahi, temel ölçütlere (m. 381, 1) uyan diğer haller de, çekişmesiz yargı işi olarak kabul edilir.

C) ÇEKİŞMESİZ YARGI USULÜ[2]

Çekişmesiz yargı işlerinde genel **görevli mahkeme**, kanunda aksine bir düzenleme[3] bulunmadıkça, **sulh hukuk mahkemesi**dir (m. 384).

Yetkili mahkeme, kanunda aksine hüküm yoksa, çekişmesiz yargı için **talepte bulunan kişinin** veya ilgililerden birinin **oturduğu yer mahkemesidir** (m. 384; karş. m. 5 vd.).

Kanun (m. 385, 1), çekişmesiz yargı işlerinde, niteliğine uygun düştüğü oranda, **basit yargılama usulü** (m. 316-322) hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir. Kanunda kullanılan "niteliğine uygun düştüğü oranda" ibaresi, çekişmesiz yargı bakımından çok anlamlı olup, aslında basit yargılama usulü hükümleri, çekişmesiz yargıda çok sınırlı bir biçimde uygulanabilir. Çünkü çekişmesiz yargı, çekişmeli yargıdan farklı olarak, bir dava olmadığı için, davacı ve davalı taraf ve buna bağlı olarak dava ile ilgili pek çok durum, çekişmesiz yargıda gündeme gelmez.

Çekişmesiz yargıda, "dava" değil "**talep**" ve buna paralel olarak davacı değil, "**talepte bulunan**" kişi veya "**ilgili**" kişi (m. 384) vardır. Bu sebeple örneğin, basit yargılama usulündeki davaya cevap ile ilgili hükmün (m. 317) çekişmesiz yargı bakımından uygulanabilirliği söz konusu olmaz. Keza, çekişmesiz yargıda talep edenin (ilgilinin) karşısında bir hasım (karşı taraf) bulunmaması sebebiyle, iddianın ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı hükmünün (m. 319) çekişmesiz yargıda uygulanabilmesi, kural olarak, mümkün değildir; kaldı ki, çekişmesiz yargıda **kendiliğinden araştırma ilkesinin** geçerli olması (m. 385, 2) da bu konuda önem taşımaktadır.

Benzeri şekilde, çekişmesiz yargı işleri, genellikle **dosya üzerinden** incelenip karara bağlanacak türden ve **acele** karar alınmasını gerektiren hususlardır. Bu nedenle, basit yargılama usulüyle ilgili ön inceleme ve tahkikata ilişkin m. 320 hükmü, çekişmesiz yargıda çok sınırlı bir şekilde uygulanabilir. Bu çerçevede, genel olarak duruşma yapılmayabilir (karş. m. 320, 1-3); duruşma açılması (yapılması) halinde, talepte bulunan gelmese bile dosyanın işlemden kaldırılması (m. 150) ve buna bağlı olarak dosyanın yenilenmesi söz konusu olmaz (karş. m. 320, 4). Çekişmesiz yargının özelliği gereği, hükmün tefhimine gerek yoktur ve gerekçeli kararın yazımı için öngörülen bir aylık süre çekişmesiz yargı için çok uzundur (karş. m. 321).

---

2 Bkz. Aslı Aras, Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, Ankara 2017.

3 Örneğin nüfus işlerinde görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesi; konkordato mühleti verilmesinde (İİK m. 285) ve iflâsın kaldırılmasında (İİK m. 182) asliye ticaret mahkemesidir.

Basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler (m. 118-315) uygulanır (m. 322). Dolayısıyla, dava dilekçesinin içeriği (m. 118) hakkında basit yargılama usulü hükümleri arasında düzenleme bulunmadığı için, m. 118 hükmü, basit yargılama usulüne tâbi bir davada uygulanacaktır. Ancak çekişmesiz yargı işi, bir dava olmadığından, çekişmesiz yargı için mahkemeye başvuran kişinin vereceği dilekçenin içeriği, dava dilekçesinin içeriği (m. 118) gibi değildir. HUMK'nun yürürlükte olduğu dönemde, çekişmesiz yargı hakkında açık hüküm bulunmaması sebebiyle, çekişmesiz yargı işlerinde de başvuru dilekçesi, genellikle aynen dava dilekçesi gibi hazırlanmakta, davacı ve davalı tabirleri kullanılmakta idi. Oysa bugün HMK'nda çekişmesiz yargı açık bir şekilde düzenlendiğinden, başvuru dilekçesi çekişmesiz yargının niteliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Çekişmesiz yargıda uygulanacak olan usul, niteliğine uygun olduğu oranda basit yargılama usulü hükümleri olmakla birlikte; mühürleme (m. 382, 2/g, 1), deftere geçirme (m. 382, 2/c, 8) ve yemin tutanağı (m. 382, 1/g, 2, 4) gibi çekişmesiz yargı işlerinde uygulanacak usul açısından, basit yargılama usulü hükümleri elverişsizdir. Bu gibi çekişmesiz işlerde uygulanacak usul, konusunda m. 387 hükmü konulmuş ve Yönetmelikte bu konu düzenlenmiştir (Y m. 209-211).

Mühürleme (m. 386; 382, 2/g, 1), taşınır malların koruma altına alınması amacıyla bir yerde tutularak kullanılmasının önlenmesi veya bir taşınmazın kullanılmasının, değiştirilmesinin önlenmesi ya da belirli bir faaliyetin durdurulmasıdır. Taşınır mallar deftere geçirildikten sonra bir torba veya kapalı bir yere konularak muhafaza altına alınır ve uygun araçlarla mühürlenir. Taşınmazlarda mühürleme işlemi, taşınmaza giriş ve çıkışın engellenmesi veya bir faaliyetin önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Mühürleme işlemleri yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından yer, gün ve saat belirtilip tutanağa bağlanarak imzalanır (Y m. 209).

Defter tutma (deftere geçirme) (m. 386; 382, 2/c.8), taşınır ve taşınmaz mallar ile borç, alacak ve hakların kayıt altına alınmasıdır. Defter tutma işlemleri, yazı işleri müdürü, yazı işleri personeli veya bilirkişi eliyle yaptırılabilir. Defter tutma işleminde, taşınır malların sıra numarası, cinsi, adeti, miktarı, nerede bulundukları, değeri; taşınmaz malların sıra numarası, tapu veya diğer tanım bilgileri, değerleri; borç, alacak ve hakların sıra numarası, niteliği, vadesi ve miktarı, borçlu, alacaklı ve hak sahibinin kimlik bilgileri, kayda geçirilir. Defter tutma işlemleri elektronik ortamda yapılır. Zorunlu hallerde fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Defter tutma işlemi fizikî ortamda yapıldığı takdirde defterin her sayfası ayrı ayrı numaralandırılır, imzalanır ve mühürlenir. Defterin sonu görevli personel veya bilirkişi tarafından imzalanır. Elektronik veya fizikî ortamda tutulan defter ilgili hâkim tarafından güvenli elektronik imza ya da el ile imzalanarak onaylanır (Y m. 210).

Yemin tutanağı (m. 386; 382, 1/g, 2, 4), mevzuat uyarınca hâkim huzurunda yemin etmeleri gereken kamu görevlileri, (örneğin noterler) bilirkişiler

ve diğer kişilerin yapacakları yemine ilişkin düzenlenen tutanaktır. Yemin tutanağında, mahkemenin veya hukuk dairesinin adı, hâkimin ve zabit kâtibinin adı ve soyadı, sicili, imzası; yemin eden kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası; yeminin yapıldığı yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alır. Yemin tutanağı yaptırılan yeminin niteliğine göre taşıması gereken diğer kayıtları da içerir. Yemin tutanağı elektronik ortamda düzenlenir. Zorunlu hallerde fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır (Y m. 211).

HMK m. 387 hükmüne göre; çekişmesiz yargı işlerinde verilen karara karşı hukukî yararı (menfaati) bulunan ilgililer, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, **istinaf yolu**na başvurabilirler. Ancak, çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar **temyiz edilemez** (m. 362, 1/ç). Bu konudaki özel hükümler saklıdır (m. 387) (bu konuda bkz. HUMK geçici m. 3).

Aksine kanunî düzenleme bulunmadıkça, çekişmesiz yargı kararları, nitelikleri gereği, **maddî anlamda kesin hüküm** (m. 303) **oluşturmaz** (m. 388). Bu sebeple, çekişmesiz yargıda verilen ve kanun yoluna gitmeden veya gittikten sonra şekle kesinleşen hükme rağmen, aynı konuda yeniden talepte bulunmak mümkündür[4]. Yeniden yapılan talep, çekişmeli yargıdaki kuralın aksine, kesin hükmün varlığı sebebiyle reddedilmez. Kararın haksız olduğunun anlaşılması veya koşulların değişmesi halinde, verilen kararın değiştirileceği kabul edilmektedir. Ancak çekişmesiz yargıda verilen kararın maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmemesi, kararın her zaman değiştirilebileceği anlamına gelmez. Çünkü kararların değiştirilebilirliği, hukukî istikrar ve güveni sarsar. Bu nedenle, her durumda olmamakla beraber, çekişmesiz yargıda verilen kararın haksız, hukuka ve gerçeğe aykırı olması halinde, talepte bulunanın hukukî yararı bulunması üzerine değiştirilebilmesi mümkündür.

---

4 Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Mahkeme Kararıyla Düzeltilmiş Nüfus Kayıtları Hakkında Tekrar Mahkemeye Başvurulabilir mi? (Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, Ankara 2014, C. II, s. 1851-1879).

ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER

Kitabımızın buraya kadar olan kısmında, genel görevli mahkemeleri (asliye hukuk, asliye ticaret ve sulh hukuk mahkemeleri) ve bu mahkemelerde uygulanan yargılama usullerini gördük. Aşağıda ise, özel görevli mahkemelerin kuruluşu ve görevleri ile bu mahkemelerde uygulanan yargılama usullerini inceleyeceğiz.

§ 71. AİLE MAHKEMELERİ[1]

A) AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

Anayasanın 41. maddesine göre, ailenin korunması Devlete ait bir görevdir. Günümüzde birçok sahada olduğu gibi sosyal yapıdaki gelişmelerin ve karmaşıklığın, eşlerin ve çocuklarının da sorunlarının artmasına ve olumsuzluklar yaşanmasına neden olmaktadır.

Bir çok ülkenin iç hukukunda aile mahkemelerine ilişkin hükümler yer almasına rağmen, ülkemizde aileye ilişkin dava ve işlerde genel mahkemelerde görüldüğünden ve bu mahkemelerin aileye ilişkin davaların yanı sıra diğer hukuk davalarına da bakmak durumunda olmalarının sakıncaları vardı. Özellikle, ayrıca aile ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde ihtiyaç duyulan, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların genel görevli mahkeme bünyesinde bulunmaması, mevcut mahkemelerin aile hukukundan doğan dava ve işlerin çözümlenmesinde kendilerinden beklenen işlevi yeterince yerine getirmesine engel olmakta idi. Bu nedenlerle ve TMK'nun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerinden beklenen amacın gerçekleşmesi bakımından da aile mahkemelerinin kurulmasının bir ihtiyaç haline geldiği gerekçesiyle; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (4787 s. K.) ile aile mahkemeleri kurulmuştur.

Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca HSK'nun olumlu görüşü alınarak **her il**de ve **merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçe**de, **tek hâkimli** ve **asliye mahkemesi derecesi**nde olmak üzere kurulur.

Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî (idarî) sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca değiştirilebilir (4787 s. K. m. 2, I). Gerektiğinde, 1. fıkradaki usule göre bir yerdeki aile mahkemesinin birden çok dairesi kurulabilir. Bu durumda daireler numaralandırılır.

Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, HSK'nca belirlenen asliye hukuk mahkemesince bakılır (4787 s. K. m. 2, II).

---

[1] Bkz. Selma Baktır Çetiner, Aile Mahkemeleri, Ankara 2003; Süha Tanrıver, Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014.

B) AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

Aile mahkemeleri, TMK'nun Üçüncü kısım (**vesayet**; TMK m. 396-494, hariç olmak üzere), İkinci Kitabı (TMK m. 118-395) ile Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre **aile hukukundan doğan dava ve işler**; Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının **tanıma** ve **tenfizi** ile kanunlarla verilen **diğer görevleri yaparlar** (4787 s. K. m. 4).

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, görev alanına giren konularda, **yetişkinler hakkında**: evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya, resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye, bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye; **küçükler hakkında:** bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya, genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir (4787 s. K. m. 6,I).

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5. maddeye göre atanan **uzmanlar**dan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde HMK'nun 398. maddesi uygulanır (4787 s. K. m. 6, II; HMK m. 447, 2).

Aile mahkemelerine, adlî yargıda görevli, **tercihan evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş** ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan **hâkimler** arasından HSK tarafından **atama yapılır** (4787 s. K. m. 3).

C) AİLE MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ

Her aile mahkemesine; davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin **araştırma ve inceleme yapmak** ve sonucunu bildirmek; mahkemenin gerekli gördüğü hallerde **duruşmada hazır bulunmak**, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve **görüş bildirmek**; mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer **psikolog, pedagog** ve **sosyal çalışmacı** atanır. Bu kişiler yargı görevi yapmazlar; sadece mahkemeye yardımcıdırlar. Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması

hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır. Bu **uzmanlar,** HMK'nda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine (m. 36) göre reddolunabilir (4787 s. K. m. 5; HMK m. 447, 2).

Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların **sulh yoluyla çözümü**nü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir (4787 s. K. m. 7, I).

Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Aile Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkında Kanunda hüküm bulunmayan konularda, Türk Medenî Kanununun aile hukukuna ilişkin usul hükümleri ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır (4787 s. K. m. 7, II; HMK m. 447, 2). 4787 s. K.'nun 7. maddesi sınırlı bir düzenleme yapmıştır. TMK'nda aile hukukundaki dava ve işlere özgü bir kısım usul hükümleri yer almaktadır (örneğin TMK m. 184[2]). Bunun dışında aile mahkemeleri kural olarak yazılı yargılama usulü uygular.

---

[2] Bkz. Tolga Akkaya, Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Ankara 2017.

§ 72. İCRA MAHKEMELERİ

İcra mahkemesi[1], hukukî durumu (görevleri, yaptığı yargılama ve kararları) itibariyle, sulh veya asliye hukuk mahkemesi anlamında bir hukuk mahkemesi olmayıp, icra-iflâs işleri için kurulmuş özel bir mahkeme konumundadır (İİK m. 4).

Bununla birlikte icra mahkemesi, görevine giren icra-iflâs işleri hakkında karar verirken, diğer mahkemeler gibi, bağımsız bir mahkeme olarak, objektif hukuku belirli olaylara uygulamaktadır; yani, maddî anlamda yargı görevi yapmaktadır.

İcra mahkemesinde uygulanan yargılama usulü, **basit yargılama usulü**dür (İİK m. 18, 97, 251).

İcra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları özel hükümlerle düzenlenmiştir (İİK m. 353, 363 vd.).

İcra mahkemesi kararları, kural olarak, maddî anlamda kesin hüküm (HMK m. 303) teşkil etmez.

İcra mahkemesi kararlarının (kural olarak) maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmediği hallerde, bu kararlara karşı (kural olarak) yargılamanın iadesi yoluna da başvurulamaz.

---

[1] İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 5092 sayılı Kanun (Geçici m. 6), "**icra tetkik mercii**" tabirini, "icra mahkemesi"; "icra tetkik merci hâkimi" ibaresini, "icra hâkimi" olarak değiştirmiştir.

§. 73. İŞ MAHKEMELERİ

Genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ve çözümü, iş hukukunun niteliği dikkate alındığında, özel düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu nedenle, ülkemizde iş mahkemeleri, İş Mahkemeleri Kanunu (7036 sayılı) ile özel olarak düzenlenmiştir[1].

A) İŞ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

İş mahkemeleri, asliye hukuk mahkemesi derecesinde ve tek hâkimli olarak kurulur. Fakat her yerde bir iş mahkemesi yoktur; HSK'nun olumlu görüşü ile gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığı tarafından kurulur (İş Mahk. K. m. 2). Bu nedenle, iş mahkemelerini ikiye ayırarak incelemek gerekir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, İzmit, Karadeniz Ereğlisi, İskenderun gibi iş davalarının (uyuşmazlıklarının) çok olduğu yerlerde, asliye hukuk mahkemelerinin yanısıra **ayrı iş mahkemeleri** kurulmuştur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 5235 s. K. hükümlerine göre belirlenir. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir; ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı HSK tarafından belirlenir (İş Mahk. K. m. 2,1-2).

İş davası az olan yerlerde, ayrı bir iş mahkemesi kurulmaz. Bu yerlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu, iş davalarına bakmak üzere bir **asliye hukuk mahkemesi**ni görevlendirir. Bu asliye hukuk mahkemesi, iş davalarına **iş mahkeme sıfatıyla** İş Mahkemeleri Kanunundaki usul ve esaslara göre bakar (İş Mahk. K. m. 2, 3).

B) İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ

İş mahkemeleri **iş davaları**na bakarlar. Hangi davaların iş davası olduğu, İş Mahkemeleri kanununda (m. 5) ve bazı özel kanunlarda belirlenmiştir. Buna göre iş mahkemeleri:

a) **İş Kanunu**na veya Türk Borçlar Kanununda (m. 393-469) düzenlenen **hizmet sözleşmelerine tâbi işçiler** (5853 s. K.'na tâbi gazeteciler; 854 s.K.'na tâbi gemi adamları) ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına;

b) İdari para cezalarına itirazlar ile (5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere) **Sosyal Güvenlik Kurumu** veya **Türkiye İş Kurumu**nun taraf olduğu iş ve **sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan** uyuşmazlıklara,

---

[1] Bkz. Ejder Yılmaz, İş Mahkemeleri Kanununun Değiştirilmesi ihtiyacı (Sicil İş Hukuku Dergisi, 2007/8, s.5-12; Yılmaz, Makaleler Cilt 2, s.1507-1518.

c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.

C) İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA KURUMA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU[2]

Aşağıda (§ 79) görüleceği üzere, hukukumuzda arabuluculuk, kural olarak ihtiyaridir (HUAK m. 3). İş Mahkemeleri Kanunu, buna çok önemli bir istisna getirmiştir; iş uyuşmazlıklarında, bazı istisnalar[3] dışında **zorunlu arabuluculuk** söz konudur[4]. Bu nedenle davacının, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmuş olması gerekir. Davacının arabuluculuğa başvurmadan doğrudan iş mahkemesine dava açması halinde dava usulden reddedilir. Başka bir ifadeyle, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması **dava şartı**dır (İş Mahk. K. m. 3,1).

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddi-

---

2 7036 sayılı (yeni) İş Mahkemeleri Kanununun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz. Başka mahkemelerin görev alanına girerken bu Kanunla iş mahkemelerinin görev alanına dâhil edilen dava ve işler, iş mahkemelerine devredilmez; kesinleşinceye kadar ilgili mahkemeler tarafından görülmeye devam olunur. İlk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.01.2018) önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin hükümlere tâbidir (İş Mahk. K. geçici m.1).

3 **İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan** maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuk zorunlu değildir (İş Mahk. K. m. 3,3).

4 7036 s. K.'nun Gerekçesine göre: "... Tasarıyla kabul edilen önce arabulucuya başvurma zorunluluğunun, iş uyuşmazlıklarının **kısa süre içinde** ve daha **az masrafla çözülmesine** yardımcı olacağı düşünülmekte ve böylece adil yargılanma hakkının bir unsuru olan makul sürede yargılanma ilkesine riayet edilebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca bu yöntemin, maddi ya da şekli başka herhangi bir uyuşmazlığın doğmasını engellemek suretiyle uyuşmazlığı temelinden sonlandırması ve böylece sosyal barışa katkı sağlaması beklenmektedir. Arabuluculuk müzakerelerinin gizli olması dikkate alındığında, iki tarafın sırlarını korumaya elverişli bu yöntemde tarafların örselenmeden uyuşmazlığı sona erdirme imkanına sahip olacakları düşünülmektedir. 2012 yılında kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca iş uyuşmazlıkları, ihtiyari olarak arabulucuya götürülebilmektedir. 2013 yılı Kasım ayında ilk arabulucunun sicile kaydedilmesiyle başlayan uygulama sürecinde, bugüne kadar arabulucuya götürülen hukuk uyuşmazlıklarının yüzde 89'unun **işçi-işveren uyuşmazlığı olduğu ve bunların yüzde 93'e yakın oranda anlaşmayla sonuçlandığı görülmüştür**..." (bkz. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) ve Adalet Komisyonu Raporu, TBMM, Yasama Dönemi: 26 Yasama Yılı: **2, Sıra Sayısı: 491).**

ne karar verilir (İş Mahk. K. m. 3, 2). Görüldüğü üzere, bu davalarda arabulucuya başvurma zorunluluğu, özel bir dava şartı olarak kabul edilmiş olmakla birlikte, bu dava şartının incelenmesi konusunda Kanun, HMK'nda dava şartlarının incelenmesi konusundaki hükümlerden (m. 138) farklı bir düzenleme yapmıştır.

Kanun (İş Mahk. K. m. 3, 4-22), iş davalarında arabuluculuğu, özel olarak ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Buna göre; arabulucunun belirlenmesinden sonra arabulucu her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder; arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren **üç hafta** içinde sonuçlandırır. Tarafların anlaşması halinde, dava açılması söz konusu olmaz.

Eğer arabulucu, taraflara ulaşamaz, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaz yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılamazsa, arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir. Bunun üzerine ilgili kişinin iş mahkemesinde dava açabilmesi imkân dahiline girer.

Buna benzer bir durum, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce **Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurma** bakımından getirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tâbi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, **dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur**. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz (İş Mahk. K. m. 4,1).

D) İŞ MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ

İş mahkemelerinde **basit yargılama usulü** uygulanır (İş Mahk. K. m. 7, 1). Ancak Kanun, buradaki basit yargılama usulünde bazı özellikler kabul etmiş, açık düzenleme bulunmaması halinde HMK hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamıştır.

İş mahkemelerinde yetki konusu diğer mahkemelerden farklıdır. **Yetkili mahkeme,** davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki **yerleşim yeri mahkemesi** ile **işin** veya **işlemin yapıldığı yer mahkemesi**dir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. **İş kazasından doğan tazminat davaları**nda, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Bu hükümlere aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir (İş Mahk. K. m. 6).

Davaların yığılması (HMK m. 110) halinde, her bir talebe ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir (İş Mahk. K. m. 7, 2).

Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hizmet akdine tâbi çalışmaları nedeniyle **zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti** talebi ile işveren aleyhine

açılan davalarda, dava **Sosyal Güvenlik Kuruma resen ihbar** edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür (İş Mahk. K. m. 4, 2).

İş mahkemesinin vereceği kararlara karşı gidilecek **kanun yolları** bakımından HMK'nun kanun yollarına ilişkin hükümleri burada uygulanır. Kanun yoluna başvuru süresi, **ilâmın taraflara tebliğinden itibaren** işlemeye başlar. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır (İş Mahk. K. m. 7,3-5).

Bazı kararlara[5] **karşı temyiz yoluna başvurulamaz.**

---

5 Bu kararlar, İş Mahk. K. m. 8'de şöyle sayılmıştır: a) 4857 s.K. m.20 uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar. b) işveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar. C) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m.24,1 ve 5; m. 34, 4; m. 53,1; m. 71,1 kapsamında açılan davalarda verilen kararlar. ç) ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu m. 10, 8; m.14, 4 kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.

§ 74. KADASTRO MAHKEMELERİ

Kadastro mahkemeleri, genel mahkemelere ait olup da, Kadastro Kanununun uygulanması ile ilgili dava ve işlere, belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde kurulmuşlardır (Kadastro K. m. 24).

Kadastro Kanununun geçici 1. maddesine göre, 766 sayılı Tapulama Kanununa göre kurulmuş olan tapulama mahkemeleri kadastro mahkemesi adını almışlardır. Kadastro mahkemeleri, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan davalara da bakar.

Kadastro Kanununun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle TMK'nun öngördüğü tapu sicilini tutmaktır (Kadastro K. m. 1). İşte, bu amacın gerçekleştirilmesi için Kadastro Kanununun uygulanması dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işleri görmek üzere kadastro mahkemeleri kurulmuştur (Kadastro K. m. 24-25).

A) KADASTRO MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgesi olarak adlandırılır (m. 2, I). İşte, her kadastro bölgesinde, bölgedeki dava ve iş sayısına göre yeter sayıda kadastro mahkemesi kurulur (Kadastro K. m. 24).

Kadastro mahkemesi, tek hâkimli olup, asliye mahkemesi sıfatını haizdir. Kadastro mahkemesi nezdinde bir kalem, mahkeme kaleminin başında bir yazı işleri müdürü bulunur; ayrıca, yeteri kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlidir.

B) KADASTRO MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

Kadastro mahkemelerinin görevlerini, genel olarak ve zaman bakımından olmak üzere ikiye ayırarak incelemek gerekir:

Kadastro mahkemesi, **genel olarak**; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı aynî haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ve kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara bakar. Kadastro mahkemesi, özel kanunlarca görev olarak verilen dava ve işleri de görür. Kadastro mahkemesi, kadastroyu veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebilir. Ayrıca, istenmesi halinde mirasçılık belgesi (veraset belgesi) de verebilir (Kadastro K. m. 25, I). Kadastro mahkemesi yalnız kadastro işleri için geçerli ve sınırlı olmak üzere velisi ve vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayini, adlî yardım istemlerinin karara bağlanması ve ihtiyatî tedbir

konularında kararlar verebilir[1]. Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyatî tedbir kararı veren kadastro mahkemesi, bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. İhtiyati tedbir kararı alan taraf, karar gününden itibaren iki hafta içinde (m. 397) kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir hükümsüz kalır (Kadastro K. m. 25/C).

Kadastro mahkemesinin **zaman bakımından görevleri**ne gelince:

Kadastro mahkemesinin görevi[2], her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar.

Kadastro mahkemesi, kadastro bölgesinin idarî sınırları içinde yetkilidir[3].

Kadastro mahkemesi, Kadastro Kanununun 10. maddesi gereğince kadastro komisyonunca **gönderilen tutanaklara ilişkin davaları**; kadastro sonuçlarının ilânı üzerine **itirazı olanlarca açılacak davaları**; mahallî hukuk mahkemelerinden kadastro mahkemesine kendiliğinden **devredilen davaları**; kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra, kadastro tespitinden önceki haklara dayanarak, aslî **müdahil olarak katılanların iddialarına** ilişkin uyuşmazlıkları inceleyip karara bağlamakla **görevli**dir (Kadastro K. m. 26).

Kadastro işlerinde, 3553 sayılı Kanun (mecburî tahkim) hükümleri uygulanmaz.

Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanmasından sonra veya iş hacmi itibariyle kadastro mahkemesinin göreve devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro mahkemesini kaldırmaya[4] ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahallî asliye mahkemesine devretmeye yetkilidir[5]. Yani, bu devir işlemine kadar veya mahkemenin o bölgede kaldırılması kararına kadar kadastro mahkemesi görevine devam eder.

C) KADASTRO MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ

Kadastro mahkemesinde dava açılmasının ve davanın görülmesinin bazı özellikleri vardır. Önce, dava açılmasındaki özellikler daha sonra davanın görülmesi sırasında uygulanacak usul hükümlerinin özellikleri üzerinde duracağız.

---

1 Kadastro Kanununun kadastro mahkemesinin zaman bakımından görev ve yetkisini düzenleyen 26. maddesi hükmü ile kadastro başladıktan sonra akit ve tescil işlemleri ile ilgili olarak kadastro mahkemelerini görevli kılan 40. madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden veya tutanağın tamamlandığı ve düzeltildiği günden sonra doğan haklara ilişkin istekler, taksim, ortaklığın giderilmesi (şüyuun giderilmesi) veya muhdesata bağlı olarak taşınmazı iktisap, muhdesatın yıkılması veya kaldırılması ve benzeri nitelikteki mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi kadastro mahkemesinin görevleri içine girmez (Kadastro K. m. 25, III).

2 Kadastro K. m. 26, IV'de, "kadastro mahkemesinin yetkisi" ifadesi kullanılmakta ise de, burada sözü edilen, mahkemenin görevidir.

3 Yeni ilçe kurulması dışında, idarî sınırlarda yapılacak değişiklikler kadastro mahkemesinin yetkisini etkilemez (Kadastro K. m. 26, IV).

4 Karş. Anayasa m. 159, III.

5 Kadastro davasını devralan mahkeme, davaya Kadastro Kanununda yazılı usul ve esasa göre bakmaya devam eder (Kadastro K. m. 33, I).

Kadastro mahkemesinde görülecek davalar, üç şekilde açılır veya mahkemeye intikal eder:

1) **Kadastro komisyonu**, kendisine gelen itirazları Kadastro Kanununun 10. maddesine göre karara bağlar. Ancak, bu maddede öngörüldüğü şekilde, bu konuda Komisyon bir sonuca varamazsa veya kanunlarda konu mahkemenin takdirine bırakılmışsa, kadastro komisyonu konuyu kadastro mahkemesine devreder (Kadastro K. m. 10, IV; 26/A). Mahkeme, bu konuları inceleyip karara bağlamak zorundadır (Kadastro K. m. 26/A).

2) Kadastro müdürünün kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak düzenlediği **askı cetvellerine** otuz günlük askı (ilân) **süresi içinde itirazı olanlar**, bu süre içinde kadastro mahkemesinde doğrudan dava açabilirler (Kadastro K. m. 11, I; 26/B).

3) **Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili** ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala **ilişkin davalar** hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte, bu (mahallî) mahkemelerin görevi sona ereceğinden, bu davalara ait dosyalar, kendiliğinden kadastro mahkemesine devrolunur (Kadastro K. m. 27, I; 26/C)[6].

Kadastro mahkemesinde yukarıdaki şekillerde dava açılabilir. Dava açıldıktan sonra, kadastro tespitinden önceki haklara dayanarak davaya aslî müdahil olarak katılanların iddialarına (davalarına) da kadastro mahkemesi bakmakla görevlidir (Kadastro K. m. 26/D).

Kadastro Kanunu, kadastro mahkemelerinde bazı **özel usul hükümlerinin** uygulanacağını öngörmüş, bu özel usul hükümleri dışında **basit yargılama usulünün** uygulanacağını belirtmiştir (Kadastro K. m. 29).

Kadastro mahkemesinde **kendiliğinden araştırma ilkesi** (karş. HMK m. 24 vd.) uygulanır. Şöyle ki: Kadastro hâkimi, mahkemeye intikal eden dava ve işler hakkında bir dosya açar; kadastro davasının taraflarının ve ilgililerinin başvurusunu beklemeden, kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili daireden getirtir (Kadastro K. m. 28, I).

Davacı taraf, dava sebep ve delillerini dava dilekçesinde bildirmemiş ise, hâkim, davacıya bir davetiye göndererek dava sebebinin ve delillerinin neler olduğunun bildirilmesini ister. Davacı, kendisine bildirilmiş olan ilk duruşma gününe kadar dava sebeplerini ve delillerini bildirmez veya ilk duruşmaya gelip açıklamazsa, hâkim, davanın açılmamış sayılmasına ve kadastro tespitini esas alarak tescile karar verir[7]. Davanın açılmamış sayılmasına karar

---

6 Bu konularda bkz. ayrıca, "Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik" m. 3 vd. (RG 28.10.1987, sa. 19618, s. 10 vd.).

7 Ancak, kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahallî mahkemelerden devredilen dosyaların içeriğinden, malik tespiti yapılamadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığı takdirde, hâkim re'sen gerekli gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirasçıları da tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir (Kadastro K. m. 30, II).

verilmesi halinde, davacının hak düşürücü süre içinde genel mahkemede dava açma hakkı saklı kalır (Kadastro K. m. 28, II).

Kadastro mahkemesi hâkimi, **duruşma gününü** taraflara **kendiliğinden tebliğ** eder (Kadastro K. m. 28, I).

Kadastro mahkemesinde görülen davada **davacı**, kadastro tespiti sırasında **ileri sürdüğü itiraz ve delilleri ile bağlı değildir**; yeni itiraz ve delil ileri sürebilir (Kadastro K. m. 28, III; m. 141; 319).

Kadastro mahkemesinde, usulüne uygun olarak çağrılan tarafın gelmemesi halinde, o tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Tarafların hiçbiri gelmese bile **dosya işlemden kaldırılmaz**[8] (karş. m. 150; 320, 4); hâkim mevcut olan ve toplanması mümkün olan delilleri inceler ve işi (davayı) karara bağlar (Kadastro K. m. 29-30).

Kadastro mahkemesinde bir **mirasçı**, diğer **mirasçıların onayı olmadan** dava açıp bu davayı takip edebilir (Kadastro K. m. 29, II).

Kadastro tespiti sırasında mirasçılar belirlenememişse, **ölü şahıs adına da tespit** yapılabilir. İşte, bu şekilde yapılan bir tespitin konusu olan taşınmaz mal hakkında ölünün adı yazılıp ve mirasçıları denilerek mirasçılara karşı dava açılabilir. Dava sırasında, davalının **davanın açılmasından önce öldüğü anlaşılırsa**, dava mirasçılarına yönlendirilir ve onlar aleyhine **davaya devam edilir** (Kadastro K. m. 29, II).

Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, kadastro başladıktan sonra yapılan akit ve tescil işlemleri sonucu başkasına devredilirse, davaya devralan devam eder (Kadastro K. m. 26, IV).

Kadastro tutanaklarının düzenlenmesinde beyanlarına başvurulan kişiler, bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe, kadastro mahkemesince yeniden dinlenmezler. Ancak kadastro hâkimi, kadastro tutanağındaki beyanla, duruşma sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse, bu çelişkinin giderilmesi için bu kimseleri tanık olarak yeniden dinleyebilir (Kadastro K. m. 30, I).

Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile, hukuk mahkemelerinden devredilen dosyalardan dava konusu taşınmazın malikinin kim olduğu tespit edilemezse veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıların bulunduğu anlaşılırsa, **hâkim kendiliğinden** gerekli gördüğü diğer **delilleri toplayarak** taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşınmaz malın ölü bir kimseye ait olduğu anlaşılır ve bu kimsenin mirasçıları da tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir (Kadastro K. m. 30, II).

Kadastro mahkemesinde görülmekte olan dava ve işlerde **karı** ve **koca birbirlerini vekil tayin edebilirler** (Kadastro K. m. 31). Avukatın da vekil tayin edilebilecekleri doğaldır. Avukat ile dava takip edilmişse, bunlara **maktu vekâlet ücreti** takdir ve tayin olunur (Kadastro K. m. 31, III).

---

[8] Anayasa Mahkemesi bu hükmü Anayasaya aykırı bulmamıştır. Anayasa Mahkemesinin 28.02.2013 gün 04/35 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 131-133.

Kadastro davalarına **adlî tatilde de** (m. 103) **bakılır** (Kadastro K. m. 29).

Kadastro mahkemesi kararı, kendiliğinden, taraflara tebliğ olunur. Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita, ilâma eklenir. Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurmada asliye hukuk mahkemelerindeki usul uygulanır (Kadastro K. m. 32). Kadastro mahkemesi kararı, taraflar ve taraflar dışında dava konusu üzerinde hak iddia ederek davaya müdahil olarak katılanlar hakkında kesin hüküm oluşturur (m. 303). Davada taraf olmadığı halde, lehine karar verilen **üçüncü şahıs hakkında mahkemece verilen karar, tarafları ve müdahili de bağlar** (Kadastro K. m. 34).

Yukarıdaki özellikler dışında HMK'nun basit yargılama usulüne ilişkin hükümleri (m. 316-322) uygulanır (Kadastro K. m. 29, III).

§ 75. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ ve TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

Tüketicinin korunması kurumu, günümüzde bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe önem kazanan ve tüketici lehine sıkça kanun değişikliklerinin yapıldığı bir konudur. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (6052 s. K.) amacı, kamu yararına uygun olarak **tüketicinin** sağlık ve güvenliği ile ekonomik **çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici**, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçli önlemleri almak, tüketicilerin kendilerine koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir (6052 s. K. m. 1).

Konunun önemi, tüketicilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü bakımından da özel bir yargı sistemini gerektirmektedir.

Bu yüzden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkların çözümü için, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri kurulmuş ve yargılama usulü ile ilgili ayrıntılı özel düzenlememeler getirilmiştir.

A) TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

I – TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU ve GÖREVLERİ

Tüketici mahkemeleri[1], tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda görevlidir (6502 s. K. m. 73, 1). Ancak, aşağıda görüleceği üzere, belli parasal sınırı geçmeyen uyuşmazlıklarda, **tüketici hakem heyetlerine başvurma zorunluluğu**[2] (yani, **mecburî tahkim**) vardır; tüketici mahkemelerine doğrudan başvurulamaz.

Kanuna göre, "**tüketici**", ticarî veya meslekî olmayan amaçlarla hareket eden, gerçek veya tüzel kişiyi; "**tüketici işlemi**", mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticarî veya meslekî amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukukî işlemi ifade eder (6502 s. K. m. 3).

Büyük şehirlerde (örneğin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Konya) ayrı tüketici mahkemeleri kurulmuştur. Ayrı tüketici mah-

---

1 Bkz. Gökçen Topuz, Tüketici Mahkemeleri, Ankara 2018; Ejder Yılmaz/M. Ertan Yardım, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Şerhi (Milli Şerh), Editör: Hakan Tokbaş/Özlem Tüzüner, İstanbul 2016, s. 1082-1215.

2 Anayasa Mahkemesi, tüketici işlemleriyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açmadan önce tüketici hakem heyetlerine başvurma zorunluluğunu hak arama özgürlüğüne aykırı bulmamıştır. Anayasa Mahkemesinin 20.03.2008 gün ve 78/84 sayılı karar için bkz. RG 01.07.2008, sa. 26923.

kemesi bulunmayan yerlerde, asliye hukuk mahkemesi, tüketici mahkemesi olarak da görev yapar.

II – TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ

Tüketici davası da, diğer davalardaki gibi genel kural olarak, hukukî menfaati bulunan **tüketici tarafından açılır**.

Tüketici davası, aynı zamanda bir **topluluk davası** (m. 113) olarak da açılabilir. Çünkü, tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret Bakanlığı da; haksız ticarî uygulamalar ve ticarî reklâmlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hallerde, bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir (6502 s. K. m. 73, 6).

Kanunun, ayıplı malların üretiminin ve satışının durdurulması ve toplatılması hakkındaki 74. maddesinde, seri halde satışa sunulan bir malın ayıplı olması durumunda Ticaret Bakanlığı veya tüketici örgütleri, bu malın üretim ve satışının durdurulması ve piyasaya çıkmış olan ayıplı malların, bu malları satış amacıyla elinde bulunduran kişilerden (örneğin, perakende satıcılardan) toplatılması için dava açabilirler. Ayıplı malların, mahkeme kararı uyarınca toplatılması halinde, ayıplı malları satış amacıyla elinde bulunduran ve toplatma işleminden zarar gören üçüncü kişiler, ayıplı malların üreticisi aleyhine tazminat davası açabilirler (6502 s. K. m. 74).

Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından açılan davalar, Harçlar Kanununda düzenlenen **harçlardan muaftır** (6502 s. K. m. 73, 2).

Tüketici davaları, **tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde**ki tüketici mahkemesinde de açılabilir (6502 s. K. m. 73, 5). Davacı tüketiciye, seçmeli yetkili mahkeme gösteren Kanunun bu hükmünden, HMK'nun yetkiye ilişkin hükümlerine (m. 5 vd.) göre yetkili mahkemede de dava açılabileceği sonucu ortaya çıkar.

Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir (6502 s. K. m. 73, 3).

Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar, **basit yargılama usulü**ne (HMK m. 316-322) tâbidir (6502 s. K. m. 73, 4).

Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi halinde bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir (6502 s. K. m. 73, 7).

Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığına iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir (6502 s. K. m. 73, 8).

B) TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ[3]

I – TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞU ve GÖREVLERİ

Tüketici hakem heyetleri, il merkezlerinde ve gerekli görülen ilçe merkezlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulur (6502 s. K. m. 66, 1; Tüketici Hakem Heyetleri THH- Yönetmeliği m. 5).

Tüketici hakem heyetleri, bir başkan ile dört üyeden oluşan beş kişilik kurullardır. Başkan, illerde ticaret il müdürü veya görevlendirdiği memur; ilçelerde, kaymakam veya görevlendirdiği memurdur. Dört üye ise: a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye; b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye; c) Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye; ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üyedir (6501 s. K. m. 66, 2; THH Yönetmeliği m. 8-10).

Tüketici hakem heyetlerinde ayrıca yeterli sayıda **raportör** bulunur. Raportör, heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmakla görevlidir (6502 s. K. m. 67). Raportörün görevleri; tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak, gerekli yazışmaları yapmak, toplantıları hazırlamak, tutanak düzenlemek gibi idarî hususlardır (THH Yönetmeliği m. 8)[4].

Tüketici mahkemeleri hakkında yukarıda yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz üzere, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğan ve değeri belli **parasal sınırı aşmayan** uyuşmazlıklarda, önce **tüketici hakem heyetine**[5] **başvurulması zorunlu**dur. Başka bir ifadeyle, belirli parasal sınır altında kalan tüketici uyuşmazlıklarda görev, tüketici hakem heyetlerine aittir (6502 s. K. m. 68, 1/c. 1; THH Yönetmeliği m. 6). Bu parasal sınır üstünde kalan uyuşmazlıklarda, tüketici hakem heyetlerine başvurulamaz (6502 s. K. m. 68, 1/ c. 2); tüketici mahkemelerinde dava açmak gerekir.

---

3 Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi ve Sorunlar, Tüketici Hukuku Konferansı, (Makaleler-Tebliğler, Ankara 2016, s. 283-306); Gökberk Özsöker, Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara 2019.

4 Bkz. Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği.

5 2019 yılı için: Değeri 5.650 TL'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 8.480 TL'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 5.670-8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur (6502 s. K. m. 68). Bu parasal sınır, her takvim yılının başında yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır (6502 s. K. m. 68, 4; THH Yönetmeliği m. 6).

Tarafların İcra ve İflâs Kanunundan doğan hakları saklıdır (6502 s. K. 68, 1). Bu sebeple, tüketici işlemleri ile ilgili taraf isterse tüketici hakem heyetine başvurmaksızın **ilâmsız takip** yapabilir.

Tüketici hakem heyetleri, görevi ve yetkisi dışında kalan başvuruları, tüketicinin başvuru yapabileceği yerleri de belirterek başvuru sahibine iade eder (THH Yönetmeliği m. 6, 5).

Tüketici, (belli parasal sınırı aşmayan bu uyuşmazlıklarda), isterse tüketici hakem heyeti yerine, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilir. Çünkü m. 68 hükmü, tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir (6502 s. K. m. 68, 5). Öte yandan tarafların ilâmsız icra yoluna başvurması da mümkündür (7063 s. K. değişik 6502 s. K. m. 68, 1).

II – TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNDE UYGULANAN İNCELEME USULÜ

Tüketici, tüketici hakem heyetine bir **dilekçe** ile başvurur. Dilekçede; başvuru sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık konusunun değeri ve talebi ile şikâyet edilen karşı tarafa ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Tüketici, başvurusunu (örneği Yönetmeliğin ekinde bulunan) "**başvuru formu**"nu doldurarak da yapabilir. Yapılan başvuruya, varsa delil oluşturan ilgili belgeler de eklenir (THH Yönetmeliği m. 11, 1).

Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir. Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde başvuru işleme alınmaz (THH Yönetmeliği m. 11, 4-5).

Tüketici, tüketici hakem heyetine başvurduktan sonra, aynı uyuşmazlıkla ilgili olarak, aynı veya başka bir tüketici hakem heyetine yeni bir talepte bulunamaz. Aksi takdirde, karşı taraf, ikinci tüketici hakem heyetine **derdestlik itiraz**ında bulunarak, ikinci başvurunun iptalini sağlayabilir (THH Yönetmeliği m. 11, 2-3).

Tüketici hakem heyetleri, kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır (6502 s. K. m. 68, 2).

Başvurularda **yetkili** tüketici hakem heyeti, **tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu** veya tüketici işleminin **yapıldığı yerdeki** tüketici hakem heyetidir (THH Yönetmeliği m. 7, 2).

İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkilidir (THH Yönetmeliği m. 7, 1). Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir (THH Yönetmeliği m. 7, 2). İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine intikal ettirilir (THH Yönetmeliği m. 7, 3; 6502 s. K. m. 68, 3).

Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü **bilgi ve belge**yi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan **isteyebilir**. Bilgi ve belge isteme yazılarının taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde, bu süre uzatılabilir. Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir (6502 s. K. m. 69; THH Yönetmeliği m. 12).

Tüketici hakem heyeti, başkan dahil en az üç üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir; üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir (6502 s. K. m. 15)

Tüketici hakem heyeti, tüketicinin yaptığı başvuruyu, raportör tarafından hazırlanan rapor ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden inceler.

Tüketici hakem heyeti, üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olmayan özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, **bilirkişi incelemesi** yaptırabilir (THH Yönetmeliği m. 19-21).

Tüketici hakem heyeti gerekli görürse, tarafları ve bilirkişiyi dinler (6502 s. K. m. 18).

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarihi ve sırasına göre, en geç **altı ay içinde** görüşülür ve **karara bağlanır**. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir. Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılır (THH Yönetmeliği m. 23, 1-2). Türkiye'de yerleşim yeri bulunmayan yabancı uyruklu tüketicilerin uyuşmazlıkları için ikinci fıkra hükümleri uygulanır (THH Yönetmeliği m. 23).

Toplantıda alınan kararlar, (Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan örneğe uygun olarak) tutanağa geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karar tutanağı, toplantı tarihine ve gündem sırasına göre arşivlenir ve onaylı bir örneği dosyasında muhafaza edilir (THH Yönetmeliği m. 24).

Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken **tarafların talebiyle bağlı**dır. **Ancak** başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık miktarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, baş-

vuru sahibinin hukukî ilişkiyi ve asgarî bir miktarı belirtmesi ve inceleme sürecinde uyuşmazlık miktarının bilgi veya belgelerle tam olarak tespit edilmesi halinde **talep edilen miktardan daha fazlasına veya daha azına tüketici hakem heyetince karar verilebilir. Verilen kararın her hâlükârda tüketici hakem heyetinin görevi ile ilgili parasal sınırlar içerisinde olması gerekir.** Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık için ayrı ayrı başvuru yapılması durumunda, uyuşmazlığın değerleri toplamı tüketici hakem heyetinin görev sınırı içinde kalmak şartıyla, tek bir başvuruda birleştirilerek karar verilebilir. Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlığın değerleri toplamının görev sınırını aşması durumunda uyuşmazlıklar hakkında ayrı ayrı karar verilir. Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin Türk Lirası cinsinden belirtilmesi zorunludur. Uyuşmazlık bedelinin döviz cinsinden olması durumunda başvuru tarihindeki TC Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda, karşı tarafça ödenmesi gereken bilirkişi ve tebligat ücretleri kararda belirtilir (THH Yönetmeliği m. 22, 1-4).

Tüketici hakem heyeti kararı tarafları bağlar. Tüketici hakem heyeti kararı yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder (THH Yönetmeliği m. 22, 5-6; 6502 s. K. m. 70, 1/c. 1).

Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, **avukatla temsil edilebilir.** Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetleri tarafından lehine karar verilen tarafın avukatına **vekâlet ücreti ödenmesine karar verilmez** (THH Yönetmeliği m. 22, 7; 6502 s. K. m. 70, 1/c. 2).

Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilinceye kadar çözümlenmesi ve bu durumun ispatına yönelik bilgi veya belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi durumunda, tüketici hakem heyeti uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verir (THH Yönetmeliği m. 22, 8).

Tüketici hakem heyeti kararı, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak ve **Tebligat Kanunu** hükümlerine göre tebliğ edilir. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır (Tebligat K. m. 11). Kararların taraflara **taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır.** Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir (THH Yönetmeliği m. 25; 6502 s. K. m. 70, 2/ c. 1).

Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun **ilâmların yerine getirilmesi** (icrası) **hakkındaki hükümlerine** (İİK m. 24 vd.) **göre yerine getirilir** (6502 s. K. m. 70, 2/c. 2; THH Yönetmeliği m. 26).

Tarafların kimlik bilgilerine, ticaret unvanlarına ait yanlışlıklar, ifade ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, tüketici hakem heyetince resen veya taraflardan birinin yazılı talebi üzerine düzeltilebilir. Düzeltme kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlara ilişkin ek karar, tüketici hakem heyetinde bulunan nüshaların altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır ve imzalanır. Düzeltme kararları on iş günü içinde taraflara tebliğ edilir ve talep

edilmesi halinde taraflara verilmiş olan suretlere de düzeltme kararı yazılır ve imzalanır (THH Yönetmeliği m. 27).

Taraflar, **tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde** tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki **tüketici mahkemesine itiraz edebilir**. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının **icrasını durdurmaz**; ancak talep edilmesi şartıyla tüketici mahkemesi, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir (6502 s. K. m. 70, 3; THH Yönetmeliği m. 28, 1).

İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi dosya üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticaret unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan **itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir**. Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz sonucu verilen karar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir. Tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karara karşı yapılan itirazın kabulü durumunda mahkemece tüketici aleyhine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nispi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. Tarifenin maktu vekâlete ilişkin hükümleri uygulanmaz (THH Yönetmeliği m. 28, 2-5; 6502 s. K. m. 4-6).

Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda **tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır**. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir (6502 s. K. m. 70, 7; THH Yönetmeliği m. 31).

§ 76. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ

A) KURULUŞ

5846 sayılı **Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu** (5846 s. K. m. 76) ile 6769 sayılı **Sınai Mülkiyet** Kanununun[1] uygulanmasından kaynaklanan hukuk davalarını görmek üzere fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmuştur (6769 s. K. m. 156). Bu mahkeme de, özel görevli (uzmanlık) mahkemelerdendir.

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, Türk Hukukunda uzun bir zamandan beri mevcut olmakla birlikte, mahkeme hakkındaki düzenleme, yukarıda söz edilen Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sınırlı bir şekilde bulunmakta[2]; Sınai Mülkiyet Kanununun kabulüne kadar ise mahkeme hakkındaki hükümlere, ilgili KHK'larda yer verilmekte idi[3]. Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu mahkemelerin kuruluşu ile yapısı açıkça ve tabiî hâkim ilkesine uygun olarak düzenlenmiştir. Böylece fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin kuruluşu, Sınai Mülkiyet Kanunu ile gerçekleşmiştir.

Ülkemizde bazı büyük il merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir'de), ayrı fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerin yargı çevreleri, kuruldukları yerin idarî (mülkî) sınırları olarak belirlenmiştir. Bu mahkemeler, HSK'nun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 5235 sayılı Kanuna göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince bakılır (6769 s. K. m. 156).

Ayrı fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi kurulmayan yerlerde, bu mahkemelerin görevine giren davalarda, bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde, bu asliye hukuk mahkemesi; iki asliye hukuk mahkemesi olan yer-

---

1 RG 10.01.2017, sa. 29944.

2 5846 sayılı Kanunun, mahkemeye ilişkin 76. maddesinde yer alan, "Bu Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun miktarına ve Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, **görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak ihtisas mahkemeleridir"** şeklindeki düzenlemede esasen fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi adı geçmemekle birlikte, mahkemeler bu ismi taşımaktaydı. 6769 s. K. m. 189 ile 5846 s. K.'nun 76. maddesi de değişikliğe uğramıştır. Buna göre, bu Kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan dava ve işler ile bu Kanundan kaynaklanan ceza davalarında görevli mahkeme, Sınai Mülkiyet Kanununun 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerdir" (6769 s. K. m. 189 ile değişik 5846 s. K. m. 76). 6769 s. K. m. 156'da ise, açıkça "Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir" düzenlemesi yapılmıştır.

3 551 sayılı **Patent Haklarının Korunması** Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 554 sayılı **Endüstriyel Tasarımların Korunması** Hakkında KHK, 555 sayılı **Coğrafî İşaretlerin Korunması** Hakkında KHK, 556 sayılı **Markaların Korunması** Hakkında KHK, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır (6769 s. K. m. 191)

lerde, (1) numaralı asliye hukuk mahkemesi; ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde, (3) numaralı asliye hukuk mahkemesi görevlidir[4].

B) FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BAKIMINDAN AÇILACAK DAVALAR VE ÖZELLİKLERİ

Fikri haklar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklardır. İnsanın yaratıcı, yenilikçi ve özgün çalışmaları ile ortaya çıkardığı eserlerin hukukî korumasıdır. Bilimsel veya edebi çalışmalar (örneğin, bir yazarın romanı veya bir öğretim üyesinin ders kitabı), güzel sanatlar ürünü (heykel, resim vb.), bir sinema filmi veya bir beste üzerinde, onu ortaya çıkaran kişilerin (eser sahiplerinin) hakları vardır.

Fikir ürünleri, insan düşüncesi ve yaratıcılığının ürünü olup soyuttur. Bu bakımdan klasik mülkiyet hakkı koruması yetersiz kalır. Özellikle günümüzde artan teknolojik metotlar, üzerinde fikri hak söz konusu olan eserlerin taklit edilmesine, çoğaltılmasına ve kullanılmasına, yani önemli ihlâllere sebep olmaktadır. 5846 sayılı Kanun, bu hakları korumak amacıyla düzenlemeler yapmış; fikri haklarla ilgili olan ve bu Kanunda düzenlenen ilişkilerden doğan davalara fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesince bakılacağını kabul etmiştir (6769 s. K. m. 189 ile değişik 5846 s. K. m. 76).

5846 sayılı Kanun, eser sahibinin malî ve manevî haklarının korunması bakımından tespit[5], tecavüzün durdurulması, tecavüzün önlenmesi ve sebepsiz zenginleşme davası gibi davalar yanında maddî ve manevî tazminat davalarını düzenlemiştir. Bu davalarda HMK'ndaki ilkeler doğrultusunda inceleme yapılır ve karar verilir. Buna göre, mahkeme, dava türüne göre, taleple bağlılık ilkesi (m. 26) çerçevesinde tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, maddî ve manevi tazminat[6] gibi kararlardan birisine veya birden fazlasına hükmeder.

Burada açılabilecek bazı davalarda davacı lehine getirilmiş özel usul hükümleri de mevcuttur. Örneğin, davalının bazı belgeleri ibraz etmemesi halinde, davacı lehine karar verilebileceği öngörülmüştür[7].

Davacının, kesinleşmiş hükmün gazete ile ilanını talep etme hakkı da vardır[8].

---

4 Bkz. HSK 1. Dairesinin 30.05.2018 tarihli ve 839 sayılı kararı (RG 31.05.2018, sa. 30437).

5 "Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut herhangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiyebilir" (5846 s. K. m. 15, 4).

6 Manevî hakların ihlâli talebiyle açılan manevî tazminat davasında hâkim, para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir (5846 s. K. m. 70, 1). Bu genellikle, kararın gazetede ilanı veya kınama şeklinde olmaktadır.

7 "Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, **davacının iddianın doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması** hâlinde, korunmakta olan eserler, fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda öngörülen izin ve yetkileri aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan eser, fonogram, icra, film ve yayınların listelerini sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder" (5846 s. K. m. 76, 2; karş. m. 219).

Fikri haklar bakımından ihtiyati tedbirler özel bir önem taşıdığından bu konu da Kanunda özel olarak düzenlenmiştir (5846 s. K. m. 66, 4[9]; 77[10]).

C) SINAİ MÜLKİYET KANUNU BAKIMINDAN AÇILACAK DAVALAR VE ÖZELLİKLERİ

Sınai mülkiyet hakkı, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı modelleri kapsar (6769 s. K. m. 2, 1/I).

Yukarıda belirtildiği üzere, Sınai Mülkiyet Kanunu, daha önce çeşitli KHK'larda[11] dağınık bir şekilde düzenlenen sınai mülkiyete dahil olan hakları tek bir kanunda toplamış ve 156. maddesinde, bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkemenin, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi olduğu öngörülmüştür. Ancak bu Kanun dışında bazı kanunlarla da fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi görevli kılınmıştır[12].

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka, lisans, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı modellerin korunması bakımından çeşitli dava açma olanakları tanınmış ve Kanunun 149 vd. hükümlerinde bütün sınai mülkiyet hakları bakımından ortak düzenlemeler getirilmiştir (ayrıca bkz. 6769 s. K. m. 25-27; 50-51; 78-79; 138-139). Buna göre, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.

b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.

---

8 "67 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hal dışında, haklı olan taraf, muhik bir sebep veya menfaati varsa, masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan kararın gazete veya buna benzer vasıtalarla tamamen veya hulasa olarak ilan edilmesini talep etmek hakkını haizdir. İlanın şekil ve muhtevası kararda tesbit edilir. İlan hakkı, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde kullanılmazsa düşer" (5846 s. K. m. 78).

9 "Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir".

10 "Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi için veya diğer her hangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz kalanların ya da meslek birliklerinin talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza altına alınmasına karar verebilir. Kararda, emre muhalefetin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı açıklanır".

11 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ve 566 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı KHK'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin KHK yürürlükten kaldırılmıştır. (6769 s. K. m. 191, 3).

12 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanununun uygulanması bakımından da fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri görevli kılınmıştır.

ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini[13]

d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması.

e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi[14] veya ilgililere tebliğ edilmesi.

HMK, dava açılmadan önce, koşulları varsa delil tespitine olanak tanımaktadır (m. 400 vd.). Sınai Mülkiyet Kanunu ise, bu konuda daha özel bir hüküm getirmiştir. Buna göre, "Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir" hükmü bulunmaktadır (6769 s. K. m. 150, 3). Burada HMK'na göre farklılık taşıyan husus ise, delil tespiti dışında, hak sahibinin uğradığını ileri sürdüğü zararın miktarını tespit bakımından, karşı tarafın elinde bulunan sınai mülkiyet hakkının kullanımı ile belgelerin de, **davadan önce ibrazına karar verilmesini talep yetkisidir.** Oysa HMK m. 219 vd. uyarınca belgelerin ibrazı, tahkikat içerisinde gerçekleşir.

Sınai mülkiyet hakkı ihlâl edilen kişi, bu ihlâli gerçekleştirenlere karşı dava açma hakkına sahip olmakla birlikte, hakkı ihlâl eden kimseden piyasaya sürülen malları alan ve kişisel ihtiyaçları için bunları kullananlara karşı dava açamaz. Bunun yanı sıra, sınai mülkiyet hakkı sahibinin, elkoymaması nedeniyle, kendisine tazminat ödeyen kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan kişilere karşı da dava açması mümkün değildir[15].

---

[13] Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep edilemez (6769 s. K. m. 149, 4).

[14] İlanın şekli ve kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer (6769 s. K. m. 149, 3).

[15] "Sınai mülkiyet hakkı sahibi, hakkına tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması için şikâyette bulunamaz. Sınai mülkiyet hakkı sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı kendisine tazminat ödeyen kişi tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinin elkoymaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması için şikâyette bulunamaz" (6769 s. K. m. 153).

Sınai mülkiyet hakkının çok geniş bir uygulama alanı olması nedeniyle bazı hallerde, bir sınai hakkı kullanmanın bir başkasının sınai hakkını ihlâl edip etmediği bilinemeyebilir. Bu nedenle Kanun, "Menfaati olan herkes, Türkiye'de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz" şeklinde bir düzenleme getirmiştir (6769 s. K. m. 154, 1).

Kanunda, lisans alanın dava açması ve şartları ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, "Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, yapacağı bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden ister. Hak sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde talep edilen davayı açmaması hâlinde, lisans alan, yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava açabilir. Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını hak sahibine bildirmesi gerekir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı halinde ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkemenin tedbir kararı verdiği hallerde talepte bulunan lisans sahibi dava açmaya da yetkilidir. Bu halde ikinci fıkradaki şartlar yargılama devam ederken tamamlanır" (6769 s. K. m. 158).

Sınai hakların etkin bir biçimde korunması bakımından oldukça önemli olan ihtiyati tedbirler de Kanunda ayrıca düzenleme konusu edilmiştir. Bu düzenlemeyle, HMK kapsamında verilebilecek tedbirlere yenileri eklenmiş ve Kanunda ihtiyati tedbirlerle ilgili özel hüküm bulunmayan hallerde HMK'nun uygulanacağı öngörülmüştür. "**İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği"** başlıklı maddeye göre;

"(1) Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

(2) İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:

a) Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.

b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, tecavüze konu

ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde elkonulması ve bunların saklanması.

c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi

(3) İhtiyati tedbirlerle ilgili bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır " (6769 s. K. m. 159).

Kanun, **yetkili mahkeme** hakkında özel hükümler getirmiştir. Buna göre, sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir (karş. m. 16). Davacının Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması halinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum (Türk Patent ve Marka Kurumu) merkezinin bulunduğu yerdeki (Ankara'daki) mahkemedir. Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması halinde yetkili mahkeme ise, yine davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum (Türk Patent ve Marka Kurumu) merkezinin bulunduğu yerdeki (Ankara'daki) mahkemedir (6769 s. K. m. 156).

Son olarak belirtelim ki, Türk Patent ve Marka Kurumunun Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre alacağı bütün kararlara karşı açılacak davalar ile Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir (6769 s. K. m. 156, 2).

§ 77. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ ve TANINMASI[1]

A) YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

I – GENEL BİLGİ

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi (ve tanınması), Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun (MÖHUK'un) 50-63. maddeleri hükümleri ile düzenlenmiştir.

Buradaki yabancı mahkeme kararlarından kasıt, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş olan kararlardır (MÖHUK m. 50, I).

Bundan başka, yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da (Türkiye'de) tenfiz kararı istenebilir (MÖHUK m. 50, II).

II – YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Türk mahkemesinin, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye'de tenfizine (icrasına) karar verebilmesi için aşağıdaki şartların (hepsinin birlikte)[2] varlığı gerekir:

1) Yabancı mahkeme kararının, ülkesinde verildiği devlet kanunlarına göre (şeklî anlamda) **kesinleşmiş bulunması** gerekir (MÖHUK m. 50, I).

2) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık (mütekabiliyet) esasına dayanan bir anlaşma veya o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması gerekir (MÖHUK m. 54/a). "Karşılıklılık şartı", yabancı mahkeme kararlarının tenfizi için gereklidir; buna karşılık, yabancı mahkeme kararlarının (Türkiye' de) tanınması için gerekli değildir.

3) Yabancı mahkeme ilâmının (kararının) Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir (MÖHUK m. 54/b).

Buna göre, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisinin münhasır (kesin) olduğu davalar hakkında verilmiş olan yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tenfizi mümkün değildir. Örneğin, Türk mahkemelerinin Türkiye'deki taşınmazlara ilişkin davalardaki uluslararası yetkisi kesindir. Bu nedenle, yabancı mahkemelerin Türkiye'deki taşınmazlar hakkında verecekleri kararlar Türkiye'de tenfiz edilemez.

---

1 Bkz. Nuray Ekşi, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2013.

2 Hâkim, bu şartların hepsinin yerine gelmiş olması halinde zorunlu olarak tenfiz kararını verecek ve bu konuda bir takdir hakkına sahip bulunmayacaktır.

4) Yabancı mahkeme kararının Türk **kamu düzenine**[3] **açıkça aykırı bulunmaması** gerekir (MÖHUK m. 54/c).

Burada önemli olan, yabancı mahkeme kararının kendisinin değil, onun Türkiye'de tenfiz edilmesinin Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmasıdır.

5) Karşı tarafın savunma hakkına uyulmuş olması gerekir (MÖHUK m. 54/ç).

Kendisine karşı tenfiz istenen kişi (karşı taraf), hükmü veren yabancı mahkemeye (o devletin kanunları uyarınca) usulüne uygun biçimde çağrılmamış ise tenfiz kararı verilemez (MÖHUK m. 54/ç).

III – TENFİZ USULÜ

Yukarıdaki şartların varlığı halinde, yabancı mahkeme kararının Türkiye'de icra olunabilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır (MÖHUK m. 50):

1) Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme, aile hukukuna ilişkin olanlar (ki, bu konuda, **aile mahkemeleri** görevlidir; 4787 s. K. m. 4/2) hariç olmak üzere **asliye hukuk** mahkemesidir (MÖHUK m. 51, I). Fakat, yabancı mahkemede görülmüş olan dava, Türk hukuku bakımından ticarî dava niteliğinde ise, tenfiz talebinin asliye ticaret mahkemesine yapılması gerektiği kanısındayız.

Yetkili mahkeme, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin (karşı tarafın) Türkiye'deki **yerleşim yeri mahkemesi**dir. Bu kişinin (karşı tarafın) Türkiye'de yerleşim yeri yoksa, sakin olduğu (oturduğu) yer mahkemesi, Türkiye'de yerleşim yeri veya sakin olduğu yer mahkemesi de yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden biridir (MÖHUK m. 51, II).

2) Tenfiz Talebi

Tenfiz talebi, asliye hukuk (karar aile hukukuna ilişkinse aile) mahkemesine verilecek **dilekçe** ile olur. Dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Bu dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır (MÖHUK m. 52):

a) Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri,

b) Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ve ilâmın tarih ve numarası ile hükmün özeti,

c) Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir (MÖHUK m. 53):

a) Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi.

---

[3] Yargıtay, yabancı mahkeme kararının gerekçesiz olması halinde tenfizin Türk kamu düzenine aykırı olmadığını kabul etmektedir. 10.02.2012 gün ve 01/01 sayılı İBK için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 170-173.

b) İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tenfiz talebinde (dilekçesinde) yabancı mahkeme ilâmının tenfizinin istendiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

3) Tenfiz Talebinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması

Tenfiz talebini içeren dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Mahkeme, tenfiz talebini **basit yargılama usulü** hükümlerine (m. 316-322; 447, 2) göre inceleyerek karara bağlar (MÖHUK m. 55, I).

Karşı taraf, ancak (yukarıda incelenmiş olan) tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir (MÖHUK m. 55, II).

Tenfiz talebini inceleyen mahkeme, **yalnız tenfiz şartlarının** mevcut olup olmadığını (ve karşı taraf yabancı mahkeme ilâmının yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep çıkmış olduğunu ileri sürmüşse bu hususu) **inceleme konusu yapabilir**; yabancı mahkeme kararının **doğru olup olmadığını inceleyemez**. Başka bir deyişle, mahkeme, tenfiz şartlarının varlığını tespit etmiş olmasına rağmen, tenfiz kararı verip vermemek hususunda bir takdir hakkına sahip değildir; tenfiz kararı vermekle yükümlüdür.

Mahkemece, yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen tenfizine veya tenfiz talebinin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilâmının altına yazılır ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanır (MÖHUK m. 56).

Tenfiz talebinin kabul veya reddi hususunda verilen kararlarına karşı kanun yoluna başvurulması ve kanun yolunda incelenmesi, genel hükümlere tâbidir (MÖHUK m. 57, II/c. 1). Yani bu kararlara karşı, asliye hukuk mahkemesi kararları gibi (m. 341-360; 361 vd. hükümlerine göre) kanun yollarına başvurulur ve incelenir (bkz. geçici m. 3).

Tenfizine karar verilen yabancı ilâmlar, Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmlar gibi icra olunur (MÖHUK m. 57, I); yani, İİK m. 24 vd. hükümlerine göre icra edilir.

Mahkemenin yabancı mahkeme ilâmının tenfizi talebinin reddine karar vermesi halinde, bu ret kararının kesinleşmesinden sonra, davacı, aynı davayı Türk mahkemesinde yeniden açabilir. Davalı, buna karşı (yabancı mahkeme ilâmına dayanarak) kesin hüküm itirazında bulunamaz.

B) YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI

I – GENEL BİLGİ

Yabancı mahkeme kararlarının, cebrî icraya yol açmaksızın (cebrî icra olunabilirlik niteliğinden bağımsız olarak) **sadece kesin hüküm gücünün kabul edilmesine,** "tanıma" denir. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ihtiyacı kendisini başlıca şu hallerde gösterir:

1) Türkiye'de açılan davada bir yabancı mahkeme kararına dayanılarak **kesin hüküm itirazı**nda (HMK m. 303) bulunulması.

2) Türkiye'de açılan davada yabancı bir mahkeme kararına **kesin delil** olarak dayanılması.

3) Yabancı mahkeme kararına dayanarak Türkiye'de bir idarî işlem yaptırılmak istenmesi.

II – TANIMANIN ŞARTLARI

Yabancı mahkeme kararlarının (ilâmlarının) Türkiye'de tanınmasına karar verilebilmesi için gerekli şartlar, kural olarak **tenfiz şartları** gibidir; yalnız, MÖHUK m. 54'ün (a) bendi tanımada uygulanmaz (MÖHUK m. 58. Yani, tanımada "karşılıklılık şartı" aranmaz (MÖHUK m. 58) ve Türkiye'de tanınması istenen yabancı mahkeme kararının verildiği Devlet'te, Türk mahkemesinin verdiği kararın tanınıp tanınmadığına bakılmaz.

III – TANIMA USULÜ

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınmasına da (tenfizde olduğu gibi) Türk mahkemesi tarafından karar verilir (MÖHUK m. 58; 4787 s. K. m. 4/2). Ancak tanıma usulü, yabancı mahkeme kararının ne için (hangi amaçla) tanınmasının istendiğine göre bazı özellikler (farklılıklar) gösterir:

1) Kesin Hüküm İtirazı İçin Tanıma

Türk mahkemesine açılan davada bir yabancı mahkeme kararına dayanarak kesin hüküm itirazında bulunulması halinde, davaya bakan mahkeme (Türk mahkemesi), ön sorun (HMK m. 163-164) olarak, yabancı mahkeme kararının tanıma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırır (MÖHUK m. 58, I). Yani **bu halde**, yabancı mahkeme kararının tanınması için **ayrı bir tanıma davası açılmasına gerek yoktur**.

2) Kesin Delil İçin Tanıma

Türk mahkemesine açılan davada bir yabancı mahkeme kararına kesin delil olarak dayanılması halinde, davaya bakan mahkeme (Türk Mahkemesi), ön sorun (m. 163-164) olarak yabancı mahkeme kararının tanıma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırır (MÖHUK m. 58, I). Mahkeme, yabancı mahkeme kararının **tanıma şartlarını taşıdığı** kanısına varırsa, yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verir. Bunun üzerine, **yabancı mahkeme kararı** (Türk mahkemesinde görülmekte olan) **o davada kesin delil teşkil eder**.

3) İdarî Bir İşlemin Yapılması İçin Tanıma

Yabancı bir mahkeme kararına (örneğin, boşanma kararına) dayanarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılabilmesi (örnekte, boşanmanın Türkiye'deki nüfus siciline işlenebilmesi) için, bu idarî işlemin yapılmasını isteyen tarafın,

Türk Mahkemesine başvurarak yabancı mahkeme kararının tanınmasını istemesi gerekir (MÖHUK m. 58, III)[4].

Bu tanıma talebi (davası), yabancı mahkeme kararının tanıma şartlarını taşıdığının (dolayısıyla, bir hukukî ilişkinin) tespiti için yapıldığından, bir tespit davası olarak nitelendirilebilir.

Bu tanıma davası için görevli ve yetkili mahkeme, tanıma talebi (dilekçesi), tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir (MÖHUK m. 58, III).

4) Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınması

Yabancı mahkemelerce verilen çekişmesiz yargı kararlarının tanınması da aynı hükme (yani yukarıda incelenen hükümlere) tâbidir (MÖHUK m. 58, II). Ancak, çekişmesiz yargı kararları maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden (m. 388), bu kararların kesin hüküm ve kesin delil için tanınması (MÖHUK m. 58, I) söz konusu olmaz. Buna karşılık yenilik doğurucu (inşaî) nitelikteki çekişmesiz yargı kararlarının inşaî tesir (yenilik doğurma etkisi) gücünün kabulü için, MÖHUK m. 58, I hükmüne göre tanınması istenebilir. Türkiye'de idarî bir işlemin yapılabilmesi için MÖHUK m. 58, III hükmüne göre ayrı bir tanıma başvurusu yapılabilir.

C) YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ ve TANINMASI[5]

Bu konu, MÖHUK'nun 60-63. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, kesinleşmiş ve icra edilebilir hale gelmiş veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararları tenfiz edilebilir. Yabancı hakem kararının tenfizi, tarafların yazılı olarak belirledikleri yer asliye ticaret mahkemesinden (Adli Mahkemeler K. m. 5) böyle bir anlaşma yoksa, karar aleyhine olan tarafın Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer, yoksa icraya konu malların bulunduğu yer mahkemesinden istenir (MÖHUK m. 60).

---

4 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesine göre "(1) Yabancı ülke adlî ve idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. ... - (3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye'de tanınması, 27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır...".

5 Bkz. bu konuda: Baki Kuru/Ejder Yılmaz, Türkiye'de Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması (II. Tahkim Haftası, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1984, s.191-205); Banu Şit, Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2005.

BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI

§ 78. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

A) GENEL OLARAK

İnsan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşmesi, bütün Dünyada uzun zamanlardan beri giderek daha da önem ve değer kazanan bir konudur. Günümüzde bu konuda daha somut adımlar atılmış ve uluslarüstü (supranational) mahkeme aşamasına kadar gelinmiştir. Bunun önemli örneklerinden biri de, 1950 tarihli "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme" (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; AİHS) çerçevesinde, Sözleşmeye üye ülkelerin kabul ettikleri yükümlüklere uymaları için kurulmuş olan **Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi**dir (AİHS m. 19 vd.).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, üye devletlerin kabul ettikleri ve uymak zorunda oldukları çeşitli hak ve özgürlükleri ayrı ayrı göstermekte ve bunların tanımını yapmaktadır. Örneğin, yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, cezaların yasallığı, ifade özgürlüğü, etkili başvurma hakkı, ayrımcılık yasağı vb (AİHS m. 2-18). Üye devletler, bu hak ve özgürlüklere uymazlarsa, bundan zarar gören kişilerin, Devlet'e karşı, **Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuru hakkı** vardır.

Türkiye, bu Sözleşmeye 1954 yılında (6366 s. K. ile) taraf olmuş ve 1987'de de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir. Bireysel başvuru hakkının kabul edildiğinden bu yana yapılan başvuru sayısı dikkate alındığında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aleyhine karar verdiği devletler arasında ilk sıralarda olduğu görülmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkının yanı sıra, 2010 tarihli ve 5982 s. K. ile Anayasada yapılan değişiklik sonucunda **Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı** tanınmış; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda (6216 s. K. m. 45-51) bireysel başvuru müessesesi düzenlenmiş ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile (İçtüzük m. 59-84) ayrıntılı hükümler kabul edilmiştir. Böylece Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, **iç hukuk yollarından biri haline getirilmiştir**. Bunun gerekçesi, esas itibariyle Türkiye'nin insan hakları standartlarını yükseltmek ve ayrıca, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne getirilen çok sayıdaki dava yoğunluğunu azaltarak, sorunların iç hukukta çözümlenmesi amacıdır.

Gerek AİHM'ne gerek Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların sonuçları, hukuk mahkemelerinin karara bağladığı hukuk davalarını da

etkileyebilmektedir. Bu nedenle, her iki bireysel başvuru hakkı, aşağıda ana hatlarıyla incelenmiştir.

B) ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU[1]

I – KURULUŞ VE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

Anayasa Mahkemesinde, bireysel başvuruları karara bağlamak üzere, bir başkanvekili başkanlığında yedişer üyesi olan iki bölüm bulunur. Bölümler, bir başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır (6216 s. K. m. 22).

Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi önündeki ihlâl iddialarını içeren bireysel başvurularda, yalnızca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde anılan hak ve hürriyetler değil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel hak ve özgürlükler de ifade edilir.

İhlâle neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idarî ve yargısal **başvuru yollarının** tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce **tüketilmiş olması** gerekir.

Yasama işlemleri ile **düzenleyici idarî işlemler** aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi, **Anayasa Mahkemesi kararları** ile **Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler** de **bireysel başvurunun konusu olamaz** (6216 s. K. m. 45).

Bireysel başvuru, ancak ihlâle yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. **Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz.** Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz (6216 s. K. m. 46).

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, klasik anlamdaki kanun yollarından (istinaf, temyiz, yargılamanın iadesi) biri değildir. Bireysel başvuru hakkı, bireylere tanınan temel hak ve özgürlüklerin, Devlet tüzel kişiliği tarafından ihlâl edilmesi (ki, bu ihlâlin mahkeme kararları ile de gerçekleşmesi mümkündür) üzerine, Devlet hasım gösterilerek başvurulan bir hukukî çaredir.

---

[1] Bkz. Ramazan Korkmaz, Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İstanbul 2014; Sibel İnceoğlu (Editör), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Ankara 2013; Özcan Özbey, Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara 2012.

II – BİREYSEL BAŞVURU USULÜ

Bireysel başvurular, bu Kanunda ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde (İçtüzük) belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir[2].

Bireysel başvurular **harca tâbi**dir[3]. Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlâle neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır[4].

Bireysel başvurunun yapılması süreye tâbidir. Başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren on beş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Mahkeme, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder. Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahkeme yazı işleri tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline on beş günü geçmemek üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir (6216 s. K. m. 47; İçtüzük m. 64).

Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için 45 ila 47. maddelerde öngörülen şartların gerçekleşmiş olması gerekir (6218 s. K. m. 48).

Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır[5].

Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir. Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel hakkın ihlâl edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller ilgililerden istenir. Mahkeme, incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte, gerekli görürse duruşma yapılmasına da karar verebilir.

Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi

---

2 Başvurunun yapılabileceği yerler hakkında bkz. İçtüzük m. 63.

3 Bkz. Harçlar K. (I) sayılı Tarife, A Mahkeme harçları, I, 4; İçtüzük m. 62.

4 Bireysel başvuru formu ve ekleri için bkz. İçtüzük m. 59-60.

5 İçtüzük m. 66.

üzerine karar verebilir. Tedbire karar verilmesi hâlinde, esas hakkındaki kararın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı kendiliğinden kalkar (İçtüzük m. 73).

Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin incelemeleri, bir temel hakkın ihlâl edilip edilmediği ve bu ihlâlin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz (6216 s. K. m. 49).

Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının **ihlâl edildiğ**ine ya da **edilmediğ**ine karar verilir.

Bölüm, ihlâlin bir mahkeme kararından kaynaklandığını tespit ederse, aşağıdaki kararlardan birini verir:

1) İhlâli ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için **yeniden yargılama yapmak üzere** dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. İlgili mahkeme, Bölümün ihlâl kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde **yeniden yargılama yapar** ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir[6]. Bölüm kararında, gerekli görüldüğü takdirde Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ihlâlin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan kaldırılabileceği hususunda yapılması gerekenler belirtilir (İçtüzük m. 79).

2) Bölümlerce yapılan inceleme sonunda, başvurucunun bir hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi halinde, yeniden yargılama yapılmasında hukukî yarar bulunmadığı takdirde başvurucu lehine uygun bir **tazminata hükmedilebilir**.

3) Tazminat miktarının tespitinin, daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi hâlinde, Bölüm bu konuyu kendisi karara bağlamaksızın genel mahkemelerde **dava açılması yolunu gösterebilir**.

İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlâlin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak **yerindelik denetimi yapılamaz**, idarî eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.

Anayasa Mahkemesi, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden AİHS ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu Protokoller kapsamındaki herhangi birinin (örneğin adil yargılanma hakkının) kamu gücü tarafından ihlal edildiği ve ihlâlin bir mahkeme kararından kaynaklandığını 6216 s. K. m. 50, 2 uyarınca tespit ederse, ihlâli ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkeme gönderir. Bu hüküm, bir yargılamanın iadesi sebebi olarak nitelendirilebilir. Buna bağlı olarak yeniden yargılama yapılması sonucunda kesin hükmün ortadan kaldırılabileceğini de ifade etmek gerekir.

Bölümler, bir başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol açtığını tespit etmeleri ya da bu durumun yeni başvurulara yol açacağını öngörmeleri hâlinde, pilot karar usulünü uygulayabilirler. Bu usulde, konuya ilişkin Bölüm tarafından pilot bir karar verilir. Benzer nitelikteki başvurular idarî mercilerce bu ilkeler çerçevesinde çözümlenir; çözümlenmediği takdirde Mahkeme tarafından topluca görülerek

---

[6] Bkz. yargılamanın iadesi ile ilgili m. 375, 1/i; HUMK m. 445, I/11.

karara bağlanır. Bölüm, pilot karar usulünü resen, Adalet Bakanlığının ya da başvurucunun istemi üzerine başlatabilir. Pilot karar uygulaması için seçilen başvuru, gündemin öncelikli işleri arasında sayılır. Bölüm, pilot kararında, tespit ettiği yapısal sorunu ve bunun çözümü için alınması gereken tedbirleri belirtir. Bölüm, pilot kararla birlikte, bu karara konu yapısal soruna ilişkin benzer başvuruların incelenmesini erteleyebilir. İlgililer erteleme kararı hakkında bilgilendirilirler. Bölüm, gerekli gördüğü takdirde ertelediği başvuruları gündeme alarak karara bağlayabilir (İçtüzük m. 75).

Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca disiplin para cezasına hükmedilebilir (6216 s.K. m. 51).

C) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

I – KURULUŞ VE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 19. maddesine göre kurulan bir mahkemedir. Çalışma yeri, Fransa'nın Strasbourg şehridir.

Mahkeme, Sözleşmeye üye devletlerin sayısına eşit hâkimden oluşur. Hâkimler, üye devletlerin gösterdiği üç aday içinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir (AİHS m. 20-23; AİHM İçtüzüğü m. 2-7).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan devletin Sözleşmedeki (ve ilgili Protokollerdeki) yükümlülüklerini ihlâl etmesinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek kişi, hükûmet dışı kuruluş veya kişi grupları, ilgili devlete karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine **bireysel başvuru hakkı**na sahiptir (AİHS m. 34).

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hukukî niteliği gereği, iç hukukta (millî) mahkemece verilen kararların temyiz mercii değildir; ilgili devletin Sözleşmede belirtilen hak ve hürriyetleri ihlâl ettiğinin bildirilmesi üzerine denetim yapan bir mahkemedir.

Mahkeme, duruma göre, Genel Kurul, Büyük Daire, Bölüm, Daire ve Komiteler şeklinde faaliyette bulunur. Bireysel başvuru, kural olarak, yedi hâkimden oluşan Daire tarafından incelenir. Dairenin kararına itiraz, Büyük Daire tarafından değerlendirilir.

II – BİREYSEL BAŞVURU USULÜ

Mahkemeye başvurulabilmesi için, (Mahkeme uygulamasından kaynaklanan çok istisnaî haller dışında) uyuşmazlık konusu olay hakkında iç hukukta öngörülen mekanizmaların (Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu dahil), **iç hukuk kurallarının tüketilmesi gerekir**. Ancak tüketilecek iç hukuk yollarının etkin, ulaşılabilir, normal usulün bir parçası ve makul bir başarı şansı sunmuş olması gerekir; iç hukuk yollarının etkin ve yeterli olmaması halinde, iç hukuk yolları tüketilmeden de Avrupa İnsan hakları Mahkemesine başvurulabilir. İhlâl kanundan veya idarî uygulamadan ileri gelirse, iç hukuk

yollarını tüketme şartı aranmaz. Benzeri şekilde, iç hukuk yolları, makul süre içinde bitmemişse (ki, makul süre, AİHS m. 6'ye göre adil yargılanma hakkının bir unsurudur), iç hukuk yollarının tüketilmesi aranmaz.

Bireysel başvuru süreye tâbidir ve iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve **kesin karardan itibaren altı ay** içinde başvuru yapılmalıdır (AİHS m. 35, 1).

Bireysel başvuru bir dilekçe ile (bununla ilgili form kullanılarak) yapılır (AİHM İçtüğüzü m. 38, 47). Başvuran dilekçesini kendi diliyle (Türkçe olarak) yazabilir (AİHM İçtüzüğü m. 34). Bireysel başvurular ücretsizdir; yargılama giderleri, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır.

Mahkeme yapılan bireysel başvuruların usulen incelenebilir olduğunu (AİHM İçtüzüğü m. 52 vd.) tespit ederse, işin esasına incelemeye geçer. Başvurular sırasıyla ele alınır. Ancak, Mahkemenin bazı işlere öncelik tanıması mümkündür.

Mahkeme, yargılamanın her aşamasında, anlaşmazlığın Sözleşmede yer alan insan haklarına saygı ilkesine dayalı olarak sulhen (barışçıl) çözüme ulaşabilmesi için çalışır. Bu işlemler gizlidir (AİHM İçtüzüğü m. 62). Uyuşmazlığın sulhen çözümlenmesi halinde Mahkeme, olayların kısa bir özeti ile ulaşılan sonucu kapsayan bir kararla davayı düşürür (AİHS m. 39).

Duruşmalar, (istisnaî durumlar dışında) kamuya açıktır (alenîdir). Aynı şekilde, Mahkeme kalemine verilen belgeler de, kural olarak kamuya açıktır. Mahkeme, tarafların dayandığı deliller dışında kendiliğinde de delil toplayabilir; tanık, uzman kişi gibi ilgilileri dinleyebilir (AİHM İçtüzüğü m. 42).

Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda, Sözleşmenin ihlâl edildiği sonucuna varırsa, davalı devletin iç hukuku ihlâli kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme gerekirse, davacı lehine hakkaniyete uygun tazminata hükmeder (AİHS m. 41).

Üye devletler, kendilerinin taraf olduğu davalarda Mahkeme kararına uymakla yükümlüdürler. Mahkeme kararları Bakanlar Komitesine gönderilir ve bu Komite kararların uygulanmasını denetler (AİHS m. 46).

Mahkeme kararının bağlayıcılığı sebebiyle, incelenen somut olayın özeli bakımından; davalı devlet tazminata mahkûm edilmişse, bu tazminatı ödemek zorundadır. Keza, incelenen somut olayın özelliğine göre, yargılamanın yenilenmesi gerekiyorsa, bu yola gidilir. Nitekim, Türk hukuku bakımından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararı (AİHS m. 44), **yargılamanın iadesi nedeni**dir (HUMK m. 445, XI; HMK m. 375, 1/i; İYUK m. 53; CMK m. 311).

Bunun dışında, Mahkemenin kararı sebebiyle, aleyhine karar verilen ilgili devletin bazı genel tedbirler alması da gerekebilir. Örneğin, kamuoyunun ve özellikle kamu makamlarının bundan sonraki olaylarda aynı hatanın tekrarlanmamasını teminen bilgilendirilmesi; mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması; millî mahkeme kararlarında değişiklik yapılması gibi.

§ 79. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

A) GENEL BİLGİ

Tarafların aralarındaki uyuşmazlıklara, dava yerine kendi iradeleri ile, uzlaşarak son vermelerini amaçlayan ve son dönemlerde bütün Dünya'da yaygınlaştığı gözlemlenen "alternatif uyuşmazlık çözümü"[1] yollarından biri de "arabuluculuk"tur. Ülkemizde bu konu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun uygulanmasını göstermek üzere Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği[2] de yürürlüğe konulmuştur.

Arabuluculuk, "sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi" şeklinde tanımlanmaktadır (HUAK m. 2, 1/b). Kanunun ilk düzenlemesinde arabulucunun taraflara çözüm önerisi getiremeyen bir konumda tanımlanmış olmasına rağmen 7036 s. K. ile yapılan değişiklik sonucu, arabulucunun aktif bir rol üstlenebileceği, taraflara çözüm önerisi de sunabileceği benimsenmiştir.

Kanunun Genel Gerekçesinde de belirtildiği üzere, arabuluculuk (alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi), aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi, amaç yargısal yollara başvuru imkânını ortadan kaldırmak da değildir. Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır[3].

B) ARABULUCULUĞUN KONUSU VE TEMEL İLKELERİ

Arabuluculuğun konusu, tarafların üzerinde **serbestçe tasarruf** edebilecekleri (tarafların iradesine bağlı olan) iş ve işlemlerden doğan **özel hukuk uyuşmazlıkları** ile sınırlanmıştır (HUAK m. 1, 2). Uyuşmazlıkta yabancı un-

---

1 "Alternative dispute resolution" (ADR). Bu konuda bkz. Mustafa Serdar Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2016; Gülgün Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2002; Ejder Yılmaz, Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi ("Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı"nın Değerlendirilmesi), (Prof. Dr. Tuğrul Arat Armağanı, Ankara, 2012, s. 1275-1297; Yılmaz, Makaleler, C. 2, s. 1949-1970).

2 Bkz. RG 02.06.2018, sa. 30439.

3 Arabuluculuk Kanununun pek çok hükmü Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine götürülmüş; ancak Anayasa Mahkemesi, Kanunu, Anayasaya aykırı bulmamıştır. Anayasa Mahkemesinin 10.07.2013 gün ve 94/89 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul Pratik, s. 135-146.

surun bulunup bulunmaması önemli değildir; yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda da, arabuluculuk müessesesine gidilebilir.

Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler, iradî olma ve eşitlik; gizlilik; arabuluculuktaki bazı beyan veya belgelerin ileride açılacak olan davalarda, kural olarak, kullanılamamasıdır.

Arabuluculuk, kanunlarda aksi öngörülmedikçe **tarafların iradesine bağlı** bir sistemdir. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler (HUAK m. 3, 1).

İş Mahkemeleri Kanununa göre Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır[4] (İş Mahk. K. m. 3, 1). Buna karşılık, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı değildir (İş Mahk. K. m. 3, 3).

Türk Ticaret Kanununa (m. 5/A) göre de, Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır[5]. Dava şartı olarak arabuluculuk 7155 s. K. m. 23 ile HUAK 'na eklenmiş ve m. 18/A olarak düzenlenmiştir.

Gerek arabulucuya başvururken gerek tüm arabuluculuk süreci boyunca, taraflar arasında **eşitlik ilkesi** geçerlidir (HUAK m. 3, 2). Eşitlik, hemen her konuda, özellikle de uyuşmazlığın çözümünde öncelikle gözönünde tutulması gereken Anayasal bir ilkedir. Eşitlik hem yargılama yapılarak varılan çözüm yöntemlerinde hem de yargılama yapılmadan varılan çözüm yöntemlerinde ortak bir ilkedir. Taraflardan birini dışlayarak veya ona daha az söz hakkı vererek varılan sonuçta, gerçek bir uzlaşmadan ya da anlaşmadan söz edilemez. Devlet yargısı önünde eşit olan tarafların, iradî olarak başlatıp yürüttükleri arabuluculuk sürecinde de eşit olmamaları düşünülemez.

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde **elde ettiği bilgi ve belgelerle tuttuğu kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.** Aksi kararlaştırılmamışsa taraflar da bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar (HUAK m. 4/1-2). Devlet mahkemelerindeki yargılamanın, alenî olması kural (HMK m. 28) iken, tarafların devlet yargısı dışında, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığı çözmek istemelerinin en önemli sebeplerinden biri, aralarındaki uyuşmazlığın üçüncü kişilerce bilinmesini istememeleri olduğu için, taraflar aralarındaki uyuşmazlığı ve uyuşmazlığı oluşturan bilgi ve belgelerin gizli tutulmasını isterler. Arabulucu bu gizliliğe uymak zorundadır. Gizliliğin ihlâli, ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir (HUAK m. 33).

---

4 Anayasa Mahkemesi, dava şartı arabuluculuk düzenlemesinin de Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin 11.07.2018 gün ve E. 2017/178 ve K. 2018/82 sayılı kararı için bkz. RG 11.12. 2018 sa. 30622

5 Bkz. 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (RG 19.12.2018, sa. 30630).

Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dahil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak **hukuk davası açıldığında** yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki **beyan** veya **belgeleri delil olarak ileri süremez** ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz: a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteği; b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler; c) Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü, ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler (HUAK m. 5, 1). Bu düzenleme, sulh sırasındaki ikrarın bağlamayacağına ilişkin HMK m. 188, 3 hükmüne benzetilebilir. Anılan bu beyan ve bilgilerin açıklanması, mahkeme, hakem veya herhangi bir idarî makam tarafından istenemez ve bu beyan veya belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine, delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir (HUAK m. 5, 3). Birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, hukuk davası ve tahkimde ileri sürülen caiz deliller, sadece arabuluculukta sunulmaları sebebiyle kabul edilemeyecek deliller haline gelmez (HUAK m. 5, 5).

C) ARABULUCU

Arabulucu, tarafların anlaşarak arabulucular siciline (HUAK m. 19-21) kayıtlı olanlar arasından seçtikleri ve arabuluculuk faaliyetini yürüten **üçüncü bir kişi**dir (HUAK m. 2, 1/a).

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini uygulayan kimsedir.

Arabulucuların hak ve yükümlülükleri şunlardır:

Arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanabilmek için, **arabulucular siciline kayıtlı olmak** gerekir (HUAK m. 19 vd.).

Arabulucu, yapmış olduğu faaliyet karşılığı **ücret ve masraf isteme hakkı**na sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadığı sürece arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan **Arabulucu Asgarî Ücret Tarifesi**ne göre belirlenir; aksi kararlaştırılmadıkça ücret ve masraf, taraflarca eşit olarak karşılanır (HUAK m. 7).

Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya her ikisiyle aynı anda görüşebilir veya iletişim kurabilir. Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir (HUAK m. 8; 15, 6).

Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve **şahsen** yerine getirir. Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı hâlinde, bu hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklamaya rağmen taraflar, arabulucudan birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir. Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada, daha sonra taraflardan birinin avukatı olarak görev üstlenemez (HUAK m. 9).

Arabuluculuk, tamamen bir güven işidir; her iki tarafın güveninin sağlanamaması halinde arabulucu başarılı olamaz. Güven, arabulucunun kişiliği ile ilgili olduğu kadar, onun bilgisi ve mutlak tarafsızlığıyla da ilgilidir. Arabuluculuğun hukukî niteliği hakkında zaman içerisinde, benzeri durumlara paralel olarak, farklı görüşler ortaya çıkacağı ve arabuluculuğun örneğin, vekâlet veya hizmet yahut eser yapım (istisna) sözleşmesi olarak değerlendirilebileceğini tahmin etmek zor değildir. Bunlardan hangi sonuca varılacak olursa olsun, hepsindeki ortak nokta, özen borcudur; özen borcunun ifasının da "bizzat" yapılması gereklidir.

Arabulucuların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında arabulucu unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır (HUAK m. 10). Bunu **reklâm yasağı** olarak adlandırmak mümkündür.

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlüdür (HUAK m. 11). Arabulucunun, aydınlatma yükümlülüğü, başlangıçta mutlaktır, ayrıca süreç içinde de gerekli durumlarda, bilgilendirme ve aydınlatma faaliyetinde bulunmalıdır. Özellikle, sürecin aksamaya başladığı anlarda ve durumlarda, bu daha da önemlidir. Zira, arabulucunun en önemli görevi, işin niteliği gereği anlaşma zeminini korumak ve tarafları masada tutmaktır.

D) ARABULUCULUK USULÜ

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. **Mahkeme de** tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, **teşvik eder** (HMK m. 137, 1). Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise, bu teklif reddedilmiş sayılır (HUAK m. 13).

Başkaca bir usul kararlaştırılmamışsa, **arabulucu** (arabulucular) **taraflarca seçilir** (HUAK m. 14). Dava şartı olarak arabuluculuk hükümlerinin uygulanması gereken hallerde, arabulucu maddede düzenlenen şekilde seçilir (HUAK m. 18/A).

Arabulucu, seçildikten sonra, tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder. **Taraflar**, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak şartıyla, **arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler**. Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlı-

ğın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları gözönüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür (HUAK m. 15, 1-3).

Hükmün Gerekçesinde de belirtildiği üzere; arabuluculuk, niteliği gereği esnek bir yapıya sahiptir. Bu sebeple katı ve sıkı kurallara bağlı değildir. Bunun sonucu olarak da taraflar, arabuluculuk faaliyetinin nasıl yürütüleceğini ve izlenecek usûlü serbestçe kararlaştırabilirler. Taraflar, bu faaliyetin nasıl yürütüleceğini önceden veya bu faaliyetin başında kararlaştırmamış olabilirler. Bu durumda arabulucu, öncelikle uyuşmazlığın niteliği ve tarafların bu konudaki isteklerini dikkate alacak, ayrıca, uyuşmazlığın kolay ve çabuk çözümünü sağlayacak bir yol izleyecektir.

Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz (HUAK m. 15, 4). Zira, arabuluculuk yargısal bir faaliyet olmayıp **alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi**dir. Uyuşmazlık yargısal bir faaliyetle ve hâkim tarafından çözüldüğünde kullanılacak yetki ile arabuluculukta arabulucunun kullanacağı yetkiler aynı değildir. Arabulucu, uyuşmazlığın çözümünde taraflara yardımcı olan, çözüm ortamını hazırlayan kişi konumundadır; ancak **karar veren kişi değildir**. Arabulucunun yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi bakımından bu açık düzenlemeye yer verilmiştir. Bu çerçevede, hâkimin yargılama faaliyeti ile ilgili yaptığı işlemler, özellikle tahkikat işlemleri, örneğin keşif, bilirkişiye başvurma gibi işlemler arabulucu tarafından yapılamaz. Buna bağlı olarak **yargısal yetki kullanılması** ve zorlayıcı bir takım işlemler, arabuluculuk faaliyetinde **söz konusu olamaz.**

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde, **yargılama mahkemece üç ay süre ile ertelenir**. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç ay daha uzatılabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan her biri arabuluculuk müzakerelerine bizzat katılır (HUAK m. 15, 5-6).

Arabuluculuk süreci, **dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde**, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabulucuya başvurma davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri yada duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz (HUAK m. 16). Böylece, arabuluculuk faaliyeti sebebiyle geçirilen sürelerin taraflar açısından hak kaybına neden olması önlenmek istenmiştir.

Tarafların anlaşmaya varması; taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla **çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi**; taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi; tarafların anlaşarak arabulu-

culuk faaliyetini sona erdirmesi; uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi hallerinde **arabuluculuk faaliyeti sona erer** (HUAK m. 17, 1).

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı, bir **tutanak** ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanır (karş. AK m. 35/A). Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, faaliyetin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar (HUAK m. 17, 2-3).

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda varılan **anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir**; anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır (HUAK m. 18, 1).

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu **anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh** verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, **arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesi**nden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, **davanın görüldüğü mahkeme**den talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır (HUAK m. 18, 2).

İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir (HUAK m. 18, 3; HMK m. 382 vd.) ve buna ilişkin inceleme, dosya üzerinden de yapılabilir (HUAK m. 18, 3; HMK m. 385, 1; 320, 1). Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebrî icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır.

Mahkemenin bunun dışına çıkarak anlaşmanın içeriğine müdahale etmesi veya bir düzeltme yapması mümkün değildir. Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bu **başvurunun reddi** üzerine ilgili tarafından **istinaf yoluna gidilmesi hâlinde**, maktu harç alınır. Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden bir başka resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır (HUAK m. 18, 3). İstinaf mahkemesinin verdiği karar kesindir. Çünkü, çekişmesiz yargı işlerinde verilen karara karşı temyiz yoluna gidilemez (m. 362, 1/ç).

Anlaşmaya varan tarafların mahkemeden icra edilebilirlik şerhi talep etmeleri her zaman söz konusu olmaz. Zira taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilâm niteliğinde belge sayılır (HUAK m. 18, 4).

Arabuluculuğun alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olması nedeniyle hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmadığını ifade etmiştik. Ancak tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varması ve bu konuda bir an-

laşma belgesi düzenlenmesi halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz (HUAK m. 18, 5).

bkz. HUAK m. /A.

§ 80. TAHKİM

A) GENEL OLARAK

Hakkı bir başka kişi tarafından tanınmayan bir kişinin (davacının), hakkının tanınması için ancak Devlet'in mahkemelerine başvurabileceği, bunun tek istisnasının tahkim yolu (müessesesi) olduğu yukarıda belirtilmişti. Devletin mahkemelerinde davaların nasıl görüleceğini inceledikten sonra, şimdi tahkim yolunu inceleme sırası gelmiştir.

Belirtelim ki, Türk hukukunda **iç tahkim**, HMK'nun 407-444. maddelerinde; **milletlerarası tahkim**, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda düzenlenmiştir. Aşağıda yalnızca **iç tahkim** (m. 407-444) hükümleri incelenecektir. HMK'nun iç tahkime ilişkin aşağıda inceleyeceğimiz kurallarıyla Milletlerarası Tahkim Kanununda yer alan kurallar bir arada değerlendirildiğinde, tahkime ilişkin iki ayrı kanundaki düzenlemelerin büyük ölçüde benzer olduğu görülür.

Aslında genel olarak tahkim hukuku, HMK'nun iç tahkim hükümleri ile ülkemizde yürürlükte bulunan Milletlerarası Tahkim Kanunundan[1] ibaret değildir. Tahkim konusunda bunların dışında başkaca düzenlemeler ve Türkiye'nin de taraf olduğu bazı uluslararası anlaşmalar da vardır. Keza, yabancı hakem kararlarının Türkiye'de tanınıp tanınmayacağı veya tenfiz edilip edilmeyeceği konusunda gerek öğretide gerek Yargıtay kararlarında yoğun tartışmalar yapılmaktadır.

Bunun ötesinde, gerek çeşitli ülkelerde gerek ülkemizde, kurumsal olarak tahkim işlerini yapan müesseseler (**tahkim müesseseleri**) vardır. Örneğin Paris'te bulunan Milletlerarası Ticarî Tahkim (ICC) kuruluşu; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)[2] veya Türkiye Odalar ve Borsalar birliği nezdindeki TOBB Tahkimi gibi. Bu vesileyle belirtmek gerekirse, kurumsal tahkimin karşılığı "**ad hoc tahkim**"dir ve tahkim heyeti, belli (münferit) somut uyuşmazlıklarda hakem olarak görev yaparlar[3].

---

1 Milletlerarası tahkim konusunda bkz. Turgut Kalpsüz, Türkiye'de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2010.

2 Bkz. 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (RG 29.11.2014, sa. 29190).

3 Tahkim konusunda genel bilgiler için bkz: Bkz. Ejder Yılmaz, Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki Gelişim (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s.268-286; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 1175-1198); Ramazan Arslan, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri (X. Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara 2012, s.23-53); Nuray Ekşi, Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim, İstanbul 2013.

B) TAHKİMİN NİTELİĞİ[4]

Bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşmüş olan iki tarafın anlaşarak, bu uyuşmazlığın çözümlenmesini özel kişi veya kişilere bırakmalarına ve uyuşmazlığın bu özel kişi veya kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasına tahkim denir. Uyuşmazlığın çözümlenmesi kendilerine bırakılan bu özel kişi veya kişilere de hakem/hakem kurulu denir. Hakemlerin kendilerine havale edilen davayı (uyuşmazlığı) görmek hususunda hiç bir resmî sıfatları yoktur. Fakat, taraflar uyuşmazlığın çözümünü onlardan istemekle hakemlerin verecekleri karara razı olurlar ve hakemler o uyuşmazlık (dava) bakımından bir mahkeme gibi yargılama yapıp karar verirler. Bu nedenle, hakemlere (hakem heyeti'ne) "hakem mahkemesi" de denilmektedir.

Burada söz konusu olan **ihtiyarî** (isteğe bağlı) **tahkim**, yani tarafların rızaları ile başvurabilecekleri tahkim yoludur. Burada, taraflar bir davanın (uyuşmazlığın) çözümlenmesi için hakeme başvurmaya mecbur değildirler; dava normal olarak mahkemelerde görülür. Ancak taraflar anlaşarak, aralarındaki bir uyuşmazlığı (davayı), seçecekleri hakem veya hakemlere gördürebilirler.

Bazı hallerde ise, bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme başvurmak zorunludur ki, buna zorunlu (**mecburî**) **tahkim** denir. Tahkimin hangi hallerde zorunlu olduğu, özel bir kanun hükmü ile belirlenir. Zorunlu (mecburî) tahkime tâbi iş ve davalarda, taraflar Devlet mahkemelerinde dava açamazlar; kanunla gösterilen hakemlere başvurmaya (yani hakemlerde dava açmaya) mecburdurlar.

Mecburî tahkim hallerine örnekler:

Umumî, Mülhak ve Hususî Bütçelerle İdare edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı **Devlete** veya Hususi İdarelere **Ait Daire** ve **Müesseseler Arasındaki İhtilafların** Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun; Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 13, II.

Toplu iş uyuşmazlıklarında mecburî tahkim (6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi K. m. 49 vd.). Yalnız, toplu iş uyuşmazlıklarındaki mecburî tahkim, yukarıdaki tahkim hallerine nazaran bir özellik arz eder: Toplu iş uyuşmazlıklarında, taraflar uyuşmazlığın çözümlenmesi için mutlaka kanunî hakeme (6356 s. K. m. 49) başvurmak zorunda değildirler; özel hakeme de başvurabilirler (6356 s. K. m. 52). Fakat burada taraflardan biri, ortada hiç bir tahkim sözleşmesi olmadığı halde, kanunî hakeme başvurabilir ve uyuşmazlığın kanunî hakemler (Devletin bir organı olarak görev yapan Yüksek Hakem Kurulu) tarafından karara bağlanmasını isteyebilir ve bunun için karşı tarafın rızasına ihtiyaç yoktur ki, toplu iş uyuşmazlıklarındaki tahkimin mecburî olması buradan gelmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 66-72 (tüketici hakem heyeti)[5].

---

[4] Bkz. Yavuz Alangoya, Medenî Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul 1973.

[5] Bkz. yuk. § 75.

3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu m. 14.; Noterlik K. m. 49, IV[6]; 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun m. 6[7].

Zorunlu (mecburî) tahkime ilişkin bu özel kanun hükümlerinde açıklık bulunmayan hallerde (önleyici bir hüküm bulunmadıkça), HMK m. 407-444 hükümleri kıyasen uygulanır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, burada incelenecek olan ihtiyarî tahkimdir ve bundan sonraki açıklamalar, HMK m. 407-444'de düzenlenmiş olan **ihtiyarî tahkim** hakkındadır.

İhtiyarî (isteğe bağlı) tahkimin **uygulanma alanı**, Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda (4686 s. K. m. 1) yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklardır (m. 407).

Tahkim sadece, çekişmeli yargıya giren hukuk uyuşmazlıkları hakkında mümkündür. Ceza yargısında, idarî yargıda[8] ve çekişmesiz yargıda (m. 382 vd.) tahkim caiz değildir.

Konumuz olan ihtiyarî tahkim, sözleşmeye dayanır. Bu da başlıca iki ayrı sözleşmeden (MTK m. 4) oluşur:

Tahkim sözleşmesi: Tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün, hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki bir hukukî ilişkiyi düzenleyen bir sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir (m. 412, 1, 2). Tahkim sözleşmesinin hukukî niteliği konusunda öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, tahkim sözleşmesi maddî hukuk sözleşmesidir ve bu sözleşmeye maddî hukuk kuralları uygulanır; diğer bir görüşe göre ise, tahkim sözleşmesi usul hukuku sözleşmesidir ve bu sözleşmeye usul hukuku kuralları uygulanır. Bunların yanı sıra, tahkim sözleşmesinin bir yanı itibariyle maddî hukuk, diğer bir yanı itibariyle usul hukuku sözleşmesi olduğunu kabul eden karma görüş de vardır. Kanımızca tahkim sözleşmesi, taraflar arasında usulî ilişki kurmayı, değiştirmeyi veya kaldırmayı amaçlayan ve birincil (aslî) etkilerini doğrudan yargılama hukukunda ortaya çıkaran bir sözleşme olması sebebiyle, usul hukuku sözleşmesidir. Bu husus, Yargıtayın 13.04.2018 gün ve 02/04 sayılı kararında da benimsenmiştir[9].

---

6 Ejder Yılmaz, Boşalan Noterliklere Ait Daire ve Eşyaların Devri (Noterlik Hukuku Sempozyumu: III-IV-V, Ankara 1999, s.19-39; Yılmaz, Makaleler C. 1 s. 1027-1044).

7 Bkz. Ejder Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Hiçbir Yargı Merciine Başvurulamamasının Yanlışlığı (Av. Atilâ Elmas Armağanı, Ankara 2012, s. 817-841; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 2025-2042). Ayrıca Anayasa Mahkemesinin Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarının kesin olmasının Anayasaya aykırı olduğu şeklindeki 06.01.2011 gün ve 61/07 sayılı kararı için bkz. Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/ Hanağası-Usul Pratik, s. 107-110.

8 Fakat uygulamada, idarî sözleşmelere bazen tahkim şartı da konulmakta ve bu idarî sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar için, idarî mahkemeler yerine, hakemlerde dava açılmaktadır.

9 RG 18.09.2018, sa. 30539.

Hakem sözleşmesi: Bu sözleşme, taraflar ile hakem/hakemler arasında yapılır. Bununla, taraflar aralarındaki uyuşmazlığın hakem veya hakemlerce çözümlenmesini teklif, hakem/hakemler de hakem olarak o uyuşmazlığa bakmayı kabul ederler.

Uygulamada bu iki sözleşme ekseriya ayrılmaz ve ikisini de kapsar şekilde hakem sözleşmesi terimi kullanılır. Fakat, tahkim müessesesinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu iki terimi ayırmakta fayda vardır.

Tahkimin niteliği hakkındaki açıklamaların sonunda, tahkim (hakemler) ile **hakem-bilirkişiler** arasındaki farka işaret etmek yerinde olacaktır. Yukarıda görüldüğü gibi, hakem-bilirkişi tayinine ve onların raporlarının (tespitlerinin) taraflarca kabul edileceğine ilişkin anlaşma, hukukî nitelikçe m. 193'e uygun bir delil sözleşmesidir[10].

Hakem-bilirkişiler, aşağıda göreceğimiz **hakemlerden tamamen farklı kişilerdir**. "Hakem tıpkı hâkim gibi vakıaları kanun veya tarafların kararlaştırdıkları norm çerçevesinde icra ederek bir hüküm vermekle mükellef olan kimsedir. Halbuki, hakem-bilirkişi bir hukuki meselenin halli kendisine bağlı bulunduğu bir vakıayı tayin ve tespit etmekle vazifelendirilen kimsedir. Hakem-bilirkişiler, haklar ve hukuki münasebetler üzerinde karar veremezler. Bunlar ancak bir zararın vukuunun miktarını, bir şeyin kıymetini, bir kusurun mevcudiyetini ihtisaslarına binaen tayin ve tespit ederler. Bu itibarla bunlar alelâde ehlivukuftan (bilirkişiden) bu noktada farklıdırlar".

Hakem-bilirkişilerin görevi, sadece kendilerine havale edilen hususu (örneğin hasarı) tespitle sınırlıdır. Hakem-bilirkişiler, örneğin sigortalı malın hasarını tespit ettikten sonra, bu hasarı kimin ödeyeceğine karar veremezler. Hakem-bilirkişilerin yaptıkları iş sadece bir tespitten ibaret olduğundan, kararlar doğrudan doğruya icra (infaz) edilemez. Bu nedenle, hakem-bilirkişilerin kararlarına karşı kanun yoluna da başvurulamaz. Hakem-bilirkişilerin yaptıkları tespit, sadece mahkemede açılan davada hâkimin hükmüne esas teşkil eder.

Görüldüğü gibi, hakem-bilirkişiler, hakemlerden tamamen farklı kişilerdir ve kararları da bir hakem kararı değildir.

Buna karşılık, **hakem-dispeçci** (karş. TTK m. 1279 vd.) kararları, m. 407 vd. hükümlerine göre hakem kararı niteliğinde sayılmaktadır.

C) TAHKİM SÖZLEŞMESİ[11]

Tahkim sözleşmesi ile taraflar, aralarındaki bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için tahkim yoluna, yani hakeme başvurmayı (gitmeyi) kararlaştırırlar (m. 412).

Tahkim sözleşmesi, bir sözleşme olması itibariyle, aslında TBK hükümlerine tâbidir. Ancak, burada taraflar, davanın bir mahkeme yerine özel kişiler

---

[10] Bkz. Ali Yeşilırmak, Türkiye'de Ticari Hayatın Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011.

[11] Bkz. Hüseyin Afşin İlhan, Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği, Ankara 2016.

tarafından görülmesini kararlaştırdıklarından ve bu özel kişiler (hakemler) ileride görüleceği gibi, duruma göre, uyuşmazlığı kanunlara göre çözümlemek zorunda olmayıp, adalet ve nasafet esaslarına göre karar verebileceklerinden, kanun (HMK) tahkim sözleşmesini bazı özel şartlara tâbi tutmuştur. Bu özel şartların konulmasının nedeni, tarafların korunması ve bu usulün (yolun) kötüye kullanılmasının önlenmesidir.

I – TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ

Tahkim sözleşmesi müstakil (ayrı) bir sözleşme şeklinde yapılabileceği gibi bir sözleşmeye konulacak hüküm (şart) olarak da yapılabilir (m. 412):

Taraflar, doğmuş olan veya doğabilecek bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi için ayrı bir sözleşme yapabilirler. Bu sözleşmenin konusu, sadece tahkimdir. Müstakil tahkim sözleşmesine, **dar anlamda tahkim sözleşmesi** de denir.

Taraflar yaptıkları bir sözleşmeye (satım, eser yapım -istisna-, şirket vs. sözleşmesine), bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümleneceğini şart (hüküm, kloz, kayıt) olarak koyabilirler. Burada tahkim, o sözleşmenin yalnız başına konusu olmayıp, o sözleşmenin yalnız bir şartını teşkil etmektedir. Buna **tahkim şartı** denir. İşte bu şart, kanunun anladığı anlamda bir tahkim sözleşmesidir ve tahkim sözleşmesinin tâbi bulunduğu hükümlere tâbidir. Müstakil tahkim sözleşmesinin uygulaması azdır; daha çok tahkim şartına rastlanır.

Tarafların, bir tahkim sözleşmesi yapma (veya bir sözleşmeye tahkim şartı koyma) **arzularının** (istediklerinin), başka bir deyişle aralarındaki uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini istediklerinin, tahkim sözleşmesinde (veya tahkim şartında) **açıkça belirtilmesi** gerekir.

II – TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI

Tahkim sözleşmesi, her şeyden önce borçlar hukukunun sözleşmelere ilişkin kurallarına göre yapılır. Bu nedenle, bir sözleşme için gerekli genel şartların tahkim sözleşmesinde de bulunması gerekir. HMK, bundan başka bazı ek şartlar kabul etmiştir ki, burada yalnız bu ek şartlar incelenecektir.

1) Yazılı Şekil

Tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde olması lâzımdır. Bu (yazılı) şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin tarafların imzaladığı yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığı iddiasına davalının cevap dilekçesinde itiraz etmemiş olması yeterlidir. Taraflar arasındaki hukukî ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır (m. 412, 3; karş. m. 409).

2) Konusu

Tahkim sözleşmesi, tarafların iradesine tâbi olan uyuşmazlıklar için mümkündür (m. 408). Başka bir deyişle, tarafların dava konusu üzerinde kabul veya sulh yolu ile **serbestçe tasarruf edemeyecekleri hallerde,** tahkim mümkün değildir. Örneğin boşanma ve ayrılık davaları, iflâs davaları ve çekişmesiz yargı işleri için tahkim sözleşmesi yapılamaz. Aynı şekilde, taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklardan veya iki tarafın iradelerine tâbi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkimin konusu olamaz (m. 408, 1). Buna karşılık, örneğin bir alacakla veya eser sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar tahkimin konusu olabilir.

Yargıtay, kira bedelinin tespiti davalarında tahkim yoluna başvurulamayacağına karar vermiştir. Kanımızca, kira bedelinin tespiti davalarında taraflar dava konusu olan kira bedeli üzerinde serbestçe tasarruf edebileceklerinden, kira bedelinin tespiti için hakeme başvurulması da mümkün olmalıdır.

3) Uyuşmazlık Belirli Olmalıdır

Belirli bir uyuşmazlık hakkında tahkim sözleşmesi yapılabilir. Taraflar, tahkim sözleşmesi yaparken hangi uyuşmazlık hakkında bu sözleşmeyi yaptıklarını bilmelidirler. Belli bir hukukî ilişkiden (örneğin satış sözleşmesinden) doğacak uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümleneceğinin kararlaştırılmış olması halinde (tahkim şartı), uyuşmazlık yine belirli sayılır. Buna karşılık, "bundan sonra aramızda çıkacak bütün uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulacaktır" şeklindeki genel bir tahkim sözleşmesi geçerli değildir.

III – TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ

Taraflar, tahkim sözleşmesinin konusu olan uyuşmazlık hakkında dava açmak isterlerse, tahkim yoluna gitmek zorundadırlar; yani, davayı genel mahkemelerde değil, hakem veya hakem kurulunda açabilirler.

Ancak, davacı tahkim sözleşmesine rağmen davasını mahkemede açmış ise, mahkeme tahkim sözleşmesini kendiliğinden gözeterek görevsizlik kararı veremez. Mahkemenin tahkim sözleşmesini gözetebilmesi için, **davalının** (karşı tarafın) **tahkim ilk itirazı**nda bulunması gerekir (m. 116, 1/b; 413, 1). Davalı, bu tahkim ilk itirazını, (m. 116, 1/b) cevap dilekçesinde ileri sürmek zorundadır; aksi hâlde dinlenmez (m. 117, 1). Yani, davalının, cevap dilekçesini verdikten (veya cevap dilekçesi verme süresini geçirdikten) sonra yaptığı tahkim itirazı dinlenmez; mahkeme davaya bakmaya devam eder.

Davalı, cevap süresi içinde tahkim ilk itirazında bulunursa, tahkim sözleşmesi hükümsüz, etkisiz veya uygulanması imkânsız değil ise mahkeme tahkim itirazını kabul eder ve davayı usulden reddeder (m. 413, 1).

Tahkim ilk itirazının mahkemede yapılması (ileri sürülmesi), tahkim yargılamasına başlamaya veya tahkim yargılamasına devam edilmesine engel olmaz (m. 413, 2).

Davalı, cevap dilekçesi ile tahkim ilk itirazında bulunursa, mahkeme bu ilk itirazı inceleyip karara bağlar. Mahkeme, tahkim itirazını reddederse, davaya bakmaya devam eder.

Mahkemede dava görülmekte iken tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir (m. 412, 5).

Mahkeme, tahkim itirazını kabul ederse davayı usulden reddeder. Bu karar üzerine davacı, görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemleri düzenleyen m. 20 hükmünü kıyasen uygulayarak, süresi içinde tahkim davası açarsa, mahkemede dava açılması ile ortaya çıkan sonuçlar korunmuş olur; aksi halde bu sonuçlar ortadan kalkar.

Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz (m. 412, 4).

Hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin bulunup bulunmadığı veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dâhil, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Hakem veya hakem kurulunun asıl sözleşmenin geçersizliğine karar vermesi, tahkim sözleşmesini kendiliğinden hükümsüz duruma getirmez (m. 422, 1). Hakem veya hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itiraz, en geç cevap dilekçesinde (m. 428) yapılır. Tarafların hakemleri seçmiş veya seçimine katılmış olmaları, hakem veya kurulun yetkisine itiraz hakkını ortadan kaldırmaz (m. 422, 2). Hakem veya hakem kurulu, yetkisizlik itirazını ön sorun olarak inceleyip karara bağlar (m. 422, 5).

Hakem veya hakem kurulunun yetkisini aşması söz konusu olursa, bu konudaki itirazın bu durumun öğrenilmesi üzerine derhal yapılması gerekir. Fakat, hakem veya hakem kurulu, cevap dilekçesinde veya derhal itiraz edilmemesinin haklı sebebe dayandığı kanısına varırsa, süresinde ileri sürülmeyen itirazı kabul edebilir.

Bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenip çözümlenemeyeceğine ilişkin (tahkim itirazına konu olan) uyuşmazlık, mahkeme (m. 410) tarafından bir ön sorun (m. 163) olarak çözümlenir. Bu uyuşmazlık, dava konusunun belli bir tahkim sözleşmesinin (veya şartının) kapsamına girip girmediği veya bu konuda geçerli bir tahkim sözleşmesi (veya şartı) bulunup bulunmadığına ilişkin olabileceği gibi, o konuda tahkimin caiz olup olmadığına (m. 408) dair de olabilir. Ancak, tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz (m. 412, 4).

Hakemlerde açılan bir davaya karşı, davalı, "bu davanın mahkemede açılması gerektiği" hakkında hiç bir itirazda bulunmazsa, hakemler, bakmakta oldukları davanın tahkim sözleşmesi (veya şartının) kapsamına girmediğini kendiliğinden gözeterek, taraflara mahkemede dava açmaları için süre veremezler; davayı esastan inceleyip karara bağlar (m. 409; 412, 3). Çünkü, davalı bu hususta bir itirazda bulunmamakla, taraflar arasında o davanın da tahkim sözleşmesinin kapsamına girdiği hususunda, üstü örtülü (zımnî) bir anlaşma meydana gelmiştir.

D) HAKEM SÖZLEŞMESİ VE HAKEMLER

I – HAKEM SÖZLEŞMESİ[12]

Hakem sözleşmesi taraflar ile hakem (veya hakemler) arasında yapılır. Bu sözleşme tamamen borçlar hukukuna tâbi olup, bir vekâlet veya hizmet[13] sözleşmesi niteliğindedir. Hakem sözleşmesi (tahkim sözleşmesinde olduğu gibi) yazılı şekle tâbi değildir.

Az sonra görüleceği gibi, hakemler mahkeme tarafından seçilse bile, taraflar ile hakemler arasında bir hakem sözleşmesi yapılmış sayılır. Bunun gibi, taraflardan her biri kendi hakemini seçse dahi, bunu yaparken aynı zamanda diğer tarafça seçilen hakem ile sözleşme yapmış olduğu farz olunur.

Hiç kimse hakemliği kabul zorunda değildir. Bu nedenle, bir kimsenin taraflarca hakem tayin edilmesi, sadece hakem sözleşmesini hazırlayıcı bir icaptır. Sözleşme hakemin kabulü ile meydana gelir. Hakem, hakemliği kabul edince, artık sözleşme gereğince bizzat (TBK m. 506, III) hakemlik yapmak zorundadır. Hakem sözleşmesini iyi bir şekilde yerine getirmeyen hakem, TBK m. 396 ve 400'e göre sorumludur.

II – HAKEMLER

Hakem sözleşmesi ile, iki taraf arasındaki bir uyuşmazlığı çözümlemek görevini üzerine alan kimseye (veya kimselere) **hakem** denir. Hakem, kendisine (tahkimde) açılan davanın hâkimidir. Hâkimden farkı, hakemin bu hususta hiç bir resmî sıfatının bulunmaması ve tamamen tarafların iradesi ile tayin edilmiş olmasıdır. Taraflar, tek sayı olmak şartı ile, hakem sayısını serbestçe belirleyebilir; taraflar hakem sayısını belirlememişse, üç hakem belirlemiş sayılırlar (m. 415) .

Medenî hakları kullanma (fiil, eylem) ehliyetine sahip her gerçek kişi hakem seçilebilir (m. 416, 1/a). Hakem, **üçüncü kişi** olmalıdır. Taraflar veya vekilleri hakem olamazlar. Hâkimler ve savcılar hakem olamaz[14]. Buna karşılık, avukatlar ve noterler, hakemlik yapabilir (AK. m. 12/d; Noterlik K. m. 50, I).

1) Hakemlerin Seçimi

Taraflar, hakem seçim usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. Taraflar hakem seçim usulünü belirlememişlerse, hakemlerin seçilmesi aşağıdaki şekillerde olabilir:

Tek hakem seçilecek ise ve taraflar bu hakemin seçiminde anlaşamazlarsa, taraflardan birinin talebi üzerine hakem, mahkeme (m. 410; 411) tarafından seçilir (m. 416, 1/b).

Tahkim sözleşmesine göre, üç hakem seçilecek ise; bu halde, taraflar arasında eşitliğe uyulması gerekir. Bir tarafa, diğerinden daha fazla sayıda hakem tayin etme hakkı tanınamaz. Taraflardan her biri, bir hakem seçer; bu

---

12 Bkz. Âlim Taşkın, Hakem Sözleşmesi, Ankara 2005.

13 Hakem sözleşmesi, ücretli ise (kural) bir hizmet akdi, ücretsiz ise (istisna) bir vekâlet sözleşmesidir.

14 Bkz. 13.05.1964 gün ve 01/03 sayılı İBK (RG 8.7.1964, sa. 11748).

şekilde seçilen iki hakem (veya tarafların kararlaştırmalarına göre, bizzat taraflar) üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın bu yoldaki talebinin kendisine ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki bir ay içinde üçüncü hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme (m. 410; 411) tarafından hakem seçimi yapılır (m. 416, 1/c).

Üçten fazla hakem seçilecek ise, son hakemi seçecek olan hakemler, yukarıdaki bentte belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda belirlenir (m. 416, 1/ç).

Hakemin birden fazla olması hâlinde en az birinin kendi alanında beş yıl ve daha fazla kıdeme sahip bir hukukçu olması şarttır (m. 416, 1/d).

Kendisine hakemlik önerilen kimse, bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve bağımsızlığından kuşku duyulmasını haklı gösteren durum ve koşulları açıklamak; daha sonra ortaya çıkan durumları da hemen taraflara bildirmek zorundadır (m. 417, 1).

Hakemlerin seçim usulünü belirlemiş olmalarına rağmen; taraflardan biri sözleşmeye uymazsa, kararlaştırılmış olan usule göre tarafların veya taraflarca seçilen hakemlerin birlikte karar vermeleri gerektiği halde, taraflar ya da hakemler bu konuda anlaşamazlarsa, hakem seçimi ile yetkilendirilen üçüncü kişi, kurum veya kuruluş, hakem ya da hakemleri seçmezse, seçim taraflardan birinin talebi ile mahkeme (m. 410) tarafından, tarafların sözleşmesi ve hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması ilkesi gözönünde bulundurularak, yapılır. Mahkemenin bu konuda vereceği karara karşı temyiz (kanun yoluna) yoluna başvurulamaz (m. 416, 2).

Hakem veya hakemlerce görevin yerine getirilmemesi ve yeni hakem seçilmesi konusunda ayrıntılı düzenlemeler Kanunun 420 ve 421. maddelerinde yer almaktadır.

2) Hakemlerin Reddi

Hakemler, hâkimler gibi görev yaptıkları için onların da davaya bakarken **tarafsız** ve **bağımsız olmaları gerekir**. Bu nedenle, HMK'nun 417. maddesinde ret sebepleri düzenlenmiştir. Buna göre hakem, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne rağmen, taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip olmadığı, hakkında bir ret sebebi bulunduğu veya tarafsızlığından kuşku duymayı haklı gösteren durum ve koşullar gerçekleştiği takdirde reddedilebilir (m. 417, 2).

Taraflar, hakemin reddi usulünü kararlaştırmışlarsa, ret bu usule göre yapılır ve sonuçlandırılır (m. 418, 1).

Hakemi reddetmek isteyen taraf, hakemin veya hakemlerin seçiminden ya da ret sebebini öğrendiği tarihten itibaren iki hafta içinde ret talebinde bulunabilir ve bu talebini karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bunun üzerine reddedilen hakem çekilmezse veya diğer taraf reddi kabul etmezse ret hakkında hakem kurulunca karar verilir (m. 418, 2).

Hakem kurulundan bir veya birden çok hakemin reddini talep eden taraf, ret talebini ve gerekçesini hakem kuruluna bildirir. Hakem kurulu tarafından talebinin kabul edilmediğini öğrenen taraf, bu tarihten itibaren bir ay içinde

mahkemeye (m. 410) başvurarak hakem kurulu kararının kaldırılmasını ve talebi gibi karar verilmesini isteyebilir (m. 418, 3).

Tek hakemin veya hakem kurulu çoğunluğunun veya tümünün reddi için ancak mahkemeye (m. 410) başvurulabilir. Bu başvuru üzerine mahkeme kesin karar verir (m. 418, 4). Mahkemenin ret talebini kabul etmesi halinde, tahkim sona erer. Ancak, reddedilen ve mahkemenin kararı ile haklarındaki ret talebi uygun bulunan hakem veya hakemler tahkim sözleşmesinde ismen belirlenmemişse yeniden hakem seçimi yoluna gidilir (m. 418, 5).

3) Hakem Ücreti

Hakemler, gördükleri hizmete karşılık bir ücret alırlar (m. 440). Ancak, hakemler kendi ücretlerini kendileri tayin edemezler.

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakem veya hakemlerin ücreti, dava konusunun miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alınarak, hakem veya **hakem kurulu ile taraflar arasında** kararlaştırılır veya taraflar, m. 440 hükümlerine göre ücreti belirleyebilirler. Yani, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında anlaşma sağlanamazsa ücret, m. 440, 3'de belirtilen (Hakem) Ücret Tarifesine göre belirlenir (m. 440, 2-3). Hakem ücretine ilişkin diğer hususlar da 440. maddenin 4-6. fıkralarında düzenlenmiştir.

E) TAHKİM USULÜ

Daha önce de belirttiğimiz gibi, **taraflar**, tahkim yargılamasında uygulanacak usule ilişkin kuralları, HMK'nun emredici kuralları saklı kalmak kaydıyla, **serbestçe kararlaştırabilirler**. Taraflar böyle bir sözleşme yapmamışlarsa, hakem veya hakem kurulu tahkim yargılamasını, HMK'nun tahkime ilişkin m. 407-444 hükümlerini gözeterek, uygun bulduğu bir şekilde yürütür (m. 424, 1). Tahkimde de (mahkemelerde olduğu gibi) tarafların eşitliği, hukukî dinlenilme hakkının tanınması ve tasarruf ilkesi gibi ilkeler kural olarak geçerlidir.

I – DAVA AÇILMASI

Tahkim yeri, taraflarca veya hakem veya hakem kurulunca kararlaştırılır (m. 425).

Tahkim davası da, hukuk mahkemelerinde olduğu gibi **dava dilekçesi ile açılır** (m. 428). Taraflarca kararlaştırılan veya hakem tarafından belirlenecek süre içinde, davacı tahkim sözleşmesiyle (veya şartıyla) birlikte varsa esas sözleşme ile iddiasını dayandırdığı vakıaları ve talebini delilleri ile; davalı ise savunmasını ve dayandırdığı vakıaları delilleri ile birlikte ve dilekçeyle hakem ve hakem kuruluna sunar (m. 428, 1).

Dava hakem belirlendikten veya hakem kurulu oluştuktan sonra açılır. Ancak Kanun, daha önceki bir tarihi, **davanın açılması zamanı** olarak kabul etmektedir (m. 426; karş. m. 118, 1). Bunun nedeni, hakem kurulunun oluşmasının uzunca bir zaman sürmesi ve bu arada dava sürelerinin geçmesi ihtimalinin bulunmasıdır.

Hakemler mahkeme tarafından seçilecekse (m. 416, 1), dava, hakemlerin tayini için **mahkemeye başvurulduğu tarihte** açılmış sayılır (m. 426, 1).

Hakemlerin tayini taraflara ait ise, **davacının** hakemini seçip, **davalıya** hakemini seçmesini **bildirdiği tarihte** (m. 426, 1) dava açılmış sayılır (m. 426, 1).

Hakemlerin tayini bir üçüncü kişiye ait ise, hakemlerin belirlenmesi için üçüncü kişi, kurum veya kuruluşa başvurulduğu tarihte dava açılmış sayılır (m. 426, 1).

Hakemler tahkim sözleşmesinde ismen tayin edilmişlerse, dava, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi talebinin karşı tarafça alındığı tarihte açılmış sayılır (m. 426, 1).

Taraflardan biri, mahkemeden ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararı almış ise, iki hafta içinde tahkim davası açılmazsa, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kendiliğinden kalkar (m. 326, 2).

Dava açılmasının bazı sonuçları, hakemlerde dava açılması ile de meydana gelir. Örneğin, hakemlerde dava açılması ile de zamanaşımı kesilir (TBK m. 154/2). Hakemlerde dava açılması ile derdestlik hali meydana gelir. Hakemlerde dava açıldıktan sonra, davacı, davalının açıkça rızası olmadıkça, davasını geri alamaz. Buna karşılık, taraflar aksini kararlaştırmış olmadıkça veya hakem veya hakem kurulu aksine karar vermedikçe, tahkim yargılaması sırasında iddia veya savunmalarını değiştirebilir veya genişletebilirler; ancak değiştirme ve genişletme ile tahkim anlaşması kapsamı dışına çıkılamaz (m. 428, 3; karş. m. 141).

Mahkemelerde vekâleten dava takip etmek avukatların tekelinde olduğundan, hakemler önünde vekâleten dava takip etme yetkisi de, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir (AK m. 35).

II – YARGILAMA USULÜ

Hakemlerin uygulayacakları yargılama usulünü, taraflar tahkim sözleşmesinde (veya daha sonraki bir sözleşmede) tespit etmiş olabilirler (m. 424). Bu halde, hakemler tahkim sözleşmesinde tespit edilen yargılama usulünü uygularlar. Uygulamada hakemler, **hakem sekreteri** atamakta ve işlemleri bu sekreter eliyle yürütmektedirler. Hakem sekreteri ücreti, hakemler tarafından tespit edilmektedir.

Taraflar arasında bu konuda bir sözleşme yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını HMK'nun 407-444. maddeleri hükümlerini gözeterek uygun bulduğu bir şekilde yürütür (m. 424, 1). Hakemler, HMK'na göre tahkikat yapabilecekleri gibi, tespit edecekleri başka bir yargılama usulünün uygulanmasına da karar verebilirler.

Ancak, her iki halde de, hakemler bir yargılama usulünün ana kurallarına uymak zorundadırlar. Örneğin, hakemler her iki tarafa da eşit işlem yapmakla yükümlüdürler. Bu nedenle, davalıya tebligat yapılıp onun savunması alınmadan karar verilmesi hukuka aykırı olacaktır. Kısaca, tarafların hukukî dinlenilme hakkının (m. 27; 423) kullandırılması zorunludur.

Hakem veya hakem kurulu, yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine karar verebileceği gibi, delillerin gösterilmesi, sözlü beyanlarda bulunulması

veya bilirkişiden açıklama istenmesi (m. 431) gibi nedenlerle duruşma yapılmasına da karar verebilir (m. 429, 1).

Hakemler, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, talep üzerine, ihtiyatî tedbir kararı verebilir. Mahkeme (m. 410), talep üzerine alınan tedbir kararının icra edilebilirliğine karar verir (m. 414, 1-2).

Hakemlerde açılmış olan bir dava, üçüncü kişilere ihbar edilebilir (m. 61, 62) ve üçüncü kişiler hakemlerde açılmış bir davaya müdahale edebilirler (m. 66 vd.).

Hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin (m. 412) mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir (**competence-competence**). Bu karar verilirken, bir sözleşmede yer alan tahkim şartı (m. 412, 2), sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem veya hakem kurulunun asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, tahkim sözleşmesinin kendiliğinden hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz (m. 422, 1).

Hakem veya hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itiraz (karş. m. 413), en geç cevap dilekçesinde (m. 428; karş. m. 422, 3) yapılır. Tarafların hakemleri bizzat seçmiş veya hakem seçimine katılmış olmaları (m. 416), hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz etme haklarını ortadan kaldırmaz. Hakem veya hakem kurulunun yetkisini aştığına ilişkin itiraz derhal (karş. m. 422, 2) ileri sürülmelidir (m. 422, 2-3).

Hakem veya hakem kurulu, yukarıda belirtilen her iki hâlde de gecikmenin haklı sebebe dayandığı sonucuna varırsa, süresinde ileri sürülmeyen itirazı kabul edebilir. Hakem veya hakem kurulu, yetkisizlik itirazını, ön sorun (m. 164) şeklinde inceler ve karara bağlar; yetkili olduğuna karar verirse, tahkim yargılamasını sürdürür ve davayı karara bağlar (m. 422, 4-5).

III – TAHKİM SÜRESİ

Hakem veya hakemler, taraflar aksini kararlaştırmadıkça, **bir yıl** içinde hüküm vermek zorundadırlar (m. 427).

Bu bir yıllık tahkim süresinin başlangıcı: 1) Birden fazla hakem varsa, hakemlerin **ilk toplantı**larını yapmış oldukları (toplantı tutanağının düzenlendiği) tarih (m. 427); 2) Hakemin bir kişi olması halinde, hakemin seçildiği tarihtir.

Taraflar tahkim süresini uzatabilirler. Tahkim süresi, tahkim sözleşmesinde gösterilmiş olsa bile, taraflar bunu uzatabilirler. Tarafların anlaşamamaları halinde, taraflardan birinin başvurusu üzerine, mahkemece (m. 410) süre uzatılabilir. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir (m. 427, 2).

Tahkim süresinin bitmesi tarihi ile taraflarca bu sürenin uzatılması tarihi arasında hakemlerce usul işlemi yapılmış ise süreyi uzatan taraflar bu işlemi kabul etmiş sayılırlar; yani bu işlemler batıl değildir.

Tahkim kısmındaki hükümlere göre mahkemenin görevine giren anlaşmazlık ve işlerde ve hakemler tarafından bakılan davalarda, adlî tatil hükümleri (m. 103, 1/g) uygulanmaz.

IV – HAKEM KARARI

Hakem veya hakem kurulunun yargılama sonucunda, nasıl nihaî karar vereceğini, kararın şekli ve içeriğini incelemeden önce, tahkim yargılamasının, nihaî karar dışında, hangi hâllerde sona erebileceğini tespit etmek gerekir:

Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak çözümünde davalının hukukî yararı bulunduğunu kabul etmesi hâli hariç, davacı davasını geri alırsa; taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa; hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın devamını gereksiz veya imkânsız bulursa; tahkim süresinin uzatılması talebi mahkemece reddedilirse; tarafların kararına rağmen hakem kurulu oybirliğiyle karar veremezse; HMK m. 442 hükmüne göre yatırılması gereken yargılama giderleri avansı yatırılmazsa, tahkim yargılaması sona erer (m. 435, 1).

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması konusunu düzenleyen m. 437 hükmü saklı kalmak üzere, hakem veya hakem kurulunun yetkisi, yargılamanın sona ermesiyle ortadan kalkar (m. 435, 2).

Hakemler birden fazla ise, yani bir hakem kurulu oluşturulmuşsa, taraflar aksini kararlaştırmamışsa, hakem kurulu, **bütün üyelerin hazır bulunması ile oluşur**; bütün üyelerin hazır bulunmasıyla müzakerede bulunulur, işlem yapılır ve karar (ara karar ve nihaî karar) verilir. Başka bir ifadeyle, üyelerin tamamı bir araya gelmemişse müzakere ve işlem yapılamaz, karar verilemez. Çünkü üyelerin tamamının birlikte toplanması halinde "hakem kurulu"ndan söz edilebilir. Bu sebeple **eksik üye ile müzakere ve işlem yapılamaz, karar verilemez.** Aksi halde yapılan müzakere, işlem veya karar yok hükmündedir. Bununla birlikte, taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa, üyelerin tamamının bir araya gelmesi halinde, oy çokluğu ile işlem yapılabilmesi ve karar verilebilmesi mümkündür. Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu başkanı yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir.

Hakem veya hakemler, taraflarca açıkça yetkili kılınmışlarsa, **hakkaniyet ve nasafet kurallarına** göre veya dostane çözüm yoluyla karar verebilir (m. 433).

Hakem kararı, tarafların dava konusunda sulh olmaları halinde, sulhü tespit eden bir karar şeklinde de olabilir (m. 434).

Hakem kararının şekli ve içeriği, m. 436'da gösterilmiştir. Buna göre, hakem kararında şunların bulunması gerekir: 1) Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve soyadları. 2) Tarafların ve varsa temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadı, unvanları ve adresleri. 3) Kararın dayandığı hukukî sebepler ile gerekçesi. 4) Bir sıra numarası altında, açık ve kesin bir biçimde taraflara yüklenen hak ve borçlar ile yargılama giderleri (taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkmış tarafa yüklenir) (m. 441). 5) Karara karşı iptal davası açılabileceği ve süresi. 6) Tahkim yeri ve karar tarihi. 7) Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin imzası ve varsa karşı oy yazısı (m. 436, 1).

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, hakem veya hakem kurulu kısmî kararlar verebilir (m. 436, 2).

Hakem veya hakem kurulu başkanı, kararı taraflara bildirir; ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye (m. 410) gönderilir ve mahkemece saklanır (m. 436, 3).

Evvelce daha farklı bir süre öngörülmemişse, taraflardan her biri, hakem kararının kendisine bildirilmesinden (m. 436, 3) itibaren iki hafta içinde, karşı tarafa da bilgi vererek ve hakem veya hakem kuruluna başvurup; hakem kararında bulunan hesap, yazı ve benzeri maddî hataların düzeltilmesini ve/veya karara ilişkin belirli bir konunun veya kararın bir bölümünün tavzihini isteyebilir (m. 437, 1). Maddî hatanın düzeltilmesi veya tavzih talebinin karara bağlanması süresi, kural olarak, talep tarihinden itibaren bir aydır. Taraflardan her biri, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmüş olmasına rağmen karara bağlanmamış konularda **tamamlayıcı hakem kararı** verilmesini isteyebilir; istem uygun bulunursa, tamamlayıcı hakem kararı, kural olarak, bir ay içinde verilir. Bu karar, taraflara bildirilir ve hakem kararının bir parçasını oluşturur (m. 437, 4-5).

HMK ile tahkim konusunda getirilen önemli bir değişiklik, hakem kararlarının icra edilebilmesi için kesinleşmesinin gerekmemesi ve verildiği anda icra edilebilir olmasıdır (m. 439, 4).

Buna karşılık, karar hakkında zamanaşımı (İİK m. 39), kararın verildiği tarihten itibaren işlemeye başlar ve karar tarihi ile tebliğ tarihi arasında on sene geçtiği takdirde, hakem kararı zamanaşımına uğrar.

Kesinleşen hakem kararı, maddî anlamda **kesin hüküm**[15] (m. 303) teşkil eder[16]. Hakem kararı, aynı taraflar arasında, aynı konuda ve aynı sebeple açılan yeni bir davada **kesin delil** teşkil eder.

F) HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLU[17] (İPTAL DAVASI)

I – İPTAL SEBEPLERİ

Hakem kararlarına karşı başvuru yolu, (yalnızca) **iptal davasıdır**. Yani, hakem kararına karşı, iptal davasından (m. 439) başka başvuru yolu yoktur[18].

---

15 Bkz. Ersin Erdoğan, Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi, Ankara 2017.

16 Bkz. 23.10.1972 gün ve 02/12 sayılı İBK (RG 18.12.1972, sa. 14395).

17 Ejder Yılmaz, Hakem Kararlarının Denetimi (Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara 2009, s. 107-136; Yılmaz, Makaleler C. 2, s. 1805-1828); Sema Taşpınar Ayvaz, Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları Konusunda HMK Hükümlerinin Uygulanması, İç Tahkim ve Uygulamaları (XLII Çözüm Arama Konferansı, Ankara 2013, s. 47-57); Ejder Yılmaz, Tahkimde İtirazın İptali Davası ve Tahkime Elverişlilik Kuralı (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, s. 531-554); Ejder Yılmaz, Tahkime İlişkin Kanun Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması (Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan, Legal Hukuk Dergisi Özel sayı, İstanbul 2014, s. 531-534); Seyhan Selçuk, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hakem Kararlarının İptali, Ankara 2018; Şaziye Tuba Ulukuş Bulut, MTK İle Karşılaştırmalı Olarak HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali, Ankara 2018.

18 HUMK m. 533'e göre, hakem kararlarına karşı, doğrudan doğruya temyiz yoluna başvurulmakta idi.

İptal sebepleri, HMK'nun 439. maddesinin 2. fıkrasında sınırlı sayıda belirlenmiştir.

Bu hükme göre: 1) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu; 2) Hakem veya hakemlerin seçiminde, sözleşmede belirlenen veya HMK'nun tahkime ilişkin kısmında (m. 407-444) düzenlenen usule uyulmadığı; 3) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği; 4) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar verdiği; 5) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği veya talebin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı; 6) Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması hâlinde, bu kısımda (m. 407-444) yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu; 7) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukukî dinlenilme hakkına riayet edilmediği; 8) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı; 9) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu; iptal davasını gören mahkeme tarafından tespit edilirse, hakem karar iptal edilebilir.

Görüldüğü üzere iptal sebepleri, genellikle biçimsel hukuka aykırılıklardan ibarettir ve hakemlerin takdirinin değerlendirilmesi bu sebepler arasında sayılmamıştır.

II – İPTAL USULÜ

İptal davası, tahkim yerindeki (m. 425) **istinaf** (bölge adliye) mahkemesinde (m. 410)[19] açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür (m. 439, 1).

İptal davası, hakem kararının veya tavzih, düzeltme ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği (m. 436, 437) tarihten itibaren **bir ay** içinde açılabilir (m. 439, 4).

İptal davası açılması, kararın icrasını durdurmaz. Ancak, taraflardan birinin talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın yetkili mahkemece (m. 410) icrası durdurulabilir (m. 439, 4).

Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi kapsamı dışında kalan bir konuda karar verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında, tahkim sözleşmesi kapsamında olan konuların kapsam içinde olmayan konulardan ayrılması mümkün olduğu takdirde, davaya bakan mahkeme, hakem kararının sadece tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan konuları içeren bölümünü iptal edebilir (m. 439, 3).

Mahkeme aksine karar vermedikçe, iptal talebini dosya üzerinden inceleyerek karara bağlar (m. 439, 5).

İptal davasının kabulüne karar verilir ve bu karar temyiz edilmezse veya yukarıda açıklanan 2, 4, 5, 6 ve 7 numaralı iptal nedenlerinin var olduğu tes-

---

[19] Bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, Asliye Ticaret Mahkemeleri Hakkında Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Tahkimde Görevli Mahkeme (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, İzmir 2015, C. 1, s. 469-482).

pit edilip iptal talebi kabul edilirse, taraflar da aksini kararlaştırmamışlarsa, taraflar hakemleri ve tahkim süresini yeniden belirleyebilirler. Tarafların eski hakemleri seçmeleri de mümkündür (m. 439, 7).

İptal davası hakkında verilen istinaf mahkemesi kararı aleyhine **temyiz yoluna başvurulabilir** (m. 361, 1). Temyiz incelemesi, yukarıda incelenen iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelik ve ivedilikle incelenip karara bağlanır. Temyiz yoluna başvurulması, kararın icrasını durdurmaz (m. 439, 6).

III – YARGILAMANIN İADESİ

Kesinleşmiş hakem kararlarına karşı, m. 443 hükümlerine göre yargılamanın iadesi yoluna gidilebilir. Bu hükme göre, kesin hüküm niteliği kazanmış mahkeme kararlarına karşı başvurulabilecek olağanüstü kanun yolu olan yargılamanın iadesine ilişkin HMK'nun 374-381. maddeler hükümleri, niteliğine uygun düştüğü şekilde tahkime de uygulanacaktır (karş. m. 444). Başka bir deyişle, tahkimde, yargılamanın iadesi sebeplerinden sadece 375. maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g), (h), (ı) ve (i) bentleri uygulanır (m. 443, 2) (bkz. HMK geçici m. 3).

Yargılamanın iadesi davası, **mahkemede** (m. 410) **görülür** (m. 443, 2). Mahkeme, yargılamanın iadesi davasını kabul ederse, hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlık hakkında yeni bir karar verilebilmesi için dosyayı yeni hakeme veya hakem kuruluna gönderir. Bu durumda, hakem veya hakem kurulu, 421. maddeye yeniden seçilir veya oluşturulur (m. 443, 3).

§ 81. EKLER[1]

Ek No. 1

DAVA DİLEKÇESİ[2]

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI .....: Ali Ak, Elmadağ Caddesi, Umut Sokak No.45, Çankaya-Ankara

DAVALI.....: Bülent Borlu, Anafartalar Caddesi, Savaş Sokak, Ulus-Ankara

KONUSU.....: Yüz bin liralık alacak davasıdır.

VAKIALAR.....:

1- Davalı Bülent Borlu, 01.03.2019 tarihinde benden yüz bin lira ödünç para almıştır (01.03.2019 tarihli senet).

2- Bu parayı, 30.06.2019 tarihinde bana ödemesi gerekirken, ödememiştir.

3- Kendisine 02.07.2019 gününde Ankara 120. Noteri vasıtasıyla gönderdiğim ihtarname de cevapsız kalmıştır (02.07.2019 tarihli noter ihtarnamesi).

Bu nedenle, davalıya karşı dava açmak zorunda kalmış bulunmaktayım.

DELİLLER.....: 01.03.2019 tarihli senet; 02.07.2019 tarihli noter ihtarnamesi, yemin.

HUKUKÎ SEBEPLER.....: Türk Borçlar Kanununun 386-392 ve 117-120. maddeleri.

TALEP SONUCU.....: Davalının 2.000 lira temerrüt (gecikme) faizi ve 100 lira ihtarname gideri ile birlikte toplam 102.100 (yüz iki bin yüz) lirayı ve ayrıca dava tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizini ödemeye mahkûm edilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 01.11.2019

Davacı Ali AK
(imza)

---

1 Dilekçe örnekleri için bkz. Ejder Yılmaz/H.Ümit Yılmaz, Hukuk Rehberi, (5 Cilt) Ankara 2006.

2 Dava dilekçesinin içeriği hakkında bkz. HMK m. 119.

Ek No. 2

CEVAP DİLEKÇESİ[3]

ANKARA 92. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya Esas No: 2019/1076

DAVALI.....: Bülent Borlu, Anafartalar Caddesi, Savaş Sokak, Ulus-Ankara

VEKİLİ.....: Avukat Cemal Güçlü, Anadolu Plaza, Kat. 8/23, Balgat-Ankara.

DAVACI.....: Ali Ak, Elmadağ Caddesi, Umut Sokak No.45, Çankaya-Ankara

D.KONUSU.....: Müvekkilime karşı açılan 102.100 liralık alacak davasına karşı ilk itirazlarımızı ve esasa ilişkin cevap dilekçemizdir.

A) YETKİ İTİRAZIMIZ:

Bu davada, Mahkemeniz yetkili değildir. Çünkü, Müvekkilimin yerleşim yeri Ankara değildir, Kayseridir. Dava dilekçesinde gösterilen adres, müvekkilimin iş seyahatleri nedeniyle Ankara'ya geldiği zamanlar kullandığı geçici bir adrestir. Bu nedenle, mahkemeniz yetkisiz olup, yetkili mahkeme Kayseri Mahkemeleridir.

B) ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ:

1) Müvekkilimin Davacıdan 100.000 lira aldığı doğrudur. Ancak müvekkilim bu parayı, ödünç olarak değil, Davacıya satmayı vaat ettiği traktörün 250.000 liralık satış bedeline mahsuben almıştır.

2) Sözleşmeye göre, müvekkilim 30.04.2019 gününe kadar traktörü gümrükten çekip Davacıya (kalan 150.000 lira karşılığı) teslim edemezse, Davacı sözleşmeden rücu edilebilecek ve verdiği 100.000 lirayı geri isteyebilecek idi. Oysa müvekkilim, Davacıya daha önce 20.05.2019 günlü bir ihtarname ile, traktörü teslime hazır olduğunu, Davacının kalan 150.000 lirayı ödemek şartı ile traktörü gelip almasını, 10 gün içinde 150.000 lirayı ödeyip traktörü teslim almadığı takdirde, kendisinin sözleşmeden rücu etmiş sayılacağını Davacıya bildirmiştir. Davacı sözleşmeye göre kendisine verilen süre içinde 150.000 lirayı ödeyip traktörü teslim almamış ve bu nedenle sözleşme gereğince söz-

---

[3] Cevap dilekçesine yazılması gereken hususlar hakkında bkz. HMK m. 129.

leşmeden rücu etmiş sayılmıştır; bunun üzerine müvekkilim 100.000 lirayı tazminat olarak muhafaza etmeye hak kazanmıştır.

3) Davacının müvekkilime gönderdiği 02.07.2019 günlü ihtarname, müvekkilimin eline geçmemiştir. Müvekkilimin dava dilekçesini tebellüğ ettikten sonra yaptığı tahkikat sonucunda öğrendiğine göre, bu ihtarname müvekkilimin oturduğu apartmanın kapıcısına tebliğ edilmiş ve kapıcı da bunu müvekkilime vermeyi unutmuştur. Bu nedenle yapılan tebliğ usulsüzdür.

Bu nedenlerle, müvekkilim davacıya borçlu değildir. Aleyhine açılmış olan dava haksızdır, reddi gerekir.

DELİLLER.....: 01.03.2019 günlü sözleşme, 20.05.2019 günlü ihtarname ve yemin[4].

HUKUKÎ SEBEPLER.....: HMK m. 116, 1/a,c; TTK m. 4; TBK m. 156, I.

TALEP SONUCU.....: Yetki itirazımızın kabul edilerek, davanın yetkisizlikten dolayı reddine; yetki itirazımızın yerinde görülmediği takdirde, açıkladığımız nedenlerden dolayı esas bakımından da kanuna uygun olmayan davanın reddine karar verilmesini, vekâleten saygı ile arz ve talep ederim. 20.12.2019

Davalı Bülent Borlu
Vekili

Avukat Cemal Güçlü
(imza)

4 Delillerin hasrı için bkz. yuk. § 26, A, I.

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ

— A —

Actio dublex 561
Ad hoc tahkim 785
Adalet Akademisi 107
Adalet Bakanı 112, vd.
– yardımcısı 112, 113
Adi ikrar 398 vd.
Adi kanun yolları **588**
Adi kanunî karineler 388
Adi senetler **404 vd.**
Adi şirketin taraf ehliyeti 256
Adil yargılanma hakkı **144 vd.**
Adlî mahkemeler **75 vd.**, 209, 586, 611, 664
Adlî tatil **175 vd.**
Adlî yardım **728 vd.**
Adlî yargı **75 vd.**, 264, 288
– bölümleri 75 vd.
Adliye memurları **133 vd.**
Ahzukabz yetkisi 279
Aile hukukuna ait dava ve işler
– görev 742
Aile mahkemeleri **741 vd.**
Aktif husumet ehliyeti 268
Aleniyet ilkesi **147 vd.**
Aleyhe bozma yasağı 620, 657, 672
Aleyhe hüküm verme yasağı 621, 657
Alternatif
– dava **313 vd.**
Anayasa
– aykırılık 490
– Mahkemesi **70 vd.**, 772 vd.
– yargısı 70 vd.
– –medenî yargıdan farkı 71 vd.
Apostil 275, 410
Ara kararları 169, **475 vd.**, 643
Arabulucu **780 vd.**
Arabuluculuk **778 vd.**
– konusu ve temel ilkeleri **778 vd.**
– usulü **781 vd.**
Asgarî vekâlet ücreti 724 vd.
Asıl dava 221, 486, 505, **519 vd.**, 585, 641, 645, 683
Aslî müdahale 504 vd., 511, 534, 546, 548
Asliye
– hukuk mahkemeleri 87, 100 vd., 123, 132, 141, 196 vd., 318, 644, 650, 666, 741, 755, 761, 768
– – görevleri 100 vd., 196 vd.
– ticaret mahkemeleri 87, **197 vd.**, 202, 768, 771
Atiye terk 336 (ayrıca bkz. Davanın geri alınması)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 146, 636, 776 vd.
Avukatlık **135 vd.**
– Asgarî Ücret Tarifesi **726 vd.**
– hakları **139 vd.**
– Kanunu 135 vd., 271
– Kanunu Yönetmeliği 136
– mesleği **136 vd.**
– Meslek Kuralları 137
– ödevleri **138 vd.**
– stajı 136
– stajyeri 139
– tebligat yetkisi 140
– uzlaştırma yetkisi 139
– ücreti **722 vd.**

Ayırma kararı 214, 507, 511 vd.
Aynî davalar 311
Azil
– vekil **282 vd.**

— B —

Bağlantı 311 vd., 400, 490 vd., 507 vd., 519 vd., 541, 649, 727
Bağlantılı bileşik ikrar **400**
Bağlantısız bileşik ikrar **401**
Bakanlıklar 255 vd.
Barolar **137 vd.**
Basit ikrar **398 vd.**
Basit yargılama usulü 733 vd.
Başvurma harcı 329, 520, 530, 574, 584, 599, 731
Bazı kişivarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi **332**
Bedelin indirilmesi davası 74
Bekletici sorun **488 vd.**
Belediye 142, 209, 264, 562, 569, 632, 756, 786
Belge **402 vd.**
Belirsiz alacak ve tespit davası 292, **301 vd.**, 321
Beyaza imza 429, 431
Beyyine (bkz. Delil)
Beyyine başlangıcı (bkz. Delil Başlangıcı)
Beyyine külfeti (bkz. İspat yükü)
Beyyine sözleşmesi (bkz. Delil Sözleşmesi)
Bileşik ikrar **399 vd.**
Bilirkişi **450 vd.**
– başvurulabilecek haller **451**
– başvurulması zorunlu haller 451
– görevinin ihtiyariliği 456 vd.
– görevinin yerine getirilmesi 454
– görevlendirilmesi **454**
– hukukî sorumluluğu davası **461**
– incelemesine karar verilmesi **453 vd.**
– listeleri 454
– raporu 457 vd.
– yasaklılığı ve reddi **456 vd.**
– seçimi **454**
– sorumluluğu **461**
– tanıklıktan farkı **450**
– ücreti **461**
Birden fazla hukuk mahkemesi arasındaki iş dağılımı 102, 104, 239
Birden fazla vekil **280**
Bireysel başvuru **772 vd.**
Birlikte dava 257, 512, 539 vd.
Bizzat ihkakı hak 55
Boşanma davasında yetki 224
Bozma
– kararı 241, 243, 528, 614 vd., **620 vd.**, **657 vd.**
– sebepleri 383, **613 vd.**, **646 vd.**, 660
Bölge adliye mahkemeleri **87 vd.**, 243
Büyükşehir belediyesi 209, 244, 256, 264

— C —

Can sigortalarında yetki **223**
Celse 368 (ayrıca bkz. Duruşma)
Celse harcı 407, 413, 714, 721, 722
Cevaba cevap dilekçesi **346 vd.**
Cevap dilekçesi 341 vd.
– davada **341 vd.**
– istinafta **600**
– kanunî eksiklik bulunması **343**
– karar düzeltmede 670
– karşı davada **522**
– mahkemeye verilmesi **343 vd.**
– temyizde **616**, **651**

– verilmemesinin sonuçları **345**
– verilmesinin sonuçları **345**
Cevap süresi **344 vd.**
Ceza mahkemeleri 76 vd., 240, 700 vd.
Ceza muhakemesi hukuku 76
Ceza ve hukuk mahkemesi kararlarının birbirine etkisi **700 vd.**
Ceza yargısı **76 vd.**
– medenî yargıdan farkı 76
Class action 316
Coğrafî işaret 763
Coğrafî teminat 116
Cumhuriyet Başsavcısı 131, 663
Cumhuriyet savcıları **131 vd.**

— Ç —

Çekişme yokluğu ölçütü 81
Çekişmeli yargı 78
– çekişmesiz yargıdan farkı **79 vd.**
– niteliği ve önemi 78
Çekişmesiz yargı 79 vd., 202, 221, 224, 225, 250, 613, 694, **737 vd.**
– basit yargılama usulü 738
– çekişmeli yargıdan farkı 79 vd.
– görev 738
– işleri **737 vd.**
– kavramı 737
– kendiliğinden harekete geçme ilkesi 738
– kesin hüküm 740
– niteliği 737
– talep 738
– ilgili 738
– yargılama usulü **738 vd.**
– yargılamanın iadesi 740
– yetki 738
Çift taraflı dava 561

— D —

Danıştay 73, 82 vd., 112 vd.
Dava 248 vd.
– açılması **318 vd.**
– – hakemlerde **792 vd.**
– açılma zamanı **330**
– açılmasının sonuçları **332 vd.**
– arkadaşlığı **539 vd.**
– – ihtiyarî **540 vd.**
– – mecburî **544 vd.**
– çeşitleri **298 vd.**
– dilekçesi **318 vd.**
– – örneği **801**
– dosyası **373**
– dosyasının işlemden kaldırılması **549 vd.**
– ehliyeti **258 vd.**
– engelleri 340 vd.
– hakkı 248
– – kötüye kullanılması 248
– konusu 321
– sebebi 323 vd.
– – davanın genişletilmesinde 348
– – derdestlikte 334
– – ıslahta 527
– – kesin hükümde 688 vd.
– takipçileri 271
– vekâletnamesi **274 vd.**
– vekilleri 140
Dava çeşitleri **298 vd.**
Dava dilekçesinin içeriği **319 vd.**
– kanunî eksiklik bulunması 328 vd.
Dava konusuna ilişkin dava şartları **300 vd.**
Dava konusunun devri **514 vd.**
Dava sebebinin değiştirilmesi 349
Dava şartları 285 vd.
– davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi **333**

Dava takip tekeli **272**
Dava takip yetkisi **265 vd.**
Dava vekâletnamesi 273 vd. (ayrıca bkz. Vekâletname)
Davacı 250
Davada sıfat **266 vd.**
Davada tarafların temsili **260 vd.**, **269 vd.**
Davadaki özel durumlar **484 vd.**
Davadan feragat **557 vd.**
Davaların ayrılması **511 vd.**
Davaların birleştirilmesi **507 vd.**
Davaların yığılması **314 vd.**
Davalı 250
Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi **213 vd.**
Davalının mütemerrit olması **333**
Davalının yerleşim yeri **210 vd.**
Davanın
– geri alınması **335 vd.**
– ihbarı **495 vd.**
– ıslahı **525 vd.**
– kabulü **562 vd.**
– kısmen ıslahı **530 vd.**
– konusuz kalması 478
– takipsiz bırakılması 549 vd.
– tamamen ıslahı **530 vd.**
– yenilenmesi **552 vd.**
Davaya
– cevap **337 vd.**
– müdahale (katılma) **499 vd.**
– – aslî **504 vd.**
– – fer'î **499 vd.**
Davaya son veren usul işlemleri **556 vd.**
Davaya vekâlet **269 vd.**
– davada vekil olabilecekler **270 vd.**
– verilmesi **273**
Davayı
– genişletme ve değiştirme yasağı **347 vd.**
– geri alma yasağı **335 vd.**
– inceleme zorunluluğu **333**
– inkâr **338**, 345
– müracaata bırakma **549 vd.**
– mütekabile (bkz. Karşı dava)
– takipten vazgeçme **549 vd.**
Davayı kabul **562 vd.**
Davetiye 183 vd., 207, 236, 273, 353, 358, 371, 375, 378, 445, 473, 500, 515, 619, 708, 735, 746, 751
Defter tutma **739**
Def'i 342, **356**
Değişiklik davası **706 vd.**
Değiştirerek ve düzelterek onama 624, 662
Delil 380 vd.
– avansı 180, 717 vd., 728 vd.
– başlangıcı **424 vd.**
– çeşitleri **394 vd.**
– gösterilmesi **390 vd.**
– hasredilmesi **391**
– incelenmesi **392**
– – daha sonra delil gösterilmesi **392**
– konusu **381 vd.**
– sistemleri 383
– sözleşmesi **468 vd.**
– – münhasır **469**
– – münhasır olmayan **470**
– – şekli **470**
Delillerin tespiti **582 vd.**
Derdestlik 83, 294, 316, **334 vd.**, 530, 551, 694, 757, 795
Devlet davaları 264
Devletin sorumluluğu 127
Diplomatik muafiyet **287**

Diplomatik temsilci 287
Direnme kararı 96, 124, 476, 587, 605, 615, **624 vd.**, 655, **659 vd.**
Disiplin para cezası 77, 125, 446, 602, 618
Dizi listesi **373**
Doğal yargıç 145 (ayrıca bkz. Tabiî hâkim)
Doğruyu söyleme yükümlülüğü **163 vd.**
Dosyanın işlemden kaldırılması **549 vd.**
Dosyanın yenilenmesi **552 vd.**
Duruşma 368 vd.
– açıklığı (alenîliği) **147 vd.**
– basit usulde **735 vd.**
– davet 135, 162, 183 vd., 235, 283, 353, 358, 365, 369, 374 vd, 437, **500**, **549** vd., 578, 656, 658, 711, 735 vd.
– düzeni (disiplini) 159 vd.
– gizliliği (bkz. Gizli duruşma)
– günü ve saati **371**
– hakemlerde 795
– harcı 714
– temyizde 619, 655 vd.
– tutanağı 567, 735
– zorunluluğu **370**
Duruşmaya gelmeme 549 vd.
Düplik 354 (ayrıca bkz. İkinci cevap dilekçesi)
Dürüstlük ilkesi **163 vd.**
Düzelterek onama
– temyizde 623, 662
Düzenleme biçimindeki noter senetleri **409 vd.**

— E —

Eda davaları **298 vd.**
Eda hükmü **477**
Ehlivukuf 450 (ayrıca bkz. Bilirkişi)
Ek cevap süresi 344 vd.
Ek süre 146, 208, 234, 345 vd., 354
Elektronik veri 60, 403 vd.
Esas hukuk 54
Esas kaydı 330
Esasa cevap
– davada **337 vd.**
– karşı davada **523**
Esasa ilişkin nihaî kararlar **476 vd.**
Eski hale getirme **178 vd.**
Evi terk eden eşe ihtar 80, 142

— F —

Faiz 156, 301, 303, 327, 388, 480, 527, 620, 662, 711
Feragat
– davadan **557 vd.**
– istinaf yolundan **600**
– kanun yoluna başvurmadan 590
– temyizden **617 vd.**, 662, 669, 686
Ferdileştirme ilkesi 323
Fer'î müdahale **499 vd.**
Fevkalâde kanun yolları **589 vd.**
Fiil ehliyeti 259
Fiilî karineler **387**
Fikir ve sanat eserleri **762 vd.**
Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri **761 vd.**
Fuzulî işgal 201

— G —

Gayrimenkul davaları 218 vd.
Geçici hukukî korumalar **571 vd.**
Geçici olarak oturulan yer **223 vd.**
Geçici yetkili noter yardımcısı 142
Genel dava vekâletnamesi **274**
Genel görevli mahkemeler **101 vd.**

Genel mahkeme-özel mahkeme ilişkisi 104
Genel mahkemeler 101 vd.
– mahkemeler arasındaki iş dağılımı 102
Genel müdürlükler (kamuda) 255
Genel vekâletname **274**
Genel yetki **210 vd.**
Gerçek kişiler
– dava ehliyeti **258 vd.**
– taraf ehliyeti **251 vd.**
Gerekçe **695 vd.**
Gerekçeli inkâr **399**
Gerekçeli karar 171
Gider avansı 290, 329 vd., 463, 512, 717, 728 vd.
Gizli belgenin incelenmesi 373
Gizli duruşma 148, 487
Görev 196 vd.
– hususunun incelenmesi **204 vd.**
– itirazı 204 vd.
– kuralının niteliği **204**
– sözleşmesi 204
Görev uyuşmazlığı **83 vd.**
Görevsizlik kararı **206**
– üzerine yapılacak işlemler **206 vd.**
Grup davası 316
Güvenli elektronik imza 366, 369, 403 vd., 416, 457, 482, 591, 734, 739, 757

— H —

Hadise 486 vd.
Hak düşürücü süre 207, 332, 359, 367, 516, 551 vd., 735, 752
Hak ehliyeti 251
Hakem
– kararı **797 vd.**
– – iptali **798 vd.**
– reddi **793**
– seçimi **792 vd.**
– sözleşmesi **792 vd.**
– ücreti **794**
Hakem-bilirkişi 469 vd., 788 vd.
Hakem-dispeççi 788
Hâkim 106 vd.
– adaylığı **107**
– bağımsızlığı **111**
– ceza sorumluluğu 126
– denetimi 112 vd.
– disiplin sorumluluğu 126
– eğitimi 107
– hukukî sorumluluğu **126 vd.**
– mesleği **107 vd.**
– özlük işleri 108 vd., 112
– sorumluluğu **126 vd.**
– stajı 107
– tarafsızlığı 117 vd.
– teminatı **115**
– tayin 108 vd., 112
– terfi 108 vd., 112
Hâkimin
– davaya bakmasının yasak olması **117 vd.**
– – çekinmesi usulü 120
– – halleri 118
– – kavram 117
– reddi **120 vd.**
– – kavram 120
– – kendini reddi **123**
– – ret sebepleri **120 vd.**
– – ret usulü **123 vd.**
Hâkimin hukuk kurallarını kendiliğinden uygulaması **162 vd.**
Hâkimin tâyin ettiği süreler 171 vd.
Hâkimler ve Savcılar Kanunu 59, 107 vd.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 67, 102, 107 vd., 598, 745
Hâkimlerin idarî faaliyeti 79

Hâkimlerin sorumluluğu
– cezaî 126
– disiplin 126
– hukukî **126 vd.**
Hâkimlik **106 vd.**
Hâkimlik mesleği **107 vd.**
Hakların yarışması 315
Haksız fiilden doğan davalarda yetki **217**
Harca tâbi davalar 713 vd.
Harca tâbi olmayan davalar 716
Harçlar 713 vd.
– Kanunu 328
– maktu 329, 599, 714 vd., 783
– nispî 329, 599, 714 vd.
– peşin (bkz. peşin harç)
Harçtan muafiyet 716
Hâsılı davaya iştirak yasağı 724
Hasımsız dava 80, 250
Hayat sigortalarında yetki 223
Hayat tecrübesi kuralları 387
Hazırlama ilkesi **154**
Hileli tebligat 678
Hukuk daireleri
– Yargıtay **89 vd.**
– Bölge Adliye Mahkemeleri 89 vd.
Hukuk davalarında iş dağılımı 102
Hukuk Genel Kurulu **93**
Hukuk kurallarının resen uygulanması **162 vd.**
Hukuk mahkemesi ile idarî mahkeme ilişkisi **73 vd.**
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 51, **57**, 467, 594, 743, 766
– idarî yargıda uygulanması 73 vd.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 51, 57, 65, 593 vd.
Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi 185, 246
Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk **778 vd.**
Hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının birbirine etkisi **700 vd.**
Hukuk yargısı **77 vd.**
Hukukî
– fiil 424, **427 vd.**, 434
– ilişki şartı **303**
– işlem **418 vd.**
– sebep 151, 162 vd., 312, 315, 317, 319, 323 vd., 329, 338, 342, **349 vd.**, **353**, **360**, 381, 396, **437**, 479, 492, 526, 541, 610, 690 vd., 735
– yardım **244 vd.**
Hukukî dinlenilme hakkı **148 vd.**
Hukukî ilişki
– tespiti **303 vd.**
Hukuki yarar **290 vd.**
Husumet **266 vd.**
Hüküm 475 vd.
– çeşitleri 476 vd.
– doğurduğu sonuçlar 483
– fıkrası 327, 474, 479 vd., 502, 672, 688, 695 vd., 710 vd.
– gerekçesi **479**
– içeriği 479 vd.
– kesinleşmesi 686 vd.
– mahkemeleri **87**
– sonucu 474, 480, **693**
– tashihi **708 vd.**
– tavzihi **709 vd.**
– tefhimi 474
– uyuşmazlığı **85**
– verilmesi **473 vd.**

— I —

Islah 525 vd.
Israr kararı 658 (ayrıca bkz. Direnme kararı)
Iztırar hali 55

— İ —

İadei muhakeme 592, 628, 673, 674 (ayrıca bkz. Yargılamanın iadesi)
İcra mahkemesi 490, 642, 684, 695, **744**
İcranın durdurulması
– istinafta 601
– temyizde 617 vd., 653
– yargılamanın iadesinde 639
İç tahkim **785 vd.**
İçtihat birliği 100
İçtihatların birleştirilmesi **96 vd.**
İdare mahkemeleri 72 vd.
İdarî faaliyet (mahkemenin)114
İdarî davalar 72
İdarî faaliyet 72
İdarî eylem 72
İdarî işlem 72
İdarî yargı **72 vd.**
– medenî yargıdan farkı 73 vd.
İdarî Yargılama Usulü Kanununda hüküm bulunmayan haller 73 vd.
İddianın genişletilmesi yasağı **347 vd.**
İfa yeri mahkemesinin yetkisi 216 vd.
İflâs davası 222, 226
İhbar **495 vd.**
İhtisas mahkemeleri 761 (ayrıca bkz. Özel mahkemeler)
İhtiyarî bekletici sorun **491 vd.**
İhtiyarî dava arkadaşlığı **540 vd.**
İhtiyarî tahkim 786
İhtiyatî haciz 122, 129, 176, 207, 226, 237, 278, 335, 537, 571 vd., 730, 733, 795
İhtiyatî tedbirler **573 vd.**
İki taraf bulunması şartı **288**
İkinci cevap dilekçesi **354 vd.**
İkinci derece mahkemeleri 72, **89 vd.**, 593, 664
İkrar 396 vd.
– basit **398 vd.**
– bileşik **399 vd.**
– bölünmesi 399 vd.
– dönme **397 vd.**
– etkisi **398**
– mahkeme dışı **397**
– mahkeme içi **397**
– vasıflı **399**
İl özel idaresi 256, 264
İlâm 410, 472, 482, 483
– harcı 321, 329, 482, 512, 520, 524, 552, 560, 564, 568, 574, 599, **714 vd.**
İlân yolu ile tebliğ **191**
İlk derece mahkemeleri **87 vd.**
İlk itirazlar **340 vd.**
İlkeler **144 vd.**
İmza
– cevap dilekçesinde **343**
– dava dilekçesinde **328**
İnanca 533 (ayrıca bkz. Teminat)
İnkâr
– davayı 172, **345**, 355, 360
– gerekçeli **399**
– imzayı 357, 405 vd., 411 vd.
– vakıaları **338**, 342, 360
İnşaî davalar **308 vd.**
İnşaî hüküm 309 vd.
İnşaî karar 310 vd.
İnşaî tesir 309 vd.
İptidaî itirazlar (bkz. İlk itirazlar)
İradî taraf değişikliği **352**
İradî temsil 269 vd.
İspat **380** vd.
– hakkı **382**
– konusu **380**

– yükü **383 vd.**
İstek **80**
İstem **80**
İstem sonucu 54, 139, 326, 527, 530, 559
İsticvap **376 vd.**
– davetiyesi 378
– kararı 377 vd.
– konusu **377**
– usulü **377 vd.**
İstiktap 407
İstinabe **245 vd.**
İstinaf 65, 66, 69, 77, 84, 88, 89 vd., 94, 95, 97, 105, 126, 173, 176, 177, 181, 293, 363, 522, 558, 576, 578, 579, 587, 588, **593 vd.**
İstinaf mahkemeleri 58, 66, 69, 84, 88, **89 vd.**, 97, 105, 120, 124, 126, 151, 175, 181, 240, 243, 383, 454, 483, 508, 510, 513, 558, 563, 587, 588, 590, 591, 592, 593 vd., 623 vd., 643, 647, 662, 664, 730, 748, 800 (ayrıca bkz. Bölge adliye mahkemeleri)
– görevleri **91 vd.**
İş
– davaları 104, 389, 479, 745 vd.
– mahkemeleri **745 vd.**
– Kanunu 745 vd.
İş bölümü
– mahkemeler arasında 102, 509
– Yargıtay daireleri arasında 95 vd., 654
İş dağılımı 102
İşlemden kaldırma **549 vd.**
İtiraz **357**
İura novit curia **162 vd.**
İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi **333**
İzalei şüyu davası **201**, 561

— K —

Kabul **562 vd.**, 566
Kadastro
– davaları 253, **425**, 750
– Kanunu 59, 101, 425, **749 vd.**
– mahkemeleri 101-102, **749 vd.**
– yargılama usulü 750 vd.
Kademeli dava 311 vd.
Kalem teşkilâtı (bkz. Mahkeme kalemi)
Kamu avukatları 137
Kamu tüzel kişileri 72, 228, 229, 230, 233, 255 vd., 263, 271, 546, 754, 773
Kamulaştırma davaları 452
Kanun yararına temyiz 133, 153, 589, **626 vd.**, **662 vd.**
Kanun yolları 586 vd.
Kanunda düzenlenmemiş diğer deliller 395, 442, 463, **467**
Kanunî
– deliller 395 vd.
– hâkim güvencesi 103, **145**
– karineler 387 vd.
– temsil 179, 189, 190, 252, 259 vd., 263, 266, 269, 273, 289, 319, 321, 328, 331, 342, 343, 378, 440, 443, 479, 598, 610, 615, 630, 631, 650 vd., 678 vd., 732, 768
Karar düzeltme 664 vd.
– başvurulması 669 vd.
– incelemesi 670 vd.
– istenecek kararlar 665 vd.
– karara bağlanması 671 vd.
– sebepleri 668 vd.
– süresi 669
– talebi 665, 672

Karar ve ilâm harcı 714 vd.
Kararlar 475 vd.
– çeşitleri 475
Karineler 387 vd.
Karma dava 311
Karmaşık ikrar 399
Karşı delil 161, 345, 355, **388 vd.**, 405, 435
Karşı dava 344, **519 vd.**, 595, 666, 695, 715, 764
– yetki **221 vd.**
Karşılık dava 196, 221, **519**, 607, 727 (ayrıca bkz. Karşı dava)
Katılma yolu ile istinaf **600**
Katılma yolu ile karar düzeltme **670**
Katılma yolu ile temyiz **616 vd.**, 645, 650
Kayyım 119, 212, 252, 254, **261 vd.**, 496, 511, 630, 678, 737, 749
Kaza (bkz. Yargı)
Kaziyei muhkeme 685 (ayrıca bkz. Kesin hüküm)
Kendiliğinden araştırma ilkesi **155 vd.**, 160, 161, 351, 376, 391, 394, 398, 445, 738, 751
Kendiliğinden hak alma 52, 55
Kendiliğinden harekete geçme ilkesi 152, **153 vd.**
Kesin delil sistemi 383
Kesin deliller 150, 156, 299, 301, 304, **394 vd.**, 398, 402 vd., 418 vd., 424 vd., 433 vd., 442, 443
Kesin hukukî koruma 571, 582
Kesin hüküm 685 vd.
– bulunmaması 285, **294**
– çeşitleri 685 vd.
– dava şartı 289
– gerekçede 695 vd.
– hakem kararlarında 695, 798
– hüküm fıkrası 695
– icra mahkemesi kararlarında 695, 744
– itirazı 685 vd., **691 vd.**, 697, 706, 770 vd.
– kesin delil teşkil etmesi 698
– maddî anlamda **688 vd.**
– sona ermesi 686
– şeklî anlamda 560, 589, 628, 664, **685 vd.**
– yargılamanın iadesi sebebi 635, 679
Kesin kanunî karineler 387 vd.
Kesin süreler 172 vd.
Kesin olmayan yetki 210, 221, **228**, 233, 238, 242
Kesin yargı (bkz. Kesin hüküm)
Kesin yetkili mahkeme 210, 212, 215 vd., **227 vd.**
Keşif 176, 205, 208, 219, 220, 244, 247, 348, 350, 363, 365, 375, 391, 395, 442, **463 vd.**, 510, 531, 558, 563, 567, 583 vd., 603, 659, 715, 717 vd., 782
Kısa karar 172, **474**
Kısmî dava 161, 196, 290, **299 vd.**, 306, 327, 332, 420, 488, 508, 698
Kıymetli evrakın iptali 81, 737
Kişisel varlığı haklarına ilişkin davalar **203 vd.**, 212, **224**
Köy **264**, 443

— L —

Lisans alanın dava açması **765**

— M —

Maddî anlamda kesin hüküm 267, 334, 506, 560, 565, 569, 589, 628, 629, 642, 673, 684 vd., **688 vd.**, 706, 707, 740, 744, 771, 798

– sona ermesi 706 vd.
Maddî anlamda yargı 67, 68, 79, 744
Maddî hukuk **54 vd.**, 58, 60 vd., 64, 66, 71, 152, 154, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 177, 248, 251, 265 vd., 279, 291, 303, 308, 332, 339, 340, 357, 360, 367, 380, 381, 528, 544, 545, 548, 560, 565, 569, 570, 593 vd., 646, 647, 649
Mahcur 259
Mahkeme 67, **87 vd.**
– binası 247
– harçları 599, 774
– hükmü 661, 662, 671, 672, 676
– için konulmuş süreler (mahkemeye yönelik süreler) 172
– kalemi 133, 330, 344, 373, 414, 599, 718, 749, 777
– kararı 56, 60, 88, 91, 94, 122, 131, 168, 242, 290, 308, 309, 383, 411, 455, 464, 493, 497, 514, 537, 560, 569, 602, 605, 633, 639, 660, 667, 675, 676, 685, 688, 709, 753, 755, 767 vd., 775, 777, 800
– mübaşiri 133, 135, 749
– usul işlemleri 166, 168, 169, 549
– zabıt kâtipleri 133, **134**, 140
Mahkemeler arasında hukukî yardım **244 vd.**, 286
Mahkemeler teşkilâtı 87 vd.
Mahkemelerin görev ve yetkisi **194-238**
Mahkemelerin idarî faaliyeti 67
Mahkemelerin yargısal faaliyeti 67, **79**, 246
Mahkemeye ilişkin dava şartları **286 vd.**, 296, 370
Maktu harç 329, 599, 651, 714, 715, 783
Maktu vekâlet ücreti 726, 752, 760
Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı 89, 129, 171
Mal sigortalarında yetki (bkz. Zarar sigortalarında yetki)
Malvarlığı davaları 101, **196 vd.**, 200, 202, 204, 206, 596
Marka 542, 763, 764
Mecburî tahkim 58, 715, 750, 754, **786**, 787
Mecburî (zorunlu) dava arkadaşlığı 254, 256, 257, 484, 511, 534, 539, 540, **544 vd.**, 563
Medenî haklardan yararlanma ehliyeti **251 vd.**
Medenî hakları kullanma ehliyeti 258 vd., 263, 283, 630, 792
Medenî usul hukuku ile ilgili yönetmelikler 59
Medenî usul hukukunun kaynakları **56 vd.**
Medenî usul hukukunun yer bakımından uygulanması **60**
Medenî yargı 58, 68 vd., **76**, **77**, 78, 81, 83, 88, 103, 127, 144, 148, 152, 154, 159, 162, 194, 228, 239, 700, 702
Menfî tespit davası 226, 298, **307**, 332, 336, 405, 406, 488, 697
Merci tayini 91, **239 vd.**, 605, 613
Meslek kuralları 136, 137, 138
Meşru müdafaa 55
Mevsuf ikrar (bkz. Vasıflı ikrar)
Miras ortaklığı **257**, 258
Mirasçılık belgesi 81, 141, 142, 143, 221, 227, 283, 665, 737, 749
Muhakeme 51, 87
Muhakeme masrafları (bkz. Yargılama giderleri)
Muhakemenin iadesi (bkz. Yargılamanın iadesi)

Muhkem kaziye 685, 693 (ayrıca bkz. Kesin hüküm)
Mukabil dava 73, 221, 519, 622 (ayrıca bkz. Karşı dava)
Mukabil delil 388 (ayrıca bkz. Karşı delil)
Murafaa 655, 727 (ayrıca bkz. Duruşma)
Mutad mesken 211, 212, 289, 501, 533, 534 vd., 730
Mutlak temyiz (bozma) sebepleri 479, 614, **647**, **648**
Muvazaa 161, 271, 423, 428 vd., 432, 531, 698
Mübaşirler **133**, **135**
Müdahale 132, 148, 168, 201, 233, 257, 278, 287, 289, 293, 298, 311, 350, 352, 394, 478, 484, 495, 498, **499-506**, 511, 521, 522, 526, 533 vd.
Müddeabih 196, 203, 353, 526, 693 (ayrıca bkz. Dava konusu)
Müddetler (bkz. Süreler)
Mühürleme 572, 739
Mümeyyiz küçük 259
Münhasır delil sözleşmesi 468, **469 vd.**
Münhasır olmayan delil sözleşmesi 468, **470 vd.**
Müracaata bırakma 335
Mürekkep ikrar 399 (ayrıca bkz. Bileşik ikrar)
Müspet tespit davası **307**
Mütekabil dava (bkz. Karşı dava)
Mütelâhik davalar 163, **315**
Müvekkil 139, 189, 253, 269, 271 vd., 279 vd., 422, 440, 558, **722 vd.**

— N —

Neticei talep 692 (ayrıca bkz. İstem sonucu)
Nihaî karar 92, 105, 120, 122,125, 126, 151, 169, 170, 180, 205, 206, 235, 236, 291, 297, 330, 335, 374, 472 vd., **475 vd.**, 483, 486, 487, 501, 509, 555, 556, 558, 563, 579, 584, 586, 588 vd., 595 vd., 611 vd., 625, 626, 643 vd., 659 vd., 685, 693 vd., 721, 797
Nispî harç 329, 599, 651, 714, 715
Nispî temyiz sebepleri 647, **648 vd.**
Nispî vekâlet ücreti 726
Nizalı kaza (bkz. Çekişmeli yargı)
Nizasız kaza 737 (ayrıca bkz. Çekişmesiz yargı)
Normal kanun yolları 588, 594, 611
Noter 79, 80, 136, **141 vd.**, 183, 185, 274, 275, 408 vd., 412, 739, 792
– odası 142
– senetleri 141, **409 vd.**
Noterlik Kanunu 59, 141, 409, 410 vd.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği 141

— O —

Objektif dava birleşmesi 196, **314**, **315**, 327, 539, 559
Olaylar 322, 325, 351, 526, 562, 593, 610, 691, 692 (ayrıca bkz. Vakıalar)
Olağan kanun yolları **588**, 589, 594, 628, 664, 673, 686
Olağanüstü kanun yolları **589**, 800
Olumlu görev uyuşmazlığı **83**, 490
Olumsuz görev uyuşmazlığı 83, **84 vd.**, 207, 240

Onama kararı
– düzelterek **624**, 657, 661, 665, 668, 671, 672, 760
– temyizde 624, 661, 672
Onaylama biçiminde noter senetleri 409, **410**
Organik (şeklî) anlamda yargı **67**
Orman sınırlamasına itiraz davaları 74, 256
Ortak yetkili mahkeme **213**, 217
Ortaklığın giderilmesi davaları **201**, 310, 561, 750
Oturum 184, 270, 276, 277, 281, 282, 283, 321, 338, 363, 368, 372, 376, 378, 437 vd., 464, 473, 474, 529, 564, 568, 649, 724 (ayrıca bkz. Duruşma)

— Ö —

Ölmüş kişi adına dava açılması 253
Ölmüş kişiye karşı dava açılması 252, 243
Ölüm 252 vd., 261, 282, 283
Ön inceleme 64, 73, 95, 96, 134, 150, 158, 162, 168, 181, 183, 205, 235, 295, 296, 331, 333, 341, 346 vd., 353 vd., 358, **362 vd.**, 370, 374, 375, 382, 383, 472, 484, 524, 549, 560, 565, 566, 568, 602 vd., 607, 617, 640, 654, 656, 671, 718, 735, 738
– duruşması 150, 158, 162, 168, 181, 183, 205, 235, 296, 348, 353, 356, 358, 364, **365 vd.**, 390, 391, 560, 735
Ön sorun 148, 181, 235, 341, 375, 405, 406, 412, **486 vd.**, 501, 677, 770, 791, 796
Özel dava şartları **294**
Özel dava vekâletnamesi 274, 281
Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlık 52, 55, 74, 76 vd., 101, 287
Özel hukuk kişilerine karşı açılan davalar 75
Özel hukuk tüzel kişileri 72, 75, 222, 227, 230, **255**, **263**, 773
Özel (görevli) mahkemeler 59, 100, 101, 102, **103 vd.**, 145, 194 vd., 226, 232, 240, 629, 636, 644, 655, **741 vd.**
Özel yetki kuralları 210, **215 vd.**, 223 vd., 233
Özel yetkili mahkemeler 211, 215, 216, 227, 228, 232, 235

— P —

Pasif husumet ehliyeti 267, 268
Patent 761, 763, 765
Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları **201**, 561
Peşin harç 716

— R —

Reddi hâkim (hakimin reddi) 117, 118, **120 vd.**, 125, 167,168, 370, 486, 487, 644, 655, 666, 716, 743
Reformatio in peius (aleyhe bozma yasağı) 620, 657
Replik 346
Resen araştırma ilkesi 73, 76, 133, **155**, **156**, 169, 249
Resen düzenlenen noter senetleri **409**
Resmî bilirkişiler 456
Resmî çalışma gün ve saatleri 189, 464
Resmî senetler 403, **408 vd.**, 429, 430, 494
Resmî tatil günleri 174, 190, 464

— S —

Sahtelik
– davası 152, 405, **406 vd.**, 411, 412, 488, 494, 701
– iddiası 76, 152, **405 vd.**, **411 vd.**, 487, 494, 701
Sair kanunî deliller 325
Salâhiyet 194 (ayrıca bkz. Yetki)
Savcılar 230, 439, 496, 700, 716, 792
Savunma vasıtaları (Savunma araçları) **339 vd.**
Savunmayı genişletme (ve değiştirme) yasağı **355 vd.** 516, 526, 553, 641, 683
Seçimlik davalar **313**, **314**, 326, 327
SEGBİS 159, 244, 369, 378
Senede karşı senetle ispat zorunluğu **428 vd.**
– istisnaları **430 vd.**
Senet 402 vd.
– adi senet **403 vd.**, 429
– çeşitleri **403 vd.**
– çıkıntılar ve silintiler 413, 414
– ispat gücü 404, 408, 411 vd.
– resmî senet **408 vd.**, 429, 430
– sahtelik 405 vd., 411 vd., 487, 488, 494, 632, 675, 701
Senetle ispat zorunluluğu **418 vd.**, 424 vd., 426, 444, 468
– istisnaları 391, 420
Sıfat 132, 152, 250, 251, 265, **266 vd.**
– dava şartından farkı 267, 268
Sınıf davası 316
Sınırlı dava ehliyeti 259
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki **223**
Somutlaştırma yükü **322**, 390
Sözleşmeden doğan davalarda yetki 210, **216**, **217**
Sözlü yargılama 281, 333, 368, 371, 374, 375, 463, 472, **473 vd.**, 734
Sözlü yargılama usulü 734
Sözlülük-yazılılık ilkesi **161 vd.**
Sulh **566 vd.**
– teşvik 121, 153, 364, 365, 366, 566, 735
Sulh hukuk mahkemeleri 101 vd.
– genel (görevli) mahkeme 101 vd., 200 vd., 240, 738
– görevleri 101, 200 vd., 612, 613, 733
– temyiz süresi 650
Sübjektif hakkın yokluğu ölçütü 81
Süreler **171 vd.**

— Ş —

Şahısvarlığı haklarına ilişkin davalar 203, 204, 212, 224 (ayrıca bkz. Kişivarlığı haklarına ilişkin davalar)
Şahitler 443 (ayrıca bkz. Tanık)
Şeklî anlamda kesin hüküm 493, 506, 560, 589, 685, **686 vd.**, 689
Şeklî hukuk 54
Şube 222, 223, 226, 250, 534
Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi **222**
Şüyuun izalesi (giderilmesi) davası 218, 310, 561, 709, 750 (bkz. Ortaklığın giderilmesi davası)

— T —

Tabiî hâkim 103, **145**, 229, 629, 761
Tahkikat 64, 92, 94, 105, 121, 134, 150, 151, 157, 158, 162, 165, 168, 180, 244, 268, 270,

276, 281, 285, 296, 302, 303, 312, 313, 323, 331, 351, 353, 357, 358, 362 vd., **374 vd.**, 380, 382, 396, 437, 438, 472, 473, 474, 481, 484, 491, 492, 496, 497, 501, 503, 510, 519, 524, 528, 532, 549, 550, 552, 562, 564, 582, 603, 606, 611, 641, 672, 683, 718, 728, 731, 735, 736, 738, 764, 782, 798
– sona ermesi **472 vd.**
Tahkim 56, 58, 153, 167, 176, 199, 279, 330, 340, 574, 666, 715, 733, 780, **785 vd.**
– iç tahkim 785
– ihtiyarî 786
– itirazı 790, 791
– ilk itirazı 790
– iptal davası 612, 614, **798 vd.**
– iptal sebepleri 798
– konusu 790
– mecburî 58, 750, 754, **786**, 787
– milletlerarası 785
– müesseseleri 785, 788
– niteliği **786 vd.**
– sözleşmesi 786, **788 vd.**, 799
– süresi **796 vd.**
– şartı 199, 787, **789**, 790, 796
– usulü **794 vd.**
– yargılamanın iadesi **800**
Tahliye davaları 200, 201, 218, 267, 298, 311, 478, 522, 537, 545, 569, 692
Takas 166, 279, 339, 346, 354, 359, 399, 401, 518, 519, **520 vd.**, 528, 696
– def'i 339, 518, 696
– karşı davada 520 vd.
Takdirî delil sistemi 383
Takdirî deliller 76, 377, **395**, 397, 398, 418, 419, 429, 436, **442**, 461, 465, 466, 468, 470, 585, 648, 698, 702
Talep sonucu 156, 251, 265, 300 vd., 311, 312, 314 vd., 319, 322 vd., 335, 337, 338, 343, 346, 348 vd., 374, 380, 381, 383, 396, 477, 480, 526, 556, 557, 562 vd., 566, 589, 590, 598, 688, 690, 692, 693, 695, 719, 734
Talep sonucunu değiştirmek 348
Taleple bağlılık ilkesi **156-157**, 700
Talepten fazlaya hüküm 307, 480
Tam dava ehliyeti 259
Tam ehliyetsizler 260
Tamamlayıcı yemin 435
Tanık 94, 109, 122, 134, 146, 147, 156, 158 vd., 167, 180, 183, 205, 208, 219, 231, 244 vd., 250, 287, 325, 363, 365, 372, 375, 377 vd., 380, 384, 391, 392, 394, 395, 397, 403, 409, 417, 419 vd., 426 vd., 436, 442, **443 vd.**, 456, 457, 464, 465, 467, 468 vd., 532, 570, 582 vd., 633, 634, 648, 659, 660, 676 vd., 717, 718, 752, 777, 780
– caiz olan haller 443 vd.
– çekinme **446 vd.**
– davet edilmesi 445
– dinlenmesi 448
– gösterilmesi 444
– listesi 156, 325, 444, 445, 517, 527, 552, 553
Tanıkla ispat yasağı **418**, 427, 428
Tanıma 199, 212, 742, **769 vd.**
Taraf ehliyeti 250, **251 vd.**, 265 vd., **288**, 542
Taraf sıfatı 250, **266 vd.**, 289, 506, 516
Taraf teşkili 149, 183, 337, 631
Taraf usul işlemleri 120, **166 vd.**, 556
Tarafın ölümü 254

Tarafın sorguya çekilmesi 269, **376**, 377 (ayrıca bkz. İsticvap)
Taraflar **250 vd.**
Taraflarca getirilme ilkesi **154 vd.**, 160, 161, 162, 164, 169, 324, 376, 391, 394, 398, 445, 700
Tarafların ikinci dilekçeleri **346 vd.**
Tarafların taaddüdü 539 (ayrıca bkz. Dava arkadaşlığı)
Tarafta iradî değişiklik 167, **352**, 527, 544
Tasarım 542, 763
Tasarruf ilkesi 130, **151 vd.**, 156, 164, 549, 550, 556, 560, 620, 650, 700, 794
Tashih **708 vd.**
Taşınır davaları **311**
Taşınmaz davaları 224, **311**, 451, 644
Tatil 141, **174-177**, 190, 344, 389, 464
– adlî **175 vd.**, 190, 329, 343, 464, 753, 796
– günleri 174, 177, 190, 464
Tavzih 666, **708 vd.**, 719, 797, 798, 799
Tebligat 67, 135, 140, 142, 149, 160, 174, 177, 179, 180, **183 vd.**, 211, 246, 247, 252, 253, 254, 260, 277, 280 vd., 287, 320, 330, 370, 444, 464, 497, 507, 511, 585, 619, 635, 650, 655, 656, 678, 717, 728, 730, 758 vd., 795
– hilesi 635, 678
– yabancı ülkelerde 247
Tek taraflı dava 80, 250
Teksif ilkesi **157**
Temerrüt 327, 527
Teminat 111 vd., 133, 136, 167, 181, 212, 289, 294, 501, 530, 531, **533 vd.**, 575 vd., 618, 640, 653, 670, 682, 730, 766, 799
Temsil 78, 110, 113, 135, 173, 179, 185, 189, 190, 251, 252, 255, 257 vd., **269 vd.**, 282, 283, 287, 289, 316, 319, 321, 328, 331, 342, 343, 378, 424, 425, 440, 443, 447, 479, 543, 545, 558, 562, 564, 598, 610, 615, 630, 631, 638, 640, 641, 650, 651, 656, 678, 683, 722, 724, 732, 734, 735, 759, 768, 774, 780, 797 (ayrıca bkz. Davaya Vekâlet)
– belgesi 273, 274, 289
Temyiz 611 vd., 643 vd.
– bozma kararı 614, 615, **620 vd.**, 646, **657 vd.**
– dilekçesi **614 vd.**, 624, **650 vd.**
– direnme 96, 122, 476, 587, 605, 608, 615, 624 vd., 655, 659 vd.
– duruşma 65, 619, 651, 655 vd.
– düzelterek onama kararı 624, 662
– edilebilen kararlar 612, 643 vd.
– edilemeyen kararlar 612, 644 vd.
– feragat 617, 662, 669
– harç ve giderler 615, 651
– icraya etkisi 615, 617-618
– incelemesi 609, 611, 613, 615, 618, 619, 620, 624, 625, 626, 648, 651, **653 vd.**
– iş mahkemesi kararları 644, 748
– kanun yararına 133, 153, 589, **626 vd.**, **662-663**
– katılma yoluyla 616, 650
– kötüniyetli 618
– onama kararı 94, 625, 661-662
– sebepleri 598, 613, 614, 615, 618, **646 vd.**, 657, 668
– süresi 614, 650
– – asliye hukuk mahkemesi kararlarında 650

– – sulh mahkemelerinde 650
– talebi 619, 620, 645, **650 vd.**, 654, 655, 656, 662, 665 vd.
Tenfiz 199, 204, 212, 220, 221, 715, 742, **767 vd.**, 785
Tensip tutanağı 160, 168, **331**, 362
Terditli davalar **311 vd.**, 326
Tereke ile ilgili davalar 220, 252, 257, 258
Tespit davaları 200, 201, 216, 218, 292, 293, 298, 301, **303 vd.**, 326, 439, 449, 462, 477, 488, 490, 517, 540, 582, 645, 677, 689, 715
Tespit hükmü 299, 305, **307**, 309, 477
Teşkili tarafeyn 149 (ayrıca bkz. Taraf teşkili)
Tetkik hâkimi 93, 95, 654
Tevzi bürosu 319, 329, 734
Tevzi formu 319, 329, 330
Ticaret mahkemeleri 87, 105, 124, **197 vd.**, 202, 247, 483, 666, 738, 768, 771
Ticarî dava 64, **197 vd.**, 155, 415, 733, 768, 779
– mutlak 197
– nispî 198
Ticarî defterler 81, 155, 176, 245, 415, 416, 417, 422, 737
Topluluk davası 316, 477, 755
Tutanaklar 129, 134, 139, 148, 169, 368, **372-373,** 532, 750-752
Tüketici 230, 233, 295, 316, 716, 754 vd.
– davası 755
– hakem heyeti **756 vd.**
– mahkemeleri **754 vd.**
– – yargılama usulü 755
– – yetkisi 755
Türk hukuku 51, 57, 61, 62, 68, 69, 87, 104, 127, 132, 148, 150, **162**, 163, 270, 690, 761, 768, 777, 785, 799
Türk Milleti adına 67, 87, 106, 111, 112, 147, 479
Türkiye Adalet Akademisi 107 (ayrıca bkz. Adalet Akademisi)
Türkiye Barolar Birliği **136-137**
Türkiye Noterler Birliği 142
Tüzel kişiler 52, 75, 78, 133, 139, 140, 185, 187, **190**, 191, 211, 213, 222, 227, 230, 251, 254 vd., 263 vd., 271, 286, 316, 440, 534, 591, 630, 655, 700, 729, 754, 773
– adli yardım 729
– dava ehliyeti **263 vd.**
– taraf ehliyeti **251 vd.**
– tebligat 185, 187, **190**
– temsili **263 vd.**
– yerleşim yeri **213**

— U —

Uluslararası yetki 209, 767
Usul hukukuna dayanan
– savunma vasıtaları 340
– temyiz sebepleri 647
Usul işlemleri 64, 120, 161, 163, **165 vd.**
Usul ekonomisi 85, 89, 125, 133, 146, **157 vd.**, 173, 242, 253, 313, 374, 444, 455, 484, 488, 489, 491, 504, 505, 507, 510, 519, 544, 593, 628
Usule ilişkin nihaî kararlar **477-478**, 643, 695, 721
Usulî itirazlar 234, **340-341**
Usulî kazanılmış (müktesep) hak 170, 171, 205, 475, 476, 590, **621-623**
Usulsüz tebligat 174, 179, **191-193**

Uyuşmazlık çözüm yolları **55-56**, 363, 757
Uyuşmazlık kavramı 55-56
Uyuşmazlık Mahkemesi 68, 69, **82 vd.**, 88, 240, 490
Uyuşmazlık yargısı 69, **82**
Uzman görüşü 395, 442, **466**
Uzmanlık mahkemeleri 103, 145, 761 (ayrıca bkz. Özel mahkemeler)

— Ü —

Ücret sözleşmesi 284, 723 vd.
Üst derece ve yüksek mahkemeler **88 vd.**

— V —

Vakıalar 53, 88, 150, 151, 154 vd., 160 vd., 268, 280, 305, 306, 312-313, 315, 317, 319, **322 vd.**, **338 vd.**, 345, 346, **348 vd.**, 354 vd., 359-360, 368, 374 vd., 376 vd., 380 vd., 390, 391, 394, 396, 398, 402, 437, 440, 443, 450, 455 vd., 467, 479, 492, 503, 527, 530, 541, 562, 582 vd., 593, 611, 646, **690 vd.**, 734, 735, 747, 788, 794
Vakıalara dayandırma ilkesi (teorisi) 323-324
Vasıflı (Nitelikli) ikrar **399**
Vasi 119, **261**, 378, 440
Vazgeçme 556 vd., 560, 568, 779
Vazife 194 (ayrıca bkz. Görev)
Vekâlet 119, 131, 138, 139, 140, 184, 249, 253, 266, **269 vd.**
– ücreti 139, 164, 272, 277, 284, 327, 478, 512, 524, 555, 564, 568, 602, 618, 622, 623, 656, 662, 669, 717, **719 vd.**, 752, 759, 760
– – müvekkilin vekile ödeyeceği 722 vd.
– – sözleşmesi 723, 724
– – yargılama gideri olan 717, **719** vd.
Vekâletname 139, 140, 148, 189, 253, 269, 272, **273 vd.**
– kapsamı 278 vd.
– – özel yetki verilmesi gereken haller 279-280
– şekli 269-270
– verilmesi 274-275
Vekil 119, 123, 130, 137, 140, 164, 178, 179, 183, 184, 185, **189**, 252, 253, 258, 259, 262, 263-264, **269 vd.**, 289, 317, 319, **321**, 328, 342, 343, 369 vd., 396, 419, 437, 440, 441, 473, 558, 562, 563, 564, 566, 568, 591, 598, 602, 610, 615, 618, 622, 630-631, 635, 638, 640, 641, 648, 650, 651, 656, 662, 678, 682, 714, 717, 719 vd., 726, 730, 734, 735, 752, 766, 792
– azli 282
– iflâsı 283
– istifası 281-282
– ölümü 282
– tayini 263, 269 vd., 280, 730
Vekille temsil zorunluluğu **270**
Veli 259, **261**, 378, 440, 749
Veraset ilâmı 221, 665
Viyana Sözleşmesi 287

— Y —

Yabancı mahkeme kararları 204, 742, 767 vd.
Yaklaşık ispat 381, **575**, 731
Yalan tanıklık 449, 633, 676, 677, 704

Yargı 67 vd.
– çeşitleri **68 vd.**
– çevresi 90, 91, 92, 132, 138, 141, 159, **209**, 239, **244** vd., 378, 440, 441, 448, 462, 464, 488, 491, 509 vd., 577, 583, 595, 603 vd., 608, 613, 741, 745, 761
– erki 145
– görevlileri **106 vd.**
– hakkı 246, **286 vd.**, 296
– kolları **68 vd.**, 83, 240
– muafiyeti 286, **287**
– tanımı 67
– yeri belirlenmesi 77, 120, 207, 236, **239 vd.**, 661, 666 (ayrıca bkz. Merci tayini)
– yetkisi 57, 67, 86, 87, 103, 106, **111**, 112, 114, 116, 127, 139, 145, 147, 209, **286**, 778
– **yolu 68 vd.**
– – dava şartı 288
– – ilişkisi 71, 77, 194
– – adli yargı 75 vd.
– – idari yargı 71 vd.
– – uyuşmazlığı 69, 73, 74, 240, 490
– – – olumlu 83
– – – olumsuz 84
Yargılama 51 vd., 68 vd., 76, 81, 86 vd., 109, 114, 115, 120, 126, 128-131, 133, 134, 136, 144 vd., 165 vd., 181, 205, 207, 248, 251, 262, 265, 270, 272, 276, 281, 282, 285, 297, 303, 315, 318, 321, 322, 324, 328, 329, 331, 341, 353, 358, **362 vd.**
– giderleri 120, 157, 164, 181, 206, 272, 276, 277, 283, 289, 301, 308, 310, 327, 338, 352, 466, 477, 478, 481, 501, 512, 516, 519, 531 vd., 535 vd., 555, 559, 564, 565, 568, 584, 585, 590, 602, 605, 710, **713 vd.**, 719 vd., 725, 728 vd., 777, 797
– harçları 329, **713 vd.**
– şartları 285, 297 (ayrıca bkz. Dava şartları)
– usulü 54, 56, 57, 59, 64, 73, 86, 104, 158, 162, 234, 315, 318, 331, 337, 450, 479, 520, 558, 610, 659, 700, 702, 733 vd.
Yargılama ve hüküm **472 vd.**
Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi **159-160**
Yargılamanın iadesi 91, 120, 164, 170, 262, 273, 280, 377, 439, 449, 462, 475, 587, 589, **628 vd.**, **673 vd.**, 689, 704, 706, 744, 773, 775, 800
– hakem kararına karşı 800
Yargılamanın yapılış şekli **368 vd.**
Yargılamanın yenilenmesi 53, 205, 592, 628, 631, 633 vd.,673, 676, 777 (ayrıca bkz. Yargılamanın iadesi)
Yargılamaya hakim olan ilkeler **144 vd.**
Yargısal faaliyet 67, 68, 79, 128, 246
Yargıtay 58, 59, 60, 63, 66, 69, 75, 77, 80, 83, 84, 88, 89, 91, **92 vd.**, 103, 113 vd., 121, 122, 123, 131, 149, 162, 172, 173, 175, 177, 181, 183, 200, 201, 215, 225, 239, 240, 243, 252, 256, 267, 268, 296, 304, 317, 324, 325, 345, 357, 370, 376, 377, 387, 389, 393, 397, 400, 428, 452, 453, 460, 462, 476, 479, 482, 483, 504, 511, 527, 528, 558, 563, 587, 594, 611 vd., 631, 632, 644 vd., 650 vd., 658 vd., 679, 691, 692, 693, 730, 735, 737, 748, 768, 785, 790

– Başsavcısı 84, 93, 98, 133, 626, 663
– Büyük Genel Kurulu 93, 95, 98, 130, 243, 611
– görevleri **94 vd.**
– hukuk dairelerinin görevleri 94-95
– Hukuk Genel Kurulu 93
– – görevleri 96
– İç Yönetmeliği 92, 97, 175, 654
– Kanunu 60, 87, **92**, 97, 117, 654
Yasaklı hâkim 117, 120, 126
Yaşam deneyimi kuralları 387
Yazı işleri müdürü 123, 124, **133 vd.**, 142, 184, 372, 373, 415, 482, 537, 576, 577, 578, 591, 624, 658, 661, 672, 719, 739, 749
Yazılı delil başlangıcı 64, 424, 425 (ayrıca bkz. Delil başlangıcı)
Yazılı yargılama usulü 64, 150, 158 162, 234, 318, 344, 362, 473, 479, 523, 525, 610, 733 vd., 743
Yemin 64, 77, 79, 125, 135, 156, 159, 168, 207, 231, 245, 279, 283, 324, 325, 365, 375, 384, 394, 395, 403, 417, 427, 433, **435 vd.**, 445, 446, 448, 455, 456, 457, 467, 469, 470, 501, 532, 622, 634, 648, 677, 705, 717, 738, 739, 740
– iadesi 439
– kaçınma 439
– konusu 437
– reddi (bkz. iadesi)
– teklifi 324, 325, 365, 384, 417, 427, 433, **435 vd.**, 501, 622
Yemin tutanağı **739,** 740
Yeni delil gösterilmesi 207, 324, **392**, 641, 683
Yenileme 174, 176, **552 vd.**
Yenilik doğuran (inşaî) davalar 298, 304, **308 vd.**, 694, 699
Yenilik doğuran hüküm 477, 699
Yerleşim yeri 164, **186**, 190, 204, **210 vd.**, 227, 512, 531, 534, 535, 542, 576, 730, 747, 755, 757, 758, 766, 768, 771
Yetki 194, **209 vd.**
– anlaşması (sözleşmesi) 215, 217, 219, 220, 223, 228, **229 vd.**, 595, 598, 607, 747
– boşanma davalarında 224, 225
– çekişmesiz yargı işlerinde 224
– davalıların birden fazla olması halinde 213
– davalının yerleşim yeri 210 vd., 219 vd., 225, 542, 766
– gayrimenkul (taşınmaz) davalarında 218 vd.
– geçici oturulan yer 223-224
– genel yetki **210 vd.**
– haksız fiilden doğan davalarda 217
– iç yetki 209
– iş mahkemelerinde 747
– itirazı 215, 219, 220, 225, 227, 228, 232, **233 vd.**
– – incelemesi 235
– – süresi 234
– karşı davada 221-222
– kesin yetki **210**, 212, 213, 215, 216, 217, 219 vd., **227 vd.**, 236, 242, 288
– kesin olmayan yetki 210, 216, 221, **228**, 233, 238, 242
– miras ile ilgili davalarda 220-221
– niteliği 227-228
– ortak yetkili mahkeme 213, 214, 217, 315, 512
– özel yetki 210 vd., **215 vd.**, **224 vd.**

– sigorta sözleşmesinden doğan davalarda 223
– son yerleşim yeri mahkemesi 220-221
– sözleşmeden doğan davalarda 216-217
– sözleşmesi **228 vd.**, 595, 598, 607, 747
– – caiz olduğu haller 230
– – etkisi 232-233
– – şekli 231
– şartı 217, 219, 223, 229, 231
– şubenin bulunduğu yer mahkemesi 222
– taşınmaz davalarında 218-219
– Türkiye'de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılan davada 211-212
– Türkiye'nin her yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu haller 227
– uluslararası yetki 209, 767
– zarar sigortalarında 223
Yetkisizlik kararı 164, 211, 214, 225, **235 vd.**, 242, 243, 288, 296, 319, 362, 476, 478, 487, 531, 543, 556, 644, 721, 722
– yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 236-237
Yönetmelikler 59, 646
Yüce Divan 70

— Z —

Zabıt kâtibi **133-134**, 140, 331, 366, 369, 372, 373, 378, 447, 463, 475, 479, 481, 482, 610, 740, 749
Zabıt varakası 372
Zamanaşımı 121, 131, 154, 168, 177, 207, 208, 237, 253, 276, 277, 302, 303, 332, 336, 338, 339, 346, 347, 354, 356, 358, 361, 362, 366, 367, 426, 427, 462, 475, 482, 483, 493, 501, 504, 516, 517, 527, 529, 530, 543, 546, 547, 551, 581, 595, 636, 639, 747, 782, 795, 798
– belirsiz alacak davasında 302-303
– def'i 121, 154, 276, 339, 346, 347, 354, 356, 358, 361, 367, 475, 501, 504, 517, 529, 543, 547
– kesilmesi 208, 237, 303, **332**, 336, 354, 529, 530, 551, 795
– olağanüstü zamanaşımı 546
– kısmî davada zamanaşımı 332
Zaman bakımından uygulanma **61 vd.**
Zilyetliğin korunması 201
Zorunlu bekletici sorun 489, **490**
Zorunlu dava arkadaşlığı 254, 256, 257, 484, 511, 534, 539, 540, **544 vd.**, 558, 563, 597, 649 (ayrıca bkz. Mecburî dava arkadaşlığı)
Zorunlu tahkim 58, 715, 750, **786**, 787 (ayrıca bkz. Mecburî tahkim)